Avant-propos de la deuxième édition

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Avant- propos de la deuxième édition, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 5-14
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Avant- propos de la deuxième édition, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 5-14
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

La première édition de cet ouvrage avait été conçue comme un manuel, principalement destiné aux étudiants de l'Université du Luxembourg, auprès de qui il devait combler un manque. Enseignant à l'époque le droit des contrats et le régime général des obligations dans cette université, j'avais constaté la difficulté que les étudiants pouvaient avoir à faire le lien entre le cours oral, les exercices demandés en droit luxembourgeois, et les manuels de droit français (ou plus rarement de droit belge) qui constituaient, jusque-là, leur principale source de documentation écrite. L'utilité pédagogique de cet ouvrage devait encore s'accroître avec la mise en place à Luxembourg du nouveau bachelor en droit qui dissocie le cours – désormais centré sur une approche transnationale de la matière – des travaux dirigés axés sur le droit luxembourgeois. Les étudiants pouvaient ainsi trouver dans ce manuel une présentation systématique du droit national, qui ne leur était plus dispensée sous la forme d'un cours oral. Cet objectif pédagogique demeure, et cette seconde édition a conservé les lignes directrices de la première quant à son contenu et à ses techniques d'exposition. Du point de vue du contenu, l'approche se distingue évidemment de celle d'une encyclopédie qui tend, sur chaque question, à l'exhaustivité. Il s'agit ici, fondamentalement, d'un ouvrage de formation, qui ne vise pas à tout dire, mais seulement à délivrer les connaissances essentielles à l'apprentissage d'un savoir de juriste. S'agissant des techniques d'exposition, je les ai souhaitées les plus pédagogiques possibles. Ce souci pédagogique a commandé, dans une large mesure, la structure des développements, qui cherche à n'aborder les questions que dans l'ordre où elles sont accessibles à un lecteur débutant, en évitant de traiter d'abord des questions dont la compréhension suppose des connaissances qui ne seront dispensées que dans des développements ultérieurs. Dans tous les cas où cela n'était pas possible, je me suis efforcé de donner une présentation sommaire de la question ne devant être abordée qu'ensuite ou dans le cadre d'un autre cours, et j'ai, volontairement, multiplié les renvois aux développements postérieurs ou antérieurs pour bien montrer les liens entre les différentes questions. Par ailleurs, pour éviter aux étudiants débutants de se perdre dans les détails, j'ai utilisé la désormais classique distinction, due à Jean Carbonnier, entre les développements en gros caractères, destinés à donner un premier aperçu de la matière, et les « petites lignes » permettant d'approfondir où cela apparaîtra utile (notamment pour la préparation des travaux dirigés) ou donnant des indications complémentaires à des

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Avant- propos de la deuxième édition, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 5-14
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

lecteurs plus avancés. Contrairement à Carbonnier et à ses suiveurs, cependant, j'ai intégré les développements en petites lignes dans la continuité des développements, pour mieux montrer les liens entre les grands principes et les détails, tout en veillant à ce qu'il soit possible de lire en continu même en sautant les passages en petites lignes.

Cependant, tout en maintenant cette approche pédagogique, j'ai cherché, dans cette seconde édition, à répondre davantage aux besoins des professionnels du droit de la place luxembourgeoise, dont j'avais constaté qu'ils constituaient une part importante des lecteurs, au moins autant que les étudiants en droit. Or la première édition ne contenait, sur la plupart des questions, qu'une présentation assez superficielle de la jurisprudence luxembourgeoise, du reste très difficile d'accès à l'époque, et pour une présentation plus complète (essentielle pour les avocats et les magistrats), il était souvent renvoyé à l'ouvrage de droit des obligations d'O. Poelmans[1], qui donnait une analyse détaillée de la jurisprudence luxembourgeoise récente sur les matières traitées. Malheureusement, cet ouvrage n'a pas pu connaître de mise à jour récente, en raison du décès tragique de son auteur en 2021. C'est pourquoi il m'a paru nécessaire, dans cette nouvelle édition, d'essayer de combler le vide laissé, en intégrant dans les développements des références beaucoup plus nombreuses aux décisions des cours et tribunaux du Luxembourg, en mettant l'accent sur les décisions les plus récentes. Cela m'a été rendu possible par le développement de bases de données publiques rendant l'accès à ces décisions plus facile, même si des progrès restent à faire. En dépit des limites imposées à la fois par la taille de l'ouvrage et par la difficulté de sélectionner les décisions les plus pertinentes au sein d'une masse foisonnante, j'espère ainsi que l'ouvrage répondra davantage aux besoins des professionnels du droit.

Là n'est cependant pas la principale nouveauté de cette seconde édition. Comme l'expliquait l'avant-propos de la première édition, ce manuel ne pouvait pas être complètement similaire à ceux qui existent déjà, sur la même matière, en droit français ou en droit belge. Même si, comme ceux-ci, il devait être centré sur le droit national du pays, dans la tradition de l'enseignement du droit civil en Europe, le particularisme du droit luxembourgeois imposait et

[1] O. POELMANS, *Droit des obligations au Luxembourg, Principes généraux et examen de jurisprudence*, coll. Les Dossiers du Journal des tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2013.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Avant- propos de la deuxième édition, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 5-14
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

impose plus que jamais une ouverture beaucoup plus grande sur les droits étrangers que celle qui est d'usage dans les manuels – d'où l'approche comparative indiquée dans le sous-titre de l'ouvrage. On sait en effet que le droit luxembourgeois des obligations (et en particulier des contrats) trouve ses bases textuelles dans le Code civil de 1804, adopté par le Luxembourg au XIXe siècle lors de son indépendance comme par la Belgique voisine. À l'époque de la première édition, il existait une très large identité textuelle entre les trois pays pour le Titre III du Livre III du Code civil relatif aux contrats et aux obligations conventionnelles, qui avait été le moins affecté par les réformes législatives nationales intervenues depuis le XIXe siècle. Certes, cela ne signifiait pas que le droit des obligations était resté le même en France, en Belgique et au Luxembourg. D'une part, il fallait tenir compte des différences souvent importantes pouvant exister quant aux textes spéciaux relatifs aux différents contrats (dont la théorie générale du contrat ne saurait être séparée) ou dans les matières périphériques ayant des incidences sur les relations contractuelles (incapacités, régimes matrimoniaux, voies d'exécution, faillites, etc.). D'autre part, même si les textes étaient les mêmes, ils pouvaient être interprétés (et complétés sur les points qu'ils ne règlaient pas) différemment par la jurisprudence de chaque pays. Cependant, si les divergences sur ce terrain pouvaient être assez marquées entre la France et la Belgique, la jurisprudence luxembourgeoise en matière contractuelle est, elle, toujours restée très proche de celle de la Cour de cassation française. La raison principale en est que, jusqu'à une période récente, il n'existait pas d'université au Luxembourg, et que les magistrats luxembourgeois, de même que les juristes en activité au Luxembourg ont été pendant longtemps formés ailleurs, dans l'immense majorité des cas en France. Les juges dans leurs décisions, comme les avocats dans leurs conclusions, ont dès lors toujours eu une tendance naturelle à se référer aux décisions des juridictions françaises et aux opinions doctrinales des auteurs français, parfois aussi, bien que plus rarement, à la doctrine et à la jurisprudence belges – souvent sans marquer la distance qui s'impose avec ce qui ne devrait être qu'une source d'inspiration comparative, et en intégrant complètement ces éléments de droit français ou belge à leur raisonnement. Il en résulte qu'il était – et qu'il est toujours – rigoureusement impossible de faire l'étude du droit luxembourgeois comme s'il s'agissait d'un système clos, complètement autonome, sans se référer constamment au modèle français, et parfois aux interprétations reçues en

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Avant- propos de la deuxième édition, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 5-14
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Belgique. C'est d'autant plus impossible que, sur de nombreuses questions, la jurisprudence luxembourgeoise, évidemment peu abondante compte tenu de la taille du pays, n'a jamais eu l'occasion de prendre position (ou ne l'a pas fait depuis très longtemps), et qu'on sera naturellement porté, pour combler les vides, à aller chercher les solutions et les opinions françaises (ou plus rarement belges). C'est pourquoi, dans la précédente édition de ce manuel, je me livrais à une comparaison systématique des solutions et des opinions doctrinales françaises et belges, soit pour aider à mieux situer les solutions luxembourgeoises lorsqu'elles existaient, soit, si elles n'existaient pas encore, pour offrir plusieurs alternatives au développement de la jurisprudence future.

Il faut sur tous ces points parler presque toujours à l'imparfait, car le paysage s'est complètement transformé depuis la première édition, avec l'entrée en vigueur, en France et en Belgique, de deux réformes d'ensemble du droit des obligations. Si, à l'époque, la réforme française était déjà bien avancée, et si l'ouvrage y faisait de constantes références, on ne connaissait pas encore la version définitive de ce qui devait devenir l'ordonnance de 2016. Quant à la réforme belge, elle était encore dans les limbes, et ce n'est qu'à partir de 2015 qu'a été entreprise une refonte d'ensemble du Code civil, dans le cadre de laquelle est intervenue la loi de 2022 entrée en vigueur le 1er janvier 2023 créant un nouveau Livre 5 relatif au droit des obligations. Il en résulte que, désormais, l'identité textuelle des trois codes en droit des obligations a complètement disparu, et que le droit luxembourgeois est devenu en quelque sort orphelin de ses modèles, et principalement du modèle français. Face à ce bouleversement, le ministère de la justice luxembourgeois a entrepris, en liaison avec l'Université du Luxembourg, de se lancer à son tour dans une réforme du droit des obligations. Une commission composée d'universitaires et de praticiens, dans laquelle l'auteur de ces lignes est tout particulièrement impliqué, prépare actuellement un avant-projet devant être soumis au ministère à la fin de l'année 2025. S'il paraît évident que, dans le cadre de cette réforme, le Luxembourg restera, comme la France et la Belgique du reste, dans le cadre conceptuel et méthodologique du système du Code civil de 1804, il devra décider dans quelle mesure il s'inscrit dans la ligne des réformes française et belge, et quelles solutions de l'un ou de l'autre droit il choisit de privilégier. Dans l'attente, le présent ouvrage doit donc mettre constamment

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Avant- propos de la deuxième édition, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 5-14
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

en relation les solutions luxembourgeoises actuelles non seulement avec les solutions antérieures retenues en France et en Belgique – en ce qu'elles peuvent encore servir de source d'inspiration aux tribunaux luxembourgeois – mais aussi avec les solutions nouvelles issues des réformes, qui peuvent servir de guide pour l'évolution future du droit luxembourgeois. Cela a naturellement imposé la refonte complète de nombreux développements axés sur les seules solutions antérieures françaises et belges.

Mais, même si le recours aux droits français et belge s'impose prioritairement au Luxembourg dans un souci de cohérence du système, on peut penser que, de nos jours, ces droits ne devraient plus y servir de référence exclusive, et que d'autres droits peuvent aussi être pris en considération dans l'optique de la réforme à venir. Rien n'interdit, en particulier, de regarder du côté des codes qui, issus à l'origine du Code Napoléon, ont évolué ou ont été refaits pour s'adapter aux transformations de la société et des idées, en intégrant parfois au passage des influences d'autres systèmes[2]. Rien n'interdit non plus, sur certains points au moins, de prendre en considération certaines solutions reçues dans les droits germaniques où, on le verra, le législateur luxembourgeois contemporain a lui-même été (à la marge) puiser quelques concepts. Et, bien sûr, rien n'interdit de s'inspirer des multiples projets qui fleurissent actuellement en matière de droit des contrats, qu'ils soient nationaux (notamment français), ou européens (Principes du droit européen du contrat, DCFR, Droit commun européen de la vente). Le « petit » Luxembourg, pays européen par excellence, pourrait ainsi, tout en restant fidèle au système conceptuel du Code civil, être un lieu privilégié de circulation des idées et des concepts juridiques des différents pays d'Europe (comme l'est actuellement son université) et un laboratoire d'expérimentation de certaines solutions européennes.

Cette nécessaire ouverture comparative, largement faite dans la précédente édition, et continuée dans celle-ci, doit contribuer à donner à cet ouvrage un caractère moins dogmatique que celui qu'ont habituellement les manuels de droit civil. Dans la tradition de l'enseignement du droit national, les auteurs de manuels (qui sont, le plus souvent, des professeurs) cèdent souvent à la tentation de vouloir délivrer à leur lecteur une sorte de « vérité » – dont

[2] On songe en particulier au Code civil du Québec, ou, dans le cadre européen, au Nieuw Burgerlijk Wetboek néerlandais de 1992 ou au récent Codul civil roumain.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Avant- propos de la deuxième édition, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 5-14
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

les étudiants, du reste, attendent très souvent la révélation. Que de fois, ayant indiqué en cours qu'il n'existait pas, sur tel ou tel point de jurisprudence au Luxembourg, et ayant exposé, principalement à partir de la jurisprudence et de la doctrine françaises et belges, les différentes solutions envisageables, ai-je entendu un(e) étudiant(e) me demander : « Alors c'est quoi, Monsieur, « la » solution ? ». Bien entendu, lorsqu'on enseigne et écrit à l'intérieur d'un système juridique aussi riche que l'est par exemple le droit français, où existent une multitude de textes interprétés et complétés par une jurisprudence foisonnante, il est rare qu'on ne puisse pas dire, au minimum, quelle est « la » solution reçue en droit positif (même si, en réalité, on construit souvent assez largement cette solution à travers des choix subjectifs, par exemple dans la sélection des décisions qu'on cite ou dans la lecture qu'on en fait). Par ailleurs, lorsqu'on est un acteur parmi d'autres d'une communauté doctrinale, on est naturellement amené à faire comme les autres, à donner son opinion sur telle ou telle solution, voire à soutenir, pour ses étudiants ou pour ses lecteurs, que la solution qu'on prône est la seule « bonne », voire la seule « vraie ». On contribue ainsi à inscrire dans la tête de ses étudiants ce qu'un auteur a appelé « le dogme de la solution unique »[3]. Curieusement, la mise en perspective historique des solutions, qui révèle leur constante évolution, n'aboutit pas toujours à remettre en cause ce dogme, soit parce qu'on présente l'évolution historique comme un constant progrès vers la « bonne solution » enfin découverte par la jurisprudence ou par les auteurs modernes, soit parce que, à l'inverse, on se réfugie dans une sorte d'essentialisme historique consistant à tenir pour seules « vraies » les conceptions qui ont été forgées par tel auteur prestigieux du passé et consacrées un temps par les textes ou les tribunaux, et à présenter comme autant de déviations les évolutions postérieures qui s'en écartent[4]. De même, les quelques éléments de droit comparé qu'on s'oblige aujourd'hui, fort heureusement, à donner aux étudiants ne contribuent guère à nourrir le relativisme à l'intérieur du système dans la mesure où les solutions étrangères, parce qu'elles se rattachent à un arsenal conceptuel différent, ne peuvent pas se dresser en rivales des solutions nationales.

3 M. BOUDOT, *Le dogme de la solution unique*, sous la direction de O. PFERSMANN, thèse, Aix-Marseille 3, 1999.

4 Pour un exemple caractéristique, voy. le célèbre (et remarquable) article de P. REMY, « La "responsabilité contractuelle" : histoire d'un faux concept », *RTD civ.*, 1997, p. 323.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Avant- propos de la deuxième édition, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 5-14
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Il en va tout autrement lorsque l'ouverture comparative s'impose en quelque sorte *ab initio*, non pour donner un éclairage rétrospectif au droit national, mais pour contribuer d'emblée à sa compréhension et à sa construction. Le dogmatisme paraît alors d'autant plus déplacé qu'on a, dans le cas du Luxembourg, constamment sous les yeux, pour combler les vides, des solutions différentes, consacrées comme « vraies » dans des droits nationaux différents (principalement le droit français et le droit belge), mais élaborées avant les réformes récentes à partir des mêmes textes, avec le même arsenal conceptuel, à l'intérieur du même système de pensée. Il est évidemment un peu difficile de soutenir, en présence de deux interprétations divergentes du même texte, non par deux auteurs français ou belges, mais par deux cours de cassation, que l'une était dans le vrai et l'autre dans l'erreur, alors surtout que ces interprétations jurisprudentielles et doctrinales différentes sont aujourd'hui passées dans les textes issus des réformes. On peut bien entendu mesurer les avantages et les inconvénients de l'une et de l'autre position, et conclure que l'une semble préférable à l'autre, mais on ne peut en aucune manière tenir sur la question un discours de vérité. L'auteur de ces lignes le peut d'autant moins que, compte tenu du contexte précédemment décrit, il était, à l'époque de la première édition, un des seuls professeurs à enseigner le droit luxembourgeois des contrats, sans être adoubé pour cela par une communauté doctrinale qui tire sa légitimité de la reconnaissance mutuelle que se portent ses membres. En l'absence d'une telle reconnaissance, il faudrait une prétention folle pour prétendre, à soi seul, révéler aux juges d'un pays dont on n'est même pas un ressortissant, lorsqu'ils ne se sont pas encore prononcés, quelle est « la » solution qu'ils doivent retenir, ou, s'ils en ont déjà donné une, leur délivrer une bonne ou une mauvaise note. Je cherche donc toujours, dans le présent ouvrage, à me tenir à distance de ce « dogme de la solution unique », et à centrer le discours sur les problèmes, et sur les différentes solutions qui semblent raisonnablement possibles, principalement, mais pas exclusivement, à l'intérieur du système « franco-belgo-luxembourgeois ».

Du coup, on peut espérer que ce manuel trouvera un public au-delà du cercle des étudiants en droit et des professionnels du droit au Luxembourg, et qu'il pourra, en raison de la comparaison presque systématique qu'il est amené à faire entre les interprétations

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Avant- propos de la deuxième édition, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 5-14
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

et les conceptions françaises, belges (et, lorsqu'elles existent, luxembourgeoises), intéresser certains juristes français ou belges, spécialement universitaires, qui pourraient y trouver des éclairages nouveaux de nature à revivifier quelques questions stérilisées par une pensée trop exclusivement nationale.

Il me reste, pour terminer ces longues explications, à remercier très sincèrement Zohra Mchirgui, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler dans le cadre du projet de réforme du droit luxembourgeois des contrats, et qui m'a apporté une aide précieuse dans la recherche de la jurisprudence récente des cours et tribunaux luxembourgeois, dans l'actualisation des références.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Avant- propos de la deuxième édition, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 5-14
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

1. Première idée du contrat. Au lieu que l'État (ou, plus largement, la collectivité compétente pour édicter les règles) fixe d'en haut, de manière autoritaire, les droits et les obligations des individus, il peut leur laisser une certaine autonomie pour le faire eux-mêmes, par les accords qu'ils passent entre eux, sachant que ces accords vont lier les parties, vont leur imposer des droits et des obligations comme si c'était la loi elle-même qui leur avait imposé. C'est ce type d'accord par lequel des personnes organisent elles-mêmes leurs relations, d'une manière qui les engage, qu'on appelle con24trat. Par exemple, au lieu d'attendre de devenir propriétaire d'une maison par l'effet du décès de vos parents (dont vous hériterez par l'effet de la loi), vous pouvez, dès maintenant, acheter une maison que vous aurez choisie, à un prix que vous aurez déterminé par accord avec le vendeur. Ce contrat vous rendra propriétaire comme si c'était la loi qui vous l'avait attribué, et fera perdre la propriété au vendeur, mais vous ne pourrez pas, en contrepartie, échapper au paiement du prix que vous aurez stipulé ni le faire modifier. Le contrat apparaît ainsi comme un *mode de régulation « horizontale »* à disposition des acteurs sociaux par opposition à la régulation « verticale », telle qu'elle s'exprime par les différents actes unilatéraux émanant de l'État et des personnes publiques (lois, règlements, décisions administratives).

2. Importance du phénomène contractuel. Un rapide recensement des « choses » qui se nomment elles-mêmes contrats ou qui sont considérées comme des contrats fait prendre conscience de la présence importante du phénomène contractuel dans notre société – comme d'ailleurs dans toute société du monde contemporain. On note d'emblée la diversité de ses utilisations : le contrat permet ainsi d'organiser la production des biens et des services (en se groupant avec d'autres dans une société pour avoir des capitaux suffisants, en embauchant des salariés par des contrats de travail, en achetant des matières premières destinées à la production, en faisant venir de tels biens d'autres régions ou d'autres parties du monde grâce à des contrats de transport de marchandises, etc.), de consommer (en achetant des biens destinés à la nourriture, à l'habillement, etc.), de se loger (soit en achetant, soit en louant une maison ou un appartement), de se déplacer (en passant des contrats de transport avec la compagnie de chemin de fer, d'autobus, ou avec la compagnie aérienne), de régler ses litiges (en transigeant sur la réparation d'un dommage qu'on vous a causé par exemple), etc. Les exemples donnés montrent, par ailleurs, que le contrat n'est pas seulement

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 17-21
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

un instrument d'échanges de biens et de services à l'intérieur d'un état déterminé, mais qu'il est également utilisable pour organiser des relations transfrontières – par exemple lorsque le ressortissant d'un pays achète un bien à un vendeur situé sur le territoire d'un autre pays (notamment par la voie du commerce électronique), lorsqu'une personne voyage d'un pays à l'autre, lorsqu'une société est constituée entre des personnes de nationalité différente, etc. Cette internationalisation du contrat est particulièrement importante dans un pays comme le Luxembourg, tant en raison de sa petite taille (qui amène quotidiennement de multiples échanges avec les pays voisins) que de la nature de ses principales activités économiques, essentiellement internationales.

3. Rôles respectifs du contrat et de la loi dans l'organisation sociale. Selon les époques, et selon les pays, le contrat, en tant que mode de régulation laissé à l'initiative des acteurs, a pu et peut avoir une place plus ou moins importante dans l'organisation sociale par rapport à la régulation verticale, venant d'en haut, dont le modèle est la loi. Cette question des rôles respectifs du contrat et de la loi apparaît d'emblée comme la question fondamentale, éminemment politique, qui domine toute la matière. Aucune société ne peut, à l'évidence, fonctionner exclusivement à partir de l'un ou de l'autre mode. Une société où les individus seraient entièrement libres de régler leurs relations par leurs accords privés et où rien ne serait décidé par la loi (sinon cette règle de liberté absolue), virerait très vite à l'anarchie. À l'inverse, un monde où l'État déciderait de tout pour ses sujets, sans jamais tenir compte de leurs choix de vie personnelle, serait irrespirable. Toute société est donc organisée sur la base d'un mélange entre les deux modes de régulation, la régulation horizontale par le contrat et la régulation verticale par la loi, en tirant plus ou moins d'un côté ou de l'autre : entre le libéralisme économique effréné qui dominait dans l'Europe du XIXe siècle et le communisme totalitaire de l'ex URSS où tous les échanges économiques étaient planifiés par l'État, il y a une grande distance, et une place pour toutes sortes de formules intermédiaires. Plus précisément, les choix politiques en faveur du « plus de contrat » ou du « plus de lois » peuvent se situer sur deux plans complémentaires. D'une part, il faut déterminer quels sont les domaines de la vie sociale qui sont ouverts aux accords contractuels. De ce point de vue, on observe que, dans toutes les sociétés, certains secteurs étaient traditionnellement considérés comme relevant du monopole

LARCIER INTERSENTIA
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 17-21
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

de l'État, et soustraits en conséquence aux accords privés : ainsi en allait-il, par exemple, de la justice ou de l'organisation familiale. On constate aujourd'hui une tendance, dans les pays occidentaux du moins, à ouvrir ces domaines aux accords contractuels – phénomène qu'on désigne souvent sous le nom de « contractualisation » de la société[5]. Par exemple, en matière familiale, où le seul accord de volontés traditionnellement admis était le mariage (dont les effets étaient et sont encore largement entièrement régis par la loi), on permet parfois aujourd'hui au couple d'organiser contractuellement sa vie commune ou ses relations avec ses enfants. De même, le monopole régalien de la justice est aujourd'hui battu en brèche par la reconnaissance, et la promotion par l'État lui-même, de ce qu'on nomme les « modes alternatifs de règlement des différends » (arbitrage, médiation, conciliation, etc.) qui reposent principalement sur des contrats entre les parties au litige. D'autre part et surtout, dans les domaines où le contrat est admis comme mode normal d'organisation sociale, se pose la question de savoir jusqu'où peut aller la liberté, l'autonomie reconnue aux parties. On sent bien que cette liberté ne peut jamais être totale, et que d'impérieux motifs d'intérêt social s'opposent au développement sans frein des initiatives individuelles : aucun système juridique, par exemple, ne peut admettre la validité d'un contrat par lequel on paierait quelqu'un pour tuer une autre personne. Mais, au-delà de ces limites minimales, on peut concevoir que l'État aille plus ou moins loin dans les exigences imposées aux contractants, par exemple, en fixant un loyer maximum dans les contrats de bail, en interdisant des clauses par lequel un vendeur exclurait sa garantie pour les défauts de la chose qu'il vend, en imposant la fixation d'un délai minimum de préavis à l'employeur qui veut licencier son salarié, etc. Ces solutions techniques sont l'expression de choix fondamentaux de politique juridique que nous retrouverons tout au long de cet ouvrage, mais dont il est nécessaire de souligner l'importance dès le début.

4. Diversité des conceptions du contrat. Même s'il n'a pas eu toujours, et s'il n'a pas partout, la même importance, le contrat est un mode d'organisation sociale qui existe depuis très longtemps[6], et qui

5 Voy. sur ce phénomène, au sein d'une littérature abondante : S. CHASSAGNARD-PINET et D. HIEZ (dir.), *Approche renouvelée de la contractualisation*, Aix-en-Provence, PUAM, 2003 et S. CHASSAGNARD-PINET et D. HIEZ (dir.), *Approche critique de la contractualisation*, Paris, LGDJ, 2007.

6 On trouve mention d'accords de volontés organisant des relations entre individus dans le Code d'Hammourabi (1750 avant J.-C.).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 17-21
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

est connu aujourd'hui de tous les systèmes juridiques. Cependant, il en va du contrat comme du mariage : toutes les sociétés, tous les systèmes juridiques ne l'ont pas conçu (et ne le conçoivent pas) de la même manière[7].

En droit romain (qui est à l'origine de nombreuses règles du Code civil passées dans le droit luxembourgeois moderne), le contrat était conçu, à l'origine du moins, comme un acte formaliste, une sorte de rite quasi-religieux : les parties n'étaient tenues que si elles s'étaient engagées en suivant le rite. Ce n'est que progressivement, tout au long de l'Ancien droit français, qu'on s'est dégagé de ce formalisme pour faire du contrat, principalement, un accord de volontés, un échange de promesses : les contractants sont tenus parce qu'ils l'ont voulu, parce qu'ils ont donné leur parole. C'est le principe du consensualisme qui s'exprime à travers la célèbre formule de Loysel : « On lie les bœufs par les cornes et les hommes par des paroles »[8]. À partir de là s'installe l'idée que, ce qui est essentiel dans le contrat, c'est la volonté de ceux qui le passent, et on va même jusqu'à fonder sur cette seule volonté la force obligatoire du contrat. Même si cette idée ne correspond plus guère au droit des contrats modernes, elle influence profondément encore notre manière de penser.

Mais cette conception qui met au premier plan l'accord de volontés, l'échange de promesses, n'est pas aussi universelle qu'on pourrait le croire. Dans les droits de *common law* (droit anglais et droits dérivés), le contrat est plutôt conçu comme un échange économique, un marché, et c'est de cela qu'il tire sa force (pas seulement de ce qu'il a été voulu). Celui qui s'engage n'est tenu par son engagement contractuel que s'il a reçu quelque chose en échange – d'où l'exigence, en *common law*, à côté de l'accord de volontés des parties, d'une contrepartie à l'engagement, la *consideration*. Il va en résulter que la catégorie « *contract* » en droit anglais, est plus étroite que celle des contrats dans les pays du Code civil : elle n'inclut pas les accords dans lesquels une seule partie s'engage sans rien recevoir en échange (par exemple une donation). Cette conception économique du contrat amène, également, une organisation assez

7 Sur les différentes conceptions du contrat en Europe, voy. C. JAUFFRET-SPINOSI, « Les grands systèmes contractuels européens », in R. CABRILLAC, D. MAZEAUD, A. PRÜM (dir.), *Le contrat en Europe, aujourd'hui et demain*, coll. Droit privé comparé et européen, vol. 8, Paris, Société de législation comparée, 2007, pp. 9 et s. ; H. KÖTZ, B. FAUVARQUE-COSSON, C. SIGNAT et D. GALBOIS-DEHALLE, *Droit européen des contrats*, Paris, Sirey, 2019.

8 A. LOYSEL, *Institutes coutumières*, 1607.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 17-21
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

différente des sanctions de l'inexécution des obligations assumées par les parties, qui seront davantage centrées sur l'octroi d'une compensation pécuniaire que sur l'exécution forcée de la promesse qui, on le verra, domine le droit luxembourgeois.

5. Plan de l'introduction. Tous ces développements de départ ne sont que des notations très superficielles, sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, mais elles permettent d'ores et déjà de comprendre que la manière dont le contrat est défini et réglementé en droit luxembourgeois est éminemment relative. On doit garder cela à l'esprit lorsqu'on découvre la matière. Nous le ferons en quatre étapes : dans un premier temps, nous présenterons les sources du droit des contrats au Luxembourg (**Chapitre I**), nous approfondirons ensuite la notion de contrat (**Chapitre II**), avant de présenter les différents types de contrats (**Chapitre III**). Nous terminerons en exposant les grands principes qui dominent la matière, et qui constituent les fondements du droit des contrats (**Chapitre IV**).

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 17-21
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Chapitre I
Les sources du droit luxembourgeois des contrats

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

6. Problématique des sources. Il n'est pas d'usage, dans les manuels, de commencer l'exposé d'une matière par ses sources. La plupart des manuels de droit des contrats commencent par définir les grandes notions (l'obligation, le contrat, l'acte juridique, etc.), par présenter les classifications des contrats (contrats synallagmatiques et unilatéraux, à titre onéreux et à titre gratuit, etc.), puis à exposer les grands principes qui dominent la matière (la liberté contractuelle, la force obligatoire, etc.), et ce n'est généralement qu'en fin d'introduction que la question des sources – où trouve-t-on les règles ? – est, éventuellement, abordée. Cette démarche n'est cependant pas très rationnelle, si on admet que ces grandes notions, ces classifications, ces principes généraux, n'existent pas en tant que tels dans la réalité concrète. Ce ne sont que des constructions intellectuelles – éminemment relatives comme on l'a vu – qui trouvent leur origine dans des textes légaux ou réglementaires, des interprétations jurisprudentielles et des écrits doctrinaux, parfois dans des coutumes et des pratiques – tout ce qu'il est convenu d'appeler les « sources du droit ». C'est donc, logiquement, par l'exposé de ces sources qu'il convient de commencer l'étude de toute matière, et, en particulier, celle du droit des contrats.

7. Évolution des sources. Le droit des contrats, au Luxembourg comme dans les autres pays européens, connaît actuellement un profond bouleversement de ses sources. Longtemps purement national (**Section 1**), il intègre en effet aujourd'hui de multiples sources internationales et européennes (**Section 2**).

SECTION 1. LES SOURCES NATIONALES

8. Droit textuel et interprétation. Le droit des contrats, au Luxembourg, est d'abord un droit écrit, qui trouve sa source première dans la loi, et même un droit codifié, dont les assises se trouvent dans le Code civil (**§ 1**). Mais ces sources textuelles ne seraient rien sans l'interprétation qui en a été faite, et qui continue d'en être faite par la jurisprudence et la doctrine (**§ 2**).

§1. Les sources textuelles

9. Code civil et autres textes. C'est dans le Code civil, d'abord imposé par l'occupant français à l'époque napoléonienne puis conservé lors de l'accession du Luxembourg à l'indépendance, que

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

se trouvent les bases de la matière. Mais, depuis le XIX[e] siècle, et surtout dans la période récente, le Code a été complété par de nombreux textes spéciaux, qui sont restés à l'état de lois séparées, ou qui ont été rassemblées dans d'autres codes.

A) *Le Code civil*

10. Racines historiques du Code civil en matière contractuelle. Parce qu'il a reçu et conservé le Code Napoléon, le Luxembourg s'inscrit, en droit des contrats comme dans la plupart des matières de droit privé, dans la tradition historique française. Sans qu'il soit utile de consacrer de longs développements à cet arrière-plan historique, qui n'est pas spécifiquement luxembourgeois[9], il faut rappeler que le Code est le produit du croisement de règles d'origines très diverses : d'une part, il s'inscrit dans le prolongement de l'Ancien droit français, produit lui-même d'un mixage, lentement acquis au cours du temps, de règles de droit romain, de coutumes d'origine germanique, de grands principes de droit naturel dégagés par la doctrine des XVII[e] et XVIII[e] siècles, de quelques solutions du droit canonique, et de nombreux textes édictés par l'autorité royale ; d'autre part, il incorpore, à des degrés variables selon les matières, les principes de liberté et d'égalité éclos lors de la période révolutionnaire. On retrouve, en droit des contrats, ce mélange d'influences. De très nombreuses solutions techniques trouvent ainsi leur origine en droit romain, notamment quant au régime des obligations nées du contrat (ce que traduit de manière très visible l'utilisation, en la matière, de nombreux termes issus du latin : subrogation, dation, novation, dol, etc.). Mais ces solutions se sont profondément transformées au cours des siècles, par le mélange avec des règles d'autres origines. La synthèse des solutions admises en droit français à la veille de la Révolution française avait été faite par Pothier, dans son important Traité des obligations[10], dont se sont inspirés sur de très nombreux points les auteurs du Code civil. Sur le fond, d'une manière générale, l'esprit du droit des contrats dans le Code civil est très différent de celui du droit romain. Comme on l'a déjà dit, à la conception formaliste du droit romain, le Code a substitué une conception consensualiste, qui fait reposer le contrat sur

[9] Sur l'histoire du droit des obligations (largement commune aux trois pays du Code civil), voy. D. DEROUSSIN, *Histoire du droit des obligations*, 2[e] éd., Paris, Economica, 2012 (cité *infra*, DEROUSSIN).

[10] R.-J. POTHIER, *Traité des obligations*, 1[re] éd., 1761. Réédition : Paris, Dalloz, 2011, préface J.-L. HALPERIN.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'échange des promesses, sur l'accord de volontés, et qui s'était développée lentement au fil des siècles dans l'Ancien droit, à partir de considérations empruntant à la fois au droit canonique fondé sur la morale chrétienne et au droit naturel qui met en avant la raison et la toute-puissance de l'individu. C'est sur cet accord de volontés qu'est fondée, dans le Code, la force obligatoire du contrat, grand principe dont les rédacteurs du Code sont allés chercher la formulation célèbre « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (C. civ., art. 1134), chez Domat, auteur français du XVII[e] siècle représentatif de l'École du droit naturel[11]. Le principe de la liberté contractuelle, qui limite à un petit nombre de règles l'intervention de l'État dans les rapports de droit privé est quant à lui un acquis du Siècle des Lumières, qui a triomphé lors de la Révolution française avec l'affirmation de la liberté du commerce et de l'industrie et qui a servi de base au développement du libéralisme économique.

L'entrée en vigueur du Code civil a en principe fait disparaître toutes les règles antérieures (coutumes, ordonnances royales, droit canonique, etc.). Cependant, en droit des contrats comme dans d'autres matières, la doctrine et la jurisprudence modernes, dans les trois pays du Code civil, continuent de se référer à certaines règles de l'Ancien droit, exprimées sous forme d'adages ou de maximes, souvent en langue latine. Nous rencontrerons ainsi, au fil des développements, les adages *Nemo auditur propriam turpitidem allegans* (nul n'est admis à se prévaloir de sa propre turpitude), *Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum* (ce qui est temporaire par voie d'action est perpétuel par voie d'exception), *Contra non valentem agere non currit praescriptio*, etc. Ces règles, parfois visées par la Cour de cassation française dans ses décisions, comme des « principes », n'ont en réalité aucune valeur normative par elles-mêmes. Elles ne valent que ce que la jurisprudence moderne veut leur faire dire – et nous verrons que l'interprétation n'en est pas toujours la même dans les trois pays du Code civil[12].

11. Place du droit des contrats dans le Code civil. Le droit des contrats est réglementé dans le Code, dans le Livre III, venant après le Livre II consacré aux biens (Des biens et des différentes modifications de la propriété) et intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ». Cet intitulé peut surprendre, si on considère que de très nombreux contrats produisent des effets tout autres que de faire acquérir la propriété : il suffit de songer au contrat de bail, dans lequel le locataire paye pour avoir la jouissance d'un bien dont il ne deviendra jamais propriétaire. Au-delà de l'importance que revêtait pour les rédacteurs du Code le droit de propriété – qui

11 J. Domat, *Les lois civiles dans leur ordre naturel*, 1689.

12 Par exemple à propos de *Nemo auditur,* voy. *infra*, n° 467.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

apparaît ainsi comme un pivot de l'ensemble du droit civil – cet intitulé s'explique parce que les auteurs ont réglementé le droit des contrats en pensant principalement au cas particulier de la vente (qui n'est qu'un des contrats parmi bien d'autres, même s'il est le plus important en pratique), et parce que, comme nous le verrons plus loin, dans la conception du Code civil, la vente a pour effet direct d'opérer le transfert de propriété (ce qui n'est pas le cas, loin de là, dans tous les systèmes juridiques).

Plus précisément, dans le Livre III, le droit des contrats occupe principalement le Titre III, intitulé « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » (C. civ., art. 1101 à 1369)[13], qui est consacré aux règles générales qui s'appliquent à tous les contrats, quels qu'en soient la nature et l'objet – ce qu'on appelle traditionnellement le « droit commun des contrats ». Plus loin dans le Code, après avoir traité des « engagements qui se forment sans convention », puis des régimes matrimoniaux, les rédacteurs ont posé les règles spéciales applicables à différents contrats particuliers : la vente, le bail, le mandat, le prêt, le dépôt, le cautionnement, etc. (Titres VI et s.)[14].

12. Évolution des textes du Code civil sur le contrat. Au Luxembourg, ces textes relatifs aux contrats n'ont pas été beaucoup modifiés – surtout si on considère les articles 1101 à 1326 du Code civil posant les règles générales, qui font l'objet du présent ouvrage. Plus de 90 % des articles demeurent dans leur état d'origine, et il en allait de même, jusqu'à une période récente, en France et en Belgique, de sorte que les textes en la matière étaient très largement identiques dans les trois pays. Au Luxembourg, les principales modifications datent des cinquante dernières années. Certaines sont un quasi-recopiage de réformes françaises : il en va ainsi de la réforme de la clause pénale (clause fixant le montant des dommages et intérêts dus par une partie en cas d'inexécution de ses obligations)[15] intégrée à l'article 1152 et aux articles 1226 et suivants, du Code civil, par la loi du 15 mai 1987. D'autres ont été plutôt reprises de la Belgique : ainsi de la réforme de la cession de créance (C. civ., art. 1689 et s.) résultant d'une loi du 21 décembre 1994 fortement inspirée d'une loi belge édictée quelques mois auparavant ; ainsi

13 Sauf indication contraire, les textes du Code civil cités sont ceux du Code civil du Luxembourg.

14 Sur cette distinction entre règles générales et règles spéciales aux différents contrats, voy. *infra*, n° 78.

15 Voy. *infra*, n°s 866 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

également des textes sur l'astreinte (condamnation judiciaire d'un débiteur à payer une somme d'argent par période de retard dans l'exécution de ses obligations)[16], dont la formulation actuelle, datant de 1976, est le fruit de la transposition au Luxembourg d'un acte uniforme aux trois pays du Benelux. Mais certaines modifications sont spécifiquement luxembourgeoises : il faut ici surtout citer la très importante loi du 15 mai 1987 qui, outre la réforme de la clause pénale déjà citée, a créé de nouveaux articles relatifs à l'inexécution des obligations contractuelles (mise en demeure, exception d'inexécution) et, surtout, a introduit dans le Code civil divers mécanismes de protection des contractants faibles très inspirées du droit allemand (lésion qualifiée de l'article 1118 du Code civil, réglementation des conditions générales des contrats dans l'article 1135-1 du Code civil). Cette influence allemande reste cependant très exceptionnelle, et, d'une manière générale, le Code civil du Luxembourg, en matière contractuelle, était, jusqu'à la réforme française, presque identique au Code civil français.

13. Réforme du droit des obligations en France. Cette très faible distance textuelle entre le Code civil du Luxembourg et le Code françaisa cependant été complètement remise en cause à la suite de la réforme complète, en 2016, de la partie consacrée au droit des contrats dans le Code civil français. Une telle réforme, dont il était question depuis longtemps, avait d'abord été envisagée comme une partie de la révision générale du Code civil, envisagée dès le début du XXe siècle à l'occasion du centenaire du Code, et remise à l'ordre du jour au lendemain de la seconde guerre mondiale, avec la nomination en 1945 d'une commission de révision du Code civil. Mais les travaux de cette commission s'étant enlisés, Il avait été décidé, à partir du début des années 1960, de procéder à la révision du Code par petits morceaux, en commençant par les matières qui semblaient les plus urgentes. C'est ainsi que le droit de la famille connut, à partir de ces années, un nombre important de réformes qui ont complètement remodelé le Code civil tant en ce qui concerne les aspects personnels des relations familiales (mariage, divorce, filiation) que leurs aspects patrimoniaux (successions, régimes matrimoniaux) – réformes qui ont du reste, en partie, influencé le Luxembourg. Le droit des contrats n'a cependant été que très peu affecté par ces réformes, sauf sur quelques points de détail, et le législateur français

16 Voy. *infra*, n° 746.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

semblait avoir renoncé à une réforme d'ensemble, peut-être dans l'attente d'une réglementation européenne. Cependant, la question a ressurgi à l'occasion du bicentenaire du Code civil en 2004. Un certain nombre d'auteurs se sont émus du décalage existant entre les textes de 1804 et la réalité du droit des contrats (et plus généralement du droit des obligations[17]), et, dans l'objectif de rendre le droit français plus lisible et plus attractif, ont souhaité une réforme d'ensemble, tendant au minimum à mettre en harmonie la lettre du Code avec les évolutions jurisprudentielles considérables survenues depuis 1804. Devant l'inertie des pouvoirs publics, plusieurs groupes doctrinaux se sont alors constitués pour élaborer des propositions de textes. Un premier groupe, animé par P. Catala, a abouti en 2006 à la rédaction d'un avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription[18], tandis qu'un second groupe, constitué par F. Terré, a plus récemment publié trois projets de réforme du droit des contrats, du droit de la responsabilité civile et des règles générales du droit des obligations[19]. Le premier de ces avant-projets avait, dans un premier temps, inspiré une importante réforme du droit de la prescription, intervenue en 2008. S'agissant du droit des contrats, la réforme attendue a davantage tardé. Après avoir diffusé en 2008 un premier projet de réforme, amendé en 2009, qui avait suscité beaucoup de critiques de la part de la doctrine, le Ministère de la justice français a présenté, au début de l'année 2015, un nouveau projet, qui tentait de faire une sorte de synthèse entre les précédents. Ce projet, après diverses modifications, a finalement été adopté par une ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Conformément au droit constitutionnel français, cette ordonnance (adoptée sans vote par le Parlement, sur la base d'une habilitation législative préalable) a été ultérieurement ratifiée, non sans quelques modifications, par une loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, qui est elle-même entrée en vigueur

[17] Nous verrons plus loin que le droit des contrats est regardé dans le système franco-belgo-luxembourgeois comme une partie du droit des obligations, regroupant les règles relatives à la naissance et aux effets d'un rapport entre un créancier et un débiteur. Le droit des obligations comprend notamment, à côté du droit des contrats, le droit de la responsabilité civile.

[18] P. CATALA, *Rapport sur l'avant-projet de réforme du droit des obligations (Articles 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription (Articles 2234 à 2281 du Code civil)*, Paris, La Documentation française, 2005 (cité *infra*, « Projet Catala »).

[19] F. TERRÉ (dir.), *Pour une réforme du droit des contrats*, Paris, Dalloz, 2008 ; Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Dalloz, 2011 ; Pour une réforme du régime général des obligations, Dalloz, 2013, coll. Thèmes et commentaires (cité *infra*, « Projet Terré »).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

le 1er octobre 2018[20]. Même si cette réforme, au-delà de quelques nouveautés importantes, est d'abord une codification des solutions jurisprudentielles antérieures, les juristes du Luxembourg ne peuvent pas rester indifférents à la nouvelle rédaction du Code civil français, dès lors que, nous le verrons, la jurisprudence et la doctrine française constituent traditionnellement la source d'inspiration principale des tribunaux luxembourgeois. Dans l'attente d'une éventuelle réforme luxembourgeoise, ces derniers devront se demander s'ils continuent de suivre les solutions jurisprudentielles anciennes, ou s'ils doivent s'inspirer plutôt des nouvelles solutions, dans la mesure où elles sont compatibles avec le texte actuel du Code.

14. Réforme du droit des obligations en Belgique. La question se pose avec d'autant plus d'acuité que, de son côté, le législateur belge a lui aussi procédé, très récemment, à une importante réforme du droit des obligations. À la différence de la France, cette réforme s'inscrit dans une réforme d'ensemble du Code civil, qui se trouve désormais, dans ses parties refaites, complètement restructuré. Le droit des obligations fait désormais l'objet du livre 5 du nouveau code, résultant d'une loi du 28 avril 2022 et entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Comme en France, la responsabilité extracontractuelle avait été laissée en dehors de la réforme, mais cette matière a fait l'objet d'une loi du 7 février 2024, portant le livre 6 du nouveau Code civil, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. À la différence de la France, le livre 5 ne contient pas non plus les règles sur la preuve des obligations, qui ont été réformées en 2019, et qui font l'objet d'un livre 8 du nouveau code. En conséquence de cette restructuration d'ensemble, la numérotation des articles du Code civil belge s'est trouvée complètement bouleversée. Les concepteurs de la réforme, suivant le modèle néerlandais, ont adopté une numérotation distincte pour chaque livre : ainsi, dans le livre 5, les articles 5-1 à 5-270 prennent la place des articles 1100 à 1314 du Code civil originaire (toujours en vigueur au Luxembourg).

[20] Sur les apports de la réforme française voy : F. Chenede, *Droit des obligations et des contrats : consolidations, innovations, perspectives*, 3e éd., Paris, Dalloz, 2023 ; O. Deshayes, Th. Genicon et Y.M. Laithier, *Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : commentaire article par article*, 2e éd., Paris, LexisNexis, 2018 ; N. Dissaux et C. Jamin, *Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 : commentaire des articles 1100 à 1386-1 du Code civil*, Paris, Dalloz, 2016 ; N. Dissaux et C. Jamin, *Réforme du droit des contrats : 10 articles à connaître*, Paris, Dalloz, 2018.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Sur le fond, les solutions du nouveau droit des obligations belge sont dans une large mesure, comme en France, la mise en forme textuelle des solutions antérieures telles qu'elles résultaient des évolutions jurisprudentielles[21]. Dans la mesure où, comme nous le verrons tout au long de cet ouvrage, la jurisprudence belge s'était, sur un certain nombre de points, écartée du modèle français, ces différences se retrouvent dans les textes issus de la réforme. De même, les innovations consacrées par la réforme belge révèlent quelques différences avec celles reçues en France. Quoi qu'il en soit, il est clair que les tribunaux luxembourgeois ne peuvent plus directement se référer aux solutions belges, comme ils le faisaient parfois avant la réforme.

15. Vers une réforme du droit des contrats au Luxembourg. La perte, ou du moins la profonde transformation des modèles de référence, en même temps que le souci de ne pas faire apparaître le droit luxembourgeois des contrats comme un droit vieilli, semblent avoir convaincu la plupart des juristes luxembourgeois de la nécessité d'une réforme d'ensemble de la matière. Lors des Assises du Code civil organisées par l'Université du Luxembourg et le Ministère de la justice en 2021, les réponses à un questionnaire adressé aux membres de la communauté juridique faisaient ressortir une forte majorité en faveur du caractère prioritaire de la réforme du droit des obligations[22]. Suite à ces Assises, un processus de réforme a été mis en place dans le cadre d'une convention passée entre le ministère et l'Université. Ce processus repose sur des groupes de réflexion ouverts à toutes les personnes intéressées, chargés d'élaborer des propositions de textes ultérieurement soumis au ministère. Un tel groupe, consacré à la réforme de la prescription extinctive, a fonctionné depuis le second semestre 2022 et le projet de texte a été soumis au ministère fin 2023. Un second groupe a été mis en place, pour une durée de deux ans, en juillet 2023 pour réfléchir à la réforme du droit des contrats. Il sera ultérieurement doublé d'un troisième groupe chargé de la réforme du régime général de l'obligation.

21 Sur la réforme belge voy. R. JAFFERALI (coord.), *Le livre 5 du Code civil et le nouveau droit des contrats*, coll. UB3, Bruxelles, Larcier, 2022 ; I. CORBISIER, *La réforme du droit belge des contrats dans la perspective du droit luxembourgeois*, coll. Les dossiers du Journal des tribunaux Luxembourg, Bruxelles, Larcier, 2023.

22 Voy. P. ANCEL, « Quelles réformes pour le Code civil luxembourgeois ? Rapport de synthèse sur la deuxième session des assises du Code civil », *J.T.L.*, 2022/5, 15 octobre 2021, pp. 133-138

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

B) *Les autres textes*

16. Autres codes et autres lois. Il ne faudrait pas oublier, d'abord, que, dès l'origine, une partie des textes du droit des contrats se trouvait (et se trouve toujours) dans un autre code de l'époque napoléonienne, également conservé par le Luxembourg, le Code de commerce de 1807. Si ce code, au Luxembourg comme en France, a été largement vidé de sa substance depuis la fin du XIXe siècle, il conserve certaines règles particulières aux contrats commerciaux, comme les règles de preuve (C. comm., art. 109) et de prescription (C. comm., art. 189) ; certains contrats particuliers y sont également réglementés (le transport de marchandises, le contrat de commission). Mais, depuis la fin du XIXe siècle, et de manière accélérée dans la période récente, de très nombreuses lois sont intervenues en matière contractuelle, sans être intégrées dans le Code civil – soit qu'elles restent à l'état de lois séparées, soit qu'elles s'intègrent dans d'autres codes de création postérieure aux codes napoléoniens. Beaucoup de ces textes extérieurs au Code civil concernent des contrats particuliers : on citera par exemple la loi du 21 septembre 2006 sur le bail d'habitation (qui déroge sur de nombreux points aux articles 1713 et suivants du Code civil), et, surtout, les nombreuses lois réglementant le contrat de travail – qui ne faisait l'objet, dans le Code civil, sous le nom de « louage de services » que de deux articles (C. civ., art. 1780 et 1781) – et qui ont été rassemblées en 2006 dans un code particulier, le Code du travail. Mais d'autres textes sont des textes transversaux, qui touchent au droit commun des contrats. On citera par exemple la loi du 14 août 2000 sur le commerce électronique, ou la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement des particuliers. Cette dernière se rattache à un bloc particulièrement important de lois récentes, les lois de protection des consommateurs, dont beaucoup sont la transposition de directives européennes, et qui ont été, en partie, rassemblées en 2011 dans un nouveau Code de la consommation. On ne saurait, aujourd'hui, traiter du droit des contrats sans y intégrer les solutions de ces codes et de ces lois spéciales – qui montrent, déjà, que la stabilité du Code civil en la matière est assez illusoire. Elle l'est encore bien plus si on considère l'importance que revêtent, en droit des contrats, les sources interprétatives que sont la jurisprudence et la doctrine.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§ 2. Les sources interprétatives

A) *La jurisprudence*

17. Interprétation et comblement des lacunes. Encore que l'œuvre des rédacteurs du Code Napoléon ait été, à juste titre, universellement admirée, elle a dû, au fil du temps, être complétée par les décisions des tribunaux. Portalis, le principal auteur du code de 1804, l'anticipait déjà, du reste, dans son célèbre Discours préliminaire : « Un code, quelque complet qu'il puisse paraître, n'est pas plutôt achevé, que mille questions inattendues viennent s'offrir au magistrat […]. De là, chez toutes les nations policées, on voit toujours se former, à côté du sanctuaire des lois, et sous la surveillance du législateur, un dépôt de maximes, de décisions et de doctrines qui s'épure journellement par la pratique et par le choc des débats judiciaires, qui s'accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui a constamment été regardé comme le vrai supplément de la législation »[23]. Même si, pendant la première moitié du XIXe siècle, la doctrine dite de l'exégèse avait oublié ces sages paroles et faisait semblant de croire que toutes les solutions étaient dans le Code ou pouvaient en être déduites, il a bien fallu admettre, à la fin du XIXe siècle, que la jurisprudence avait un rôle essentiel à jouer dans l'élaboration des solutions du droit positif. En matière contractuelle, dans les trois pays du Code civil, ce rôle s'est développé sur deux plans. D'une part, il a fallu, au fil du temps, combler un certain nombre de lacunes, régler des questions qui n'avaient pas été abordées par le Code ou ne l'avaient été que partiellement : en particulier, les rédacteurs du Code étaient restés complètement silencieux sur le processus de formation du contrat (la rencontre de l'offre et de l'acceptation) ainsi que sur les relations des parties pendant la période précédant la formation du contrat (période de négociations). De même, ils n'avaient réglé que par quelques textes très éclatés la question des sanctions du défaut des conditions de validité des contrats. Jusqu'aux récentes réformes des textes en France et en Belgique, ces questions relevaient donc principalement de règles jurisprudentielles, et c'est toujours le cas au Luxembourg. D'autre part, sur les points réglés par la loi, la jurisprudence a, au fil du temps, considérablement fait évoluer l'interprétation des textes, en fonction de la transformation des relations économiques et sociales

[23] J.-E. PORTALIS, *Discours préliminaire sur le projet de Code civil*, présenté le 1er Pluviôse an IX (ce texte fondamental est accessible sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

depuis le début du XIXe siècle, et de l'évolution des conceptions et des valeurs dominantes. C'est ainsi que des notions cadres du droit des contrats, comme celles d'ordre public et de bonnes mœurs (C. civ., art. 6), celle de bonne foi (C. civ., art. 1134, al. 3), ou celle de cause (C. civ., art. 1131) n'ont plus aujourd'hui le même contenu qu'elles avaient pour les juges de l'époque du Code : sans entrer pour l'instant dans le détail des solutions, on notera simplement que ces notions générales ont permis d'intégrer dans le droit des contrats modernes l'idée de protection des contractants en situation de faiblesse, presque complètement absente des préoccupations des rédacteurs du Code. Sur certains points, on peut observer que la jurisprudence n'a pas hésité à aller ouvertement contre le sens explicite des textes : ainsi lorsque, à l'encontre de la lettre de l'article 1142, du Code civil qui indique que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur », la jurisprudence affirme que le créancier victime de l'inexécution a le droit de contraindre son débiteur à l'exécution en nature ; ou encore lorsque, dans la période récente, la jurisprudence affirme que la résolution du contrat pour inexécution (c'est-à-dire son anéantissement) peut être déclarée de manière unilatérale par le créancier, alors que l'article 1184 du Code civil pose que « la résolution doit être demandée en justice ». Même si ces interprétations « déformantes » sont moins nombreuses ici que dans le domaine voisin de la responsabilité civile, il n'est pas exagéré de dire que, depuis le XIXe siècle, la jurisprudence a largement transformé le droit des contrats.

18. Jurisprudence luxembourgeoise et jurisprudence française. Il va de soi que la jurisprudence n'est pas nécessairement la même dans les trois pays du Code civil, et, comme on le verra dans le cours de cet ouvrage, les exemples d'interprétations ou de solutions divergentes ne manquent pas entre la France et la Belgique. Au Luxembourg, cependant, la jurisprudence, peu abondante en raison de la population limitée du Grand-Duché, est largement calquée sur la jurisprudence française. Comme on l'a expliqué dans l'avant-propos de cet ouvrage, cela tient pour l'essentiel à ce que, en l'absence d'université au Luxembourg avant 2003, les magistrats luxembourgeois, et les avocats qui plaident devant eux, ont été très souvent formés en France. La jurisprudence et la doctrine françaises sont donc pour eux une sorte de référence « naturelle », alors surtout qu'ils ne trouvent guère, dans une doctrine spécifiquement

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

luxembourgeoise, des propositions qui permettraient de s'en écarter. Ce lien très étroit de la jurisprudence luxembourgeoise avec le droit français est particulièrement sensible dans les arrêts de la Cour d'appel ou les jugements des deux tribunaux d'arrondissement, longuement motivés en fait et en droit, et qui contiennent habituellement l'indication explicite de leurs sources. On y observe que, dans la plupart des cas, les décisions de la Cour de cassation française ou les positions des auteurs français ne sont pas citées de manière comparative, comme des éléments à prendre en compte parmi d'autres dans la recherche de la meilleure solution, mais sont intégrés à la motivation, sur le même plan que d'éventuels précédents luxembourgeois, et sans discussion, comme s'il s'agissait de justification suffisante de la solution adoptée. Comme l'observe sans complaisance un auteur luxembourgeois en matière de responsabilité civile, on a parfois « l'impression que la Cour de cassation française est considérée comme la juridiction suprême luxembourgeoise »[24]. On observe ainsi assez souvent que, dans le fil de l'argumentation, les arrêts de la Cour de cassation française sont cités sans même la précision qu'il s'agit de décisions françaises[25]. De même, les auteurs français sont régulièrement cités, comme porteurs de l'interprétation à retenir, sur le même plan que la doctrine luxembourgeoise (s'il y en a). Reste à savoir comment ce lien évoluera à la suite de la récente réforme française qui privera largement les juges luxembourgeois de leur modèle de référence.

Nous verrons cependant, au fil des développements, que, sur certains points, il existe une jurisprudence spécifiquement luxembourgeoise. Les juges, savent très bien, lorsqu'ils le souhaitent, s'écarter de la position suivie en France. En témoigne, par exemple, un arrêt de la Cour d'appel du Luxembourg relative à la cession de clientèle civile, dans lequel la Cour refuse de suivre la position

[24] G. RAVARANI, « La responsabilité civile des personnes privées et publiques », 3e éd., *Pas.*, 2014, p. 24, note 3 (cité *infra*, RAVARANI).

[25] Voy., p. ex., Cour d'appel, 30 juin 1993 : « L'existence d'un vice caché n'exclut pas par elle-même l'exercice d'une action en nullité d'un contrat pour erreur sur la qualité substantielle de l'objet. La victime d'une erreur sur la substance, consécutive à un vice caché de la chose, bénéficie donc d'une option en vertu de laquelle elle reste libre de se prévaloir de l'une ou l'autre voie ouverte par la loi : article 1110 du Code civil ou articles 1641 et suivants du Code civil, cette dernière action étant soumise au bref délai de l'article 1648 du Code civil (*cf.* dans ce sens Civ 3e 18 mai 1988 et Civ. 1re 28 juin 1988, D. 1989, som. p. 229, Rev. trim. dr. civ. 1989, p. 342) » ; Cour d'appel, 10 janvier 2007, *Pas.*, 33, p. 491 : « Le manquement à une obligation précontractuelle d'information, manquement reproché par l'appelant à la banque, ne suffit pas à caractériser la réticence dolosive si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement (Cass, com. 28 juin 2005 : RTD civ., 2005, p. 591) ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

consacrée en 2000 par la Cour de cassation française : après avoir noté que « […] la Cour de Cassation française a, par une décision du 7 novembre 2000, initié un revirement jurisprudentiel, qui de toute manière ne s'impose pas aux juridictions luxembourgeoises, et suivant laquelle la cession d'une clientèle médicale n'est pas illicite à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient […] », la juridiction luxembourgeoise critique cette solution, et conclut « Voilà pourquoi la Cour reste attachée à la jurisprudence citée ci-avant et suivant laquelle la clientèle médicale n'est en principe pas dans le commerce »[26]. Il faut donc bien attirer l'attention des étudiants – mais aussi des avocats, souvent trop prompts à s'abriter derrière la seule position française – sur le fait que la jurisprudence luxembourgeoise est une jurisprudence autonome, qui peut, au fil du temps, évoluer différemment de celle de la Cour de cassation française, alors surtout que les textes interprétés ne sont, aujourd'hui, plus les mêmes. Les mêmes considérations s'imposent en ce qui concerne la doctrine.

B) *La doctrine*

19. Importance de la doctrine en droit des contrats. On peut définir la doctrine, d'une manière générale, comme l'ensemble des auteurs qui s'expriment sur le droit, ou comme l'ensemble des opinions émises par ces auteurs. Plus précisément, au sein de la grande diversité des discours savants sur le droit, l'activité doctrinale désigne le travail consistant à analyser et à synthétiser les solutions du droit positif, et à émettre des opinions sur ce qu'elles devraient être. Comme on l'a dit, le droit des contrats est, dans beaucoup de pays, et tout spécialement en France, considéré comme la matière de base dans la formation des juristes. C'est une matière fortement marquée par la tradition universitaire, dans laquelle la doctrine s'est depuis longtemps fortement investie. C'est sans aucun doute, en France, la partie du droit civil, et du droit en général, qui a suscité le plus de traités, de manuels, de thèses et d'articles. Le travail des auteurs ne consiste pas seulement à analyser, à interpréter et à commenter les textes légaux (les articles du Code et les lois spéciales) et les décisions de justice. Il consiste aussi, comme dans d'autres matières, mais peut-être plus nettement, à donner de ces diverses solutions une présentation systématique tendant à

[26] Cour d'appel, 13 juin 2013, n° 37470, *Pas.*, 36, p. 790.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

en établir la cohérence d'ensemble[27]. À cette fin, la doctrine établit un certain nombre de « théories », qui sont des constructions intellectuelles reliant de manière logique les diverses solutions du droit positif sur tel ou tel point. Par exemple, il existe, en droit « franco-belgo-luxembourgeois » des contrats une « théorie des nullités », qui, à partir de solutions éparses dans la loi et la jurisprudence, établit dans quels cas on peut demander la nullité d'un contrat, qui peut la demander, pendant combien de temps, etc. en rattachant les solutions à une distinction, créée de toutes pièces par les auteurs entre les « nullités absolues » et les « nullités relatives » – distinction aujourd'hui consacrée par les textes en France et en Belgique. Sur de nombreux points, lorsque tous les auteurs ne sont pas d'accord, il existe plusieurs théories opposées, dont l'une finit souvent (mais pas toujours) à l'emporter sur les autres. Ainsi, la notion de cause, présente dans le Code civil comme une des conditions de validité du contrat, mais non définie, a donné lieu à l'élaboration de multiples théories, la théorie dominante distinguant traditionnellement, en France et au Luxembourg (mais pas en Belgique) entre la cause objective et la cause subjective, etc. L'ensemble de ces « théories », de ces constructions doctrinales, sont reliées au sein d'une « théorie générale du contrat », qui cherche à articuler et à présenter de manière cohérente l'ensemble des solutions de la matière. La comparaison de plusieurs manuels français ou belges de droit des contrats, *a fortiori* la comparaison d'un manuel français et d'un manuel belge, devraient aisément convaincre les étudiants, cependant, que, au-delà de constantes incontournables, la « théorie générale » du contrat n'a pas exactement le même contenu pour tout le monde[28].

La doctrine a eu, depuis le XIXe siècle, un rôle essentiel dans l'évolution du droit des contrats dans les pays du Code civil. Au-delà des solutions légales et jurisprudentielles ponctuelles inspirées par telle ou telle opinion doctrinale, la jurisprudence (et parfois la loi) ont incorporé, au fil du temps, certaines des grandes « théories » qui ont été précédemment évoquées, et qui font dès lors maintenant

27 Cette double activité de la doctrine est magistralement décrite par deux auteurs français à l'aide d'une métaphore culinaire « D'une part, elle lave et dénoyaute les cerises après en avoir enlevé les queues : autrement dit, elle élimine les contradictions, obscurités ou insuffisances du droit à l'état brut. D'autre part, elle élabore une pâte (la dogmatique) pour enrober les cerises (classer les solutions normatives) et faire du tout son clafoutis (le système) » (Ph. JESTAZ et C. JAMIN, « L'entité doctrinale française », *D.*, 1997, pp. 167 et s.).

28 Sur l'ambiguïté de la théorie générale du contrat voy. E. SAVAUX, *La théorie générale du contrat, mythe ou réalité*, Paris, LGDJ, 1997.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

partie du droit positif. Ainsi, même avant son intégration dans les codes français et belge, il était devenu impossible de traiter de la nullité du contrat en faisant abstraction de la distinction de la nullité relative et de la nullité absolue (alors pourtant que ces termes étaient totalement absents des textes du Code civil originaire). De même, la question de l'effet du contrat à l'égard des tiers doit aujourd'hui être présentée à partir de la distinction – purement doctrinale à l'origine, mais reprise par la jurisprudence et aujourd'hui consacrée par les textes en France et en Belgique – entre l'effet relatif du contrat et son opposabilité. Lorsqu'on aborde une matière aussi marquée par la doctrine que le droit des contrats, on doit être conscient que cette matière n'est pas seulement composée des textes et de la jurisprudence, mais aussi de ce que la doctrine en dit[29].

20. Importance de la doctrine française au Luxembourg. Dans les pays d'Europe continentale, la doctrine est essentiellement composée d'universitaires, de « docteurs » qui enseignent dans les universités, et l'activité doctrinale est étroitement liée à l'enseignement, et cela est spécialement vrai en droit des contrats, matière qui est considérée, dans beaucoup de pays, comme le cœur de la formation des juristes. Les praticiens, qui jouent un rôle essentiel dans l'application et dans la construction du droit positif sont relativement peu investis dans le travail de systématisation et de mise en ordre des solutions, surtout dans cette matière. La jeunesse de l'université du Luxembourg explique dès lors qu'en droit luxembourgeois des contrats, il n'existe qu'une doctrine embryonnaire, le plus souvent elle-même très marquée par la formation que les auteurs ont reçu en France ou, dans une moindre mesure, en Belgique. On voit cependant depuis quelques années se développer une littérature juridique importante émanant de praticiens, mais dont l'objet est plutôt de donner une exacte description des solutions – contribuant ainsi fort heureusement à leur connaissance[30] – que de tenir un discours systématique susceptible d'inspirer aux tribunaux des positions dissidentes par rapport au modèle français. Dès lors, pour

[29] Ce que les auteurs précités expriment, à partir de leur métaphore des cerises, c'est que « […] entre ce droit là (en gros, le code civil au lendemain de sa promulgation) et celui qui apparaît à la lecture d'un traité de droit civil, il y a la même différence qu'entre le kilo de cerises et le clafoutis […] » (Ph. JESTAZ et C. JAMIN, « L'entité doctrinale française », *op. cit.*).

[30] En droit des obligations, il faut citer tout particulièrement l'ouvrage de O. POELMANS, *Droit des obligations au Luxembourg, Principes généraux et examen de jurisprudence*, *op. cit.*, qui contient un examen très complet de la jurisprudence en droit des obligations entre 2000 et 2011 (cité *infra*, POELMANS).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

les juges et les avocats luxembourgeois, la doctrine, en droit des contrats, est d'abord la doctrine française, particulièrement développée. On peut ici faire les mêmes remarques que celles qui ont été faites précédemment par rapport à la jurisprudence française : les auteurs français, les manuels et les encyclopédies françaises, sont régulièrement cités dans les décisions luxembourgeoises (et dans les conclusions des avocats), comme porteurs de l'interprétation à retenir, et sans même l'indication qu'il s'agit de sources doctrinales. La doctrine belge est également citée, mais de manière beaucoup plus épisodique.

On peut citer comme exemple du statut des sources doctrinales françaises un passage caractéristique d'un jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg relatif à la rupture des pourparlers : « Situés très en amont de la formation du contrat, les pourparlers n'ont en principe aucune portée juridique ; ils ne sauraient en principe engager les parties respectives. Constituant la période dite de gestation du contrat, les pourparlers ne peuvent donc lier les parties : ils peuvent d'ailleurs toujours être rompus en vertu de la maxime "Pas de contrat vaut mieux qu'un mauvais contrat" (*cf.* J. Carbonnier, Droit civil, T. IV, n° 17, page 62 ; J. Ghestin, Traité de droit civil, Le contrat, page 178) ». De même, un arrêt sur la violence économique, qui reprend les conditions posées par la Cour de cassation française dans son arrêt du 3 avril 2002 recopie textuellement – en la citant – une chronique de D. Mazeaud parue en 2001[31].

SECTION 2. LES SOURCES INTERNATIONALES ET EUROPÉENNES

21. Le contrat, instrument d'échanges internationaux. Le contrat est l'instrument privilégié des échanges économiques internationaux : les importations et les exportations de marchandises d'un pays à l'autre se font par le biais de contrats de vente passés entre les agents économiques des différents pays, tandis que la livraison de ces marchandises suppose la conclusion, par le vendeur ou l'acheteur, de contrats de transport internationaux, la réalisation de grands travaux dans certains pays, surtout en voie de développement, passe souvent par l'appel à des entreprises étrangères, avec lesquelles sont passés des contrats d'entreprise, les opérations financières internationales se réalisent par la conclusion de contrats entre banques ou entre banques et investisseurs. Jusqu'à une période récente, les contrats internationaux concernaient surtout les entreprises, les particuliers ne passant de contrats avec une partie étrangère qu'à l'occasion de déplacements à l'étranger, mais le développement du commerce électronique a entraîné un

31 Cour d'appel, 10 juillet 2013, n° 38314.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

développement extraordinaire des contrats transfrontières passés par des particuliers, qui, par un simple clic, peuvent acheter des biens ou obtenir des services de contractants situés à l'autre bout du monde (sans toujours avoir conscience, du reste, de passer un contrat international). Dans la mesure où le droit des contrats n'est pas le même d'un pays à l'autre, il faut en principe, si un litige survient à propos d'un tel contrat international, déterminer quel est le droit national qui lui est applicable (**§ 1**). Cependant, pour faciliter les échanges internationaux, ont été élaborées, à l'échelle internationale, et, plus récemment, dans le cadre européen, des règles uniformes ou harmonisées en matière contractuelle (**§ 2**).

§1. Le droit national applicable à un contrat international

22. Problème du conflit de lois. Chaque fois qu'on a affaire à une situation juridique internationale, il faut, en principe, rechercher quelle est la loi nationale (ou plus largement, le droit national) applicable à cette situation. Ce problème, dit du conflit de lois, est traditionnellement réglé par chaque État dans son propre droit : la loi applicable ne sera pas alors nécessairement déterminée selon les mêmes critères selon le juge saisi du litige. En droit luxembourgeois, la question des conflits de lois fait l'objet d'un texte très sommaire dans le Code civil, l'article 3, qui ne dit rien de la loi applicable à un contrat international, et qui a dû être complété par la jurisprudence. Cependant, dans un certain nombre de matières, il existe des conventions internationales qui posent des règles de conflit de lois, ce qui permet d'unifier, non pas les règles substantielles applicables aux matières considérées, mais la manière dont, dans les différents pays parties à la convention, les juges détermineront la loi applicable. Tel est précisément le cas en droit des contrats, à l'intérieur de l'Union européenne : en 1968 avait été conclue sur cette question une Convention de Rome, qui a été, en 2008, transformée en un règlement européen, le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles[32], ci-après « Règlement Rome I »[33]. Désormais, au Luxembourg comme dans les autres pays européens, lorsqu'un juge est confronté à un contrat international, il

[32] *J.O.U.E.*, L. 177, 4 juillet 2008.

[33] Pour le distinguer du règlement Rome II relatif à la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

doit en principe déterminer le droit national applicable à ce contrat en suivant les règles de conflit posées par le Règlement Rome I du 17 juin 2008.

23. Solutions du problème en matière contractuelle : la loi d'autonomie. Le règlement Rome I a consacré, en la précisant, une solution qui avait été admise antérieurement par la plupart des jurisprudences nationales : en principe, la loi applicable à un contrat international est la loi choisie par les parties [Règlement Rome I, art. 3 (1)]. Ce système est dit de la loi d'autonomie, car il est l'expression de l'idée d'autonomie privée qui est à la base de la notion même de contrat. Il appartient donc aux parties, au moment où elles concluent le contrat, de déterminer elles-mêmes à quelle loi le contrat est soumis (et donc quelle loi devra être appliquée par le juge en cas de litige). Dans de nombreux cas, donc, les contrats internationaux contiendront une clause de choix de la loi applicable, et le contrat sera d'ailleurs rédigé, normalement, en tenant compte des dispositions de cette loi. Il arrive cependant très souvent que les parties ne choisissent pas la loi applicable, soit qu'elles n'y pensent pas, soit qu'elles ne parviennent pas à se mettre d'accord (chaque partie souhaitant l'application de sa propre loi). Dans un tel cas, le contrat n'est pas nul, mais, en cas de problème, il faudra déterminer la loi applicable en se basant sur d'autres critères que la volonté des parties. Le Règlement Rome I fixe lui-même ces autres critères : en principe, à défaut de choix, la loi nationale applicable sera celle du pays où le contractant qui fournit la prestation caractéristique a sa résidence habituelle (par exemple la loi allemande si le vendeur a sa résidence en Allemagne) [Règlement Rome I, art. 4, (2)]. Mais il existe de nombreuses règles dérogatoires, notamment pour les contrats de travail, les contrats de transport, ou les contrats dans lesquels une des parties est un consommateur. Il n'est évidemment pas nécessaire, dans un manuel général de droit des contrats, d'entrer dans le détail de ces règles. Mais au moins faut-il qu'un étudiant qui commence l'apprentissage de cette matière ait conscience, dès le début, de ce que le droit du pays où il est formé ne sera pas nécessairement applicable à tous les contrats qui y sont conclus. Cela est particulièrement vrai au Luxembourg, où, en raison de la petite taille du pays et de la nature de son activité économique, sont passés chaque jour de nombreux contrats avec des contractants étrangers, et qui sont très souvent soumis au droit d'un autre pays.

LARCIER INTERSENTIA
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Confronté à un cas pratique mettant en jeu une relation contractuelle, le premier réflexe d'un(e) étudiant(e) devra toujours être de se demander quel est le droit qui lui est applicable.

§ 2. L'élaboration de règles uniformes en matière contractuelle

24. Intérêts des règles uniformes. Au-delà des conventions internationales qui unifient les règles de conflit de lois (sur le modèle du Règlement Rome I), il peut paraître important d'élaborer des règles substantielles uniformes communes à plusieurs états (sur la formation et les effets des contrats). Si de telles règles existent, elles peuvent rendre inutile, dans leur domaine d'application, le recours au mécanisme complexe des conflits de lois pour déterminer la loi nationale applicable au contrat : ce contrat sera directement soumis aux règles uniformes. Ces règles semblent donc de nature à faciliter les échanges économiques internationaux, en ce qu'elles évitent aux contractants de se poser la question de la loi applicable à leur contrat, et en ce qu'elles peuvent rendre plus aisée la solution des litiges que les contrats internationaux peuvent susciter. C'est dans cette optique qu'ont été élaborés, à l'échelon mondial, certains instruments internationaux de droit des contrats (**1**). On a également assisté jusqu'à une période récente, à l'échelle européenne, à un important mouvement d'harmonisation, voire d'uniformisation, du droit des contrats, qui a pris des formes diverses, mais qui est actuellement à l'arrêt (**2**). Dans l'un comme dans l'autre cas, on peut assez vite se rendre compte des limites de ces instruments et des difficultés qu'ils suscitent.

A) *Instruments internationaux*

25. Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises (ci-après « CVIM »). À l'échelon mondial, le texte le plus important est celui de la Convention de Vienne, signée en 1980 sous l'égide de la CNUDCI (Commission des Nations unies sur le droit du commerce international), sur la vente internationale de marchandises[34]. Cette convention, qui a été signée et ratifiée par 80 états du monde – dont le Luxembourg depuis 1997 –, édicte des règles uniformes relatives à la formation et aux effets des

[34] Abréviation française : CVIM ; abréviation anglaise : CISG. Cette convention est accessible sur le site web de la CNUDCI : http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

contrats de vente de marchandises passés entre des entreprises (elle ne concerne pas les ventes faites par des professionnels à des consommateurs). Elle s'applique chaque fois que les deux contractants sont établis dans des états ayant ratifié la convention, ou que la loi applicable au contrat (désignée comme expliqué plus haut) est la loi d'un état partie. Cela signifie qu'en principe, un contrat de vente de marchandises passé entre une entreprise luxembourgeoise et une entreprise d'un autre pays partie à la convention de Vienne (par exemple la France, la Chine, le Mexique, etc.) n'est pas régi par les règles que nous allons étudier dans ce manuel (celles qui trouvent leur base dans le Code civil), mais par la CVIM (sauf si les parties en ont expressément écarté l'application). Il en va de même d'un contrat passé entre une entreprise luxembourgeoise et une entreprise d'un pays non partie à la Convention, si ce contrat a été soumis par les parties au droit luxembourgeois (ou français, ou chinois, ou mexicain, etc.) : le droit luxembourgeois, aujourd'hui, pour les ventes internationales, ce n'est plus, à titre principal, le droit du Code civil, mais le droit de la CVIM. C'est dire toute l'importance pratique de cet instrument pour le commerce international. Il faut cependant d'emblée en souligner les limites : d'une part, la CVIM ne règle pas tous les problèmes qui peuvent se poser en matière de vente et, sur certains points importants (le transfert de propriété, les vices du consentement, la validité de certaines clauses, etc.), il faudra continuer de se référer au droit national applicable au contrat (ce qui du coup laisse subsister le problème du conflit de lois) ; d'autre part, les litiges soumis à la CVIM continuent à être tranchés par des tribunaux nationaux (luxembourgeois, français, chinois, etc.), selon les règles complexes de la compétence internationale, et il se peut que ces différents tribunaux, composés de juges formés dans le cadre de leur tradition juridique nationale, donnent à des règles de la CVIM des interprétations divergentes. C'est un problème général de l'unification du droit.

26. Principes UNIDROIT sur les contrats du commerce international. UNIDROIT (abréviation pour Institut international pour l'unification du droit privé) est une organisation intergouvernementale sous l'égide de laquelle sont élaborées un certain nombre de conventions internationales. À côté de ces conventions, soumises à la signature et à la ratification des états, UNIDROIT a élaboré un corps de règles, appelés Principes, qui ont vocation à régir les

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

contrats du commerce international[35]. Publiés à l'origine en 1994, ils ont été révisés à plusieurs reprises, pour la dernière fois en 2016. À la différence de la CVIM, ces principes ne concernent pas seulement la vente, mais, tout comme cette convention, ils ne visent à régir que les contrats entre entreprises. La grosse différence avec la CVIM est que ces principes, qui n'ont pas été signés ni ratifiés par les États, n'ont pas la valeur d'une convention internationale. Ils ne s'appliquent pas de plein droit, mais seulement si les contractants les ont choisis. Cependant, même s'ils n'ont pas été choisis expressément, ils peuvent aussi servir de source d'inspiration aux juges et surtout aux arbitres internationaux pour interpréter les contrats internationaux, mais aussi le droit applicable à ces contrats[36]. Ils ont également vocation à inspirer les législateurs nationaux ou les auteurs de conventions internationales en matière contractuelle.

27. ***Lex mercatoria.*** Les textes qui viennent d'être signalés ne sont pas les seuls qui jouent un rôle dans le commerce international. La Chambre de commerce internationale, association privée qui regroupe les principaux acteurs du commerce international élabore régulièrement un certain nombre de règles modèles auxquels les parties aux contrats d'affaires internationaux peuvent se référer au lieu de régler dans le détail leurs droits et leurs obligations (Incoterms en matière de vente, Règles et usances uniformes en matière de crédit documentaire, de garanties, etc.). Au-delà de ces instruments écrits, les pratiques généralement suivies dans les relations commerciales internationales sont à la source d'une sorte de coutume propre aux acteurs économiques, dans laquelle on voit parfois un ordre juridique spécifique, la *lex mercatoria* (loi des marchands). À tout le moins, on voit se dégager progressivement un certain nombre de principes généraux propres au commerce international, qui jouent surtout un rôle important lorsque les litiges qui s'y rapportent sont confiés à des juridictions arbitrales (et dont les Principes Unidroit précédemment cités peuvent être regardés comme une sorte de traduction). Le droit des contrats internationaux dépasse dès lors très largement les règles élaborées par les différents états.

B) *L'harmonisation européenne du droit des contrats*

28. Droit européen positif. Jusqu'à une période récente, l'Union européenne n'était intervenue en matière contractuelle que dans des domaines limités, par le biais de directives d'harmonisation devant être transposées dans le droit interne des États membres. Ces directives concernent surtout les contrats de consommation, c'est-à-dire les contrats passés entre professionnels et consommateurs. Elles visent, au premier chef, à instaurer au sein de l'Union un niveau minimal de protection des consommateurs, soit dans

35 Les Principes sont accessibles sur : http://www.unidroit.org

36 Pour un exemple caractéristique d'influence des Principes UNIDROIT sur l'interprétation de la CVIM par la jurisprudence belge en matière d'imprévision, voy *infra*, n° 516.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

certains types de contrats (vente de biens immobiliers à temps partagés, contrats de crédit à la consommation, contrats de voyage à forfait, etc.), soit dans des contrats passés dans des circonstances particulières qui les rendent particulièrement dangereux pour le consommateur (contrats de consommation passés au domicile du consommateur ou plus généralement hors de l'établissement du professionnel, contrats passés sous la forme électronique), soit dans n'importe quel contrat, à propos de certains aspects qui ont semblé mériter des dispositions protectrices particulières (directive sur la garantie des biens de consommation, directive sur les clauses abusives). En Europe, aujourd'hui, et au Luxembourg en particulier, une grande partie des règles applicables aux contrats de consommation provient de la transposition de ces directives. Même si celles-ci ne couvrent qu'un domaine limité, elles ont eu, et continuent d'avoir une grande influence sur l'évolution du droit des contrats dans les états membres, notamment en ce qu'elles ont habitué les esprits à l'idée de protection des contractants en situation de faiblesse, qui, est, nous le verrons, un des traits marquants du droit contemporain des contrats. Traditionnellement, ces directives étaient conçues comme des règles d'harmonisation minimale, n'empêchant pas les états membres d'introduire dans leur droit des règles plus protectrices des consommateurs. Mais, dans la mesure où, derrière l'objectif de protection des consommateurs, l'intervention de l'Union européenne a également pour but d'assurer une égalité de concurrence entre les entreprises des différents pays, et de favoriser le développement du marché, la tendance actuelle est de dériver vers une harmonisation plus complète, qui laisse moins d'autonomie aux états dans la transposition. L'une des directives récentes les plus importantes, celle du 25 octobre 2011[37], est très représentative de cette tendance, qui est assez mal vécue dans les états qui avaient jusque-là un niveau élevé de protection des consommateurs. En dehors du droit de la consommation, il faut citer d'autres directives qui touchent au droit des contrats, soit en édictant des règles spécifiques à certains aspects des contrats entre entreprises (dir. 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales), soit, plus exceptionnellement, en posant des règles transversales concernant aussi bien les contrats

[37] Dir. 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiée par Dir. 2019/2161 UE.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

entre entreprises et les contrats entre particuliers. Tel est le cas de l'importante directive de 1985 concernant la responsabilité du fait des produits défectueux[38], qui réglemente la réparation des dommages subis par une personne du fait du défaut de sécurité d'un produit mis dans le commerce. Même si cette directive ne concerne pas directement le droit des contrats (elle peut s'appliquer à la réparation d'un dommage subi par une personne qui n'a aucun lien contractuel avec le fabricant du produit), elle traite de questions qui, jusque-là, dans certains états membres, et notamment au Luxembourg, étaient traités par le biais de techniques de droit des contrats[39].

Dans un tout autre domaine, il faut ici mentionner l'importance que peuvent avoir, en droit des contrats, les textes européens relatifs aux droits de l'homme, qu'il s'agisse de la Convention européenne des droits de l'homme, ou de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Certes, ces textes ne contiennent pas directement de règles relatives aux contrats, mais les principes fondamentaux du droit des contrats – la liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat, avec les multiples limites qui leur sont apportées – ne peuvent plus se lire aujourd'hui sans référence aux droits fondamentaux reconnus par ces instruments, et à l'interprétation qu'en donnent les deux cours de Strasbourg et de Luxembourg[40].

29. Projets doctrinaux de droit européen des contrats. Depuis une trentaine d'années, s'est développé, en Europe, un mouvement tendant à dépasser cette approche dite « sectorielle » du droit européen des contrats, et à édicter des règles générales qui seraient applicables à tous les contrats sans distinction ni d'objet ni de parties, et qui auraient vocation, soit à doubler les droits nationaux, soit même à s'y substituer. Dans un premier temps, ce mouvement a été initié par des groupes savants, composés de professeurs de droit et parfois de praticiens de différents pays d'Europe, qui se sont mis à la tâche de rédiger des règles de droit des contrats qui pourraient être communes à tous les pays européens. Il faut citer ici tout particulièrement un groupe animé par le professeur italien G. Gandolfi, qui a publié en 2001 un « Code européen des contrats »[41], et, surtout,

38 Dir. 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

39 À propos des « chaînes de contrats », voy. *infra*, n° 1111.

40 Voy., p. ex. : Cour d'appel, 29 janvier 2009, 34, p. 401 (examen du bien-fondé d'une demande en résolution d'un contrat de travail fondée sur un abus de la liberté d'expression du salarié au regard de l'article 10 de la C.E.D.H.). Sur l'ensemble de la question, voy. A. Pelissier, « La participation des droits fondamentaux à la construction d'un droit européen des contrats », in R. Cabrillac, D. Mazeaud, A. Prüm (dir.), *Le contrat en Europe, aujourd'hui et demain*, coll. Droit privé comparé et européen, vol. 8, Paris, Société de législation comparée, 2007, pp. 27 et s.

41 Cité *infra*, « Code Gandolfi ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

le groupe animé par le professeur danois O. Lando, qui a élaboré des Principes de droit européen du contrat (PDEC ou PECL, dits habituellement Principes Lando)[42]. Ce groupe Lando a été relayé, à partir de 1997 par l'important réseau de juristes européens animé par le professeur allemand C. Von Bar, le *Study group on a European civil code*, qui nourrissait l'ambition d'élaborer un Code civil européen, dépassant très largement le seul droit des contrats, et qui a déjà publié, en plusieurs volumes des « *Principles of European law* ». Ces différents projets doctrinaux, quelle que soit leur dénomination (Principes ou Code), n'ont aucune valeur normative en eux-mêmes, dans la mesure où ils émanent de personnes privées qui n'ont aucune compétence législative dans l'Union européenne. Même si on peut concevoir que ces textes soient choisis par des contractants à titre de règles applicables à leur contrat (comme les Principes UNIDROIT), ce n'est en fait jamais le cas. Ces différents textes apparaissent en réalité comme des sources d'influence, susceptibles de faire évoluer les jurisprudences nationales et d'inspirer les législateurs nationaux dans leurs projets de réformes. À l'échelon national, en effet, s'est développée, à tort ou à raison, l'idée qu'il y a un intérêt à ne pas consacrer des solutions trop éloignées des autres pays européens, et les projets doctrinaux, eux-mêmes fruits d'une recherche de compromis entre diverses solutions nationales, passent pour traduire les solutions modernes dont chaque droit national pourrait s'inspirer. Même si cette aspiration au rapprochement des droits n'est pas unanimement partagée (surtout dans les pays marqués par une longue et forte tradition juridique, comme la France), et si elle ne connaît pour l'instant guère de traductions concrètes, on peut d'ores et déjà constater, sur des aspects importants du droit des contrats, une certaine « européanisation » des solutions à laquelle les projets doctrinaux de droit européen des contrats ont servi de catalyseur. Les récentes réformes française et belge sont particulièrement révélatrices de ces influences.

30. Projets de la Commission européenne. À partir du début des années 2000, les institutions de l'Union européenne ont elles-mêmes marqué leur intention de dépasser l'approche sectorielle des directives de protection des consommateurs, pour élaborer un véritable droit européen des contrats, en prenant le relais des groupes doctrinaux tout en s'appuyant sur eux. La Commission européenne a publié

42 Cité *infra*, « PDEC ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

successivement trois communications, assorties de consultations des acteurs politiques, économiques et sociaux des États : une première communication en date de juillet 2001 visait « à élargir le débat sur le droit européen des contrats en associant le Parlement européen, le Conseil et les parties prenantes, y compris des entreprises, des juristes, des universitaires et des associations de consommateurs ». Elle a été suivie en février 2003 d'une seconde communication, établissant un « plan d'action » pour le droit européen des contrats, puis d'une troisième, en octobre 2004, indiquant la « voie à suivre ». À la suite de cette dernière communication, a été lancé un appel pour l'élaboration d'un « Cadre commun de référence » qui contiendrait, outre l'énoncé de principes fondamentaux fondant le droit des contrats européen, la définition de concepts-clés et un certain nombre de règles types. Cette tâche a été menée par deux groupes de chercheurs : d'un côté, le Study group de C. Von Bar a préparé un projet de « *Draft common frame of reference* » (DCFR), qui s'inscrit dans le cadre de son œuvre d'ensemble d'élaboration d'un Code civil européen ; de l'autre, un groupe français, sous l'égide de l'Association Henri Capitant et de la Société de législation comparée, a proposé une version révisée et commentée des Principes Lando[43]. À partir de ces propositions doctrinales, la Commission a nommé un groupe d'experts chargé d'élaborer un texte, dans le cadre général fixé, en juillet 2010, par un Livre vert « relatif aux actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises ». Tout cela a débouché, en octobre 2011, sur une « proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente », qui constitue actuellement l'étape la plus avancée de ce droit européen des contrats en construction.

31. Le Droit commun européen de la vente (DCEV)[44]. Ce texte était très nettement en retrait par rapport à ce qui avait été envisagé antérieurement : il ne s'agissait pas, en effet, d'un texte général de droit des contrats, mais d'un texte dont le domaine d'application était restreint aux ventes transfrontalières, tant entre entreprises que dans les relations entre entreprises et consommateurs. Si ce texte

43 *Principes contractuels communs*, vol. 7, coll. Droit privé comparé et européen, Paris, Société de législation comparée, 2008. Ce volume est complété par un autre intitulé : *Terminologie contractuelle commune*, vol. 6, coll. Droit privé comparé et européen, Paris, Société de législation comparée, 2008.

44 En anglais CESL. Le projet sera cité ci-après sous son signe francophone DCEV.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

mérite néanmoins d'être envisagé dans un manuel de droit commun des contrats, c'est parce qu'il ne contenait pas seulement, loin de là, des règles spécifiques à la vente (les obligations du vendeur et de l'acheteur), mais aussi, et surtout, de très nombreuses règles générales de droit des contrats (formation du contrat, conditions de validité des contrats, sanctions de l'inexécution, etc.) qui, dans le domaine d'application limité du texte, auraient eu vocation à s'appliquer à la place des articles 1101 et suivants du Code civil, objet de cet ouvrage. Le texte, s'il était entré en vigueur, ne se serait cependant pas substitué aux droits nationaux : les parties à un contrat de vente transfrontalier relevant de son domaine d'application auraient eu le choix soit de soumettre leur contrat à un droit national choisi par elles, soit de déclarer applicable le DCEV. Le DCEV ne se serait appliqué qu'en vertu d'un choix exprès – ce pour quoi on parlait d'un « instrument optionnel ». Le projet de DCEV a été assez mal reçu dans les différents pays de l'Union européenne, où, au-delà des critiques multiples formulées sur le contenu du texte, beaucoup de juristes éprouvaient la crainte de voir leur droit national perdre de son importance. C'est pourquoi la Commission européenne a décidé, au moins momentanément, d'abandonner le projet, pour se concentrer sur une réglementation plus spécifique des contrats passés par Internet. Le DCEV a finalement débouché sur deux directives à objet beaucoup plus limité, l'une portant sur les ventes en ligne, l'autre sur les contrats de fourniture de contenu numérique[45]. En dépit de son échec, le DCEV reste cependant une sorte de préfiguration de ce que pourrait être un futur droit européen des contrats, et on ne saurait en faire abstraction dans le présent ouvrage, au moins à titre de comparaison avec les solutions actuellement admises sur le fondement du Code civil, et parfois d'inspiration pour leur évolution.

45 Directive (UE) 2019/771 et directive (UE) 2019/770 du 20 mai 2019.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les sources du droit luxembourgeois des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 23-50
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Chapitre II
La notion de contrat en droit luxembourgeois

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

32. Article 1101 du Code civil. Maintenant que nous savons quelles sont les sources du droit des contrats au Luxembourg, il est temps de passer à l'étude de son contenu, en commençant par la notion même de contrat. Cette notion est explicitement définie dans le Code civil par l'article 1101 du Code civil, qui ouvre le titre III du Livre III relatif aux « contrats et aux obligations conventionnelles en général ». Ce texte définit le contrat comme « une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Dans le Code civil français, cette définition, qui figure toujours à l'article 1101, a été considérablement modifiée. Le contrat est désormais défini comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». La définition est encore plus nouvelle en Belgique, où l'article 5-4 du Code civil dispose que « Le contrat, ou convention, est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes avec l'intention de faire naître des effets de droit. »

Si on s'en tient pour l'instant à la définition luxembourgeoise, on peut s'en servir pour dégager, dans un premier temps, les éléments essentiels de la notion de contrat au Luxembourg (**Section 1**). Cette définition, qui fait apparaître le contrat comme un mode particulier de création d'obligations, nous permettra ensuite de distinguer le contrat des autres sources d'obligations (**Section 2**).

SECTION 1. LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA NOTION DE CONTRAT

33. Trois éléments. On peut déduire de l'article 1101 du Code civil que le contrat suppose la conjonction de trois éléments. Le contrat est, d'abord « une convention » : le terme indique expressément la nécessité d'un accord entre deux ou plusieurs personnes, de la concordance de plusieurs volontés (**§ 1**). Par cette convention, les personnes « s'obligent » les unes envers les autres, ce qui, au minimum, postule une volonté de s'engager juridiquement (**§ 2**). Plus précisément, elles s'obligent « à faire, à ne pas faire ou à donner quelque chose », ce qui fait du contrat un acte créateur d'obligations, au sens technique de ce terme (**§ 3**). C'est surtout sur ce troisième point que les nouvelles définitions française et belge innovent.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

§ 1. Un accord

34. Un accord entre deux ou plusieurs personnes. La notion de convention, qui ouvre l'article 1101 du Code civil, postule que deux personnes au moins se mettent d'accord (un vendeur et un acheteur, un bailleur et un locataire, un employeur et un salarié, etc.). Cette exigence minimum pour qu'il y ait contrat – qui se retrouve dans les nouvelles définitions française et belge_ – permet de distinguer le contrat des actes juridiques unilatéraux, par lesquels une seule personne manifeste sa volonté de produire des effets juridiques[46]. Par exemple, le testament, que le testateur fait seul (et souvent en secret) pour régler la dévolution de ses biens n'est pas un contrat, à la différence de la donation, qui suppose, en droit luxembourgeois du moins, un accord entre le donateur et le bénéficiaire de la donation (donataire).

Mais, comme l'indique expressément l'article 1101 du Code civil, le contrat peut aussi être passé entre plus de deux personnes : « une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres »[47]. Cette hypothèse de pluralité de parties recouvre des situations très différentes les unes des autres. Il peut d'abord arriver que, dans un contrat normalement bipartite (la vente, le bail, etc.), plusieurs personnes, qui ont un intérêt commun, se mettent ensemble pour passer le contrat : c'est le cas par exemple lorsque deux conjoints achètent ensemble un bien, ou lorsque deux personnes, propriétaires en indivision d'un immeuble, le donnent toutes deux à bail à un tiers. Dans ces hypothèses, on peut en général raisonner comme si les deux parties ayant la même position contractuelle (les deux acheteurs, les deux bailleurs) n'étaient qu'une seule et même personne : la relation contractuelle se noue entre les deux vendeurs d'un côté, et les deux acheteurs de l'autre. Mais des problèmes spécifiques peuvent naître lorsqu'il s'agit de savoir si chacun des contractants est débiteur ou créancier de la totalité des obligations naissant du contrat, ou seulement d'une partie (par exemple : le vendeur peut-il demander à chacun des acheteurs la totalité du prix ?). Nous retrouverons ces questions lorsque nous étudierons les modalités des obligations[48]. Les problèmes spécifiques sont plus nombreux dans une seconde série d'hypothèses, qui est celle des contrats véritablement multipartites : un accord est passé entre plusieurs personnes qui ont chacune un intérêt distinct. C'est le cas notamment lorsque plusieurs personnes (elles peuvent être des milliers !) se mettent ensemble pour fonder une société, ou une association. Chaque contractant trouve alors en face de lui, sur le même plan, tous les autres : la relation contractuelle se noue entre chaque associé, et la totalité des autres. Le nouveau droit belge consacre un article spécifique à ces contrats multipartites, défini simplement comme « un contrat conclu par plus de deux parties » (C. civ. be, art. 5-12). En toute hypothèse, les conventions entre plusieurs personnes doivent être distinguées des actes juridiques collectifs (par exemple, la délibération d'un conseil), qui supposent la conjonction de plusieurs volontés mais qui ne créent pas de relation entre les différents participants à l'acte[49].

46 Sur les actes juridiques unilatéraux, voy. *infra*, n°s 61 et s.

47 Sur la pluralité de parties, voy. M.-L. MATHIEU-IZORCHE, « Une troisième personne bien singulière », *RTD civ.*, 2003, p. 51.

48 Voy. *infra*, n°s 615 et s.

49 Sur les actes juridiques collectifs, voy. *infra*, n° 67.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

35. Un accord avec ou sans échange. Dans l'immense majorité des cas, l'accord contractuel réalise un échange économique, ce qui signifie que chaque contractant apporte, ou s'engage à apporter quelque chose à l'autre : l'acheteur paye un prix, et le vendeur lui transfère en échange la propriété d'un bien ; le salarié travaille, et l'employeur lui paie son salaire ; chaque associé, dans une société commerciale, fait un apport et reçoit en échange une part de bénéfices ; etc. Cependant, ce n'est pas toujours le cas : lorsqu'il pose que « une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres », l'article 1101 du Code civil ne veut pas dire que chaque partie doit contracter des obligations envers la ou les autres. Dans la conception du contrat qui est celle du Code civil, il peut y avoir un contrat même si les deux parties se mettent d'accord pour que l'une fasse quelque chose envers l'autre (transfère un bien, effectue un service, mette de l'argent à disposition, etc.) sans rien recevoir en échange. En témoigne la présence, dans les titres du Code relatifs aux différents contrats, de contrats pouvant être gratuits (le mandat, le dépôt, le prêt d'argent, etc.), ou même étant nécessairement gratuits, sans contrepartie (le prêt d'une chose, le cautionnement, la donation déjà citée). En témoignent aussi, dans les textes qui suivent immédiatement l'article 1101, les classifications des contrats qui distinguent les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux, les contrats à titre onéreux et à titre gratuit. On voit là que le Code, dans sa conception du contrat, met au premier plan l'accord de volontés, et ne se préoccupe pas de sa finalité économique[50]. De ce point de vue, la notion de contrat dans les pays du Code civil (et, au-delà, dans les pays de *civil law*) se distingue fondamentalement de la conception plus restrictive des droits de *common law*, où le contrat ne peut en principe exister que si chaque contractant fournit à l'autre une contrepartie servant de *consideration* au contrat.

36. Un accord formel ou non formel. Un autre point à préciser est que l'accord de volontés visé à l'article 1101 du Code civil dans la notion de « convention » n'est pas nécessairement un accord formel. Dans le langage courant, « passer un contrat » signifie, souvent, signer un document écrit matérialisant l'accord des parties. Telle n'est pas la conception du droit civil. D'une part, en vertu du principe dit du consensualisme, un contrat peut en principe être passé sans aucune forme, de manière orale (tu peux me prêter 100 € jusqu'à

[50] Sauf lorsque cette finalité est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Voy. *infra*, n°s 368 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

demain ? D'accord, mais il faut absolument que tu me les rendes avant demain soir), voire tacite (en montant dans un bus, je passe un contrat de transport avec la compagnie de transports urbains). C'est le cas de nombreux contrats de la vie courante. D'autre part, même lorsque le contrat est passé par écrit (ce que la loi exige parfois, et qui est de toute façon très courant en pratique), ce n'est pas l'acte écrit qui constitue le contrat (même si dans la vie courante, on dira parfois : qu'est-ce que j'ai fait de mon contrat de travail ?), ce papier n'est que la matérialisation de l'accord sous-jacent qui est, lui-même, le contrat. Si toute trace écrite de l'accord a disparu, le contrat n'en existera pas moins toujours (même si on peut alors avoir des difficultés à le prouver). Pour bien distinguer, on désigne parfois le document écrit sous l'appellation d'*instrumentum* (ou acte instrumentaire), pour l'opposer au *negotium* (ce qui a été négocié, l'accord qui constitue le contrat, l'acte juridique).

§2. Des volontés de s'engager juridiquement

37. ***Animus contrahendi.*** Tous les accords passés entre deux ou plusieurs personnes ne sont, à l'évidence, pas des contrats. Par exemple, si je vous invite à dîner chez moi pour manger votre plat préféré (des *Paschtéite* ?[51]) et que vous acceptez, ou si nous convenons ensemble d'un rendez-vous pour discuter de vos résultats à l'examen, il apparaît évident que ce ne sont pas là des contrats. Il en résultera que, si je vous sers une *Feiersténgszalot*[52] (que vous détestez !) au lieu des *Paschtéit*, ou si je ne viens pas au rendez-vous, vous ne pourrez pas mettre en œuvre les mesures qui sanctionnent l'inexécution d'un contrat[53]. Pour rendre compte de cette évidence (apparente, comme la plupart des évidences), on dit généralement que les personnes qui passent de tels accords n'ont aucune intention de s'engager juridiquement, de se placer sous l'empire du droit. Apparaît ici un élément essentiel de la notion de contrat, qu'on peut rattacher, dans la définition de l'article 1101 du Code civil, à la formule selon laquelle les personnes parties au contrat « s'obligent ». Cette formule peut être prise dans un sens étroit, qui signifie créer une obligation, devenir débiteur (et nous verrons effectivement un peu plus loin que, dans la conception classique,

51 Des bouchées à la reine, un des plats typiques du Luxembourg.

52 Salade de viande, autre plat luxembourgeois.

53 Sur ces remèdes, voy. *infra*, n°s 673 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

seuls sont des contrats au sens strict les accords qui produisent un tel effet). Mais, dans un sens plus général, « s'obliger » signifie d'abord, fondamentalement « s'engager juridiquement », c'est-à-dire accepter que ce qu'on a voulu puisse être sanctionné par le droit, qu'on puisse demander à un juge (et, au-delà, à la force publique) de le faire respecter. C'est là le minimum pour qu'on soit en présence d'un contrat : il faut que les parties aient l'intention de s'engager juridiquement, de passer un accord sanctionné par le droit. Il faut, disent aujourd'hui certains auteurs, qu'existe chez les parties un *animus contrahendi*[54]. Dans les textes modernes de droit des contrats, cette idée apparaît souvent de manière beaucoup plus explicite que dans l'article 1101 du Code civil : ainsi, le nouvel article 1101 du Code civil français définit le contrat comme « un accord de volontés […] destiné *à* créer, modifier… des obligations ». Plus nettement encore, la nouvelle définition belge parle de « l'intention de faire naître des effets de droit. » Cela permet de tenir hors de la notion de contrat (mais pas nécessairement en dehors du droit) des accords de volontés dans lesquels les parties n'ont aucune intention juridique.

Cela ne veut pas dire que ces accords restent complètement en dehors du droit : si, vous ayant invité à dîner, je vous sers de la nourriture avariée, et que vous êtes victime d'une intoxication alimentaire, vous pourrez engager ma responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en prouvant que j'ai commis une faute (par exemple en laissant traîner la nourriture hors du réfrigérateur). De même, si je vous fais venir des États-Unis pour un rendez-vous d'affaires, et que j'oublie de venir, vous pourrez, sur le même fondement, me demander des dommages et intérêts pour compenser votre perte de temps et vos frais de transport. On raisonne de la même manière en cas de rupture des fiançailles ou d'une relation de concubinage : ces relations, qui reposent sur l'accord des deux membres du couple, ne sont pas, en droit luxembourgeois (pas plus qu'en droit français ou belge), considérées comme des contrats, mais, si la rupture intervient dans des conditions particulièrement brutales, injustifiées, insultantes pour l'autre, elle peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur[55]. Mais, dans tous ces cas, ce n'est pas sur le fondement d'une inexécution contractuelle que la victime obtiendra réparation, et elle ne pourrait pas se contenter de dire que l'autre a manqué à une obligation née du contrat : elle devra prouver une faute particulière. Il pourrait en aller différemment en présence d'un contrat : si, par exemple, vous avez été intoxiqué par la nourriture que vous a servi un traiteur, avec lequel vous avez passé un contrat, vous pourrez obtenir réparation sans avoir à prouver la faute du traiteur, parce que celui-ci avait l'obligation contractuelle de vous servir de la nourriture saine.

54 Voy. p. ex. : en France : M. Fabre-Magnan, *Droit des obligations*, t. 1, *Contrat et engagement unilatéral*, 4e éd., coll. Thémis, Paris, PUF, 2016 (cité *infra*, Fabre-Magnan), n° 150 ; en Belgique : P. Wéry, *Droit des obligations*, vol. 1, *Théorie générale du contrat*, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2021 (cité *infra*, Wéry), n° 40.

55 Cour d'appel, 4 juillet 2012, n° 37596.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

38. Portée. L'idée que la qualification de contrat repose sur la volonté de s'engager juridiquement, de produire des effets de droit, doit cependant être précisée. D'une part, la volonté contractuelle ne coïncide pas nécessairement avec la volonté psychologique, avec la conscience de s'engager juridiquement, de produire des effets de droit (A). D'autre part, même si cette conscience existe (ce qui est le plus souvent le cas tout de même !), il n'est absolument pas nécessaire que les parties aient en tête tous les effets que leur accord peut produire, la détermination de ces effets échappant dans une large mesure aux volontés individuelles (B).

A) *Volonté contractuelle et volonté psychologique de s'engager*

39. Contrats de la vie quotidienne. Lorsqu'on dit que les parties au contrat ont la volonté de s'engager juridiquement, ce n'est en aucune manière une description de ce qui se passe dans la tête des personnes lorsqu'elles choisissent volontairement de faire quelque chose qui a des effets juridiques. La question n'est pas de savoir si elles ont ou non réellement la volonté de produire ces effets. Ce qui compte, ce n'est pas la volonté psychologique, mais la volonté qui est considérée comme juridique par le droit en se fondant sur la généralité des cas, sur le *plerumque fit*[56]. Dans de nombreuses relations de la vie quotidienne, qui sont qualifiées juridiquement comme étant des contrats, la volonté de produire des effets de droit, de s'engager juridiquement, fait absolument défaut ou du moins n'est pas consciente : lorsque vous achetez un « *streusel* » chez le boulanger le matin, lorsque vous montez dans le bus pour venir assister au cours, ou lorsque vous entrez dans un parking avec votre voiture, il est douteux que vous soyez conscient(e) de passer des contrats, et que vous ayez en tête les multiples effets juridiques que ces actes de la vie quotidienne peuvent produire. Pourtant, ces actes seront sans hésitation regardés comme étant des contrats, donc des actes juridiques, parce qu'ils correspondent au schéma d'actes ainsi qualifiés par la loi (la vente, le contrat de transport, le dépôt). La qualification d'un acte comme contractuel ou non va dès lors surtout susciter des difficultés dans le cas de relations sociales atypiques, qui n'entrent pas dans un des moules contractuels établis par la loi (ou par la jurisprudence). Il appartiendra alors au juge de dire, au cas par cas, si tel accord est ou non un contrat, et la recherche de la volonté des parties semble alors s'imposer. Mais, là

[56] Expression latine utilisée pour désigner ce qui se passe le plus souvent (*quod plerumque fit*).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

encore, la volonté recherchée ne sera pas nécessairement la volonté réelle, ce peut-être une volonté supposée en fonction des effets que le juge veut faire produire à l'accord. Deux situations particulières, celle des relations bénévoles et celle des *gentlemen's agreements*, le montrent bien.

40. Relations bénévoles. Comme on l'a déjà vu, dans le système du Code civil, rien ne s'oppose à ce qu'une relation gratuite soit considérée comme un contrat. L'article 1105 du Code civil prévoit explicitement que « le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit ». Il en va ainsi de la donation, du prêt permettant à une personne d'utiliser un bien (prêt à usage, essentiellement gratuit selon l'article 1876 du Code civil), du dépôt (qui peut, selon les cas être gratuit ou rémunéré), etc. Cependant, en dehors des cas prévus par la loi, la nature contractuelle ou non des accords bénévoles peut prêter à discussion, dans la mesure où, très souvent, on ne peut discerner aucune intention juridique particulière des parties. Cela n'avait pas empêché la jurisprudence française, pendant longtemps, de considérer comme un contrat le transport bénévole (le fait de prendre quelqu'un, un auto-stoppeur ou un ami, gratuitement à bord de sa voiture), ce qui permettait, en cas d'accident, de retenir la responsabilité du transporteur selon les règles de la responsabilité contractuelle. Cette solution a été abandonnée en 1968 par la jurisprudence française, suivie par la Cour de cassation du Luxembourg[57]. Mais le problème se pose aujourd'hui dans les cas d'assistance bénévole : si par exemple un de vos amis vous aide à déménager votre appartement, peut-on voir là un véritable contrat ? En principe, on devrait répondre par la négative, faute d'*animus contrahendi*, mais les juges n'hésitent pas à considérer, dans certaines circonstances, qu'on est en présence d'un contrat faisant naître pour l'assisté une obligation d'assurer la sécurité de l'assistant. Cela permettra à celui-ci d'obtenir plus facilement réparation que sur le fondement

[57] Cass., 25 juin 1970, *Pas.*, 21, p. 295 – La solution actuelle est plus favorable aux passagers victimes, car elle leur permet (au Luxembourg) d'engager la responsabilité du conducteur sur le fondement de l'article 1384 du Code civil qui, dans l'interprétation qu'en donne la jurisprudence, institue une responsabilité de plein droit ne supposant pas la preuve d'une faute. Au contraire, la reconnaissance d'un contrat de transport bénévole aboutissait à exclure l'application de ce texte, et à ne retenir la responsabilité contractuelle du conducteur, tenu d'une simple obligation de moyens, qu'en cas de faute prouvée. La solution était commandée par des considérations de faveur envers le conducteur qui prenait gracieusement un passager à son bord.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de la responsabilité délictuelle[58]. Il en ira ainsi, notamment, lorsque l'aide aura été sollicitée[59]. Au-delà du souci de protéger la victime, la reconnaissance de ce « fantôme de contrat »[60] peut être commandée par des considérations de politique sociale : ainsi, si le juge soupçonne que l'aide « bénévole » dissimule un travail au noir, il pourra être tenté de retenir l'existence d'un contrat, pour pénaliser l'assisté sur qui pèsera alors une obligation plus lourde.

41. ***Gentlemen's agreements.*** Il arrive que les parties à un accord qui est, d'une manière générale, regardé comme un contrat, comme un acte juridique, déclarent explicitement leur intention de ne pas s'engager juridiquement. C'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle les engagements d'honneur[61], ou, dans la terminologie anglaise, les *gentlemen's agreements*. Par exemple, au cours de la négociation d'un contrat futur, deux entreprises mettent noir sur blanc, à un moment donné, leurs points d'accord, en s'engageant « sur l'honneur » à ne pas les remettre en cause au cours des discussions ultérieures. Ou encore, au moment de la rupture d'une relation hors mariage, l'un des membres du couple fait à l'autre la « promesse morale » de l'aider financièrement en cas de besoin. En principe, si l'une des parties manque à un tel « engagement » (qui, juridiquement, n'en est pas un), le juge ne pourrait pas mettre en œuvre les sanctions de l'inexécution d'un contrat. Tout au plus, dans des cas exceptionnels, l'auteur de la rupture pourrait être condamné à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Mais, d'une part, la volonté réelle des parties peut être ambiguë, et il n'est pas toujours facile de savoir où passe la frontière entre les engagements d'honneur et les véritables accords contractuels. D'autre part, il arrive que les juges, pour des raisons d'opportunité, passent outre de la volonté exprimée, et décident de donner force obligatoire à un accord que les parties elles-mêmes

58 Le résultat est contraire à celui qui résultait naguère en France de la reconnaissance d'un contrat de transport bénévole : en l'absence de contrat, la victime ne pourrait le plus souvent se fonder que sur l'article 1382 du Code civil (devenu en France l'article 1242), qui subordonne la responsabilité à la preuve d'une faute, alors que l'obligation de sécurité contractuelle est, dans ce cas, une obligation de résultat qui permet d'obtenir des dommages et intérêts sans avoir à démontrer la faute de l'assistant. La différence montre la complexité des considérations de politique juridique qui peuvent amener la reconnaissance d'un contrat.

59 Voy. p. ex. en France : Cass. fr. (1re civ.), 17 décembre 1996, n° 94-21838. Au Luxembourg : Cour d'appel, 10 mars 1992, *Pas.*, 29, p. 5 ; 15 janvier 1997, nos 16643 et 16484 ; 8 mai 2002, n° 25301 ; 7 mars 2007, n° 29170.

60 RAVARANI, n° 493.

61 B. OPPETIT, « L'engagement d'honneur », *D.*, 1979, chroniques, p. 109.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ont qualifié de purement moral. Il s'agit d'éviter qu'une partie, qui a créé envers l'autre une relation de confiance en lui faisant croire qu'elle tiendrait sa promesse, ne puisse ensuite s'en défausser trop facilement. Dans un arrêt remarqué de 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation française a ainsi jugé qu'une société qui s'était engagée « moralement » à ne pas copier les produits commercialisés par une autre « avait exprimé la volonté non équivoque et délibérée de s'obliger envers la société concurrente »[62]. Ce type de décision montre bien que la volonté de s'obliger, telle qu'elle est retenue par les juges pour donner à un accord la qualification contractuelle, peut-être tout à fait distincte des intentions réelles que les parties avaient en tête au moment où elles ont passé l'acte.

42. **La volonté contractuelle comme volonté juridique.** Cette relativisation du rôle de la volonté comme élément de qualification du contrat a conduit certains auteurs à donner une définition purement positiviste du contrat, consistant à dire que, au fond, un contrat, c'est ce que la loi ou le juge qualifie comme tel[63]. Ce gommage de l'élément volontaire dans la définition du contrat est sans doute excessif, dans la mesure où, dans l'immense majorité des cas, les accords qui sont qualifiés de contrats reposent sur une réelle volonté de s'engager. Dans tous les accords importants, comportant une contrepartie financière, la volonté de se lier ne fait aucun doute, et les parties cherchent à déterminer en détail les effets juridiques attachés à leur contrat.

Il faut néanmoins bien être conscient que, même dans ces hypothèses, la volonté prise en considération n'est jamais une volonté psychologique pure, mais une volonté que la loi ou le juge considère comme juridique. Ainsi, pour déterminer si le contrat est valable, on n'exige pas que la volonté des contractants soit parfaitement éclairée et libre de toute contrainte : même si le droit sanctionne les « vices du consentement », ceux-ci ne sont pris en considération que de manière limitée, en tenant compte de certains impératifs de sécurité juridique, et beaucoup de contractants se retrouveront juridiquement engagés sans avoir vraiment compris la portée de leur engagement, ou parce qu'ils ont été contraints de passer le contrat par des nécessités économiques. De même, lorsqu'on recherche, pour interpréter les clauses d'un contrat, « l'intention des parties », cette recherche est souvent complètement divinatoire et aboutira à tenir pour volonté des parties ce que le juge considérera comme la volonté normale de contractants abstraits dans des circonstances analogues[64]. En outre, comme on va le voir, même si elles ont une volonté claire de s'engager, les

62 Cass. fr. (com.), 23 janvier 2007, n° 05-13189.

63 F. Collart Dutilleul, « Quelle place pour le contrat dans l'ordonnancement juridique ? », in *La nouvelle crise du contrat*, coll. Thèmes et commentaires, Paris, Dalloz, 2003, pp. 225 et s., spéc. p. 230. Sur cette définition Voy. P. Ancel, « Sur une approche nominaliste du contrat », in *Liber amicorum François Collart Dutilleul*, Paris, Dalloz, 2017, pp. 5-25

64 Ces différents aspects ont été particulièrement bien mis en évidence dans la thèse fondamentale, malheureusement non publiée, de G. Rouhette, *Contribution à l'étude critique de la notion de contrat*, 1965. On trouvera un bon résumé des idées soutenues par cet auteur dans : P. Jacques, *Regards sur l'article 1135 du Code civil*, Paris, Dalloz, 2005. Voy. aussi : Association Henri Capitant, *Hommage à Georges Rouhette*, coll. Thèmes et commentaires, Paris, Dalloz, 2014.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

parties n'auront pas nécessairement d'intention particulière relative à tous les effets juridiques que leur accord produira, et qui seront, pour une large part, déterminés par la loi ou le juge.

B) *Volonté contractuelle et détermination des effets du contrat*

43. Tout n'est pas contractuel dans le contrat. Dans une formule célèbre, mais souvent mal comprise, le célèbre sociologue français de la fin du XIXe siècle, Emile Durkheim, a affirmé que « tout n'est pas contractuel dans le contrat »[65]. La formule indique que, contrairement à ce qu'une approche excessivement volontariste du contrat avait pu faire croire pendant la plus grande partie du XIXe siècle, le contrat n'est pas exclusivement le produit de la volonté des parties, il est en réalité un mélange complexe d'éléments subjectifs (voulus par les parties) et objectifs (prévus, voire imposés de l'extérieur). Aussi bien, quand on dit que les parties à un contrat doivent avoir la « volonté de produire des effets de droit », cela ne signifie pas qu'elles ont la maîtrise de ces effets. Plusieurs phénomènes juridiques établissent le contraire de manière concordante.

44. Effets voulus et effets non voulus. Il faut être conscient que, même si le contrat suppose un accord de volontés, et un accord « destiné à produire des effets de droit », les parties n'ont jamais en tête, au moment où elles se mettent d'accord, la totalité des effets que le contrat peut produire. Cela est évident dans les « petits » contrats de la vie quotidienne, où les parties ont tout au plus la conscience de passer un accord produisant des effets juridiques, mais sans en connaître le détail : qui songe, en achetant un gâteau chez le pâtissier, aux règles juridiques qui pourront s'appliquer si la crème qui le garnit est avariée et provoque une intoxication alimentaire ? Mais, même dans les contrats les plus volontairement construits, comportant toutes sortes de clauses énumérant les différents droits et obligations des parties, il est rare que les rédacteurs aient pensé à toutes les difficultés qui pourraient surgir, et aux solutions qui devraient leur être données, et il peut aussi arriver qu'ils gardent volontairement le silence sur tel ou tel point sur lequel l'accord des contractants ne peut se faire. Dans de telles hypothèses, la détermination des effets produits par le contrat ne peut pas reposer sur la volonté des parties, par hypothèse absente, elle procédera de la loi ou de la décision du juge. D'une part, dans un

65 E. DURKHEIM, *De la Division du travail social*, 1893, p. 189.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

système légaliste comme celui du Luxembourg, il existe toute une série de textes légaux, dans le Code civil ou ailleurs, qui viennent déterminer les effets des principaux contrats pour le cas où les parties ne l'auraient pas fait elles-mêmes : c'est ce qu'on appelle des *lois supplétives*. D'autre part, si la solution ne se trouve pas dans les textes, il appartiendra au juge, saisi d'un litige sur un point non réglé par les parties, de déterminer lui-même les effets que doit produire le contrat. Dans le Code civil, cette fonction complétive de la loi et de la jurisprudence en matière contractuelle est explicitement prévue par un texte fondamental, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, l'article 1135 du Code civil (dont on trouve l'équivalent dans de nombreux textes juridiques), selon lequel « [l]es conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'usage, l'équité, ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». Dans une approche strictement volontariste du contrat, ces « suites » contractuelles déduites de « l'usage, l'équité, ou la loi » étaient rattachées à la volonté implicite des parties, et les lois supplétives, en particulier, étaient souvent présentées comme des « lois interprétatives de volonté ». Cette approche est aujourd'hui très contestée : on doit plutôt lire, dans l'article 1135 du Code civil, la reconnaissance, par le législateur, qu'une partie des effets du contrat échappe à la volonté des parties, et est fixée, objectivement, par la loi ou le juge[66].

Dans les pays de *common law*, où il existe beaucoup moins de réglementations légales des différents contrats, les parties seront souvent soucieuses d'échapper aux incertitudes que peut présenter la détermination par le juge des effets non prévus dans le contrat. On peut ainsi expliquer la pratique contractuelle de ces pays, où la rédaction des contrats, comportant parfois plusieurs centaines de pages, sera souvent extrêmement détaillée. Dans les pays de droit civil, les contractants prendront moins souvent la peine d'entrer dans le détail de toutes les questions, sachant que les points non abordés seront souvent réglés à titre supplétif par des textes légaux.

45. Effets imposés par la loi ou le juge. Les effets des contrats déterminés par la loi seront parfois imposés aux parties, nonobstant toute volonté contraire de celles-ci : on est alors en présence de *lois impératives*. Ces lois, qui sont une traduction de la notion d'ordre public, sont de plus en plus nombreuses dans le droit contemporain des contrats. La jurisprudence, de son coté, impose également à certains contractants des obligations qui n'ont absolument pas été envisagées par les parties au moment de leur engagement, et qu'elles ne peuvent du reste pas écarter : c'est ainsi que la jurisprudence

66 Voy. not. P. Jacques, *Regards sur l'article 1135 du Code civil*, *op. cit.*

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

française, suivie au Luxembourg, a « découvert », ou plus exactement créé, dans de nombreux contrats, des obligations impératives de sécurité (faisant peser sur un contractant la charge de la réparation des dommages corporels subis par l'autre lors de l'exécution du contrat), ou des obligations d'information et de conseil. Cette création d'obligations par le juge est souvent qualifiée, à la suite de L. Josserand de « forçage du contrat »[67], par des auteurs qui présupposent que la seule source normale des effets du contrat est la volonté des parties. Ce « forçage », de même que les lois impératives qui déterminent le contenu du contrat contre la volonté des parties, montre au contraire que les parties ne sont pas complètement maîtresses des effets juridiques de leur accord, que le contrat est un ensemble complexe d'éléments volontaires (subjectifs) et objectifs (fixés par la loi ou le juge). Ce mélange peut s'opérer dans des proportions variables selon la marge d'autonomie que le système juridique souhaite laisser aux parties dans l'organisation de leurs relations. Nous verrons que, dans le droit luxembourgeois moderne, comme dans tous les droits des pays européens, la part de l'imposé par rapport à celle du voulu est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque du Code.

La question se pose cependant de savoir jusqu'où on peut aller dans cette diminution de la part de la volonté dans le contrat, sans complètement vider la notion de contrat de sa substance. Est-on encore en présence d'un contrat si tous les effets de l'accord des parties sont prédéterminés par la loi, de sorte que la marge d'autonomie laissée aux « contractants » se limite à se soumettre (ou à refuser de se soumettre) à ce statut prédéterminé ? Traditionnellement, pour sauvegarder le rôle de la volonté comme « essence » du contrat, on avait tendance à répondre à cette question par la négative. C'est dans cet esprit que, dans l'opinion majoritaire, on considère toujours que le mariage, alors même qu'il repose incontestablement sur un accord de volontés destiné à produire des effets de droit, n'est pas un contrat, mais, dit-on, une institution[68]. Ce terme vise à signifier que, pour reprendre la présentation qui ouvrait ce manuel, on a quitté le modèle de régulation horizontale représenté par le contrat pour basculer dans un système de régulation verticale, où c'est la loi qui décide pour les individus. En se mariant, les époux se sont placés sous un régime entièrement légal qui traduit la conception que la société se fait des relations familiales. La discussion pourrait être rouverte. D'une part, le mariage s'est, dans une certaine mesure, « contractualisé », notamment avec la reconnaissance du divorce par consentement mutuel dont les époux peuvent régler eux-mêmes les effets. D'autre part, avec le

[67] L. JOSSERAND, « L'essor moderne du concept contractuel », in *Recueil d'études des sources du droit en l'honneur de François Geny*, t. II, *Sources générales des systèmes juridiques actuels*, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1934, pp. 333 et s., spéc. p. 340.

[68] Attention ! Ne confondez pas le mariage lui-même, avec le « contrat de mariage » par lequel les futurs époux, avant de se marier, décident devant notaire du choix de leur régime matrimonial, et qui est, incontestablement, un véritable contrat, même s'il est soumis par le Code à des règles très spécifiques.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

développement de l'interventionnisme étatique dans les relations privées, on s'est habitué à des contrats « hyper réglementés » dans lesquels les parties n'ont guère que la latitude d'entrer ou non dans un moule dont le contenu est presque entièrement fixé par la loi. La limite à ne pas dépasser, cependant, est celle de l'exigence d'une volonté des parties d'entrer ou non dans la relation même largement préréglée par la loi : il ne sert à rien de parler de contrat si les règles légales s'imposent de toute façon aux sujets de droit, qu'ils aient ou non exprimé la volonté de s'y soumettre.

Le problème des frontières de la notion de contrat a été beaucoup agité en France ces dernières années, avec le développement de ce qu'un auteur a appelé les « contrats pédagogiques »[69]. Dans un certain nombre de cas, le législateur français a imposé à des sujets de droit de signer des documents appelés « contrats », énumérant un certain nombre de droits et d'obligations de toute façon prévus par la loi pour s'appliquer aux personnes concernées. Il en a été ainsi du Plan de retour à l'emploi (PARE), document que, en vertu d'une convention agréée entre les partenaires sociaux, le demandeur d'emploi était obligé de signer pour avoir droit aux allocations chômage, mais qui, pour l'essentiel, reprenait les obligations légales de l'une et l'autre « partie », celle du demandeur d'emploi de rechercher du travail et celle de l'organisme social de verser des allocations pendant une certaine période, en précisant simplement les modalités. Après quelques hésitations, la Cour de cassation française a décidé qu'il ne s'agissait pas là d'un véritable contrat[70]. Le problème s'est également posé pour la « charte des thèses », document prévu par un arrêté ministériel, et que les universités imposent désormais de signer à chaque doctorant et à l'enseignant-chercheur qui les encadre pour rappeler les relations de nature réglementaire qui les unissent : le Conseil d'État français a jugé que la signature de ce document « […] n'a pas pour objet et ne pourrait d'ailleurs avoir légalement pour effet d'établir une relation de nature contractuelle entre les signataires »[71]. Même si la mode de ces pseudo-contrats ne semble pas avoir atteint le Luxembourg, ces exemples n'en sont pas moins révélateurs d'un certain amenuisement du rôle de la volonté des parties dans la définition même du contrat.

46. Effets voulus par l'un et imposés à l'autre. Les limites du rôle de la volonté dans la détermination des effets produits par le contrat sont également illustrées par l'important phénomène des **contrats d'adhésion**, mis en évidence par la doctrine française dès la fin du XIXe siècle, et aujourd'hui largement reconnu[72]. La notion désigne des contrats où la majeure partie des effets sont prédéterminés par un des contractants, généralement sous forme de conditions générales susceptibles de régir les relations avec une multitude de cocontractants potentiels. Il suffit de songer aux contrats proposés à leur clientèle par les grands distributeurs, par les opérateurs de

69 J. Rochfeld, « Le PARE ou les virtualités du "contrat pédagogique" », *R.D.C.*, 2005, p. 257 ; « Le contrat de responsabilité parentale, une nouvelle figure du "contrat pédagogique" », *R.D.C.*, 2006, p. 665. M. Mekki, « Le discours du contrat : quand dire, ce n'est pas toujours faire », *R.D.C.*, 2006, p. 297.

70 Cass. fr. (soc.), 31 janvier 2007, n° 04-19464.

71 C.E. fr., 21 décembre 2001, n° 220997.

72 R. Saleilles, *De la déclaration de volonté : contribution à l'étude de l'acte juridique dans le Code civil allemand (art. 116 à 144)*, Paris, Pichon, 1901, p. 129.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

services téléphoniques ou Internet, par les compagnies de location de voitures, par les banques ou les compagnies d'assurance. Compte tenu du déséquilibre considérable qui existe entre le contractant rédacteur des clauses et le client, celui-ci n'a, dans l'immense majorité des cas, aucune possibilité de discuter les clauses du contrat qui lui sont soumises (à supposer même qu'il ait le temps et l'envie d'en prendre connaissance). La volonté de ce cocontractant ne joue donc aucun rôle dans la détermination des effets du contrat, elle se limite à une acceptation en bloc du contrat dans son principe, qui entraîne l'adhésion plus ou moins forcée, plus ou moins consciente, à toutes les clauses prérédigées par l'autre. Le rôle très limité de la volonté de l'adhérent est particulièrement évident dans la pratique contemporaine des contrats passés par Internet, où la volonté de contracter s'exprime simplement par deux clics, l'un pour reconnaître (de manière évidemment mensongère) qu'on a pris connaissance des conditions générales du vendeur, l'autre pour confirmer l'achat, le tout sans avoir la moindre idée du détail des effets que le contrat fait produire. Lorsque, au début du XXe siècle, les juristes ont pris conscience du phénomène des contrats d'adhésion, on s'est interrogé pour savoir s'il s'agissait de véritables contrats : le rôle très limité de la volonté de l'adhérent amenait alors certains auteurs à soutenir qu'on était plutôt en présence d'une sorte de réglementation unilatérale d'origine privée devant être appréhendée par le droit par des mécanismes de contrôle analogues à ceux développés pour les actes administratifs. En quelque sorte, les contrats d'adhésion s'apparenteraient davantage au modèle de régulation verticale qu'à celui de régulation horizontale s'exprimant à travers le contrat. Cette conception ne l'a pas emporté, et les contrats d'adhésion sont aujourd'hui, partout, considérés comme de véritables contrats, même si, comme nous le verrons à maintes reprises, les législations modernes édictent de nombreuses règles pour contrebalancer le caractère unilatéral de la détermination des effets contractuels, en protégeant le contractant faible contre les excès de pouvoir de l'autre. Ces règles interviennent notamment dans les relations entre contractants professionnels et consommateurs, où le phénomène des contrats d'adhésion est particulièrement développé. Pour l'instant, ce qui nous importe dans cette prise en compte des contrats d'adhésion par les règles du droit des contrats, c'est qu'elle révèle l'acceptation par la communauté des juristes de l'idée que la volonté des parties (ou du moins, ici, d'une partie), peut ne jouer dans un contrat qu'un rôle très limité : au fond, ce qu'on

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

admet aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir contrat du seul fait que la personne qui le passe a le choix de dire oui ou non, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait un quelconque pouvoir d'en discuter les effets. La notion de contrat d'adhésion a fait son entrée dans le Code civil du Luxembourg dès 1997 (C. civ., art. 1135-1), elle est également présente, depuis les réformes, dans les codes français et belge.

§ 3. La création d'obligations

47. Notion d'obligation. À suivre la lettre de l'article 1101 du Code civil, le contrat n'est pas un accord destiné à faire naître n'importe quel effet de droit. Les parties doivent, selon le texte « s'obliger à faire, à ne pas faire ou à donner quelque chose ». Le texte établit ici un lien entre le contrat et la notion, issue du droit romain, d'obligation. Dans son sens strict, l'obligation est un rapport juridique entre deux personnes par lequel l'une (le débiteur) s'oblige à quelque chose envers une autre (le créancier). L'article 1101 du Code civil ouvre du reste un titre intitulé « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général », et les obligations dont il est question sont réglementées plus loin, après les règles relatives à la formation et aux effets des contrats, dans les articles 1136 et suivants du Code civil qui distinguent les différentes espèces d'obligations, en définissent les différentes modalités particulières, puis traitent de leur mode d'extinction. Dans tous ces articles, qui constituent la base de ce qu'on appelle le « régime général de l'obligation », il est bien question de rapports entre créanciers et débiteurs, donc d'obligations au sens strict. C'est en ce sens que, dans la tradition de l'enseignement dans les pays du Code civil, le droit des contrats est traité comme une partie du « droit des obligations » – en parallèle aux autres sources d'obligations que sont la responsabilité civile et les quasi-contrats.

48. Obligation civile et obligation naturelle. En principe, toute obligation implique le pouvoir pour le créancier de contraindre, par diverses voies de droit, le débiteur à l'exécution de la prestation. Ce pouvoir de contrainte semble cependant connaître une exception avec ce qu'on appelle les obligations naturelles (par opposition aux obligations ordinaires, dites civiles). Il s'agit de cas où on considère qu'une personne est obligée envers une autre, alors même que le créancier ne peut exiger en justice l'exécution de cette obligation. L'obligation se traduit alors seulement par le fait que, si elle est

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

exécutée volontairement, le débiteur ne pourra pas ensuite dire qu'il a payé quelque chose qu'il ne devait pas pour obtenir restitution de ce qu'il a versé. Cette solution est expressément visée par l'article 1235 du Code civil (devenu 1302 en France). Par ailleurs, si on a commencé d'exécuter une obligation de ce type, on devra aller jusqu'au bout : l'obligation se transformera alors en une obligation civile, dont l'exécution pourra être exigée en justice, et éventuellement donner lieu à contrainte. D'une manière générale, ce type d'obligation est liée à l'idée d'un devoir de conscience assumé par une personne (par exemple l'aide financière apportée à un frère ou une sœur à l'égard de qui on n'est tenu d'aucune obligation alimentaire, la rémunération volontaire d'un service qui vous a été rendu gracieusement…). En droit français, ce cas de figure est désormais visé, sans cependant que le terme « obligation naturelle » soit employé, par l'article 1100, alinéa 2, du Code civil, selon lequel une obligation peut naître « de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui ». L'article 5-2 du nouveau Code civil belge donne de l'obligation naturelle une définition explicite : « L'obligation naturelle est une obligation dont l'exécution ne peut être exigée ». La notion est bien connue de la jurisprudence luxembourgeoise[73], mais elle ne vise pas *a priori* les obligations naissant d'un contrat, puisque ces obligations, en vertu de la force obligatoire du contrat, ont nécessairement un caractère contraignant.

45-2. Plan suivi. L'article 1101 invite, d'emblée, à faire une distinction entre les divers types d'obligations qui peuvent faire l'objet d'un contrat (**A**). Il amène également à faire une distinction – dont la portée doit être fortement relativisée – entre le contrat *stricto sensu* et les conventions qui n'ont pas pour objet la création d'obligations, mais d'autres types de rapports de droit (**B**).

A) *La distinction des divers types d'obligations contractuelles*

49. Diversité des obligations contractuelles. Les obligations qui naissent d'un contrat peuvent avoir les objets les plus divers (livrer un bien, payer une somme d'argent, donner un conseil ou une information, assurer la sécurité d'une personne ou de ses biens, construire une maison, etc.). Dans sa définition du contrat, l'article 1101 du Code civil, reprenant en partie une classification du droit romain,

[73] Voy. p. ex. Cour d'appel, 13 juillet 2016, n 42892.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

regroupe ces objets multiples en trois catégories : faire, ne pas faire et donner quelque chose. Ces trois catégories sont par la suite reprises à propos des effets du contrat, aux articles 1136 et suivants du Code civil[74]. Cette classification tripartite, qui est aujourd'hui souvent contestée en doctrine, et qui a disparu du code français après la réforme[75] (**1**), n'est pas exclusive d'autres classifications, introduites par la doctrine et la jurisprudence (**2**).

1) *La classification de l'article 1101 du Code civil*

50. Obligations de faire. Ce sont les obligations les plus courantes, dans lesquelles le débiteur s'oblige envers le créancier à une action, à une prestation positive. Constituent de telles obligations, par exemple : l'obligation du vendeur de livrer la chose vendue à l'acheteur, l'obligation du salarié de faire le travail pour lequel il est payé, l'obligation du bailleur de mettre la chose louée à disposition du locataire, l'obligation pour un entrepreneur de construire la maison qui lui a été commandée, l'obligation pour le teinturier de nettoyer le vêtement qui lui a été confié, l'obligation pour l'avocat de délivrer des conseils pertinents à son client, l'obligation mise à la charge de certains professionnels par la loi ou la jurisprudence d'informer le contractant consommateur, etc. On pourrait y ajouter les obligations de payer une somme d'argent, qui sont sans doute les plus fréquentes (et auxquelles d'ailleurs on pense immédiatement lorsqu'on évoque les qualités de créancier et de débiteur). Mais, en réalité ces obligations constituent une catégorie transversale qui s'intègre particulièrement mal dans la classification tripartite de l'article 1101 du Code civil. Elles constituent plutôt un des termes d'une autre classification, que nous retrouverons plus loin.

Au sein de la catégorie générale des obligations de faire, telle qu'on l'entend aujourd'hui, le droit romain faisait une distinction entre les obligations de *facere* (faire quelque chose, au sens strict) et les obligations de *praestare*, ayant pour objet la remise d'une chose à titre d'usage à une personne qui n'en devient pas propriétaire. Telle est, par exemple, l'obligation du bailleur (qui remet la chose louée entre les mains du locataire) ou du prêteur à usage (prêt d'un livre, d'une voiture, etc.). Certains auteurs français ont plaidé récemment pour la redécouverte de cette catégorie, écartée par les rédacteurs du Code civil, mais qui, selon eux, mériterait d'être distinguée

[74] Chapitre III, De l'effet des obligations, Section 2 : De l'obligation de donner, Section 3 : De l'obligation de faire ou de ne pas faire.

[75] Mais non du code belge. Elle a disparu de la définition du contrat, mais figure aujourd'hui à l'article 5.46 relatif à l'objet du contrat. Le texte ajoute à la classification traditionnelle une quatrième catégorie, celle des obligations « de garantir quelque chose ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de celle des obligations de faire[76]. La spécificité de cette obligation réside en ce que la prestation s'accomplit en un moment (la remise de la chose) mais prolonge ensuite ses effets dans le temps, le bailleur ou le prêteur étant tenus de laisser le locataire ou l'emprunteur user de la chose jusqu'à la fin du contrat. Les rédacteurs du premier avant-projet français de réforme du droit des obligations, le projet Catala de 2005, avaient tenu compte de cette spécificité en introduisant dans leur projet, à côté des trois catégories de l'article 1101 du Code civil, la notion d'« obligation de donner à usage ». Ce raffinement – qui ne semble guère avoir trouvé d'écho en Belgique ni au Luxembourg – ne paraît guère présenter d'intérêt pratique. La notion n'a pas été reprise par la réforme française de 2016, pas plus que dans le nouveau droit belge.

51. Obligations de ne pas faire. Les obligations de ne pas faire sont celles dans lesquelles le débiteur s'oblige à s'abstenir de quelque chose. Par exemple, dans un contrat de distribution contenant une clause d'exclusivité, le distributeur s'engage à ne se fournir en marchandises qu'auprès de son cocontractant, et à ne pas les acheter ailleurs. Un cadre salarié d'une banque s'engage, s'il vient à quitter son travail, à ne pas se faire réembaucher dans un certain délai par une autre banque de la même place. Le vendeur d'un immeuble est obligé, de par la loi, à ne pas troubler la jouissance de son acquéreur, etc. Ces obligations de ne pas faire obéissent à un régime spécial quant à la sanction de leur inexécution[77].

52. Obligations de donner. Si les deux premières catégories visées par l'article 1101 du Code civil semblent correspondre à une distinction rationnelle (encore que l'intérêt en soit assez limité), la troisième catégorie, celle des obligations de donner, appelle davantage de discussion. Le terme utilisé est particulièrement trompeur : « donner », ici, ne signifie pas, comme dans le langage courant, « faire un cadeau ». C'est en réalité la traduction française du terme latin « *dare* », qui signifiait « transférer la propriété »[78]. L'obligation de donner est donc l'obligation de transférer la propriété d'une chose. C'est une obligation qu'on va rencontrer dans différents contrats qui ont cet objet : le plus important est bien sûr la vente (transfert de propriété contre paiement d'un prix), mais il faut aussi penser à l'échange (dans lequel le prix est remplacé par un bien de valeur équivalente), et à la donation (où le transfert s'opère à titre gratuit). Cependant, comme nous allons le voir, l'existence dans ces différents

76 G. PIGNARRE, « À la redécouverte de l'obligation de *praestare* – Pour une relecture de quelques articles du code civil », *RTD civ.*, 2001, p. 41.

77 Voy. en particulier l'article 1145 du Code civil. Voy. *infra*, n° 828.

78 On retrouve cette étymologie dans l'expression de « dation en paiement », qui est la remise d'un bien en paiement à la place d'une somme d'argent. Voy. *infra*, n° 651.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

contrats d'une « obligation de transférer la propriété » est en réalité assez douteuse : c'est une des principales critiques qu'on peut adresser à la classification de l'article 1101 du Code civil.

La difficulté vient de ce que, dans le système du Code civil, les contrats qui ont pour objet de transférer la propriété (la vente, mais aussi l'échange et la donation) produisent cet effet de plein droit, dès le moment de leur formation. On dit que le transfert de propriété s'opère *solo consensu*[79]. Cette solution, qui tranche avec celle qui était admise en droit romain et encore dans l'Ancien droit français, a été posée par les rédacteurs du Code civil dans l'article 1138 du Code civil qui dispose que « l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes » et que « elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée ». On la retrouve exprimée très nettement à propos de la vente, dans l'article 1583 du Code civil selon lequel « la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Il en résulte, par exemple que, si je vous ai vendu ma voiture, que je dois vous livrer une semaine plus tard, et que, entre le moment de la vente et celui de la livraison, ma voiture vient à être détruite par une explosion survenue dans mon garage, vous devez quand même me la payer puisque vous en êtes, dès la vente, devenu propriétaire, et que c'est logiquement au propriétaire de supporter les risques de perte ou de destruction de la chose[80]. Par ailleurs, si je vous vends un bien et que vous ne me le payez pas, vous n'en devenez pas moins propriétaire, et si je veux rentrer dans mes fonds, je ne pourrai que saisir le bien comme n'importe quel créancier[81]. Dans le nouveau droit français des contrats, la règle est posée de manière générale par l'article 1196 du Code civil selon lequel, « [d]ans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat ». La solution est beaucoup moins claire dans le nouveau droit belge, parce que l'article 5.79 renvoie pour le moment du transfert de propriété à l'article 3.14 § 2 (texte du Livre sur les biens). Or celui-ci dispose que : « Le transfert ou la constitution d'un droit réel se réalise par un acte juridique translatif ou constitutif émanant d'une personne disposant du pouvoir de disposition, en exécution d'un titre valable emportant obligation de donner » – ce qui pourrait être interprété comme introduisant une dissociation entre l'acte de vente et l'acte translatif de propriété. Mais les divers exposés des motifs des différentes versions du projet attestent que les rédacteurs n'ont pas entendu abandonner le principe du transfert de propriété *solo consensu*. Cette règle du transfert *solo consensu* semble dès lors priver de toute consistance l'obligation de donner de l'article 1101 du Code civil : dès que la vente est passée, la propriété est transférée, sans que le vendeur n'ait rien à faire ni à dire ; il n'est donc plus débiteur d'aucune « obligation » à cet égard. L'obligation de transférer la propriété s'éteint au moment même où elle naît. La seule obligation du vendeur est de livrer la chose, ce qui, on l'a vu, est une obligation de faire. Il est vrai que, dans un certain nombre de cas, comme le prévoit maintenant le nouvel article 1196 du Code civil français, le transfert de propriété est différé par rapport au contrat « par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi » : il en va ainsi, en vertu de la loi, lorsque la chose vendue est une chose

79 Il vaudrait mieux dire « *solo contractu* » dans la mesure où, de plus en plus souvent, dans le droit moderne, la validité de la vente est subordonnée au respect d'un certain formalisme.

80 Sur cette « théorie des risques » voy. *infra*, n°s 766 et s.

81 Voy. *infra*, n° 720.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

fongible (auquel cas, selon l'article 1585 du Code civil, le transfert ne s'opérera qu'au moment de l'individualisation, donc le plus souvent de la livraison) ; il en va ainsi, également, lorsque conventionnellement les parties décident de reporter le transfert de propriété au moment du paiement du prix (clause dite de réserve de propriété). Mais, même dans ces hypothèses, le transfert de propriété ainsi différé s'opère de manière complètement automatique, par l'effet de la livraison ou du paiement, de sorte que la prétendue « obligation de donner » ne se distingue pas de l'obligation de faire ou de payer qui pèse à titre principal sur le vendeur ou sur l'acheteur. Ces considérations expliquent qu'il existe aujourd'hui, dans la doctrine française, un certain courant en faveur de la disparition de la notion d'obligation de donner, jugée (à juste titre selon moi) parfaitement inutile[82]. Cependant, on trouve toujours certains auteurs pour défendre cette distinction[83], qui semble toujours ancrée dans la doctrine belge[84]. Les projets français de réforme du droit des obligations révèlent bien les hésitations doctrinales à ce sujet : alors que l'avant-projet de 2005 (projet Catala), avait maintenu cette notion[85], elle a complètement disparu du projet de 2009 du groupe Terré[86], ainsi que du projet ministériel de 2015, qui traitent des effets du contrat sur le transfert de propriété, sans présenter cet effet comme l'objet d'une obligation, et c'est finalement la position qui a été adoptée dans le texte de l'ordonnance de 2016. En revanche, le nouveau texte belge fait toujours référence à cette obligation dans l'article 5-46 du Code civil qui la définit comme celle qui « tend au transfert d'un droit ou à la constitution d'un droit réel ». Ce pourrait n'être qu'une question de présentation, car, sur le fond, les auteurs et les nouveaux textes français et belge sont d'accord pour maintenir la règle selon laquelle, dans les contrats translatifs de propriété, le transfert s'opère par le seul échange des consentements (même s'il y a sur ce point une ambiguïté dans les nouveaux textes belges). La volonté de certains de rattacher cet effet légal du contrat à une fantomatique « obligation de donner » (ce qui, on le verra, n'a strictement aucune conséquence pratique) s'explique par l'idée, profondément ancrée dans la doctrine française et belge, que les différents aspects de la force obligatoire du contrat (ici : le transfert de propriété) se ramènent à des « obligations », dont on entend alors la notion de manière très large[87].

Le principe du *transfert solo consensu* distingue nettement les droits des pays du Code civil d'autres systèmes juridiques (plutôt majoritaires) où le transfert de propriété est dissocié de la conclusion du contrat, pour être, généralement, lié à la remise effective du bien. Cette dissociation, héritée du droit romain, est poussée à l'extrême en droit allemand, où une opération ayant pour objet le transfert de propriété d'une chose (comme la vente) se décompose en plusieurs contrats : dans un premier temps, la vente proprement dite n'est qu'un contrat faisant naître des obligations (*Schuldvertrag*) – le vendeur s'obligeant à transférer la propriété et à livrer la chose ; dans un deuxième temps (qui peut en pratique suivre immédiatement) il faut un

82 Voy. not. en ce sens : M. FABRE MAGNAN, « Le mythe de l'obligation de donner », *RTD civ.*, 1996, p. 85.

83 Voy. not. : J. HUET, « Des différentes sortes d'obligations et plus particulièrement de l'obligation de donner, la mal nommée, la mal aimée », in *Études offertes à Jacques Ghestin : le contrat au début du XXIe siècle*, Paris, LGDJ, 2001, p. 426.

84 Voy. P. VAN OMMESLAGHE, *Traité de droit civil belge*, t. II, *Les obligations*, vol. 1, coll. De Page, Bruxelles, Bruylant, 2013, n° 10 (cité *infra*, VAN OMMESLAGHE, vol. 1).

85 Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, art. 1152 et s.

86 Pour une réforme du droit des contrats, *ibid.*, art. 93 et s.

87 Pour une critique de cette idée voy. *infra*, n°s 483 et s., et P. ANCEL, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », *RTD civ.*, 1999, p. 771.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

second contrat pour transférer la propriété (*dinglicher Vertrag*), ce qui suppose soit la remise de la chose en matière mobilière, soit l'inscription au Livre foncier (*Grundbuch*) pour les immeubles (et, en théorie, le transfert de la propriété de l'argent s'analyse en un troisième contrat). Ce principe de séparation (*Trennungsprinzip*), qu'on retrouve en droit suisse ou en droit autrichien, est, en Allemagne, complété par un principe d'abstraction (*Abstraktionsprinzip*) en vertu duquel le second contrat est indépendant, pour sa validité, du premier. En droit anglais, et d'une manière générale dans les pays de *common law*, les règles sont moins rigides, mais il n'existe pas, comme dans les pays du Code civil, de lien nécessaire entre la conclusion du contrat et le transfert de propriété ; tout dépend de l'intention des parties, qu'on déduit parfois de certaines présomptions légales[88]. Dans ces systèmes, on comprend qu'on puisse parler d'une « obligation de donner », puisque le vendeur doit accomplir certaines choses pour que le transfert s'opère. Au-delà de l'existence ou non de cette obligation, il faut surtout noter les différences fondamentales de conception entre les systèmes juridiques quant aux rapports entre le contrat et la propriété. Dans les pays du Code civil, la question du transfert de propriété est considérée, d'abord, comme une question de droit des contrats, et régie comme telle par le Code : ce n'est pas un hasard si tout le droit des contrats est régi dans un Livre curieusement intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ». Dans beaucoup d'autres pays, et notamment dans les droits germaniques, le transfert de propriété par contrat relève fondamentalement du droit des biens. Ces conceptions différentes, profondément ancrées dans la pensée des juristes des pays considérés, explique qu'il soit très difficile de concevoir une réglementation uniforme de la question, à l'échelle internationale ou européenne : c'est pourquoi les différents instruments ou projets d'unification du droit de la vente laissent soigneusement cette question hors de leur champ[89].

2) *Les autres classifications des obligations selon leur objet*

53. Obligations monétaires et obligations non monétaires. L'immense majorité des contrats emportent, pour l'une des parties, l'obligation de payer une somme d'argent à l'autre. Cependant, cette catégorie d'obligations n'est pas visée par l'article 1101 du Code civil. C'est qu'il s'agit en quelque sorte d'une catégorie transversale, à cheval sur les trois catégories de l'article 1101 du Code civil. Dans la plupart des cas, l'obligation de payer peut être considérée comme une obligation de faire, dans la mesure où le débiteur doit accomplir, pour payer, une prestation positive : sortir l'argent de son portefeuille, tirer un chèque, émettre un virement, introduire sa carte de paiement ou de crédit dans la machine, etc. Mais, dans la pratique contemporaine, ce peut être aussi une obligation de ne pas faire : par exemple, l'abonné téléphonique qui a donné au moment de son abonnement une autorisation de prélèvement mensuel du montant de ses communications s'oblige à ne pas révoquer

88 J. Cartwright, *Contract law: An introduction to the English Law of contract for the civil lawyer*, 3e éd., Oxford, Hart Publishing, 2016, p. 55 (cité *infra*, Cartwright).

89 Il en va ainsi de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, et du projet européen de règlement portant droit commun européen de la vente.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

cette autorisation, et à ne pas retirer l'argent de son compte pour éviter le paiement effectif. Dans tous les cas, l'obligation de payer se rattache aussi à l'obligation de donner (si on croit à l'autonomie de cette obligation), puisque le paiement se traduira par le transfert de propriété des unités monétaires au profit du créancier.

Quoi qu'il en soit, les obligations monétaires présentent, par rapport aux autres obligations de faire ou de ne pas faire, qui n'ont pas un objet monétaire, une spécificité accusée. D'une part se pose à leur égard un problème d'évaluation qui n'a pas de sens pour les autres obligations : lorsqu'une dette a été contractée en une certaine monnaie et que la valeur de cette monnaie change dans le temps, on se demande si le débiteur doit payer le montant nominal, ou si ce montant peut être révisé en fonction de l'évolution du pouvoir d'achat qu'il procure (si j'ai prêté 1 000 € il y a dix ans, et que je récupère aujourd'hui la même somme, il est clair qu'elle ne me permettra pas d'acheter autant de choses qu'il y a dix ans !). D'autre part, les obligations de somme d'argent paraissent plus faciles à faire exécuter, en cas de défaillance du débiteur, que les obligations ayant un objet non monétaire : comme nous le verrons plus loin, si mon emprunteur ne me rembourse pas la somme que je lui ai prêtée, je pourrai saisir ses biens, les faire vendre, et me payer sur leur prix ; si mon plombier refuse de venir réparer la tuyauterie de ma salle de bains, j'aurai à première vue plus de mal à le contraindre. Cette différence explique la règle posée – de manière à vrai dire très maladroite – par l'article 1142 du Code civil selon lequel « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ». Contrairement à ce qu'on pourrait croire, et à ce que la place du texte dans le Code laisserait supposer, le texte n'établit pas une règle spécifique aux obligations de faire ou de ne pas faire par opposition aux obligations de donner (pour lesquelles, nous le verrons, le problème de l'exécution forcée se pose de manière complètement différente). Le texte entend en réalité établir une différence entre les obligations de faire ou de ne pas faire non monétaires (qu'il est, de prime abord, impossible de faire exécuter par la force) et les obligations de payer une somme d'argent (susceptibles d'une exécution forcée directe)[90].

54. **Obligations de moyens et obligations de résultat.** On mentionnera ici seulement pour mémoire cette distinction d'origine doctrinale, aujourd'hui clairement consacrée par la jurisprudence dans les trois pays du Code civil (et qui est

[90] Sur la signification exacte de l'article 1142 du Code civil, voy. *infra*, n[os] 718 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

reprise textuellement dans l'article 5.72 du nouveau Code civil belge). C'est une sous-distinction des obligations de faire : dans certains cas, celui qui s'est engagé à faire quelque chose est tenu d'atteindre le résultat promis (par exemple, la livraison d'un bien), alors que dans d'autres, il doit seulement mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre ce résultat (par exemple, le médecin, qui ne s'oblige pas à guérir le malade, mais seulement à le soigner correctement). La distinction est surtout importante lorsqu'il s'agit de savoir à quelles conditions un contractant peut être déclaré responsable du dommage subi par l'autre – et c'est pour cela qu'elle a été inventée. Lorsque l'obligation est de résultat, le débiteur est responsable du seul fait que le résultat n'a pas été atteint, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa faute. Lorsqu'on est en présence d'une obligation de moyens, le débiteur ne sera responsable que si la victime prouve qu'il n'a pas mis tous les moyens en œuvre pour atteindre le résultat – donc qu'il a commis une faute. Nous retrouverons en détail cette distinction lorsque nous étudierons la responsabilité contractuelle[91].

B) *La distinction du contrat et des conventions non génératrices d'obligations*

55. Principe. Ainsi défini comme faisant naître une ou plusieurs obligations, le contrat se distingue d'autres accords de volonté, par lesquels les parties entendent bien se lier juridiquement, et qui produisent des effets juridiques, qui « obligent » les parties (en ce sens qu'ils les engagent) mais qui ne créent pas un rapport d'obligation dans ce sens strict. Prenons l'exemple d'une remise de dette, accord réglementé par les articles 1282 à 1288 du Code civil, par lequel un créancier se met d'accord avec son débiteur pour éteindre l'obligation en tout ou en partie : il s'agit bien d'un accord faisant naître, pour le créancier, un véritable engagement, en ce sens qu'il ne pourra pas revenir sur la remise et exiger le paiement de l'intégralité de la dette ; mais il ne s'agit pas d'un accord créateur d'une obligation, puisque tout au contraire, l'effet juridique produit (et voulu) est d'éteindre une obligation préexistante. Un autre exemple est celui d'un accord par lequel les deux parties à un contrat international conviennent de soumettre leur contrat à la loi de tel ou de tel pays : là encore, cet accord est obligatoire, en ce sens que le juge saisi d'un litige relatif à ce contrat devra appliquer la loi désignée, sans qu'aucune des parties ne puisse s'y opposer, mais on ne peut pas dire que cet accord rend l'une des parties créancière ou débitrice de l'autre. Si on prend l'article 1101 du Code civil à la lettre, ces accords ne sont pas de véritables contrats. Pour rendre compte de cette distinction, la doctrine française du XIXe siècle, en s'appuyant sur le texte de l'article 1101 du Code civil, a développé

91 Voy. *infra*, n°s 822 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

une distinction entre la convention et le contrat : la convention est tout accord de volontés par lequel les parties entendent se lier juridiquement, produire des effets juridiques (quels qu'ils soient), le contrat, au sens strict, est une convention productrice d'obligations. Le contrat apparaît donc, dans cette présentation, comme une variété particulière de convention.

56. Portée limitée. Si cette distinction peut apparaître rationnelle, elle est largement dépourvue d'intérêts pratiques et, du reste, les rédacteurs du Code civil ont, dans de nombreux articles, utilisé indifféremment l'un ou l'autre terme. Il est vrai que, lorsque la convention est *stricto sensu* un contrat, c'est-à-dire lorsqu'elle fait naître des obligations, des conséquences particulières se produiront (qui sont les effets de ces obligations). Mais l'accord en lui-même, dans l'un et l'autre cas, obéira aux mêmes règles de formation, et produira le même effet fondamental, qui est de lier les parties, de leur « tenir lieu de loi » comme le dit l'article 1134 du Code civil (qui utilise du reste le terme de convention, et non celui de contrat). C'est pourquoi la distinction entre contrat et convention tend aujourd'hui à être abandonnée. Elle avait disparu dans les projets français de réforme du droit des contrats : dans le nouvel article 1101 du Code civil issu du projet de 2015, le contrat était défini comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des effets de droit ». Mais, dans la version définitive du texte, la notion d'obligation a été réintroduite, quoique de manière différente par rapport au texte antérieur : selon le nouvel article 1101, le contrat n'est pas seulement l'accord de volontés tendant à faire naître des obligations, mais aussi à les modifier, les transmettre ou les éteindre. Il en résulte que la notion de convention non contractuelle subsiste, mais avec un domaine d'application sensiblement réduit : la remise de dette, par exemple, est aujourd'hui un contrat *stricto sensu*, et on ne voit guère que les clauses de désignation d'une loi ou d'une juridiction qui constituent aujourd'hui des « conventions » sans être à proprement parler des contrats[92]. Le législateur belge a, quant à lui, complètement abandonné la notion d'obligation dans la définition du contrat, et, partant, la distinction entre contrat et convention : les deux termes sont expressément assimilés dans le nouvel article 5-4, et le critère de définition est désormais l'intention de produire des

[92] Pour une critique de cette nouvelle définition du contrat, voy. C. WITZ, « La définition du contrat dans le Code civil français réformé – Retour sur la distinction entre le contrat et la convention », in *Festschrift für Alfons Bürge*, Zürich, Schulthess, 2017, pp. 639 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

effets de droit, et non plus des obligations. D'une manière générale, dans cet ouvrage, on considérera les deux termes de contrat et de convention comme synonymes, sauf à signaler, sur telle ou telle question particulière, les problèmes spécifiques liés à l'existence d'obligations ou, au contraire, à leur absence.

Dans la plupart des codes modernes, on donne une définition du contrat plus large que celle de l'article 1101 du Code civil, et qui englobe d'autres effets que la seule création d'obligations. Ainsi le Code civil du Québec, dans son article 1433, indique-t-il que « Le contrat crée des obligations et quelquefois les modifie ou les éteint », et précise que « En certains cas, il a aussi pour effet de constituer, transférer, modifier ou éteindre des droits réels ». Le nouveau code roumain, qui s'en inspire, dispose dans son article 1166 que « Le contrat est l'accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes dans le but de constituer, modifier ou éteindre un rapport juridique ». De même, en droit européen, le projet de Cadre commun de référence définit le contrat comme « *an agreement which rises to, or is intended to give rise to, a binding legal relationship, or is intended to have some other legal effect* ».

57. Le droit des contrats, partie du droit des obligations. Les remarques précédentes ne doivent pas conduire à occulter l'importance des obligations au sens strict dans le droit des contrats. Dans l'immense majorité des cas, les conventions ont pour effet de faire naître des obligations, et c'est aussi pourquoi, du reste, la notion de contrat et celle de convention peuvent de manière générale être considérées comme synonymes. On ne peut donc guère comprendre le droit des contrats si on n'étudie pas en même temps les règles qui sont relatives aux obligations qui peuvent en naître. Certes, sur de nombreux points (leurs modalités, leur exécution, leur transmission, leur extinction, etc.), les obligations contractuelles sont soumises aux mêmes règles que les obligations naissant d'autres sources (par exemple les obligations naissant de la loi, l'obligation de réparer qui naît, en dehors de tout contrat, d'un fait générateur de responsabilité, les obligations naissant d'un quasi-contrat). C'est pourquoi, dans la tradition universitaire française (récemment importée sur ce point au Luxembourg), on a pris l'habitude de sortir ces règles générales du droit des contrats, et de les étudier à part, dans le cadre de ce qu'on appelle le « régime général des obligations ». Cette présentation a été consacrée par les réformes française et belge du droit des contrats : le texte français, qui donne une nouvelle structure au Livre III du Code civil, distingue les sources des obligations (Titre III : contrat, responsabilité civile, quasi-contrats) du régime général des obligations (Titre IV, de même les sources des obligations et le régime général font l'objet de deux titres distincts dans le nouveau Code civil belge. La distinction constitue

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

également le cadre de la réforme en cours du droit des obligations au Luxembourg, puisqu'il a été décidé de confier à deux groupes de travail distincts la réforme du droit des contrats et celle du régime général de l'obligation. Si elle est rationnelle, la distinction a l'inconvénient de vider l'enseignement du droit des contrats d'une partie de sa substance, et de nuire à sa compréhension[93]. C'est aussi une présentation très éloignée de la pratique, car dans l'immense majorité des cas, les règles du « régime général de l'obligation » s'appliquent à des obligations d'origine contractuelle. Du reste, dans le nouveau texte français, certaines questions, qui relèvent techniquement du régime général, sont rattachées au droit des contrats auquel elles sont intimement liées dans la pratique : c'est le cas notamment de l'exécution en nature de l'obligation, qui figure dans le Code civil belge dans le titre relatif au régime général. C'est pourquoi il m'a semblé préférable, dans le présent ouvrage, de retrouver la présentation originaire du Code, et de traiter du régime des obligations conventionnelles au titre des effets du contrat – tout en rappelant bien, à chaque occasion, que ces règles ont également vocation à s'appliquer aux obligations nées d'autres sources – au sein desquelles il faut, maintenant, situer le contrat.

SECTION 2. LA DISTINCTION DU CONTRAT ET DES AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS

58. Classification légale des sources d'obligations. Les règles du Code civil relatives aux contrats s'inscrivent dans le cadre général d'une réglementation des sources d'obligations. Le contrat ayant été défini, au début du Titre III du Livre III, comme un accord de volontés générateur d'obligations, le Code poursuit, dans le Titre IV du même Livre, par la présentation des « engagements qui se forment sans convention ». Ce titre s'ouvre par un article 1370, texte complexe qui distingue les engagements (obligations) nés de « l'autorité seule de la loi » (par exemple les obligations d'un propriétaire envers ses voisins, les obligations d'un tuteur envers l'incapable dont il doit gérer les affaires) de ceux qui naissent d'un « fait personnel à celui qui se trouve obligé ». Au sein de ces derniers, le Code distingue les quasi-contrats d'une part, les délits et quasi-délits d'autre part.

[93] Un exemple caractéristique : il est extrêmement difficile d'expliquer à un(e) étudiant(e) ce qu'est la stipulation pour autrui, technique spécifiquement contractuelle, si on n'a pas auparavant étudié les règles relatives à la cession de créance (encore que celles-ci relèvent du régime général des obligations).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Cette classification a été beaucoup critiquée depuis l'époque du Code, et la doctrine a essayé de proposer des classifications plus rationnelles, principalement à des fins pédagogiques. La distinction la plus couramment admise aujourd'hui est celle entre les actes et les faits juridiques.

59. La distinction des actes et des faits juridiques. D'origine purement doctrinale, la distinction des actes et des faits juridiques repose sur le rôle de la volonté dans la production d'obligations, et, plus largement d'effets juridiques. On désigne sous le nom *d'acte juridique* toute manifestation de volonté en vue de produire des effets de droit : le contrat est l'archétype des actes juridiques, en tant qu'il repose, comme nous l'avons vu précédemment, sur la volonté des parties de s'engager juridiquement, et plus spécialement de créer des obligations. Les *faits juridiques* sont des événements produisant des effets juridiques non voulus par les personnes qui y sont impliqués. Ces événements peuvent être absolument non volontaires (par exemple : le décès d'une personne pour des causes naturelles, qui ouvre sa succession), mais ils peuvent aussi faire intervenir la volonté d'un ou plusieurs acteurs, sans que toutefois cette volonté soit dirigée vers la production d'effets juridiques, ou du moins sans que les effets juridiques qu'ils produisent soient liés à la volonté de les produire. Ainsi, le meurtre volontaire d'une personne produit bien entendu des effets juridiques, en ce qu'il expose son auteur à des sanctions pénales, ainsi qu'à une obligation civile de réparer le préjudice subi par les proches de la victime. Cependant, ce n'est en aucune manière un acte juridique car la volonté du meurtrier n'est pas dirigée vers ces effets juridiques : le meurtrier tue pour se débarrasser de sa victime, non pour être condamné pénalement et civilement.

La distinction des actes et des faits juridiques ne figure pas comme telle dans le Code civil. La notion d'acte juridique (*Rechtsgeschäft*) a d'abord été développée au XIXe siècle par la doctrine allemande, avant d'être consacrée dans le code allemand de 1900 (*Bürgerliches Gesetzbuch*, ci-après « BGB »). À cette même époque, elle s'est implantée dans la doctrine française, et elle fait maintenant partie de la pensée des juristes des pays du Code civil. Elle a même été intégrée, récemment, dans certains textes du Code. Ainsi au Luxembourg, les termes « acte juridique » figurent aujourd'hui dans l'article 1326 et dans l'article 1341 du Code civil, relatifs à la preuve, où ils ont été introduits par une loi de 1986. La distinction entre actes et

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

faits juridiques est désormais expressément utilisée par l'article 1100 du code français pour définir les différents modes de naissance des obligations, et elle sert de base à l'organisation du titre relatif aux sources d'obligations dans le nouveau Code civil belge. Cependant, pour l'essentiel, dans le système franco-belgo-luxembourgeois, la distinction entre les actes et les faits juridiques ne présente pas d'intérêt pratique immédiat, elle est surtout une grille de classification des différentes sources d'obligations. On peut s'en servir pour mieux cerner la notion de contrat, d'abord en le distinguant des autres actes juridiques (**§ 1**), puis en le situant par rapport aux différents types de faits juridiques (**§ 2**).

§1. La distinction du contrat et des autres types d'actes juridiques

60. Le contrat, acte juridique de référence. La notion d'acte juridique n'a jamais acquis dans le système de pensée des juristes français, belges ou luxembourgeois, la même importance qu'en Allemagne. En droit allemand, le *Rechtsgeschäft* constitue une notion centrale du BGB : le code allemand édicte en effet, dans sa partie générale (*Allgemeiner Teil*) toute une série de règles communes à tous les actes juridiques, pour traiter ensuite, dans diverses parties, des règles spécifiques aux contrats. Toute autre est la méthode du Code civil, qui, à l'inverse, pose, dans les articles 1101 et suivants, les règles relatives aux contrats, que la doctrine et la jurisprudence ont ensuite tenté de transposer, avec plus ou moins de bonheur, aux autres actes juridiques. Ce n'est guère qu'en matière de preuve que, depuis peu de temps, en France et au Luxembourg, on a introduit dans le Code civil une règle visant directement les actes juridiques[94]. En doctrine, on a également tendance à raisonner à partir des actes juridiques en général pour déterminer le régime des nullités. Mais, d'une manière générale, le contrat demeure le modèle de référence, à partir duquel on va définir les règles spécifiques applicables aux actes unilatéraux (**A**), et, dans une moindre mesure, aux actes collectifs (**B**).

[94] « L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage […] doit être constaté dans un titre […] » (C. civ., art. 1326). La notion n'apparaît pas dans le texte belge, qui a conservé sa rédaction primitive.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

A) *Les actes juridiques unilatéraux*

61. Notion. Accord entre au moins deux personnes, le contrat se distingue de l'acte unilatéral, par lequel une seule personne prétend, par sa seule volonté, produire des effets juridiques. Par exemple, un testament, qui est un acte de volonté d'une personne agissant seule, a pour effet de transmettre la propriété des biens de cette personne, à son décès, aux personnes désignées. Lorsqu'un débiteur est en retard pour payer sa dette, le créancier peut, par un acte formel, le mettre en demeure de payer – ce qui aura pour effet, au minimum, de faire courir des intérêts de retard. Le bailleur d'un immeuble qui veut mettre fin au bail doit délivrer à son locataire un congé, sans lequel le bail continuera à courir.

62. Régime juridique. Le Code civil connaît et réglemente (parfois sommairement) différents actes unilatéraux (le testament, la mise en demeure, le congé, la résiliation unilatérale, etc.), mais il n'en donne aucune réglementation d'ensemble, analogue à celle qui figure aux articles 1101 et suivants du Code civil pour le contrat. Pour combler les trous laissés par les multiples règles particulières posées par la loi pour tel ou tel acte unilatéral, on transpose habituellement aux actes unilatéraux les règles élaborées pour le contrat. C'est ce que fait désormais expressément en France le nouvel article 1100-1, qui après avoir précisé que les actes juridiques peuvent être conventionnels ou unilatéraux, ajoute qu'« ils obéissent, en tant que de raison, aux règles qui gouvernent les contrats ». De même, dans le nouveau Code civil belge, l'article 5.126 dispose que « chaque acte juridique unilatéral est soumis aux règles qui lui sont propres et, dans la mesure où celles-ci n'y dérogent pas, aux règles qui s'appliquent aux contrats ainsi qu'au régime général de l'obligation ». Il est bien évident, cependant, que certaines règles, qui n'ont de sens que par rapport à l'existence d'un accord entre les deux contractants, ne peuvent pas être appliquées aux actes unilatéraux, et que la transposition des règles applicables au contrat ne peut s'opérer, comme le dit le texte français qu'« en tant que de raison »… Ce particularisme des actes unilatéraux par rapport au contrat s'observe tant en ce qui concerne leur formation, qu'en ce qui touche leurs effets. Nous retrouverons ces règles spécifiques à propos de chaque question, tout au long des développements[95].

[95] Voy. *infra*, n°s 128, 208, 246, 360 et s., 492 et 683.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

63. La question de l'engagement unilatéral de volonté. Il convient cependant d'étudier au préalable une question transversale, qui est celle de savoir si l'acte unilatéral, comme le contrat, peut avoir pour effet de créer des obligations. Cette question doit bien être précisée. Le propre d'un acte juridique est de produire des effets juridiques voulus par son ou ses auteurs. Lorsqu'on regarde les actes juridiques unilatéraux prévus par le Code civil, on constate qu'ils produisent des effets juridiques variés. Le testament, par exemple, a pour effet de transférer la propriété des biens légués après le décès du testateur en dérogeant aux règles normales de transmission du patrimoine aux héritiers. La mise en demeure fait courir des intérêts de retard contre le débiteur en retard pour payer ce qu'il doit. La révocation d'un mandataire, prévue à l'article 2004 du Code civil, met fin au mandat et retire au mandataire son pouvoir de représentation. Et, s'agissant de ces effets, les actes unilatéraux ont en principe, comme les conventions, force obligatoire en ce sens qu'ils lient leur auteur comme le ferait un accord de volontés : le bailleur qui a donné congé à son locataire, par exemple, ne peut pas ensuite changer d'avis et imposer au locataire de rester dans les lieux. Mais on se demande si un acte unilatéral peut aussi, comme le contrat, faire naître des obligations au sens strict, c'est-à-dire rendre une personne créancière et une autre débitrice.

Plus précisément, la question est de savoir si, par un acte unilatéral, on peut se rendre soi-même débiteur d'autrui, se créer une obligation à soi-même envers un tiers. Par exemple, si j'ai perdu mon chat, et que je passe une annonce ou que j'appose une affiche à l'épicerie de mon quartier en promettant 100 € de récompense à toute personne qui le retrouvera, est ce que je serai tenu d'honorer mon engagement ? Si j'ai offert à quelqu'un de lui vendre ma maison pour 500 000 € en lui laissant un certain délai pour réfléchir à ma proposition, est ce que, pendant ce délai, je suis obligé de maintenir cette offre ? C'est la question dite de l'engagement unilatéral de volonté, sur laquelle se sont concentrées les discussions doctrinales depuis l'époque du Code civil.

La question de l'acte unilatéral comme source d'obligations n'est habituellement posée que dans ce sens, tant il semble évident que, à l'inverse, dans un système de droit moderne, une personne privée ne peut pas, par un acte unilatéral, se rendre créancière d'un tiers qui deviendrait alors débiteur contre son gré. Dans la mesure où les personnes privées sont placées, en droit, sur un pied d'égalité, aucune personne privée n'a sur les autres, en l'absence d'une relation contractuelle, un pouvoir

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

lui permettant d'imposer à autrui une quelconque obligation[96]. Ce type de pouvoir semble être l'apanage des personnes publiques, pour qui les actes juridiques unilatéraux sont du reste le mode ordinaire de régulation des rapports sociaux, et qui imposent habituellement des obligations aux sujets de droit par cette voie unilatérale (par exemple, les obligations fiscales pesant sur les contribuables). En droit privé, en revanche, le seul moyen qu'on a de rendre un tiers débiteur est de lui faire accepter cette obligation par un contrat. Cette affirmation, pour incontestable qu'elle soit, doit cependant être nuancée. D'une part, il arrive fréquemment que, dans le cadre d'une relation contractuelle privée, une personne reçoive le pouvoir d'imposer des obligations à une autre : c'est le cas en particulier dans le contrat de travail, caractérisé par un pouvoir de subordination du salarié à l'employeur, ce qui permet à celui-ci de demander, dans le cadre général de ce qui a été convenu au départ, toutes sortes de services. Même si les multiples obligations qui pèsent au jour le jour sur le salarié peuvent être rattachées à l'obligation générale d'accomplir le travail résultant du contrat, il n'est pas toujours facile de déterminer ce qui, dans les ordres qui sont donnés au salarié, relève du contrat et du pouvoir général d'organisation qui appartient à l'employeur en tant que propriétaire de son entreprise. D'autre part, il faut d'emblée avoir conscience que de très nombreux contrats sont en fait imposés, sinon dans leur principe, du moins dans leur contenu à une des parties par l'autre qui est en situation de force : on vise ici la figure, déjà abordée, des contrats d'adhésion (notamment ceux qui sont passés entre les professionnels et les consommateurs) dans lesquels l'accord donné par la partie qui adhère au contrat dissimule mal le pouvoir de fait de l'autre de poser les règles. Avec ce phénomène des contrats d'adhésion, sur lequel nous reviendrons, on touche aux limites de la distinction du contrat et de l'acte unilatéral.

64. Position de la doctrine classique. Pour la doctrine du XIXe siècle dans les pays du Code civil (souvent appelée la doctrine classique), il était inconcevable qu'un acte unilatéral puisse faire naître une obligation à la charge de son auteur. Seul le contrat, accord de volontés, pouvait faire naître une obligation. Pour justifier cette opinion, on invoquait d'abord un argument de texte : l'article 1370 du Code civil, qui énumère les sources d'obligations autres que le contrat (les délits et quasi-délits, les quasi-contrats, les obligations naissant de la loi) ne fait aucune mention de l'acte unilatéral. On mettait également en avant un argument, supposé rationnel, tiré de la toute-puissance de la volonté individuelle, qui, nous le verrons, constitue le fondement de la force obligatoire du contrat dans la pensée du XIXe siècle : si, pensait-on, la volonté était assez puissante pour se lier, elle pouvait tout autant se délier – alors que, dans le contrat, la liberté de se désengager trouve sa limite dans la volonté de l'autre partie. On estimait également que la reconnaissance de l'acte unilatéral comme fondement d'une obligation n'avait guère d'utilité, car, dans l'immense majorité des

[96] Naturellement, il n'en a pas toujours été ainsi : aux temps où existait l'esclavage, il était possible à une personne privée d'imposer toutes sortes de sujétions à une autre.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

cas, on peut justifier les limites à la liberté de revenir sur un engagement qu'on a pris soi-même en recourant à d'autres sources d'obligation. Par exemple, pour sanctionner la révocation intempestive d'une offre de contracter, on peut y voir une faute génératrice de responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Dans le cas de la promesse de récompense, on peut dire que celui, en connaissance de cause, ramène l'animal égaré a tacitement accepté l'offre de récompense faite dans l'annonce ; quant à celui qui n'a pas lu l'annonce, il n'a aucune raison de réclamer la récompense ! Tous ces arguments peuvent sembler rationnels, mais en réalité ils reposent sur des présupposés qui sont ceux de la doctrine de la première moitié du XIXe siècle. Un présupposé volontariste d'abord, qui fait de la volonté une source autonome des obligations contractuelles[97], n'ayant d'autre limite à sa toute-puissance que la volonté de l'autre partie. Si on admet au contraire que la volonté n'a de valeur créatrice de droit qu'en vertu de la loi, et dans les limites que celle-ci lui pose, on peut très bien admettre que la loi permette à une personne de s'engager seule, tout en lui interdisant de revenir sur son engagement. Un présupposé légaliste ensuite, selon lequel tout le droit est dans la loi, et spécialement dans le Code, et qui conduit à refuser par principe d'envisager d'autres sources d'obligations que celles qui sont citées par le Code. On n'était pas encore, à cette période, conscient de l'importance de la jurisprudence comme source de droit. Mais nous verrons qu'à la fin du XIXe siècle, la Cour de cassation française n'a pas hésité à reconnaître, avec l'enrichissement sans cause, une source d'obligation non prévue par les textes. Quant à la possibilité de recourir à d'autres techniques pour justifier la sanction de la révocation de certains engagements unilatéraux, elle relève souvent de l'artifice, et n'a de sens que parce que, précisément, au départ, on se refuse à admettre l'acte unilatéral comme source d'obligations.

65. Évolution des idées. L'affaiblissement, à la fin du XIXe siècle, des présupposés légalistes et volontaristes, a conduit, peu à peu, à l'évolution des idées relatives à l'engagement unilatéral. Cette évolution est également liée à la pénétration dans le monde du Code civil d'idées venues d'ailleurs, et en particulier du monde germanique. Le BGB, qui place, comme nous l'avons vu, la notion d'acte juridique au centre de sa construction du droit civil, fait une

97 Voy. *infra*, n°s 89 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

large place aux actes unilatéraux, et admet, au moins dans certains cas, qu'un acte unilatéral puisse faire naître un engagement. Il en va ainsi en cas de promesse de récompense (*Auslobung*), selon le § 657 BGB[98]. Aussi bien, dès la fin du XIX[e] siècle, un auteur comme Saleilles, qui travaillait sur le projet du BGB alors en préparation, prônait-il l'introduction en France du concept d'engagement unilatéral[99]. Par ailleurs, dans les trois pays du Code civil, on a assisté, au fil du temps, à la reconnaissance par le législateur de nombreux cas d'actes unilatéraux faisant naître des obligations – preuve de l'utilité sociale de la notion. Sans chercher à en faire ici une liste exhaustive, on citera par exemple dans les trois pays, les textes relatifs aux effets de commerce (qui permettent à une personne, en signant une lettre de change, de s'engager à en payer le montant à toute personne qui en deviendrait porteur[100]), ou, plus récemment, les lois permettant la constitution d'une société par une seule personne[101]. La notion d'engagement unilatéral peut sembler utile pour donner à ces textes une armature conceptuelle et les intégrer dans un système d'ensemble cohérent. En Belgique, dès les années 1930, De Page, le père du droit civil belge moderne, estimait que rien ne s'opposait à la reconnaissance, à côté du contrat, de l'acte unilatéral comme source d'obligations, et la doctrine belge contemporaine est très généralement dans ce sens[102]. En France, la reconnaissance a été plus tardive, et la doctrine continue d'exprimer certaines réticences. Mais, si la plupart des auteurs pensent que l'engagement unilatéral ne doit être admis que dans des cas particuliers, et demeurer une « source d'appoint », la possibilité même que la volonté unilatérale puisse être une source d'obligations, n'était, dès avant la réforme

98 § 657 *Bindendes Versprechen*: « *Wer durch öffentliche Bekanntmachung eine Belohnung für die Vornahme einer Handlung, insbesondere für die Herbeiführung eines Erfolges, aussetzt, ist verpflichtet, die Belohnung demjenigen zu entrichten, welcher die Handlung vorgenommen hat, auch wenn dieser nicht mit Rücksicht auf die Auslobung gehandelt hat* ».

99 R. Saleilles, *Théorie générale de l'obligation*, n[os] 138 et s., 245 et s., 278 et s.

100 Au Luxembourg, la loi uniforme résultant de la Convention de Genève sur la lettre de change et le billet à ordre du 7 juin 1930 n'a été introduite que tardivement par une loi du 8 janvier 1962 (voy. le texte coordonné du 15 décembre 1962, *Mém.*, 1962, p. 1219).

101 Au Luxembourg, la possibilité de créer une société par la volonté d'une seule personne « dans les cas prévus par la loi » (C. civ., art. 1832) a été reconnue par la loi du 28 décembre 1992, prise sur le modèle français de la loi du loi du 11 juillet 1985 portant création de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

102 H. De Page, *Traité élémentaire de droit civil belge*, t. III, 2[e] éd., n[o] 51. Pour une présentation approfondie de la question en droit belge, voy. not. P. Van Ommeslaghe, *Traité de droit civil belge*, t. II, *Les obligations*, vol. 2, coll. De Page, Bruxelles, Bruylant, 2013, n[os] 704 et s. ; L. Simont, « L'engagement unilatéral », in *Les obligations en droit français et en droit belge. Convergences et divergences*, Bruxelles, Bruylant, 1992 et Paris, Dalloz, 1994, p. 17.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de 2016, pratiquement plus discutée[103], de sorte que l'opposition que certains sont tentés de faire sur la question entre la France et la Belgique est sans doute un peu forcée.

66. Reconnaissance jurisprudentielle. La jurisprudence, pour sa part, en France et en Belgique, n'a pas hésité à reconnaître des engagements unilatéraux en dehors des cas prévus par les textes. En Belgique, même si elle a refusé de consacrer un « principe général du droit suivant lequel la manifestation unilatérale de la volonté fait naître des obligations »[104], la Cour de cassation a, dès 1974, consacré l'engagement par volonté unilatérale comme source autonome d'obligations[105], et, en 1980, elle a explicitement fondé sur cette notion la force obligatoire reconnue à l'offre de contracter[106]. Dans le nouveau Code civil belge, l'article 5-125 qui définit l'acte juridique unilatéral dispose explicitement que « [l]'auteur de cet acte peut notamment s'engager par sa seule volonté en faveur d'autrui », sans toutefois préciser dans quels cas un tel engagement peut être reconnu. En France, la consécration légale n'est pas aussi nette. On peut cependant la déduire de la combinaison de l'article 1100 du Code civil, selon lequel les obligations naissent d'actes juridiques, et de l'article 1100-1, qui précise que les actes juridiques peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Mais, avant la réforme, l'engagement unilatéral avait été nettement consacré comme source autonome d'obligations par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, pour reconnaître la valeur juridique des primes promises par l'employeur à ses salariés[107] ou, plus récemment, d'engagements pris par des dirigeants sociaux d'assumer certaines dettes incombant

[103] Voy. p. ex. : F. TERRE, P. SIMLER, et Y. LEQUETTE, *Droit civil. Les obligations*, 11e éd., Paris, Dalloz, 2013, nos 50 et s. (cité *infra*, TERRE, SIMLER, LEQUETTE 2013) ; B. FAGES, *Droit des obligations*, 4e éd., Paris, LGDJ, 2013, no 8 (cité *infra*, FAGES 2013) ; M. FABRE MAGNAN, *Droit des obligations* I, 2012,., qui n'hésite pas à intituler son manuel « Contrat et engagement unilatéral ».

[104] Cass. be., 14 mai 2007, no C.05.0553.F.

[105] Cass. be., 18 décembre 1974 (*Pas.*, 1975, I, p. 425) selon lequel une prime de fin d'année peut être due non seulement en vertu d'un contrat « mais aussi en vertu d'une obligation unilatérale souscrite par l'employeur » et celle-ci ne constitue pas une libéralité soumise aux formes prescrites pour une libéralité.

[106] Cass. be, 9 mai 1980, *Arr. Cass.*, 1979-1990, p. 1139 ; *Pas.*, 1980, I, p. 1127 ; *J.T.*, 1981, p. 206. Sur la valeur juridique de l'offre voy. *infra*, no 144.

[107] La solution semble avoir été admise pour la première fois par Cass. fr. (soc.), 4 avril 1990, no 86-42626, qui juge « que l'employeur n'est en droit de revenir à tout moment sur un engagement unilatéral que si celui-ci a été pris pour une durée indéterminée ». La même solution avait été admise dès 1974 par la Cour de cassation belge : Cass. be., 18 décembre 1974, *Pas.*, I, p. 425 ; *R.C.J.B.*, 1980, p. 65, note M. COIPEL, « La théorie de l'engagement par volonté unilatérale ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

à leur société[108]. On peut également rattacher à cette notion les arrêts qui admettent qu'en reconnaissant un enfant qu'il sait ne pas être le sien, un homme « avait contracté vis-à-vis de l'enfant et de la mère l'obligation de se comporter comme un père en subvenant notamment aux besoins de l'enfant qu'il a reconnu »[109]. La Chambre sociale a même fondé certaines de ses décisions sur « les règles régissant la dénonciation et la mise en cause des engagements unilatéraux de l'employeur »[110]. Au Luxembourg, la Cour d'appel a, dans une décision, explicitement reconnu qu'un engagement unilatéral pouvait être source d'obligations, mais « seulement dans des circonstances particulières ». Pour la Cour, « l'engagement unilatéral a tout d'abord un caractère subsidiaire et ne s'applique que lorsque les autres techniques juridiques se révèlent impropres à fournir une solution satisfaisante. Il faut ensuite que l'engagement unilatéral présente une certaine utilité, c'est-à-dire qu'il paraisse opportun de faire peser sur le déclarant une obligation immédiate et irrévocable. Il faut finalement que la volonté du déclarant soit certaine et réfléchie »[111]. Cette position reflète assez bien l'opinion dominante de la doctrine française. Dans cette affaire, relative à un accord donné par un propriétaire à ce que son voisin construise un bâtiment jusqu'à la limite de sa propriété, la Cour a cependant estimé que ces conditions n'étaient pas réunies, au motif que cet accord pouvait s'analyser « comme une faveur ou une complaisance […] mais non comme un acte juridique unilatéral posé de façon réfléchie, générateur d'obligations ». Dans une autre affaire, à l'inverse, la Cour a bien admis qu'une promesse faite par une personne, sans l'accord de son bénéficiaire, pouvait faire naître une obligation au profit de celui-ci, mais sans se référer à la notion d'engagement unilatéral[112].

La notion d'engagement unilatéral n'est pas inconnue du droit européen. Cependant, parmi les projets européens, seul le *Draft common frame of reference* peut être cité ici, car les autres textes (Principes du droit européen du contrat, Code européen du droit des contrats, Droit commun européen de la vente) ne concernent que les contrats. L'article 1:103 du DCFR dispose quant à lui que *a valid unilateral promise or undertaking is binding on the person giving if it is intended to be legally binding without acceptance* ».

[108] Cass. fr. (1re civ.), 17 octobre 2012, n° 11-20124 ; Cass. fr. (1re civ.), 28 novembre 2012, n° 11-20674 ; Cass. fr. (3e civ.), 12 février 2013, n° 11-21314.

[109] Cass. fr. (1re civ.), 21 juillet 1987, n° 85-16887 ; Cass. fr. (1re civ.), 10 juillet 1990, n° 88-15 105.

[110] Cass. fr. (soc.), 2 mai 2001, n° 99-41 264.

[111] Cour d'appel, 12 décembre 2001, n° 24768. ; dans le même sens Trib. Diekirch, 17 octobre 2017, n° 20378.

[112] Cour d'appel, 12 juillet 2006, *Bull. Droit et banque*, 2008, n° 42, p. 56, note P. Kayser.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

B) *Les actes juridiques collectifs*

67. Notion. La notion d'acte collectif est utilisée en droit pour désigner plusieurs types de mécanismes juridiques. Dans un premier sens, on vise des accords entre des groupements de personnes – ou des personnes représentant des groupements – qui produisent des effets sur les personnes membres de ces groupements (et même parfois sur des personnes qui y sont extérieures). L'exemple typique est celui de la convention collective de travail, qui est passée entre un ou plusieurs syndicats de salariés et un ou plusieurs syndicats d'employeurs, et qui va produire des effets à l'égard de l'ensemble des salariés membres des syndicats signataires ainsi qu'à tous les salariés des employeurs tenus par la convention[113]. Ces actes ne sont que des variétés de contrats soumis à un régime juridique particulier, notamment du point de vue des effets à l'égard des tiers. Mais il existe aussi des actes collectifs qui ne sont pas des contrats : c'est le cas lorsque plusieurs personnes membres d'une collectivité prennent ensemble une décision – par exemple la délibération d'un conseil communal ou d'une assemblée générale d'associés d'une société[114]. On ne peut pas dans ces hypothèses parler d'un contrat ou d'une convention entre les membres du groupe (parce que ceux-ci ne se mettent pas à proprement parler d'accord) mais plutôt d'une « conjonction » de volontés qui vont (majoritairement au moins) dans le même sens. Comme les actes unilatéraux, ces actes collectifs obéissent, par analogie, à certaines règles du droit des contrats (par exemple, en ce qui concerne la capacité ou le consentement des personnes impliquées), mais ils présentent une spécificité accusée. Dans le Code civil français, le nouvel article 1100-1, selon lequel les actes juridiques peuvent être « conventionnels ou unilatéraux » fait complètement l'impasse sur les actes collectifs. Il en va de même du nouveau Code civil belge.

§ 2. La distinction du contrat et des sources d'obligations non volontaires (faits juridiques)

68. Diversité des faits juridiques. – L'article 1370 du Code civil, qui ouvre le titre consacré aux « engagements qui se forment sans convention » – ce qui correspond, en gros, à ce qu'on appelle aujourd'hui les faits juridiques – révèle bien la grande diversité de ces sources non volontaires d'obligations. Le texte distingue les engagements qui « résultent de l'autorité seule de la loi » de ceux qui « naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé ». Les premiers constituent un véritable « fourre-tout » ne donnant lieu à aucun régime juridique d'ensemble : aux deux exemples donnés par le texte (les obligations résultant du voisinage, les obligations d'un tuteur ou d'un administrateur des biens d'un incapable), on pourrait ajouter : les obligations alimentaires résultant d'un lien de parenté ou d'alliance, les obligations fiscales envers l'État, les obligations

113 C. trav., art. L. 162-8.

114 L'avant-projet français de réforme du droit des obligations et de la prescription (projet Catala) définissait l'acte juridique collectif comme « la décision prise collégialement par les membres d'une collectivité ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

naissant à la charge des héritiers à la suite d'un décès, etc. Les seconds donnent lieu en revanche à des règles spécifiques, qui font l'objet des articles suivants : ce sont les *délits et quasi-délits* (c'est-à-dire les faits générateurs de responsabilité civile extracontractuelle), et les *quasi-contrats*. Les rapports de ces notions avec celle de contrat doivent être ici précisés.

A) *Contrat et faits générateurs de responsabilité civile extracontractuelle*

69. Principe de la distinction. Les « délits et quasi-délits » visés à l'article 1370 du Code civil, et donnant lieu, ensuite, aux articles 1382 et suivants du Code civil, désignent des faits qui ont causé un dommage à autrui et dont l'auteur doit répondre, en réparant ce dommage. Il s'agit, en d'autres termes des faits générateurs de responsabilité civile. Plus précisément, la notion de « délit » désigne un fait commis avec l'intention de causer le préjudice à autrui, tandis que le quasi-délit désigne des faits non intentionnels. Mais cette distinction n'a, en général, aucun intérêt pratique dans le système du Code civil, et elle a pratiquement disparu du langage juridique moderne, où on parlera en général de la « responsabilité délictuelle » pour désigner tous les faits générateurs de responsabilité visés aux articles 1382 et suivants du Code civil : la faute intentionnelle ou non (C. civ, art. 1382 et 1383), le fait d'un chose qu'on a sous sa garde ou d'une personne dont on doit répondre (C. civ., art. 1384), le fait d'un animal ou d'un bâtiment en ruine dont on est propriétaire (C. civ., art. 1385 et 1386). On parlera aussi (et plus fréquemment dans le langage juridique moderne) de responsabilité extracontractuelle, dans la mesure où ces textes n'ont vocation à s'appliquer que lorsque le dommage a été causé en dehors d'un contrat. Les différents faits visés – et spécialement la faute – apparaissent comme des violations de devoirs généraux de la vie sociale, qui pèsent par principe sur toute personne vis-à-vis d'autrui. Entre l'auteur du fait dommageable et la victime, il n'existe pas, au départ, de véritable obligation (sauf à considérer que tout le monde est créancier de tout le monde). C'est le fait générateur du dommage qui fait naître l'obligation de réparer, dont la victime est créancière et l'auteur du dommage débiteur.

Il n'en va pas de même lorsque le dommage a été causé dans le cadre de liens contractuels préexistants qui unissaient la victime et l'auteur du dommage, par suite de l'inexécution, de l'exécution

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

tardive, ou de la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle. L'une des conséquences de ce manquement aux obligations nées d'un contrat sera d'obliger le contractant à réparer le préjudice qu'il a ainsi causé à l'autre : l'obligation de réparer vient ici se superposer à l'obligation préexistante née du contrat. Cette obligation de réparer dite « responsabilité contractuelle » a été traitée séparément par les rédacteurs du Code civil, au titre des effets du contrat, aux articles 1142 et suivants du Code civil – même si la doctrine et la jurisprudence ont, nous le verrons, établi de nombreuses règles communes aux deux responsabilités, à tel point qu'un certain courant doctrinal prône aujourd'hui l'instauration d'un régime unitaire[115]. Par ailleurs, les domaines de ces deux responsabilités ne sont pas aussi nettement séparés qu'on pourrait le croire, et de nombreux problèmes de frontière existent. Les rapports entre les deux responsabilités ont été traités différemment par la réforme française et par la réforme belge. Alors qu'en Belgique, les textes relatifs à la responsabilité contractuelle ont été immédiatement modifiés dans le livre V relatif au droit des obligations, il a été décidé en France de ne pas y toucher, dans l'attente d'une réforme d'ensemble de la responsabilité civile – ce qui manifeste une certaine prise de position en faveur de l'approche unitaire des deux responsabilités.

70. **Domaines respectifs de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle.** Si la plupart des droits européens connaissent cette distinction entre les deux types de responsabilités, les domaines respectifs de l'une et de l'autre sont très différents selon les systèmes juridiques. Tel préjudice qui, en droit luxembourgeois, sera réparé sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pourra très bien relever en droit anglais du *tort law* ou en droit allemand du « *Deliktsrecht* » – ou l'inverse. Sans entrer ici dans le détail d'une question qui sera traitée en détail lorsque nous étudierons la responsabilité contractuelle, il est important de signaler les incertitudes qui entourent la délimitation du champ des deux responsabilités, et la relativité de la distinction, car cela permet de bien comprendre la relativité des frontières de la notion même de contrat. Comme on l'a déjà vu à propos des relations bénévoles, certaines situations peuvent être, selon ce qu'en dit la loi ou la jurisprudence, être traitées tantôt comme des contrats (dont l'inexécution donne lieu à une responsabilité contractuelle), tantôt comme des faits juridiques donnant lieu à responsabilité dans les conditions des articles 1382 et suivants du Code civil. Par ailleurs, lorsqu'un contrat a été passé, il n'est pas évident de considérer que tous les dommages qu'une des parties peut causer à l'autre au cours de l'exécution de ce contrat relèvent de la responsabilité contractuelle. On peut hésiter à se situer sur le terrain du contrat lorsque le fait générateur du dommage peut tout aussi bien être considéré comme le manquement à des devoirs généraux de la vie sociale qui pèseraient de la même manière sur toute personne n'ayant pas passé le contrat : par exemple, faut-il traiter différemment la responsabilité d'une clinique qui commet une

[115] Sur cette question voy. *infra*, n° 805.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

erreur dans le traitement d'un patient lorsque cette clinique a passé un contrat avec le patient (qui est venue la voir volontairement) et lorsqu'elle soigne une personne qui a lui a été amenée, inconsciente à la suite d'un malaise (et qui n'a donc pas pu passer de contrat) ? D'une manière générale, les domaines respectifs de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle dépendent, non seulement de ce qu'on considère comme étant un contrat, mais encore des obligations que la loi ou le juge rattachent au contrat : ainsi, pendant tout le XIX[e] siècle, on traitait sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil la responsabilité du transporteur de personnes (compagnie de chemin de fer, compagnie maritime, etc.), jusqu'à ce que la Cour de cassation française, en 1910, « découvre » dans le contrat de transport une « obligation de sécurité » à la charge du transporteur[116], ce qui a eu pour effet de faire passer la responsabilité du transporteur dans le domaine du contrat. Les solutions en la matière ne dépendent absolument pas d'une sorte d'« essence du contrat » (certaines situations, certaines obligations seraient par essence contractuelles, et d'autre pas), mais de considérations de politique juridique, liées au souci plus ou moins grand qu'on a, à un moment donné, de protéger les victimes d'accidents, et à la comparaison des solutions sur les deux terrains de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle. La consécration de l'obligation de sécurité dans le contrat de transport de personnes remonte à une période où, globalement, la responsabilité délictuelle était moins favorable aux victimes que la responsabilité contractuelle, elle a permis d'indemniser plus facilement les victimes d'accidents de transport. Les rapports entre les deux responsabilités se sont plutôt inversés depuis, notamment avec la consécration en jurisprudence de cas importants de responsabilité délictuelle sans faute. On a du coup aujourd'hui tendance à vouloir « décontractualiser » de nombreux cas de responsabilité. Les mêmes considérations peuvent expliquer la position prise par le droit positif sur la délicate question de savoir si les deux responsabilités peuvent se « cumuler », c'est-à-dire si la victime d'un dommage dû à l'inexécution d'une obligation contractuelle, mais dont le fait générateur peut tout aussi bien tomber sous le coup des articles 1382 et suivants du Code civil, peut, à son choix, choisir l'un ou l'autre fondement pour demander réparation de son dommage[117]. Sur tous ces points, les positions des différents droits nationaux en Europe sont extrêmement diverses, et nous verrons même qu'il existe, au sein des pays du Code civil, d'importantes différences entre la France, le Luxembourg et la Belgique.

B) *Contrats et quasi-contrats*

71. Les quasi-contrats du Code civil. Les rédacteurs du Code civil ont défini les quasi-contrats à l'article 1371 comme « les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ». Le moins qu'on puisse dire de cette définition est qu'elle est particulièrement imprécise. Les effets des quasi-contrats (les engagements qui en résultent) pourraient être aussi bien ceux d'un contrat ou d'un fait générateur de responsabilité. De même, la notion de « fait purement volontaire de l'homme »

116 Voy. *infra*, n° 534.

117 Voy. *infra*, n[os] 814 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pourrait s'appliquer aussi bien à un contrat, ou à un délit civil : si, volontairement, je cause un dommage à autrui, cela m'engage envers la victime, pourtant ce n'est pas un quasi-contrat, mais un délit ! Si, volontairement, je m'engage à payer une somme à autrui, ce n'est pas un quasi-contrat, mais un contrat ! Les traits caractéristiques de la notion n'apparaissent que si on considère les deux quasi-contrats régis par le Code civil, aux articles 1372 à 1381, la gestion d'affaire, et le paiement de l'indu. La *gestion d'affaire* désigne la situation où une personne s'occupe des affaires d'une autre pour lui rendre service, mais sans que cette dernière le lui ait demandé : par exemple, pendant que mon voisin est en vacances, un violent orage enlève son toit, pour lui éviter de gros dommages, je le répare (ou je paye un entrepreneur pour le réparer), sans attendre son retour. À certaines conditions, la gestion d'affaires fait naître une obligation pour le gérant lui-même, qui est tenu d'aller jusqu'au bout de son activité, elle peut également, si elle est utile au géré, créer à sa charge une obligation de rembourser le gérant pour les frais qu'il a engagés. Le *paiement de l'indu*, vise le cas où une personne paye par erreur une somme qu'elle ne devait pas (par exemple, une caisse d'assurances sociales paye des prestations à un bénéficiaire qui ne remplit pas les conditions pour les recevoir), ou la paye à quelqu'un d'autre que son véritable créancier (je vire par erreur, parce que je me trompe dans les chiffres, sur le compte de *Primus* une somme que je devais à *Secundus*). À certaines conditions, un tel paiement fera naître chez celui qui a reçu le paiement (l'*accipiens*) l'obligation de rembourser (de répéter, selon la formule traditionnelle) celui qui l'a payé (le *solvens*)[118].

On voit bien, dans ces deux hypothèses, ce qui différencie ces situations de la responsabilité civile : les faits considérés n'ont pas causé de dommage à autrui, tout au contraire ils lui ont procuré un avantage – le problème venant de ce que cet avantage a été procuré sans contrepartie[119]. C'est ce qu'exprime la définition (peu améliorée) des quasi-contrats dans le nouvel article 1300 du Code civil français : « faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit ». On exprime parfois cela en disant que les quasi-contrats sont des faits juridiques licites

[118] Sur le paiement de l'indu, voy. *infra*, n°s 642 et s.

[119] Ce qu'exprime la définition (peu améliorée) des quasi-contrats dans le nouveau droit français (C. civ. art. 1300) : les quasi-contrats font naître un engagement de celui qui « en profite sans y avoir droit ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

(idée reprise dans l'article 5.127 du nouveau Code civil belge), alors que les délits et quasi-délits, générateurs de responsabilité civile sont des faits illicites. Les délits et quasi-délits obligent dès lors à réparation, alors que les quasi-contrats obligent à restitution, même si, dans les deux cas, l'objectif est de rétablir l'équilibre anormalement rompu entre deux patrimoines. On voit aussi ce qui différencie les quasi-contrats des contrats : même s'ils sont volontaires chez une des parties au moins, les quasi-contrats ne reposent pas sur une volonté de s'engager juridiquement, de faire naître une obligation. La différence avec le contrat apparaît nettement dans le cas de la gestion d'affaires, où le géré (mon voisin dans l'exemple ci-dessus) peut se trouver obligé (à me rembourser) alors qu'il n'a nullement donné son accord à mon intervention. Dans le cas du paiement de l'indu, l'*accipiens* a sans doute accepté le paiement, mais il ne s'est en rien obligé à le rembourser, et, de son côté, le *solvens* qui, par hypothèse croyait payer le créancier, n'a aucunement entendu faire une avance à l'autre partie. Les obligations qui naissent de ces situations reposent donc, non sur la volonté des parties, mais sur la loi. Néanmoins, on peut noter une certaine ressemblance extérieure avec des situations contractuelles : le géré sera obligé de rembourser le gérant « comme si » il l'avait chargé contractuellement de lui rendre le service, celui qui a reçu le paiement indu sera tenu de rembourser « comme si » le *solvens* lui avait prêté de l'argent. C'est ce qui explique l'appellation ambiguë de « quasi-contrat », qui s'applique tout de même mieux à la gestion d'affaires qu'au paiement de l'indu. Dans certaines situations, en effet, on peut hésiter entre la qualification de contrat et celle de gestion d'affaires : ainsi, lorsqu'une personne rend service à une autre, on peut, dans certains cas, y voir soit une gestion d'affaires, soit un contrat tacite (si on peut déduire des circonstances un consentement implicite de la personne à qui le service a été rendu). En revanche, le rapprochement avec un prêt est très artificiel dans le cas de paiement de l'indu, et il n'y a guère de problèmes de frontières entre ces deux qualifications.

La catégorie des quasi-contrats, que les rédacteurs du Code civil, ont tiré des *Institutes* de Justinien, a souvent été critiquée par la doctrine française. On lui reproche à la fois son inutilité (les obligations quasi-contractuelles pourraient être considérées simplement comme des obligations d'origine légale) et son ambiguïté. La notion mêle en effet deux idées très différentes : la ressemblance (très artificielle) avec des relations contractuelles (où manquerait seulement la volonté de s'engager !), et l'idée de rééquilibrer deux patrimoines dont l'un s'est accru sans raison au détriment d'un autre. Aussi bien, si la plupart des systèmes juridiques européens

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

connaissent les deux mécanismes de la gestion d'affaire et du paiement de l'indu, leur regroupement dans la catégorie des « quasi-contrats » est typique du Code civil et des droits qui s'en sont inspirés. C'est pourquoi un des projets français de réforme du droit des obligations, celui préparé sous la direction de F. Terré, proposait d'abandonner la catégorie des quasi-contrats[120]. Cependant, la notion est profondément ancrée dans la mentalité juridique de ces pays, et, au fil du temps, on a pris l'habitude d'y rattacher d'autres situations non envisagées par le Code. Finalement l'ordonnance de 2016 a maintenu la catégorie en ajoutant aux deux cas actuels celui de l'enrichissement sans cause (devenu enrichissement injustifié), et le nouveau droit belge a fait de même.

72. Enrichissement sans cause. Il est des cas où une personne reçoit au détriment d'une autre un avantage sans aucun fondement juridique, sans que cette situation rentre dans l'un des deux cas prévus par les articles 1372 à 1381 du Code civil. La question se pose alors de savoir si le système juridique doit intervenir pour restaurer l'équilibre anormalement rompu entre les deux patrimoines. La jurisprudence française a été confrontée au problème en 1892 dans une affaire célèbre : un marchand avait fourni des engrais à un fermier qui ne les avait pas payés ; peu de temps après, le bail rural avait pris fin, et le propriétaire de la terre avait retrouvé son terrain valorisé par l'apport d'engrais. Le fournisseur impayé pouvait-il demander au propriétaire, qui s'était ainsi enrichi sans rien débourser la compensation de son appauvrissement ? À l'évidence, on n'était pas ici dans un cas de paiement de l'indu, et les conditions de la gestion d'affaires n'étaient pas réunies, car, en fournissant les engrais, le marchand n'avait eu aucune intention de rendre service au propriétaire, de « gérer son affaire ». Dans cette affaire, la Cour de cassation française, en s'appuyant sur une vieille tradition romaine réinterprétée[121], posa, d'une manière générale, qu'il existait un « principe d'équité qui défend de s'enrichir au détriment d'autrui »[122]. De ce principe, découle une action, dite « *de in rem verso* », qui permet à l'appauvri d'obtenir de l'enrichi la compensation financière de son appauvrissement. Cette solution fut par

120 Voy. les explications très convaincantes de P. REMY, « Des autres sources d'obligations », in *Pour une réforme du régime général des obligations*, Paris, Dalloz, 2013, pp. 29 et s.).

121 En droit romain, on avait posé le principe que « nul ne doit s'enrichir au détriment d'autrui » (POMPONIUS, *Digeste*, 50-17), mais il n'en résultait que des actions dans des cas particuliers. L'action *de in rem verso*, qui a donné son nom au mécanisme dans les pays du Code civil, était une de ces actions particulières.

122 Cass. fr., Req., 15 juin 1892., *Patureau-Miran c/ Boudier*, Grands arrêts de la jurisprudence civile 11e éd., 2000, no 227. L'arrêt est connu sous le nom d'arrêt Boudier. Sur le terrain des sources du droit, l'arrêt, qui se fonde seulement sur un « principe d'équité », marque de manière très caractéristique l'émancipation de la jurisprudence française par rapport aux textes du Code civil à la fin du XIXe siècle.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la suite reprise en Belgique et au Luxembourg[123], tandis que, à la même époque le principe général d'une action en restitution pour enrichissement injustifié était consacré dans les codes allemand et suisse[124]. L'arrêt de 1892 avait affirmé, de manière quelque peu imprudente, que cette action « n'ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n'est soumis à aucune condition déterminée ; qu'il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d'établir l'existence d'un avantage qu'il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit ». Mais par la suite, la jurisprudence française n'eut de cesse de contenir l'action dans d'étroites limites, et elle a été en cela fidèlement suivie par la jurisprudence luxembourgeoise. Selon une formule désormais classique, qui se trouve pour la première fois dans un arrêt français de 1915, « l'action *de in rem verso* ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit, et qu'elle ne peut être intentée en vue d'échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d'un contrat déterminé »[125]. Il ne suffit pas que l'enrichissement et l'appauvrissement apparaissent injustes, il faut qu'ils soient sans « cause » juridique, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas justifiés par une règle de droit. Si par exemple, j'ai acheté un bien trop cher par rapport au prix du marché, on pourrait dire que je me suis appauvri injustement, mais cet appauvrissement (et l'enrichissement corrélatif du vendeur) n'est pas « sans cause », car, comme nous le verrons, il existe une règle du droit des contrats qui pose qu'en principe un contrat est parfaitement valable même si les prestations des parties sont déséquilibrées[126]. Admettre que l'acheteur pourrait agir contre le vendeur pour obtenir la compensation de son appauvrissement serait remettre en cause cette règle. De même, si j'ai laissé prescrire mon droit de créance contre mon débiteur, je ne peux soutenir que celui-ci s'est enrichi sans cause à mon détriment, car la prescription

123 On trouve mention de l'action dans la jurisprudence luxembourgeoise dès la fin du XIX[e] siècle : Cour d'appel, 17 décembre 1897, *Pas.*, 4, p. 439.

124 BGB, 6§ 811 à 822. CO Suisse, art. 62 à 67.

125 Cass. fr. (civ.), 2 mars 1915, *G.A.J.C.*, 11[e] éd., n° 228. On retrouve cette formule dans de nombreuses décisions luxembourgeoises, not. : Cass., 30 mai 1974, 22, p. 413, et, dans la période récente : Cour d'appel, 13 juin 2001, *Pas.*, 32, p. 151. Voy. encore récemment Cour d'appel, 5 juin 2024, n° CAL-2022-00541.

126 Voy. *infra*, n[os] 259 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

(que certains peuvent trouver injuste !) constitue précisément la cause de l'enrichissement de l'un et de l'appauvrissement de l'autre. Il faut ajouter que l'action, lorsqu'elle est admise, ne produit que des effets limités : l'appauvri ne peut pas nécessairement obtenir la compensation intégrale de son appauvrissement, il ne peut réclamer que la plus faible des deux sommes représentant l'appauvrissement et l'enrichissement. Ces solutions jurisprudentielles ont été très largement reprises en France par les nouveaux articles 1303 à 1303-4 et en Belgique par les articles 5.135 à 5.137 du nouveau code, l'enrichissement sans cause ayant été, dans les deux pays, renommé « enrichissement injustifié ».

Bien que l'enrichissement sans cause soit aujourd'hui, dans l'enseignement du droit civil, rattaché aux quasi-contrats, parce qu'on y retrouve l'idée de base d'un avantage reçu d'autrui comme source d'obligations, le rapprochement terminologique avec la notion de contrat apparaît encore plus artificiel que pour les quasi-contrats du Code civil. En effet, les situations dans lesquelles on peut recourir à l'enrichissement sans cause sont souvent très éloignées de relations contractuelles – soit parce que l'appauvri et l'enrichi n'ont pas été en relations personnelles[127], soit parce que ces relations ne se prêtent pas à la qualification contractuelle. Par exemple, la question de l'enrichissement sans cause est fréquemment posée dans le cadre de relations de couple, lorsque l'un des conjoints (le plus souvent la femme) travaille sans être rémunérée pour aider l'autre (cas typique de la femme d'un médecin qui assure bénévolement le secrétariat de son mari). Lorsque le couple se sépare, celui qui a ainsi travaillé gratuitement vient souvent réclamer une indemnité à l'autre qui, soutient-il, s'est enrichi sans cause à son détriment – tout le débat portant alors sur le point de savoir si l'aide apportée ne s'inscrivait pas dans la contribution normale aux charges du ménage ou si elle n'était pas motivée par une intention libérale, ce qui constituerait une cause à l'enrichissement et à l'appauvrissement. Il est difficile dans ce type de situations d'imaginer une action qui serait fondée sur un contrat (notamment un contrat de travail), car il est clair que les époux ou les concubins n'ont eu aucune intention de s'engager contractuellement l'un envers l'autre.

73. **Vers un quasi-contrat innomé ?** Dans la période récente, plusieurs décisions très remarquées de la Cour de cassation française se sont fondées directement sur la notion de quasi-contrat de l'article 1371 du Code civil, pour admettre une action en paiement alors que la situation ne rentrait dans aucune des catégories précédentes. Cette jurisprudence, très contestée (et à juste titre) par la doctrine française, n'a pas jusque-là trouvé d'écho au Luxembourg. On ne l'évoque ici que parce qu'elle est particulièrement caractéristique des problèmes de frontières entre les différentes qualifications juridiques possibles pour une même situation.

Le problème posé dans ces affaires était celui des loteries publicitaires qui sont proposées aux consommateurs. Vous recevez par courrier ou par mail l'annonce que vous avez gagné une somme importante (ou un voyage, ou une voiture, ou tout autre lot, etc.) dans une loterie organisée par un professionnel vendeur de biens ou de services. Pour recevoir votre lot, dit l'annonce, il vous suffit de renvoyer un

[127] C'est le cas chaque fois que la valeur a transité par le patrimoine d'un tiers (comme dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt *Boudier*).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

bon de participation. On vous indique que le jeu est sans obligation d'achat, mais que vous pouvez en profiter pour commander tel ou tel bien (le fauteuil relax qui soulagera votre mal de dos, le fer à repasser magique qui repasse tout seul, etc.). Naturellement, si vous êtes un consommateur averti, vous ne vous laisserez pas prendre, et vous comprendrez facilement que des milliers de gens ont reçu le même courrier que vous ; vous saurez découvrir, en bas de la page, la mention, écrite en caractères minuscules, indiquant que le gain est subordonné à un tirage au sort, et qu'il ne vous est nullement acquis. Mais cela ne sera pas évident pour un grand nombre de consommateurs naïfs, souvent des personnes âgées, qui croiront avoir gagné le gros lot, et qui, pour être plus sûrs de le recevoir commanderont une des marchandises proposées. Certaines de ces personnes, ne recevant pas le lot promis, essaieront ensuite d'agir en justice pour l'obtenir. Les tribunaux français, mus par le souci de sanctionner les comportements déloyaux de certains professionnels, ont parfois admis de telles actions sur des fondements divers. Certains arrêts ont vu dans la relation entre le professionnel qui organise la loterie et le consommateur qui y souscrit un contrat comportant l'obligation de remettre le lot promis[128], ou, un peu différemment, un engagement unilatéral de remettre le lot[129] (analyses qui se heurtent à la volonté clairement exprimée par le professionnel, même de manière peu visible, de subordonner la remise du lot à un tirage au sort) ; d'autres arrêts ont, plus raisonnablement, estimé que l'organisateur de la loterie qui trompe sciemment le consommateur sur les conditions de remise du lot commet une faute génératrice de responsabilité civile délictuelle, et l'obligeant à réparer le préjudice subi par le consommateur (généralement un simple préjudice moral, réparé par des dommages et intérêts inférieurs à la valeur du lot promis)[130]. Finalement, c'est sur le fondement d'un quasi-contrat, au visa de l'article 1371 du Code civil, que la Cour de cassation française, dans un arrêt de 2002, a permis au consommateur trompé de réclamer la somme promise[131] : partant de la définition vague de l'article 1371 du Code civil, la Cour juge que « l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ». Dans cette décision (suivie de plusieurs autres), la notion de quasi-contrat, qui n'était jusque-là qu'une catégorie (contestée) regroupant des mécanismes juridiques spécifiques (gestion d'affaires, paiement de l'indu, enrichissement sans cause), devient une notion technique opérationnelle, susceptible de fonder directement une action. On peut donc parler d'un quasi-contrat innomé, comme il existe, nous allons le voir[132], des contrats innomés n'entrant dans aucune catégorie prédéfinie par la loi. La méthode paraît bien discutable, car la situation visée ne correspond en rien à l'idée d'avantage reçu par autrui qui fait l'unité (relative) de la catégorie. Il serait préférable, plutôt que de se livrer à ce type de manipulations des qualifications, de sanctionner le comportement déloyal du professionnel par l'édiction d'un texte spécial[133]. En droit luxembourgeois, les loteries publicitaires sont spécialement visées au titre des pratiques commerciales

128 Cass. fr. (1re civ.), 12 juin 2001, n° 98-20309.

129 Cass. fr. (1re civ.), 28 mars 1995, n° 93-12678.

130 Cass. fr. (1re civ.), 19 octobre 1999, n° 97-10570.

131 Cass. fr. (ch. mixte), 6 septembre 2002, n° 98-22981.

132 Voy. *infra*, n° 76.

133 C'est ce que fait le droit allemand dans le § 661 a du BGB, intégré dans le Code par une loi du 30 juin 2000 : « *Ein Unternehmer, der Gewinnzusagen oder vergleichbare Mitteilungen an Verbraucher sendet und durch die Gestaltung dieser Zusendungen den Eindruck erweckt, dass der Verbraucher einen Preis gewonnen hat, hat dem Verbraucher diesen Preis zu leisten* ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

agressives par l'article L122-7 (8) du Code de la consommation. Le nouveau droit français laisse cependant subsister cette possibilité pour la jurisprudence de consacrer des quasi-contrats innomés : l'article 1300 du Code civil français énonce que les quasi-contrats « régis par le présent titre » sont la gestion d'affaires, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié, ce qui laisse entendre qu'il peut y avoir d'autres quasi-contrats. L'article 5.127 du Code civil belge, en revanche, donne une liste limitative des trois quasi-contrats.

LARCIER INTERSENTIA
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La notion de contrat en droit luxembourgeois, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 51-98
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Chapitre III
Les différents types de contrats

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

74. De l'ordre dans la diversité. On l'a vu d'emblée, la notion de contrat recouvre des pratiques extrêmement diverses, de l'achat d'une baguette de pain chez le boulanger à l'accord de coopération passé entre des entreprises multinationales, en passant par le contrat de travail, le transport de marchandises ou de personnes, le cautionnement donné pour garantir une obligation, la donation d'un bien, etc. La liste est infinie. Pour essayer d'appréhender cette diversité, les juristes classent habituellement les contrats en diverses catégories. Ces catégorisations sont elles-mêmes de deux types. D'une part, le droit positif distingue, pour les soumettre à des règles particulières, différents types de contrats en fonction de leur objet et de leur but (la vente, le bail, le contrat de travail, etc.) ; cette catégorisation des différents contrats dits « spéciaux » constitue une classification ouverte, qui peut toujours être complétée par de nouveaux types en fonction de l'évolution des règles juridiques, et qui laisse toujours place à des contrats n'entrant dans aucune des catégories prédéfinies (**Section 1**). D'autre part, il existe des classifications transversales, reposant sur des critères variés, qui s'appliquent à l'ensemble des contrats quelle que soit leur qualification spéciale ; à la différence des précédentes, ces classifications, généralement binaires, sont fermées en ce que tous les contrats appartiennent nécessairement à l'une ou à l'autre des catégories prédéterminées (**Section 2**).

SECTION 1. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRATS SPÉCIAUX

75. La vente, le bail et les autres. Comme on l'a déjà expliqué[134], le Code civil contient deux séries de règles relatives aux contrats. Le Titre III du Livre III, intitulé « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » (C. civ., art. 1101 à 1369), est consacré aux règles générales qui s'appliquent à tous les contrats, quel qu'en soient la nature et l'objet – ce qu'on appelle traditionnellement le « droit commun des contrats ». Plus loin dans le Code, après avoir traité des « engagements qui se forment sans convention », puis des régimes matrimoniaux, les rédacteurs ont posé les règles spéciales applicables à différents contrats particuliers : la vente, le bail, le mandat, le prêt, le dépôt, le cautionnement, etc. (C. civ., Titres VI et suivants). D'autres types de contrats soumis à des règles spéciales sont réglementés dans d'autres codes (le contrat de travail) ou

134 Voy. *supra*, n° 13.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

dans des lois non codifiées. Comme l'indique l'article 1107 du Code civil, ces différents contrats, qui ont une « dénomination propre », et qu'on appelle pour cela *contrats nommés*, ne sont pas pour autant soustraits aux règles générales des articles 1101 et suivants du Code civil. Celles-ci s'y appliquent dans toute la mesure où les règles spéciales ne les écartent pas.

Les règles particulières aux différents contrats nommés ne sont pas étudiées dans cet ouvrage. Elles relèvent, dans le cadre des études de droit, d'un cours différent consacré aux « contrats spéciaux ». Il n'est donc pas question ici d'entrer dans le détail des critères de distinction entre la vente et le bail, ou entre le contrat d'entreprise et le contrat de travail. On se contentera de signaler que la liste de ces contrats spéciaux est en constante évolution, le législateur pouvant toujours décider de soumettre à des règles particulières un contrat présentant telle ou telle caractéristique. Par ailleurs la loi peut créer des sous-catégories à l'intérieur d'un modèle déterminé, pour les soumettre à des règles particulières venant s'ajouter ou déroger aux règles applicables à la catégorie principale : par exemple, à l'intérieur du contrat de bail[135], on distingue aujourd'hui le bail d'habitation[136], le bail commercial[137], le bail rural[138]. La tendance moderne, liée à un interventionnisme croissant de l'État dans les relations contractuelles, est à une différenciation de plus en plus fine des types de contrats. Le droit des contrats se présente ainsi, sur de nombreux points, comme un empilement de règles qu'il faut combiner les unes avec les autres.

76. Contrats innom(m)és[139]**.** Peut-on passer un contrat qui n'entre pas dans une des catégories prévues et réglementées par la loi ? Cela n'a pas toujours été admis. Le droit romain ne connaissait à l'origine que des figures nommées, qui seules méritaient le nom de « *contractus* » et qui donnaient lieu à une action en justice. Cependant, à la période byzantine, le prêteur commence à accorder des actions dans des situations qui n'entrent dans aucun des modèles classiques : ainsi apparaissent ce qu'on appelle aujourd'hui les contrats innomés. Le développement progressif du principe de

135 Régi par les articles 1714 à 1751, du Code civil.

136 Régi par les articles 1752 et 1762-2, du Code civil et par la loi du 21 septembre 2006.

137 Régi par les articles 1762-3 à 1762-8, du Code civil (issus d'un arrêté grand-ducal du 31 octobre 1936).

138 Régi par les articles 1763 à 1778, du Code civil.

139 On admet les deux orthographes.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

liberté contractuelle[140] aboutit à permettre, d'une manière générale, la conclusion de contrats ne correspondant à aucun modèle prédéterminé, et cette liberté est expressément consacrée dans le Code civil. L'article 1107 du Code civil indique en effet que les contrats « n'ayant pas de dénomination propre » sont soumis aux règles générales du Titre III. Ils ne sont du reste soumis qu'à ces règles, puisque, par hypothèse, aucune règle spéciale n'est posée pour ces contrats.

Ainsi peuvent se développer, en théorie à l'infini, des pratiques contractuelles qui s'écartent des modèles fixés par la loi. Nombre de contrats très utilisés aujourd'hui dans la vie des affaires sont ainsi apparus en dehors de toute réglementation légale spécifique. On peut prendre ici l'exemple de la garantie autonome : le Code civil (art. 2011 à 2043) prévoit qu'une personne peut garantir le remboursement de la dette d'une autre par un contrat nommé appelé cautionnement, et dont l'une des caractéristiques est que la caution est tenue exactement de la même manière que le débiteur, et qu'elle dispose donc des mêmes moyens de défense que lui ; pour donner plus de sécurité aux créanciers, la pratique a imaginé un type de contrat – couramment appelé garantie autonome ou indépendante – dans lequel une personne s'engage à payer une certaine somme en garantie de la dette d'une autre, mais sans pouvoir opposer au créancier les moyens de défense appartenant au débiteur. On pourrait également citer les contrats de franchise (qui permettent à une entreprise de mettre en place un réseau de distributeurs indépendants en leur imposant des méthodes de vente spécifiques), le leasing (technique de financement d'un bien dans laquelle l'utilisateur est simplement locataire du bien acheté à son intention par l'établissement de crédit), le time-sharing (contrat d'utilisation à temps partiel d'un bien immobilier), etc. Tous ces contrats ont bien un nom, mais, tant qu'ils ne font pas l'objet d'une réglementation légale, ils constituent des contrats « innomés ».

Il faut avoir conscience que les contrats innomés ne le restent pas nécessairement longtemps. D'abord, lorsqu'une pratique contractuelle se répète, les acteurs économiques eux-mêmes, souvent relayés par la doctrine, auront tendance à lui donner un nom (les exemples précédents en témoignent). Ensuite, si cette pratique contractuelle donne lieu à des contentieux répétés, on peut assister

140 Voy. *infra*, n°s 102 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

à l'éclosion de règles jurisprudentielles relatives au contrat considéré[141]. Enfin, le législateur lui-même peut se saisir de cette pratique pour la réglementer, et en faire un véritable contrat nommé/normé. Il en a été ainsi, en France, du leasing (devenu crédit-bail depuis une loi de 1966), ou de la garantie autonome (intégrée dans le Code civil lors de la réforme du droit des sûretés en 2006). Au Luxembourg, la fiducie (transfert en pleine propriété d'un ensemble de biens à des fins de gestion ou de garantie) a d'abord été une pratique, avant d'être consacrée par un règlement grand-ducal de 1983, puis par une loi du 27 juillet 2003. La garantie autonome est désormais consacrée par la loi du 10 juillet 2020 sur les garanties professionnelles de paiement. Il y a, d'une manière générale, une tendance accusée des législateurs contemporains à soumettre à une réglementation de plus en plus de pratiques contractuelles au départ innomées.

SECTION 2. LES CLASSIFICATIONS TRANSVERSALES

77. Intérêts et critères des classifications. Au-delà des différents types spéciaux soumis ou non à des règles particulières, les juristes des pays du Code civil ont éprouvé le besoin de classer les multiples contrats dans des catégories générales. Toutes ces classifications sont d'origine doctrinale, mais certaines ont été reprises par la loi : le Code civil opère ainsi diverses classifications dans les articles 1102 à 1107 (contrats synallagmatiques et unilatéraux, contrats à titre onéreux et à titre gratuit, contrats commutatifs et aléatoires). D'autres sont restées purement doctrinales, même si elles peuvent, à l'occasion, être consacrées par la jurisprudence (contrats à exécution successive et à exécution instantanée, contrats d'adhésion et contrats négociés, etc.). En France et en Belgique, la réforme du droit des obligations a repris, pour l'essentiel, les classifications traditionnelles, et a été l'occasion de consacrer quelques distinctions auparavant purement doctrinales ou jurisprudentielles (C. civ. fr., art. 1106 à 1111-1, C. civ. be., art. 5.5 à 5.12).

Ces classifications visent à fixer des règles différentes selon les catégories qu'elles distinguent. Par exemple, lorsque les articles 1109 et 1110 du Code civil distinguent les contrats synallagmatiques et unilatéraux, cela veut dire que, sur certains points,

[141] Cela a en particulier été le cas, au Luxembourg comme ailleurs, pour la garantie autonome.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

les règles applicables à un contrat sont différentes selon que ce contrat relève de l'une ou de l'autre catégorie. C'est dire que les classifications prévues par la loi ou proposées par la doctrine, ne relèvent pas de la nature des choses, ce ne sont que des constructions, propres à un système et évolutives à l'intérieur de ce système. Il faut être conscient que la manière dont on classe les contrats n'est pas une simple question technique, mais qu'elle dépend de choix de politique juridique qui commandent l'importance qu'on attache à tel ou tel critère dans la réglementation des relations contractuelles.

Aussi est-il caractéristique d'observer une évolution importante dans les critères pris en compte pour élaborer les différentes classifications des contrats. Les plus traditionnelles – dont, en premier lieu, celles qui sont expressément visées aux articles 1101 à 1106 du Code civil – sont liées à des critères objectifs, tenant aux caractéristiques intrinsèques des contrats (leur structure ou leur processus de formation) (**§ 1**). D'autres classifications, souvent plus récentes, reposent sur un critère subjectif en ce qu'elles prennent en compte les personnes qui passent le contrat (**§ 2**).

§ 1. Classifications objectives

A) *Classifications fondées sur la structure des contrats*

78. Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux. C'est la première des classifications envisagées par le Code, aux articles 1102 et 1103 (C. civ. fr., art. 1106, C. civ. be., art. 5.6), et elle reste, quant à ses conséquences techniques, la plus importante. Selon l'article 1102 du Code civil, le contrat est synallagmatique ou bilatéral[142] lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Ces contrats, qui sont les plus nombreux, reposent sur l'idée d'échange entre deux prestations : chaque partie s'oblige envers l'autre parce que l'autre lui fournit quelque chose en échange. La vente, le bail, le contrat de travail, etc. sont des contrats synallagmatiques. À l'inverse, dans certains contrats, une partie s'oblige à quelque chose envers une autre, sans rien recevoir en échange. Par exemple, dans un contrat de donation, le donateur se dessaisit de la propriété d'un bien, sans que le donataire ne lui paye rien, ni ne lui donne rien en contrepartie. Ces contrats, dans lesquelles, selon

[142] Cette seconde dénomination est quasiment tombée en désuétude.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la définition de l'article 1103 du Code civil, « une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement », sont dits unilatéraux[143].

La distinction présente divers intérêts pratiques en ce que certains mécanismes juridiques, liés à la réciprocité des obligations, sont spécifiques aux contrats synallagmatiques (la lésion, l'exception d'inexécution, la résolution pour inexécution dans la conception traditionnelle, etc.). Ces mécanismes ne valent pas en principe pour les contrats unilatéraux, mais ceux-ci n'obéissent pas, quant à eux, à un régime juridique uniforme. L'intérêt premier de cette catégorie est de rappeler que, dans le système du Code civil, à la différence des droits de *common law*, il peut y avoir un contrat sans échange économique.

Bien que très simple dans son principe, la distinction des articles 1102 et 1101 du Code civil n'est pas toujours d'une application simple. D'abord, le droit peut artificiellement traiter comme un contrat unilatéral un accord visant à réaliser un échange économique. Il en va ainsi du prêt d'argent avec intérêt, dans lequel, économiquement, on peut voir l'échange d'une prestation du prêteur (mettre pendant un certain temps une somme d'argent au profit de l'emprunteur) contre la rémunération versée par l'emprunteur (les intérêts). Cependant, traditionnellement, dans le système du Code civil, on traite le prêt comme un contrat unilatéral, parce que la remise de la somme prêtée est considérée comme une condition de validité du contrat (ce qui fait du prêt un contrat réel). Dès lors, une fois la somme remise, il ne semble y avoir d'obligations qu'à la charge de l'emprunteur (rembourser le capital et payer les intérêts)[144]. Cette analyse est cependant aujourd'hui remise en cause par la jurisprudence qui admet que, dans certains cas au moins, le prêt n'est pas un contrat réel[145]. Ensuite, il arrive parfois que, dans le cadre d'une relation contractuelle initialement conçue comme unilatérale, une obligation vienne accidentellement à naître, au cours de l'exécution du contrat, à la charge de la partie non obligée au départ. Par exemple, si j'ai demandé à un de mes amis de me garder ma moto pendant un séjour que je fais à l'étranger, et que celui-ci a accepté de le faire gracieusement, on est en présence d'un contrat de dépôt, contrat en principe unilatéral, qui n'oblige que le dépositaire à garder la chose déposée. Mais si, pendant mon absence, le bien déposé a besoin de réparations (par exemple parce que le local où il était entreposé a été inondé), mon ami devra le faire réparer, et je serai tenu de lui rembourser le coût de la réparation. Mon ami pourra même refuser de me rendre ma moto tant que je ne l'aurai pas remboursé, comme si on était dans le cadre d'un contrat synallagmatique (C. civ., art. 1947). Dans un tel cas, on parle parfois d'un contrat synallagmatique imparfait. D'une manière plus générale, aujourd'hui, les intérêts de la distinction entre contrats synallagmatiques et

[143] Attention ! Ne confondez pas les contrats unilatéraux, qui sont des contrats (donc des accords entre au moins deux personnes) ne faisant naître d'obligation que pour une personne, avec les actes juridiques unilatéraux, qui émanent d'une seule personne (p. ex. : un testament) – sur les actes unilatéraux, voy. *supra*, n°s 61 et s.

[144] Cette analyse se fonde sur l'article 1892, du Code civil qui définit le prêt comme « un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses […], à la charge par cette dernière de lui en rendre autant […] ».

[145] Voy. *infra*, n° 926.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

contrats unilatéraux tendent à se réduire, car la jurisprudence française admet parfois l'application, aux contrats unilatéraux, de certains mécanismes juridiques traditionnellement regardés comme spécifiques des contrats synallagmatiques[146].

La notion de contrat synallagmatique elle-même recouvre des opérations diversifiées. On se représente habituellement ces contrats comme traduisant une relation bilatérale d'échange entre deux contractants : l'un s'engage à quelque chose en contrepartie de ce qu'il reçoit de l'autre. Déjà, on peut observer que l'échange est plus complexe lorsqu'il intervient entre plus de deux parties : A fait quelque chose pour B, qui fait en contrepartie quelque chose pour C, qui fournit lui-même une prestation à C. Surtout, au sein des contrats synallagmatiques, on peut discerner des cas où, même si les parties s'engagent bien réciproquement les unes envers les autres, l'essentiel n'est pas dans un échange de prestations, mais dans la mise en place d'une organisation permanente (ainsi dans le contrat de société ou d'association). À partir de cette observation, un auteur français a construit la distinction entre les *contrats-échange* (la vente, le bail, le contrat de travail, le mandat, etc.) et les *contrats-organisation*[147]. Cette distinction est restée pour l'instant purement doctrinale. En droit positif, on peut discerner des particularités du régime des « contrats-organisation », mais la distinction n'a pas vraiment reçu de consécration jurisprudentielle.

79. Contrats à titre onéreux et contrats à titre gratuit. Cette seconde classification est envisagée par les articles 1105 et 1106 du Code civil (C. civ. fr., art. 1107, C. civ. be., art. 5.7). Selon l'article 1105 du Code civil, « le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit » : on parle plus volontiers aujourd'hui de contrat à titre gratuit. Selon l'article 1106 du Code civil, « le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose ». De prime abord, cette classification semble faire double emploi avec la précédente, et il est vrai que les deux classifications se recoupent largement : tous les contrats synallagmatiques sont à titre onéreux, et l'immense majorité des contrats unilatéraux sont à titre gratuit. La coïncidence n'est pas parfaite cependant, dans la mesure où, comme on l'a vu, un contrat techniquement unilatéral comme le prêt, peut donner lieu à une rémunération du prêteur. De même, un contrat comme le cautionnement, qui est unilatéral par nature (parce que la caution s'engage à payer la dette d'un débiteur envers le créancier sans que celui-ci ne lui fournisse rien en échange) peut être à titre onéreux (si la caution est rémunérée par le débiteur, ce qui est fréquent lorsque la caution est un établissement de crédit). Par ailleurs, la considération que le contrat est à titre onéreux ou gratuit commande d'autres intérêts que ceux de la

146 Voy. *infra*, n° 739 à propos de la résolution pour inexécution.

147 Voy. P. Didier, « Brèves notes sur le contrat-organisation », *Mélanges en hommage à François Terré*, Paris, LGDJ, 1999, pp. 633 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

distinction synallagmatique-unilatéral : ce qui compte, ici, ce n'est pas la structure technique de l'opération (l'existence ou non d'une contrepartie), mais la motivation de l'engagement (bénévole ou intéressé). D'une manière générale, lorsqu'un contractant s'engage de manière bénévole, le droit se montrera plus protecteur à son égard qu'à l'égard des contractants intéressés : d'où, en particulier, un formalisme plus accusé au moment de l'engagement (c'est caractéristique dans la donation) et une responsabilité moins facilement retenue en cas de mauvaise exécution (un dépositaire à titre gratuit, par exemple, sera moins facilement reconnu responsable en cas de perte ou de détérioration du bien déposé qu'un dépositaire salarié – un garde-meubles – à l'égard duquel, parce qu'il se fait payer, on se montrera plus exigeant).

80. Contrats commutatifs et contrats aléatoires. Visée à l'article 1104 du Code civil (C. civ. fr., art. 1109, C. civ. be., art. 5.8), cette distinction apparaît comme une classification interne aux contrats synallagmatiques. En principe, dans de tels contrats, la valeur de chaque prestation est appréciable au moment de la conclusion du contrat, et chaque partie s'engage parce qu'elle reçoit en échange une chose ou une prestation qu'elle considère comme équivalente à ce qu'elle donne. Par exemple, si j'achète un immeuble 800 000 €, c'est parce que je considère que les avantages que je retirerai de cet immeuble valent le sacrifice financier que je consens à faire pour en devenir propriétaire. Ces contrats reposent sur un principe de « justice commutative », au sens de la philosophie d'Aristote ; c'est pourquoi on les nomme « contrats commutatifs ». Et l'un des problèmes de base du droit des contrats est de savoir ce qui se passe lorsque l'équivalence envisagée par les parties ne correspond pas à l'équivalence objective entre les prestations : dans mon exemple, est ce que je pourrai faire annuler la vente si je m'aperçois que l'immeuble acheté 800 000 € valait beaucoup moins cher d'après les prix du marché ? (ou, à l'inverse, mon vendeur pourrait-il faire tomber la vente si le prix qu'il a accepté de recevoir était plus faible que le prix du marché ?). Nous verrons que la réponse du droit luxembourgeois est en principe négative, parce que ce qui compte, ce n'est pas l'équivalence objective entre les prestations mais, comme l'indique bien l'article 1104 du Code civil, le fait que chaque prestation soit « regardée » comme équivalente à l'autre. Mais nous verrons aussi qu'il existe d'importantes exceptions.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Cette question n'a pas de sens dans certains contrats synallagmatiques où il existe, dès le départ une incertitude, un aléa, connu et accepté par les parties, sur la valeur ou même sur l'existence d'une des prestations réciproques. Si je participe à un jeu d'argent, je sais ce que je débourse (disons 15 € pour acheter le bulletin à gratter), mais je ne sais pas si je recevrai quelque chose en retour. Je ne recevrai rien, si le bulletin est perdant, mais je peux recevoir beaucoup (peut-être 1 000 fois plus que ma mise) s'il est gagnant. Et, bien sûr, je n'accepte de courir le risque de perdre 15 € sans rien recevoir en échange que parce que j'ai une chance de gagner beaucoup. C'est ce type de contrat que l'article 1104 du Code civil appelle contrat aléatoire. Bien évidemment, il n'est ici pas question de faire annuler le contrat au motif que je n'ai rien reçu en échange de mes 15 €, car il n'est pas question ici d'une recherche d'équivalence entre ce que l'un donne et ce que l'autre reçoit : l'équivalent, comme le dit l'article 1104 du Code civil, « consiste dans la chance de gain ou le risque de perte pour chacune des parties ». Et la nullité ne peut être envisagée que si le jeu est faussé (par exemple si tous les bulletins étaient perdants) de sorte que toutes les chances de gain sont pour une des parties (l'organisateur du jeu) et tous les risques de perte pour l'autre (le joueur)[148].

Les contrats aléatoires sont extrêmement nombreux. On citera ici : le contrat d'assurance (dans lequel l'assuré paie des primes sans savoir si le risque assuré se réalisera un jour, de sorte qu'il paiera peut-être à fonds perdu pendant des années), le contrat de vente contre rente viagère (dans lequel le prix de vente est fixé sous forme d'une somme à verser périodiquement par l'acheteur pendant toute la vie du vendeur, de sorte que le prix final sera plus ou moins élevé selon la durée de la vie du vendeur), de nombreux contrats de placement boursier (dans lesquels le prix de revente des titres achetés est fixé en fonction de leur cours actuel, ce qui peut, selon l'évolution de ce cours, faire gagner ou perdre beaucoup d'argent à l'investisseur). Cependant, comme pour toutes les autres classifications, la frontière entre les contrats commutatifs et les contrats aléatoires n'est pas toujours aisée à déterminer, parce qu'il existe, dans beaucoup de contrats commutatifs, une part d'incertitude. Dira-t-on par exemple qu'une vente de matériel d'occasion, faite à bas prix, et sans garantie de la part du vendeur, est une vente aléatoire, au motif que l'acheteur peut, selon les cas, faire une très bonne affaire (si la chose fonctionne très bien), ou avoir perdu son argent (si elle tombe en panne le lendemain de l'achat) ?

81. Contrats à exécution instantanée et contrats à exécution successive. À la différence des précédentes, cette distinction n'est pas prévue par le Code civil de 1804. C'est une distinction qui a été élaborée par la doctrine française, et à laquelle la jurisprudence, dans

148 Voy. *infra*, n° 352, à propos de la nullité pour absence de cause.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

les trois pays du Code civil, attache certains effets. Elle repose sur la structure temporelle du contrat. Dans certains contrats, dits à exécution instantanée, les effets principaux se produisent en une seule fois, au moment même de la formation ou à un moment ultérieur : il en va ainsi dans le contrat de vente où, en principe, dès le moment de l'accord de volontés, la propriété passe sur la tête de l'acheteur, le vendeur est obligé de livrer la chose et l'acheteur de la payer. Dans d'autres contrats, en revanche, les effets du contrat s'étalent dans le temps, les obligations des parties s'exécutant par une série de prestations successives : il en va ainsi du contrat de bail (au moins du bail immobilier, dans lequel le locataire paye périodiquement un loyer en contrepartie de la mise à disposition continue de l'immeuble que lui procure le bailleur) ou du contrat de travail (le salarié travaille régulièrement pour l'employeur qui lui verse périodiquement un salaire). C'est ce qu'on appelle les contrats à exécution successive. Cette distinction est prise en compte lorsqu'il s'agit de déterminer les effets de l'anéantissement des contrats, soit par suite de leur nullité, soit en raison de leur inexécution : alors que l'anéantissement est en principe rétroactif pour les contrats instantanés (ce qui amène une restitution des prestations effectuées), il n'opère normalement que pour l'avenir dans les contrats successifs. Par ailleurs, la notion de durée du contrat n'a pas exactement le même sens dans l'un et l'autre cas, les contrats à exécution successive pouvant être conclus pour une durée déterminée ou non, et faire l'objet d'une résiliation unilatérale en cours d'exécution. La distinction a été consacrée dans le nouvel article 1111-1 du Code civil français. Elle n'apparaît toujours pas en revanche dans le nouveau Code civil belge.

Cette distinction est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il arrive en effet fréquemment qu'un contrat rentrant en principe dans la catégorie des contrats « à exécution instantanée » s'exécute de manière échelonnée dans le temps : ainsi dans une vente, il est fréquent que l'acheteur paye le prix en plusieurs fois, ou que le vendeur livre le bien en plusieurs parties. Cela ne suffit cependant pas à en faire des contrats à exécution successive parce que les différentes mensualités, ou les différentes livraisons, ne sont que des fractions de la prestation globale que doit fournir l'acheteur ou le vendeur. De même, le contrat d'entreprise ayant pour objet la construction d'une maison – ce qui suppose nécessairement un certain temps – n'est pas, malgré ce que les termes employés suggéreraient, un contrat « à exécution successive », parce que les différentes étapes de la construction ne sont que des parties d'une prestation globale – à la différence d'un contrat de travail dans lequel le salarié, jour après jour, fournit des prestations qui s'ajoutent les unes aux autres. Ces exemples montrent que la terminologie traditionnelle est particulièrement inadaptée pour rendre compte de la distinction. Plutôt que la durée d'exécution du contrat, ce qui est important c'est le caractère global ou non, divisible ou non des prestations objet du contrat, car c'est cela qui explique les conséquences différentes

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de l'anéantissement du contrat, ou la possibilité (ou l'impossibilité) de mettre fin au contrat en cours d'exécution. Nous aurons l'occasion de repréciser cette distinction lorsque nous examinerons ces questions[149].

Dans le prolongement de la distinction technique traditionnelle des contrats à exécution instantanée et des contrats à exécution successive, il faut évoquer ici une autre classification doctrinale moderne, qui prend également en compte la manière dont le contrat s'inscrit dans la durée. Il s'agit de la distinction, d'origine américaine, entre les *contrats relationnels* et les *contrats transactionnels*. La notion de contrat relationnel a été forgée par l'auteur américain I. MacNeil[150] pour désigner des contrats de longue durée dans lesquels les relations personnelles des parties sont essentielles (par exemple : les contrats de distribution). Ces contrats devraient être soumis à un régime particulier, notamment du point de vue du rôle de la bonne foi dans les relations entre contractants. L'auteur oppose ces contrats aux accords destinés à se dénouer rapidement (contrats transactionnels), comme la vente, pour lesquels la théorie classique du contrat semble avoir été davantage conçue. Bien que la notion de contrat relationnel se soit répandue dans la doctrine européenne, et qu'elle s'appuie sur une observation fine des pratiques contractuelles, cette distinction ne s'est pas encore vraiment cristallisée dans le droit positif, et on ne peut, pour l'instant, attacher aucune conséquence technique particulière au fait qu'un contrat corresponde au modèle décrit par MacNeil. On n'en trouve en tout cas aucune trace dans la jurisprudence luxembourgeoise.

B) *Classifications fondées sur le processus de formation des contrats*

82. Contrats consensuels, solennels et réels. Il s'agit d'une classification doctrinale traditionnelle, qui repose sur les exigences nécessaires à la validité du contrat. Cette classification ne se trouve pas énoncée dans le Code civil de 1804, mais elle est aujourd'hui consacrée par l'article 1109 du Code civil français et par l'article 5-5 du nouveau Code civil belge (qui parle de contrats formels là où le code français emploie le terme traditionnel de « solennels »). En principe, dans le système du Code civil, le contrat se forme par le seul échange des consentements, sans qu'aucune formalité ne soit requise pour sa validité : on parle alors de contrats *consensuels*. Par exception, cependant, différents contrats (de plus en plus nombreux) sont assujettis, pour leur validité, à la rédaction d'un acte écrit (qui peut être, selon les cas, un acte notarié ou un acte sous seing privé, devant parfois comporter des mentions spécifiques, éventuellement manuscrites) : on les désigne sous le nom de contrats *solennels*, et la forme requise est appelée solennité. Le Code civil a par ailleurs

149 Voy. *infra*, n°s 542 et s.

150 I. R. MACNEIL (1929-2010), juriste américain d'origine écossaise. Sa théorie du contrat relationnel a été exposée pour la première fois dans : « The Many Futures of Contracts » (1974), 47 *Southern California Law Review*, p. 691.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

laissé subsister certains contrats dans lesquels, comme en droit romain, la remise (tradition) d'une chose est une condition de validité : il en va ainsi du prêt d'une chose (ou prêt à usage), du contrat de gage, du dépôt, etc. Ces contrats sont appelés contrats *réels* (du latin *res*). Cette classification, à la différence des précédentes, est purement terminologique, en ce sens qu'elle ne vise pas à déterminer le régime de contrats répondant à certaines caractéristiques, mais seulement à donner un nom à certaines sortes de contrats en fonction du régime qui s'y applique. Le fait de classer tel ou tel contrat dans la catégorie des contrats consensuels, solennels ou réels est une simple opération d'étiquetage, qui résulte de la découverte dans la loi ou dans la jurisprudence des règles régissant la formation du contrat considéré.

83. Contrats d'adhésion et contrats négociés. Cette distinction, pendant longtemps purement doctrinale, mais indispensable à la compréhension du droit moderne des contrats, ne repose pas, comme la précédente sur la manière dont les contrats doivent être conclus, mais sur la manière dont ils se forment effectivement. À l'époque du Code civil, la plupart des contrats se formaient dans le cadre d'une discussion, plus ou moins libre, entre les deux parties, et c'est à partir de ce modèle que les rédacteurs du Code ont pensé le droit des contrats. Ces *contrats négociés* (ou de gré à gré) existent toujours, dans des contextes très divers : que l'on pense par exemple à la vente d'une maison ou d'un appartement, dont le vendeur et l'acheteur vont discuter non seulement le prix, mais aussi le moment où le vendeur devra libérer les lieux, les modalités de paiement par l'acheteur, les conditions de garantie du bien, etc. Que l'on songe aussi aux grands contrats internationaux (pour la prise de contrôle d'une entreprise par une autre, pour la vente d'armes, pour la réalisation d'une opération de construction, etc.) dont la négociation peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais, à côté de ces contrats qui apparaissent vraiment comme le résultat d'un accord de volontés, on a vu apparaître, dès le XIXe siècle, des contrats où une des deux parties prédétermine et impose à l'autre le contenu du contrat (souvent sous la forme de conditions générales prérédigées), l'autre partie n'ayant que la possibilité de dire oui ou non, d'adhérer ou non à ce contenu prédéterminé sans pouvoir discuter le détail des clauses. C'est le cas aujourd'hui de l'immense majorité des contrats passés par les consommateurs (achat d'une voiture ou d'un matériel quelconque, abonnement téléphonique

LARCIER INTERSENTIA
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

ou à l'Internet, location de voiture, contrats de transport, etc.), en particulier lorsqu'ils sont passés par voie informatique. Ces *contrats d'adhésion*, dont le processus de formation semble interroger la notion même de contrat, ont été mis en évidence pour la première fois, à la fin du XIX[e] siècle, par Saleilles, qui semble avoir inventé l'expression[151]. Ils ont fait l'objet, depuis, de nombreuses études doctrinales dans divers pays[152]. Dans l'immense majorité des cas, ces contrats sont la manifestation d'une situation d'inégalité entre les parties (consommateur face à un professionnel, petit fournisseur de produits face à un géant de la distribution, etc.), et appellent souvent une réglementation protectrice de la partie la plus faible. Il s'agit principalement d'éviter que la partie adhérente ne se voie imposer des clauses dont elle n'aurait même pas conscience au moment où elle signe le contrat, ou dont le contenu non négociable la désavantagerait de manière excessive.

Face à ce phénomène, le droit peut adopter plusieurs positions. On peut, d'abord, sans formaliser dans la loi la distinction des contrats d'adhésion et des contrats négociés, laisser aux tribunaux le soin de remédier au cas par cas aux injustices qui peuvent résulter du caractère unilatéral de la détermination du contenu contractuel. Beaucoup de droits nationaux ont pendant longtemps suivi cette voie. On peut aussi choisir de poser dans la loi des règles générales de protection des contractants qui se voient imposer des conditions contractuelles non négociables. Cette voie suppose qu'on définisse de manière précise les catégories de contrats ouvrant droit à une telle protection. De ce point de vue, deux angles d'approche (pouvant du reste se cumuler à l'intérieur d'un même système) peuvent encore être adoptés. Le premier consiste à réserver la protection à certaines catégories de contractants supposés en situation de faiblesse (en particulier les consommateurs dans les contrats qu'ils passent avec les professionnels). Tel est le modèle retenu dans la réglementation européenne des clauses abusives, et qui se retrouve nécessairement dans tous les droits nationaux européens par le jeu de la transposition des directives européennes sur la protection

151 R. Saleilles, *De la déclaration de volonté, contribution à l'étude de l'acte juridique dans le Code civil allemand, (Art. 116 à 144)*, Paris, Pichon, 1901, p. 129.

152 En France, on trouve des développements intéressants sur les contrats d'adhésion chez L. Josserand, « L'essor moderne du concept contractuel », in *Recueil d'études des sources du droit en l'honneur de François Geny*, t. II, *Sources générales des systèmes juridiques actuels*, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1934, pp. 333 et s., spéc. pp. 336-337. *Adde* G. Berlioz, *Le contrat d'adhésion*, Paris, LGDJ, 1973.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

des consommateurs. Mais certains droits nationaux ont adopté un autre modèle, à la place (s'il s'agit de droits de pays non membres de l'Union européenne) ou en plus (s'il s'agit de pays membres). Il s'agit alors de soumettre à une réglementation particulière les contrats ou les clauses de contrats qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle, et ceci indépendamment de la personnalité des contractants (la réglementation légale ayant alors vocation à s'appliquer tant à des contrats entre professionnels qu'à des contrats entre professionnels et consommateurs). C'est ce modèle de réglementation qui a été adopté en Allemagne dans une loi de 1976 sur les conditions générales des contrats « *Allgemeine Geschäftsbedingungen* », passée depuis dans le BGB. Aux termes du § 305 du BGB[153] « Les conditions générales des contrats sont toutes les conditions contractuelles prérédigées pour un grand nombre de contrats, qu'une partie au contrat (l'utilisateur) impose à l'autre partie lors de la conclusion du contrat… On n'est pas en présence de conditions générales si les conditions du contrat sont négociées en particulier entre les parties ».

Le droit luxembourgeois combine les deux modèles. D'une part, par l'effet de la transposition de diverses directives européennes, le Code de la consommation du Luxembourg contient une réglementation spécifique des contrats passés entre consommateurs et professionnels. D'autre part, la loi du 15 mai 1987, où se reconnaît une inspiration allemande, a introduit dans le Code civil, à l'article 1135-1, une réglementation spécifique des « conditions générales d'un contrat préétablies par l'une des parties »[154]. Ce texte a été complété par une loi du 26 mars 1997 qui a défini plus précisément ce qu'il faut entendre par « clause n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle », en se référant expressément à la notion de « contrat d'adhésion ». Cette loi a marqué l'entrée dans le Code civil luxembourgeois de cette notion.

Jusqu'à une période récente, le Code civil luxembourgeois se distinguait sur ce point des codes français et belge, dans lesquels la notion de contrat d'adhésion n'avait pas encore été intégrée. C'est désormais chose faite à la suite des réformes intervenues dans ces deux pays. En Belgique, l'article 5-10 du nouveau Code civil dispose que « Le contrat est un contrat d'adhésion lorsqu'il est rédigé préalablement et unilatéralement par une partie et qu'il n'est pas négociable. Le fait que certaines

153 « *Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt* […] *Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt sind* ».

154 Voy. *infra*, n°s 169 et s.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

clauses du contrat soient négociables n'exclut pas l'application du présent article au reste du contrat lorsque l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion. » En France, la distinction entre contrat d'adhésion et contrat de gré à gré apparaît dans le nouvel article 1110 selon lequel « [l]e contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ». On remarquera que la définition belge du contrat d'adhésion paraît plus extensive que celle du code français (laquelle a été assez profondément modifiée en 2018 lors de la ratification de l'ordonnance de 2016).

84. **Contrats-cadre et contrats d'application**. Il s'agit là encore d'une distinction crée par la doctrine à partir de l'observation des pratiques contractuelles. Certains contrats sont passés entre deux parties qui sont amenés à avoir ultérieurement des relations contractuelles suivies (par exemple un producteur qui est amené à vendre régulièrement ses produits à un de ses distributeurs, une compagnie pétrolière qui livre régulièrement de l'essence et divers produits d'entretien à un exploitant de station-service). Le contrat passé au départ de ces relations – qu'on appellera contrat-cadre, va définir les conditions applicables aux contrats ultérieurs (dits contrats d'application) : la manière dont les commandes seront passées, le mode de détermination du prix des marchandises livrées, les sanctions de la mauvaise exécution des contrats d'application. Les contrats-cadres suscitent un contentieux spécifique, notamment au sujet de la détermination du prix des contrats d'application. La distinction apparaît désormais dans le nouvel article 1111 du Code civil français et dans l'article 5-9 du nouveau Code civil belge.

§2. Classifications fondées sur des critères subjectifs

85. **Contrats civils et contrats administratifs**. Ce ne sont pas seulement des personnes privées qui passent des contrats ; un contrat peut aussi être passé entre des personnes publiques (l'État et l'Université, par exemple), ou, beaucoup plus souvent, entre une personne publique et une personne privée. Même si le contrat n'est pas le mode d'action premier de l'administration – qui agit principalement par voie d'actes juridiques unilatéraux – il est souvent utilisé pour servir de multiples fins de l'action publique. On peut songer, par exemple, aux contrats de bail que l'État passe avec des propriétaires privés pour loger ses différents services, aux contrats qu'une personne publique passe avec un entrepreneur privé pour faire réaliser des travaux sur le domaine public (construction d'un pont, d'une route, etc.), aux contrats de travail que l'Université,

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

établissement public, passe avec ses employés, etc. En droit français, cette intervention d'une personne publique comme partie à un contrat est à la base d'une différenciation marquée entre les contrats de droit privé, relevant du Code civil, et les contrats administratifs. Même si l'administration peut passer des contrats de droit privé, la plupart des contrats qu'elle passe sont soumis à un régime juridique spécifique, élaboré depuis la fin du XIXe siècle par la jurisprudence du Conseil d'État, et qui est caractérisé par une inégalité des prérogatives reconnues aux deux contractants – dont le trait le plus typique est la reconnaissance au profit de l'administration d'un droit de résiliation unilatérale. En Belgique, de même, on distingue les contrats de l'administration (soumis aux règles du Code civil) et les contrats administratifs proprement dits, qui obéissent à un régime spécifique, dérogatoire au droit privé[155]. Il n'en va pas de même au Luxembourg. Sans doute, certains contrats passés par l'administration sont soumis à des règles spéciales – il en va ainsi, notamment, des marchés publics, définis par la loi du 25 juin 2009 comme « des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d'une part, un ou plusieurs opérateurs économiques et, d'autre part, un pouvoir adjudicateur et ayant comme objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation d'un service ». Mais, en dehors de ces réglementations spéciales, il n'existe pas de régime juridique général propre aux contrats administratifs, qui sont soumis, par principe, aux règles du Code civil, et qui relèvent, en cas de litige, de la compétence des juridictions judiciaires[156]. C'est là une particularité notable du droit luxembourgeois.

86. Contrats civils et contrats commerciaux. À l'instar de nombreux systèmes juridiques, le droit luxembourgeois confère un statut spécial à certains acteurs de la vie économique qui ont une activité professionnelle indépendante tournée vers la recherche de bénéfices, ainsi qu'un régime juridique particulier aux contrats qui sont passés à cette fin ou dans le cadre de cette activité. Ces règles spéciales applicables aux commerçants et aux contrats commerciaux sont, pour partie, regroupées dans un code distinct du Code civil, le Code de commerce, mais celui-ci est aujourd'hui largement vidé de sa substance au profit de lois spéciales non codifiées. L'article 1107 du Code civil, qui définit le champ d'application des règles générales du droit des contrats, réserve l'application des « règles particulières

[155] WÉRY, n° 73.
[156] RAVARANI, n° 774.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

aux transactions commerciales […] établies par les lois relatives au commerce ». Ces règles particulières sont cependant assez peu nombreuses. On peut principalement citer : le principe de la liberté de la preuve (C. comm., art. 109), la prescription de dix ans en matière commerciale (au lieu de trente ans en matière civile) (C. comm., art. 189), la présomption de solidarité en matière commerciale. Mais pour l'essentiel, les contrats commerciaux sont soumis aux règles générales du droit des contrats. Par ailleurs, l'un des intérêts principaux de la distinction entre contrats civils et commerciaux en France et en Belgique – la compétence juridictionnelle – n'existe pas au Luxembourg, dans la mesure où le pays n'a pas de juridictions commerciales distinctes des juridictions civiles, mais simplement des chambres spécialisées au sein des tribunaux d'arrondissement et de la Cour d'appel.

87. Contrats entre particuliers, entre professionnels, et entre professionnels et consommateurs. Beaucoup plus importante que la distinction liée à la qualité de commerçant ou de non-commerçant des contractants, est aujourd'hui celle qui tient à leur qualité de professionnel ou de non-professionnel – distinction qui apparaît explicitement à l'article 5-11 du nouveau Code civil belge. De nombreuses règles spécifiques sont en effet posées pour les contrats qui sont passés entre un contractant agissant dans le cadre de son activité professionnelle (qu'elle soit ou non commerciale au sens du Code de commerce), et un contractant qui agit, hors d'une telle activité, pour la satisfaction de ses besoins particuliers, celui qu'on nomme le consommateur. Comme on l'a déjà dit, ces règles particulières ont été édictées principalement dans le but d'assurer une protection particulière à cette seconde catégorie de contractants, considérés, d'une manière générale, comme des contractants inexpérimentés, sans compétence technique particulière, et en état d'infériorité économique vis-à-vis de leurs cocontractants professionnels. Ces règles, qui tendent aujourd'hui à constituer une branche de droit séparée du droit civil, ne sont pas propres au Luxembourg. Non seulement elles se sont développées, depuis une quarantaine d'années, dans de nombreux pays, mais surtout elles constituent un des aspects principaux de la réglementation européenne. Depuis les années 1970, l'Union européenne a édicté un nombre considérable de directives de protection des consommateurs, dont le but est du reste tout autant de favoriser le développement du marché de la consommation à l'intérieur de l'Europe

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

que de protéger des contractants en situation de faiblesse. Sans vouloir être exhaustif, on citera par exemple : la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs[157], la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait[158], la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil[159] (remplaçant des directives antérieures sur les contrats à distance et les contrats hors établissement), etc. Ces différentes directives n'étaient, jusque-là, que des directives d'harmonisation minimale laissant aux états membres la faculté de mettre en place des règles plus protectrices des consommateurs dans leur droit national, mais une des dernières directives publiées, celle du 25 octobre 2011, pose un certain nombre de règles auxquelles les états membres ne peuvent déroger ni dans un sens ni dans l'autre. Les directives européennes ont été transposées au Luxembourg où elles constituent aujourd'hui la base essentielle du droit de la consommation. Les différentes règles, qu'elles soient issues de transpositions ou qu'elles soient spécifiquement nationales, ont été, sur le modèle français, regroupées dans un code spécial, le Code de la consommation, par une loi du 8 avril 2011. L'article L. 010-1 de ce code définit son champ d'application à travers les notions de consommateur et de professionnels : est un consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale », est un professionnel « toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

L'édiction de ces règles spéciales aux contrats de consommation, qui sont profondément dérogatoires aux règles du Code civil sur de nombreux points, permet de mettre à part deux autres catégories de contrats qui n'y sont pas soumis : ce sont d'une part

157 *J.O.C.E.*, L. 095, 21 avril 1993.

158 *J.O.C.E.*, L. 158, 23 juin 1999.

159 *J.O.U.E.*, L. 304/64, 22 novembre 2011.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

les contrats entre professionnels, et d'autre part les contrats entre particuliers n'agissant pas dans le cadre de leur activité professionnelle (la vente d'un immeuble d'habitation, la vente d'une voiture d'occasion, etc.). Ces contrats restent donc soumis au droit commun, civil ou commercial, même si, nous le verrons, ce droit commun est lui-même aujourd'hui influencé par certains des principes du droit de la consommation, notamment en ce qui concerne l'idée de protection des contractants en situation de faiblesse. C'est un des points que nous allons mettre en évidence en étudiant maintenant les fondements du droit des contrats.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les différents types de contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 99-119
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Chapitre IV
Les fondements du droit des contrats

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

88. Le mystère de la force obligatoire. Le contrat, si on y réfléchit, se voit doté, dans l'ordonnancement juridique, d'une force extraordinaire. Si je vous prête de l'argent, en convenant avec vous que vous me rembourserez le 5 novembre 2015, et que, ce jour-là, vous ne me remboursez pas, je pourrai, sur la base de notre contrat, vous assigner en justice, et demander à un tribunal de l'État de vous condamner à me rembourser. Si vous ne déférez pas à cette condamnation, je pourrai, muni du jugement, aller trouver un huissier – officier ministériel nommé par le Grand-Duc – pour qu'il poursuive contre vous la saisie de vos biens. Et, si vous refusez de laisser l'huissier faire son travail, vous pourrez y être contraint par le recours à la force publique, etc. On ne s'en étonne guère, tant l'habitude confère aux choses les plus extraordinaires la force de l'évidence. Pourtant il y a là quelque chose de mystérieux. Pourquoi et comment un simple accord entre deux personnes privées, qui ne sont l'une et l'autre que des sujets de l'État, peut-il être assez puissant pour qu'on puisse, sur son fondement, déclencher tout un processus qui fait intervenir les agents de l'État ? Pourquoi et comment un tel accord peut-il, pour reprendre la formule si frappante de l'article 1134 du Code civil, « tenir lieu de loi » à ceux qui l'ont fait, une « loi » que les tribunaux devront appliquer, que l'huissier et la force publique seront amenés, s'il le faut, à faire exécuter ?

Depuis longtemps, juristes et philosophes du droit cherchent à répondre à ces questions, à donner une explication, à chercher un fondement de cette force obligatoire du contrat, à travers un certain nombre de « théories ». Ces explications, qui se présentent parfois comme scientifiques, ou philosophiques, sont en réalité fortement teintées d'idéologie, elles reflètent des choix politiques, car, selon la théorie qu'on adopte, on est conduit à enfermer la force obligatoire dans des conditions plus ou moins strictes et à lui donner une portée plus ou moins grande. L'évolution des conceptions du contrat au fil des siècles (**Section 1**), va donc de pair avec une évolution des principes généraux autour desquels est construit le droit positif (**Section 2**).

SECTION 1. LES CONCEPTIONS DU CONTRAT

89. La volonté et la loi. Toutes les théories s'articulent autour des rôles respectifs qu'il convient de donner, dans le contrat, aux volontés individuelles des contractants et à la « loi », conçue comme

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'expression de la volonté générale et comme porteuse des intérêts de la société. Le mot « loi », ici ne doit pas être pris dans un sens étroit (les textes édictés par l'organe de l'État ayant le pouvoir législatif), il est synonyme du droit émanant de l'État, voire des organisations supranationales (l'Europe), quelle qu'en soit la forme, légale ou jurisprudentielle. La question est de savoir comment s'articulent ces deux sources dans l'organisation des relations interindividuelles : la volonté des individus n'est-elle qu'un instrument au service de l'organisation sociale voulue par la loi, ou est-elle une source première, que la loi doit en principe respecter, de la régulation des relations entre les hommes ? Dans les pays du Code civil, c'est plutôt la seconde conception, qui, à la suite d'une longue évolution historique, a dominé la construction du droit des contrats. Cette conception s'exprime, d'une manière presque caricaturale, à travers la théorie dite de « l'autonomie de la volonté ». C'est par rapport à cette théorie classique (**§ 1**) que se sont construites, en réaction plus ou moins marquée, toutes les théories modernes du contrat (**§ 2**).

§1. L'autonomie de la volonté

90. Formulation. À la question « Pourquoi le contrat tient-il lieu de loi aux parties ? » on répondait tout simplement, au XIXe siècle : « parce qu'elles l'ont voulu ». C'est cette idée selon laquelle c'est la volonté des contractants, et elle seule, qui fonde la force obligatoire du contrat, qui a été nommée, *a posteriori*, la théorie de l'autonomie de la volonté. Il est rare, à dire vrai, qu'on trouve cette conception exprimée de manière très explicite dans la doctrine du XIXe siècle. C'est surtout à partir du début du XXe siècle que la théorie de l'autonomie de la volonté a été systématisée, par des auteurs qui voulaient la critiquer[160].

On en trouve cependant une expression presque caricaturale sous la plume d'un auteur français du XIXe siècle, Larombière, dans son traité de droit des obligations datant de 1857. Commentant l'article 1134 du Code civil, l'auteur écrit : « L'obligation qui résulte de tout contrat est préexistante à la loi civile. Le législateur l'a trouvée toute créée, et n'a eu qu'à en régler les détails d'exécution et le mode de poursuite. Que l'homme puisse contracter et s'obliger,

[160] Cette présentation critique a été principalement l'œuvre d'E. GOUNOT, *Le principe de l'autonomie de la volonté en droit privé*, Dijon, 1912.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

c'est la plus grande des nécessités sociales, le plus noble attribut de la liberté et de la moralité humaine. Tout contrat reçoit sa première sanction de la conscience, de même qu'il puise toute sa force dans la volonté des contractants. Que l'on ne dise donc pas que les conventions n'ont de force obligatoire que parce que les lois civiles l'ont ordonné, comme s'il leur avait été possible de supprimer en l'homme la liberté et la conscience. C'est une grande erreur, si l'on s'imagine rehausser et ennoblir le principe de nos relations sociales, en y faisant partout apparaître le mécanisme artificiel d'une opération purement humaine. Le caractère mystérieusement divin de leur origine est mieux fait pour commander le respect et l'obéissance. Le contrat sera plus fort quand on aura dit de l'obligation : la conscience le veut, que lorsqu'on aura dit : les hommes l'ont voulu. En s'appuyant ainsi sur la morale, les lois civiles auront doublé de force »[161]. On comprend bien, en lisant ce passage, pourquoi on a parlé d'autonomie de la volonté : Larombière présente la volonté comme un fondement de la force obligatoire indépendant de la loi, comme une source naturelle, voire divine, de l'obligation contractuelle, qui préexiste à la loi (« Le législateur l'a trouvée toute créée ») et qui s'impose à elle.

Cette conception conduit à reconnaître aux contractants une liberté quasi-absolue dans l'organisation de leurs relations : la doctrine du XIXe siècle exalte le principe de la liberté contractuelle. En même temps, le caractère quasi-sacré prêté au respect de la volonté des contractants conduit à une conception très rigide de la force obligatoire du contrat : ce qui a été voulu doit être respecté, un contractant ne doit jamais pouvoir se soustraire à ses engagements.

91. Origine. L'idée que c'est la volonté des contractants, et elle seule, qui fonde la force obligatoire du contrat – qui a dominé la pensée juridique dans les pays du Code civil pendant tout le XIXe siècle – s'est construite très progressivement au cours de l'histoire. Comme on l'a déjà dit, en droit romain, le contrat était conçu comme reposant sur un rite quasi-religieux impliquant l'accomplissement de certains actes ou l'échange de certaines paroles sacramentelles. Par la suite, avec la désolennisation progressive du contrat, s'est développée l'idée que, ce qui était important, c'était ce que les parties avaient voulu, l'engagement qu'elles avaient pris

[161] L. Larombiere, *Théorie et pratique des obligations*, t. 1, 1857, pp. 360 et 361, Commentaire de l'article 1134 du Code civil.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'une envers l'autre. Cette nouvelle conception prend appui sur la morale chrétienne, qui insiste en particulier sur le respect de la parole donnée, formulée dans la maxime « *pacta sunt servanda* », qui, aujourd'hui encore, sert à exprimer le principe de la force obligatoire. C'est dans cette mouvance que s'inscrit la formule déjà citée de Loysel, qui pose le principe du consensualisme « On lie les bœufs par les cornes et les hommes par des paroles »[162]. Le texte de Larombière précédemment reproduit porte bien les traces de cette origine chrétienne d'un principe « mystérieusement divin » fondé sur la « conscience ». Par la suite, la conception du contrat fondé sur la volonté des contractants se renforce, au XVIII[e] siècle, avec la montée en puissance de la philosophie individualiste, articulée autour de la volonté et de la liberté de l'homme maître de ses actions. Le contrat – dont Rousseau fait même, avec la notion de « contrat social », la base de la construction de la société toute entière, le fondement de toute autorité politique – est l'expression de cette liberté. On en trouve, là aussi, des traces dans le texte de Larombière, lorsqu'il présente le contrat comme « la plus grande des nécessités sociales, le plus noble attribut de la liberté et de la moralité humaines ».

92. Justifications. Au-delà des justifications morales et de philosophie politique qui viennent d'être évoquées, la doctrine de l'autonomie de la volonté répond à des considérations beaucoup plus utilitaires. Elle se développe à un moment où, dans le prolongement de la Révolution française, se met en place le système économique libéral. Le contrat en est l'instrument premier : le rôle prééminent reconnu à la volonté dans le contrat a pour conséquence première la reconnaissance d'une liberté quasi-absolue des parties dans l'organisation de leurs relations. C'est cette liberté qui permet de vendre des marchandises, d'employer des ouvriers, de rassembler des capitaux, etc. sans être soumis contraintes imposées par l'État. La célèbre formule « Laissez faire, laissez passer ! », présentée comme une formule-clé du libéralisme, peut se traduire, sur le plan du droit par « Laissez contracter ». Par ailleurs, le caractère absolu de la force obligatoire que postule l'autonomie de la volonté assure la sécurité nécessaire au développement des échanges économiques, qui supposent que chaque acteur puisse compter sur la bonne exécution des marchés passés, ou, à défaut, sur une rigoureuse sanction

[162] A. LOYSEL, *Institutes coutumières*, 1607.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de la défaillance. En raison de ces deux conséquences – la liberté contractuelle quasi-absolue, et une rigoureuse force obligatoire – l'idée d'autonomie de la volonté apparaît comme étant au service du libéralisme économique : ainsi conçu, le contrat permet de faire circuler les biens et les services sans contrainte tout en assurant la sécurité dans les échanges.

93. Critiques. Cette vision exclusivement volontariste du contrat ne tarda pas à être remise en cause. Il fut aisé de faire remarquer, d'abord, qu'elle était difficilement conciliable avec le droit positif : même s'ils étaient imprégnés de la philosophie individualiste du XVIIIe siècle, les rédacteurs du Code civil avaient clairement marqué que, pour eux, le contrat n'était pas une source de droit autonome par rapport à la loi. D'une part, l'article 6 du Code civil, pose qu'on « ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs » – marquant ainsi les limites de la liberté contractuelle. D'autre part, l'article 1134 du Code civil, lui-même, tout en semblant hausser le contrat au niveau de la loi, subordonne cette force obligatoire à la condition que le contrat soit « légalement formé » – ce qui est tout le contraire de l'affirmation d'une volonté autonome. Du reste, il est aisé de comprendre que, dans n'importe quelle société, une telle autonomie serait inconcevable, sauf à aboutir à une totale anarchie. Il ne saurait donc de toute façon être question que d'une autonomie relative, bornée par la loi. Et l'affirmation de l'autonomie de la volonté signifie en réalité – et n'avait sans doute pas d'autre signification dans la pensée des auteurs du XIXe siècle – que, par principe, le législateur doit laisser aux acteurs sociaux le maximum de liberté possible pour organiser leurs relations, dans les limites nécessaires de l'intérêt général strictement conçu.

Même ainsi conçue, cependant, l'autonomie de la volonté a pu être assez vite critiquée dans ses conséquences, en lien avec la remise en cause des conséquences sociales du libéralisme.

Dans l'approche libérale du contrat, celui-ci est supposé parvenir à la meilleure organisation possible de la société, non seulement du point de vue de son développement économique, mais encore au regard des intérêts individuels des contractants. On part de l'idée que chacun est le meilleur juge de ses intérêts. Dès lors, laisser les individus régler librement leurs relations par le contrat, et donner pleine force aux contrats passés est donc le meilleur moyen de

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

satisfaire les intérêts des contractants. C'est le sens qu'on donne habituellement à la formule célèbre d'un économiste français de la fin du XIX[e] siècle, Fouillée « Qui dit contractuel dit juste »[163]. Si, donc, un contrat apparaît comme déséquilibré, on ne peut pas le remettre en cause parce que la partie qui a accepté ce déséquilibre a jugé que c'était conforme à ses intérêts. Ce raisonnement, cependant, n'est concevable que dans une société idéale – et utopique – où les individus sont non seulement égaux en droit, mais aussi en fait. Dans une société où il y a des forts et des faibles, où, selon la célèbre formule de Hobbes, « l'homme est un loup pour l'homme », laisser les contractants régler librement leurs relations aboutit très souvent à permettre l'exploitation par le fort de la faiblesse de l'autre, et il peut apparaître nécessaire, socialement, que la loi limite la toute-puissance des volontés individuelles. Au « Qui dit contractuel dit juste », on peut opposer la formule tout aussi célèbre – et qui est toujours d'actualité – de Lacordaire, homme d'église français du XIX[e] siècle : « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime, c'est la loi qui affranchit »[164].

Les théories modernes du contrat ont toutes, à des degrés divers, intégré ces diverses considérations.

§ 2. Les théories modernes du contrat

94. La volonté subordonnée à la loi. Plus personne ne soutient, au strict sens du terme que la volonté est « autonome » par rapport à la loi. Il serait du reste encore plus difficile de le soutenir qu'à l'époque du Code civil tant se sont multipliées les atteintes que le droit moderne porte à la liberté contractuelle et à la force obligatoire du contrat. Toutes les théories modernes du contrat admettent donc une certaine subordination du contrat à la loi, tant en ce qui concerne ses conditions de validité qu'en ce qui concerne ses effets. Les conventions n'ont force obligatoire, à l'intérieur d'un ordre juridique donné que dans la mesure où la loi (ou plus largement le droit) en dispose ainsi. Il y a cependant plusieurs manières de concevoir cette subordination. Dans la conception normativiste du contrat, telle qu'elle a été développée par Kelsen, le contrat

163 A. FOUILLEE, *La science sociale contemporaine*, 2[e] éd., 1885, p. 410. IL n'est pas sûr que chez cet auteur, la formule ait eu le sens qu'on lui prête habituellement.

164 H.-D. LACORDAIRE, *Conférences de Notre-Dame de Paris*, t. III, Cinquante-deuxième conférence (Du double travail de l'homme, 16 avril 1848).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

apparaît comme un acte créateur de norme, qui se situe au niveau inférieur de la hiérarchie des normes : la loi habilite en quelque sorte les contractants à édicter des normes pour ce qui les concerne, en définissant au départ le domaine, les conditions et la portée de cette habilitation. On peut trouver cette explication artificielle, dans la mesure où le champ d'action ainsi laissé aux individus pour passer des contrats n'est pas délimité au départ, en raison de la possibilité qu'ont les contractants de passer des contrats innommés qui n'entrent dans aucun des cadres préétablis par la loi. On peut plutôt avoir l'impression que les personnes passent de multiples accords, à l'intérieur ou en dehors de ces cadres, sachant que la loi n'accepte de donner force obligatoire qu'à ceux qui répondent aux conditions qu'elle a posées, et dans la mesure qu'elle juge utile. Encore faut-il se demander pourquoi la loi laisse (ou confère) aux personnes privées ce pouvoir exceptionnel de créer du droit par leurs accords de volonté. Faute de pouvoir justifier cela par la seule toute puissance de la volonté, qui s'imposerait à la loi, les auteurs modernes mettent en avant toutes sortes de valeurs sociales que le contrat est censé servir et qui, à la fois, fondent sa force obligatoire et en dictent les limites, plus ou moins importantes : utilité et justice, solidarité, confiance, efficacité, liberté et sécurité, etc. Encore que certaines d'entre elles se présentent comme cherchant à déterminer le « vrai » fondement de la force obligatoire, il faut bien voir que ces différentes théories sont des prises de position idéologiques sur ce que, selon leurs auteurs, le contrat devrait être, sur le rôle plus ou moins important qu'il faudrait reconnaître aux volontés individuelles dans la société, et, corrélativement, au pouvoir de contrôle de la loi et du juge sur ces volontés.

95. Utilité et justice. Une première explication, qui se trouve en filigrane dans l'ouvrage de Gounot[165], et qui a été systématisée en France dans les années 1970 par J. Ghestin, se trouve dans les valeurs d'utilité et de justice que serviraient – ou devraient servir – les accords de volonté privés[166]. Si la loi reconnaît en principe la valeur de tels accords, ce n'est pas parce que le pouvoir de la volonté des individus s'imposerait à elle, mais parce que c'est en général ce qui

165 E. Gounot, *Le principe de l'autonomie de la volonté en droit privé*, Dijon, 1912, spéc. pp. 210 et s., pour qui c'est au nom du « bien commun » que la société sanctionne le contrat.

166 Voy. la plus récente expression de cette théorie in : J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, *Traité de droit civil, La formation du contrat : le contrat, le consentement*, t. 1, 4e éd., Paris, LGDJ, 2013 ; *adde* pour la présentation initiale de cette conception : J. Ghestin, « L'utile et le juste dans les contrats », *D.*, 1982, chron. 1.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

conduit aux résultats les plus justes pour les individus et ce qui produit le plus d'utilité pour l'ensemble de la société. En conséquence, selon l'auteur « le législateur, conformément au droit objectif qui le dépasse, ne devrait sanctionner le contrat que parce qu'il est utile et à condition qu'il soit juste »[167]. S'il apparaît que tel ou tel type de contrat est socialement nuisible (par exemple il porte une atteinte dommageable à la liberté de la concurrence) ou qu'il peut conduire à des résultats injustes (en amenant un contractant faible à consentir des sacrifices sans proportion avec les avantages qu'il reçoit), le législateur peut intervenir pour prohiber ou pour réglementer ces contrats, ou pour apporter des correctifs à leur force obligatoire. Il peut aussi, permettre au juge d'intervenir à la marge pour corriger les injustices et remédier aux déséquilibres. Dans sa version la plus récente, l'auteur insiste cependant sur la place, à côté de ces deux « principes directeurs » d'utilité et de justice, de la liberté contractuelle, qui doit se concilier avec ces valeurs objectives.

Le fait de mettre sur le même plan utilité et justice conduit naturellement à admettre que certains contrats puissent parvenir à des résultats injustes pour une partie prise individuellement, dès lors qu'ils présentent une utilité sociale suffisante pour justifier ces sacrifices. D'autres analyses, plus contemporaines, mais qui restent très minoritaires dans les pays du Code civil, vont mettre davantage l'accent sur la justice sociale que les contrats devraient prioritairement servir, imposant ainsi davantage de limitations à la liberté individuelle[168].

96. Solidarité. Dans les années 1990, s'est développé un courant doctrinal qui a trouvé son inspiration dans les écrits de certains auteurs du début du XXe siècle, et tout particulièrement chez R. Demogue, dont un passage du Traité des obligations est souvent cité : « Les contractants forment une sorte de microcosme. C'est une petite société ou chacun doit travailler dans un but commun qui est la somme des buts individuels poursuivis par chacun, absolument comme dans la société civile ou commerciale. Alors à l'opposition entre le droit du créancier et l'intérêt du débiteur tend à se substituer une certaine union »[169]. L'idée, développée par les auteurs « solidaristes », est que c'est dans ces liens d'union qui doivent régner entre

[167] J. GHESTIN, *Traité de droit civil, La formation du contrat*, 3e éd., 1993, n° 226.

[168] Voy. de différents auteurs : « Manifeste pour une justice sociale en droit européen des contrats », *RTD civ.*, 2005, p. 713.

[169] R. DEMOGUE, *Traité des obligations en général*, t. VI, *Effets des obligations*, Paris, Librairie Arthur Rousseau, 1932, n° 3.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

les contractants qu'on doit chercher le fondement, et les limites, de la force obligatoire du contrat, celui-ci devenant un instrument permettant de développer la solidarité entre les membres de la société[170]. Le contrat implique donc qu'il existe entre les contractants toutes sortes de devoirs (de coopération, de collaboration, de transparence, etc.) qui trouvent place au sein de la notion générale de bonne foi, à laquelle les solidaristes donnent un rôle central en droit des contrats. Il en résulte des pouvoirs importants reconnus au juge pour opérer le contrôle de l'équilibre contractuel, tant au stade de la formation du contrat que, plus encore, au stade de son exécution, dans la manière dont les contractants mettent en œuvre la force obligatoire du contrat.

97. Confiance. Dans une optique très différente – encore qu'elle rejoigne parfois, par ses résultats, l'approche précédente – certains auteurs vont parfois chercher le fondement de la force obligatoire du contrat dans l'idée de confiance que chaque contractant doit avoir dans le comportement de l'autre – ou, selon une autre formulation, dans les attentes légitimes que peut avoir le destinataire de la promesse. Cette approche, qui connaît un certain succès dans les pays du Code civil[171], est importée des pays de *common law*. Il faut rappeler que, en *common law*, le contrat est d'abord conçu comme un échange économique : c'est parce que chaque contractant fournit quelque chose à l'autre qu'il peut compter que l'autre lui fournira quelque chose en échange. Le rôle central que joue dans le droit des contrats en *common law* la *consideration* s'explique ainsi : en principe, celui qui ne fournit rien à l'autre n'a pas de raison d'attendre que l'autre respecte sa promesse. C'est dans ce contexte que s'est construite, dans la doctrine anglaise, la théorie de la *reliance* : ce qui fonde la force obligatoire, c'est que celui à qui une promesse est faite a pu faire confiance à l'autre, légitimement croire que cette promesse serait tenue, et que le droit doit protéger ces attentes légitimes (même d'ailleurs, exceptionnellement, dans

170 Parmi les très nombreux écrits des auteurs appartenant ou ayant appartenu à ce courant : Voy. C. Jamin, « Plaidoyer pour le solidarisme contractuel », in *Études offertes à J. Ghestin, Le contrat au début du XXIe siècle*, Paris, LGDJ, 2001, p. 441. D. Mazeaud, « Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ? », in *L'avenir du droit, Mélanges en hommage à François Terre*, PUF., Dalloz, éd. Juris-classeur, 1999, p. 617.

171 Voy. p. ex. en France : S. Calmes, *Du principe de la protection de la confiance légitime en droits allemand, communautaire et français*, Paris, Dalloz, 2001, préf. D. Truchet ; en Belgique : X. Dieux, *Le respect dû aux anticipations légitimes d'autrui. Essai sur la genèse d'un principe général de droit*, Bruxelles, Bruylant, LGDJ, 1995, préf. M. Hanotiau, av.-pr. P. Van Ommeslaghe.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

des cas où aucune *consideration* n'a été fournie). Cette conception tranche par rapport aux théories habituellement développées dans les pays de droit civil, dans la mesure où elle situe le fondement de la force obligatoire, non du côté de celui qui s'est obligé (et qui, de ce fait, est tenu de respecter sa parole), mais du côté de celui à qui la promesse a été faite, dont il ne faut pas décevoir les attentes. Sur le plan de ses résultats, cependant, elle rejoint certaines analyses plus traditionnelles en ce que l'idée qu'il ne faut pas décevoir les attentes de l'autre peut s'intégrer dans l'exigence générale de bonne foi mise en avant, notamment, par le courant solidariste[172].

98. Efficacité. C'est également des pays de *common law*, mais plus spécialement des États-Unis que viennent les approches qui mettent l'accent sur l'efficacité économique que doit présenter le contrat. Ces approches s'inscrivent principalement dans le cadre de l'analyse économique du droit, et plus spécialement de l'un de ses courants, emmené par R. Posner[173]. Ce courant cherche à apprécier si les règles de droit permettent d'atteindre l'utilité économique recherchée par la société, et qui se définit comme la somme des utilités individuelles des acteurs, considérés comme des agents économiques rationnels. Dans cette optique, le contrat n'est efficace que s'il permet à chaque contractant de retirer de ce qu'il reçoit un avantage supérieur à la perte qu'il subit en contrepartie. Le contrat ne doit être validé par le droit que s'il est efficace, et sa force obligatoire doit également être pensée en fonction de cette efficacité : du point de vue de l'utilité économique, il faut inciter un contractant à rompre le contrat s'il en retire un profit supérieur au profit attendu par l'autre de l'exécution, en ne le condamnant qu'à des dommages et intérêts limités à la perte de ce profit[174]. Ce type d'analyse heurte profondément la plupart des juristes des pays du Code civil, habitués à considérer la force obligatoire sous un angle moral[175]. C'est une des raisons pour lesquelles l'analyse économique du droit – qui ne peut pourtant pas se résumer à ce type d'analyses[176] – a beaucoup de mal à s'y implanter.

---

172 Voy. très typique de cette interpolation : D. MAZEAUD, « La confiance légitime et l'estoppel », *R.I.D.C.*, 2006/2, p. 363.

173 R. POSNER, *Economic Analysis of law*, Wolters Kluwer, 8e éd., 2010.

174 Pour une excellente présentation (critique) de cette théorie, voy. FABRE-MAGNAN, p. 739.

175 Voy. cependant Y.-M. LAITHIER, *Étude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat*, Paris, LGDJ, 2004, préf. H. MUIR-WATT.

176 Pour une présentation des différents courants, voy. T. KIRAT, *Économie du droit*, coll. Repères, Paris, La découverte, 1999.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

99. Liberté et sécurité. Alors même qu'ils se démarquent de la théorie de l'autonomie de la volonté, dans la conception caricaturale qu'on a pu en donner à une certaine époque, un certain nombre d'auteurs restent aujourd'hui fidèles à la vision libérale de la société qui était sous-jacente à cette théorie. Pour ce courant, qui tend même aujourd'hui à se renforcer dans un contexte de mondialisation des échanges, la reconnaissance par le droit de la force obligatoire des accords privés se justifie principalement par l'idée que la meilleure organisation sociale possible est celle qui laisse les individus eux-mêmes décider de leurs intérêts et gérer leurs relations comme ils l'entendent. Le droit des contrats doit donc d'abord reposer sur les valeurs de liberté et de sécurité : liberté, dans la mesure où les échanges économiques doivent pouvoir se développer de la manière la plus fluide possible, sécurité, dans la mesure où les acteurs doivent pouvoir compter fermement sur le respect des accords passés. Sans nier la nécessité de limites fondées sur le nécessaire respect de l'intérêt général ou un minimum de justice sociale ; les auteurs libéraux vont donc se montrer *a priori* réticents face au développement de l'interventionnisme du législateur en matière contractuelle (qui limite la liberté) et, plus encore, au développement des pouvoirs du juge, qui, en affaiblissant la force obligatoire, risque de porter atteinte à la sécurité qu'on peut attendre du contrat. Aussi bien ces auteurs se montreront-ils extrêmement hostiles à tous les courants qui mettent en avant les exigences de justice sociale et de solidarité, au risque, selon eux, de déstabiliser les échanges économiques[177].

100. À la recherche d'un équilibre. Comme on l'a dit d'emblée, aucune de ces théories – dont il n'est possible ici que de donner une présentation sommaire et, partant, caricaturale – n'est apte à donner « le » fondement de la force obligatoire du contrat. Ce ne sont que des prises de position sur ce que le contrat doit être, sur les valeurs que le droit des contrats doit véhiculer. À cet égard, lorsqu'on aborde cette matière fondamentale, on doit surtout être conscient de ce que, en tous temps et en tous lieux, le droit s'efforce d'établir un équilibre entre ces différentes valeurs, le point d'équilibre étant évidemment très différent d'une époque à l'autre et d'un pays à l'autre. D'un côté, aucun système ne peut sacrifier

[177] Voy. p. ex. pour une approche très critique du solidarisme contractuel : Y. Lequette, « Bilan des solidarismes contractuels », in *Études de Droit privé : Mélanges offerts à Paul Didier*, Paris, Economica, 2008, p. 247.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

complètement les valeurs de liberté et de sécurité qui constituent, d'une certaine manière, l'essence du contrat : si le droit laisse aux acteurs sociaux le soin de régler eux-mêmes une partie de leurs relations, c'est parce que l'État ne peut évidemment tout régler d'en haut, décider de quels biens et de quels services chaque personne a besoin, et qui doit les lui fournir, qui doit travailler pour qui et à quelles conditions, etc. Le droit des contrats n'aurait aucun sens s'il ne laissait pas, précisément, un minimum de liberté aux contractants sur tous ces points. Et il n'aurait pas davantage de sens si ce mode de régulation laissait à chaque contractant la faculté de se retirer à tout moment des accords passés ou de les modifier à tout moment, parce qu'il n'y aurait aucun intérêt à passer des contrats si on ne pouvait pas compter raisonnablement sur leur exécution. D'un autre côté, cependant, dans aucun système, la liberté laissée aux individus de régler leurs relations ne peut être totale – et c'est précisément pour cela que la doctrine de l'autonomie de la volonté est insoutenable. Même dans une société hyperlibérale, il y a toujours un minimum de règles d'intérêt général à respecter, pour éviter l'anarchie totale. Mais, entre les deux extrêmes – le maximum de liberté et le maximum de contraintes – on peut arrêter le balancier à de multiples points. La question cruciale est de savoir quelle place on fait, dans le droit des contrats, aux considérations de justice sociale. Il est clair que la liberté contractuelle, si on la pousse à son maximum (en ne la limitant que par le minimum de règles destinées à éviter l'anarchie) conduit à une société profondément injuste, où le faible sera systématiquement exploité par le fort. La célèbre formule de Lacordaire « Entre le fort et le faible […] » est toujours d'actualité, et la même idée a été reprise, aux États-Unis à la fin du XXe siècle par le courant des « *Critical legal studies* » pour lequel la liberté contractuelle est d'abord la liberté d'opprimer les faibles[178]. Veut-on aujourd'hui d'une société où un employeur serait libre de faire travailler un ouvrier 15 heures par jour, sans repos hebdomadaire, en ne le payant que 500 € par mois ? Bien sûr, personne ne veut cela aujourd'hui, même dans un état libéral comme le Luxembourg, mais les auteurs libéraux font observer que, à vouloir trop protéger les faibles, on décourage l'initiative des forts, et cela risque de compromettre le développement économique de la société toute entière, donc de se retourner contre les classes défavorisées qui ne

[178] Voy. not. D. KENNEDY, « Freedom and constraint in adjudication : a critical phenomenology », *Journal of legal education*, vol. 36, 1986.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

profiteront pas de l'enrichissement général. Aussi bien, dès qu'on sort des exemples caricaturaux, la réponse qu'on peut donner à tel ou tel problème concret est nettement moins évidente. Est-il normal qu'un employeur puisse licencier sans motif ses salariés ? Non, mais si on encadre trop le licenciement, les employeurs seront plus hésitants à embaucher. Si un emprunteur, confronté à la maladie et au chômage, ne peut plus rembourser régulièrement les échéances de son prêt, n'est-il pas humain de lui accorder des délais, voire des remises ? Sans doute, mais, dira la banque, que faites-vous de la force obligatoire du contrat ? Si c'est comme cela, à l'avenir, je ne prêterai plus à ceux pour qui il y a un risque, même minime, de défaillance ! Si j'ai dû vendre mon appartement parce que j'avais un besoin pressant de liquidités, et que mon acheteur, connaissant ma situation, m'a fait baisser le prix jusqu'à un montant dérisoire, n'est-il pas normal que je puisse faire annuler cette vente, à laquelle je n'ai pas vraiment consenti ? Cela serait juste, mais où irait-on si tous ceux qui ont vendu à un prix trop bas où acheté trop cher pouvaient remettre en cause leur contrat ? Il est sans doute inutile de multiplier les exemples, ceux-ci suffisent sans doute à convaincre que le droit des contrats, y compris dans ses aspects les plus techniques et les plus abstraits, est une matière éminemment politique. Derrière la réponse que le droit positif apportera à ces différents cas, il y a des choix de société. Nous verrons des choix de ce type tout au long de cet ouvrage, à propos de telle ou telle question très précise. Mais il n'est pas inutile d'essayer, avant d'entrer dans le détail des différentes questions, de découvrir les principes généraux auxquels ces solutions se rattachent.

SECTION 2. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT LUXEMBOURGEOIS DES CONTRATS

101. Un droit libéral-social. Au regard des développements qui précèdent, il nous semble qu'on peut rendre compte de l'état actuel du droit luxembourgeois des contrats en disant qu'il est « libéral-social ». Libéral en ce que il continue de mettre au premier plan de la régulation des relations contractuelles les deux principes fondamentaux de la liberté contractuelle et de la force obligatoire du contrat, piliers d'un ordre juridique libéral. Mais social en ce que la liberté contractuelle telle qu'elle est aujourd'hui conçue n'a plus grand-chose à voir avec celle qui était présentée au XIXe siècle comme la conséquence de « l'autonomie de la volonté », et qu'elle

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

est largement limitée par des préoccupations de justice sociale, notamment par le souci de protéger certaines catégories de contractants en situation de faiblesse. Les mêmes préoccupations, jointes à des considérations d'efficacité économique, aboutissent également à tempérer la force obligatoire du contrat, quitte à diminuer quelque peu la sécurité de cet instrument juridique. Social aussi en ce que liberté contractuelle et force obligatoire doivent aujourd'hui se lire à la lumière d'une notion longtemps marginale, mais aujourd'hui omniprésente, celle de bonne foi.

Ce qu'on peut dire ici du droit luxembourgeois, à ce niveau de généralité, correspond plus ou moins à ce qu'on pourrait dire du droit des trois pays du Code civil. Un des projets de réforme français du droit des contrats, celui présenté par la Chancellerie en 2008, érigeait du reste en « principes directeurs » la liberté contractuelle, la force obligatoire et la bonne foi, et, même si l'expression, ambiguë, de principes directeurs a disparu dans le texte définitif, on y retrouve bien, au titre des dispositions liminaires du droit des contrats, les trois mêmes piliers de la matière (art. 1102, 1003, 1104). Au-delà, on pourrait tenir un discours assez proche dans la plupart des pays d'Europe – sauf à tenir compte du particularisme accusé des droits de *common law*. L'Europe d'aujourd'hui est une Europe à dominante libérale, qui s'est construite sur les postulats d'une économie de marché – on le lui reproche assez et souvent à juste titre – et il est logique qu'on retrouve, dans tous les projets européens d'harmonisation du droit des contrats les grands principes de liberté contractuelle et de force obligatoire. Ces projets, en même temps, valorisent le rôle de la bonne foi, et ils intègrent (plus ou moins) le souci de protéger les contractants en situation de faiblesse, qui est un des points forts du droit européen positif, et qui irrigue en conséquence tous les droits nationaux des états membres. Naturellement, dès qu'on entre dans les détails, on rencontre de substantielles différences entre les droits, et nous verrons, au fil des développements, que le droit luxembourgeois se révèle parfois plus libéral que ses voisins, mais aussi parfois plus social. L'équilibre global n'est pas moins le même, entre une liberté contractuelle limitée (§ 1), une force obligatoire tempérée (**§ 2**) et une bonne foi omniprésente qui vient en contrepoint des deux autres principes (**§ 3**).

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§ 1. La liberté contractuelle

102. Différents aspects de la liberté contractuelle. De prime abord, on peut concevoir sous différents angles la liberté reconnue aux individus de régler eux-mêmes leurs relations par contrat. Au niveau le plus fondamental, c'est d'abord la liberté de contracter ou de ne pas contracter : dans un monde idéal, on ne devrait jamais être obligé de s'engager envers les autres, mais, à l'inverse, on pourrait toujours le faire si on en a envie. C'est, ensuite, la liberté de contracter avec qui on veut : si je veux vendre ma maison, je peux l'offrir au public (si la personne de l'acheteur m'est indifférente), mais je peux aussi choisir de ne la proposer qu'à telle ou telle personne ; si je veux m'associer avec autrui pour monter une entreprise, je suis libre de le faire avec la ou les personnes que j'aurai choisies. Allant plus avant, si je passe un contrat, je suis libre de déterminer, en accord avec mon cocontractant, le contenu de celui-ci : quel prix pour quelle(s) prestation(s), à quel moment, où, comment, avec quelles conséquences si l'un d'entre nous n'exécute pas, etc. Pour ce faire, nous pouvons sans doute nous « caler » sur un des modèles de contrats que propose la loi (une vente, un mandat, un contrat de bail, etc.), mais nous ne serons pas tenus de suivre toutes les règles que la loi pose pour ces contrats : ces règles sont, normalement, supplétives. Et nous pouvons même choisir de conclure un contrat innommé, qui ne correspond à aucun des cadres prévus par la loi, etc. Enfin, la liberté contractuelle, c'est, ou ce devrait être, la liberté de passer le contrat comme on le veut, en choisissant les formes qui nous semblent les plus adaptées : par écrit, oralement, par signes, etc. Ce qui compte, ou devrait compter, dans cette conception idéale, c'est ce que nous voulons, peu important la manière dont nous l'exprimons. Tel est le sens du principe déjà évoqué du consensualisme.

103. La liberté contractuelle, du Code civil à aujourd'hui. Il est remarquable qu'aucun texte du Code civil de 1804 n'affirme expressément le principe de la liberté contractuelle. Le principe n'y apparaît qu'en creux, à travers les silences du Code relativement à certaines exigences, où à travers les exceptions qui lui sont apportées. C'est ainsi qu'on peut lire l'affirmation de la liberté de contracter dans l'article 1123 du Code civil, selon lequel « Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi », la liberté de ne pas contracter n'apparaissant quant à elle

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

qu'à travers la nécessité du « consentement de celui qui s'oblige » posée par l'article 1108 du Code civil comme une des conditions de validité du contrat, et on peut considérer que cette exigence postule, implicitement, la liberté de choisir la ou les personnes envers qui on s'oblige. Ce même article ne pose aucune condition de forme pour l'expression du consentement au contrat, et c'est par là qu'on voit que les rédacteurs du Code ont voulu consacrer le principe du consensualisme, acquis dans l'Ancien droit français depuis Loysel. La liberté de déterminer le contenu du contrat, enfin, peut être déduite d'une lecture *a contrario* de l'article 6 du Code civil. Si celui-ci prévoit qu'« [o]n ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs », c'est, dit-on, qu'on peut déroger à toutes les autres. Il suffit par ailleurs de feuilleter les pages du Code consacrées aux différents contrats pour découvrir de très nombreux textes posant des règles en précisant que celles-ci ne s'appliquent que « s'il n'y a eu stipulation contraire » ou « s'il n'en a été autrement convenu ».

Dans les nouveaux droits français et belges, le principe de liberté contractuelle est désormais explicitement posé, par des textes qui en détaillent les divers aspects. L'article 1102 du Code civil français dispose ainsi que « [c]hacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ». De même, l'article 5.14 du nouveau Code civil belge déclare que « [h]ors les cas prévus par la loi, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter et de choisir son cocontractant, sans avoir à justifier les raisons de son choix » et que « [l]es parties sont libres de donner le contenu de leur choix au contrat, pourvu qu'il satisfasse aux conditions de validité prévues par la loi ». Cependant, comme on le remarque déjà à la lecture de ces textes, ces articles indiquent en même temps que cette liberté n'est pas absolue, qu'elle peut être limitée par la loi. C'est un lieu commun que de dire que, depuis l'époque du Code civil, ces limites se sont multipliées, à tel point que, dans certains domaines, cette liberté peut apparaître résiduelle. Mais, quelle que soit l'importance de cet encadrement légal (**A**), la liberté contractuelle n'en reste pas moins un principe de base du droit des contrats (**B**).

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

A) *Une liberté très encadrée*

104. Liberté de contracter ou de ne pas contracter. Il faut d'emblée souligner que ce premier aspect de la liberté contractuelle est, en fait, totalement théorique. Il est théorique d'affirmer qu'on est toujours libre de ne pas contracter alors que, dans une société où (heureusement !) l'État ne pourvoit pas autoritairement aux besoins de tous ses sujets en leur imposant tout aussi autoritairement leurs activités, on doit constamment passer des contrats pour assurer sa subsistance : pour travailler, pour se loger, pour se nourrir, etc. Et il est tout aussi théorique d'affirmer qu'on est toujours libre de contracter, alors que, même dans un pays qui n'est certes pas le plus pauvre d'Europe, une partie non négligeable de la population ne dispose que de revenus lui permettant de se loger et de se nourrir, sans avoir jamais l'occasion, en fait, de passer les multiples contrats lui permettant de s'acheter un appartement, de voyager au soleil, ou d'aller au spectacle, etc. La liberté de contracter ou de ne pas contracter ne s'exerce donc qu'à l'intérieur de ces très importantes limites de fait. Mais, même dans ce cadre étroit, elle est loin d'être absolue en droit, et elle ne l'a jamais été.

Le Code civil posait déjà des limites à la liberté de contracter : l'article 1123 du Code civil déjà cité, qui en excepte les personnes « déclarées incapables par la loi » en est la preuve directe. Nous verrons cependant que cette interdiction de contracter faite à certaines personnes – les incapables – n'a pas toujours la même portée : dans la plupart des cas, où il s'agit de protéger la personne frappée d'incapacité, l'interdiction consiste seulement à empêcher la personne elle-même de passer le contrat, qui pourra être passé en son nom et à sa place par un représentant légal ; ce n'est que dans des cas exceptionnels que la loi interdit de manière absolue à une personne de passer un contrat, même par l'intermédiaire d'autrui[179]. Ce n'est que dans ces cas que l'incapacité constitue une véritable atteinte à la liberté contractuelle. Et les atteintes de ce type, qui sont en même temps des restrictions à la personnalité juridique, ont plutôt eu tendance à régresser depuis l'époque du Code, avec la suppression d'institutions qui fermaient par principe à certaines personnes l'accès à la vie juridique (esclavage, mort civile).

[179] Voy. *infra*, n°s 284 et s. la distinction entre incapacités d'exercice et incapacités de jouissance.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Il n'en va pas de même des atteintes à la liberté de ne pas contracter, qui n'existaient pas dans le Code, et qui sont apparues à l'époque moderne, notamment en matière d'assurance. La loi impose à diverses personnes d'assurer leur responsabilité, en raison des dommages qu'elles peuvent causer à leurs clients (notaires, avocats), à leurs cocontractants (locataires), ou aux tiers avec qui elles peuvent accidentellement entrer en contact (assurance obligatoire imposée aux automobilistes[180]). Il faut cependant relativiser la portée de ces obligations. En aucun cas, elles n'aboutissent à ce que le contrat puisse être passé sans le consentement de la personne – sinon ce ne serait plus un contrat – mais, si le contrat obligatoire n'est pas passé, la personne obligée encourra des sanctions (sanction pénale dans le cas du défaut d'assurance automobile, résiliation du bail si le locataire n'assure pas son logement, etc.).

105. Liberté de choisir son cocontractant. Cette liberté, qui semblait évidente à l'époque du Code civil, connaît aujourd'hui plusieurs limites, justifiées par des considérations très diverses. L'atteinte à la liberté peut être plus ou moins importante selon que la loi interdit, négativement, à un contractant de sélectionner ses cocontractants, ou qu'elle lui impose, positivement, de passer le contrat avec telle personne plutôt qu'avec telle autre.

D'une manière générale, lorsqu'on offre un contrat au public, on est libre de se réserver la possibilité de sélectionner la personne avec qui, finalement, on passera le contrat. Cette liberté se trouve cependant limitée aujourd'hui, d'une manière générale, par l'interdiction des discriminations : si je veux louer l'appartement dont je suis propriétaire, je peux sans doute refuser un locataire potentiel parce qu'il n'est pas solvable, mais je ne peux certainement pas refuser la location à quelqu'un en raison de sa religion, de sa couleur de peau ou de son orientation sexuelle. Pour de tout autres raisons, liées à la liberté de la concurrence, la loi interdit aux personnes qui produisent ou vendent des marchandises ou qui offrent des prestations de service au public de sélectionner leur clientèle en refusant de satisfaire à la demande de certains acheteurs ou demandeurs de services (RGD 9 décembre 1965, art. 4) : il s'agit ici d'éviter qu'un producteur ou un vendeur ne tourne l'interdiction de fixer des prix imposés à ses distributeurs, en ne vendant ou en

[180] L. du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ne prêtant ses services qu'à ceux qui accepteraient de revendre à leurs propres clients aux prix fixés. Avec ces exemples, on a déjà idée de la diversité des motifs qui peuvent amener la loi à limiter la liberté contractuelle.

On franchit un pas supplémentaire dans cette limitation, lorsque la loi impose, positivement cette fois, d'offrir par priorité un contrat à certaines personnes qui bénéficient d'un droit de le conclure par préférence à toute autre. Lorsqu'il s'applique à un contrat de vente, ce droit est appelé « droit de préemption » (étymologiquement, droit d'acheter avant). Par exemple, selon l'article 15 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail d'habitation, « le locataire dont le bail court depuis au moins dix-huit ans bénéficie d'un droit de préemption sur le logement loué, à moins que celui-ci ne fasse l'objet d'une vente par adjudication publique ou qu'il ne soit cédé à un membre de la famille du bailleur parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement ou qu'il ne fasse l'objet d'une cession gratuite », l'indivisaire d'un bien en copropriété bénéficie du même droit en cas de vente de sa part par un autre co-indivisaire (C. civ., art. 815-14), etc. Ces droits de préemption, qui sont beaucoup plus nombreux en droit français, constituent incontestablement une atteinte importante au droit de choisir son cocontractant.

106. Liberté de choisir la forme du contrat. On surprend toujours les non-juristes lorsqu'on leur dit qu'un contrat peut être valablement passé sans le respect d'aucune forme, tant ce principe du consensualisme – aujourd'hui posé expressément par l'article 1172 du code français et par l'article 5.28 du code belge – est aujourd'hui largement vidé de sa substance. D'une part, en fait, plus personne n'accepterait aujourd'hui de passer un contrat important sans rédiger un écrit, qui pourra tout à la fois servir de preuve et permettre de détailler par toute une série de clauses les droits et obligations des parties. La pratique des contrats d'adhésion, qui reposent sur des conditions générales préétablies par une partie, contribue à ce développement de la « paperasserie contractuelle ». D'autre part, en droit, le principe du consensualisme connaît aujourd'hui de très nombreuses exceptions. On passera ici sur les limites indirectes que la loi apporte au principe, en exigeant le respect de certaines formes, soit pour faire la preuve du contrat, soit pour assurer son opposabilité aux tiers[181] : si elles sont très importantes en pratique,

[181] Voy. *infra*, n°s 417 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ces règles ne remettent pas en cause le principe, puisque le contrat passé sans les formes requises n'en est pas moins valable entre les parties (cf. C. civ. fr., art. 1173, C. civ. be., art. 5.29, al. 4). Mais dans de multiples cas, la loi exige le respect de certaines formes pour la validité même du contrat. Le Code civil connaissait déjà un tel formalisme, consistant soit dans la remise d'une chose (contrats réels comme le prêt ou le gage), soit dans la rédaction d'un écrit, généralement authentique (constitution d'hypothèque). Si la forme réelle est aujourd'hui très marginale, l'exigence d'un écrit, le plus souvent assorti de diverses mentions obligatoires, est devenu monnaie courante. L'une des raisons du développement de ce formalisme tient dans le souci du législateur contemporain de protéger certaines catégories de contractants considérés comme étant en situation de faiblesse, en attirant leur attention sur l'importance de l'engagement, et en les informant le plus complètement sur son contenu. C'est pourquoi le droit de la consommation est aujourd'hui le plus grand réservoir d'exigences formelles, tant dans la législation nationale que dans les textes européens, positifs ou prospectifs. Ce souci de protection des contractants faibles, qui est un des aspects dominants du droit des contrats contemporains, se retrouve du reste au niveau du fond du droit, en ce qu'il vient, aussi, limiter la liberté de déterminer le contenu du contrat.

107. Liberté de déterminer le contenu du contrat. Comme on l'a dit précédemment, le Code civil n'affirme la liberté de déterminer le contenu du contrat que de manière implicite, à travers les limites qu'il lui pose : l'interdiction de déroger aux « lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs », marquant la suprématie de l'intérêt général sur les intérêts individuels. Cette règle a été conservée à la même place dans le Code civil français après la réforme, mais elle a été doublée par l'article 1102, alinéa 2 selon lequel « [l]a liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public ». Dans le nouveau code belge, l'article 6 a été repris, sous une forme sensiblement différente à l'article 1.3, qui dispose qu'« [o]n ne peut déroger à l'ordre public ni aux règles impératives[182] ». À l'époque du Code, ces limites étaient peu nombreuses : l'ordre public et les bonnes mœurs ne recouvraient qu'un petit noyau de règles visant à assurer le maintien de la paix et de la sécurité publiques, de l'organisation de l'État, et des structures

[182] Sur la différence faite en droit belge entre ordre public et règles impératives voy. *infra*, n° 389.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

fondamentales de la société civile (notamment de ses structures familiales, dont la notion de bonnes mœurs visait tout spécialement à assurer la pérennité). Or depuis le début du XIXe siècle, la notion d'ordre public (dont les bonnes mœurs ne sont qu'un aspect particulier) a connu des mutations considérables, qui se traduisent par des limitations de plus en plus importantes de la liberté contractuelle. On peut observer, d'abord, un gonflement considérable des règles qui composent l'ordre public : il n'est plus guère de domaine où, aujourd'hui, les parties puissent fixer librement leurs droits et leurs obligations, parce que s'imposent toujours à elles de multiples contraintes relatives à l'urbanisme, à l'environnement, à la concurrence, à la protection des consommateurs, à la santé publique, etc. Cette augmentation quantitative est allée de pair, ensuite, avec une remarquable diversification qualitative de la notion d'ordre public. D'une part, à l'époque du Code, la liberté des contractants ne trouvait de limite que dans le respect des principes fondamentaux de l'ordre social, le législateur n'intervenant pas directement dans les relations économiques. Mais, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, le développement de l'interventionnisme de l'État a entraîné l'apparition de ce qu'on a appelé un « ordre public économique » distinct, par ses finalités et ses modes d'action, de l'ordre public dit « politique » du Code civil. D'autre part, à l'intérieur de cet ordre public économique sont apparues des règles visant, non pas directement à assurer le respect de l'intérêt général (intérêt commun), mais à protéger certaines catégories de contractants en situation de faiblesse, et considérés comme inaptes à défendre eux-mêmes leurs intérêts dans les relations contractuelles (les salariés, les locataires, plus récemment les consommateurs, etc.). Cet ordre public dit « de protection » dans la doctrine française marque une rupture considérable avec l'esprit du Code civil, qui raisonnait sur un type de contractant abstrait, et non situé socialement. Enfin, il faut observer que la diversification de l'ordre public touche également ses sources. À l'époque du Code, c'était principalement du législateur que venaient les limitations à la liberté contractuelle, comme le laisse entendre la formulation même de l'article 6 du Code civil. L'évolution intervenue depuis se traduit par une montée en puissance du rôle du juge, qui peut, dans certains cas, annuler, au nom de l'ordre public, un contrat ou une clause contractuelle alors même qu'aucune loi ne les prohibe expressément : la réglementation des clauses abusives dans les contrats de consommation en est un exemple caractéristique. À cela s'ajoute l'importance

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

prise aujourd'hui, pour la détermination de ce qu'est l'ordre public comme pour tous les autres aspects du droit des contrats, par les sources supranationales : le droit de l'Union européenne (pour tout ce qui touche, notamment, à la protection des consommateurs), et le droit européen des droits de l'homme (composante essentielle de l'ordre public moderne) sont aujourd'hui au tout premier rang des « lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs » de l'article 6 du Code civil.

On a parfois parlé, à propos de cette évolution, de « déclin de l'autonomie de la volonté », ce qui est une expression contestable. Le Code civil n'a jamais consacré, on l'a dit, cette prétendue « autonomie de la volonté », qui n'est qu'une conception doctrinale des rapports du contrat et de la loi, et non un principe général qui aurait, à un moment donné, dominé le droit positif. Ce qui a décliné, sans doute, c'est la liberté contractuelle (un des principes qu'on prétendait expliquer par l'idée d'autonomie de la volonté), et, tout ce qu'on peut dire, c'est que ce déclin démontre, plus encore qu'à l'époque du Code, que la volonté n'est pas autonome par rapport à la loi.

B) *Un principe maintenu*

108. Réaffirmations du principe. Il est remarquable qu'à une époque où, comme on vient de le voir, les atteintes à la liberté contractuelle se sont multipliées, cette liberté soit réaffirmée comme un principe dans tous les textes modernes de droit des contrats, tant dans les législations nationales[183] qu'au niveau international et européen. Pour les PDEC : « les parties sont libres de conclure un contrat et d'en déterminer le contenu, sous réserve des exigences de la bonne foi et des règles impératives posées par les présents Principes ». L'article 1-1 des Principes Unidroit dispose que « les parties sont libres de conclure un contrat et d'en fixer le contenu », formule qu'on retrouve dans le Code Gandolfi, tandis que le DCFR proclame, dans son article 1:102 que « *Parties are free to make a contract or other juridical act and to determine its contents, subject to the rules on good faith and fair dealing and any other applicable mandatory rules* ». L'exposé des motifs de ces principes affirme haut et fort que la liberté contractuelle est le « *starting point* » du droit des contrats : « *As a rule, natural and legal persons should be free*

[183] Voy., p. ex., l'article 1255 du Codigo civil espagnol, l'article 1322 du Codice civile italien (*Autonomia contrattuale*).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

to decide whether or not to contract and with whom to contract. They should also be free to agree on the terms of their contract… If, for instance, the parties to a contract are fully informed and in an equal bargaining position when concluding it, the content of their agreement can be presumed to be in their interest and to be just as between themselves. "Qui dit contractuel, dit juste" »[184]. Et, on l'a dit, la réforme française comme la réforme belge ont intégré dans le Code civil l'affirmation explicite de la liberté contractuelle.

109. Vigueur du principe. Ces réaffirmations du principe ne sont pas purement théoriques. Contrairement à ce qu'une présentation sommaire – et donc caricaturale – des nombreuses exceptions qui lui sont apportées pourrait laisser croire, le déclin de la liberté contractuelle n'est ni général, ni constant. D'une part, le gonflement de l'ordre public affecte surtout les contrats ayant un objet économique, alors que, d'un autre côté, l'ordre public, sous l'angle particulier des bonnes mœurs, est plutôt en recul dans les matières familiales et personnelles, où la libéralisation des mœurs rend possible de nombreux accords naguère prohibés – la limite dans ce domaine devant plutôt être cherchée du côté de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Même dans le domaine des relations économiques, la liberté contractuelle, si elle est aujourd'hui très limitée dans les contrats de consommation, règle encore très largement dans les contrats entre entreprises, spécialement dans les contrats internationaux où les parties peuvent choisir la loi la plus favorable à l'organisation la plus souple de leurs relations. Plus que jamais, dans un contexte de mondialisation des échanges, la liberté contractuelle a de beaux jours devant elle. D'autre part, même dans les relations juridiques purement internes, on aurait tort de dépeindre l'évolution comme un mouvement constant vers toujours plus d'ordre public, et toujours moins de liberté. Selon les périodes, les vicissitudes de l'économie, les options politiques des dirigeants, on note, soit un renforcement de l'encadrement législatif, soit, à l'inverse, une tendance à une « flexibilité » plus grande des rapports sociaux (notamment en droit du travail). Chacun sait bien que c'est plutôt dans cette seconde direction que va aujourd'hui le balancier.

110. Fondamentalisation du principe. Jusqu'à une période récente, on considérait qu'il appartenait à chaque législateur national de déterminer l'étendue de la liberté qu'il entendait reconnaître

[184] DCFR, Principles, n° 3.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

aux personnes passant des contrats relevant de sa compétence – ou, si on préfère, l'étendue des limites qu'il souhaitait lui apporter par l'édiction de règles d'ordre public. Il apparaît aujourd'hui que les états eux-mêmes peuvent se trouver contraints dans l'édiction de ces limites, la liberté contractuelle se voyant désormais reconnaître, dans certains de ses aspects, une valeur supralégislative. Même si cette jurisprudence n'a pas eu pour l'instant d'équivalent au Luxembourg, il n'est pas sans intérêt de noter que le Conseil constitutionnel français a, dans plusieurs décisions, reconnu la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle sur le fondement de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen[185]. Selon cette jurisprudence, il n'est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle, que « des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ». Par ailleurs, au Luxembourg comme dans les autres pays européens, certaines limitations de la liberté contractuelle peuvent être condamnées par la CJUE si elles vont à l'encontre de la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux à l'intérieur de l'Union européenne[186]. Et certains auteurs se demandent si la Cour eur. D.H. n'est pas en passe de consacrer la liberté contractuelle comme une liberté fondamentale, dont elle pourrait imposer le respect aux états[187] Bien entendu, cette élévation de la liberté contractuelle au rang d'un principe supralégislatif, qui s'imposerait aux états eux-mêmes n'interdit pas au législateur national d'édicter des règles d'ordre public limitant cette liberté, mais il n'est plus désormais entièrement libre de le faire.

§ 2. La force obligatoire

111. Principe de la force obligatoire. Il ne suffit pas, pour assurer la place du contrat dans un système juridique, d'affirmer la liberté de contracter ou de ne pas contracter, et d'assurer aux personnes qui passent un contrat un minimum de liberté dans la détermination

185 Jurisprudence constante depuis C. const., 19 décembre 2000, n° 2000-437DC. Voy. encore récemment C. const., 28 décembre 2020, n° 2020-813, Loi de finances pour 2021.

186 Voy. p. ex. C.J.C.E., 28 avril 2009, aff. C-518/06, *Commission c/ Italie*, à propos d'une atteinte à la liberté des assureurs italiens de ne pas contracter.

187 J.-P. MARGUENAUD, « Un petit pas de plus vers l'assimilation européenne de la liberté contractuelle à une liberté fondamentale », *Rev. contr.*, 2009, p. 1211. Sur l'ensemble de la question voy. C. JAMIN, « Le droit des contrats saisi par les droits fondamentaux », in *Repenser le contrat*, Paris, Dalloz, 2009.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de son contenu. Il faut encore que les contrats passés en conformité avec la loi se voient dotés d'une certaine force obligatoire. Dans une première approche, qui sera ultérieurement précisée, cela signifie que les parties sont liées par le contrat, qu'une personne qui s'est engagée par contrat ne doit pas pouvoir se dégager unilatéralement, et que, si elle n'exécute pas les obligations que le contrat met à sa charge, elle doit encourir un certain nombre de sanctions. Il ne servirait à rien de permettre aux individus de passer des contrats s'ils pouvaient, ensuite, s'en dégager à leur guise, faire comme si le contrat n'avait pas été passé. Le contrat est donc nécessairement, en même temps que l'exercice d'une liberté, une aliénation (limitée et temporaire) de celle-ci. La sécurité des relations sociales, la prévisibilité des actions des individus, ne peuvent être assurée qu'à ce prix.

La force obligatoire apparaît donc, dans tous les systèmes juridiques, comme un principe de base du droit des contrats. Mais c'est sans doute dans le Code civil que ce principe est affirmé de la manière la plus frappante, dans un article célèbre hérité de Domat, l'article 1134 du Code civil, qui constitue sans doute le texte le plus fondamental de toute la matière : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Ce texte a été repris, avec de légères modifications formelles, par l'article 1103 du Code civil français et par l'article 5.69 du nouveau Code civil belge. La formule utilisée, qui assimile le contrat à la loi, explique qu'en Belgique, plutôt que de parler de la force obligatoire, on parle du principe de la « convention-loi ».

112. Relativisation de la force obligatoire. Pendant longtemps, dans les pays du Code civil, la force obligatoire a été conçue comme un dogme, un principe absolu auquel il était impossible de porter atteinte, hors de quelques exceptions posées par la loi elle-même, et dont on s'efforçait de réduire la portée. Cette conception rigide, que la formule même de l'article 1134 du Code civil semblait encourager, était directement liée à la toute-puissance qu'on prétendait reconnaître aux volontés individuelles : dès lors que les contractants s'étaient volontairement engagés, rien ne pouvait les délier. On peut trouver un symbole de cette conception dans un arrêt célèbre de la Cour de cassation française de 1876, l'arrêt dit du Canal de Craponne[188]. Dans cette affaire, la Cour de cassation a censuré la

[188] Cass. fr. (civ.), 6 mars 1876, GAJC, 12e éd., n° 165. Pour une étude approfondie de cet arrêt, voy. *infra*, n° 512.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

décision d'une Cour d'appel qui s'était permis, en cette seconde moitié du XIXe siècle, d'augmenter le montant d'une redevance pour l'utilisation des eaux d'un canal d'irrigation qui avait été fixée dans un contrat passé au XVIe siècle, et qui, avec le temps, était devenue insuffisante pour permettre au propriétaire l'entretien du canal. Pour la Cour « dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse apparaître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ». Encore que cette solution jurisprudentielle ait été suivie en Belgique et au Luxembourg, la motivation de l'arrêt nous apparaît, aujourd'hui, bien caricaturale. L'idée que rien ne puisse aller contre la volonté des parties, même exprimée plusieurs siècles plus tôt, est aujourd'hui bien dépassée. Si le principe de la force obligatoire est nécessaire pour assurer la sécurité des relations juridiques, on le met aujourd'hui en balance avec d'autres intérêts, principalement celui d'assurer une certaine justice dans les relations contractuelles, de venir au secours de la partie faible, mais aussi celui de l'efficacité économique du contrat qu'une force obligatoire conçue de façon trop rigide contribue parfois à desservir. Aussi bien, dans le droit des contrats modernes, la force obligatoire est-elle assortie d'un certain nombre de limites.

113. Limites à la force obligatoire. Il serait vain, ici, de dresser un catalogue de toutes les limites qui sont apportées aujourd'hui à la force obligatoire, et que nous retrouverons par la suite. Nous verrons ainsi que le droit reconnaît parfois le droit à certains contractants de se retirer unilatéralement, et sans motif, d'un contrat régulièrement passé : les droits de rétractation reconnus aux consommateurs dans divers contrats en sont l'exemple le plus caractéristique. Nous verrons aussi que, dans diverses hypothèses, la loi permet au juge d'apporter des modifications à un contrat valablement conclu, soit pour remédier à un déséquilibre (révision des clauses pénales excessives), soit, plus souvent, pour venir en aide à un débiteur en difficulté à qui seront accordés des délais de paiement, voire des remises partielles de dettes (sursis de paiement aux commerçants en difficulté, traitement judiciaire du surendettement). Sans, pour l'instant, entrer dans les détails, on se limitera ici à deux remarques générales. D'une part, ces limites sont beaucoup moins nombreuses que celles, résultant de règles d'ordre public, qui sont apportées à la liberté contractuelle. On peut le comprendre si on considère que

LARCIER INTERSENTIA
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

les atteintes à la force obligatoire, intervenant en cours d'exécution du contrat, et affectant des contrats par hypothèse valablement passés, sont beaucoup plus nuisibles à la sécurité juridique que les limitations *a priori* de la liberté contractuelle, qui, connues au départ, permettent, en théorie du moins, aux contractants potentiels de savoir ce qui leur est permis et ce qui leur est interdit. D'autre part, et pour la même raison, ces limites à la force obligatoire sont beaucoup plus strictement encadrées par la loi que celles apportées à la liberté contractuelle. Il est très exceptionnel, dans les pays du Code civil, que les juges se reconnaissent eux-mêmes, en l'absence d'une autorisation législative qui fixerait les limites de leur intervention, à modifier le contenu d'un contrat. Là encore, la sécurité juridique que doit procurer le contrat est plus gravement atteinte par une intervention judiciaire non encadrée que par une disposition législative. Cela peut expliquer que, jusqu'à une période récente, en dépit des critiques qu'elle suscitait, la jurisprudence « Canal de Craponne » n'avait pas été officiellement abandonnée dans les pays du Code civil. Elle vient cependant de l'être, en France et en Belgique, où les réformes ont introduit dans le Code civil un article consacrant la possibilité pour le juge d'adapter un contrat gravement déséquilibré par suite d'un changement de circonstances (C. civ. fr., art. 1195, C. civ. be., art. 5.74). En France, cependant, tout comme la liberté contractuelle dont elle est regardée comme un aspect, la force obligatoire s'est vu reconnaître une valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, de sorte que le législateur n'est pas complètement libre pour y porter atteinte. Selon une jurisprudence constante : « Le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789. »[189]

§ 3. La bonne foi

114. Une exigence centrale du droit des contrats moderne. Venant après l'affirmation de la force obligatoire du contrat, l'article 1134, alinéa 3 du Code civil pose que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». Cette notion de bonne foi en matière contractuelle remonte au droit romain, où elle avait permis,

[189] Voy. en dernier lieu : Cons. const., 26 octobre 2023, n° 2023-1065 QPC, Association France énergie éolienne et autres.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

progressivement, de reconnaître une action au profit d'un contractant alors même que les formes archaïques du contrat n'avaient pas été respectées. Les contrats de bonne foi s'opposaient alors aux contrats dits aujourd'hui « de droit strict » toujours soumis au formalisme traditionnel. Cette opposition n'a plus cours aujourd'hui, dès lors que la formation des contrats est en principe consensuelle, et on peut donc considérer que tous les contrats sont « de bonne foi ». Mais, dans les droits modernes, la notion a pris une autre signification, en ce qu'elle impose à chaque contractant, dans tous les contrats, de se comporter de manière loyale, correcte vis-à-vis de son ou de ses partenaires, conformément à la confiance qu'on a pu susciter chez lui au moment de la conclusion du contrat. Ainsi conçue, l'exigence de bonne foi va venir, en contrepoint des deux autres principes fondamentaux, atténuer certains excès de la liberté contractuelle, et tempérer la rigueur de la force obligatoire pour les parties, en les contraignant à dépasser ce que prescrit strictement le contrat. Elle apparaît ainsi comme un des instruments permettant d'assurer une certaine justice contractuelle.

115. Une exigence largement reconnue en Europe. Si on met pour l'instant à part l'article 1134, alinéa 3 du Code civil, cette notion trouve, dans les droits européens modernes, sa première expression dans le § 242 du BGB, qui commande au débiteur contractuel d'exécuter sa prestation comme le commandent « la confiance et la croyance » (*Treu und Glauben*) en considération des usages[190]. On retrouve aujourd'hui cette exigence dans de très nombreux codes nationaux européens[191], et elle est passée, sous des formulations et à des places variables, dans tous les projets européens. Par exemple, l'article 1 :201 des PDEC (reprenant sur ce point l'article 1.7 des Principes Unidroit) pose, au titre des devoirs généraux des contractants, que « chaque partie est tenue d'agir conformément aux exigences de la bonne foi ». L'article 2 du DCEV proclame quant à lui que « Il incombe à chaque partie d'agir conformément au principe de bonne foi et de loyauté ». Dans le DCFR, l'exigence de « *good faith and fair dealing* » est définie d'une manière générale par l'article 1:103 du Livre I comme « *a standard of conduct*

[190] « *Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern* ».

[191] Voy., p. ex. : Italie Codice civile, art. 1337, 1375 (buena fede) et 1175 (corretezza) ; Pays-Bas BWB, art. 6:2 and 6:248 (redelijkheid en billijkheid) ; Espagne Codigo civil, art. 7 et 1258 (buena fe).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

characterised by honesty, openness and consideration for the interests of the other party to the transaction or relationship in question », et la suite du texte en contient de nombreuses applications. De même la notion de bonne foi apparaît dans 44 dispositions du Code Gandolfi ! Cependant, au sein de ce concert général (moins harmonieux peut-être qu'une première impression pourrait le laisser croire), il convient de mettre à part les droits de *common law*, et tout particulièrement le droit anglais, qui rejettent clairement un principe général de « *good faith* » en droit des contrats, et qui se montrent attachés à une conception plus « littérale » de la force obligatoire, qui leur semble plus apte à favoriser la sécurité des relations contractuelles[192]. Ce rejet de principe n'empêche cependant pas ces droits de consacrer, sur d'autres fondements, certaines solutions qui, dans les droits d'Europe continentale, sont présentées comme des applications de la bonne foi[193].

116. Une exigence tardivement reconnue dans les pays du Code civil. Bien que le Code civil contienne, avec l'article 1134, alinéa 3, une affirmation générale de l'exigence de bonne foi, du moins au stade de l'exécution du contrat, ce texte n'a, jusqu'à une période récente, connu que des applications limitées. Au XIXe siècle, on considérait que ce texte ne constituait qu'une affirmation que, contrairement au droit romain, tous les contrats étaient « de bonne foi ». Ce n'est que plus récemment que le texte a véritablement « explosé » en doctrine et en jurisprudence. En France, cette redécouverte a trouvé ses racines dans le texte précédemment cité de Demogue comparant le contrat à une « petite société » où les contractants sont tenus de collaborer ensemble à un but commun[194], et qui a été valorisé, à partir du début des années 1980 par le courant doctrinal dit « solidariste »[195]. En Belgique, le développement du rôle de la bonne foi a été favorisé par l'importance croissante de la doctrine néerlandophone, influencée par le droit néerlandais, et, au-delà, par la conception allemande du « *Treu und Glauben* »[196]. Dans ces deux

192 Voy. Cartwright, pp. 64 à 67.

193 Sur ces « équivalents fonctionnels » du principe de bonne foi en droit anglais, voy. J. Smits, *Contract law. A comparative introduction*, 3e éd., Cheltenham, Edward Elgar, 2021, pp. 145 et s. (cité *infra*, Smits).

194 Sur ce texte, voy. *supra*, n° 96.

195 Voy. *supra*, n° 96.

196 Sur la bonne foi en droit belge voy : J.F. Romain, *Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé. Des atteintes à la bonne foi, en général et de la fraude, en particulier (fraus omnia corrumpit)*, Bruxelles, Bruylant, 2000.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pays, la réforme du droit des contrats a été l'occasion de consacrer explicitement le rôle de la bonne foi, d'une manière plus étendue que dans l'article 1134, alinéa 3. En France, le nouvel article 1105 pose désormais d'une manière générale que « [l]es contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». En Belgique, si on ne trouve pas une telle disposition générale en tête du chapitre du nouveau code consacré au droit des contrats, la bonne foi apparaît ensuite dans de nombreuses dispositions du texte (au sujet de la rupture des négociations, de l'obligation d'information, de la détermination du contenu des contrats…). Au Luxembourg, à défaut d'une véritable réflexion doctrinale sur le sujet, la jurisprudence n'est naturellement pas restée insensible à ce mouvement, et on en trouve des applications remarquables dans la jurisprudence récente. C'est cependant essentiellement sur la jurisprudence et la doctrine françaises et belges qu'il faudra s'appuyer pour essayer de préciser la notion de bonne foi (**A**) et le rôle qu'elle joue en droit des contrats (**B**).

A) *Notion de bonne foi en droit des contrats*

117. Bonne foi objective et bonne foi subjective. Dans le Code civil, et dans la jurisprudence des pays du Code, la notion de bonne foi est utilisée dans deux sens complètement différents.

Dans un sens qu'on peut dire subjectif[197], la notion s'applique d'abord à une représentation mentale, et désigne la croyance légitime dans une situation : est de bonne foi celui qui, ne connaissant pas la réalité d'une situation, s'est fié à son apparence et s'est comporté en conséquence. Dans certains cas, la loi ou la jurisprudence protègent cette personne en la faisant profiter de l'apparence. Cette acception de la notion de bonne foi trouve particulièrement à s'appliquer en droit des biens, en cas d'erreur sur la propriété d'un bien. Son application la plus connue est l'article 2279 du Code civil (2276 du Code civil français) « En fait de meubles, la possession vaut titre ». Ce texte permet à celui qui a acquis un meuble n'appartenant pas à celui qui lui a transmis d'en devenir propriétaire par le fait de la possession. Bien que le texte ne le dise pas, il est constant qu'il ne s'applique que si le possesseur était de bonne foi au moment de l'acquisition, c'est-à-dire s'il ignorait que son vendeur n'était pas propriétaire ; est de mauvaise foi, au contraire, celui qui savait que le vendeur était un voleur ou un usurpateur. La notion

[197] La formule « bonne foi subjective » est expressément utilisée dans l'article 1.9 du nouveau Code civil belge.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de bonne foi, dans cette acception, trouve aussi à s'appliquer en droit des contrats, notamment dans le cadre de relations tripartites, lorsqu'une des trois personnes en cause s'est méprise sur la réalité des relations entre les autres. Par exemple, l'article 1240 du Code civil valide le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession d'une créance dont il se trouve ensuite évincé[198]. Cependant, ce n'est pas ce sens qui nous intéresse ici, mais un second sens, qui s'applique cette fois, non plus à une représentation mentale, mais au comportement d'une personne – et en ce sens, parce qu'on ne s'intéresse plus à ce que les acteurs ont dans la tête mais à ce qu'ils font, on peut parler de bonne foi objective : la notion de bonne foi désigne alors la loyauté dans le comportement d'un contractant, le fait que ce contractant ait agi correctement, honnêtement, vis-à-vis de l'autre. C'est dans ce sens que l'article 1134, alinéa 3 du Code civil dispose que les conventions doivent être « exécutées de bonne foi ». L'exigence de bonne foi, prise dans ce sens, joue un rôle très différent de celui qui est assigné à la bonne foi subjective. Cette dernière permet d'accorder une protection particulière à celui qui a cru à l'apparence, en dérogeant aux règles légales qui, si elles étaient appliquées indépendamment de cette considération subjective, le priveraient d'un droit ou d'un avantage : celui qui a acquis d'un non-propriétaire ne devrait pas avoir de droit sur la chose, la bonne foi permet, positivement, de lui accorder plus que ce qu'il devrait avoir en droit strict. À l'inverse, si on considère la bonne foi objective, il faut observer que le contractant qui a eu un comportement de bonne foi (loyal, honnête) ne mérite pas une protection particulière, il n'a que les droits que lui assurent les règles normales du droit des contrats (et notamment la force obligatoire). L'exigence de bonne foi joue ici négativement, en ce qu'elle aboutit à priver du bénéfice des règles normales du droit des contrats celui qui y a manqué, qui a fait preuve de mauvaise foi dans son comportement. Elle permet de poser des limites au droit strict, et en particulier, à la liberté contractuelle et à la force obligatoire du contrat.

Les deux sens sont donc fondamentalement différents, même si on s'aperçoit qu'il existe des « ponts » entre les deux, certaines situations pouvant être appréhendées sous les deux angles (celui de la croyance légitime d'un contractant et celui du comportement loyal de l'autre). Il en va ainsi dans la situation où un contractant, par ses actes ou par ses paroles, a fait croire à son cocontractant qu'il allait maintenir ou accorder un avantage, sur lequel l'autre a pu compter, et qu'il adopte ensuite un comportement

198 Pour une application particulière dans le cas de la cession de créance lorsque le débiteur d'une créance cédée paye « de bonne foi » son créancier originaire parce qu'il ignore que celui-ci a cédé sa créance à un tiers, voy. *infra*, n° 1009.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

contraire. C'est dans cette situation que la *common law* utilise le mécanisme de l'estoppel, et que, dans les pays du Code civil, on consacre un principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui. Si on essaie de raccrocher cette question à la problématique générale de la bonne foi, on peut la traiter soit sous l'angle de la bonne foi de celui qui s'est fié au comportement de son cocontractant, soit sous l'angle de la mauvaise foi de celui qui s'est contredit au détriment de son cocontractant.

118. Différents aspects de la bonne foi contractuelle. Si on s'en tient maintenant à la notion objective, qui est celle de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil – et de tous les textes de droit comparé et de droit européen précédemment cités – on s'aperçoit qu'il est difficile de donner une définition très précise de cette « bonne foi ». Comme on l'a dit, l'idée générale est que chaque contractant doit se comporter de manière loyale : dans les textes et les décisions de jurisprudence, du reste, les deux termes de bonne foi et de loyauté sont fréquemment accolés : le DCEV parle ainsi du « principe de bonne foi et de loyauté », le DCFR, de « *good faith et fair dealing* ». Au-delà, on peut discerner différents aspects de cette exigence : les parties doivent coopérer (ou collaborer) lorsqu'une difficulté survient pour essayer de la résoudre, elles ne doivent pas induire en erreur leur cocontractant par leurs paroles ou leur comportement, ne pas se contredire constamment, elles doivent faire preuve de patience, de tolérance, à l'égard des petits manquements de l'autre, elles doivent le mettre en garde contre les problèmes susceptibles d'affecter l'exécution du contrat, elles ne doivent pas profiter des circonstances pour placer l'autre dans une situation difficile, etc. Certains de ces aspects sont parfois mis à part, soit dans les présentations doctrinales, soit dans les textes et projets législatifs. Par exemple, le DCEV, après avoir posé le principe général de bonne foi (DCEV, art. 2), prévoit dans un article séparé que « les parties sont tenues de coopérer l'une avec l'autre pour l'exécution de leurs obligations » (DCEV, art. 3). Les PDEC consacrent un article spécial (PDEC, art. 1:202) au « devoir de collaboration » en vertu duquel « chaque partie doit à l'autre une collaboration qui permette au contrat de sortir son plein effet », tandis que l'article 1.8 des Principes Unidroit pose une « interdiction de se contredire », qui apparaît dans d'autres textes sous l'angle d'un « principe de cohérence ». Ces articles, qui posent des règles plus précises que le principe général de bonne foi, peuvent être très utiles, mais ce ne sont, fondamentalement, que des applications particulières dudit principe[199].

[199] Comp. à propos du projet Terré : C. AUBERT DE VINCELLES, « Les principes généraux relatifs au droit des contrats », in *Pour une réforme du droit des contrats*, Paris, Dalloz, 2008, p. 117.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

119. Pouvoir d'appréciation du juge. C'est bien sûr au juge qu'il appartiendra, si un litige survient entre les parties, de dire quel devait être leur comportement au regard de l'exigence de bonne foi. Il devra le faire en considération de la personnalité des parties, de leur plus ou moins grande compétence, de leur rapport plus ou moins égalitaire, des pratiques habituellement suivies dans le contrat considéré, des circonstances particulières de l'espèce, etc. Le caractère extrêmement vague de la notion donne naturellement un grand pouvoir d'appréciation au juge, qui peut, au nom de la bonne foi, atténuer plus ou moins la rigueur de la force obligatoire du contrat. C'est pour cette raison que la notion de bonne foi est regardée avec réticence par les auteurs libéraux, qui y voient un instrument particulièrement nuisible à la sécurité des échanges. C'est la même raison qui explique l'hostilité de principe des *common lawyers* à un principe général de bonne foi. Comme l'exprime un commercialiste anglais : « La prévisibilité du résultat juridique d'une affaire est plus importante qu'une absolue justice. Il est nécessaire dans une relation commerciale que les hommes d'affaires puissent au moins savoir où ils en sont […]. La dernière chose que nous souhaitons est de compromettre les affaires par un vague concept de loyauté qui rend les décisions judiciaires imprévisibles »[200]. Ces craintes sont cependant largement démenties par l'observation des systèmes juridiques où la bonne foi joue un rôle important, et où les affaires ne se sont pas pour autant effondrées. Toute la difficulté, bien sûr, est, comme toujours, de trouver un équilibre entre la sécurité et la justice.

B) *Rôle de la bonne foi en droit des contrats*

120. Bonne foi dans la formation et bonne foi dans l'exécution. L'article 1134, alinéa 3 du Code civil ne vise explicitement que la bonne foi dans l'exécution du contrat. La lecture des travaux préparatoires du Code civil nous apprend cependant que, dans sa première version, ce texte disposait que les conventions « doivent être formées et exécutées de bonne foi ». De même, dans la formulation du principe de bonne foi par de nombreux textes modernes, on englobe très souvent ses deux sphères d'application. Par exemple, l'article 2 du DCEV pose que « il incombe à chaque partie d'agir conformément au principe de bonne foi et de loyauté », sans distinguer à quel stade de la vie du contrat on se situe. L'article 1104

200 R. Good, cité par Smits, p. 143.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

du Code civil français dispose désormais quant à lui de manière très explicite que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Dans les pays du Code civil, du reste, la jurisprudence n'avait pas hésité, même avant les réformes en France et en Belgique, à se servir de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil pour étendre l'exigence de bonne foi au stade de la formation du contrat. Nous verrons ainsi qu'elle s'en est servie pour limiter le droit de rompre les négociations, ainsi que pour faire peser sur les parties des obligations précontractuelles dont l'inobservation peut affecter la validité du contrat. Nous verrons aussi que c'est l'exigence de bonne foi qui a inspiré, au niveau européen, la législation sur les clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs : la directive européenne sur les clauses abusives définit expressément une telle clause comme celle qui « en dépit de l'exigence de bonne foi,… crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ».

Au stade de l'exécution du contrat, l'exigence de bonne foi vient atténuer la portée de la force obligatoire. Nous verrons que la jurisprudence s'en sert pour faire peser sur les contractants certaines obligations permettent d'assurer ou de restaurer un certain équilibre dans les relations contractuelles. Elle s'en sert aussi pour neutraliser l'exercice déloyal par un contractant de certaines des prérogatives que lui confère le contrat : l'exigence de bonne foi rejoint alors largement la prohibition de l'abus de droit, inscrite à l'article 6-1 du Code civil du Luxembourg.

Ces différents aspects ne sont ici qu'évoqués. Ils seront développés de manière plus précise lors de l'examen des questions sur lesquelles la bonne foi joue un rôle[201].

****

121. Plan de l'ouvrage. Les développements précédents sur la bonne foi montrent que celle-ci s'inscrit aux deux stades de la vie du contrat : au stade de sa formation, et au stade des effets qu'il produit. C'est autour de ces deux temps que nous articulerons les développements du présent manuel : dans un premier temps, nous

[201] Voy. not. n°s 173, 233 (bonne foi dans le processus de formation du contrat), 472 et s. (bonne foi dans l'exécution du contrat).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

étudierons à quelles conditions le droit subordonne la formation d'un contrat valable. Puis nous nous demanderons quels effets produit le contrat valablement formé. C'est un plan extrêmement traditionnel, qui sert de base – avec d'infinies variantes – à l'exposition de la matière dans la plupart des manuels et traités tant en France qu'en Belgique. Nous l'avons ici choisi pour permettre au lecteur (notamment étudiant) de faire plus facilement le « pont » entre le présent manuel et les ouvrages correspondants de droit français et de droit belge, qui devront souvent être utilisés à titre complémentaire à celui-ci[202]. Il ne faut pas se dissimuler, cependant, l'extrême artifice de ce plan traditionnel. D'une part, certaines questions sont « à cheval » sur les questions de formation et d'exécution : la question de savoir si telle ou telle clause contractuelle est ou non valable, par exemple, est très souvent liée aux effets que cette clause prétend produire au stade de l'exécution du contrat. D'autre part, en pratique, la plus grande partie du contentieux contractuel se situe au stade de l'exécution du contrat : c'est plus souvent parce que son cocontractant l'assigne en exécution du contrat, ou pour faire sanctionner son inexécution, que l'autre partie se défend en soutenant que ce contrat ne la lie pas, parce qu'il n'a pas été formé valablement. Les questions relatives à la formation (première partie) ne se posent donc, dans l'immense majorité des cas, qu'à propos des effets qu'on veut faire produire au contrat (deuxième partie).

[202] Il va de soi que le présent ouvrage, centré sur les particularismes du droit luxembourgeois, ne peut prétendre se substituer, pour l'étude approfondie des droits français et belge, aux manuels correspondants dans ces deux droits.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les fondements du droit des contrats, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 121-157
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

122. Questions à distinguer. Deux (ou plusieurs) personnes sont entrées volontairement en relation. À quelles conditions une telle relation sera-t-elle reconnue par le droit comme ayant force obligatoire, comme « tenant lieu de loi » entre les parties (pour reprendre la formule de l'article 1134 du Code civil ?). Telle est la question à laquelle nous avons à répondre dans cette première partie.

Cette question est plus complexe qu'il n'y paraît. On peut rationnellement la décomposer en trois questions – celle de la qualification, celle de l'existence, et celle de la validité du contrat – que le juriste devrait à première vue se poser dans l'ordre suivant :

1/ Cette relation est-elle susceptible de recevoir la *qualification* de contrat au regard du droit positif ? Nous avons donné d'emblée les éléments de réponse à cette question lorsque nous avons cherché à définir la notion de contrat, à partir de l'article 1101 du Code civil. Nous savons par exemple que, si je vous invite à dîner, et que vous acceptez, cet accord n'est pas normalement qualifié de contrat dans les pays du Code civil (ni ailleurs en général). En revanche, si vous voulez m'acheter un livre (ou tout autre objet) que je suis disposé à vous vendre, cet accord, s'il est effectivement passé, sera qualifié de contrat. La réponse à cette première question – savoir si la relation en cause est un contrat – commande la suite, car, si l'accord ne mérite pas d'être qualifié de contrat, il est inutile de se demander si cet accord a été effectivement passé (si le contrat « existe ») et s'il répond aux conditions de validité posées par la loi. Il est également important de comprendre que, dans un tel cas, on ne dira pas que « le contrat n'existe pas », encore moins que « le contrat est nul », on dira simplement que ce qui lie les personnes en cause (par exemple : l'invitation à dîner) n'est pas un contrat. Il en résultera alors qu'aucune des règles du droit des contrats ne sera applicable (en particulier sur la question de la responsabilité que l'une des deux personnes peut encourir envers l'autre si un dommage a été causé à l'autre dans le cadre de cette relation).

2/ La deuxième question est celle de *l'existence* du contrat. À supposer (on n'y reviendra plus) que la relation entre les deux parties soit susceptible d'être qualifiée de contrat, on doit se demander si les deux parties ont effectivement conclu ce contrat, si elles se sont effectivement mises d'accord. Par exemple, si je vous propose de m'acheter l'édition 2025 du « Code Larcier de Droit luxembourgeois » pour le prix de 100 €, et que vous me dites que vous le voulez bien, mais seulement pour 60 €, on dira que nous n'avons

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 161-164
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

conclu aucun contrat de vente – même si, à la différence du cas précédent, c'est bien un contrat que nous avions l'intention de conclure. La réponse à ce type de question est loin d'être aussi évidente que l'exemple précédent pourrait le laisser croire. Elle dépend de règles complexes qui régissent le *processus de formation* du contrat, qui peuvent se montrer plus ou moins exigeantes selon les systèmes juridiques : par exemple, certains droits se contenteront, pour admettre l'existence d'un contrat, d'un accord sur les éléments essentiels du modèle contractuel choisi, même s'il existe une divergence sur un point mineur, alors que d'autres exigeront un accord sur tous les points. Par ailleurs, des différences importantes peuvent exister entre les systèmes quant au moment exact auquel on considérera que le contrat est formé (notamment dans le cas des contrats par correspondance), ou encore sur les solutions à donner lorsqu'un des partenaires à la négociation du contrat fait une proposition puis la retire ensuite. Ceci doit vous faire comprendre que la question de l'existence du contrat n'est pas une simple question de fait, mais qu'elle est liée à des règles juridiques dont il faudra faire l'étude.

3/ La question de l'existence du contrat doit être distinguée de celle de sa *validité*. Ce n'est pas parce qu'un accord a été effectivement passé entre deux personnes, et que cet accord répond à la qualification de contrat, que le droit lui reconnaîtra nécessairement force obligatoire. Rappelons ici que la liberté contractuelle, si elle est le principe dans les sociétés libérales (et dans la plupart des pays du monde), n'est jamais absolue, parce que l'ordre juridique étatique ne peut pas tolérer des contrats qui iraient contre l'intérêt social. Par ailleurs, on conçoit que, dans un but de protection des intérêts individuels des contractants, le droit leur permette de remettre en cause des accords qu'ils ont passés sans avoir une claire conscience des enjeux de leur engagement, ou à un moment où ils n'étaient pas en pleine possession de leurs moyens, ou parce qu'ils ont été victimes d'un abus de la puissance économique de l'autre partie. Ces diverses considérations, sur lesquelles on reviendra, expliquent que tous les systèmes juridiques subordonnent la force obligatoire du contrat au respect de certaines *conditions de validité*. Pour bien comprendre la différence avec la problématique de l'existence du contrat, et du processus de formation, reprenons l'exemple de la vente de l'ouvrage de « droit luxembourgeois ». Cette fois vous acceptez bien de me l'acheter au prix que je vous propose, mais sans savoir que toutes les pages

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 161-164
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

correspondant au droit des contrats sont manquantes dans mon exemplaire : dans un tel cas, le contrat a bien été passé, mais vous pourrez ensuite prétendre que vous avez été victime d'une erreur et que ce contrat n'est pas valable. Ou encore : vous acceptez de m'acheter l'ouvrage au prix exorbitant de 500 €, mais c'est parce que vous êtes un de mes étudiants et que je vous promets que le sujet de l'examen est dissimulé entre les pages 145 et 146, etc. Voilà bien sûr un contrat que l'ordre juridique ne peut pas tolérer : il existe, il a bien été passé, mais il pourra être annulé pour violation de l'ordre public.

La distinction entre la problématique de l'existence du contrat et celle de sa validité a été pendant longtemps méconnue dans la tradition de l'enseignement dans les pays du Code civil, et notamment en France parce que le Code civil de 1804 ne traitait pas directement des questions relatives au processus de formation du contrat. Il ne traitait que des conditions de validité, dans les articles 1108 et suivants (toujours en vigueur au Luxembourg). Dans une méthode d'enseignement du droit civil qui a longtemps été fondée sur l'étude systématique des articles du Code, on avait alors pris l'habitude de traiter de la question de l'existence du contrat, sous l'angle de la première des quatre conditions de validité posées par l'article 1108 du Code civil, à savoir le consentement – la question de l'existence du contrat étant alors ramenée à celle de l'existence du consentement. Cette présentation, si elle se trouvait encore dans certains manuels modernes[203], tendait cependant à être abandonnée, et même avant les réformes française et belge, la plupart des ouvrages distinguaient nettement, quoiqu'avec une terminologie variable, la question du processus de formation du contrat de

celle de ses conditions de validité – distinction qui apparaît du reste dans la plupart des codes modernes et dans les différents projets nationaux et européens de droit des contrats. Elle a été consacrée explicitement par la réforme française de 2016, qui distingue, au sein du chapitre consacré à la formation du contrat, « la conclusion du contrat » (art. 1112 et s.) de sa « validité » (art. 1128 et s.). De même, le nouveau code belge distingue, en reprenant une formulation doctrinale antérieure, ce qui relève de la « conclusion

[203] Voy. p. ex. Flour, Aubert, Savaux 2014, pp. 111 et s. Curieusement, cette présentation a été maintenue dans une édition postérieure à la réforme, alors qu'elle ne correspond plus à la distinction faite par le Code civil français entre conclusion et validité du contrat (Flour, Aubert, Savaux 2022, pp. 241 et s.).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 161-164
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

dynamique du contrat » (art. 5.14 et s.) et les conditions de validité du contrat (art. 5.27 et s.). Nous suivrons également cette distinction dans les développements qui vont suivre.

En même temps, il faut souligner que cette distinction n'est pas aussi tranchée qu'on pourrait le croire. D'une part, même si les sanctions des deux séries de règles sont théoriquement très différentes (l'inexistence du contrat si le processus de formation n'a pas été mené à bien, la nullité du contrat si une condition de validité fait défaut), nous verrons qu'elles peuvent se recouper dans certains cas. D'autre part, dans le système des pays du Code civil, certaines règles se situent à la frontière des deux problématiques : ainsi, lorsque la loi subordonne la formation du contrat au respect de certaines conditions de forme, ce formalisme est parfois considéré comme une condition de validité du contrat, parfois comme une condition de son existence même. Même la distinction – primaire – entre la question de la qualification de contrat et celle de son existence ou de sa validité est une distinction relative, et n'est pas conçue de la même manière selon les systèmes juridiques : ainsi, l'existence d'une contrepartie à un engagement (*consideration*) est traditionnellement considérée, dans les systèmes de *common law*, comme un élément de la qualification même de contrat (un accord sans *consideration* n'est pas un contrat), alors que, dans les pays du Code civil, c'est seulement une condition de validité des contrats synallagmatiques (traditionnellement rattachée à la notion de cause).

LARCIER INTERSENTIA
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 161-164
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

123. Entre sécurité et liberté. L'intitulé de ce titre peut être trompeur. On peut avoir l'impression qu'il s'agit de décrire un processus, d'expliquer comment les choses se passent lorsque deux ou plusieurs personnes passent un contrat – un peu comme on décrirait la manière dont on fait les enfants ou dont se forment les fleurs. Il n'en est rien, le droit n'est pas une science naturelle, et, ce qu'il s'agit ici de décrire, ce ne sont pas des faits (même si leur prise en considération est essentielle), mais des normes, des règles (légales ou jurisprudentielles). Il ne s'agit pas d'expliquer comment un contrat se forme, mais comment il doit se former pour être reconnu par le droit. Et, comme on l'a déjà dit, les règles qui régissent cette question ne sont pas nécessairement les mêmes d'un système juridique à l'autre. Nous allons voir du reste qu'elles ne sont pas exactement les mêmes d'un pays à l'autre à l'intérieur du « système » du Code civil.

C'est que la manière dont le droit structure le processus de formation du contrat ne dépend pas seulement de considérations techniques (comment s'y prendre pour que ça marche ?), elle est aussi fonction de certaines considérations de politique juridique. Quelle place veut-on accorder à la liberté des parties (qui leur permettrait, jusqu'au moment où le contrat est définitivement formé, de changer d'avis, de se retirer du processus entamé), et quelle place veut-on faire à l'inverse, à l'exigence de sécurité (qui postule que, dans la phase de discussion du contrat, chaque partie puisse compter sur une certaine permanence du comportement de l'autre) ? Nous allons voir que ce balancement entre sécurité et liberté est au cœur de nombreuses règles régissant le processus de formation du contrat.

124. Silence du Code civil. Ces règles, on les chercherait en vain dans le Code civil de 1804, dont c'est une des principales lacunes en matière contractuelle. Les rédacteurs du Code sont restés complètement muets sur ces questions, et, comme on l'a déjà signalé, n'ont envisagé la formation du contrat qu'à travers ses conditions de validité. Ce n'est que dans le cadre de certains contrats déterminés que des règles, du reste très incomplètes, sont posées. Les questions, cependant, n'ont pas tardé à se poser devant les tribunaux, et c'est à la jurisprudence, dans les trois pays, qu'il a appartenu de poser des règles sur le processus de formation du contrat. Ces règles ont été systématisées par la doctrine, qui, en retour, a contribué à les faire évoluer. Suivant l'exemple des projets européens d'harmonisation du droit des contrats, ainsi que de nombreux codes modernes, les réformateurs français et belges ont fort heureusement comblé les

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 167-169
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

lacunes du code sur ces questions, qui sont désormais réglementées en détail aux articles 1112 et suivants du code français, et aux articles 5.14 et suivants du nouveau Code civil belge.

125. Nécessité de manifestations de volonté. Même si, comme on l'a vu précédemment, la volonté des parties n'est pas tout dans le contrat, elle reste, dans tous les cas, absolument nécessaire pour qu'on puisse parler d'un contrat. Même lorsque les effets du contrat sont largement prédéterminés par la loi, la volonté des parties est, au moins, un élément déclencheur de la production de ces effets. Et même lorsqu'on est en présence d'un contrat que la loi oblige à passer (contrats imposés), une manifestation de volonté des parties n'en est pas moins nécessaire pour que ce contrat soit effectivement conclu.

Cette volonté des parties, qui, en dépit de toutes les évolutions, reste consubstantielle à la notion même de contrat, doit se manifester d'une manière ou d'une autre, sous la forme d'un consentement exprès ou tacite donné à l'engagement. Certes, on oppose souvent, sur ce point, le système du Code civil, où ce qui compte, c'est la volonté interne des parties (ce qu'elles avaient vraiment en tête), au système allemand, qui n'attacherait d'importance qu'à la volonté déclarée (ce qu'elles ont dit ou fait). Cette opposition, dont la portée a été largement surestimée, peut jouer un rôle lorsqu'il existe une discordance entre la volonté réelle et la volonté déclarée (pour l'appréciation d'éventuels vices du consentement, pour l'interprétation du contrat notamment). Elle est en revanche sans importance lorsqu'il s'agit de savoir si un contrat est ou non formé. À ce stade, si les parties, qui ont en tête de passer un contrat entre elles, ne disent rien et ne font rien pour manifester leur volonté, le contrat ne pourra pas être conclu. Ceci ne remet pas en cause le principe du consensualisme, précédemment évoqué, dès lors qu'il n'est pas nécessaire en principe que les volontés des parties se manifestent d'une manière formelle. Sauf règles particulières (nombreuses) les parties peuvent se mettre d'accord par la signature d'un acte écrit, par un échange de paroles ou de signes, par un comportement qui ne laisse aucun doute sur leurs intentions, etc. pourvu qu'elles manifestent cette volonté de contracter d'une manière ou d'une autre. Le nouvel article 1113 du Code civil français pose à la fois très clairement la nécessité d'une manifestation de volonté, et l'indifférence des formes qu'elle peut revêtir.

LARCIER INTERSENTIA
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 167-169
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

126. Des discussions à l'accord. Pendant longtemps, la formation du contrat a été vue comme un processus instantané, reposant sur la « rencontre », la concordance à un moment donné de deux (ou de plusieurs) manifestations de volonté (**Sous-titre I**). Cette rencontre est de toute façon nécessaire pour que le contrat soit formé, mais, dans de très nombreux cas, elle est l'aboutissement d'un processus de plus ou moins longue durée, auquel le droit moderne s'intéresse largement compte tenu des enjeux pratiques qu'il suscite (**Sous-titre II**).

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 167-169
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

127. Rencontre d'une offre et d'une acceptation. Vous entrez dans une boulangerie et vous voyez en vitrine un *streusel* au prix de 2,50 €. Lorsque la vendeuse vous demande ce que vous voulez, vous lui répondez « un *streusel*, s'il vous plaît ». Dès ce moment – sans que vous en ayez nécessairement conscience – un contrat s'est formé. Le boulanger, en exposant le gâteau et en en affichant le prix, vous a fait une *offre*, et vous avez émis une *acceptation* en faisant votre choix. L'exemple est simple, et dans ce cas, aucune difficulté ne surgira sur la formation même du contrat. Il a le mérite de souligner qu'un contrat peut se former de manière extrêmement informelle : c'est la conséquence du consensualisme qui reste un principe dominant du droit des contrats.

Cependant, dans de nombreux cas, des difficultés peuvent surgir, soit du côté de l'offre (**Chapitre I**), soit du côté de l'acceptation (**Chapitre II**) pour savoir si le contrat s'est ou non formé.

128. Actes unilatéraux. Cette présentation n'a évidemment aucun sens pour les *actes juridiques unilatéraux*, qui ne font pas l'objet d'une acceptation de la part de la ou des personnes qu'ils concernent. La question qui se pose alors (et qui, elle, n'a pas de sens pour les contrats), est de savoir si, pour produire ses effets, la manifestation de volonté unilatérale doit être portée à la connaissance de la ou des personnes qu'elle concerne. De ce point de vue, les auteurs français et belges ont pris l'habitude de distinguer, en s'inspirant du modèle allemand, deux catégories d'actes unilatéraux. Les uns, qui sont dits *réceptices*, supposent d'avoir été « reçus », c'est-à-dire portés à la connaissance de leur destinataire : il en va ainsi, par exemple, de la mise en demeure ou du congé délivré à un locataire. D'une manière générale, les actes unilatéraux générateurs d'obligations (les engagements unilatéraux) obéissent à cette exigence : leur force obligatoire, en effet, ne se justifie que par le fait qu'ils font naître une attente, une confiance dans la personne du créancier potentiel. D'autres actes unilatéraux, plus rares, peuvent produire leurs effets sans avoir été portés à la connaissance de la personne concernée : on peut citer ici l'exemple du testament, ou de la reconnaissance d'un enfant né hors mariage.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 173
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Chapitre I
L'offre de contracter

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

129. Problématique. La période qui précède la conclusion d'un contrat est nécessairement initiée par une proposition qu'une personne fait à une autre (par lettre, par mail, verbalement, etc.) ou à plusieurs autres (une annonce dans un journal ou sur un site Web, la présentation d'un produit dans une vitrine, sur les rayonnages d'un magasin ou par Internet, etc.). Cette première proposition, qui pourra être suivie de contre-propositions ou de propositions modificatives, ne constitue cependant pas nécessairement une offre au sens du droit. Dans tous les systèmes juridiques européens, on va identifier, parmi les multiples propositions croisées qui peuvent s'échanger au cours des discussions préalables à la formation du contrat, celle qui, à un moment donné, méritera d'être qualifiée d'offre (**Section 1**), et à laquelle on fera produire des effets spécifiques (**Section 2**).

SECTION 1. LA QUALIFICATION D'OFFRE

130. Finalité. La qualification d'offre (ou, selon une terminologie ancienne mais encore utilisée par certains tribunaux, de pollicitation) vise à isoler, au sein de la période précontractuelle, une proposition présentant des caractéristiques telles qu'un simple « oui » formulé par le destinataire de cette proposition suffise à former le contrat. Cette idée apparaît très clairement dans un arrêt de la Cour de cassation de Belgique rendu à propos d'une offre d'emploi : « l'offre d'emploi requiert essentiellement que l'expression définitive de la volonté de l'une des parties en présence ne doive qu'être acceptée pour que le contrat se forme »[204]. Mais cette idée vaut d'une manière générale pour tous les contrats, et elle permet de rendre compte des solutions admises dans les trois pays. Elle explique les éléments nécessaires à la qualification (**§ 1**), mais aussi l'indifférence d'autres éléments (**§ 2**).

§1. Éléments nécessaires à la qualification d'offre

131. Une proposition précise et ferme. Un jugement du Tribunal de Luxembourg résume très bien la position commune des jurisprudences des trois pays du Code civil » Il y a offre véritable et ferme, lorsqu'elle manifeste une intention de se lier juridiquement et qu'elle contient des indications précises et suffisamment complètes

[204] Cass. be., 1er février 1982, *Pas. be.*, 1982, I, p. 690.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pour que le contrat puisse se former par une acceptation pure et simple »[205]. On reconnaît ici deux éléments : la fermeté de l'offre (l'intention de se lier) et sa précision (des indications suffisamment complètes). Ces deux éléments se retrouvent dans les nouveaux textes français et belge. Le nouvel article 1114 du Code civil français dispose ainsi que « [l]'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ». De même, selon l'article 5.19 du nouveau Code civil belge, « [l]'offre est une proposition de conclure un contrat qui contient tous les éléments essentiels et substantiels du contrat visé et qui implique la volonté de l'offrant d'être lié par le contrat en cas d'acceptation ».

Ces deux éléments se retrouvent, avec des formulations variables, dans de multiples droits nationaux, ainsi que dans divers textes internationaux et projets européens. On citera par exemple la formule de l'article 1188 du nouveau Code civil roumain « Une proposition constitue une offre de contracter dès lors qu'elle contient suffisamment d'éléments nécessaires à la formation du contrat et exprime l'intention de l'offrant de s'obliger en cas d'acceptation du destinataire », ou encore celle de l'article 31 du DCEV selon lequel « Une proposition est une offre lorsque : (a) elle manifeste la volonté d'aboutir à un contrat si elle est acceptée ; et (b) présente un contenu suffisant et est suffisamment certaine pour faire naître un contrat ».

On examinera successivement l'exigence de précision de l'offre, puis celle de fermeté.

A) *La précision de l'offre*

132. Éléments essentiels du contrat. La première condition requise pour qu'on soit en présence d'une offre véritable est que la proposition de contracter soit suffisamment précise. Cela ne signifie pas qu'elle doit contenir tous les détails relatifs au contenu du contrat à conclure, il suffit qu'elle en contienne les éléments essentiels, ceux sur lesquels l'accord des parties est absolument nécessaire pour que le contrat puisse se former. C'est ce que dit très bien la Cour d'appel : » Il n'est pas nécessaire que l'offre se présente sous la forme d'un projet complet de contrat, mais il suffit qu'elle fixe les éléments essentiels de la convention y proposée »[206].

Comme l'indiquent bien les formules précédemment citées, cette notion de précision est éminemment relative, parce que les éléments essentiels à la formation d'un contrat sont variables d'un contrat à

[205] Trib. Luxembourg, 24 janvier 2002, n° 68830, *BIJ*, 2004, p. 119.

[206] Cour d'appel, 14 octobre 1998, *Pas.*, 30, p. 499 ; Trib. Luxembourg, 8 décembre 2023, n° TAL-2023-06232.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'autre. Par exemple, pour un contrat de vente, l'offre de contracter doit au minimum comporter la détermination de la chose mise en vente, et le prix proposé[207]. Si je vous « offre » de vous vendre ma maison sans vous proposer un prix, ce n'est pas juridiquement une offre, mais une simple invitation à entrer en pourparlers. Il n'est pas nécessaire en revanche que je vous précise combien de temps vous aurez pour me payer, ni à quel moment je vous remettrai les clés. Pour d'autres contrats, on se montrera moins exigeant encore : ainsi, pour un prêt (qui peut-être à titre gratuit), il suffit de la détermination de la chose prêtée, pour un contrat de prestation de services, l'offre suppose seulement la précision du service à effectuer, etc. Les exigences posées par le droit pour la précision de l'offre ne constituent qu'un minimum. L'offrant peut bien sûr, d'emblée, assortir son offre de précisions supplémentaires (outre la chose et le prix de vente, le moment de livraison, les conditions de paiement du prix, etc.), qui vont se trouver ainsi « essentialisés ». S'il ne le fait pas, du reste, le destinataire de l'offre se contentera rarement du minimum, et exigera souvent, avant de prendre parti, des éléments supplémentaires. Mais, s'il disait « oui » sans demander d'autres précisons, le contrat serait formé, et cela suffit à ce que la proposition de contracter ne contenant que ces éléments soit qualifiée d'offre.

Pour bien comprendre cette notion d'éléments essentiels, et la signification variable de cette idée de « précision » de l'offre, il faut savoir que, dans aucun système juridique, il n'est requis, pour la formation d'un contrat, que les parties se mettent d'accord sur tous les aspects de leurs relations : si un litige survient sur un point qui n'a pas été spécialement convenu entre elles, la loi (ou la jurisprudence) peut dans une large mesure donner la solution. Tel est le sens qu'on peut donner à l'article 1135 du Code civil « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature »[208]. Cependant, il est des points qui, pour chaque contrat, ne peuvent pas être décidés par la loi ou le juge en l'absence d'accord des parties. Si on prend l'exemple de la vente, le Code civil prévoit bien à quel moment doit intervenir la livraison ou le paiement du prix, à quelle garantie le vendeur est tenu, quelles sanctions seront applicables si une partie n'exécute pas ses engagements, etc. Mais nul ne peut en principe, à la place des parties, décider quelle chose fera l'objet du contrat, et à quel prix cette chose sera vendue. C'est pourquoi l'accord des parties est absolument nécessaire sur ces points, et il ne peut pas y avoir offre de vente en l'absence de ces deux éléments. Pour un contrat de prestation de services, en revanche, il est généralement admis que le prix peut n'être fixé, par accord des parties, qu'une fois la prestation effectuée, et, en l'absence d'accord, que le juge peut fixer le prix à leur place : du coup, l'offre de prestation de services ne comporte pas nécessairement le prix. À l'inverse, la loi peut se montrer beaucoup

207 Cour d'appel, 14 octobre 1998, préc.

208 Voy. *infra*, n°s 534 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

plus exigeante quant aux éléments à déterminer au départ : ainsi, dans les pays de l'Union européenne, la réglementation du crédit à la consommation (qui provient de la transposition d'une directive européenne) exige, dans un souci de protection des consommateurs emprunteurs, que ceux-ci soient fixés dès le départ sur de nombreux éléments du crédit qu'ils désirent contracter (le taux d'intérêt, les conditions de l'assurance, la durée, les sanctions du non-remboursement, etc.)[209]. Cela accroît considérablement l'exigence de précision de l'offre.

B) *La fermeté de l'offre*

133. Intention de se lier juridiquement. Toutes les formules précédemment citées subordonnent la qualification d'offre au fait que l'auteur de la proposition ait l'intention d'être lié juridiquement en cas d'acceptation de la part du destinataire. C'est ce qu'on nomme l'exigence de fermeté de l'offre. Si je vous dis « seriez-vous intéressé(e) à acheter ma maison pour 800 000 € ? Si vous me dites oui, je verrai si je veux vous la vendre après en avoir discuté avec ma femme », on considérera qu'il ne s'agit pas là d'une proposition ferme. Votre réponse positive ne suffira pas à former le contrat.

Il n'y aura donc pas offre, d'une manière générale, si la proposition de contracter est assortie de réserves quant à la formation ultérieure du contrat. Il faut cependant distinguer deux types de réserves, subjectives (**1**) et objectives (**2**).

1) *Réserves subjectives*

134. Principe. Il peut d'abord s'agir, comme dans l'exemple précité, de réserves subjectives, tenant à l'acceptation ultérieure d'une autre personne, ou de celui qui fait la proposition. Un exemple fréquent en pratique du premier cas est celui d'une proposition formulée au nom d'une entreprise par un employé qui n'a pas de pouvoir de représentation, et qui fait la soi-disant « offre » sous réserve de l'accord ultérieur de la direction (par exemple la proposition que vous fait l'employé d'un garage de vous reprendre votre voiture à tel prix, en précisant que ce prix doit être validé par son patron). Quant aux réserves tenant à l'acceptation ultérieure du proposant, elles sont particulièrement fréquentes en pratique, et le plus souvent implicites. Ainsi, une « offre d'emploi » formulée par petite annonce, même si elle est assortie de précisions suffisantes quant au travail et quant au salaire, n'a d'offre que le nom, car il va de soi que l'employeur n'embauchera la personne qui répondra qu'après avoir

[209] C. Consomm., art. L. 224-6.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

vérifié ses compétences et les avoir comparées avec celles d'autres candidats potentiels. De même, une offre de location n'oblige pas le propriétaire à accepter comme locataire la première personne qui se présente, car il voudra auparavant vérifier sa solvabilité. De même encore, selon un arrêt de la Cour d'appel, la « proposition d'assurance » qu'une compagnie d'assurance adresse à un client n'est pas juridiquement une offre, car l'assureur attend de connaître l'état exact des risques à couvrir que le client lui indiquera avant d'accepter (ou non) de l'assurer[210]. D'une manière générale, dans les contrats dits « *intuitu personae* », c'est-à-dire où la considération de la personne du cocontractant est déterminante, les propositions de contracter faites à personne indéterminée seront toujours supposées être sous réserve d'agrément ; elles ne constituent donc pas des offres véritables. Dans toutes ces hypothèses, ce n'est pas celui qui prend l'initiative du contrat qui est l'offrant, c'est celui qui répond à la proposition.

135. Licéité. De telles réserves ne sont pas toujours licites. Certaines réserves d'agrément peuvent tomber sous le coup de la prohibition des discriminations, sur le terrain de la protection des droits de l'homme. Comme on l'a déjà signalé, si on peut contracter (ou refuser de contracter) avec qui on veut, c'est à la condition que le choix du contractant ne soit pas dicté par des motifs discriminatoires à l'encontre de certaines catégories d'êtres humains (la race, le sexe, la religion, l'orientation sexuelle, etc.)[211]. Une réserve d'agrément qui serait fondée sur une telle discrimination serait donc nulle, outre qu'elle exposerait son auteur aux sanctions pénales prévues par les textes. On a vu, également, qu'un commerçant qui propose des marchandises ou des services au public ne peut pas en principe se réserver le droit de refuser de contracter avec tel ou tel client, ce qui constituerait un refus de vente prohibé[212].

Sur un tout autre terrain, les réserves d'agrément ont parfois été contestées au regard de l'article 1174 du Code civil qui prohibe dans les contrats les conditions purement potestatives de la part du débiteur, c'est-à-dire des clauses par lesquelles le débiteur subordonne la naissance ou la disparition de son engagement à sa volonté discrétionnaire[213]. Dans un arrêt de 1980, la Cour de cassation française avait considéré que constituait une telle condition la clause d'un bon de commande signé par le préposé d'un garage subordonnant la vente de véhicules neufs à l'agrément écrit de la société[214]. Confrontée à plusieurs reprises à la même pratique, la Cour d'appel du Luxembourg a d'abord suivi cette solution[215], avant de s'en écarter, mais en se fondant sur deux argumentations différentes. Alors que, en 2001, elle avait considéré que la condition n'était pas purement potestative, parce que la décision du garage était liée à des éléments objectifs (la rentabilité de la vente envisagée compte-tenu

210 Cour d'appel, 18 novembre 1987, *Pas.*, 27, p. 195.
211 Voy. *supra*, n° 105.
212 Voy. *supra*, n° 105.
213 Voy. *infra*, n°s 593 et s.
214 Cass. fr. (com.), 9 décembre 1980, n° 79611550.
215 Cour d'appel, 20 décembre 1989, *Pas.*, 17, p. 362.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

du coût de la reprise du véhicule ancien du client)[216], elle a, beaucoup plus pertinemment, observé en 2005 que la clause d'agrément incriminée ne constituait pas du tout une condition. Celle-ci est en effet une clause d'un contrat effectivement passé, alors que dans ce cas, on se situe dans la phase préliminaire de formation du contrat, et la réserve d'agrément est simplement un élément qui empêche de considérer la proposition du garage comme une offre. C'est alors le client, et non le garage, qui formule l'offre de contracter, (je vous offre de vous acheter un véhicule neuf à tel prix, et de vous vendre mon vieux véhicule à tel prix), que le garage est libre ou non d'accepter[217]. Il n'en reste pas moins que de telles clauses, qui inversent artificiellement le processus de formation du contrat, peuvent être dangereuses pour l'acheteur, qui, lui, est engagé par son offre et qui ne peut pas chercher ailleurs dans l'attente de la décision définitive du garage. C'est pourquoi le droit européen de la consommation les condamne au titre des clauses abusives lorsque le client est un consommateur. Aux termes du (n) de l'annexe de la directive 93/13/CE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs[218] sont abusives (donc nulles) les clauses ayant pour objet ou pour effet « de restreindre l'obligation du professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière ». La transposition de cette disposition se trouve actuellement au Luxembourg dans l'article L. 211-3 24 du Code de la consommation.

2) *Réserves objectives*

136. Compatibilité avec l'offre. Des réserves subjectives, incompatibles avec la qualification d'offre, il faut distinguer les *réserves objectives*, qui subordonnent la formation du contrat à des éléments objectifs sur lesquels l'offrant n'a pas de prise. Le cas le plus important en pratique est celui de l'offre de vente de marchandises faite « dans la limite des stocks disponibles ». Ce type de réserves (implicites dans certains contrats : par exemple la vente de billets pour un spectacle) n'empêche pas la proposition de contracter d'être une offre : tant qu'il reste des marchandises à vendre (ou des places disponibles), le seul fait pour un client de se présenter pour acheter au prix proposé suffit à former le contrat.

§ 2. Éléments normalement indifférents à la qualification d'offre

A) *La forme de l'offre*

137. Consensualisme. Dans un système consensualiste, comme l'est celui du Code civil, la forme de l'offre est normalement indifférente. La proposition de contrat peut être signifiée de n'importe

216 Cour d'appel, 16 janvier 2001, *Pas.*, 32, p. 187.

217 Cour d'appel, 27 avril 2005, *Pas.*, 33, p. 70 ; pourvoi rejeté par Cass., 4 mai 2006, n° 2281 du registre.

218 *J.O.C.E.*, L. 95, 21 avril 1993.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

quelle manière : par une lettre écrite, par un courriel, par une petite annonce, oralement, voire tacitement (par l'exposition d'une marchandise en vitrine, par le stationnement d'un taxi aux abords d'une gare ou d'un hôtel, etc.). Il faut seulement qu'elle se manifeste d'une manière ou d'une autre, de telle façon que le ou les destinataires aient pu en avoir connaissance : même si, dans le système juridique du Code civil, la volonté interne l'emporte sur la volonté déclarée, la prise en compte de ce que les parties ont voulu suppose que la volonté ait été extériorisée.

En droit belge où, comme nous allons le voir, l'offre à personne déterminée est traitée comme un acte juridique réceptice (c'est-à-dire ne prenant effet que par sa réception par le destinataire), on lie l'exigence d'extériorisation à cette nature juridique. En droit français, où cette conception n'est pas admise d'une manière générale, la nécessité d'une manifestation de volonté s'explique simplement par des raisons pratiques : le contrat ne peut pas se former s'il reste dans la tête des contractants. La solution est de toute façon la même.

Cependant, comme il a déjà été signalé, et comme on le verra plus en détail plus loin, la validité du contrat est très souvent subordonnée, dans le droit contemporain, au respect de certaines exigences formelles (notamment la rédaction d'un écrit, parfois par acte authentique, parfois avec certaines mentions obligatoires, *etc.*). Cela ne signifie pas nécessairement qu'une proposition de passer un tel contrat ne pourra pas être qualifiée d'offre si elle est faite sous une autre forme (par exemple, une lettre pour un contrat devant être passé par acte notarié). Si cette offre est acceptée, toujours hors des formes requises, on n'en considérera pas moins qu'un contrat a été passé, sauf à ce que ce contrat puisse, à la demande d'une des parties ou d'un tiers, être annulé pour vice de forme. Un tel contrat pourra en outre assez souvent être considéré comme une promesse de contrat, ayant une valeur en soi. Le non-respect des formes requises ne devrait aboutir à disqualifier la proposition de contracter que dans les cas, de plus en plus nombreux dans le droit contemporain, où la loi réglemente le processus de formation d'un contrat en soumettant l'offre elle-même à des formes spécifiques.

B) *Les destinataires de l'offre*

138. Offre au public. La proposition de contracter peut être adressée à une personne déterminée, mais elle peut aussi viser des personnes indéterminées, que celui qui désire passer le contrat

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ne connaît pas. Cette indétermination du destinataire n'est pas, en soi, incompatible avec la qualification d'offre : dans tous les droits européens, le fait pour un commerçant de mettre un produit en vitrine, en rayon, ou de le proposer sur un site Internet est traité comme une offre, de sorte que le fait pour un client de déclarer vouloir acheter ce produit suffit à la conclusion du contrat – le droit européen interdisant en principe, comme on l'a vu, d'assortir ce type de proposition d'une réserve d'agrément de l'acheteur[219]. En dehors de ce contexte, cependant, on se demande si les « offres » au public faites par le moyen d'une petite annonce, dans un journal ou sur un site Web, constituent des offres véritables, de sorte qu'un simple oui émanant d'une personne quelconque suffirait à former le contrat. La question ne se pose que si, par ailleurs, cette proposition remplit les conditions précédentes de fermeté et de précision – ce qui ne sera pas souvent le cas[220]. La jurisprudence luxembourgeoise ne semble pas eu avoir l'occasion de se prononcer sur cette question, qui suscite des réponses différentes en France et en Belgique.

En droit français, la Cour de cassation avait nettement affirmé que la proposition faite au public pouvait constituer une offre au même titre que celle adressée à une personne déterminée : il en résulte que « l'offre faite au public lie le pollicitant à l'égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l'offre faite à personne déterminée »[221]. Cette solution a été explicitement consacrée par le nouvel article 1114 du Code civil. En Belgique, où la jurisprudence était assez incertaine et la doctrine divisée, la valeur juridique de l'offre faite au public est désormais reconnue par l'article 5.19 du nouveau Code civil selon lequel « [l]'offre au public ne peut être modifiée ou retirée dès qu'elle a été extériorisée ». En dehors des pays du Code civil, les positions sur cette question sont également très variables d'un pays à l'autre[222], de même que dans les différents projets d'harmonisation européenne et textes internationaux[223]. Il

219 Sur le refus de vente, voy. *supra*, n° 105.

220 Comme on l'a vu, de nombreuses annonces (offres d'emploi, offres de location) sont assorties d'une réserve implicite d'agrément du cocontractant, qui, si elle est licite, suffit à disqualifier la proposition en simple invitation à faire des offres.

221 Cass. fr. (3e civ.), 28 novembre 1968, *Bull. civ.*, III, n° 507.

222 Pour un aperçu voy. H. BEALE, B. FAUVARQUE-COSSON, J. RUTGERS, D. TALLON, S. VOGENAUER, *Contract Law : Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe*, 2nd Edition, Hart Publishing, 2010, pp. 252 et s.

223 Le PDEC [art 2 :201 (2)] et le DCFR [II 4 :201 (2)] posent en principe que l'offre faite au public constitue une offre véritable ; le DCEV [art. 31 (3)], le Code Gandolfi (art. 13), la CVIM [art. 14 (2)], posent le principe contraire, sauf situations particulières.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

faut cependant avoir conscience que la question ne présente que des enjeux limités, car, même si on considère que la proposition de contrat faite au public constitue bien une offre véritable, elle n'aura pas des effets aussi complets que l'offre faite à une personne déterminée, comme nous allons le voir maintenant.

SECTION 2. LES EFFETS DE L'OFFRE

139. Distinction. Les effets de l'offre se situent sur deux plans, qu'il faut nettement distinguer. D'une part, l'offre constitue un des éléments nécessaires à la formation du contrat, qui peut à tout moment être complété pour former le contrat (**§ 1**), d'autre part, elle constitue, en elle-même et avant toute acceptation, une manifestation de volonté susceptible d'obliger l'offrant (**§ 2**). Si le premier effet, incontestable, ne mérite qu'une rapide mention, l'autre, très discuté, et qui donnait lieu jusqu'aux récentes réformes à des solutions différentes en France et en Belgique, doit être examinée plus longuement.

§1. L'offre comme élément du contrat en formation

140. Un « oui » suffit. Le premier enjeu de la qualification d'offre appliquée à une proposition de contracter est qu'un simple « oui » formulé par son destinataire suffit à former le contrat. Si, en revanche, faute de précision ou de fermeté, la proposition n'est qu'une simple invitation à discuter, l'accord donné par l'autre ne formera pas le contrat.

Selon la position qui est désormais consacrée aussi bien en droit belge qu'en droit français, ce premier effet de l'offre se produira aussi bien lorsque l'offre est faite au public que lorsqu'elle est faite à une personne déterminée. Si je vois dans le journal une petite annonce qui m'intéresse, proposant un bien déterminé à un prix déterminé, il suffit que je sois le premier à accepter pour que le contrat soit formé, sans que l'auteur de l'annonce puisse me dire qu'il a changé d'avis.

L'intérêt pratique de cette solution est cependant assez limité. D'une part, l'auteur de l'annonce pourra toujours prétendre qu'il a vendu à quelqu'un d'autre et l'acheteur potentiel aura bien du mal à prouver le contraire. D'autre part, il sera assez fréquent que, dans le cas d'une proposition au public, on puisse considérer qu'il y a une réserve implicite d'agrément, dès lors que le contrat comporte un *intuitu personae* marqué (contrat de travail, contrat de bail). Dès lors, une telle proposition ne pourra

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

pas être qualifiée d'offre, et c'est, à l'inverse, la réponse du candidat au travail ou au logement qui pourra être considérée comme une offre (je veux bien travailler pour vous à tel salaire, ou louer votre appartement à tel prix, si vous en êtes d'accord).

§ 2. L'offre comme manifestation de volonté obligeant l'offrant

141. Problématique. La question est ici de savoir si l'offre, en elle-même, avant même d'avoir été acceptée (donc de former le contrat) produit des effets juridiques. Plus précisément, il s'agit de savoir si elle lie l'offrant, si elle fait naître une obligation à son égard, de telle sorte qu'il ne pourrait pas librement la révoquer. Cette question a été et continue d'être très discutée, parce qu'elle est liée à une question plus fondamentale qui est celle de savoir si on peut s'engager par sa volonté unilatérale. On exposera d'abord les termes de la discussion, avant de voir quelles solutions sont consacrées dans les pays du Code civil.

A) *La discussion*

142. Politique juridique : liberté ou sécurité. La question est d'abord une question de politique juridique, qui amène à trancher entre des intérêts opposés. D'un côté, il y a la liberté de l'offrant, qui voudrait pouvoir changer d'avis jusqu'à la conclusion du contrat : il a fait une proposition à quelqu'un à certaines conditions, mais il peut, avant que cette proposition ne soit acceptée, vouloir renoncer à son projet de contrat, ou trouver quelqu'un d'autre qui est prêt à accepter des conditions plus favorables pour lui (par exemple, un acheteur potentiel qui est prêt à payer plus cher). Peut-on admettre que sa liberté d'agir soit limitée alors que le destinataire de l'offre n'a pas fait connaître sa position ? Mais, d'un autre côté, le destinataire de l'offre peut espérer une certaine sécurité : il veut se donner un minimum de temps pour réfléchir, confronter l'offre qui lui a été faite avec d'autres propositions. Peut-être va-t-il, en comptant sur le maintien de cette offre pendant un certain temps, renoncer à d'autres propositions qui lui sont faites en parallèle. Peut-être aussi va-t-il engager des frais dans la perspective du contrat qu'il souhaite passer (par exemple, des frais de voyage pour aller voir le bien qui lui est proposé). Peut-on admettre dans ces circonstances que l'autre puisse librement changer d'avis ?

Les rédacteurs du Code civil, tout imprégnés de l'idée de liberté, pensaient que seul le contrat pouvait engager. Ils suivaient ici l'idée de Pothier selon lequel « la pollicitation, aux termes du droit naturel,

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ne produit aucune obligation proprement dite ; et celui qui a fait cette promesse peut s'en dédire tant que cette promesse n'a pas été acceptée par celui à qui elle a été faite »[224]. C'est sans doute pour cela du reste qu'ils ne s'étaient pas préoccupés du processus de formation du contrat ni de la période précontractuelle, qui constituait pour eux une sorte de néant juridique. Progressivement, cependant, on a assisté à une prise en compte des intérêts du destinataire de l'offre, qui a amené à poser des limites au principe de la libre révocabilité de l'offre et à sanctionner, dans certains cas, le retrait de l'offre avant la formation du contrat. Dans la période moderne, le souci d'assurer une certaine sécurité au destinataire de l'offre a gagné du terrain dans les pays du Code civil, avec la montée en puissance dans le droit des contrats, partout en Europe, de l'exigence de bonne foi dans les relations contractuelles (y compris lors de la phase de formation) et de l'idée de confiance, qui amène à fonder la force obligatoire du contrat en se plaçant non pas seulement du côté de celui qui s'engage, mais aussi du côté de celui qui reçoit l'engagement[225]. Aussi bien, l'évolution des solutions dans les pays du Code civil rejoint-elle très largement celle qu'on peut observer dans d'autres droits nationaux, et qui se reflète dans tous les textes, règles-modèles et projets européens.

Reste cependant à savoir comment on va fonder sur le plan de la technique juridique ces limites, aujourd'hui bien admises, à la liberté de l'offrant de retirer son offre tant qu'elle n'est pas acceptée. De ce point de vue, plusieurs pistes ont pu être explorées, et elles sont souvent, aujourd'hui, combinées.

143. Responsabilité extracontractuelle ? Une première manière de fonder les limites à la libre révocabilité de l'offre s'appuie sur l'article 1382 du Code civil (1240 dans le Code civil français), texte de base de la responsabilité civile extracontractuelle. On maintient entier le principe selon lequel l'offre ne fait naître aucun engagement tant qu'elle n'est pas acceptée, mais on admet que le retrait de l'offre peut, dans certaines circonstances (par exemple, s'il est particulièrement brutal et sans motif), constituer une faute délictuelle, qui, si elle cause un préjudice au destinataire de l'offre, entraînera la condamnation de son auteur à des dommages et intérêts. On retrouve ici une manière de raisonner qui est couramment utilisée

224 Pothier, *Traité des obligations*, n° 4.

225 Voy. *supra*, n° 97.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pour sanctionner la rupture de certaines relations familiales auxquelles le système juridique n'accorde pas force obligatoire (les fiançailles et le concubinage). Elle permet de même, comme nous le verrons plus loin, de justifier l'allocation de dommages et intérêts en cas de rupture abusive des pourparlers[226]. Appliqué à l'offre, ce recours au droit commun de la responsabilité extracontractuelle présente l'avantage de préserver la cohérence d'un système où, traditionnellement, seul le contrat (donc l'accord de volontés) est une source volontaire d'obligations. Mais il est clair que cette technique, respectueuse de la liberté de l'offrant, ne confère qu'une sécurité limitée au destinataire de l'offre. D'une part, il n'est pas possible de poser des règles générales déterminant dans quels cas la révocation de l'offre est fautive ; cela ne peut guère se déterminer qu'au cas par cas, et laisse une large place à l'appréciation des juges du fond. D'autre part, le droit de la responsabilité civile conduit assez naturellement à ne reconnaître comme sanction de la révocation fautive de l'offre que l'allocation de dommages et intérêts. Même si ce n'est pas complètement impossible, il paraît difficile de justifier sur ce terrain que le contrat puisse être formé contre le gré de l'offrant qui a retiré son offre.

144. Engagement unilatéral ? Une autre voie, qui paraît plus protectrice du destinataire de l'offre, consiste à voir dans l'offre, au moins dans certains cas, la source volontaire d'un véritable engagement, d'une véritable obligation. Pour adopter une terminologie moderne – et importée comme on l'a vu de la science juridique germanique – on cherche alors à voir dans l'offre un véritable acte juridique, et non un simple fait juridique générateur de responsabilité. Cette approche était évidemment très difficile à admettre pour les auteurs du XIXe siècle, en raison du présupposé selon lequel une manifestation de volonté unilatérale ne pouvait pas faire naître d'obligation à la charge de son auteur.

De nos jours, cependant, comme on l'a vu[227], le postulat de l'impossibilité des engagements unilatéraux a largement perdu de sa force, et il est démenti, dans les trois pays du Code civil, par de nombreuses solutions du droit positif. Il ne paraît donc plus impossible de justifier les limites à la révocabilité de l'offre en analysant celle-ci, dans certains cas au moins, comme un acte juridique

226 Voy. *infra*, n° 176.

227 Voy. *supra*, n°s 63 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

porteur d'un engagement unilatéral. Depuis De Page, la doctrine belge n'a pas hésité à franchir le pas, et nous verrons que cette position a été consacrée par la Cour de cassation de Belgique. La doctrine française est en revanche, d'une manière générale, restée plus réservée sur cette source d'obligations et a tendance à ne l'admettre que dans les cas expressément prévus par les textes. S'agissant de l'offre, la majorité des auteurs continuent d'y voir un simple fait juridique ne créant pas par principe d'obligation, mais dont le retrait abusif est susceptible d'entraîner la responsabilité délictuelle de son auteur[228]. Dans une thèse importante de 1970, un auteur[229] a proposé de distinguer : si l'offre est assortie d'un délai déterminé pour l'acceptation, on pourrait l'analyser comme un véritable acte juridique générateur d'une obligation de maintien ; l'offre non assortie d'un délai ne constituerait, elle, qu'un simple fait juridique. Si cette distinction est parfaitement soutenable, elle ne se traduisait pas de manière aussi tranchée dans les solutions de la jurisprudence française, et la réforme du droit des obligations ne l'a pas consacrée aussi nettement.

145. **Avant-contrat ?** Au XIXe siècle, à l'époque où il semblait exclu d'admettre un engagement unilatéral, Demolombe, auteur d'un célèbre traité de droit civil, avait cherché à tourner la difficulté en tentant de ramener l'offre à un contrat[230]. Nous verrons un peu plus loin que dès avant le contrat définitif, les deux futurs contractants peuvent passer des contrats préliminaires (parfois appelés avant-contrats) ; l'un de ces avant-contrats est la promesse unilatérale de contrat, par laquelle l'un des deux s'engage d'ores et déjà à passer le contrat définitif tandis que l'autre (qui accepte d'ores et déjà cette promesse) dispose d'une option lui permettant, dans un certain délai, de passer ou non ce second contrat. Pour Demolombe, lorsque l'offre de contracter était assortie d'un délai, elle pouvait s'analyser en une promesse unilatérale tacite de passer le contrat offert : l'offrant promet de passer le contrat si le destinataire de l'offre lui répond positivement dans le délai fixé, et ce destinataire accepte tacitement cette « promesse ». Cette analyse a été beaucoup raillée en raison de son caractère artificiel. Elle n'est cependant pas si absurde : celui qui reçoit une offre avec délai comprend bien qu'il a un temps de réflexion, qu'il n'a aucun intérêt à refuser puisqu'elle est dans son intérêt exclusif. Ainsi, entre la véritable promesse unilatérale, formellement acceptée par son bénéficiaire, et l'offre assortie d'un délai, la différence est souvent plus de forme que de fond.

228 Pour un état complet de la question voy. J. Ghestin, G. Loiseau et Y.-M. Serinet, *La formation du contrat*, t. 1, *Le contrat – le consentement*, 4e éd, Paris, LGDJ, 2013, n°s 856 et s.

229 J.-L. Aubert, *Notions et rôle de l'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat*, coll. Bibliothèque de droit privé, Paris, LGDJ, 1970.

230 C. Demolombe, *Traité des contrats et des obligations conventionnelles en général*, t. XXIV, Paris, Imprimerie générale A. Lahure, 1877, n° 64.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

B) *Les solutions*

146. Différents points. Bien que le débat ait été souvent centré sur la question de la révocabilité de l'offre, il a d'autres incidences, notamment sur le point de savoir si l'offre devient caduque en cas de décès de l'offrant ou par suite du dépassement du délai. Sur ces différentes questions, il n'existe que peu de décisions luxembourgeoises, et il faut donc principalement se référer aux solutions admises en France et en Belgique, qui divergent sur certains points. Les projets européens et textes internationaux peuvent également servir de guide.

1) *La révocabilité de l'offre*

147. Révocation et rétractation. Il faut d'emblée bien distinguer deux questions. La première est celle de savoir à partir de quand l'offre prend effet. Dans tous les systèmes qui traitent l'offre comme un acte juridique, il est admis que cet acte n'acquiert force obligatoire qu'à partir du moment où la proposition a été reçue par son ou ses destinataires du moins lorsqu'elle est faite à une ou plusieurs personnes déterminées : l'offre est un acte réceptice[231]. Il en résulte que, jusque-là, l'offrant peut toujours rétracter son offre (par exemple, en envoyant au destinataire un mail avant qu'il ne reçoive la lettre contenant l'offre)[232]. La même solution s'impose *a fortiori* si on ne voit dans l'offre qu'un simple fait, car on ne voit pas en quoi le fait de retirer l'offre avant qu'elle ne parvienne au destinataire, alors qu'elle n'a créé chez celui-ci aucune attente, pourrait constituer une faute délictuelle. Aussi bien la solution est-elle consacrée par le nouvel article 1115 du Code civil français et par l'article 5.19 du nouveau Code civil belge. Toute autre est la question de savoir si l'offre peut être retirée une fois qu'elle est parvenue au destinataire[233]. Pour éviter toute confusion, il vaudrait mieux, dans ce cas, parler de la question de la révocation de l'offre, et réserver le terme de rétractation au retrait de l'offre avant qu'elle ne soit parvenue à son destinataire, mais les textes ne distinguent pas toujours.

231 Voy. *supra*, n° 163.

232 Voy. p. ex. en ce sens : UNIDROIT art. 2-1-3 « L'offre, même irrévocable peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l'offre ». Le projet français de 2015 consacre la même solution dans son article 1115.

233 L'utilisation des termes « rétractation » et « révocation » pour désigner ces deux situations n'est qu'une convention de langage, qui n'est pas toujours suivie (Voy. p. ex. le projet français de 2008, qui parlait à l'inverse de rétractation pour désigner la révocation après réception de l'offre). L'essentiel est de bien distinguer les deux situations.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

148. Principe et exceptions. Traditionnellement, dans le système du Code civil, le principe est celui de la révocabilité de l'offre, qu'on relie à l'impossibilité de s'engager unilatéralement : seul le contrat, accord de volontés, peut rendre débiteur. L'offrant peut donc retirer son offre jusqu'à ce qu'elle ait été acceptée. Ce principe, bien admis par la jurisprudence luxembourgeoise[234], continuait d'être posé par la jurisprudence française Mais en France, ce principe avait été largement vidé de sa substance par diverses exceptions. Tout d'abord, si l'offrant avait fixé un délai pour l'acceptation, la jurisprudence admettait depuis le XIXe siècle qu'il ne pouvait pas la révoquer pendant ce délai. Dans un premier temps, la Cour de cassation avait posé que « si une offre de vente peut en principe être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s'est expressément engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque »[235], mais, plus récemment, elle avait fait disparaître de cette formule le mot « expressément », en considérant que le seul fait de fixer un délai impliquait un tel engagement[236]. Mais ensuite, même si l'offre n'est pas assortie d'un délai, il avait parfois été jugé qu'elle devait être maintenue pendant un délai raisonnable. On retrouve ces solutions après la réforme dans le nouvel article 1116 selon lequel l'offre « ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable ». Les mêmes solutions se retrouvent en Belgique, où elles apparaissent comme une conséquence logique de la position de la Cour de cassation qui analyse l'offre comme un engagement unilatéral[237] : l'offre de contracter est irrévocable si elle a été faite avec délai, mais aussi, même si l'offrant n'a pas fixé de délai déterminé pour l'acceptation, pendant un délai raisonnable[238]. Ces solutions sont désormais consacrées par l'article 5.19 du nouveau Code civil belge. Elles se retrouvent du reste dans la plupart des droits nationaux en Europe, et elles sont reprises, avec des formulations diverses, dans tous les projets européens et dans les textes internationaux[239]. Un peu différemment, la proposition de règlement portant droit commun européen de la vente prévoyait

234 Trib. Luxembourg 7 avril 1948, Pas. 14. P. 399 ; Cour d'appel, 27 avril 2005, *Pas.*, 33, p. 70. L'affirmation n'est qu'incidente, la Cour n'étant pas dans cette affaire confrontée à un cas de révocation d'une offre.

235 Cass. fr. (3e civ.), 10 mai 1968, n° 66-13187.

236 Cass. fr. (3e civ.), 7 mai 2008, n° 07-11690.

237 Cass. be., 9 mai 1980, *Pas. be.*, I, p. 1120, préc.

238 Wéry, n° 133.

239 Voy. p. ex. : PDEC art. 2 :202 ; DCFR, art. II-4 :202 ; DCEV, art. 32.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

que l'offre est irrévocable si l'offrant l'a expressément indiqué, s'il a fixé un délai ou si « le destinataire de l'offre était raisonnablement fondé à la croire irrévocable et s'il a agi sur la foi de l'offre ». La jurisprudence luxembourgeoise pourrait s'inspirer d'une telle formule, qui marque nettement la montée en droit européen d'un modèle de contrat fondé sur l'idée de confiance[240].

Dans les nouveaux textes de droit français ou belge, le principe de l'irrévocabilité de l'offre pendant un certain délai est affirmé sans distinguer selon que l'offre est faite à personne indéterminée ou au public. Il faut cependant observer que ce principe ne n'aura qu'une portée limitée lorsque l'offre est faite au public : même si on considère qu'une petite annonce suffisamment précise et ferme constitue une véritable offre, il va de soi qu'une telle proposition, qui ne crée aucune confiance particulière chez ses multiples destinataires (lesquels peuvent toujours s'attendre à ce que l'offre soit acceptée par quelqu'un d'autre), peut toujours être retirée par son auteur.

149. Sanctions de la révocation illicite. S'il existe, entre les différents droits, et notamment entre les droits des pays du Code civil, une certaine unité quant aux cas où l'offre est irrévocable, il n'en va pas de même quant à la sanction d'une révocation illicite. La question est de savoir si, dès lors que le destinataire de l'offre accepte celle-ci dans le délai qui lui était imparti mais après la révocation, on doit considérer que le contrat est néanmoins formé (contre le gré de l'offrant) ou si le destinataire victime de la révocation illicite peut seulement obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il subit. La réponse dépend dans une certaine mesure du fondement qu'on assigne à l'irrévocabilité de l'offre. Si on estime que l'offre fait naître un véritable engagement unilatéral, on sera porté à admettre que la rupture de cet engagement, qui lie l'offrant, doit être sans effet et qu'elle n'empêchera pas la formation du contrat. Au contraire, si on voit dans l'offre un simple fait juridique, dont la révocation peut, dans certaines circonstances, constituer une faute délictuelle, la sanction « naturelle » sera la condamnation à des dommages et intérêts – même si on ne peut pas complètement exclure une réparation en nature consistant dans la conclusion du contrat. Mais, au-delà du fondement technique, la position à prendre est liée, plus fondamentalement, à la conception qu'on se fait du rôle de la volonté et de la force obligatoire de l'engagement. Dans la conception volontariste traditionnelle du contrat, on répugnera à admettre qu'un contrat puisse se former alors qu'une des parties a finalement exprimé sa volonté de ne pas le passer. Si en revanche,

[240] Sur la confiance comme fondement possible de la force obligatoire du contrat, voy. *supra*, n° 97.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

on pense que la force obligatoire est liée également à d'autres facteurs, et notamment à la confiance que chaque partie peut avoir dans le comportement ou les paroles de l'autre, il devient possible d'admettre que le retrait de la volonté puisse rester sans effet. C'est la solution que consacrent les deux plus récents projets européens, le DCFR du groupe Von Bar et le projet de règlement sur la vente, qui indiquent que la révocation de l'offre est « sans effet » si elle intervient dans l'un des cas où l'offre est irrévocable. En France, en revanche, doctrine et jurisprudence restaient majoritairement inscrites dans une logique volontariste, et, en dépit de certaines formules ambiguës, aucune décision de la Cour de cassation n'avait jamais admis la conclusion du contrat contre le gré de l'offrant[241]. Certains projets français de réforme du droit des contrats n'avaient cependant pas hésité à consacrer la conclusion forcée du contrat[242], mais le texte finalement retenu dans le cadre de la réforme de 2016 prévoit que la rétractation illicite de l'offre empêche la conclusion du contrat et engage seulement la responsabilité extracontractuelle de son auteur (C. civ. fr., art. 1116). De ce point de vue, la révocation de l'offre en violation de l'obligation de maintien se distingue de la révocation d'une promesse de contrat pour laquelle, nous le verrons, la réforme de 2016 a consacré le principe de la formation forcée du contrat[243]. En Belgique, en revanche, certains auteurs se prononçaient en faveur de la formation forcée du contrat malgré le retrait de l'offre[244], ce qui était logique compte tenu de la valeur d'engagement unilatéral reconnue à l'offre, mais la jurisprudence n'avait semble-t-il jamais eu l'occasion de se prononcer sur la question. L'article 5.19 du nouveau Code civil belge ne dit rien sur la sanction de la révocation illicite. Il appartiendra aux tribunaux luxembourgeois, s'ils étaient confrontés au problème, de choisir la solution qui correspond à la conception qu'ils se font du contrat, et à la place respective qu'ils veulent faire à la volonté de celui qui s'engage et à la confiance dans la parole de l'autre.

241 Un arrêt de 1958, parfois cité en ce sens, concernait en réalité un cas où l'acceptation était intervenue avant la révocation [Cass. fr. (1re civ.), 17 décembre 1958, *D.*, 1959, p. 33].

242 Projet Terré, art. 18 : « La révocation de l'offre faite à personne déterminée, en violation de cette obligation de maintien, n'empêche pas la formation du contrat » ; projet Catala, art. 1105-4.

243 Voy. *infra*, n° 186.

244 Wéry, n° 135 ; Van Ommeslaghe, n° 320.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

2) *La caducité de l'offre*

150. Problématique. La question est ici de savoir combien de temps l'offre demeure effective lorsqu'elle n'est pas révoquée par son auteur. Deux types d'événements semblent de nature à faire tomber automatiquement l'offre, à la rendre caduque : d'une part, le décès de l'offrant, et d'autre part, l'écoulement du délai fixé par l'offrant.

151. Caducité liée au décès ou à l'incapacité. Le destinataire de l'offre peut-il encore l'accepter après le décès de l'offrant ? L'analyse qu'on fait de l'offre est ici déterminante. Si on voit dans l'offre un simple fait juridique sans effet obligatoire, on doit logiquement considérer que l'offre ne tient que tant que la volonté de son auteur subsiste : le décès faisant disparaître cette volonté, il doit rendre l'offre caduque, et toute acceptation postérieure doit être regardée comme sans effet, sauf si les héritiers sont d'accord pour reprendre l'offre faite par le défunt. La même solution doit valoir en cas d'incapacité de l'offrant, dès lors que celui-ci n'est plus en état d'émettre une volonté valable. En revanche, si on considère que l'offre fait naître un engagement unilatéral, cet engagement s'impose aux héritiers comme toutes les obligations nées sur la tête de leur auteur[245]. Logiquement, la doctrine belge, qui raisonne à partir de la qualification d'engagement unilatéral admis par la Cour de cassation, se prononçait dans ce sens[246]. L'article 5.19 du nouveau code belge ne dit rien de la question. La solution était beaucoup plus discutée en France, où la nature juridique de l'offre est beaucoup plus incertaine. Après avoir admis en 1983 le maintien d'une offre après le décès de l'offrant[247], la Cour de cassation française était revenue sur cette solution en 1989[248]. Mais, dans un arrêt de 1997, elle avait, à nouveau, affirmé que le décès de l'offrant n'entraînait pas la caducité de l'offre dès lors que celle-ci était assortie d'un délai[249]. Cet arrêt, rendu au visa de l'article 1134 du Code civil était sans doute, dans la jurisprudence française, la prise de position la plus nette en faveur de l'idée de force obligatoire de l'offre. Les divers projets français de réforme du droit des contrats étaient

245 Sur la transmission aux héritiers des engagements contractuels, voy. *infra*, n°s 1036 et s.

246 WÉRY, n° 136 ; VAN OMMESLAGHE, n° 320.

247 Cass. fr., 9 novembre 1983, n° 82-12996.

248 Cass. fr., 10 mai 1989, n° 87-18130.

249 Cass. fr. (3e civ.), 10 décembre 1997, n° 95-16461.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

très divisés sur cette question[250], mais finalement l'ordonnance de 2018 a prévu la caducité automatique de l'offre en cas de décès ou d'incapacité de l'offrant, et la loi de ratification de 2018 a étendu la solution au cas de décès du destinataire (C. civ. fr., art. 1117), ce qui marque clairement que les auteurs de la réforme n'ont pas considéré l'offre comme un véritable acte juridique unilatéral. En toute hypothèse, conformément au droit commun, qui exclut la transmission aux héritiers des engagements *intuitu personae*, l'offre doit devenir caduque si le contrat proposé était étroitement lié à la personne du défunt[251]. Les solutions applicables au décès et à l'incapacité de l'offrant personne physique devraient également s'appliquer en cas de dissolution de l'offrant personne morale, ou de faillite.

152. Caducité liée à l'écoulement du temps. Quelle que soit l'analyse qu'on en donne, une offre de contrat n'est pas destinée à se maintenir indéfiniment. Il est traditionnellement admis que, si elle est assortie d'un délai, l'offre deviendra automatiquement caduque à l'expiration de ce délai si elle n'a pas été acceptée avant, sans que l'offrant ait besoin de la révoquer expressément. Les solutions sont moins claires si aucun délai n'a été fixé ; il paraît opportun de considérer que l'offre tombe au bout d'un délai raisonnable, qui sera, en cas de contestation, apprécié par le juge. Les projets européens sont en ce sens[252], et c'est également la solution consacrée par nouveaux textes français et belges[253] En toute hypothèse, il faut admettre la caducité de l'offre lorsque son destinataire décide de la rejeter : l'offrant peut dès lors se considérer comme délivré de son engagement, et une acceptation ultérieure serait sans effet[254].

[250] Pour la caducité liée au décès : art. 16 du projet Terré, art. 1118 du projet de 2015 ; pour le maintien de l'offre après décès lorsqu'elle est faite avec délai : art. 1105-3 du projet Catala.

[251] Il est évident par exemple que l'offre faite par une personne âgée et malade d'embaucher une assistante à domicile pour lui prodiguer des soins ne lie pas les héritiers après le décès de la personne.

[252] Voy., p. ex., l'article 15 du Code européen des contrats « si aucun délai n'est indiqué, après l'écoulement d'une certaine période que l'on pourra considérer comme raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire ou de la coutume, ainsi que de la vitesse des moyens de communications auxquels on a recouru ».

[253] C. Civ. fr., art. 1117, C. civ. be., art. 5.19.

[254] Dans ce sens, not., les articles 2 :203 des PDEC, II-4 :203 du DCFR et 33 du DCEV, l'article 5.19 du nouveau Code civil belge.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'offre de contracter, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 175-195
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Chapitre II
L'acceptation du contrat

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

153. Problématique. Dans l'immense majorité des cas, l'acceptation du contrat ne suscite aucune difficulté : la personne à qui l'offre était faite donne une réponse positive, et cela suffit à former le contrat. Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples : on se demande parfois s'il y a vraiment eu acceptation, et, lorsque celle-ci a bien eu lieu, quels sont ses effets.

SECTION 1. LES CONDITIONS D'EXISTENCE DE L'ACCEPTATION

154. Fond et forme. On ne peut considérer qu'il y a eu acceptation du contrat que si la volonté de conclure le contrat est manifeste, et que si elle est parfaitement concordante à l'offre.

§1. Une volonté manifeste

155. Volonté expresse ou tacite. Dans un système juridique qui consacre le principe du consensualisme, la réponse positive à une offre de contracter peut se manifester de diverses manières. Elle peut être expresse, ce qui s'entend aussi bien de la rédaction ou de la signature d'un écrit que (sous réserve d'importantes difficultés de preuve) d'une affirmation verbale. Mais elle peut aussi être tacite[255], et, dans la pratique, elle se déduira très souvent de l'exécution du contrat par celui à qui il a été proposé.

Il est vrai que, dans un nombre croissant d'hypothèses, la loi exige le respect de formes particulières pour la conclusion du contrat, et notamment la rédaction d'un écrit. Mais, comme on l'a déjà souligné à propos de l'offre, le non-respect de ces exigences ne se traduira pas par l'inexistence du contrat, mais seulement par sa nullité : si le contrat a été accepté sans respecter les formes, on ne pourra pas soutenir que le contrat n'a pas été passé, le contractant qui veut échapper au contrat devra agir en justice pour en obtenir l'annulation[256]. La différence n'est pas purement théorique car, comme on le verra plus loin, la nullité pour vice de forme est le plus souvent une nullité relative qui ne peut être soulevée que par le contractant que la loi voulait protéger en édictant les formes. L'inexistence d'un contrat non accepté pourrait en revanche être soulevée par n'importe laquelle des deux parties (y compris l'offrant qui pourrait essayer de se libérer du contrat en soutenant que son offre n'a jamais été acceptée).

156. Silence. Si l'acceptation peut être tacite, et résulter du comportement du contractant, il est traditionnellement admis qu'en principe le silence gardé par celui qui reçoit l'offre ne vaut pas acceptation. En droit, qui ne dit mot ne consent pas. La Cour de cassation

255 Trib. Luxembourg, 5 mars 2019, n° TAL-2018-01095.

256 Voy. *infra*, n° 446.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

française l'a affirmé à maintes reprises[257], et la solution est également admise sans discussion en Belgique[258]. Elle est commune du reste à la plupart des droits nationaux, ainsi qu'aux différents projets nationaux et européens[259]. Ce principe est cependant écarté, partout, chaque fois que des circonstances particulières permettent d'interpréter le silence comme une acceptation[260]. Ces solutions sont désormais expressément consacrées, dans des termes légèrement différents, dans le Code civil français (art. 1120)[261] et dans le nouveau Code civil belge (art. 5.20)[262]. La jurisprudence luxembourgeoise récente offre de nombreux exemples de ce « silence circonstancié » qui emporte acceptation du contrat[263]. Il en va ainsi, notamment, en vertu des usages professionnels, ou en raison des rapports antérieurs entre les parties. Si, par exemple, un commerçant a l'habitude, chaque mois, de commander à un de ses fournisseurs une certaine quantité de marchandises, et que, un mois donné, il ne répond pas à l'offre de livraison que lui fait le fournisseur, celui-ci est fondé à penser que c'est parce qu'il est d'accord. Un arrêt de la Cour d'appel, en date du 18 décembre 2013, rappelle ainsi que, en matière commerciale, le silence peut valoir acceptation, en fonction des circonstances souverainement acceptées par les juges du fond : « l'acceptation de la teneur de la correspondance commerciale peut résulter du silence du destinataire d'une lettre. Il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part. Cette obligation se justifie par l'usage selon lequel, entre commerçants qui se connaissent et sont déjà en relations d'affaires, ou entre lesquels des pourparlers sont en cours, l'un des correspondants ne peut laisser l'autre dans l'incertitude en s'abstenant de répondre aux lettres qu'il reçoit. Compte tenu de la rapidité nécessaire des

257 Solution constante au moins depuis Cass. fr. (civ.), 25 mai 1870, *S.*, 1870, I, p. 341 ; dans la période récente voy. p. ex. : Cass. fr. (1re civ.), 5 avril 1993, *Bull.*, I, n° 181 ; Cass. fr. (1re civ.), 24 mai 2005, *Bull.*, n° 223.

258 WÉRY, n° 162 ; VAN OMMESLAGHE, n° 329.

259 Unidroit, art. 2-1-6 (1) ; CVIM, art. 18 ; PEDC, art. 2:204 ; DCFR, art. II-4:204 ; DCEV, art. 34. Projets français : Catala, art. 1105-6 ; Terré, art. 20 ; Chancellerie 2015, art. 1121.

260 Cass. fr. (1re civ.), 24 mai 2005, *Bull.*, n° 223.

261 « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières. »

262 « Une acceptation ne peut être déduite d'un silence, sauf s'il en résulte autrement de la loi, des usages ou des circonstances concrètes. »

263 Cass., 9 juin 2005, *D.A.O.R.*, 2009, n° 90, p. 139 et note D. PHILIPPE confirmant Cour d'appel, 26 mai 2004, *D.A.O.R.*, 2009, n° 90, p. 144 ; Trib. Luxembourg, 16 mai 2008, *D.A.O.R.*, 2009, n° 90, p. 147 ; Trib. Luxembourg, 11 mai 2007, rôle n° 105558, cité au *BIJ*, 2007, p. 110.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

transactions commerciales, il serait anormal de ne pas faire connaître immédiatement un refus ou une désapprobation »[264]. Ces considérations fondent la théorie de la facture acceptée, qui permet, dans les relations entre commerçants, de déduire du silence gardé à la réception d'une facture à la fois un accord au sujet de l'existence et des modalités d'un contrat et un accord sur la créance affirmée par celui qui a émis la facture en exécution de ce contrat[265]. Cependant, l'arrêt de 2013 précise que la règle selon laquelle le silence vaut acceptation entre commerçants « n'est pas une règle absolue. Les commerçants ne sont pas obligés de répondre à toutes les lettres qu'ils reçoivent, s'ils ne les approuvent pas. Ils peuvent notamment établir que leur silence s'explique par d'autres circonstances ». Le silence vaudra certainement acceptation, en revanche, s'il a été antérieurement convenu entre les parties, par exemple dans le contrat-cadre qui régit leurs relations commerciales, qu'il en sera ainsi. Mais il ne suffirait pas que l'auteur de l'offre ait, unilatéralement, déclaré qu'à défaut de réponse dans un certain délai, le destinataire serait censé avoir accepté : cette manifestation de volonté unilatérale ne peut pas lier l'autre partie. Lorsqu'elle vise un consommateur, cette pratique peut tomber sous le coup de la prohibition des clauses abusives, ou être réprimée au titre des pratiques commerciales déloyales[266].

Traditionnellement, en droit français, on admet également que le silence vaut acceptation lorsque l'offre est faite dans l'intérêt exclusif du destinataire, celui-ci n'ayant aucune raison de refuser le contrat. Cette solution, qui n'a pas été reprise lors de la réforme de 2016, est cependant très contestable, car un contrat ne faisant naître à titre principal aucune obligation pour l'une des parties peut se révéler ultérieurement désavantageux pour elle. Ainsi, un prêt à titre gratuit peut exposer l'emprunteur à des frais d'entretien de la chose ou le rendre responsable des dommages causés par la chose. Une convention d'assistance bénévole – dont la Cour de cassation française admet qu'elle peut se former sans que l'assisté n'ait rien dit ni rien fait pour l'accepter – peut de même obliger l'assisté à réparer le dommage causé à celui qui l'a aidé. L'idée que le silence suffit à former de tels contrats ne devrait donc jouer que dans les cas où c'est le contractant silencieux qui se prévaut du contrat : mais c'est alors la demande d'exécution qui vaut acceptation tacite[267].

---

264 Cour d'appel, 18 décembre 2013, n° 39360, *Pas.*, 36, p. 737, obs. P. Ancel.

265 Pour des applications récentes de cette théorie fréquemment invoquée devant les juridictions luxembourgeoises : Cour d'appel, 2 avril 2014, n° 37655 ; Cour d'appel, 20 avril 2021, n° 46/21 ; Trib. Luxembourg, 15 février 2022, n°2022TALCH01/00042.

266 C. Consomm., art. L. 122-7 (6) qui considère comme une pratique agressive en toutes circonstances le fait « d'exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation ».

267 Par exemple dans le cas du cautionnement, lorsque le créancier demande le paiement à la caution alors qu'il n'a pas préalablement exprimé son consentement au contrat : Trib. Luxembourg, 16 mai 2007, n° 103930, *BIJ*, 2007, p. 183.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§ 2. Une volonté concordante à l'offre

157. Problème des divergences. En principe, l'acceptation ne forme le contrat que si elle est exactement conforme à ce qui a été proposé. Si vous m'offrez de me vendre votre maison au prix de 500 000 €, et que je vous réponds que je veux bien l'acheter, mais seulement au prix de 450 000 €, ce n'est pas une acceptation. Ma réponse constitue alors une contre-offre : elle inverse la position des parties dans la négociation contractuelle, faisant de moi l'offrant de l'achat au nouveau prix, et de vous le destinataire, qui peut ou non accepter cette offre, ou me faire, à son tour, une nouvelle offre (475 000 € par exemple)[268]. La solution est évidente lorsque la divergence porte sur des points essentiels du contrat (dans l'exemple donné : le prix de vente). Mais que décider si les divergences ne portent que sur des points de détail ? Par exemple, nous sommes d'accord sur la chose et le prix, mais vous me proposez de libérer les lieux le 1er octobre, alors que je veux avoir la jouissance de la maison dès le 1er septembre. Cette divergence mineure empêchera-t-elle le contrat de se former, alors que, sur le point en désaccord (la date de délivrance du bien vendu), la loi contient des règles supplétives qui pourraient s'appliquer ? Traditionnellement, dans les pays du Code civil, il était admis que toute divergence, même mineure, empêchait la formation du contrat : les règles supplétives contenues dans la loi ne sont destinées à s'appliquer que si les parties n'ont pas envisagé la question, elles ne permettent pas de régler des désaccords ouverts. Cette position s'était maintenue en France avant la réforme[269], et elle est reprise sans nuance par le nouvel article 1118 du Code civil. En Belgique, la doctrine contemporaine était beaucoup plus nuancée, et la jurisprudence semblait faire la différence entre les désaccords sur les éléments essentiels ou ceux que les parties considèrent comme substantiels – qui empêchent toujours la formation du contrat – et ceux qui ne portent que sur des éléments accessoires, qui n'y feraient pas obstacle[270]. Cette solution est reprise dans l'article 5.20 du nouveau Code civil, selon lequel « [l]'acceptation est toute déclaration ou autre comportement du destinataire de l'offre qui exprime l'accord sur celle-ci,

268 Voy. p. ex. : Trib. Diekirch, 27 juillet 2021, n° TAD-2018-0069.

269 Voy. p. ex. TERRÉ, SIMLER, LEQUETTE 2013, n° 121 ; P. MALAURIE, L. AYNES, P. STOFFEL-MUNCK, *Droit civil : Les obligations*, 6e éd., Issy les Moulineaux, Defrénois, 2013, n° 473 (cité *infra*, MALAURIE AYNES STOFFEL-MUNCK 2013).

270 Voy. sur cette question les développements nourris de P. VAN OMMESLAGHE, n° 325, les auteurs et les décisions citées.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

sans ajouts, limitations ou autres modifications *concernant des éléments essentiels ou substantiels* ». Tous les projets européens et textes internationaux vont dans le même sens. On peut prendre comme exemple l'article 38 du DCEV : après avoir énuméré un certain nombre d'adjonctions ou de modifications qui sont considérées comme altérant substantiellement les termes de l'offre, le texte prévoit que « la réponse dont il est certain qu'elle acquiesce à l'offre mais qui énonce ou implique des adjonctions ou modifications à celle-ci n'en vaut pas moins acceptation, à condition que ces adjonctions ou modifications n'altèrent pas substantiellement les termes de l'offre. Les adjonctions ou modifications font alors partie intégrante du contrat ». L'offrant peut cependant s'opposer à la formation du contrat en réagissant rapidement à ces modifications[271]. La jurisprudence luxembourgeoise pourrait s'inspirer de ces solutions souples, du moins pour les contrats d'affaires dans lesquels une certaine rapidité et une certaine fluidité des négociations est souhaitable. Sans aller jusque-là, la Cour d'appel, dans un arrêt récent juge au moins « pour qu'il y ait contre-proposition, impropre à former le contrat, il faut que la divergence entre l'offre et l'acceptation traduise un réel désaccord, et que tel n'est pas le cas lorsque l'acceptation ne fait que préciser l'objet du contrat sans le modifier ou rappelle l'existence d'une règle de droit commun applicable en toute hypothèse »[272]. Mais, rappelant que les « principes du droit européen des contrats » invoqués par l'appelant, n'ont pas de valeur en droit positif, la Cour maintient qu'un désaccord, même s'il ne porte que sur un élément accessoire, empêche la formation du contrat[273].

La question des divergences se pose en particulier dans le cadre de ce qu'on appelle les *accords de principe* qui peuvent intervenir au cours d'une négociation : les parties, qui ne sont pas en accord sur tous les points, décident, sans attendre, de formaliser leur accord sur le principe du contrat et sur les points déjà réglés. Au minimum, cela implique qu'elles s'engagent à poursuivre la négociation pour tenter de régler les désaccords persistants. Mais que va-t-il se passer si, au terme des négociations, des désaccords subsistent ? Certains auteurs estiment que le contrat définitif devrait quand même se former, dès lors que le désaccord ne porte pas sur un élément essentiel du contrat, sauf si les parties ou l'une d'elles ont par avance subordonné la conclusion du contrat au point restant en discussion[274]. Telle est la

[271] Voy. des dispositions approchantes dans la CVIM (art. 19), le DCFR (art. II-4 :208), le Code Gandolfi [art. 16 (7)].

[272] Cour d'appel, 12 juin 2024, n° CAL-2023-00632.

[273] En l'espèce, le désaccord portait sur le pourcentage de la retenue de garantie et les modalités de libération de celle-ci, ainsi que sur le caractère forfaitaire ou non des prestations offertes.

[274] Van Ommeslaghe, n° 325.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

position des Principes Unidroit (art. 2:114). Cette solution peut sembler choquante dans une logique volontariste, si le désaccord qui subsiste est un désaccord ouvert. Mais c'est une solution raisonnable si on veut éviter qu'une partie ne puisse, en refusant obstinément son accord sur un point secondaire du contrat, réduire à néant l'accord de principe.

158. Conflit entre conditions générales. On peut relier à cette question celle de savoir ce qui se passe lorsque les deux contractants ont émis des conditions générales qui règlent différemment certains points. Si on s'en tenait à la position classique qui exige une concordance parfaite des deux volontés, on devrait considérer qu'une telle divergence empêche purement et simplement la formation du contrat. Cette solution, cependant, ne paraît pas très raisonnable, dans la mesure où, très souvent, la divergence ne sera pas consciente au moment de la formation du contrat (les parties n'épluchant pas dans le détail les conditions générales du cocontractant), et n'apparaîtra qu'ultérieurement, si un litige naît sur un point réglé de manière différente par les deux contractants. La meilleure solution paraît être alors de neutraliser les conditions générales des deux parties sur le point litigieux, en considérant que les clauses en conflit n'ont pas été acceptées, et à revenir sur ce point aux solutions légales supplétives. C'est cette solution qui est reprise avec des nuances par différents projets européens et textes internationaux. Par exemple, l'article 39 du DCEV dispose que « Lorsque les parties sont parvenues à un accord, mais que l'offre et l'acceptation renvoient à des clauses contractuelles types incompatibles, le contrat est néanmoins conclu. Les clauses contractuelles types font partie intégrante du contrat pour autant qu'elles sont pour l'essentiel communes aux parties ». Cela ne vaut cependant que sauf volonté clairement exprimée par l'une des parties[275]. En France, c'est cette solution qui est désormais consacrée par l'article 1119 du Code civil, selon lequel « [e]n cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet ». L'article 5.23 du nouveau Code civil belge consacre en principe la même solution, mais il prévoit que, par dérogation, « le contrat ne se forme pas si, préalablement ou sans retard injustifié après la réception de l'acceptation, une partie indique expressément, et non au moyen de conditions générales, qu'elle ne veut pas être liée par un tel contrat ».

[275] Dans le même sens : Principes Unidroit, art. 2-1-22.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

SECTION 2. LES EFFETS DE L'ACCEPTATION

159. Formation du contrat. De prime abord, les effets de l'acceptation sont très simples à décrire : l'acceptation forme le contrat, et les parties sont désormais liées par la force obligatoire de celui-ci. Cependant l'affirmation requiert diverses précisions quant au moment (**§ 1**), et quant à l'étendue (**§ 2**) de cet effet formateur.

§1. Moment de la prise d'effet de l'acceptation

160. Principe : formation immédiate du contrat. En principe, l'acceptation forme immédiatement le contrat, et les deux parties se trouvent alors liées par la force obligatoire. Ce principe suscite cependant des difficultés particulières dans le cas des contrats à distance, où on peut hésiter sur le moment exact de la prise d'effet de l'acceptation (**A**). Il faut par ailleurs s'interroger sur la portée, par rapport à ce principe, des délais de réflexion qui sont accordés à certains contractants par la législation contemporaine avant ou après l'acceptation du contrat (**B**).

A) *Contrats à distance*

161. Problématique. Il arrive fréquemment que les deux contractants ne se trouvent pas au même endroit lorsque le destinataire de l'offre accepte celle-ci (contrats passés par téléphone, par échange de courriers électroniques ou par correspondance). C'est ce qu'on appelle traditionnellement, non sans ambiguïté, les « contrats entre absents »[276], ou, selon une terminologie plus moderne également utilisée en droit de la consommation, des « contrats à distance »[277]. Dans ces contrats, il peut exister un décalage temporel entre l'émission de l'acceptation et sa réception par l'offrant (ce qui est le cas lorsque l'acceptation est envoyée par courrier postal), et on peut alors s'interroger sur le moment où cette acceptation forme le contrat : lorsqu'elle est émise ou lorsqu'elle est reçue ? Cette

[276] Le terme « absents » n'a rien à voir ici avec le mécanisme juridique de l'absence qui vise les personnes dont on ne sait pas si elles sont vivantes ou mortes (C. civ., art. 112 et s.). Il s'agit seulement ici de personnes qui ne sont pas en présence l'une de l'autre.

[277] Il faut cependant prendre garde à ce que l'expression « contrats à distance » a en droit de la consommation un sens plus précis (Voy. C. consomm., art. L. 222-1), qui ne recouvre pas toutes les hypothèses envisagées ici. Par exemple, un contrat conclu par échange de courriers n'est pas un « contrat à distance » au sens des textes qui protègent les consommateurs, alors qu'il est le type même du contrat dans lequel la détermination du moment du contrat peut faire difficulté.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

question présente de nombreux intérêts pratiques. Elle commande les solutions à admettre chaque fois que l'offre cesse d'avoir force obligatoire (par révocation, par expiration du délai, par suite du décès de l'offrant) entre le moment où l'acceptant émet son acceptation et le moment où elle est reçue par l'offrant (ou ses héritiers). Si on estime que l'acceptation a produit ses effets dès le moment où elle a été émise, ces événements seront sans effet puisque le contrat aura déjà été formé avant ; si on estime que le contrat ne se forme qu'à la réception de l'acceptation, il ne pourra pas se former dès lors que l'offre aura cessé de produire effet avant cette réception. Même si l'offre n'est pas révoquée ou ne devient pas caduque entre l'envoi de l'acceptation et sa réception, il peut être très important de déterminer à quel moment précis s'est formé le contrat : pour la détermination de la loi applicable au contrat en cas de changement de législation ou pour savoir à partir de quand un contractant bénéficie des droits que lui donne le contrat[278].

À la question du moment de formation du contrat, on lie parfois celle du *lieu de formation*, qui se pose dans tous les contrats à distance, même s'ils sont instantanés. La question est la même : le contrat se forme-t-il au lieu où l'acceptant a donné son accord (généralement chez lui) ou au lieu où l'offrant a reçu cet accord ? Cependant, cette question, qui avait parfois une incidence autrefois sur la loi applicable au contrat ou sur le tribunal compétent pour en connaître, n'a pratiquement plus aujourd'hui aucun intérêt, du moins dans le contexte européen. S'agissant de la compétence territoriale des tribunaux en matière contractuelle, c'est le lieu d'exécution du contrat et non celui du lieu de conclusion qui peut être pris en compte (voy. en matière interne l'art. 28 C. proc. civ. et en matière internationale l'art. 7 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I *bis*)). S'agissant de la loi applicable aux contrats internationaux, le lieu de conclusion n'a plus d'incidence, en matière de forme du contrat, que lorsque les parties au contrat se trouvent dans le même pays (Règlement Rome I, art. 11), peu important alors que le contrat ait été conclu entre personnes présentes ou non. Lorsque le contrat a été passé entre deux personnes se situant dans des pays différents, l'article 11, 2 du Règlement a écarté la règle traditionnelle « *locus regit actum* » qui faisait dépendre la loi applicable à la forme du contrat du lieu de conclusion.

162. Théories. Les deux questions du moment et du lieu de formation du contrat, généralement liées, ont suscité de nombreux débats dans les pays du Code civil. Pour les uns, le contrat doit se former au moment de l'émission de l'acceptation, parce que, dès ce moment, il existe deux volontés concordantes, dont la juxtaposition suffit à caractériser l'accord. Oui mais, rétorquent les partisans de la formation au moment de la réception, les volontés ne se sont pas encore rencontrées, et ce n'est que cette rencontre qui peut former le contrat. Ces arguments dogmatiques, qui

[278] Par exemple dans le cas d'un contrat d'assurance, si l'assuré est victime d'un accident entre le moment où l'assurance a envoyé son acceptation du contrat, et le moment où l'assuré a pris connaissance de cette acceptation : voy. les faits caractéristiques de Cour d'appel, 18 novembre 1987, *Pas.*, 27, p. 195.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

cherchent à découvrir une sorte de vérité dans la formation du contrat, ne permettent guère d'avancer dans la résolution du problème, d'autant plus que, de toute façon, les partisans de l'une et de l'autre théorie sont obligés de s'écarter de la pureté des principes pour tenir compte de considérations pratiques. Si on raisonne en termes de « concordance » des volontés, il est impossible de prendre en compte la date de l'émission de l'acceptation, généralement impossible à déterminer, et il faut se rabattre sur le moment de l'expédition du courrier ; à l'inverse, la « rencontre » des volontés ne pourra jamais être située au moment même où l'offrant prend effectivement connaissance de l'acceptation, mais en pratique au moment où la lettre d'acceptation lui est remise. Au-delà, il faut voir que la solution adoptée dépend moins de considérations théoriques que d'un choix de politique juridique : veut-on prioritairement favoriser la liberté de l'offrant, qui, tant qu'il n'a rien reçu, doit pouvoir changer d'avis ou contracter ailleurs, ou se sentir désengagé dès lors qu'il n'a rien reçu à l'expiration du délai fixé pour l'acceptation ? Veut-on au contraire protéger le destinataire de l'offre qui, ayant posté son acceptation avant que l'offrant lui ait fait savoir qu'il la retirait, et qui n'est pas maître du moment où cette acceptation est reçue, peut penser avoir emporté l'affaire ? Ce type de considérations, du reste, inciterait peut-être à faire preuve d'une certaine souplesse dans les solutions adoptées. Il n'est peut-être pas nécessaire, en particulier, de lier absolument la question du moment et la question du lieu, qui répondent à des préoccupations différentes. Et on peut parfaitement dissocier les diverses conséquences attachées à la détermination du moment de formation, par exemple en traitant différemment le problème de la révocation, et celui de la caducité, comme le montrent les solutions adoptées par les projets européens et les textes internationaux[279].

163. Solutions. C'est une des questions sur lesquelles les trois pays du Code civil ont longtemps adopté des solutions différentes, mais qui se sont aujourd'hui rejointes. La Cour de cassation française, après avoir longtemps renvoyé la solution à l'appréciation souveraine des juges du fond, avait semblé prendre parti, dans un arrêt de 1981, en faveur du système de l'émission, tout en réservant la possibilité d'un accord contraire des parties[280]. Il est vrai qu'un arrêt plus récent consacrait le système de la réception, mais en application d'une législation spéciale[281]. En Belgique, en revanche, la Cour de cassation avait, dès 1960, consacré, de manière claire et indiscutable, le système de la réception à propos d'un contrat de cautionnement. La Cour considérait en effet que, malgré le caractère unilatéral du contrat, « le contrat requiert pour sa formation, non pas seulement la simple coexistence de volontés qui ignorent leur consensus, mais bien leur véritable concours à un moment donné, c'est-à-dire la conscience de leur commun accord sur l'objet du contrat » et elle précisait que « cette condition n'est remplie, dans

279 Voy. *infra*.

280 Cass. fr. (comm.), 7 janvier 1981, n° 79-13499. La portée de l'arrêt est discutée car, tout en procédant par voie d'affirmation générale, il ne fixe pas la solution par un attendu de principe.

281 Cass. fr. (3e civ.), 16 juin 2011, n° 09-72679.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

le cas envisagé, que lorsque le pollicitant a eu ou, en tout cas, a pu avoir connaissance de l'acceptation explicite ou tacite de son offre »[282]. Cette solution avait été confirmée plus récemment, et la Cour avait précisé que « ce moment détermine également le lieu où le contrat est présumé avoir été conclu »[283]. C'est cette solution qui l'a finalement emporté dans les deux réformes, tant en France (C. civ. fr., art. 1121) qu'en Belgique (C. civ. be., art. 5.21). C'est également le système de la réception qui est suivi, depuis longtemps, par la jurisprudence luxembourgeoise, tant pour la détermination du moment[284], que du lieu de formation du contrat[285]. La Cour d'appel a précisé à plusieurs reprises que, ce qui compte, ce n'est pas le moment où l'offrant prend effectivement connaissance de l'acceptation, mais celui où, ayant reçu la lettre ou le message, il a été en mesure de le faire[286]. Elle précise également que les parties peuvent toujours fixer un autre moment pour la formation de leur contrat[287].

Cette solution semble aujourd'hui très largement majoritaire dans les droits des pays européens, et elle est consacrée, sans exception, par tous les textes internationaux et projets européens pour la détermination du moment de formation du contrat[288]. La plupart de ces textes réservent expressément la possibilité de stipulations contraires. D'un point de vue théorique, cette solution marque la pénétration dans les systèmes juridiques européens de la conception allemande des actes réceptices, selon laquelle les actes unilatéraux (comme l'acceptation) ne prennent effet qu'à compter de leur réception par leur destinataire. D'un point de vue pratique, le système se recommande par une meilleure prise en considération des intérêts en présence : l'offrant n'a généralement aucun moyen de savoir si son correspondant a ou non expédié une acceptation, alors que l'acceptant peut prendre ses précautions en expédiant sa lettre suffisamment tôt pour que l'offrant la reçoive avant la date limite. Il convient cependant de relever que les textes internationaux et les projets européens vont généralement plus loin dans cette prise en considération des intérêts concrets en nuançant la solution de principe. D'abord, ces textes mettent à part le cas où l'acceptation résulte d'un comportement du contractant (par exemple, l'expédition

[282] Cass. be., 16 juin 1960, *R.C.J.B.*, 1962, p. 20, note J. VAN RYN, « L'acceptation de l'offre de contracter faite par correspondance ».

[283] Cass. be., 25 mai 1990, *Pas.*, 1990, I, p. 1087 ; *adde* Cass. be., 19 juin 1990, *Pas.*, 1990, I, p. 1182. Pour un exposé comparatif des solutions françaises et belges en la matière, voy. E. VAN DEN HAUTE, « La formation des contrats : de l'offre à l'acceptation », in *Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge*, *op. cit.*, pp. 18-21.

[284] Cour d'appel, 16 juillet 1896, *Pas.*, 4, p. 209 ; Cour d'appel, 27 mars 1903, *Pas.*, 6, p. 248.

[285] Trib. Luxembourg, 18 mars 1961, *Pas.*, 18, p. 337.

[286] Cour d'appel, 18 novembre 1987, *Pas.*, 27, p. 195 ; Trib. Luxembourg, 13 juin 1997, n° 448/97 ; Trib. Luxembourg, 2 juillet 2008, n° 524/08, n°s 111088.

[287] Cour d'appel, 18 novembre 1987, précité, à propos du contrat d'assurance, pour lequel il est fréquent que les conditions générales de l'assureur fixe le point de départ de la couverture du risque au moment où l'assureur reçoit la proposition d'assurance dûment complétée par l'assuré, sans attendre l'acceptation définitive du contrat par l'assureur.

[288] Code Gandolfi, art. 16 (2) ; PDEC, art. 2:205 ; DCFR, art. II-4 :205 ; DCEV, art. 35 ; Principes Unidroit, art. 2-1-6 ; CVIM, art. 18 (2). Ces textes ne règlent pas la question du lieu.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

des marchandises), pour lequel le système de la réception n'est pas viable. Ensuite, si l'acceptation, expédiée à temps, parvient trop tard au destinataire par suite d'un retard anormal dans la transmission, le contrat pourra néanmoins se former. Enfin et surtout, la consécration du système de la réception ne commande que la solution en cas d'arrivée de l'acceptation après le délai fixé ; en revanche, pour savoir jusqu'à quand l'offrant qui n'a pas fixé de délai peut révoquer son offre, les textes exigent que cette révocation parvienne au destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son acceptation[289] – le destinataire n'ayant pas reçu cette révocation étant fondé à penser qu'il peut encore accepter. On est donc loin de la consécration univoque d'un « système » qui perdure dans les nouveaux droits français et belge.

164. Contrats électroniques. De très nombreux contrats se concluent aujourd'hui par la voie de l'Internet, notamment dans le cadre des relations entre professionnels et consommateurs. Cette pratique a amené le législateur européen à intervenir par plusieurs directives, la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, relative à un cadre communautaire pour les signatures électroniques[290] et la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »)[291], à la fois pour sécuriser ce type de transactions et pour protéger les clients qui contractent par cette voie (notamment les consommateurs). Ces directives ont été transposées au Luxembourg par une loi du 14 août 2000, modifiée à plusieurs reprises et notamment par une loi du 5 juillet 2004[292]. L'importance de ces textes est considérable pour appréhender l'un des aspects les plus importants de la pratique contractuelle contemporaine et nous les retrouverons à maintes reprises au cours de cet ouvrage. Parmi leurs nombreuses dispositions, certaines concernent le processus de conclusion du contrat, qui se déroule en plusieurs étapes. Selon l'article 51 de la loi du 14 août 2000, le prestataire de services (celui qui offre des biens ou des services sur Internet) doit d'abord fournir au destinataire du service (le client potentiel), avant que celui-ci ne passe commande, un certain nombre d'informations techniques « de manière claire, compréhensible et non équivoque » : différentes étapes à suivre pour conclure le contrat, accessibilité du contrat après sa conclusion, moyens techniques

[289] Voy., p. ex., les Principes UNIDROIT, art. 2-1-4. La même formule se retrouve dans tous les autres textes ou projets (CVIM, PDEC, DCFR, DCEV) à l'exception du Code Gandolfi.

[290] *J.O.U.E.*, L. 13, 19 janvier 2000.

[291] *J.O.U.E.*, L. 178, 17 juillet 2000.

[292] Pour une présentation générale, voy. P. Ancel et A. Fievee, *Contrats et immatériel, rapport luxembourgeois aux Journées espagnoles de l'Association Henri Capitant*, 2014, à paraître.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de correction des erreurs avant passation du contrat définitif, langues proposées pour la conclusion du contrat, éventuels codes de conduite. En outre, les clauses contractuelles et les conditions générales doivent être fournies au destinataire du service de manière à lui permettre de les conserver et de les reproduire. L'article 52 de la loi du 14 août 2000 prévoit en outre que le prestataire doit mettre à disposition du destinataire des moyens appropriés pour lui permettre de corriger ses erreurs avant la passation de la commande, et il doit lui accuser réception par voie électronique et sans délai injustifié. Dans sa rédaction initiale, le texte prévoyait que le contrat n'était conclu que quand le destinataire du service avait reçu cet accusé de réception (ce qui revenait à reconnaître jusque-là au destinataire un droit de rétractation). Cette disposition allait plus loin que la Directive qui ne se prononçait pas sur le moment de la conclusion du contrat, laissé au droit commun, mais seulement sur le moment où l'accusé de réception doit être considéré comme reçu : en 2004, le législateur luxembourgeois est revenu en arrière et a supprimé dans la loi toute mention du moment de formation du contrat. Le texte actuel précise simplement que « la commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès » – ce qui est bien dans l'esprit du système de la réception, mais ne renseigne pas précisément sur le moment où se forme le contrat. Conformément au droit commun, celui-ci doit donc être considéré comme passé lorsque le prestataire de services reçoit la commande (valant acceptation par le client du bien ou du service qui lui est proposé).

Deux remarques générales doivent être faites au sujet de ces exigences. D'une part, les textes ne prévoient aucune sanction de leur non-respect (contrairement au droit français qui prévoit que le contrat n'est pas valablement conclu si le destinataire n'a pas eu la possibilité de vérifier le détail de la commande et son prix et de corriger d'éventuelles erreurs : C. civ. fr., art. 1127-2). D'autre part – et c'est encore une particularité du droit luxembourgeois – toutes ces exigences (à la seule exception de la communication au destinataire des conditions générales pouvant être conservées et reproduites) peuvent être écartées par une convention contraire si les deux contractants sont des professionnels. On suppose que cette convention contraire doit être passée de manière préalable entre les parties (notamment dans le contrat-cadre qui régit leurs relations) et ne peut pas résulter d'une clause du contrat conclu par la voie électronique.

LARCIER INTERSENTIA
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

B) *Délais de réflexion*

165. Finalité et modalités. En principe, le destinataire d'une offre peut l'accepter sans attendre, aussitôt qu'il a reçu l'offre, et cette acceptation forme immédiatement le contrat. Le consensualisme, qui est comme on l'a vu un des principes directeurs du droit des contrats, peut alors favoriser la passation de contrats irréfléchis, insuffisamment mûris, conclus en quelque sorte « sur un coup de tête ». S'il vient à regretter le contrat passé, le contractant qui s'est ainsi engagé à la légère ne trouvera dans le droit classique des contrats que des remèdes très limités : comme nous le verrons plus loin, la possibilité de faire annuler le contrat pour vice du consentement n'est ouverte que dans des situations exceptionnelles. Ce n'est que pour quelques contrats particulièrement graves que le Code civil prend en compte la nécessité d'une réflexion approfondie des contractants ou de l'un d'eux en imposant un certain formalisme (notamment la passation d'un acte devant notaires)[293]. Les législations modernes, dans de nombreux pays, et le législateur européen, tout en développant davantage ce formalisme protecteur, ont mis en place d'autres techniques en faisant bénéficier certains contractants particulièrement vulnérables – notamment les consommateurs – de délais de réflexion dans la phase de conclusion du contrat. Ces délais de réflexion sont de deux types, et leur incidence sur le moment de formation du contrat est très différente. La distinction est faite clairement par le nouvel article 1122 du Code civil français. Parfois, les textes donnent, voire imposent, au contractant protégé un délai de réflexion *avant* la formation du contrat (1). Beaucoup plus souvent, la loi permet au contractant de réfléchir *après* la formation du contrat, en lui permettant de se rétracter dans la période qui suit immédiatement cette formation (2).

1) *Réflexion antérieure à la conclusion du contrat*

166. Formation retardée. Il s'agit ici d'éviter que le contractant protégé ne s'engage trop vite : on va lui permettre – et parfois lui imposer – de réfléchir pendant un certain temps avant de signer. Le modèle d'un tel dispositif de protection se trouve dans la réglementation française des contrats de crédit immobilier : d'une part, la banque qui propose à un particulier un crédit destiné à l'acquisition ou à la construction d'un immeuble doit maintenir son offre

[293] Voy. *infra*, n°s 430 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pendant un délai minimal de 30 jours à compter de sa réception ; d'autre part, l'emprunteur ne peut accepter l'offre que 10 jours après qu'il l'a reçue, aucun versement ne pouvant intervenir avant cette acceptation[294]. C'est donc bien ici la formation même du contrat qui est retardée par la volonté du législateur. Un tel dispositif a été introduit dans le Code de la consommation luxembourgeois lors de la transposition de la directive européenne 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel. Cette directive prévoit, entre autres, l'instauration d'un délai de réflexion au profit des particuliers emprunteurs : aux termes de l'article 14 de cette directive « [l]es États membres définissent une période de sept jours au moins pendant laquelle le consommateur disposera d'un délai suffisant pour comparer les offres, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause ». Les États membres avaient le choix d'instaurer cette période, soit sous la forme d'un délai de réflexion avant la conclusion du contrat de crédit (ce qui est le modèle français), soit sous la forme d'un délai pour l'exercice d'un droit de rétractation après cette conclusion. C'est la première formule qui a été choisie par le législateur luxembourgeois : l'article L 226-8 (4) du Code de la consommation dispose que « [l]e consommateur dispose d'un délai de réflexion de quatorze jours calendrier pendant lequel le prêteur a l'obligation de maintenir les conditions indiquées dans son offre ». Contrairement à la solution française, le texte prévoit que ce délai s'impose au prêteur (qui doit maintenir son offre pendant sa durée), mais non à l'emprunteur qui peut accepter l'offre à tout moment pendant le délai de réflexion. Cette solution, posée en principe par la directive, réduit considérablement le caractère protecteur du délai de réflexion.

2) *Réflexion postérieure à la conclusion du contrat : les droits de rétractation*

167. Principe et applications. De très nombreux textes contemporains accordent à un contractant le droit de revenir sur son acceptation dans une courte période qui suit la conclusion du contrat. Un tel droit de repentir, ou, selon la terminologie qui tend aujourd'hui à l'emporter, de rétractation, est en particulier reconnu par de nombreuses directives européennes au profit des consommateurs dans certains contrats où le risque d'un engagement irréfléchi paraît

294 C. consomm. fr., art. L. 312-10 et L. 312-11.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

particulièrement élevé. En droit luxembourgeois, la grande majorité des droits de rétractation résulte de la transposition de ces directives. L'article L.221-3 du Code de la consommation prévoit depuis 2014 que « pour tout contrat visé par les chapitres 2 à 4 du présent titre, le consommateur a le droit de se rétracter par écrit ou sur tout autre support durable, sans indication de motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze jours calendrier ». Cela vise en particulier, sous réserve de diverses exceptions, les contrats à distance et hors établissement, les contrats de « *time-sharing* » (utilisation de biens à temps partagé) et les contrats de crédit à la consommation. L'article 221-3 fixe en principe le point de départ du délai, qui est, soit le jour de la réception du bien pour les contrats portant sur un bien, soit le jour de la conclusion du contrat pour les prestations de service. Ce texte détermine également les modalités d'exercice de la rétractation, qui doit intervenir par écrit, sur support durable, et sans indication de motifs ; il suffit que la rétractation soit envoyée dans le délai, non qu'elle soit reçue. Divers autres textes sont relatifs à l'information sur le droit de rétractation ou sur son absence, ainsi que sur les effets de l'exercice de ce droit, qui ne doit pas pénaliser le consommateur. En dehors du Code de la consommation, le droit luxembourgeois ne semble connaître qu'un seul autre cas de droit de rétractation, en matière de contrat d'assurance sur la vie de plus de 6 mois : l'assuré a le droit de « renoncer aux effets du contrat » dans les 30 jours à partir du moment où il est informé que le contrat est conclu (L. 27 juillet 1997, art. 100). Les cas de droit de rétractation sont beaucoup plus nombreux en droit français et en droit belge.

168. Nature juridique. La nature juridique des droits de rétractation a été abondamment discutée dans les doctrines française et belge[295]. On peut songer à deux types d'analyses. La première se situe sur le terrain de la formation du contrat : le droit de rétractation apparaît comme une exception au principe de la formation instantanée du contrat ; l'idée est que le consentement du contractant a besoin d'un certain temps pour « mûrir » après la signature de l'acte, ce n'est qu'au bout du délai qui lui est donné pour réfléchir qu'on considérera qu'il a vraiment accepté, et que le contrat se formera. Cette analyse – qui connaît diverses variantes – correspond bien à la finalité des droits de rétractation, et s'accorde avec le délai très court qui est donné au contractant pour se rétracter. Cependant,

[295] Voy. p. ex. en Belgique, Wéry, n°s 208 et s. ; en France : Terre, Simler, Lequette, Chenede 2023 n° 342, et les auteurs cités.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

techniquement, cette analyse est incompatible avec le fait que, dans l'immense majorité des textes qui le consacrent, l'existence d'un droit de rétractation n'empêche pas l'exécution du contrat pendant le délai laissé pour se rétracter – ce qui semble bien indiquer que le contrat est d'ores et déjà formé. On est alors conduit à voir dans les droits de rétractation une limite au principe de la force obligatoire du contrat : le contrat est formé, il lie les parties et fait naître immédiatement des droits et des obligations, mais cette formation n'est pas encore définitive dès lors que la loi autorise un contractant à anéantir le contrat par sa seule volonté. Cette analyse est très clairement consacrée par l'article 5.22 du nouveau Code civil belge, qui définit le droit de rétractation comme celui en vertu duquel « une partie dispose *après la conclusion du contrat* d'un délai pendant lequel elle peut porter à la connaissance de l'autre partie qu'elle renonce au contrat ». Selon certains auteurs, le droit de rétractation ferait partie de la catégorie des droits potestatifs permettant à un contractant de déterminer unilatéralement le sort d'un contrat (à l'image d'une faculté de dédit ou du droit d'option dans les promesses de contrat)[296]. Le régime juridique du droit de rétractation correspond assez bien à cette analyse : pendant toute la durée du délai, le contrat existe déjà, et il peut être exécuté (par exemple, le bien acheté peut être livré, et l'acheteur peut en payer le prix[297].

§ 2. Étendue de l'acceptation

169. Principe de l'acceptation en bloc du contrat. Dans la conception classique du contrat, on considère comme allant de soi que l'acceptation s'applique en bloc à tout le contenu du contrat. De deux choses l'une, en effet : ou bien le destinataire de l'offre émet des réserves sur certaines des conditions qui lui sont offertes par son partenaire, et cela empêche la formation du contrat tout entier, ou bien il exprime son accord sans réserve, et le contrat est formé dans les termes mêmes de l'offre. Cette conception se comprend dans le contexte d'un contrat négocié, dans lequel les deux parties sont à même de parfaitement connaître et de discuter les propositions de l'autre – situation à partir de laquelle ont raisonné les rédacteurs du Code civil. Mais on sait que dans la pratique contractuelle contemporaine, un grand nombre de contrats sont des contrats

296 Voy. *infra*, n° 494.

297 Il y a cependant des exceptions : ainsi en matière de « *time sharing* », l'article L. 223-9 du Code de la consommation interdit tout paiement avant l'expiration de la période de rétractation.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

d'adhésion, dans lesquels l'une des parties a préétabli des conditions générales qu'elle ne permet pas à l'autre partie de discuter, et que celle-ci, dans l'immense majorité des cas, ne lit même pas[298]. Est-il alors raisonnable de considérer que, dans un tel contexte, l'acceptation, consciente quant aux éléments essentiels du contrat (la chose ou le service, le prix, le délai de livraison, les conditions de paiement, etc.), s'étend également aux conditions générales dont l'acceptant n'a pas eu, de fait, véritablement connaissance ? La réponse de principe à cette question ne fait cependant aucun doute : même dans un tel contexte, celui qui accepte le contrat l'accepte en totalité, même pour les clauses qu'il n'a pas lues ou pas comprises. Tout le monde sait bien qu'un tel consentement est complètement fictif, mais le droit des contrats moderne repose nécessairement sur cette fiction : raisonner autrement, en exigeant que tous les contractants aient lu et compris les conditions générales préétablies par l'autre, ouvrirait la voie à une contestation systématique des multiples contrats de la vie quotidienne, et serait incompatible avec le développement des échanges économiques. Au moins le fait d'en avoir conscience amène à poser un certain nombre de limites, si on veut que ces contrats, pour nécessaires qu'ils soient, ne soient pas des instruments d'une exploitation généralisée de certains contractants.

170. Limite : l'article 1135-1 du Code civil. Le moyen le plus efficace pour éviter les abus dans l'utilisation des conditions générales consiste sans doute à interdire purement et simplement l'insertion dans les contrats d'adhésion de certaines clauses particulièrement dangereuses et déséquilibrées : nous retrouverons plus loin ce contrôle de validité des clauses dans les contrats entre professionnels et consommateurs, qui est l'objectif premier de la législation européenne sur les clauses abusives[299]. Mais le système juridique peut également intervenir en instaurant un contrôle de l'intégration dans le contrat des conditions générales préétablies par un contractant : ces conditions générales, ou certaines clauses en faisant partie, seront écartées du contrat dans certaines hypothèses où il apparaît que l'adhérent au contrat n'a pas eu la possibilité effective d'en avoir connaissance ou de les comprendre. Ces conditions ou ces clauses ne seront pas nulles, elles seront considérées comme n'ayant

[298] Sur la description générale du phénomène, voy. *supra*, n° 83.
[299] Voy. *infra*, n°s 411 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pas été acceptées[300], et de ce fait, elles seront inopposables au cocontractant de l'émetteur[301]. Le droit allemand a été pionnier dans l'instauration d'un tel contrôle avec la loi de 1976 sur les conditions générales des contrats (AGBG), désormais intégrée dans le BGB aux § 305 et suivants. Aux termes du § 305, les conditions générales ne deviennent partie intégrante du contrat que si lors de la conclusion du contrat leur émetteur « 1/ les indique expressément à l'autre partie ou si cela n'est possible compte tenu du type de contrat qu'au prix de difficultés disproportionnées, les affiche de manière clairement visible au lieu de la conclusion du contrat et 2/ donne à l'autre partie, de manière appropriée, en tenant compte éventuellement d'un handicap corporel de celle-ci dont il peut avoir connaissance, la possibilité d'avoir connaissance de leur contenu, et si l'autre partie accepte leur validité »[302]. Le § 305c prévoit en outre que ne font pas partie du contrat les clauses des conditions générales qui « sont tellement inhabituelles d'après les circonstances, en particulier d'après l'apparence extérieure du contrat, que le cocontractant de l'émetteur ne peut pas compter dessus »[303].

D'inspiration allemande, la grande loi luxembourgeoise du 15 mai 1987 a, entre autres nouveautés considérables, intégré dans le Code civil un article 1135-1 qui repose sur la même idée que le § 305 du BGB, mais qui est beaucoup moins précis. Aux termes de ce texte, « Les conditions générales d'un contrat préétablies par l'une des parties ne s'imposent à l'autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées ». Dans sa

300 Sur la distinction entre les deux questions, voy. Cass., 15 février 2001, *Pas.*, 2001, p. 168, qui pose à juste titre que le fait qu'une clause soit déclarée opposable au contractant de l'émetteur n'exclut pas qu'elle puisse être annulée sur le fondement de la réglementation des clauses abusives.

301 Le terme « inopposabilité » qui désigne ici la non-intégration de la clause dans le contrat, n'a pas le même sens que l'inopposabilité aux tiers (qui désigne les cas où le tiers à un contrat peut faire comme si le contrat n'avait pas été passé. Voy. *infra*, n° 429).

302 « *Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil eines Vertrags, wenn der Verwender bei Vertragsschluss 1. die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der art. des Vertragsschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsschlusses auf sie hinweist und 2. der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise, die auch eine für den Verwender erkennbare körperliche Behinderung der anderen Vertragspartei angemessen berücksichtigt, von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen, und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist* ».

303 *Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die nach den Umständen, insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags, so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner des Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen braucht, werden nicht Vertragsbestandteil.*

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

version d'origine, l'article 1135-1 contenait un second alinéa prévoyant que « sauf acceptation spéciale par écrit, sont toujours inopposables les clauses qui prévoient en faveur de celui qui a établi les conditions générales des limitations de responsabilité, la possibilité de se retirer du contrat ou d'en différer l'exécution, le recours obligatoire à l'arbitrage, ainsi que celles attribuant compétence à d'autres juridictions que celles normalement compétentes », mais cet alinéa, particulièrement exigeant à l'égard des émetteurs de conditions générales, et qui avait suscité diverses difficultés en jurisprudence[304] a été abrogé par la loi du 5 juillet 2004, pour permettre l'intégration de telles clauses dans les contrats conclus par voie électronique. Une loi du 26 mars 1997 est venue en revanche compléter le texte en précisant ce qu'il faut entendre par clauses n'ayant pas fait l'objet de négociations individuelles : il s'agit de clauses rédigées préalablement par l'une des parties, de sorte que l'autre partie n'a pu avoir aucune influence sur son contenu. Le texte précise également que le fait que certaines clauses aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas son application au reste des clauses. En toute hypothèse, c'est à celui qui se prévaut d'une clause à prouver qu'elle n'a pas été préétablie. Il importe enfin de souligner que, à la différence de la législation sur les clauses abusives (qui ne s'applique que dans les contrats de consommation) l'article 1135-1 du Code civil est applicable à tous les contrats d'adhésion, que le contrat ait été passé entre un professionnel et un consommateur, ou entre deux professionnels. Dans le cas des contrats de consommation, l'article L. 211-1 du Code de la consommation renvoie au texte de droit commun de l'article 1135-1 du Code civil, même si certains textes spéciaux viennent alors compléter cette règle générale[305]. La qualité des parties au contrat peut cependant jouer un rôle dans l'appréciation que le juge pourra faire du caractère opposable ou non des conditions générales, comme le révèlent les applications jurisprudentielles de l'article 1135-1 du Code civil.

171. Applications jurisprudentielles. L'article 1135-1 du Code civil est très souvent invoqué par une partie qui cherche à échapper à certaines clauses contractuelles qui lui sont défavorables, mais

304 La Cour d'appel avait en particulier décidé à plusieurs reprises que l'article 1135-1 du Code civil ne pouvait s'appliquer en présence d'une convention internationale ou d'un règlement européen prévoyant un formalisme moins strict pour certaines catégories de clauses. Voy., p. ex., pour la clause compromissoire : Cour d'appel, 26 juillet 2005, *Pas.*, 33, p. 116.

305 Voy. S. Brucher, N. Thieltgen et M. Bena, « La protection juridique des intérêts du consommateur dans le Code civil », in *Le bicentenaire du Code civil – Une contribution luxembourgeoise*, Luxembourg, éd. Portalis, 2008, pp. 174 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'argument est très rarement retenu. Les juges recherchent à la fois si le contractant à qui l'autre partie prétend appliquer des clauses préétablies a pu avoir connaissance de l'inclusion de ces clauses dans le contrat et s'il a pu accéder à leur contenu.

Sur le premier point, c'est la *place* des clauses par rapport au contrat qui joue un rôle essentiel. Selon une jurisprudence constante, l'article 1135-1 du Code civil n'exige pas que la partie contractante ait signé les conditions générales d'un contrat préétabli, mais il suffit qu'elle ait été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et qu'elle puisse être considérée comme les ayant acceptées[306]. D'une manière générale, on admettra sans difficulté l'applicabilité des clauses figurant au verso du contrat. Un arrêt récent de la Cour d'appel relève ainsi que « la première page du Contrat renvoie expressément aux conditions générales qui se trouvent au verso du document. Si ces conditions y sont écrites dans une police légèrement plus réduite, la Cour constate cependant que la présentation (avec des chapitres et sous-chapitres sous-lignés et/ou en gras) des différentes clauses permet une lecture assez aisée et compréhensible des modalités applicables au Contrat à conclure, de sorte qu'il faut en déduire que A a bien été en mesure de les connaître au moment de la signature du Contrat et que sa signature emporte également acceptation desdites conditions générales »[307]. Les juges se montrent plus exigeants lorsque les conditions générale figurent sur un support distinct de l'écrit signé (conditions générales affichées dans les locaux de l'entreprise émettrice ou imprimées sur un document séparé). Ces clauses ne seront opposables que si le cocontractant a eu la possibilité effective d'en avoir connaissance. Pour des conditions générales figurant sur Internet, il a même été jugé que la simple possibilité d'en prendre connaissance ne suffit pas à les rendre opposables au contractant en l'absence de preuve qu'il en ait eu connaissance et les ait acceptées avant la signature du bordereau d'expédition[308]. Pour se couvrir, certains professionnels font signer à leurs clients une mention par laquelle ils reconnaissent avoir eu communication des conditions générales. Cette reconnaissance empêche en principe le contractant de contester ensuite l'application des clauses : la jurisprudence luxembourgeoise estime que cette clause suffit à établir que le contractant a eu connaissance de

306 Voy. en dernier lieu, Cour d'appel, 5 janvier 2024, n° TAL-2023-03184.

307 Cour d'appel, 30 novembre 2021, n° CAL-2021-00123.

308 Cour d'appel, 16 février 2021, n° CAL-2020-00169.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

conditions générales reproduites en annexe[309]. Il en va autrement cependant dans les contrats entre professionnels et consommateurs, où l'article L. 211-3 (23) du Code de la consommation déclare abusives « les clauses qui constatent de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ». Le consommateur pourra donc toujours établir que le professionnel ne lui a jamais communiqué ses conditions générales. La *forme* des clauses est également importante : la Cour d'appel a pu ainsi, sur le fondement de l'article 1135-1 du Code civil, écarter du contrat des conditions générales rédigées en caractères tellement minuscules qu'elles étaient illisibles par une personne dotée d'une acuité visuelle ordinaire[310]. On se montrera d'autant plus exigeant que les clauses ont un *contenu* inhabituel ou surprenant : dans le prolongement de l'ancien alinéa 2 de l'article 1135-1 du Code civil, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a ainsi décidé que les clauses exorbitantes du droit commun (clause pénale, clause de compétence, stipulation d'intérêts supérieurs au taux légal) ne sont admises que si les parties sont en relations d'affaires suivies ou si l'attention du contractant a été attirée spécialement sur elles[311]. Il en va de même, lorsque les parties sont en relations suivies, lorsque la clause ne figurait pas dans les précédents contrats : dans ce cas, la Cour d'appel juge que « les conditions générales de vente doivent, pour être opposables, être communiquées au co-contractant pour qu'il puisse en prendre connaissance ; faute de quoi l'acceptation ne saurait être tacite »[312].

S'agissant de savoir si la partie a pu comprendre le sens des clauses qu'on lui oppose, la *langue* du contrat doit être prise en considération, et ce facteur est particulièrement important dans la société multilingue du Luxembourg. La Cour d'appel a ainsi déclaré inopposables des conditions générales rédigées en *langue* étrangère et annexées à la facture dans une hypothèse où les parties n'étaient pas en relations d'affaires suivies[313]. Il en irait autrement cependant si les parties, ayant toutes deux la qualité de professionnels, sont en relations d'affaires habituelles, le contractant qui accepte pendant plusieurs années de telles conditions sans se renseigner sur leur

309 Trib. Luxembourg, 27 mars 2001, n° 10245 ; Cour d'appel, 30 juin 2021, n° CAL-2020-00625 ; Cour d'appel, 19 octobre 2021, n° CAL-2018-00755 ; Trib. Luxembourg, 17 novembre 2021, n° TAL-2021-03769.

310 Cour d'appel, 18 mai 2011, n° 36778, *BIJ*, 2011, p. 122.

311 Trib. Luxembourg, 12 mars 2009, n° 107903, *BIJ*, 2009, p. 108 ; Trib. Luxembourg, 4 février 2005, n° 94999, *BIJ*, 2005, p. 168 ; Trib. Luxembourg, 7 mai 2004, n° 86468, *BIJ*, 2004, p. 204.

312 Cour d'appel, 22 octobre 2014, Pas. 37, p. 17 ; Cour d'appel, 10 janvier 2018, Pas. 38, p. 664 ; Cour d'appel, 15 février 2022, n° CAL-2020-00831.

313 Cour d'appel, 6 février 2002, n° 25422, *BIJ*, 2003, p. 7.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

contenu est ensuite malvenu à contester leur application[314]. Le fait que les conditions générales soient rédigées en langue française et que les appelants seraient de nationalité brésilienne ne porte pas à conséquence dans la mesure où il n'est pas établi que ces derniers ne comprennent pas la langue française dans laquelle l'accord est rédigé et que, de surcroît, ces derniers ont signé l'accord de sous-bail sans émettre de réserve quant à la langue utilisée[315]. Même rédigées dans la langue du contractant, les clauses peuvent s'avérer incompréhensibles en raison de leur *style* : dans certains cas extrêmes, elles pourraient être écartées[316]. Dans la plupart des cas, cependant, l'imprécision ou l'ambiguïté d'une clause ne suffira pas à l'exclure du contrat ; dans le cas des contrats passés entre un professionnel et un consommateur, la clause sera alors, selon l'article L. 211-12 (2) du Code de la consommation, interprétée en faveur du consommateur[317].

172. Relativité de la protection – L'article 1135-1 du Code civil du Luxembourg ne remet pas en cause le principe de l'acceptation en bloc du contrat, ni la fiction d'un consentement à des clauses qu'on n'a, en fait, même pas regardées. Comme le rappelle régulièrement la Cour d'appel, le contrôle de l'intégration des conditions générales dans le contrat n'aboutit pas en effet à exiger du contractant adhérent qu'il les ait effectivement connues et comprises ; il suffit qu'il ait eu la possibilité d'en avoir connaissance et de les comprendre[318]. Et, sur ces deux points, le texte, beaucoup moins précis que les articles du BGB dont il s'inspire, laisse au juge un très large pouvoir d'appréciation. Il n'est donc pas sûr que les solutions auxquelles on aboutit en droit luxembourgeois soient différentes de celles consacrées par la jurisprudence en France ou en Belgique, alors même que ces pays ne contenaient pas dans le Code civil, jusqu'aux réformes récentes, une disposition générale de ce type, et se contentaient, soit de textes spéciaux relatifs à certains contrats, soit des dispositions spécifiques de protection des consommateurs. Cela n'empêchait pas les juges, dans ces pays, de se livrer à un contrôle de l'insertion des conditions générales dans les contrats, en écartant notamment celles dont il n'est pas établi qu'elles ont été portées à la connaissance du cocontractant[319]. L'article 1135-1 du Code civil n'en est pas moins, symboliquement, très important en

314 Trib. Luxembourg, 1er juillet 2011, n° 135628, *BIJ*, 2012, p. 93.

315 Trib. Luxembourg, 18 juin 2019, nos TAL-2018-05293 et TAL-2018-05691 et TAL-2018-05804.

316 Comp. Cour d'appel (comm.), 10 juillet 2013, *Pas.*, 36, p. 431 qui conclut cependant au caractère suffisamment clair d'une clause figurant dans les conditions générales d'un contrat de cautionnement.

317 Sur cette interprétation *contra proferetem*, voy. *infra*, n° 528.

318 Cour d'appel, 15 février 2022, n° CAL-2020-00831.

319 Voy. en droit français : Cass. fr. (1re civ.), 3 décembre 1991, n° 89-20856 ; Cass. fr., (1re civ.), 30 juin 1992, n° 90-21491 ; en droit belge : VAN OMMESLAGHE, nos 330 et s. et les nombreux arrêts cités.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ce qu'il prend clairement en compte, au titre du droit commun des contrats, le phénomène des contrats d'adhésion. Lors de la réforme de 2016 en France, on a introduit dans le Code civil un article 1119 aux termes duquel « [l]es conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées », tandis que, en Belgique, l'article 5.23 du nouveau code, issu de la réforme de 2023, dispose, de manière un peu plus précise que « [l]'inclusion des conditions générales d'une partie dans le contrat requiert leur connaissance effective par l'autre partie ou, à tout le moins, la possibilité pour celle-ci d'en prendre effectivement connaissance, ainsi que leur acceptation ». Mais il n'est pas sûr que ces textes modifient de manière sensible les solutions jurisprudentielles.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'acceptation du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 197-221
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

173. Il y a quelque chose avant le contrat. Obnubilés par le rôle de l a volonté dans le contrat, les auteurs des pays du Code civil ont pendant longtemps réduit le processus de formation du contrat à une sorte d'instant magique, celui de la rencontre de l'offre et de l'acceptation. Cette approche est aujourd'hui dépassée, et le droit contemporain porte une attention particulière à la période qui précède et prépare l'éventuelle conclusion du contrat, à la fois pour encadrer son déroulement (**Chapitre I**) et pour imposer aux éventuels contractants certaines obligations (**Chapitre II**). Les nouveaux textes français et belges en témoignent de manière éloquente.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 225
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Chapitre I
Le déroulement de la période précontractuelle

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

174. Notion. De très nombreux contrats sont conclus de manière instantanée, sans que la rencontre de l'offre et de l'acceptation soit précédée de discussions. C'est le cas de la plupart des contrats de la vie quotidienne (l'achat de biens de consommation courante, les contrats de transport journaliers, les contrats de service usuels avec le garagiste, le teinturier, le plombier, etc.) ainsi que des contrats d'adhésion, même plus importants, où toute discussion est de toute façon exclue en fait. Mais, dans les contrats plus complexes, les parties « s'approchent » l'une de l'autre progressivement, et des *négociations* parfois serrées précèdent la conclusion du contrat (**Section 1**). Il arrive aussi fréquemment que, dans l'attente de la conclusion d'un éventuel contrat définitif, les parties passent d'ores et déjà des *contrats préliminaires* destinés à préparer ce contrat définitif (**Section 2**).

SECTION 1. LES NÉGOCIATIONS PRÉCONTRACTUELLES

175. Problématique. Lorsque les parties sont engagées dans un processus de négociation, de pourparlers, la question principale qui se pose est de savoir si chacune d'elles peut s'en retirer unilatéralement. Quasiment ignorée de la doctrine au XIXe siècle, cette question est aujourd'hui une des plus importantes dans la pratique contractuelle, et elle suscite, au Luxembourg comme ailleurs, un abondant contentieux devant les tribunaux. La raison en est dans le développement exacerbé de la concurrence entre les entreprises, dans un contexte de mondialisation de l'économie. Les négociations de gros contrats peuvent durer très longtemps, amener chacun des partenaires à engager des frais importants, et faire naître chez chacun des espérances de profits considérables. Si, finalement, une partie décide de ne pas donner suite, la déception sera à la hauteur de l'attente et des frais engagés, surtout si le contrat espéré est passé avec un tiers. La partie qui a perdu le marché sera parfois tentée de se plaindre d'une rupture injustifiée et d'un comportement déloyal de son partenaire, et elle agira en justice pour tenter d'obtenir une compensation du préjudice subi.

Il faut bien distinguer la problématique de la rupture des pourparlers de celle de la révocation de l'offre. Au cours des négociations, chaque partie peut être amenée à formuler, à un certain moment, une proposition précise qui mérite la qualification d'offre, l'autre pouvant répondre par une acceptation avec réserves, qui constitue alors une nouvelle offre. Les négociations peuvent ainsi se composer d'un échange plus ou moins long d'offres et de contre-offres, jusqu'à l'acceptation définitive. Si la partie qui a formulé une offre (ou une contre-offre) change aussitôt d'avis sans laisser

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

à l'autre le temps de réfléchir, ou retire sa proposition sans attendre l'expiration du délai qu'elle a fixé à son partenaire, la rupture des pourparlers qui en résulte s'analyse en une révocation illicite de l'offre, et la sanction est à chercher sur ce terrain[320]. La question de la rupture des pourparlers n'apparaît de manière autonome que lorsque l'une des parties se retire des discussions alors qu'aucune offre précise n'a été formulée, ou si la partie qui se retire est le destinataire de l'offre, qui la refuse ou ne prend pas la peine d'y répondre.

176. Principe de liberté. En principe, chaque partie est libre de mettre fin à tout moment à une négociation entamée en vue de la conclusion d'un contrat. Par hypothèse, les parties ne sont encore liées par aucun accord, et elles doivent jusqu'au bout demeurer libres de s'engager ou de ne pas s'engager. Aucune d'elles ne peut, en effet, être obligée de passer un contrat dont elle ne veut pas. C'est là une conséquence de la notion même de contrat, qui repose nécessairement sur le consentement des contractants, et du principe de la liberté contractuelle. Ce principe est traditionnellement posé par la jurisprudence, au Luxembourg comme dans les autres pays du Code civil[321] et dans tous les systèmes juridiques européens. Ainsi, la Cour d'appel du Luxembourg, dans un arrêt du 14 juillet 2005, affirme que « En principe on en saurait imputer une faute à l'encontre d'une personne décidant de mettre un terme à des pourparlers entretenus depuis un certain temps avec un partenaire avec lequel elle espérait conclure un contrat »[322]. De même, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, citant des auteurs français, indique clairement que « Situés très en amont de la formation du contrat, les pourparlers n'ont en principe aucune portée juridique ; ils ne sauraient en principe engager les parties respectives. Constituant la période dite de gestation du contrat, les pourparlers ne peuvent donc lier les parties : ils peuvent d'ailleurs toujours être rompus en vertu de la maxime "Pas de contrat vaut mieux qu'un mauvais contrat" »[323]. La liberté de rompre les pourparlers est également affirmée aujourd'hui par la plupart des textes internationaux et des projets européens[324]. Le nouvel article 1112 du Code civil français pose que « [l]'initiative, le déroulement et *la rupture* des négociations précontractuelles sont

320 Voy. *supra*, n°s 146 et s.

321 Voy. p. ex. en droit français : A. BENABENT, *Droit des obligations*, 15e éd., Paris, LGDJ, 2016, n° 803 ; en droit belge : VAN OMMESLAGHE, n° 338 et les arrêts cités.

322 Cour d'appel, 14 juillet 2005, n° 27088.

323 Trib. Luxembourg, 24 janvier 2002, n° 68830, *BIJ*, 2004, p. 119 confirmé par Cour d'appel, 11 juin 2003, n° 26817.

324 Code Gandolfi, art. 16 ; PDEC, art. 2:301 (1) ; Principes Unidroit, art. 2.1.15 ; DCFR, art. 3:301 (1). Seuls la CVIM et le DCEV ne reprennent pas une telle règle, mais c'est parce qu'ils laissent la période précontractuelle en dehors de leur champ d'application.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

libres », tandis que l'article 5.15 du nouveau code belge dispose que « [l]es parties sont libres d'entamer, de mener et *de rompre* des négociations précontractuelles ».

177. Limite : le manquement à la bonne foi. Comme souvent en droit des contrats, et plus spécialement dans la phase de conclusion du contrat, l'impératif de liberté des parties entre en conflit avec le souci d'assurer une certaine sécurité dans les relations juridiques. Les négociations peuvent durer longtemps, entraîner des frais importants, et faire naître chez chacun des partenaires l'espérance de conclure le contrat, en l'amenant du coup à renoncer à d'autres opportunités. Dans un tel contexte, il peut paraître anormal de laisser chaque contractant complètement libre de se retirer à tout moment et sans aucun motif. Dans cette optique, la plupart des systèmes juridiques posent depuis longtemps des limites à la liberté de rompre, qui sont aujourd'hui habituellement rattachées à l'exigence de bonne foi dans la conduite des négociations. Cette exigence est aujourd'hui admise explicitement par plusieurs codes nationaux[325], et elle est posée par les différents textes internationaux et projets européens[326]. Seuls les droits de *common law* restent réticents à l'idée de consacrer un devoir général de bonne foi dans la phase de négociation du contrat, et la responsabilité pour rupture des pourparlers n'y est admise que de manière tout à fait exceptionnelle[327]. Dans le Code civil de 1804, comme on l'a vu précédemment, la bonne foi n'apparaît, dans l'article 1134, alinéa 3, qu'à propos de l'exécution du contrat, mais la jurisprudence, dans les trois pays du Code civil, n'a pas hésité à en faire un principe général, applicable également lors de la phase de formation du contrat, et justifiant en particulier l'octroi de dommages et intérêts dans les cas de rupture abusive des pourparlers. Cette responsabilité est parfois rattachée, de manière plus précise, à la notion d'abus de droit, mais on peut considérer que cette notion n'est, en matière contractuelle, qu'un cas particulier de manquement à la bonne foi. C'est ce fondement qui est retenu par le nouvel article 1112 français, qui, immédiatement

325 Voy. p. ex. le Code civil italien, art. 1337 : « *Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede* ».

326 Principes Unidroit, art. 2.1.15 (2) : « la partie qui, dans la conduite ou la rupture des négociations, agit de mauvaise foi est responsable du préjudice qu'elle cause à l'autre partie » ; DCFR, art. 3:301 « (2) *A person who is engaged in negotiations has a duty to negotiate in accordance with good faith and fair dealing. This duty may not be excluded or limited by contract. (3) A person who has negotiated or broken off negotiations contrary to good faith and fair dealing is liable for any loss caused to the other party to the negotiations* ».

327 Voy. Cartwright, pp. 71 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

après avoir posé le principe de la liberté de rompre les négociations, précise que celles-ci « doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».

178. Nature de la responsabilité pour rupture abusive des pourparlers. Dans la plupart des systèmes juridiques, et en particulier dans les pays du Code civil, il ne fait aucun doute que la responsabilité encourue dans les cas de rupture abusive des pourparlers précontractuels est une responsabilité délictuelle, techniquement fondée sur l'article 1382 du Code civil[328]. Tant que le contrat n'est pas passé, les parties ne sont pas encore obligées l'une envers l'autre, et la bonne foi apparaît plutôt comme un devoir général de comportement, plutôt que comme une véritable obligation[329]. Il n'en va autrement que si les parties ont, au cours de leurs négociations, conclu un contrat visant à organiser celles-ci ou à fixer leurs points d'accord – situations qui seront examinées plus loin dans le cadre de l'étude des contrats préliminaires[330].

Cette analyse se distingue de celle qui est menée en droit allemand où, à partir d'un article célèbre de Ihering[331], la doctrine et la jurisprudence ont érigé la faute commise dans la période précontractuelle – *culpa in contrahendo* – en une source distincte de responsabilité, rattachée par analogie à la responsabilité contractuelle. L'idée développée par Ihering est que, pendant la période précontractuelle, il se forme tacitement entre les partenaires à la négociation un rapport juridique particulier par lequel les parties sont engagées à se comporter loyalement l'un envers l'autre. Cette analyse a été consacrée par la jurisprudence, avant d'être reprise lors de réforme allemande du droit des obligations de 2000 dans le § 311 (2) du BGB aux termes duquel un rapport de droit comportant les devoirs prévus par le § 241 alinéa 2 naît non seulement de la conclusion d'un contrat mais aussi de l'engagement de négociations contractuelles. Ce rapport de droit fait naître pour chaque partie l'obligation de prendre en considération les droits, les biens et les intérêts de chaque partie[332]. Cette construction (qui a influencé le droit néerlandais et le droit suisse) se justifie en droit allemand par les règles très restrictives qui régissent la responsabilité délictuelle, et en particulier par la difficulté de réparer sur son fondement les préjudices économiques purs (c'est-à-dire ceux ne consistant pas dans l'atteinte à

328 Cour d'appel, 28 janvier 2004, n° 27591 ; Cour d'appel, 13 février 2014, n° 38087.

329 La responsabilité pour rupture des pourparlers a été également considérée comme délictuelle par la Cour de justice des Communautés européennes au regard de la Convention de Bruxelles sur les conflits de juridictions : C.J.C.E., 17 septembre 2002, *Tacconi*, aff. C.334/00, *Rev. crit. DIP*, 2003, p. 668, note P. RÉMY-CORLAY.

330 Voy. *infra*, n° 190.

331 R. VON IHERING, « Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen", *Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts*, 1861, IV, 1.

332 § 311 : « *Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 entsteht auch durch… die Aufnahme von Vertragsverhandlungen.* » ; § 241 Abs. 2: « *Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter undInteressen des anderen Teils verpflichten* ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

un bien), qui sont précisément ceux que subit la victime d'une rupture abusive des pourparlers. Il n'y a pas grand intérêt à la transposer dans les systèmes juridiques issus du Code civil, où la responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 permet de réparer n'importe quel préjudice causé par n'importe quelle faute. C'est donc sans signification technique particulière qu'on utilise parfois dans les pays du Code civil, et tout particulièrement au Luxembourg, l'expression « *culpa in contrahendo* », pour désigner les fautes commises lors de la conduite des pourparlers[333]. Nous verrons cependant que, dans la jurisprudence contemporaine, les idées de Ihering trouvent un écho plus précis lorsque la négociation a abouti à la conclusion du contrat et que c'est dans le cadre de l'exécution de celui-ci qu'une des parties cherche à faire sanctionner des fautes commises lors de la phase précontractuelle. De prime abord, on pourrait croire que le législateur belge, lors de la réforme, a été influencé par les théories allemandes, car l'article 5.17 relatif à la responsabilité pour rupture des pourparlers s'intitule « Responsabilité précontractuelle », mais le texte de l'article dément cette impression, car il dispose que « [l]es parties peuvent engager leur responsabilité extracontractuelle l'une envers l'autre pendant les négociations précontractuelles ».

179. Cas de responsabilité pour rupture abusive des pourparlers. Il est extrêmement difficile de donner une vision synthétique des cas dans lesquels la jurisprudence admet la responsabilité pour manquement à la bonne foi en cas de rupture abusive des pourparlers, car cette jurisprudence dépend grandement de l'appréciation au cas par cas des circonstances de fait. On peut cependant, au-delà de la grande variété des espèces, discerner l'idée générale selon laquelle « la rupture des pourparlers est fautive si elle viole la confiance légitime de l'autre partie »[334]. Cette idée trouve parfois un écho dans la jurisprudence luxembourgeoise[335]. Deux séries d'hypothèses entrent dans ce cadre général. La première est expressément visée par la plupart des textes internationaux et projets nationaux et européens : c'est le cas où une des parties a engagé la négociation alors qu'elle n'avait, dès le départ, aucune intention de conclure le contrat (par exemple, dans le seul but de recueillir des renseignements sur l'autre entreprise) ; on peut y assimiler le cas où une partie, qui, à un moment donné, sait qu'elle ne veut pas conclure le contrat, continue de négocier sans avertir son cocontractant. L'autre hypothèse est celle où les négociations ont déjà duré très longtemps et où le projet de contrat est très avancé, de sorte que chaque partie peut croire qu'on ira jusqu'au bout : dans une telle hypothèse, il n'est pas interdit de rompre, mais il est interdit de le faire brutalement et sans

333 Voy., p. ex., Ravarani, n°s 484 et s. Un arrêt ancien de la Cour d'appel avait cependant eu recours à la notion pour justifier le caractère contractuel de la responsabilité liée à une faute dans la période de formation du contrat (Cour d'appel, 26 avril 1908, *Pas.*, 10, p. 576).

334 Wéry, n° 125.

335 Voy. p. ex. Cour d'appel, 12 décembre 2023, n° CAL-2022-00126, qui cite la doctrine belge.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

motif. C'est surtout de ce type de situations qu'ont eu à connaître les tribunaux luxembourgeois[336]. On peut citer par exemple un arrêt de la Cour d'appel de 2019 qui, après avoir rappelé les principes relatifs à la rupture des pourparlers, juge qu'« en mettant ainsi fin aux discussions de manière brutale, sans préavis, après avoir négocié de manière concrète pendant plusieurs mois, tout en continuant à faire croire à (l'autre partie) qu'elle pouvait s'attendre à ce que le contrat entre parties soit conclu, (le contractant) a commis une faute qui est de nature à engager sa responsabilité délictuelle »[337]. En revanche, n'est pas fautif le fait pour une partie de « ne pas prolonger inutilement des pourparlers qui ne se trouvaient qu'à un état embryonnaire et (d'y mettre) un terme afin de préserver ses intérêts, pour un motif inscrit d'emblée dans les documents contractuels communiqués à (l'autre partie) »[338].

180. Étendue de la responsabilité pour rupture abusive des pourparlers. Il est acquis, dans presque tous les systèmes juridiques, que la victime d'une rupture fautive des pourparlers ne peut pas exiger que le contrat soit passé contre le gré de son partenaire[339]. La solution s'impose d'autant plus en droit luxembourgeois que, on l'a vu, on n'admet pas que la révocation illicite d'une offre puisse être sanctionnée par la conclusion forcée du contrat, alors même que, dans ce cas, on pourrait voir dans l'offre un véritable engagement unilatéral valant consentement anticipé au contrat[340]. *A fortiori* cette conclusion forcée paraît-elle exclue lorsqu'on se situe, comme c'est le cas pour la rupture des pourparlers, sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Sans doute est-il admis, d'une manière générale, que la victime d'un fait illicite puisse demander une réparation en nature de son préjudice[341], mais il paraît difficile de justifier par cette idée la formation d'un contrat contre la

336 Cour d'appel, 13 février 2008, n° 32877, *Pas.*, 34, p. 155 ; Cour d'appel, 16 novembre 2005, n° 29933 ; Cour d'appel, 9 janvier 2003, n° 25595 ; Cour d'appel, 11 juin 2003, n° 26817 ; Trib. Luxembourg, 18 novembre 2008, n° 202/08 XI ; Trib. Luxembourg, 5 mai 2009, n° 106/09 XI ; Trib. Luxembourg, 26 janvier 2007, n° 34/07 XI ; Trib. Luxembourg, 24 mars 2010, n° 94/10 XI ; Trib. Luxembourg, 24 janvier 2002, n° 68830, *BIJ*, 2004, p. 119.

337 Cour d'appel, 7 février 2019, n° 43414.

338 Cour d'appel, 28 octobre 2021, n° 45021.

339 Il n'en va autrement qu'en droit néerlandais où la jurisprudence a parfois admis que la partie qui avait rompu les négociations puisse être judiciairement contrainte de les reprendre (Gerechtshof Amsterdam, 7 mai 1987, De Ziener, NJ 1988, 430). Voy. H. BEALE *et alii*, *Contract law*, *op. cit.*, pp. 415 et s.

340 Voy. *supra*, n° 149.

341 Sur la réparation en nature, voy. RAVARANI, n°s 1221 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

volonté d'une des parties. La victime de la rupture fautive ne peut donc prétendre qu'à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu'elle a subi.

Mais quel est exactement le préjudice réparable ? Il faut distinguer ici deux types de préjudices bien différents. D'une part, la négociation qui n'a pas abouti a pu occasionner un certain nombre de frais (frais de déplacement, coût d'élaboration de plans, rapports comptables et autres documents, rémunération des conseils pendant la négociation, temps de travail du personnel de l'entreprise, etc.), en même temps que, peut-être, elle a empêché la victime de donner suite à d'autres projets concurrents. Ce type de préjudice correspond à ce que la doctrine allemande, à la suite de Ihering, appelle l'atteinte à l'intérêt négatif (*negatives Interesse*), ou, dans les pays de *common law* au « *reliance interest* » : réparer ce type de préjudice revient à replacer la partie déçue dans la situation où elle se serait trouvée si la négociation avortée n'avait pas eu lieu. Mais d'autre part, cette partie peut soutenir que, si le contrat espéré avait été passé, et exécuté, elle aurait pu réaliser des bénéfices dont elle se trouve frustrée par suite de l'échec des négociations : ce préjudice correspond à l'atteinte à l'intérêt positif, ou, dans la terminologie anglaise et américaine, à l'« *expectation interest* ». Dans presque tous les systèmes juridiques (hors ceux du Code civil), la jurisprudence n'accepte de réparer, en cas de rupture des pourparlers, que l'atteinte à l'intérêt négatif – ce qui est la règle habituellement suivie lorsqu'un contrat n'est pas conclu : la victime de la rupture ne peut obtenir que le remboursement des frais exposés lors des négociations, ainsi qu'une indemnité compensant les occasions perdues de contracter avec un tiers. Il n'y a guère qu'en droit néerlandais qu'on admet la compensation de l'*expectation interest* (c'est-à-dire des bénéfices que le contrat manqué aurait procurés), du moins dans le cas où les négociations ont été rompues très peu de temps avant la conclusion prévue du contrat.

En droit français, pendant longtemps, on ne s'est pas posé ce type de question, dans la mesure où, traditionnellement, les juges du fond évaluent souverainement le montant des dommages et intérêts, tant en matière contractuelle qu'en matière délictuelle, sans que la Cour de cassation exerce son contrôle. Les juges pouvaient donc, selon les circonstances, accorder à la victime de la rupture toute indemnisation qui leur semblait correspondre au préjudice subi, ce qui pouvait couvrir à la fois les frais liés à la négociation et la perte des bénéfices escomptés du contrat (même si ceux-ci ne pouvaient en général être réparés que de manière partielle, par le biais de la notion de perte d'une chance). C'est du reste en raison de cette appréciation souveraine que la distinction entre l'intérêt positif et l'intérêt négatif ne s'est jamais vraiment implantée dans la doctrine et la jurisprudence françaises. Cependant, depuis un arrêt très important de 2003 (Manoukian), la Cour de cassation française a décidé d'encadrer la réparation du préjudice lié à la rupture des pourparlers, en posant que « les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat »[342]. Désormais, en droit français comme dans la plupart des autres pays européens, la victime de la rupture ne peut obtenir que le remboursement les frais occasionnés par les négociations rompues, ainsi que, peut-être, la compensation du préjudice lié aux occasions perdues. Cette solution a été explicitement consacrée lors de la réforme par l'article 1112 du Code civil français selon lequel « [e]n cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en

342 Cass. fr., 26 novembre 2003, n°s 00-10243 et 00-10949.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages ». L'article 5.17 du nouveau Code civil belge, sans doute influencé par le droit néerlandais, se montre plus nuancé. S'il pose en principe qu'« en cas de rupture fautive des négociations, cette responsabilité implique que la personne lésée soit remise dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée s'il n'y avait pas eu de négociations » (ce qui est l'intérêt négatif), il ajoute que « lorsque la confiance légitime que le contrat serait sans aucun doute conclu a été suscitée, cette responsabilité peut impliquer la réparation de la perte des avantages nets attendus du contrat non conclu ».

Sur cette question, la jurisprudence luxembourgeoise semble pencher vers une approche restrictive du préjudice indemnisable. Certaines décisions, dans la lignée de la jurisprudence française traditionnelle, avaient estimé qu'il appartient au juge d'apprécier selon les circonstances, l'étendue du préjudice subi, en y incluant éventuellement la perte d'une chance de réaliser les gains attendus du contrat non passé[343]. Mais les arrêts les plus récents, se référant à l'arrêt *Manoukian*, limitent par principe le dommage réparable aux frais engagés lors de la négociation ainsi qu'aux occasions manquées, et refusent d'indemniser la perte des avantages attendus du contrat non conclu ou même de la perte d'une chance de les obtenir[344]. C'est sans doute cette seconde voie qui devrait, à l'avenir, être privilégiée.

SECTION 2. LES CONTRATS PRÉLIMINAIRES

181. Notion et terminologie. Il arrive fréquemment que les parties, avant le contrat qui les liera définitivement, passent un ou plusieurs contrats destinés à préparer ce contrat définitif, soit en organisant les négociations qui doivent y conduire, soit en en fixant par avance certaines conditions, soit parfois en s'engageant d'ores et déjà à sa conclusion. Traditionnellement, ces accords sont nommés avant-contrats, ce qui est une terminologie ambigüe, car elle tend à faire oublier que ces avant-contrats sont déjà, en eux-mêmes, des contrats. La doctrine contemporaine parle plus volontiers de contrats préliminaires ou de contrats préparatoires. Au sein de ces contrats, qui sont très divers, on peut faire une distinction entre ceux qui engagent au moins une partie à la conclusion du contrat

343 Cour d'appel, 9 janvier 2003, n° 25595 ; Trib. Luxembourg, 26 janvier 2007, n° 34/07 XI ; Cour d'appel, 5 mars 2008, n° 19272.

344 Cour d'appel, 13 février 2008, *Pas.* 34, p. 155 ; Trib. Luxembourg, 1er juin 2011, n° 125/11 XI ; Cour d'appel, 24 juin 2015, n° 38213 ; Trib. Luxembourg, 1er décembre 2023, n° TAL-2019-09591.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

définitif (§ 1) et ceux qui n'emportent pas un tel engagement (§ 2) – sauf à noter que, en pratique, la question sera parfois de savoir dans quelle catégorie entre l'accord passé par les parties.

§1. Les contrats engageant au contrat définitif

182. Promesses de contrat. On peut, par un contrat, s'engager à passer ultérieurement un autre contrat. C'est ce qu'on appelle une promesse de contrat. Il en existe deux sortes, selon qu'une seule, ou que les deux parties, s'engagent à passer le contrat ultérieur. Dans le premier cas, on parlera de promesse unilatérale (A), dans le second de promesse synallagmatique (B).

A) *Les promesses unilatérales*

183. Notion. L'hypothèse est que l'une des deux parties est d'ores et déjà décidée à conclure un contrat, mais que l'autre hésite encore. On peut dans un tel cas, en rester au stade de l'offre, en laissant à celui qui hésite un délai de réflexion. Mais, pour fixer davantage la situation, les parties peuvent conclure un contrat par lequel le premier (le promettant) manifeste d'ores et déjà son consentement au contrat projeté si, dans un certain délai, l'autre (le bénéficiaire de la promesse) se décide à le passer. Le promettant est d'ores et déjà engagé au contrat principal, le bénéficiaire dispose d'une option – ce que traduit bien la terminologie allemande d'*Optionsvertrag* utilisée pour désigner ce type de contrat. Les promesses unilatérales sont ignorées du Code civil de 1804 : l'article 1589, qui est relatif aux promesses de vente, ne concerne que les promesses synallagmatiques portant engagement réciproque des parties de vendre et d'acheter[345]. Mais elles ont fait leur entrée dans le Code civil français (art. 1124) et dans le nouveau code belge (art. 5.25 intitulé « contrat d'option ou promesse unilatérale de contrat » Il s'agit de contrats très répandus dans la pratique. L'application principale en est la promesse unilatérale de vente, surtout utilisée pour les ventes immobilières et pour les ventes d'actions (les *stock options* consenties aux salariés ou aux dirigeants d'une entreprise en sont une illustration particulière). Mais on peut aussi bien, à l'inverse, faire une promesse d'achat : ainsi lorsque le vendeur d'un bien s'engage à vous le racheter si, dans un certain délai, vous décidez

345 Voy. *infra*, n°s 188 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de le remplacer par un nouveau[346]. Au-delà, n'importe quel type de contrat peut faire l'objet d'une promesse : un bail, un prêt (l'ouverture de crédit qu'une banque fait à un client, celui-ci étant libre ou non d'emprunter les fonds), un contrat de travail (une promesse d'embauche faite à l'issue d'un stage par exemple), etc. Comme on le voit à travers les exemples précédents, la promesse peut être, soit un contrat isolé destiné à préparer un autre contrat, soit un élément d'un contrat ayant un objet plus général.

184. Analyse du mécanisme. La promesse unilatérale, à la différence de l'offre, est déjà un véritable contrat, puisqu'il y a accord des deux parties – cet accord étant habituellement concrétisé dans la pratique par la signature d'un écrit. Mais cet accord ne fait naître l'obligation de passer le contrat définitif que pour une seule partie, l'autre est libre de passer ou non le contrat définitif – ce pourquoi on parle de promesse unilatérale. Cette promesse n'est cependant pas nécessairement un contrat unilatéral, dans la mesure où, très souvent, le promettant exige du bénéficiaire le versement d'une certaine somme en contrepartie de l'avantage qui lui est consenti, et en compensation du sacrifice consenti par le promettant en immobilisant son bien : cette somme, qui est en quelque sorte le prix de la promesse[347], fait alors de la promesse unilatérale un contrat synallagmatique. Mais cela n'en devient pas pour autant une promesse synallagmatique, dès lors que le bénéficiaire ne s'oblige pas à passer le contrat définitif[348].

La figure juridique de la promesse unilatérale peut sembler curieuse dans le système du Code civil. Nous verrons en effet que le Code prohibe les contrats conclus sous une condition purement potestative de la part de celui qui s'oblige – c'est-à-dire les contrats où le débiteur subordonne son obligation à sa volonté arbitraire[349]. Cependant, outre que la portée de cette prohibition est très incertaine, on peut soutenir que tel n'est pas le cas dans la promesse de

346 Le Code civil réglemente spécialement cette vente avec option de rachat sous le nom de vente à réméré (C. Civ., art. 1659 et s.). En droit français, le terme de « réméré » a été supprimé par une loi de 2009.

347 Cass. fr. (1re civ.), 5 décembre 1995, no 93-19874.

348 À une certaine époque, la Cour de cassation française avait paru estimer que, si le montant stipulé était très élevé, de telle sorte que cela pouvait contraindre en fait le bénéficiaire à lever l'option, cela pouvait entraîner la requalification de la promesse en promesse synallagmatique (Cass. fr. (comm.), 8 novembre 1972, no 71-12479), mais cette jurisprudence semble abandonnée : Cass. fr. (comm.), 25 avril 1989, no 87-17281 ; Cass. fr. (1re civ.), 1er décembre 2010, no 09-65.673.

349 Voy. *infra*, nos 593 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

vente : on ne peut pas dire que le bénéficiaire s'oblige à acheter s'il veut. Il est plus juste de dire qu'il ne s'oblige pas du tout, le contrat lui donne simplement un droit d'option. La doctrine voit aujourd'hui dans ce droit d'option l'exemple type des droits potestatifs « pouvoirs par lesquels leurs titulaires peuvent influer sur les situations juridiques préexistantes en les modifiant, les éteignant, ou en en créant de nouvelles au moyen d'une activité propre unilatérale »[350].

Souvent présentée comme évidente, la distinction de la promesse unilatérale de contrat et de l'offre de contracter illustre bien en réalité la relativité des constructions juridiques. Lorsqu'une personne dit (ou écrit) à l'autre qu'elle lui propose tel bien à tel prix, et qu'elle lui laisse tel délai pour donner sa réponse, on analysera la situation comme une offre de contracter, dans laquelle on verra, éventuellement, dans le droit moderne, un acte juridique unilatéral, qui pourra devenir contrat au jour où le destinataire acceptera. Rien à voir, dira-t-on, avec une promesse, qui repose d'ores et déjà sur l'accord des deux parties. Pourtant, on pourrait tout aussi bien dire que, dans le premier cas, le destinataire de la proposition accepte tacitement d'avoir un certain délai pour répondre (puisqu'il n'a aucun intérêt à le refuser, et que, on l'a vu, dans un tel cas, le silence peut valoir acceptation) : on verrait alors dans la situation une promesse unilatérale tacite. C'était du reste, au XIXe siècle, l'analyse qui permettait à Demolombe de reconnaître une certaine force obligatoire à l'offre, à une époque où on ne reconnaissait pas la valeur juridique de l'engagement unilatéral. Il paraît aujourd'hui inutile de passer par ce détour du contrat tacite, mais, au fond, l'analyse de Demolombe n'était pas aussi artificielle qu'on le prétend maintenant ; au moins doit-on reconnaître qu'entre la promesse expressément acceptée, et l'offre assortie d'un délai, la différence n'est pas dans la nature des choses, mais dans la représentation juridique qu'on en donne. Du reste, on continuera habituellement à qualifier d'offre une proposition de contracter assortie d'un délai, même si le destinataire prend la peine de répondre explicitement qu'il va réfléchir pendant le délai qui lui est imparti. On basculera plus volontiers vers la qualification de promesse si l'accord des parties sur le délai de réflexion est formalisé.

Du côté du promettant, l'analyse du mécanisme n'est pas évidente. On pourrait dire que le promettant, de son côté, contracte une double obligation : d'abord l'obligation de passer le contrat définitif, qui est une obligation de faire, ensuite l'obligation de ne rien faire qui puisse empêcher cette passation – et notamment, dans le cas de la promesse unilatérale de vente, de ne pas vendre le bien promis à quelqu'un d'autre. Mais cette analyse en termes d'obligations est aujourd'hui, à juste titre, contestée, car on voit mal comment le fait de consentir à un contrat futur peut-être l'objet d'une obligation. Il semble préférable de dire que le promettant n'a pas l'obligation de consentir, mais qu'il a d'ores et déjà consenti au

350 I. Najjar, *Le droit d'option. Contribution à l'étude du droit potestatif et de l'acte unilatéral*, Paris LGDJ, 1967, p. 102. Sur les droits potestatifs, voy. aussi J. Rochfeld, « Les droits potestatifs accordés par le contrat », in *Le contrat au début du XXIe siècle, Études offertes à J. Ghestin*, Paris, LGDJ, 2000, pp. 746 à 768.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

contrat définitif, et qu'il ne peut révoquer ce consentement en raison de la force obligatoire du contrat de promesse. Cette analyse est nettement consacrée par le nouvel article 1124 du Code civil français qui définit la promesse comme « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ». Il est remarquable que la Cour d'appel du Luxembourg, qui analysait antérieurement la promesse de vente comme un contrat ayant pour objet de transférer la propriété[351], a repris presque textuellement la formule de l'article 1124 dans un arrêt de 2016[352]. Cette analyse a des conséquences importantes tant quant aux conditions de validité de la promesse que sur ses effets.

185. Conditions de validité de la promesse. Parce qu'elle oblige d'ores et déjà le promettant au contrat définitif, la promesse n'est valable que si elle contient déjà les éléments essentiels de ce contrat. Ce point est désormais précisé en France et en Belgique parmi les éléments de la définition même de la promesse. Pour la même raison, c'est en principe au jour de la promesse que s'apprécient les conditions de validité du contrat qui tiennent au promettant. C'est ainsi que le promettant doit être capable dès le jour de la promesse, celle-ci, s'il s'agit d'une promesse de vente, étant considérée à son égard comme un acte de disposition[353]. En revanche, parce que le bénéficiaire n'est pas obligé d'acheter, c'est seulement au jour de la levée de l'option qu'il doit avoir la capacité de disposer. Par ailleurs, parce que c'est seulement au jour de la levée de l'option que se forme le contrat définitif, c'est à ce moment-là qu'on appréciera, en cas de vente immobilière, s'il y a eu ou non une lésion[354].

186. Effets de la promesse avant l'exercice de l'option. Tant que dure le délai d'option et que le bénéficiaire n'a pas fait connaître sa position, la promesse fait seulement naître un droit contre le promettant sans produire encore aucun des effets du contrat définitif. On voit bien la différence dans le cas d'une promesse unilatérale de vente : le bénéficiaire n'acquiert du fait de la promesse aucun droit réel sur le bien qui en est l'objet, et dont la propriété ne lui

351 Cour d'appel, 9 décembre 2009, n° 33501.
352 Cour d'appel, 2 mars 2016, n° 32854.
353 Cour d'appel, 27 juin 2007, n° 31749.
354 Cour d'appel, 25 novembre 1921, Pas. 11. P. 221.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

sera transférée que si la vente est finalement passée. Il n'en a pas moins, dès le jour de la promesse, un droit personnel qui fait partie de son patrimoine, et qu'il peut en principe céder, dont il peut garantir l'exécution en prenant des sûretés, et qui se transmettra à ses héritiers s'il décède.

Que va-t-il se passer si le promettant ne respecte pas ses obligations – soit que, au mépris de la promesse, il décide finalement de ne pas passer le contrat définitif, soit qu'il passe le contrat avec un tiers ? Cette question – qui ne semble pas s'être posée jusqu'à maintenant au Luxembourg – a donné lieu, en France, à d'importantes controverses. Depuis un arrêt très remarqué de 1993[355], la Cour de cassation française avait estimé de manière presque constante que le promettant, dans une promesse unilatérale de vente, ne pouvait pas être contraint de passer le contrat définitif avec le bénéficiaire, et que celui-ci ne pouvait obtenir que des dommages et intérêts, sauf stipulation expresse en sens contraire[356]. La solution, généralement critiquée en doctrine[357], était fondée sur l'article 1142 du Code civil, selon lequel « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ». Il est vrai que, comme nous le verrons plus loin, la portée de ce texte était, avant la réforme française, et est toujours au Luxembourg, très réduite, et qu'il n'excluait pas, d'une manière générale qu'un contractant puisse être condamné, au besoin sous astreinte (c'est-à-dire sous la menace d'avoir à payer une somme d'argent), à exécuter en nature ses obligations de faire ou de ne pas faire. Mais la jurisprudence considérait traditionnellement que toute contrainte à exécuter en nature est exclue lorsque l'obligation inexécutée présente un caractère strictement personnel, et on peut considérer que tel est le cas pour l'obligation de passer un contrat : n'est-il pas contraire à la notion même de contrat que de condamner quelqu'un à consentir à un contrat dont il ne veut pas ? Pour répondre à ce type d'arguments, mis en avant par les rares auteurs qui approuvent la solution de la Cour de cassation[358], on peut cependant soutenir, comme il a déjà été dit, qu'il ne s'agit nullement ici de contraindre quelqu'un à consentir, parce que, précisément, le promettant a déjà, au moment de la promesse, donné son consentement au contrat définitif, et que la levée de l'option, valant acceptation de ce contrat, suffira à la former, sans que le promettant puisse s'y opposer[359]. La formation du contrat définitif serait donc un effet direct de la force obligatoire du contrat de promesse[360]. Si le tribunal contraint le promettant à faire quelque chose, c'est seulement à passer les actes matériels nécessaires à la concrétisation du contrat (notamment à signer l'acte authentique), et une telle obligation, qui n'a rien de spécialement personnel, paraît tout à fait susceptible d'exécution

355 Cass. fr. (3e civ.), 15 décembre 1993, n° 91-14999 ; *Defrénois*, 1994, p. 795, note P. Delbecque ; *JCP G*, 1995, II, p. 22366, note D. Mazeaud ; *RTD civ.*, 1994, p. 588, obs. J. Mestre.

356 Cass. fr. (3e civ.), 27 mars 2008, n° 07-11721 ; Cass. fr. (3e civ.), 11 mai 2011, n° 10-12.875 ; Cass. fr. (comm.), 30 septembre 2011, n° 10-19626. Un arrêt de 2010 avait paru s'orienter dans une autre direction [Cass. fr. (3e civ.), 8 septembre 2010, n° 09-13345], mais la Cour est revenue dès 2011 à sa position habituelle.

357 Voy., p. ex., D. Houtcieff, *Droit des contrats*, 8e éd., Bruxelles, Bruylant, 2023, (cité *infra*, Houtcieff) n° 209 et les auteurs cités.

358 Voy. p. ex. D. Mainguy, « L'efficacité de la rétractation de la promesse de contracter », *RTD civ.*, 2004, pp. 1 et s. .

359 Fages, n° 60.

360 P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », *RTD civ.*, 1999, pp. 771 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

forcée. Aussi bien, dès lors que le texte français, comme on l'a vu, a consacré cette analyse, il a fort logiquement posé, contrairement à la jurisprudence antérieure, que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis »[361]. La même solution semble admise en Belgique[362] où, curieusement, la question n'a pas suscité les mêmes débats qu'en France. Le nouvel article 5.25 se contente d'affirmer que « [l]orsqu'un contrat avec un tiers viole le pacte de préférence ou le contrat d'option, le bénéficiaire dispose contre le débiteur des sanctions de l'inexécution », ce qui semble inclure l'exécution forcée, donc la formation du contrat définitif contre le gré de l'offrant. Même si on admet cette solution, une difficulté supplémentaire surgit lorsque le promettant a vendu le bien objet de la promesse à un tiers. Dans une telle hypothèse, on ne peut pas dire que le promettant a vendu la chose d'autrui – ce qui serait une cause de nullité de la vente sur le fondement de l'article 1599 du Code civil – puisque le promettant est toujours propriétaire tant que le bénéficiaire n'a pas levé l'option. Il en résulte que la vente au tiers est en principe valable et lui transfère la propriété du bien. Le bénéficiaire de la promesse ne pourrait pas récupérer le bien si ce tiers ignorait l'existence de la promesse (ce qui est tout à fait possible, dans la mesure où, en droit luxembourgeois, les promesses de vente ne font l'objet d'aucune publicité, même en matière immobilière). Il ne pourra obtenir que des dommages et intérêts du promettant. Si en revanche le tiers connaissait l'existence de la promesse, il pourra, au minimum, être condamné à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en tant que complice de la violation par le promettant de ses obligations contractuelles[363]. Si on admet l'exécution en nature des promesses, on pourra même envisager que le contrat passé avec ce tiers de mauvaise foi soit annulé, et que le bénéficiaire initial lui soit substitué. Cette solution, qui avait été admise dès avant la réforme par la Cour de cassation française en matière de pacte de préférence[364], est désormais, dans le nouveau texte français, applicable à la promesse de contrat : l'article 1124 du Code civil prévoit seulement la nullité du contrat passé avec le tiers, mais cette nullité fera revivre la promesse, qui pourra alors, si le bénéficiaire le désire, découcher sur le contrat définitif. Beaucoup plus explicite, l'article 5.26 du nouveau Code civil belge prévoit qu'« [à] l'encontre du tiers qui est complice de la violation du pacte de préférence ou du contrat d'option, le bénéficiaire peut également demander la réparation du dommage subi, l'inopposabilité du contrat ou sa substitution au tiers dans le contrat conclu ». Au Luxembourg, on ne peut guère citer qu'un jugement de 2013 qui, tout en posant que « la question de savoir si la promesse unilatérale de vente est susceptible d'une exécution forcée en nature obtient en principe une réponse négative », admet que, lorsque le tiers acquéreur était de mauvaise foi, la vente qui lui a été consentie peut être déclarée inopposable au bénéficiaire[365].

Une autre question se pose dans l'hypothèse où la promesse ne fixe pas le délai laissé au bénéficiaire pour la levée de l'option. Il est difficile d'admettre dans un tel cas que le promettant est tenu indéfiniment. On admet dès lors qu'il peut à tout

361 Pour une critique virulente de cette solution, voy. M. FABRE-MAGNAN, « De l'inconstitutionnalité de l'exécution forcée des promesses unilatérales de vente. Dernière plaidoirie avant adoption du projet de réforme du droit des contrats », *D.*, 2015, 826.

362 WÉRY, n° 180, qui ne cite cependant aucune décision ; VAN OMMESLAGHE, n° 372, n'examine pas la question.

363 Sur la responsabilité du tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle, voy. *infra*, n°s 970 et s.

364 Voy. *infra*, n° 193.

365 Trib. Luxembourg, 2 janvier 2013, n° 143530.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

moment mettre le bénéficiaire en demeure de lever l'option dans un certain délai, à défaut de quoi le promettant sera libéré de son engagement. Cette solution a été consacrée par la jurisprudence française, et elle a été récemment reprise par le Tribunal de Luxembourg[366].

187. Effets de la promesse au moment de l'exercice de l'option. À l'issue du délai qui lui est laissé pour opter, le bénéficiaire doit prendre parti. Il peut naturellement le faire avant, en déclarant à tout moment qu'il accepte le contrat définitif ou qu'il y renonce. Si aucun délai n'a été fixé pour la levée de l'option, la jurisprudence française considère que le promettant peut mettre en demeure à tout moment le bénéficiaire de prendre parti. À défaut, le bénéficiaire peut lever l'option jusqu'à l'expiration du délai de prescription. Cette solution est également retenue par la jurisprudence luxembourgeoise[367].

Si le bénéficiaire ne lève pas l'option, le contrat définitif ne se formera pas et la promesse deviendra caduque. Dans le cas où le bénéficiaire avait versé une certaine somme lors de la promesse, le promettant conservera cette somme, mais le bénéficiaire, qui n'était pas obligé de passer le contrat définitif, ne pourra pas être condamné à des dommages et intérêts supplémentaires. À l'inverse, il ne pourra pas prétendre faire réduire la somme comme il le pourrait d'une clause pénale, c'est-à-dire d'une somme stipulée à titre de dommages et intérêts[368] : cette somme, qui ne sanctionne pas l'inexécution d'une obligation, mais qui constitue, comme on l'a déjà dit, le prix de l'avantage consenti au bénéficiaire, ne peut pas s'analyser en une clause pénale révisable[369].

Si le bénéficiaire lève l'option, c'est-à-dire accepte le contrat définitif, cette acceptation, se superposant au consentement préalablement donné par le promettant, formera ce contrat. Il est admis que cette formation ne s'opère pas de manière rétroactive – ce qui serait le cas si on analysait la promesse comme un contrat sous condition de l'acceptation du bénéficiaire. C'est donc au jour de la levée de l'option, et non au jour de la promesse, qu'on appréciera si les conditions de validité du contrat étaient remplies – par exemple, si les parties étaient capables ou si la valeur de l'immeuble vendu n'était pas trop élevée par rapport au prix[370].

366 Trib. Luxembourg, 7 février 2024, n° TAL-2021-02477.

367 Cour d'appel, 7 février 2007, n° 31077 ; Trib. Luxembourg, 7 février 2024, n° TAL-2021-02477.

368 Sur la notion de clause pénale et la révision judiciaire d'une telle clause, voy. *infra*, n°s 866 et s.

369 Cass. fr (1re civ.), 5 décembre 1995, préc.

370 En matière de vente d'immeubles, le prix trop faible peut constituer une lésion, cause de nullité du contrat. Voy. *infra*, n° 261.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

B) *Les promesses synallagmatiques*

188. Notion. Dans ce type de promesse, les deux parties s'obligent réciproquement à passer ultérieurement un contrat entre elles. L'utilité d'un tel contrat préliminaire n'est pas de prime abord évidente : on peut se demander pourquoi, si les parties sont toutes deux d'accord pour passer le contrat, elles ne le font pas immédiatement. La formule présente cependant un intérêt lorsque la passation du contrat requiert l'accomplissement de certaines formalités qui prennent du temps (notamment, la passation d'un acte authentique). Les parties peuvent alors vouloir, sans attendre, manifester leur accord. C'est à cette fin que la promesse synallagmatique est très souvent utilisée en matière de vente immobilière, où elle prend la forme du compromis de vente que le vendeur et l'acheteur signent habituellement, dès qu'ils sont d'accord sur le prix et les conditions de la vente, sans attendre la rédaction de l'acte authentique par le notaire. On peut également concevoir de passer une telle promesse synallagmatique lorsque, au cours de négociations, les parties sont d'accord sur le principe du contrat mais veulent encore discuter sur certains points de détail. La question qui se pose, dans ces différents contextes, est de savoir quels sont les rapports entre cette promesse et le contrat définitif.

189. Principe : la promesse de contrat vaut contrat. En principe, parce que les deux parties ont exprimé leur accord, la promesse synallagmatique suffit à les lier, c'est elle qui constitue le contrat doté de force obligatoire, et l'acte qui sera signé ultérieurement ne sera qu'un acte d'exécution, dressé pour des raisons probatoires ou de publicité[371]. Telle est la signification qu'on peut donner à l'article 1589 du Code civil, selon lequel « la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ». Dans ce cas, comme le souligne la Cour d'appel, la réitération par acte authentique n'est qu'une modalité d'exécution du contrat de vente[372]. Il en résulte que, si l'une des deux parties se refuse à passer l'acte authentique, l'autre pourra l'y faire condamner, au besoin sous astreinte, et il est admis que, à défaut pour la partie récalcitrante d'y satisfaire, le jugement de condamnation vaudra acte authentique. Par ailleurs, contrairement à ce qui a été vu

371 Sur les fonctions de la rédaction de l'acte authentique, voy. *infra*, n° 433.

372 Cour d'appel, 7 juillet 2022, n° CAL-2021-00945.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pour la promesse unilatérale, les conditions de validité du contrat s'apprécient toutes au jour de la promesse et non au jour de la passation de l'acte définitif.

Ce principe n'est pas remis en cause lorsque les parties décident, dans leur compromis, de retarder les effets de la vente à la passation du contrat définitif – par exemple en stipulant, ce qui est très fréquent en pratique, que le transfert de propriété du bien vendu, la remise des clés et le paiement du prix auront lieu seulement au jour de la rédaction de l'acte authentique. En dépit de ces stipulations, la vente n'en aura pas moins force obligatoire dès le jour de la signature du compromis, et produira tous les effets qui n'auront pas été spécialement différés par les parties[373]. Il en va de même dans le cas, également très fréquent, où les parties insèrent dans leur compromis une ou plusieurs conditions subordonnant la réalisation effective de la vente à des événements extérieurs (l'obtention d'un permis de construire pour des travaux à réaliser sur l'immeuble vendu, l'obtention d'un crédit pour financer l'acquisition). Si elles suspendent la naissance des obligations contractuelles, de telles conditions ne remettent pas en cause le principe même de la force obligatoire du contrat, et, si elles se réalisent, celui-ci sera réputé conclu dès le jour de la promesse[374].

190. Exceptions : dissociation entre la promesse et le contrat définitif. Il peut cependant arriver que les parties souhaitent dissocier la promesse et le contrat définitif, en repoussant la conclusion de celui-ci au jour de la rédaction du second acte. C'est ce que rappelle un arrêt de la Cour d'appel, en se référant à un arrêt de la Cour de cassation française : « La réitération par acte authentique d'une promesse synallagmatique de vente peut être une condition de validité du contrat de vente si les parties ont fait de cette réitération un élément constitutif de leur volonté »[375]. Les parties n'en sont alors pas moins liées par un premier contrat doté de force obligatoire, et celle qui se refuserait à passer le contrat définitif engagerait certainement sa responsabilité. Mais, dans une telle hypothèse, le tribunal

[373] Voy. Cour d'appel, 15 mai 2002, n° 25788 (en l'espèce, les parties à un compromis de vente avaient différé la tradition de la chose et le paiement du prix, mais n'avaient rien dit du transfert de propriété ; la Cour a considéré que ce transfert s'était opéré dès le jour du compromis) ; Trib. Luxembourg, 28 octobre 2021, n° TAL-2020-03730.

[374] Voy. *infra*, n° 600.

[375] Cour d'appel, 10 juillet 2014, n° 40507, citant Cass. fr. (3e civ.), 17 juillet 1997, n° 95-22.180.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de Luxembourg a semblé considérer qu'à défaut de passation de l'acte authentique, la seule sanction envisageable était l'allocation de dommages et intérêts[376].

191. Accords de principe. On peut, au regard de ces analyses, reprendre la question des *accords de principe* qui sont passés au cours d'une négociation, pour fixer les points de convergences des parties en attendant un accord complet sur tous les éléments[377]. Dans certains cas, comme on l'a vu, on considérera que les divergences subsistantes sont trop importantes pour lier définitivement les parties, et l'accord ne pourra pas valoir promesse de passer le contrat définitif, il n'emportera que l'engagement de poursuivre les négociations sur les points encore en discussion. Comme le souligne le Tribunal de Luxembourg, « cette obligation est de moyens et non de résultat : c'est un engagement de négocier qui est conclu, et non une obligation de conclure le contrat définitif ». La principale conséquence est alors que, si l'une des parties rompt les négociations et que cette négociation apparaît contraire à la bonne foi, elle engagera sa responsabilité contractuelle et non pas délictuelle comme c'est la règle en cas de rupture des pourparlers[378]. On peut en outre penser que cette responsabilité sera plus facilement retenue que s'il n'y avait pas eu d'accord de principe. Dans d'autres cas, on pourra considérer que les parties sont déjà liées, même si le contrat définitif ne sera conclu qu'à l'issue des négociations. Si celles-ci achoppent sur les points accessoires restant en discussion, cela ne devrait pas empêcher la conclusion de ce contrat, les solutions légales sur les points considérés se substituant alors aux solutions sur lesquelles les parties restent en désaccord. À tout le moins doit-on considérer que, dans un tel cas, la partie qui se refuserait à signer l'acte définitif engagerait sa responsabilité.

SECTION 3. LES CONTRATS N'ENGAGEANT PAS AU CONTRAT DÉFINITIF

192. Les contrats organisant les négociations. Parmi les contrats préliminaires les moins contraignants figurent ceux par lesquels les parties à une négociation organisent celle-ci. Il existe ici toute une palette d'accords envisageables, qui n'entrent dans aucune catégorie prédéfinie, et dont la force obligatoire se fonde uniquement sur le principe de la liberté contractuelle. Elles peuvent ainsi préciser par un accord

376 Trib. Luxembourg, 29 avril 2004, n° 8553.

377 Voy. *supra*, n° 157.

378 Trib. Luxembourg, 29 avril 2010, n°s 118390 ; 239/2010

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

préalable, au moment où elles entrent en contact, les modalités matérielles des négociations (lieux et dates des rencontres, désignation des personnes habilitées à négocier, documents à échanger, répartition des frais, etc.). Les parties peuvent également passer des accords de confidentialité, en s'engageant expressément à ne pas révéler à autrui et à ne pas utiliser pour elles-mêmes les renseignements, de nature technique ou financière, qu'elles auraient pu apprendre sur l'autre partie au cours des négociations. Elles peuvent s'engager à négocier pendant un certain temps, et sur certains points : tel est le sens qu'on peut donner aux accords de principe lorsqu'ils ne valent pas encore accord au contrat définitif. Même s'ils ne comportent aucun engagement de passer le contrat définitif, tous ces accords ont déjà pleine force obligatoire et font naître des obligations à la charge des parties, dont le manquement sera sanctionné par une responsabilité contractuelle (dont le montant peut d'ailleurs être précisé).

193. Le pacte de préférence. Souvent étudié en même temps que les promesses, le pacte de préférence en est en réalité très différent, car il n'emporte pas engagement de conclure un contrat ultérieur. Dans ce contrat, le promettant s'engage envers le bénéficiaire, non pas à conclure avec lui un contrat, mais à lui proposer par préférence à toute autre personne pour le cas où il déciderait de le passer[379]. Le nouvel article 1123 du Code civil français le définit comme « le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter », et on retrouve une définition équivalente dans l'article 5.24 du nouveau Code civil belge. Par exemple, je vous vends une partie de mon terrain, en me réservant pour l'instant l'autre partie ; mais je vous promets que, si un jour je décide de vendre cette autre partie, je vous la proposerai en priorité. Le pacte de préférence se rencontre également en droit des sociétés, lorsqu'un actionnaire ou un groupe d'actionnaires s'engagent, s'ils vendent leurs actions, à les proposer prioritairement aux associés actuels. Le pacte apparaît donc comme une limitation conventionnelle de la liberté de choisir son cocontractant. Il constitue l'équivalent conventionnel des droits de préemption que la loi accorde de plein droit à certaines catégories de personnes[380].

379 Sur la distinction entre pacte de préférence et promesse de contrat, voy. Cour d'appel, 28 novembre 2001, n° 25242 ; Cour d'appel, 11 janvier 2024, n° CAL-2022-00583.

380 Voy. *supra*, n° 105. Sur cette analogie voy. Cour d'appel, 2 mai 2024, n^{os} CAL-2019-00502, CAL-2019-00987 et CAL-2020-00667, qui qualifie le pacte de preference de "droit de préemption conventionnel"

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

À la différence des promesses, le pacte de préférence n'a nul besoin de contenir au départ les éléments essentiels du contrat concerné, et en particulier le prix qui sera ultérieurement proposé[381]. Il suffit que l'objet de ce contrat soit déterminé au départ. Quant à ses effets, ils sont moindres que ceux d'une promesse unilatérale, puisque le bénéficiaire n'a aucun droit à la conclusion du contrat envisagé, il n'a qu'un droit de priorité si le promettant désire passer le contrat. Un arrêt récent de la Cour d'appel traduit cela en notant que « [l]e pacte peut donc rester longtemps sans effet obligationnel, tout en ayant force obligatoire »[382]. Si le promettant veut passer le contrat objet du pacte, il devra l'offrir prioritairement au bénéficiaire, qui sera libre d'accepter ou non au prix et aux conditions proposées. S'il n'accepte pas, le promettant sera libre d'offrir le bien à un tiers, aux mêmes conditions. Il faut en tout cas que l'offre aux tiers ne soit pas faite à des conditions plus favorables, et en particulier que le prix proposé aux tiers ne soit pas plus bas que celui qui a été proposé au bénéficiaire du pacte, sinon il serait facile au promettant de frauder les droits de celui-ci, en lui proposant à un prix exorbitant pour l'amener à refuser, pour offrir ensuite à un tiers à un meilleur prix. L'article 5.24 du nouveau Code civil belge précise à cet égard que, si de nouvelles conditions plus favorables étaient proposées au tiers, il faudrait procéder à une nouvelle notification au bénéficiaire du pacte. Pour accélérer le processus, le nouveau droit français permet au tiers intéressé par le contrat objet du pacte de de demander par écrit au bénéficiaire du pacte de dire dans un certain délai s'il entend s'en prévaloir. À défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire sera censé avoir renoncé au pacte. L'utilité et l'efficacité de cette « action interrogatoire », dont il existe d'autres exemples dans le nouveau droit français, est cependant contestée par la doctrine[383].

Comme pour les promesses unilatérales, se pose la question de savoir quelle est la sanction si le promettant manque à ses obligations, en proposant le contrat à un tiers sans l'avoir préalablement proposé au bénéficiaire. Comme en matière de promesse, il est clair qu'on ne pourra rien faire contre le tiers si celui-ci ignorait l'existence du pacte ; dans ce cas, le bénéficiaire devra se contenter de dommages et intérêts de la part du promettant qui a manqué à son obligation, et éventuellement du notaire qui, connaissant l'existence du pacte, a prêté son concours pour rédiger le contrat passé avec le tiers[384]. Si, en revanche, le tiers était de mauvaise foi, il pourrait également

381 Dans ce sens : Cour d'appel, 13 décembre 2006, n° 30474, *BIJ*, 2007, p. 43.

382 Cour d'appel, 11 janvier 2024, préc.

383 Voy. p. ex. HOUTCIEFF, n° 217.

384 Trib. Luxembourg, 14 juillet 2023, n° TAL-2022-02719.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

être condamné à des dommages et intérêts. Mais dans un tel cas, le bénéficiaire du pacte pourrait-il demander l'annulation de la vente et sa substitution au tiers dans le contrat illicitement passé ? Après avoir hésité, la Cour de cassation française l'avait admis dans un important arrêt de chambre mixte du 26 mai 2006, à la condition que le tiers ait connu l'existence du pacte ainsi que l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir[385], et cette solution a été consacrée par le nouvel article 1123 du Code civil français En Belgique, la Cour de cassation n'avait admis avant la réforme que la nullité de la vente conclue en violation d'un pacte de préférence avec un acquéreur de mauvaise foi[386], mais la substitution du bénéficiaire dans les droits du tiers avait été admise par plusieurs juridictions du fond[387]. L'article 5.26 du nouveau Code civil belge applique désormais à la violation du pacte de préférence les mêmes sanctions qu'à la promesse unilatérale, incluant donc la substitution du bénéficiaire dans le contrat passé avec le tiers de mauvaise foi. Les tribunaux luxembourgeois n'ont été que rarement confrontés à la difficulté jusqu'à présent. Dans un arrêt de 1990, la Cour d'appel avait refusé d'annuler un contrat conclu au mépris d'un droit de préemption légal[388]. Mais, dans un jugement de 1999, le Tribunal de Luxembourg, tout en posant, par une interprétation contestable de l'article 1165 du Code civil, que le pacte de préférence est inopposable aux tiers[389], admet que la nullité de la vente contractée en fraude des droits du bénéficiaire du pacte de préférence ne peut cependant être prononcée qu'en cas de collusion frauduleuse entre le promettant et le tiers acquéreur, c'est-à-dire lorsqu'il est rapporté en preuve que le tiers a participé en connaissance de cause à la violation du pacte de préférence, ce qui suppose non seulement qu'il en ait eu connaissance, mais encore qu'il ait connu l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir[390].

194. Les contrats-cadres. Cette notion, d'origine doctrinale rend compte d'une pratique contractuelle fréquente entre des personnes qui sont en relations régulières – le plus souvent des rapports d'affaires entre entreprises. Le nouvel article 1111 du Code civil français le définit comme « un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques essentielles de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution ». Une définition similaire se trouve dans l'article 5.9 du nouveau code belge. On peut raisonner sur le cas d'une entreprise qui se fournit habituellement en marchandises auprès d'une autre. Il existe plusieurs manières d'organiser contractuellement ce type de relations. Une première formule consiste à passer un nouveau contrat à chaque achat de marchandises : dans un tel cas, les conditions applicables à chaque opération peuvent théoriquement

385 Cass. fr. (ch. mixte), 26 mai 2006, n° 03-19376.

386 Cass. be., 27 avril 2006, *R.G.D.C.*, 2008, p. 507.

387 Bruxelles, 16 septembre 1999, *J.T.*, 2001, p. 71 ; Civ. Bruxelles, 10 mars 1992, *Pas.*, 1992, III, p. 62 ; Comm. Namur, 22 février 1990, *T.R.V.*, 1991, p. 234.

388 Cour d'appel, 23 octobre 1990, *Pas.* 28, p. 70.

389 Sur la distinction entre l'effet relatif des contrats et leur opposabilité aux tiers, voy. *infra*, n° 953 et s.

390 Trib. Luxembourg, 20 novembre 1999, n° 63384.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

être renégociées à chaque fois (même si, en pratique, les parties reproduiront souvent de manière constante les mêmes conditions, le silence gardé par l'acheteur à la réception de l'offre de son fournisseur conforme aux conditions habituelles valant, comme on l'a vu, acceptation tacite de ces conditions). À l'opposé, les parties peuvent passer, une fois pour toutes, un contrat unique définissant la périodicité des fournitures, leur prix, le délai de livraison, les conditions de paiement, etc. Le contrat-cadre constitue en quelque sorte une formule intermédiaire : les parties passent au départ un contrat qui fixe le cadre général des relations contractuelles ultérieures (le délai de livraison, les conditions de paiement, les conditions de garantie des marchandises vendues, les garanties du paiement du prix, les sanctions de l'inexécution par une des parties de ses obligations, etc.), chaque livraison donnant lieu ensuite à un contrat spécifique – appelé contrat d'application – dans lequel sont déterminées les conditions particulières de l'opération (notamment la quantité de marchandises achetées, et leur prix, déterminé selon les critères fixés dans le contrat-cadre). Cette formule est très utilisée dans les réseaux de distribution (contrats de franchise, de concession, etc.), ainsi que pour organiser les relations entre les banques et leurs clients (qu'ils soient professionnels ou particuliers).

Le contrat-cadre apparaît donc comme un contrat préliminaire aux différents contrats d'application, mais il est très différent des autres contrats préliminaires, qui disparaissent une fois que le contrat qu'ils préparent est passé. Le contrat-cadre, lui, va subsister lors de la passation des contrats ultérieurs – c'est même son intérêt principal – de sorte que les contractants seront soumis aux règles des deux contrats qui vont en quelque sorte se superposer. En soi, le contrat-cadre n'oblige pas les parties à passer les contrats d'application, il en fixe simplement les règles pour le cas où ils seraient passés. Un contrat-cadre peut donc demeurer sans effet concret si aucun contrat d'application n'est ensuite conclu : ainsi, les contrats-cadres passés entre une banque et son client prévoient généralement les règles applicables aux opérations de crédit pouvant intervenir entre eux ; mais le client n'est nullement obligé de solliciter des crédits, pas plus que la banque n'est tenue de lui en accorder. Il arrive cependant fréquemment qu'un contrat-cadre fasse d'emblée naître des obligations entre les parties. Ainsi les contrats-cadres du secteur de la distribution contiennent fréquemment, à la charge de l'une ou l'autre partie ou des deux, une obligation d'exclusivité (ce

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

qui implique, par exemple, que le distributeur s'oblige à n'acheter telle ou telle marchandise qu'à son fournisseur, et/ou, à l'inverse, que le fournisseur s'oblige à n'approvisionner que les membres de son réseau de distribution). Il est également fréquent que les parties s'obligent à passer entre elles un certain nombre de contrats d'application (ainsi lorsque le distributeur s'oblige à acheter à son fournisseur une quantité minimale de marchandises par an). Dans ce cas, le contrat-cadre s'accompagne d'une promesse de contracter.

La formule du contrat-cadre soulève diverses difficultés spécifiques, notamment quant à la détermination du prix dans les contrats d'application. Nous les retrouverons dans la suite des développements[391].

391 Voy. *infra*, n°s 325 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le déroulement de la période précontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 227-251
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Chapitre II
Les obligations liées à la période précontractuelle

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les obligations liées à la période precontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 253-2...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les obligations liées à la période precontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 253-2...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

195. Obligations ou devoirs ? Comme nous l'avons vu en étudiant la question de la rupture des pourparlers, les parties à un futur contrat sont d'ores et déjà tenues, dans la période précontractuelle, à une exigence générale de bonne foi. Cette exigence, à laquelle on rattache aujourd'hui la responsabilité pour rupture abusive des pourparlers, fonde également un certain nombre d'exigences positives de comportement : d'une part, une obligation de confidentialité sur les éléments appris lors de la négociation du contrat, d'autre part et surtout, certaines obligations d'information sur divers éléments du contrat envisagé. De prime abord, dans la mesure où le contrat n'a pas encore été passé, les exigences de comportement mises à la charge des parties pendant la période précontractuelle ne devraient pas être qualifiées d'obligations mais plutôt de devoirs, dont la violation est sanctionnée par la responsabilité délictuelle[392]. De nombreux textes et projets nationaux, internationaux et européens, parlent du reste du « devoir de confidentialité » ou du « devoir d'information »[393]., et cette terminologie se retrouve tant dans l'article 1112-1 du Code civil français que dans l'article 5. 16 du nouveau Code civil belge. L'usage se répand cependant de plus en plus, dans la doctrine, dans la jurisprudence, et même dans certains textes, de parler d'obligations – spécialement pour les « obligations d'information »[394], ce qui conduit parfois, de manière contestable, à en sanctionner la violation par la responsabilité contractuelle[395]. Cette tendance, qui est particulièrement développée dans la jurisprudence française contemporaine, apparaît comme une sorte de reconnaissance de la théorie de la *culpa in contrahendo* développée par Ihering : l'idée est que, dès avant la conclusion du contrat, les parties ne sont plus des étrangers l'un à l'autre qui n'ont l'un par rapport à l'autre que les devoirs généraux de la vie en société, ce sont des contractants en puissance, sur qui pèsent déjà des obligations spécifiques. S'il est conclu par la suite, le contrat produit ici une sorte d'effet de halo, de sorte que le comportement du contractant, même s'il a été antérieur à la conclusion du contrat, sera rattaché à la relation contractuelle en cours de constitution.

[392] Sur la distinction entre obligations et devoirs généraux de la vie sociale, en lien avec la distinction de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle, voy. *supra*, n°s 69 et 70.

[393] Principes Unidroit, art. 2.1.6 ; Code Gandolfi, art. 7 (Devoir d'information) et 8 (Devoir de réserve) ; DCFR, art. II-3:101 et s. (*Information duties*) et II-3:301 (*confidentiality duties*).

[394] C'est la terminologie adoptée par les directives européennes de droit de la consommation, ainsi que par le DCEV, art. 13 et s.

[395] Voy. *infra*, n° 204 pour la violation des obligations d'information précontractuelles.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les obligations liées à la période precontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 253-2...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

SECTION 1. L'OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ

196. Principe. Il est fréquent que, au cours des négociations, un des partenaires soit amené à révéler à l'autre des éléments importants sur son entreprise, d'ordre financier ou technique ; l'autre est alors tenu de ne pas les révéler ni d'en faire un usage personnel (par exemple en copiant les procédés de fabrication dont il a eu connaissance). Les parties peuvent, au début de leurs négociations préciser contractuellement la portée et les sanctions de cette obligation de confidentialité, mais, même en l'absence d'un tel contrat, il est admis que la confidentialité s'impose au titre de l'exigence générale de bonne foi. Cette obligation (ou ce devoir) est fréquemment explicitée dans les textes et projets internationaux et européens : ainsi, selon l'article 2.1.6 des Principes Unidroit « Qu'il y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours des négociations, reçoit une information donnée à titre confidentiel par l'autre partie, est tenue de ne pas la divulguer ni l'utiliser de façon indue à des fins personnelles. Le manquement à ce devoir est susceptible de donner lieu à une indemnité comprenant, le cas échéant, le bénéfice qu'en aura retiré l'autre partie »[396]. Le nouvel article 1112-2 du Code civil français dispose de même que « [c]elui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun ». ». La jurisprudence luxembourgeoise récente ne donne cependant pas d'exemple de ce principe.

SECTION 2. LES OBLIGATIONS D'INFORMATION

197. Problématique. Tout contrat fait naître pour les parties un certain nombre de risques, et constitue une sorte de pari sur l'avenir : celui qui achète un bien peut se trouver confronté, ensuite, à des défectuosités, à des problèmes de fonctionnement du bien, ou (spécialement pour les biens immobiliers) à un risque de dépréciation de ce bien sur le marché, ou au fait que, compte tenu de diverses circonstances, le bien acheté ne présente plus aucune utilité pour lui, celui qui contracte un crédit pour financer un achat ou une activité risque de voir sa situation défavorablement évoluer dans l'avenir de sorte qu'il aura du mal à rembourser le crédit, celui qui fait des investissements financiers en espérant faire de gros bénéfices risque

396 Voy. aussi Code Gandolfi, art. 8 ; PDEC, art. 2 :302.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les obligations liées à la période precontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 253-2...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de tout perdre si le marché boursier s'effondre ou si l'entreprise dans laquelle il a investi fait faillite, etc. Dans une société libérale, où tous les contractants sont supposés libres et égaux, il appartient en principe à chaque contractant de se renseigner sur les risques de l'opération qu'il s'apprête à passer (en examinant soigneusement le bien qu'il achète, en prenant toutes informations sur l'état du marché, sur la solvabilité de l'emprunteur qu'il cautionne, sur la charge financière d'un emprunt, etc.), avant de prendre la décision de contracter ou de ne pas contracter à telle ou telle condition. On sait cependant que cette société de contractants parfaitement libres et égaux n'est qu'un mythe, et elle l'est tout particulièrement en ce qui concerne les possibilités qu'ont les différents contractants d'accéder aux informations nécessaires pour mesurer les avantages et les inconvénients d'une opération contractuelle. Entre de très nombreux contractants, il existe une asymétrie d'informations qui déséquilibre considérablement le jeu du contrat : un banquier est évidemment mieux placé que son client, au moins si celui-ci est un particulier, pour apprécier les risques d'une opération financière, le vendeur d'une chose est plus à même de connaître les défauts de cette chose que l'acheteur qui l'examine au moment de l'achat, le constructeur d'une maison peut, mieux que son client, mesurer les avantages et les inconvénients de tel matériau ou de telle technique mis en œuvre dans la construction, etc. Le droit des contrats, dans la plupart des systèmes juridiques modernes, a largement intégré ce type de considérations, et fait de plus en plus souvent peser dans la phase précédant la formation du contrat[397], des obligations d'information sur le contractant qui est le plus apte à s'informer, au profit du contractant le plus faible ou le moins compétent.

L'importance, les conditions, le degré, les conséquences du non-respect des obligations d'information précontractuelles dans un système juridique dépendent d'abord de considérations de politique juridique, et de l'équilibre qu'on souhaite établir entre les valeurs de liberté et de responsabilité individuelles (qui fait peser sur tout un chacun un devoir de se renseigner), et la protection des contractants les plus faibles (qui amène à multiplier les obligations d'information). Aussi bien, même si aujourd'hui le droit de l'Union européenne joue un rôle important d'harmonisation dans ces

[397] Dans certains contrats, il peut en outre exister des obligations d'information pendant la phase d'exécution du contrat. Voy., p. ex., en matière de cautionnement, l'article 2016 du Code civil (red. L. 8 janvier 2013) qui oblige le créancier à donner à la caution une information périodique sur l'état du passif garanti.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les obligations liées à la période precontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 253-2...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

matières (notamment en droit de la consommation), il peut exister des divergences importantes entre des droits pourtant très proches. Un exemple suffira à en convaincre : le droit français reconnaît depuis au moins trente ans qu'un établissement de crédit qui demande un cautionnement doit informer la caution sur la solvabilité du débiteur principal (donc sur les risques de défaillance, entraînant l'obligation pour la caution de payer à la place de ce débiteur) ; la jurisprudence luxembourgeoise, en revanche, dans un pays où l'activité bancaire joue un rôle économique majeur, a mis du temps à consacrer une telle obligation d'information, et la Cour d'appel a longtemps considéré « qu'il appartient à la caution de s'informer sur la situation du débiteur principal, et non à la banque de l'en informer »[398].

198. Source des obligations d'information. Au Luxembourg comme dans la plupart des pays, c'est d'abord la jurisprudence qui a obligé certains contractants en situation de force à délivrer des informations précontractuelles à leurs cocontractants. Ces obligations d'information jurisprudentielle peuvent être rattachées, tout comme la responsabilité liée à la rupture des pourparlers, à l'exigence générale de bonne foi dans la phase de formation du contrat. Leur reconnaissance et leur étendue sont très liées aux situations de fait, et dépendent de nombreux éléments qui se laissent mal appréhender à travers des formules générales. Cependant, dans la période la plus récente, le législateur est intervenu pour reconnaître à la charge de certains contractants des obligations beaucoup plus précises à la fois quant à leur objet, leurs modalités et leurs sanctions. Le droit de la consommation est, au Luxembourg comme dans d'autres pays, le domaine d'élection de ces obligations d'information législatives, qui sont très souvent d'origine européenne, mais on les rencontre aussi dans d'autres contrats. Contrairement à la jurisprudence qui procède au cas par cas à partir de critères généraux, les textes en la matière contiennent en général de longues listes d'informations qui doivent être fournies selon les différents types de contrats, et de la manière dont elles doivent l'être. Le projet de droit commun européen de la vente (aujourd'hui caduc), où les obligations d'information mises à la charge du vendeur n'occupent pas moins de 10 pages et 15 longs articles, en distinguant selon les modalités de la vente et la qualité des parties offre un exemple presque caricatural de cette méthode législative. Il est évidemment

[398] Cour d'appel, 14 mars 2001, n° 21151 ; Cour d'appel, 21 janvier 2015, n° 40587.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les obligations liées à la période precontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 253-2...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

hors de question, dans un manuel de droit commun des contrats, de faire un inventaire détaillé des décisions des tribunaux et des différents textes relatifs aux obligations d'information. On se propose seulement d'en donner une grille d'analyse à travers quelques considérations générales relatives au domaine (**§ 1**), à l'objet (**§ 2**) et aux sanctions (**§ 3**) de ces obligations.

§1. Domaine des obligations d'information

199. Jurisprudence. La jurisprudence fait peser une obligation d'information sur un contractant dans de nombreux cas, qu'il est difficile de synthétiser en une formule générale[399]. Le critère de base est celui de l'inégalité des contractants dans la connaissance des informations importantes pour la conclusion du contrat. Même si ce texte n'a aucune valeur normative au Luxembourg, l'article 1112-1 nouveau du Code civil français, repris du projet Terré, nous semble assez bien rendre compte de l'attitude actuelle des tribunaux luxembourgeois (comme de ceux d'autres pays) : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Le Tribunal de Luxembourg en 2022 ne dit guère autre chose : « Une obligation de renseignement existe chaque fois qu'un déséquilibre des connaissances entre les cocontractants peut être mis en évidence, c'est-à-dire lorsque l'une des parties ignore légitimement des informations qui lui étaient utiles et que l'autre connaissait ou se devait de connaître. »[400] Il résulte de ce texte que le premier élément à considérer pour la reconnaissance ou la non reconnaissance d'une obligation d'information réside dans les qualités respectives des contractants : l'obligation d'information sera le plus souvent mise à la charge d'un contractant professionnel vis-à-vis de son cocontractant non professionnel ou consommateur, parce que, normalement, les professionnels connaissent bien mieux les choses qu'ils vendent ou les services qu'ils commercialisent que leurs clients consommateurs. Mais ce critère n'est pas absolu. D'une part, même un contractant non-professionnel a le devoir de se renseigner sur ce qu'il achète, et de poser les bonnes questions en

[399] Pour des exemples, voy. Ravarani, n° 513 ; et plus particulièrement pour les obligations d'information pesant sur les banquiers Ravarani, n°s 564-565, 578-580, 593-595 (avec le concours de I. Riasseto).

[400] Trib. Luxembourg, 11 mai 2022, n° TAL-2021-06520.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les obligations liées à la période precontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 253-2...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

fonction de ce qu'il recherche dans le bien ou le service objet du contrat, pour que son cocontractant puisse l'informer et le conseiller utilement. D'autre part, à l'inverse, une obligation d'information peut être reconnue même au profit d'un contractant professionnel, s'il existe entre les deux contractants une asymétrie d'information : un banquier, par exemple, n'est pas déchargé de toute obligation à l'égard de ses clients professionnels, qui ne sont pas nécessairement spécialisés en matière financière. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, d'une manière générale, les tribunaux se montreront moins exigeants quant à l'information à délivrer aux professionnels, sur qui pèse un devoir de se renseigner plus étendu. La qualité des parties n'est pas du reste le seul élément à prendre en compte. Les juges prennent également en considération la manière dont le contrat est passé : l'obligation d'information sera plus facilement reconnue si on est en présence d'un contrat d'adhésion que d'un contrat négocié – dans lequel chaque contractant a plus de facilité pour prendre les renseignements nécessaires – ainsi que dans les contrats passés à distance, et spécialement par voie informatique, dans lesquels l'absence de contact direct entre les contractants doit être compensée par une information renforcée. Sera enfin prise en compte la plus ou moins grande complexité de l'opération. D'une manière générale, on attend davantage d'explications et de conseils lorsqu'on achète un ordinateur que lorsqu'on choisit un aspirateur, lorsqu'on investit dans un produit financier complexe que lorsqu'on place son argent sur un compte d'épargne. S'agissant de l'obligation d'information pesant sur un établissement de crédit, la Cour d'appel souligne ainsi que « la nature, le contenu et les limites de l'information à donner varient en fonction de la simplicité ou de la complexité du produit bancaire visé, de la qualité du client, qu'il soit néophyte inexpérimenté ou lui-même professionnel et des circonstances particulières de l'espèce visée »[401]. On va du reste retrouver ces différents critères à travers les nombreux textes spéciaux qui font peser sur un contractant une obligation d'information.

200. Textes spéciaux. Comme on l'a dit, l'immense majorité de ces textes sont édictés dans le cadre du droit de la consommation, et ils sont le produit de la transposition de directives européennes. Le Code de la consommation du Luxembourg contient à cet égard un texte général, l'article L. 111-1, aux termes duquel « avant la conclusion de

[401] Cour d'appel, 10 novembre 2021, n° CAL-2019-01044.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les obligations liées à la période precontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 253-2...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

tout contrat, le professionnel doit mettre, de façon claire et compréhensible, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des biens ou services, y compris des contenus numériques et des services numériques, qu'il propose ». L'article L. 112-1 impose quant à lui au professionnel d'informer le consommateur sur le prix des produits et services qu'il offre. Des obligations d'information plus spécifiques sont ensuite reconnues dans différents contrats (C. consomm., art. L. 221-1 et s.), soit à raison de leurs modalités de conclusion (contrats à distance : C. consomm., art. L. 222-3 et L. 222-14), soit à raison de leur objet (contrats d'utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme, contrats de revente et d'échange : C. consomm., art. L. 223-4 ; voyages à forfait : art. 225-3, contrats de crédit à la consommation : C. consomm., art. L. 224-6, contrats de crédit immobilier : art. 226-7 et s.).

Le droit luxembourgeois connaît également un certain nombre d'obligations d'information textuelles qui s'appliquent à tout contractant, en raison de la nature du contrat passé. Il en va ainsi dans le contrat d'assurance (L. 27 juillet 1997, art. 10, art. 62-2 lorsque le contrat est passé à distance, art. 62-6 pour les contrats passés par voie électronique), pour les prestataires de services de la société de l'information (L. 14 août 2000 sur le commerce électronique, art. 5 et 51), et surtout pour les contrats financiers où le législateur est venu prendre le relais de la jurisprudence. L'article 37-3 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, issu de la transposition au Luxembourg de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil[402], réglemente ainsi longuement les règles de conduite que doivent suivre les établissements de crédit et les entreprises d'investissements lors de la fourniture de services d'investissement à des clients[403]. Au titre de ces règles figure notamment l'obligation pour l'établissement de « communiquer aux clients et aux clients potentiels des informations appropriées sous une forme compréhensible » sur un certain nombre d'éléments, ainsi que de recommander au client, en fonction de sa situation, « les services d'investissement et les instruments financiers qui lui conviennent ».

402 *J.O.U.E.*, L. 145/1, 30 avril 2004.

403 Pour une application, voy. Cour d'appel, 24 juin 2021, n° 40643.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les obligations liées à la période precontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 253-2...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§ 2. Objet des obligations d'information

201. Renseigner. Selon les circonstances, l'obligation d'information qui peut être mise à la charge d'un contractant peut avoir plusieurs objets. Au minimum, on demandera une information objective sur la chose ou sur le service objet du contrat : on parlera ici d'une obligation d'information au sens strict, ou d'une obligation de renseignement. Celle-ci peut elle-même avoir plusieurs aspects. Elle portera à titre principal sur les caractéristiques de la chose ou du service objet du contrat (par exemple, la consommation en eau ou en électricité d'un appareil ménager, le kilométrage d'une voiture, le prix des produits ou services, le taux d'intérêt d'un prêt, le coût de l'assurance demandée à l'emprunteur, la rentabilité attendue d'un investissement, etc.). C'est à ce type d'information que se réfère l'article L. 111-1 du Code de la consommation. L'obligation d'information peut concerner des aspects matériels, mais elle intègre aussi parfois des aspects juridiques : ainsi lorsque l'article L. 212-31 du Code de la consommation oblige le vendeur professionnel qui propose une garantie commerciale pour ses produits d'informer par écrit l'acheteur de l'existence et de la durée de la garantie légale, ou lorsque l'article L. 222-14 (4) oblige, dans les contrats à distance portant sur des services financiers, le professionnel à informer le client de l'existence éventuelle de procédures extrajudiciaires de règlement des litiges. Au-delà de ces différents aspects, cette obligation de renseignement précontractuelle, qui est destinée à éclairer la décision de contracter ou de ne pas contracter, ou à choisir entre différents biens ou services proposés, ou entre différents contractants, doit être bien distinguée de l'obligation de renseignement qui interviendra une fois que le contrat sera conclu, et qui portera sur la manière de se servir du bien acquis (le mode d'emploi) et sur les précautions à prendre lors de son utilisation.

Dans des arrêts très remarqués, la Cour de cassation française a posé qu'un acheteur, même compétent ou professionnel, n'était pas tenu d'informer le vendeur, même totalement profane, sur la valeur du bien vendu. Cette solution a été posée pour la première fois à propos de la vente de clichés du photographe Baldus, à un prix plus de 20 fois inférieur à leur valeur sur le marché de l'art. Dans cette affaire, le vendeur ignorait complètement la notoriété de l'artiste, alors que l'acheteur, qui lui avait déjà acheté et revendu des clichés similaires à un prix beaucoup plus élevé, savait parfaitement qu'il achetait les photos à un prix dérisoire. La Cour de cassation n'en a pas moins considéré que l'acheteur n'était tenu d'aucune obligation d'information à l'égard du vendeur, et que le contrat ne pouvait donc pas être annulé pour réticence dolosive[404]. La même solution a été réitérée à propos de l'achat, à bas prix, par un

[404] Cass. fr. (1re civ.), 3 mai 2000, nº 98-11381. Sur la réticence dolosive, voy. *infra* nº 242.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les obligations liées à la période precontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 253-2...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

agent immobilier d'une maison vendue par un agriculteur devenu manœuvre[405]. Ces solutions ont été présentées dans les arrêts comme spécifiques à l'erreur commise par le vendeur, et on pourrait les expliquer par l'idée qu'un vendeur est censé bien connaître la valeur de ce qu'il vend, et en tout cas que c'est à lui de se renseigner sur cette valeur avant de fixer son prix. On a pu cependant se demander s'il ne conviendrait pas d'admettre, de manière bilatérale, qu'en principe un contractant (qu'il soit vendeur ou acheteur) n'est pas tenu de renseigner l'autre sur la valeur du bien qu'il vend ou qu'il achète. Si on raisonne sur le cas de la vente d'un appartement, il paraît difficile d'admettre que l'acheteur puisse reprocher à son vendeur de lui avoir vendu trop cher par rapport au prix du marché, et de ne pas lui avoir dit qu'il pourrait trouver des biens équivalents à un moindre prix dans le voisinage. Il apparaît normal, dans un système économique libéral, que le vendeur essaie de vendre le plus cher possible et que l'acheteur essaie d'acheter le moins cher possible, sans avoir à fournir spontanément à l'autre tous les éléments lui permettant de conclure un contrat plus avantageux. Cette solution a été consacrée lors de la réforme française par le nouvel article 1112-1 du Code civil qui exclut par principe toute obligation d'information sur la valeur. Il en résulte, nous le verrons, que la réticence dolosive, qui est en principe une cause de nullité, ne peut pas être prise en considération lorsqu'elle porte sur la valeur[406]. Cette exclusion peut cependant paraître excessive. On peut penser en effet que le principe posé pourrait céder dans des cas exceptionnels où il existe entre les deux parties une inégalité telle (dans la compétence, dans l'expérience, dans les possibilités d'information de l'un et de l'autre) que la « loi du marché » a été faussée (et à dire vrai, on peut se demander si ce n'était pas le cas dans les deux affaires françaises précédemment rapportées). Le nouveau Code civil belge, dans lequel l'obligation d'information est rattachée à la bonne foi, ne pose pas une telle exclusion de principe de l'obligation d'information sur la valeur et laisse la solution à l'appréciation du juge, ce qui paraît une solution assez sage.

202. Conseiller et/ou mettre en garde. La jurisprudence et le législateur vont parfois plus loin dans l'exigence d'information. Un contractant peut être tenu d'éclairer son partenaire sur les avantages et les inconvénients que le contrat envisagé peut présenter, subjectivement, pour lui. On peut ainsi concevoir qu'un vendeur ou un fabricant de matériels complexes indique à son client quel serait, pour lui, le matériel le plus adapté : un jugement du tribunal de Luxembourg a ainsi estimé qu'un fabricant de pelles mécaniques doit signaler à son client que le modèle qu'il désire est tout à fait inadapté à l'usage qu'il veut en faire. De même un assureur est censé éclairer son client sur le choix de différentes formules d'assurance, en fonction de sa situation personnelle. L'obligation d'information prend alors la forme d'une obligation de mise en garde ou de conseil. On parlera d'obligation de mise en garde, lorsque le contractant est simplement tenu de signaler à son cocontractant les dangers que peut présenter pour lui l'opération considérée. Il

405 Cass. fr. (3e civ.), 17 janvier 2007, n° 06-10442.

406 Voy. *infra* n° 248.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les obligations liées à la période precontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 253-2...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

a été, par exemple, jugé qu'un pressing doit informer son client sur les risques d'un nettoyage de vêtement, ou, dans un tout autre domaine qu'un assureur doit informer l'assuré non-professionnel sur les risques d'une assurance insuffisante. On parlera d'obligation de conseil lorsque le contractant professionnel doit orienter le choix de son client vers la formule la plus adaptée pour lui. C'est surtout dans le domaine financier que se sont développées ces obligations de conseil et de mise en garde, souvent du reste mal distinguées par les tribunaux luxembourgeois[407]. Ainsi, en matière de prestations de services d'investissement, l'article 37-3 (5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 prévoit que l'établissement doit demander au client de lui indiquer « ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé pour être en mesure d'évaluer si le service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client » et s'il estime « sur la base des informations reçues […] que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, il doit l'en avertir ». En matière de crédit, où il n'existe pas de texte similaire, c'est la jurisprudence qui fait peser sur le banquier le devoir d'avertir le client des risques d'endettement excessif qui peuvent résulter de l'opération envisagée. Suivant l'exemple de la jurisprudence française, et conformément aux principes généraux en matière d'information et de conseil, les tribunaux luxembourgeois font, dans ces domaines, la différence entre les clients avertis et non avertis[408].

On se demande jusqu'où va l'obligation de conseil ou de mise en garde : le contractant qui en est tenu (le plus souvent un professionnel) doit-il seulement tenter de dissuader son client de passer un contrat inadapté ou dangereux pour lui en lui délivrant les informations nécessaires pour lui permettre de mesurer les risques, ou doit-il, si le client s'obstine, refuser purement et simplement de passer le contrat ? C'est cette conception du devoir de conseil qui est traditionnellement retenue en matière notariale : le notaire qui estime que l'opération est désavantageuse pour son client est responsable s'il accepte néanmoins de prêter son concours à la passation de l'acte. En matière bancaire et financière, la jurisprudence luxembourgeoise, respectueuse de la liberté contractuelle,

[407] Sur le détail, voy. RAVARANI, n°s 578 à 580, 593 à 595 (avec I. RIASSETO).

[408] Voy. p. ex. : Cour d'appel, 9e ch., 16 février 2012, n° 36102 ; Cour d'appel, 8 juin 2022, n° CAL-2021-00538.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les obligations liées à la période precontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 253-2...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

est généralement réticente à s'engager dans cette dernière voie : la banque n'est tenue que d'avertir le client des risques, de le conseiller sur ce qui est le plus approprié pour lui, mais c'est au client qu'il appartient, in fine, de décider s'il veut ou non s'engager dans l'opération[409]. Certaines décisions ont cependant, en matière de crédit, admis que le banquier devait refuser d'octroyer le crédit à un client non averti lorsque celui-ci apparaissait déraisonnable[410]. Le législateur européen a récemment franchi le pas en matière de crédit immobilier : aux termes de l'article 18 de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010[411] : « les États membres veillent à ce que […] le prêteur accorde uniquement le crédit au consommateur si le résultat de l'évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat ». Cette solution figure désormais en droit luxembourgeois à l'article L.226-12 (5) du Code de la consommation selon lequel « le prêteur ne peut accorder le crédit au consommateur que si le résultat de l'évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit immobilier seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat ».

§ 3. Sanctions des obligations d'information

203. Preuve du manquement. D'une manière générale, il est admis par les tribunaux luxembourgeois que c'est à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation d'information de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation[412]. Le nouvel article 1112-1 du Code civil français consacre expressément cette solution. Il semble que la solution ne soit pas la même s'agissant du devoir de conseil. La Cour d'appel a ainsi jugé qu'il appartenait au client du notaire de prouver que celui-ci a manqué à

409 RAVARANI, n° 580.

410 Cour d'appel, 23 mars 1994, cité par RAVARANI RIASSETTO, n° 609 ; *contra* : Cour d'appel, 1er juillet 2009, n° 32960.

411 *J.O.U.E.*, L. 60/34, 28 février 2014.

412 Cour d'appel, 26 octobre 2016, n° 42304 ; Cour d'appel, 22 mars 2017, n° 43051 ; Cour d'appel, 6 mars 2019, n° 45274 ; Cour d'appel, 20 juin 2024, n° CAL-2022-00111.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les obligations liées à la période precontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 253-2...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

son devoir de conseil[413], et il a été de même récemment été jugé, en matière d'assurance qu'en cas de manquement au devoir de conseil, en cas de mauvais conseil ou de conseil inadéquat notamment, il appartient au créancier de prouver la réalité de ce mauvais conseil[414]. Mais la solution contraire a été donnée pour l'avocat[415].

204. Responsabilité du contractant. La question de la sanction du manquement à une obligation d'information n'apparaîtra, en général, que si la personne insuffisamment ou mal informée a passé le contrat, dont elle découvre ultérieurement les inconvénients. Ce contractant pourra alors demander réparation du préjudice qu'il subit du fait de cette opération. Dans un droit comme le droit luxembourgeois qui admet par principe la réparation de tout préjudice, il peut s'agir aussi bien du préjudice patrimonial (coûts et perte de clientèle résultant pour une entreprise de l'inadaptation du matériel acheté, perte de capital résultant d'un placement inapproprié, dégradation de la situation liée à un crédit excessif, etc.) que du préjudice moral. Les dommages et intérêts peuvent, éventuellement, se compenser avec ce que le contractant victime doit à l'autre partie au titre du contrat malheureux.

On se demande si la responsabilité encourue est contractuelle ou extracontractuelle. La réponse de principe ne fait aucun doute lorsque l'obligation d'information est l'obligation précontractuelle, qui vise à éclairer un contractant potentiel sur l'opportunité de passer le contrat ou sur le choix du produit ou du service : ce n'est pas une obligation née du contrat qui a été violée, mais une exigence de comportement mise à la charge d'un futur contractant par la loi ou la jurisprudence. Comme on l'a dit, il vaudrait mieux du reste parler de « devoir d'information » plutôt que d'obligation. Cette qualification est expressément retenue par le nouvel article français. La responsabilité pour manquement à un tel devoir est donc une responsabilité délictuelle[416]. Il n'en va autrement que lorsque l'obligation d'information ou le conseil s'inscrit dans le cadre d'une relation contractuelle préexistante : c'est très souvent le cas dans le contexte bancaire et financier, où la personne qui demande un crédit ou qui s'apprête à faire une opération de placement est déjà

413 Cour d'appel, 12 novembre 2014, n° 40203.

414 Cour d'appel, 20 juin 2024, n° CAL-2022-00111.

415 Cour d'appel, 1er juin 2022, nos CAL-2020-00808 et CAL-2020-00968.

416 Voy. p. ex. : Cass. fr. (comm.), 3 mai 2006, n° 04-19 315 ; Cass. fr. (comm.), 13 septembre 2011, n° 10-18323.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les obligations liées à la période precontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 253-2...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

cliente de la banque, avec qui elle a passé un contrat-cadre faisant naître des obligations spécifiques. De même, la responsabilité est contractuelle lorsque le défaut d'information ou de mise en garde porte sur une chose déjà achetée, car il y a alors manquement à une obligation contractuelle d'information. En pratique, cependant, la distinction n'est pas toujours claire, et on peut constater que, dans la jurisprudence française, il arrive que la violation d'une obligation de renseignements précontractuelle soit sanctionnée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle ce qui est très significatif de l'effet de « halo » qu'exerce le contrat passé sur tout ce qui s'est passé avant. Devant les tribunaux luxembourgeois, on observe que, la plupart du temps, lorsqu'un contractant se plaint d'un manquement à l'obligation d'information de l'autre, il invoque « la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle », et les juridictions, si elles accordent des dommages et intérêts, ne précisent pas souvent sur quel fondement elles le font.

Dans le droit de la consommation, il arrive que le législateur assortisse le manquement à certaines obligations d'information de sanctions pénales, censées être plus dissuasives que la seule responsabilité civile. On citera, par exemple, l'article L. 223-13 du Code de la consommation, qui punit d'une amende de 251 à 25 000 € les professionnels qui (entre autres) ne délivrent pas les informations précontractuelles requises pour les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, ou l'article L. 224-25 du même Code qui prévoit des sanctions pénales pour un certain nombre d'infractions à la réglementation du crédit à la consommation (dont divers manquements aux obligations d'information).

205. **Nullité du contrat.** Dans certains cas, la violation de l'obligation précontractuelle d'information pourra également être sanctionnée par la nullité du contrat. Il pourra en aller ainsi, tout d'abord, lorsque les informations devant être communiquées s'inscrivent dans le cadre d'exigences de forme (mentions obligatoires dans le contrat) : le manquement à ces exigences peut alors être sanctionné par la nullité totale ou partielle du contrat[417]. Par ailleurs, et surtout, le manquement à l'obligation d'information peut être sanctionné par la nullité sur le terrain des vices du consentement : celui qui a été mal informé peut soutenir qu'il n'aurait pas passé le contrat s'il avait reçu les informations nécessaires, ce qui peut constituer un des deux vices du consentement des articles 1110 (erreur spontanée) et 1116 (dol ou erreur provoquée) du Code civil. Le nouvel article 1112-1 du Code civil français prévoit la possibilité d'annulation du contrat en cas de manquement à l'obligation d'information « dans les conditions

417 Voy. *infra*, n° 444.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les obligations liées à la période precontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 253-2...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

prévues aux articles 1130 et suivants », c'est-à-dire par les textes relatifs aux vices du consentement. L'existence d'une obligation d'information n'a pas d'incidence directe sur le jeu de l'article 1110 du Code civil, qui vise une erreur spontanée, que la victime a commise toute seule, sans intervention de son cocontractant. En revanche, il y a une relation étroite entre la reconnaissance d'une obligation d'information et la possibilité de faire annuler le contrat pour dol. Cette notion désigne, comme on le verra plus loin plus en détail, une tromperie émanant d'un contractant et qui a déterminé l'autre à contracter. Dans sa conception traditionnelle, le dol suppose des manœuvres positives ou du moins des mensonges du contractant ; mais la jurisprudence moderne assimile à ces manœuvres la simple réticence, c'est-à-dire le fait d'avoir gardé le silence sur un élément du contrat dont on savait qu'il avait une incidence déterminante sur le consentement de l'autre partie. Il existe un lien étroit entre l'admission de la réticence dolosive et l'existence d'une obligation d'information : le dol ne sera caractérisé que si le contractant qui a gardé le silence était tenu d'informer son cocontractant sur l'élément considéré. Cependant, à l'inverse, le seul fait qu'un contractant ait manqué à son obligation d'information ne suffira pas à caractériser la réticence dolosive, et à entraîner la nullité du contrat. Il faut encore, d'une part que le défaut d'information ait eu un effet déterminant sur le consentement au contrat, et d'autre part qu'il ait été fait avec l'intention de tromper, et non par simple négligence[418]. Nous allons retrouver bientôt ces solutions plus en détail, lorsque nous étudierons le dol au titre des conditions de validité du contrat, qui sont l'objet du titre suivant.

[418] Voy. *infra*, n°s 242 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les obligations liées à la période precontractuelle, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 253-2...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

206. Problématique de la validité. On a précédemment distingué[419] la question de l'existence d'un contrat (articulée autour de la rencontre des volontés), de celle de la validité, qui suppose qu'un contrat s'est formé, et qui vise à déterminer si ce contrat est conforme aux conditions que le droit positif met à la reconnaissance de sa force obligatoire. Il faut en effet rappeler que tout accord de volontés visant à produire des effets juridiques n'est pas nécessairement apte à en produire au regard du droit. Qu'on admette – dans une optique positiviste – que le contrat tire sa force de la loi, ou que l'on reste fidèle à l'idée que c'est la volonté qui constitue le fondement premier de la force obligatoire[420], on ne peut ignorer que la loi pose toute une série de conditions pour reconnaître cette force obligatoire. Aussi bien, l'article 1134 du Code civil n'accorde-t-il cette force qu'aux conventions « légalement formées », et, tout de suite après les dispositions préliminaires relatives à la notion et aux classifications des contrats, les rédacteurs du Code ont consacré tout un chapitre (C. civ., art. 1108 à 1133) aux « conditions essentielles pour la validité des conventions ».

207. Validité et nullité. La notion de validité trouve son antonyme dans celle de nullité : lorsque le contrat n'est pas valable, il est nul. Cet apparent truisme mérite cependant d'être précisé, si on veut bien comprendre, dès le départ de ce titre, la portée exacte des conditions de validité posées par la loi. Dans les pays du Code civil, à la différence de nombreux autres systèmes juridiques, la nullité du contrat est traditionnellement conçue comme une sanction exclusivement judiciaire, qui suppose toujours la décision d'un tribunal. La personne – qu'elle soit un contractant ou un tiers – qui estime que l'une des conditions de validité du contrat fait défaut ne peut donc pas, *ipso facto*, déclarer que le contrat ne vaut rien. Le contrat doit, avant d'être anéanti, avoir été examiné par un tribunal qui jugera si oui ou non les conditions de validité ont été respectées. Pour cela, il faut que le tribunal soit saisi de la question de la nullité, et la question essentielle est de savoir qui peut le saisir : toute personne qui y a un intérêt peut-elle agir en nullité d'un contrat ? Et si le tribunal est saisi d'un litige pour une autre question que celle de la nullité (par exemple, parce qu'une partie en demande l'exécution) et qu'il découvre qu'une condition de validité fait défaut au contrat (ou à une clause du contrat) peut-il soulever d'office la nullité, même si

419 Voy. *supra*, n° 122.

420 Sur les théories explicatives de la force obligatoire, voy. *supra*, n°s 88 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 271-273
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la partie défenderesse à l'action en exécution ne le fait pas ? Et encore : pendant combien de temps est-il possible de demander la nullité d'un contrat ? L'action en nullité est-elle atteinte par la prescription ? Peut-on enfin admettre qu'une personne, qui pourrait agir en nullité d'un contrat, renonce à le faire (parce qu'elle estime finalement que le contrat est bon pour elle) ? Et quels sont les effets d'une telle renonciation ? Pour répondre à toutes ces questions, on fait, dans les pays du Code civil, une distinction entre deux catégories de nullités, qu'on appelle les nullités relatives et les nullités absolues. Cette distinction, aujourd'hui explicitement consacrée dans le Code civil français et dans le nouveau Code civil belge, correspond à deux séries de conditions de validité – en gros, celles qui sont éditées dans l'intérêt d'une partie, et celles qui correspondent à des préoccupations d'intérêt général. Dans le premier cas, la nullité est dite relative, elle ne peut être demandée que par la partie protégée, pendant un temps très limité, et on peut renoncer à la demander. Dans le second cas, la nullité est dite absolue, elle peut être soulevée pendant trente ans par toute personne qui y a intérêt, et on ne peut pas y renoncer. Nous entrerons plus tard dans le détail de cette distinction, beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air[421], mais il importait de la signaler d'emblée pour qu'on comprenne bien qu'il est trop simple de dire qu'« un contrat qui n'est pas valable est nul ». En réalité, il vaut mieux dire qu'un contrat qui n'est pas valable peut être annulé mais qu'il ne le sera pas nécessairement. Il ne le sera pas si aucune des personnes ayant qualité pour demander l'annulation ne fait cette demande, ou si elle la fait trop tard, ou si elle y renonce dans un cas où la nullité est relative. Du coup, même si cela peut paraître choquant, il faut être conscient que de très nombreux contrats qui se concluent chaque jour sans être conformes à toutes les conditions de validité posées par la loi, seront exécutés comme s'ils étaient valables (de même qu'il y a beaucoup d'auteurs d'infractions qui ne sont jamais punis !) parce que personne ne peut ou ne veut en demander la nullité. Les conditions de validité posées par le droit n'ouvrent donc que des virtualités d'anéantissement, plus ou moins susceptibles de se réaliser selon que la nullité est absolue ou relative.

Il était nécessaire d'expliquer cela – et donc de donner un premier aperçu du régime des nullités contractuelles – avant d'entrer dans le détail du *contenu des conditions de validité* (**Sous-titre I**) puis de leurs *sanctions* (**Sous-titre II**).

421 Voy. *infra*, n°s 442 et s.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 271-273
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

208. **Validité des contrats et validité des actes unilatéraux.** Si le processus de formation des actes unilatéraux est, par nature, différent de celui des contrats, on peut en revanche transposer généralement aux actes unilatéraux les conditions de validité applicables aux contrats, sous réserve de quelques différences de détail. Les règles relatives aux vices du consentement, par exemple, sont applicables aux actes unilatéraux, sous la seule réserve de l'exigence, pour le dol (tromperie) que les manœuvres destinées à tromper émanent du cocontractant. De même, les règles relatives à la capacité, à l'objet, à la cause, à l'ordre public et aux bonnes mœurs sont applicables par principe aux actes unilatéraux. Tout au plus peut-on observer que, d'une manière générale, les actes unilatéraux sont soumis à un formalisme plus accusé que celui des contrats, soit pour informer clairement le destinataire de l'acte (mise en demeure, congé, etc.), soit pour protéger l'auteur de l'acte en l'amenant à réfléchir sur ce qu'il fait, soit encore pour prévenir des difficultés de preuve. On peut également noter que la mise en œuvre des nullités des actes unilatéraux présente certaines particularités. Sur tous ces points, les différences seront signalées au fil des développements.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 271-273
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

209. L'article 1108 du Code civil et au-delà. L'article 1108 du Code civil, qui ouvre le chapitre consacré à la validité du contrat, pose que « quatre conditions […] sont essentielles pour la validité d'une convention ». Ces quatre conditions, qui sont le consentement, la capacité, l'objet et la cause, sont ensuite développées dans les quatre sections qui suivent. Ce texte, même s'il est essentiel, donne cependant une vision un peu réductrice des conditions de validité. Aux quatre conditions qu'il pose, il faut en effet en ajouter deux autres. D'une part, l'article 6 du Code civil, situé dans le titre préliminaire, pose une exigence générale de conformité du contrat à l'ordre public et aux bonnes mœurs, qui recoupe certaines conditions de l'article 1108 du Code civil (notamment l'exigence d'un objet et d'une cause licites), mais qui les dépasse très largement, et qui mérite donc d'être étudié à part. D'autre part, l'article 1108 du Code civil ne fait aucune mention des conditions de forme du contrat. C'est logique dans la mesure où, le Code reposant comme on le sait sur le principe du consensualisme, la forme n'est pas une « condition essentielle » à la validité des conventions en général, mais seulement de certains contrats particuliers. Cependant, dans le droit moderne, les contrats qui sont assujettis pour leur validité à des conditions formelles sont de plus en plus nombreux, de sorte qu'on ne peut plus faire abstraction de ces conditions dans un exposé de droit commun des contrats. Au total, ce sont donc six conditions de validité qui doivent ici être étudiées.

210. Logiques mêlées. Dans un esprit de systématisation très français, on pourrait ici être tenté de faire des regroupements entre ces différentes conditions. Cependant, aucun des critères de regroupement auxquels on pourrait songer n'est vraiment satisfaisant, tant les logiques qui sous-tendent les différentes conditions de validité sont étroitement mêlées.

C'est ainsi qu'on distingue parfois les conditions subjectives – celles qui tiennent aux parties comme le consentement et la capacité –, et les conditions objectives, qui tiennent à des éléments extérieurs (l'objet du contrat, la cause entendue comme sa finalité économique, la conformité à l'ordre public, les exigences formelles). Cette distinction marque la part respective dans le droit des contrats du subjectivisme (qui correspond à l'idée de respecter les accords de volonté privés, qui fondent la régulation horizontale de la société) et de l'objectivisme (qui marque le poids de l'ordre social, et de la « régulation verticale »). Cependant, il faut remarquer que certaines conditions qui tiennent aux parties font intervenir des éléments objectifs (ainsi lorsque l'article 1110 du Code civil subordonne l'annulation du contrat pour erreur au fait que l'erreur porte sur la substance de la chose objet de l'engagement), et que, surtout, les considérations subjectives sont très présentes dans les conditions objectives (ainsi lorsque, pour apprécier la cause du contrat, on s'intéresse aux mobiles personnels des parties).

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 277-278
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Dans un esprit un peu différent, Carbonnier distinguait, dans son manuel désormais classique, les conditions liées à la structure du contrat, sans lequel l'accord ne pourrait pas « tenir debout » (consentement, capacité, objet, cause) et celles qui traduisent l'exigence de conformité à l'ordre social (l'ordre public et les bonnes mœurs, la forme)[422]. Mais la distinction est très artificielle, car les conditions « structurelles » sont pétries de considérations liées à la conformité à l'ordre social (les incapacités visent à la protection des faibles, les vices du consentement permettent de sanctionner certains comportements déviants, la cause et l'objet doivent être licites, etc.).

La distinction la plus opérationnelle est sans doute celle qui est fondée sur les intérêts protégés par les différentes conditions de validité. On remarque en effet que certaines conditions sont destinées à protéger les intérêts particuliers des contractants ou de l'un d'eux (le consentement, la capacité) tandis que d'autres sont tournées vers la défense de l'intérêt général (qu'exprime au premier chef l'exigence de conformité à l'ordre public). Cette distinction est très importante, et il faut l'avoir constamment présente à l'esprit, dans la mesure où elle fonde actuellement la distinction précédemment évoquée entre les nullités absolues et les nullités relatives. Elle ne peut cependant servir de base à la présentation des différentes conditions, car, là encore, les deux séries de considérations sont souvent mêlées, et en outre, les différentes conditions posées par la loi peuvent servir, selon les cas, à protéger l'un et l'autre intérêt : ainsi certaines incapacités visent à protéger l'intérêt général, la notion de cause, telle qu'elle est actuellement utilisée par la jurisprudence, peut servir soit à assurer la protection d'un contractant, soit à empêcher la conclusion de contrats contraires à l'intérêt social, et nous verrons que la notion même d'ordre public (qui semble synonyme d'intérêt général) peut être utilisée pour protéger des intérêts privés.

C'est donc en six chapitres que nous étudierons les conditions de validité du contrat : le consentement (**Chapitre I**), la capacité (**Chapitre II**), l'objet (**Chapitre III**), la cause (**Chapitre IV**), la conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs (**Chapitre V**) et enfin les conditions de forme (**Chapitre VI**).

422 J. CARBONNIER, *Droit civil, Les biens, Les obligations*, coll. Quadrige, 2004, n° 938, Paris, PUF, p. 1972 (cité *infra*, CARBONNIER).

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 277-278
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Chapitre I
Le consentement

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

211. Condition d'existence et condition de validité du contrat. Au sein des quatre conditions posées par l'article 1108 du Code civil pour la validité des conventions, le consentement occupe une place particulière, car, avant d'être une condition de validité, il est, d'abord, comme nous l'avons déjà vu, une condition d'existence même du contrat. Si l'offre faite par une personne à une autre n'a pas été acceptée, si les volontés ne se sont pas rencontrées, aucun contrat n'est formé. Mais ensuite, même lorsqu'il y a bien acceptation d'une offre, le système juridique peut exiger, pour que le contrat soit valable, que le consentement des parties présente certaines qualités. Si par exemple, une personne n'a accepté le contrat que parce qu'elle y a été contrainte par l'autre, on pourra considérer que son consentement n'est pas un « vrai » consentement, et cela pourra conduire à l'annulation du contrat pour violence. C'est en ce sens que l'article 1109 du Code civil dispose que « il n'y a point de consentement lorsque le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». Le consentement – un consentement présentant certaines « qualités », un « consentement de bon aloi » selon l'expression d'un auteur belge[423] – n'est plus alors une condition d'existence, mais, aussi, une condition de validité du contrat. Les deux aspects ont été pendant longtemps confondus dans la doctrine des pays du Code civil, parce que, le Code ayant totalement passé sous silence la question du processus de formation du contrat, l'habitude avait été prise d'en traiter dans le cadre de l'article 1108 du Code civil, en distinguant, au sein des développements consacrés au consentement comme condition de validité, l'existence du consentement (offre et acceptation) et son intégrité. Comme il a déjà été dit – mais il faut y insister – les deux questions sont pourtant bien différentes, et elles sont aujourd'hui clairement distinguées, à la suite des réformes récentes, dans le Code civil français, et dans le nouveau Code civil belge[424]. Les sanctions ne seront du reste pas les mêmes dans les deux cas : en l'absence de volonté de contracter, si l'offre n'est pas acceptée, le contrat n'est tout simplement pas formé, et chaque « non contractant » pourra s'en prévaloir ; si en revanche, le contrat s'est formé, mais que le consentement ne présente pas les qualités exigées par la loi, cela donnera lieu seulement à une action en nullité (qui sera, de surcroît, une action en nullité relative, ouverte au seul contractant qui n'a pas donné un « vrai consentement »).

423 Wéry, n°s 225 et s.

424 Voy. *supra*, n° 122.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

212. L'introuvable « vrai consentement ». Le mythe de la volonté, seule source de la force obligatoire du contrat, aboutit souvent à présenter les choses comme si le droit exigeait, positivement, pour la validité du contrat, un « vrai consentement », une « vraie volonté » de la part de chaque contractant. Il n'en est rien. Chaque jour sont passés des milliers de contrats dans lesquels une partie ne comprend pas toutes les implications de son engagement, ou qu'une partie passe parce qu'elle n'a pas le choix (il faut bien se loger, se nourrir, se déplacer, etc.), ou sans suffisamment réfléchir, quitte à s'en mordre les doigts ensuite (si j'avais su, je n'aurais pas emprunté, je n'aurais pas acheté ce bien), ou parce qu'elle ne sait pas résister aux pressions d'autrui (moi, je ne voulais pas, mais c'est mon conjoint qui a insisté, etc.). Aucun système juridique ne permet aux milliers de contractants qui se sont engagés dans ces conditions de remettre en cause le contrat en soutenant simplement qu'ils n'ont pas vraiment consenti. D'une part parce qu'il est impossible, sur le terrain du droit, de fixer les limites de ce qu'est un « vrai consentement », une vraie volonté psychologique. D'autre part et surtout parce que l'admission de telles actions aboutirait à une insécurité généralisée des relations juridiques en raison de la remise en cause perpétuelle des engagements souscrits. C'est pourquoi tout système juridique va devoir fixer des seuils à partir desquels la volonté ne sera pas considérée comme suffisamment « pure », comme présentant une « intégrité » suffisante pour être source d'obligations juridiques, en intégrant non seulement des considérations psychologiques, mais aussi des facteurs moraux et sociaux.

Dans beaucoup de systèmes juridiques modernes, ces facteurs tendent à devenir prédominants, et la recherche d'un « vrai » consentement est quelque peu éclipsée par l'idée de savoir qui doit supporter les risques d'un contrat qui n'a pas été « vraiment » consenti.

213. De la sanction à la prévention des défauts du consentement. Dans le Code civil, la protection des contractants contre les défauts du consentement n'est assurée qu'*a posteriori*, par l'annulation du contrat dans lequel le consentement a été altéré, avec, dans certains cas, l'octroi de dommages et intérêts pour le contractant qui en a été victime. Cette logique sanctionnatrice, qui suppose l'exercice d'une action en justice pour faire tomber le contrat, s'avère peu adaptée pour les petits contrats de la vie quotidienne où l'intérêt du contractant à obtenir la nullité est souvent trop limité pour justifier un recours devant les tribunaux. C'est pourquoi le législateur

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

moderne met souvent en place, à côté de la protection *a posteriori* assurée par le Code civil (**Section 1**), des techniques de prévention des altérations du consentement (**Section 2**).

SECTION 1. LA PROTECTION DU CONSENTEMENT DANS LE CODE CIVIL : L'ANNULATION DU CONTRAT LIÉE À L'ALTÉRATION DU CONSENTEMENT

214. Défaut *de* consentement et défauts *du* consentement. À l'origine, dans le Code civil, la nullité du contrat « mal consenti » n'était prévue que dans des hypothèses où le consentement avait été « vicié » parce que le contractant avait été victime d'une erreur (spontanée ou provoquée) ou d'une contrainte. Cependant, la jurisprudence annulait aussi les contrats consentis par une personne atteinte d'un trouble mental qui l'empêchait de comprendre ce qu'elle faisait en contractant. En 1982, cette solution a été intégrée dans le Code civil, et on peut désormais distinguer deux types d'altérations du consentement donnant lieu à nullité : le cas du trouble mental, prévu aux articles 489 et 489-1 du Code civil (**Sous-section 1**), et les vices du consentement énumérés aux articles 1109 à 1118 (**Sous-section 2**).

SOUS-SECTION 1. LA NULLITÉ DU CONTRAT CONSENTI SOUS L'EMPIRE D'UN TROUBLE MENTAL

215. Trouble mental et incapacité. Les personnes atteintes, de manière habituelle, de troubles mentaux, et dont on pense qu'elles ne sont pas aptes à pourvoir à leurs intérêts, peuvent être placées sous un régime de protection (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle) qui entraînera une restriction plus ou moins importante de leur capacité. L'un des effets de cette incapacité sera la nullité des contrats qui auront été passés par l'incapable, dans des conditions différentes suivant les régimes[425]. Mais il peut aussi arriver qu'une personne atteinte d'un trouble mental passe un contrat alors qu'elle n'a pas (ou pas encore) été placée sous un régime de protection. Quelle sera alors la valeur juridique d'un tel acte ? Le Code civil de 1804 ne contenait aucune réponse à cette question, mais, dans les trois pays du Code civil, il était admis qu'un contrat passé sous l'empire d'un trouble mental pouvait être annulé pour « absence de consentement » (entendez : absence d'un « vrai consentement » ; la

[425] Voy. *infra*, n° 290.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

situation n'a rien à voir avec celle où les volontés ne se sont pas rencontrées), et c'est encore le raisonnement suivi en Belgique, où le Code n'a pas été complété sur ce point[426]. Le cas du trouble mental n'apparaît que de manière allusive dans l'article 5.31 qui traite comme une cause de nullité relative le cas où le contrat s'est formé « alors que le consentement d'une des parties fait défaut ». En France, lors d'une réforme du droit des incapacités en 1968, on a intégré dans le Code un article 489 (devenu depuis l'article 414-1), aux termes duquel « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit », et cette formule a été textuellement reprise à l'article 489 du Code civil du Luxembourg lors de la réforme du droit des incapacités par la loi du 11 août 1982. Le trouble mental, ou, pour reprendre la formule du texte, l'insanité d'esprit est donc devenu une cause spécifique de nullité. Bien que le texte soit intégré dans le titre XI du Livre 1er du Code relatif aux majeurs protégés, et non dans le Titre relatif aux contrats, il faut bien voir que la nullité qu'il édicte n'est pas une nullité pour incapacité, mais une nullité qui sanctionne un défaut du consentement[427]. La distinction a des conséquences importantes en ce qui concerne les conditions, et le régime de la nullité.

216. Conditions de la nullité pour trouble mental. Le texte s'applique à tous les actes juridiques et pas seulement aux contrats. Il ne définit pas ce qu'il faut entendre par insanité d'esprit, ou par trouble mental. Selon la jurisprudence française (abondante et qui peut ici servir de modèle), il est nécessaire que le discernement soit aboli pour que le contrat puisse être annulé : un simple état dépressif ne justifierait pas l'annulation. Selon la formule d'un arrêt de la Cour d'appel du Luxembourg, « pour donner lieu à la nullité du contrat, conclu par une personne non interdite ni internée, l'état de démence de celle-ci doit avoir altéré ses facultés au point qu'elle n'est plus capable d'administrer convenablement ses biens et qu'elle est exposée à commettre des actes préjudiciables à sa fortune »[428]. Mais peu importe la cause de cette absence de discernement : le contrat

426 WÉRY, n° 224 ; VAN OMMESLAGHE, nos 133 et s. et les arrêts cités.

427 Il faut cependant observer que, en droit international privé, la jurisprudence française a jugé que la nullité pour trouble mental, expression d'une sorte de « capacité naturelle » devait être rattachée à la catégorie « capacité ». Cass. fr. (civ.), 25 juin 1957, *Rev. crit.*, 1957, 680, note BATIFFOL. Il en résulte que la loi applicable pour déterminer les conditions et le régime de cette nullité est la loi personnelle du contractant et non la loi applicable au contrat (qui régit la nullité pour vice du consentement). Cette solution ne correspond guère aux solutions en droit interne.

428 Cour d'appel, 7 juillet 1969, *Pas.*, 21, p. 260.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pourrait ainsi être annulé s'il avait été passé par un contractant en état d'ébriété, sauf à ce que, dans un tel cas, ce contractant soit ensuite condamné à indemniser l'autre partie du préjudice qu'il subit du fait de l'annulation.

L'important est d'observer que, dès lors que la personne n'a pas été placée sous un régime de protection, il ne suffit pas de prouver, pour obtenir la nullité de l'acte, que cette personne avait habituellement des problèmes de discernement. Le texte indique que ceux qui agissent en nullité sur le fondement de l'article 489 du Code civil doivent prouver l'existence d'un trouble mental « au moment de l'acte ». Là est la différence essentielle entre la nullité pour trouble mental de l'article 489 du Code civil et la nullité pour incapacité : dès lors qu'une personne souffre habituellement de troubles mentaux, elle peut être placée sous un régime de protection, et l'incapacité qui en résultera alors entraînera la nullité de tous les actes que l'incapable ne pouvait plus accomplir seul, sans qu'il soit nécessaire de prouver, à chaque fois, que l'acte avait été accompli dans un moment de folie (et sans que, à l'inverse, le fait qu'il ait été accompli dans un intervalle de lucidité permette de le valider). En revanche, le demandeur à l'action en nullité pour trouble mental doit prouver que la personne manquait de discernement au moment même où le contrat a été passé, de sorte que celui-ci peut être considéré comme n'ayant pas été vraiment consenti[429]. Ce principe est cependant atténué dans la mesure où le trouble mental étant un fait juridique, sa preuve peut normalement en être apportée par tous moyens (témoignages et présomptions de fait), et, en pratique, si c'est la personne même qui a passé l'acte qui vient ensuite le contester, le fait qu'elle établisse qu'elle était habituellement en état de démence dans la période qui a entouré l'acte passé vaudra comme présomption de fait du trouble mental au moment même de l'acte. Un arrêt de la Cour d'appel pose ainsi que « au cas où une personne, non interdite ni internée, demande la nullité d'un contrat, au motif qu'elle n'était pas saine d'esprit lors de sa conclusion, la preuve de l'insanité d'esprit peut être déduite de ce que cette personne était en état de démence, soit avant, soit après

[429] Pour des applications récentes : Cour d'appel, 24 octobre 2012, n° 36995 (arrêt cassé par Cass., 24 octobre 2013, mais sur un autre point). L'arrêt se contente de la preuve du trouble mental à la « date » de l'acte, ce qui semble un peu moins exigeant que le « moment » visé par le texte. Sur cet arrêt voir les observations de O. Poelmans, *D.A.O.R.*, 2014/112, 142 ; Cour d'appel, 9 juillet 2014, n° 39996 ; Cour d'appel, 7 juin 2018, n° 42450 ; Cour d'appel, 6 décembre 2023, n° CAL-2021-00267.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la date du contrat et à une époque rapprochée de cette date, à moins que le cocontractant n'établisse que malgré son état général de démence, ladite personne se trouvait dans un intervalle lucide au moment de la conclusion du contrat »[430]. La question relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, et échappe donc au contrôle de la Cour de cassation[431].

L'action en nullité est soumise par l'article 489-1 du Code civil à des conditions plus restrictives dans le cas où elle est exercée après la mort de la personne qui a passé l'acte. Ces règles visent à éviter que les héritiers ne remettent trop facilement en cause les contrats passés par la personne décédée, pour récupérer des biens dont celle-ci aurait disposé, à un moment où la preuve du trouble mental sera généralement plus difficile à rapporter. C'est pourquoi l'action en nullité ne pourra être exercée que dans des hypothèses où l'insanité d'esprit paraît évidente. Il en est ainsi, tout d'abord, lorsque l'acte porte en lui-même la preuve du trouble mental (par exemple parce qu'il est incohérent ou qu'il révèle un certain délire dans les motifs exprimés). Il en va ainsi ensuite lorsque, dès avant le décès, des démarches avaient été faites pour placer la personne sous un régime de protection : soit qu'elle ait été déjà placée sous un régime de sauvegarde de justice, soit qu'une demande en justice ait été faite en vue de son placement sous tutelle ou sous curatelle[432]. Ces restrictions ne s'appliquent cependant pas aux testaments et aux donations que la personne décédée aurait faits à un moment où elle était atteinte du trouble mental.

Dans un cas particulier, à l'inverse, la loi se montre moins exigeante sur la preuve à apporter. Il s'agit du cas où, postérieurement à l'acte, l'auteur de l'acte a été mis en tutelle. Dans ce cas, l'article 503 du Code civil (repris, comme l'article 489, du droit français) dispose que « les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits ». Il ne sera donc plus nécessaire, dans ce cas, de prouver le trouble mental au moment même de l'acte. L'article 503 du Code civil fait en quelque sorte rétroagir l'incapacité dans la période antérieure.

217. Régime de la nullité pour trouble mental. À l'époque où la nullité pour trouble mental n'était pas prévue par la loi, on traitait volontiers en France cette nullité comme une nullité absolue. Cette qualification correspondait à une conception des nullités qui fondait leur régime sur la gravité du défaut infectant le contrat[433] : on considérait alors que le trouble mental provoquait une absence totale de consentement, jugée plus grave qu'un simple vice du consentement (erreur, dol ou violence) n'entraînant qu'une nullité relative. Ce type de raisonnement est aujourd'hui abandonné : d'une part, le trouble mental peut être traité comme un cas particulier de défectuosité du

430 Cour d'appel, 7 juillet 1969, *Pas.*, 21, p. 260.

431 Cass., 22 janvier 2009, N° 03/09 ; Cass., 13 octobre 2022, N° 119/2022

432 Pour une application récente de ces dispositions : Trib. Luxembourg, 7 avril 2017, n°s 164485, 166433 et 167474.

433 Voy. *infra*, n° 440.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

consentement, qui n'est en lui-même ni plus ni moins graves que les autres vices (et en particulier que le vice de violence) ; d'autre part et surtout, comme on l'a déjà signalé, la distinction des nullités relatives et des nullités absolues est aujourd'hui fondée sur l'intérêt protégé par la règle posant la condition, et non plus sur la gravité du défaut. Or, de ce point de vue, lorsque la loi prévoit la nullité des contrats passés par des personnes atteintes de troubles mentaux, c'est pour protéger ces personnes contre leurs actes – tout comme elle protège les incapables en leur interdisant de passer des contrats. Il semble donc logique que la nullité pour trouble mental soit traitée comme une nullité relative, tout comme la nullité pour vice du consentement et la nullité pour incapacité, entre lesquelles elle se situe. Cette logique a été suivie par la loi française de 1968 qui a intégré la nullité pour trouble mental dans le Code, et elle se retrouve dans l'article 489 du Code civil luxembourgeois[434]. Le texte précise en effet expressément que « du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un ». Cela signifie qu'une autre personne, et en particulier le cocontractant, ne peut pas demander la nullité de l'acte, même si elle y avait intérêt. La solution est la même que celle qui est prévue par l'article 1125 du Code civil pour la nullité pour incapacité. Bien que le texte ne le précise pas, il faut appliquer la même solution lorsque la personne qui a passé l'acte est décédée : seuls ses héritiers peuvent agir en nullité (aux conditions restrictives évoquées plus haut) et le cocontractant qui voudrait se débarrasser du contrat (par exemple, parce qu'il a acheté le bien trop cher) ne peut pas se fonder sur le trouble mental de son cocontractant pour le faire annuler.

SOUS-SECTION 2. LA NULLITÉ DU CONTRAT CONSENTI SOUS L'EMPIRE D'UN VICE DU CONSENTEMENT

218. Problématique générale : entre protection du consentement et sanction des comportements déloyaux. On regroupe habituellement sous l'appellation de « vices du consentement » une série de situations où un contractant a consenti au contrat de manière consciente, mais dans des circonstances faussant son libre-arbitre – soit parce qu'il s'est trompé (erreur) ou qu'on l'a trompé (dol) sur un élément important pour lui par rapport aux attentes qu'il avait en

[434] Voy. égal. en droit belge, en l'absence de texte : Cass. be., 21 octobre 1971, *Pas. be.*, 1972, I, p. 175.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

passant le contrat, soit parce qu'il a été contraint (violence) de donner son consentement. Ce sont ces « vices » qu'annonce l'article 1109 du Code civil « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». Ces différents vices sont chacun réglementés dans les articles suivants : l'erreur dans l'article 1110 du Code civil, la violence dans les articles 1111 à 1115 du Code civil, le dol dans l'article 1116 du Code civil. À ces trois vices originaires du Code civil, la loi déjà citée du 15 mai 1987 a ajouté un quatrième dans l'article 1118 du Code civil, la lésion, visant le cas où un contractant a abusé de la faiblesse de l'autre pour l'amener à conclure un contrat déséquilibré.

Pour rendre compte de la nullité du contrat dans ces différentes hypothèses, on dit souvent que le consentement doit être « intègre » pour être pris en compte par le droit. Cette présentation est trompeuse, car elle pourrait laisser croire que l'intégrité du consentement est une condition positive de la validité du contrat. Or ce n'est pas vraiment cela. Comme on l'a déjà dit, il y a de très nombreux cas où un contractant ne connaît pas tous les éléments importants pour lui lorsqu'il s'engage, et de plus nombreux encore où on est contraint par les circonstances de passer un contrat dont on se passerait bien, sans que, pour autant, on puisse en tirer argument pour faire annuler le contrat. Un consentement qui n'est pas parfaitement éclairé ni complètement libre peut donc être la source d'un engagement valable. C'est même le cas normal, et la nullité n'est en réalité prévue par la loi que dans des hypothèses présentées comme exceptionnelles. C'est qu'on ne peut pas aller trop loin dans l'idée de protection du consentement d'un contractant sans nuire gravement aux intérêts de l'autre, qui n'est pas nécessairement pour quelque chose dans l'erreur commise ou dans la contrainte subie par celui dont le consentement a été « vicié », et qu'il n'y a aucune raison de le priver du bénéfice du contrat. Si quelqu'un m'achète mon appartement à Luxembourg parce qu'il vient d'y obtenir un emploi, mais que, quelque temps après, il perd cet emploi, admettra-t-on qu'il puisse faire tomber la vente qui, finalement, ne répond pas à ses attentes ? Si une banque met comme condition de l'octroi du crédit à une entreprise que le dirigeant de celle-ci fournisse son cautionnement (c'est-à-dire s'engage à payer la banque en cas de défaillance de l'entreprise), ce dirigeant pourrait-il ensuite faire annuler le cautionnement – et priver la banque de la garantie qu'elle s'était ménagée – en soutenant qu'il a été donné sous la contrainte ?

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Pour faire la balance entre les intérêts du contractant victime du vice et ceux de son cocontractant, et déterminer dans quels cas les contrats peuvent être annulés pour vice du consentement, deux séries de facteurs peuvent être pris en considération. On peut tenir compte, d'abord, de l'objet et de la gravité de l'atteinte à l'intégrité du consentement : si j'achète un tableau, par exemple, il paraît plus normal d'annuler le contrat si je me suis trompé sur l'authenticité du tableau (que je croyais être un Picasso alors que ce n'est qu'une copie), que si j'ai faussement cru qu'il représentait mon grand-père, à la fois parce que la première erreur se sera certainement traduite par le paiement d'un prix trop élevé, et parce que mon cocontractant pouvait légitimement s'attendre à ce que l'authenticité du tableau soit un élément déterminant de mon consentement. Mais on peut aussi prendre en compte le comportement du cocontractant : s'il n'est pour rien dans le vice du consentement de l'autre, ou au moins s'il l'ignorait, on admettra moins facilement la nullité du contrat que si ce cocontractant savait que le consentement de l'autre était vicié, *a fortiori* si c'est lui qui avait provoqué ce vice. Dans ce dernier cas, en effet, il n'y a aucune raison de conserver à ce cocontractant le bénéfice du contrat, et l'idée de sanction va venir en surimpression de celle de protection du consentement.

Selon les systèmes juridiques, la place donnée à ces deux facteurs dans la détermination des cas de nullité pour vice du consentement est très différente. En droit anglais, par exemple, c'est la considération du comportement du cocontractant qui est prédominante : le droit anglais n'admet en principe la nullité que si c'est le cocontractant qui a provoqué le vice, soit par la contrainte qu'il a exercée sur l'autre (*duress*), soit par les fausses informations qu'il lui a données (*misrepresentation*). L'erreur spontanée (*mistake*) n'est que très exceptionnellement une cause de nullité[435]. Dans les droits continentaux, en revanche, on continue de penser la « théorie » des vices du consentement en se plaçant principalement du côté de celui qui en a été victime, et on tient compte, en premier lieu, pour annuler le contrat de la nature et de l'importance de l'atteinte à l'intégrité du consentement. Cependant, on introduit aussi, de manière variable d'un droit à l'autre, la considération du comportement du cocontractant pour ouvrir plus ou moins largement l'action en nullité.

435 J. SMITS, *Contract law. A comparative introduction*, 3e éd., Cheltenham, Edward Elgar, 2021, pp. 159 et s. ; CARTWRIGHT, pp. 163 et s., spéc. p. 176.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Dans le système du Code civil, et en particulier en droit luxembourgeois, la combinaison de ces deux types de considérations apparaît tout particulièrement dans la différentiation de deux vices affectant le caractère éclairé du consentement : l'erreur (§ 1) et le dol (§ 2). Elle est également sensible dans la réglementation de la violence (§ 3). Elle est enfin à la base de la conception du vice du consentement introduit en 1987, la lésion qualifiée (§ 4).

219. Nullité relative. Avant d'entrer dans le détail de ces différents vices du consentement, il faut souligner un point commun : c'est que la nullité qui sanctionne ces différents vices est une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par le contractant qui en a été victime. Il s'agit en effet d'une nullité édictée pour protéger ce contractant. Pour les trois vices du consentement originaires (erreur, dol et violence), l'article 1117 du Code civil renvoie aux articles 1304 et suivants du Code civil qui définissent le régime de cette action. L'action en nullité pour lésion – traditionnellement appelée action en rescision – obéit, elle, à un régime spécifique, prévu par l'article 1118 du Code civil lui-même, mais qui se rattache globalement au régime des nullités relatives. Dans certains cas, la victime du vice pourra en plus obtenir des dommages et intérêts, lorsque l'altération de son consentement sera imputable au comportement de son cocontractant ou d'un tiers. En outre, la question se pose parfois de savoir si, en lieu et place de l'anéantissement du contrat vicié, le contractant victime du vice ne pourrait pas demander, ou se voir imposer par le juge, la révision du contrat. Nous retrouverons toutes ces questions à propos des différents vices concernés, et d'une manière plus générale lorsque nous étudierons les sanctions des conditions de validité du contrat[436].

§ 1. L'erreur (C. civ., art. 1110)

220. Définition – Distinction de l'erreur vice du consentement et de l'erreur-obstacle. Dans une première approche, l'erreur prise en compte par l'article 1110 du Code civil peut être définie comme une fausse représentation de la réalité que s'est faite une partie (traditionnellement appelée l'*errans*) au moment où elle a passé le contrat. Pour prendre l'exemple le plus classique, donné par Pothier – l'un des principaux inspirateurs du Code civil sur cette question – il

[436] Voy. *infra*, n° 444.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

y a erreur si « voulant acheter une paire de chandeliers d'argent, j'achète de vous une paire de chandeliers que vous me présentez à vendre, que je prends pour des chandeliers d'argent, quoiqu'ils ne soient que de cuivre argenté »[437]. De ce point de vue, l'erreur de l'article 1110 du Code civil doit être clairement distinguée d'un autre type d'erreur, que les rédacteurs du Code civil n'ont pas envisagée, et qui est habituellement désignée par la doctrine sous le nom d'« erreur-obstacle ». Cette notion recouvre des hypothèses, relativement rares en pratique, de malentendus entre les contractants : l'un offre à l'autre une chose (en pensant lui prêter), l'autre accepte (en pensant que la chose lui est donnée), l'un propose à l'autre de lui vendre un lot de copropriété (qui est pour lui un lot de 60 m²), l'autre, par suite d'une erreur dans la description du lot, accepte en pensant acheter un local de 213 m²[438], ou encore, en période de changement d'unité monétaire, l'un propose à l'autre de lui vendre un bien en indiquant comme prix « 100 000 » (pour lui, c'est 100 000 €), l'autre accepte en pensant qu'il s'agit de 100 000 francs luxembourgeois. Un exemple typique est fourni par un jugement du tribunal de Luxembourg du 31 janvier 2020, dans une affaire où un acheteur, par suite d'un bug informatique, avait commandé des produits sans s'apercevoir de l'augmentation considérable des prix pratiqués par son vendeur dans le but d'en empêcher la commande par un site informatique (250 000 € au lieu de 654 € en application des anciens prix !)[439] Dans toutes ces hypothèses, l'erreur ne consiste pas dans une fausse représentation de la « réalité », pour la simple raison qu'il n'y a pas de réalité objective sur laquelle une des parties serait dans le vrai, et l'autre dans le faux. Le contrat n'est objectivement ni un prêt ni une donation, il est l'un ou l'autre selon ce que les parties veulent faire, le bien vendu n'est ni le lot de 60 m² ni celui de 213 m², il ne pourrait être que le lot sur lequel les deux parties seraient d'accord ; le « vrai » prix n'est ni 100 000 €, ni 100 000 LUF, ni de 250 000, ni de 654 €. il pourrait être l'un ou l'autre selon ce que les parties auraient décidé d'un commun accord, etc. Et le problème vient ici précisément de ce que les parties ne se sont pas mises d'accord sur la nature du contrat, sur le bien ou sur le prix, d'où il faut déduire que le contrat ne s'est pas formé du tout. La situation est exactement la même que si je vous disais : « voulez-vous acheter

437 Pothier, *Traité des obligations*, précité, p. 12.

438 Exemple tiré de Cass. fr. (3e civ.), 21 mai 2008, n° 07-10772.

439 Trib. Luxembourg, 31 janvier 2020, n° TAL-2018-06469.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

mon bien pour 100 000 € ? », et que vous me répondiez « non, je ne veux le payer que l'équivalent de 100 000 LUF » – la seule différence étant que, par suite de la formulation ambiguë de la proposition et de la réponse, le désaccord n'apparaît pas immédiatement. On est typiquement en présence d'une hypothèse d'inexistence. C'est donc de manière assez contestable que certains arrêts français traitent cette « erreur-obstacle » comme un vice du consentement sanctionné par l'annulation du contrat, en la soumettant de surcroît au régime de la nullité relative[440]. D'autres arrêts cependant voient plus exactement dans ce type d'erreur un « obstacle à la rencontre des consentement », et en tirent pour conséquence qu'elle est une cause d'annulation même si elle est inexcusable[441]. La Cour d'appel du Luxembourg semble consacrer la même idée : se référant à des auteurs français, un arrêt de 2020 relève que, dans un tel cas « l'accord ne s'est pas opéré parce que les parties n'ont pas, en réalité, voulu la même chose […] L'erreur commise par les parties est si grave qu'elle met obstacle à la rencontre des volontés »[442]. Le jugement précité du tribunal de Luxembourg distingue de même nettement l'erreur obstacle de l'erreur vice du consentement, mais n'en soumet pas moins la nullité pour erreur obstacle au régime de la nullité relative[443]. C'est la même position, assez ambigüe, qui a été adoptée par les auteurs de la réforme belge : tout en y voyant « une erreur faisant obstacle à la rencontre des consentements », l'article 5.31 du nouveau Code civil belge dispose que le contrat n'est dans un tel cas « frappé de nullité que si l'erreur est déterminante et excusable »[444]. Il vaudrait mieux renoncer purement et simplement dans un tel cas à parler d'erreur et de nullité, et permettre à chaque partie, à tout moment, de faire valoir que le contrat n'a pas été passé (sauf à celui qui a été, par sa faute, à l'origine du malentendu, à en répondre sur le terrain de la responsabilité civile)[445]. Dans les développements qui vont suivre, nous ne parlerons plus que de l'erreur vice du consentement, fausse représentation par une des parties d'une réalité objective.

440 Cass. fr. (3e civ.), 26 juin 2013, n° 12-20.934

441 Cass. fr. (3e civ.), 21 mai 2008, précité.

442 Cour d'appel, 18 novembre 2020, n° CAL-2020-00310, citant Terré, Simler, Lequette, 10e édition, p. 221 (erreur alléguée sur la nature du régime matrimonial choisi par les parties à un contrat de mariage ; erreur non retenue car non prouvée).

443 Trib. Luxembourg, 31 janvier 2020, n° TAL-2018-06469.

444 Sur la discussion doctrinale de cette question en droit belge, voy., p. ex., WÉRY, n° 240.

445 Voy. en ce sens la présentation très convaincante de la question par FABRE-MAGNAN, pp. 318 et s.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Dans la doctrine belge antérieure à la réforme, l'erreur vice du consentement était parfois définie comme une distorsion entre la volonté déclarée et la volonté réelle. Cette présentation, qui remonte à De Page[446], ne correspond guère à ce qu'est l'erreur de l'article 1110 du Code civil. Dans les cas visés par cet article, la volonté déclarée par l'*errans* correspond bien à ce que celui-ci veut vraiment : je veux acheter ces chandeliers d'argent, et c'est ce que je vous dis. Mais la volonté réelle est en décalage avec la réalité (je veux acheter ces chandeliers parce que je les crois en argent, alors qu'en réalité ils sont en métal argenté). La définition héritée de De Page correspond en réalité à des situations très différentes, où, volontairement (par jeu), ou par suite d'un lapsus, un contractant fait une offre qui ne correspond pas à ce qu'il veut vraiment : par exemple dans le cas où je vous propose de vous vendre ma voiture pour 1 000 €, alors que je pense 10 000 €. En principe, dans un tel cas, on tiendra compte de la volonté réelle (sauf à ce qu'elle soit prouvée), et on retombera alors dans l'hypothèse de l'erreur-obstacle, mais, si le prix annoncé est crédible, et fait naître une attente légitime chez l'autre, on pourra parfois considérer qu'il lie l'offrant[447]. Cette situation a été expressément envisagée par l'article 5.32 du nouveau code belge sous la dénomination (inconnue en droit français) d'erreur matérielle. Aux termes de cet article « L'erreur matérielle qui procède d'une discordance involontaire entre la volonté réelle commune des parties et leur volonté déclarée ne rend pas le contrat nul mais peut toujours être rectifiée. »

221. Distinction de l'erreur et du dol. Il importe d'emblée de tirer au clair les rapports de la nullité pour erreur, relevant de l'article 1110 du Code civil et de la nullité pour dol, fondée sur l'article 1116 du Code civil. On dit souvent que l'erreur de l'article 1110 du Code civil est une erreur spontanée – le contractant s'est trompé tout seul – alors que le dol est une erreur provoquée par un comportement déloyal du cocontractant. Cette opposition est un peu simpliste : s'il est vrai que le dol est toujours une erreur provoquée, l'erreur de l'article 1110 du Code civil peut être, quant à elle, aussi bien une erreur spontanée qu'une erreur provoquée. La différence est que, si l'action en nullité est fondée sur ce texte, on se placera exclusivement du côté de la victime, en faisant abstraction du comportement du cocontractant. Les deux vices se recouvrent donc partiellement, et, dans de nombreux cas, la victime d'une erreur aura le choix entre le fondement de l'article 1110 du Code civil (en démontrant que les conditions restrictives posées par ce texte sont réunies) et celui de l'article 1116 du Code civil (si elle démontre que son erreur a été causée par des manœuvres dolosives. Le choix de l'un ou l'autre fondement déterminera les conditions de la nullité, qui ne sont pas du tout les mêmes dans l'un et l'autre cas. Il n'aura en revanche pas d'incidence directe sur les sanctions, contrairement à ce qu'on croit

446 DE PAGE, *Traité*, t. I, 1962, p. 48. Cette analyse est aujourd'hui reprise par VAN OMMESLAGHE, n° 136, et au Luxembourg, par POELMANS, n° 60.

447 Dans ce sens, WÉRY, n° 223.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

souvent. Si l'erreur a été provoquée par le comportement déloyal du cocontractant, la victime pourra, tout en agissant sur le fondement de l'article 1110 du Code civil, demander à la fois la nullité du contrat et des dommages et intérêts (ou seulement des dommages et intérêts si elle préfère garder le bénéfice du contrat). Le plus souvent, en pratique, les victimes d'erreurs essaient de cumuler les deux fondements : ils soutiendront à la fois que leur erreur porte sur la substance ou sur la personne (ce qui entraîne la nullité sur le fondement de l'article 1110 du Code civil) et que, de toute façon, même si ce n'était pas le cas, cette erreur a été provoquée par des manœuvres, donc qu'elle constitue un dol au sens de l'article 1116 du Code civil. Selon les circonstances, les juges pourront, soit annuler sur les deux fondements, soit annuler sur l'un des deux fondements si les conditions de l'un ou l'autre texte sont réunies, soit ne pas annuler du tout si les faits ne constituent ni une erreur au sens de l'article 1110 du Code civil ni un dol au sens de l'article 1116 du Code civil. De nombreuses décisions de la Cour d'appel illustrent cette utilisation cumulative des deux textes[448].

Cette indifférence du comportement et même de l'état d'esprit du cocontractant dans le régime juridique de l'erreur de l'article 1110 est caractéristique du système des vices du consentement dans le Code civil. Dans d'autres droits nationaux, en effet, le comportement du cocontractant de l'*errans* joue un rôle essentiel dans le régime de la nullité pour erreur, et cette position se retrouve dans les différents projets européens. Ainsi, en droit néerlandais, la nullité pour erreur ne peut être obtenue que dans l'un des trois cas suivants : l'erreur a été provoquée par une fausse information de l'autre, ou elle résulte du silence gardé par l'autre sur une circonstance qu'il savait importante pour son cocontractant, ou encore l'autre a commis la même erreur[449]. Ces trois cas se retrouvent, avec quelques différences de formulation, dans les Principes du droit européen des contrats (art. 4:103), dans le DCFR (art. II-7:201), et récemment encore dans le DCEV (art. 48). En droit français, belge ou luxembourgeois, ces circonstances sont absolument indifférentes pour admettre ou non la nullité pour erreur sur le fondement de l'article 1110 du Code civil (désormais art. 1132 C. civ. fr., art. 5.34 C. civ. be.). Il importe peu que l'erreur ait été commise par le seul contractant qui en a été victime ou qu'elle ait été commune aux deux contractants.

448 Voy., p. ex., Cour d'appel, 9 février 2000, *Pas.*, 31, p. 356 (erreur sur l'existence de sûretés assortissant une opération complexe de crédit bancaire : la Cour refuse d'annuler pour dol au motif que la banque n'était pas de mauvaise foi, mais elle annule pour erreur en considérant que les sûretés font partie intégrante de la substance du prêt) ; Cour d'appel, 10 janvier 2007, *Pas.*, 33, p. 491 (erreur commise par une caution sur la solvabilité du débiteur principal : la Cour refuse à la fois d'annuler pour dol – parce qu'elle estime que la banque n'a pas l'obligation d'informer la caution sur la situation du débiteur – et pour erreur – parce que l'erreur est jugée inexcusable en raison des liens amicaux très proches entre la caution et le débiteur) ; Cour d'appel, 23 février 2022, n° CAL-2019-00631 (même refus d'annulation sur les deux fondements, au motif que le contractant ne prouve pas que son erreur avait été déterminante de son consentement).

449 BWB, art. 6:228.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Et il importe peu, surtout, que l'erreur ait été spontanée ou provoquée par le comportement du cocontractant (que celui-ci soit, du reste, de bonne ou de mauvaise foi), que le contractant victime se soit trompé tout seul ou qu'il ait été trompé. Le comportement du cocontractant n'est pris en compte, en théorie du moins[450], que pour caractériser le dol.

222. Admission restrictive de la nullité pour erreur. Précisément parce qu'il ne tient aucun compte du comportement du cocontractant, l'article 1110 du Code civil conçoit la nullité pour erreur comme une solution exceptionnelle, comme le montre bien sa formulation restrictive « l'erreur *n*'est une cause de nullité *que* […] » « elle *n'est pas* une cause de nullité, *à moins que* […] ». C'est que, dans l'hypothèse où le contractant s'était trompé tout seul, sans qu'on ne puisse rien reprocher à son cocontractant on considère que c'est à ce contractant, en principe, de supporter les risques d'une telle erreur, sauf dans des cas jugés particulièrement graves où le souci de protection du consentement prendra le pas sur les intérêts du cocontractant. Cette approche, qui s'accorde avec l'idée de sécurité juridique précédemment évoquée, a amené les rédacteurs du Code à n'admettre l'erreur comme cause de nullité que si elle porte sur certains objets (A). S'y ajoutent certaines exigences quant aux caractères que doit présenter cette erreur (B).

A) *L'objet de l'erreur*

223. Sur quoi s'est-on trompé ? Selon l'article 1110, l'erreur n'est une cause de nullité *que* si elle a porté sur la « substance » de la chose objet du contrat (1), ou, de manière exceptionnelle, sur la personne du cocontractant (2). Les autres erreurs, même si elles ont été déterminantes du consentement, sont indifférentes à la validité du contrat (3).

1) *Erreur sur la substance*

224. Conception objective et conception subjective : de la substance aux qualités substantielles. Le terme « substance » utilisé dans l'article 1110 du Code civil peut s'entendre de plusieurs manières. Dans un premier sens, purement objectif (ou matériel), on peut l'entendre comme désignant la matière même

[450] En pratique, on peut supposer que, même s'ils sont saisis d'une nullité pour erreur, les juges tiendront sans doute compte, dans l'application plus ou moins restrictive qu'ils feront de l'article 1110 du Code civil, du comportement du cocontractant.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

dont est faite la chose sur laquelle porte le contrat. On illustre habituellement cette conception à l'aide de l'exemple des chandeliers développé par Pothier[451]. Cette conception est cependant depuis longtemps abandonnée. D'abord parce que tous les contrats ne portent pas sur une chose composée d'une certaine matière : même s'il a visiblement été écrit par les rédacteurs du Code civil en pensant au modèle du contrat de vente d'une chose corporelle, le texte doit pouvoir aussi s'appliquer à des contrats qui n'ont pas un objet matériel comme le prêt d'argent, le mandat, le cautionnement, les contrats de service, ou, aujourd'hui, à tous les contrats qui portent sur des biens incorporels (la vente d'un logiciel, d'une marque, la cession d'un droit d'auteur, etc.)[452]. Ensuite parce que, même dans les contrats portant sur une chose (et en particulier dans la vente), la matière de cette chose est très souvent indifférente. Certes, dans l'exemple du chandelier, la matière paraît essentielle pour l'acheteur, et il semble normal qu'il puisse faire annuler la vente. En revanche, si j'achète un tableau signé par un peintre célèbre, ce qui compte pour moi n'est pas que la toile soit de telle ou telle qualité pas plus que le type de peinture utilisée, c'est à l'évidence que le tableau ne soit pas un faux. Il paraîtrait donc absurde que je puisse faire annuler la vente au motif que le tableau est peint à la peinture acrylique et non à l'huile, mais que je sois sans recours si le tableau n'est qu'une vulgaire copie ! C'est pourquoi, depuis très longtemps, la doctrine et la jurisprudence interprètent la notion de substance de manière subjective, en considération de l'intention des parties lors de la conclusion du contrat : l'erreur sera une cause de nullité chaque fois qu'elle portera sur une « qualité substantielle » de l'objet du contrat, c'est-à-dire la caractéristique normalement attendue par le contractant de la chose ou du service sur lequel porte le contrat. Cette idée était du reste déjà présente chez Pothier, qui ne prenait l'exemple du chandelier que pour illustrer l'idée selon laquelle « l'erreur annule la convention […] lorsqu'elle porte sur la qualité que les contractants ont eue principalement en vue, et qui fait la substance de cette chose ». Cette conception, qui s'est progressivement imposée dans la jurisprudence française

451 Voy. *supra*, n° 220.

452 Sans doute tous ces contrats portent sur une prestation monétaire. Mais chacun sait bien qu'aujourd'hui la matière dont sont faits les billets et les pièces est indifférente, et que, du reste, la plupart des prestations monétaires sont aujourd'hui complètement dématérialisées.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

au cours du XIX[e] siècle[453], est également reçue en Belgique. La Cour de cassation belge affirmait ainsi avant la réforme que la substance est « tout élément qui a déterminé principalement la partie à contracter, de telle sorte que, sans cet élément, le contrat n'aurait pas été conclu »[454]. On retrouve la même idée dans les nouveaux textes issus des réformes française et belge. En France, l'article 1132 du Code civil dispose que l'erreur est une cause de nullité lorsqu'elle porte « sur les qualités essentielles de la prestation due », tandis que l'article 5.34 du nouveau code belge pose que l'erreur « n'est une cause de nullité que lorsqu'une partie a, de manière excusable, une représentation erronée d'un élément qui l'a déterminée à conclure le contrat, alors que l'autre partie connaissait ou devait connaître ce caractère déterminant ». La jurisprudence luxembourgeoise suit exactement la même ligne. On trouve ainsi dans plusieurs décisions la formule selon laquelle « par « substance il faut entendre toute qualité dont la considération a été la cause déterminante de l'engagement »[455].

225. Exemples. Il paraît inutile, dans le cadre nécessairement limité de ce manuel, de donner une longue liste – qui ne saurait de toute façon être exhaustive – des multiples applications qui ont pu être faites de la notion d'erreur sur les qualités substantielles[456]. En dehors du cas topique de l'erreur sur l'authenticité d'une œuvre d'art, qui suscite toujours une jurisprudence abondante, on citera, parmi les cas qui ont été retenus par la jurisprudence luxembourgeoise : l'erreur commise par l'acheteur d'un terrain sur la constructibilité de celui-ci[457], l'ignorance par l'acheteur d'un véhicule automobile que ce véhicule était gagé (ce qui limitait le droit de jouissance du véhicule)[458], l'erreur commise par l'acheteur d'un appartement sur la surface de celui-ci[459], l'erreur commise par

[453] La première affirmation nette de cette conception se trouve dans Cass. fr. (civ.), 28 janvier 1913, *S.*, 1913, 1, p. 487 : « l'erreur doit être considérée comme portant sur la substance même de la chose, lorsqu'elle est de telle nature que, sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ».

[454] Cass. be., 3 mars 1967, *Pas.*, 1967, I, p. 811.

[455] Trib. Luxembourg, 1[er] mars 1966, *Pas.*, 20, p. 142 ; Cour d'appel, 9 février 2000, *Pas.*, 31, p. 356 ; Cour d'appel, 30 novembre 2021, n° CAL-2021-00123.

[456] Sur les infinies subtilités de la notion voy. tout particulièrement en droit français : GHESTIN, LOISEAU, SERINET, n[os] 1127 et s.

[457] Cour d'appel, 8 janvier 1997, *Pas.*, 30, p. 200 ; Trib. Diekirch, 22 octobre 2019, n° 2019TADCH01/131.

[458] Cour d'appel, 8 février 2006, n° 30012, *BIJ*, 2006, p. 174.

[459] Cour d'appel, 12 juillet 2017, n° 43228.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'acheteur de parts sociales sur la situation financière de la société[460], ou encore la croyance erronée d'un prêteur à l'existence de sûretés garantissant le prêt[461]. Ces derniers exemples montrent que la notion de « substance », dans la conception retenue, peut aussi bien s'appliquer à une prestation immatérielle : comme le relève un arrêt de la Cour d'appel, « La nullité peut être invoquée alors même que l'erreur ne porte pas sur une chose matérielle. À la substance de la chose, la jurisprudence assimile en effet la substance de la prestation étant entendu que l'article 1110 s'applique à toute convention quel qu'en soit l'objet et quelle qu'en soit la nature »[462].

226. Appréciation *in abstracto* ou appréciation *in concreto* ? À partir du moment où on introduit dans la notion de substance la considération de ce que la partie victime de l'erreur avait en vue lors de la conclusion du contrat, se pose la question de savoir jusqu'où on va dans la prise en compte des attentes subjectives du contractant. Doit-on considérer concrètement ce que ce contractant avait personnellement en tête lorsqu'il s'est engagé (appréciation *in concreto*), ou doit-on seulement tenir compte des qualités que, dans le type de contrat considéré, un contractant a normalement en vue (appréciation *in abstracto*) ? Ainsi, lorsqu'on achète un tableau, c'est, en général, son authenticité qui est importante, et qui sera considéré comme une qualité substantielle. Mais il se peut que j'achète un tableau, signé d'un peintre notoire, parce que je crois qu'il représente mon arrière-grand-père : si je découvre ensuite qu'il n'en est rien, pourrai-je faire annuler la vente, alors même que l'authenticité du tableau n'est pas discutée ? De prime abord, alors même que mon erreur porte bien sur une « qualité » du tableau, la réponse paraît devoir être négative, car il n'y a pas de raison de faire supporter au cocontractant les risques d'une annulation liée à des considérations qui me sont strictement personnelles. Cela n'exclut pas complètement qu'on puisse prendre en considération une qualité spécifiquement attendue par un contractant. Simplement, l'annulation sera plus difficile à obtenir dans ce cas que si l'erreur a porté sur une qualité normalement substantielle. D'une part, sur le terrain de la preuve, celui qui se plaint d'une erreur sur une qualité normalement substantielle n'aura pas en principe à prouver que

460 Cour d'appel, 18 mai 2006, *BIJ*, 2006, p. 203 (à la limite de l'erreur sur la valeur !).

461 Cour d'appel, 9 février 2000, *Pas.*, 31, p. 356 « Le prêt et les suretés y attachées forment un tout. Les sûretés font ainsi partie de la substance même de l'objet du contrat ».

462 Cour d'appel, 30 juin 1993, *Pas.*, *29*, p. 253.

LARCIER INTERSENTIA
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

cette qualité substantielle était pour lui déterminante : si j'achète un tableau au prix d'un original et que je découvre ensuite que c'était une copie, on présumera que l'authenticité était pour moi une qualité déterminante. En revanche, si je recherchais autre chose dans le tableau (le sujet représenté, par exemple), il m'appartiendra de le prouver positivement – ce qui sera souvent très difficile. D'autre part, si c'est une qualité normalement substantielle qui fait défaut, on peut facilement accepter que le cocontractant puisse perdre le bénéfice du contrat (même s'il n'est pour rien dans l'erreur commise), parce que, lors de la conclusion du contrat, il a pu penser que cette qualité était un élément essentiel du contrat, et savoir que l'autre ferait tomber le contrat si elle se révélait fausse. Il n'en va pas de même si une partie a contracté en considération d'une qualité spécifique qu'elle seule recherchait : cette qualité ne pourra alors être prise en considération que si cette partie a fait part à l'autre de ce qu'elle attendait précisément du contrat[463]. Cette qualité entrera alors, selon une expression consacrée, dans le « champ contractuel », et on pourra admettre que le cocontractant ainsi informé a accepté le risque de l'annulation du contrat en cas de défaut de cette qualité[464]. Cette distinction apparaît en filigrane dans le nouvel article 1133 du Code civil français, selon lequel « [l]es qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ». On trouvait déjà ce type de formule, reprise de la jurisprudence française antérieure, dans un arrêt de la Cour d'appel du Luxembourg posant que l'erreur doit « avoir atteint une qualité expressément ou implicitement convenue entre parties »[465]. On dit parfois que, dans un tel cas, l'erreur doit être « commune »[466], mais cette expression est particulièrement ambiguë : il ne s'agit nullement d'exiger que les deux contractants se soient trompés (ce qui est parfois exigé en droit comparé), mais seulement que « les qualités substantielles de la chose sur lesquelles a porté l'erreur doivent avoir été comprises comme telles dans la commune intention des deux parties contractantes »[467]. Bien entendu, la différence entre les deux situations n'est pas toujours aussi nette que dans l'exemple un

463 Dans ce sens, très net : Cour d'appel, 22 novembre 2017, Pas. 39, p. 35.

464 Il lui appartient alors, s'il n'accepte pas ce risque, d'introduire dans le contrat une clause indiquant qu'il ne garantit pas la qualité recherchée.

465 Cour d'appel, 8 janvier 1997, *Pas.*, 30, p. 200, préc.

466 POELMANS, n° 61.

467 VAN OMMESLAGHE, n° 140.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

peu caricatural qui a été pris (l'erreur sur l'authenticité / l'erreur sur le sujet représenté par le tableau), et le fait de savoir si la qualité sur laquelle a porté l'erreur était ou non une qualité normalement substantielle dépend largement des particularités de l'espèce, telles que les juges les apprécient. La Cour d'appel a ainsi considéré que le fait qu'un appartement, qualifié d'habitable dans l'acte de vente, se révèle ensuite inapte à servir de résidence principale à l'acquéreur, ne justifiait pas l'annulation de la vente, l'habitabilité à titre de résidence principale n'étant pas, selon les juges, une qualité substantielle *in abstracto*. Il appartenait à l'acheteur de faire savoir à son vendeur quelle destination précise il entendait donner à l'appartement[468].

227. **Erreur sur la prestation de l'autre et erreur sur sa propre prestation.** Il importe peu en principe que l'erreur porte sur la prestation de l'autre ou sur sa propre prestation. Ainsi, en matière de vente, on a l'habitude de raisonner sur l'exemple d'une erreur commise par l'acheteur sur les qualités de la chose qu'il achète. Mais l'erreur peut aussi bien être commise par un vendeur sur les caractéristiques de la chose qu'il vend : ainsi, si je trouve dans mon grenier un tableau que je vends à bas prix en croyant qu'il n'a aucune valeur, et que je découvre ensuite qu'il s'agit d'une toile d'un grand peintre du XVIIe siècle, je pourrai faire annuler la vente. Cette solution est illustrée dans la jurisprudence française par une affaire célèbre relative à la vente par des particuliers au musée du Louvre d'un tableau qui était, au moment de la vente, attribuée à « l'école des Carrache », mais qui, ensuite, a été présenté par le musée comme une œuvre originale de Nicolas Poussin – peintre beaucoup plus prestigieux. Bien que, finalement, cette attribution à Poussin n'ait jamais pu être établie de manière certaine, les vendeurs ont pu obtenir la nullité de la vente au motif que leur consentement avait été vicié par « la conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de Nicolas Poussin »[469]. Le nouvel article 1133 du Code civil français précise à cet égard que « [l]'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie ». Il faut cependant signaler que d'une manière générale, un vendeur aura plus de mal à faire annuler la vente qu'un acheteur, dans la mesure où on est censé mieux connaître les choses qu'on vend que celles qu'on achète, et où, en conséquence, l'erreur commise par le vendeur sera plus facilement considérée comme inexcusable – ce qui, nous le verrons, est de nature à exclure la nullité[470].

228. **Erreur de fait et erreur de droit.** L'erreur sur une qualité substantielle peut être liée non seulement à des caractéristiques factuelles de l'objet du contrat, mais également à l'ignorance du contenu d'une règle de droit. Il en va ainsi lorsque cette règle affecte l'utilisation qu'on compte faire de la chose qu'on achète. Ainsi, le défaut de constructibilité du terrain qui peut entraîner la nullité de la vente s'il a été ignoré de l'acheteur, peut tenir aussi bien à des caractéristiques physiques du sol (empêchant

468 Cité par POELMANS, p. 82.

469 L'affaire a duré plusieurs années, et a donné lieu à deux arrêts de la Cour de cassation : Cass. fr. (1re civ.), 22 février 1978, n° 76-11551 ; Cass. fr. 1re civ.), 13 janvier 1983, n° 82-12237 (pour un exposé complet de l'affaire voy. GAJC, t. 2, n°s 147 et 148).

470 Voy. *infra*, n° 236.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

d'y édifier une construction solide) qu'à des règles d'urbanisme justifiant le refus de délivrance du permis de construire. La maxime « nul n'est censé ignorer la loi », qui signifie qu'on ne peut pas prétendre échapper à une sanction pénale en alléguant l'ignorance de la règle qu'on a violée, n'est pas de nature à empêcher dans un tel cas l'action en nullité. Les nouveaux textes français et belge précisent désormais que l'erreur peut être aussi bien de droit que de fait (C. civ. fr., art. 1132, C. civ. be., art. 5.34, al. 2). Cependant, là encore, une erreur de droit pourra plus facilement être considérée comme inexcusable, si la règle de droit dont on a ignoré l'existence ou le contenu était facile à connaître[471].

229. **Erreur sur la substance et vice caché**. Lorsque l'erreur porte sur une qualité substantielle d'une chose vendue, le domaine de l'article 1110 du Code civil recoupe fréquemment celui d'un texte spécifique au contrat de vente, l'article 1641 du Code civil relatif à la garantie des vices cachés. Selon ce texte, le vendeur est tenu à garantie « à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ». Or, si la chose est atteinte d'un défaut caché, ne peut-on dire aussi que l'acheteur, qui a cru qu'elle n'avait pas ce défaut, a commis une erreur sur la substance de cette chose ? A-t-il alors le choix entre les deux actions, ou faut-il considérer que la règle spéciale (C. civ., art. 1641) l'emporte sur la règle générale (C. civ., art. 1110) ? La question se pose parce que les deux actions n'obéissent pas aux mêmes conditions ni ne conduisent aux mêmes effets : l'action en nullité pour erreur peut être exercée dans les cinq ans suivant la découverte du vice, alors que le vice caché doit être dénoncé dans un « bref délai » suivant sa découverte et donner lieu à une action dans le délai d'un an suivant cette dénonciation[472] ; l'article 1110 du Code civil conduit à la nullité du contrat, l'article 1641 du Code civil à sa résolution ou à la réduction du prix, avec, dans les deux cas, la possibilité d'obtenir des dommages et intérêts, mais à des conditions différentes. Cette question a suscité une évolution remarquable dans la jurisprudence française : alors qu'elle avait jugé, dans un premier temps, que l'existence d'un vice caché n'excluait pas la possibilité pour l'acheteur d'agir en nullité pour erreur, sans être alors tenu par le bref délai[473], la Cour de cassation estime, depuis 1996, que la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de l'action[474]. La même évolution s'observe dans la jurisprudence luxembourgeoise. La Cour d'appel avait jugé, en 1997, et encore en 2006 (donc bien après le revirement français de 1996), que l'existence d'un vice caché n'excluait pas par elle-même l'exercice d'une action en nullité d'un contrat pour erreur sur la qualité substantielle de l'objet et que victime d'une erreur sur la substance, consécutive à un vice caché de la chose, bénéficiait donc d'une option en vertu de laquelle elle restait libre de se prévaloir

471 Voy. *infra*, n° 236 à propos du caractère inexcusable de l'erreur commise par un acheteur d'un appartement qui n'avait pas pris connaissance du règlement de copropriété avant la vente.

472 Les solutions ne sont pas exactement les mêmes en droit français, où une ordonnance de 2005 a supprimé la notion traditionnelle de « bref délai », et où l'action en garantie doit être exercée dans le délai de deux ans suivant la découverte du vice. En droit belge, l'action doit être exercée dans un bref délai suivant la découverte du vice Mais, dans les trois droits, le délai pour agir est très différent de celui de l'action en nullité pour erreur.

473 Cass. fr. (1re civ.), 26 juin 1988, n° 87-11918.

474 Cass. fr. (1re civ.), 14 mai 1996, n° 94-13921 ; Cass. fr. (3e civ.) 7 juin 2000, GAJC, t. 2, 12e éd., nos 267-268.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de l'une ou l'autre voie ouverte par la loi[475]. Mais, en 2008, elle a jugé que « toute possibilité de cumul de l'action en nullité avec l'action rédhibitoire pour vice caché est exclue. En présence d'un vice caché, la garantie des vices constitue l'unique fondement possible de l'action de l'acheteur, ainsi tenu d'agir à bref délai sans pouvoir se prévaloir de l'erreur commise par lui »[476]. Cette solution, qui se distingue de celle qui est toujours admise en Belgique[477], n'est peut-être pas à l'abri des critiques : on ne voit pas bien pourquoi, lorsqu'une situation de fait tombe sous le coup de deux qualifications juridiques, l'une devrait nécessairement exclure l'autre. La solution ne se justifie que lorsque le vice caché dont se plaint l'acheteur concerne une chose qui n'était pas encore déterminée au moment de la vente, par exemple le défaut d'une voiture neuve fabriquée en série : on ne peut pas dire que l'acheteur a commis une erreur sur une qualité de « la » voiture achetée, puisqu'on ne savait pas encore, au moment de la vente, laquelle précisément lui serait livrée ; la situation relève alors exclusivement de la garantie des vices cachés, qui est une obligation à laquelle est tenu le vendeur dès lors qu'il a livré une chose défectueuse. Mais on ne peut certainement pas raisonner ainsi pour la vente d'un corps certain – et notamment la vente d'un immeuble – pour laquelle le défaut existait dès le moment de la vente, et est la source, dès ce moment, d'une erreur de l'acheteur. En toute hypothèse, la solution actuellement retenue par la jurisprudence luxembourgeoise ne vaut que lorsqu'on est en présence d'un véritable « défaut » de la chose, qui la rend impropre à son usage : tel n'est pas le cas d'une caractéristique de la chose, importante pour l'acheteur, qui peut avoir une incidence sur la valeur de la chose, mais non sur son usage. Ainsi le fait qu'une œuvre d'art ne soit pas authentique n'est pas, en soi, un « défaut » de l'œuvre ; serait en revanche un défaut le fait que la toile soit atteinte de moisissures qui entraînent sa destruction progressive. La frontière entre les deux situations est cependant parfois difficile à tracer, et c'est peut-être une raison supplémentaire d'admettre l'option de l'acheteur entre les deux actions, sous peine de réduire à peu de choses le domaine de la nullité pour erreur sur la substance dans la vente. Ainsi, le refus de permis de construire au motif que le terrain est en zone inondable n'est-il pas un « défaut » de ce terrain ?

2) *Erreur sur la personne*

230. Contrats intuitu personae. Dans certains contrats, la personnalité du cocontractant est indifférente. Si j'achète un appartement, par exemple, il m'est *a priori* égal que mon vendeur soit une personne honorablement connue, ou qu'il ait été naguère condamné pour vol ou même pour un crime sexuel. Dans ce type de contrats, le fait qu'on se soit trompé sur la personne de son cocontractant ne doit donc pas ouvrir droit à faire annuler le contrat. Il n'en ira pas nécessairement de même dans les nombreux contrats

475 Cour d'appel, 8 janvier 1997, *Pas.*, 30, p. 2000 ; Cour d'appel, 18 mai 2006, n° 28582, *BIJ*, 2006, p. 203.

476 Cour d'appel, 12 mars 2008, *Pas.*, 34, p. 189 (précisant cependant, suivant encore en cela la position de la Cour de cassation française, que le vice caché n'exclut pas une action en nullité pour dol) Dans le même sens, plus récemment : Cour d'appel, 5 octobre 2016, *Pas.*, 38, p. 273 ; *JN Obligations*, 2017/2, pp. 31-34, note H. WESTENDORF ; Cour d'appel, 6 mars 2019, n° 45274 ; Trib. Diekirch, 26 juillet 2021, n° TAD-2021-00764 ; Cour d'appel, 27 janvier 2022, n° CAL-2020-00452.

477 VAN OMMESLAGHE, n° 148.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

qui sont conclus en considération des qualités personnelles de son cocontractant : un employeur, par exemple, embauche un salarié en considération de ses compétences, un banquier prête de l'argent en tenant compte des facultés de remboursement de l'emprunteur, et, si je m'associe avec quelqu'un pour créer une entreprise, j'ai besoin de savoir quelles sont les qualités et quels sont les défauts de mon futur associé. C'est ce qu'on appelle des contrats « *intuitu personae* ». On peut alors concevoir que, si on conclut un contrat de ce type, en croyant que l'autre partie a des qualités bien précises dont il est en réalité dépourvu, cette erreur puisse être une cause de nullité du contrat. C'est précisément ce que dispose l'article 1110, alinéa 2 du Code civil, qui, après avoir posé qu'en principe l'erreur sur la personne du cocontractant n'est pas une cause de nullité du contrat, réserve le cas où la « considération de cette personne (est) la cause principale de la convention ». Cette solution est reprise par le nouvel article 1134 du Code civil français et par l'article 5.34 du nouveau Code civil belge. Ce cas d'erreur est d'application beaucoup plus rare que le précédent, et la jurisprudence luxembourgeoise n'en offre que de rares exemples. On peut citer une décision du Tribunal de Luxembourg qui annule pour erreur la vente d'un véhicule par un garage concessionnaire d'une marque à une société dans l'ignorance que celle-ci était un revendeur professionnel non agréé qui commercialisait des véhicules neufs en dehors des réseaux de distribution[478]. Dans la plupart des cas où ce type d'erreur est invoqué, l'action en nullité est repoussée, soit parce que le contrat ne présentait pas un caractère *intuitu personae*, soit parce que les qualités sur lesquelles l'erreur était supposée porter n'étaient pas entrées dans le champ contractuel[479].

L'article 1110, alinéa 2 du Code civil pose trois séries de questions. D'abord dans quels cas exactement peut-on parler d'un contrat *intuitu personae* ? Le texte ne vise que les contrats où la considération de la personne est la « cause principale de la convention », ce qui est assez restrictif. La jurisprudence française admet plus largement l'application du texte dans les cas où les qualités du cocontractant sont importantes, sans pour autant constituer le motif principal du contrat : ainsi, par exemple, dans le contrat de bail où les qualités du locataire sont certes importantes mais ne sont pas la cause première du contrat pour le bailleur qui cherche d'abord à rentabiliser son bien. Et, comme le montre le jugement précité du Tribunal de Luxembourg, même un contrat de vente peut, dans certains cas, intégrer la considération de la personnalité de l'acheteur. Ensuite sur quelle personne l'erreur doit-t-elle porter ? Le texte ne vise que l'erreur sur la personne « avec qui on a l'intention de contracter », mais la jurisprudence française admet parfois comme cause de nullité l'erreur sur

[478] Trib. Luxembourg, 24 octobre 2007, n° 104402, *BIJ*, 2007, p. 193.
[479] Voy. p. ex. Cour d'appel, 23 octobre 2019, n° CAL-2018-00609.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

une personne qui n'était pas partie au contrat, mais dont les qualités étaient importantes pour l'exécution de celui-ci : ainsi une convention d'arbitrage passée entre deux personnes en litige a-t-elle pu être annulée parce que l'une des parties avait ignoré que l'arbitre désigné (tiers à cette convention) avait avec l'autre des liens qui compromettaient son indépendance. Enfin quels sont les types d'erreurs à prendre en compte ? Là-dessus, il est bien admis aujourd'hui que cette erreur ne doit pas s'entendre seulement d'une erreur sur l'identité de la personne de son cocontractant, mais aussi, et principalement, d'une erreur sur les qualités que l'on recherchait chez ce contractant (sa compétence[480], sa solvabilité, son honnêteté, etc.). Comme pour les qualités substantielles de la chose, ces qualités s'apprécient en principe *in abstracto* en fonction du type de contrat, mais on peut aussi tenir compte de certaines qualités spécifiques si elles sont entrées dans le champ contractuel.

3) *Erreurs indifférentes*

a. *Erreur sur les motifs*

231. Principe : erreur indifférente. Quelle que soit la conception extensive que la jurisprudence moderne ait de la « substance » au sens de l'article 1110 du Code civil, il faut, pour que l'erreur soit une cause de nullité, qu'elle porte sur une qualité, sur une caractéristique intrinsèque de l'objet du contrat. Ne constitue pas en revanche une cause de nullité l'erreur sur des éléments extérieurs à l'objet du contrat, alors même qu'ils commandent l'intérêt ou l'utilité que le contrat présente pour cette partie, et qu'ils ont constitué les motifs déterminants de son engagement. Un exemple souvent donné est celui de la personne qui, croyant qu'elle va obtenir un emploi dans une autre ville, y achète un appartement. Si elle n'obtient pas l'emploi, l'appartement ne lui servira à rien (ou du moins ne présentera pas pour elle l'utilité attendue), mais elle ne pourra pas faire annuler la vente. Un exemple plus actuel, tiré d'un arrêt de la Cour de cassation française, est celui d'une personne qui achète un immeuble dans le but de bénéficier d'avantages fiscaux ; or, finalement, ces avantages fiscaux ne peuvent pas être obtenus, et l'acheteur se retrouve avec un immeuble sans intérêt pour lui. Peu importe, dit la Cour de cassation, « l'erreur sur un motif extérieur du contrat extérieur à celui-ci n'est pas une cause de nullité du contrat, quand bien même ce motif aurait été déterminant »[481]. De même, si une personne se plaint du manque de rentabilité du

480 Cependant le seul fait qu'un contractant n'exécute pas correctement la mission qui lui a été confiée – ce qui constitue un cas d'inexécution du contrat – ne suffit pas à établir que ce contractant était dès le départ incompétent pour réaliser cette mission, et à faire annuler le contrat pour erreur sur la personne : Trib. Luxembourg (6e comm.), n° 1148/2014, 6 novembre 2014, n° 143341.

481 Cass. fr. (1re civ.), 13 février 2001, n° 98-15092.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

bien qu'elle a acheté (que ce soit un immeuble qu'elle ne parvient pas à louer aussi cher qu'elle l'avait espéré, ou une entreprise dont l'exploitation ne permet pas d'obtenir autant de bénéfices que prévus), elle ne peut pas en principe faire annuler la vente[482]. La même solution est consacrée depuis longtemps au Luxembourg. Dès 1904, la Cour d'appel avait ainsi affirmé que « Lorsque l'erreur ne porte ni sur la nature de la convention, ni sur l'objet même de celle-ci, ni enfin sur la substance de l'objet, il ne saurait y avoir contrat nul, ni contrat annulable. Spécialement, lorsqu'une des parties contractantes s'est trompée dans ses calculs, qu'elle a été déçue dans ses espérances, et que, par suite de faits indépendants de sa volonté, les prix de revient de son industrie se sont modifiés, ce sont là des circonstances dont elle aurait pu éventuellement tenir compte lors de la passation de son contrat, mais qui n'ont pu avoir pour effet de vicier son consentement »[483]. On retrouve la même idée dans un jugement plus récent du Tribunal de Luxembourg. Dans cette affaire, une société chargée de l'entretien d'un immeuble destiné à être vendu avait accepté de passer un avenant réduisant la durée de son contrat initial, parce qu'elle espérait conclure avec le client un nouveau contrat pour l'entretien de ses nouveaux locaux. Ce contrat ayant été finalement passé avec une autre société, elle cherchait à faire annuler l'avenant, pour bénéficier de son paiement jusqu'au terme initial. Le tribunal lui répond que « l'erreur invoquée par la société ne porte pas sur une qualité substantielle du contrat […] la méprise invoquée porte exclusivement sur les espérances personnelles liées à la conclusion d'un nouveau contrat après le terme de l'avenant ». C'est une erreur sur les motifs, insusceptible d'entraîner la nullité du contrat[484]. Pour comprendre ces solutions, il faut repartir de l'idée que c'est en principe à chacun de juger de l'intérêt que tel ou tel contrat peut présenter pour lui, et de supporter le risque de l'inutilité ou de la moindre utilité de l'opération. Si on peut accepter un partage des risques, en admettant la nullité du contrat, lorsque la perte d'intérêt du contrat est dû à un élément intrinsèque à celui-ci (la « substance » de l'article 1110 du Code civil), il n'en va pas de même lorsqu'elle est due à un élément extérieur,

[482] Voy., p. ex., Cass. fr. (3e civ.), 31 mars 2005, n° 03-20096 : « l'appréciation erronée de la rentabilité économique de l'opération n'était pas constitutive d'une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement de la SCI à qui il appartenait d'apprécier la valeur économique et les obligations qu'elle souscrivait ».

[483] Cour d'appel, 17 juin 1904, *Pas.*, 6, p. 469.

[484] Trib. Luxembourg (6e comm.), n° 1038/2014, 16 octobre 2014, n° 156951.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

dont les conséquences doivent rester exclusivement à la charge de celui qui s'est à tort fondé dessus et qui a mal anticipé les risques de l'opération : c'est le problème de l'acheteur si l'appartement ne lui sert finalement à rien parce qu'il n'obtient pas sa mutation, si son investissement n'est pas aussi rentable que prévu, s'il ne fait pas autant d'économies fiscales que prévu…

Le caractère indifférent en principe de l'erreur sur les motifs a été consacré en France par le nouvel article 1135 du Code civil, selon lequel « [l]'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité… ». La solution est beaucoup moins nette en Belgique. Reprenant une formule antérieure de la Cour de cassation belge, l'article 5.34 du nouveau Code civil prévoit la nullité lorsque l'erreur de la partie a porté sur « un élément qui l'a déterminée à conclure le contrat, alors que l'autre partie connaissait ou devait connaître ce caractère déterminant ». Rien ne dit ici que cet élément doit être une qualité intrinsèque de la chose ou de la prestation objet du contrat, et la formule peut tout aussi bien viser un élément extérieur qui a été le motif déterminant pour l'une des parties. Cette solution est à mettre en rapport avec la conception unitaire de la cause reçue en Belgique[485]. La différence avec les solutions reçues en France et au Luxembourg est cependant moins grande qu'on pourrait le pense si on considère les limites qui sont apportées au caractère indifférent de l'erreur sur les motifs.

232. Limites. On notera d'abord que le nouveau texte français déroge à la solution pour les libéralités : une libéralité peut être annulée en cas d'erreur sur le motif qui a déterminé son auteur à la faire. Cette dérogation s'explique dans la mesure où le bénéficiaire de la libéralité, qui n'a rien fourni en échange, ne peut pas se plaindre de la perte des avantages qui lui ont été consentis. En dehors de ce cas, en France et au Luxembourg, il ne suffit pas que le motif extérieur soit connu de l'autre pour que l'erreur sur les motifs devienne une cause de nullité, à la différence de ce qui est admis en Belgique[486]. Elle ne peut le devenir que dans deux hypothèses. La première est celle où le cocontractant, qui connaît

485 I. CORBISIER, n° 30. Voy. *infra*, n° 346.

486 Cass. fr. (1re civ.), 13 février 2001, préc. : « c'est à bon droit que l'arrêt énonce que l'absence de satisfaction du motif considéré savoir la recherche d'avantages d'ordre fiscal alors même que ce motif était connu de l'autre partie, ne pouvait entraîner l'annulation du contrat ».

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

le motif déterminant l'autre partie à conclure le contrat, et qui sait que ce motif ne correspond pas à la réalité, le pousse néanmoins à contracter par des manœuvres dolosives, (par exemple, en faisant croire à l'acheteur qu'il bénéficierait d'avantages fiscaux illusoires), ou du moins le laisse contracter sans rien lui dire (ce qui constitue une réticence dolosive). L'idée qu'il appartient à chaque contractant de supporter le risque de l'inutilité que l'opération peut avoir pour lui tombe naturellement dès lors que le jeu a été faussé par le cocontractant[487]. La nullité pourra alors être obtenue sur le fondement du dol. L'autre hypothèse est celle où le cocontractant, sans savoir que le motif déterminant de l'autre est inexact ou ne se réalisera pas, accepte expressément de faire dépendre le contrat de cet élément. C'est ce que dispose le nouvel article 1135 du Code civil français selon lequel l'erreur sur les motifs est une cause de nullité du contrat si les parties en ont fait « expressément un élément déterminant de leur consentement ». On peut cependant se demander si, dans un tel cas, on n'est pas plutôt en présence d'une condition – clause qui, comme nous le verrons plus loin, fait dépendre le sort du contrat d'un événement extérieur incertain[488]. Par exemple : j'achète cet appartement sous condition d'obtenir ma mutation dans cette ville dans le délai de 3 mois ; j'achète cet immeuble à condition que son acquisition me permette de bénéficier de tel avantage fiscal. Dans un tel cas, si la condition ne se réalise pas, le contrat ne sera pas nul, mais il deviendra caduc. On ne se situe plus du tout sur le terrain des vices du consentement. Le glissement de la question de validité du contrat à celle de sa caducité pour non-réalisation de la condition était déjà sensible dans un arrêt de la Cour d'appel du Luxembourg de 2007, qui posait que « l'erreur sur les motifs de l'engagement ne peut devenir cause de nullité que si les parties ont érigé les motifs en condition de leur engagement »[489].

233. **Difficultés d'application**. Il faut cependant avoir clairement conscience que la frontière entre l'erreur sur la substance – cause de nullité – et l'erreur sur les motifs – indifférente – est difficile à tracer et que sa délimitation dépend souvent de considérations de politique juridique de la part des tribunaux autant sinon plus que de la distinction technique entre une « qualité substantielle » et un « motif extérieur ». On peut, pour s'en convaincre, prendre l'exemple d'une caution qui s'engage à garantir

487 Voy. *infra*, n°s 247 et s. sur l'idée que le dol permet de retenir comme cause de nullité des erreurs qui ne le sont pas normalement lorsqu'elles sont spontanées.

488 Voy. *infra*, n°s 588 et s.

489 Cour d'appel, 10 janvier 2007, *Pas.*, 33, p. 491.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

le remboursement d'un crédit accordé à une personne qu'elle croit parfaitement solvable, et qui découvre ensuite que, dès le moment de son engagement, elle était déjà dans une situation financière désespérée. Cette caution peut-elle faire annuler son engagement au motif que, si elle avait connu la situation financière du débiteur, elle ne se serait jamais engagée ? On peut analyser la situation de deux manières. On peut dire, d'abord, que la solvabilité du débiteur est un élément extérieur au contrat passé entre le créancier et la caution : la fausse appréciation de cette solvabilité a certes déterminé son consentement au contrat, mais c'est une erreur sur les motifs, qui ne saurait entraîner la nullité du cautionnement. Mais on peut dire aussi : pas du tout ! La caution a cru qu'elle prenait un engagement de secours, qui ne s'exécuterait qu'au cas où le débiteur ne pourrait pas rembourser. Le fait que le débiteur était, d'emblée, dans une situation désespérée a en réalité transformé le sens de cet engagement, qui devenait un engagement principal dont l'exécution était d'ores et déjà certaine. C'est donc bien la substance de l'engagement qui a été atteinte. Ces deux analyses sont techniquement aussi défendables l'une que l'autre. La jurisprudence luxembourgeoise, suivant en cela une position constante de la Cour de cassation française, refuse en principe de considérer ce type d'erreur comme une erreur sur la substance : elle considère que « la caution qui invoque la nullité de son engagement pour cause d'erreur sur la solvabilité du débiteur principal doit établir que cette solvabilité constituait pour elle l'élément déterminant de la garantie et qu'elle a fait connaître expressément cette circonstance au créancier »[490]. L'exemple du défaut de rentabilité économique d'une entreprise est également caractéristique : d'une manière générale, comme on l'a dit, cette erreur est une simple erreur sur les motifs qui n'est pas susceptible d'entraîner la nullité. Mais il peut en aller autrement si, dès le moment de la vente, il était certain que, en raison de la situation de l'entreprise, celle-ci ne pourrait être rentable, auquel cas l'erreur commise par l'acheteur pourrait être considérée comme une erreur sur la substance. C'est ce qui explique, par exemple, que la Cour d'appel du Luxembourg ait annulé l'achat de parts sociales dans l'ignorance de la situation financière véritable de l'entreprise[491]. Les frontières entre les deux situations sont cependant très délicates à déterminer[492].

b. *Erreur sur la valeur*

234. Principe : erreur indifférente. Il est bien admis qu'en principe l'erreur sur la valeur économique du bien objet du contrat n'est pas une cause de nullité. Si, par exemple, j'achète un appartement au prix de 900 000 €, et que je découvre ensuite que je l'ai payé beaucoup trop cher par rapport au prix habituellement pratiqué dans le même secteur pour des biens comparables, je ne peux pas faire annuler la vente. La solution est habituellement présentée comme une conséquence de la règle inscrite à l'article 1118 du Code civil selon laquelle la lésion – c'est-à-dire le déséquilibre entre les prestations des contractants – n'est pas en principe une cause de

490 Cour d'appel, 6 octobre 1993, *Pas.*, 29, p. 279 ; Cour d'appel, 20 mars 2002, *D.A.O.R.*, 2002, n° 64, p. 479, note O. POELMANS ; Cour d'appel, 10 janvier 2007, *Pas.*, 33, p. 491.

491 Cour d'appel, 18 mai 2006, préc.

492 Voy. not. sur la question en droit français : FLOUR AUBERT SAVAUX 2014, n° 203-1.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

nullité du contrat[493]. Ce principe – repris aujourd'hui à l'article 1168 du Code civil français et à l'article 5.38 du nouveau Code civil belge – est lui-même une conséquence de l'approche libérale du droit des contrats, que traduit bien le célèbre aphorisme de Fouillée « qui dit contractuel dit juste »[494] : d'une manière générale, dans une économie de marché, il n'y a pas d'autre prix, d'autre valeur, que celle qui a été librement fixée entre les acteurs. Si j'ai accepté d'acheter l'appartement plus cher que la valeur habituelle, c'est parce que j'y tenais (et que, peut-être, je me suis mal renseigné avant sur le prix du marché). Ce prix – certes élevé – constitue par principe « le juste prix », et il contribuera du reste à faire évoluer à la hausse le « prix du marché » dans le secteur considéré. Certes, dans un certain nombre de cas, le législateur admet la nullité pour lésion, pour des raisons diverses, mais cette nullité n'est pas liée à l'existence d'une erreur de celui qui en a été victime, et elle obéit à un régime juridique particulier, qui n'est pas celui de l'article 1110 du Code civil. Par ailleurs, nous verrons que, comme l'erreur sur les motifs, l'erreur sur la valeur devient une cause de nullité lorsqu'elle a été provoquée par des manœuvres dolosives du cocontractant, mais ce sera sur le fondement de l'article 1116 du Code civil et non de l'article 1110 du Code civil. En dehors de ces cas, l'erreur sur la valeur ne saurait être admise, en elle-même, comme cause de nullité. La solution est désormais expressément affirmée par l'article 1136 du Code civil français et l'article 5.34 du nouveau Code civil belge.

La portée de la solution ne saurait cependant être exagérée. L'erreur sur la valeur devient une cause de nullité lorsqu'elle n'est que la conséquence d'une erreur sur la substance : si j'achète une œuvre d'art que je crois authentique, alors que ce n'est qu'une copie, il est évident que, dans l'immense majorité des cas, je la paierai beaucoup plus cher que le prix que j'aurais payé pour la copie si j'avais su que c'en était une. Je pourrai alors faire annuler la vente, mais pour erreur sur la substance. Les nouveaux textes

493 Dans sa rédaction originelle, l'article 1118 du Code civil disposait que « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes », ce qui indiquait clairement qu'elle ne les viciait pas d'une manière générale. L'actuelle rédaction luxembourgeoise, selon laquelle « sauf les règles particulières à certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, la lésion vicie le contrat lorsque […] » est moins nette, mais nous verrons que cette prise en compte de la lésion n'existe que dans des conditions très restrictives, et que, en dehors de ces conditions, le principe traditionnel demeure.

494 Voy. *supra*, n° 93.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

français et belge font clairement la distinction entre la « pure » erreur sur la valeur et celle qui résulte d'une erreur sur une qualité de l'objet du contrat.

B) *Caractères de l'erreur*

1) *Caractère déterminant*

235. Portée de l'exigence. D'une manière générale, les vices du consentement ne sont pris en considération que s'ils ont déterminé la volonté de celui qui en a été victime. Dans le droit français issu de la réforme, cette exigence est du reste posée par l'article 1130 du Code civil comme une règle commune à tous les vices du consentement, et il en va de même dans l'article 5.33 du nouveau Code civil belge. Auparavant, on déduisait cette exigence pour l'erreur de l'article 1109 du Code civil – toujours en vigueur au Luxembourg –, selon lequel le consentement n'est pas valable s'il « n'a été donné que par erreur ». Autrement dit, la victime de l'erreur doit démontrer que, si elle avait connu la réalité, elle n'aurait pas contracté, ou du moins pas aux mêmes conditions. En pratique, cependant, cette exigence ne joue qu'un rôle limité sur le terrain de l'article 1110 du Code civil, car elle se confond largement avec l'exigence d'une erreur sur une qualité substantielle. Dans la mesure où celle-ci est définie comme la qualité que la partie avait en vue en passant le contrat et qui a déterminé son consentement, la victime de l'erreur fera d'une pierre deux coups : en prouvant que la qualité manquante était substantielle, elle prouvera en même temps que l'erreur sur cette qualité a été déterminante pour elle. Comme il a été indiqué plus haut, cette preuve sera plus ou moins facile à apporter selon que la qualité manquante était une qualité normalement substantielle pour un contractant moyen, *in abstracto*, ou qu'il s'agit d'une qualité spécifiquement importante pour le contractant considéré.

La notion même d'erreur déterminante peut être comprise de manière plus ou moins extensive. L'erreur est certainement déterminante dans les cas où le contractant, s'il avait connu la réalité, aurait purement et simplement renoncé au contrat. Mais, dans un certain nombre de cas, le contractant, s'il avait été bien informé, aurait tout de même conclu le contrat, mais à des conditions plus avantageuses pour lui. Dira-t-on que dans ce cas aussi, l'erreur a été déterminante et quelle en sera la sanction ? Par exemple, j'ai acheté un tableau, en croyant que ce tableau était l'œuvre d'un peintre notoire – ce qui s'est révélé faux par la suite. Cependant, même si je l'avais su, j'aurais peut-être acheté le tableau – car il me plaisait beaucoup – mais il est évident que je l'aurais acheté moins cher. Est-ce que, dans un tel cas, je pourrai agir en nullité de la vente ? Cette question est très discutée sur

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

le terrain du dol, où elle sert de base à une distinction classique entre le dol dit principal, sanctionné par la nullité du contrat, et le dol incident, qui ne serait, selon une certaine tradition, que sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts[495]. Curieusement, cette distinction n'est jamais faite en cas d'erreur spontanée, ou supposée telle, sans doute parce que, dans ce cas, on ne peut pas concevoir, de manière générale, les dommages et intérêts comme une sanction alternative à la nullité (puisque l'erreur de l'article 1110 du Code civil n'est pas toujours due à une faute du cocontractant). Il semble donc qu'on puisse agir en nullité même si l'erreur commise a déterminé seulement les conditions du contrat, non son principe même. La solution est désormais certaine en droit français, dans la mesure où le nouvel article 1133 pose que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». Elle l'est beaucoup moins en droit belge, car l'article 5.33 définit l'erreur de la partie contractante comme « la représentation erronée d'un élément qui l'a déterminée à conclure le contrat », sans évoquer où l'erreur a seulement déterminé les conditions de conclusion du contrat. Le problème vient de ce que, dans un tel cas, le contractant victime n'a pas vraiment le choix : il ne peut que demander la nullité, et non une simple diminution de prix (sauf bien sûr si son cocontractant en est d'accord dans le cadre d'une transaction). À l'inverse, l'autre contractant ne peut pas imposer à la victime de compenser la différence de prix entre le bien attendu et le bien effectivement obtenu. Dans le système du Code civil, il est extrêmement difficile d'obtenir du juge une révision du contrat, sauf dans les cas où la loi le permet expressément[496], parce que cela semble aller à l'encontre du principe de la force obligatoire du contrat : si le consentement est vicié, la seule solution semble être de faire tomber le contrat, non de le rééquilibrer. Il est à noter que dans certains pays où les règles du droit des contrats sont plus récentes, on a expressément prévu la possibilité d'un simple rééquilibrage du contrat vicié par une erreur[497]. Nous retrouverons la question d'une manière plus générale en étudiant les sanctions des conditions de validité du contrat[498].

2) *Caractère excusable*

236. La négligence, obstacle à la nullité. On ne peut certes pas exiger que tout contractant, avant de s'engager, se livre à des recherches longues, approfondies et coûteuses pour savoir, par exemple, si le tableau ou le meuble qu'il achète est ou non authentique, ou si le terrain qu'il achète, présenté comme constructible, ne contient pas en son sous-sol de précieux restes archéologiques qui s'opposeraient à toute construction. Cependant, on estime que le contractant ne mérite pas la protection du droit s'il n'a pas pris, avant de signer le contrat, les précautions élémentaires qui lui auraient permis d'éviter une erreur ; dans un tel cas, son erreur sera

495 Voy. *infra*, n° 249.

496 Voy. p. ex. *infra*, à propos de la lésion.

497 Voy., p. ex., l'article 6 :230 du Code civil néerlandais ou l'article 1407 du Code civil du Québec.

498 Voy. *infra*, n° 479.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

considérée comme inexcusable, et son action en nullité sera repoussée. C'est ce qu'exprime très bien un arrêt de la Cour d'appel du Luxembourg du 16 juin 1970, qui reprend ici une position constante des jurisprudences française et belge : « L'erreur sur une qualité substantielle de la chose dans laquelle a versé un contractant […] n'est une cause de nullité du contrat que si cette erreur n'était pas facilement décelable. Si le contractant a, au contraire, disposé des moyens et du temps nécessaire pour déceler l'erreur, mais que par légèreté ou négligence il n'a pas procédé à certaines vérifications élémentaires, l'erreur dans laquelle il a versé est inexcusable, alors qu'un homme normalement raisonnable et avisé ne se serait pas exposé à la commettre. L'erreur inexcusable constitue une faute dont celui qui y a versé conserve les risques et qui s'oppose à l'annulation du contrat »[499]. On notera en particulier la formule finale qui rattache la question de la nullité pour erreur à la notion de charge des risques : les limites posées par l'article 1110 du Code civil quant à l'objet de l'erreur visent, comme on l'a déjà souligné, à délimiter le cercle des risques d'erreur qu'on peut faire supporter à son cocontractant ; mais il paraît normal de faire repasser les risques sur la tête de l'*errans* dès lors que l'erreur a été provoquée par sa faute inexcusable. Cette règle selon laquelle l'erreur n'est pas une cause de nullité si elle est inexcusable est aujourd'hui consacrée par le nouvel article 1132 du Code civil français et par l'article 5.34 du nouveau Code civil belge.

Toute la difficulté consiste évidemment à déterminer à partir de quand la faute de la victime de l'erreur sera considérée comme inexcusable, ou, en d'autres termes, quelle est l'étendue exacte de l'obligation de se renseigner qu'on veut faire peser sur chaque contractant. Cette question dépendra évidemment largement de l'appréciation du juge dans chaque cas d'espèce, mais on peut, en s'appuyant sur quelques exemples jurisprudentiels récents, pointer un certain nombre d'éléments qui sont habituellement pris en considération. On tiendra compte en particulier des compétences du contractant victime de l'erreur – d'une manière générale, l'obligation de se renseigner sera plus étendue, et l'erreur considérée plus facilement comme inexcusable, si le contractant est un professionnel, ou du moins un contractant averti, plutôt que s'il est un

[499] Cour d'appel, 16 juin 1970, *Pas.*, 21, p. 362. La formule est reprise par plusieurs arrêts récents : Cour d'appel, 12 juillet 2017, n° 43228 ; Cour d'appel, 30 mars 2022, n° CAL-2021-00148.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

profane[500] – et de la plus ou moins grande facilité des recherches à faire pour découvrir la réalité[501]. On tiendra compte également de la plus ou moins grande confiance que le contractant peut faire dans son cocontractant : si on achète un tableau dans une galerie d'art reconnue, on sera plus facilement excusable que si on achète à un particulier. Et, au-delà, c'est le comportement de ce cocontractant qui peut être pris en considération : nous verrons plus loin que, selon la jurisprudence, le dol (c'est-à-dire la tromperie du cocontractant) rend toujours l'erreur excusable ; cela doit logiquement valoir même si le contractant décide d'agir, non sur le terrain de l'article 1116 du Code civil, mais sur celui de l'article 1110 du Code civil.

§2. Le dol (C. civ., art. 1116)

237. Vice bicéphale. Bien que le texte de l'article 1116 du Code civil ne l'indique pas explicitement, la notion de dol est depuis longtemps interprétée comme recouvrant les cas où un contractant a été victime d'une erreur provoquée par des manœuvres de son cocontractant. Le contractant ne s'est pas trompé tout seul, il a été trompé. L'article 1116 du Code civil ne fait pas pour autant double emploi avec l'article 1110 du Code civil, parce que l'existence des manœuvres imputables au cocontractant (A), amène à retenir l'erreur comme cause de nullité beaucoup plus largement que lorsqu'elle a été spontanée (B).

[500] Voy. p. ex. Cour d'appel, 25 novembre 2021, n° CAL-2019-00311 à propos d'une erreur sur la portée d'une condition suspensive contenue dans une promesse de vente au profit d'un promoteur. L'arrêt relève que le caractère excusable ou non de l'erreur est apprécié « in concreto, en tenant compte notamment de l'expérience et de la profession de celui qui l'invoque. En l'espèce, il eût appartenu à l'intimée, en tant que professionnelle de la construction et de la promotion immobilière, de procéder à des vérifications élémentaires sur les possibilités de réalisation de son projet, avant la conclusion du compromis de vente litigieux, et de s'enquérir en particulier des conditions, notamment de durée, dans lesquelles elle pourrait obtenir la libération de l'immeuble dont il s'agit ». Voy. aussi Cour d'appel, 22 novembre 2017, *Pas.*, 39, p. 35.

[501] Par exemple a été considérée comme inexcusable la faute d'un acheteur d'un lot de copropriété qui aurait pu, en lisant le règlement de copropriété avant la vente, s'apercevoir que les combles du lot n'étaient pas aménageables : Cour d'appel, 7 février 2007, *Pas.*, 33, p. 39. À l'inverse, on ne peut exiger de l'acheteur d'un véhicule immatriculé au Luxembourg qu'il se renseigne sur une éventuelle inscription de gage sur le véhicule en France, alors qu'il n'avait aucune raison de savoir que le véhicule y avait été antérieurement immatriculé : Cour d'appel, 8 février 2006, n° 30012, préc. De même a été considérée comme excusable l'erreur d'un acheteur sur la surface de l'appartement acheté, dès lors que les conditions de visite, en présence d'une vingtaine d'autres personnes, ne pouvaient pas lui permettre de vérifier cette superficie : Cour d'appel, 12 juillet 2017, n° 43228.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

A) *Les manœuvres constitutives de dol*

238. Texte incomplet. L'article 1116 du Code civil ne définit pas la notion de manœuvres dolosives (**1**). Il indique en revanche clairement que ces manœuvres doivent émaner du cocontractant (**2**).

1) *Notion de manœuvres*

239. Éléments à prouver. L'article 1116, alinéa 2 du Code civil indique que « le dol ne se présume pas, il doit être prouvé ». Par ce texte, qui semble être une simple reprise du droit commun de la preuve, les rédacteurs du Code ont sans doute voulu différencier nettement le dol de l'erreur, en indiquant clairement qu'il ne suffit pas à celui qui se prétend victime d'un dol d'établir qu'il a été victime d'une erreur, il lui faut encore établir l'existence de manœuvres ayant provoqué cette erreur. L'erreur ne fait jamais présumer le dol. Cette preuve peut se faire par tous moyens (témoignages, documents écrits, etc.), puisqu'il s'agit d'un fait juridique. Elle n'est pas toujours aisée cependant, car il faut prouver non seulement un élément matériel, mais aussi un élément intentionnel.

a. *Élément matériel*

240. Artifices. La notion de manœuvres dolosives s'entend d'abord de comportements actifs d'un contractant faits dans le but de tromper l'autre. Il peut s'agir d'une véritable mise en scène, d'artifices : en droit romain, Cicéron donnait déjà l'exemple du vendeur d'une propriété de campagne à Syracuse, qui avait fait venir des comparses sur des bateaux de pêche pour faire croire à l'acheteur que les eaux devant ses jardins étaient très poissonneuses[502]. Aujourd'hui, on songe plutôt à la production de documents falsifiés, par exemple d'un faux certificat d'expertise pour faire croire à l'authenticité d'une œuvre d'art, ou de fausses pièces comptables pour tromper l'acheteur d'une entreprise sur sa valeur, ou pour convaincre une caution qu'elle peut s'engager sans risque aux côtés d'un débiteur (qui est en réalité en très mauvaise situation financière). De même constitue certainement un dol le fait de trafiquer le compteur d'une voiture pour faire croire que le kilométrage est moindre que celui qui a été effectivement parcouru.

[502] CICÉRON, *Les offices, Livre III, Chapitre XIV, Combien il est infâme d'ajouter le dol à la dissimulation – Définition du dol et de la mauvaise foi.*

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

241. Mensonges. Sans aller jusqu'à de tels artifices, le dol peut consister dans une simple affirmation mensongère du contractant – sachant que, si le mensonge a été seulement proféré oralement, il peut être difficile à prouver. Du mensonge dolosif (le mauvais dol, *dolus malus*), cependant, on distingue traditionnellement l'exagération qui est permise à un contractant dans la présentation des qualités du service ou du bien qu'il propose (le *dolus bonus*). « On ne pourrait trouver le dol, disait ainsi la Cour d'appel en 1919, dans tout fait d'un vendeur qui exalte sciemment la valeur de sa chose au-delà de la vérité »[503]. Le vendeur d'un appartement qui, pour vous convaincre d'acheter, vous vante de manière passionnée les agréments de sa terrasse où il fait bon paresser au soleil ne peut être accusé de dol, alors même que le climat luxembourgeois ne permet pas d'en profiter si souvent ! Il est cependant difficile de tracer avec précision la limite entre ce genre d'habileté permise et le mensonge caractérisé constitutif de dol. D'une manière générale, il convient de rechercher si le contractant a pu raisonnablement se laisser abuser par les propos de son cocontractant – ce qui permet du reste de faire échapper à la qualification de dol aussi bien de petites exagérations que, à l'inverse, des exagérations tellement énormes qu'aucun contractant raisonnable ne peut y croire.

La publicité se nourrit très souvent de ce type d'exagération – qu'il s'agisse de vous convaincre des qualités gustatives d'un produit (les raviolis en boîte : aussi délicieux qu'en Italie !), des vertus rajeunissantes d'une crème de beauté, ou de l'utilité d'un nouvel appareil ménager censé vous éviter une corvée dans la maison, etc. En matière de publicité, cependant, la notion de *dolus bonus* a aujourd'hui considérablement reculé, depuis que les législateurs nationaux, sous la contrainte de diverses directives européennes, répriment pénalement les pratiques de publicité trompeuse. Selon l'article L-122-2 du Code de la consommation du Luxembourg, une pratique commerciale est réputée trompeuse « si elle contient des informations fausses ou si d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes […] et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement »[504] – ce qui est de nature à englober beaucoup de pratiques que, traditionnellement, on considérait comme relevant de l'habileté commerciale permise.

242. Réticence dolosive. Si le fait de mentir, ou *a fortiori* de se livrer à des artifices pour tromper l'autre constitue incontestablement un dol, qu'en est-il lorsqu'un contractant se contente, passivement,

503 Cour d'appel, 17 octobre 1919, *Pas.*, 11, p. 190.

504 Voy. aussi l'article 17 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, qui appréhende aussi la publicité trompeuse sous l'angle de la protection des concurrents.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de garder le silence sur un élément du contrat qu'il connaît et dont l'ignorance par le cocontractant est de nature à déterminer son consentement ? Par exemple, je vous vends une maison qui offre une très belle vue sur le paysage environnant. Je sais cependant que, dans quelques mois, vont commencer des travaux de construction d'un immeuble qui vous bouchera partiellement la vue. Mais je me garde bien de vous le dire, parce que je crains que, si vous en étiez informé, vous ne renonciez à l'acquisition. Pourrez-vous faire annuler le contrat pour dol, bien que je ne vous aie pas positivement menti ? Il est admis depuis longtemps, au Luxembourg comme dans les autres pays du Code civil, qu'une simple réticence de ce type puisse constituer un dol[505]. Dans la jurisprudence française, cette solution est parfois rattachée à l'idée d'une obligation de contracter de bonne foi[506], et cette formule a été reprise par la Cour de cassation du Luxembourg[507]. Dès lors, l'erreur commise, dans un tel cas, pourra être considérée comme une erreur provoquée – ce qui, on le verra, permettra de la retenir plus largement que si elle avait été spontanée. Cette assimilation de la réticence à un dol est désormais consacrée expressément par l'article 1137 du Code civil français et par l'article 5.35 du nouveau Code civil belge. Il n'en va ainsi, cependant, qu'à deux conditions.

La première condition, pour qu'il y ait réticence dolosive, est que celui qui n'a rien dit était obligé de dire ce qu'il savait[508]. La qualification de réticence dolosive est étroitement liée à la reconnaissance d'une obligation d'information à la charge du contractant. Il conviendra donc dans chaque cas de rechercher sur qui pesait la charge de l'information : était-ce au contractant bénéficiaire de l'erreur d'informer l'autre, ou était-ce à la victime de se renseigner sur les éléments du contrat qui étaient importants pour elle ? Comme on l'a vu précédemment, une obligation d'information sera en général plus facilement reconnue à la charge des contractants professionnels confrontés à des profanes. Par exemple, si, moi qui suis un simple particulier amateur d'art mais pas expert, j'achète un tableau dans

505 Voy. déjà Trib. Luxembourg, 24 juin 1959, *Pas.*, 17, p. 495.

506 Voy. p. ex. : Cass. fr. (1re civ.), 13 mai 2003, nº 01-11511 à propos du silence gardé par un banquier bénéficiaire d'un cautionnement sur la situation financière du débiteur principal (solution non reprise au Luxembourg).

507 Cass., 13 juin 2013, nº 47/13, *Pas.*, 2014, p. 768 et obs P. ANCEL, p. 739.

508 Cf. la rédaction de l'article 5.35 du Code civil belge : « Une manœuvre peut consister en une rétention intentionnelle d'informations dont on dispose et que l'on devait communiquer en vertu de l'article 5.16. »

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

une galerie d'art, je suis fondé à attendre de mon vendeur qu'il me renseigne exactement sur ce qu'il sait de ce tableau ; à l'inverse, si c'est moi qui vends à la galerie un tableau que je tiens de mes ancêtres, ce n'est pas à moi de dire (même si je le sais) qu'il y a un doute sur l'attribution du tableau à tel peintre célèbre. Mais il n'y a pas là une règle absolue, et il ne faudrait surtout pas retenir que tous les contractants professionnels sont tenus d'informer leur contractant profane sur tous les éléments du contrat, et qu'à l'inverse un profane qui connaît des éléments importants que l'autre ignore n'est jamais tenu de les lui révéler. Ainsi la jurisprudence luxembourgeoise considère-t-elle, contrairement à la jurisprudence française, que la banque qui demande un cautionnement n'est pas en principe tenue d'informer la caution de la situation financière du débiteur garanti[509]. C'est, dans tous les cas, à la caution de se renseigner. Il n'y aurait donc dol que si la banque avait communiqué des éléments erronés sur cette situation financière.

De ce que la réticence dolosive est liée à l'existence d'une obligation d'information, le nouvel article 1137 du Code civil français déduit que la réticence dolosive n'est pas constituée lorsque le contractant s'est contenté de garder le silence sur la valeur de la chose ou de la prestation objet du contrat. C'est la conséquence de l'exclusion par l'article 1112-1 de toute obligation d'information sur la valeur. Il n'est pas sûr que cette solution rigoureuse doive être transposée en droit luxembourgeois[510].

Il n'est cependant pas suffisant, pour caractériser la réticence dolosive, que celui qui s'est tu ait été tenu d'une obligation d'information. Il faut encore qu'il se soit tu volontairement, dans le but de tromper l'autre. C'est que, comme nous allons le voir, la notion de manœuvres dolosives n'implique pas seulement un élément matériel, mais aussi un élément intentionnel.

b. *Élément intentionnel*

243. Intention de tromper. Le dol est un comportement malhonnête, déloyal. Aussi bien ne peut-il y avoir dol que si le contractant a agi, ou s'est tu, dans le but de tromper l'autre. Cette intention de tromper ne fait généralement aucune difficulté lorsqu'il y a eu une mise en scène ou des mensonges. Elle est souvent moins évidente

[509] Cour d'appel, 14 mars 2001, n° 21151. Voy. encore Cour d'appel, 30 mars 2021, n^{os} CAL-2019-00586 et CAL-2019-00715.

[510] Voy. *infra*, n° 248.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

lorsque le contractant s'est contenté de se taire, alors même qu'il était tenu d'une obligation d'information. Il a pu le faire par négligence, parce qu'il n'a pas pensé à délivrer l'information. Il a pu le faire aussi parce qu'il a pensé que l'information n'était pas importante pour son cocontractant. Un tel défaut d'information ne procédant pas de l'intention de tromper n'est pas un dol. Cette solution, aujourd'hui reprise par les nouveaux textes français et belge, est clairement affirmée par la Cour d'appel du Luxembourg, qui se réfère explicitement à un arrêt de la Cour de cassation française de 2005[511] : « si le dol, délit civil, peut résulter d'un simple silence, il faut cependant pour qu'il entraîne un vice du consentement, qu'il repose sur une faute intentionnelle, que l'auteur des manœuvres, mensonges ou réticence, ait agi intentionnellement pour tromper le contractant. Le manquement à une obligation précontractuelle d'information, manquement reproché par l'appelant à la banque, ne suffit pas à caractériser la réticence dolosive si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement »[512]. La Cour d'appel a par ailleurs précisé que « l'intention requise n'est pas celle de causer un préjudice, mais celle de tromper, en suscitant l'erreur ou en profitant de celle-ci »[513]. En l'absence d'une telle intention, s'il y a manquement à une obligation d'information jurisprudentielle ou légale, le contractant qui n'a pas délivré l'information requise n'en sera pas moins sanctionné par des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a (involontairement) causé à l'autre, et, éventuellement, si cela est prévu par la loi, par une amende pénale. Mais l'erreur consécutive à cette absence d'information sera alors considérée comme une erreur spontanée, relevant de l'article 1110 du Code civil, et elle n'entraînera la nullité du contrat que si elle porte sur la substance ou sur la personne.

2) *L'auteur des manœuvres*

244. Principe : les manœuvres doivent émaner du cocontractant. Il n'y a dol, selon l'alinéa 1er de l'article 1116 du Code civil que si les manœuvres ayant déterminé le consentement ont été « pratiquées par l'autre partie ». Cette exigence, reprise fidèlement par la jurisprudence luxembourgeoise[514], est dans la logique de

511 Cass. fr. (comm.), 28 juin 2005, *RTD civ.*, 2005, p. 591.

512 Cour d'appel, 10 janvier 2007, *Pas.*, 33, p. 491.

513 Cour d'appel, 17 octobre 2018, n° 44575 ; Cour d'appel, 1er juillet 2020, n° CAL-2019-01175.

514 Voy. p. ex. : Cour d'appel, 13 janvier 1998, *Pas.*, 30, p. 465 ; Cour d'appel, 6 mars 2019, n° 45274

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la distinction du dol et de l'erreur de l'article 1110 du Code civil. Ce qui justifie que le dol soit soumis à un régime différent de celui de l'erreur, c'est le souci de sanctionner le cocontractant, qui, en raison de son comportement malhonnête, devra supporter le risque de l'erreur qu'il a provoquée de manière beaucoup plus large que s'il n'y était pour rien. Or il n'y a aucune raison de raisonner ainsi, et de sanctionner le cocontractant, si l'erreur a été provoquée par les manœuvres d'un tiers, sans que ce contractant y soit pour quelque chose. Dans un tel cas, tout doit se passer, à son égard, comme si l'erreur avait été spontanée, et elle ne sera retenue comme cause de nullité que dans les conditions restrictives posées par l'article 1110 du Code civil (donc si elle porte sur la substance ou sur la personne).

La jurisprudence française fait une application intéressante de la solution de l'article 1116 du Code civil quant à l'auteur des manœuvres à propos du contrat de cautionnement, lorsque la personne qui s'est portée caution s'est trompée sur la situation financière du débiteur (ce qui, en soi, n'est pas considéré comme une erreur sur la substance au sens de l'article 1110 du Code civil). Si cette erreur a été provoquée par des manœuvres du débiteur lui-même (qui a par exemple communiqué à la caution une comptabilité falsifiée), ce ne sera pas un dol, car le contrat de cautionnement est conclu entre le débiteur et le créancier, le débiteur n'y est pas partie[515].

245. Limites : tiers assimilés au contractant. Le fondement de la solution en dicte les limites. Le dol sera constitué si le cocontractant a été le complice du tiers auteur des manœuvres, *a fortiori* s'il a été l'instigateur de celles-ci[516] : si par exemple c'est un tiers qui a fourni de fausses pièces comptables ou une fausse expertise, mais qu'il l'a fait à la demande du cocontractant, celui-ci pourra bien sûr être considéré comme auteur d'un dol. Cette solution est aujourd'hui consacrée par le nouvel article 1138 du Code civil français, selon lequel le dol est constitué « lorsqu'il émane d'un tiers de connivence ». Il est également admis traditionnellement que le cocontractant doit être reconnu comme l'auteur des manœuvres dolosives commises par son préposé ou par son représentant[517], auquel la jurisprudence luxembourgeoise refuse cependant d'assimiler un

[515] Cass. fr. (2e civ.), 27 juin 1973, *D.*, 1973, p. 733, note P. MALAURIE. En droit français, cette solution est compensée par le fait que la jurisprudence fait peser sur le créancier, lorsque c'est une banque, une obligation d'information sur la situation financière du débiteur – ce qui amène souvent à annuler le cautionnement pour dol par réticence du créancier, partie à la convention. Mais cette jurisprudence, on l'a vu, n'a pas cours au Luxembourg.

[516] Cour d'appel, 13 janvier 1998, préc.

[517] Cour d'appel, 13 janvier 1998, préc. ; Cour d'appel, 6 mars 2019, n° 45274.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

simple intermédiaire non pourvu de pouvoirs de représentation[518]. Le nouvel article 1137 du Code civil français, consacrant les solutions jurisprudentielles antérieures, adopte à cet égard une position très extensive, puisqu'il assimile au représentant et au préposé le gérant d'affaires et le porte-fort du cocontractant, alors même que ces personnes n'ont aucun pouvoir de représentation[519]. La Cour de cassation française a cependant précisé que, si le dol émane d'un tiers assimilé au cocontractant, il entraîne la nullité du contrat, mais non la responsabilité personnelle de ce cocontractant, sauf s'il avait été complice du tiers[520]. À la différence du texte français, l'article 5.33 du nouveau Code civil belge ne procède pas par énumération des tiers assimilés au contractant, il dispose que « [l]e dol, la violence et l'abus de circonstances émanant du complice du cocontractant ou d'une personne dont ce dernier doit répondre sont assimilés à ceux du cocontractant ».

246. Limite : actes unilatéraux. Il est traditionnellement admis que la solution de l'article 1116 du Code civil ne s'applique pas si l'acte passé sous l'empire d'une erreur est un acte unilatéral. Par hypothèse, dans un tel acte, il n'y a pas de cocontractant[521], et on ne pourrait donc jamais les annuler pour dol si on appliquait à la lettre l'article 1116 du Code civil. C'est pourquoi on admettra qu'il y a dol dès lors que les manœuvres émanent de la personne qui a bénéficié de l'acte : l'hypothèse typique est celle du testament qui a été fait en faveur d'une personne à la suite de manœuvres émanant de celle-ci. Par une sorte de glissement, il est également affirmé par la doctrine française que le dol émanant d'un tiers peut être pris en considération dans le cas d'une donation[522], alors même que celle-ci est un contrat unilatéral, non un acte juridique unilatéral. La solution, qui n'est pas attestée par la jurisprudence récente, serait justifiée par le souci d'une protection accrue du consentement dans les libéralités, où une partie se dépouille sans contrepartie.

B) *L'erreur provoquée par le dol*

247. Nécessité d'une erreur. Historiquement, le dol était moins conçu comme un vice du consentement que comme un délit civil, c'est-à-dire comme un comportement répréhensible, contraire à la bonne foi, qui était d'abord sanctionné par des dommages et intérêts, et qui n'est devenu que progressivement une cause de nullité

518 Il en va ainsi notamment des agents immobiliers : Cour d'appel, 22 novembre 2017, *Pas.*, 39, p. 35 ; Cour d'appel, 6 mars 2019, préc. ; Trib. Luxembourg, 14 juillet 2023, n° TAL-2021-08344 ; Cour d'appel, 14 décembre 2023, n° CAL-2020-00910.

519 Sur la gestion d'affaires, voy. *supra*, n° 71 ; sur le porte-fort, voy. *infra*, n° 300.

520 Cass. fr., (ch. mixte), 29 octobre 2021, n° 19_18.470.

521 Rappelons qu'il ne faut pas confondre les actes unilatéraux (comme le testament) avec les contrats unilatéraux, qui sont des contrats n'emportant d'obligation que pour une seule partie (p. ex. le cautionnement).

522 Voy., p. ex., TERRE, SIMLER, LEQUETTE, CHENEDE 2023, n° 303.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

du contrat distincte de l'erreur[523]. C'est pourquoi la définition de l'article 1116 du Code civil met l'accent sur les « manœuvres » ayant amené une personne à s'engager, sans dire précisément de quelle manière ces manœuvres ont pesé sur le consentement. Il résulte cependant d'une longue tradition historique que ces manœuvres doivent consister dans une « tromperie », d'où il résulte qu'elles doivent avoir provoqué une erreur chez le cocontractant. Cette exigence apparaît désormais de manière explicite dans l'article 5.35 du Code civil belge selon lequel « le dol n'est une cause de nullité que lorsqu'une partie a été trompée par les manœuvres… », tandis que la nécessité d'une erreur n'apparaît toujours pas dans le nouvel article 1137 du Code civil français, qui définit le dol comme « le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ». Cette omission ne devrait pas modifier l'interprétation traditionnelle. En dépit de cette interprétation, l'article 1116 du Code civil ne fait pas pour autant double emploi avec l'article 1110 du Code civil. En effet, le souci de sanctionner le cocontractant auteur du dol va amener à retenir l'erreur provoquée comme cause de nullité beaucoup plus largement que si elle avait été spontanée, à la fois quant à son objet (**1**) et quant aux caractères qu'elle doit présenter (**2**).

Dans les années 1970, en droit français, un certain courant doctrinal et jurisprudentiel avait tenté de remettre en cause cette tradition, en admettant la nullité pour dol dans des hypothèses où un contractant avait abusé de la faiblesse de son cocontractant, sans provoquer à proprement parler une erreur[524]. La notion de dol, ainsi étendue, aurait permis de sanctionner des comportements de professionnels profitant de certaines situations (démarchage à domicile notamment) pour extorquer aux consommateurs des contrats non véritablement voulus. Cette conception a cependant été assez vite condamnée par la Cour de cassation française[525], et elle est du reste devenue inutile avec le développement, en droit de la consommation de techniques spécifiques de protection des consommateurs (notamment le droit de rétractation)[526]. Au Luxembourg, les hypothèses où un contractant abuse de la faiblesse de l'autre pour lui extorquer un contrat désavantageux sont aujourd'hui prises en compte sur le terrain de la lésion, par l'article 1118 du Code civil.

523 Sur l'évolution historique du dol DEROUSSIN, *Histoire du droit des obligations*, pp. 507 et s.

524 Un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 30 janvier 1970 (*D.*, 1970, p. 297) est particulièrement représentatif de cette tendance. Cet arrêt annule pour dol une donation qu'une vieille dame avait consentie à l'issue d'une nuit où les donataires avaient fait pression sur elle.

525 Cass. fr. (1re civ.), 10 juillet 1995, n° 93-17388.

526 Sur ces techniques, voy. *infra*, n° 274.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

1) *Objet de l'erreur provoquée par un dol*

248. Objet indifférent. Là est la principale différence quant aux conditions de l'annulation entre l'erreur et le dol. Alors que, comme nous l'avons vu précédemment, l'erreur spontanée n'est une cause de nullité que lorsqu'elle porte sur la substance ou sur la personne dans les contrats *intuitu personae*, elle l'est tout aussi bien, dès lors qu'elle a été provoquée, si elle porte sur les motifs personnels du contractant ou sur la valeur de l'objet du contrat[527]. Si, par exemple, j'ai sciemment délivré à mon acheteur des informations fausses lui faisant croire que son acquisition allait lui permettre de réaliser la défiscalisation qu'il recherche, il pourra demander la nullité du contrat alors même que ces motifs ne constituent pas une qualité du bien acheté. Si, pour convaincre l'acheteur de mon immeuble que le prix que je lui propose est le « juste prix », je lui communique des documents falsifiés faisant état d'une moyenne équivalente des prix dans le voisinage (alors que celle-ci est en réalité beaucoup plus basse), le contrat pourra être annulé pour dol (alors qu'il ne pourrait pas l'être si j'avais laissé l'acheteur se documenter lui-même sur les prix habituellement pratiqués)[528]. On voit ici clairement que le comportement déloyal d'un contractant renverse la charge des risques d'une erreur qui, en principe supportée par le contractant victime qui se trompe tout seul, passe sur la tête de l'auteur du dol.

L'affirmation traditionnelle selon laquelle le dol rend indifférent l'objet de l'erreur doit cependant être nuancée lorsque l'erreur porte sur la valeur du bien ou du service objet du contrat. Le contrat pourra certainement être annulé dans un tel cas si l'erreur sur la valeur a été provoquée par un comportement positif du cocontractant, c'est-à-dire par des artifices ou des mensonges : ainsi dans l'exemple précédemment cité de faux documents produits pour tromper un acheteur sur le prix habituel des biens immobiliers dans le voisinage. Il en va autrement, cependant, si le dol consiste dans une simple réticence du contractant sur la valeur réelle du bien qu'il vend ou qu'il achète. Comme on l'a vu, en droit français, le nouvel article 1112-1 du Code civil, élargissant le domaine de la jurisprudence *Baldus*, exclut par principe toute obligation d'information

527 Voy. pour des rappel récent de cette solution : Trib. Luxembourg, 25 octobre 2023, n^{os} TAL-2019-05900 et TAL-2021-01434 ; Trib. Diekirch, 19 décembre 2023, n° TAD-2022-00720.

528 Voy. à propos d'une cession d'actions Cour d'appel, 5 novembre 2014, n° 35227, qui admet implicitement qu'un dol sur la valeur pourrait être une cause de nullité, mais qui estime qu'un tel dol n'est pas prouvé en l'espèce.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

précontractuelle sur la valeur du bien ou de la prestation objet du contrat[529]. Il en résulte que l'absence d'information sur la valeur ne saurait jamais constituer une réticence dolosive ; pour qu'elle devienne une cause de nullité, l'erreur sur la valeur doit avoir été causée par des manœuvres ou des mensonges. Telle est la solution posée par le nouvel article 1137 du Code civil français, selon lequel « ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». Si cette solution paraît admissible en principe, on peut se demander si elle ne devrait pas céder dans le cas d'une déloyauté particulièrement évidente du contractant qui a tu l'information. C'est un point sur lequel les auteurs de la réforme en préparation au Luxembourg auront certainement à se prononcer. En toute hypothèse, en droit luxembourgeois, les cas où une erreur sur la valeur est provoquée par des manœuvres du cocontractant peuvent aussi être traitées sous l'angle de l'article 1118 du Code civil.

2) *Caractères de l'erreur provoquée par un dol*

249. L'erreur provoquée par le dol doit être déterminante. Commune à tous les vices du consentement, l'exigence du caractère déterminant du dol est exprimée de manière particulièrement nette par l'article 1116 du Code civil, selon lequel les manœuvres doivent être telles que « sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Le texte consacre ici implicitement une distinction traditionnelle entre le dol principal – celui sans lequel la victime n'aurait pas contracté du tout – et le dol incident – celui qui n'a pas déterminé le principe même de la conclusion du contrat, mais simplement les conditions auxquelles il a été passé (s'il n'avait pas été trompé, le contractant aurait quand même passé le contrat, mais il aurait payé moins cher). Historiquement, il était admis que, dans ce second cas, la victime du dol ne pouvait pas faire annuler le contrat, mais simplement obtenir des dommages et intérêts pour compenser la différence de valeur. C'est cette conception que semble consacrer la formule de l'article 1116 du Code civil. Bien que parfois critiquée en raison de son caractère artificiel, la distinction s'est fermement maintenue dans la jurisprudence belge, où le dol incident n'est sanctionné que par une action en dommages et intérêts[530] (laquelle, en Belgique, se prescrit plus rapidement que l'action en nullité du

529 Voy. *supra*, n° 201.

530 Cass. be., 6 mai 1971, *Pas. be.*, 1971, I, p. 814 ; Bruxelles, 14 mars 2008, *R.G.D.C.*, 2009, p. 365.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

contrat). Et cette solution semble confortée à la suite de la réforme belge du droit des obligations, dans la mesure où l'article 5.34 ne prévoit la nullité pour erreur que si celle-ci a déterminé la partie « à conclure le contrat ». En droit français, en revanche, la Cour de cassation, qui avait un temps consacré la même solution, a semblé ensuite vouloir l'abandonner[531], et le nouvel article 1130 du Code civil pose désormais clairement que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté *ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes* »[532]. La jurisprudence luxembourgeoise ne semble pas clairement fixée. Si la Cour d'appel a rappelé en 2023 la solution traditionnelle sanctionnant le dol incident par l'allocation de dommages et intérêts[533], un jugement récent du tribunal de Diekirch semble vouloir se rallier à la position française actuelle[534]. Ces décisions sont cependant peu caractéristiques, dans la mesure où, dans les deux affaires, la victime de la tromperie se contentait de demander des dommages et intérêts. On peut remarquer que, dans le cas voisin de la lésion qualifiée (abus de faiblesse ayant provoqué une disproportion entre les prestations contractuelles), l'article 1118 du Code civil laisse à la victime le choix entre l'annulation du contrat et sa révision, sans qu'il y ait à se demander si, en l'absence d'abus, cette victime aurait ou non passé le contrat ou l'aurait seulement passé à des conditions différentes. Il serait sans doute opportun d'adopter une solution analogue en cas de dol incident, en laissant à la victime le soin de juger si elle veut faire tomber le contrat, ou si elle veut le garder en compensant le déséquilibre par des dommages et intérêts.

250. L'erreur provoquée par un dol est nécessairement excusable. Nous avons vu précédemment que, sur le terrain de l'article 1110 du Code civil, le caractère inexcusable de l'erreur faisait obstacle à l'annulation du contrat. Lorsque l'erreur a été provoquée par des manœuvres dolosives, il a toujours été admis, de manière bien compréhensible, que de telles manœuvres conduisaient à admettre plus facilement le caractère excusable de l'erreur. Mais il

531 Cass. fr. (3e civ.), 22 juin 2005, n° 04-10415, *R.D.C.*, 2005, p. 1025, obs. STOFFEL-MUNCK.

532 Voy. déjà dans ce sens : Projet Catala, art. 1111-1 ; Projet Catala, art. 36 ; Projet de la Chancellerie de 2008, art. 51, qui reprennent tous la même formule, inspirée d'un arrêt français de 1913.

533 Cour d'appel, 29 juin 2023, n° CAL-2022-00386. dans le même sens Trib. Luxembourg, 15 décembre 2023, n° TAL-2018-08461.

534 Trib. Diekirch, 19 décembre 2023, n° TAD-2022-00720.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

n'y avait là rien d'automatique, et un arrêt de la Cour d'appel du Luxembourg avait jugé, en 1970, que « le dol n'est une cause de nullité du contrat que si les mensonges employés par un contractant étaient tels que son cocontractant ne pouvait pas vérifier facilement les allégations mensongères, lesquelles ont ainsi provoqué chez lui une erreur invincible et partant excusable »[535]. Cependant, un arrêt de la Cour de cassation française du 21 février 2001 est allé plus loin en posant que « une réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée », et la solution a été ultérieurement reprise par un arrêt de la Cour de cassation du Luxembourg en date du 13 juin 2013, qui la rattache à l'obligation de contracter de bonne foi[536]. Dans cette affaire le vendeur d'une voiture avait omis d'informer son acquéreur d'un vice important concernant le kilométrage de la voiture, et ce défaut d'information avait été considéré par la Cour d'appel comme constituant une réticence dolosive. La Cour d'appel n'en avait pas moins refusé d'annuler la vente, au motif que l'acheteur était lui-même un revendeur professionnel, et qu'il aurait dû se renseigner sur le kilométrage réel du véhicule, son erreur étant dès lors inexcusable. Suivant le pourvoi de l'acheteur qui invoquait la jurisprudence française, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au motif que « le vendeur doit contracter de bonne foi ; que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ». Cette solution est aujourd'hui explicitement consacrée par l'article 1139 du Code civil français, et par l'article 5.35 du nouveau Code civil belge.

La solution peut surprendre, et elle a suscité diverses interrogations dans la doctrine française. Elle s'explique si on considère les liens qui existent entre la notion de réticence dolosive et la reconnaissance d'une obligation d'information à la charge du contractant. Si on admet, dans l'affaire jugée au Luxembourg, que le silence gardé par le vendeur sur le kilométrage réel de la voiture est une réticence dolosive, c'est parce qu'on considère qu'il avait l'obligation d'informer l'acheteur sur cet élément ; cela revient à dire que ce n'était pas à l'acheteur de se renseigner, ce qui exclut que son erreur puisse être regardée comme inexcusable. La solution est donc moins la conséquence d'un lien de causalité entre la réticence dolosive et le caractère excusable de l'erreur que le résultat d'une appréciation globale de la charge de l'information pesant sur les parties, qui permet de conclure à la fois à l'existence d'une réticence dolosive et au caractère excusable de l'erreur[537].

535 Cour d'appel, 16 juin 1970, *Pas.*, 21, p. 362.

536 Cass., 13 juin 2013, n° 47/13. *Pas.*, 36, p. 768 et obs. P. Ancel, p. 739.

537 Voy., en ce sens, Flour, Aubert, Savaux 2022, n° 349.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§ 3. La violence

251. Définition. Peu diserts sur l'erreur et le dol, les rédacteurs du Code civil n'ont pas consacré moins de 5 articles à la violence, les articles 1111 à 1115 du Code, ce qui n'est pas à la mesure de son importance pratique relativement limitée. Mais, à une époque où la liberté contractuelle était portée au pinacle, la violence apparaissait sans doute comme le plus grave des vices du consentement. À la différence de l'erreur et du dol, la violence affecte en effet la liberté du consentement au contrat : la victime de la violence contracte parce qu'elle y est contrainte par des menaces. Par exemple, pour vous contraindre à me vendre votre magasin, qui fait concurrence au mien, je n'hésite pas à vous envoyer des hommes de main qui vous menacent de mort si vous n'y consentez pas[538]. Comme le dol, la violence apparaît comme un vice bicéphale : selon une formule de la jurisprudence luxembourgeoise « c'est la crainte qu'elle inspire qui vicie le consentement. Cependant à la différence de l'erreur, la crainte n'est sanctionnée qu'à travers la violence qui l'a provoquée »[539]. Les conditions de l'annulation du contrat pour violence se situent dès lors tant du côté de celui qui en a été victime – lorsqu'on considère l'importance de la crainte qui l'a poussée à contracter (**A**) – que du côté de celui qui, par ses menaces, a provoqué cette crainte (**B**).

A) *La crainte provoquée par la violence*

252. Objet et gravité. Pour savoir si le contrat doit être annulé pour violence, il faut rechercher si les menaces ont provoqué chez le contractant une crainte suffisante pour annihiler sa liberté de décision. Il peut s'agir, selon l'article 1112 du Code civil, aussi bien de menaces sur la personne (c'est l'exemple de départ) que de menaces sur la « fortune » (entendez, plus généralement, les biens) du contractant (je menace de faire sauter votre magasin si vous ne me le vendez pas). Et l'article 1113 du Code civil précise qu'il faut prendre en considération non seulement les menaces affectant le contractant lui-même mais aussi celles qui sont exercées à l'encontre des membres de sa famille : le texte ne vise que les menaces sur le conjoint, les ascendants ou les descendants, mais cette énumération

[538] Ce qui apparaît être un exemple d'école sous les cieux luxembourgeois, semble malheureusement être une pratique assez répandue dans les régions d'Europe où sévit la mafia.

[539] Trib. Luxembourg, 24 février 2022, n° TAL-2020-09028.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ne doit sans doute pas être comprise comme limitative. De même, bien que les textes ne le précisent pas, il faut admettre que la crainte qui pousse à passer le contrat peut concerner aussi bien les aspects moraux de la personnalité que la vie ou l'intégrité physique de la personne : si, pour vous amener à contracter, je menace de révéler votre orientation sexuelle que vous voulez tenir secrète, il peut y avoir violence aussi bien que si je vous menace de mort. Ce qui est important, c'est que les menaces, quelle qu'aient été leur objet ou leur destinataire, aient été « de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'un "mal considérable et présent" ». Ici encore, il ne faut pas prendre le texte à la lettre : un mal « présent », ce n'est pas nécessairement un événement malheureux qui doit se produire immédiatement (comme dans le cas où on contracte avec un pistolet sur la tête), c'est un mal que l'auteur de la violence présente comme devant se produire très prochainement. Pour savoir si les menaces ont été suffisamment impressionnantes, le texte renvoie à l'impression qu'elles ont pu faire sur une « personne raisonnable », ce qui semble appeler une appréciation *in abstracto*. Mais l'alinéa 2 de l'article 1112 du Code civil tempère cette formule en disposant qu'on doit avoir égard « à l'âge, au sexe et à la condition des personnes ». En pratique, lorsque des violences sont exercées, on tiendra compte de toutes les caractéristiques physiques et psychologiques de la personne, pour savoir si elle a pu réellement se laisser impressionner par les menaces. L'appréciation se fait donc plutôt *in concreto*.[540] Les nouveaux textes français et belge évitent cette contradiction dans les critères, et adoptent une formulation plus générale qui laisse au juge l'entier pouvoir d'apprécier s'il y a violence ou non. L'article 1140 du Code civil français dispose ainsi qu'« [i]l y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable », et l'article 5.36 du nouveau Code civil belge parle d'une contrainte qui fait craindre au contractant « une atteinte considérable à l'intégrité physique ou morale ou aux biens de cette partie ou de ses proches ». On notera par ailleurs que les textes sur

[540] Pour un exemple de cette appréciation *in concreto* : Cour d'appel, 7 décembre 2006, *Pas.*, 33, p. 376 (personne menaçant un non-voyant de ne plus lui apporter son aide s'il ne consentait pas à emprunter de l'argent à son profit ; caractère déterminant non admis car le non-voyant, exerçant normalement un métier, « aurait à tout moment pu avoir recours à un ensemble de mesures dont bénéficient les personnes souffrant d'un certain degré de dépendance ») ; Cour d'appel, 3 décembre 2020, n° CAL-2019-00968 soulignant qu'il en résulte « une individualisation judiciaire de la violence »

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la violence ne distinguent pas, comme c'est le cas en matière de dol, selon que les menaces ont déterminé la conclusion même du contrat (si vous ne m'aviez pas menacé, je ne vous aurais pas vendu mon bien), ou seulement ses conditions (je vous l'aurais vendu, mais moins cher). Dans les deux cas, la victime de la violence pourra demander la nullité du contrat[541], éventuellement assortie de dommages et intérêts.

B) *Les menaces constitutives de violence*

253. Comportements admissibles et non admissibles. Comme pour tous les vices du consentement, les règles relatives à la nullité pour violence ne reposent pas uniquement sur des considérations psychologiques : il ne suffit pas, pour faire annuler un contrat, de montrer qu'on n'a pas eu le choix, qu'on a été contraint de le passer parce qu'autrement on aurait été exposé à un « mal considérable et présent ». Il faut encore établir que cette absence de liberté a été causée par un comportement socialement répréhensible du cocontractant ou d'un tiers. Et, aussi étonnant que cela puisse paraître, toutes les menaces qui peuvent être exercées sur une personne pour l'amener à passer un contrat ne sont pas nécessairement répréhensibles. On le voit d'abord si on considère les conditions générales que doivent remplir les menaces pour constituer le vice de violence (**1**). On le voit surtout à propos du problème de la violence économique, qui constitue aujourd'hui l'aspect le plus actuel de la matière (**2**).

1) *Conditions générales*

254. Nature des menaces. Les articles 1111 à 1115 du Code civil, qui traitent de l'objet et de la gravité de la crainte que les menaces ont provoquée chez le contractant victime, ne disent rien de la nature de ces menaces. On distingue traditionnellement la violence physique et la violence morale. La première (je vous contrains à signer en pointant une arme sur vous) est exceptionnelle. Le plus souvent, la violence résulte de paroles qui menacent la personne ou ses proches de porter atteinte à sa vie, à son intégrité corporelle, à sa réputation, à ses biens, etc. En toute hypothèse, la victime devra prouver l'existence des menaces, ce qui ne sera pas toujours

[541] Comme pour tous les vices du consentement, il s'agit d'une nullité relative (voy. *supra*, n° 219). L'article 1115 prévoit explicitement que le vice de violence peut être couvert par la confirmation, c'est-à-dire la renonciation à agir en nullité (voy. *infra*, n°s 454 et s.).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

facile : en témoigne un arrêt de la Cour d'appel où une femme alléguait que son compagnon lui aurait extorqué des reconnaissances de dette en exerçant sur elle des violences physiques, mais sans pouvoir en apporter la preuve[542]. Aussi bien, les cas où la nullité pour violence est admise dans la jurisprudence luxembourgeoise sont-ils exceptionnels.

255. Origine des menaces. L'article 1111 du Code civil précise d'emblée que les menaces constitutives de violence peuvent émaner aussi bien d'un tiers que du cocontractant. Cette solution, qui est un héritage du droit romain, est contraire à celle qui est posée par l'article 1116 du Code civil en matière de dol, qui n'est constitué que si les manœuvres dolosives émanent du cocontractant. La différence est plus limitée qu'il n'y paraît si on considère que le dol de l'article 1116 du Code civil vient doubler un autre vice du consentement, l'erreur : si les manœuvres émanent d'un tiers, le contrat n'en pourra pas moins être annulé si l'erreur porte sur la substance ou sur la personne. Les atteintes à la liberté du consentement, elles, ne sont appréhendées que par les articles sur la violence, et il aurait sans doute été trop difficile de distinguer celles qui devraient être sanctionnées seulement si elles étaient dues au fait du cocontractant, et celles qui pourraient l'être quelle s'en soit l'origine. La prise en compte de l'atteinte au consentement l'a donc emporté ici sur l'idée de sanction du cocontractant. On notera cependant que le nouveau texte belge s'écarte de cette position traditionnelle puisqu'il ne retient la violence que si la contrainte émane du cocontractant.

On ne va pas, cependant, jusqu'au bout de cette logique, car on exige, au moins, pour que le contrat puisse être annulé que les menaces consistent dans un comportement positif d'une personne, et qu'elles ne proviennent pas d'un événement extérieur. En principe, un contrat passé sous l'empire d'un état de nécessité ne peut pas être annulé pour vice de violence. Si, par exemple, je tombe en panne sur une route de montagne, la nuit, par la neige, je vais être obligé de me faire dépanner au plus vite, à peine de mourir de froid si je reste sur place. Je me verrai contraint de signer un contrat de dépannage au tarif élevé des dépannages de nuit. Je ne pourrai pas pour autant le faire annuler, car la menace qui m'amené à contracter dans ces conditions n'émane pas d'une personne déterminée, mais d'événements extérieurs indépendants de

[542] Cour d'appel, 8 mai 2014, n° 39487.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

toute volonté humaine. Il pourrait en aller autrement cependant si le dépanneur avait profité de ma situation de détresse pour m'extorquer un contrat à un prix exorbitant, beaucoup plus élevé que les tarifs habituellement pratiqués pour ce genre de dépannage. On pourrait alors considérer que le contrat a été passé sous l'empire d'une menace émanant du cocontractant lui-même (qui m'a menacé de me laisser mourir sur place si je ne payais pas le prix fort), donc d'une violence au sens des articles 1111 et suivants du Code civil[543]. Pourtant, que le contrat ait été passé à un prix normal, ou à un prix trop élevé, mon consentement a été tout autant vicié (si j'avais pu l'éviter, je n'aurais pas passé le contrat). La différence entre les deux cas – que nous retrouverons dans le cas plus général d'un contrat passé sous l'empire des nécessités économiques – est dans le comportement du cocontractant, légitime dans le premier cas, illégitime dans le second. On débouche alors sur une autre condition du vice de violence.

256. Illégitimité des menaces. La jurisprudence, en France et en Belgique, admettait traditionnellement que certaines menaces qui pèsent sur la volonté de contracter d'une personne sont légitimes, et ne sont pas de nature à entraîner la nullité du contrat[544]. Cette solution, aujourd'hui consacrée par l'article 1141 du Code civil français et par l'article 5.36 du nouveau Code civil belge[545], est également admise par la jurisprudence luxembourgeoise : un arrêt de la Cour d'appel relève ainsi que « pour constituer une violence au sens des articles 1111 et 1112 du Code civil, la menace doit être illégitime dans le sens où cette violence ne doit pas être légale, comme par exemple, menacer quelqu'un de porter atteinte à son intégrité physique s'il ne signe pas un contrat. En revanche, une menace légitime et légale, telle la menace d'assigner en justice, qui est une voie de droit est admise »[546]. On voit bien là, une nouvelle fois, que la problématique des vices du consentement ne dépend pas exclusivement de la plus ou moins grande gravité du vice, elle

543 En droit luxembourgeois, le contrat serait plutôt annulé sur le fondement de l'article 1118 du Code civil sanctionnant la « lésion qualifiée ». Voy *infra*, n°s 264 et s.

544 Pour la France, voy. déjà Cass. fr., 25 février 1879, *S.*, 1879, 1, p. 273. Pour la Belgique, Cass. be., 15 mai 2000, *Pas. be.*, 2000, p. 898.

545 « La violence n'est une cause de nullité que lorsqu'une partie conclut un contrat sous une contrainte illégitime de son cocontractant… »

546 Cour d'appel, Travail, 20 décembre 2018, n° 44974. Voy. déjà implicitement Cour d'appel, 10 juillet 2013, n° 38314 ; *J.T.L.*, 2014/2, n° 32, pp. 45-48 ; sur cet arrêt, voy. obs. P. ANCEL, *Pas.*, 2014, p. 740 et O. POELMANS, *D.A.O.R.*, 2014, p. 57.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

intègre aussi des considérations sur le comportement de celui qui a été à son origine. On voit parfois une trace de cette idée dans l'article 1114 du Code civil, selon lequel « la seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat »[547]. Ce texte, d'application extrêmement rare aujourd'hui, semble légitimer les pressions que les parents peuvent exercer sur leurs enfants pour les amener à réaliser certaines opérations. Cependant ce texte ne va pas jusqu'à légitimer des menaces effectives, puisqu'il exclut le cas où il y a eu des « violences exercées ». Dans le droit contemporain, l'illustration la plus caractéristique de l'idée de violence légitime se trouve dans la jurisprudence qui refuse d'annuler les contrats passés sous la menace de l'exercice de voies de droit – hypothèse aujourd'hui spécialement visée par l'article 1141 du Code civil français. Par exemple, un de mes créanciers, à qui je n'ai pas payé ma dette, me menace de saisir ma maison (ce qui est parfaitement dans son droit). Mais il me propose, pour éviter les inconvénients de cette saisie, de m'acheter ma maison, à un prix qui viendra se compenser avec ce que je lui dois. Dans un tel cas, je ne pourrai pas faire annuler la vente au motif que je ne l'ai consentie que pour échapper aux poursuites dont j'étais menacé. De même, la transaction qu'un employeur fait signer à un salarié en le menaçant, à défaut, de le licencier pour faute grave, n'est pas en principe annulable pour violence[548]. La légitimité de la violence ne sera cependant admise dans un tel cas qu'à deux conditions : il faut que les menaces aient été légitimes à la fois quant aux moyens utilisés et quant au but poursuivi[549]. Légitimité quant aux moyens : le contrat pourra être annulé si mon créancier m'a menacé de voies de droit inexistantes (en me faisant croire qu'il pourrait me saisir alors qu'il n'en avait pas le droit)[550], ou si l'employeur menace le salarié d'un licenciement injustifié. Légitimité quant au but : même si le créancier a effectivement le droit de me poursuivre, il ne faut pas qu'il se serve de cette menace pour m'extorquer un contrat excessivement avantageux pour lui (par exemple, en m'achetant ma maison pour une bouchée de pain, alors que la saisie aurait permis d'en tirer une somme beaucoup plus élevée). L'article 1141 du Code civil français

547 Flour, Aubert, Savaux 2022, n° 357 ; Wéry, n° 259 ; Poelmans, n° 66.

548 C'était l'hypothèse de Cour d'appel, 20 décembre 2018, préc.

549 Cass. fr. (1re civ.), 3 novembre 1959, *D.*, 1960, p. 187, note Holleaux.

550 Voy. déjà : Cour d'appel, 29 avril 1904, *Pas.*, 06, p. 477 (nullité de l'obligation contractée sous la menace de poursuites répressives imaginaires).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

exclut le caractère légitime de la violence « lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif ». On retrouve la même idée que celle qui est précédemment apparue à propos de l'exploitation abusive de l'état de nécessité (voir ci-dessus l'exemple du dépanneur)[551]. Et c'est la même idée que nous allons retrouver avec le problème très actuel de la « violence économique ».

2) *La « violence économique »*

257. Principe : la « violence économique » n'est pas une cause de nullité du contrat. De très nombreux contrats sont passés sous l'emprise des nécessités économiques. Je n'accepterais jamais de vendre la maison de campagne que je tiens de mes grands-parents si je pouvais supporter financièrement les coûts élevés de son entretien. Un étudiant n'accepterait jamais de louer un studio de 20 m^2 à Paris ou à Luxembourg pour 800 € par mois s'il n'y était pas contraint par l'état du marché immobilier dans ces villes. Un dirigeant social n'accepterait jamais de se porter caution, sur son patrimoine personnel, des dettes de sa société s'il ne savait que, à défaut d'un tel cautionnement, la banque ne ferait pas crédit à son entreprise, la condamnant à une mort certaine. Il est clair cependant que, dans une économie de marché, de tels contrats ne sauraient être annulés pour vice de violence, et qu'on ne saurait reprocher à l'acheteur de ma maison de campagne, au bailleur du studio, ou à la banque qui a obtenu le cautionnement d'avoir conclu des contrats passés sous l'emprise de telles nécessités : la conclusion de tels contrats n'est pas, en soi, illégitime. Les raisons en sont parfaitement exprimées par un arrêt de la Cour d'appel du Luxembourg, rendu précisément dans une affaire où un dirigeant social prétendait faire annuler pour violence un cautionnement qu'il avait donné à un fournisseur, qui, autrement, menaçait de ne plus accorder de crédit à sa société[552] : « la violence n'est pas établie par le seul état de dépendance économique d'une partie à l'égard de l'autre dès lors que celle-ci n'en profite pas pour imposer des conditions anormales […] Pour des raisons élémentaires de sécurité juridique, on ne peut, en effet, admettre l'anéantissement d'un contrat conclu sous la contrainte économique que si des conditions

[551] Et on peut faire la même remarque que pour cet autre exemple : en droit luxembourgeois, c'est plutôt sur le terrain de la lésion qualifiée (C. civ., art. 1118) que sur celui de la violence qu'un tel contrat disproportionné serait annulé.

[552] Cour d'appel, 10 juillet 2013, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

supplémentaires sont remplies, tant il est vrai que la conclusion d'un contrat s'inscrit souvent dans un rapport de forces […] La violence économique, qui est à apprécier *in concreto*, ne saurait ainsi être constituée uniquement par les difficultés économiques d'une entreprise ou résulter du seul usage par le fournisseur de sa force économique dans des rapports avec des dirigeants d'entreprise rompus aux affaires […] En matière commerciale, il n'est ni anormal ni illégitime pour un créancier de demander en vue de garantir ses droits l'engagement personnel du dirigeant de la personne morale, son cocontractant. Si (la société dans cette espèce) avait, selon toute évidence en raison de sa situation financière précaire, besoin d'une ouverture de crédit pour régler des factures de matériel nécessaire à son exploitation commerciale, il n'était nullement répréhensible en soi de la part de son cocontractant, soucieux de ses droits, de solliciter, à titre de garantie, l'engagement de l'administrateur qui, de par ses fonctions dans la société, est, comme il convient de le relever, quand-même une personne supposée avertie du fait de sa confrontation habituelle aux affaires »[553].

258. Limites : l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique du cocontractant. Le passage précité de l'arrêt, qui s'inspire explicitement de la jurisprudence française, laisse cependant entendre que, dans certains cas, la violence économique pourrait entraîner la nullité du contrat. Cette idée avait été pour la première fois admise par la Cour de cassation française dans un arrêt très remarqué du 30 mai 2000[554], posant que la contrainte économique ayant poussé la victime d'un sinistre à conclure une transaction désavantageuse avec un assureur pouvait constituer le vice de violence[555]. Par la suite, un arrêt de 2002 avait précisé dans quelles conditions – restrictives – une telle nullité pourrait être admise : ce ne peut être, dit la Cour de cassation que s'il y a eu « exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne »[556]. L'arrêt luxembourgeois de 2013 reprend et développe la même idée, en s'inspirant du

553 Voy. aussi Cour d'appel, 23 mars 2016, n° 42441.

554 Cass. fr. (1re civ.), 30 mai 2000, n° 98-15242.

555 L'arrêt ne se prononce pas explicitement en faveur de la nullité dans cette espèce. Il censure seulement l'arrêt d'appel qui avait refusé d'annuler la transaction pour lésion, sans rechercher si la contrainte économique ne constituait pas le vice de violence.

556 Cass. fr. (1re civ.), 3 avril 2002, n° 00-12.932.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

commentaire d'un auteur français[557] : « Le contrat doit présenter pour la victime un caractère désavantageux : seule l'exploitation de la situation par le cocontractant caractérise la violence cause d'annulation. La contrainte économique devant être illégitime, il faut que le contractant en position de force abuse de la situation pour obtenir un avantage excessif […] Il faut que le cocontractant ait profité de la situation de détresse économique et de l'impossibilité de négocier, dans laquelle se trouvait son partenaire, pour lui imposer un contrat profondément déséquilibré dont il retire un profit ou un avantage excessif. Le cocontractant doit avoir abusé de l'inégalité contractuelle qui présidait à la conclusion du contrat et procédait à la contrainte économique dont son partenaire était victime, pour confisquer l'intérêt du contrat à son profit exclusif et créer, en raison de ce déséquilibre excessif, une injustice contractuelle inadmissible. » Depuis, la réforme française de 2016 a consacré dans le nouvel article 1143 cette possibilité d'annuler un contrat pour violence économique, mais dans des termes assez restrictifs « [i]l y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». Dans le nouveau Code civil belge, l'article 5.37 reprend la même idée, mais dans des termes beaucoup plus larges, en sanctionnant l'« abus de circonstances », « lorsque, lors de la conclusion du contrat, il existe un déséquilibre manifeste entre les prestations par suite de l'abus par l'une des parties de circonstances liées à la position de faiblesse de l'autre partie ». Cependant, en droit luxembourgeois, dans de telles hypothèses, le remède est plutôt à chercher, comme nous allons le voir, du côté de la lésion qualifiée de l'article 1118 du Code civil, plutôt que dans une extension de la notion de violence de l'article 1112 du Code civil. Le recours à la notion de « violence économique » ne jouera au Luxembourg qu'un rôle résiduel, dans des hypothèses où, comme dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt de 2013, l'article 1118 du Code civil ne peut pas trouver à s'appliquer[558].

[557] D. MAZEAUD, *D.*, 2001, sommaires commentés, p. 1140.

[558] La lésion, qui suppose un déséquilibre entre les prestations, ne peut pas être invoquée dans un contrat unilatéral comme le cautionnement.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§4. La lésion

259. Problématique générale de la lésion. On appelle lésion, dans le Code civil, un déséquilibre entre les prestations des parties dans un contrat synallagmatique. Par exemple, une personne achète un bien à un prix beaucoup plus élevé que celui habituellement payé pour des biens équivalents, ou, à l'inverse, le vendeur accepte un prix beaucoup plus faible que celui du marché, le client d'une entreprise quelconque paye un prix exorbitant un service qui est généralement facturé moins cher, etc. La question de savoir si un tel déséquilibre peut être une cause de nullité du contrat, ou, du moins, s'il peut être corrigé par le juge, est une question centrale du droit des contrats. Elle est liée à la place qu'on veut faire jouer, face à la liberté contractuelle, aux considérations de justice en matière contractuelle. Comme on l'a déjà dit, dans les droits d'inspiration libérale, la lésion n'est pas, normalement, une cause de nullité ni de révision du contrat, ce qu'on justifie par plusieurs considérations. D'une part, la valeur des biens ou des services n'est pas considérée comme une donnée objective susceptible de donner prise à un contrôle du législateur ou du juge : elle n'est que le produit de la rencontre de l'offre et de la demande sur un marché, et celui-ci n'est autre que l'ensemble des contrats qui sont passés au sujet des biens ou des services analogues. On présuppose donc que le bien n'a d'autre valeur que celui qui a été discuté et fixé par le contrat. D'autre part, même s'il apparaît que la valeur fixée dans le cadre d'un contrat déterminé s'écarte notablement de celle du marché, le droit n'a pas à intervenir pour sanctionner ou corriger cet écart : dans une société libérale, chaque contractant est supposé être le meilleur juge de ses intérêts, de sorte que le prix qui a été accepté par tel ou tel contractant dans le contrat est celui qui était pour lui le prix adéquat, le juste prix compte tenu des circonstances objectives et subjectives qui entourent la conclusion du contrat. Si, par exemple, j'accepte de vendre mon appartement beaucoup moins cher que ce qu'il vaut sur le marché, c'est parce que je suis extrêmement pressé de le vendre pour pouvoir acheter un autre bien : mon intérêt est donc d'accepter ce prix bas. C'est le sens qu'on prête habituellement à la célèbre formule de Fouillée « qui dit contractuel dit juste ».

Les rédacteurs du Code civil s'inscrivaient dans cette logique. Venant à la suite des articles relatifs aux vices du consentement, l'article 1118 du Code civil disposait que « La lésion ne vice les

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section ». La même idée est aujourd'hui reprise, dans des termes légèrement différents, par l'article 1168 du Code civil français et par l'article 5.38 du nouveau Code civil belge. La rédaction restrictive du texte originaire (ne […] que) indiquait clairement qu'en principe la lésion ne permettait pas de remettre en cause le contrat. Il n'en allait autrement, comme nous le verrons, que si le contrat lésionnaire avait été passé par un incapable, ou dans certains contrats (le partage et la vente d'immeubles). Dans ces hypothèses, qui existent toujours en droit luxembourgeois, la lésion apparaît comme un déséquilibre objectif, dont on ne recherche pas la cause. Mais, à côté de ces cas très exceptionnels de lésion objective (**A**), le législateur luxembourgeois, suivant certains exemples étrangers, a introduit dans l'article 1118 du Code civil, un cas plus général où le déséquilibre entre les prestations est pris en considération parce qu'il apparaît comme le résultat de l'exploitation de la faiblesse d'un contractant par l'autre : c'est ce qu'on appelle la lésion qualifiée (**B**).

A) *Les lésions objectives*

260. Cas exceptionnels. Dans sa version d'origine, le Code n'admettait la lésion comme cause de nullité que de manière exceptionnelle, soit à raison de la nature particulière du contrat (1), soit en raison de la personnalité du contractant victime de la lésion (2). Même si ces cas sont inspirés par l'idée que, très probablement, la lésion s'explique par un vice du consentement du contractant victime, la loi ne fait pas de la preuve d'un tel vice une condition nécessaire de l'annulation. Le vice est en quelque sorte présumé à partir de la lésion.

1) *Dans certains contrats*

261. Vente d'immeubles. Rédigé à une époque où les biens immobiliers constituaient la composante essentielle des fortunes, le Code civil, d'une manière générale, entoure de précautions particulières les contrats portant sur des immeubles. C'est dans cette optique qu'on peut expliquer l'article 1674 du Code civil, qui permet au vendeur d'un immeuble de demander la rescision[559] de la vente s'il a été lésé de plus des 7/12e dans le prix de vente par rapport à

[559] Le terme de rescision est traditionnellement synonyme de nullité. Largement tombé en désuétude, il continue cependant d'être utilisé lorsqu'on parle de la lésion.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

la valeur de l'immeuble. On n'entrera pas ici dans le détail de l'étude des articles 1674 et suivants du Code civil, qui relève du droit spécial de la vente. On se contentera de donner les traits caractéristiques de l'action. L'action en rescision n'est ouverte qu'au vendeur, et non à l'acheteur (C. civ., art. 1683)[560]. Elle est enfermée dans un délai très court (deux ans à partir de la vente) (C. civ., art. 1676), et le vendeur n'est admis à faire la preuve de la lésion que si, de prime abord, « les faits articulés sont assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion » (C. civ., art. 1677). Si tel est le cas, l'action sera recevable, mais la preuve de la lésion devra ensuite être rapportée par un rapport de trois experts nommés par le tribunal (C. civ., art. 1678 à 1680). L'action en rescision conduit en principe à la nullité de la vente, chaque partie devant alors restituer ce qu'il a reçu. Mais l'acheteur peut empêcher l'annulation, et garder la chose, en offrant de payer le supplément permettant d'atteindre le juste prix, sous la déduction toutefois du dixième du prix total – ce qui, finalement, lui permet quand même de faire une bonne affaire[561]. Toute cette réglementation, très restrictive, est bien révélatrice du caractère exceptionnel que présentait, pour les rédacteurs du Code, l'admission de la lésion comme cause de nullité. Il faut également souligner le caractère objectif de cette réglementation : tout comme la jurisprudence française et belge, les tribunaux luxembourgeois jugent que la lésion légalement constatée est par elle-même et à elle seule une cause de rescision de la vente, indépendamment des circonstances qui ont pu l'accompagner ou lui donner naissance. Dès lors que la lésion des 7/12e est prouvée, le vendeur n'a donc pas à apporter, en plus, la preuve que ce déséquilibre est dû à une erreur, un dol ou une contrainte exercée par l'acheteur. Et, à l'inverse, l'acheteur ne peut pas repousser l'action en prouvant que la vente a été consentie librement[562].

262. Partage. Le partage est l'acte qui met fin à une situation d'indivision entre deux ou plusieurs personnes (des cohéritiers, deux conjoints mariés sous le régime de communauté, deux personnes qui ont acheté un bien en commun, etc.) en attribuant à chacun sa part. Le partage peut résulter d'un jugement, si les coindivisaires ne parviennent pas à se mettre d'accord, mais, le plus souvent, il

[560] Sur la possibilité pour l'acheteur de demander la rescision sur le fondement de l'article 1118 du Code civil, voy. *infra*, n° 274.

[561] Sur le mode de calcul de ce supplément, voy. Cour d'appel, 17 mars 2004, *Pas.*, 32, p. 474.

[562] Trib. Luxembourg, 3 janvier 1962, *Pas.*, 18, p. 500.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

se déroulera à l'amiable, sous la forme d'un contrat entre les copartageants. Les rédacteurs du Code civil ont attaché une importance particulière à l'égalité entre les copartageants, et c'est pourquoi, exceptionnellement, ils ont ouvert une action en rescision « lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart ». Le texte ne vise que le partage entre cohéritiers, mais il est également applicable au partage résultant de la dissolution de la communauté entre époux (C. civ., art. 1476). La rescision n'est pas seulement ouverte contre l'acte de partage lui-même, mais aussi contre tous les actes qui pour effet de faire cesser l'indivision, par exemple contre un acte de vente ou d'échange entre les cohéritiers (C. civ., art. 888). Comme la lésion dans la vente d'immeuble, il s'agit d'une lésion purement objective, en ce qu'il n'est pas nécessaire de prouver que le contractant lésé a été victime d'une erreur, d'un dol ou d'une violence de la part de ses copartageants. L'action est ouverte même si, dans l'acte de partage, le copartageant lésé déclare expressément qu'il renonce à invoquer la nullité. Une telle renonciation, constituant ce qu'on appelle une confirmation de l'acte nul[563], ne peut intervenir que postérieurement au partage[564].

2) *À l'égard de certaines personnes*

263. Incapables. Nous verrons plus loin que certaines catégories de personnes sont considérées par la loi comme étant inaptes à passer par elles-mêmes des contrats, soit à raison de leur âge (mineurs), soit à raison de leur état mental (majeurs protégés). Ces personnes ne peuvent passer de contrats que par l'intermédiaire d'un représentant (parents, tuteur) ou, dans certains cas, avec l'assistance d'un tiers (curateur). Si un incapable passe un acte pour lequel il aurait dû être représenté ou assisté, cet acte n'est pas toujours nul sur le seul fondement de l'incapacité. Dans certains cas, la nullité est subordonnée à la condition que l'acte ait été lésionnaire. C'est le cas pour les mineurs qui passent seuls des actes d'administration (par exemple la vente d'un bien meuble) ; on applique ici l'article 1305 du Code civil selon lequel « la simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé contre toutes sortes de conventions ». Il en va également ainsi pour les actes d'administration passé par un majeur en curatelle, ainsi que, d'une manière générale, pour tous les

563 Voy. *infra*, n°s 454 et s.

564 Cass., 15 décembre 2011, n° 71/11, n° 2905 du registre. Sur l'explication de cette solution, voy. *infra*, n° 456.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

contrats passés par les majeurs sous sauvegarde de justice, ceux-ci n'étant pas frappés d'une véritable incapacité (C. civ., art. 491-2 al. 2). En revanche, les actes passés par le majeur en tutelle sont frappés d'une nullité relative, sans qu'il soit nécessaire de prouver le caractère désavantageux de l'acte pour l'incapable[565].

B) *La lésion qualifiée*

264. Principe. Dans de nombreux systèmes juridiques, le principe « Qui dit contractuel dit juste » a été remis en cause, avec la prise en considération progressive de la situation de faiblesse de certains contractants (bien au-delà du cercle des incapables), à l'égard desquels l'idée selon laquelle toute personne est la meilleure juge de ses intérêts n'a pas beaucoup de sens. S'est alors progressivement répandue l'idée que le droit pouvait intervenir, d'une manière générale, dans les cas où contractant qui profite de sa situation de force pour convaincre son cocontractant en situation de faiblesse, ou pour lui imposer, de conclure un contrat particulièrement déséquilibré au profit du fort et au détriment du faible. Cette idée avait été mise en œuvre, dès 1900, dans le § 138 du BGB affirmant la nullité d'un acte juridique « par lequel quelqu'un, par l'exploitation d'une situation de contrainte, de l'inexpérience, du manque de capacité de jugement ou d'une faiblesse notable de la volonté, fait promettre à autrui, pour lui ou pour un tiers, une prestation qui est dans une disproportion frappante avec sa propre prestation »[566]. Peu de temps après, le Code des obligations suisse posait dans son article 21 que « En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience ». La même idée a été reprise depuis, avec d'infinies variantes dans la formulation, par de nombreuses législations nationales (dont, en particulier, celle du Luxembourg)[567]. Elle se retrouve aujourd'hui dans

565 Pour une vue plus détaillée des différents régimes de protection, voy. *infra*, n° 290.

566 « *Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen.* ».

567 Sans prétention à l'exhaustivité, on citera le droit néerlandais (BWB, art. 3 : 44), le droit roumain (Noul Cod civil, art. 1221), le droit autrichien (ABGB, § 879).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de nombreux textes internationaux et projets européens[568]. On a vu qu'elle est aujourd'hui consacrée, dans des termes très différents, par l'article 1141 du Code civil français sous l'angle de la violence économique, et par l'article 5.37 du Code civil belge sous la dénomination d'« abus de circonstances »[569].

On parle généralement de « lésion qualifiée » pour désigner ce type de disposition, ce qui n'est pas très explicite. L'idée est de distinguer cette lésion provoquée par l'exploitation abusive de la situation de force, donc par un comportement répréhensible du cocontractant, des cas de lésion objective, résultant d'un déséquilibre excessif entre les prestations, sans considération de son origine. Ce déséquilibre objectif continue à n'être pris en considération, dans tous les systèmes juridiques, que dans des hypothèses exceptionnelles. La sanction de la lésion qualifiée peut être rattachée au souci de stigmatiser des comportements contractuels particulièrement choquants – c'est dans ce sens qu'elle apparaît, dans le code allemand, comme une application particulière de la notion d'atteinte aux « bonnes mœurs ». Dans le droit moderne on y verra plutôt un aspect particulier de la protection des contractants faibles, et on peut analyser la lésion qualifiée comme un quatrième vice du consentement, à côté des vices traditionnels[570], qu'elle peut du reste recouper dans certains cas. Par rapport à ces derniers, la lésion qualifiée apparaît cependant comme une notion hybride, qui fait intervenir non seulement l'idée qu'un contractant a été abusé ou contraint, mais qui prend également en compte le résultat économique qui en résulte, alors que celui-ci n'est pas en principe important dans le cadre des vices du consentement classiques : le contrat est annulé pour erreur, dol ou violence du seul fait qu'il n'a pas été « vraiment » consenti, peu important qu'il ait été ou non économiquement désavantageux pour la victime.

Ce type de dispositif suscite généralement beaucoup de réticences chez les tenants d'une vision libérale du droit des contrats. On l'accuse volontiers de faire une trop grande place à l'interventionnisme judiciaire – surtout si le juge a le pouvoir, non seulement d'annuler le contrat, mais de le rééquilibrer – et d'être source, en

568 Voy. : PDEC, art. 4:109 ; PCC, art. 4:208 ; DCFR, art. II-7:207, DCEV, art. 51 ; Principes Unidroit, art. 3 :10.

569 Voy. *supra*, n° 258.

570 C'est sous cet angle qu'elle est réglementée dans les PDEC, les Principes Unidroit, le DCFR ou le DCEV ainsi que dans divers droits nationaux, dont, aujourd'hui, les droits français et belge.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

conséquence, d'une certaine insécurité juridique. Ces craintes apparaissent quelque peu excessives si on considère l'exemple des pays qui, comme l'Allemagne, connaissent depuis longtemps le mécanisme de la lésion qualifiée : ce mécanisme n'a certes pas entraîné la ruine de l'instrument contractuel ni empêché le développement de l'économie. Il est clair, cependant, qu'il faut, dans la rédaction de tels textes, chercher à instaurer un équilibre entre les préoccupations de justice contractuelle et le souci d'éviter une remise en cause trop facile des engagements. D'où la nécessité d'encadrer suffisamment le mécanisme.

265. La version luxembourgeoise de la lésion qualifiée : l'article 1118 du Code civil. Le mécanisme de la lésion qualifiée a été introduit au Luxembourg par la loi du 15 mai 1987, qui s'est clairement inspirée du texte suisse. Cette introduction s'est faite, de manière remarquable, par une modification de l'article 1118 du Code civil, dont le principe s'est trouvé renversé. Au lieu de « la lésion ne vicie les conventions qu'à l'égard de certaines personnes ou dans certains contrats » – texte d'origine – le texte dispose désormais, positivement, que « sauf les règles particulières à certains contrats ou à certaines personnes, la lésion vicie le contrat lorsque […] ». Suivent les conditions et les effets de cette prise en compte de la lésion.

Comme tous les textes de ce type, l'introduction de cet article a suscité à l'époque de vifs débats. Développant un discours typique de la doctrine libérale, le Conseil d'État avait ainsi estimé que « cette réforme n'a pu s'imposer ni dans le droit français ni dans le droit belge, où le courant dominant de la doctrine lui est resté hostile et ce en dépit des mêmes motifs invoqués en sa faveur chez nous. Il en résulterait une insécurité juridique parce qu'il s'agit de principes nouveaux dont il faudrait assurer l'intégration dans notre système juridique. Une telle opération serait d'autant plus délicate que le texte proposé fait appel – tant pour la définition de l'élément objectif requis dans le chef des cocontractants que pour ce qui est de l'élément subjectif requis dans le chef des cocontractants à l'effet de déclencher les sanctions prévues par une nouvelle disposition – à des notions très flexibles, voire très vagues, dont le contenu serait à préciser par étapes successives sur le vu de cas litigieux concrets »[571]. Avec le recul, ces craintes font presque sourire si on

[571] Cité dans : *Culture et droit civil au Luxembourg*, par un collectif d'auteurs du groupe luxembourgeois de l'Association Henri Capitant, in *Travaux de l'Association Henri Capitant, Droit et culture, Journées louisianaises*, Tome LVIII / 2008, p. 159-183, spéc. p. 174.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

considère que le texte n'a jusqu'ici fait l'objet que d'un nombre très limité d'applications, et ne s'est pas traduit par une explosion du contentieux contractuel : même si l'article 1118 a été invoqué plusieurs fois devant les tribunaux luxembourgeois, un seul arrêt, à ce jour, a prononcé la nullité d'un contrat sur ce fondement[572].

1) *Conditions de prise en considération de la lésion*

266. Dualité de conditions. La lésion vicie le contrat si deux séries de conditions sont réunies : d'une part des conditions objectives, tenant au défaut d'équivalence entre les prestations, et d'autre part des conditions subjectives, tenant à la disparité de forces des deux contractants et à l'exploitation abusive par le contractant fort de la situation de faiblesse de l'autre. Cette dualité de conditions distingue la lésion qualifiée de l'article 1118 du Code civil à la fois des autres vices du consentement et des cas de lésion objective. L'article 1118 du Code civil précise qu'il appartient au contractant qui prétend faire annuler le contrat pour lésion de prouver que ces différents éléments sont réunis, mais ce n'est là que l'application du droit commun de la preuve.

a. *Conditions objectives*

267. Contrats concernés. Le texte exige « une disproportion évidente au moment de la conclusion du contrat entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-partie de l'autre ». Cette condition présuppose que le contrat considéré soit un contrat synallagmatique, où il existe une prestation et une contrepartie. L'article 1118 du Code civil ne peut pas s'appliquer dans les contrats unilatéraux, dans lesquels un contractant s'engage sans recevoir de contre-prestation, et où il ne peut pas exister, à proprement parler, de défaut d'équivalence, ni, *a fortiori*, dans les actes unilatéraux : la Cour d'appel a ainsi très justement écarté l'application du texte à une libéralité, dans une hypothèse où les héritiers du testateur (une vieille dame qui avait fait un testament au profit de sa femme de ménage) soutenaient que la valeur du bien donné était excessive par rapport aux services rendus par la bénéficiaire[573]. De même, si une caution, qui s'est engagée à payer la dette d'autrui, soutient que le créancier

[572] Cour d'appel, 10 novembre 2010, *Pas.*, 35, p. 283. Sur l'article 1118, voy. H. WESTENDORF, « La lésion, vice du consentement prévu à l'article 1118 du Code civil », note sous Cour d'appel, 10 mars 2021, n° 57/21, n° CAL-2019-00459, et 30 novembre 2021, n° 146/21, n° CAL-2021-00123, *JN Obligations*, 2022/3, pp. 137-139.

[573] Cour d'appel, 11 juin 2008, n° 27137, *BIJ*, 2008, p. 93.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

lui a extorqué son consentement à un contrat particulièrement désavantageux pour elle en abusant de sa situation de force, elle ne peut pas se fonder sur l'article 1118 du Code civil. Dans ces hypothèses, la seule voie (très étroite) qui est ouverte pour contester l'acte est celle du vice de violence, qui a vocation à s'appliquer dans tous les actes juridiques et qui ne présuppose pas que le contrat obtenu par violence soit lésionnaire[574]. C'est une des différences notables entre la voie de la violence économique, choisie par le législateur français pour sanctionner les cas d'exploitation abusive d'une situation de dépendance[575], et la voie de la lésion choisie au Luxembourg. En revanche, l'article 1118 du Code civil s'applique *a priori* à tous les contrats synallagmatiques. Certes, le texte commence par la formule « sauf les règles particulières à certains contrats ou à certaines personnes », décalquée de la rédaction originaire, pour indiquer qu'à côté du mécanisme de la lésion qualifiée qu'il institue, il existe des cas spéciaux de lésion (lésion subie par un incapable, lésion dans la vente d'immeubles ou dans le partage, etc.). Mais, de notre point de vue, cette formule ne doit pas nécessairement conduire à exclure l'application de l'article 1118 du Code civil dans des contrats où une règle spéciale ouvre la possibilité d'une annulation pour une lésion purement objective. Même si les conditions de cette annulation ne sont pas réunies on peut concevoir l'application de la règle générale de l'article 1118 du Code civil, dès lors que la lésion a été provoquée par l'exploitation abusive de la situation de faiblesse. La Cour d'appel du Luxembourg en a cependant décidé autrement, en jugeant que l'article 1118 du Code civil ne pouvait pas être invoqué par l'acheteur d'un immeuble, au motif que les articles 1674 et suivants du Code civil édictent une réglementation spéciale sanctionnant la lésion de plus des 7/12e subie par le vendeur, et excluant la nullité en cas de lésion subie par l'acheteur[576].

Cette décision nous semble hautement contestable. La règle « *lex specialis generalibus derogant* », invoquée par la Cour d'appel, ne serait pertinente que si l'article 1118 du Code civil posait un cas général de lésion objective (par exemple, en édictant que, par principe, pour tous les contrats, une lésion de plus de la moitié de la valeur est une cause de nullité) ; une telle règle ne vaudrait que sous réserve de textes édictant une proportion différente. Mais, même si elle a vocation à s'appliquer

574 Voy. à propos d'un cautionnement : Cour d'appel, 10 juillet 2013, n° 38314, cité *supra*, n° 256.

575 Le nouveau texte français permet l'annulation du contrat dès lors que l'abus de dépendance a conduit le cocontractant à passer un contrat qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence de la contrainte, et permis à l'auteur de l'abus de tirer du contrat « un avantage excessif » – ce qui est beaucoup plus large que la disproportion entre les prestations.

576 Cour d'appel, 24 mars 2010, *J.T.L.*, 2011, p. 101.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

à tout contrat et à tout contractant, la règle de l'article 1118 du Code civil n'apparaît nullement comme une règle générale par rapport à ce type de textes, dès lors que la nullité du contrat y est subordonnée, non seulement à un défaut objectif d'équivalence, mais encore à l'exploitation abusive d'une situation de faiblesse (condition qui n'est nullement requise dans les textes spéciaux relatifs à la lésion). On peut donc parfaitement concevoir qu'un vendeur d'immeubles puisse obtenir la nullité du contrat dans deux cas : s'il a été lésé de plus des 7/12e (cas spécial prévu par l'article 1674 du Code civil) ou si, ayant subi une lésion moindre, il a été victime d'une exploitation abusive de sa situation de faiblesse (cas de l'article 1118 du Code civil). Du reste, il serait paradoxal que les articles 1674 et suivants, édictés à l'époque du Code civil pour assurer au vendeur d'immeuble une protection particulière à une époque où la lésion n'était pas en principe une cause de nullité, se retourne aujourd'hui contre lui en le privant de la protection générale de l'article 1118 du Code civil. Mais l'arrêt de 2010 est d'autant plus contestable que c'est l'acheteur d'un immeuble qu'il prive du droit de se prévaloir de l'article 1118 du Code civil, et qu'on ne comprend alors vraiment pas pourquoi une réglementation spéciale protectrice des vendeurs devrait priver les acheteurs d'immeubles du bénéfice d'une protection accordée à tous les contractants. Il est vrai que l'article 1683 du Code civil dispose que « la rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur », mais il paraît évident que ce texte, écrit en 1804, ne vise que la rescision pour lésion de l'article 1674, et que les rédacteurs du Code n'ont pu vouloir priver l'acheteur d'un texte, écrit en 1987, et édictant un nouveau cas de nullité pour lésion applicable par principe à tout contractant[577].

Le seul contrat pour lequel on pourrait contester l'applicabilité de l'article 1118 du Code civil serait le contrat de transaction, pour lequel l'article 2052 du Code civil exclut, d'une manière générale, qu'il puisse être attaqué pour cause de lésion. C'est du reste pour tourner l'application de ce texte que la Cour de cassation française, confrontée en 2000 à une demande en nullité d'une transaction dans laquelle la victime d'un accident avait, sous l'emprise de la nécessité économique, accepté de son assureur une indemnité très faible, avait posé que « la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion »[578]. Cependant, on peut soutenir que l'article 2052 du Code civil, qui se justifie par le caractère *a priori* incertain des droits des parties, n'a de sens que pour les seules lésions objectives, et qu'il ne devrait pas exclure l'application d'un texte sanctionnant l'exploitation abusive de la situation de faiblesse de l'une des parties. Dans ce sens, il faut remarquer que l'arrêt de la Cour de cassation belge qui a consacré une règle de lésion qualifiée analogue à l'article 1118 du Code civil du Luxembourg a expressément précisé que cette règle s'appliquait également en matière de transaction. Un arrêt de 2011 de la Cour d'appel du Luxembourg semble du reste avoir fait application, sans le dire, de l'article 1118 du Code civil à une transaction passée entre un salarié et son employeur en considérant que les sommes versées au salarié étaient dérisoires par rapport aux concessions qui lui étaient faites par son employeur et que la transaction revêtait un caractère léonin en ce qu'elle présentait une asymétrie financière certaine et anormale au profit de l'employeur[579].

577 On peut du reste remarquer que personne n'a jamais contesté qu'un acheteur d'immeuble placé sous sauvegarde de justice pourrait se prévaloir de l'article 491-2 pour faire annuler pour lésion l'acte qu'il a passé.

578 Cass. fr. (1re civ.), 30 mai 2000, *Bull.*, I, n° 169, préc.

579 Cour d'appel, 26 mai 2011, n° 36087, *BIJ*, 2011, p. 164, cité par O. POELMANS, qui y voit une application implicite de l'article 1118 du Code civil.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

268. Disproportion évidente. En exigeant une « disproportion évidente » entre la prestation et sa contre-partie, l'article 1118 du Code civil ne chiffre pas précisément l'importance du déséquilibre susceptible de vicier le contrat. C'est une caractéristique commune de tous les textes qui, dans les droits nationaux ou dans les textes et projets internationaux et européens, admettent le mécanisme de la lésion qualifiée. De ce point de vue, ces textes se distinguent clairement de tous ceux qui font, objectivement, de la lésion, une cause de nullité quelle qu'en soit l'origine, et qui reposent sur un chiffrage précis : ainsi, en droit luxembourgeois, la lésion du vendeur d'immeubles de plus des 7/12e, ou la lésion du plus du quart dans le partage. Ici, dans la mesure où la cause de nullité tient à l'exploitation abusive d'une situation de force, il appartient au juge d'apprécier au cas par cas si le déséquilibre du contrat est suffisamment important pour révéler la possibilité d'un tel abus. Il est clair qu'il ne suffit pas d'établir que la valeur du bien qu'on a acquis est inférieure au prix payé pour obtenir la nullité du contrat[580]. Dans le seul arrêt qui ait jusqu'ici admis la nullité d'un contrat sur le fondement de l'article 1118 du Code civil, la Cour d'appel a estimé que la disproportion évidente était caractérisée dans un contrat de vente d'actions d'une société, où l'acheteur avait payé 225 000 € pour obtenir 50 % des actions d'une société dont la valeur bilantaire était quasi-nulle[581].

L'article 1118 du Code civil précise que cette disproportion doit s'apprécier au moment de la conclusion du contrat. Cette exigence est commune à toutes les hypothèses de lésion, qu'il faut bien distinguer des cas où le déséquilibre entre les prestations apparaît postérieurement à la formation du contrat, par suite de l'évolution des circonstances économiques. Il n'y a pas lésion, par exemple, si la valeur du bien que j'ai acheté, en le payant à son juste prix au moment du contrat, vient ensuite à se déprécier par suite de l'effondrement du marché, ou si je m'engage à fabriquer un certain matériel, et que le prix fixé, correct à l'origine s'avère par la suite beaucoup trop faible par suite d'une augmentation considérable du prix des matériaux nécessaires à la fabrication. Ces situations, qu'on désigne habituellement sous le nom d'imprévision, ne sont en aucune manière des vices de formation du contrat, même si se pose

[580] Trib. Luxembourg, 15 février 2008, n° 103193, *BIJ*, 2008 p. 93 à propos de la cession d'une société.

[581] Cour d'appel, 10 novembre 2010, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

aussi, à leur propos, la question de savoir si elles peuvent entraîner un anéantissement ou une adaptation du contrat déséquilibré[582]. Cependant, l'appréciation, au regard de l'article 1118 du Code civil, de l'équivalence des prestations au moment de la conclusion du contrat, n'exclut pas qu'on puisse tenir compte, pour déterminer la valeur d'un bien, des évolutions qui sont susceptibles de l'affecter par la suite : la valeur actuelle d'un immeuble, par exemple, peut dépendre des projets de construction ou d'urbanisme dans le voisinage, s'ils sont suffisamment certains au moment de la vente[583].

Des difficultés particulières peuvent surgir pour déterminer le moment exact de la formation du contrat dans les contrats qui se concluent en plusieurs étapes, notamment dans le cas où la passation du contrat définitif est précédée d'une promesse. La lésion doit-elle s'apprécier au moment de la conclusion de la promesse ou de celle de l'acte définitif ? S'agissant de la lésion de plus des 7/12e dans la vente d'immeuble, la jurisprudence, au Luxembourg comme en France, distingue selon que la promesse est synallagmatique ou unilatérale. Dans le premier cas, la promesse valant vente selon les termes de l'article 1589 du Code civil, c'est à sa date qu'on doit estimer la valeur de l'immeuble[584] ; dans le second, le contrat n'est formé qu'à la levée de l'option, et c'est à ce moment qu'on doit apprécier une éventuelle lésion[585]. Il n'est pas sûr cependant qu'on doive transposer cette distinction, qu'on associe habituellement au caractère purement objectif de la lésion de l'article 1674 du Code civil[586], à la lésion de l'article 1118 du Code civil. Celle-ci n'étant prise en compte que si elle a été le résultat d'une exploitation abusive de la situation de faiblesse d'un contractant, il paraît logique de se placer toujours au moment où le contractant lésé a donné son consentement : dans une promesse unilatérale, le promettant ne pourra se prévaloir de l'article 1118 du Code civil que si la disproportion existait dès le moment de la promesse, car une disproportion apparue postérieurement ne saurait être le résultat d'une exploitation de sa faiblesse ; c'est en revanche au jour de la levée de l'option qu'il faudrait apprécier l'existence d'une lésion subie par le bénéficiaire.

b. *Conditions subjectives*

269. Personnalité des contractants. L'article 1118 du Code civil est un texte d'application générale, qui n'est pas réservé à certaines catégories de contractants. En particulier, il s'applique aussi bien dans les relations entre deux professionnels, ou entre deux non professionnels, que dans les relations entre un professionnel et un

582 Voy. *infra*, n° 479.

583 Dans ce sens à propos de la lésion de plus des 7/12e dans la vente d'immeubles : Cour d'appel, 19 juin 2001, *Codex*, 2001/9, p. 190.

584 Cass. fr. (3e civ.), 30 juin 1992, n° 90-19882 ; 30 mars 2011, n° 10-13756.

585 Cour d'appel, 25 novembre 1921, *Pas.*, 11, p. 221, suivant une solution consacrée en France par Cass. fr. (civ.), 14 novembre 1916, *D.*, 1921, 1, p. 34, et constamment reprise depuis (voy. p. ex. Cass. fr. (3e civ.), 29 septembre 1999, n° 97-21738).

586 Voy., p. ex., FLOUR, AUBERT, SAVAUX (2014), n° 245, qui observent que la solution retenue en matière de promesse unilatérale de vente est incompatible avec l'analyse de la lésion comme un vice du consentement.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

consommateur. Même si le texte, en 1987, a été pensé dans une optique consumériste, c'est un texte de droit commun des contrats et non de droit de la consommation. Il est du reste remarquable que le seul arrêt luxembourgeois qui ait annulé un contrat pour lésion sur le fondement de l'article 1118 du Code civil ait été relatif à un contrat passé entre deux sociétés commerciales au sujet d'une vente d'actions, et l'arrêt note bien que la lésion est « un vice du consentement à caractère général, qu'il s'agisse de relations contractuelles impliquant un ou plusieurs consommateurs finaux ou de relations contractuelles entre commerçants »[587].

270. Force et faiblesse. La nullité du contrat pour lésion suppose cependant qu'il ait existé, au moment de la formation du contrat, un déséquilibre entre les deux contractants, l'un étant en situation de faiblesse et l'autre en situation de force, mais ce déséquilibre ne repose pas sur une présomption tenant à l'appartenance des contractants à des catégories prédéterminées (le consommateur et le professionnel notamment), et il doit donc être apprécié au cas par cas par les juges. L'article 1118 du Code civil énumère, de manière apparemment limitative, les éléments d'où peuvent résulter la faiblesse du contractant lésé : il s'agit de « la gêne, de la légèreté ou de l'inexpérience » de ce contractant – termes textuellement repris de l'article 21 du Code des obligations suisse. Le premier élément, la « gêne » est celui qui rapproche le plus nettement le concept de lésion qualifiée de celui de violence économique : est ici visée la situation de la personne qui contracte pour se sortir d'une situation financière difficile, ou pour éviter de s'y mettre (par exemple, celui qui vend un bien à bas prix pour rembourser ses créanciers ou pour se procurer des moyens d'existence). Les deux autres éléments, la légéreté et l'inexpérience, visent des situations qui sont plutôt traditionnellement appréhendées sur le terrain de l'erreur ou du dol : ici, le contractant lésé n'a pas été contraint de passer le contrat, mais il n'était pas en mesure d'apprécier la valeur du bien ou du service objet du contrat. L'article 1118 pourrait donc permettre d'appréhender des situations relevant traditionnellement de la réticence dolosive – par exemple la situation ayant donné lieu en France à l'arrêt *Baldus*[588]. On peut être étonné, à la lecture de l'article 1118 du Code civil, de voir mettre sur le même plan

[587] Cour d'appel, 10 novembre 2010, préc.
[588] Voy. *supra*, n° 248.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'inexpérience – qui est une situation de faiblesse objective[589] – et la légèreté, qui désigne plutôt le comportement du contractant qui s'engage trop vite, sans réfléchir ou sans se renseigner suffisamment – ce qui, à première vue, devrait conduire à priver ce contractant de toute protection[590]. Cependant, il ne faut pas oublier que la nullité du contrat sur le fondement de l'article 1118 du Code civil est de toute façon subordonnée à un abus de la part du cocontractant en situation de force – ce qui, par principe, est de nature à rendre excusable la « légèreté » du plus faible.

271. Exploitation abusive. Comme le dol ou la violence, la lésion qualifiée est un vice du consentement « bicéphale », où il ne faut pas seulement considérer la situation de celui qui en a été victime, mais aussi le comportement de l'autre. La nullité ne sera retenue que si la disproportion résulte d'une « exploitation » par ce cocontractant de sa situation de force, en « abusant sciemment » de la faiblesse de l'autre. Cette idée se retrouve dans tous les textes nationaux et les projets européens relatifs à la lésion qualifiée, et c'est elle qui servait, dans la jurisprudence française, à caractériser la violence économique. On la retrouve dans le nouvel article 1141 du Code civil français (abus de la situation de dépendance) et dans l'article 5.37 du Code civil belge (abus de circonstances). Il est très difficile de préciser de manière abstraite cette notion d'exploitation abusive, qui ne peut qu'être appréciée au cas par cas par les juges, par comparaison avec le comportement normalement attendu des acteurs économiques. C'est précisément cette marge d'appréciation qui peut être génératrice d'une certaine insécurité, et qui fonde les critiques des juristes libéraux par rapport à ce type de dispositions. Les termes employés par le législateur devraient cependant inciter les juges à ne faire application de l'article 1118 du Code civil que dans des circonstances exceptionnelles, et tel est bien l'état actuel de la jurisprudence luxembourgeoise.

589 Ainsi, dans l'arrêt de 2010, la Cour retient l'inexpérience de la société acheteuse, spécialisée dans la gestion de biens immobiliers, activité qui ne lui donne pas de compétences particulières dans l'évaluation d'actions, face à la société vendeuse qui, elle, est spécialisée dans les opérations financières.

590 Voy. *supra*, n° 236, sur le terrain de l'article 1110 du Code civil, la notion d'erreur inexcusable.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

2) *Effets de la lésion*

272. Nature de la sanction : nullité ou réduction. Dans la continuation des textes relatifs aux vices du consentement, la lésion est présentée d'abord par l'article 1118 du Code civil comme une cause de nullité du contrat : « la lésion vicie le contrat ». En matière de lésion, cette nullité porte traditionnellement le nom de « rescision », et l'article 1118 du Code civil reprend ce terme dans son dernier alinéa ; il n'existe cependant pas de différence substantielle entre cette nullité et les autres nullités contractuelles. Cependant, le texte ouvre à la partie lésée la possibilité de demander, en lieu et place de la nullité, la « réduction des obligations lésionnaires », c'est-à-dire, en pratique, la diminution du prix excessif[591]. Cette possibilité de révision du contrat – qu'on retrouve dans le nouveau texte belge – est dans la logique des textes spéciaux relatifs à la lésion, même si elle en diffère techniquement : ainsi, en cas de lésion subie par un majeur sous sauvegarde de justice, l'article 491-2 du Code civil dispose que les actes passés pourront « être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès » ; de même, dans le cas de la lésion de plus des 7/12e dans la vente d'immeuble, l'article 1681 du Code civil donne à l'acquéreur le choix de rendre l'immeuble ou de le garder en fournissant le supplément du juste prix[592]. En revanche, elle distingue nettement la lésion des autres vices du consentement, qui, traditionnellement, ne peuvent entraîner que l'annulation du contrat et non sa révision[593]. De ce point de vue aussi, la lésion qualifiée n'aboutit pas nécessairement au même résultat que la notion de violence économique retenue en droit français pour traiter de situations analogues : le nouvel article 1141 français ne prévoit comme sanction que la nullité du contrat obtenu à la suite de l'abus. On voit bien ici le caractère hybride de la nullité pour lésion, qui est fondée à la fois sur un vice du consentement et sur un déséquilibre objectif entre les prestations. En pratique, cependant, la différence n'est pas si nette dans la mesure où la victime d'un vice du consentement provoqué par le comportement du cocontractant peut se contenter

591 Le texte ne semble pas permettre, à l'inverse, à un vendeur lésé d'exiger de son acheteur le paiement d'un prix plus élevé, qu'il ne serait pas nécessairement en mesure de payer.

592 Sauf à remarquer que, dans ce cas, c'est le contractant avantagé qui a le choix, et qui peut bloquer l'action en nullité du vendeur en offrant de payer un prix plus élevé. L'article 1118 du Code civil donne, lui, le choix de la sanction au contractant lésé (qui ne peut cependant imposer à son cocontractant de payer plus cher). Les PDEC, les Principes UNIDROIT et le DCFR ouvrent quant à eux la possibilité au juge d'adapter le contrat déséquilibré à la demande de l'une ou de l'autre partie.

593 Voy. *supra*, n° 249 les discussions à propos du dol incident.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de demander des dommages et intérêts au lieu d'agir en nullité, ce qui, en fait, aboutit au même résultat économique qu'une réduction des obligations lésionnaires.

273. Régime de l'action. L'action en rescision est, de manière certaine, une action en nullité relative, qui ne peut être exercée que par le contractant lésé. Même s'il y avait intérêt, le cocontractant ayant provoqué la lésion, ne pourrait s'en prévaloir pour faire tomber le contrat qu'il regretterait d'avoir passé. De prime abord, par ailleurs, le juge qui constaterait une situation de lésion ne pourrait pas prononcer d'office la nullité du contrat si le lésé ne la demandait pas[594]. Et, comme dans les autres cas de nullité relative, le contractant lésé peut confirmer le contrat, c'est-à-dire renoncer à en invoquer la nullité – cette renonciation ne pouvant néanmoins intervenir dans le contrat lui-même[595]. Sur un point, cependant, l'action en rescision se distingue des actions en nullité relative : cette action (de même que l'action en réduction) doit être intentée dans le délai d'un an suivant la conclusion du contrat. La différence avec les autres actions en nullité relative pour vice du consentement se situe sur deux plans : ces autres actions se prescrivent par cinq ans, et ce délai court seulement du moment où le vice a cessé, alors que l'action pour lésion est éteinte au bout d'un an suivant la conclusion du contrat même si le contractant n'a pris conscience de la lésion que beaucoup plus tard[596]. Ce bref délai de l'action – repris du texte suisse qui a servi de modèle – est significatif du souci du législateur de ne pas compromettre la sécurité juridique. En pratique, il contribue à expliquer le très faible impact qu'a eu le mécanisme de l'article 1118 au Luxembourg : sur les 18 décisions accessibles sur justice.lu ayant eu à se prononcer sur une demande fondée sur l'article 1118, 7 écartent cette demande au motif de la forclusion pour dépassement du délai, 8 au motif que les conditions de fond n'étaient pas établies, et, comme on l'a dit, une seule, l'arrêt du 10 novembre 2010, annule un contrat sur le fondement de ce texte.

[594] Sauf à signaler dès maintenant une tendance contemporaine à permettre (voire à imposer) au juge de venir au secours des contractants en situation de faiblesse en soulevant d'office une nullité qu'ils ne penseraient pas à invoquer (voy. *infra*, n° 415 en matière de clauses abusives).

[595] C'était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de 2010, où la société lésée avait, dans le contrat, renoncé par avance à tout recours contre son cocontractant. Cette clause n'empêche pas la Cour de prononcer la nullité du contrat. Comp. pour la lésion dans le partage : Cass., 15 décembre 2011, cité *supra*, n° 262.

[596] Techniquement le délai d'un an s'analyse comme un délai de forclusion et non de prescription. Voy. *infra*, n° 945.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

SECTION 2. LA PROTECTION DU CONSENTEMENT DANS LA LÉGISLATION CONTEMPORAINE : LA PRÉVENTION DES ALTÉRATIONS DU CONSENTEMENT

274. Spécificités de la législation contemporaine en matière de protection du consentement. Comme on a pu s'en rendre compte à la lecture des développements précédents, la « théorie » des vices du consentement s'avère tout à fait inapte à garantir que, dans tous les cas, le consentement donné par les contractants soit parfaitement libre, éclairé et réfléchi, et telle n'a jamais été l'ambition des rédacteurs du Code. D'une part, la protection du consentement par les articles 1109 et suivants du Code civil est très lacunaire, et ne permet de sanctionner que les vices les plus graves, en laissant volontairement hors de son champ certaines altérations du consentement dont on considère que le cocontractant n'a pas à supporter les conséquences. D'autre part, il s'agit par principe d'une protection *a posteriori*, qui suppose une action en justice exercée par la victime du vice et tendant principalement à la nullité du contrat. Or ce type de remède apparaît tout à fait inadapté pour toute une série de petits contrats de la vie quotidienne pour lesquels le contractant ayant commis une erreur sur le bien ou le service ou n'ayant pas su résister à la pression d'un vendeur trop pressant renoncera le plus souvent à se lancer dans un procès au résultat aléatoire pour faire tomber le contrat.

Le droit moderne a mis en place toute une série de techniques visant à une protection plus efficace du consentement. Ces techniques se distinguent de la protection classique par les vices du consentement de deux manières. D'une part, il s'agit de techniques de prévention, visant à faire en sorte que le contractant ne s'engage que bien informé sur l'objet du contrat et en ayant bien réfléchi à l'utilité que le contrat présente pour lui – même si, bien entendu, en cas de non-respect des règles posées, il faudra bien passer au stade des sanctions. D'autre part, alors que les règles du Code civil sont des règles de droit commun, applicables par principe à tous les contrats et à tous les contractants, les dispositifs modernes sont conçus comme ne devant s'appliquer que dans certains contrats, supposés particulièrement dangereux, ou à certaines catégories de contractants. C'est surtout sur ce second plan que les règles contemporaines sont en rupture avec l'esprit du Code civil, lequel, sous réserve des règles relatives aux incapables, mettait sur un pied d'égalité tous les contractants, quel que soit leur statut social ou leur situation par rapport à l'autre partie. Comme on l'a déjà vu,

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

le droit moderne des contrats a rompu avec ce postulat d'égalité, et met en place des mécanismes de protection spécifiques de certaines catégories de contractants en situation de faiblesse – qu'il s'agisse des travailleurs salariés face à leur employeur, des locataires face à leur bailleur, ou, surtout, des consommateurs face aux professionnels. C'est surtout pour cette dernière catégorie de contractants qu'ont été mis en place, dans la législation contemporaine, des mécanismes spéciaux de prévention des altérations du consentement, et ceci explique que ces mécanismes ne soient pas spécifiques au droit luxembourgeois : issus pour la plupart du droit de la consommation européen, ils se rencontrent, au-delà d'inévitables différences de détail, dans tous les droits de l'Union européenne, et ils sont précisés par la jurisprudence de la CJUE. Ces différents mécanismes ont déjà été rencontrés à propos de l'étude de la phase de formation du contrat, ou seront traités dans la suite des développements. C'est pourquoi il ne convient que d'en dresser ici un rapide panorama synthétique (**§ 1**), avant de se demander comment ils se combinent avec la protection traditionnelle fondée sur les vices du consentement (**§ 2**).

§1. Les différentes techniques

275. Obligations d'information. La technique de prévention la plus simple et la plus répandue consiste à imposer au contractant qui a des connaissances ou des compétences particulières sur le bien ou le service qu'il propose de délivrer à l'autre des informations sur ce bien ou ce service, qu'il s'agisse d'informations objectives ou de conseils ou mises en garde sur l'utilité qu'ils peuvent avoir pour le cocontractant. Ces obligations d'information, dont nous avons précédemment fait l'inventaire[597], sont de nature à éviter un certain nombre d'erreurs de la part de l'autre – qu'il s'agisse d'erreurs sur la substance qui pourraient être prises en compte sur le fondement de l'article 1110 du Code civil, ou d'erreurs sur les motifs qui ne donneraient lieu en principe à aucune sanction. Même si leur domaine est beaucoup plus large, les obligations d'information sont une constante dans tous les textes européens et nationaux de protection des consommateurs. On les retrouvait, avec une réglementation particulièrement détaillée, dans la défunte proposition de règlement européen sur la vente[598].

[597] Voy. *supra*, n°s 197 et s.

[598] DCEV, art. 13 à 29. Ces textes distinguent les informations qui doivent être fournies par un professionnel à un non-professionnel et celles qui doivent être fournies entre professionnels.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

276. Formalisme. Comme on l'a déjà dit, le principe, en droit luxembourgeois comme dans l'immense majorité des droits modernes, est celui du consensualisme, selon lequel un contrat est valable même s'il ne se coule pas dans le moule de formes particulières. Ce principe connaît cependant une multitude d'exceptions, sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir[599]. Il ne s'agit ici que de situer les exigences formelles par rapport à la problématique de la protection du consentement. Dans un grand nombre de cas, en effet, les formes requises ont pour finalité d'attirer l'attention d'un contractant, ou des deux, sur l'acte passé, sur son contenu et ses conséquences, pour éviter que ce contractant ne s'engage à la légère, par de simples paroles trop vite prononcées. Cette technique de protection du consentement était déjà connue dans le Code civil, pour certains contrats particulièrement dangereux : l'exemple le plus significatif est celui de la constitution d'hypothèque qui, selon l'article 2127 du Code civil, « ne peut être consentie que par acte passé en la forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins ». Mais ce formalisme protecteur du consentement s'est considérablement répandu dans le droit moderne, et il irrigue en particulier, là encore, tout le droit de la consommation, notamment dans ses dispositions d'origine européenne. En général, le législateur qui édicte des exigences formelles dans ce but ne se contente pas de la simple rédaction d'un écrit sous seing privé. Pour les actes les plus graves, il peut exiger la rédaction d'un acte authentique, l'intervention du notaire, tenu d'une obligation de conseil, devant alors assurer une parfaite information des contractants et favoriser leur réflexion au moment de l'engagement. Mais, dans la législation contemporaine, on va plutôt, tout en se contentant d'un acte sous seing privé, exiger que cet acte (généralement prérédigé par une partie) contienne certaines mentions obligatoires destinées à informer le contractant faible sur le contenu et les conséquences du contrat : le formalisme devient alors le support de l'obligation d'information. Parfois, on va jusqu'à exiger que le contractant qu'on veut protéger écrive de sa main une mention montrant qu'il a parfaitement conscience du contenu de son engagement : cette formule, très répandue dans le droit français de la consommation, ne semble cependant pas, jusque-là, avoir séduit le législateur

599 Voy. *infra*, n°s 417 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

luxembourgeois[600]. Les vertus de ces exigences formelles comme technique de protection du consentement sont très discutées dans la doctrine française. Rien ne garantit, en effet, que le contractant que l'on souhaite protéger lira bien les mentions informatives figurant dans le contrat, et l'accumulation même de ces mentions risque d'avoir un effet décourageant pour lui. À la limite, on peut même se demander si la multiplication de ces mentions ne peut pas se retourner contre le contractant en l'empêchant de soutenir ensuite qu'il a été mal informé[601].

277. Délais de réflexion et droits de rétractation. Ce type de règles, déjà étudiées[602], consiste à imposer au contractant qu'on souhaite protéger un certain délai avant qu'il ne puisse accepter le contrat, ou, beaucoup plus fréquemment, à lui permettre de revenir sur son acceptation pendant un court délai suivant celle-ci. Dans les deux cas, il s'agit d'éviter que le contractant ne s'engage à la légère, ou sous la pression de son cocontractant, en lui laissant le temps de réfléchir soit avant, soit après la conclusion du contrat. Les droits de rétractation constituent une pièce essentielle du droit européen de la consommation, et c'est seulement dans ce cadre qu'ils sont aujourd'hui reconnus en droit luxembourgeois (alors que, dans d'autres pays, et notamment en France, ils peuvent être reconnus en dehors du domaine spécifique de la consommation). Ces droits permettent d'appréhender des situations de contrats passés sous pression, ou de manière non réfléchie, qui ne pourraient pas tomber sous le coup des vices du consentement traditionnels : le fait pour un consommateur de céder sur un coup de tête à la tentation d'un achat déraisonnable, ou de se laisser impressionner par le « baratin » d'un vendeur ou d'un démonstrateur bien rôdés aux techniques de vente, ne pourrait jamais constituer, en soi, un dol ou une violence. Cependant, il faut souligner que ces droits ne sont reconnus, au profit des consommateurs, que dans des cas limités, soit à raison de la gravité de l'engagement (contrats de crédit), soit à raison des circonstances particulières où le contrat est passé (contrats à distance, contrats hors établissement).

600 L'exigence d'une telle mention écrite par un contractant se trouve dans le Code civil à l'article 1326 pour les contrats et actes unilatéraux emportant obligation de payer une somme d'argent. Mais, bien qu'on lui donne communément aujourd'hui une fonction de protection du consentement, cette exigence n'a été à l'origine conçue par les rédacteurs du Code civil que comme une règle de preuve du contrat. Sur cette ambiguïté, voy. *infra*, n° 424.

601 Voy. *infra*, n° 281.

602 Voy. *supra*, n°s 167 et s.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

278. Interdiction des pratiques commerciales déloyales. Les articles L. 122-1 et suivants du Code de la consommation luxembourgeois interdisent, conformément à diverses directives européennes, toute une série de pratiques commerciales déloyales définies comme des pratiques contraires aux exigences de la diligence professionnelle, et qui sont susceptibles « d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur ». Derrière cette idée d'altération du comportement économique, on peut sans peine discerner celle d'altération du consentement : le consommateur est poussé, par les pratiques déloyales, à passer un ou plusieurs contrats qu'il n'aurait pas passés autrement. Plus précisément, on reconnaît, derrière les deux types de pratiques commerciales déloyales, les deux types d'altération du consentement que visent à sanctionner les articles 1109 et suivants du Code civil : l'interdiction des pratiques trompeuses (C. consomm., art. L. 122-2 à L. 122-4) vise à éviter que le consommateur ne donne un consentement insuffisamment éclairé (ce qui est à la base de la réglementation classique de l'erreur et du dol), tandis que l'interdiction des pratiques commerciales agressives (C. consomm., art. L. 122-5 à L. 122-7) vise à protéger la liberté du consommateur, et recoupe dans une certaine mesure l'interdiction de la violence dans le Code civil[603]. Cependant, il serait très réducteur de ne présenter la réglementation des pratiques commerciales déloyales que sous cet angle. Il faut voir en effet que cette réglementation a pour but, au moins autant que de protéger les consommateurs, de réguler le marché en faisant en sorte que certains agents économiques ne détournent, par leurs pratiques anormales, une clientèle qui aurait pu se diriger ailleurs.

§ 2. La combinaison des techniques de prévention avec la protection fondée sur les vices du consentement

279. Sanctions spécifiques indépendantes des vices du consentement. Le non-respect des exigences posées par la loi pour prévenir certaines altérations du consentement justifie des sanctions spécifiques qui ne supposent pas la démonstration que le contractant protégé a été effectivement victime d'une telle altération. Parmi ces sanctions, le droit pénal occupe une place prépondérante : ainsi, dans le droit de la consommation, le fait pour un professionnel de

[603] Voy., p. ex., l'article L. 122-6 a, b et e qui vise des circonstances qui pourraient tomber sous le coup de l'article 1112 du Code civil.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ne pas satisfaire aux obligations d'information qui lui incombent, entraîne, dans certains cas au moins, l'application de sanctions pénales[604], de même que le fait de n'avoir pas mis à disposition du consommateur le formulaire de rétractation[605] ; les pratiques commerciales déloyales sont de même sanctionnées pénalement par l'article L. 122-8 du Code de la consommation. L'intérêt de ces sanctions pénales, plus ou moins dissuasives, est qu'elles peuvent être mises en œuvre sans l'intervention d'un consommateur précis qui en aurait été victime, à la demande d'une association de consommateurs ou sur dénonciation de quiconque en aurait connaissance. Le non-respect de ces diverses dispositions peut également être sanctionné sur le plan civil. En particulier, le non-respect du formalisme de protection est souvent assorti de la nullité du contrat. Même s'il s'agit le plus souvent d'une nullité relative, ne pouvant être invoquée que par le contractant que la loi voulait protéger, celui-ci n'aura pas besoin de prouver que le défaut des mentions informatives qui auraient dû figurer dans le contrat a effectivement altéré son consentement, et que les informations manquantes étaient essentielles pour lui.

C'est du reste une des raisons pour lesquelles de nombreux auteurs, du moins dans la doctrine française, critiquent le formalisme en droit de la consommation. On l'accuse volontiers de favoriser la mauvaise foi de contractants qui se servent du prétexte du non-respect des règles de forme pour faire tomber un contrat dont ils veulent se débarrasser alors qu'ils l'auraient passé de toute façon même si les formes avaient été respectées. Mais c'est précisément la menace de telles actions en nullité qui peut inciter les professionnels à respecter les obligations qui leur incombent, au profit de l'ensemble des consommateurs pour qui les formes exigées peuvent avoir un rôle informatif.

280. Elargissement de la protection fondée sur les vices du consentement. L'existence, pour tel type de contrat ou pour telle catégorie de contractants, de techniques spécifiques de protection du consentement, n'interdit évidemment pas, en principe, au contractant victime d'un vice relevant des articles 1109 et suivants du Code civil de s'en prévaloir pour demander la nullité du contrat. On observe même que, dans un cas, le développement de ces techniques a entraîné un remarquable élargissement de la protection fondée sur le droit commun. C'est en effet, comme on l'a déjà vu,

604 Voy., p. ex., l'article L. 122-9 du Code de la consommation (défaut d'étiquetage ou défaut d'indication du prix) ou l'article 25 de la loi portant introduction du Code de la consommation (défaut d'information en matière de contrat de crédit).

605 Voy., p. ex., l'article L. 223-13 du Code de la consommation à propos du droit de rétractation mentionné à l'article L. 223-6 dudit Code.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

le développement des obligations d'information précontractuelles qui a amené la montée en puissance de la notion de dol par réticence. C'est parce qu'on considère qu'un contractant était tenu d'informer l'autre sur tel élément du contrat, qu'on peut admettre que l'absence d'information constitue une faute assimilable à un dol. Il convient cependant de rappeler que, en soi, le manquement à une obligation d'information ne suffit pas à constituer un dol par réticence : il faut encore que ce défaut d'information ait été fait consciemment, dans le but d'inciter l'autre à contracter, en sachant que l'élément dissimulé était déterminant de son consentement[606].

281. Restriction de la protection fondée sur les vices du consentement ? Dans d'autres cas, cependant, on peut se demander si le développement des techniques préventives de protection du consentement n'a pas pour effet de restreindre la possibilité pour le contractant de se prévaloir des vices du consentement du Code civil. Si toutes les mentions informatives prévues par la loi ont été respectées, le contractant ainsi dûment informé pourra-t-il encore soutenir qu'il a été victime d'une erreur sur les éléments qui ont été ainsi portés à sa connaissance ? Si le contractant a bénéficié, hors de la présence de l'autre partie, d'un délai de réflexion obligatoire avant la signature du contrat, ou d'un droit de se rétracter après cette signature, ce qui lui a permis de prendre conseil d'autres personnes, pourra-t-il encore accuser l'autre d'avoir abusé de sa légèreté sur le fondement de l'article 1118 ? Il est certain que, en elles-mêmes, le respect des règles protectrices n'exclut pas le recours aux règles du droit commun, mais elles peuvent rendre leur application plus difficile[607].

606 Voy. *supra*, n° 242.

607 Sur l'ensemble de ces questions, on pourra consulter, en droit français : C. Aubet de Vincelles, *Altération du consentement et efficacité des sanctions contractuelles*, préf. Y. Lequette, Paris, Dalloz, 2002.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le consentement, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 279-357
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Chapitre II
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

282. Problématique. Le principe de la liberté contractuelle ne signifie évidemment pas que toute personne est apte à passer n'importe quel contrat. D'abord, dans tous les systèmes juridiques, la loi interdit à certaines catégories de personnes de passer des contrats, ou certains contrats, soit pour protéger ces personnes supposées être en situation de faiblesse, soit, plus exceptionnellement, par méfiance à l'égard de ces personnes : ces personnes se voient privées, plus ou moins complètement, de la *capacité* de contracter, qui est une des conditions de validité des contrats (**Section 1**). Ensuite, il faut tenir compte de l'objet du contrat et des effets qu'on veut lui faire produire : si on a, en principe, le pouvoir d'engager par contrat sa personne et son patrimoine, on n'a pas normalement le pouvoir d'engager la personne ou le patrimoine d'autrui, même s'il existe des exceptions dans les deux sens. Même s'il n'apparaît pas en tant que tel dans l'article 1108 du Code civil, le *pouvoir* de contracter est aussi une condition de validité des contrats (**Section 2**).

SECTION 1. LA CAPACITÉ DE CONTRACTER

283. De la capacité aux incapacités. Dans l'article 1108 du Code civil, la capacité de contracter apparaît, après le consentement, comme la seconde condition de validité du contrat. Mais cette condition, développée ensuite aux articles 1123 à 1125-1 du Code civil, n'est traitée que sous un angle négatif. L'article 1123 du Code civil dispose en effet que « toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ». C'est dire que la capacité est le principe, et que ce n'est que par exception que certaines personnes sont déclarées incapables, l'incapacité, qui porte une grave atteinte à la liberté contractuelle, ne pouvant résulter que d'une disposition légale. L'article 1124 du Code civil énumère alors deux catégories d'incapables, les mineurs non émancipés et les majeurs protégés, qui font l'objet ailleurs dans le Code d'une réglementation détaillée. Ces deux catégories ne correspondent cependant qu'à un des types d'incapacités connus du droit luxembourgeois, celles que la doctrine appelle les *incapacités d'exercice* (**§ 1**), et qu'elle distingue des *incapacités dites de jouissance*, résultant de textes épars (**§ 2**). Alors que la première notion ne concerne que les personnes physiques, la seconde peut s'appliquer aussi aux personnes morales.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§ 1. Les incapacités d'exercice

284. Notion. Le Code civil n'utilise pas la terminologie « incapacités d'exercice ». L'expression a été inventée par la doctrine française (et reprise par la doctrine belge[608]) pour distinguer les incapacités visées à l'article 1124 du Code civil (mineurs et majeurs protégés) des incapacités dites de jouissance. L'idée – qu'il faudra développer – est que ces incapacités n'affectent que l'exercice des droits des personnes visées : le mineur et le majeur protégé ne se voient pas privés de la possibilité d'acquérir des droits (ou de devenir titulaire d'obligations) par contrat (un bien peut être acheté ou vendu à un mineur par exemple), mais ils ne peuvent pas passer le contrat par eux-mêmes, il faut que quelqu'un (leur tuteur par exemple) le passe en leur nom. Dans la tradition des pays du Code civil, la matière est considérée comme relevant du droit des personnes[609], et elle n'est donc pas habituellement traitée[610], ou seulement de manière sommaire[611], dans les cours de droit des contrats. Il convient cependant de poser ici, au regard du droit des contrats, et de manière comparative, la problématique générale de ces incapacités (**A**), avant de voir son application en droit luxembourgeois, dans les deux grandes catégories d'incapacités d'exercice, celle des mineurs et celles des majeurs protégés (**B**).

A) *La problématique générale des incapacités d'exercice*

285. Finalité des incapacités d'exercice. Dans tous les systèmes juridiques, les incapacités d'exercice qui frappent les mineurs et les majeurs protégés ont pour but de protéger des personnes qui, soit en raison de leur âge, soit en raison de l'altération de leurs facultés personnelles, sont jugées inaptes à gérer leurs affaires, et en particulier à passer elles-mêmes des contrats. Il y a de ce point de vue un lien assez étroit entre la condition de capacité et la condition de consentement posées à l'article 1108 du Code civil : l'incapacité, du moins lorsqu'elle repose sur l'âge ou sur des troubles mentaux, apparaît comme une sorte de présomption d'altération du consentement. Alors que, en l'absence d'un régime de protection,

608 Voy. p. ex. WÉRY, n° 269 et les auteurs cités.

609 Ce n'est pas nécessairement le cas partout : ainsi, dans le BGB, la « *Geschäftsfähigkeit* » fait partie intégrante de la théorie des actes juridiques (BGB, § 105 ff).

610 Voy. p. ex. pour le droit belge : VAN OMMESLAGHE, n° 130.

611 Voy. p. ex. en droit français TERRÉ, SIMLER, LEQUETTE, CHENEDE 2023, n°s 149 à 154 ; FLOUR, AUBERT, SAVAUX 2022, n°s 371 à 380. ; en droit belge : WÉRY, n°s 269 à 280.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

il appartient à la personne qui prétend qu'elle a passé le contrat sous l'empire d'un trouble mental de prouver que ce trouble existait au moment même de l'acte[612], la seule constatation de l'incapacité suffira à faire présumer que le consentement donné a été déficient et à justifier en principe la nullité de cet acte. Le droit comparé enseigne cependant que la frontière entre les deux situations ne relève pas de l'évidence, et que ce que nous traitons comme une absence de consentement (l'acte passé sous l'empire d'un trouble mental) peut, ailleurs, être considéré comme une incapacité[613].

Si elle est incontestablement dominante, cette finalité de protection de l'incapable n'est cependant pas la seule. À l'arrière-plan du droit des incapacités, on trouve aussi, plus ou moins accentuée, surtout pour les incapables majeurs, l'idée de protéger la famille proche, et notamment les héritiers potentiels de l'incapable, contre des actes qui pourraient leur nuire. Lorsque les enfants d'une personne âgée demandent son placement sous un régime de protection, c'est, souvent, pour éviter qu'elle ne dilapide le patrimoine dont ils doivent hériter. En droit luxembourgeois, cette idée de protection de la famille apparaît même dominante dans le cas, visé par le second alinéa de l'article 488 du Code civil, où la mise sous un régime de protection vise un majeur, dont les facultés physiques ou mentales ne sont pas altérées, mais qui par « sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales ». Le souci de protéger la famille, qui transparaît ici nettement, ne va cependant pas jusqu'à ouvrir aux membres de la famille (sauf à celui qui serait nommé tuteur ou curateur) la qualité pour agir en nullité des actes passé au mépris de cette incapacité.

286. Sanction des incapacités d'exercice. Cette finalité de protection a des conséquences très importantes en ce qui concerne le régime de la nullité : édictée pour protéger l'incapable, la nullité pour incapacité est logiquement une nullité relative, dans un système qui fait dépendre le régime de la nullité des intérêts protégés par la règle non respectée. Il en résulte en particulier que, comme l'affirme expressément l'article 1125 du Code civil, « les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui ils ont contracté », et cette solution semble se retrouver dans tous les droits européens. Seul l'incapable (après sa majorité ou après la fin du régime de protection), son représentant ou son curateur, peuvent invoquer cette nullité – et ceci même si le contrat s'avérait désavantageux pour le cocontractant. Nous verrons en outre que cette idée de protection de l'incapable a des répercussions quant aux effets de la nullité, qui ne soit pas se retourner contre l'incapable, et qui ne l'obligera pas à restituer ce qu'il a reçu.

612 Voy. *supra*, n° 216.

613 Voy. ainsi en droit allemand le BGB, § 104.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

287. Limites aux incapacités d'exercice. On enseigne que les incapacités d'exercice sont des incapacités générales. Il faut entendre par là qu'elles ne visent pas des actes déterminés, à la différence des incapacités dites « de jouissance », qui interdisent seulement à l'incapable de passer un ou plusieurs contrats limitativement énumérés par la loi. Cette caractéristique s'accorde avec la finalité de protection des incapacités, dans la mesure où les personnes incapables sont *a priori* jugées trop faibles pour donner un consentement valable. Cependant, cela ne signifie évidemment pas qu'un incapable ne peut passer aucun contrat. Il serait absurde, par exemple, d'interdire à un mineur d'acheter un livre, ou d'empêcher une personne âgée atteinte d'une légère déficience mentale de faire ses courses dans un supermarché. Il faut, dans la détermination des limites des incapacités, tenir compte à la fois de la gravité des actes passés et du degré d'inaptitude des personnes protégées. Tous les systèmes juridiques prennent en considération ces deux éléments, en mettant plus ou moins l'accent sur l'un ou l'autre[614]. Ainsi, s'agissant de l'incapacité des mineurs, le droit allemand (et les droits qui s'en sont inspirés) introduit au départ une distinction nette selon l'âge de l'enfant : en dessous de 7 ans, l'enfant est complètement incapable et tous les actes qu'il peut passer sont par principe nuls, sauf ceux de la « vie quotidienne »[615] ; au-delà, le mineur a une « capacité limitée », en ce qu'il peut accomplir seul certains actes (ceux qui lui procurent un bénéfice exclusif, ceux qu'il peut accomplir avec les moyens que lui ont procuré ses représentants légaux). Les droits des pays du Code civil ne connaissent pas cette distinction rigide fondée sur l'âge, mais ils autorisent le mineur à passer seul les « actes de le vie courante » (à quoi correspond, dans le droit anglais, les « *contracts for necessaries* »[616]), et pour savoir ce qui entre dans cette catégorie, on sera naturellement amené à tenir compte de l'âge de l'enfant : l'achat d'un vélo, par exemple, pourra être considéré comme un acte de la vie courante pour un adolescent, mais pas pour un enfant de 9 ans. S'agissant des majeurs protégés, de même, tous les systèmes connaissent une gradation entre les régimes de protection, allant de régimes lourds (pour les majeurs atteints de troubles mentaux graves et continus) interdisant par principe toutes sortes de contrats au majeur, à des régimes plus légers où l'incapacité est limitée à certains

614 Pour une présentation comparative, voy. SMITS, pp. 91 et s.

615 BGB, §§ 105 et 105a.

616 *Sale of Goods Act* 1979, Section 3 (2).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

actes graves, voire est remplacée par une protection occasionnelle contre certains actes désavantageux[617]. Cette gradation des régimes peut se combiner avec une catégorisation des contrats. Dans les pays du Code civil, la doctrine a ainsi élaboré une catégorisation tripartite des actes, passée en partie dans le Code civil du Luxembourg, en distinguant les actes de disposition (qui affectent la consistance du patrimoine : par exemple une vente ou un achat d'immeuble), les actes d'administration (qui sont des actes de gestion normale du patrimoine : par exemple la location d'un bien immobilier, la vente de biens mobiliers de peu de valeur), et les actes conservatoires (qui visent à la conservation du patrimoine : par exemple la souscription d'une assurance). Un autre élément à considérer, et qui est pris en compte de manière différente selon les systèmes, est le résultat économique concret du contrat passé : selon les cas, le contrat passé par l'incapable sera annulé par principe, même si l'incapable en retire un bénéfice, ou seulement s'il est désavantageux pour lui. C'est par exemple cette idée qui, en droit allemand, justifie que les mineurs de plus de 7 ans puissent passer seuls des contrats dont ils « tirent seulement un avantage juridique ». Dans le droit des incapacités luxembourgeois, il y a de nombreux cas où le contrat passé ne sera annulé que s'il est lésionnaire[618].

Ces différentes limites aux incapacités sont pensées dans l'intérêt de la personne protégée elle-même. Mais, à l'arrière-plan, on voit aussi se profiler les intérêts des tiers qui contractent avec les incapables, et qui ne sont pas nécessairement au courant de l'incapacité. Le fait de ne pas annuler les actes les moins graves, ou de ne prévoir leur nullité que s'ils sont désavantageux pour l'incapable est aussi un moyen de protéger les tiers de bonne foi. Pour les actes les plus graves, les tiers sont censés se renseigner sur la capacité de ceux avec qui ils contractent, en vérifiant leur âge, et, pour les majeurs, en s'assurant qu'ils ne sont pas soumis à un régime de protection. À cet effet, tous les systèmes juridiques, et en particulier le droit luxembourgeois, organisent une publicité des décisions judiciaires ouvrant un tel régime.

288. Remèdes aux incapacités. Le principe des incapacités du mineur et du majeur protégé est, comme on l'a dit, qu'elles n'affectent que l'exercice des droits, et non la possibilité d'en devenir

617 Ainsi dans le régime luxembourgeois de la sauvegarde de justice.

618 Voy. *infra*, n°s 289 et 290.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

titulaire. Un mineur ou un majeur incapable peuvent devenir propriétaire, créancier, débiteur par contrat, mais ils ne peuvent passer seuls les contrats qui leur permettent d'atteindre ce résultat. Il faut donc que quelqu'un puisse, soit passer les contrats à la place et au nom de l'incapable, soit l'aider à le passer. On peut concevoir que cette assistance ou cette représentation de l'incapable soit décidée au cas par cas, par un tribunal, lorsqu'il y a besoin de passer un acte au nom de la personne protégée : c'est le cas, en droit anglais, pour les mineurs, pour lesquels la loi n'organise pas de régime général de protection. Mais le plus souvent, dans les droits continentaux, et en particulier en droit luxembourgeois, la loi organise des régimes de protection des incapables, en déterminant par avance qui peut agir à la place ou aux côtés de l'incapable, et quels sont ses pouvoirs. La catégorisation des actes en fonction de leur gravité, qui sert à délimiter l'étendue de l'incapacité, peut aussi servir à déterminer les pouvoirs de la personne ou des personnes chargées d'assister ou de représenter l'incapable : ainsi, en droit luxembourgeois, le tuteur d'un majeur protégé ou d'un mineur peut passer seul un acte d'administration au nom de son pupille, mais il a besoin de l'autorisation du conseil de famille pour faire des actes de disposition, et, dans l'administration légale, de tels actes ne peuvent être faits que par accord entre les deux parents (ou avec l'autorisation du juge des tutelles) alors que les actes d'administration peuvent être faits par un parent agissant seul. Certains actes, cependant, apparaissent tellement graves qu'ils ne peuvent pas être faits par un représentant au nom de l'incapable : par exemple, on ne conçoit pas qu'un tuteur puisse faire une donation d'un bien appartenant à un mineur, parce que cela appauvrirait celui-ci sans aucune contrepartie. Pour ce type d'actes, l'incapacité est irrémédiable et se rapproche d'une incapacité de jouissance.

B) *Les deux catégories d'incapacités d'exercice en droit luxembourgeois*

289. Mineurs. Depuis la loi du 6 février 1975, la majorité, au Luxembourg, est fixée à l'âge de 18 ans (C. civ., art. 388), comme dans tous les pays européens aujourd'hui. En dessous de cet âge, le mineur est incapable, sauf s'il a été émancipé, ce qui, dans le droit actuel, ne peut être que l'effet du mariage intervenu avant la majorité.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

L'incapacité des mineurs est une incapacité générale d'accomplir les actes de la vie civile (et donc, en particulier, les contrats). Cependant, l'article 389-3 du Code civil réserve les cas où « la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ». Cela vise, notamment, les actes dits « de la vie courante ». Pour passer les autres contrats, un mineur a donc besoin d'être représenté. Cette représentation est normalement assurée par les parents, si au moins un des parents du mineur est vivant et non déchu de l'autorité parentale, dans le cadre du régime dit de l'administration légale. Selon les cas (C. civ., art. 389-1 et 389-2), cette administration légale est pure et simple (la représentation s'exerçant conjointement par les deux parents) ou placée sous le contrôle du juge des tutelles (qui doit autoriser les actes les plus importants). Si les parents sont tous deux décédés ou déchus de l'autorité parentale, ou si l'enfant n'a pas de filiation établie, on ouvrira une tutelle : le mineur sera alors représenté par son tuteur, assisté d'un conseil de famille, sous contrôle du juge des tutelles. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la tutelle des mineurs sont longuement réglées aux articles 394 à 475 du Code civil.

Si un mineur passe seul un acte pour lequel il aurait dû être représenté, cet acte peut être annulé, à la demande du mineur lui-même devenu majeur, ou, pendant la minorité, à la demande de son représentant légal. Cependant, cette nullité n'est pas soumise aux mêmes conditions selon que l'acte est un acte de disposition ou un acte d'administration (c'est-à-dire un acte que le tuteur ou un des parents aurait pu faire sans autorisation). Dans le premier cas, l'incapacité suffit à entraîner la nullité, et le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation : on parle parfois de nullité de droit ou de nullité « en la forme ». Pour les actes d'administration en revanche (et *a fortiori* pour les actes conservatoires) une vieille jurisprudence française, jamais remise en cause, considère que la nullité ne peut être prononcée que si l'acte est lésionnaire (la disproportion étant ici appréciée par le juge)[619]. Cette solution devrait s'appliquer également au Luxembourg. On peut du reste la rattacher à l'article 1305 du Code civil selon lequel « la simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé contre toutes sortes de conventions ».

[619] Cass. fr. (civ.), 18 juin 1844, *D.*, 1944, 1, p. 123 ; Cass. fr. (civ.) 25 mars 1861, *D.P.*, 1861, 1, p. 202, *GAJC*, t. 1, n°s 53-54.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

290. Majeurs protégés. Il s'agit, selon la formule de l'article 488 du Code civil, de majeurs « qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts ». Il s'agira le plus souvent d'une altération des facultés mentales, mais le texte peut également s'appliquer à des personnes atteintes d'une infirmité physique lourde, qui ne peuvent pas matériellement, exprimer leur volonté de manière verbale ou écrite[620]. Comme nous l'avons vu précédemment[621], lorsqu'une personne atteinte d'un trouble mental passe un contrat sans avoir conscience de la portée de son acte, ce contrat peut être annulé pour absence de consentement sur le fondement de l'article 489 du Code civil. Mais, si l'altération des facultés personnelles n'est pas épisodique, il peut être nécessaire de placer la personne sous un des régimes de protection prévus par les articles 488 et suivants du Code civil. Ces textes sont issus d'une loi du 11 août 1982, qui a complétement réorganisé la matière en s'inspirant du modèle français mis en place en 1968[622]. Une nouvelle réforme est actuellement en cours de préparation.

Dans le droit luxembourgeois actuel, il existe trois régimes de protection, gradués suivant l'importance de l'altération. Le premier, et le plus léger, est la *sauvegarde de justice*. Ce régime, qui peut être ouvert par simple déclaration d'un médecin au juge des tutelles, ne rend pas incapable la personne protégée : cette personne peut continuer à passer des contrats, mais ceux-ci pourront être « rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès » sans qu'il soit nécessaire de prouver que, au moment où l'acte a été passé, la personne était sous l'empire d'un trouble mental (C. civ., art. 491-2). La lésion dont il est question ici est un déséquilibre dont l'importance est appréciée au cas par cas par le juge, et qui n'a pas à répondre aux conditions restrictives de l'article 1118 du Code civil. La notion d'excès s'entend d'un acte qui n'est pas nécessairement disproportionné en lui-même, mais qui apparaît déraisonnable par rapport aux capacités patrimoniales de son auteur. Les deux autres régimes, la *tutelle* et la *curatelle*, supposent, eux, une décision judiciaire, rendue par le juge des tutelles à la demande de diverses personnes, et ils ont pour effet de rendre le majeur incapable de contracter. Cette incapacité n'est

620 Dans ce cas, l'incapacité n'est pas un remède à l'altération du consentement, elle est un moyen de permettre à l'incapable de passer des actes qu'il n'a pas la possibilité de passer lui-même.

621 Voy. *supra*, n°s 215 et s.

622 Ce modèle français a, depuis, été profondément réformé par une loi de 2007.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

cependant pas aussi étendue dans l'un et l'autre régime. La tutelle, qui est le régime le plus lourd, se traduit par une incapacité générale du majeur, qui doit être représenté par son tuteur pour tous les actes de la vie civile (sous réserve des actes que le juge, en ouvrant la tutelle ou postérieurement, lui permettrait d'accomplir seul ou avec la simple assistance du tuteur) ; elle est organisée sur le même modèle que la tutelle des mineurs. Les actes passés par le majeur en tutelle sont frappés d'une nullité relative, sans qu'il soit nécessaire de prouver ni l'existence d'un trouble mental, ni le caractère désavantageux de l'acte pour l'incapable. En revanche, le majeur en curatelle peut continuer à passer des contrats, mais, pour les actes les plus graves (actes de disposition), il doit être assisté par son curateur. Pour les autres actes (actes d'administration) : il bénéficie de la même protection que les majeurs sous sauvegarde de justice (rescision pour lésion ou réduction pour excès). Les actes de disposition passés par le majeur sous curatelle sans l'assistance de son curateur sont en principe nuls, mais, selon un arrêt de la Cour d'appel, cette nullité est facultative pour le juge qui jouit d'un pouvoir d'appréciation, en tenant compte de la bonne ou de la mauvaise foi du tiers, et du caractère plus ou moins désavantageux de l'acte pour le majeur[623].

§2. Les incapacités de jouissance

291. Notion. Pas plus que la notion d'incapacité d'exercice, celles de « capacité de jouissance » ou d'« incapacité de jouissance » ne se trouvent dans le Code civil. Ces notions sont le produit d'une construction doctrinale, qui date de la fin du XIXe siècle, et qui vise à regrouper sous une même étiquette diverses situations où une personne se voit purement et simplement interdire de passer certains types de contrats – donc de devenir titulaire des droits ou débiteur des obligations que ces contrats pourraient faire naître. Le point commun à toutes ces situations, qui les distingue nettement des incapacités d'exercice, est que ces incapacités sont irrémédiables : non seulement l'incapable ne peut pas passer lui-même les contrats considérés, mais personne ne peut le faire en son nom ou à sa place. Au-delà, la notion d'incapacités de jouissance recouvre une grande diversité de situations, tant quant à la finalité

[623] Cour d'appel, 24 octobre 2012, n° 36995, obs. O. Poelmans, *D.A.O.R.*, 114/12. Cette solution, qui ne résulte pas clairement de l'article 510-1 du Code civil, fait écho à celle qui figure maintenant dans le Code civil français à l'article 465 2° (texte issu de la loi du 5 mars 2007).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

des interdictions que quant à leur sanction. Il faut au moins distinguer selon que l'incapacité frappe une personne physique ou une personne morale.

A) *Les incapacités de jouissance des personnes physiques*

292. Spécialité. À la différence des incapacités d'exercice qui frappent le mineur ou le majeur protégé, les incapacités de jouissance frappant les personnes physiques ne visent, dans le droit actuel, que des actes juridiques déterminés. En effet, interdire par principe à une personne de passer des contrats, par elle-même ou par l'intermédiaire d'un représentant, reviendrait à l'empêcher de devenir titulaire de droits et d'obligations, donc, d'une certaine manière, à la priver de sa personnalité juridique. Or dans nos conceptions modernes, il paraît inconcevable qu'un être humain ne soit pas reconnu comme une personne à part entière, ce qui implique l'aptitude à devenir titulaire de droits et d'obligations.

Historiquement, cela n'a pas toujours été le cas. Les esclaves, dans l'Antiquité, et jusqu'au XIXe siècle dans les colonies de divers pays occidentaux, n'étaient pas considérés, du point de vue juridique, comme de véritables personnes pouvant devenir propriétaires, créanciers ou débiteurs, ils étaient considérés comme des éléments du patrimoine de leur maître. Mais il est vrai que le Luxembourg n'ayant jamais eu de colonies, n'a jamais eu à abolir l'esclavage[624]. En revanche, ce pays a connu, dans la première version de son Code civil, l'institution de la « mort civile » qui frappait les condamnés à certaines peines dites « afflictives » (notamment les condamnés à mort dans l'attente de leur exécution et les condamnés au bagne). Selon l'article 25 du Code civil de 1804, le « mort civil » perdait la propriété de tous ses biens, ne pouvait plus en recevoir, ni en donner, ni les transmettre. Il était donc frappé d'une incapacité de jouissance généralisée. La mort civile a été abolie au Luxembourg par la Constitution de 1848[625].

293. Diversité. Les situations correspondant à la notion d'incapacité de jouissance sont extrêmement diverses en droit luxembourgeois. Elles correspondent à deux finalités différentes. Certaines correspondent à un renforcement d'une incapacité d'exercice, visant à interdire que des actes particulièrement graves, causant un sacrifice sans contrepartie, ne puissent être passés, non seulement par un mineur ou un majeur incapable lui-même, mais aussi par son représentant, même muni de toutes les autorisations possibles : c'est ainsi que, dans aucune circonstance, le représentant légal d'un mineur ou d'un majeur protégé ne peut faire une donation des biens de

624 En France, l'esclavage a été aboli par un décret du 27 avril 1848.

625 Elle l'a été en France en 1854, et en Belgique dès 1831.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'incapable, ni donner un cautionnement en son nom. La finalité est ici clairement la protection – renforcée – de l'incapable lui-même, et la sanction d'une telle incapacité doit logiquement être, comme dans le cas des incapacités d'exercice, la nullité relative de l'acte interdit. Mais les incapacités de jouissance les plus nombreuses correspondent à une tout autre finalité, qui est plutôt de protéger les cocontractants, les tiers, ou la collectivité, d'une personne dont on se méfie. Ces incapacités peuvent être considérées comme des aspects particuliers de l'ordre public[626]. Le Code civil connaissait, depuis l'origine, une incapacité de ce type avec l'incapacité frappant les médecins et autres personnels de santé, de bénéficier d'un testament ou d'une donation de la part d'une personne qu'ils ont traité pendant la maladie dont elle meurt (C. civ., art. 909). Cette incapacité (qui frappe également les ministres des cultes) vise bien sûr à éviter que ces personnes n'usent de leur influence pour extorquer au malade une libéralité. Il ne s'agit donc nullement ici de protéger l'incapable, mais la personne malade qui serait tentée de faire la donation ou le testament. Bien entendu, pour que l'interdiction soit efficace, il convient que personne ne puisse accepter la libéralité au nom et à la place du médecin, de l'infirmier(e) ou du prêtre. À cet effet, l'article 911 du Code civil annule les libéralités qui seraient faites au profit d'une « personne interposée » et présume que c'est le cas des libéralités faites à certains membres de la famille proche. On retrouve la même logique dans un texte plus récent, issu d'une loi du 11 août 1982, et figurant à l'article 1125-1 du Code civil, interdisant aux personnels des maisons hébergeant des personnes âgées ou des malades mentaux de se rendre acquéreur des biens appartenant à ces personnes ou de prendre à bail le logement qu'elles occupaient avant leur admission. Là encore, l'interdiction est justifiée par une certaine défiance à l'égard de ces personnels et un souci de protéger les personnes âgées ou les malades mentaux qui, en raison de leur état de faiblesse, pourraient céder trop facilement aux pressions des soignants. Comme dans le cas de l'incapacité de l'article 909 du Code civil, il s'agit d'une incapacité irrémédiable, personne ne pouvant passer au nom de l'incapable les actes qui lui sont interdits, et on retrouve à l'article 1125-1, alinéa 2, du Code civil des présomptions analogues d'interposition de personne. La finalité particulière de ces incapacités postule que la sanction ne doit pas être une nullité relative qui ne pourrait être

626 Dans ce sens I. Maria, *Les incapacités de jouissance*, *op. cit.*, n°s 487 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

invoquée que par l'incapable : pour que la règle soit efficace, il faut que la nullité puisse également (et principalement !) être invoquée par le cocontractant, mais aussi par tout intéressé[627]. On est donc en présence d'une nullité absolue.

B) *Les incapacités de jouissance des personnes morales*

294. Capacité relative. Même si elle est aujourd'hui considérée, dans les pays du Code civil, comme une « réalité », qui ne dépend pas d'une reconnaissance expresse par le législateur[628], la personnalité juridique des groupements n'est pas nécessairement conçue comme devant être aussi complète que celle des personnes physiques. D'une manière générale, les groupements dotés de la personnalité morale sont créés pour atteindre un but déterminé (économique, culturel, humanitaire, religieux, etc.), et la capacité de passer des actes juridiques ne leur est reconnue que dans la mesure où des actes entrent dans le champ de leur activité[629]. Il existe ici un principe de spécialité des personnes morales, dont la portée est cependant très différente d'un type de groupement à l'autre, en fonction des textes qui les régissent. En droit français, le nouvel article 1145 du Code civil dispose à cet égard que « [l]a capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles ». En droit luxembourgeois, le principe de spécialité est particulièrement marqué pour les associations et les fondations, groupements sans but lucratif : l'article 15 de la loi du 21 avril 1928[630] dispose que « l'association ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée », ce qui implique la nullité de tous contrats par lesquels une association prétendrait acquérir des droits sur un immeuble complètement extérieur à son activité.

627 C'est pourquoi il est regrettable que la règle de l'article 1125-1 ait été intégrée dans le Code, sur le modèle français, dans la section sur les incapacités, juste après l'article 1125 qui dispose que « les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui elles ont contracté ».

628 La question de savoir si la personnalité juridique des groupements est une « réalité » ou une « fiction » a été abondamment discutée, depuis le XIX[e] siècle, d'abord en Allemagne (F.-C. VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, Berlin, 1840, trad. française par C. GUÉNOUX, Paris, 1841, pp. 234 et s.), puis en France (L. MICHOUD, *La théorie de la personnalité morale et son application en droit français*, Paris, LGDJ, 1906). La Cour de cassation française a nettement consacré la théorie de la réalité [Cass. fr. (2[e] civ.), 28 janvier 1954, *Comité d'établissement de Saint-Chamond*, n° 54-07081].

629 Sur cette relativité de la personnalité juridique des groupements, voy. J. ROCHFLED, *Les grandes notions du droit privé*, coll. Thémis droit, Paris, PUF, 2011, pp. 85 et s.

630 Mémorial A n° 23, 5 mai 1928, http://eli.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1928/04/21/n2.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

L'article 16 de la même loi soumet par ailleurs à autorisation ministérielle le droit pour les associations de recevoir des libéralités entre vifs (donations) ou testamentaires. Ces règles sont également applicables aux fondations (L. 21 avril 1928, art. 35 et 36). L'article 910 soumet de même à autorisation les libéralités au profit des personnes morales de droit public. Il s'agit là de restrictions analogues à celles qu'on désigne pour les personnes physiques sous le nom d'incapacités de jouissance : nul ne peut passer les actes interdits ou non autorisés au nom de la personne morale, et ces interdictions, justifiées par des considérations d'intérêt général, doivent être sanctionnées par des nullités absolues. Pour les sociétés, le principe de spécialité est beaucoup plus théorique : certes, les représentants des sociétés ne peuvent en principe que passer des actes qui entrent dans l'objet social[631], mais il s'agit plus d'une restriction de pouvoir des représentants (destinée à protéger les associés contre les abus de pouvoir des représentants[632]) que d'une limite à la capacité de la société elle-même, rien n'interdisant en principe à la société de passer des contrats étrangers à l'objet social si tous les associés sont d'accord. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'un acte ne correspondant pas à l'objet social pourra, en soi, être frappé de nullité : ainsi, en droit français, il peut en aller ainsi d'un cautionnement donné par une société (même du consentement de tous les associés) pour garantir les engagements d'un de ses associés ou dirigeants, soit en vertu de textes spéciaux[633], soit si l'acte est contraire à l'intérêt social[634]. Même si le droit luxembourgeois ne contient aucun texte à cet égard, la solution jurisprudentielle pourrait semble-t-il y être transposée sans difficulté. De même, sauf cas exceptionnel, une société commerciale, conçue pour procurer des bénéfices à ses associés, ne devrait pas pouvoir faire des libéralités à des tiers[635]. Ces exemples ne sont donnés ici que pour illustrer la diversité des limites qui peuvent être apportées à la capacité des personnes morales de passer des actes juridiques. Ils permettent

631 Voy., p. ex., pour les sociétés anonymes l'article 53 de la loi du 10 août 2015, pour les sociétés à responsabilité limitée l'article 191*bis*.

632 Sauf à signaler que, dans certaines sociétés, les actes dépassant l'objet social peuvent être opposables à la société si le cocontractant ignorait ce dépassement (L. 10 août 1915, art. 60*bis* red. L. 23 novembre 1972).

633 Pour les sociétés anonymes : C. comm. fr., art. L. 225-4 ; pour les sociétés à responsabilité limitée : C. comm. fr., art. L. 223-21.

634 Cass. fr. (3e civ.), 12 septembre 2012, n° 11-17.948.

635 Mais il en irait autrement si la libéralité entrait, même indirectement, dans l'objet social : ainsi pour les activités de mécénat visant à renforcer l'image de marque de l'entreprise (Wéry, n° 280).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

en même temps de comprendre la distinction qu'il convient de faire entre la capacité (de la personne morale elle-même) et le pouvoir (des dirigeants).

SECTION 2. LE POUVOIR DE CONTRACTER

295. Notion. Il n'est pas suffisant de savoir si la personne qui passe un contrat est, d'une manière générale, apte à passer les actes juridiques du type considéré (par exemple, un adolescent peut-il seul acheter un vélo ? Une association peut-elle acheter un immeuble ?) – question à laquelle répondent les règles de capacité précédemment évoquées. Il faut encore se demander si le contractant est apte à engager par l'acte précis qu'il passe les biens concernés par cet acte ou la personne sur laquelle cet acte aura des répercussions. Par exemple, alors même que je suis, d'une manière générale, tout à fait capable, et que, en conséquence, je peux valablement passer un contrat de vente d'immeuble, ou emprunter de l'argent, etc. il paraît évident que je ne peux pas, en principe, vendre tel immeuble qui ne m'appartient pas, emprunter de l'argent en convenant avec le prêteur que ce n'est pas moi mais mon ami(e) qui le remboursera. Dans ces deux cas, on dira que, alors même que je suis capable, je n'ai pas le pouvoir de vendre le bien d'autrui, ou de charger un tiers de rembourser mon prêt. Le verbe « pouvoir », appliqué aux actes juridiques, peut donc avoir deux sens très différents selon le contexte dans lequel on l'emploie. il y a une grande différence entre les deux propositions : « le mineur ne peut pas vendre un immeuble qui lui appartient » et « le tuteur ne peut pas vendre seul un immeuble appartenant au mineur ». La première affirmation se réfère à la *capacité* du mineur (son aptitude à passer telle ou telle catégorie d'actes juridiques), la seconde est relative au *pouvoir* du tuteur (son aptitude à engager par ses actes tel ou tel bien).

Bien qu'elle soit d'une importance pratique considérable, cette notion du pouvoir de contracter ne fait l'objet, dans le Code civil du Luxembourg, d'aucune réglementation générale. On n'en trouve que des applications particulières, par exemple dans les textes définissant les pouvoirs des représentants légaux des incapables, ou dans les articles relatifs au mandat « acte par lequel une personne donne à une autre le *pouvoir* de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » (C. civ., art. 1984). On trouve cependant, au sein des règles générales du droit des contrats, un texte, curieusement placé

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

à la suite des textes sur les vices du consentement, l'article 1119 du Code civil, selon lequel « on ne *peut*, en général, s'engager ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même ». Bien qu'on le lise surtout aujourd'hui comme déterminant les effets du contrat à l'égard des tiers[636], cet article pose, d'abord, une règle de validité des contrats, en distinguant le pouvoir (normal) de passer des contrats pour soi-même (**§ 1**) du pouvoir (exceptionnel) de passer des contrats pour autrui (**§ 2**).

§1. Le pouvoir de passer des contrats pour soi-même

296. Principe. Le principe est que, à partir du moment où on est capable, on peut, par ses actes, engager valablement sa personne ou son patrimoine. On peut aussi bien, pour reprendre les termes de l'article 1119 du Code civil « s'engager », c'est-à-dire se rendre personnellement débiteur, que « stipuler » (c'est-à-dire se rendre créancier[637]), on peut plus largement faire produire à un contrat n'importe quel effet, pourvu bien sûr qu'il soit licite, et qu'il ne concerne que « soi-même », c'est-à-dire sa personne ou ses biens.

297. Exceptions. Dans certains cas exceptionnels, une personne, alors même qu'elle est parfaitement capable, se trouve privée du pouvoir d'engager par contrat des biens qui lui appartiennent. En droit civil, le cas le plus caractéristique est celui de l'article 215, alinéa 2 du Code civil, texte introduit au Luxembourg en 1972[638] sur le modèle français de la réforme des régimes matrimoniaux de 1965. Ce texte, qui s'applique quel que soit le régime matrimonial des époux, prévoit que « les conjoints ne *peuvent* l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni ». L'époux qui vend l'appartement dans lequel il vit avec son conjoint et éventuellement avec les enfants doit donc s'assurer du consentement de l'autre, et ceci même si le bien lui appartient en propre[639]. La sanction du défaut de consentement du conjoint est différente de celle qui sanctionne une incapacité, tant d'exercice que de jouissance : il

636 Voy. *infra*, n° 956.

637 Dans le langage moderne, ce terme a pris un autre sens : « stipuler », c'est, d'une manière plus générale, prévoir quelque chose dans un contrat, et une « stipulation » est aujourd'hui synonyme de clause contractuelle, quel qu'en soit le contenu.

638 L. 12 décembre 1972, Memorial 1972, 1909.

639 C'est-à-dire s'il en était propriétaire par succession ou s'il l'a reçu par donation ou testament.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

s'agit d'une nullité relative, mais qui ne peut être invoquée que par le conjoint n'ayant pas donné son consentement dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte ; la nullité ne peut donc être demandée ni par le conjoint vendeur ni par l'acheteur[640]. D'autres restrictions importantes au pouvoir de contracter sur ses propres biens sont liées aux procédures ouvertes en cas de non-paiement des dettes d'une personne, qui se traduisent par un blocage plus ou moins étendu des biens dans son patrimoine, en vue d'assurer le paiement des créanciers : c'est ainsi que la saisie d'un ou de plusieurs biens d'un débiteur a pour effet de les rendre inaliénables par le saisi[641] ; de même, l'ouverture d'une procédure de faillite contre un commerçant (personne physique ou morale) a pour effet de le dessaisir de l'administration de tous ses biens, qui sont désormais gérés par un curateur nommé par le tribunal (C. comm., art. 444). Le texte prévoit que les actes passés en violation de ces règles sont « nuls de droit », sans préciser qui peut invoquer la nullité[642]. D'une manière plus générale, la notion de défaut de pouvoir permet de rendre compte de tous les cas où un bien est frappé d'inaliénabilité, soit par l'effet d'une disposition légale[643], soit par une stipulation conventionnelle[644]. Enfin, il faut évoquer tous les cas où un bien se trouve être la propriété commune de plusieurs personnes, qu'il s'agisse de biens indivis (par exemple, entre plusieurs héritiers dans l'attente du partage de la succession) ou des biens dépendant de la communauté de conjoints mariés sans contrat de mariage. On trouve dans le Code civil de multiples règles définissant les pouvoirs de chaque copropriétaire sur les biens communs[645].

640 Dans ce sens : Cass., 23 janvier 2014, n° 5/14, n° 3278. Trib. Luxembourg, 14 juillet 2023, n° TAL-2021-08344.

641 Voy. p. ex. pour la saisie immobilière : N.C.P.Civ., art. 823.

642 Destinée à protéger les créanciers, cette nullité ne devrait logiquement pouvoir être invoquée que par les organes de la procédure qui sont chargée de représenter les intérêts de ceux-ci. Dans le même esprit, la jurisprudence française estime que les actes passés par le débiteur soumis à la procédure en violation du dessaisissement sont inopposables à la procédure [Cass. fr. (comm.), 23 mai 1995, n° 93-16.930].

643 Exemple typique du droit luxembourgeois : l'inaliénabilité par le Grand-Duc des biens dépendant du fidéicommis grand-ducal [Décret grand-ducal portant coordination du Pacte de famille du 30 juin 1783, art. 10 (Memorial B n° 51, 23 juin 2012)].

644 Bien qu'il n'existe pas au Luxembourg d'équivalent de l'article 900-1 du Code civil français, les clauses d'inaliénabilité sont reconnues par la jurisprudence luxembourgeoise à condition d'être temporaire et de correspondre à un intérêt sérieux et légitime (voy., p. ex., Trib. Luxembourg, 7 juin 2001, n° 67-952).

645 Voy pour l'indivision : C. civ., art. 815-2 et s., issus de la loi du 8 avril 1993 ; pour la communauté entre conjoints : C. civ., art. 1421 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Les différents exemples donnés permettent de voir ce qui distingue le défaut de pouvoir d'une incapacité. La différence tient à ce que l'interdiction qui est faite à la personne de passer tel ou tel acte ne tient pas, dans les cas de défaut de pouvoir, à des considérations touchant à cette personne (qui mériterait une protection particulière ou dont on se méfierait), mais plutôt au statut des biens objets des actes sur lesquels on veut, pour des raisons diverses (protection de la famille, protection des créanciers, protection du ou des autres propriétaires du bien, etc.) assurer un certain contrôle. Le régime juridique du défaut de pouvoir n'est pas uniforme, il varie grandement selon la finalité de la règle. Dans certains cas, le défaut de pouvoir est irrémédiable, aucun acte ne pouvant être fait sur le bien par quiconque (inaliénabilités), mais la plupart du temps, les actes interdits au titulaire du droit pourront être faits avec une autorisation (du conjoint, du copropriétaire indivis, etc.) ou par un représentant (curateur à la faillite). De même, il n'existe pas de régime unique des sanctions du défaut de pouvoir : tantôt l'acte est nul, d'une nullité absolue ou d'une nullité relative ne pouvant être soulevée que par le tiers dont les intérêts sont protégés (conjoint), tantôt l'acte est inopposable à ce tiers (ce qui est une sanction typique du défaut de pouvoir, que nous retrouverons dans les cas de défaut ou de dépassement de pouvoir d'un représentant).

§2. Le pouvoir de passer des contrats pour autrui

298. Principe et exception. En principe, on n'a pas le pouvoir d'engager les biens ou la personne d'autrui par les contrats qu'on passe (**A**). Mais, dans de nombreux cas, on peut se faire attribuer un tel pouvoir, soit par l'effet d'une disposition légale, soit par une décision judiciaire, soit par un contrat avec la personne concernée : c'est le mécanisme de la représentation (**B**). Dans les deux cas, se pose la question des sanctions qui frappent l'acte accompli sans pouvoir, ou en dehors des pouvoirs conférés au représentant (**C**).

A) *Le principe : l'absence de pouvoir de contracter pour autrui*

299. Article 1119 du Code civil. L'article 1119 du Code civil selon lequel « on ne peut, en général, s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même » est surtout lu, aujourd'hui, comme un texte relatif aux effets du contrat : un contrat ne peut pas, en principe, faire naître pour les tiers de droits ni d'obligations. L'article 1119 du Code civil apparaît ainsi comme une expression, à côté de l'article 1165 du Code civil, du principe dit de l'effet relatif du contrat[646]. Cependant, il ne faut pas oublier que, comme en témoigne sa place dans le Code, le texte pose

[646] Sur lequel voy. *infra*, n°s 953 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

d'abord une règle de validité du contrat : il signifie d'abord qu'un contrat par lequel une personne prétendrait passer un contrat affectant la personne ou les biens d'un tiers serait nul, ou du moins ne pourrait pas produire les effets recherchés[647], à moins bien sûr qu'il n'en ait reçu le pouvoir comme nous le verrons plus loin.

300. Fausse exception : la promesse de porte-fort. Immédiatement après l'article 1119, l'article 1120 du Code civil lui apporte une apparente exception en posant que « néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ». Cependant, loin d'être une exception au principe précédent, ce texte en est en réalité une application. L'hypothèse est qu'une personne qui n'a reçu aucun pouvoir d'une autre (ou qui est en dehors des pouvoirs qu'elle en a reçus) promet que cette autre personne fera ou ne fera pas quelque chose. Par exemple, je sais que vous cherchez à vendre votre appartement ; je découvre par hasard un acheteur potentiel, qui me fait une offre d'achat à un prix très intéressant ; je n'ai pas le moyen de vous joindre sur le moment, mais je pense que vous ne voudriez pas laisser passer l'occasion ; je dis alors au tiers que j'accepte pour vous (alors même que vous ne m'avez donné aucun mandat) et que je me « porte-fort » que vous ratifierez[648]. Bien entendu, dans un tel cas, ce contrat que je passe avec l'acquéreur potentiel ne vous lie pas : vous pouvez toujours dire que vous n'êtes pas d'accord, que vous ne voulez plus vendre ou que le prix ne vous convient pas. La vente que j'ai prétendu faire pour vous, vous est complètement inopposable : c'est l'application directe du principe de l'article 1119 du Code civil. Vous ne serez tenu(e) que si vous ratifiez la vente – ce que peut toujours faire la personne non engagée en cas de défaut ou de dépassement de pouvoir de son prétendu représentant[649]. On considérera alors que la vente a été passée avec vous depuis le début, sans qu'il soit nécessaire que l'acquéreur réitère son consentement. Dans le cas d'une telle ratification, qui n'est soumise à aucune forme particulière, je serai alors libéré, sans avoir à garantir l'exécution du contrat, qui sera alors le vôtre[650]. Cependant, si le contrat que j'ai passé

[647] Sur les sanctions du défaut de pouvoir, voy. *infra*, n°s 309 et s.

[648] La situation serait la même si vous m'aviez donné mandat, mais pour vendre à un prix inférieur à celui que me propose l'acquéreur.

[649] Voy. *infra*, n°s 312 et s.

[650] Cour d'appel, 17 janvier 2001, *Pas.*, 32, p. 19, qui admet cependant que le porte-fort peut aussi s'engager à garantir l'exécution (voy. *infra*, n°s 312 et s.).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

avec l'acquéreur ne vous engage pas, il m'engage, moi, car je lui ai promis quelque chose, j'ai promis que vous ratifieriez[651]. Donc, si vous ne ratifiez pas, c'est moi qui ai manqué à mon obligation – considérée comme une obligation de résultat – et l'acquéreur pourra me demander des dommages et intérêts pour compenser le préjudice qu'il subit du fait de ses attentes déçues (par exemple si, croyant à la ratification, il a manqué une autre occasion d'achat). C'est précisément ce que dit l'article 1120 du Code civil, qui prévoit « l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement ». Sur tous ces points, le droit luxembourgeois ne s'écarte pas du droit français[652] ni du droit belge[653], dont les solutions ont été reprises dans le nouvel article 1204 du Code civil français, et dans l'article 5.106 du nouveau Code civil belge.

Les utilisations de la promesse de porte-fort sont multiples[654]. Traditionnellement, cette technique est utilisée au stade de la formation d'un contrat, comme dans l'exemple ci-dessus, pour tourner le défaut ou le dépassement de pouvoir d'un mandataire. C'est à ce « porte-fort de formation » qu'on principalement songé les rédacteurs du Code civil, en prévoyant expressément le cas où le tiers non engagé ne ratifie pas le contrat passé pour lui. Mais la formulation de l'article 1120 du Code civil est beaucoup plus générale et laisse la porte ouverte à d'autres utilisations. Dans la période récente, on a imaginé d'utiliser la promesse de porte-fort comme une garantie d'exécution d'un contrat déjà formé : le promettant s'engage ici envers un créancier à ce que son débiteur exécute son engagement. Si le débiteur n'exécute pas, celui qui s'est porté fort devra indemniser le créancier pour le préjudice qu'il subit (les dommages et intérêts étant normalement équivalents à la dette impayée). L'opération – connue depuis longtemps dans les droits allemand et suisse sous le nom de « *Garantievertrag* », ressemble très fortement, dans sa finalité économique, à un cautionnement, mais la technique utilisée est différente : au lieu que la caution s'engage directement à payer la dette du débiteur, le porte-fort s'engage à indemniser le créancier si le débiteur ne le paye pas. Il en résulte que les règles du cautionnement sont en principe inapplicables à cette opération. La jurisprudence luxembourgeoise a reconnu sans ambigüité la validité de cette promesse de porte-fort sûreté[655], alors

651 Cour d'appel, 26 février 1897, 4, p. 343. Le tiers pour lequel on s'est porté fort, est libre de tout engagement jusqu'au moment de la ratification, mais le porte-fort ainsi que la partie avec laquelle il a contracté, sont immédiatement liés dans les termes du contrat, et les engagements y contenus sont exigibles et exécutoires en dehors de la ratification du tiers.

652 Sur lequel voy., p. ex., Flour, Aubert, Savaux 2022, n°s 693 à 696.

653 Sur lequel voy. not. Wéry, n°s 914 à 921.

654 Voy. les nombreux exemples donnés par Van Ommeslaghe, t. I, n°s 523 et 524.

655 Cour d'appel, 17 janvier 2001, *Pas.*, 32, p. 19 (qui précise néanmoins que cette utilisation est exceptionnelle) ; Cour d'appel, 19 juin 2019, n° 44788 ; Trib. Luxembourg, 25 avril 2023, n° TAL-2021-09224. Sur cette utilisation du porte-fort comme garantie en droit luxembourgeois, voy. A. Cuny de la Verrière, *Sûretés et garanties au Grand-Duché de Luxembourg, Vademecum*, coll. Promoculture, Bruxelles, Larcier, 2014, n° 93. H. Westendorf et O. Poelmans, « La promesse de porte-fort – Notion et diversité », *JN Obligations*, 2021/1-2, pp. 108-112.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

que la Cour de cassation française en réduit considérablement l'efficacité[656]. La Cour de cassation belge a également reconnu ce porte-fort d'exécution sur le fondement de l'autonomie de la volonté[657].

301. **Stipulation pour autrui (renvoi).** S'il n'est pas possible de passer un contrat rendant un tiers débiteur ou produisant des effets sur ses biens, l'article 1121 du Code civil prévoit qu'on peut, par un contrat, faire naître un droit de créance au profit d'un tiers. C'est ce qu'on appelle une stipulation pour autrui, dont l'exemple le plus caractéristique est l'assurance-vie souscrite au profit d'un tiers bénéficiaire. Cependant le bénéficiaire d'une telle stipulation n'est en aucune manière considéré comme une partie au contrat : le contrat n'est pas passé pour lui, mais simplement à son profit. C'est pourquoi l'étude de ce mécanisme sera faite au titre des effets du contrat, et non dans le cadre des règles relatives au pouvoir de contracter pour autrui[658].

B) *Limite : la représentation, pouvoir de contracter pour autrui*

302. **Notion.** Mécanisme connu de tous les systèmes juridiques modernes, et d'une importance considérable en pratique, la représentation ne faisait l'objet, dans le Code civil de 1804, d'aucune réglementation générale, et il en va toujours ainsi au Luxembourg. Le Code l'aborde principalement à propos du mandat, contrat défini comme ayant pour objet la représentation d'une personne par une autre, et à partir duquel, en droit français, s'est construite la théorie de la représentation[659]. Dans les autres pays européens, la notion de représentation est détachée du contrat de mandat, et elle est conçue comme un élément de la théorie générale de l'acte juridique ou des obligations. Par exemple, en droit allemand, la représentation est réglementée, d'une manière générale, dans la partie préliminaire du BGB à propos de l'acte juridique *Vertretung und Vollmacht*, § 164 à 181), et la plupart des codifications modernes contiennent une telle réglementation générale, comme du reste les textes internationaux (Unidroit) et les projets européens (PDEC, DCFR). Lors de la réforme française de 2016, on a intégré dans le code un paragraphe relatif à la représentation (art. 1153 à 1161), immédiatement après les articles relatifs à la capacité de contracter. On trouve également des règles

656 Cass. fr. (comm.), 13 décembre 2005, n° 03-19217 (qui admet la validité de la promesse de porte-fort utilisée pour garantir l'exécution d'un contrat, mais qui juge que dans ce cas, l'engagement du promettant est accessoire à l'obligation principale, comme le serait un cautionnement). Cependant, un arrêt plus récent a précisé que, contrairement à l'engagement d'une caution, la promesse de porte-fort n'était pas soumise à l'article 1326 C. Civ. (Cass. (comm.), 18 juin 2013, n° 12-18.890).

657 Cass. be., 24 mars 2016, R. W, 2016-2017, p. 1119, note I. SAMOY.

658 Voy. *infra*, n° 621.

659 Sur l'historique de ce lien entre mandat et représentation dans la doctrine des pays du Code civil, voy. F. ZENATI-CASTAING et T. REVET, *Cours de droit civil, Contrats (Théorie générale – Quasi-contrats)*, Paris, PUF, 2014, n° 34 (cité *infra*, ZENATI-CASTAING REVET).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

générales relatives à la représentation dans le nouveau code civil belge, mais ces règles, se trouvent, comme en Allemagne, dans le livre 1er contenant les dispositions générales du droit civil. Elles figurent à l'article 1.8 du Code.

1) *Les sources de la représentation*

303. Représentation conventionnelle. Le pouvoir donné à une personne d'en représenter une autre dans la vie juridique peut d'abord résulter d'un contrat passé entre ces deux personnes. Tel est l'objet principal du contrat de mandat, réglementé aux articles 1984 et suivants du Code civil (ainsi que par divers textes spéciaux dont on ne peut pas faire l'étude ici). Contrairement à d'autres systèmes juridiques, où le mandat peut avoir pour objet des services de diverses natures, l'article 1984 du Code civil définit spécifiquement ce contrat comme celui par lequel « une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » – ce qui permet de le distinguer du contrat d'entreprise ou de prestation de services qui a pour objet l'accomplissement d'actes matériels. Cependant, il existe d'autres contrats qui peuvent avoir pour objet l'octroi d'un pouvoir de représentation : c'est le cas du contrat de commission, réglementé par les articles 91 et suivants du Code de commerce, par lequel le commettant charge un commissionnaire d'agir pour son compte mais en son nom propre[660]. Un pouvoir de représentation conventionnelle peut aussi résulter, à l'occasion, d'autres contrats qui n'ont pas principalement cet objet : par exemple, un employeur peut, dans le cadre d'un contrat de travail, confier à un salarié la charge de le représenter en certaines circonstances. Dans tous ces contrats, les parties déterminent librement l'étendue des pouvoirs du représentant, qui peuvent valoir pour certains actes seulement (pouvoir spécial) ou pour l'ensemble des affaires du mandant (pouvoir général) (C. civ., art. 1987). Dans ce dernier cas, cependant, le représentant n'a que le pouvoir de passer des actes d'administration ou des actes conservatoires pour le représenté, la conclusion d'actes de disposition devant résulter d'un mandat exprès (C. civ., art. 1988). Ces solutions sont aujourd'hui reprises d'une manière générale pour tous les cas de représentation par le nouvel article 1155 du Code civil français.

On se demande si le mandataire a le pouvoir de passer des *contrats avec lui-même* – d'un coté au nom du mandant, d'un autre côté en son nom propre. Par exemple, celui qui a reçu mandat de vendre une chose peut-il s'en porter personnellement

660 C'est ce qu'on appelle une représentation imparfaite. Voy. *infra*, n° 308.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

acquéreur ? Si techniquement rien ne l'interdit, dans la mesure où l'accord se fait entre deux volontés différentes, il s'agit d'une pratique particulièrement dangereuse car le mandataire risque de profiter de la situation pour passer un contrat avantageux pour lui. C'est pourquoi, la jurisprudence belge l'interdisait d'une manière générale, sauf autorisation expresse du mandant[661], et cette solution est désormais consacrée par l'article 1.8, paragraphe 6, du nouveau Code civil belge. Il n'en allait pas de même de la jurisprudence française, mais l'article 1596 du Code civil (également applicable au Luxembourg) interdit expressément au mandataire (et plus généralement à tout représentant) de se porter acquéreur du bien qu'il est chargé de vendre. Désormais, l'article 1161 du Code civil français contient, sur le modèle des PEDC[662], une interdiction plus générale, au nom de la prévention des conflits d'intérêts, mais sous réserve de l'autorisation ou de la ratification du représenté. Ces solutions devraient sans difficulté être transposées au Luxembourg. Les contrats avec soi-même sont en tout cas généralement interdits, au Luxembourg comme ailleurs, dans les cas de représentation légale (notamment pour les représentants des incapables : C. civ., art. 450)

304. Représentation légale. Le pouvoir d'agir au nom d'autrui peut aussi être conféré à une personne par la loi. La représentation légale des incapables, dans le cadre des régimes d'administration légale des mineurs et de tutelle (des mineurs et des majeurs protégés) en est l'exemple le plus évident. C'est alors la loi qui définit, de manière plus ou moins précise, l'étendue des pouvoirs du représentant – ces pouvoirs pouvant être, dans certains cas, modulés par le juge.

On peut aussi, aujourd'hui, présenter comme une forme de représentation légale les pouvoirs des dirigeants de sociétés[663]. Dans une conception contractuelle de la société, ces dirigeants ont été longtemps présentés comme des mandataires désignés par la société pour la représenter, mais cette analyse est aujourd'hui fortement remise en cause, et elle paraît incompatible avec les dispositions des textes sur les sociétés qui déterminent les pouvoirs des dirigeants. Dans la société anonyme, par exemple, l'article 441-5 de la loi du 10 août 1915 prévoit que « le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social » ; les statuts de la société peuvent certes limiter ces pouvoirs, mais l'article 441-5, alinéa 3 prévoit que « les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent au conseil d'administration et qui résultent soit des statuts, soit d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées ». On trouve des dispositions similaires pour les autres types de sociétés (art. 442-7 et art. 500-4) L'étendue du pouvoir de représentation, dans les rapports avec les tiers, résulte donc seulement de la loi, le dépassement des pouvoirs statutaires ne pouvant être sanctionné que par la responsabilité du dirigeant envers la société[664].

661 Cass. be., 18 mars 2004, n° C020249N, qui y voit un « principe général du droit ».

662 Art. 3 :205. Voy. égal. : DCFR, l'art. II-6 :109 et Principes Unidroit, art. 2.2.7.

663 En droit belge, on estime que les actes passés par les organes de la société ne le sont pas vraiment par représentation, le groupement n'ayant aucune volonté propre et ne pouvant s'exprimer que par ses organes (*cf.* C. soc. be., art. 61).

664 Voy. J.-P. WINANDY, *Manuel de droit des sociétés*, Luxembourg, Legitech, 2008, p. 236 ; I. CORBISIER, *La société contrat ou institution ? Droits étasunien, français, belge, néerlandais, allemand et luxembourgeois*, Bruxelles, Larcier, 2011 ; A. PRÜM et A. STEICHEN ; *Précis de droit des sociétés*, 7e éd., Bruxelles, Larcier, 2024, à paraître.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

305. Représentation judiciaire. Dans des cas exceptionnels le pouvoir de représenter peut résulter d'une décision judiciaire. On rencontre notamment cette formule dans le cadre des régimes matrimoniaux, lorsqu'un des époux est hors d'état de manifester sa volonté : l'autre peut alors se faire habiliter par le juge à le représenter, pour certains actes particuliers ou de manière générale (C. civ., art. 219 et 1429). L'octroi de pouvoirs de représentation à l'un époux peut s'accompagner d'un retrait des pouvoirs de l'autre sur ses propres biens.

2) *Les effets de la représentation*

306. Deux types de représentation. Du point de vue des effets, on distingue habituellement deux types de représentation, la représentation parfaite et la représentation imparfaite. Cette distinction, implicitement faite par le nouvel article 1154 du Code civil français, est explicitée par le nouvel article 1.8, paragraphe 1, du nouveau Code civil belge, qui utilise aussi les termes de représentation immédiate ou médiate. Elle n'est pas spécifique aux pays du Code civil. On la retrouve dans les différents textes et projets européens et internationaux de droit des contrats[665].

a. *La représentation parfaite ou immédiate*

307. Transparence du représentant. Dans ce type de représentation – qui est le type normal – le représentant agit au nom du représenté, il n'exprime pas sa volonté propre, mais celle d'autrui. Tout se passe donc comme si c'était le représenté qui passait le contrat avec le tiers. Les effets du contrat passé avec le tiers se produisent alors directement sur la tête et dans le patrimoine du représenté, qui est seul débiteur des obligations nées du contrat (par exemple, payer le prix de vente), seul titulaire des droits qui en résulte (celui qui achète par l'intermédiaire d'un mandataire devient immédiatement propriétaire de la chose et c'est à lui, et seulement à lui, que le vendeur doit livrer la chose)[666]. Aucun rapport contractuel ne se forme entre le tiers contractant et le représentant, qui peut seulement être tenu à l'égard du tiers de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle si son comportement lors de la conclusion du contrat a été fautif. Le nouvel article 1154 du Code civil français exprime cela en disant que « [l]orsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le

665 PEDC, art. 3:102 (qui parle de représentation directe et indirecte) ; DCFR, art. II-6:106 ; Principes Unidroit, art. 2.2.3 et 2.2.4 (représentation avec ou sans divulgation de la représentation).

666 *Cf.* l'article 1154 du Code civil français : « Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul engagé » ; voy. égal. : DCFR, art. 6:105 et PEDC, art. 3:202.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté », tandis que le Code civil belge dispose qu'« [e]n cas de représentation immédiate, l'acte juridique accompli par le représentant produit ses effets entre le représenté et le tiers. » (C. civ. be., art. 1.8 § 3) On exprime parfois cela en disant que le représentant est transparent, il n'est que la bouche qui parle ou que la main qui signe, un « simple truchement matériel »[667]. Mais cette présentation est ambiguë : en réalité le représentant exprime bien une volonté, mais celle-ci est, par l'effet d'une fiction, considérée comme étant celle du représenté. Il en résulte par exemple que, si le représentant est victime d'un vice du consentement lors de la conclusion du contrat, ce vice pourra être cause de nullité du contrat, invocable par le représenté[668] ; à l'inverse, si c'est le mandataire qui trompe le tiers avec qui le contrat est passé, ce dol sera considéré comme émané du cocontractant et non d'un tiers, ce qui en fera une cause de nullité du contrat[669]. En réalité, le mandant ne devient transparent que lorsque l'acte est conclu, en ce qui concerne ses effets. C'est ce qu'exprime parfaitement une formule des travaux préparatoires du Code civil selon laquelle la personne du mandataire disparaît « comme un échafaudage devenu inutile après la construction de l'édifice »[670].

b. *La représentation imparfaite ou indirecte*

308. Effets en deux temps. Il arrive qu'une personne passe un contrat pour le compte d'autrui, mais en son propre nom. C'est ce qui se passe dans le cas du contrat commercial de commission (C. comm., art. 91) : le commissionnaire est un intermédiaire qui vend ou achète des marchandises, ou qui passe un contrat de transport, pour le compte d'une autre entreprise à qui incombera, en définitive, la charge des contrats conclus, et qui en bénéficiera. Par exemple, dans le cas de commission d'achat, c'est le commettant qui devra, *in fine*, supporter le paiement du prix, et c'est lui qui aura en définitive les marchandises achetées. Mais, dans un premier temps, les effets du contrat passé se produiront dans les

667 A. BENABENT, *Droits des contrats spéciaux et commerciaux*, 14e éd., Paris, LGDJ, 2021, n° 692.

668 Droit français : Cass. fr., 8 novembre 1984, n° 82-14816 (violence exercée sur la personne d'un dirigeant social) – Droit belge : Cass. be., 7 janvier 2010, n° C.08.0594N (trouble mental du représentant).

669 Droit français : Cass. fr., 24 mai 1994, n° 92-14344. Cf. le nouvel article 1138 du Code civil français.

670 P.-A. FENET, *Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil*, t. 14, p. 596 (accessible sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France : http://gallica. bnf. Fr/).

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

rapports entre le tiers (acheteur, vendeur, client du transporteur) et le commissionnaire : dans l'exemple précédent, c'est au commissionnaire, et seulement à lui, que le vendeur pourra demander le paiement du prix, et c'est à lui qu'il livrera en principe les marchandises. Ce représentant, dit l'article 1154 du Code civil français « est seul engagé à l'égard du cocontractant. », tandis que l'article 1.8 du Code civil belge dispose qu'« [e]n cas de représentation médiate, l'acte juridique accompli par le représentant produit ses effets entre ce dernier et le tiers ». Ce n'est que dans un deuxième temps que le commissionnaire répercutera sur le commettant les effets du contrat passé (en lui livrant les marchandises et en lui demandant le remboursement du prix payé). En principe, cependant, aucun lien contractuel ne se crée entre le commettant et le tiers, ce qui, pour certains auteurs, exclut toute idée de représentation[671].

C) *Sanction du défaut ou du dépassement de pouvoir*

309. Inefficacité de l'acte. En principe, un acte passé par une personne qui prétend en engager une autre alors qu'elle n'en a pas le pouvoir est inefficace à l'égard de cette dernière, qui n'a aucune raison d'être engagée par un contrat qu'elle n'a pas consenti. Cela vaut aussi bien en cas d'absence totale de pouvoir (la promesse pour autrui, en l'absence de tout mandat) que dans le cas – beaucoup plus fréquent en pratique – de dépassement de pouvoir par un représentant (le mandataire qui passe un contrat en dehors du champ de la procuration qui lui a été donnée). Cependant, la nature et, partant, le régime de cette inefficacité, sont très incertains (**1**). Par ailleurs, l'inefficacité de l'acte passé sans pouvoir peut être écartée par le jeu de différentes circonstances (**2**).

1) *Nature de l'inefficacité de l'acte*

310. Nullité, inopposabilité ou inexistence ? Ce qui paraît essentiel, c'est que la personne non représentée ne soit pas tenue par l'acte qu'on a voulu passer pour elle. Mais il y a plusieurs voies pour parvenir à ce résultat. Le plus simple, et le plus logique, est de dire que cette personne n'a pas consenti à l'acte ; celui-ci est donc, à son égard, inexistant (comme lorsqu'on n'a pas accepté une offre qui vous était faite). C'est ce qu'on exprime habituellement en disant que cet acte lui est inopposable, mais cette formulation

671 Voy. p. ex. dans la doctrine belge : Van Ommeslaghe, n° 417 ; en France : P. Collart-Dutilleul et P. Delebecque, *Contrats civils et commerciaux*, 9e éd., Paris, Dalloz, 2011, n° 666.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

est maladroite car l'inopposabilité s'entend généralement d'un acte qui est valable entre les parties mais dont les tiers peuvent faire abstraction. Or ici, l'acte n'a aucun effet à l'égard de quiconque, au moins dans la représentation parfaite[672], puisque le prétendu représentant n'a pas prétendu s'engager personnellement, et il n'est donc, pas plus que le prétendu représenté, engagé par l'acte ; ce dernier peut seulement engager sa responsabilité délictuelle. Quoi qu'il en soit, l'intérêt de cette sanction (qu'on la qualifie d'inexistence ou d'inopposabilité) est que le prétendu représenté n'a pas besoin de faire prononcer la nullité, il lui suffit, à tout moment, et sans pouvoir se voir opposer aucune prescription, déclarer qu'il est étranger à l'acte. Il n'en va pas de même si on considère que l'acte passé sans pouvoir est nul : la personne au nom de qui on a prétendu s'engager doit alors agir en nullité pour faire tomber l'acte, et elle doit respecter le délai mis par la loi pour une telle action. Logiquement, une telle nullité, faite pour protéger les intérêts particuliers du prétendu représenté, devrait être qualifiée de nullité relative, ce qui enferme l'action dans un délai de prescription de 5 ans[673].

Le droit positif, au Luxembourg, hésite entre ces deux voies. En matière de représentation des incapables, il est traditionnellement admis que le dépassement de ses pouvoirs par le représentant légal est sanctionné par une nullité relative[674]. En revanche, dans le cas du dépassement de pouvoir d'un mandataire, la Cour d'appel, s'appuyant sur la lettre de l'article 1998, alinéa 2 du Code civil, a semblé pencher pour l'inopposabilité au prétendu représenté[675], mais dans une affaire ancienne où cette qualification était sans enjeu. Les mêmes hésitations prévalaient en France jusqu'à la réforme : la solution traditionnelle était la nullité de l'acte accompli sans pouvoir[676], mais plusieurs arrêts récents de certaines chambres de la Cour de cassation avaient clairement opté pour l'inopposabilité[677], et la même solution avait été admise à plusieurs reprises en cas de dépassement de pouvoir d'un

672 Dans la représentation imparfaite, le représentant qui a dépassé ses pouvoirs, ayant agi en son nom, est personnellement engagé par l'acte, mais il ne peut pas en répercuter les effets sur le prétendu représenté. On est bien ici en présence d'une inopposabilité.

673 Voy. *infra*, n°s 450 et s.

674 Cour d'appel, 11 février 1949, 15, p. 181 (cependant l'arrêt ajoute que l'acte « est inopposable à celui pour qui il a été fait »). Voy. en France : Cass. fr. (ass. plén.), 28 mai 1982, n° 79-13660 ; Cass. fr. (1re civ.), 4 juillet 2007, n° 06-16639.

675 Cour d'appel, 30 juillet 1920, *Pas.*, 11, p. 1.

676 Cass. fr. (1re civ.), 9 juin 1976, n° 73-10157 (nullité absolue) ; pour la nullité relative, plus récemment : Cass. fr. (1re civ.), 25 mai 1992, n° 90-19969 ; Cass. fr. (1re civ.), 2 novembre 2005, n° 02-14614 ; Cass. fr. (1re civ.), 9 juillet 2009, n° 08-15413.

677 Cass. fr. (3e civ.), 6 octobre 2004, n° 01-00896 ; Cass. fr. (comm.), 11 mars 2014, n° 12-22877 « le mandant, qui n'est pas tenu des actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné, dispose à l'encontre de ces actes d'une action en inopposabilité qui n'est pas de celles qui se prescrivent par le délai prévu à l'article 1304 du code civil ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

dirigeant social[678]. C'est cette solution, admise par les Principes du droit européen du contrat[679], que consacre désormais l'article 1156, alinéa 1, du Code civil français. Cependant, l'alinéa 2 prévoit que, en plus, « lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité ». Cette nullité, destinée à protéger le tiers, s'ajoute à la possibilité pour la personne non représentée de faire déclarer l'acte inopposable à son égard. Par ailleurs, l'article 1157 consacre une solution spécifique lorsque le représentant, tout en agissant dans le cadre de ses pouvoirs, les a détournés au détriment du représenté. Dans ce cas, celui-ci est en principe tenu, mais il peut invoquer la nullité du contrat « si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer ». L'article 1.8, paragraphe 4, du nouveau Code civil belge prévoit, de manière plus imprécise, qu'« [e]n cas de représentation immédiate, si le représentant excède ses pouvoirs, l'acte juridique ne lie pas le représenté à l'égard des tiers », ce qui semble bien viser l'inopposabilité (ou plus exactement l'inexistence) de l'acte accompli sans pouvoir.

2) *Limites à l'inefficacité de l'acte*

311. Fondements. Le défaut de pouvoir peut être couvert dans certaines circonstances. Cette couverture peut s'expliquer par deux types de considérations : soit parce que la personne qu'on a prétendu engager se déclare finalement d'accord avec l'acte passé pour elle – elle peut alors le ratifier (**a**) – soit, très différemment, dans un but de protection du tiers qui, de bonne foi, a traité avec le prétendu représentant, se fiant à l'apparence de pouvoirs (**b**).

a. *La ratification*

312. Domaine et régime. La possibilité pour la personne de ratifier un acte passé sans pouvoir pour son compte est admise explicitement par l'article 1998 alinéa 2 du Code civil en matière de mandat, ainsi que par l'article 1120 du Code civil à propos de la promesse de porte-fort. Mais il faut sans doute y voir un correctif général à l'absence ou au dépassement de pouvoir, comme l'admettent le nouveau droit français (C. civ. fr., art. 1156, al. 3) ainsi que le nouveau droit belge (C. civ. be., art. 1.8, § 4), à l'image de différents projets européens[680]. Un incapable devenu ou redevenu capable, par exemple, peut très bien ratifier un acte irrégulier passé par son tuteur. L'article 1998 du Code civil prévoit que la ratification peut être expresse ou tacite : elle peut résulter, par exemple, de

[678] Inopposabilité à la société des cautionnements donnés par un dirigeant sans l'autorisation du conseil d'administration (comme l'exige le droit français) : Cass. fr. (comm.), 8 décembre 1998, n° 96-11.542 ; Cass. fr. (comm.), 8 décembre 2009, n° 08-20.039.

[679] Art. 3:204.

[680] PDEC, art. 3 :207 ; DCFR, art. II-6 :111.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'exécution volontaire, par le pseudo-représenté, de l'acte passé en son nom. Il est traditionnellement admis dans les jurisprudences française et belge que cette ratification a un effet rétroactif, et le nouveau texte belge le précise expressément : tout va se passer comme si, dès l'origine, celui qui a passé le contrat avait le pouvoir de le faire[681]. Comme le dit la Cour de cassation belge « par la ratification de l'engagement du porte-fort, le tiers s'approprie l'acte avec effet rétroactif entre parties au jour où il a été passé »[682]. Héritée du principe traditionnel « *Ratihabitio mandato aequiparatur* » (la ratification équivaut au mandat)[683], et reçue dans tous les droits continentaux aussi bien qu'en *common law*, consacrée dans les divers textes et projets internationaux et européens[684], cette solution doit sans aucun doute être admise en droit luxembourgeois. Cependant, la ratification ne peut pas remettre en cause les droits que des tiers auraient acquis sur le bien objet de l'acte depuis la passation de celui-ci.

Comme l'a très justement relevé un arrêt de la Cour d'appel du 16 février 2000, la ratification dont il est ici question doit être distinguée de la confirmation des actes nuls, et ceci alors même que l'article 1338 du Code civil relatif à la confirmation emploie indifféremment les deux termes[685]. La confirmation, dont nous ferons l'étude à propos du régime des nullités[686], est la renonciation à agir en nullité d'un acte qui ne répond pas à toutes les conditions de validité posées par la loi, elle ne touche en rien le contrat qui demeure vicié à l'origine, mais contre lequel le renonçant ne peut plus agir ; aussi bien n'a-t-elle qu'un effet relatif et n'empêche pas les autres titulaires de l'action en nullité, s'il y en a, d'attaquer le contrat. La ratification, qui est un mécanisme spécifique aux cas de défaut ou de dépassement de pouvoir, émane nécessairement de la personne pour le compte de qui le contrat a été passé, et elle a pour effet d'effacer le vice originaire du contrat. Les conditions et les effets des deux actes ne sont pas exactement les mêmes.

b. *L'apparence*

313. Théorie générale de l'apparence. Dans un certain nombre de cas, le droit fait produire des effets à un acte ou à un fait qui, en principe, ne devrait pas en produire, dans le but de protéger les

681 Voy. p. ex. : France : Cass. fr. (3e civ.), 12 mai 2010, n° 08-20544 ; Belgique : Cass. be., 5 novembre 1979, *Pas. be.*, 1980, p. 286. Voy. R. JAFFERALI, *Confirmation, ratification et condition suspensive. La rétroactivité des droits contractuels inachevés*, préf. P.-A. FORIERS, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 112 et s.

682 Cass. be., 5 novembre 1979, préc.

683 WÉRY, n° 171.

684 Voy. p. ex. : Principes Unidroit, art. 2.2.9 « Une fois ratifié, l'acte produit les mêmes effets que s'il avait été, dès l'origine, accompli en vertu d'un pouvoir ».

685 Cour d'appel, 16 février 2000, 31, p. 239.

686 Voy. *infra*, nos 454 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

tiers qui se sont fiés à l'apparence créée par cet acte ou ce fait. Ces solutions légales ou jurisprudentielles, synthétisées par la doctrine sous forme d'une « théorie générale » sont habituellement rattachées à l'adage traditionnel d'origine latine « *Error communis facit jus* ». Cette théorie trouve précisément son application principale en cas de défaut ou de dépassement de pouvoir d'un mandataire, avec les solutions jurisprudentielles relatives au mandat apparent. On peut également lui rattacher un certain nombre de solutions légales spécifiques.

314. Mandat apparent. Bien qu'elle se soit développée principalement dans le contexte de dépassements de pouvoir d'un mandataire, la théorie du mandat apparent peut trouver application dans tous les cas de représentation, légale, conventionnelle ou judiciaire. Cette théorie permet au tiers, qui, en raison de circonstances particulières, a pu croire aux pouvoirs du représentant, de s'abriter derrière cette apparence pour exiger l'exécution de la part du prétendu représenté. Celui-ci va alors se trouver engagé, alors même qu'il n'avait nullement consenti à l'acte supposé passé en son nom. Cette construction est connue à peu près de tous les droits européens[687], mais elle peut reposer sur deux conceptions différentes qui se traduisent à travers les conditions que la jurisprudence (ou parfois la loi) met à l'engagement du pseudo-représenté. Dans une première conception, cet engagement (par hypothèse non voulu) est lié au comportement de la personne qui a laissé croire au tiers que l'acte était passé pour son compte. Cette conception était traditionnellement celle des jurisprudences française et belge, qui voyaient dans le mandat apparent une application particulière du droit de la responsabilité civile : le pseudo-mandant n'était engagé que s'il avait commis une faute consistant à créer l'apparence de pouvoir, son engagement apparaissant en quelque sorte comme une forme de réparation en nature du préjudice causé au tiers. Mais, dans une deuxième conception, l'engagement du prétendu représenté est seulement lié à un jugement de valeur porté sur l'état d'esprit du tiers qui s'est trompé : il s'agit de savoir si, compte tenu des circonstances, ce tiers était fondé à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire, en d'autres termes si son erreur peut être considérée comme légitime, même si le prétendu représenté n'est absolument

[687] « *Duldungs-und Anscheinsvollmacht* » en Allemagne et en Autriche, « *rappresentenza apparente* » en Italie – Pour un panorama comparatif, voy. F. Ranieri, *Europäisches Obligationenrecht*, 3. Auflage, Springer Verlag, Wien, 2009, pp. 500 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pour rien dans cette erreur. Telle était, jusqu'à la réforme, la position de la jurisprudence française, depuis un important arrêt d'Assemblée plénière du 13 décembre 1962, selon lequel « le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs »[688]. En vertu de cette jurisprudence, l'origine de l'apparence était donc en principe indifférente[689]. Le nouvel article 1156 du Code civil français consacre une position intermédiaire. Selon ce texte, le représenté n'est pas engagé en cas de défaut ou de dépassement de pouvoirs du représentant « sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ». Le comportement du représenté est cité par le texte comme la principale circonstance ayant pu provoquer l'erreur, mais l'adverbe « notamment » indique que cette erreur peut être légitime en d'autres circonstances, indépendantes de ce comportement. En revanche, l'article 1.8, paragraphe 5, du nouveau Code civil belge, consacrant la jurisprudence antérieure[690], pose que l'apparence de pouvoir n'est prise en considération que si elle est imputable au représenté, en raison de ses déclarations ou de son comportement, même cependant si ce comportement n'est pas fautif.

La jurisprudence luxembourgeoise se rattache plutôt à la position française. Si elle a pu se fonder naguère sur la faute du mandant[691], la Cour d'appel affirme depuis longtemps que, pour que la théorie du mandat apparent « puisse trouver à s'appliquer, il faut que la croyance de celui qui invoque à son profit cette théorie, aux pouvoirs de mandataire de celui avec qui il a traité, soit légitime. Pour que la croyance soit légitime, il faut à la fois qu'il y ait eu apparence de mandat et que les circonstances aient autorisé celui qui se prévaut de la théorie à ne pas vérifier la réalité des pouvoirs du mandataire apparent »[692] – formule dans laquelle on reconnaît l'influence de la

688 Cass. fr. (ass. plén.), 13 décembre 1962, n° 57-11569.

689 A. BENABENT, *Droit civil, Les contrats spéciaux civils et commerciaux*, 14e éd., Paris, LGDJ, 2021, n° 733.

690 Cass. be., 20 janvier 2000, n° C960202N ; Cass. be., 25 juin 2004, n° C020122F.

691 Cour d'appel, 30 juillet 1920, *Pas.*, 11, p. 1.

692 Cour d'appel, 13 janvier 1998, *Pas.*, 30, p. 465 ; Cour d'appel, 1er avril 2009, *Pas.*, 34, p. 512. Voy. en dernier lieu : Cour d'appel, 12 juin 2024, n° CAL-2022-00642 ; Trib. Luxembourg, 11 juin 2024, n° TAL-2024-02211.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

jurisprudence française[693]. Bien entendu, pour apprécier le caractère légitime ou non de l'erreur, il faut tenir compte de toutes sortes de circonstances, parmi lesquelles la qualité professionnelle du tiers et le comportement du prétendu mandant[694], mais celui-ci, selon la Cour de cassation, « ne constitue qu'une circonstance devant permettre de renforcer la légitimité de l'erreur commise par le tiers dans des cas où les autres circonstances ne sont pas à elles seules totalement concluantes »[695]. Ce n'est en aucune manière, contrairement à la solution belge, un élément nécessaire à l'engagement du prétendu représenté[696].

315. Solutions légales. Certains textes, qui peuvent être considérés comme des applications de la théorie de l'apparence, permettent d'écarter, au profit d'un tiers de bonne foi, la nullité ou l'inopposabilité d'un acte passé par un représentant ayant agi sans pouvoirs. On peut d'abord relever les textes du Code civil en matière de mandat qui rendent inopposables au tiers de bonne foi la fin du mandat résultant de sa révocation (C. civ., art. 2005) ou du décès du mandant (C. civ., art. 2008). Il faut également citer ici les textes du droit des sociétés qui rendent inopposables au cocontractant d'un dirigeant social les limitations des pouvoirs de ce dirigeant : si l'inopposabilité aux tiers des limitations statutaires ou conventionnelles des pouvoirs des dirigeants semble plutôt s'expliquer par l'origine légale de ces pouvoirs[697], les textes qui instaurent la validité même des actes qui dépassent l'objet social dès lors que le tiers n'en a pas eu connaissance (L. 10 août 1915, article 441-13 pour les sociétés anonymes et art. 600-5 pour les sociétés en commandite par action) semblent bien liés à l'idée d'apparence. On peut également évoquer, bien qu'elle ait un domaine d'application beaucoup plus général, la règle de l'article 2279 du Code civil[698] « en fait de meubles, possession vaut titre » : si une personne vend un bien mobilier qui ne lui appartient pas et qu'elle n'a pas le pouvoir de vendre, l'acheteur peut devenir propriétaire s'il entre en possession de bonne foi, c'est-à-dire dans l'ignorance de l'absence de droit ou de pouvoir du vendeur.

693 Certains arrêts recopient textuellement la formule de l'arrêt français de 1962 : voy., p. ex., Cour d'appel, 14 juillet 2005, n° 28713 ; Cour d'appel, 12 janvier 2021, n^{os} CAL-2019-00115 et CAL-2019-00142.

694 Cour d'appel, 5 juin 1985, *Pas.*, 26, p. 349.

695 Cass., 18 décembre 1997, *Pas.*, 30, p. 331.

696 Dans ce sens Poelmans, n°s 268 et s. Voy. les différentes espèces citées par cet auteur.

697 Voy. *supra*, n° 304. Aussi bien cette inopposabilité n'est-elle pas subordonnée à la bonne foi du tiers qui a traité avec le tiers dans l'ignorance du dépassement de pouvoirs.

698 C. civ. fr., art. 2276.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'aptitude à contracter : capacité et pouvoir, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 359-391
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Chapitre III
L'objet

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

316. Une notion hétéroclite. Le Code civil pose à l'article 1108, comme troisième condition de validité du contrat, « un objet certain qui forme la matière de l'engagement », et cette condition est ensuite développée aux articles 1126 à 1130 du Code civil. Commune à l'origine aux trois codes français, belge et luxembourgeois, et à différents codes directement inspirés du Code Napoléon[699], cette présentation s'articule autour d'une notion particulièrement hétéroclite. La lecture des articles 1126 à 1130 du Code civil montre que les rédacteurs du Code ont utilisé le terme « objet » dans des sens divers. Ainsi, dans l'article 1126 du Code civil, le terme désigne soit « une chose qu'une partie s'oblige à donner » – donc un bien (corporel ou incorporel) sur lequel porte le contrat (par exemple, la chose que l'on vend) – soit une chose « qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire » – donc un service, une prestation (par exemple, la construction d'une maison dans un contrat d'entreprise, le paiement d'une somme d'argent à la place du débiteur dans un cautionnement, etc.). Ce service ou cette prestation peut être, en particulier, comme le précise l'article 1127 du Code civil « le simple usage ou la simple possession d'une chose ». Ainsi on peut dire qu'un contrat de bail a pour objet, à la fois, la chose louée (premier sens) et la jouissance de la chose que le bailleur s'oblige à procurer au locataire. Les textes relatifs à l'objet sont centrés tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre de ces significations, de sorte qu'il est assez difficile de donner de la matière une présentation systématique. La doctrine française moderne avait encore accru la polysémie du terme en distinguant parfois l'objet de l'obligation (dans l'un ou l'autre des sens précédents) et l'objet du contrat[700], désignant l'opération globale mise en place par les parties : ainsi, dans ce sens très général, on dira qu'un contrat de bail a pour objet de procurer à une partie (le locataire) la jouissance d'une chose dont elle n'est pas propriétaire, moyennant paiement d'un loyer. Dans le nouveau Code civil belge, l'article 5.46 s'articule autour de cette distinction, mais présentée autrement : l'objet du contrat est défini comme les obligations ou les autres effets de droit que le contrat fait naître, l'objet de l'obligation est « une prestation qui peut consister à faire ou ne pas faire quelque chose, à donner quelque chose ou à garantir quelque chose » (par où on reconnaît la distinction traditionnelle entre les

699 Voy., p. ex., Codigo civil espagnol, art. 1271 ; Codice civile italien, art. 1346 et s.

700 Voy., p. ex., A.S. LUCAS-PUGET, *Essai sur la notion d'objet du contrat*, préf. M. FABRE-MAGNAN, Paris, LGDJ, 2005.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

différents types d'obligations). Dans le Code civil français, depuis la réforme de 2016, la notion d'objet n'apparait plus en elle-même comme une condition de validité du contrat, elle est fondue avec la cause dans la condition assez floue de « contenu », mais on la retrouve dans les articles 1162 à 1167, qui reprennent de manière simplifiée les anciens articles 1126 à 1130. Cependant, ces textes font disparaître la notion d'objet du contrat, et ne visent que l'objet de l'obligation défini comme « une prestation présente ou future » sans autre précision.

La nouvelle présentation française s'inspire des projets européens, dont aucun ne reprend la notion d'objet, et qui se réfèrent tous à la notion de « contenu » du contrat, sous laquelle on regroupe, selon des combinaisons variables, des règles relatives au contrat lui-même et des exigences relatives aux clauses contractuelles. Une telle présentation se retrouve dans le Code Gandolfi (art. 25 et s.), les PDEC (art. 6 :101 et s), le DCFR (art. II-9 :101 et s.) et le DCEV (art. 66 et s.). Dans les projets européens, on relie fréquemment à cette question du contenu les règles relatives à l'interprétation (la détermination par le juge du contenu du contrat), alors que le Code civil français distingue nettement, à propos du contenu du contrat, ce qui commande sa validité (art. 1162 et s.), et la manière dont il est interprété par le juge (art. 1188 à 1192).

La polysémie du terme « objet » s'accompagne d'une grande diversité des problèmes que la notion d'objet permet de résoudre, en considération d'intérêts eux-mêmes très variables. Une première exigence, qui sert à la fois à assurer la viabilité du contrat et à protéger chaque partie contre l'autre, impose aux parties de déterminer avec suffisamment de précision l'objet de leur engagement (**Section 1**). Une seconde série d'exigences, principalement conçues dans un but de protection de l'intérêt général, concerne les caractéristiques que l'objet ainsi déterminé doit présenter pour que le contrat soit valable (**Section 2**).

SECTION 1. LA DÉTERMINATION DE L'OBJET DU CONTRAT

317. Article 1129 du Code civil. Selon ce texte « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ». Bien que le texte n'apparaisse pas immédiatement dans la section relative à l'objet, l'exigence de détermination qu'il pose apparaît première : lorsqu'on passe un contrat, il faut, d'abord, déterminer à quoi on s'engage. Cependant, au-delà de l'exigence qu'il pose (**§ 1**), le texte est très elliptique sur les manières dont peut s'effectuer la détermination de l'objet (**§ 2**).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§ 1. L'exigence de détermination

318. Condition d'existence du contrat. D'une manière générale, on ne conçoit pas que les parties au contrat ne déterminent pas à quoi ils s'engagent. Bien que l'article 1129 du Code civil ne parle que de la détermination de la « chose » (l'objet au sens strict), cette exigence s'applique, de manière plus générale à tout le contenu de l'engagement : si le contrat porte sur un service, il faut qu'on puisse savoir en quoi il consiste exactement. Surtout, si le contrat est à titre onéreux, il faut qu'on puisse connaître le montant du prix qui sera payé par une partie à l'autre. Dans les nouveaux textes français et belges, l'exigence de détermination porte, d'une manière plus générale sur les prestations constituant l'objet des obligations nées du contrat (ce qui recouvre à la fois les choses et les services, ainsi que le prix). Bien sûr, il n'est pas nécessaire que les parties fixent dans le détail tous les aspects du contrat, il suffit qu'elles en déterminent les éléments dont elles ont seules la maîtrise, ceux pour lesquels le juge ne pourrait pas se substituer à elles et pour lesquelles il n'existe aucune règle supplétive permettant de combler l'imprécision des termes du contrat conformément à l'article 1135[701]. L'exigence de détermination, dans son principe même, se confond ainsi avec la nécessité pour les parties de se mettre d'accord sur les éléments essentiels du contrat. De ce point de vue, elle apparaît moins comme une condition de validité du contrat que comme une condition structurelle de son existence même : à défaut de détermination des éléments essentiels, il faut considérer que les parties ne se sont pas mises d'accord, qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés.

Ainsi conçue cette exigence de détermination de l'objet du contrat n'a cependant qu'une portée limitée. Elle condamne seulement les contrats dans lesquels les parties, non seulement n'auraient pas déterminé les éléments essentiels du contrat au moment de sa conclusion, mais n'auraient même pas prévu, implicitement ou explicitement, un moyen de les déterminer par la suite : l'objet du contrat n'est alors ni déterminé, ni déterminable, comme l'exige au minimum l'article 1129, alinéa 2 du Code civil. Cette indétermination absolue, qui empêche le contrat d'être viable, connaît quelques illustrations jurisprudentielles au Luxembourg. La Cour d'appel a ainsi considéré comme nul un contrat par lequel une personne s'était engagée à s'approvisionner, pendant une période déterminée, en

[701] Sur ce texte, voy. *infra*, n° 532 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

différents produits pétroliers, chez un fournisseur, sans qu'un minimum ou un maximum de ces fournitures n'ait été convenu, et sans qu'aucun élément ne permette de savoir quelle avait été l'intention des parties quant à la détermination de la quantité[702]. Il en va de même d'un contrat de vente d'une partie de terrain, non précisément située, et dont la superficie « d'environ plus ou moins un are » devait être fixée « suivant un futur mesurage cadastral »[703]. Cela condamne également les contrats dans lesquels les parties, faute de pouvoir se mettre d'accord au moment de la conclusion sur un élément essentiel, conviennent qu'elles le détermineront ultérieurement d'un commun accord : si cet accord n'intervient pas, le juge n'aurait en effet aucun moyen de fixer cet élément manquant.

§ 2. Les modes de détermination de l'objet

319. Différentes formules. Le texte de l'article 1129 du Code civil, qui est centré sur la détermination de la chose objet du contrat est assez elliptique sur la manière dont la détermination de cette chose peut s'opérer. On y apprend cependant que si les parties doivent procéder, dès la conclusion du contrat, à la détermination de la nature de la chose (A), il suffit, pour la quantité à fournir, qu'elle soit déterminable (B).

A) *Détermination initiale de la nature de la chose*

320. Distinction selon la nature de la chose objet du contrat. Au moment même où elles contractent, les parties doivent se mettre d'accord sur un minimum d'éléments. Ce minimum n'est pas le même selon que la chose objet du contrat est un corps certain ou une chose de genre. Dans le premier cas – que le texte n'envisage pas directement – le contrat porte sur une chose spécifique, qui ne peut pas être remplacée par une autre : tel appartement, telle voiture d'occasion, telle œuvre d'art. Il est alors nécessaire que, dès le jour du contrat, les parties aient défini de manière précise la chose qui est vendue, prêtée, louée, qui doit être réparée, etc. On ne conçoit pas que cette détermination soit renvoyée à une date ultérieure. Il en va autrement lorsque le contrat porte sur une chose de genre, c'est-à-dire une chose d'un certain type, substituable sur le marché par d'autres choses du même type : une voiture de telle

[702] Cour d'appel, 12 janvier 1983, *Pas.*, 25, p. 429.
[703] Cour d'appel, 11 janvier 2006, n° 29797, *BIJ*, 2006, p. 70.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

marque et de tel modèle (mais pas spécialement celle-ci qui est actuellement sur le parking du garage), 25 bouteilles de Riesling produit par tel viticulteur (peu importe que ce soient celles qui sont à tel endroit ou à tel autre dans la cave), telle quantité de sucre, de blé, de bananes et plus généralement toutes les choses qui sont « vendues au poids, au compte ou à la mesure » (C. civ., art. 1585). L'article 1129 du Code civil a été écrit pour ces choses-là : il est alors nécessaire, nous dit le texte, que le contrat en détermine l'espèce dès sa conclusion. On ne peut pas se contenter d'acheter à un concessionnaire automobile « une voiture » de sa marque, il faut au moins en déterminer le modèle. Si on achète du vin à un viticulteur de la Moselle qui cultive plusieurs cépages, il faudra au moins préciser si on veut du Riesling ou du Pinot gris. Par analogie, si le contrat a pour objet une prestation (faire ou ne pas faire quelque chose) il faut que les parties se mettent d'accord sur la nature de la prestation à fournir : le contrat doit au moins déterminer la nature des travaux que devra faire un entrepreneur, la mission qui est confiée à un avocat, etc. La notion d'espèce est cependant plus ou moins élastique, le degré de précision nécessaire dépend beaucoup de la nature de la chose, des habitudes qui existent ou non entre les parties, des usages professionnels, etc. En général, il n'est pas indispensable de préciser la qualité de la chose : si rien n'a été dit, le débiteur devra, selon l'article 1246 du Code civil, fournir une qualité moyenne. On retrouve cette idée dans le nouvel article 1166 du Code civil français selon lequel « [l]orsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie ». On retrouve ici l'idée que l'exigence de détermination ne vaut que dans la mesure où il n'existe pas une règle supplétive permettant de déterminer ce que les parties n'ont pas fixé elles-mêmes. Pour les choses de genre cette détermination initiale de l'espèce est suffisante. Les parties peuvent être plus précises et déterminer, dès ce moment, la « quotité » – c'est-à-dire, en langage plus moderne, la quantité de la chose. Mais ce n'est pas nécessaire ; l'article 1129, alinéa 2 du Code civil dispose en effet que « la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ». On passe alors de la détermination à la déterminabilité.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

B) *Détermination postérieure*

321. Licéité du procédé. Si les parties doivent se mettre d'accord tout de suite sur la nature de la chose ou de la prestation objet du contrat, elles peuvent se contenter de fixer la manière dont seront ensuite déterminés les éléments quantitatifs de leur relation. La formule de l'article 1129, alinéa 2 du Code civil, qui parle de la « quotité de la chose » englobe non seulement la quantité de marchandises à fournir (combien d'hectolitres de vin, de quintaux de blé, de mètres de tissu, etc. ?), mais aussi la « quantité » d'argent à payer en contrepartie, c'est-à-dire le prix – et c'est même l'aspect le plus important en pratique de la question. On peut même, par analogie, étendre l'article 1129, alinéa 2 du Code civil à la détermination de l'étendue exacte des prestations à fournir par un contractant (combien de temps pour faire le travail demandé, jusqu'où aller dans les investigations et les démarches demandées à un expert, etc. ? Cette souplesse laissée par le texte s'explique aisément. D'une part, il arrive souvent que les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur certains éléments du contrat (le prix notamment) et, pour éviter que l'opération n'échoue, elles peuvent décider que ces éléments seront fixés ultérieurement en fonction de certains critères ou d'une certaine procédure (une évaluation par expert, par exemple). D'autre part, dans les contrats dont l'exécution s'échelonne dans le temps, les parties n'ont pas toujours la maîtrise de tous les éléments quantitatifs, et ne disposent pas nécessairement de toutes les informations nécessaires pour les fixer. Par exemple, lorsqu'on passe un contrat d'entreprise portant sur des travaux de réparation, il n'est pas toujours facile de savoir au début quelle sera l'étendue du travail que devra faire le maçon, le plombier ou le garagiste, et donc le prix qui devra lui être payé. Dans les contrats-cadres[704] qui prévoient la conclusion de contrats ultérieurs qui peuvent s'échelonner sur une longue période, et intervenir dans un contexte économique très évolutif, il peut apparaître imprudent de fixer une fois pour toutes le prix de fournitures ou de services pouvant intervenir plusieurs années après. Aussi bien les nouveaux textes français et belges prévoient-ils d'une manière générale, sans plus se référer à la « quotité de la chose » que la prestation objet du contrat doit être « déterminée ou déterminable ». Selon l'article 1163 du Code civil français et l'article 5.46 du nouveau Code civil belge, la prestation

[704] Sur cette notion, voy. *supra*, n° 194.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

est déterminable dès lors qu'elle peut être fixée sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. Se référant au texte français, un jugement récent du Tribunal de Luxembourg pose que « la prestation doit être déterminée ou déterminable. Cela implique que l'on sache précisément ce à quoi s'engage le débiteur au moment de la conclusion du contrat, ou bien que l'on puisse conclure le contrat à partir d'une prestation qui sera déterminée ultérieurement, au moment de l'exécution du contrat, sans qu'il soit nécessaire de renouveler l'accord des parties… »[705], par référence à des critères objectifs. Le but est d'éviter qu'une seule partie ne puisse ensuite déterminer la prestation à son bon vouloir.

Encore faut-il se demander par quels procédés on peut aboutir à la fixation définitive des éléments qui n'ont pas été déterminés au départ. Sur ce point, l'article 1129 actuel est muet, et les nouveaux textes belges et français adoptent des solutions assez différentes. On est ici amené à faire une distinction selon que le procédé de détermination mis en place est indépendant de la volonté des parties au contrat (**1**) ou qu'il repose sur la volonté unilatérale d'une des parties (**2**).

1) *Détermination indépendante de la volonté des parties*

322. Détermination en fonction d'éléments objectifs. L'idéal, pour chaque partie, est que les éléments restant à déterminer puissent l'être en fonction d'éléments objectifs sur lesquels l'autre n'ait aucune prise. Une solution simple est de se référer à un tarif habituellement pratiqué par un des contractants ou dans le cadre d'une profession (et dont l'autre partie peut avoir connaissance) : c'est la solution qui sera habituellement utilisée dans les contrats d'entreprise, si les parties n'ont pas par avance déterminé de manière forfaitaire le prix de l'intervention. Cependant, pour que ce mode de détermination soit à l'abri de toute critique, il faut que le tarif appliqué ait été fixé une fois pour toutes au départ, et que la partie qui fournit la prestation n'ait pas le moyen de le modifier. Pour certains biens ou services, on pourra aussi se référer à un prix de marché, si celui-ci peut être aisément et objectivement déterminé, ce qui sera le cas en particulier lorsque ces biens font l'objet d'une cotation officielle (titres cotés en bourse, par exemple), ou si la valeur de ces biens ou services est reflétée par un indice officiel (par exemple, le coût de la

[705] Trib. Luxembourg, 13 février 2024, n° TAL-2023-02838.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

construction)[706]. Le nouveau texte français se montre plus souple : la prestation (qu'il s'agisse du prix ou d'une prestation en nature) est considérée comme déterminable « lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties » (C. civ. fr., art. 1163, al. 3).

Une difficulté particulière surgit lorsque l'élément choisi par les parties pour fixer le prix ou l'étendue de la prestation disparaît ultérieurement (par exemple un tarif de référence qui cesse d'être publié). Dans ce cas la détermination devient impossible, et, logiquement, le contrat devrait tomber. Cependant, le nouvel article 1167 du Code civil français prévoit que « [l]orsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus ». Cette formule s'inspire de l'article 6:107 des PDEC.

323. Détermination par un tiers. Une autre formule qui fait échapper la détermination de l'objet à la volonté d'une partie, est de renvoyer à la décision d'un tiers expert pour fixer les éléments sur lesquels les parties n'ont pas pu se mettre d'accord. Cette formule est prévue expressément dans le cas de la vente par l'article 1592 du Code civil, selon lequel le prix « peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers »[707], mais on peut l'utiliser pour tous les contrats. Encore faut-il cependant que le tiers choisi soit véritablement indépendant de l'une ou de l'autre partie.

S'ils sont certainement licites dans leur principe, ces procédés peuvent susciter des difficultés d'application si le mode choisi ne peut pas techniquement être mis en œuvre, pour des raisons indépendantes de la volonté des parties. Il en va ainsi, en particulier si le tiers désigné « ne veut ou ne peut faire l'estimation » : dans ce cas, l'article 1592 du Code civil prévoit que « il n'y a point de vente »[708]. Cette solution draconienne correspond à la conception traditionnelle dans les pays du Code civil,

706 De tels indices peuvent servir à la détermination initiale du prix d'un contrat ; mais ils sont le plus souvent utilisés pour faire varier un prix fixé au départ. Sur ces clauses d'indexation, voy. *infra*, n° 654.

707 Le texte utilise à tort le terme « arbitrage ». L'arbitrage est un mode de règlement des litiges par une juridiction privée. Ici, les parties ne sont pas à proprement parler en litige, leur désaccord sur le prix étant insusceptible d'être tranché par un juge par application de règles de droit. Le renvoi au tiers s'analyse plutôt comme un mandat commun donné par les parties au tiers pour fixer le prix en leur nom. La décision du tiers lie les deux parties, comme tout acte fait par un représentant au nom du représenté. C'est pourquoi, en droit français, on a remplacé en 2016 la formule « laissé à l'arbitrage d'un tiers » par « laissé à l'estimation d'un tiers ».

708 On remarquera que, conformément à ce qui a été soutenu précédemment, la sanction de cette impossibilité de détermination d'un élément essentiel du contrat n'est pas simplement la nullité du contrat, mais son inexistence.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

qui limite l'intervention du juge dans le contrat. L'évolution de la conception du rôle du juge en matière contractuelle pourrait cependant conduire à une solution plus pragmatique consistant à permettre au juge de se substituer au tiers défaillant, ou de nommer un autre tiers (de même qu'il peut désormais en droit français substituer un nouvel indice à celui qui a disparu). Les différents projets européens vont généralement dans ce sens : ainsi l'article 6 :106 des PDEC prévoit que « lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par un tiers et que celui-ci ne peut ou ne veut le faire, les parties sont présumées avoir donné au tribunal le pouvoir de lui désigner un remplaçant qui procédera à cette détermination ».

2) *Détermination par la volonté unilatérale d'une partie*

324. Problématique. Une chose est certaine : comme on l'a déjà dit, les parties ne peuvent se contenter, pour fixer les éléments quantitatifs laissés en suspens, de renvoyer à un accord de volontés ultérieur entre elles, car cet accord ne pourra peut-être jamais être obtenu de sorte que le contrat restera incomplet. Mais peut-on concevoir que les parties conviennent, au départ, de laisser le soin à l'une d'elles de déterminer ultérieurement un élément du contrat, et notamment le prix, soit directement, soit indirectement par l'application de certains facteurs dont cette partie a la maîtrise (le tarif qu'elle pratiquera au moment de la livraison, le prix du marché qui sera laissé à son appréciation, etc.) ? Le Code civil ne règle pas expressément la question. Contrairement à une lecture qui est souvent faite de l'article 1129 du Code civil, ce texte, s'il impose que l'objet soit déterminable, n'exclut nullement que cette détermination soit laissée à la décision d'une partie. Cependant, on éprouve instinctivement une certaine réticence à l'encontre d'une telle formule, qui apparaît comme particulièrement dangereuse pour l'autre partie. Au-delà, cette faculté de détermination unilatérale d'un élément essentiel d'une relation contractuelle paraît contraire à la notion même de contrat, œuvre commune de deux ou plusieurs personnes, qui ne devrait pas pouvoir être laissée à l'arbitraire d'une seule, comme le montrent du reste d'autres textes du droit des contrats[709]. D'un autre côté cependant, une telle faculté peut donner au contrat, surtout s'il est de longue durée, une grande adaptabilité, notamment en ce qu'elle permet de le faire « coller » aux évolutions du marché, et on peut concevoir que la liberté donnée à une partie pour assurer cette adaptation soit bornée par certains garde-fous

[709] On songe ici en particulier à la prohibition par l'article 1174 du Code civil des conditions purement potestatives, qui font dépendre l'existence d'une obligation contractuelle de la seule volonté du débiteur (voy. *infra*, n°s 593 et s.). Même si, techniquement, la détermination unilatérale de l'objet par une partie n'a rien à voir avec une telle condition, les raisons qui justifient la prohibition de l'article 1174 du Code civil semblent se retrouver ici.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

permettant de protéger l'autre. C'est pourquoi, dans une Europe essentiellement libérale, et très soucieuse de l'efficacité économique des rapports contractuels, la tendance générale est à permettre par principe cette détermination unilatérale de l'objet du contrat, manifestation typique de ce qu'on a appelé l'unilatéralisme contractuel[710]. En témoignent les différents textes internationaux et projets européens. À l'intérieur même des pays du Code civil, on observe une nette montée de l'unilatéralisme, même si la faculté de détermination unilatérale fait l'objet en France et en Belgique d'approches différentes, au sein desquelles la position du droit luxembourgeois est pour l'instant difficile à cerner. Cependant cette faculté, assez largement reconnue en droit commun (**a**) connaît diverses limites dans des textes spéciaux (**b**).

a. *Droit commun*

325. Droit français. Le droit civil français demeure largement attaché au principe selon lequel la détermination de l'objet du contrat ne peut pas être laissée à la décision unilatérale de l'une des parties[711]. Il y déroge cependant dans le cas le plus important, à propos de la détermination du prix. Cette position est le résultat d'une évolution jurisprudentielle remarquable, et abondamment commentée, qui s'est produite à propos de la détermination du prix dans les contrats-cadres de fourniture (notamment de produits pétroliers aux exploitants de stations-services ou de bière à des tenanciers de cafés et de restaurants). Jusqu'en 1978, la Cour de cassation française estimait que, dans ces contrats, le prix des produits fournis n'avait pas à être fixé par avance dans le contrat-cadre pour toute la durée de la relation, mais qu'il suffisait qu'il soit déterminé à l'occasion de chaque contrat de fourniture. Cela revenait à dire que le prix pouvait être laissé à la volonté unilatérale du fournisseur, dans la mesure où le fourni, étant généralement tenu dans ces contrats d'une obligation d'exclusivité, n'avait pas la possibilité de refuser d'acheter au prix qui lui était proposé par son fournisseur. Mais, à partir de 1978, dans le but de protéger le fourni, la Cour de cassation condamna les contrats ne comportant pas de

710 Sur ce phénomène, voy. not. D. MAZEAUD et C. JAMIN (dir.), *L'unilatéralisme et le droit des obligations*, Paris, Economica, 1999 – *adde* plus récemment : P. LEMAY, *Le principe de la force obligatoire du contrat à l'épreuve du développement de l'unilatéralisme*, Paris, Mare & Martin, 2014. Z. MCHIRGUI, « L'unilatéralisme en droit des contrats à travers les réformes récentes en Europe », *J.T.L.*, 2024/5, pp. 129-136.

711 Cass. fr ; (comm.), 19 novembre 1996, n° 94-14530.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

détermination initiale du prix, ou du moins ne prévoyant pas sa fixation ultérieure en fonction de critères objectifs. Elle le fit d'abord par une extension du domaine d'application de l'article 1591 du Code civil (imposant la fixation du prix dans le contrat de vente), puis par application au prix des contrats-cadres de l'article 1129 du Code civil – supposant implicitement que ce texte exigeait une détermination de l'objet indépendante de la volonté d'une partie. Cette jurisprudence, qui suscitait de multiples problèmes (quant à la nature de la nullité des contrats ne fixant pas le prix, quant aux conséquences de cette nullité), perdura jusqu'en 1995, date à laquelle, sous la pression de la doctrine libérale, la Cour de cassation jugea, dans une série d'arrêts d'Assemblée plénière, non seulement que, dans les contrats-cadres, il n'est pas nécessaire que le prix soit fixé au départ pour tous les contrats d'application[712], mais encore, d'une manière plus générale, que « l'article 1129 n'est pas applicable à la détermination du prix »[713]. La formule était manifestement inexacte en ce qu'il faut bien, de toute façon, que le contrat prévoie un mode de détermination du prix, explicitement ou implicitement : ce que voulait dire la Cour de cassation, c'est que le prix peut être fixé unilatéralement par une des parties en cours d'exécution[714]. Cependant, cette partie ne doit, dans la fixation du prix, pas commettre d'abus : si elle fixe un prix déraisonnable, l'autre peut faire sanctionner ce manquement en demandant des dommages et intérêts et/ou la résolution du contrat. Par rapport à la jurisprudence antérieure, le contrôle exercé par les tribunaux se trouve déplacé du stade de la validité du contrat à celui de son exécution[715]. Cette solution s'appliquait par principe à tous les contrats, sauf à ceux qui étaient soumis à une réglementation spéciale, et pas seulement aux contrats-cadres[716]. En revanche, la solution, présentée comme dérogatoire à l'article 1129 du Code civil, ne s'appliquait qu'à la détermination du prix, et non aux autres éléments du contrat, pour lesquels la détermination par volonté unilatérale restait interdite[717]. La réforme de 2016 a

712 Cass. fr. (ass. plén.), 1er décembre 1995, nos 91-15999, 91-19653, 91-15578.

713 Cass. fr. (ass. plén.), 1er décembre 1995, no 93-13688.

714 Dans ce sens ZENATI-CASTAING REVET, no 14, qui jugent absurde l'affirmation de la Cour de cassation.

715 Pour une application récente de la notion d'abus dans la fixation unilatérale du prix : Cass. fr. (comm.), 4 novembre 2014, no 11-14206, *R.D.C.*, 2015, no 2, p. 233, note STOFFEL-MUNCK.

716 Cass. fr. (1re civ), 6 mars 2001, no 98-17057.

717 ZENATI-CASTAING REVET, no 14 qui estiment que la solution devrait être élargie à toute détermination d'une chose de genre.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

consacré des solutions légèrement différentes dans les articles 1164 et 1165 du Code civil. Ces textes, tout comme la jurisprudence antérieure, ne concernent que la détermination unilatérale du prix, et pas d'une autre prestation. Mais, contrairement à la solution antérieure, cette détermination n'est possible que dans certains types de contrats : les contrats-cadres (art. 1164) où le procédé peut être convenu par les parties, et les contrats de prestation de service où cette fixation par une partie est de droit si le prix n'a pas été fixé au départ par accord des parties. Dans les deux cas, la partie autorisée à fixer le prix doit motiver le montant en cas de contestation, et l'abus peut être sanctionné par des dommages et intérêts ou la résolution du contrat (sans que le juge puisse fixer lui-même le prix). Ces solutions sont assez nettement inspirées de l'avant-projet Catala[718]. Le projet Terré allait, lui, beaucoup plus loin, en permettant, d'une manière générale, la fixation unilatérale de l'objet de l'obligation (et pas seulement du prix) « dès lors que les modalités de détermination ont été précisément fixées par le contrat et qu'il est fait usage de cette faculté de manière raisonnable ». Le texte rejoignait largement les positions du droit belge.

326. Droit belge. La question de la détermination de l'objet par voie de décision unilatérale est un des points sur lesquels le droit belge s'est assez sensiblement éloigné du droit français, moins d'ailleurs dans les solutions que sur la manière de poser le problème[719]. À la différence du droit français, qui traite d'une manière spécifique de la question de la détermination du prix, la doctrine belge, spécialement néerlandophone, a développé cette problématique de manière générale, pour tous les éléments de l'objet et pas seulement pour le prix. Dès avant la récente réforme, il était assez généralement admis en Belgique qu'une partie pouvait se voir confier la faculté de déterminer l'étendue de toute prestation contractuelle, monétaire ou non par voie de *partejbeslissing* (décision unilatérale). Il fallait pour cela « qu'elle y soit autorisée par une disposition légale, par les usages ou par la volonté – expresse ou tacite – des parties elles-mêmes »[720]. Au-delà de divers textes spéciaux qui prévoient expressément

[718] Voy les articles 1121-3 à 1123-5 du projet Catala.

[719] Pour la comparaison du droit français et du droit belge sur cette question, voy. P. SOUSTELLE, « L'objet du contrat. La détermination unilatérale de l'objet des obligations au temps de l'exécution du contrat », in E. VAN DEN HAUTE (dir.), *Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge*, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 25 ets.

[720] WÉRY, n° 292 et les auteurs cités ; VAN OMMESLAGHE, n° 186.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

une telle faculté, il était admis que la liberté contractuelle permet en principe « d'abandonner à l'une d'elles le soin de fixer l'objet de l'obligation »[721]. La fixation unilatérale du prix n'était, dès lors, présentée que comme une application particulière de cette *partijbeslissing*[722], et non comme une solution dérogatoire à l'article 1129 du Code civil. Cette faculté pouvait être accordée aussi pour déterminer l'étendue d'une prestation non monétaire, par exemple l'étendue des travaux qu'un prestataire de services (garagiste, plombier, etc.) peut être autorisé à faire. Cette faculté n'etait cependant admise que si elle avait été prévue par la loi, les usages ou la convention des parties : la Cour de cassation belge avait en effet jugé que, dans un contrat d'entreprise, « la règle suivant laquelle le prix des travaux est, à la fin de ceux-ci et sauf convention contraire, fixé unilatéralement et de bonne foi par l'entrepreneur, sous le contrôle marginal du juge, ne constitue pas un principe général du droit »[723]. Ces solutions ont été reprises lors de la réforme : l'article 5.49 du nouveau Code prévoit en effet d'une manière générale que « [l]a détermination de la prestation peut, en vertu de la loi, du contrat ou des usages, être confiée à une des parties ou à un tiers déterminé ou déterminable, sauf si la loi l'interdit ».

Bien que, à la différence des textes français, le nouveau texte n'en dise rien, une telle *partijbeslissing* ne peut bien entendu pas être complètement arbitraire. Elle peut, si l'autre partie la conteste, être contrôlée *a posteriori* par le juge, à qui il appartiendra de vérifier si le contractant n'a pas abusé de son droit, par exemple en imposant à l'autre un prix beaucoup trop élevé, ou en effectuant des travaux disproportionnés. Selon l'expression même de la Cour de cassation belge, il ne s'agit ici que d'un « contrôle marginal », ce qui signifie que la décision du tiers ne sera sanctionnée que si elle est manifestement déraisonnable. Dans un tel cas, conformément aux solutions généralement admises en cas d'abus de droit en Belgique[724], il semble que le juge puisse, non seulement condamner le contractant à des dommages et intérêts, mais aussi substituer à la décision abusive du créancier un prix conforme aux exigences

721 Wéry, *op. cit.* et *loc. cit.*

722 Voy., Cass., 9 novembre 2006, *R.G.D.C.*, 2009, pp. 24 et s., note J.-F. GERMAIN. J.-F. GERMAIN, « La fixation unilatérale du contenu du contrat », in *La volonté unilatérale dans le contrat*, Bruxelles, éd. Jeune Barreau, 2008, pp. 87 et s.

723 Cass. be., 9 novembre 2006, n° C050218F ; *R.G.D.C.*, 2009, pp. 24 et s., note J.-F. GERMAIN.

724 Voy. *infra*, n° 500.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de la bonne foi[725] – ce qui n'est certainement pas possible en droit français. On retrouve la même approche dans les projets européens de droit des contrats[726].

327. Droit luxembourgeois. Le droit luxembourgeois se situe ici assez nettement dans la mouvance française. Un arrêt ancien de la Cour d'appel avait jugé qu'en matière de vente de choses fongibles la quotité n'a pas besoin d'être indiquée numériquement dans le contrat, mais qu'il suffit qu'elle soit déterminable suivant les clauses de la convention ou, simplement, suivant les circonstances ou les usages, « de manière à ce que l'exécution ne soit plus subordonnée au caprice du débiteur »[727]. De même en 1970, la Cour a jugé, à propos d'une vente de fonds de commerce, qu'« il suffit pour la formation du contrat que le prix puisse être déterminé par voie de relation avec les éléments qui ne dépendent plus de la volonté ni de l'une ni de l'autre des parties »[728]. Un jugement récent du Tribunal de Luxembourg pose de même que, si on peut « conclure le contrat à partir d'une prestation qui sera déterminée ultérieurement, au moment de l'exécution du contrat, sans qu'il ne soit nécessaire de renouveler l'accord des parties », cette détermination doit se faire « par référence à des critères objectifs. L'objectif est d'éviter qu'une seule partie ne puisse ensuite déterminer la prestation à son bon vouloir »[729]. Le tribunal voit là une « exigence de bon sens » qui « vise deux objectifs : il s'agit, tout d'abord, de vérifier qu'un accord "est intervenu sur l'essentiel, la chose due" ; il s'agit, dans le même temps, de veiller à ce "que l'une des parties ne soit pas placée à la merci de l'autre" »[730]. Cependant, comme en France, la Cour d'appel déroge à cette exigence de principe en matière de contrats-cadres. Dans un arrêt de 1996, suivant très fidèlement la position française de 1995, elle a posé que « en présence d'un contrat-cadre qui s'exécute par des sous-contrats de vente lors desquels la quantité et le prix des marchandises vendues sont à chaque fois déterminées d'un commun accord, c'est seulement lors de

725 WÉRY, n° 293.

726 Voy., p. ex., l'article II-9 :105 du DCFR : « *Where the price or any other contractual term is to be determined by one party and that party's determination is grossly unreasonable then, notwithstanding any provision in the contract to the contrary, a reasonable price or other term is substituted* » ; comp. l'article 6:105 du PDEC.

727 Cour d'appel, 2 mai 1913, *Pas.*, 9, p. 132.

728 Cour d'appel, 16 juin 1970, *Pas.*, 21, p. 366 (validant une vente dans laquelle il avait été convenu que le prix « ne pouvait être inférieur à 400 000 francs »).

729 Trib. Luxembourg, 24 février 2024, préc.

730 Le tribunal cite ici : J. MESTRE, obs. : *RTD civ.*, 1995, p. 620) (JCL, art. 1162 à 1171, fasc. 30 : CONTRAT – Contenu du contrat : objet du contrat, n°s 32-34).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la passation de ces sous-contrats que les dispositions des articles 1129 et 1592 du Code civil doivent être respectées, le contrat-cadre devant contenir les éléments de précision et de compréhensibilité requis pour la validité de toute convention »[731]. Un autre arrêt, rendu à propos d'un contrat d'approvisionnement en bière, a jugé de même que la référence aux listes des prix émises par la brasserie, comporte un prix qui est déterminable, alors même que ces listes de prix sont unilatéralement fixées[732]. En 2003, la Cour a réitéré, toujours à propos d'un contrat de bière, que l'indétermination du prix des fournitures dans un contrat-cadre n'affecte pas la validité de ce contrat[733]. En dehors du contexte particulier des contrats-cadres, le tribunal de Luxembourg a, quant à lui, admis que dans un contrat d'entreprise, pour lequel aucun prix ne peut être convenu à l'avance, le client pouvait s'en remettre à l'entrepreneur pour fixer le prix après la fin des travaux, sauf au client à contester le prix en justice s'il l'estime excessif[734].

b. *Textes spéciaux*

328. **Solutions traditionnelles et nouvelles.** Une limite importante à la possibilité de déterminer unilatéralement le prix du contrat est traditionnellement tirée de l'article 1591 du Code civil selon lequel « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». À l'instar de la jurisprudence française moderne, les juridictions luxembourgeoises admettent que ce texte n'impose pas que le prix soit déterminé au moment même de la vente, il suffit qu'il soit déterminable[735]. Cependant, cette détermination ultérieure doit dépendre d'éléments objectifs (ou, comme le prévoit l'article 1592 du Code civil, de la décision d'un tiers), et non de la seule volonté de l'une des parties[736]. Cette solution rejoint celle qui est admise en France[737], ainsi que l'opinion généralement reçue en Belgique[738], et au Luxembourg.

731 Cour d'appel, 2 octobre 1996, *Pas.*, 30, p. 145 (la formule « sous-contrats » utilisée ici par la Cour d'appel désigne ce qu'il vaudrait mieux appeler « contrats d'application », le terme « sous-contrat » étant habituellement utilisé pour désigner un contrat par lequel un contractant charge un tiers d'exécuter la prestation dont elle a été chargée). Bien que la Cour relève que le prix est fixé d'un commun accord lors de chaque contrat d'application, la solution revient en fait à valider une détermination unilatérale, dès lors que, comme il a été dit, la partie tenue d'une obligation d'exclusivité ne peut pas refuser de passer les contrats d'application au prix qui lui est proposé par le fournisseur.

732 Cour d'appel, 17 décembre 1997, *Pas.*, 30, p. 305.

733 Cour d'appel, 26 mars 2003, n° 26569, *BIJ*, 2003, p. 100.

734 Trib. Luxembourg, 6 novembre 2003, n° 72902, *BIJ*, 2004, p. 26 ; Trib. Luxembourg, 15 juillet 2004, n° 83970, *BIJ*, 2004, p. 122.

735 Trib. Luxembourg, 24 février 2022, n° TAL-2020-09028.

736 Cour d'appel, 16 juin 1970, *Pas.*, 21., p. 366 ; Trib. Luxembourg, 24 février 2022, préc.

737 Voy. p. ex. : Cass. fr. (1re civ.), 14 décembre 2004, n° 01-17063.

738 WÉRY, n° 293, qui remarque cependant que l'article 1710 du Code civil relatif au louage, qui parle du « prix convenu » entre les parties, n'a jamais été interprété comme excluant la détermination unilatérale du loyer ; E. VAN DEN HAUTE, *Traité des contrats spéciaux*, Bruxelles, Larcier, 2024, vol. 1, nos 104 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Les autres textes qui excluent expressément la faculté de détermination unilatérale d'un contrat sont plus récents, et procèdent clairement de la volonté du législateur de protéger un contractant en situation de faiblesse contre les abus de pouvoir de l'autre. On citera ici l'article L. 121-4 du Code du travail, qui impose de faire figurer dans le contrat de travail le montant du salaire, la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation qui implique que la fixation du loyer résulte d'un accord initial des parties, et l'article L. 211-3 du Code de la consommation qui considère comme abusives certaines clauses permettant au professionnel de fixer ou de modifier unilatéralement le prix du contrat ou les prestations qu'il fournit[739].

SECTION 2. LES CARACTÉRISTIQUES DE L'OBJET DU CONTRAT

329. Limites à la liberté du choix de l'objet. Si la liberté contractuelle permet en principe de prendre pour objet d'un contrat n'importe quelle chose ou n'importe quelle prestation, cette liberté n'est pas sans limite. Les parties ne peuvent contracter que sur un objet qui existe (**§ 1**), qui est possible (**§ 2**) et, surtout, qui est licite (**§ 3**).

§1. L'existence de l'objet

330. Problématique. L'affirmation selon laquelle l'objet que les parties ont choisi doit exister peut être déduite de la formule de l'article 1108 du Code civil selon laquelle le contrat doit, pour être valable, avoir « un objet certain ». De prime abord, cette affirmation ne semble avoir qu'une portée pratique très limitée : on n'imagine pas que les parties prennent pour objet une chose qui n'existe pas et qui n'existera jamais. La question se pose cependant de savoir à quel moment la chose objet du contrat doit exister : les parties peuvent-elles prendre pour objet une chose qui n'existe pas encore, mais dont elles anticipent l'existence ? Et que se passe-t-il si elles contractent sur une chose qui a existé, mais qui n'existe plus ?

Dans les deux cas, lorsqu'on parle d'existence de l'objet, ce terme s'entend au sens premier de « chose » ou plus largement de « bien » sur lequel porte le contrat. Cela n'a évidemment aucun sens de se demander si la prestation que les parties s'obligent à accomplir existe ou non, la seule question est ici de savoir si elle est possible.

739 Art. L. 211-3, n°s 10 et 14.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

A) *Contrats portant sur des choses futures*

331. Principe de validité. Il arrive très souvent qu'un contrat porte sur une chose qui n'existe pas encore au jour de sa conclusion, soit que le contrat ait précisément pour objet de faire advenir cette chose à l'existence (contrat de construction d'une maison, de fabrication d'une machine par exemple), soit qu'il vise à donner immédiatement à une partie un droit ou à faire naître à sa charge une obligation par rapport à une chose à fabriquer (achat d'un véhicule neuf qui n'est pas encore sorti de la chaîne de fabrication, achat du vin provenant de la récolte à venir d'un viticulteur, cession de créances à naître d'un marché non encore passé[740], y compris de celles dont il deviendra ultérieurement propriétaire, etc.). La validité de ce type de contrat ne fait aucune difficulté, et on peut trouver assez inutile l'article 1130 du Code civil qui affirme expressément que « les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation ».

Cependant ces contrats font naître des risques particuliers : même si tout contrat est une anticipation sur l'avenir, les incertitudes qu'il génère sont évidemment beaucoup plus grandes lorsque le bien sur lequel il porte n'existe pas encore que lorsqu'il peut être immédiatement vu, touché, appréhendé. Il suffit ici de comparer la situation de l'acheteur d'une maison ancienne (qui a pu la visiter, et qui sait qu'il va pouvoir presque sûrement en prendre possession) avec celle du client qui fait construire sa maison par un entrepreneur ou qui achète un appartement sur plans. De même, le banquier qui fait crédit et qui accepte en garantie des créances résultant d'un marché que son emprunteur s'apprête à passer, est évidemment moins protégé que s'il prend une garantie sur des biens existants de son client. D'un autre côté, la faculté laissée à une personne d'engager par contrat des biens qui n'existent pas encore dans son patrimoine peut inciter cette personne à des comportements déraisonnables, au stade de son endettement ou de la manière dont elle se procurera les biens. Ces diverses considérations ont amené le législateur, soit à réglementer certains contrats portant sur des choses futures[741], soit à en interdire certains jugés particulièrement dangereux.

332. Limites. L'exception la plus importante au principe de validité des contrats portant sur des choses futures est posée par l'article 1130 du Code civil lui-même, qui prohibe ce qu'on appelle les « pactes sur succession future ». L'étude détaillée de

740 Trib. Luxembourg, 31 juillet 1936, *Pas.*, 14, p. 60.

741 Voy., p. ex., les articles 1601-1 à 1601-14 du Code civil, issus d'une loi du 28 décembre 1976, réglementant la vente d'immeubles à construire.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

cette prohibition, dont la portée est très difficile à cerner, relève du droit des successions et on se contentera d'en donner ici une idée générale : il s'agit d'interdire les contrats par lesquels on renoncerait par avance à hériter d'une personne (renonciation anticipée particulièrement dangereuse pour le renonçant, car faite à un moment où il ne connaît pas l'importance de la succession future) ou, à l'inverse, par lesquels on disposerait par avance de biens dont on ne deviendrait propriétaire qu'au décès d'une personne (ce qui, à la fois, est très incertain, et, craint-on, risque de faire naître chez le disposant le vœu de voir mourir au plus tôt celui dont on pense hériter !)[742]. Cette prohibition, qui est un aspect de l'exigence générale de conformité du contrat à l'ordre public, est sanctionnée par la nullité absolue du contrat.

C'est pour des raisons très différentes que l'article 2129, alinéa 2 du Code civil interdit d'hypothéquer des « biens à venir ». Cette prohibition vise essentiellement à éviter qu'une personne ne s'endette de manière inconsidérée en engageant par avance des immeubles dont elle ne serait pas encore propriétaire, compromettant ainsi son avenir[743] ; la règle, qui connaît diverses exceptions, est typique du souci des rédacteurs du Code civil d'assurer la conservation des immeubles dans les familles.

B) *Contrats portant sur des choses n'existant plus*

333. Nullité. Il arrive que les parties contractent sur une chose qui, sans qu'elles le sachent, n'existe plus au moment où le contrat est passé. Imaginons par exemple que je vous vende ma maison, en ignorant que, au moment même où nous signons l'acte, elle vient d'être complètement détruite par un incendie, de sorte qu'elle n'est plus qu'un tas de cendres. La question est de savoir qui doit supporter les risques de cette disparition : devez-vous quand même me payer la maison, comme ce serait le cas si la destruction avait eu lieu juste après la signature du contrat ? En matière de vente, la réponse est certainement négative : le transfert des risques liés à la vente est lié au transfert de propriété de la chose ; or dans mon exemple, ce transfert n'a pas pu avoir lieu, puisque la maison n'existait plus. Le contrat n'a plus d'objet. Aussi bien est-il logique que l'article 1601 du Code civil considère que, dans un tel cas, la vente

742 Pour la Cour d'appel, ne constitue pas en revanche un pacte sur succession future le contrat par lequel on emprunte de l'argent en stipulant que la créance ne deviendra exigible qu'au moment du décès d'une personne dont l'emprunteur doit hériter : Cour d'appel, 4 juin 2003, n° 26058, *BIJ*, 2003, p. 105 ; Cour d'appel 15 novembre 2007, *Pas.*, 34, p. 61.

743 Cette préoccupation est plus que jamais d'actualité. Mais, plus que par la règle désuète et de portée très limitée de l'article 2129 du Code civil, elle se traduit plus aujourd'hui à travers les règles protectrices des consommateurs en matière de crédit immobilier, et par les obligations prudentielles imposées aux banques lors de l'octroi des crédits (voy. à cet égard dir. 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010). Voy. les art. L.226-1 du Code de la consommation du Luxembourg.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

est nulle[744]. Bien que les articles 1126 et suivants du Code civil sur l'objet ne contiennent aucune règle générale à ce sujet, on peut sans difficulté transposer la solution à tous les contrats portant sur une chose : si la chose n'existe plus au moment où le contrat est passé, le contrat n'a plus aucune utilité économique et aucune des deux parties ne peut être tenue de l'exécuter. Le locataire n'a évidemment pas à payer les loyers si l'appartement qu'il loue avait été détruit au moment de la signature, pas plus que celui qui s'est engagé à réparer une chose ayant disparu ne peut être sanctionné s'il ne fait pas le travail. Les solutions doivent être clairement distinguées de celles qui s'appliquent lorsque la chose objet du contrat périt après la formation de celui-ci. La question relève alors de la théorie des risques, qui définit les effets de la force majeure sur l'exécution du contrat[745]. On retrouve la même distinction à propos du cas des prestations impossibles, que nous allons maintenant examiner.

§ 2. La possibilité de l'objet

334. Impossibilité absolue et impossibilité relative. Bien que, dans le Code civil, aucune règle générale ne figure à ce sujet, il est généralement admis que le contrat est nul si la prestation à laquelle s'est obligée l'une des parties était impossible à exécuter. Cette exigence apparaît du reste expressément dans une série de textes et projets récents, nationaux et européens[746]. Elle n'a qu'une portée assez limitée. En effet, le contrat ne sera nul que si l'impossibilité était absolue, et non relative par rapport aux capacités et aux compétences du débiteur. Si je m'engage à faire quelque chose qui dépasse totalement mes compétences – par exemple donner un concert de violon pour fêter votre anniversaire –, ou que mon emploi du temps surchargé ne me permet pas de faire dans les délais, je ne pourrai me soustraire à mon engagement en invoquant l'impossibilité que représente pour moi une telle prestation. Le contrat est valable, et je serai sanctionné pour ne pas l'avoir exécuté. La nullité ne pourra être prononcée que si la prestation était objectivement impossible à réaliser pour toute personne[747].

[744] L'article 1601, alinéa 2 du Code civil règle le cas – beaucoup plus compliqué – où la chose vendue est seulement détériorée, l'acheteur ayant alors le choix entre le maintien du contrat avec réduction du prix ou l'abandon de la vente.

[745] Voy *infra*, n° 766.

[746] Voy. p. ex. : Code Gandolfi, art. 25 ; Code civil français 2015, art. 1163 ; Nouveau Code civil belge art. 5.47.

[747] Dans ce sens : Trib. Luxembourg (2e comm.), n° 2196/14, 7 novembre 2014.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Entrent évidemment dans cette catégorie les cas précédemment examinés où le contrat avait pour objet une chose qui n'existait plus lors de sa conclusion : il était du coup absolument impossible de la livrer, de la louer, de la réparer, etc. Mais on y rangera aussi des contrats qui promettent une prestation irréalisable en l'état actuel de la science et des techniques (même si on peut penser qu'elle le sera un jour) : si un organisateur de voyages interplanétaires vous promet, moyennant un prix très élevé, de vous emmener sur Mars dans les 10 ans à venir, vous pourrez sans doute faire annuler ce contrat, pour ne pas avoir à payer ou pour vous faire rembourser le prix du billet[748]. Cette nullité devrait logiquement être considérée ici comme une nullité relative, car elle a pour but de protéger celui qui s'est fait promettre la prestation impossible. On pourrait aussi traiter comme objet impossible les prestations interdites par une disposition légale ou réglementaire – par exemple la livraison de marchandises dans un pays frappé par un embargo international. Mais, dans un tel cas, la nullité (absolue) sera plutôt prononcée sur le fondement d'une contrariété à l'ordre public.

Le tribunal de Luxembourg a annulé pour impossibilité de l'objet un contrat par lequel un associé de société avait promis à une autre personne, moyennant le paiement d'une certaine somme, qu'elle le ferait nommer comme gérant de cette société. Le tribunal estime que cet objet était impossible, car l'associé, titulaire de moins de 50 % des parts sociales, n'avait aucun pouvoir sur la nomination du gérant, qui relevait de l'assemblée générale[749]. Cette décision est assez contestable, car on pourrait plutôt voir dans l'engagement pris une promesse de porte-fort[750] : l'associé, alors même qu'il n'a pas de pouvoir, se porte fort de ce que la société nommera la personne comme gérant. Quel que soit le raisonnement tenu, le résultat est cependant à peu près le même, du moins si la personne n'est finalement pas acceptée comme gérant : la nullité du contrat pour impossibilité de l'objet conduit au remboursement par l'associé de la somme qu'il a fait payer à la personne ; l'inexécution par l'associé de la promesse aboutit à le faire condamner à des dommages et intérêts qui intégreront au moins le remboursement de la somme payée pour rien.

335. Impossibilité initiale et impossibilité ultérieure. Il faut bien distinguer le cas où l'objet est impossible dès la conclusion du contrat, ce qui est susceptible d'entraîner la nullité de celui-ci, et le cas, beaucoup plus fréquent en pratique, où la prestation objet du contrat, possible à l'origine, devient par la suite, en raison de

748 L'organisateur, de son côté, qui ne pourra pas tenir sa promesse, ne sera tenu d'aucune responsabilité contractuelle. Mais il pourrait être tenu d'une responsabilité délictuelle, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour vous avoir fautivement fait miroiter un voyage impossible.

749 Trib. Luxembourg (2e comm.), n° 2196/14, 7 novembre 2014.

750 Voy. *supra*, n° 300.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

circonstances extérieures imprévisibles et irrésistibles, impossible à exécuter. On est alors en présence de ce qu'on appelle la force majeure. Celle-ci, intervenant au stade de l'exécution du contrat, n'a aucune incidence sur la validité de celui-ci, mais elle a d'importantes conséquences quant aux sanctions de l'inexécution. La différence d'effets apparaît clairement dans le cas des contrats translatifs de propriété : alors qu'une impossibilité initiale de livrer la chose, tenant à ce que cette chose avait déjà été détruite lors de la conclusion du contrat, libérera les deux parties (l'acheteur et le vendeur), l'impossibilité tenant à la destruction de la chose après la conclusion du contrat ne libérera pas en principe l'acheteur, devenu propriétaire de la chose, et devant supporter les risques liés à sa destruction. Par ailleurs, l'impossibilité prise en compte n'est pas nécessairement la même aux deux stades : une impossibilité relative, tenant à l'incapacité personnelle d'exécuter du débiteur, peut constituer, dans une conception extensive, un cas de force majeure, alors qu'elle ne peut pas entraîner la nullité du contrat.

§ 3. La licéité de l'objet

336. Licéité de l'objet et exigence générale de conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs. D'une manière générale, le contrat doit être licite, c'est-à-dire conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Il s'agit là d'une exigence transversale, dont nous ferons plus loin l'étude de manière générale[751], et qui affecte en particulier les différents aspects de l'objet du contrat. Le contrat pourra être annulé, si une prestation mise à la charge d'une partie est contraire à l'ordre public : ainsi si l'une des parties s'engage envers l'autre à tuer un tiers. Il sera également frappé de nullité si, alors même que chaque prestation, en elle-même, est licite, leur juxtaposition au sein de l'opération contractuelle est, elle, contraire à la loi : ainsi, il n'est pas en soi illicite de faire des travaux de jardinage pour quelqu'un qu'on veut aider ; et il n'est pas en soi illicite de payer quelqu'un en rémunération d'un service. Mais, au Luxembourg, on ne peut, en vertu de la loi du 2 septembre 2011, exercer une profession d'artisan, de commerçant, ou d'industriel que si on dispose d'une autorisation d'établissement. Donc, si je demande à quelqu'un qui n'a pas cette autorisation de me faire mon jardin moyennant finances, le contrat a un objet contraire à

751 Voy. *infra*, n°s 388 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'ordre public, alors même que, en soi, chacune des prestations qu'il contient est licite. Dans ces différentes hypothèses, l'intervention de l'ordre public ne présente pas de spécificité du fait qu'il touche à l'objet, entendu comme prestation prévue par le contrat (objet de l'obligation), ou comme opération mise en place par le contrat (objet du contrat). L'intervention de l'ordre public va en revanche se traduire de manière spécifique lorsqu'on prend en considération la chose sur laquelle porte le contrat : l'ordre public s'oppose en effet, de manière plus ou moins large, à ce que certaines choses puissent être choisies comme objet d'un contrat. C'est ce qu'on appelle les choses « hors du commerce », visées à l'article 1128 du Code civil. On précisera ici cette notion (**A**), avant d'en présenter quelques applications caractéristiques (**B**).

A) *Notion de choses hors du commerce*

337. Relativité. L'article 1128 du Code civil dispose que « il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent faire l'objet de conventions ». La notion de « commerce » dont il est question ici ne se réfère pas au sens moderne d'activité commerciale opposée à l'activité civile. Il s'agit plus largement du « commerce juridique », désignant toute forme de convention ayant pour objet l'échange ou la circulation des biens. Repris de la notion romaine des « *res extra commercium* », le texte, rédigé de manière assez maladroite, signifie simplement que certaines choses – ou plus largement certains biens – ne sont pas susceptibles de faire l'objet de contrats, mais il ne nous indique pas quelles sont des choses « hors du commerce ». La détermination de ces choses résulte, soit de textes spéciaux (par exemple, l'interdiction de la vente de stupéfiants), soit de la jurisprudence (par exemple, l'indisponibilité du corps humain).

En réalité, la notion de « choses hors du commerce » ne doit pas être prise de manière trop absolue. Il est très exceptionnel qu'une chose ou un bien ne puisse faire l'objet d'aucune convention. Si on prend l'application la plus caractéristique des choses hors du commerce, le corps humain, on s'aperçoit assez vite que celui-ci peut faire l'objet de très nombreux contrats : du contrat de soins passé avec un médecin, au contrat par lequel on se fait couper les cheveux par son coiffeur, en passant par tous les contrats de travail qui supposent une prestation corporelle du salarié. Comme très souvent, les rédacteurs du Code civil, lorsqu'ils ont rédigé les textes

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

du droit des contrats, avaient en tête le modèle de la vente[752], et la plupart des choses hors du commerce sont simplement des choses qui ne peuvent pas être vendues, ce qui n'exclut pas qu'elles puissent faire l'objet d'autres contrats. Les textes et la jurisprudence permettent de savoir, pour chaque chose de ce type, quels sont les contrats qui sont admissibles et à quelles conditions ils le sont. La prohibition des contrats portant sur des choses hors du commerce n'est, de ce point de vue, qu'un aspect particulier de l'interdiction des contrats contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et elle relève du même régime et des mêmes sanctions. C'est pourquoi les auteurs de la réforme française de 2016 n'ont pas jugé utile de maintenir cette règle spécifique dans le Code civil. Elle a été maintenue en revanche à l'article 5.48 du nouveau Code civil belge. La notion peut surtout avoir un intérêt symbolique : elle indique que, pour certaines choses, il y a de prime abord une réticence du droit à les intégrer dans une relation contractuelle ; la présence d'une telle chose dans un contrat allume donc une sorte de « signal d'alarme », amenant à n'admettre que de manière exceptionnelle la licéité de ce contrat.

La notion de choses hors du commerce connaît de multiples applications, et il est vain de prétendre ici en donner une énumération exhaustive, ni d'entrer dans le détail des différentes prohibitions et réglementations, dont l'étude relève d'autres disciplines. On se contentera d'en donner ici quelques applications caractéristiques.

B) *Applications*

338. Intérêt public. L'exclusion (relative) du commerce juridique de certaines choses est fréquemment justifiée par des considérations d'intérêt public. C'est ce qui explique, par exemple, que l'État ou les communes ne peuvent pas aliéner les biens qui font partie du domaine public, c'est-à-dire ceux qui sont affectés à un usage public (les routes, les ponts, les rivières navigables, etc.)[753]. Cependant – illustration de ce qui a été dit plus haut – cela n'exclut pas de manière générale la conclusion de contrats sur le domaine public, notamment des contrats par lesquels la personne publique confie

[752] Voy. *supra*, n° 224 à propos de l'erreur sur la substance.

[753] Sur la définition (incertaine) du domaine public en droit luxembourgeois, voy. M. THEWES et T. CHEVRIER, « La gestion des biens du domaine public », *Ann. dr. lux.*, 2010, n° 20, pp. 275 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

à un tiers la gestion de certains biens, ou accorde des concessions temporaires de leur usage[754]. Le lien avec l'intérêt public exclut aussi, dans une perspective différente, tous les contrats par lesquels le titulaire d'une fonction publique prétendrait la céder à un tiers : comme le dit une vieille décision luxembourgeoise « Les emplois, offices et fonctions qui impriment au titulaire un caractère public, ne peuvent être l'objet d'une convention privée »[755]. Et c'est encore l'intérêt public qui justifie la prohibition – à géométrie très variable suivant les pays – du commerce des drogues. Cependant, on voit là encore que la prohibition est relative : même si, au Luxembourg, la vente de cannabis demeure en principe interdite malgré la loi du 10 juillet 2023, la vente de produits interdits peut s'opérer dans certaines conditions à des fins médicales.

339. Personne humaine. La notion de choses hors du commerce s'applique ensuite à toutes sortes de biens qui sont en rapport avec la personne humaine. L'indisponibilité du corps humain, déjà évoquée, en est la principale application. Même si le droit luxembourgeois n'a pour l'instant pas développé, ni en législation, ni en jurisprudence, des règles générales aussi fournies que celles qui existent en droit français[756], ce principe est incontestable. On peut aujourd'hui le rattacher aux articles 12 et 13 de la Constitution du Grand-Duché. Le premier pose que « [l]a dignité de la personne humaine est inviolable », le second que « [t]oute personne a droit à son intégrité physique et mentale ». Il ne fait aucun doute qu'au Luxembourg, un contrat par lequel une personne prétendrait vendre son corps à une autre (par exemple, pour permettre à celle-ci de réaliser des expériences) serait nul. Il s'agit sans aucun doute d'une nullité absolue, parce que, même si cette prohibition peut permettre, de manière concrète, de protéger contre lui-même un contractant qui serait tenté de consentir à des actes trop dangereux pour sa vie ou sa santé[757], elle se justifie plus fondamentalement par l'idée de sacralité de la personne humaine, qui ne peut être réduite au

754 M. THEWES et T. CHEVRIER, « La gestion des biens du domaine public », *op. cit.*

755 J.d.P. Wiltz, 25 juin 1887, *Pas.*, 2, p. 463. qui annule une convention par laquelle un conseiller communal donne sa démission moyennant un prix stipulé et payé par un tiers (l'annulation est fondée sur la cause illicite, alors qu'elle relève plutôt de l'illicéité de l'objet).

756 Voy. not. les articles 16 à 16-9 du Code civil français, issus de diverses lois récentes relatives à la bioéthique, et regroupées sous un chapitre intitulé « Du respect du corps humain ».

757 Il suffit de songer à ce qui se passe dans certains pays où les pauvres consentent, pour des raisons financières, à vendre leurs organes.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

statut de chose[758]. Cependant, comme on l'a dit, les contrats portant sur le corps humain ne sont pas interdits d'une manière générale. Ils peuvent être valables s'ils sont justifiés par un intérêt thérapeutique, soit pour la personne concernée (contrat médical), soit, dans des conditions limitées et seulement s'ils sont à titre gratuit, pour un tiers[759]. En dehors d'un intérêt thérapeutique, les atteintes même consenties au corps ne seront licites que si elles sont de faible gravité – les limites de ce qui est permis et interdit n'étant pas clairement fixées[760]. Un des problèmes actuellement les plus discutés est celui des conventions de gestation pour autrui, passées avec une mère porteuse qui, en quelque sorte, loue son corps pour porter l'enfant qui sera ensuite attribué à une autre femme. Le projet de loi n° 6568 portant réforme de la filiation se proposait de prohiber explicitement cette pratique sur le territoire luxembourgeois, en introduisant un alinéa 2 à l'article 6 prohibant les contrats contraires à l'ordre public, tout en reconnaissant sous certaines conditions la filiation des enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger ». Mais le Conseil d'État s'y est opposé au motif que le sujet devait passer par une loi spéciale. Dans plusieurs arrêts récents, la Cour d'appel, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et l'évolution de la Cour de cassation française, a admis l'exequatur d'un jugement étranger reconnaissant la filiation à l'égard de parents luxembourgeois d'un enfant né à l'étranger d'une mère porteuse[761].

Au-delà de l'indisponibilité du corps humain, la sacralité de la personne humaine justifie la prohibition de différents contrats portant sur les aspects moraux de la personnalité. Bien qu'on parle souvent à cet égard d'un principe d'indisponibilité des droits de la personnalité, il n'est pas, en soi, interdit d'engager, par contrat, des intérêts protégés au titre des droits de la personnalité : ainsi ne sont pas illicites les contrats par lesquels une personne notoire (un

758 En droit romain le statut de choses *extra commercium* s'appliquait d'abord aux choses sacrées « *res divinae* ».

759 Voy. la loi du 15 mars 1979 sur la transfusion sanguine, la loi du 25 novembre 1982 sur le don d'organes, la loi du 1er août 2007 sur le don de tissus humains.

760 Voy. à cet égard à propos de pratiques sexuelles sado-masochistes entraînant des lésions corporelles significatives l'arrêt de la Cour eur. D.H., 17 février 2005, *K.A. ET A.D. c. Belgique*, nos 42758/98 et 45558/99, qui ne condamne ces pratiques que parce que, en l'espèce, elles n'avaient pas été véritablement consenties, semblant ainsi admettre que le consentement à de telles atteintes aurait pu être licite.

761 Cour d'appel, 6 mai 2020, n° CAL-2018-00957 ; Cour d'appel, 15 mai 2024, n° CAL-2022-01098.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

sportif, un acteur, un chanteur) autorise une entreprise à utiliser son nom comme marque, ou monnaye la publication de son image ou la divulgation de faits relatifs à sa vie privée. Ce qui serait interdit, en revanche, serait de passer un contrat par lequel on renoncerait complètement à la protection d'un droit de la personnalité : ainsi un contrat par lequel une personne autoriserait sans limite de temps ni d'utilisation la publication de photos la représentant – ce qui serait considéré comme une renonciation illicite à son droit à l'image[762].

340. **Cession de clientèle.** Une application caractéristique de la notion de choses hors du commerce dans la jurisprudence française a longtemps été longtemps constituée par l'interdiction des cessions de clientèle civile. La Cour de cassation française estimait que, à la différence d'une clientèle commerciale, élément essentiel du fonds de commerce, liée à toutes sortes d'éléments matériels (la situation, l'enseigne, les produits vendus, les installations, etc.), la clientèle d'un professionnel libéral (un médecin, un dentiste, un avocat, etc.), est trop étroitement attachée à la personne du professionnel pour que celui-ci puisse la « vendre » au profit de son successeur. Cette jurisprudence n'interdisait pas, cependant, à un professionnel libéral de présenter, moyennant rémunération, son successeur à sa clientèle, dès lors que le contrat apparaissait comme un contrat de service, et non comme une cession. Peut-être pour faire cesser une sorte d'hypocrisie – qui faisait dépendre la validité du contrat des seuls termes utilisés par les parties – la Cour de cassation française a, dans un arrêt très remarqué de 2000[763] admis que « la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite », à condition toutefois que « soit sauvegardée la liberté de choix du patient ». Cette jurisprudence a été depuis étendue à d'autres clientèles civiles[764]. Cependant, confrontée à la question de la validité de la cession de la clientèle d'un chirurgien-dentiste, la Cour d'appel du Luxembourg a, dans un arrêt fortement motivé[765], refusé de suivre cette évolution jurisprudentielle française. Notant que le revirement de 2000 « ne s'impose pas aux juridictions luxembourgeoises », la Cour estime (non sans raison) que le critère de la liberté de choix des patients posé par la jurisprudence française est loin d'être clair. Elle juge de surcroît que l'objet de la convention de cession n'est pas suffisamment déterminé, dès lors que la clientèle médicale est « essentiellement volatile » et que, précisément, chaque patient a le choix de suivre ou de ne pas suivre le successeur du médecin. On note ainsi que s'opère un glissement (assez pertinent) du fondement traditionnel de l'article 1128 du Code civil (l'interdiction de contracter sur les choses hors du commerce) vers l'article 1129 du Code civil (l'exigence de la détermination de l'objet). L'arrêt estime également que l'interdiction de la cession des patientèles n'est contraire ni à la jurisprudence de la Cour eur. D.H. qui avait admis que la clientèle d'un expert-comptable pouvait constituer une valeur patrimoniale, ni à l'article 56 du Traité de l'Union européenne sur l'interdiction des restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union qui concerne les prestations transfrontalières.

762 Réf. Luxembourg, 20 novembre 1978, *Pas.*, 25, p. 358.

763 Cass. fr. (1re civ.), 7 novembre 2000, n° 98-17731.

764 Cass. fr. (1re civ.), 20 janvier 2004, n° 00-15313 ; Cass. fr. (comm.), 24 septembre 2003, n° 00-10355.

765 Cour d'appel, 12 juin 2013, *Pas.*, 36, p. 790.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

La Cour maintient cependant les limites antérieurement admises à l'incessibilité des clientèles civiles. D'une part, elle admet que le médecin puisse utiliser sa notoriété pour « promouvoir celle de l'autre », le contrat de présentation du successeur à la clientèle étant un service qui peut se monnayer. Tel n'était cependant pas le cas en l'espèce parce que la cession avait été réalisée après la mort du praticien, par ses héritiers. D'autre part, elle admet, conformément à sa jurisprudence antérieure, que la clientèle civile peut devenir un bien patrimonial si « elle dépend non plus de facteurs d'attirance personnels mais objectifs, tels la performance d'une équipe de praticiens, l'efficacité de l'organisation, la qualité des instruments de travail, le caractère complet des services offerts, l'accessibilité aux soins, la situation géographique favorable de l'exploitation ». On se rapproche alors de la cession d'une clientèle commerciale.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'objet, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 393-421
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Chapitre IV
La cause

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

341. Première notion. À quoi sert (ou doit servir le contrat) ? Pourquoi s'engage-t-on ? C'est à ces questions que veut répondre la quatrième condition posée par l'article 1108 du Code civil pour la validité d'une convention : il faut que le contrat ait « une cause licite dans l'obligation ». Cette condition est reprise aux articles 1131 et suivants du Code civil. Aux termes de l'article 1131 du Code civil : « L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».

On peut d'emblée déduire de ces textes, inchangés depuis 1804, que, pour que le contrat soit valable, il faut qu'il serve à quelque chose (qu'il ait une cause), et que ce quelque chose ne soit pas mauvais pour la société (que cette cause soit licite). En d'autres termes, il faut que le contrat soit utile à la fois individuellement et socialement.

Au-delà de cette première idée, la notion de cause apparaît comme d'une redoutable complexité. On ne trouve dans le Code aucune définition de la cause, et, bien que cette notion se rattache à une longue tradition historique, sa signification exacte, et l'utilisation qu'on peut en faire, font l'objet, depuis longtemps, de multiples controverses doctrinales, qui ont plutôt contribué à obscurcir la notion qu'à la clarifier[766]. De son côté, la jurisprudence, dans les trois pays du Code civil – et surtout en France – a utilisé la cause, surtout dans la période récente, de manière très diversifiée, et parfois assez différente d'un pays à l'autre, ce qui a encore ajouté à la complexité de la matière. On cite toujours une boutade attribuée à un professeur parisien des années 1950, qui disait à ses étudiants « Si vous avez bien compris la cause, c'est qu'on vous l'a mal expliquée ! ». Même si on ne peut donner ici de cette question qu'une vue simplifiée, on essaiera néanmoins de concilier pédagogie et exactitude.

342. Droit comparé – Tirée du droit romain[767], la cause est devenue au fil du temps, après des évolutions considérables, un élément caractéristique des systèmes juridiques des pays du Code civil et de ceux qui s'en sont inspiré[768]. Mais cette notion, qui traduit un certain contrôle par le droit de l'utilité du contrat, est loin d'être universellement admise. Dans de nombreux droits nationaux, on considère que les parties, dès lors qu'elles sont d'accord, sont les meilleurs juges de l'utilité que le contrat présente pour elle et pour la société, sauf à censurer, au nom de l'ordre public, les contrats servant des buts contraires à l'intérêt social. Le droit allemand, par

766 Pour une synthèse monumentale, voy. J. Ghestin, *Cause de l'engagement et validité du contrat*, Paris, LGDJ, 2006.

767 Sur les origines historiques de la notion de cause et son évolution voy. D. Deroussin, *Histoire du droit des obligations*, *op. cit.*, pp. 318 et s.

768 Voy. p. ex. : Code civil espagnol, art. 1274 et s. ; Code civil italien, art. 1343 et s. ; Code civil roumain, art. 1235 et s. ; Code civil du Québec, art. 1410 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

exemple, ne connaît pas de notion de cause comme condition de validité du contrat, et le concept, qui semble voisin, de fondement contractuel (*Geschäftsgrundlage*), développé par la jurisprudence et aujourd'hui consacré par le § 313 du BGB, y joue un rôle tout à fait différent[769]. D'autres systèmes juridiques, en revanche, à l'instar des droits issus du Code civil français, subordonnent la reconnaissance de la force obligatoire du contrat à la condition que celui-ci présente une certaine utilité économique que le droit contrôle. De ce point de vue, l'exigence de la cause doit être rapprochée de celle de la consideration dans les droits de common law, qui aboutit à n'admettre comme contrats « enforceable » que les accords dans lesquels chaque partie reçoit quelque chose en échange de son propre engagement, c'est-à-dire les accords qui constituent des « bargains », des affaires économiques. Nous verrons cependant que la notion de considération ne correspond qu'à un des aspects de la cause dans les pays du Code civil, et qu'elle joue en common law un rôle bien différent de celui qui est attribué aux articles 1131 et suivants du Code civil[770].

Les différents projets européens d'harmonisation du droit des contrats proposent d'abandonner purement et simplement la notion de cause – tout comme celle de *consideration* d'ailleurs –, pour atteindre par d'autres moyens les objectifs poursuivis dans les systèmes « causalistes ». Certains aspects de la notion se trouvent parfois intégrés dans la notion plus vague de « contenu » du contrat.

Cette position a fortement influencé les auteurs de la réforme française de 2016. Depuis l'époque du Code civil, en France, il s'est toujours trouvé des auteurs pour contester l'utilité de la notion, et pour en dénoncer la complexité. Bien qu'une partie de la doctrine y soit restée fortement attachée, l'ordonnance de 2016 a purement et simplement fait disparaître du Code civil la notion de cause, sauf à en maintenir les principales fonctions dans des dispositions spéciales insérées au sein des conditions relatives au « contenu du contrat ». Cependant, le législateur belge a fait le choix inverse, en maintenant la cause parmi les conditions de validité du contrat, tout en la définissant autrement que dans la conception française traditionnelle. Dans le cadre de la réforme actuellement en préparation, le Luxembourg devra donc choisir entre les deux modèles, sauf à

769 Sur cette notion, qui a servi à consacrer en droit allemand la révision du contrat pour imprévision, voy. *infra*, n° 510.

770 Sur la comparaison entre cause (objective) et *considération*, voy. *infra*, n° 350.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

trouver une troisième voie. Les développements qui vont suivre, en permettant de voir à quoi sert actuellement la notion de cause au Luxembourg, éclaireront peut-être le débat.

343. Différentes conceptions possibles. La question « pourquoi s'engage-t-on ? » peut être comprise de plusieurs manières, car on peut s'interroger sur l'utilité ou sur la finalité d'un contrat sous plusieurs angles. On peut le faire de manière *abstraite*, en s'interrogeant sur la finalité normale de tout contrat appartenant à une catégorie déterminée (un contrat synallagmatique, une vente, un bail, etc.). Dans une telle conception, on dira par exemple qu'un contrat de vente (n'importe quel contrat de vente) sert à transférer la propriété d'un bien contre le paiement d'un prix, ou d'une manière plus générale que tout contrat synallagmatique sert à réaliser une opération d'échange économique. Dès lors, un contrat appartenant à cette catégorie aura une cause si l'échange est effectif, ce qui suppose que chaque partie s'engage à une prestation réelle. Mais on peut aussi s'interroger très différemment sur la finalité *concrète* de tel ou tel contrat particulier pour les personnes qui le passent. Toute vente, par exemple, a pour finalité d'échanger la propriété d'un bien contre de l'argent. Mais pourquoi M. Schmotz achète-t-il telle maison ? Pourquoi accepte-t-il de payer un prix pour devenir propriétaire ? Est-ce pour y vivre avec sa famille ? Est-ce pour y installer son cabinet d'avocat ou son entreprise de plomberie ? Voire abriter les activités d'un petit groupe de terroristes ? La première démarche, qui ne tient pas compte des motivations spécifiques des parties, peut être qualifiée *d'objective*, tandis que la seconde, qui s'intéresse à l'utilité que le contrat présente pour les sujets concernés, peut être dite *subjective*.

Derrière cette dualité de conceptions se dissimule une autre opposition quant à l'intérêt que présente la notion dans la problématique générale de la validité du contrat[771]. Pourquoi se pose-t-on ce type de questions ? On peut, dans les deux approches, avoir en vue soit la protection des intérêts individuels d'un contractant, soit la protection des intérêts sociaux. Ainsi, lorsqu'on s'intéresse à

[771] La notion de cause est aussi utilisée comme instrument de qualification du contrat, pour savoir si l'opération réalisée entre les parties entre dans telle ou telle catégorie (p. ex., pour savoir si une vente à bas prix n'est pas en réalité une donation que le vendeur a voulu faire à l'acheteur). Sur la fonction de qualification de la cause, voy. J. Rochefeld, *Cause et type de contrat*, préf. J. Ghestin, Paris, LGDJ, 2000.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'utilité abstraite d'une catégorie de contrats, et qu'on se demande si tel contrat particulier répond à cette utilité, s'il sert effectivement à réaliser ce pour quoi le contrat a été conçu, cela peut-être au nom de l'intérêt social parce qu'on pense qu'il faut « rayer de la carte » des contrats qui ne servent à rien, mais ce sera plus souvent parce qu'on veut éviter qu'une personne ne s'engage pour rien, sans rien recevoir en échange. Et c'est alors la *protection des intérêts individuels* qui pourrait justifier la nullité d'un contrat pour « absence de cause ». Cet objectif peut être poussé plus ou moins loin selon qu'on se contente, pour que le contrat soit acceptable, que l'obligation ait une contrepartie (quelle que soit sa valeur) ou qu'on exige uncertain équilibre entre les prestations fournies. C'est aussi la protection des intérêts individuels qui peut être poursuivie lorsqu'on s'intéresse aux motifs personnels qui ont amené tel ou tel contractant à s'engager – si on accepte d'annuler le contrat dans des hypothèses où ces motifs ne correspondent pas à la réalité. Par exemple, j'achète une maison dans une ville où je crois être muté, et finalement je ne le suis pas : on pourrait être tenté de dire que, dans un tel cas, mon contrat manque de cause. Mais, la recherche des motifs ou des mobiles individuels peut aussi – et aura plus souvent – pour finalité la *protection des intérêts de la société*, comme le montre l'exemple précédemment donné de l'achat d'une maison pour y poursuivre des activités terroristes. Abstraitement considérée, sous le seul angle d'un échange d'un bien contre un prix, cette vente est parfaitement licite. Mais on peut dire qu'elle a, dans ce cas particulier, une « cause illicite », et l'annuler pour cette raison. La cause peut alors servir à opérer un contrôle plus fin de la conformité du contrat à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

344. Diversité des approches dans les systèmes juridiques causalistes. Cette dualité de notions – abstraite/objective, ou concrète/subjective – et cette dualité de fonctions possibles de la cause – protection de l'intérêt social ou protection des intérêts individuels d'un contractant – sont appréhendées de manière variable selon les systèmes juridiques qui connaissent la notion de cause – et en particulier dans la sphère franco-belgo-luxembourgeoise. Dans certains pays, les deux notions de cause seront nettement distinguées (c'est le cas, on le verra, du Luxembourg, sur le modèle français), dans d'autres on connaît une notion unique de cause, qui peut être soit purement objective, soit purement subjective, soit une combinaison

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

des deux. Et certains systèmes n'utiliseront la notion de cause que dans un but de protection individuelle ou que dans un but de protection sociale, ou dans cette double finalité.

345. Conception dualiste de la cause en droit français. La doctrine française du XIXe siècle n'envisageait la cause que de manière objective, abstraite, par rapport à l'utilité économique générale des grandes catégories de contrats. C'est pourquoi cette conception est souvent appelée la « théorie classique de la cause ». Cette conception a été, au tournant du XXe siècle, sévèrement critiquée en doctrine, comme parfaitement inutile ; Planiol, en particulier, a prétendu que la cause, ainsi entendue, se confondait avec l'objet du contrat[772]. C'est pourquoi, dans la doctrine du XXe siècle, certains auteurs ont cherché à renouveler la théorie de la cause en introduisant la considération des motifs, des mobiles personnels des parties : cette théorie dite « moderne » de la cause a notamment été développée par Josserand[773]. En dépit des efforts d'une partie de la doctrine pour développer une conception unitaire, mêlant objectivisme et subjectivisme[774], le droit français moderne s'est orienté vers une conception dualiste de la cause, qui fait une place à chacune des deux conceptions précédemment exposées, en assignant à chacune un rôle différent quant aux intérêts protégés. La conception objective de la cause a un rôle à jouer lorsqu'on se demande si le contrat a ou non une cause, une véritable raison d'être. Elle est alors un instrument permettant de protéger les intérêts individuels de chaque contractant, d'éviter qu'un contractant ne s'engage inutilement, pour rien. La conception subjective, elle, n'est retenue que lorsqu'il s'agit de contrôler la conformité du contrat à l'ordre public et aux bonnes mœurs : ce contrôle va se faire, entre autres, au regard des mobiles des contractants. La cause, dans cette conception, apparaîtra comme un moyen d'assurer la protection de l'intérêt général. La cour de cassation française a consacré nettement la distinction dans un arrêt du 12 juillet 1989, qui, pour annuler un contrat de vente de matériel d'occultisme, oppose la « cause de l'obligation » de chaque partie (qui est l'obligation de l'autre : le

772 Planiol, *Traité élémentaire de droit civil*, t. II, Paris, LGDJ, 1900, pp. 322 et s. ; en Belgique ce courant « anti-causaliste » a été illustré par F. Laurent, *Principes de droit civil*, t. XVI, 1878, pp. 150 et s.

773 L. Josserand, *Les mobiles dans les actes juridiques*, 1928 rééd., préf. D. Deroussin, Paris, Dalloz, 2006.

774 Cette approche unitaire est notamment illustrée par H. Capitant, *De la cause des obligations*, Paris, Dalloz, 1923.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

prix pour l'un, l'acquisition du matériel pour l'autre), et la « cause du contrat de vente », qui réside dans les mobiles déterminants d'une partie (permettre l'exercice d'une profession prohibée)[775]. D'une manière générale, les décisions de la jurisprudence française qui utilisent la notion de cause le font, soit dans un sens, soit dans l'autre, et leur font jouer des rôles différents. Cependant, dans la jurisprudence récente avant la réforme, on avait assisté à un certain brouillage de la conception dualiste, certains mobiles personnels des parties étant intégrés dans la définition de la cause objective à travers la notion d'économie du contrat[776]. C'est pourquoi certains auteurs, estimant que ces utilisations menaçaient la sécurité juridique, plaidaient pour l'abandon de la distinction rigide entre deux types de causes ayant des rôles différents[777]. Cette distinction reste néanmoins la première clé de compréhension du droit français – et du droit luxembourgeois – en la matière.

346. Conception unitaire de la cause en droit belge[778]. La Cour de cassation belge, en revanche, adoptait avant la réforme une formulation mêlant les deux aspects (objectif et subjectif) dans une conception unitaire, qui avait été antérieurement développée en doctrine[779]. Pour annuler un contrat qui ne permettait pas d'atteindre le but que l'une des parties avait en tête, elle avait jugé que « dans un contrat synallagmatique, la cause des obligations de l'une des parties ne réside pas exclusivement dans l'ensemble des obligations de l'autre partie, mais dans celui des mobiles qui a principalement inspiré son débiteur et l'a déterminé à contracter »[780]. Cette formule, reprise d'un précédent arrêt concernant un testament[781], implique qu'il n'y a pas deux notions de cause mais une seule. La notion de mobiles déterminants, qui définit ainsi la cause en droit belge, vise bien sûr les mobiles personnels à tel ou tel contractant particulier (la

775 Cass. fr. (1re civ.), 12 juillet 1989, nº 88-11443.

776 Voy. *infra*, nº 357.

777 Voy. notamment J. ROCHFELD, « Vº Cause », *Rép. dr. civ.*, spéc. nos 14 et s. et J. ROCHFELD, *Cause et type de contrat*, *op. cit.* Cet auteur propose de distinguer cause typique et cause atypique.

778 Pour une comparaison du droit belge et du droit français, voy. P.A. FORIERS, « La cause en droit français et en droit belge », in E. VAN DEN HAUTE (dir.), *Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge*, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 43 et s.

779 Cette conception unitaire a été notamment défendue par P. VAN OMMESLAGHE, « L'objet et la cause », in P.-A. FORIERS (dir.), *Actualité du droit des obligations*, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 54 et s.

780 Cass. be., 14 mars 2008, nº C-05-0380-F.

781 Cass. be., 21 janvier 2000, nº C980335F.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

cause subjective au sens du droit français), mais elle inclut également la raison de s'engager commune à tous les contractants d'une même catégorie de contrats (la cause objective du droit français) : si le vendeur (tout vendeur) accepte de vendre, c'est d'abord parce qu'on lui promet en échange le versement d'un prix[782]. Même si, dans sa formulation, elle apparaît plus proche de la conception subjective française, cette conception permet en réalité d'adopter une définition commune de la cause dans toutes les catégories de contrats, et de faire jouer aux deux types de « mobiles » aussi bien un rôle de protection de l'intérêt général qu'un rôle de protection des intérêts individuels d'une partie. C'est cette conception « englobante » qui a été retenue par les auteurs de la réforme de 2023. L'article 5.53 du nouveau Code civil belge dispose que « [l]a cause s'entend des mobiles qui ont déterminé chaque partie à conclure le contrat, dès lors qu'ils sont connus ou auraient dû l'être de l'autre partie ».

347. Droit luxembourgeois. La jurisprudence luxembourgeoise suit ici clairement le modèle français dualiste. La Cour d'appel fait nettement la distinction entre les deux conceptions de la cause, et ne leur fait pas jouer le même rôle. Un arrêt du 21 février 1991[783] est particulièrement caractéristique à cet égard. Cet arrêt avait à juger de la validité d'un contrat d'entreprise ayant un objet parfaitement licite (la réfection d'une maison), mais en contravention de la loi déterminant les conditions d'accès aux professions artisanales[784] : en d'autres termes, il s'agissait de travail au noir, et la personne chargée des travaux n'avait pas l'autorisation administrative d'exercer la profession d'artisan. Les juges commencent par reprendre à leur compte une formule de J. Carbonnier qui était citée dans les conclusions « Quand il ne s'agit que de savoir si la cause existe, il suffit d'en prendre une vue schématique, tandis que, quand on recherche si elle est licite, il faut la regarder de plus près, en faire apparaître les détails et la couleur. La caractère licite de la cause concerne la cause concrète, subjective ». L'arrêt observe ensuite que « étant donné qu'en l'occurrence il s'agit d'examiner le caractère de licéité de la cause du contrat conclu entre les parties, il faut dépasser le simple constat de la cause, abstraite et objective, et aller plus loin, jusqu'à

782 Van Ommeslaghe, n° 195.

783 Cour d'appel, 21 février 1991, *Pas.*, 28, p. 148. Voy. récemment Trib. Diekirch, 31 juillet 2023, n° TAD-2019-01506.

784 L. 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi que de certaines professions libérales.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'analyse de la cause concrète et subjective ». Pour les juges, la cause abstraite était « pour l'une des parties d'obtenir de l'argent, et pour l'autre d'obtenir des travaux de réfection ». La cause subjective était en revanche « pour l'une d'obtenir des services plus avantageux par un cocontractant en situation illégale et pour l'autre d'obtenir rémunération sans devoir remplir les obligations légales imposées aux artisans ». Les juges semblent avoir bien retenu la leçon de l'arrêt de la Cour de cassation française de 1989[785]. Tout en ayant conscience de son excessive rigidité, il convient donc de partir de cette distinction entre les deux notions de la cause (avec les deux fonctions qui leur sont associées) pour exposer le droit positif. Nous allons développer successivement la cause objective, instrument de protection des intérêts individuels des contractants (**Section 1**), puis la cause subjective, instrument de protection de l'intérêt social (**Section 2**)[786]. La question de la preuve de la cause, qui transcende en partie cette distinction, sera examinée ensuite (**Section 3**).

SECTION 1. LA CAUSE OBJECTIVE, INSTRUMENT DE PROTECTION DES INTÉRÊTS INDIVIDUELS DES CONTRACTANTS

348. Différentes terminologies. Comme on vient de l'expliquer, la cause au sens objectif s'entend de l'utilité générale d'un type de contrat, abstraitement considérée sans tenir compte de ce que recherchent spécifiquement les parties à tel ou tel contrat. C'est, dit la Cour d'appel du Luxembourg, « le but immédiat et direct qui conduit (*le débiteur*) à s'engager »[787]. On parle parfois de cause proche[788] ou immédiate (*causae proximae*), parce qu'il n'est pas nécessaire, pour la déterminer, de fouiller dans les mobiles des parties : la cause d'une vente, d'un bail, d'une donation apparaît d'emblée, du seul fait qu'on est en présence d'un contrat de ce type. Dans une certaine tradition doctrinale française, on parle aussi

785 Sauf à remarquer que dans l'espèce luxembourgeoise, il n'était sans doute pas nécessaire d'aller rechercher les motifs des parties (la cause subjective) pour annuler le contrat. Il aurait suffi d'observer que le contrat, qui violait une réglementation légale, était contraire à l'ordre public. Voy. *infra*, n° 388.

786 Dans les ouvrages belges, la présentation est nécessairement différente en raison de la conception unitaire de la cause : les auteurs distinguent entre la question de l'existence de la cause (qui peut concerner aussi bien la raison objective de l'engagement que les motifs personnels des parties) et celle de sa licéité. C'est aussi cette présentation qui est utilisée par O. POELMANS dans son ouvrage de droit des obligations au Luxembourg (*op. cit.*, n°s 95-101).

787 Cour d'appel, 2 juillet 2024, n° CAL-2022-00210.

788 Cette terminologie est utilisée par l'arrêt de la Cour d'appel du 21 février 1991, en alternance avec celles de « cause abstraite » ou de « cause objective ».

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

parfois, en reprenant la terminologie du Code de 1804, de « cause de l'obligation » (par opposition à la cause du contrat qui désigne les mobiles personnels des parties), parce qu'on regarde les choses du point de vue des parties : on se demande pourquoi un acheteur s'oblige à payer un prix et on répond que c'est pour recevoir la chose en échange. Cette terminologie est très peu claire, mais il faut la connaître, parce que c'est celle qu'utilise actuellement la Cour d'appel, à l'imitation de la Cour de cassation française[789]. Il serait sans doute préférable, en droit luxembourgeois, de s'en tenir à la notion de cause objective ou abstraite.

Quoi qu'il en soit, cette cause objective s'apprécie par grandes catégories de contrats, et elle n'a pas le même contenu pour les contrats synallagmatiques et pour les contrats unilatéraux (**§ 1**). Il existe par ailleurs certaines exceptions à l'exigence d'une telle cause, dans le cadre de ce qu'on appelle les actes abstraits (**§ 2**).

§1. Le contenu de la cause objective

A) *La cause objective dans les contrats synallagmatiques*

349. Définition. C'est dans les contrats synallagmatiques que la notion objective de cause est le plus facile à définir, et c'est en se situant dans le cadre de ces contrats qu'on a précédemment tenté de faire comprendre la distinction entre cause objective et cause subjective. Dans un contrat synallagmatique, la cause réside dans l'idée d'échange, de réciprocité des obligations – ou, selon une autre présentation, on peut dire que la cause des obligations d'une partie réside dans les obligations de l'autre, dans l'existence d'une contrepartie attendue de l'autre. Dans un arrêt récent, la Cour d'appel juge ainsi que, dans un contrat de franchise, « la cause de l'obligation du franchisé de payer un droit d'entrée et des redevances, trouve sa contrepartie dans l'obligation essentielle contractée par le franchiseur. Il s'agit, pour le franchiseur, de la mise à disposition d'un concept, qui se concrétise par la transmission d'un savoir-faire, de signes distinctifs et d'une assistance. La transmission du savoir-faire du franchiseur et son assistance – initiale et perdurant au long du contrat – constituent ainsi la cause de l'engagement du franchisé »[790]. Un contrat synallagmatique pourra être annulé

789 Notamment dans l'arrêt du 12 juillet 1989, préc.
790 Cour d'appel, 2 juillet 2024, préc.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

pour absence de cause si, par suite de circonstances particulières, la contrepartie qui sert normalement de cause dans le type de contrat considéré fait défaut en l'espèce. Deux précisions importantes doivent ici être apportées. D'une part, pour que le contrat ait une cause, il suffit que chaque obligation ait une contrepartie, il n'est absolument pas nécessaire que cette contrepartie soit équivalente à la prestation réciproque. Comme on l'a déjà vu, la lésion n'est pas, en principe, en droit luxembourgeois, une cause de nullité ; elle ne le devient que si elle résulte de l'exploitation abusive de la faiblesse de l'autre (C. civ., art. 1118) ou dans des cas particuliers (lésion de plus des 7/12e dans la vente d'immeuble, lésion de plus du quart dans le partage, lésion subie par un incapable, etc.), et, dans ces hypothèses, le contrat ne sera pas annulé pour insuffisance de la cause, mais directement pour lésion[791]. D'autre part, il faut noter que la cause, ainsi entendue, s'apprécie au moment de la formation du contrat[792]. Il faut bien distinguer le cas d'absence de cause, où dès le départ un contractant s'engage sans contrepartie, du cas où la contrepartie existe au départ, mais où le contractant n'exécute pas son obligation, ne fournit pas ce qui était promis[793]. Nous verrons que, dans une telle hypothèse, le contrat pourra être anéanti, par le jeu de la résolution, mais ce mécanisme (même si on peut le rattacher à l'idée générale de réciprocité, et à la théorie de la cause largement entendue[794]) est très différent de la nullité pour absence de cause[795]. Il est aisé de se rendre compte que, dans cette conception étroite de la cause, l'utilité de la notion est très limitée (1). Cependant, la jurisprudence française récente révèle certaines extensions possibles de la notion qui pourraient accroître son utilité (2).

350. **Cause objective et *consideration*.** On fait très souvent le rapprochement, en droit comparé, entre la notion de cause dans les pays influencés par le Code civil et la notion fondamentale de « *consideration* » dans les droits de *common law*. Les deux notions sont effectivement très proches, si du moins on se situe dans le cadre de la conception objective de la cause au sens français. La *consideration* désigne, tout comme la cause objective dans les contrats synallagmatiques, la contrepartie que doit avoir tout engagement contractuel. Et, dans les deux systèmes, il n'est

791 Voy. *supra*, nos 264 et s.

792 Cour d'appel, 11 mars 2020, n° CAL-2018-01025.

793 Pour un rappel de cette distinction, voy. Cour d'appel, 19 décembre 2007, n° 30376, *BIJ*, 2008, p. 71 ; Cour d'appel, 7 janvier 2015, n° 40790.

794 Pour une extension du rôle de la cause au stade de l'exécution du contrat, voy. H. CAPITANT, *De la cause des obligations*, *op. cit.*

795 Voy. *infra*, nos 753 et s.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

pas nécessaire que la contrepartie soit équivalente à l'engagement pris : selon une expression tirée d'un ancien arrêt « même un grain de poivre peut servir de *consideration* ». Cependant, en principe du moins, les deux notions ne jouent pas du tout le même rôle dans le droit des contrats : alors que la cause est une simple condition de validité des contrats, la *consideration* est une condition de l'existence même d'un contrat[796]. En *common law*, il n'y a pas de contrat si une partie s'engage sans contrepartie : le contrat sert nécessairement à réaliser un échange économique. Ce n'est pas dire que le droit anglais ne connaît pas les engagements gratuits, mais ils n'appartiennent pas à la catégorie « contract », et ils n'obéissent pas aux règles générales du droit des contrats. Dans le système du Code civil, les contrats peuvent être aussi bien unilatéraux que synallagmatiques. Ce n'est que si les parties ont voulu passer un contrat synallagmatique qu'on vérifiera que l'engagement de chacun a bien une contrepartie réelle, une cause au sens objectif. Si, en revanche, le contrat est unilatéral, l'exigence d'une contrepartie n'a évidemment pas de sens, et on définira la cause autrement, en fonction de l'utilité propre à chaque type de contrat entrant dans cette catégorie générale.

1) *Conception étroite de la cause objective*

351. Applications limitées. Dans l'immense majorité des cas, chaque contractant est en mesure de savoir s'il reçoit ou non quelque chose en échange de son propre engagement. S'il accepte de s'engager alors qu'il n'y a aucune contrepartie, c'est, en général, parce qu'il veut faire une libéralité, et le contrat, en apparence synallagmatique, sera alors, non pas annulé pour absence de cause, mais requalifié en donation. Il peut cependant arriver que, dans un contrat conçu par les parties comme synallagmatique, donc comme devant entraîner des obligations réciproques, la contrepartie offerte par l'un n'existe pas en réalité, qu'elle soit illusoire, sans que les contractants (et en tout cas le contractant qui s'engage ainsi pour « du vent ») en soient nécessairement conscients. On en trouve un certain nombre d'illustrations dans les jurisprudences française et belge. Une illustration caractéristique est fournie par une affaire française du XIXe siècle où un jeune homme, tiré au sort pour faire son service militaire, avait payé un autre, non tiré au sort, pour qu'il le remplace, en ignorant que le contingent auquel il appartenait avait été dispensé du service. Il s'était donc engagé pour rien, et il a pu obtenir l'annulation du contrat et la restitution des sommes payées[797]. Plus récemment, on trouve dans la jurisprudence française

[796] Sur la notion de *consideration*, voy. Cartwright, pp. 125 et s. où la consideration est mise sur le même plan que l'intention de contracter. Voy. aussi pour une approche comparative : T. Kadner-Graziano, *Le contrat en droit privé européen, Exercices de comparaison*, 2e éd., Bâles et Bruxelles, Helbing and Lichtenhahn et Bruylant 2010, pp. 113 et s. J. Smits, *Contract law. A comparative introduction*, *op. cit.*, pp. 77 et s.

[797] Cass. fr. req., 30 juillet 1873, *DP*, 1873, 1, p. 330.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

plusieurs arrêts qui annulent pour absence de cause un contrat passé par une personne avec un généalogiste qui promet, moyennant paiement d'une quote-part de la succession, de lui révéler sa qualité d'héritier d'un parent, lorsqu'il est établi que de toute façon l'héritier aurait appris autrement l'existence de la succession par un notaire ; dans un tel cas, l'héritier a accepté de payer pour rien, pour qu'on lui révèle un « secret de polichinelle »[798]. On citera également une affaire belge dans laquelle une entreprise avait accepté de payer à une commune une certaine somme pour être dispensée d'une taxe, en ignorant que, la délibération du conseil communal n'ayant jamais été approuvée par l'autorité de tutelle, elle n'était pas soumise à cette taxe[799]. Mais on ne rencontre pas, du moins dans la jurisprudence accessible, d'illustration de ce type de situations en droit luxembourgeois.

352. Contrats aléatoires. Le plus souvent, aujourd'hui, la nullité pour absence de cause concerne des contrats aléatoires, où l'absence de cause s'identifie avec l'absence d'aléa. On peut raisonner à partir d'une hypothèse d'école. J'achète un billet de loterie, et je ne gagne rien : bien, sûr, en principe, je ne peux pas m'en plaindre ; certes je n'ai rien reçu en échange du prix que j'ai payé, sinon un morceau de papier absolument sans valeur, mais mon engagement n'en avait pas moins une contrepartie, qui était précisément dans la chance de gagner plus que le prix du billet. Il en irait autrement cependant si je découvre *a posteriori* que tous les billets étaient perdants, et que je n'avais donc aucune chance de gagner : dans ce cas, mon engagement serait effectivement sans cause. Cette idée explique certaines solutions dans des hypothèses plus sérieuses. Ainsi l'article 1974 du Code civil prévoit la nullité d'un contrat de rente viagère créé sur la tête d'une personne qui était déjà morte au jour du contrat[800], et l'article 1975 du Code civil étend la nullité au cas où la personne était encore vivante, mais décède dans les vingt jours d'une maladie dont elle était déjà atteinte au jour du contrat[801] : celui qui achète ainsi un bien moyennant paiement d'une rente viagère dont il est d'emblée certain qu'il ne paiera

798 Voy. p. ex. Cass. fr. (1re civ.), 20 janvier 2010, n° 08-20459.

799 Cass. be., 10 juillet 1924, *Pas. be.*, 1924, I, p. 458.

800 Il faut supposer que le contrat est conclu par l'intermédiaire d'un représentant ou que la rente est constituée sur la tête d'un tiers du contrat.

801 La jurisprudence française étend la solution au-delà du délai de vingt jours, s'il était d'ores et déjà certain au jour du contrat que le bénéficiaire de la rente décéderait à très court terme. Voy. p. ex. Cass. fr. (3e civ.), 2 février 2000, n° 98-10714.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

aucune mensualité ne fournit aucune contrepartie réelle à son cocontractant qui, de son côté perd la propriété du bien vendu sans rien recevoir en échange. Dans le même ordre d'idées, on annulerait un contrat d'assurance couvrant les dommages pouvant être causés à un bien si le risque couvert s'était déjà réalisé (ou était déjà certain) au jour du contrat : là encore, la compagnie d'assurance est perdante à tous les coups, on peut dire que son engagement est sans cause[802]. Toutes ces hypothèses sont, on le voit, assez exceptionnelles, et il est significatif qu'on n'en trouve guère d'illustration dans la jurisprudence luxembourgeoise. Tout au plus peut-on y rattacher un arrêt ancien de la Cour d'appel qui annule pour défaut de cause une transaction – contrat par lequel deux parties en litige le règlent d'un commun accord – dans laquelle une des parties ne fait aucun sacrifice alors qu'il est de l'essence de la transaction que chaque contractant sacrifie une partie des avantages qu'il pouvait espérer[803].

353. Sanction du défaut de cause. En France, la nullité pour absence de cause a longtemps été considérée comme une nullité absolue, au motif que la cause est un élément essentiel du contrat, et cette solution se retrouve encore dans certains arrêts récents[804]. Cependant, dans une conception moderne des nullités, qui fait dépendre de leur régime des intérêts protégés par la règle violée, il est logique de considérer que la nullité pour absence de cause, qui vise à protéger les intérêts d'un contractant dont on veut éviter qu'il s'engage pour rien est une nullité relative, à la disposition du contractant victime de l'échange faussé. La jurisprudence récente de la Cour de cassation française est nettement dans ce sens[805]. En Belgique, la même solution est admise sans discussion par la doctrine[806]. Dans son dernier état, la jurisprudence luxembourgeoise semble cependant vouloir s'en tenir à la nullité absolue du contrat en cas d'absence de cause[807].

802 Cass. fr., 9 novembre 1999, n°s 97-16306 et 97-16800.

803 Cour d'appel, 28 novembre 1902, *Pas.*, 6, p. 245 (mais la solution, très classique, peut tout aussi bien se rattacher à la condition, spéciale à la transaction, qui exige des concessions réciproques de la part des contractants).

804 Cass. fr. (comm.), 23 octobre 2007, n° 06-13.979 (à propos d'une vente sans prix sérieux, considérée, par extension, comme une vente dépourvue de cause).

805 Voy. p. ex. Cass. fr. (3e civ.) 21 septembre 2011, n° 10-21.900.

806 Voy. p. ex. Wéry, n° 325 ; Van Ommeslaghe, n° 204.

807 Voy. *infra*, n° 446.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

354. **Utilité douteuse de la notion de cause dans ces hypothèses.** Dans les différentes hypothèses citées, on pourrait sans doute aboutir à la nullité du contrat sans passer par la notion de cause. D'abord, si l'obligation d'une partie est sans cause, si elle ne reçoit rien en échange de son engagement, c'est parce que l'autre ne s'oblige à rien de concret, donc que son obligation est sans objet. On pourrait donc tout aussi bien annuler le contrat pour absence d'objet. C'était la base de la critique anticausaliste de Planiol. À cela on a répondu que la notion de cause permet d'établir un lien entre les deux obligations réciproques ; si elle n'existait pas, a-t-on dit, seule l'obligation sans objet tomberait et l'autre partie serait néanmoins tenue de s'exécuter. Cette réponse n'est guère convaincante, car la réciprocité entre les prestations dans un contrat synallagmatique peut être reconnue sans qu'il soit nécessaire d'utiliser le concept technique de cause. Même dans les droits qui ne connaissent pas la notion de cause, nul n'aurait l'idée de maintenir un contrat synallagmatique si l'une des obligations n'existe pas. Le nouveau droit des contrats français, qui abandonne la notion de cause, parvient au même résultat par des moyens différents. L'article 1169 du Code civil dispose qu'« [u]n contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». La notion de cause, dans les différentes hypothèses examinées, n'est donc pas vraiment opérationnelle, elle ne constitue qu'un habillage parmi d'autres possibles de solutions qui s'imposent de toute façon. Ensuite, il faut remarquer que, dans ces hypothèses, on pourrait tout aussi bien aboutir à la nullité du contrat en se plaçant sur le terrain des vices du consentement. Normalement, en effet, celui qui s'engage sans rien recevoir en contrepartie ne le sait pas ; s'il le sait, comme on l'a dit, c'est qu'il veut faire une libéralité, et il convient, non d'annuler le contrat mais de le requalifier[808]. Dès lors, la situation pourrait tout à fait relever de l'article 1110 du Code civil, l'ignorance de l'absence de cause – la fausse cause, selon l'expression de l'article 1131 du Code civil[809] – pouvant être facilement considérée comme un cas particulier d'erreur sur la substance. La notion de cause n'en demeure pas moins chargée d'une certaine force symbolique, en ce qu'elle souligne l'importance de l'idée d'échange dans les contrats synallagmatiques. Ce poids symbolique explique que de nombreux droits, pourtant inspirés du droit français, aient jugé utile de la maintenir dans le cadre de réformes récentes.

2) *Extensions*

355. **Renouveau de la notion de cause dans la jurisprudence française.** Dans la jurisprudence française, la notion de cause, appliquée aux contrats synallagmatiques, avait connu, avant la réforme, un renouveau considérable, parce que la Cour de cassation française en avait fait un instrument de protection de l'équilibre contractuel. Cette extension du rôle de la cause, qui prenait plusieurs aspects, n'a trouvé qu'un écho très limité dans la jurisprudence luxembourgeoise,

808 Voy. p. ex. : Cour d'appel, 22 novembre 2006, *Pas.*, 33, p. 346 (à propos d'une vente à prix dérisoire dissimulant une donation du prétendu vendeur au prétendu acheteur).

809 Encore que certains auteurs, en France, tentaient de donner à la « fausse cause » une signification différente de l'absence de cause, on considérera, comme le faisait déjà Pothier (Traité n° 21), que les deux expressions recouvrent exactement la même situation. Sur le cas très différent de la cause faussement indiquée dans l'acte constatant le contrat, voy. *infra*, n° 384.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

et ce ne serait pas forcément une très bonne chose de suivre sur ces points la jurisprudence française. Certes, il n'est pas en soi critiquable que la jurisprudence donne à une notion classique de nouvelles significations, mais sur cette question, les déformations du concept étaient telles qu'elles lui avaient fait perdre toute consistance. La plupart des contorsions auxquelles se livrait la Cour de cassation française ont cessé d'être nécessaires depuis qu'on a on introduit dans le Code civil français certaines techniques de protection de l'équilibre contractuel connues en droit comparé, et reprises dans les projets européens, et c'est plutôt dans cette direction qu'il serait souhaitable de s'orienter au Luxembourg. Du reste, ce sont ces extensions inconsidérées, vilipendées par la doctrine libérale, qui ont contribué, en France, à justifier le rejet, au moins formel, de la notion de cause. Le fait que, en Belgique, on n'ait jamais connu ce type d'extensions, peut expliquer, à l'inverse, que, dans le nouveau code belge, on n'ait pas jugé nécessaire de supprimer la notion. Dans l'optique de la réforme actuellement en cours de discussion au Luxembourg, il paraît donc nécessaire d'évoquer les principales évolutions auxquelles la cause avait donné lieu dans la jurisprudence française. Ces évolutions affectaient soit la notion elle-même, soit les contextes dans lesquels on la fait jouer.

a. *Évolution de la notion*

356. De l'exigence d'une contrepartie à l'exigence d'une contrepartie sérieuse. Il s'agit d'une extension de la notion de cause déjà ancienne, et qui est sans doute la moins contestable. Comme on l'a dit, la notion de cause objective ne permet pas normalement d'assurer l'équivalence entre les prestations, mais seulement l'existence d'une contrepartie à chaque prestation. Cependant, depuis longtemps déjà, la jurisprudence, en France et au Luxembourg, considère que, dans certains cas, la valeur fournie en échange d'une prestation est tellement faible que c'est comme si on ne fournissait rien du tout, donc comme s'il n'y avait pas de cause[810]. C'est ce qui permet d'annuler les contrats de vente dans lesquels le prix fixé n'est pas sérieux, est dérisoire par rapport à la valeur de la chose : cette solution, classique en France[811], et aujourd'hui

[810] Il faut noter que le rattachement à la théorie de la cause, s'il est systématiquement fait par la doctrine, ne se trouve pas toujours dans les décisions jurisprudentielles, qui se fondent assez souvent sur l'article 1591 du Code civil qui exige un prix dans la vente.

[811] Cass. fr. req., 3 mai 1922, *S.*, 1922, 1, p. 310.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

consacrée par le nouvel article 1169 du Code civil[812], n'a pas été suivie en Belgique[813], mais elle a également été affirmée depuis longtemps au Luxembourg. La Cour de cassation avait ainsi posé dès 1903 que « l'existence d'un prix sérieux est une condition essentielle de toute vente ; on ne saurait considérer comme vente, malgré les termes dont les parties se sont servies, le contrat auquel aucun prix sérieux n'a été stipulé »[814]. Cette action en nullité pour vileté du prix est distincte d'une action en rescision pour lésion : elle peut être exercée même dans les cas où la loi n'admet pas la lésion comme cause de nullité (vente de biens meubles, notamment d'actions ou de parts sociales) ou lorsque les conditions de l'action en rescision pour lésion ne sont pas remplies[815]. La nullité pour prix dérisoire sera notamment admise lorsque le prix est inférieur aux revenus que le bien vendu aurait procuré au vendeur s'il l'avait conservé[816], ou encore si le prix fixé est symbolique (un euro, un franc) alors que la chose vendue a une valeur réelle[817] Encore faut-il bien voir qu'un prix en apparence dérisoire peut constituer une cause suffisante, si la chose achetée n'a elle-même qu'une faible valeur[818], ou si la vente s'insère dans un ensemble contractuel d'où résultent d'autres contreparties pour le vendeur[819]. Par ailleurs, comme l'a rappelé récemment la Cour d'appel du Luxembourg, le prix très faible fixé par les parties peut déguiser une intention libérale du « vendeur » à l'égard de l'acheteur : la vente ne sera alors pas annulée, mais simplement requalifiée en donation[820]. De toute façon, la portée de cette jurisprudence admettant la nullité pour prix dérisoire ne doit pas être surestimée : la nullité ne sera admise que dans des cas

812 Ce texte prévoit la nullité des contrats à titre onéreux lorsque la contrepartie convenue est « dérisoire »

813 P.-A. FORIERS, *La cause en droits français et belge*, *op. cit.*, n° 20 ; E. VAN DEN HAUTE, *Traité des contrtas spéciaux,* vol. 1, Bruxelles, Larcier, 2024, n° 100.

814 Cass., 15 mai 1903, 6, p. 277. Pour un rappel récent, voy. Cour d'appel, 22 novembre 2006, *Pas.*, 33, p. 346.

815 P. ex., dans une vente d'immeubles, l'action en nullité pour vileté du prix peut être utilisée alors que le délai de 2 ans posé par l'article 1676 du Code civil est expiré : Cass. fr. (3e civ.), 15 décembre 2010, n° 09-16838.

816 Voy. p. ex., en France : Cass. fr. (3e civ.), 12 juin 1996, n° 94-16988.

817 Cass. fr. (3e civ.), 17 mars 1981, n° 79-15388.

818 Par exemple des ventes pour le prix symbolique de un franc d'actions sans valeur réelle en raison des pertes importantes de la société : Cass. fr. (comm.), 3 janvier 1985, n° 83-15520.

819 Cass. fr. (3e civ.), 3 mars 1993, n° 91-15613, *Bull. civ.*, III, n° 28 ; Cass. fr. (1re civ.), 13 juin 2006, n° 04-15456.

820 Cour d'appel, 22 novembre 2006, préc. La donation déguisée est en principe tout à fait valable, mais elle est soumise au régime juridique des donations, notamment du point de vue fiscal, ou vis à vis des héritiers du donateur, qui peuvent la faire réduire si elle porte atteinte à leur réserve.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

exceptionnels, où la faiblesse du prix confine à son absence totale, et il est clair que le seul fait que le prix fixé soit inférieur à la valeur de la chose n'est pas suffisant pour faire annuler la vente[821]. D'autres déformations de la notion de cause, non suivies pour l'instant au Luxembourg, sont peut-être plus remarquables.

357. De la cause objective à l'économie du contrat : la subjectivisation de la notion de cause. Dans la conception classique, la cause objective est appréciée de manière purement abstraite, par rapport au type de contrat considéré, sans aucune considération de ce que recherchaient spécialement les parties dans leur contrat. Or, dans la jurisprudence française, certains arrêts, finalement peu nombreux mais « montés en épingle » par la doctrine solidariste[822], avaient introduit, dans l'appréciation de la cause objective, certaines considérations tirées de la volonté particulière des parties, par l'intermédiaire de la notion d'économie du contrat. L'arrêt le plus caractéristique est certainement rendu par la Cour de cassation française le 3 juillet 1996 dans l'affaire dite des cassettes vidéo : dans cette affaire, un couple de petits commerçants avaient voulu créer dans leur village de 1134 habitants un « point club vidéo » et avaient pour cela souscrit un contrat avec une société qui leur fournissait régulièrement, moyennant finances, les cassettes à louer. Malheureusement, la clientèle locale s'était vite révélée insuffisante pour assurer la rentabilité de l'opération : le couple devait payer les cassettes que leur livrait régulièrement la société, alors qu'ils ne trouvaient pas assez de clients pour les louer. Les commerçants avaient alors cherché à se dégager en invoquant l'absence de cause de leur engagement. Dans la conception classique, la notion de cause était inopérante : dès lors que les cassettes étaient bien mises à la disposition du couple, leur obligation de payer le prix avait bien une contrepartie, peu important que ces cassettes ne leur permettent pas de faire les bénéfices escomptés. La Cour de cassation n'en approuve pas moins la Cour d'appel d'avoir annulé le contrat, aux motifs que « s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme P. dans le cadre de la convention de création d'un "point club vidéo" »[823]. On le voit, le résultat n'est atteint qu'en introduisant dans la notion de cause des considérations subjectives (ce que recherchaient les commerçants en passant le contrat, l'« économie voulue par les parties »)[824]. Traditionnellement, ces considérations subjectives ne sont prises en compte que lorsqu'il s'agit d'apprécier la conformité du contrat à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Ici, elles sont prises en compte, alors qu'elles étaient pourtant parfaitement licites (il est licite de vouloir tirer des bénéfices de son commerce) pour annuler le contrat qui ne permettait pas d'atteindre l'objectif que s'étaient fixés les parties : on fait donc jouer à une cause appréciée subjectivement le rôle qui s'attache habituellement à la cause objective. Il faut néanmoins remarquer que la « subjectivisation » à laquelle se livrent ici les juges reste modérée : les mobiles ici mis en évidence (la diffusion des cassettes auprès

821 Voy. p. ex. Cass. fr. (1re civ.), 4 juillet 1995, n° 93-16198 à propos d'une bague vendue à un prix inférieur au quart de sa valeur à la suite d'une erreur d'étiquetage.

822 Voy. *supra*, n° 96.

823 Cass. fr., 3 juillet 1996, n° 94-14800, *D.*, 1997, p. 500, note P. Reignie.

824 Sur cette notion : S. Pimont, *L'économie du contrat*, Aix-en-Provence, PUAM, 2004.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de la clientèle) ne sont pas les mobiles spécifiques de M. et Mme P., c'est l'objectif normalement poursuivi par n'importe quel commerçant qui passerait un contrat de ce type. Il n'en reste pas moins qu'il y a là une évolution sensible de la manière dont est appréciée la cause. La solution de l'arrêt n'a cependant jamais été reprise, et dans un arrêt (inédit) de 2009 rendu dans une situation tout à fait similaire, la Cour de cassation avait semblé vouloir revenir à une conception plus orthodoxe de la cause[825].

Quelques mois après l'arrêt des cassettes vidéo, la Cour de cassation française a rendu un autre arrêt, également très remarqué, où s'observe la subjectivisation de l'appréciation de la cause objective. Il s'agit du célèbre arrêt Chronopost[826]. En l'espèce, un entrepreneur avait, pour répondre à un appel d'offres, envoyé sa réponse en recourant aux services de la société d'expédition rapide Chronopost. Il était prévu dans le contrat que le pli devait arriver le lendemain. Le courrier étant arrivé en retard, après la date limite de réponse à l'appel d'offres, l'entrepreneur n'avait pas pu participer au marché, et il avait assigné Chronopost en responsabilité. Il s'était alors vu opposer une clause du contrat limitant l'indemnisation en cas de retard dans la délivrance du courrier au remboursement du prix payé. La Chambre commerciale annule cette clause au visa de l'article 1131 du Code civil, au motif que « spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société B. dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite ». Ici encore, même si la Cour de cassation n'utilise pas la notion d'économie du contrat, l'idée est la même que dans le précédent arrêt : pour apprécier ce qu'est la « cause » de l'obligation prise par l'entrepreneur de payer le prix du transport du courrier, il ne faut pas rester au stade d'une appréciation abstraite, qui serait pertinente pour n'importe quel contrat de transport de marchandises (le client paye pour que le transporteur transporte les marchandises ou le courrier d'un point à un autre), il faut regarder ce que recherche une personne qui accepte de payer un prix élevé dans un contrat de transport rapide. La réponse est qu'elle recherche l'arrivée certaine de son courrier à la date promise, cette arrivée dans le délai fixé est pour le transporteur une « obligation essentielle », de sorte que la clause qui exclut toute responsabilité en cas d'arrivée tardive contredit la « portée de l'engagement », elle prive de cause l'obligation de payer le prix. Ici encore, on introduit une certaine dose de subjectivité dans la notion objective de cause, pour contrôler l'existence d'une contrepartie réelle. Comme dans le cas précédent, cette subjectivisation est modérée : on ne recherche pas pourquoi l'entrepreneur voulait absolument que son pli arrive le lendemain, on pourrait tenir le même raisonnement pour toute personne acceptant de payer un transport rapide de son courrier, quels que soient ses motifs. Mais on a tout de même dépassé l'appréciation purement abstraite qui serait valable pour n'importe quel contrat de transport. On est plus en présence d'un affinement de la notion de cause objective que d'une véritable transformation. L'arrêt Chronopost est cependant remarquable à un autre point de vue, en ce qu'il fait jouer la notion de cause, non pour annuler le contrat qui en était

825 Cass. fr. (comm.), 9 juin 2009, n° 08-11420 qui rappelle que « la cause de l'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique réside dans l'obligation contractée par l'autre ».

826 Cass. (comm.) 22 octobre 1996, n° 93-18632, *D.*, 1997, p. 121, note A. SERIAUX ; *Defrénois*, 1997, p. 333, note D. MAZEAUD ; *JCP G*, 1997, I, n° 4002, obs. M. FABRE-MAGNAN ; voy. égal. sur cet arrêt, C. LARROUMET, « Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité », *D.*, 1997, chron., p. 145 ; J.-P. CHAZAL, « La théorie de la cause… À propos de l'arrêt Chronopost », *JCP G*, 1998, I, p. 152.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

privé, mais pour retrancher la clause qui produisait cet effet. L'évolution concerne ici le contexte dans lequel la notion est mobilisée. Contrairement à la solution de l'arrêt « point club vidéo », celle de l'arrêt *Chronopost* a été reprise dans les textes issus de la réforme française de 2016, mais sans référence à l'idée de cause. Selon le nouvel article 1170 du Code civil français, « [t]oute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».

b. *Évolution du contexte de mise en œuvre de la notion de cause objective*

358. **Utilisation de la notion de cause à propos de clauses contractuelles.** La notion de cause objective était jusqu'à une période récente, utilisée à propos de l'ensemble du contrat – lequel pouvait avoir ou non une cause. Dans la jurisprudence française récente, on l'utilise aussi à propos de clauses particulières de certains contrats. C'est ainsi que dans les années 1980, la Cour de cassation a annulé, sur le fondement de l'article 1131 du Code civil, certaines stipulations de « dates de valeur » contenues dans des contrats bancaires[827]. Il s'agit de clauses qui amènent à distinguer, pour la comptabilisation des opérations faites sur un compte bancaire, la date où l'opération est réalisée (par exemple, un virement, la remise ou le retrait d'espèces, la remise d'un chèque, etc.) et la date de sa prise en compte pour le calcul du solde débiteur ou créditeur du compte. Par exemple, une banque peut stipuler que, lorsqu'un client retire de l'argent dans un distributeur au moyen d'une carte, cette opération sera comptabilisée au jour J-1. En revanche, un virement reçu au jour J n'accroîtra le solde créditeur qu'au jour J+1. Si ces décalages sont compréhensibles pour des opérations dont le traitement demande un certain temps à la banque (par exemple, la remise d'un chèque, peu pratiquée du reste au Luxembourg), elle peut sembler l'être moins pour des remises ou des retraits d'espèces, qui produisent leur effet instantanément. Un décalage peut alors aboutir à faire payer au client des intérêts sur un solde maintenu artificiellement en position débitrice, alors que la somme d'argent nécessaire à combler le découvert a déjà été remise. C'est ce type de dates de valeur relatives à des opérations en espèce que la Cour de cassation française a condamné, et elle l'a fait sur le fondement de l'absence de cause. Bien qu'elle soit appliquée à une clause particulière du contrat, et non au contrat dans son ensemble, le raisonnement peut se comprendre : le client paye un prix (les intérêts), alors qu'aucun crédit ni aucun service ne lui est fourni en échange. Il est cependant douteux que la jurisprudence luxembourgeoise, globalement plus sensible aux intérêts des banques que les tribunaux français, s'inspire un jour de cette solution. Dans un contexte un peu différent, l'arrêt Chronopost, précédemment étudié, repose également sur une application de la notion de cause à une clause du contrat. À la différence du cas des dates de valeur, cependant, ce n'est pas la clause elle-même qui contient un engagement sans cause ; la clause a pour effet de priver de cause l'engagement du client dans le contrat tout entier. Logiquement, cela aurait dû conduire à l'annulation du contrat tout entier, mais cela aurait été sans intérêt pour le client, qui voulait en réalité être dédommagé de la mauvaise exécution de ce contrat. Par une sorte de tour de passe-passe, la Cour de cassation a alors préféré annuler la clause, pour redonner au contrat la cause qui lui faisait défaut. On sent bien ici que la notion de cause est complètement instrumentalisée, dans le but de protéger un contractant en situation d'infériorité économique. Ce type de détournement d'une notion classique pour atteindre un tel but est simplement dû au fait que – pas plus d'ailleurs que le

827 Voy. p. ex. : Cass. fr. (comm.), 6 avril 1993, n° 90-21898.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

droit luxembourgeois – le droit français ne contenait pas, contrairement à d'autres droits, de réglementation générale des clauses abusives qui pourrait permettre de condamner des clauses de ce type dans des contrats passés entre professionnels. Le recours à la notion de cause devient inutile lorsque les clauses envisagées (les dates de valeur, les clauses exclusives de responsabilité) sont insérées dans un contrat passé entre un professionnel et un consommateur, car elles peuvent alors tomber sous le coup de la qualification de clause abusive[828]. L'intégration dans le Code français d'un texte général sur les clauses abusives (art 1171) n'a cependant pas empêché les auteurs de la réforme française de consacrer la jurisprudence *Chronopost* dans le nouvel article 1170, dont le domaine d'application est plus large, car ne se limitant pas aux contrats d'adhésion.

359. **Utilisation de la notion de cause au stade de l'exécution du contrat.** La jurisprudence française récente révèle une nouvelle distorsion dans l'utilisation de la notion de cause objective, toujours dans le but de permettre un certain contrôle de l'équilibre contractuel. Dans la théorie classique, la cause est exclusivement conçue comme une condition de validité du contrat, et c'est bien ainsi que la présentent les articles 1108, 1131 à 1133 du Code civil. C'est donc, traditionnellement, au seul moment de la formation du contrat qu'on apprécie si le contrat a ou non une cause : ce principe est traditionnellement affirmé tant en France[829] qu'en Belgique[830], et il a été rappelé à plusieurs reprises par la Cour d'appel du Luxembourg[831], ainsi que par la Cour de cassation[832]. Si, par la suite, un des contractants ne fournit pas la prestation promise, on ne peut certainement pas dire que le contrat manque de cause : c'est un contrat parfaitement valable qui n'est pas exécuté, ce qui va déclencher les sanctions de l'inexécution contractuelle. On peut, il est vrai, pour justifier certaines de ces sanctions, faire appel à la notion de cause : dans un ouvrage des années 1930 demeuré célèbre, Henri Capitant, un des grands civilistes français de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, avait soutenu que la cause, dans les contrats synallagmatiques, devait se définir comme la considération, chez chaque contractant, de l'exécution de l'obligation de l'autre. Je m'engage, non pas seulement parce que l'autre s'oblige envers moi, mais parce que je compte bien qu'il exécutera son engagement. Cette analyse permet de rendre compte de l'interdépendance des obligations dans un contrat synallagmatique et d'expliquer des mécanismes comme la résolution du contrat pour inexécution (permettant à un contractant, en cas d'inexécution des obligations de l'autre, de faire tomber le contrat pour se soustraire à ses propres obligations) ou l'exception d'inexécution (permettant à la victime de l'inexécution de ne pas exécuter ses propres obligations tant que l'autre n'a pas exécuté les siennes). Cependant, la cause joue ici un rôle plus explicatif qu'opérationnel : les mécanismes évoqués sont de toute façon reconnus par le droit positif sans qu'on ait besoin de faire appel à la notion de cause[833]. Mais, dans la jurisprudence récente, en France, on avait parfois utilisé la cause pour fonder des solutions nouvelles au stade de l'exécution du contrat. La disparition de la cause, plus ou moins largement

828 Sur cette notion, voy. *infra*, n° 411.

829 Voy. p. ex. Cass. fr. (3e civ.), 17 juillet 1996, n° 93-19432.

830 Cass. be., 21 janvier 2000, n° C980335F, *J.T.*, 2000, p. 573, note P.-A. FORIERS.

831 Cour d'appel, 9 juillet 2003, n° 27411, *BIJ*, 2003, p. 171 ; Cour d'appel, 19 décembre 2007, n° 303376, *BIJ*, 2008, p. 171 ; Cour d'appel, 11 mars 2020, n° CAL-2018-01025.

832 Cass., 12 février 2015, n° 11/15, n° 3403 du registre.

833 Il faut ajouter qu'ils sont reconnus même dans les systèmes juridiques qui ne connaissent pas la cause, ce qui laisse planer quelques doutes sur l'analyse de Capitant. Voy. H. CAPITANT, *De la cause des obligations*, préc., pp. 309 et s.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

entendue, est alors susceptible d'entraîner, non la nullité du contrat, mais sa caducité. La décision la plus caractéristique est un arrêt très remarqué de la Chambre commerciale du 29 juin 2010[834], qui statue sur le cas d'un contrat dont l'équilibre avait été bouleversé par l'évolution des circonstances économiques : il s'agissait en l'espèce d'un contrat de maintenance dont l'exécution était devenue plus onéreuse que ce qui était prévu à l'origine en raison de l'augmentation du coût des matières premières et des matériaux qui avait accru le prix des pièces de rechange, de sorte que le montant de la redevance ne suffisait plus à couvrir les frais du contractant chargé de l'entretien. On est ici en présence du problème dit de l'imprévision, dont nous aurons l'occasion de faire l'étude ultérieurement[835]. Nous verrons qu'en principe l'évolution des circonstances ayant présidé à la conclusion du contrat, même lorsqu'elle a pour effet de bouleverser l'équilibre prévu par les parties, ne justifie ni une adaptation ni une résiliation du contrat : tenu par la force obligatoire, le contractant doit exécuter le contrat quelque onéreux qu'il soit devenu pour lui. Cependant, dans l'affaire jugée en 2010, la Cour de cassation semblait vouloir remettre en cause ce principe en s'appuyant sur la notion de cause : elle estime, au visa de l'article 1131 du Code civil, que le juge, avant d'ordonner l'exécution d'un tel contrat, doit rechercher si l'évolution du prix des matières premières « n'avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance, de déséquilibrer l'économie générale du contrat tel que voulu par les parties et de priver de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit ». L'arrêt est doublement remarquable : d'une part, il applique, dans les mêmes termes que l'arrêt des cassettes vidéo (économie du contrat, contrepartie réelle), une notion de cause élargie incluant l'objectif de rentabilité économique recherché par le contractant ; d'autre part, il fait jouer cette notion au stade de l'exécution du contrat, en jugeant qu'un contrat originairement rentable (à la différence de l'affaire des cassettes vidéo, où dès le départ il était sûr que le contrat ne serait pas rentable) peut devenir caduc si, ultérieurement, cette rentabilité ne peut plus être atteinte. Cette solution, cependant, avait été remise en cause par un arrêt de 2014, dans lequel la Cour de cassation rappelle que la cause s'apprécie au moment de la formation du contrat[836]. On voit, à travers cet exemple, l'importance des distorsions que la Cour de cassation faisait subir à la notion classique de la cause : comme le relève O. Poelmans, « En France, la cause est progressivement passée du rôle de rempart contre le déséquilibre contractuel à celui d'instrument de garantie que le contrat présente et conserve l'économie en considération de laquelle les contractants se sont engagés »[837]. Ici encore, ces « dérives », selon l'expression de l'auteur, sont devenues inutiles depuis que le droit français a intégré, sur le modèle de très nombreux droits nationaux, de textes internationaux et de projets européens, un mécanisme de révision du contrat pour imprévision (C. civ. fr., art. 1195). Et c'est sans doute la même voie qu'il conviendrait de suivre en droit luxembourgeois, plutôt que de s'inspirer en la matière des acrobatiques solutions jurisprudentielles françaises.

834 Cass. fr. (comm.) 29 juin 2010, n° 09-67369, inédit.

835 Voy. *infra*, n°s 508 et s.

836 Cass. fr. (comm.), 18 mars 2014, n° 12-029453.

837 Poelmans, n° 96.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

B) *La cause objective dans les contrats et les actes juridiques unilatéraux*

360. Diversité. Lorsque le contrat est unilatéral, c'est-à-dire ne fait naître d'obligations que pour une partie, la finalité économique ne peut pas être recherchée dans l'existence d'une contrepartie. Il en va de même pour les actes juridiques unilatéraux, qui transfèrent un droit ou qui obligent l'auteur de l'acte envers une autre personne. Contrairement à ce qu'on a fait dans les contrats synallagmatiques, on ne peut pas donner ici de définition générale de la cause ; elle est très différente d'un type d'acte à l'autre, car ces différents actes ont des utilités économiques très diverses. On se bornera ici à envisager les principales hypothèses.

361. Cause du prêt. Dans le système du Code civil, le prêt (qu'il s'agisse du prêt d'argent ou du prêt d'une chose qu'on doit rendre après s'en être servi) est le principal contrat unilatéral. Ce caractère unilatéral est directement lié au caractère réel du contrat, qui est une survivance historique[838]. Le contrat ne se forme que par la remise à l'emprunteur de la chose ou de la somme prêtée[839] ; dès lors seul l'emprunteur est tenu d'une obligation, celle de restituer la chose ou la somme. Dans cette analyse, si on veut se tenir sur le terrain de la cause objective, sans prendre en considération les mobiles pour lesquels l'emprunteur emprunte ou le prêteur prête, on peut simplement dire que la cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la remise qui lui a été faite de l'objet du prêt. Si on ne lui a rien remis, il ne doit rien restituer ! Cependant, là encore, on peut s'interroger sur l'utilité du recours à la notion de cause. Si la chose ou la somme n'a pas été remise, le contrat de prêt est nul de toute façon, et il ne peut faire naître aucune obligation.

L'analyse pourrait changer si on abandonnait – ce qui serait sans doute souhaitable – le caractère réel du prêt. La jurisprudence française s'est déjà engagée dans cette voie pour les prêts d'argent consentis par les banques[840]. Le prêt d'argent peut alors être traité comme un contrat synallagmatique : la banque s'engage à mettre l'argent à disposition de l'emprunteur pendant un certain temps, et l'emprunteur s'engage à restituer et à payer des intérêts. Dans ce cas, on peut dire que la rémunération du crédit constitue la cause de l'obligation du prêteur, ce qui correspond à la fonction économique de ce type de contrat. En revanche, même si on renonçait au caractère réel du prêt à usage (prêt d'une chose non fongible, qui est nécessairement

838 Sur la notion de contrat réel, voy. *infra*, n° 431.

839 C. civ., art. 1875 « Le prêt à usage […] est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre » et non : « s'engage à livrer ».

840 Cass. fr., 5 juillet 2006, n° 04-12588.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

gratuit) ou du prêt d'argent sans intérêt, on ne pourrait guère les analyser comme des contrats synallagmatiques et voir la cause dans la réciprocité des obligations. On ne peut pas dire en effet que celui qui prête un livre ou une voiture s'engage à laisser le livre ou la voiture à disposition pour qu'on lui rende au bout d'un certain temps. L'obligation de restituer ne peut pas être considérée comme une contrepartie de celle de mettre à disposition ; en réalité le prêteur non rémunéré s'engage sans contrepartie, et la cause ne peut alors être recherchée que dans des éléments extérieurs, complètement différents d'un prêt à l'autre, qui poussent le prêteur à s'engager (les relations de famille, d'amitiés ou d'affaires qu'il a avec l'emprunteur). Mais on est alors sur le terrain de la cause subjective. Le même phénomène s'observe pour les libéralités.

362. Cause des libéralités. Une libéralité peut prendre deux formes : une donation (qui est un contrat unilatéral entre le donateur et le donataire) ou un testament (qui est un acte juridique unilatéral). La problématique de la cause est la même dans les deux cas. On dit habituellement que la cause de ces actes réside dans l'intention libérale du donateur ou du testateur. En d'autres termes, celui-ci fait une libéralité parce qu'il a envie de gratifier le bénéficiaire. C'est du pur verbalisme, et cela n'ajoute rien à l'analyse juridique de l'opération. En réalité, ce qu'on veut dire, c'est que si on fait une donation ou un testament en faveur de quelqu'un, c'est parce qu'on a des raisons particulières de l'avantager, et, si ces raisons ne correspondent pas à la réalité, ou si elles disparaissent, il convient de faire tomber la libéralité[841]. Mais alors, on est sur le terrain des mobiles, de la cause subjective, qui vont effectivement jouer, comme on le verra plus loin, un rôle particulièrement important pour ce type d'actes.

363. Cause du cautionnement. Comme on l'a déjà vu, le cautionnement est un contrat par lequel une personne (la caution) s'engage envers un créancier à satisfaire à l'obligation d'une tierce personne (le débiteur principal). Le cautionnement est un contrat unilatéral, en ce que l'obligation de la caution envers le créancier est sans contrepartie de la part de celui-ci. La détermination de la cause du cautionnement a suscité de nombreux débats dans la doctrine française. Sans entrer dans le détail de ces controverses, on indiquera simplement ici que la Cour de cassation française a considéré que la cause de l'engagement de la caution se trouvait dans la considération du crédit fait au débiteur principal : la caution s'engage pour que le débiteur puisse obtenir un crédit (ou, dans d'autres circonstances, pour que la personne cautionnée puisse louer un appartement, ou obtenir des délais de paiement d'un de ses fournisseurs, etc.)[842]. Bien qu'elle soit présentée sous une forme subjective, cette définition de la cause s'inscrit dans la conception abstraite et objective de la cause, car elle est valable pour n'importe quel contrat de cautionnement, quels que soient les mobiles personnels qui poussent la caution à s'engager (les relations personnelles ou professionnels qu'elle a avec le débiteur principal). On pourrait donc dire tout aussi bien que la cause est dans l'obligation principale du débiteur : si finalement le débiteur n'obtient pas son crédit, ou son bail, l'obligation de la caution n'a plus de raison d'être, et le cautionnement doit être annulé. Il en va de même si l'obligation principale est nulle. La solution est absolument certaine, et elle se retrouve en droit luxembourgeois : ainsi, dans un arrêt de 1956, la Cour d'appel juge que « le cautionnement ne pouvant exister que

841 Cass. fr., 6 octobre 1959, *D.*, 1960, p. 515, note Malaurie.

842 Cass. fr. (comm.), 8 novembre 1972, n° 71-11879.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

sur une cause valable, est nul s'il a trait à une convention nulle »[843]. Cependant, pour arriver à ce résultat incontestable, il n'est nul besoin de recourir à la notion de cause : l'article 2012 du Code civil (devenu l'article 2293 du Code civil français) dispose expressément que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable », et ce texte, qui est une application particulière du caractère accessoire du cautionnement, suffit à régler la question. Comme souvent, le recours à la notion de cause ne joue qu'un rôle explicatif, et n'a pas d'intérêt opérationnel pour fonder les solutions.

§ 2. Exceptions à l'exigence de la cause : les actes abstraits

364. Notion d'acte abstrait : droit allemand. Pour comprendre la problématique des actes abstraits, un détour par le droit allemand s'impose. En droit allemand, on reconnaît la valeur des actes juridiques abstraits, c'est-à-dire détachés de leur cause. Cette notion connaît plusieurs applications. L'une d'elles réside précisément dans ce qu'on appelle le principe d'abstraction (*Abstraktionsprinzip*), hérité de Savigny, qui trouve surtout à s'appliquer à propos des contrats ayant pour objet un transfert de propriété. En droit allemand, on opère une séparation entre le contrat obligationnel (*schuldrechtlicher Vertrag*) qui fait naître des obligations pour les parties (par exemple le contrat de vente, qui fait naître l'obligation de payer pour l'acheteur, et pour le vendeur l'obligation de livrer et de transférer la propriété) et le contrat réel (*dinglicher Vertrag*), qui opère le transfert. Le second contrat est abstrait, c'est-à-dire qu'il est indépendant du premier : le transfert peut s'opérer valablement même si le premier contrat est nul. Il en résulte que l'acheteur à qui la propriété a été valablement transférée peut se prévaloir de son droit de propriété sans que le vendeur puisse lui opposer la nullité du contrat de vente. Cette application du principe d'abstraction ne peut trouver aucune correspondance en droit luxembourgeois dès lors que le contrat de vente opère à la fois création des obligations des parties et transfert (en principe immédiat) de la propriété[844]. Une autre application, dont il est plus facile d'imaginer la transposition en droit luxembourgeois, est celle des promesses abstraites de payer. Le § 780 du BGB permet de faire par écrit une promesse de payer (*Schuldversprechen*) ou une reconnaissance de dette (*Schuldanerkenntnis*) de sorte que « la promesse fonde l'obligation

843 Cour d'appel, 31 mars 1954, *Pas.*, 16, p. 121.

844 Sur les actes abstraits en droit allemand voy. C. WITZ, *Droit privé allemand, 1. Actes juridiques, droits subjectifs*, Paris, Litec, 1992, n°s 127 et s.; M. FROMONT et J. KNETSCH, *Droit privé allemand*, 2e éd., Paris, LGDJ, 2017, n°s 306 et s.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

de manière autonome »[845]. Cela signifie que celui qui a souscrit une telle promesse doit s'exécuter sans pouvoir démontrer qu'en réalité la raison pour laquelle il l'a établie n'existait pas (par exemple, il a promis de payer en contrepartie de marchandises qu'on devait lui livrer et qu'il n'a jamais reçues). Cela ne signifie pas, cependant, qu'il devra supporter définitivement la charge d'une dette inexistante. S'il établit, après avoir payé, que sa promesse ne correspondait à aucune obligation, il pourra recourir contre le bénéficiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause (*ungerechtfertige Bereicherung*). C'est pourquoi il est quelque peu abusif de présenter de tels actes comme des actes « sans cause », car l'exigence d'une raison valable de l'engagement se retrouve au stade des recours. L'intérêt de tels actes est de procurer au bénéficiaire une très grande sécurité de paiement, en évitant que l'exécution de l'obligation ne soit retardée par des contestations peut-être infondées. S'il y a des contestations, elles ne seront examinées qu'ensuite, lors d'un éventuel recours, dans le cadre duquel le débiteur (ou supposé tel) occupera la position de demandeur au procès (toujours moins avantageuse que celle de défendeur). L'abstraction de tels engagements n'est cependant pas totale, même au stade de la demande en paiement, car le signataire pourra toujours se défendre en démontrant que la cause de son engagement était illicite ou immorale.

365. Les actes abstraits en droit luxembourgeois : principe. On présente parfois l'exigence de la cause dans le Code civil comme un obstacle à la reconnaissance des actes abstraits, et certains auteurs ont précisément vu dans la suppression de la cause en droit français l'avantage de permettre le développement de tels actes. En réalité les deux choses ne sont pas nécessairement liées. Même si la cause (entendue dans son sens objectif) est une condition de validité des contrats, cela n'interdit pas que, dans des hypothèses particulières, on puisse reconnaître la validité d'actes abstraits en droit luxembourgeois, dès lors que ces actes ne sont pas à proprement parler des actes sans cause, mais des actes détachés de leur cause pour leur exécution. Si l'absence de cause ne peut pas être invoquée pour faire obstacle à la demande en paiement formée par le créancier, elle réapparaîtra ultérieurement, au stade des recours, qui peuvent

[845] « *Zur Gültigkeit eines Vertrags, durch den eine Leistung in der Weise versprochen wird, dass das Versprechen die Verpflichtung selbständig begründen soll (Schuldversprechen), ist, soweit nicht eine andere Form vorgeschrieben ist, schriftliche Erteilung des Versprechens erforderlich. Die Erteilung des Versprechens in elektronischer Form ist ausgeschlossen.* »

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

permettre au débiteur de récupérer ce qu'il a payé sans raison. Aussi bien, les auteurs de la réforme belge, alors même qu'ils maintenaient la cause comme condition de validité des contrats, ont-ils pris soin de préciser que « [l]es parties peuvent convenir d'abstraire le contrat de sa cause, à moins que la loi l'interdise » (C. civ. be., art. 5.54). C'est pourquoi, dans le débat qui ne manquera pas de surgir sur le maintien ou non de l'exigence de la cause en droit luxembourgeois, il faudra laisser de côté la question des actes abstraits. Ceux-ci, du reste, existent déjà en droit luxembourgeois, et on peut en donner deux exemples (qui se retrouvent du reste en droit français ou en droit belge).

366. Application : les engagements cambiaires. Le premier exemple est ancien : il s'agit de l'engagement cambiaire, c'est-à-dire de l'engagement de payer souscrit sur une lettre de change (variété particulière d'effet de commerce). La lettre de change est un titre par lequel une personne (le tireur) donne l'ordre à une autre (le tiré) de payer une certaine somme à une personne désignée (le bénéficiaire). Ce titre fait naître, de la part de tous ceux qui le signent, des engagements abstraits, c'est-à-dire autonomes par rapport aux rapports juridiques qui fondent son émission, et qu'on peut considérer comme leur cause. C'est ce qui résulte de l'article 17 de la loi uniforme concernant la lettre de change et le billet à ordre[846] selon lequel « les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ». Supposons, par exemple, qu'un commerçant ait commandé des marchandises à son fournisseur, qui lui a accordé un délai de paiement. Pour représenter sa créance, le fournisseur (tireur) émet sur son client (tiré) une lettre de change, que le client accepte de payer en y apposant sa signature. Pour obtenir des liquidités sans attendre le délai consenti à son client, le fournisseur transmet la lettre de change à une banque, en la désignant comme bénéficiaire de l'effet ; celle-ci lui verse alors le montant de l'effet diminué des intérêts pour la durée restant à courir jusqu'à l'échéance. À l'échéance, la banque bénéficiaire s'adresse au client pour obtenir son paiement. Le client, qui a signé, est alors

[846] La matière a fait l'objet en 1930 d'une unification internationale par des conventions signées à Genève. La loi uniforme résultant de ces conventions a été introduite au Luxembourg par une loi du 8 janvier 1962.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

obligé de payer la banque même s'il n'a jamais reçu les marchandises – c'est-à-dire même si son engagement s'avère sans cause. Mais il pourra ensuite tenter de récupérer ce qu'il a payé sans cause auprès de son fournisseur.

367. Application : les garanties bancaires autonomes. Le second exemple, plus récent, est celui des garanties bancaires autonomes, qui sont des créations de la pratique bancaire internationale. Il s'agit d'engagements de payer qui sont souscrits par un garant (le plus souvent une banque) en vue de couvrir l'exécution d'un engagement commercial ou financier pris par une personne (donneur d'ordre) envers une autre (bénéficiaire). Cela ressemble à un cautionnement, mais, à la différence de l'engagement de la caution, qui est accessoire à l'obligation principale qui le cause[847], l'engagement du garant est autonome : il s'engage à payer le bénéficiaire sans pouvoir opposer aucune exception (moyen de défense) ou contestation tirées du contrat principal garanti (qui constitue pourtant la raison d'être, la cause de la garantie). Par exemple, si la garantie a été donnée pour couvrir un marché de travaux, la banque garante devra payer la somme demandée par le maître de l'ouvrage (bénéficiaire) sans pouvoir prétendre que le marché a été correctement exécuté ou que les retards ne sont pas dus à la faute de l'entrepreneur (donneur d'ordre). On a beaucoup débattu de la cause de ces garanties, non prévues dans le Code civil, et l'apparente « absence de cause » de l'engagement du garant a pu faire douter, un temps, de leur compatibilité avec le droit commun des contrats[848]. On peut cependant admettre que, en dépit de son caractère non accessoire, la cause de l'engagement du garant se trouve bien dans la considération de l'obligation principale à garantir (qui est du reste très habituellement indiquée dans l'engagement de garantie). S'il est vrai que le garant ne peut pas se défendre sur ce terrain pour refuser de payer, il le peut à nouveau si l'absence ou la nullité de l'obligation garantie est évidente, manifeste, et, dans le cas contraire, s'il a payé une obligation inexistante ou nulle, le pseudo-débiteur, amené à le rembourser, pourra recourir contre le bénéficiaire qui se sera enrichi sans cause. Dans un arrêt de 2012[849],

847 Voy. *supra*, n° 363. Sur les garanties autonomes, voy. A. Prüm, *Les garanties à première demande : essai sur l'autonomie*, Paris, Litec, 1994.

848 Elles ont cependant été consacrées par le législateur français lors de la réforme du droit des sûretés, à l'article 2321 du Code civil.

849 Cour d'appel, 19 décembre 2012, n° 36931.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la Cour d'appel du Luxembourg a jugé avec pertinence que « [l]a garantie autonome est une garantie contractuelle de nature personnelle dont la singularité réside dans son autonomie par rapport au contrat de base ce qui se traduit par l'inopposabilité au créancier de toute exception relative au contrat […] L'obligation du souscripteur d'une garantie autonome est non seulement nouvelle, mais indépendante de celle du débiteur principal. Ce caractère constitue la pierre angulaire du concept. L'existence d'un contrat de base, est la raison d'être de la constitution de la garantie. Elle en est, plus précisément, la cause. Il ne peut y avoir de garantie sans obligation à garantir. Autonomie ne signifie donc pas absence de référence à contrat principal. La référence à un contrat principal est de l'essence de la garantie qu'elle soit autonome ou non. Le garant appelé à exécuter son engagement ne peut opposer au bénéficiaire de la garantie d'autres exceptions que celles tirées du contrat de garantie lui-même ». Le législateur luxembourgeois a récemment consacré de manière expresse ce mécanisme, en lui donnant un champ d'application particulièrement étendu. La loi du 10 juillet 2021 met en place un système de « garantie professionnelle de paiement », substitut du cautionnement, tout entier fondé sur la liberté contractuelle, et dont l'élément essentiel se trouve dans l'article (4) aux termes duquel « [s]auf convention contraire, le garant ne pourra opposer aucune exception tenant aux créances ou risques concernés ». On est donc bien en présence d'un acte abstrait au sens précédemment défini.

SECTION 2. LA CAUSE SUBJECTIVE, INSTRUMENT DE PROTECTION DE L'INTÉRÊT SOCIAL

368. Utilité. Dans ce second sens, la cause désigne les motifs ou, mieux, les mobiles[850] personnels qui ont inspiré les contractants, ou l'un d'eux, pour la passation de tel ou tel contrat particulier. On peut concevoir que ces mobiles personnels aient une importance juridique dans deux séries d'hypothèses. D'une part, on peut se demander quel sort il faut réserver au contrat lorsque ces mobiles se révèlent contraires à la réalité – de sorte qu'on pourrait penser que le contractant, déçu dans ses espérances, s'est engagé sans cause ; le contrat pourrait alors être annulé pour absence

[850] Bien que les deux termes soient souvent utilisés l'un pour l'autre, il semble préférable de réserver le terme de « mobiles » pour désigner les raisons que les parties ont dans la tête lorsqu'elles contractent, le terme de « motifs » désignant plutôt les raisons indiquées par elles dans le contrat.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ou fausseté de la cause, et la cause servirait, ici aussi, à protéger les intérêts individuels du contractant qui se serait engagé pour rien. D'autre part, les mobiles peuvent aussi être pris en compte par le droit lorsqu'ils sont illicites ou immoraux – de sorte qu'un contrat, qui a un objet en lui-même parfaitement correct, pourrait être annulé en considération des raisons particulières qui ont amené un contractant (ou les deux) à passer le contrat, pour des raisons tenant cette fois à l'intérêt général. En principe, comme on l'a déjà dit, c'est seulement sur ce second plan que la cause subjective joue un rôle en droit luxembourgeois : contrairement à la cause objective, les mobiles ne sont normalement pas pris en considération dans les hypothèses d'absence, de fausseté ou de disparition de la cause (**§ 1**), mais seulement en cas d'illicéité ou d'immoralité de la cause (**§ 2**).

§1. Absence, fausseté ou disparition de la cause subjective

369. Principe. En droit luxembourgeois comme traditionnellement en droit français, la première partie de l'article 1131 « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause […] ne peut avoir aucun effet » est considérée comme ne visant en principe que la cause objective. Elle ne s'applique pas à la cause considérée sous son angle subjectif et concret, aux mobiles personnels des parties. Si ces mobiles se révèlent contraire à la réalité, on ne dira pas que le contrat manque de cause ou que la cause est fausse. Pour reprendre un exemple déjà pris ailleurs, si j'achète une maison dans une ville où je viens d'être nommé, et que, par la suite, ma nomination, entachée d'irrégularité, est annulée, je ne pourrai pas faire annuler en conséquence la vente de la maison au motif que le contrat n'avait en réalité pas de cause. Ce cas correspond exactement à celui que nous avons déjà rencontré en traitant de l'erreur[851] ; or nous avons vu que l'erreur qui porte sur les motifs du contrat n'est pas en principe une cause de nullité, parce qu'il appartient à chaque contractant de supporter le risque d'une inutilité du contrat lorsque celle-ci dépend d'éléments extérieurs à celui-ci. Il en va ainsi, en principe, même si les mobiles personnels du contractant étaient parfaitement connus de l'autre, et qu'ils sont entrés dans le champ contractuel – à moins que le cocontractant ait su que ces mobiles ne correspondaient pas à la réalité (auquel cas il pourrait y avoir dol, qui est une cause de nullité

[851] Voy. *supra*, n° 231.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

même s'il porte sur des éléments extérieurs au contrat[852]). *A fortiori*, l'erreur sur les motifs n'a pas d'incidence sur le contrat lorsque les éléments qui avaient justifié la passation du contrat pour une des parties disparaissent par la suite, dès lors que, comme on le sait déjà, l'existence ou l'absence de la cause s'apprécient au moment de la formation du contrat. La Cour de cassation française a eu l'occasion de faire application de ces principes en matière de cautionnement, en refusant de libérer une caution qui s'était engagée à garantir les dettes de la société dont elle était alors dirigeante, et qui avait perdu par la suite ses fonctions de direction[853]. Le seul moyen d'intégrer les mobiles personnels d'un contractant dans le contrat est d'en faire expressément une condition de l'engagement – solution aujourd'hui reprise par l'article 1135 du Code civil français –, ce qui suppose bien sûr que le cocontractant en soit d'accord : par exemple la caution peut stipuler que son engagement prendra fin si elle cesse d'être dirigeante, et je peux acheter sous la condition que je sois effectivement nommé dans cette ville[854]. La Cour d'appel du Luxembourg est clairement sur cette longueur d'ondes lorsqu'elle affirme que « il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les motifs ou les mobiles qui ont pu avoir poussé une partie à s'engager. Il appartient à celle-ci de faire connaître à son cocontractant la cause de son obligation et d'en faire une modalité ou une condition de son engagement, si elle entend éventuellement se prévaloir de la disparition de cette cause pour mettre un terme à son obligation »[855].

370. Position divergente du droit belge. Sur ce terrain, les solutions luxembourgeoises et françaises s'opposent de prime abord à la position du droit belge. Dans la mesure où la cause y est définie, de manière unitaire, comme les mobiles déterminants ayant amené chaque contractant à s'engager (ce qui inclut non seulement la contrepartie attendue, mais aussi les raisons personnelles de passer le contrat), l'erreur commise par une partie sur les raisons qu'elle avait de s'engager pourra être traitée, en droit belge, comme un cas d'absence ou de fausseté de « la » cause. La jurisprudence antérieure à la réforme allait déjà dans ce sens. L'arrêt du 14 mars

852 Voy. la jurisprudence française sur les contrats ayant pour but la défiscalisation, citée au n° 231.

853 Cass. fr. (comm.), 8 novembre 1972, n° 71-11879.

854 Sur la condition, voy. *infra*, n°s 588 et s.

855 Cour d'appel, 6 octobre 1993, *Pas.*, 29, p. 279. Voy. égal., en matière de cautionnement : Trib. Luxembourg, 4 mars 2004, n° 79361.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

2008, par lequel la Cour de cassation belge affirme clairement sa conception unitaire de la cause, dans la ligne de la position défendue par P. Van Ommeslaghe, est très significatif à cet égard. Dans cette affaire, une personne avait acheté un immeuble pour y exploiter un commerce de blanchisserie, étant entendu que le vendeur de l'immeuble devait également céder à l'acheteur les parts de la société exploitant la blanchisserie. Or ces parts n'avaient pas été cédées. Les obligations de l'acheteur avaient bien une cause objective au sens du droit français et luxembourgeois : en contrepartie du paiement du prix, il devenait bien propriétaire de l'immeuble. Mais la raison pour laquelle il avait acheté faisait défaut puisqu'il ne pouvait pas exploiter le commerce. Pour la Cour de cassation belge, cela justifie la nullité de la vente de l'immeuble pour absence de cause[856]. Ce type de solution doit sans doute être maintenu après la réforme. L'article 5.53 du nouveau code belge définit la cause comme les « mobiles qui ont déterminé chaque partie à conclure le contrat » et l'article 5.54 envisage spécialement la nullité du contrat pour « fausse cause » à condition que l'erreur ait été déterminante et excusable. Aussi bien, les textes sur l'erreur n'excluent pas l'erreur sur les motifs comme cause de nullité. Cependant, il faut rappeler que, selon l'article 5.53, les mobiles de chaque partie ne constituent la cause que s'ils « sont connus ou auraient dû l'être de l'autre partie », c'est-à-dire s'ils sont entrés dans le champ contractuel. La différence essentielle avec le droit français, et le droit luxembourgeois actuel, est qu'il n'est pas besoin pour cela de stipulation expresse.

En réalité, même si le droit belge part d'une conception différente de la cause, il n'est pas sûr qu'il aboutisse à des solutions si différentes de celles reçues en France et au Luxembourg, dans la mesure où le principe de départ dans ces deux pays est susceptible de nombreuses exceptions.

371. Exceptions : absence, fausseté ou disparition de la cause dans les libéralités. Comme on l'a vu précédemment, dans les libéralités, il n'est pas facile de distinguer cause objective et cause subjective. La définition classique de la cause comme « l'intention libérale » n'est qu'un faux-semblant, car, lorsqu'on se demande si le donateur ou le testateur avait véritablement une intention libérale, on est, inévitablement, amené à s'interroger sur les mobiles personnels qui l'avaient amené à faire la libéralité. Et du coup, on est amené à admettre la nullité pour défaut d'intention libérale – donc

856 Sur cette jurisprudence, voy. P.-A. Foriers, *La cause en droits français et belge*, *op. cit.*, n°s 10-11.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pour absence de cause – des libéralités qui avaient été commandées par un motif ne correspondant pas à la réalité telle que se la représentait le donateur. On peut prendre l'exemple d'un homme qui fait une donation à une personne qu'il croit être son enfant – et qui découvre *a posteriori* qu'en réalité un autre était le père[857]. La Cour de cassation française a de même admis qu'une donation-partage pouvait être annulée si les raisons fiscales qui avaient justifié l'acte étaient remises en cause par l'annulation rétroactive du texte qui instituait les avantages fiscaux recherchés[858].

Une difficulté supplémentaire surgit dans le cas fréquent où les raisons qui avaient poussé l'auteur de la donation ou du testament à faire la libéralité correspondaient bien à la réalité au moment où l'acte a été fait, mais disparaissent par la suite en raison de l'évolution des relations personnelles entre le gratifiant et le bénéficiaire (ce sont deux époux qui divorcent, deux concubins qui se séparent, deux amis qui se fâchent, etc.). Le problème est différent selon la nature de la libéralité. Si c'est un testament, il est toujours révocable (C. civ., art. 1035) ; du coup, le testateur qui a perdu les raisons de gratifier le bénéficiaire a toujours la possibilité de révoquer la libéralité en faisant un nouveau testament. S'il ne le fait pas, ses héritiers n'ont pas la possibilité de faire tomber le testament en argüant de l'absence ou de la disparition de la cause, car on peut présumer que la volonté exprimée dans le testament a persisté jusqu'au décès du testateur. C'est ce qu'a jugé la Cour d'appel du Luxembourg[859], tout comme, plus récemment, la Cour de cassation française[860]. On ne peut pas raisonner de la même manière s'il s'agit d'une donation, qui est en principe irrévocable. En dehors des cas où le droit des libéralités permet, par exception, la révocation de la donation (C. civ., art. 953 : en cas d'inexécution des conditions, d'ingratitude du donataire, ou de survenance d'enfants ; C. civ., art. 1096 : pour les donations entre époux pendant le mariage), on pourrait songer à permettre au donateur de demander la caducité[861] de la libéralité en invoquant la disparition de sa cause. Cette solution a été admise à quelques reprises par la jurisprudence française, qui, on le sait, n'hésitait pas à faire jouer un rôle à la cause après la formation du contrat[862]. On peut se demander si, nonobstant la suppression dans le code français de la notion de cause, on pourrait aujourd'hui fonder la solution sur le nouvel article 1186 qui prévoit la caducité du contrat « si l'un de ses éléments essentiels disparaît ». Paradoxalement, la Cour de cassation belge, alors même qu'elle assimilait par principe la cause aux mobiles

857 Solution admise en France par Cass. fr. req., 7 juillet 1931, *Dalloz hebdomadaire*, 1931, p. 445.

858 Cass. fr. (1re civ.), 11 février 1986, n° 84-15.513, *Bull. civ.*, I, n° 25.

859 Cour d'appel, 1er décembre 2004, *Pas.*, 33 p. 32.

860 Cass. fr. (1re civ.), 15 décembre 2010, n° 09-70.834 ; Civ. (1re ch.), 15 février 2012, n° 10-23.026, jugeant « qu'il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer ».

861 En toute hypothèse, la sanction ne peut pas être la nullité, car l'acte était bien valable au jour de sa formation. Sur la distinction entre nullité et caducité, voy. *infra*, n° 437.

862 Civ. (1re ch.), 22 octobre 2008, n° 06-20.286, jugeant que « c'est par une interprétation souveraine de l'intention commune des parties que la cour d'appel a estimé que l'engagement à durée indéterminée pris par Mme Y […] d'accorder à son mari la jouissance gratuite de l'ancien domicile conjugal et de ne pas vendre le bien sans son autorisation n'avait été souscrit qu'en considération des liens matrimoniaux qui unissaient les époux à la date de conclusion de la convention et avait pris fin avec la dissolution du mariage ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

déterminants, s'en était tenue, après quelques hésitations, à l'idée que la cause s'apprécie au moment de la formation, et que la disparition ultérieure des mobiles ayant fondé la libéralité n'entraîne pas la caducité de celle-ci[863]. Le nouveau Code civil belge ne prévoit la caducité du contrat que dans le cas de disparition de l'objet (art. 5.244 et 5.265), ce qui semble conforter cette position. C'est un point qu'il conviendrait de trancher précisément dans le cadre de la réforme luxembourgeoise.

372. **Exceptions : cas des contrats liés (renvoi).** Dans la jurisprudence française antérieure à la réforme la notion de cause avait acquis, un temps, une nouvelle utilité dans le cadre des ensembles contractuels. Il s'agit d'hypothèses où plusieurs contrats sont conclus en considération les uns des autres, de telle sorte que, dans l'esprit des parties, la disparition de l'un (par suite d'une annulation ou d'une résolution) doit se traduire par la disparition du ou des autres qui lui sont liés. Avant la réforme, la jurisprudence de la Cour de cassation française, suivie par certains arrêts luxembourgeois, acceptait de répercuter les causes de disparition d'un contrat sur ceux qui lui sont liés, lorsqu'il est établi que ces différents contrats sont interdépendants ou que, selon une formule aujourd'hui plus répandue, ils forment un ensemble indivisible. Cette jurisprudence est aujourd'hui consacrée par le nouvel article 1186 du Code civil français. Pour justifier ces solutions, certains arrêts français se référaient explicitement à l'idée d'absence de cause pour rendre compte de l'interdépendance du lien entre les contrats[864], et plusieurs visaient dans leurs motifs l'article 1131 du Code civil[865]. Cependant, ce lien avec la cause, qui supposait de sortir de la conception traditionnelle de la cause, est aujourd'hui abandonné, et les solutions sont directement justifiées par les notions d'interdépendance et d'indivisibilité. Nous les retrouverons lorsque nous étudierons la question de la caducité du contrat.

§2. Illicéité ou immoralité de la cause subjective

373. **Principe.** Le contrat pourra être annulé si les mobiles d'une partie sont illicites ou immoraux, sur le fondement de l'article 1133 du Code civil[866]. Le contrôle des mobiles illicites ou immoraux peut parfaitement être considéré comme un aspect particulier de l'exigence générale de conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs posée par l'article 6 du Code civil. L'intérêt généralement prêté à la notion de cause illicite ou immorale, par rapport à cette exigence générale, est qu'elle semble permettre un contrôle plus large, ou plus approfondi, de la conformité du contrat à l'ordre

863 Cass. be., 21 janvier 2000, n° C980335F, *J.T.*, 2000, p. 573 (pour un testament) ; Cass. be., 12 décembre 2008, n° C.06.0332.N, *R.W.*, 2008-2009, p. 1690. Voy. P.-A. Foriers, *La cause en droits français et belge*, p. 74.

864 Cass. fr. (1re civ.), 13 juin 2006, n° 04-15.456 (sauf à remarquer que le recours à la notion de cause et à l'article 1131 du Code civil permet ici, à l'inverse, de justifier la validité d'un contrat qui, en lui-même ne comportait pas de contrepartie, au motif que ce contrat s'insérait dans un ensemble indivisible qui lui donnait une cause).

865 Voy. p. ex. Cass. fr. (comm.) 5 juin 2007, n° 04-20.380, préc.

866 Bien que le texte ne vise que la cause « illicite », il inclut dans cette notion le cas où la cause est contraire aux bonnes mœurs, et l'usage, ici suivi, est de distinguer cause illicite et cause immorale (même s'il ne s'agit que de deux aspects de l'illicéité au sens large).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

public et aux bonnes mœurs. Un contrat, alors même qu'il serait parfaitement correct par son objet, peut se révéler critiquable si on creuse davantage et qu'on s'intéresse aux mobiles personnels des parties : par exemple, l'achat d'un appartement est, en soi, un acte parfaitement licite, mais on peut considérer qu'il ne l'est plus si on découvre qu'en réalité l'acheteur a l'intention de se servir de l'appartement pour s'y livrer à une activité illicite ou immorale (prostitution, trafic de drogue, activités terroristes, etc.). Cette extension du contrôle de conformité du contrat à l'ordre public repose sur l'idée – plus ou moins justifiée – que la menace de la nullité du contrat (s'ajoutant éventuellement à d'autres sanctions) pourrait contribuer à dissuader de se livrer à ces activités répréhensibles[867].

Dans la jurisprudence luxembourgeoise, les limites entre la nullité pour cause illicite ou immorale et les autres cas de violation de l'ordre public sont particulièrement flottantes, et on observe que, très souvent, les solutions que les cours et tribunaux rattachent à la « cause illicite » pourraient tout aussi bien être justifiées par l'illicéité de l'objet ou tout simplement par le fait que le contrat est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ». Par exemple, lorsque la Cour d'appel annule un contrat d'entreprise « au noir » passé avec une personne n'ayant pas l'autorisation d'exercer une activité commerciale ou artisanale, il n'est guère utile d'observer que « la cause subjective a été pour l'une des parties d'obtenir des services plus avantageux par un cocontractant en situation illégale et pour l'autre d'obtenir rémunération sans devoir remplir les obligations légales imposées aux artisans en situation régulière »[868], dès lors que, en soi, et quels que soient les mobiles des parties, un tel contrat est objectivement illicite. Certaines décisions, du reste, annulent directement ce type de contrats pour violation de l'ordre public, sans le détour par la notion de cause[869]. De même le recours à la notion de cause illicite n'est guère pertinent lorsqu'il s'agit d'annuler un contrat de contrebande par lequel une partie s'engage à introduire sur le territoire du Grand-Duché des marchandises interdites[870], ce qui est, en soi, illicite. L'utilisation de la notion de cause n'a de sens que dans les cas où la convention est objectivement licite, et où elle ne devient condamnable que par les mobiles personnels des contractants. Même dans ces hypothèses, du reste, certains s'interrogent sur l'utilité de la notion de cause. Il serait tout à fait possible de comprendre, dans l'affirmation générale de l'article 6 du Code civil, que les conventions doivent respecter l'ordre public et les bonnes mœurs aussi bien dans leurs motifs que dans leur objet : le droit comparé montre

867 Cela est parfois le cas : ainsi la nullité d'une convention destinée à frauder le fisc, qui prive les contractants des avantages attendus, sera souvent une sanction plus efficace que les pénalités fiscales. Mais dans d'autres cas, l'effet dissuasif est plus que douteux : l'annulation d'un contrat de bail d'un appartement qui n'a été loué que pour permettre aux locataires de se livrer à la prostitution ou de cacher de la drogue n'est sans doute pas le moyen le plus efficace de lutter contre ces fléaux.

868 Cour d'appel, 21 février 1991, *Pas.*, 28, p. 148 ; Voy. encore récemment Trib. Diekirch, 31 juillet 2023, n° TAD-2019-01506.

869 Trib. Luxembourg, 3 février 2017, n° 167372.

870 Cour d'appel, 18 janvier 1918, *Pas.*, 10, p. 546.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

bien que, même dans les systèmes qui ne connaissent pas la notion de cause, on opère un tel contrôle de la licéité des mobiles des parties[871]. Telle est du reste la position du nouveau droit français, qui, tout en abandonnant la notion de cause, compense aisément cet abandon par l'affirmation que « le contrat ne peut déroger à l'ordre public « ni par ses stipulations, *ni par son but* » (art. 1162). La question est essentiellement terminologique.

A) *Conditions de la nullité pour cause immorale ou illicite*

374. Deux ou trois conditions ? Dans la jurisprudence luxembourgeoise, la nullité pour cause illicite ou immorale est, pour l'instant, soumise au moins à deux conditions. Il faut d'abord caractériser l'illicéité ou l'immoralité du mobile, et il faut ensuite que ce mobile ait été déterminant de la volonté contractuelle. Une troisième condition est plus incertaine : on se demande si le mobile illicite ou immoral d'une partie doit être connu par l'autre.

1) *Un mobile illicite ou immoral*

375. Notion. L'article 1133 du Code civil définit la cause illicite comme celle qui est « prohibée par la loi, contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ». Ce texte renvoie donc directement à la notion générale d'ordre public de l'article 6 du Code civil dont nous aurons l'occasion de faire l'étude par la suite. Sans pour l'instant entrer dans le détail, on peut remarquer que la formulation de l'article 1133 du Code civil nous apprend deux choses importantes. D'une part, la notion d'immoralité (ou de contrariété aux bonnes mœurs) n'y apparaît pas comme une notion distincte de l'illicéité (la contrariété à l'ordre public), elle n'en est qu'un aspect particulier. Nous verrons plus en détail par la suite que cette notion se rapporte principalement aux comportements d'ordre sexuel qui, à un moment et en un lieu donné, sont considérés comme tolérables par l'ordre social. D'autre part, l'article 1133 du Code civil nous indique aussi implicitement que la « contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs » ne se réduit pas aux comportements illégaux (qui sont prohibés par la loi) : la jurisprudence considère parfois comme contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs des activités qui ne sont pas interdites, mais qui, en une période et en un lieu donnés, apparaissent comme contraires à l'ordre social. Par exemple au Luxembourg, la prostitution n'est

[871] Voy. p. ex. en droit suisse : P. Tercier et P. Pichonnaz, *Le droit des obligations*, 5e éd., Zürich, Schulthess, n° 727, citant ATF 134 III 52 (nullité pour illicéité d'un prêt consenti en vue de permettre un commerce de stupéfiants).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pas illégale, mais elle est néanmoins toujours considérée comme une activité immorale, qui ne peut donc constituer ni l'objet ni la cause d'un contrat valable.

376. Applications. Les diverses applications que la jurisprudence luxembourgeoise fait de la nullité pour cause illicite (ou immorale) illustrent bien cette interpénétration des notions. En dehors du domaine strict des bonnes mœurs, on trouve ainsi des décisions qui annulent pour cause illicite des contrats passés pour frauder le fisc (par la dissimulation d'une partie du prix dans un acte de vente par exemple), un contrat d'association entre deux personnes dont le but est de permettre à l'un des associés d'exercer sous le nom de l'autre une activité qui lui est interdite par une clause de non-concurrence[872], une clause contractuelle visant à dissuader un contractant d'agir en justice en prévoyant le paiement d'une indemnité dans ce cas (ce qui porte atteinte au droit de toute personne d'agir en justice)[873], ou encore, comme on l'a vu, les contrats qui visent à faire effectuer un travail par une personne n'ayant pas les autorisations nécessaires. Mais ce sont surtout en matière de bonnes mœurs qu'on trouve les applications les plus caractéristiques de la notion de cause illicite. La nullité du contrat passé en vue de l'exploitation d'une « maison de débauche » en est l'exemple typique, qu'il s'agisse du contrat « de louage de services » passé entre le proxénète et les prostituées qui travaillent pour lui[874] (qu'on pourrait tout aussi bien annuler pour objet contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs) ou d'un contrat de vente ou de location d'immeubles destinés à permettre à ses occupants à exercer une activité de prostitution[875]. Traditionnellement, on admettait également la nullité pour cause illicite des libéralités destinées à encourager le (en pratique la) bénéficiaire à avoir avec le donateur ou le testateur des relations sexuelles hors mariage, à une époque où on considérait le concubinage comme immoral. Cette jurisprudence illustrait particulièrement bien le mécanisme de la nullité pour cause illicite ou immorale : en soi, il n'était pas interdit de faire une donation à son concubin ou à sa concubine, mais, s'il était établi que la donation

872 Cour d'appel, 5 janvier 1927, *Pas.*, 11, p. 316 (qui qualifie curieusement ce contrat de contraire aux « bonnes mœurs »).

873 Trib. Luxembourg, 29 octobre 1969, *Pas.*, 21, p. 284.

874 Cour d'appel, 4 novembre 1968, *Pas.*, 21, p. 23 – Comp. en France Cass. fr. (soc.), 8 janvier 1964, *D.*, 1964, p. 267.

875 Voy. en France Cass. fr. req., 1er avril 1895, *DP*, 1895, 1, p. 263 (qui annule un prêt destiné à une telle acquisition).

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

avait pour but de rémunérer ou d'inciter à la continuation de relations sexuelles auxquelles le/la bénéficiaire n'aurait pas consenti autrement, la nullité était encourue[876]. La donation était en revanche licite si elle était faite par reconnaissance ou pour assurer l'avenir de la femme ou de l'enfant né de la relation[877]. Il paraît évident cependant que cette jurisprudence est aujourd'hui dépassée, et il est peu probable qu'un juge annule aujourd'hui une libéralité entre concubins (de même sexe ou de sexe différent), quels qu'en soient les motifs.

La question peut cependant se poser lorsqu'il s'agit d'un concubinage adultère, qui constitue pour le ou les partenaires mariés par ailleurs, une violation du devoir de fidélité entre époux posé par l'article 212 du Code civil. La jurisprudence française se montre aujourd'hui très libérale, même dans ce cas. Dès 1999, la Première chambre civile de la Cour de cassation avait jugé que n'était pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire[878], et cette solution a été reprise en 2004 dans des termes tout à fait généraux par l'Assemblée plénière, qui affirme que « n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère »[879]. Abondamment commenté, et diversement apprécié en doctrine, cet arrêt concernait cependant une hypothèse extrême où un homme de 95 ans avait fait un testament en faveur d'une femme de 64 ans sa cadette dans le but, selon la Cour d'appel, de « rémunérer ses faveurs ». L'évolution semble moins nette en Belgique, même s'il n'existe pas de décisions très récentes : la Cour de cassation considérait encore en 1977 qu'une libéralité entre concubins était nulle si l'un des mobiles déterminants de la convention était de faire naître, de maintenir ou de rémunérer les relations sexuelles[880], et de nombreux arrêts de cours d'appel jusqu'au début des années 1990, ont annulé des libéralités faites dans le cadre d'un concubinage adultère[881]. Cependant, l'évolution des mœurs et des conceptions a été considérable depuis cette période et il n'est pas sûr que ces solutions soient encore d'actualité.

2) *Un mobile déterminant*

377. Preuve. Lorsqu'il est allégué qu'un contrat a été inspiré par un mobile illicite ou immoral, il appartient au juge de déterminer quelle a été la « vraie raison » de l'acte. Or, pour des raisons bien

876 Comp. Cour d'appel, 13 juillet 1959, *Pas.*, 18, p. 7 (à propos d'une donation faite par une femme aux parents de son concubin dans le but supposé de se ménager les faveurs de ceux-ci, donc de favoriser la continuation du concubinage. La nullité n'est cependant pas admise parce que la cause immorale était inconnue des bénéficiaires).

877 Voy. ainsi, à une époque où la loi interdisait de reconnaître un enfant adultérin : Cour d'appel, 29 avril 1904, *Pas*, 6, p. 394 qui juge que « une obligation contractée dans le but de prendre des mesures pour assurer l'avenir d'une fille séduite et de son enfant, même adultérin, n'a rien d'illicite, ni de contraire à l'article 340 du Code civil ».

878 Cass. fr. (1re civ.), 3 février 1999, n° 96-11946.

879 Cass. fr. (ass. plén.), 29 octobre 2004, n° 03-11238, *GAJC*, 12e éd., n° 28-29.

880 Cass. be., 23 juin 1977, *J.T.*, 1978, p. 83.

881 Voy. les arrêts cités par Van Ommeslaghe, n° 239.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

compréhensibles, cette raison sera très rarement explicitée dans l'acte, et elle sera même souvent dissimulée derrière d'autres motifs « officiels ». Il appartiendra à celui qui se prévaut de la nullité de prouver la réalité du mobile illicite, et d'établir que sans ce mobile, il n'aurait pas contracté. Cette preuve ne pourra généralement se faire que par présomptions, notamment tirées des relations des parties antérieurement et postérieurement à l'acte.

On rattache souvent à la notion de cause et du caractère déterminant du mobile, la question de savoir si la nullité d'une clause contractuelle est limitée à cette clause ou s'étend au contrat tout entier. On admet traditionnellement que la nullité affecte tout le contrat si la clause en question a été la « cause impulsive et déterminante » du contrat, c'est-à-dire si les parties attachaient à la clause une importance telle qu'elles n'auraient pas contracté en son absence. Il s'agit cependant d'une question très différente parce que l'insertion d'une clause peut rarement être considérée comme le mobile déterminant du contrat : si la clause est considérée comme essentielle, le contrat sera annulé, non parce qu'il répond à un mobile illicite ou immoral, mais par l'effet d'une extension de la nullité de la clause. Nous retrouverons cette question en étudiant les effets de la nullité[882].

3) *Un mobile connu de l'autre partie ?*

378. Solution traditionnelle. Il arrive que les parties, lorsqu'elles passent un contrat, poursuivent un but commun : c'est le cas notamment lorsque le contrat vise à mettre sur pied une organisation (société, association) ou une relation s'inscrivant dans un réseau. Dans ces hypothèses, on peut parfois identifier un mobile illicite ou immoral commun aux deux parties, et la nullité du contrat ne fera aucun doute : ainsi si plusieurs personnes montent une société pour exercer une activité illicite ou mettent en place un réseau de distribution de drogue. Mais, dans l'immense majorité des cas, l'illicéité ou l'immoralité n'affectera que les mobiles personnels d'une des parties, ceux de l'autre étant complètement différents : je vends mon immeuble pour récupérer des fonds et permettre à mes enfants de faire des études, tandis que mon acheteur veut installer dans cet immeuble un hôtel destiné à la prostitution. Dans ce type de situation, on se demande s'il faut, pour que le contrat soit annulé, que le mobile illicite ou immoral ait été connu de l'autre partie. Traditionnellement, dans les trois pays du Code civil, la réponse était positive. Au Luxembourg, la Cour d'appel avait ainsi affirmé très nettement en 1959 que « Dans les contrats à titre onéreux, le mobile immoral ne constitue une cause illicite au sens des articles 1131 et 1133 du Code civil, entraînant

882 Voy. *infra*, n°s 472 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la nullité de la convention, que s'il est connu de toutes les parties ayant contracté et que, correspondant au but collectif de l'opération, il a pénétré dans le contrat dont il est devenu un élément constitutif. Le mobile psychologique immoral personnel à l'une des parties au contrat qui est resté dissimulé à son cocontractant n'entre pas à titre d'élément déterminant dans la conclusion du contrat qui est le produit de l'accord de deux ou plusieurs volontés et ne peut donc affecter la validité de la convention »[883]. L'arrêt refuse d'annuler un prêt fait par une femme aux parents de son concubin dans le but supposé de se « faire bien voir » de ceux-ci, et donc de favoriser la continuation du concubinage (mobile considéré à l'époque comme immoral), au motif que les parents, ignorant les relations entre cette femme et leur fils, ne connaissaient pas cette cause immorale. La formule de la « cause illicite correspondant au but collectif de l'opération » se retrouve dans des arrêts plus récents[884].

Au-delà de considérations théoriques un peu obscures, la raison d'être de cette solution tenait au souci de protéger le contractant innocent, c'est-à-dire celui avait contracté dans l'ignorance du mobile illicite de l'autre. Il s'agissait d'éviter que celui-ci ne puisse se voir imposer la nullité du contrat (qui est en principe, on le verra, une nullité absolue), alors qu'il n'avait en rien participé à son illicéité. Cependant cette solution produisait des effets pervers, dans la mesure où, du coup, elle conduisait aussi à interdire à ce contractant innocent de se prévaloir de la nullité, ce qui réduisait considérablement les chances d'annulation du contrat pourtant contraire à l'ordre public, et l'effet dissuasif que la menace d'annulation était censée avoir vis-à-vis du contractant indigne. Celui-ci en effet ne courrait aucun risque d'être privé du bénéfice de son contrat dès lors qu'il prenait soin de dissimuler ses mauvaises intentions à son cocontractant.

379. Évolution. Ces considérations avaient amené la jurisprudence à abandonner la solution traditionnelle en France et en Belgique. En France, le revirement résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 1998 selon lequel « un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant

883 Cour d'appel, 13 juillet 1959, *Pas.*, 18, p. 7.
884 Cour d'appel, 21 février 1991, *Pas.*, 28, p. 148.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

de la conclusion du contrat »[885]. Cette solution a été consacrée par le nouvel article 1162 du Code civil français, qui prévoit la nullité du contrat pour but illicite « que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». La Cour de cassation belge avait suivi la même position en 2000, en jugeant, pour annuler une convention ayant pour but d'organiser une fraude fiscale, que « s'agissant de l'intérêt général, il suffit que l'une des parties ait contracté à des fins illicites et qu'il n'est pas nécessaire que ces fins soient connues du cocontractant »[886]. Mais cette solution n'a pas été reprise lors de la réforme de 2023 : l'article 5.53 du nouveau Code civil, qui définit la cause comme les mobiles, précise que ceux-ci doivent être « connus ou auraient dû l'être de l'autre partie ». Dans un arrêt du 14 mars 2001, la Cour d'appel du Luxembourg s'est ralliée à la solution française, en admettant que « l'annulation d'un acte pour cause illicite ou immorale, peut être mise en œuvre aussi bien par un contractant innocent que par un contractant "turpis" » – ce qui présuppose que l'innocence d'un des contractants n'est pas, en soi, un obstacle à l'action en nullité[887]. Cette solution est couramment admise depuis[888]. Elle présente le gros avantage d'ouvrir largement l'action en nullité, en permettant en particulier au contractant innocent de faire tomber le contrat s'il y a intérêt. Elle est donc conforme au but d'intérêt général que poursuit la règle qui a été violée. Evidemment, en contrepartie, la solution peut paraître défavorable au contractant innocent, qui peut se trouver privé du bénéfice du contrat si le cocontractant coupable, un tiers intéressé ou le Ministère public agit en nullité. Mais cet inconvénient – qui était précisément celui que voulait éviter la jurisprudence traditionnelle – est en réalité assez limité dans la mesure où, comme nous le verrons, le cocontractant coupable aura rarement intérêt à soulever la nullité[889], et où, si cette nullité est prononcée, le contractant innocent pourra obtenir des dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu'il subit du fait de l'annulation[890]. L'élargissement des conditions de la nullité se trouve ainsi tempérée en raison du régime spécifique de cette nullité.

885 Cass. fr. (1re civ.), 7 octobre 1998, n° 96-14359.

886 Cass. be., 12 octobre 2000, n° C990136F.

887 Cour d'appel, 14 mars 2001, *Pas.*, 32, p. 48.

888 Trib. Diekirch, 18 décembre 2018, n° 20.899 ; Trib. Diekirch, 31 juillet 2023, n° TAD-2019-01506.

889 Voy. *infra*, n° 467 à propos de la règle *Nemo auditur.*

890 Sur les dommages et intérêts en cas d'annulation du contrat, voy. *infra*, nos 480 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

B) *Régime de la nullité pour cause immorale ou illicite*

380. Nullité absolue. À la différence de la nullité pour absence de cause, qui est aujourd'hui considérée (au moins dans la jurisprudence française) comme une nullité relative, la nullité pour cause illicite ou immorale est, logiquement, dans la plupart des cas, une nullité absolue. Le but du contrôle de la licéité des mobiles des contractants est en effet d'assurer la sauvegarde de l'intérêt général. Il en résulte que cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, et donc en particulier par les deux contractants. Il faut seulement mettre à part le cas – sans doute assez exceptionnel – où la règle que l'un des contractants a voulu écarter est une règle d'ordre public « de protection » (ou, dans la terminologie belge, une règle impérative) destinée à protéger les intérêts de l'autre contractant. Dans cette hypothèse, il serait logique de considérer que la nullité est relative, et ne peut être soulevée que par le cocontractant protégé. Dans tous les autres cas, depuis que la jurisprudence admet que la nullité n'est pas subordonnée à la connaissance par le cocontractant du mobile illicite ou immoral de l'autre, la nullité peut être demandée indifféremment par le contractant innocent ou par le contractant coupable. Elle ne produira en revanche pas nécessairement les mêmes effets à l'égard des deux.

381. ***Nemo auditur*** **(renvoi).** En principe, comme nous le verrons par la suite, l'annulation d'un contrat produit un effet rétroactif : les parties seront remises dans le même état où elles étaient avant la conclusion du contrat. Il en résulte en particulier que, si un contractant avait déjà exécuté le contrat, il se verra restituer sa prestation. Cette règle connaît cependant diverses exceptions, dont une va s'appliquer en particulier dans le cas des contrats annulés pour cause illicite ou immorale. Dans un tel cas, on appliquera parfois un adage traditionnel : « *Nemo auditur propriam turpitudinem allegans* » (nul n'est entendu lorsqu'il allègue sa propre turpitude). Contrairement à ce que sa formulation pourrait laisser croire, cet adage, du moins dans l'interprétation qui lui est donnée en France et au Luxembourg, ne s'oppose pas à ce qu'un contractant coupable d'illicéité ou d'immoralité puisse agir en nullité du contrat contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il s'oppose seulement à ce qu'il obtienne restitution de ce qu'il a versé en exécution du contrat annulé[891]. C'est ce qu'on appelle l'exception d'indignité. Bien que certains auteurs et certaines décisions cantonnent cette règle à la seule nullité pour cause illicite ou immorale (et même parfois à la seule cause immorale), elle a en réalité un domaine d'application beaucoup plus large, et peut s'appliquer (à certaines conditions) dans tous les cas de contrariété du contrat à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Cependant, il est intéressant d'observer les conséquences particulières que cette règle produit dans le cas qui nous occupe ici d'un contrat annulé pour cause illicite ou immorale, dans l'hypothèse fréquente où l'illicéité n'est pas commune aux deux

[891] Cour d'appel, 26 mars 1998, *Pas.*, 31, p. 13 ; Cour d'appel, 1er mars 2000, *Pas.*, 31, p. 367.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

contractants. Cette règle est de nature à dissuader le contractant coupable de demander la nullité du contrat dès lors qu'il l'a déjà exécuté, puisqu'il ne pourrait en tirer aucun bénéfice ; du coup, elle met très souvent à l'abri le contractant innocent d'une action en nullité intentée par l'autre. À l'inverse, la règle renforce l'effet dissuasif que la menace de la nullité peut avoir sur le contractant indigne : celui-ci court en effet le risque, s'il exécute le contrat, et que l'autre agit en nullité, de devoir restituer tout ce qu'il a reçu de son cocontractant, sans pouvoir lui-même demander restitution de ce qu'il a versé.

SECTION 3. LA PREUVE DE LA CAUSE

382. Différentes hypothèses. Contrairement à l'objet, qui résulte toujours explicitement de ce à quoi les parties s'engagent, la cause, qu'elle soit prise dans son sens objectif ou subjectif, n'est pas toujours apparente dans l'acte qui constate le contrat. Il faut distinguer selon que la raison d'être du contrat est exprimée (**§ 1**) ou non (**§ 2**).

§1. La cause exprimée

383. Cause objective. Le problème de la preuve de la cause ne se pose pas chaque fois que le contrat se rattache explicitement à une catégorie contractuelle déterminée : on en connaît alors nécessairement la cause objective puisque celle-ci se détermine par catégorie d'actes, et non en fonction de tel ou tel acte particulier. Par exemple, si les parties passent une vente, elles n'ont nul besoin d'indiquer que l'engagement du vendeur est causé par le paiement du prix attendu de l'acheteur, et que celui du vendeur vise à obtenir la propriété du bien. Cela tient à la nature même de la vente, de même que, dans tous les contrats synallagmatiques on pourra dire que chaque contractant s'engage pour recevoir quelque chose en échange. La seule recherche à faire sera de se demander si, dans tel contrat particulier, cette contrepartie existe bien.

384. Cause subjective. Le problème est ici très différent, car les mobiles personnels des contractants sont spécifiques à chaque contrat : le seul fait que le contrat se présente comme une vente, un bail, un mandat n'indique donc en rien pourquoi les parties ont voulu le passer. Il arrive cependant qu'on puisse connaître ces mobiles à la seule lecture du contrat, lorsque les parties ont pris la peine d'assortir leurs engagements d'un « exposé des motifs », expliquant pourquoi elles ont décidé de passer le contrat. Un tel exposé peut être utile lorsqu'il s'agira d'interpréter le contrat. Mais il se peut aussi

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

que les « motifs » indiqués soient inexacts, qu'ils ne correspondent pas aux « mobiles » réels des parties – et ce sera fréquemment le cas lorsque les parties auront contracté pour une cause illicite ou immorale qu'elles auront cherché à dissimuler. En soi, le fait que les motifs indiqués soient inexacts n'a pas d'incidence sur la validité du contrat. Comme l'indiquent d'anciens arrêts de la Cour d'appel, « la convention dont la cause exprimée est fausse est néanmoins valable si elle a d'ailleurs une cause réelle et licite ; en effet, l'article 1131 du Code civil ne dit pas que l'obligation ne peut avoir aucun effet lorsque la cause a été faussement indiquée, mais seulement qu'il en est ainsi lorsqu'elle a été contractée sur une fausse cause »[892]. La cause indiquée peut cependant être contestée, soit par exemple parce que les mobiles réels peuvent avoir une incidence sur l'interprétation à donner du contrat, soit, surtout, pour démontrer que la cause dissimulée est en réalité immorale ou illicite, ce qui entraînera la nullité du contrat.

§2. La cause non exprimée

385. L'article 1132 du Code civil. Aux termes de cet article, « La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée ». Ce texte est rédigé d'une manière ambiguë, parce qu'il mélange la question de la validité de la convention (acte juridique, *negotium*) avec celle de la valeur de l'écrit (acte instrumentaire, *instrumentum*) qui la constate[893]. L'hypothèse visée est qu'un acte dressé pour constater ou pour créer une obligation ne mentionne pas la cause, la raison d'être de cette obligation : une personne reconnaît qu'elle est débitrice d'une autre, ou promet de payer une certaine somme à une autre, sans indiquer pourquoi elle reconnaît ou prend un tel engagement (est-ce en vertu d'un prêt qui lui a été consenti ? pour faire une libéralité ? pour s'acquitter d'une obligation naturelle ? etc.). C'est ce qu'on appelle habituellement les « billets non causés ». Peut-être qu'en réalité, cette personne ne doit rien : par exemple, elle a reconnu devoir de l'argent que son père avait emprunté, mais sans savoir qu'il avait déjà remboursé avant de mourir. Peut-être aussi que la raison pour laquelle elle s'engage est illicite ou immorale : par exemple, elle promet de payer une somme d'argent à un homme politique pour que celui-ci lui accorde des

892 Cass., 20 février 1914, 9, p. 186 ; Cour d'appel, 12 mars 1920, 11, p. 90.

893 Sur cette distinction, voy. *supra*, n° 36.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

passe-droits. Quelle valeur faut-il accorder à de tels actes ? On est ici dans une problématique complètement différente de celle qui a été précédemment examinée lorsqu'on s'interrogeait sur la cause d'un contrat dont, par hypothèse, on connaissait la nature (une vente, un prêt, un cautionnement, etc.). La difficulté, ici, est qu'on ne sait pas quel est le contrat, ou plus largement la relation juridique, qui fonde la reconnaissance de dette ou la promesse de payer.

386. Règle de preuve. Il ne faut surtout pas voir dans l'article 1132 du Code civil l'équivalent du § 780 du BGB qui donne la possibilité de rédiger une promesse de payer ou une reconnaissance de dette abstraite[894]. Au Luxembourg, pas plus qu'en France ou en Belgique, l'article 1132 du Code civil n'est utilisé pour fonder la validité des engagements de payer abstraits. Le texte, en effet, ne dit pas que la convention est valable « quoique l'engagement n'ait pas de cause », mais seulement « quoique la cause n'en soit pas exprimée ». Aussi bien, de manière constante dans les trois pays, l'article 1132 du Code civil est-il seulement interprété comme posant une règle de preuve, qui serait du reste davantage à sa place au sein des articles 1315 et suivants du Code civil relatifs à la preuve que dans le chapitre relatif aux conditions de validité du contrat. L'article 1132 du Code civil signifie en effet seulement que l'acte écrit portant engagement de payer qui ne porte pas la mention de sa cause est suffisant à constituer une preuve suffisante de cet engagement : l'existence d'une cause, et d'une cause licite est présumée dans le silence de l'acte. Cependant, la personne de qui émane un tel billet non causé a toujours la possibilité d'apporter la preuve que cet engagement n'a pas de cause (par exemple, parce qu'elle a cru qu'elle devait quelque chose alors qu'en réalité elle ne devait rien, ou que la dette avait déjà été remboursée), ou que la cause était illicite ou immorale (par exemple, l'engagement de payer a été pris en rémunération de services sexuels tarifés)[895]. Cette preuve peut être apportée par tous moyens : l'article 1341 du Code civil exige sans doute que la preuve « contre et outre » le contenu d'un acte écrit soit elle-même apportée par écrit, mais ici, il s'agit de prouver un élément qui, par hypothèse, ne figure pas dans l'acte et qui n'est destiné ni à le contredire ni à aller au-delà de ses termes.

894 Sur ce texte et les actes abstraits, voy. *supra*, n° 386.

895 Voy. p. ex. : Cour d'appel, 2 avril 2003, n° 26706, *BIJ*, 2003, p. 58 ; Cour d'appel, 8 janvier 2003, n° 25832, *BIJ*, 2003, p. 80 ; Cour d'appel, 7 juin 2018, n° 42450 ; Cour d'appel, 28 juin 2018, n° 44216. Pour un exemple d'annulation de l'acte dans un cas où il était prouvé que la reconnaissance de dette n'avait pas de cause, voy. Cour d'appel, 9 novembre 2016, n° 36039.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Le portée purement probatoire de la règle de l'article 1132 explique que, dans le droit français issu de la réforme de 2016, elle n'ait pas été reprise au sein des textes reprenant les exigences relatives à la cause (ni, malheureusement, dans le titre sur la preuve). Le législateur belge l'a cependant maintenue à l'article 5.55 du nouveau Code civil.

387. Conclusion : vers l'abandon de la notion de cause ? Face à ce qui était ressenti comme un facteur d'isolement du droit des pays du Code civil dans le contexte européen, la réforme française de 2016 a choisi, on l'a dit, d'abandonner la notion de cause, sans pour autant changer les solutions qui y sont actuellement rattachées. Cet abandon a même été présenté comme un des traits principaux du dernier projet présenté par le Ministère de la justice : « il est proposé de ne plus faire appel à la notion de cause, mais de préciser les différentes fonctions régulatrices ou correctrices jusqu'à présent assignées à cette notion par la jurisprudence »[896]. Que penser de cet abandon, vivement critiqué par de nombreux auteurs, et le droit luxembourgeois devrait-il suivre la même voie ? On peut être partagé. D'un côté, la notion de cause est un des éléments caractéristiques de la culture juridique des pays du Code civil, et de tous ceux qui s'en sont inspirés. On peut éprouver quelque irritation de voir que la principale raison qui conduit le législateur français à l'abandonner semble être une volonté de « faire moderne » en s'alignant sur une tendance qui semble majoritaire en Europe, alors pourtant que de nombreux systèmes juridiques dans le monde, inspirés du droit français, continuent de marquer leur attachement à cette notion[897]. Le fait que la notion de cause ait été maintenue lors de la réforme du Code civil belge fait que, maintenant, de manière paradoxale, c'est le droit français qui se trouve isolé au sein des droits auxquels il a servi de modèle. D'un autre côté, on peut se demander si cet attachement se justifie autrement que par le respect de la tradition, tant l'utilité de la notion de cause paraît sujette à discussion. On a vu que les quelques solutions qui peuvent se rattacher à la notion objective de cause, strictement entendue, pourraient être aisément expliquées par le recours à d'autres mécanismes (absence d'objet, vice du consentement). De même, il est douteux qu'il soit

896 Présentation du projet de réforme, Paris, Dalloz, 2013, p. 2770.

897 La notion de cause a été par exemple conservée dans le nouveau Code civil du Québec (art. 1410 et s.) ainsi que dans le nouveau Code civil roumain (art. 1235 et s.). Elle est également maintenue dans les projets actuels de réforme des droits civils d'Amérique latine.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

indispensable de faire appel à la notion subjective de cause pour justifier l'annulation des contrats inspirés par des mobiles illicites ou immoraux, ce qui n'est qu'un aspect de la contrariété des contrats à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Il est vrai que, dans la période récente, le rôle de la cause a été considérablement étendu par la jurisprudence, au moins en France, et que la notion semble être redevenue un instrument technique central en droit des contrats. Mais il faut souligner que la plupart de ces extensions – du reste non reçues au Luxembourg – ne se justifiaient que par l'absence, en droit français, d'instruments plus adaptés que l'évolution des conceptions en droit des contrats paraît appeler (contrôle des clauses abusives dans les contrats entre professionnels, admission de la lésion qualifiée, admission de la révision pour imprévision, etc.). On peut en conséquence se demander s'il ne serait pas préférable, comme l'a fait le législateur français, d'intégrer dans le système, par des dispositions expresses, les différentes solutions actuellement couvertes par le recours à de cause, plutôt que de rassembler sous une même notion, devenue exagérément complexe à force de déformations, des solutions aussi disparates. Néanmoins, la notion de cause est si profondément enracinée dans la culture juridique des pays du Code civil qu'on peut penser que sa suppression, en France, sera purement formelle, et qu'elle subsistera dans le discours doctrinal alors même qu'elle aura disparu des textes.

LARCIER INTERSENTIA
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La cause, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 423-470
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Chapitre V
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes mœurs)

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

388. Première idée. Dans aucun système juridique, la liberté qu'ont les parties de déterminer le contenu de leur contrat n'est totale. Elle est limitée par un certain nombre de règles qui expriment des intérêts et des valeurs que le système place en dehors des atteintes de conventions particulières. Dans le Code civil, ces intérêts et ces valeurs qui limitent la liberté contractuelle trouvent leur expression dans la notion d'ordre public, qui est une des notions fondamentales du droit des contrats. De prime abord, ces intérêts et ces valeurs correspondent à la notion d'intérêt général – opposé aux intérêts particuliers des parties – mais nous verrons que, dans une certaine conception de l'ordre public, il peut s'agir aussi d'intérêts particuliers, du moins d'intérêts de certaines catégories de contractants.

De manière significative, les rédacteurs du Code civil n'ont pas directement fait figurer cette exigence fondamentale au sein des conditions de validité du contrat, où elle n'apparaît qu'à travers quelques-unes de ses manifestations (l'interdiction de contracter sur des choses qui ne sont pas dans le commerce de l'article 1128 du Code civil, l'exigence d'une cause licite des articles 1108, 1131 et 1132 du Code civil). L'idée de la limitation de la liberté contractuelle par l'ordre public apparaît de manière générale dans le Code dès le titre préliminaire, au sein de ce qu'on pourrait appeler les « principes constitutionnels du droit civil », dans l'article 6 du Code civil, qui peut être considéré, avec l'article 1134 du Code civil, comme un des deux articles de base du droit des contrats. Aux termes de cet article « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». On remarquera d'emblée que le texte distingue deux notions, celle d'ordre public et celle de bonnes mœurs. Cependant, il est aujourd'hui bien admis que les bonnes mœurs ne constituent pas une notion distincte de l'ordre public, elles n'en constituent qu'un élément, qu'un aspect particulier (traditionnellement la partie de l'ordre public qui a trait aux comportements sexuels). En France et en Belgique, la notion de bonnes mœurs a du reste purement et simplement disparu des nouveaux textes du droit des contrats. C'est pourquoi on traitera, dans ce chapitre, de l'ordre public en général, sauf à expliciter la notion de bonnes mœurs lorsqu'on étudiera le contenu de ces règles.

La signification de la notion d'ordre public en droit des contrats apparaît de prime abord comme très différente de celle qu'elle peut revêtir dans d'autres branches du droit, notamment en droit

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

administratif où elle désigne plutôt, de manière plus restrictive, la sécurité des citoyens et la stabilité des institutions que les autorités publiques sont chargées de garantir (par exemple, lorsqu'une manifestation de rue est réglementée pour éviter des débordements ou des atteintes à la propriété ou à la sécurité des riverains). Les deux notions sont cependant évidemment liées : la protection de la sécurité publique est un élément de base de l'ordre public en droit des contrats (ce qui justifie, par exemple, la nullité d'un contrat par lequel une des deux parties s'engagerait à porter atteinte à la vie ou à la propriété d'autrui), et, d'un autre côté, l'ordre public en droit administratif déborde très largement la protection de la sécurité et des institutions pour s'étendre à la défense de valeurs qui constituent, aussi, des éléments de l'ordre public contractuel (par exemple, lorsque l'administration interdit un spectacle à connotation raciste).

389. Exigence transversale. Déjà rencontrée à propos de l'objet du contrat (choses hors du commerce), et à propos de la cause subjective, la notion d'ordre public déborde très largement ces aspects. Elle s'étend à tous les aspects du contenu contractuel – ce qu'on peut considérer comme son objet au sens large. Elle s'applique à chaque prestation des parties, comme à l'opération contractuelle dans son ensemble. Elle s'applique aussi, séparément, à chaque clause du contrat : il arrive très souvent qu'un contrat, parfaitement licite dans sa globalité, contienne une ou plusieurs clauses qui heurtent l'ordre public (par exemple, des clauses d'irresponsabilité du professionnel dans un contrat de vente de biens à un non-professionnel). La question se posera alors de savoir si la nullité affectant la clause contraire à l'ordre public s'étendra ou non à tout le contrat[898]. On doit même observer que l'exigence de conformité à l'ordre public déborde le contenu du contrat et de ses différentes clauses. Parfois, en effet, la contrariété à l'ordre public tient, non pas au contenu du contrat, à sa matière, mais à la personne qui le passe : les incapacités de jouissance, déjà rencontrées, constituent de ce point de vue un aspect particulier de l'ordre public, un ordre public *rationae personae* (par opposition à l'ordre public *rationae materiae* qui s'applique au contenu du contrat). Et on peut même considérer, en un certain sens, que de nombreuses exigences formelles applicables à divers contrats, et qui limitent la

[898] Voy. *infra*, n° 472.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

liberté contractuelle, font partie de la notion d'ordre public. Tout dépend, cependant, comme nous allons le voir, de la définition précise qu'on donne de cette notion.

390. Deux définitions possibles : finalité et caractère d'ordre public. La notion d'ordre public recèle, dans le droit moderne, une ambiguïté fondamentale, qui se traduit à travers deux manières différentes de le définir. Dans un premier sens possible, l'ordre public se définit par son contenu, ou plus exactement par la finalité des règles qui le composent. Dans ce sens, l'ordre public se compose de toutes les règles qui visent à assurer la prééminence de l'intérêt général (public) sur les intérêts privés des parties. C'est en ce sens que l'article 6 du Code civil vise les « lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs » : ce sont des lois (ou plus largement des règles) qui, en un temps et en un lieu donné, correspondent aux valeurs supérieures de l'ordre social. La protection de la sécurité des personnes et des biens, le maintien des institutions publiques, l'interdiction des discriminations entre les différentes catégories de citoyens, la nécessité d'une certaine régulation des comportements sexuels, etc. font, de ce point de vue, incontestablement partie de l'ordre public en ce sens, on serait tenté d'écrire, avec des majuscules, l'Ordre Public. Mais, dans le langage juridique moderne, on emploie souvent, y compris dans la loi, l'expression « ordre public » dans un autre sens, pour désigner cette fois le caractère de certaines règles de droit, sans référence particulière à leur finalité, à la nature des intérêts que ces règles visent à protéger. Lorsqu'on dit que telle loi est « d'ordre public »[899], on veut simplement dire qu'on ne peut y déroger conventionnellement, que tout contrat ou toute clause contraire sont nuls. L'expression « loi d'ordre public » est alors simplement prise comme synonyme de « loi impérative », par opposition aux lois supplétives, qui peuvent être écartées par des stipulations contractuelles. L'ordre public désigne alors toutes les règles qui viennent limiter la liberté contractuelle, quelles que soient leur finalité.

À l'époque du Code civil, cette dualité de sens ne posait guère de problème, car les deux sens se recouvraient très largement : les lois auxquelles on ne pouvait pas déroger, les lois impératives, étaient principalement, sinon exclusivement, celles qui

[899] Voy. p. ex. en jurisprudence : Cour d'appel, 19 juin 1984, *Pas.*, 26, p. 184, affirmant que « L'institution de la garantie décennale (due par l'entrepreneur de construction) est d'ordre public ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

« intéressaient » l'ordre public et les bonnes mœurs, qui visaient à la défense de l'intérêt général et c'est exactement ce que dit l'article 6 du Code civil. C'est du reste pour cela, par une sorte de facilité de langage, qu'on parle de « lois d'ordre public » pour désigner toutes les lois impératives. Mais, depuis l'époque du Code civil, on a vu se multiplier, au sein de ce qu'on appelle très généralement « l'ordre public » en tant qu'ensemble de règles limitant la liberté contractuelle, des règles qui visent, non pas directement à protéger l'intérêt général, mais les intérêts particuliers de contractants appartenant à certaines catégories jugées être en situation de faiblesse et donc dignes d'une protection spécifique. Les règles de protection des consommateurs, déjà rencontrées à maintes reprises, de même que les règles protectrices des salariés en droit du travail, les règles protectrices des locataires dans les baux commerciaux ou à usage d'habitation, etc. sont des exemples caractéristiques de ce qu'on appelle parfois « l'ordre public de protection ». Il est clair que ces règles ne correspondent plus à la notion traditionnelle d'Ordre Public, puisqu'elles n'ont pas, du moins pas directement, une finalité d'intérêt général. Nous verrons du reste que la sanction de la violation de ces règles n'est pas, en principe, la même que celle qui frappe la violation de l'Ordre Public traditionnel. Elles n'en sont pas moins « d'ordre public » en ce sens qu'elles sont impératives, qu'on ne peut pas y déroger. Les deux sens de la notion – la finalité d'ordre public (d'intérêt général) et le caractère d'ordre public (impératif) ne coïncident donc plus nécessairement.

391. Distinction terminologique entre règles d'ordre public et règles impératives ? On peut se demander, face à ce dualisme de signification, s'il ne faudrait pas adopter une terminologie différenciée pour distinguer les deux sens. On pourrait convenir de ne parler d'ordre public, de règles d'ordre public, que dans le sens traditionnel de l'article 6 du Code civil, à savoir les règles ayant une finalité d'intérêt général, tandis que, pour les règles protectrices des intérêts particuliers des contractants en situation de faiblesse (l'ordre public de protection), on parlerait simplement de « règles impératives ». Tel est l'usage qui s'est instauré en Belgique, à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 1948 qui a posé que « n'est d'ordre public proprement dit que la loi qui touche aux intérêts essentiels de l'État ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

économique ou moral de la société »[900]. Cet « ordre public proprement dit » est devenu, dans la jurisprudence postérieure, l'« ordre public » tout court[901], que la Cour de cassation belge distingue des lois impératives, notamment lorsqu'il s'agit de savoir si la nullité qui assortit la violation des règles est absolue ou relative[902]. La doctrine belge a intégré cette distinction, et les manuels belges présentent traditionnellement la matière en distinguant ordre public (et bonnes mœurs) et dispositions impératives[903]. Pour P. Van Ommeslaghe, par exemple, « les lois impératives se distinguent des règles d'ordre public en ce qu'elles visent la protection d'intérêts privés et non plus celle de l'intérêt général mais que l'on ne peut y déroger lors de la conclusion des actes juridiques en raison de la protection apportée à des contractants considérés comme plus faibles »[904]. Le nouveau droit belge des contrats a intégré cette terminologie : par exemple l'article 5.51 du nouveau Code civil dispose que « [l]a prestation est illicite lorsqu'elle crée ou maintient une situation qui est contraire à l'ordre public ou à des dispositions légales impératives », et l'article 5.56 fait la même distinction à propos de la cause. Surtout, l'article 5.58 relatif à la classification des nullités dispose que « [l]a nullité est absolue lorsque la règle violée est d'ordre public, ayant ainsi pour objet principal la sauvegarde de l'intérêt général » alors que « [l]a nullité est relative lorsque la règle violée est impérative, ayant ainsi pour objet principal la sauvegarde d'un intérêt privé ».

La jurisprudence luxembourgeoise n'ignore pas cette distinction. Même si la plupart des décisions suivent la terminologie française, en parlant notamment de « l'ordre public de protection »[905], on peut au moins citer un jugement du Tribunal de Luxembourg qui se réfère explicitement à la terminologie belge[906]. Le tribunal, pour déterminer la sanction de la violation de certaines règles de droit des sociétés, se demande s'il s'agit de règles d'ordre public, sanctionnées

900 Cass. be., 9 décembre 1948, *Pas. be.*, 1948, I, p. 699.

901 Voy. récemment Cass. be., 29 avril 2011, *RG*, n° C.10.0183.N.

902 Voy. p. ex. Cass. be., 27 septembre 2010, R.G. n° S.09.0108.F : « Est une disposition impérative et non d'ordre public la règle de compétence territoriale suivant laquelle ressortit au juge du domicile de l'assuré la contestation relative aux droits et obligations d'un travailleur salarié en matière d'assurance obligatoire maladie-invalidité ».

903 Voy. Wéry, pp. 323 et s., spec. n° 312 ; Van Ommeslaghe, pp. 357 et s.

904 Van Ommeslaghe, n° 219.

905 Cour d'appel, 15 décembre 1992, *Pas.*, 29, p. 37 ; Cour d'appel, 9 juillet 2008, *Pas.*, 34, p. 270 ; *BIJ*, 2008, p. 160.

906 Trib. Luxembourg, 23 décembre 2015, n°s 145.724 et 145.725, *JN Obligations*, 2016, n° 2, p. 9, note A. Waisse.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

par une nullité absolue, ou « de dis positions simplement impératives censées protéger certaines catégories de personnes lesquelles ont pu renoncer à cette protection en accordant décharge ». On continuera cependant ici selon la terminologie utilisée en France, de parler d'ordre public, ou de règles d'ordre public pour désigner toutes les règles impératives, qu'elles aient ou non une finalité d'ordre public, sauf à distinguer à l'intérieur de cette masse, quand le besoin s'en fera sentir, les règles protectrices de l'intérêt général, et les règles protectrices des intérêts de certaines catégories de contractants. Il ne nous paraît pas forcément très satisfaisant, en effet, de réserver l'usage de l'expression « règles impératives » aux seules règles d'ordre public de protection, alors que toutes les règles composant l'ordre public présentent ce même caractère d'impérativité. Par ailleurs, il n'est pas nécessairement souhaitable d'introduire, au sein de l'ensemble des règles d'ordre public, une distinction trop tranchée, au niveau même de la terminologie, entre l'ordre public « proprement dit » (qui serait en quelque sorte le seul « vrai ») et l'ordre public de protection. Nous verrons en effet que, même derrière les règles d'ordre public de protection, les considérations d'intérêt général ne sont pas complètement absentes, et que le régime des sanctions de la violation de ces règles, s'il est incontestablement différent de celui de l'ordre public traditionnel, n'est pas non plus complètement analogue à celui de la violation de pures règles d'intérêt privé.

392. Objet des développements. Il n'est pas question de faire ici une étude, même partielle, des multiples règles d'ordre public qui viennent aujourd'hui, en droit luxembourgeois, limiter la liberté de déterminer le contenu d'un contrat. Ces règles sont innombrables, et se rencontrent dans toutes les branches du droit, l'étude de chacune de ces règles ressortant des différentes branches – que ce soit le droit du travail, le droit de la concurrence, le droit des sociétés, le droit financier, le droit de l'environnement, etc. Une telle étude systématique serait du reste parfaitement vaine, tant le contenu de la notion est essentiellement variable. On se limitera ici à une présentation générale des sources de l'ordre public (**Section 1**) et à une réflexion d'ensemble sur son contenu (**Section 2**).

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

SECTION 1. LES SOURCES DE L'ORDRE PUBLIC

393. L'illicite, au-delà de l'illégal. Pris à la lettre, l'article 6 du Code civil qui interdit de déroger aux « lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs », semble indiquer que seule la loi peut limiter la liberté contractuelle en posant des règles d'ordre public. On pourrait le comprendre, dès lors qu'on considère que la liberté contractuelle est un principe fondamental du droit des contrats, auquel on ne peut porter atteinte que de manière exceptionnelle. En réalité, les juges, en tant qu'ils créent des normes jurisprudentielles interprétant ou complétant les lois jouent aussi un rôle important dans la détermination du contenu de l'ordre public : l'illicite, entendu comme tout ce qui est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, est donc plus large que l'illégal – entendu comme ce qui est prohibé par la loi. Le rôle des juges à cet égard est double. D'une part, ils contribuent à déterminer les limites de l'ordre public légal (**§ 1**), d'autre part, ils créent directement des normes jurisprudentielles d'ordre public (**§ 2**).

§1. L'ordre public légal

394. Ordre public textuel. Dans tout ordre juridique, et en particulier au Luxembourg, il existe de nombreuses lois qui se disent expressément d'ordre public. Les formules qui l'indiquent sont diverses. Parfois, on trouve explicitement l'affirmation que « la présente loi est d'ordre public ». Mais plus souvent, le caractère impératif de la règle est indiqué à travers l'affirmation de la nullité des conventions contraires : « il est interdit, nonobstant toute convention contraire de […] », « toute convention contraire est nulle », « toute clause contraire est nulle (ou réputée non écrite) »[907]. Ces formules s'opposent à celles qui, à l'inverse, indiquent explicitement le caractère supplétif d'une loi : « les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur […] s'il n'y a eu stipulation contraire » (C. civ., art. 1608), « la délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en est l'objet, s'il n'en a été autrement convenu » (C. civ., art. 1609), « Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit […] » (C. civ., art. 1627), « Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire » (C. civ., art. 1986), etc.

[907] Voy. p. ex. C. civ., art. 1601-14 – Sur la distinction entre clauses nulles et clauses réputées non écrites, voy. *infra*, n° 475.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Ces formules, dans un sens ou dans l'autre, ne laissent aucun pouvoir d'interprétation au juge, qui doit considérer, selon les cas, que le texte est impératif ou supplétif.

395. Ordre public virtuel. Dans de nombreux cas, cependant, les textes de loi ne disent pas s'ils sont impératifs ou supplétifs, n'indiquent pas si les parties peuvent ou non y déroger. Il appartient alors aux tribunaux, confrontés à des contrats ou à des clauses qui prétendent écarter un texte de ce type, de dire s'il s'agit ou non d'une loi « intéressant l'ordre public et les bonnes mœurs ». Dans divers domaines, la réponse ne fait guère de doute. Ainsi, il est certain que toutes les règles de droit pénal, qui visent à réprimer les comportements nuisibles à l'ordre social, sont d'ordre public, de sorte que toute convention par laquelle une partie s'engagerait à commettre une infraction pénale doit *a priori* être considérée comme nulle. Il en va de même des règles de droit fiscal : si ces règles n'excluent pas que des contribuables passent des conventions avec l'administration fiscale (soit pour déterminer à l'avance le montant de l'impôt – les fameux *rulings* – soit pour transiger sur le montant d'une pénalité), elles ne peuvent en revanche être écartées par des conventions entre particuliers qui auraient pour objet ou pour effet d'éluder le paiement de l'impôt. Pour des raisons très différentes, les règles du droit du travail ou du droit de la consommation, en tant qu'elles visent à protéger des contractants en situation de faiblesse, sont très largement d'ordre public. Dans d'autres domaines, on peut davantage hésiter. Par exemple, les règles qui organisent les juridictions de l'État sont en général d'ordre public – de sorte qu'on ne peut pas par exemple décider dans un contrat que la juridiction chargée de trancher les litiges à naitre entre les parties sera composée autrement que ne le prévoient les textes. Mais on peut en revanche, dans certaines limites, prévoir que ces litiges seront tranchés par une autre juridiction que celle qui serait territorialement compétente – par exemple que, pour un contrat entre des parties habitant à Diekirch, les litiges seront de la compétence du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg[908]. Dans les relations entre particuliers ou entre professionnels, là où n'intervient pas le droit de la consommation, la liberté contractuelle est large-

[908] Compte tenu de la petite taille du pays, cette question se pose rarement. Se pose en revanche très fréquemment la question de la validité des clauses de compétence territoriale dans les contrats internationaux (peut-on attribuer au tribunal de Luxembourg un litige qui serait normalement de la compétence des tribunaux français ?). Mais cette question est réglée expressément par le règlement européen dit Rome I.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ment reconnue. On considère ainsi que les règles générales relatives aux contrats sont par principe supplétives, sauf si leur caractère impératif est expressément affirmé ou s'il résulte de l'objet du texte. L'article 5.3 du nouveau Code civil belge l'affirme très clairement. De même, la plupart des règles spéciales du Code civil relatives aux différents contrats sont considérées comme supplétives même si elles ne le disent pas explicitement. Cependant, la jurisprudence reconnaît de plus en plus souvent le caractère impératif de certaines règles. Pour ne prendre ici qu'un exemple, la jurisprudence luxembourgeoise a considéré que l'article 1792 du Code civil, qui fait peser sur l'entrepreneur de construction une garantie pendant 10 ans des ouvrages qu'il construit, est un texte d'ordre public, de sorte que l'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa garantie[909]. On s'épuiserait inutilement à passer en revue les différents domaines du droit où les juges ont découvert des règles d'ordre public. L'essentiel est ici de comprendre que la jurisprudence a un rôle essentiel pour déterminer si tel ou tel texte, qui ne le dit pas expressément, est ou non d'ordre public. Cet ordre public découvert dans les textes est habituellement appelé « ordre public virtuel ».

Lors de la réforme française de 2016, un passage du Rapport au Président de la République a jeté le trouble en indiquant que, à défaut de mention contraire dans la loi, toutes les dispositions légales nouvelles devaient être considérées comme supplétives, ce qui condamnerait l'idée d'un ordre public virtuel. Les commentateurs s'accordent cependant à considérer que cette directive ne sera pas suivie, et que les juges pourront toujours décider du caractère impératif d'une loi qui ne le préciserait pas[910].

396. **Questions de droit constitutionnel.** La question des sources de l'ordre public a des incidences en droit constitutionnel. En premier lieu, il faut savoir ce qu'il faut entendre par « loi » dans l'article 6 du Code civil : s'agit-il seulement des lois au sens strict, formel, celles qui sont édictées par la Chambre des députés, organe du pouvoir législatif, ou l'ordre public peut-il être contenu dans d'autres textes émanant de l'État ? La réponse ne fait aucun doute pour la Constitution, qui est supérieure aux lois : il est incontestable, par exemple que les articles 12 à 14, qui garantissent un certain nombre de droits fondamentaux et de libertés, peuvent être invoqués à l'encontre de conventions qui prétendraient écarter ces droits. *A fortiori* beaucoup de règles d'ordre public peuvent être trouvées dans les règles issues de traités internationaux, supérieures aux normes internes : le droit de l'Union européenne

909 Cour d'appel, 29 juin 1984, *Pas.*, 26, p. 184.

910 Voy. not. O. Deshayes, Th. Genicon et Y.M. Laithier, *Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : commentaire article par article*, 2e éd., Paris, LexisNexis, 2018, pp. 12 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

est un réservoir inépuisable de règles d'ordre public (droit de la concurrence, droit financier, droit de la consommation, etc.), de même que, dans un autre domaine, la Convention européenne des droits de l'homme. À l'autre bout de la chaîne des normes, il est moins évident en revanche que des actes réglementaires, inférieurs à la loi (les règlements grand-ducaux), puissent intervenir directement pour limiter la liberté contractuelle. En droit français, il résulte clairement du partage de compétence opéré par les articles 34 et 37 de la Constitution, que les « principes généraux du droit des obligations » – dont fait partie la liberté contractuelle – relèvent du domaine exclusif de la loi. En droit luxembourgeois, où les règlements ne peuvent en principe intervenir que pour compléter la loi, ils ne peuvent sans doute pas poser directement de nouvelles limites à la liberté contractuelle. Mais les règlements qui complètent la loi peuvent préciser la portée des règles d'ordre public fixées par la loi.

La question se pose ensuite de savoir si le législateur national est complètement libre lorsqu'il décide de poser des règles d'ordre public limitant la liberté contractuelle. En droit français, le Conseil constitutionnel considère aujourd'hui que la liberté contractuelle, tout comme la liberté d'entreprendre, est un principe à valeur constitutionnelle protégé sur le fondement de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Le Conseil estime dès lors de manière constante que, s'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle des limitations justifiées par un motif d'intérêt général, c'est à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi[911]. Au Luxembourg, sans affirmer d'une manière générale le caractère constitutionnel de la liberté contractuelle, la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la constitution, dans le cadre d'une question préjudicielle, l'article 1762-6, paragraphe 4, du Code civil qui restreint la liberté des parties liées par un contrat de sous-location de fixer librement le prix du bail à un montant supérieur à celui convenu dans le cadre du bail principal. Pour la Cour, ce texte apporte une restriction disproportionnée au principe de la liberté du commerce et de l'industrie garanti par l'article 11 (6) de la Constitution (devenu l'article 35 de la constitution révisée)[912]. Pour la Cour, « la liberté du commerce et de l'industrie couvre la liberté de fixer librement par voie conventionnelle le prix des produits et services sujets à transaction économique ». La loi peut bien entendu établir des restrictions à cette liberté (qui est un des aspects de la liberté contractuelle), mais à la condition que ces restrictions soient « rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but ». La solution est donc proche de celle de la jurisprudence constitutionnelle française.

§ 2. L'ordre public jurisprudentiel

397. Bonnes mœurs. Contrairement à ce que l'article 6 du Code civil pourrait laisser croire, l'ordre public ne tient pas tout entier dans des lois. À côté de l'ordre public légal, on peut découvrir des normes d'ordre public directement créées par les tribunaux pour limiter la liberté contractuelle. Ce phénomène est traditionnel dans le domaine particulier des bonnes mœurs : si certains comportements

911 Pour une application récente : C. const. fr., 13 juin 2013, n° 2013-672 DC.

912 Cour const., 23 décembre 2022, n° 00176.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

contraires aux bonnes mœurs sont interdits par la loi [notamment par la loi pénale qui réprime certains comportements touchant à la morale sexuelle : interdiction du proxénétisme et de l'exploitation de la prostitution (C. pén., art. 379*bis* et s.)], la notion de bonnes mœurs a, en droit des contrats, un contenu essentiellement jurisprudentiel. C'est ainsi que, alors même que la loi luxembourgeoise n'a jamais réprimé, ni interdit le fait de vivre en couple ou d'avoir des relations sexuelles sans être marié[913], la jurisprudence a, au Luxembourg comme en France et en Belgique, longtemps considéré que les actes juridiques qui avaient pour but de favoriser de telles relations sexuelles (notamment les libéralités entre concubins destinées à inciter l'un des partenaires à continuer la vie commune) étaient nulles pour cause immorale – c'est-à-dire contraire aux bonnes mœurs. Si cet exemple est certainement dépassé aujourd'hui, il ne fait guère de doute que, si le problème se posait devant les tribunaux, ceux-ci considéreraient toujours que le contrat passé entre un(e) prostitué(e) et son ou sa client(e) est contraire aux bonnes mœurs, alors même que, au Luxembourg comme dans beaucoup de pays, la prostitution n'est pas en elle-même interdite par la loi.

398. En dehors des bonnes mœurs. En dehors des bonnes mœurs, la création directe de règles d'ordre public par le juge est plus récente, et sans doute moins fréquente. Elle n'est cependant pas exceptionnelle. C'est ainsi que, parmi les diverses obligations que le juge met à la charge d'une partie dans certaines relations contractuelles, alors que ces obligations ne sont ni expressément voulues par les parties, ni prévues par la loi, certaines, fondées sur la volonté supposée des parties sont conçues comme supplétives, mais d'autres sont considérées comme imposées par des considérations d'ordre public, et ne peuvent en conséquence pas être écartées par une clause du contrat : on ne concevrait pas, par exemple, qu'un contractant s'exonère de l'obligation de sécurité mise à sa charge par la jurisprudence[914]. Il faut également signaler ici le rôle essentiel joué par la jurisprudence dans le cadre de la législation sur les clauses abusives, qui est un des aspects caractéristiques de l'ordre public de protection des consommateurs[915] : certes, c'est ici la loi qui interdit de stipuler dans un contrat entre un professionnel et un consommateur une clause « qui entraîne dans le contrat un

[913] À la différence de certains droits d'origine religieuse.

[914] Sur cette obligation de sécurité, voy. *infra*, n° 534.

[915] Voy. *infra*, n°s 411 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur » (C. consomm., art. L. 211-2) ; mais c'est principalement aux tribunaux qu'il appartient de préciser quelles sont les clauses qui créent un tel déséquilibre, au-delà de la liste non limitative qu'en donne le législateur (C. consomm., art. L. 211-3).

SECTION 2. LE CONTENU DE L'ORDRE PUBLIC

399. Variabilité de l'ordre public. Le contenu de l'ordre public n'est nullement défini par l'article 6 du Code civil. Ce texte renvoie implicitement à la multitude des règles légales et jurisprudentielles qui, dans tous les domaines du droit, disent ce qui est permis et ce qui est interdit dans un contrat. Ces règles sont essentiellement variables dans le temps et dans l'espace, car elles dépendent des conceptions qu'on se fait, à un moment donné et en un pays donné, des éléments essentiels à l'ordre social, et des valeurs dont on veut assurer la suprématie face aux intérêts individuels. En droit romain, on pouvait vendre un être humain qui avait le statut d'esclave et qui était assimilé à une chose, dans le droit luxembourgeois moderne, un tel contrat, contraire à la dignité de la personne humaine, est évidemment « contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ». À l'inverse, on n'imaginait pas, au début du XIXe siècle que deux personnes de même sexe puissent s'engager par contrat à vivre ensemble, alors qu'aujourd'hui elles peuvent par convention organiser leur partenariat[916], et même, désormais, se marier. D'une manière générale, les règles qui composent aujourd'hui l'ordre public en droit luxembourgeois n'ont plus grand-chose à voir avec ce que recouvrait cette notion en 1804, date de rédaction du Code civil. Des différences aussi spectaculaires peuvent s'observer si on compare ce que recouvre la notion d'ordre public dans différents pays : dans beaucoup de pays du monde, où s'applique la loi islamique, il est interdit de vendre du porc, alors que cette viande, qui est une des nourritures préférées des luxembourgeois, est ici en vente dans tous les supermarchés ; à l'inverse, même depuis la loi du 10 juillet 2023 qui autorise la culture du cannabis pour sa consommation personnelle, la vente de ce produit est interdite au Luxembourg, alors que certains pays européens en autorisent la vente etc. Même entre les

[916] L. 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, art. 6. On peut considérer que le partenariat lui-même, alors même qu'il est soumis à une réglementation très spécifique, est un contrat.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

trois pays très proches que constituent le Luxembourg, la France et la Belgique, qui partagent largement la même culture juridique, on peut observer de multiples différences dans le contenu de l'ordre public et donc dans l'étendue de la liberté contractuelle.

400. **Différents cercles de l'ordre public.** À l'intérieur même d'un ordre juridique, à une époque et à un moment donné, l'ordre public contractuel apparaît comme une notion à géométrie variable. Il peut revêtir plusieurs contenus selon le rôle qu'on veut lui faire jouer. On peut d'abord distinguer un ordre public substantiel et un ordre public procédural, en ce sens que certaines règles, qu'il est interdit d'écarter directement dans un contrat, peuvent faire l'objet de conventions ayant pour objet le règlement des litiges qui y sont relatifs : par exemple, on ne peut pas par contrat instituer une entente entre entreprises qui aurait pour effet de porter atteinte à la libre concurrence ; mais, si deux entreprises ont passé un accord qui pourrait être qualifié d'entente anti-concurrentielle, elles peuvent prévoir dans leur contrat que les litiges à naître entre elles (y compris sur le point de savoir si ce contrat est ou non licite au regard du droit de la concurrence) seront tranchés par voie d'arbitrage. Surtout, il faut distinguer l'ordre public au sens du droit national (l'ordre public interne) et l'ordre public au sens du droit international privé. Lorsque deux parties passent un contrat qu'elles soumettent à une loi étrangère, et qu'un litige relatif à ce contrat vient devant un juge luxembourgeois, celui-ci doit normalement juger de la validité de ce contrat au regard des règles contenues dans la loi étrangère désignée. Dans certains cas, cependant, le juge luxembourgeois peut considérer que ce qui est permis par cette loi étrangère est trop choquant au regard des conceptions nationales du Luxembourg, il pourra alors annuler le contrat ou certaines clauses au nom de sa contrariété à l'ordre public international. C'est, par exemple, ce qui se passerait si venait en discussion devant un juge luxembourgeois un contrat de travail passé dans un pays dont le droit admet que le salarié peut travailler 20 heures par jour, sans aucun jour de repos dans la semaine : si le salarié, qui a été licencié parce qu'il refusait de se soumettre à ces conditions inhumaines, vient réclamer des dommages et intérêts à son ancien employeur maintenant installé au Luxembourg, il paraît évident que le juge déclarera le licenciement injustifié, et qu'il rejettera l'argumentation de l'employeur prétendant que le contrat n'a pas été respecté. Cet ordre public international, cependant, est beaucoup plus restreint que ce qui serait considéré comme d'ordre public pour un contrat passé et exécuté au Luxembourg : si la loi étrangère fixe la durée hebdomadaire du travail à 42 h au lieu de 40 h, le juge l'appliquera et ne considérera pas qu'elle est contraire à l'ordre public international.

401. **Expansion quantitative de l'ordre public.** La première impression que l'on a, lorsqu'on considère le contenu actuel de l'ordre public au Luxembourg, c'est celle de son extension considérable depuis l'époque du Code civil. À cette époque, l'ordre public était conçu comme une limite exceptionnelle à la liberté contractuelle. La plus grande partie des règles édictées par le Code civil en matière de contrats était composée de règles supplétives, et on ne peut qu'être frappé, lorsqu'on lit les textes du Code relatifs aux différents contrats, par la prolifération des expressions qui réservent la volonté contraire des parties. Il est clair que, depuis le début du

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

XIXe siècle, les règles impératives se sont multipliées, plus d'ailleurs dans des lois spéciales laissées à l'extérieur du Code que dans le Code lui-même, et qu'il n'est aujourd'hui plus guère de contrat qui ne doive respecter, par certains aspects au moins, des contraintes légales pour sa formation ou pour la détermination de son contenu. Cette expansion quantitative de l'ordre public correspond à la montée de l'interventionnisme économique, mais aussi à la prise de conscience progressive des dangers du libéralisme sur la situation des contractants les plus faibles.

Ce discours courant – surtout chez ceux qui regrettent le phénomène – doit cependant être nuancé d'un double point de vue. D'une part, cette montée en puissance de l'ordre public n'affecte pas de manière égale tous les domaines. Si on considère les relations économiques, elle concerne plus les contrats entre parties d'inégale puissance économique que les contrats entre entreprises. Et, si on regarde le domaine des relations personnelles et familiales, le constat est plutôt à l'inverse celui d'un certain recul de l'ordre public, lié à la libéralisation des mœurs et à la diversification des structures familiales. D'une manière générale, la notion de bonnes mœurs apparaît aujourd'hui beaucoup plus restreinte qu'à l'époque du XIXe siècle. D'autre part, contrairement à l'image qu'on en donne souvent, le mouvement d'expansion de l'ordre public n'est pas un mouvement continuel, qui verrait une accumulation toujours plus importante de règles impératives bridant de plus en plus les initiatives privées. En réalité, l'évolution est plus chaotique, alternant des périodes d'interventionnisme étatique avec des moments de retour à un plus grand libéralisme – de flexibilité comme on dit aujourd'hui en matière sociale.

Si on compare le Luxembourg aux pays voisins, on peut sans doute dire que, d'une manière générale, le pays a été moins touché par le développement de l'interventionnisme étatique que la France ou la Belgique, et qu'il reste un des pays les plus libéraux d'Europe en matière économique. La souplesse de sa réglementation financière, qui déroge sur de nombreux points au droit commun figurant dans le Code civil[917], en est l'aspect le plus voyant, mais on pourrait en donner beaucoup d'autres exemples : comparez par exemple le droit des baux d'habitation en France (hyper réglementé et très favorable aux locataires) avec la loi du 21 septembre 2006 au

[917] Sur cette question, voy. P. GEORTAY et P. KINSCH, « L'agencement du droit commun et des normes dérogatoires. Le cas du droit privé financier », in *Droit bancaire et financier au Grand-Duché de Luxembourg*, Bruxelles, Lacier-Intersentia, 2024

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Luxembourg ! Le développement dans divers domaines de la législation européenne, porteuse de multiples réglementations d'ordre public, est cependant de nature à réduire cet écart.

402. Diversification qualitative de l'ordre public. Au-delà de cette expansion quantitative, dont on ne peut donner que quelques exemples, c'est surtout la diversification qualitative de l'ordre public qui mérite ici d'être soulignée. La doctrine, spécialement en France, a essayé de rendre compte de cette évolution à travers un certain nombre de distinctions, sans doute un peu trop rigides, mais qui peuvent servir utilement comme point de départ à la présentation des divers aspects de l'ordre public. On retiendra ici la distinction entre l'ordre public politique et l'ordre public économique (§ 1), ainsi que la notion d'ordre public de protection, distinguée de l'ordre public ayant pour but la défense de l'intérêt général (§ 2).

§1. Ordre public politique et ordre public économique

403. Conception de l'ordre public dans le Code civil. Les rédacteurs du Code civil avaient de l'ordre public une conception très restrictive. La liberté contractuelle ne devait être limitée que par un petit nombre de règles ayant pour but d'assurer la défense des principes de base de l'organisation sociale. Sont donc interdites toutes conventions par lesquelles on chercherait à porter atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou aux biens d'autrui (le contrat avec le tueur à gages, l'association de malfaiteurs en vue de perpétrer une ou plusieurs infractions), ainsi que celles qui viseraient à faire tomber par la force le pouvoir politique en place (un complot contre l'État). Les bonnes mœurs visées à l'article 6 du Code civil sont conçues dans la même optique : cette notion ne vise pas, comme on pourrait le croire, à vérifier que les contrats sont conformes à la morale, elle permet seulement de vérifier que le contrat est conforme aux manières de vivre communément admises dans une société donnée. À l'époque du Code civil, la contrariété aux bonnes mœurs s'applique principalement à des comportements sexuels jugés déviants (la vie commune hors mariage notamment), et la notion permet de protéger la famille « légitime », considérée comme une structure de base de la société de l'époque. L'ensemble de ces règles constitue ce que, plus tard, on a appelé un ordre public politique – parce qu'elles visent principalement à maintenir l'ordre dans la « polis », la cité au sens antique.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

En revanche, à cette époque, il n'est pas question que l'État s'immisce dans l'organisation des relations économiques entre les individus : n'oublions pas que le Code civil a été conçu et édicté dans le prolongement de la Révolution française qui, en réaction contre l'organisation sociale de l'Ancien régime, avait notamment proclamé la liberté du commerce et de l'industrie. Dans cette optique, pour les rédacteurs du Code, non seulement un commerçant pouvait s'établir librement, mais il pouvait aussi passer librement tous les contrats nécessaires à son activité : pas question de fixer impérativement dans la loi le montant des salaires que ce commerçant devait verser à ses employés, ni de réglementer le contenu des contrats qu'il devait passer avec ses fournisseurs ni avec ses clients – dès lors que ces contrats ne menaçaient pas l'« ordre public » au sens restreint précédemment indiqué.

404. Transformations de l'ordre public politique. L'ordre public du Code civil, très proche de l'ordre public au sens commun du terme, existe bien sûr toujours. Il est toujours interdit de passer un contrat avec un tueur à gages, de monter une association de malfaiteurs ou de payer un fonctionnaire de l'État pour obtenir une faveur. Mais, d'une certaine manière, cet ordre public politique est plus restreint aujourd'hui qu'au XIXe siècle, avec la reconnaissance de libertés fondamentales aux individus, et notamment de la liberté d'association. Alors qu'au XIXe siècle, la création d'une association devait être autorisée préalablement par les pouvoirs publics – ce qui était en soi une atteinte importante à la liberté contractuelle – la loi du 11 mai 1936 et l'article 26 de la Constitution reconnaissent désormais la liberté de s'associer sans autorisation préalable – même si bien entendu cela ne s'oppose pas à la dissolution a priori de toute association dont le but serait l'atteinte à la sécurité publique (une association terroriste par exemple). Le recul de l'ordre public traditionnel est surtout sensible avec le r étrécissement continuel de la notion de bonnes mœurs – dont l'évolution déjà signalée de la jurisprudence relative aux libéralités entre concubins est l'exemple le plus significatif. Ce recul est, lui aussi, lié à la reconnaissance au profit des individus d'un certain nombre de droits et libertés fondamentaux dans le domaine de leur vie privée.

Par un remarquable retournement des valeurs, ces droits et libertés fondamentaux sont devenus un des aspects les plus prégnants de l'ordre public moderne. La Cour européenne des droits de l'homme, alors même qu'elle semble prête à traiter la liberté

LARCIER INTERSENTIA
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

contractuelle comme une liberté fondamentale[918], a par ailleurs clairement érigé les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme comme des limites nécessaires à cette liberté[919] : si cette Cour ne peut pas, directement, annuler des conventions privées, elle peut condamner un État dont les dispositions législatives et la jurisprudence aboutiraient à reconnaître la validité de contrats ou de clauses contractuelles allant à l'encontre d'un de ces droits fondamentaux[920]. Les juridictions nationales, de leur côté, intègrent la protection des droits de l'homme dans l'appréciation de la validité des contrats ou des clauses contractuelles : les stipulations d'un contrat de bail ou d'un contrat de travail, par exemple, ne peuvent pas porter atteinte sans raison suffisante à la liberté de la vie privée, à la liberté de religion ou à la liberté d'expression du locataire ou du salarié[921]. Naturellement, comme toujours en matière de droits de l'homme, ces libertés ne sont pas absolues : la liberté de la vie privée ne s'oppose évidemment pas à ce qu'un locataire se voie interdire d'installer un zoo dans son appartement, et la liberté de religion ne saurait permettre à l'employé d'un établissement d'enseignement de se livrer à du prosélytisme auprès des élèves. Conformément à la méthode suivie par la Cour de Strasbourg, le juge devra vérifier au cas par cas si l'ingérence résultant du contrat dans la liberté du contractant « correspond à un besoin social impérieux, si elle est proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis pour la justifier sont pertinents et suffisants »[922]. Quoi qu'il en soit, ce nécessaire respect par les contrats des droits et libertés fondamentales peut être rattaché à l'ordre public « politique », en ce que, au-delà de la protection

[918] Voy. *supra*, n° 110.

[919] Voy. N. Bareït, « La liberté contractuelle sous la toise de la Convention européenne des droits de l'homme », in *Droits fondamentaux, ordre public et libertés économiques*, *Institut Universitaire Varenne*, coll. Colloques et Essais, Paris, LGDJ, 2013, pp. 51 et s.

[920] Cour eur. D.H., 16 décembre 2008, *Khurshid Mustafa and Tarzibachi c/ Sweden* ; *RTD civ.*, 2009, p. 281, note J.-P. Marguenaud ; *R.D.C.*, 2010, p. 131, note C. Grimaldi (à propos d'une clause d'un contrat de bail d'habitation interdisant au locataire d'installer une antenne parabolique, et qui pourrait être considérée comme attentatoire à la liberté de recevoir des informations garantie par l'article 10 de la Convention).

[921] Voy. p. ex. en France : Cass. (3e civ.), 6 mars 1996, n° 93-11113 (clause privant un locataire de la possibilité d'héberger ses proches) ; Cass. (soc.), 12 janvier 1999, n° 96-40755 (clause de mobilité dans un contrat de travail privant sans raison le salarié de la liberté de choisir son domicile).

[922] Cour d'appel, 29 janvier 2009, 34, p. 401 (examen du bien-fondé d'une demande en résolution d'un contrat de travail fondée sur un abus de la liberté d'expression du salarié, au regard de l'article 10 de la Cour eur. D.H. Le raisonnement ici suivi l'est à propos de la mise en œuvre d'une sanction de l'inexécution du contrat, mais on peut le transposer à l'examen de la validité d'une clause contractuelle).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

des intérêts de tel ou tel individu, il traduit la suprématie, dans notre société, de certaines valeurs constituant le socle de la vie en commun. On peut y voir, d'une certaine manière, la version moderne de la notion de bonnes mœurs, largement vidée par ailleurs de son contenu traditionnel. Les notions générales de respect de la personne humaine, et de dignité humaine, qui constituent le rempart ultime contre certains excès de l'économie de marché, procèdent de la même logique. Dans le projet de réforme français de 2015, l'article 1102 relatif à la liberté contractuelle intégrait expressément parmi les limites à cette liberté, l'interdiction de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux « à moins que cette atteinte soit indispensable à la protection d'intérêts légitimes et proportionnée au but recherché ». Cette mention a disparu dans le texte définitif de l'ordonnance (C. civ. fr., art. 1103), mais il faut considérer que ces droits et libertés fondamentaux sont une partie intégrante de l'ordre public.

405. Développement de l'ordre public économique. À côté de cet ordre public politique profondément transformé, on a assisté, depuis la seconde moitié du XIXe siècle, à la montée progressive d'un « ordre public économique », caractérisé par l'intervention directe de l'État (et, aujourd'hui, de l'Union européenne) dans la régulation des relations économiques : réglementation des prix, des salaires et des conditions de travail, interdiction des ententes anticoncurrentielles, réglementation des contrats de consommation, etc.[923] Cet ordre public économique présente des caractéristiques assez différentes de celles de l'ordre public « classique ». Alors que celui-ci repose sur un nombre limité de règles générales, l'ordre public économique se présente généralement sous la forme d'une multitude de réglementations très minutieuses, et souvent différenciée par types de contrats – ce dont la réglementation d'origine européenne des contrats de consommation offre un exemple parfois caricatural. Cette réglementation est par nature extrêmement évolutive, suivant l'évolution des techniques, des pratiques, du contexte économique et des choix politiques des gouvernants – ce qui tranche avec une relative stabilité de l'ordre public traditionnel, traduisant des principes de base de la vie en société. On note encore que, alors que les règles traditionnelles sont essentiellement prohibitives – interdisant certains contrats ou certaines clauses – l'ordre public économique se

[923] G. FARJAT, *L'ordre public économique*, Paris, LGDJ, 1963.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

présente aussi, très souvent, sous la forme de prescriptions positives, indiquant comment le contrat doit être conclu, quelles mentions obligatoires il doit contenir, quels droits et quelles obligations il doit prévoir pour les parties, etc. Surtout, comme on l'a déjà signalé, cet ordre public économique se caractérise par une diversification des finalités des règles impératives, qui n'ont plus nécessairement pour but premier la défense de l'intérêt général, mais qui peuvent aussi poursuivre la protection de catégories particulières. Cette distinction, cependant, n'est pas propre à l'ordre public économique, et elle mérite ici une étude particulière.

§2. Ordre public de défense de l'intérêt général et ordre public de protection d'intérêts particuliers

406. Principe et applications. La distinction entre les règles d'ordre public qui ont pour objectif la défense de l'intérêt général et celles qui visent à la protection d'intérêts particuliers de certains contractants est aujourd'hui essentielle pour comprendre la notion d'ordre public et le rôle qu'elle joue en droit des contrats, même si elle doit être relativisée. Après en avoir exposé le principe général (**A**), on en présentera une application particulière, celle de la réglementation des clauses abusives (**B**).

A) *Principes généraux*

407. Ordre public de direction et ordre public de protection. Au sein de la notion d'ordre public économique, la doctrine française distingue depuis longtemps ce qu'on a nommé « l'ordre public économique de direction » et « l'ordre public économique de protection »[924]. Le premier vise à favoriser et à orienter le développement économique de la société : la réglementation des prix, par exemple, pour éviter l'inflation et la chute des exportations qui s'en suivraient, la régulation de la concurrence pour éviter que certaines entreprises ne se retrouvent en situation de monopole, entrent dans cette catégorie[925]. Cet ordre public de direction est certes très différent de l'ordre public politique traditionnel, en ce qu'il véhicule une conception de l'intérêt général fondamentalement différente de celle qui

[924] Sur l'historique de la notion : G. Couturier, « L'ordre public de protection ; heurs et malheurs d'une vieille notion neuve », in *Études en l'honneur de Jacques Flour*, Defrénois, 1979, p. 95.

[925] Voy. C. Jamin, « Théorie générale du contrat et droit des secteurs régulés », *D.*, 1995, chron., p. 2342.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

prévalait à l'époque du Code civil, où on pensait que la meilleure manière de favoriser le développement économique de la société était précisément de ne pas réguler les relations économiques et de les abandonner aux forces du marché. Néanmoins, cet ordre public de direction s'inscrit toujours, d'une certaine manière, dans la notion d'ordre public au sens de l'article 6 du Code civil, en ce qu'il a pour but, comme l'ordre public traditionnel, d'assurer la protection de l'intérêt général, des intérêts supérieurs de la société face aux égoïsmes individuels – cet intérêt général étant simplement autrement conçu que dans une époque de libéralisme absolu. Il n'en va pas de même de l'ordre public dit « de protection », qui regroupe des règles visant à rééquilibrer le jeu contractuel, en protégeant des catégories de contractants supposées être en situation de faiblesse, contre les abus de la liberté contractuelle des contractants en situation de force. L'expression « ordre public de protection » a été, à l'origine, essentiellement inventée pour désigner les règles de protection des salariés contre les employeurs dans le contrat de travail, qui constituent une partie essentielle du droit du travail – et on a longtemps identifié « ordre public de protection » et « ordre public social ». Mais on l'applique aujourd'hui, tout aussi bien, à la protection des locataires contre les bailleurs dans les différents types de bail, et, surtout, aux règles de protection des consommateurs, qui en constituent sans doute l'aspect le plus caractéristique. Cet « ordre public de protection » apparaît, de prime abord, fondamentalement différent de celui de l'article 6 du Code civil, en ce qu'il ne s'identifie pas, directement du moins, à l'intérêt général : on ne peut pas dire des règles de protection des salariés, des locataires, des consommateurs, etc. qu'elles « intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». Il ne s'agit pas, ici, de dresser un rempart de protection de l'intérêt général contre l'expression (supposée voulue par les deux contractants) des intérêts individuels dans le contrat, il s'agit de protéger les intérêts individuels d'un contractant faible contre la libre expression des intérêts individuels de l'autre. C'est pour cela que, comme on l'a dit précédemment, en droit belge, on refuse de parler de « règles d'ordre public » pour désigner cet ordre public de protection, qui constitue seulement des « règles impératives ».

408. Généralisation. Elaborée à propos de l'ordre public économique, la distinction entre l'ordre public de direction et l'ordre public de protection est en réalité révélatrice d'une distinction plus générale entre deux catégories de règles « d'ordre public »

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

(ou, si on préfère, impératives). Le Code civil connaissait déjà, en effet, dans le cadre des différents contrats, un certain nombre de règles impératives qui n'avaient pas pour but d'assurer la sauvegarde de l'intérêt général, mais bien de protéger les intérêts d'un contractant supposé être en situation de faiblesse. Tel est bien le but, par exemple, de la réglementation impérative du contrat de gage, par lequel un débiteur remet une chose à son créancier en garantie d'une dette. Certains aspects de cette réglementation, très traditionnelle, sont inspirés par l'idée que le débiteur, obligé de fournir une garantie pour obtenir son crédit, n'est généralement pas en situation de discuter librement avec le créancier, qui risque de lui imposer des conditions déséquilibrées : c'est ce qui justifie, notamment, l'interdiction dans un tel contrat du « pacte commissoire » (clause prévoyant qu'à défaut de remboursement le créancier deviendra automatiquement propriétaire de la chose gagée), que la Cour d'appel du Luxembourg a, très justement, rattachée à la notion moderne d'ordre public de protection[926]. La très ancienne prohibition de l'usure dans les contrats de prêt peut se rattacher à la même idée de protection des emprunteurs amenés par le besoin à consentir à des conditions anormales imposées par le prêteur[927]. Le pouvoir de révision des clauses pénales excessives[928], qui ne peut pas être écarté par une clause contraire, s'inscrit dans la même logique. Allant au-delà, on peut se demander si on ne pourrait pas tout aussi bien rattacher à l'idée d'ordre public de protection les règles générales du droit des contrats qui interdisent ou limitent la conclusion de contrats par les mineurs ou par les majeurs protégés, qui prévoient, à travers la notion de cause, la nécessité d'une contrepartie dans les contrats synallagmatiques, ou qui permettent au juge, nonobstant toute clause contraire, d'accorder des délais de grâce à un débiteur en difficulté, ou qui imposent une obligation d'information précontractuelle. Ces dernières règles, cependant, apparaissent profondément différentes de l'ordre public de protection moderne, en ce qu'elles reposent sur une vision abstraite des contractants, tous supposés libres et égaux, alors que la législation moderne met à part certaines catégories de contractants, supposés être, eux, en situation de faiblesse dans les relations contractuelles. La spécificité de l'ordre public de protection moderne est surtout

926 Cour d'appel, 15 décembre 1992, *Pas.*, 29, p. 37.

927 Idée autrefois largement inspirée par des préjugés antisémites, les juifs étant, dans l'Ancien droit, les seuls autorisés à pratiquer le prêt à intérêt.

928 Voy. *infra*, n° 881.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

évidente lorsque cette catégorisation est justifiée, non par les caractéristiques physiques ou mentales de la personne, ni même par la nature du contrat passé, mais – comme c'est le cas de la protection des consommateurs – par l'appartenance du contractant à telle ou telle catégorie socio-professionnelle, considération totalement absente du Code civil.

409. Conséquences – À la différence de la distinction entre ordre public politique et ordre public économique, qui reste purement descriptive, la distinction entre ordre public de direction et ordre public de protection – ou, plus largement, entre ordre public de défense de l'intérêt général et règles impératives protectrices des intérêts de certains contractants – a d'importantes conséquences en droit positif. Une première conséquence de la distinction tient à l'étendue des limites que les deux types d'ordre public apportent à la liberté contractuelle. L'ordre public classique, et l'ordre public économique de direction, ne sont pas susceptibles de plus ou de moins : il est interdit de déroger, de quelque manière que ce soit, aux règles posées. Il n'en va pas de même des règles d'ordre public de protection qui, en général, ne posent qu'un socle minimum de droits devant être garantis aux personnes protégées, mais n'interdisent pas d'y déroger par des règles plus favorables. Par exemple, le droit du travail n'impose qu'un salaire minimum, et une durée maximum de travail, mais il n'interdit évidemment pas à l'employeur de fixer un salaire supérieur, ni une durée de travail moindre pour tel ou tel salarié. En ce sens on parle parfois d'un ordre public relatif, par opposition à l'ordre public traditionnel, qualifié d'absolu.

Mais c'est surtout au niveau des sanctions qui s'attachent à la violation des règles que la distinction est importante. Traditionnellement, la nullité pour violation de l'ordre public et des bonnes mœurs est considérée comme le type même de la nullité absolue, qui sanctionne la violation d'une règle d'intérêt général. C'est vrai sans aucun doute pour l'ordre public traditionnel, politique, et pour les bonnes mœurs qui y sont rattachées. Mais la solution s'impose également pour l'ordre public économique de direction, qui est aussi, nous l'avons vu, dirigé vers la sauvegarde d'une certaine conception de l'intérêt général. Il n'en va pas de même, en revanche, pour l'ordre public de protection : dès lors que les intérêts protégés sont les intérêts particuliers des contractants appartenant à une certaine catégorie, la nullité doit logiquement être une nullité relative, à la disposition du contractant protégé. Telle est effectivement, nous le

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

verrons, la solution du droit positif, même si, pour ce type de règles, le régime de la nullité est quelque peu « gauchi » par rapport au droit commun des nullités relatives[929]. Il y a là, du reste, un argument pour relativiser la distinction.

410. **Relativisation.** Même si elle est un élément essentiel pour la compréhension des conditions de validité du contrat, la distinction entre ordre public de protection et ordre public de direction (plus largement de sauvegarde de l'intérêt général) doit être relativisée, à la fois dans son principe et dans sa mise en œuvre. Dans son principe, d'abord, l'opposition entre l'intérêt général et la protection de certaines catégories de contractants ne peut pas être poussée jusqu'au bout. Si le droit estime nécessaire de protéger les salariés ou les consommateurs, c'est au nom d'une certaine conception des rapports sociaux qui dépasse les simples intérêts individuels de tel ou tel travailleur ou de tel ou tel consommateur. Une société sur le modèle de la société libérale du XIX[e] siècle nous paraît aujourd'hui inadmissible et les règles qui visent à protéger les contractants faibles et à promouvoir une certaine justice contractuelle font, à ce titre, partie de ce que nous considérons être de l'intérêt général – même s'il est vrai que cet intérêt général ne sera violé que s'il est porté atteinte aux intérêts particuliers des contractants appartenant aux catégories protégées. Surtout, il faut bien voir que les règles qui visent à protéger les contractants faibles sont souvent inspirées en même temps, par d'autres considérations qui relèvent, elles, directement de l'intérêt général : la protection de la paix sociale pour les règles protectrices des consommateurs, le développement du marché des produits et des services pour les règles protectrices des consommateurs, etc.

Cela explique que la distinction ordre public de protection/ordre public de direction soit parfois difficile à mettre en œuvre, car pour certaines règles, il est difficile de savoir quelle est la finalité dominante. Un exemple typique est fourni par la réglementation française des clauses d'indexation (clauses faisant varier une prestation monétaire dans un contrat en fonction de l'évolution de certains indices extérieurs – le coût de la construction, le niveau général des prix, etc.). En droit français, de telles clauses ne sont permises que si l'indice choisi n'est pas un indice général, et que s'il est en rapport avec l'objet du contrat ou l'activité de l'une des parties. Cette réglementation, dont il n'existe pour l'instant pas d'équivalent général au Luxembourg[930], peut être conçue comme un moyen de protéger le contractant pour lequel le jeu de l'indice entraînerait une augmentation trop importante du prix (ordre public de protection), mais aussi comme un moyen de contrôler l'évolution des prix, en évitant les dérapages inflationnistes. Après quelques hésitations, c'est cette dernière position qui a été retenue par la jurisprudence française, qui en a déduit que la nullité d'une clause contraire à la réglementation était une nullité absolue[931].

L'application particulière dont nous allons maintenant faire l'étude, la réglementation des clauses abusives, est très révélatrice de cette relativité de la distinction entre l'ordre public de protection et l'ordre public à finalité d'intérêt général.

929 Voy. *infra*, n° 456.

930 Voy. P. Ancel, B. Christmann, X. Dieux et F. Kutscher-Puis, « Modalités de la réglementation des clauses d'indexation de prix au Luxembourg, en France, Belgique et Allemagne », *Annales du droit luxembourgeois*, n° 21 (2011), Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 109-155.

931 Cass. fr. (comm.), 3 novembre 1988, *D.*, 1989, p. 93, note Ph. Malauriee et somm. 234, obs. J.-L. Aubert.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

B) *Application particulière : la réglementation des clauses abusives*

411. Idée générale. La réglementation des clauses abusives dans les contrats de consommation constitue une application caractéristique de la notion d'ordre public de protection. L'idée qui préside à cette réglementation est que, dans les contrats passés entre professionnels et consommateurs, le consommateur n'a pas, dans l'immense majorité des cas, la liberté de discuter les clauses qui figurent dans des conditions générales prérédigées par le professionnel (d'autant plus que, le plus souvent, le consommateur ne prendra une connaissance effective de ces clauses qu'en cas de difficulté, postérieurement au contrat). Il y a donc le risque que le professionnel en situation de force impose à son cocontractant des clauses déséquilibrées à son profit. Dans le but de protéger les consommateurs, plusieurs états ont, depuis longtemps, intégré dans leur droit des dispositions interdisant ou réglementant certaines clauses dans les contrats de consommation (et parfois même au-delà). En France, la réglementation des clauses abusives date ainsi d'une loi de 1978, en Belgique elle remonte à une loi de 1991. Au Luxembourg, la notion de clause abusive a été introduite par la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur, dont l'article 1er disposait que « Dans les contrats conclus entre un fournisseur professionnel de biens de consommation, durables ou non, ou de services et un consommateur final privé, toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur est abusive et comme telle réputée nulle et non écrite ». Par la suite, le législateur européen a pris le relais, par la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après « directive de 1993 »)[932]. Cette directive a été transposée au Luxembourg par la loi du 26 mars 1997, ultérieurement modifiée en 2000 avant d'être intégrée en 2011 dans le Code de la consommation. La réglementation luxembourgeoise des clauses abusives figure actuellement aux articles L. 211-2 et suivants de ce Code.

La réglementation des clauses dans les contrats de consommation présente deux aspects qu'il faut bien distinguer. D'une part, on trouve dans les textes européens et nationaux des règles permettant

[932] *J.O.C.E.*, L. 95, 21 avril 1993.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de contrôler l'intégration des clauses dans les contrats, subordonnée à la possibilité pour le consommateur d'en avoir connaissance lors de la conclusion du contrat. Au Luxembourg, ce contrôle est prévu, en droit commun des contrats, par l'article 1135-1 du Code civil, auquel l'article L. 211-1 du Code de la consommation se contente de renvoyer. On ne reviendra pas ici sur cette réglementation, étudiée au titre des règles relatives à la formation du contrat[933]. D'autre part, la réglementation des clauses abusives permet très différemment de contrôler le contenu des clauses, en écartant du contrat les clauses qui créent un déséquilibre excessif entre les droits et obligations des parties. C'est seulement cet aspect qui nous intéresse ici au titre de l'étude de l'ordre public.

412. Domaine : différents modèles. Si tous les pays faisant partie de l'Union européenne prévoient aujourd'hui, par la force de la directive, des mécanismes de contrôle des clauses contractuelles imposées par un contractant à un autre dans des situations de déséquilibre ou d'inégalité entre les parties, ces mécanismes n'ont pas partout le même domaine d'application. Aucun pays ne semble admettre, par voie législative du moins, la possibilité d'un contrôle s'étendant à tout type de contrat, quelles qu'en soient la nature, les parties, la forme et les conditions de négociation. Le champ du contrôle est toujours limité, mais il peut l'être selon deux modèles à première vue bien différents. Dans le premier modèle – qui était jusqu'en 2016 celui du droit français – la protection contre les clauses abusives est limitée *rationae personae* à certains contrats marqués par une inégalité entre les parties, qui permet à l'un des contractants d'imposer sa volonté à l'autre. Au minimum, dans le cadre imposé par la directive de 1993, la protection du contractant faible sera instituée dans les contrats entre professionnels et consommateurs, même si rien n'interdit pour l'instant de l'élargir aussi à certains professionnels qu'on veut spécialement protéger – ce qu'a fait du reste le législateur français dans l'article L 442-1 du Code de commerce et, beaucoup plus largement, le législateur belge dans les articles VI. 91/3 et suivants du Code de droit économique belge. Dans un second modèle, la protection est *a priori* ouverte au profit de n'importe quel contractant, professionnel ou non (sous réserve de différences dans les modalités de protection), mais ce sont alors des considérations fondées sur la forme du contrat, la manière dont il est conclu et dont

933 Voy. *supra*, n°s 169 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

les clauses y sont insérées, qui vont déterminer le champ d'application du dispositif protecteur : en gros, la protection ne sera ouverte que dans les contrats d'adhésion, ceux qui n'ont fait l'objet d'aucune négociation individuelle entre les parties. L'exemple type est celui du droit allemand, où les § 305 et suivants du BGB, issus de l'intégration dans le code d'une loi de 1976, s'appliquent aux conditions générales des contrats (*Allgemeine Geschäftsbedingungen*), définies comme « toutes les conditions contractuelles préformulées pour un grand nombre de contrats que l'une des parties soumet à l'autre lors de la conclusion d'un contrat ». Le droit européen des clauses abusives cumule les deux types de critères, en réglementant les clauses abusives seulement dans les contrats de consommation, et seulement si ces contrats ne résultent pas d'une négociation individuelle, mais il n'interdit pas aux états membres d'élargir le domaine de la protection. Les réformes française et belge ont été l'occasion de changer de modèle, en introduisant dans le Code civil, un texte général de prohibition des clauses abusives dans les contrats non négociés. En France, l'article 1171 dispose que « [d]ans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». En Belgique, selon l'article 5.52 du nouveau Code civil, « [t]oute clause non négociable et qui crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties est abusive et réputée non écrite ». Dans les deux droits, cependant, cette disposition générale n'a vocation à s'appliquer que dans les contrats non régis par les dispositions spéciales à certaines catégories de contractants, restées en vigueur[934], même s'il est question en Belgique d'abroger les articles du Code de droit économique relatifs aux clauses abusives dans les contrats entre entreprises.

413. Domaine en droit luxembourgeois. Comme on l'a vu précédemment, le droit luxembourgeois a suivi le modèle allemand en ce qui concerne le contrôle de l'intégration des clauses contractuelles, ouvert par l'article 1135-1 du Code civil à tous les contrats qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle. En revanche, pour ce qui concerne la réglementation des clauses abusives – donc le contrôle du contenu des clauses – le Luxembourg a complètement suivi le modèle français antérieur à la réforme, réservant pour

[934] En France : Cass. fr. (comm.), 26 janvier 2022, n° 20-16.782 B.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'instant le contrôle des clauses abusives aux seuls contrats relevant du Code de la consommation. Cette réglementation, prévue par l'article L. 211-2 du Code de la consommation, ne s'applique qu'aux « contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ». La notion de consommateur doit s'entendre, conformément à l'article L. 010-1 du Code de la consommation comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». En contrepartie, cependant, et là encore conformément au modèle français, il n'y a dans ce texte aucune restriction quant à la forme du contrat dans lequel les clauses sont insérées : en théorie, la protection contre les clauses abusives peut s'appliquer même si le contrat entre le professionnel et le consommateur a fait l'objet d'une négociation individuelle – ce qui, il est vrai, est assez rare. C'est la qualité des contractants, et seulement elle, qui détermine la protection. De ce point de vue, la législation luxembourgeoise va plus loin que la directive européenne, qui n'impose la réglementation que dans les contrats de consommation n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle (art. 3). Elle va également plus loin en ce que, contrairement aux droits français et belge, l'article L. 211-2 du Code de la consommation n'exclut pas de son domaine d'application les clauses relatives à la définition de l'objet du contrat ni à l'équivalence entre les prestations.

En dehors des contrats de consommation, la notion de clause abusive ne se retrouve que dans un cas particulier, celui de la loi du 8 janvier 2013 sur les délais de paiement, qui s'applique également (et même principalement) dans les contrats entre entreprises ou entre entreprises et personnes publiques. Aux termes de l'article 6 de cette loi, le juge peut, à la requête d'un créancier « ordonner la cessation de l'utilisation de toute clause contractuelle ou pratique portant sur la date ou le délai de paiement, le taux d'intérêt pour retard de paiement ou l'indemnisation pour les frais de recouvrement, lorsqu'elle constitue un abus manifeste à l'égard du créancier ». Mais il n'existe pour l'instant aucun texte général qui permettrait de sanctionner une clause abusive dans un contrat entre professionnels[935], alors même que ceux-ci peuvent être, également, dans une situation de très grande inégalité économique. L'introduction, dans le Code civil du Luxembourg, d'un texte général prohibant les clauses abusives sur le modèle des nouveaux droits français et belge, si elle paraît souhaitable, aurait donc une porte beaucoup plus grande que dans ces deux droits, et il conviendrait d'en définir soigneusement le domaine d'application.

414. Définition du caractère abusif. Aux termes de l'article L. 211-2 du Code de la consommation, est abusive « toute clause ou toute combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat

[935] Cour d'appel, 19 juin 2019, n° 44562.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur ». Le texte recopie presque à la lettre l'article 3 (1) de la directive de 1993, laquelle rattache en outre explicitement le caractère abusif à la violation de l'exigence de bonne foi en matière contractuelle. Le texte donne ensuite une longue liste de clauses qui sont « notamment à considérer comme abusives ». Il faut comprendre que, pour ces clauses (dont il est inutile de recopier ici la liste), le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation : s'il rencontre dans un contrat qui lui est soumis une clause de ce type, il doit nécessairement en prononcer la nullité. Mais l'adverbe « notamment » indique en même temps que cette liste n'est pas limitative : le juge peut découvrir dans un contrat d'autres clauses qui entraînent « un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur », et en prononcer la nullité[936]. De ce point de vue, la définition extrêmement large que donne l'article de la clause abusive laisse au juge un pouvoir d'appréciation considérable, et c'est là une manifestation caractéristique de l'extension du pouvoir des juges en ce qui concerne la détermination du contenu de l'ordre public[937]. La Cour d'appel observe à cet égard que « l'appréciation du caractère abusif ou non d'une clause peut se faire, entre autres, au regard des circonstances concrètes entourant la conclusion d'un contrat, en replaçant la clause incriminée dans son contexte contractuel et en la rapprochant, le cas échéant, d'autres clauses. Ainsi, une clause qui, en soi, n'est pas nécessairement abusive, peut encourir cette qualification lorsqu'elle est combinée à d'autres dispositions contractuelles »[938].

Un exemple caractéristique de l'application judiciaire de la notion de clause abusive est offert par un arrêt de la Cour d'appel du 12 octobre 2011[939], qui déclare abusives toute une série de clauses dans un contrat d'abonnement téléphonique : clause qui dégage l'opérateur de tout engagement en ce qui concerne la « qualité de service donnée » et l'oblige uniquement à prendre les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la meilleure qualité du service, clause prévoyant une résiliation sans préavis par le fournisseur si un abonné ne se connecte pas au service pendant 6 mois consécutifs, clauses de « *fair use* », qui permettent au fournisseur d'intervenir et le cas échéant de procéder à des déconnexions et à des restrictions d'accès pour des manquements par le client à des obligations non précisément définies au contrat, clause qui confère au seul professionnel la possibilité de vérifier et de juger si le consommateur fait un usage normal, non excessif des services fournis, sans l'informer au préalable du comportement reproché. En revanche, n'a pas été jugée

936 Cour d'appel, 5 mai 2010, *Pas.*, 35, p. 187.

937 Voy. *supra*, n° 398.

938 Cour d'appel, 5 mai 2010, préc.

939 Cour d'appel, 12 octobre 2011, *Pas.*, 36, p. 51.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

excessive la clause (très habituelle) d'un contrat d'abonnement prévoyant une durée d'engagement minimale dès lors que le contrat laisse au consommateur la possibilité d'une résiliation pour motifs légitimes pendant cette période.

415. Sanctions du caractère abusif d'une clause. Le régime des sanctions est très révélateur du jeu de l'ordre public de protection. L'article L. 221-2 du Code de la consommation dispose qu'une clause abusive est « comme telle réputée nulle et non écrite ». La nullité est la sanction normale de la violation des conditions de validité du contrat (ou de ses clauses). La formule « réputée non écrite », qu'on trouvait déjà dans l'article 900 du Code civil, indique, au minimum, que cette nullité n'affecte que la clause abusive, et qu'elle laisse subsister le contrat pour le reste. Le texte est conforme à l'article 6 (1) de la directive de 1993 selon lequel « les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives ». On est en présence ici de ce qu'on appelle une nullité partielle. Cette formule est imposée par la finalité de la réglementation : le consommateur qui se trouve « piégé » par une clause abusive (par exemple, une clause excluant la responsabilité du professionnel en cas de manquement à ses obligations) veut seulement, en général, que cette clause ne lui soit pas appliquée, mais il entend le plus souvent garder le bénéfice du contrat dans lequel cette clause se trouve. La réglementation manquerait complètement son but si la nullité de la clause entraînait celle du contrat tout entier, car le consommateur serait le plus souvent dissuadé de soulever cette nullité. Cependant, les formules utilisées, « ne lient pas les consommateurs » ou « réputée non écrite », peuvent aussi être interprétées comme ayant une autre signification : elles pourraient indiquer qu'on est en présence de quelque chose de plus qu'une nullité, que la clause abusive devrait être considérée comme absence du contrat, comme inexistante – ce qui permettrait au consommateur de s'en affranchir sans passer par le cadre procédural de l'annulation. Telle est la position de la jurisprudence française, mais celle-ci ne semble pas suivie au Luxembourg[940].

Quant au point de savoir qui peut invoquer la nullité (ou l'inexistence) de la clause, il est unanimement admis, bien que le texte ne le précise pas, que seule la partie protégée (le consommateur) peut

[940] Sur le problème général des clauses réputées non écrites, voy. *infra*, n° 475.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

s'en prévaloir, et que le professionnel, lui, ne le peut pas, même dans les cas (rares) où il y aurait intérêt. Si on raisonne en termes de nullité, on dira que la nullité est relative, dans la mesure où, bien qu'il s'agisse d'une règle d'ordre public, le but est de protéger une partie au contrat contre l'autre. Ce caractère relatif de la nullité est cependant très atténué. D'une part, le Code de la consommation reconnaît à toute personne (et en particulier aux associations de consommateurs) de demander, en dehors de tout litige, au président de la chambre commerciale du Tribunal d'arrondissement de constater le caractère abusif d'une clause ou d'une combinaison de clauses et de les annuler, mais aussi d'ordonner la suppression de ce type de clause dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs. D'autre part, même dans le cadre d'un litige opposant un consommateur au professionnel à propos d'un contrat particulier, il est profondément dérogé aux solutions habituellement retenues quant au pouvoir du juge de relever d'office la nullité. En principe, une nullité relative, étant de pur intérêt privé, ne peut pas être soulevée d'office par le juge ; elle ne peut être prononcée que si la partie protégée la soulève. Or, très souvent, le consommateur, ignorant de ses droits, ne pensera pas à soulever la nullité des clauses que son cocontractant professionnel lui opposera lors d'un procès, surtout si ce procès se déroule sans l'assistance d'un avocat. Consciente de ce danger, et soucieuse d'assurer l'effectivité de la protection des consommateurs contre les clauses abusives, la Cour de justice de l'Union européenne a admis, dans plusieurs arrêts que le juge national découvrant dans un contrat une clause abusive pouvait soulever d'office la nullité des clauses, pour le cas où le consommateur ne le ferait pas[941]. Dans le dernier état de sa jurisprudence, la Cour a même considéré que le juge, non seulement pouvait, mais devait soulever d'office ce caractère abusif[942]. Cette solution a été intégrée à l'article L. 211-2 du Code de la consommation luxembourgeois par une loi du 27 août 2024. Elle peut s'expliquer techniquement si on considère que la clause n'est pas seulement nulle, mais inexistante. Mais il est remarquable que, pour justifier cette position très dérogatoire aux principes qui

941 C.J.C.E., 27 juin 2000, *Oceano Grupo Editorial*, C-240/98 ; C.J.C.E. (1re ch.), 6 octobre 2009, *Asturcom Telecomunicaciones SL c/ Cristina Rodríguez Nogueira*, C-40/08 ; C.J.U.E. (8e ch.), 16 novembre 2010, *Pohotovosť s. r. o. c/ Iveta Korčkovská*, C-76/10. Sur cette jurisprudence, voy. A. BEKA, *The ex officio doctrine in european consumer law, a procedural tool reinvigorating individual consumer litigation*, thèse Université de Luxembourg, 2015, dir. E. POILLOT.

942 C.J.U.E. (1re ch.), 26 avril 2012, *Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság c/ Invitel Távközlési Zrt.*, C-472/10.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

régissent habituellement la distinction entre nullités relatives et nullités absolues dans les pays du Code civil[943], la Cour de justice s'appuie sur « la nature et l'importance de l'intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs », amenant à considérer l'article 6 de celle-ci « comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l'ordre juridique interne, le rang de normes d'ordre public »[944]. Ici apparaît en pleine lumière l'ambiguïté des règles composant l'ordre public de protection : même si elles poursuivent une finalité de protection des intérêts particuliers de certains contractants, ce ne sont pas moins des règles qui s'appuient sur des considérations d'« intérêt public » et qui font, au plein sens du terme, partie de l'ordre public.

943 Voy. *infra*, n°s 443 et s.

944 C.J.C.E. (1re ch.), 6 octobre 2009, préc.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La conformité du contrat à l'ordre public (et aux bonnes moeurs), Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourge...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Chapitre VI
Les conditions de forme

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les conditions de forme, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 505-521
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les conditions de forme, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 505-521
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

416. Principe du consensualisme. Il faut ici rappeler que, en principe, en droit luxembourgeois comme dans les deux autres pays du Code civil, la validité d'un contrat n'est assujettie à aucune forme particulière. Il faut seulement, mais il suffit que les volontés des parties s'extériorisent d'une manière ou d'une autre, soit par un écrit, soit par un échange de paroles, soit même par des comportements significatifs. Dans le Code, ce principe n'est pas explicité, il n'apparaît qu'à travers une lecture *a contrario* de l'article 1108, et par l'absence de disposition générale relative à la forme du contrat. Le nouvel article 1172 du Code civil français affirme explicitement que « [l]es contrats sont par principe consensuels », tandis que l'article 5.28 du nouveau Code civil belge pose que « [l]e contrat se forme par le seul accord de volontés des parties ».

Aboutissement, à l'époque du Code civil, d'une longue évolution historique, ce principe apparaît comme une des manifestations de la liberté contractuelle, et on y voyait naguère un signe de la prétendue « autonomie de la volonté ». Sur le plan pratique, l'absence de formes présente différents avantages : elle permet la conclusion très rapide de multiples contrats, diminue le coût des transactions commerciales, et s'accorde bien avec une vision morale de la force obligatoire du contrat. Celui qui a « donné sa parole », de quelque manière que ce soit, est obligé de la tenir, sans pouvoir s'abriter derrière le non-respect de formes plus ou moins artificielles.

En même temps, le consensualisme est porteur de toutes sortes d'inconvénients. Passé sans formes, rapidement, le contrat risque d'être accepté à la légère, sans que les contractants aient conscience de la portée de leurs engagements, sans même, parfois, qu'elles aient vraiment conscience de s'être engagées. Passé sans formes, le contrat ne laisse pas de trace : si l'une des parties conteste ensuite l'avoir passé, ou si un désaccord surgit entre les parties quant au contenu de la convention, il sera difficile de déterminer la vérité en l'absence d'un écrit relatant les termes de l'accord. Passé sans formes, enfin, le contrat ne sera pas visible aux yeux des tiers, à l'égard de qui, pourtant, il peut produire certains effets : comment savoir, par exemple, que celui qui me propose de me vendre un de ses biens en est bien propriétaire, s'il est incapable de me communiquer un acte écrit attestant de ce qu'il l'a préalablement acheté ?

D'une manière générale, on peut dire que si le consensualisme est une expression de la liberté, il est en même temps un facteur d'insécurité des transactions.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les conditions de forme, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 505-521
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Ces diverses considérations expliquent que, depuis l'époque du Code civil, le principe du consensualisme, sans être remis fondamentalement en cause, a été « grignoté » progressivement par l'instauration de nombreuses règles formelles. Toutes ces règles, cependant, n'ont pas la même portée : certaines, constitutives de ce qu'on appelle parfois un formalisme indirect, ne conditionnent pas la validité même du contrat, mais seulement son efficacité entre les parties ou à l'égard des tiers (**Section 1**) ; ce n'est que si le non-respect des formes affecte la validité du contrat qu'on peut parler d'une véritable exception au consensualisme (**Section 2**).

SECTION 1. LE FORMALISME INDIRECT

417. Intérêt. En pratique, dès que le contrat présente une certaine importance, il est en fait, et parfois en droit, nécessaire de le constater par écrit pour en assurer la preuve (**§ 1**). Pour certains contrats, en outre, la loi requiert certaines formalités pour en assurer l'opposabilité aux tiers (**§ 2**). Ces exigences de forme, très importantes en pratique, ne remettent pas en cause le principe du consensualisme, dans la mesure où, comme l'affirment en termes quasi-similaires l'article 1173 du Code civil français et l'article 5.29 du nouveau Code civil belge, les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.

§1. Le formalisme probatoire (*ad probationem*)

418. Principe. Lorsque le contrat est passé oralement, ou tacitement, il est en principe valable, et le fait qu'aucun écrit n'ait été rédigé pour en garder trace ne posera aucun problème si, par la suite, la partie à qui ce contrat est opposé n'en conteste ni l'existence ni le contenu. Supposons que je vous prête 10 000 €, que vous devez me rembourser le 15 décembre 2025, et que, n'étant pas remboursé à cette date, je vous assigne en paiement. Si vous ne contestez pas devant le juge avoir reçu cette somme à titre de prêt, vous ne pourrez pas vous défendre en disant : « D'accord, il m'a bien prêté 10 000 €, et je devais lui rendre le 15 décembre, mais cela ne vaut rien, puisque nous n'avons pas rédigé d'écrit ». L'absence d'écrit étant indifférente à la validité du contrat, le prêt ainsi contracté n'en a pas moins force obligatoire, et le juge vous condamnera à me rembourser. C'est cela, le principe du consensualisme.

LARCIER INTERSENTIA
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les conditions de forme, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 505-521
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Les choses sont très différentes si vous contestez que je vous ai prêté 10 000 €. Le juge devra rechercher si mes allégations correspondent ou non à la vérité : c'est ici qu'entrent en jeu les règles de preuve. Rappelons d'abord que, en principe, c'est au demandeur de prouver la véracité de ce qu'il avance : cette règle fondamentale de charge de la preuve, posée par l'article 1315 du Code civil, qui dépasse largement le droit des contrats, ne sera pas étudiée ici plus avant. Dans l'exemple donné, c'est donc à moi de prouver que je vous ai prêté 10 000 €, ainsi que la date prévue pour le remboursement. Mais comment pourrai-je le faire si je n'ai pas de trace écrite ? Pourrais-je faire venir devant le juge des témoins qui étaient présents lorsque je vous ai fait le prêt ? La réponse, selon le Code civil, est en principe négative : le Code en effet exige en principe une preuve écrite des contrats, et interdit la preuve par témoins (A). Mais ce principe connaît de nombreuses exceptions (B).

Les dimensions réduites de cet ouvrage ne permettent de faire ici qu'une étude sommaire des règles de preuve, généralement étudiées dans les cours et ouvrages d'introduction au droit ou de notions générales du droit civil. Les développements qui suivent sont conçus comme de simples rappels de règles supposées connues.

A) *Principe de l'exigence d'une preuve écrite*

419. **Article 1341 du Code civil.** Selon l'article 1341 du Code civil, texte de base en la matière « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Ce texte manifeste la primauté reconnue par les rédacteurs du Code civil à la preuve écrite, censée plus sûre que tous les autres moyens de preuve, et notamment que les témoignages, dont on se méfie particulièrement. Cependant le domaine et la portée du texte doivent être précisés.

1) *Domaine de l'article 1341 du Code civil*

420. **Actes juridiques.** L'article 1341 du Code civil ne s'applique qu'à la preuve des actes juridiques. Le texte, dont la rédaction actuelle date d'une loi du 22 décembre 1986, est un des rares articles du Code civil à faire référence à cette notion, qui était à l'origine purement doctrinale[945]. Le texte initial portait qu'il doit être passé acte de « toutes choses », mais, malgré le caractère très général de cette formule, il a toujours été admis que l'exigence de la preuve écrite ne valait pas pour les faits juridiques – c'est-à-dire, rappelons-le, pour les événements qui produisent des effets juridiques indépendamment de toute manifestation de volonté des personnes impliquées. La

[945] Voy. *supra*, n[os] 59 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les conditions de forme, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 505-521
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

règle de preuve posée par l'article 1341 du Code civil est du reste le principal intérêt, en droit positif, de la distinction entre actes et faits juridiques. La distinction s'explique aisément. Au moment où un fait juridique se produit, les personnes impliquées, qui ne recherchent pas d'effets juridiques, n'ont aucune raison, et en général, aucune possibilité de se procurer un écrit attestant de cet événement : si j'ai été victime d'un accident, et que je vous réclame réparation, il est évident qu'on ne peut pas me refuser des dommages et intérêts au motif que je n'ai pas de preuve écrite de ce qui s'est passé. En revanche, lorsque, volontairement, on s'engage dans un contrat, on est censé savoir que, un jour, il faudra peut-être apporter la preuve de cet engagement, et on doit prendre ses précautions en se préconstituant une preuve écrite. L'expression « actes juridiques » ne vise pas seulement les contrats, mais aussi les actes juridiques unilatéraux. Dès 1877, la Cour d'appel affirmait que « La prohibition de l'article 1341 du Code civil ne comprend pas seulement les conventions mais encore tous les faits juridiques[946] de quelque nature qu'ils puissent être, qui sont susceptibles d'être constatés par écrit, et notamment ceux qui ont pour objet direct et nécessaire de créer, de modifier, de confirmer ou de résoudre, d'étendre ou de restreindre, ou enfin d'éteindre des droits et des obligations »[947]. Par exemple, un contractant qui prétend mettre fin à un contrat à exécution successive en exerçant son droit de résiliation[948] doit évidemment le faire par écrit, pour s'en ménager la preuve, même dans les cas où la loi n'exige pas un tel écrit à peine de nullité de l'acte.

421. Actes d'un certain montant. Selon l'article 1341 du Code civil, la preuve par écrit n'est exigée que lorsque l'acte à prouver porte « sur une somme ou valeur excédant celle qui est fixée par règlement grand-ducal ». Cette somme, fixée par un règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 à 100 000 LUF a été convertie en euros par un règlement du 1er août 2001. Elle est actuellement de 2 500 €[949]. Si, donc je ne vous ai prêté que 2 400 €, je peux prouver autrement que par écrit, mais pas si je vous ai prêté 2 600 €. Ce seuil monétaire suscite de multiples difficultés qu'il n'est pas question d'étudier en détail ici. On signalera cependant que, ce qui compte, c'est moins le montant (supposé) de l'acte que celui de la demande en justice – pourvu que le montant ne soit pas présenté comme représentant une partie seulement de la créance qu'on tiendrait de l'acte (C. civ., art. 1344). Il faut également indiquer que, si la demande n'a pas d'objet monétaire ou a un montant indéterminé, l'exigence de la preuve écrite s'applique. Surtout, il faut relever que le seuil des 2 500 € n'est pas applicable dès lors que le contrat a été constaté par un écrit, et que l'une des parties prétend apporter la preuve de l'inexactitude des mentions portées dans cet écrit : dans ce cas, le texte précise qu'il « n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, *encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre* ». Si je produis en justice un acte portant que je vous ai prêté 2 400 €, et que vous soutenez qu'en réalité, vous me devez seulement 2 000 €, vous devrez, pour le prouver, apporter un autre écrit rectifiant le montant initial.

946 Cet arrêt ancien utilise l'expression « faits juridiques » pour désigner ce que, dans la terminologie moderne, on appelle actes juridiques. À l'époque, cette dernière notion, développée par la doctrine allemande, était encore inconnue des juristes francophones, et on opposait plutôt les « faits juridiques » aux « faits matériels ».

947 Cour d'appel, 11 janvier 1877, *Pas.*, 1, p. 292.

948 Voy. *infra*, nos 546 et s.

949 À titre de comparaison : 1 500 € en France, et seulement 375 € en Belgique.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les conditions de forme, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 505-521
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

2) *Portée de l'article 1341 du Code civil*

422. **Interdiction ou obligation ?** Bien qu'il se présente comme posant une obligation pour les parties (« il doit être passé acte »), le texte doit plutôt se lire comme une interdiction : celle d'utiliser pour prouver les actes juridiques d'autres moyens de preuve que l'écrit. Mais cette interdiction est loin d'être aussi générale que le texte pourrait le laisser supposer (**a**), et les actes écrits qui peuvent être utilisés comme modes de preuve sont conçus de manière assez souple – plus encore aujourd'hui avec l'évolution des techniques (**b**).

a. *Les moyens de preuve interdits*

423. **Témoignages et présomptions.** Il faut observer que, dans le chapitre du Code civil sur la preuve, l'article 1341 du Code civil ne figure pas dans la section consacrée aux preuves littérales (par écrit), mais qu'il ouvre celle relative aux « témoignages et présomptions ». C'est que le véritable sens de cet article est d'interdire qu'on prouve un acte juridique par témoignages ou par présomptions (indices déduits des relations entre les parties, de leur comportement avant et après l'acte allégué, etc.). En creux, bien sûr, il en résulte que les parties, si elles veulent pouvoir prouver leur contrat, ont intérêt à rédiger un écrit, mais en réalité ce n'est pas le seul mode de preuve admissible. La partie qui ne peut pas produire d'écrit en justice peut toujours espérer que son adversaire fera devant le juge l'aveu de son obligation (C. civ., art. 1354 et s.) ou même lui déférer le serment, en lui faisant jurer qu'il n'est tenu de rien. Il s'agit là cependant de deux modes de preuve qui reposent sur la bonne volonté du défendeur, donc très aléatoires. L'admissibilité de l'aveu – qui peut être fait en dehors de la présence du juge – présente cependant un intérêt lorsqu'on peut assimiler à un tel aveu le comportement du défendeur qui a exécuté le contrat sans protester. La Cour d'appel a ainsi considéré que « si les droits et obligations du concédant et du concessionnaire ne sont pas réglés par une convention écrite, la preuve de l'existence d'un contrat de concession de vente exclusive peut être tirée du fait de la vente, opérée d'une manière ininterrompue, pendant une longue période, à titre exclusif par le concessionnaire de produits fabriqués par le concédant »[950]. Cependant, selon l'article 1355 du Code civil, un aveu extra-judiciaire purement verbal n'est admissible que dans le cas où la preuve testimoniale (par témoins) le serait – puisqu'on ne pourra rapporter devant le juge la preuve d'un tel aveu oral que par témoins.

b. *Les actes écrits permis*

424. **Règles générales.** « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de tous actes juridiques […] ». Le texte de l'article 1341 du Code civil indique que, en règle générale, la preuve d'un acte juridique peut être rapportée soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé[951]. Le choix entre ces deux formes d'actes est libre. Il dépend de la force plus ou moins grande que les parties veulent donner à la constatation de leur contrat. Rappelons brièvement que, si l'acte a été dressé par un notaire, en la forme authentique, il fera preuve de ce que le notaire a constaté jusqu'à inscription de faux (c'est-à-dire ouverture d'une

[950] Cour d'appel, 11 juillet 1972, *Pas.*, 22, p. 194.

[951] Noter que dans le texte, le terme « acte » est utilisé tantôt pour désigner l'*instrumentum* qui servira de preuve (Il doit être passé acte), tantôt le *negotium*, l'acte juridique. Sur cette distinction, voy. *supra*, n° 36.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les conditions de forme, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 505-521
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

procédure pénale accusant le notaire d'avoir fait un faux) ; en outre, cet acte vaudra titre exécutoire en cas de non exécution du contrat par le débiteur. Un acte sous seing privé, lui, pourra être désavoué par celui à qui on l'oppose, il ne fera preuve de son contenu que jusqu'à preuve contraire (sachant que cette preuve contraire devra elle-même être faite par écrit, selon l'article 1341 du Code civil), et il ne constituera pas par lui-même un titre exécutoire : le créancier qui voudra faire exécuter le contrat (notamment en pratiquant une saisie sur les biens du débiteur) devra, préalablement, obtenir un jugement de condamnation. En outre, lorsque l'acte est sous seing-privé, il ne fait preuve de sa date qu'entre les parties ; il n'a de date certaine à l'égard des tiers à qui on voudrait opposer le contrat qu'à compter d'un des événements prévus à l'article 1328 du Code civil (enregistrement, décès d'une partie, constatation dans un acte authentique).

Selon la forme choisie, les contractants devront respecter les règles posées par les articles 1317 à 1320 du Code civil pour les actes authentiques (texte complémentaire ?) ou par les articles 1322 à 1332 du Code civil pour les actes sous seing privé. Si la validité des actes authentiques, rédigés par le notaire, ne fait en général pas de difficulté, celle des actes sous seing privé, qui reposent exclusivement sur les parties, donne lieu à davantage de discussions. Au minimum, un tel acte doit être signé par les parties, ou par la partie qui s'engage. Mais, lorsque l'acte constate un contrat synallagmatique, il doit être établi en autant d'exemplaires que de parties ayant un intérêt différent (ce qui permettra de vérifier que l'acte n'a pas été ultérieurement modifié par une des parties (C. civ., art. 1325). Si l'acte constate l'engagement unilatéral de payer une somme d'argent ou de lui livrer un bien fongible, il peut être rédigé en un exemplaire unique, mais il doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main de la somme ou de la quantité en toutes lettres (C. civ., art. 1326). Cette mention est destinée à éviter que le créancier, qui est seul en possession de l'exemplaire unique du contrat, ne modifie le montant fixé. L'exigence de l'article 1326 du Code civil permet aussi d'attirer l'attention du débiteur sur le montant de la somme qu'il aura à payer[952]. En principe, seul l'acte original peut servir de preuve, mais dans certaines conditions, une copie peut remplacer l'original (C. civ., art. 1333 et s.). Comme pour toutes les règles de preuve, l'inobservation de ces formalités n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte juridique, mais par l'impossibilité de se servir de l'acte irrégulier comme preuve[953].

Si l'acte dressé ne répond pas à ces différentes formes, il ne pourra pas valoir comme preuve du contrat sous-jacent. Cette inefficacité (on parle souvent de nullité) n'affecte cependant que l'*instrumentum*, le titre destiné à servir de preuve. L'acte juridique constaté ne sera, quant à lui, pas nul – et il devra recevoir pleine exécution dès lors que la partie à qui on l'opposera ne contestera pas l'avoir passé.

425. **Contrats électroniques.** La fréquence des contrats passés sous forme électronique a amené les législateurs nationaux à adapter leurs règles de preuve des contrats, conçues à une époque où on ne connaissait que la rédaction sur papier (et encore, à l'époque du Code civil, sous une forme qui était généralement manuscrite). Le législateur européen s'est également préoccupé de la question, à travers différentes directives, dont, surtout, en matière de preuve, la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Cosneil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire

952 Ce rôle protecteur du consentement, qui diverge de la fonction probatoire de l'article 1326 du Code civil, est particulièrement important en matière de cautionnement.

953 Voy. pour la formalité du double Cour d'appel, 9 novembre 2017, *Pas.*, 39, p. 175.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les conditions de forme, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 505-521
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pour les signatures électroniques[954]. Cette directive a été transposée au Luxembourg par la loi du 14 août 2000 dont les dispositions portant sur la « preuve littérale » ont été intégrées dans le Code civil. Désormais, en vertu de l'article 1322-1 du Code civil, « la signature nécessaire à la perfection d'un acte sous seing privé […] peut être manuscrite ou électronique ». Cette signature électronique est définie comme « un ensemble de données, liées de façon indissociable à l'acte, qui en garantit l'intégrité et satisfait aux conditions posées à l'alinéa premier du présent article ». Cette signature électronique, créée sous certaines conditions définies dans le Règlement grand-ducal du 1er juin 2001, suffit à conférer à un acte la valeur d'un original dès lors qu'il présente des garanties fiables quant au maintien de son intégrité (C. civ., art. 1322-2). Lorsque l'acte est créé sous une forme électronique, il n'est pas nécessaire de le rédiger en deux exemplaires, et la mention de l'article 1326 du Code civil n'a plus à être écrite de la main de celui qui s'engage (ce qui n'est évidemment possible que pour les contrats constatés dans un écrit papier), dès lors qu'elle est assortie spécifiquement de la signature électronique.

B) *Limites à l'exigence d'une preuve écrite*

426. **Liberté de la preuve en matière commerciale.** – L'exigence de la preuve écrite n'est requise qu'en matière civile. Rédigé pour les « achats et ventes », mais considéré comme valant de manière générale pour tous les contrats commerciaux, l'article 109 du Code de commerce énumère tous les modes de preuve admissibles, à côté des actes authentiques ou sous seing privé : facture acceptée, correspondance, livres des parties, et même, pour terminer « la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre ». Autant dire que la preuve des contrats commerciaux peut se faire par tous moyens. Cette règle, qui constitue aujourd'hui un des principaux intérêts de la qualification civile ou commerciale d'un contrat, se justifie traditionnellement par le souci de rapidité, de fluidité, des relations commerciales, qui ne doivent pas s'embarrasser de formes particulières.

La règle ne joue cependant qu'à l'encontre de la partie qui a la qualité de commerçant. Dans le cas d'un contrat mixte – passé entre un commerçant et un non-commerçant, on applique de manière distributive les règles du droit civil et du droit commercial : le non-commerçant peut faire la preuve des obligations du commerçant par tous moyens, mais le commerçant, lui, s'il est en position de demandeur à la preuve, doit en principe prouver par écrit les obligations du débiteur non-commerçant.

427. **Limites en matière civile.** On rappellera brièvement ici deux limites à l'exigence d'un acte écrit posée par l'article 1341 du Code civil, qui sont posées par le Code civil lui-même aux articles 1347 et 1348.

La première (C. civ., art. 1347) concerne le cas où le demandeur à la preuve dispose d'un acte écrit, qui peut venir au soutien de sa prétention, mais qui ne répond pas aux conditions posées par les articles 1322 et suivants du Code civil pour valoir comme acte sous seing privé (ou *a fortiori* comme acte authentique). Ce peut être un papier non signé, ou un écrit auquel manque la mention manuscrite de l'article 1326 du Code civil, etc. Un tel écrit ne peut à lui seul servir de preuve, mais il peut constituer un commencement de preuve par écrit, et il pourra être complété par des témoignages et présomptions. Pour cela, il faut que l'écrit incomplet soit « émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et (qu'il

954 *J.O.U.E.*, L. 13, 19 janvier 2000.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les conditions de forme, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 505-521
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

rende) vraisemblable le fait allégué ». La notion de commencement de preuve par écrit a reçu un élargissement considérable lors de la réforme du droit de la preuve par la loi du 22 décembre 1986, qui a posé que « peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ». Cette disposition, d'inspiration française, atténue considérablement la portée de l'article 1341, puisque même une partie qui n'a, au départ, aucune trace écrite du contrat, peut espérer pouvoir faire la preuve par témoignage si son adversaire fait devant le juge des déclarations pouvant être interprétées comme rendant le contrat vraisemblable.

La seconde exception à l'exigence de l'écrit, prévue à l'article 1348 du Code civil, est fondée sur l'idée d'impossibilité de prouver par écrit. Cette impossibilité peut résulter de la perte ou de la destruction d'un titre écrit, par suite d'un cas de force majeure, d'un titre écrit qui avait été établi au départ (lorsque je vous ai prêté de l'argent, nous avions fait un écrit, mais il a brûlé dans l'incendie accidentel de ma maison). Mais le texte vise aussi l'impossibilité où la partie a été au départ, lors de la conclusion de l'acte, de se procurer un acte écrit – soit à raison des circonstances matérielles qui rendaient impossible la rédaction d'un écrit (dépôt de biens précieux fait par une personne dont la maison est en train de brûler), soit à raison de relations particulières entre les parties ou d'usages qui rendaient moralement impossible d'exiger la signature d'un écrit[955].

§ 2. Le formalisme de publicité

428. Principe. Nous verrons plus loin que le contrat, même s'il ne crée des droits et des obligations qu'entre les parties, n'est pas absolument sans effet à l'égard des tiers. Ceux-ci ne peuvent pas faire comme si le contrat n'avait pas été passé, ils sont tenus de respecter l'accord qui a été conclu, et ils doivent en tenir compte dans leur comportement. On rend compte de ces effets en disant que le contrat est opposable aux tiers[956]. D'une manière générale, cette opposabilité joue de plein droit, sans que les parties aient à faire quelque chose pour faire connaître aux tiers l'existence et le contenu du contrat : si mon débiteur, par exemple, vend sa maison, cela signifie pour moi que je ne pourrai plus, s'il ne me paye pas ce qu'il me doit, saisir cette maison pour me payer sur son prix ; et

955 Sur l'impossibilité morale résultant d'un usage, voy. not. Cour d'appel, 20 mars 1985, 26, p. 326 posant que « S'il est admis que la preuve littérale n'est pas requise lorsque le créancier s'est trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, encore faut-il que l'usage invoqué soit constant, notoire, public et toléré par la loi ». Sur l'impossibilité morale résultant de relations particulières entre les parties, voy. p. ex. Cour d'appel, 27 février 2013, *Pas.*, 36, p. 169, qui souligne que « les liens familiaux et d'affection liant le mandataire et le mandant n'entraînent pas automatiquement une impossibilité morale de se procurer une preuve écrite des opérations effectuées dans le cadre du mandat. Si une telle impossibilité morale peut éventuellement se concevoir pour des montants modiques, destinés à couvrir les dépenses de la vie courante des mandants, il en va autrement pour des montants plus importants ».

956 Voy. *infra*, n°s 960 et s.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les conditions de forme, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 505-521
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

cela sera vrai même si mon débiteur, lorsqu'il a vendu la maison, n'a pas pris la peine de m'en informer. Mais, dans un certain nombre de cas, la loi, pour protéger les tiers qui ont agi dans l'ignorance d'un contrat passé en dehors d'eux, subordonne l'opposabilité à la connaissance effective que ces tiers ont pu avoir du contrat, ou même – et c'est ce qui nous intéresse ici – à l'accomplissement de certaines formalités de publicité destinées à permettre aux tiers d'en avoir connaissance. L'exemple le plus important est celui des contrats de vente ou de création d'un droit réel portant sur un immeuble : ces contrats doivent faire l'objet d'une publication dans un registre public (tenu par une administration qu'on appelle la Conservation des hypothèques) pour être opposables aux tiers qui voudraient acquérir sur le même immeuble des droits concurrents. Et cette publication présuppose que le contrat de vente ait été préalablement rédigé par acte authentique. Si j'achète un bien immobilier à une personne, je dois savoir si cette personne n'a pas déjà vendu le même bien à un tiers. Pour le savoir, je peux aller me renseigner à la conservation des hypothèques. Si mon vendeur a déjà vendu à quelqu'un d'autre, et que cette vente a été publiée, je le verrai, et cette vente me sera opposable. Je ne devrai alors pas acheter à nouveau l'immeuble. Si en revanche, mon vendeur avait déjà vendu, mais que cette précédente vente n'avait pas été publiée, l'immeuble apparaîtra toujours à la Conservation des hypothèques comme appartenant à mon vendeur, et je pourrai acheter sans crainte. Si, par la suite le premier acheteur vient me dire qu'il avait acheté avant moi, je pourrai lui dire que, puisque la publicité n'a pas été faite, la vente qui lui a été consentie m'était inopposable. Un mécanisme du même type, bien que reposant sur une formalité très différente, se rencontre lorsqu'un créancier cède à un tiers sa créance contre son débiteur. L'effet normal d'une telle cession est que c'est désormais le cessionnaire de la créance qui est le créancier, et c'est à lui que le débiteur doit désormais payer. Cependant, pour que la cession soit opposable à ce débiteur, la loi impose l'accomplissement de certaines formalités – notamment une notification à ce débiteur. Si cette formalité n'a pas été accomplie, le débiteur, ignorant l'existence de la cession de créance, peut valablement se libérer entre les mains de son créancier originaire, sans que le cessionnaire puisse lui demander de payer une deuxième fois. Le débiteur non averti pourra en effet dire au cessionnaire : vous ne m'avez pas prévenu, donc la cession ne m'est pas opposable, et, pour moi, c'est toujours le cédant qui est mon créancier.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les conditions de forme, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 505-521
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

429. Sanction. Sans entrer dans le détail des différentes formalités de publicité, il faut bien voir que, dans toutes ces hypothèses, la sanction est simplement l'inopposabilité du contrat aux tiers que la loi veut protéger. Ceux-ci pourront faire comme si le contrat n'avait pas été passé : l'acheteur de l'immeuble comme s'il n'avait pas été déjà vendu et comme si son vendeur en était toujours propriétaire, le débiteur de la créance cédée comme s'il n'avait pas changé de créancier. Mais le contrat non publié n'est pas nul. Il reste valable entre les parties (le vendeur et le premier acheteur, le cédant et le cessionnaire de la créance). Sans doute, il ne pourra pas être exécuté (si j'ai acheté un immeuble et que je suis évincé par un second acquéreur qui a publié avant moi, mon vendeur ne pourra pas me livrer l'immeuble), mais cette inexécution sera alors sanctionnée conformément aux règles générales de l'inexécution contractuelle, parce que le contrat non publié a force obligatoire entre les contractants. C'est ce qui permet d'affirmer que les formalités de publicité relèvent d'un formalisme indirect, qui ne porte pas atteinte, en droit, au principe du consensualisme.

SECTION 2. LE FORMALISME DIRECT

430. Expansion du formalisme. Si les formes probatoires et les formes de publicité étaient déjà répandues à l'époque du Code civil, il était en revanche exceptionnel que le Code subordonne la validité d'un contrat au respect de certaines formes. Au fil du temps, ce formalisme *ad validitatem* a gagné du terrain dans la plupart des systèmes juridiques européens, au Luxembourg comme ailleurs, même si le droit luxembourgeois est loin d'être le plus formaliste (surtout si on le compare au droit français qui lui sert habituellement de modèle). Cette expansion du formalisme est souvent présentée comme un retour en arrière, une renaissance du formalisme contractuel ancien[957]. C'est une vision un peu simpliste car le formalisme actuel poursuit, en général, des objectifs très différents de ceux du passé. Le formalisme ancien, notamment en droit romain, était principalement ce qu'un auteur moderne a appelé un formalisme « instituant », destiné à inscrire l'engagement contractuel dans l'ordre social par le respect d'un certain nombre de rites. Ce type de

[957] Voy. ainsi en Belgique : WÉRY, n° 106 ; VAN OMMESLAGHE, n° 113 qui parle de « résurgence » ; en France : X. LAGARDE, « Observation critique sur la renaissance du formalisme », *JCP*, 1999, I, p. 170.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les conditions de forme, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 505-521
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

formalisme a survécu dans le Code civil, mais de manière tout à fait marginale, à travers la figure des contrats réels, dont la validité est subordonnée à la remise d'une chose (§ 1). Dans le droit moderne, on rencontre surtout des contrats solennels, où la forme exigée est la rédaction d'un écrit, et le but poursuivi est plutôt de protéger le consentement des parties ou de l'une d'elles (§ 2).

§1. Contrats réels

431. Survivance. On trouve encore, dans le Code civil, trois contrats dont la validité – et peut-être même l'existence – est, à suivre la lettre des textes, subordonnée à la remise d'une chose par un contractant à un autre. C'est ce qu'on appelle des contrats réels. C'est d'abord le cas du prêt, qu'il s'agisse du prêt à usage « contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge par le premier de la rendre après s'en être servi » (C. civ., art. 1875) ou du prêt de consommation « contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à charge pour cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité » (C. civ., art. 1892) – ce qui est le cas notamment du prêt d'argent[958]. Dans les deux cas, la « livraison » de la chose ou de la somme prêtée est un élément de formation du contrat. Est également un contrat réel le contrat de dépôt, qui, selon l'article 1919, « n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée ». Enfin le contrat de nantissement, par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de sa dette (C. civ., art. 2071), et qui est surtout pratiqué sur des choses mobilières sous le nom de gage.

Le caractère réel de ces trois contrats est cependant aujourd'hui bien atténué. Pour le dépôt et pour le gage, la remise effective de la chose n'est pas toujours exigée : l'article 1919 du Code civil se contente d'une « tradition feinte » de la chose déposée (qui peut donc rester dans des locaux du déposant, dès lors qu'elle est confiée à la surveillance et à la garde du dépositaire), et, en matière de gage commercial, l'article 114 du Code de commerce assimile au cas où le bien gagé a été mis en possession du créancier celui où il est « réputé être en cette possession ». La même

[958] Bien qu'ils portent le même nom, les deux contrats obéissent à un régime juridique tout à fait différent, notamment parce que, dans le prêt de consommation, l'emprunteur devient propriétaire des choses ou sommes prêtées.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les conditions de forme, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 505-521
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

formule se retrouve dans l'article 5 de la loi du 5 août 2005 pour le gage sur instruments financiers, de loin le plus pratiqué au Luxembourg. Par ailleurs, dans les trois cas, la jurisprudence a admis que, même si le contrat lui-même supposait la remise de la chose, il était possible aux parties, dès avant cette remise, de passer une promesse de contrat ayant force obligatoire. Cette promesse ne produit cependant pas les mêmes effets que le contrat définitif : ainsi, si une banque a consenti une promesse de prêt à un client, celui-ci ne peut contraindre la banque à lui remettre les fonds[959].

En France et en Belgique, le recul de la catégorie des contrats réels est encore plus net. Dans ces deux pays, le contrat de gage a cessé d'être un contrat réel, car désormais la dépossession du débiteur et la remise de la chose au créancier n'est plus qu'un moyen d'assurer l'opposabilité aux tiers du gage, cette opposabilité pouvant également être assurée par l'inscription du gage dans un registre[960]. En droit français, la Cour de cassation considère également depuis quelques années que le prêt n'est pas un contrat réel lorsqu'il est consenti par un professionnel du crédit[961]. Cependant, la catégorie des contrats réels a été maintenue dans les deux pays lors des réformes récentes (C. civ. fr., art. 1172, al. 3, C. civ. be., art. 5.29, al. 1 et 2).

§ 2. Contrats solennels

432. Notion. On nomme habituellement contrats solennels des contrats dont la validité est subordonnée à l'exigence d'un écrit, qui peut être, suivant les cas, soit un acte authentique, soit un acte sous seing privé. Cette terminologie est reprise dans le nouveau droit français (C. civ. fr., art. 1172, al. 2), tandis que le nouveau droit belge préfère parler de contrat formel (C. civ. be., art. 5.5 et 5.29, al. 3). Dans la plupart des cas, les textes qui exigent un écrit indiquent expressément si c'est à peine de nullité du contrat ou seulement pour servir de preuve. Mais ce n'est pas toujours le cas, et il appartient alors à la jurisprudence de dire quelle est la sanction du défaut d'écrit. Par exemple, l'article 2044 du Code civil prévoit que le contrat de transaction « doit être rédigé par écrit ». Suivant en cela la jurisprudence française, la Cour d'appel du Luxembourg semble considérer qu'il s'agit là d'une simple règle de preuve, mais qui, à la différence de l'article 1341 du Code civil, a une portée générale et s'applique même en matière commerciale[962].

959 Cour d'appel, 28 mai 2008, n° 32446, *BIJ*, 2008, p. 469.

960 C. civ. fr., art. 2337 ; L. 11 juillet 2013 be. (non encore entrée en vigueur), art. 2.

961 Cass. fr. (1re civ.), 19 juin 2008, n° 06-19056.

962 Cour d'appel, 1er décembre 1922, *Pas.*, 11, p. 529.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les conditions de forme, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 505-521
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

433. Exigence d'un acte authentique. Dans le Code civil, les rares textes qui subordonnaient la validité d'un contrat à la rédaction d'un écrit, exigeaient un acte authentique, passé par devant un notaire. C'était le cas pour quatre contrats : la donation (C. civ., art. 931), le contrat de mariage (C. civ., art. 1394), la subrogation conventionnelle par le débiteur C. civ., art. 1250 2)[963], et enfin la constitution d'hypothèque (C. civ., art. 2127, qui exige deux notaires ou un notaire et deux témoins). Ce formalisme très rigoureux répond à des objectifs multiples. Parfois, l'objectif premier est de protéger le consentement des parties ou de l'une d'elles, en attirant leur attention sur la gravité de l'acte passé. Le devoir de conseil qui pèse sur le notaire sert bien cette finalité, qui est particulièrement sensible dans le cas de la donation (par laquelle le donateur se dépouille irrévocablement et sans contrepartie d'un bien), et de la constitution d'hypothèque (qui grève un immeuble d'un droit réel et en diminue la valeur). Mais le formalisme poursuit également d'autres buts, en ce qu'il peut permettre à l'autorité publique de vérifier la régularité des actes passés, et surtout de protéger les tiers en leur permettant d'avoir connaissance plus facilement des actes passés (les héritiers du donateur à qui la donation faite par acte authentique ne pourra pas être dissimulée, les créanciers d'un époux qui doivent savoir quel est le statut des biens de leur débiteur, les créanciers du constituant de l'hypothèque, etc.). Ces objectifs mêlés expliquent qu'on considère traditionnellement que la nullité qui sanctionne la violation d'une de ces formes exigées par le Code civil est une nullité absolue[964].

Les exigences formalistes du Code civil pour les quatre contrats précédemment cités font toujours partie du droit positif. Il faut cependant remarquer qu'elles ont été considérablement atténuées par la jurisprudence, dans les trois pays du Code civil, en matière de donation. Les tribunaux ont en effet admis que la rédaction d'un acte authentique pouvait être remplacée, du moins pour l'argent et les choses mobilières, par la remise effective de la chose donnée au bénéficiaire : c'est ce qu'on appelle le don manuel. On explique généralement cette solution, qui va directement à l'encontre de l'article 931 du Code civil, par l'idée que le donateur prend tout aussi bien conscience de ce qu'il fait en se dépouillant matériellement de la chose qu'en signant un acte authentique. Au Luxembourg, la validité des dons manuels est acquise au moins depuis 1875[965].

963 Pour l'explication de ce contrat, voy. *infra*, n° 1026.

964 Voy. *infra*, n° 446.

965 Cour d'appel, 28 janvier 1875, *Pas.*, 01, p. 32. Pour une application plus récente : Cour d'appel, 24 novembre 2011, *Pas.*, 35, p. 723, qui considère qu'un virement bancaire peut constituer un don manuel.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les conditions de forme, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 505-521
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Dans la législation postérieure au Code civil, l'exigence de rédaction d'un acte authentique est plutôt rare, mais elle touche des actes importants de la pratique. On peut citer l'article 1601-5 du Code civil (issu d'une loi du 28 décembre 1976) qui exige la rédaction d'un acte authentique comportant de nombreuses mentions obligatoires pour le contrat de vente d'immeuble à construire lorsque cet immeuble est destiné à un usage d'habitation. Le but est ici clairement de protéger le consentement de l'acheteur en l'informant de manière précise des conditions de l'opération et des caractéristiques de l'immeuble à construire. En revanche, contrairement à une idée très répandue, la vente d'un immeuble n'est pas en principe un contrat solennel : si la rédaction d'un acte authentique est, en pratique, toujours nécessaire, c'est pour pouvoir publier la vente, ce qui, on l'a vu, commande seulement son opposabilité aux tiers.

434. Exigence d'un acte sous seing privé. Dans l'immense majorité des cas, aujourd'hui, lorsque la loi subordonne la validité d'un contrat à la rédaction d'un écrit, elle se contente d'un acte sous seing privé. Ce type d'exigence se rencontre depuis longtemps à propos d'actes intéressant directement les tiers, qui doivent pouvoir savoir avec certitude ce que les parties ont convenu. C'est à cette fin, par exemple, que l'article 4 de la loi du 10 août 1915 dispose que « Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés coopératives sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil ». Mais, dans la législation moderne, c'est plutôt dans le but de protéger le consentement d'un contractant que la loi exige la rédaction d'un écrit sous seing privé. Le formalisme est ici un instrument privilégié de la politique de protection des contractants en situation de faiblesse. Ce formalisme apparaît assez différent de celui consacré pour quelques actes par le Code civil : la loi, aujourd'hui, ne se contente pas d'exiger la rédaction d'un écrit pour attirer l'attention du contractant sur la gravité de l'acte qu'il passe, elle veille surtout à ce que ce contractant soit informé de manière précise sur le contenu de l'acte, ses conséquences, ses dangers, les caractéristiques de la chose ou du service objet du contrat. Le formalisme est ici une des traductions concrètes des obligations d'information qui pèsent sur de très nombreux contractants. Ce formalisme informatif, déjà sensible dans la loi précitée de 1976 sur la vente d'immeuble à construire, se déploie en particulier dans de très nombreux textes du

LARCIER INTERSENTIA
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les conditions de forme, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 505-521
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

droit de la consommation, dont on ne peut donner ici que quelques exemples : les articles L. 223-4 et L. 223-5 du Code de la consommation pour les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, l'article L. 224-11 pour le contrat de crédit à la consommation, l'article L. 225-11 pour les contrats de voyage à forfait, etc.

Dans la mesure où ce formalisme a clairement pour but de protéger un contractant, et qu'on peut y voir un des aspects de l'ordre public de protection, il serait logique que sa violation soit sanctionnée par une nullité relative – avec, toutefois, le particularisme qu'impose le rattachement de ces règles à l'ordre public. Nous allons retrouver plus en détail la question dans les développements qui vont suivre.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les conditions de forme, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 505-521
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

435. Nullité et autres sanctions. De prime abord, il semble aller de soi que, lorsqu'un contrat ne répond pas à toutes les conditions de validité posées par la loi, il doit être frappé de nullité. Cette présentation est un peu simpliste : d'une part, la nullité du contrat est loin d'être la sanction automatique du non-respect de toutes les conditions de validité précédemment examinées (**Chapitre I**) ; d'autre part, la nullité peut être complétée, et parfois remplacée, par d'autres types de sanctions (**Chapitre II**).

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 525
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Chapitre I
La nullité du contrat

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

436. Définition et distinctions avec d'autres sanctions. La nullité du contrat est l'anéantissement d'un acte qui ne répond pas à toutes les conditions de validité posées par le droit. Dans le Code civil, elle porte parfois le nom ancien de rescision (terme encore utilisé pour la lésion, sans qu'il y ait de différence de nature entre les deux sanctions)[966]. La nullité doit être soigneusement distinguée d'autres techniques juridiques qui se traduisent, comme elle, par une perte d'efficacité d'un contrat, mais pour d'autres causes. Il convient d'abord de distinguer la nullité et l'inexistence du contrat, qui, dans sa conception stricte, désigne la situation où le contrat ne s'est pas formé (par exemple parce que l'offre n'a pas été acceptée, ou parce que les parties ne se sont pas mises d'accord sur un élément essentiel du contrat ni sur la manière de le déterminer). Dans un arrêt de 2017, la Cour d'appel fait clairement la distinction entre les deux sanctions, en posant que « [l]'inexistence d'un contrat, dont toute personne peut se prévaloir, à tout moment, suppose que l'acte litigieux n'ait pas la moindre apparence formelle. Au contraire dès l'instant que le contrat revêt, extérieurement, l'aspect d'un acte juridique, il y a là une apparence qu'il est nécessaire de détruire, ce qui suppose l'intervention du juge et l'annulation de l'acte »[967]. Nous verrons cependant que la distinction n'est pas toujours évidente, parce que, historiquement, on s'est autrefois servi de la notion d'inexistence pour sanctionner certains défauts particulièrement graves du contrat, et que, aujourd'hui, en droit français, on l'utilise encore à propos de certaines conditions de validité de clauses contractuelles[968]. La distinction est plus claire entre la nullité – qui sanctionne la violation de conditions de validité – et l'inopposabilité d'un contrat – qui sanctionne le non-respect de conditions de publicité[969], et qui se traduit seulement par l'absence d'effets de l'acte à l'égard des tiers. Cependant, là encore, la terminologie est parfois flottante, car on utilise fréquemment le terme d'inopposabilité pour désigner l'absence d'intégration dans le contrat d'une clause qui n'a pas été acceptée par un contractant (alors qu'il s'agit plutôt d'une inexistence). De même, dans la pratique, on confond parfois les termes de nullité et de résolution, alors qu'il s'agit de deux sanctions radicalement différentes, même si leurs

966 Voy. *supra*, n° 264.

967 Cour d'appel, 9 novembre 2017, *Pas.*, 39, p. 175.

968 Voy. *infra*, n° 475.

969 L'inopposabilité sanctionne aussi parfois la fraude commise par un contractant. Voy. *infra*, n°s 729 et s. à propos de l'action paulienne.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

effets sont parfois similaires. La résolution, en effet, sanctionne, non le non-respect d'une condition de validité du contrat, mais l'inexécution des obligations contractuelles[970]. Enfin, on doit distinguer la nullité de la caducité – sanction totalement ignorée des rédacteurs du Code civil, mais qui a été théorisée par la doctrine : la caducité résulte de la disparition, en cours de vie du contrat, d'un élément nécessaire à son existence. Par exemple, j'ai loué une maison – par un contrat de bail parfaitement valable au départ – mais, quelques mois plus tard, la maison est détruite par un incendie. Le bail devient alors caduc[971]. Le législateur français, en 2016, a traité de la caducité en parallèle à la nullité, dans un chapitre consacré aux « sanctions », à l'intérieur du chapitre consacré à la formation du contrat – ce qui n'est pas très logique. Il vaudrait mieux, en suivant l'exemple belge, traiter de cette question au sein des règles relatives à la durée du contrat.

437. Sources. La matière des nullités est une de celles qui ont été les plus mal traitées par les rédacteurs du Code civil. Sur la plupart des questions, le Code civil ne contient que des réponses lacunaires et dispersées, qui ne visent en général que certaines causes de nullité (par exemple, l'article 1117 du Code civil sur la nullité pour vice du consentement, l'article 1125 du Code civil sur la nullité pour incapacité, les articles 1676 et suivants du Code civil sur le régime spécifique de la rescision pour lésion, etc.). Il existe bien, curieusement placée dans le chapitre relatif à l'extinction des obligations, une section intitulée « De l'action en nullité ou en rescision des conventions » (C. civ., art. 1304 et s.), mais ces articles, particulièrement mal rédigés, ne concernent pour l'essentiel que la nullité des actes passés par les mineurs. Enfin on trouve, perdu au milieu des règles sur la preuve, l'article 1338 du Code civil relatif à la confirmation ou ratification d'une obligation nulle.

Ces défauts et lacunes – auxquels les réformes française et belge ont voulu remédier[972] – avaient laissé le champ libre à la jurisprudence pour trouver des solutions, et surtout à la doctrine pour

970 Voy. *infra*, n°s 753 et s.

971 Sur la caducité, voy., en droit français : C. PELLETIER, *La caducité des actes juridiques en droit privé en français*, Paris, L'Harmattan, 2004, pref. P. JESTAZ ; en droit belge : P.A. FORIERS, *La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élément essentiel à leur formation*, Bruxelles, Bruylant, 1998.

972 Art. 1178 et s. C. civ. fr. ; art. 5.57 à 5.63 C. civ. be.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

élaborer des « théories » de la nullité[973]. Ces théories, et les solutions jurisprudentielles qu'elles commandent, ont considérablement évolué depuis l'époque du Code civil, sur les deux grandes questions qui se posent en la matière : d'une part celle des modalités d'obtention de la nullité (**Section 1**), et d'autre part celle des effets de la nullité (**Section 2**).

SECTION 1. LES MODALITÉS D'OBTENTION DE LA NULLITÉ

438. Nullité ou annulabilité ? On dit souvent : si le contrat ne répond pas aux conditions de validité posées par la loi, il est nul. Cela paraît relever de l'évidence, mais encore faut-il se demander qui peut prononcer ou constater cette nullité : la personne qui a intérêt à faire tomber le contrat, et qui pense (à tort ou à raison) que ce contrat est affecté d'une cause de nullité peut-elle se contenter de « faire comme si » le contrat était nul, doit-elle faire une déclaration spéciale à cet effet, ou doit-elle saisir le juge pour que celui-ci prononce la nullité ? Contrairement à de nombreux droits étrangers, le droit luxembourgeois, comme traditionnellement les droits français et belge, se prononce en faveur de cette dernière solution : on considère aujourd'hui du moins, que la nullité du contrat n'est jamais une conséquence automatique du manquement à une des conditions de validité du contrat. C'est une sanction qui doit, en toute hypothèse, être prononcée par le juge, à la demande d'une des parties ou d'un tiers, parfois d'office lorsqu'il a connaître du contrat. En conséquence, tant que la nullité n'est pas prononcée, on ne peut pas encore dire que le contrat est « nul », on peut simplement dire que le contrat est susceptible d'être annulé par le juge, qu'il est annulable. Ce n'est qu'une fois que le juge aura statué qu'on pourra dire que le contrat est frappé de nullité.

Le prononcé de la nullité requiert donc toujours une action en justice (**§ 1**), dont le régime n'est pas le même suivant la cause de la nullité (**§ 2**).

[973] Pour une présentation d'ensemble de la matière, on consultera prioritairement, en droit français : Flour, Aubert, Savaux 2022, n°s 520 et s., qui y consacrent plus de 100 pages dans la dernière édition, avec une abondante bibliographie. En droit belge, voy. not. Wéry, n°s 319 et s. ; *Adde* : *Les nullités en droit belge. Sanction du vice et conséquences*, Liège, Éditions du jeune barreau, 1991.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§ 1. La nécessité d'une action en justice

439. Droit comparé. La nécessité de recourir au juge pour faire prononcer la nullité est tout sauf évidente, comme le révèle un rapide examen du droit comparé[974]. Dans un certain nombre de systèmes juridiques – en particulier en *common law* et en droit allemand – la nullité ne suppose pas d'action en justice, elle est, selon les cas, automatique ou doit être déclarée unilatéralement par la personne qui veut faire tomber le contrat (généralement une partie). Dans ces systèmes, on distingue habituellement deux types de causes d'invalidité, qu'on pourrait traduire par causes de nullité (ou d'inexistence) et causes d'annulabilité. Ainsi, en *common law*, on fait une distinction entre les cas où le contrat est « *void* » (nul de droit) et ceux où il est simplement « *voidable* » : dans les cas (rares) où le contrat est « *void* » (erreur, certains cas d'illégalité), le contrat est considéré de droit comme n'ayant aucune existence légale, et aucune des parties n'a rien à faire ; si un litige survient, le juge se bornera à constater qu'il n'y a pas de contrat valable ; dans les cas où le contrat est « *voidable* », la « *rescission* » du contrat est subordonnée à une déclaration, faite dans un certain délai, de la partie qui a qualité pour faire tomber le contrat[975]. On trouve un certain équivalent de cette distinction en droit allemand où on distingue de même la « *Nichtigkeit* » (nullité de droit), qui équivaut à une sorte d'inexistence du contrat, préexistante à toute décision judiciaire, et l'« *Anfechtbarkeit* » (contestabilité) qui suppose une déclaration unilatérale de la partie victime du vice du contrat. Ce système est repris, au niveau européen, par le DCFR, qui distingue « *nullity* » (pour la violation des règles impératives) et « *avoidance* » pour les incapacités ou vices du consentement. Bien entendu, dans ces systèmes, le juge aura tout de même son mot à dire, si un litige survient entre les deux parties, dont l'une prétend faire exécuter le contrat et l'autre prétend qu'il est nul, ou a fait une déclaration d'annulation. Mais le rôle du juge est limité à constater la nullité de droit ou à vérifier que la déclaration d'annulation a été faite régulièrement et est bien fondée. Ce n'est jamais lui qui « prononce » la nullité. Le nouveau droit français est resté fidèle à ce modèle : l'article 1178 du Code civil dispose que « [l]a nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord ».

974 Voy. R. CABRILLAC, *Droit européen comparé des contrats*, Issy-les-Moulineaux, Lextenso, 2012, pp. 148-153.

975 Sur cette distinction : CARTWRIGHT, pp. 160 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Dans le nouveau Code civil belge, la nécessité de l'intervention du juge est en revanche nuancée : l'article 5.59 pose en principe que la nullité résulte d'une décision de justice, mais il ajoute que « [à] moins que le contrat soit constaté par un acte authentique, l'annulation résulte également d'une notification écrite que toute personne habilitée à se prévaloir de la nullité adresse, à ses risques et périls, aux parties au contrat ».

Jusqu'à maintenant, en droit luxembourgeois, on est resté fidèle à la conception traditionnelle d'une annulation judiciaire. Certes, on connaît, sur le modèle français également reçu en Belgique, une distinction très importante, selon la nature du manquement aux règles de validité, entre la nullité absolue et la nullité relative, mais cette distinction ne coïncide pas avec les distinctions admises en *common law* ou en droit allemand. Du point de vue de la nécessité du recours au juge et du rôle que le juge a dans le prononcé de la nullité, en effet, les deux catégories de nullité obéissent au même régime : il faut de toute façon, pour que la nullité soit prononcée, qu'un juge soit saisi ; tant qu'il ne s'est pas prononcé, l'acte n'est jamais considéré comme nul de droit et la déclaration de la partie qui prétendrait s'en dégager n'a pas de valeur particulière.

440. Évolution des idées. Cette manière de voir, à l'intérieur des pays du Code civil, est cependant elle-même le produit d'une évolution doctrinale, rendue possible par le caractère très lacunaire des textes en la matière. Au XIXe siècle, on considérait volontiers la nullité comme un état de l'acte, une sorte de maladie qui infectait le contrat. Cela conduisait à considérer que dans certains cas, où le défaut était particulièrement grave, l'anéantissement du contrat devait être automatique, sans qu'il soit nécessaire de le faire constater par un juge : le contrat était, en quelque sorte, mort-né. On raisonnait ainsi, par exemple, en cas d'absence totale de consentement (contrat passé par une personne atteinte de trouble mental) ou en cas de défaut d'objet. C'était ce qu'on appelait, le plus souvent, l'inexistence du contrat, mais certains auteurs ne distinguaient pas cette situation de celle de la nullité absolue, alors que d'autres situaient la nullité absolue à un degré moins grave que l'inexistence. La nullité relative était, alors, de toute façon, conçue comme s'appliquant aux défauts les moins graves. Cette conception pouvait s'appuyer sur un argument de texte, dans la mesure où l'article 1117 du Code civil, relative à la nullité pour vice du consentement, précise que la convention viciée « n'est point nulle de plein droit, elle

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

donne lieu seulement à une action en nullité ou en rescision », ce qui pouvait laisser supposer que, dans d'autres cas, la nullité était de droit et ne supposait pas d'action. Cette conception classique de la nullité a été remise en cause en France au début du XXe siècle, dans d'importants travaux doctrinaux, dus notamment à Japiot et Gaudemet[976]. Pour ces auteurs, la nullité ne doit pas être considérée comme un état de l'acte juridique défectueux, mais comme la sanction de la violation d'une règle de droit : la nullité est seulement le résultat de l'exercice d'un droit de critique qui est reconnu, plus ou moins largement, à certaines personnes, et elle n'est jamais automatique. Cette conception moderne a amené à repenser complètement la distinction entre nullités relatives et nullités absolues, qui doit désormais être fondée sur la finalité de la règle violée, et non sur la gravité du défaut du contrat[977]. Elle amène également à condamner en principe l'idée d'inexistence (ou de nullité de droit) du contrat comme sanction du non-respect des conditions de validité du contrat, puisque l'anéantissement du contrat ne peut résulter que d'une décision judiciaire. Ce n'est pas dire, cependant, que la notion d'inexistence du contrat n'a pas de rôle à jouer mais elle devrait seulement désigner les cas où le contrat ne s'est pas formé (rejet de l'offre, absence de concordance entre l'offre et l'acceptation, manque d'un élément essentiel pour l'accord)[978]. Cette conception inspire aujourd'hui très largement la jurisprudence dans les trois pays du Code civil, mais on note aujourd'hui une certaine résurgence de la notion d'inexistence dans le sens classique, notamment à propos des clauses que la loi répute « non écrites », dans lesquels la jurisprudence française, suivant un important courant doctrinal, voit un cas d'inexistence légale de la clause[979].

441. Portée de l'exigence. Il ne faut pas exagérer la portée de l'exigence d'une action en justice pour faire prononcer la nullité du contrat. En effet, la partie qui pense que le contrat est atteint d'une cause de nullité n'est pas tenue d'agir elle-même en justice pour obtenir l'annulation. Elle peut – tout comme dans les systèmes

976 R. JAPIOT, *Des nullités en matière d'actes juridiques : essai d'une théorie nouvelle*, Librairie nouvelle de droit et de jurisprudence, Dijon, 1909. Les idées de Japiot ont été reprises par E. GAUDEMET, *Théorie générale des obligations*, Paris, Sirey, 1937 (rééd., Paris, Dalloz, 2004), pp. 140 et s.

977 Voy. *infra*, n° 443.

978 C'est cette conception qui semble inspirer le Code Gandolfi, qui distingue inexistence (art. 137) et nullité (art. 140).

979 Voy. *infra*, n° 475.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

qui admettent une nullité de plein droit – s'abstenir d'exécuter le contrat, et attendre que l'autre partie agisse contre elle pour obtenir l'exécution ou pour faire sanctionner son inexécution. Elle soulèvera alors la nullité par voie d'exception (c'est-à-dire de défense à l'action de son adversaire). Dans l'immense majorité des cas, c'est ainsi que les choses se passent. Une partie n'a intérêt à agir en nullité que dans deux cas : soit, de manière préventive, pour faire cesser au plus tôt l'incertitude sur le sort du contrat ou pour éviter le risque d'une condamnation pour inexécution si la nullité n'est pas prononcée, soit, surtout, si elle a déjà, dans l'ignorance de la cause de nullité, exécuté le contrat et qu'elle veut obtenir restitution des prestations versées. Par ailleurs, il est admis que, si les parties sont l'une et l'autre d'accord sur la nullité du contrat, elles peuvent la déclarer conjointement, et se libérer mutuellement du contrat – tout se passant alors comme si le contrat n'avait jamais été passé. Cette possibilité est expressément reconnue par le nouvel article 1178 du Code civil français, ainsi que par l'article 5.59 du nouveau Code civil belge.

L'exigence d'une action en justice aurait davantage de portée si le juge avait un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité ou non de prononcer la nullité lorsqu'il constate la violation d'une condition de validité. Ce pouvoir d'appréciation lui est reconnu dans certains cas : ainsi pour la nullité des actes passés par un majeur sous sauvegarde de justice, pour lesquels l'article 491-2 du Code civil invite le juge à prendre en considération « la fortune de la personne protégée, la bonne ou la mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération ». On parle alors de nullité facultative. Mais, en principe, le prononcé de la nullité est obligatoire pour le juge, dont le pouvoir d'appréciation porte seulement sur le respect ou le non-respect des conditions de validité posées par la loi (ce qui est déjà considérable). La réforme belge a introduit ce pouvoir d'appréciation en droit commun : l'article 5.57 du nouveau Code civil dispose en effet que « le contrat demeure valable […] lorsqu'il résulte des circonstances que la sanction de la nullité ne serait manifestement pas appropriée, eu égard au but de la règle violée ».

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§ 2. Le régime de l'action en justice

442. Distinction des nullités relatives et des nullités absolues. Dès lors que la nullité est vue comme le résultat possible d'une action en justice, différentes questions se posent quant au régime de cette action. La première, et la plus importante, est celle des titulaires de l'action : qui peut agir en nullité ? Seulement une partie, les deux, d'autres personnes ? Ensuite, on se demande pendant combien de temps cette action peut être exercée ? Quel est le délai de prescription de l'action ? Enfin, on se demande si la ou les parties qui peuvent agir peuvent renoncer à l'action – cette renonciation prenant le nom de confirmation de l'acte nul. Pour répondre à ces trois questions, qu'on considère comme liées, le droit luxembourgeois, sur le modèle français, fait une distinction (déjà maintes fois évoquée dans les développements précédents) entre les nullités relatives et les nullités absolues. Cette distinction n'est pas prévue de manière générale par le Code civil, elle a été construite de toutes pièces par la doctrine, à partir de textes épars. Bien qu'elle soit aujourd'hui parfois critiquée en raison de son excessive rigidité, elle a été consacrée par la réforme française (C. civ. fr., art. 1179), comme par la réforme belge (C. civ. be., art. 5.59). Il faut s'interroger sur le critère de la distinction (**A**) puis sur ses conséquences (**B**).

A) *Le critère de la distinction*

443. Évolution. Comme on l'a déjà laissé entendre, le critère de la distinction a beaucoup évolué dans la doctrine, et dans la jurisprudence. Dans la conception classique précédemment évoquée, on fondait la distinction sur la gravité du défaut affectant le contrat : les nullités absolues (parfois assimilées à l'inexistence) sanctionnaient les vices les plus graves (défaut d'objet, de cause, absence totale de consentement, violation de l'ordre public, etc.), les nullités relatives sanctionnaient des vices jugés moins graves (vices du consentement, incapacités) – sans qu'on sache bien d'ailleurs ce qui permettait de situer tel ou tel défaut de formation sur l'échelle de gravité des vices. Mais dans la conception moderne qui voit dans la nullité moins un défaut intrinsèque de l'acte que la sanction de la violation d'une règle, on fonde la distinction, on l'a déjà dit, plutôt sur l'intérêt protégé par la règle violée : la nullité est relative si la règle violée visait à protéger l'intérêt particulier d'un contractant (par exemple, nullité pour incapacité, pour vice du consentement), elle est absolue si elle vise à protéger l'intérêt général (par exemple, nullité pour

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

violation de l'ordre public traditionnel). Cette conception moderne a largement pénétré au Luxembourg la jurisprudence de la Cour d'appel et des tribunaux de première instance. Un jugement de 2019 du Tribunal de Luxembourg[980] affirme ainsi clairement que « [l]e régime de nullité applicable, qui peut être celui des nullités absolues, ou celui des nullités relatives, se détermine au regard de la nature de l'intérêt que la loi a pour finalité de protéger ». La Cour de cassation, elle, semble encore hésitante. Dans un arrêt de 2017, elle juge que le défaut de prix dans une cession d'actions est sanctionné par une nullité absolue, suivant en cela les conclusions de l'avocat général qui estimait que la conception moderne des nullités était source de trop d'incertitudes et qu'il fallait s'en tenir à la conception classique[981]. Dans une affaire plus récente, en revanche, l'avocat général considère comme allant de soi que la nullité sanctionnant la violation d'une règle d'ordre p ublic de protection est une nullité relative – solution typique de la conception moderne – mais la Cour ne prend pas parti et rejette le pourvoi pour des raisons procédurales[982]. Il est vrai que le critère de la finalité de la règle violée, s'il permet, dans la majeure partie des cas, de déterminer quels sont les cas de nullité relative, et les cas de nullité absolue, laisse subsister certaines solutions incertaines.

444. Cas de nullité relative. Il n'a jamais été contesté que la nullité pour incapacité (d'exercice) était une nullité relative : l'article 1125 du Code civil, en effet, dispose que « les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité de ceux avec qui ils ont contracté » – et c'est là une solution typique du régime des nullités relatives, dont l'invocation est réservée à la personne que la loi veut protéger. De même est sans aucun doute relative la nullité pour vices du consentement (erreur, dol, violence), mais aussi, par extension, pour lésion. Dans la doctrine du XIXe siècle, la solution 'aujourd'hui reprise par l'article 1131 du Code civil français et 5.33 du nouveau Code civil belge) paraissait justifiée par la supposée faible gravité du vice : le consentement existe, mais il a été « simplement » vicié. On la rattache aujourd'hui, de manière plus convaincante, à l'idée que la réglementation des articles 1109 et suivants du Code civil est justifiée par un objectif de protection de la partie victime de l'erreur, du dol, de la violence ou de la lésion.

980 Trib. Luxembourg, 5 juillet 2019, n° TAL-2019-00192.

981 Cass., 6 juillet 2017, n° 3823, conclusions de l'avocat général M. Schmitz.

982 Cass., 22 novembre 2012, n° 3124, conclusions de l'avocat général J. Petry.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

L'évolution des conceptions se marque bien, en revanche, pour la nullité pour trouble mental : dans la doctrine et dans la jurisprudence classiques, le trouble mental, présenté comme une « absence totale de consentement » était considéré comme un défaut plus grave que les « simples » vices, et on en déduisait qu'il commandait une nullité absolue, voire une inexistence du contrat. Le critère de la finalité de la règle violée aboutit à la qualification inverse : la nullité pour trouble mental a exactement le même but de protection que la nullité pour vice du consentement, ou que la nullité pour incapacité (dont elle se rapproche du reste considérablement), et elle doit, comme elles, être considérée comme une nullité relative. La solution, qui n'allait pas sans quelques incertitudes en jurisprudence, est désormais consacrée sans ambiguïté au Luxembourg (comme en France) par l'article 489 du Code civil, selon lequel l'action en individu n'appartient qu'à la personne atteinte du trouble ou à ses représentants. Il est remarquable qu'en Belgique, où il n'existait pas, jusqu'à la réforme, de texte spécial sur la question, la même solution avait été consacrée par la Cour de cassation, à propos d'un contrat passé par une personne en état d'ivresse : « le défaut de consentement, dit la Cour, ne rend pas la convention inexistante, mais seulement nulle ; cette nullité, qui ne protège que des intérêts privés, est relative »[983]. L'article 5.31 du nouveau Code civil reprend la solution.

445. Cas de nullité absolue. Le type même de la nullité absolue est celle qui sanctionne la violation d'une règle « intéressant l'ordre public et les bonnes mœurs », au sens de l'article 6 du Code civil. Cela s'impose quelle que soit la manière dont s'opère cette violation : à travers l'ensemble de l'opération ou par une clause particulière du contrat, par le biais d'un objet « hors du commerce » ou d'un mobile illicite ou immoral[984]. La solution se justifie tant dans l'approche classique des nullités – quoi de plus grave qu'une violation de l'ordre public ? – que dans la conception moderne – la prohibition des contrats contraires à l'ordre public visant à sauvegarder l'intérêt général. Cependant, cette conception moderne aboutit à mettre à part la violation des règles d'ordre public de protection – ou, si on suit la terminologie reçue en Belgique, des dispositions

983 Cass. be., 21 octobre 1971, *Pas. be.*, 1972, I, p. 174 (arrêt présenté par WÉRY, n° 321 comme « l'arrêt de la cafetière ivre »).

984 Pour la nullité absolue d'un contrat ayant une cause illicite : Cour d'appel, 17 janvier 2024, n° CAL-2023-00997.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

légales impératives[985] – qui visent, comme on l'a vu précédemment, à protéger les intérêts particuliers de certains contractants : cette nullité doit aujourd'hui, sans aucun doute, être considérée comme relative, même si son régime, sur plusieurs points, présente des particularités[986]. On lira avec intérêt dans ce sens un jugement de 2017 qui expose très clairement cette distinction en s'appuyant sur la doctrine française[987].

446. Solutions incertaines. Il existe encore, en doctrine et en jurisprudence, des hésitations sur certaines causes de nullité. Il en va ainsi pour les défauts qui affectent les deux éléments structurels du contrat que sont la cause et l'objet. Dans l'approche ancienne des nullités, on considérait que l'absence de cause et l'absence (ou l'indétermination) de l'objet, touchant un élément essentiel du contrat, devaient être sanctionnées par une nullité absolue. Dans un arrêt qui n'est pas si ancien, la Cour de cassation française avait même dit que le contrat dont l'objet était indéterminé était « dépourvu d'existence légale », ce qui semblait être une résurgence de la théorie de l'inexistence. Mais, dans la conception moderne des nullités, il paraît plus logique de considérer que les exigences touchant l'existence de la cause (comme contrepartie à l'engagement), à la possibilité ou à la détermination de l'objet, destinées à éviter qu'une partie ne s'engage pour rien ou qu'elle le soit soumise à l'arbitraire de l'autre, relèvent d'une nullité relative. S'agissant de la cause, telle est la solution admise aujourd'hui par la Cour de cassation française[988], et cette position a également été admise en Belgique.[989]. Cependant, dans un arrêt récent, la Cour d'appel du Luxembourg maintient que la nullité pour absence de cause est une nullité absolue, ce qui montre que les solutions luxembourgeoises en matière de nullité sont encore assez flottantes[990]. S'agissant de l'objet, le problème est un peu plus compliqué, et il convient sans doute de distinguer. La nullité relative s'impose dans les cas où la détermination de l'objet ou du prix[991] est

985 Wéry, n° 325.

986 Voy. dans ce sens les conclusions précitées de l'avocat général J. Pétry sur Cass., 22 novembre 2012, n° 31240.

987 Trib. Luxembourg, 19 décembre 2017, n° 182314.

988 Voy. p. ex. Cass. fr. (3e civ.), 21 septembre 2011, n° 10-21.900.

989 Voy. p. ex. Wéry, n° 299 ; Van Ommeslaghe, n° 204.

990 Cour d'appel, 23 novembre 2022, n° CAL-2020-01039, *JN Obligations*, 2022, n° 4, pp. 143-144, note H. Westendorf.

991 La nullité pour indétermination du prix ne concerne plus que la vente, puisque dans les autres contrats, la détermination par volonté unilatérale d'un contractant est aujourd'hui considérée comme licite. Voy. *supra*, nos 325 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

laissée à la décision unilatérale d'une partie. En revanche si l'objet est totalement indéterminé et indéterminable, il faudrait considérer que les parties ne se sont pas mises d'accord, qu'il n'y a pas eu rencontre des volontés : on n'est plus en présence d'un cas de nullité, mais bien d'inexistence du contrat, au sens où nous l'avons précisé précédemment[992]. La Cour de cassation du Luxembourg a jugé que la nullité pour défaut de prix était une nullité absolue en raison de l'absence d'un élément essentiel, à propos d'une cession de parts ne comportant pas de prix[993].

Très incertaines sont également les solutions à retenir en cas de non-respect des formes. Là encore, on considérait traditionnellement que l'acte auquel manquait une des formes requises par la loi était nul de nullité absolue, et même, parfois, qu'il n'avait pas d'existence. Ce raisonnement se conçoit pour le non-respect des formes traditionnelles exigées pour certains contrats par le Code civil, dans la mesure où ce formalisme (reposant généralement sur l'exigence d'un acte authentique) répond à des finalités multiples, mêlant intérêt d'une partie, intérêt général et intérêt des tiers[994]. Il en va de même pour les contrats réels, pour lesquels la loi fait de la remise de la chose une condition même de la définition du contrat, et c'est sans doute la notion d'inexistence (plus que de nullité absolue) qui est appropriée ici : ainsi, on peut dire que le contrat de prêt n'est pas conclu tant que la chose prêtée n'a pas été remise à l'emprunteur. Cette solution est expressément prévue par l'article 5.29 du nouveau Code civil belge selon lequel « En l'absence de remise de la chose, le contrat réel ne se forme pas ». De même, l'article 1172 alinéa 3 du Code civil français pose que « la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose ». En revanche, la nullité relative s'impose, logiquement, en cas de manquement au formalisme moderne (notamment en droit de la consommation), qui a exclusivement une finalité de protection du consentement et d'information d'un contractant : la doctrine se prononce nettement en ce sens, tant en Belgique[995] qu'en France[996], et la jurisprudence

992 Voy. *supra*, n° 310.

993 Cass., 10 juillet 2017, n° 3823, rejetant le pourvoi contre Cour d'appel, 18 mai 2016, n°s 39020 et 39430. Voy. aussi dans cette affaire Trib. Luxembourg, 9 mars 2011, n°s 131253 et 133501.

994 TERRÉ, SIMLER, LEQUETTE, CHENEDE 2023, n° 210.

995 WÉRY, n° 325 ; H. JACQUEMIN, « La nullité comme sanction de l'inobservation du formalisme contractuel », in P. WÉRY (dir.), *la nullité des contrats*, coll. Formation permanente CUP, vol 88, Bruxelles, Larcier, 2006, pp. 87 et s.

996 FLOUR, AUBERT, SAVAUX 2022, n° 546-3.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

française est maintenant en ce sens[997]. Cette solution, cependant, n'est pas sans inconvénient au regard des conséquences qu'on tire habituellement de la qualification de nullité relative. Mais c'est sans doute sur ce terrain, et non sur le principe même de cette qualification, qu'il faudrait corriger la solution.

B) *Les conséquences de la distinction*

447. Une distinction trop rigide. Dans la doctrine des pays du Code civil, la distinction entre nullité absolue et nullité relative est traditionnellement conçue de manière rigide, en ce qu'elle commande, de manière indissociable, les solutions à adopter sur les trois questions que pose le régime de l'action en annulation : qui peut agir ? Pendant combien de temps ? Peut-on renoncer à agir en confirmant l'acte nul ? Cette manière de raisonner, cependant, peut aboutir à des résultats peu opportuns, comme on le voit en particulier à propos de la sanction des règles d'ordre public de protection et des règles du formalisme protecteur du consentement : s'il parait logique, par exemple, de considérer que seul le contractant protégé par ces règles peut agir en nullité (conséquence première de la qualification de nullité relative), il peut paraître souhaitable de permettre néanmoins au juge de soulever d'office cette nullité pour venir au secours de ce contractant (alors que c'est normalement exclu si la nullité relative). De même, la qualification de nullité relative conduit en principe à admettre que le contractant protégé peut confirmer l'acte nul – c'est-à-dire renoncer à agir en nullité – et cette confirmation peut en particulier résulter de l'exécution volontaire du contrat : là encore, ce n'est pas forcément une solution souhaitable pour des contractants en situation de faiblesse. C'est pourquoi un certain nombre d'auteurs ont proposé de renoncer purement et simplement à la distinction entre nullités relatives et nullités absolues, pour déterminer les solutions au cas par cas en fonction de la finalité de la règle[998]. Sans aller jusque-là, la doctrine dominante, en France et en Belgique, plaide aujourd'hui pour une application plus pragmatique[999], ou moins rigide[1000], de la

997 Cass. fr. (comm.), 3 mai 1995, n° 93-12256 ; Cass. fr. (comm.), 5 février 2013, n° 12-11720.

998 Voy. notamment J. Chevallier, *Rapport français in Inexistence, nullité et annulabilité en droit civil, Travaux de l'Association Henri Capitant*, t. XIV, 1961-1962, pp. 513 et s.

999 M. Mekki, « Nullité et validité en droit des contrats : un exemple de pensée par les contraires », *R.D.C.*, 2006, p. 679.

1000 Flour, Aubert, Savaux 2022, n°s 535 et s. ; comp. en Belgique : E. Renard et E. Vieujean, « Nullité : inexistence et annulabilité en droit belge », *Ann. dr. Liège*, 1962, pp. 243 et s., spéc. pp. 264 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

distinction, permettant de dissocier, dans certains cas, en fonction de la finalité de la règle, les solutions à retenir sur les trois terrains de l'attribution du droit d'agir en nullité (1), de la prescription (2) et de la confirmation (3).

1) *Les personnes pouvant agir en nullité*

448. Nullité absolue. La première conséquence de la distinction réside dans la détermination des personnes qui peuvent agir en nullité. Si la nullité est absolue, c'est que l'acte est contraire à l'intérêt général, il faut donc multiplier les chances de dénonciation de la situation illicite, et d'annulation effective de l'acte. Il en résulte que tout intéressé peut agir en nullité du contrat. Attention, « tout intéressé », cela ne signifie pas « toute personne » : comme toute action en justice, l'action en nullité est soumise à la condition procédurale d'un intérêt légitime à agir en justice. Si, par exemple, je sais que telle personne que je déteste a acheté un appartement pour s'y livrer à une activité de prostitution, je ne serai pas recevable à agir en justice pour faire annuler le contrat de vente, et l'obliger à restituer l'appartement, car la volonté de nuire à l'acheteur qui m'anime n'est certainement pas un intérêt légitime à agir en justice. Qui sont donc les intéressés ? Ce sont, au premier chef et dans tous les cas, les parties elles-mêmes, sans distinction : ainsi, comme on l'a déjà vu, en cas de vente conclue pour une cause illicite ou immorale, l'action est ouverte aussi bien au contractant coupable qu'au contractant innocent, dès lors que le but n'est pas de protéger ce dernier, mais de faire tomber un acte contraire à l'ordre public. Mais peuvent aussi avoir un intérêt à agir certains tiers – qui sont tous ceux à qui le contrat, en tant qu'il leur est opposable, peut causer un préjudice. On citera par exemple les créanciers d'un vendeur ou d'un donateur, qui, par l'effet du contrat, voient sortir du patrimoine de leur débiteur un bien sur lequel ils pouvaient espérer se payer, ou la caution d'un débiteur contractuel qui, en faisant annuler le contrat principal, fera tomber du même coup l'acte de cautionnement qui en est l'accessoire. Par ailleurs, parce qu'elle poursuit une finalité d'intérêt général, la nullité peut être demandée par le Parquet (qui aurait connaissance du contrat), et, surtout, elle peut (et même doit) être soulevée d'office par le juge devant qui le contrat annulable serait porté, alors même qu'aucun des contractants en litige ne soulèverait cette nullité.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

449. Nullité relative. À l'inverse, la nullité relative ne peut être invoquée que par la partie que la loi avait pour finalité de protéger : si cette partie se satisfait du contrat, et ne veut pas en obtenir l'anéantissement, personne ne peut l'obtenir contre elle, puisque c'est dans son intérêt que la nullité est édictée par la loi. Telle est, on l'a vu, la solution expressément retenue par l'article 1125 du Code civil en matière d'incapacité, et par l'article 489 du Code civil pour la nullité pour trouble mental, mais elle vaut aussi bien en cas de nullité pour vice du consentement, pour lésion, pour absence de cause, pour non-respect d'une règle de forme ou pour violation d'une règle d'ordre public de protection. Cela signifie, en particulier, que l'autre partie ne peut, elle, jamais demander ou soulever la nullité du contrat, alors même qu'elle aurait intérêt à le faire. Il faut, ici, lever une ambiguïté : la partie qui peut agir en nullité, ce n'est pas celle à qui l'acte porte préjudice, c'est la partie que la loi voulait protéger. Ce n'est pas toujours la même chose : supposons un contrat passé par un incapable, mais qui se révèle très avantageux pour lui (par exemple, il a acheté un immeuble à un prix très inférieur à sa valeur) ; devenu capable, cet acheteur pourrait, en théorie, demander la nullité de la vente pour incapacité, mais on peut penser qu'il ne le fera pas ; seul le vendeur, à qui l'acte est préjudiciable, aurait intérêt à soulever cette nullité, mais il ne sera pas admis à le faire, car ce n'est pas dans son intérêt que cette nullité a été édictée[1001]. Il convient seulement de préciser que, à la partie protégée, il convient d'assimiler ses représentants : dans le cas de l'incapacité, tant qu'elle dure, ce n'est pas l'incapable lui-même qui pourra agir en nullité, mais son ou ses représentants légaux.

Le fait que l'action en nullité relative soit réservée à la personne que la loi avait pour finalité de protéger exclut en général que des tiers au contrat puissent agir. Il faut cependant mettre à part le cas où la règle violée n'avait pas pour but de protéger une des parties, mais un tiers : l'exemple typique est celui de l'article 215, alinéa 2 du Code civil qui subordonne la vente du logement de la famille à l'autorisation du conjoint[1002]. Le contrat non autorisé est nul d'une nullité relative, mais qui ne peut être invoquée que par le conjoint n'ayant pas donné son consentement dans l'année à partir

[1001] Le vendeur pourrait demander la nullité sur le fondement de l'article 1674 du Code civil s'il avait été lésé de plus des 7/12e. Mais c'est une autre cause de nullité, édictée cette fois dans son intérêt et dont l'acheteur, lui, ne pourrait pas se prévaloir.

[1002] Voy. *supra*, nº 297.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

du jour où il a eu connaissance de l'acte ; la nullité ne peut donc être demandée ni par le conjoint vendeur ni par l'acheteur[1003]. Il faut également souligner que les créanciers d'une partie, alors même qu'ils n'ont pas qualité pour demander en leur propre nom la nullité relative d'un contrat passé par leur débiteur, peuvent parfois, à certaines conditions, agir en nullité au nom de leur débiteur par la voie de l'action oblique[1004].

Parce que la nullité relative est d'intérêt privé, elle ne peut pas en principe, dans l'opinion traditionnelle, être soulevée d'office par le juge : si un litige naît au sujet d'un contrat dont l'une des parties était incapable au moment de sa formation, et que cet incapable ne soulève pas la nullité de ce contrat, il n'appartient pas au juge de dire « ce contrat est nul, puisque vous étiez incapable ». On a vu cependant que, en matière de clauses abusives, la CJUE avait imposé la solution contraire : confronté à un contrat dans lequel figure une clause abusive, le juge national, non seulement peut, mais doit soulever d'office la nullité de cette clause[1005]. Cette solution a été intégrée par une loi du 27 août 2024 dans l'article L.211-2 du Code de la consommation, selon lequel « Lorsqu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires, et après avoir recueilli les observations des parties, le juge écarte d'office l'application de la clause abusive. ». Cette solution pourrait être transposée, à notre avis, à toutes les exigences d'ordre public de protection, de fond ou de forme, même à celles qui ne relèvent pas du droit européen, car elle paraît nécessaire pour assurer l'effectivité de ces règles, du moins chaque fois que la situation de faiblesse qui a justifié l'édiction de la règle protectrice se prolonge au-delà du moment de la formation du contrat[1006]. Dans le cas du consommateur, par exemple, celui-ci n'est pas nécessairement conscient de la nullité du contrat qu'il a passé ou des clauses qui y figurent : s'il veut échapper à leur application, mais que, par ignorance ou parce que son cocontractant l'a convaincu que le contrat était parfaitement régulier, il ne pense pas à soulever la nullité, il apparaît entrer dans la mission du juge de « venir à son secours ».

[1003] Dans ce sens : Cass., 23 janvier 2014, n° 5/14, n° 3278 du registre ; obs. P. ANCEL, *Pas.*, 36, pp. 743-744 ; Trib. Luxembourg, 14 juillet 2023, n° TAL-2021-08344.

[1004] Voy. *infra*, n°s 723 et s.

[1005] Voy. *supra*, n° 415.

[1006] En droit français, l'article L. 141-4 du Code de la consommation prévoit désormais, d'une manière générale que « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Depuis la loi du 17 mars 2014, il le doit, conformément à la jurisprudence de la C.J.U.E., lorsque le litige met en évidence le caractère abusif d'une clause.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Allant au-delà, on peut même se demander s'il ne faudrait pas nuancer, pour toutes les causes de nullité relative (et pas seulement à la violation de l'ordre public de protection) l'affirmation traditionnelle selon laquelle le juge ne peut pas soulever d'office la nullité : ce qui est certainement exclu, c'est que le juge soulève une nullité relative contre la volonté du contractant protégé qui voudrait en obtenir l'exécution ; mais, si, à l'inverse, le contractant protégé veut faire tomber le contrat, et que le juge découvre, dans les faits qui lui sont soumis, une cause de nullité que ce contractant ne pense pas à invoquer, pourquoi ne pourrait-il pas, après avoir provoqué les observations des deux parties sur ce point, soulever cette nullité qui vient au soutien de la prétention de la partie qui pourrait l'invoquer ?[1007]

2) *La prescription de l'action en nullité*

450. Problématique. D'une manière générale, en droit luxembourgeois comme dans la plupart des systèmes juridiques, le titulaire d'un droit ne peut pas l'exercer éternellement : au bout d'un certain temps, le droit, ou du moins l'action qui permet d'en demander l'exécution, est éteinte par prescription[1008]. Cette prescription extinctive s'applique aux actions en nullité comme à toute autre action. Elle obéit à des conditions différentes selon que la nullité est relative ou absolue (**a**), mais elle produit dans tous les cas les mêmes effets, qui ne sont pas aussi absolus qu'on pourrait le croire (**b**).

a. *Conditions de la prescription*

451. Nullités relatives. La prescription des actions en nullité est une des rares questions qui ont été traitées par les rédacteurs du code de 1804 en matière de nullité, et encore de manière très incomplète. L'article 1304 du Code civil dispose que « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ». À l'origine, le délai prévu était de dix ans, mais il a été ramené à cinq par la loi du 11 août 1982. Bien que le texte ne le dise pas expressément, il a toujours été admis qu'il ne visait que les actions en nullité relative. Le délai ainsi prévu est beaucoup plus court que le délai de droit commun de la prescription qui est, au Luxembourg, de 30 ans[1009], ce qu'on peut expliquer par plusieurs considérations. D'une part, la nullité est de pur intérêt privé, et on peut supposer que la partie qui,

[1007] Dans ce sens, voy. O. Gout, *Le juge et l'annulation du contrat*, préf. P. Ancel, Aix-en-Provence, PUAM, 1999, n°s 468 et s.

[1008] Pour une présentation générale des règles relatives à la prescription, voy. *infra*, n°s 932 et s.

[1009] Il n'est plus que de 5 ans en France depuis 2008, ce qui, sur ce point, a fait disparaître la différence entre la nullité relative et la nullité absolue. Il en va de même en droit belge, où les deux délais sont de 10 ans. Mais le point de départ du délai n'est pas nécessairement le même dans les deux cas.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pouvant agir, ne l'a pas fait pendant cinq ans a finalement considéré que celui-ci était satisfaisant pour elle. D'autre part, il n'apparaît pas souhaitable que l'autre partie, qui, elle, ne peut pas agir en nullité, soit laissée trop longtemps dans l'incertitude quant à l'attitude de son cocontractant, et donc quant au sort du contrat[1010].

Encore faut-il savoir à partir de quel moment court ce délai. L'article 1304 du Code civil répond à cette question, mais seulement dans certains cas particuliers : en cas de violence, le délai court à compter du moment où la violence a cessé, en cas d'erreur ou de dol, à compter du jour où le contractant s'est aperçu qu'il s'était ou qu'il avait été trompé, en cas d'incapacité à partir du jour où le mineur est devenu majeur, et, pour les majeurs protégés à partir du jour où, leur incapacité ayant cessé, ils ont eu connaissance de l'acte qu'ils avaient passés (peut-être inconsciemment) du temps de leur incapacité. Ces solutions ne sont que l'application d'un principe général selon lequel la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas agir (*Contra non valentem agere non currit praescriptio*)[1011]. On peut donc les généraliser à d'autres causes de nullité relative. Par exemple, pour un acte passé sous l'empire d'un trouble mental, le délai ne courra qu'à compter du jour où, le trouble mental ayant cessé, la personne aura pris conscience de l'acte passé[1012]. Pour les actes contraires à un ordre public de protection, de fond ou de forme, on peut davantage hésiter : il faut rechercher à quel moment la situation qui justifiait la protection a pris fin. Parfois, la situation d'infériorité et le risque d'abus de la situation de force est lié aux relations existantes au moment de la formation du contrat, et cesse dès que le contrat est conclu : c'est alors à compter de ce moment que le délai doit courir[1013]. Mais dans d'autres cas, la situation de faiblesse perdure après la conclusion du contrat : un consommateur, par exemple, reste tout aussi inexpérimenté après la conclusion du contrat, et, s'il n'agit pas immédiatement pour faire tomber telle ou telle stipulation contractuelle contraire à une loi impérative, c'est le

[1010] Pour éviter cet inconvénient le nouveau Code civil français prévoit, assez intelligemment, que « une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion » (C. civ., art. 1183).

[1011] Voy. *infra*, n° 944.

[1012] Pour une application récente dans la jurisprudence française, Cass. fr., 15 janvier 2015, n° 13-26279.

[1013] Il en va ainsi par exemple pour la prohibition du pacte commissoire en matière de gage, qui est liée au risque que le débiteur, pressé par le besoin d'obtenir un crédit, accepte n'importe quoi de son créancier au moment du prêt.

LARCIER INTERSENTIA
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

plus souvent parce qu'il n'a aucune conscience de sa nullité. Mais cette considération aboutirait à retarder indéfiniment le point de départ du délai pour agir. C'est pourquoi on ne voit pas d'autre solution que de faire courir le délai à compter du contrat[1014]. Une solution différente semble cependant s'imposer pour les clauses abusives, qui, selon la directive de 1993, « ne lient pas les consommateurs », ce qui, selon la CJUE, implique que le consommateur (ou le juge) peut en soulever la nullité sans limite de délai[1015].

Le délai de cinq ans de l'article 1304 du Code civil ne vaut cependant que sous réserve des cas où l'action « est limitée à un moindre temps par une loi particulière ». De nombreux textes fixent en effet un délai plus court pour certaines actions en nullité, tout en en fixant le point de départ : l'article 1676 du Code civil (deux ans à compter du jour de la vente pour la rescision pour lésion dans la vente d'immeuble), l'article 1118 du Code civil (un an à partir de la conclusion du contrat pour la lésion qualifiée), l'article 215, alinéa 2 du Code civil (un an à compter du moment où le conjoint qui n'a pas donné son autorisation a eu connaissance de l'acte portant sur le logement de la famille), etc.

452. Nullités absolues. En l'absence de tout texte, il est admis que la prescription de l'action en nullité absolue est, elle, soumise au délai de droit commun de trente ans en matière civile, dix ans en matière commerciale. Ce délai court à compter de la date du contrat contraire à l'ordre public. La durée plus longue de la prescription semble commandée par l'intérêt général en cause : il faut multiplier les chances de dénonciation de la situation illicite créée par le contrat. Dans la conception classique des nullités, il était même soutenu que les actions en nullité absolue étaient imprescriptibles. Cette opinion s'imposait pour les auteurs qui identifiaient la nullité absolue à une « inexistence » de contrat, qui jouait de plein droit, sans avoir besoin d'être prononcée en justice. Cette solution n'est plus soutenue aujourd'hui lorsqu'on est en présence d'une véritable cause de nullité, dès lors qu'on admet qu'une telle nullité, même absolue, ne peut résulter que d'une décision judiciaire. Elle conserve tout son sens, à notre avis, pour les véritables cas d'inexistence, ceux qui résultent tout simplement de ce que le contrat ne s'est pas formé, faute d'une concordance entre une offre et une acceptation.

[1014] En ce sens, en France : Cass. fr. (1re civ.), 21 janvier 1992, n° 90-18121.
[1015] C.J.C.E., 21 novembre 2002, C-473/00, considérants 34 à 36.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Si j'ai dit non à une offre qu'on me faisait, je pourrai toujours, sans limite de temps, faire constater par un juge qu'aucun contrat n'a jamais été formé.

Il existe aujourd'hui en France un courant doctrinal important qui raisonne de la même manière lorsqu'on est en présence d'une clause contractuelle que la loi « répute non écrite », dans laquelle ces auteurs voient une forme d'inexistence par l'effet de la loi. La Cour de cassation française a consacré ce raisonnement dans plusieurs arrêts[1016], et il semble que la même idée ait inspiré la Cour de cassation belge[1017]. Le raisonnement rejoint du reste celui que suit la jurisprudence européenne lorsqu'elle considère que la nullité d'une clause abusive qui « ne lie pas » le consommateur peut être invoquée à tout moment[1018]. Nous retrouverons la question dans son ensemble en étudiant d'une manière générale la problématique des « clauses réputées non écrites »[1019].

b. *Effets de la prescription*

453. ***Quae temporalia.*** La prescription n'empêche pas complètement la ou les personnes qui sont titulaires de l'action d'invoquer la nullité après l'expiration du délai. Selon une règle traditionnelle, la prescription ne bloque que la possibilité d'invoquer la nullité par voie d'action, mais elle n'empêche pas de la soulever par voie d'exception, en réponse à une demande d'exécution du contrat par l'autre partie. Cette règle, qui n'était écrite nulle part dans le code de 1804, est généralement citée sous sa forme latine : *quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum* (ce qui est temporaire par voie d'action est perpétuel par voie d'exception). Il faut supposer qu'une partie, qui avait qualité pour agir en nullité, a laissé passer le délai pour agir. Mais, comme elle n'a pas encore exécuté le contrat, son cocontractant agit contre elle pour obtenir cette inexécution, et c'est pour se défendre qu'elle soulève la nullité par voie d'exception. L'adage *quae temporalia* lui permet de le faire bien que l'action en nullité soit prescrite. La solution est habituellement justifiée par la même idée que celle qui justifie la prescription elle-même : ne pas remettre en cause les situations acquises au bout d'un certain temps. La règle est applicable quelle que soit la nature de la nullité, mais en pratique elle joue surtout pour les nullités relatives, pour lesquelles il existe un décalage important entre la prescription de l'action en nullité

[1016] Cass. fr. (3e civ.), 9 mars 1988, n° 86-17869 ; Cass. fr. (3e civ.), 26 avril 1989, n° 87-18384 ; Cass. fr. (3e civ.), 19 novembre 2020, n° 19-20.405 P ; Cass. fr. (3e civ.), 30 juin 2021, n° 19-23.038 B ; Cass. fr. (3e civ.), 8 février 2024, n° 22-16.422 B.

[1017] Cass. be., 25 avril 2003, *R.G.D.C.*, 2005, p. 42, note P. WÉRY.

[1018] C.J.C.E., 21 novembre 2002, préc.

[1019] Voy. *infra*, n° 479.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

(cinq ans) et celle de l'action en exécution du contrat. Elle fait l'objet d'une jurisprudence très abondante en France, où la Cour de cassation en a fait un « principe » qu'elle vise dans ses décisions[1020]. Elle est également appliquée par la Cour de cassation belge[1021]. La solution est aujourd'hui expressément consacrée par l'article 1185 du Code civil français et par l'article 5.60 du nouveau Code civil belge. La jurisprudence luxembourgeoise applique régulièrement la règle[1022]. Il faut cependant noter que la jurisprudence française donne à la règle une portée très limitée, en ne la faisant jouer que dans les cas où l'acte n'a reçu aucun commencement d'exécution. La partie qui a commencé d'exécuter le contrat, et qui a laissé passer le délai pour agir en nullité, ne peut plus invoquer la nullité pour refuser de continuer d'exécuter[1023]. Cette solution, aujourd'hui consacrée par l'article 1185 du Code civil français, a été reprise par la jurisprudence luxembourgeoise récente[1024]. La jurisprudence belge soumet également la règle à des conditions restrictives[1025].

3) *La confirmation de l'acte nul*

454. Notion. Il arrive qu'une personne, qui pourrait agir en nullité d'un contrat, juge que, finalement, ce contrat lui convient, et qu'elle renonce à agir en nullité de celui-ci : par exemple, une personne, qui a passé, du temps de sa minorité un contrat qu'elle n'avait pas la capacité de conclure, déclare, une fois qu'elle est devenue majeure, vouloir conserver le bénéfice de cet acte. C'est ce qu'on appelle la confirmation de l'acte nul. Les rédacteurs du Code civil ont consacré à cet acte – qu'ils appellent aussi ratification[1026] – un article assez complexe, l'article 1338, qu'ils ont bizarrement placé au sein des textes relatifs à la preuve. Les dispositions de ce texte

1020 Cass. fr. (3e civ.), 10 mai 2001, n° 99-11762.

1021 Cass. be., 22 octobre 1987, *R.C.J.B.*, 1991, p. 288, note F. Glansdorff.

1022 Cour d'appel, 3 juin 2010, n° 3398 ; Cour d'appel, 7 mars 2012, n° 34544 du rôle ; Trib. Diekirch, 28 février 2017, n° 15136 ; Trib. Luxembourg, 19 décembre 2017, n° 182314 ; Cour d'appel, 25 novembre 2020, n° CAL-2018-00824.

1023 Voy. encore récemment Cass. fr. (1re civ.), 15 janvier 2015, nos 13-25512 et 13-25513 (à propos d'emprunteurs ayant commencé de rembourser le prêt).

1024 Trib. Diekirch, 28 février 2017, n° 15136 ; Cour d'appel, 25 novembre 2020, n° CAL-2018-00824.

1025 C. Eyben, « La prescription des actions en nullité et l'exception de nullité », in *La nullité des contrats*, coll. Formation permanente C.U.P., Bruxelles, Larcier, 2006, pp. 189 et s.

1026 Ce terme n'est plus utilisé aujourd'hui dans ce sens. Il désigne seulement l'acte par lequel une personne, au nom de qui un contrat a été passé par un représentant sans pouvoir, ou pour qui un tiers s'est porté fort, se déclare d'accord avec le contrat. Voy. *supra*, nos 300 et 312.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

et les solutions jurisprudentielles élaborées sur son fondement sont aujourd'hui reprises en substance par les articles 1182 du Code civil français et 5.61 du nouveau Code civil belge.

La confirmation doit être distinguée de la régularisation de l'acte, qui consiste à réparer un contrat, imparfait à l'origine, en satisfaisant *a posteriori* à la condition de validité qui lui manquait : par exemple, en ajoutant dans l'acte initial les mentions obligatoires qui n'y figuraient pas à l'origine. À la différence de la régularisation, la confirmation ne touche pas le contrat lui-même, c'est seulement une cause d'extinction de l'action permettant de le faire annuler : dans l'exemple donné, le contrat, passé à l'origine par un incapable, n'est pas refait, et il reste toujours atteint de la même cause de nullité ; mais il ne sera jamais annulé dans la mesure où l'incapable a renoncé à agir en nullité et qu'il était seul à pouvoir le faire[1027]. Cette analyse de la confirmation en commande à la fois les conditions (**a**) et les effets (**b**).

a. *Conditions de la confirmation*

455. Nature de la nullité. La confirmation n'est possible que pour les contrats nuls de nullité relative : il s'agit en effet de nullités destinées à protéger les intérêts privés d'un contractant, et celui-ci est maître de ses intérêts. De même qu'il peut seul choisir d'agir ou de ne pas agir en nullité, il peut renoncer à le faire. En revanche, si on est en présence d'une nullité absolue, il est logique de ne pas permettre la confirmation : non seulement, une telle renonciation, émanant d'une des personnes habilitées à demander la nullité, ne pourrait avoir aucun effet sur les autres intéressés, et ne pourrait de toute façon pas empêcher le juge de soulever la nullité ; mais il faut même admettre que la confirmation ne pourrait avoir aucun effet à l'égard de celui qui l'a faite, car sinon elle diminuerait les chances de faire tomber un contrat contraire à l'intérêt général, ce qui est en soi contraire à cet intérêt général.

La confirmation pourrait également être exclue dans le cas particulier des clauses réputées non écrites, alors même que la règle violée par une telle clause était protectrice des intérêts privés d'un contractant. Si on assimile, comme en droit français, ce « réputé non écrit » à un cas d'inexistence de la clause par l'effet d'une fiction légale, on doit considérer que la clause est rayée de plein droit du contrat sans qu'il soit nécessaire d'une action en justice pour la faire tomber. Par conséquent, la personne

[1027] Sur la confirmation, voy. spéc. en droit français la thèse fondamentale de G. COUTURIER, *La confirmation des actes nuls*, Paris, LGDJ, 1972.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

protégée ne peut pas renoncer à une action qui n'a pas d'objet. C'est en tout cas ce qu'il faut décider pour les clauses abusives qui, selon la directive européenne « ne lient pas » le consommateur[1028].

456. Moment de la confirmation. D'une manière générale, la confirmation ne peut intervenir que lorsque la raison qui justifiait la nullité a disparu : par exemple, un incapable ne peut confirmer que lorsque son incapacité a cessé, un contractant victime d'un vice du consentement ne peut renoncer à agir en nullité que s'il s'est aperçu de son erreur ou si la contrainte qui pesait sur lui a disparu, etc. Sinon la confirmation serait atteinte de la même cause de nullité que le contrat lui-même. Il en résulte, en particulier, qu'il n'est pas possible de renoncer à agir en nullité dans le contrat même qui est affecté de la cause de nullité. La Cour de cassation du Luxembourg a fait application de cette solution à propos de la rescision pour lésion dans un partage, en rappelant que « une confirmation du caractère lésionnaire du partage dans l'acte de partage lui-même n'est pas opérante et ne peut constituer un obstacle à l'action en rescision pour cause de lésion »[1029]. Il n'est pas utile, pour justifier la solution, de dire que « la sanction de la rescision pour cause de lésion de plus du quart, applicable au partage des biens de la communauté entre époux, est une « règle d'ordre public » : on est ici en présence d'une nullité relative, qu'il appartient à la victime de la lésion d'invoquer ou de ne pas invoquer, et à laquelle elle peut librement renoncer, selon l'appréciation qu'elle fait de ses intérêts ; mais, comme dans tous les cas de nullité relative, la protection que donne la loi serait illusoire si elle pouvait le faire dans l'acte lésionnaire lui-même, à un moment où on peut craindre la pression exercée par le ou les copartageants.

C'est également le raisonnement qu'on va suivre pour les nullités fondées sur une règle d'ordre public de protection : pour savoir si la confirmation est possible, il faut rechercher si la situation de faiblesse qui justifiait la règle a disparu. Dans un certain nombre de cas, la protection ne se justifie qu'au moment de la conclusion du contrat : c'est le cas, par exemple, pour la prohibition du pacte commissoire dans le gage, que la Cour d'appel rattache pertinemment à l'ordre public de protection[1030] ; la prohibition se justifie parce qu'on craint que, au moment où il fournit la garantie, l'emprunteur ne soit prêt à tous les sacrifices pour obtenir son crédit. Mais dès qu'il l'a obtenu, il cesse d'être sous la contrainte, et il peut renoncer à invoquer la nullité du pacte commissoire, tout comme d'ailleurs il pourrait consentir un pacte qui ne figurait pas à l'origine dans le contrat. Le même raisonnement pourrait être mené

[1028] Voy. *supra*, n° 452 à propos de l'imprescriptibilité de la sanction dans un tel cas et *infra*, n° 475 sur le problème général des clauses réputées non écrites.

[1029] Cass., 15 décembre 2011, n° 71/11, n° 2905 du registre.

[1030] Cour d'appel, 15 décembre 1992, *Pas.*, 29, p. 37. Voy. *supra*, n° 408.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

en matière de bail : le locataire, une fois qu'il a obtenu son bail, peut renoncer à invoquer la nullité de diverses clauses défavorables dont la prohibition n'est justifiée que par le souci d'éviter que le locataire ne se les fasse imposer à un moment où la nécessité d'obtenir un logement ou un lieu d'exercice de son activité le rend particulièrement vulnérable. Dans ces hypothèses, on raisonne parfois en termes de « droits acquis », et c'est ce que fait la Cour d'appel : on dit que la renonciation est possible dès que le contractant a acquis les droits qui lui sont garantis par la loi d'ordre public. Cette formule ne couvre cependant pas toutes les hypothèses, car, dans d'autre cas, la situation de faiblesse perdure après la conclusion du contrat, de sorte que la confirmation continue d'être impossible. C'est le cas en droit du travail, où, d'une manière générale, le salarié ne peut renoncer aux avantages que lui donne la loi (et donc à invoquer la nullité des clauses de son contrat qui y seraient contraires) qu'après la cessation du contrat de travail, car c'est seulement à ce moment-là qu'il retrouve sa pleine et entière liberté. C'est le cas aussi en droit de la consommation, où la situation de faiblesse du consommateur dure tant qu'il est consommateur, ce qui devrait impliquer qu'il n'aurait jamais la possibilité de confirmer un contrat ou des clauses nulles, alors même que cette nullité a été édictée dans son intérêt[1031].

457. Formes de la confirmation. Quant à la manière dont la confirmation doit avoir lieu, l'article 1338 du Code civil se montre de prime abord particulièrement exigeant : la confirmation apparaît dans l'alinéa 1er de ce texte comme un acte formel devant contenir « la substance de l'obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action (en nullité) est fondée »[1032]. Cependant l'alinéa 2 du texte réduit considérablement la portée de ces exigences, en posant qu'il n'est pas nécessaire que la confirmation soit expresse ; elle peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire de l'acte « après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée ». En pratique, c'est le plus souvent d'une telle confirmation tacite qu'il est question devant les tribunaux : lorsque l'une des parties soulève la nullité, l'autre lui rétorque qu'elle ne peut plus le faire car elle a exécuté l'acte sans protester jusque-là, et cette exécution vaut confirmation tacite. Tout le débat portera alors sur le point de savoir si l'exécution était bien « volontaire », c'est-à-dire si la partie savait que l'acte était annulable, et qu'elle l'a néanmoins exécuté en pleine connaissance de cause. C'est aussi souvent pour savoir si une telle exécution vaut ou non confirmation qu'on se demande si la nullité est relative ou absolue. On voit ainsi comment le caractère relatif attribué à une nullité peut se retourner contre la personne

[1031] S'agissant de la nullité des clauses abusives, on parvient à la même solution en disant qu'il ne s'agit pas vraiment d'une nullité, mais d'une véritable inexistence légale, qui exclut de toute façon toute confirmation.

[1032] Pour une application de ces conditions, voy. Cour d'appel, 13 décembre 2017, n° 43279 ; *J.T.L.*, 2018, p. 140 ; Trib. Luxembourg, 18 mai 2021, n° TAL-2018-06843.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

protégée – et cet inconvénient est particulièrement sensible dans les matières d'ordre public de protection, ce qui explique les distorsions que la jurisprudence, notamment européenne, fait subir au droit commun de la nullité relative dans ce domaine.

b. *Effets de la confirmation*

458. Effet relatif. Parce qu'elle n'est pas une régularisation de l'acte, mais simplement une renonciation à agir en nullité, il ne faut pas dire, comme le font certains auteurs, que la confirmation a pour effet de « valider l'acte nul ». Il n'est pas plus exact de dire que « [l]a confirmation est l'acte juridique par lequel une personne fait disparaître les vices dont se trouve entachée une obligation, contre laquelle elle aurait pu se pourvoir par voie de nullité ou de rescision »[1033]. En réalité, la confirmation n'a aucun effet sur le contrat lui-même, elle n'a d'effet qu'à l'égard de la personne qui en est l'auteur, qui ne peut plus agir en nullité de l'acte (cf art. 1185 C. civ. fr. et art. 5.81 C. civ. be.). Si plusieurs personnes avaient qualité pour agir en nullité d'un contrat – par exemple deux acquéreurs qui ont été victimes de la même erreur lors de leur acquisition – le fait que l'une d'elles confirme n'empêchera pas l'autre d'agir en nullité si elle le souhaite.

L'article 1338 du Code civil dispose par ailleurs que la confirmation produit ses effets « sans préjudice néanmoins du droit des tiers » (formule reprise par le nouvel article 1185 du Code civil français). L'hypothèse est qu'une personne, ayant passé un contrat de vente nul, vend une seconde fois le bien à un autre acheteur. Si elle confirme la première vente, cela ne pourra pas avoir pour effet de priver le second acquéreur du contrat qu'il a passé.

SECTION 2. LES EFFETS DE LA NULLITÉ

459. Effets communs à toutes les nullités. La distinction entre les nullités absolues et les nullités relatives, qui domine la matière des nullités dans les pays du Code civil, n'a d'incidence que sur le régime de l'action en nullité, donc sur la plus ou moins grande facilité à faire prononcer la nullité. Elle n'en a aucune quant aux effets de la nullité, une fois qu'elle est prononcée par le juge : qu'il soit nul de nullité absolue ou relative, un contrat est tout aussi nul. La nullité se traduit, dans tous les cas, par l'anéantissement du contrat, qui, n'étant pas « légalement formé », n'a plus force obligatoire.

[1033] Cour d'appel, 16 février 2000, *Pas.*, 31, p. 239 ; Trib. Luxembourg, 14 novembre 2014, n° 161 652.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

L'étendue exacte de cet anéantissement suscite cependant de multiples difficultés, à la fois dans le temps (§ 1), et quant aux actes qui en sont frappés (§ 2).

§1. Etendue de la nullité dans le temps

460. Retour sur le passé. Il va de soi que, lorsque le contrat sera annulé, les deux parties seront libérées des obligations qu'il avait fait naître : le contrat nul n'a plus force obligatoire. C'est du reste très souvent pour échapper à l'exécution de ses obligations qu'un contractant, qui n'a pas encore exécuté, ou pas complètement, soulèvera la nullité par voie d'exception. Mais, très souvent, le contrat aura déjà produit toutes sortes d'effets avant le prononcé de son annulation par le juge. Les obligations qu'il avait fait naître auront peut-être déjà été exécutées : le vendeur aura livré la chose et l'acheteur aura payé le prix, le prêteur aura mis la chose ou la somme à disposition de l'emprunteur et celui-ci aura commencé de rembourser, le locataire aura commencé de vivre dans les lieux loués et aura payé des loyers, etc. Certains effets auront pu également se produire de manière automatique, notamment dans les contrats translatifs de propriété, où, comme on le sait, le transfert se produit de plein droit dès le jour de l'accord : l'acheteur sera donc devenu propriétaire du bien acheté, qu'il aura peut-être loué, vendu, détérioré, etc. Or voilà qu'un juge va dire, plusieurs années plus tard, que le contrat était nul, qu'il ne valait rien ! Quelles conséquences cette annulation va-t-elle avoir sur tous ces effets passés ? Dans les pays du Code civil, on considère qu'en principe la nullité a un effet rétroactif, ce qui amène à effacer les effets passés. Mais ce principe, qui suscite beaucoup de difficultés dans sa mise en œuvre (A) connaît de multiples exceptions (B).

A) *Principe*

461. Rétroactivité. Lorsqu'un contrat est annulé, on va faire comme si, dès le début, il n'avait pas existé, ou du moins pas été apte à produire des effets légaux. On va donc chercher à effacer les effets qui, en fait, se sont produits. Cet anéantissement rétroactif va de soi dans les systèmes juridiques qui admettent que certaines causes de nullité opèrent de plein droit, sans que les parties n'aient rien à faire ni à dire, et sans que le juge ait à se prononcer – par

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

exemple, les actes qui sont « *void* » en *common law*[1034], ou frappés de « *Nichtigkeit* » en droit allemand. Il est moins évident dans le système des pays du Code civil où, par principe, toute nullité est le résultat d'une décision judiciaire, qui ne se contente pas de constater que l'acte n'a jamais existé, mais qui prononce la nullité. La rétroactivité de la nullité est alors une fiction : jusqu'à la décision du juge, l'acte était valable (et il aurait pu le rester indéfiniment si personne n'avait agi en nullité), mais on va faire comme s'il n'avait jamais eu d'existence légale. Cette fiction est, cependant, aisée à justifier : dans la mesure où la nullité sanctionne le défaut d'une des conditions de validité du contrat, il paraît conforme à l'efficacité de la sanction que les effets produits soient effacés. Si on considérait par exemple que l'annulation d'un contrat de vente n'opérait que pour l'avenir – l'acheteur devant rétrocéder la chose vendue au vendeur selon un prix fixé compte tenu de la valeur actuelle du bien – cela reviendrait à admettre qu'un contrat non légalement formé a pu avoir, un certain temps, force obligatoire.

462. Restitutions. Le caractère rétroactif a pour première conséquence que, si le contrat a déjà été exécuté, chaque partie doit restituer ce qu'elle a reçu en exécution du contrat annulé.

Ces restitutions suscitent de nombreuses difficultés qui ne peuvent ici qu'être survolées[1035]. En l'absence de réglementation spécifique dans le Code civil, la jurisprudence a traité les restitutions suite à l'anéantissement du contrat comme une forme de répétition de l'indu, relevant des articles 1376 et suivants du Code civil[1036]. Cette référence existe toujours dans la jurisprudence belge[1037], tandis que la Cour de cassation française posait dès avant la réforme que « les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu, mais seulement des règles de la nullité »[1038]. La Cour d'appel du Luxembourg préfère quant à elle fonder l'obligation de restitution sur l'enrichissement sans cause[1039]. On trouve désormais des règles très détaillées sur les restitutions tant dans le Code civil français (art. 1352 à 1352-9) que dans le nouveau Code

[1034] Voy. *supra*, n° 439.

[1035] Pour une étude approfondie en droit français, voy. P. Malinvaud, M. Mekki et J Seube, *Droit des obligations*, 17e éd., Paris, Lexis Nexis, 2023, nos 432 et s.

[1036] Voy. *infra*, nos 642 et s.

[1037] Cass. be., 24 septembre 1976, *Pas. be.*, 1977, I, p. 101.

[1038] Cass. fr. (1re civ.), 24 septembre 2002, n° 00-21278 (pour un enjeu de prescription).

[1039] Cour d'appel, 13 octobre 2010, *Pas.*, 35, p. 270.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

civil belge (art. 5.116 à 5.124), qui valent aussi bien pour le cas de la résolution que pour celui de la nullité, et qui pourraient servir de référence à la jurisprudence luxembourgeoise.

Les restitutions doivent permettre de replacer chaque partie dans la situation où elle se trouvait au moment du contrat. Il en résulte qu'il ne faut pas tenir compte des variations de valeur des prestations depuis cette époque. Si, par exemple, j'ai acheté un bien qui, à l'époque de la vente, valait 100 000, et que j'ai payé à ce prix, je devrai rendre le bien, et je ne récupérerai que 100 000, même si, entre temps, la valeur du bien était passée à 200 000[1040]. Solution logique car il convient de faire comme si le contrat n'avait jamais été passé : le vendeur aurait alors conservé le bien, et aurait profité de l'augmentation de valeur. Pour la même raison, le bien doit être restitué dans l'état où il se trouvait au moment du contrat, ce qui n'est pas toujours possible. Si l'acheteur a apporté des améliorations à ce bien, le vendeur devra lui rembourser le montant de ces améliorations. Si, à l'inverse, le bien a été détérioré, ou subi l'usure du temps, l'acheteur devra, en plus du bien, verser une somme compensant cette détérioration ou cette usure. Et, si le bien a été complètement détruit, la restitution s'opérera intégralement en valeur, cette valeur étant appréciée d'après l'état où le bien se trouvait lors de la vente. On raisonnera de la même manière en cas d'annulation d'un contrat portant sur un service, par nature irrestituable : le client récupérera le prix qu'il a payé, et il devra rembourser ce que cela a coûté au prestataire de services (qui sera, dans ce cas, privé de son bénéfice) (C. civ. fr., art. 1352-8).

Naturellement, ces restitutions ne vont pas suffire à replacer exactement le vendeur dans la situation où il était à l'origine, car, pendant tout le temps qui s'est écoulé entre le moment de la conclusion du contrat et son annulation, il aura été privé de l'usage et de la jouissance du bien, dont l'acheteur aura en revanche profité. Contrairement à la jurisprudence française, qui posait avant la réforme que les restitutions n'incluent pas la compensation de cette perte d'usage et de jouissance[1041], la Cour d'appel du Luxembourg, raisonnant sur le terrain de l'enrichissement sans cause, juge qu'une indemnité peut être versée au vendeur pour tenir compte de l'avantage que l'acheteur a retiré de l'usage de la chose[1042]. C'est la solution que consacre désormais l'article 1352-3 du Code civil français. En sens inverse, l'acheteur ne peut pas demander au vendeur de lui reverser les intérêts qu'il a pu percevoir sur le prix de vente pendant tout le temps où il a été en possession de la somme[1043]. On applique ici, par analogie, les règles relatives au paiement de l'indu, et notamment l'article 1378 du Code civil selon lequel celui qui a reçu un paiement à tort ne doit restituer les intérêts qu'à partir du jour où ils lui ont été redemandés, et non à partir du jour où il encaissé le paiement, sauf s'il était de mauvaise foi. La solution est reprise par l'article 1352-7 du Code civil français.

463. Anéantissement du transfert de propriété. La rétroactivité produit des conséquences particulièrement draconiennes dans les contrats translatifs de propriété. On va considérer en effet que ce transfert n'a jamais eu lieu, notamment que, si une vente est

[1040] Voy. en ce sens à propos d'une cession de parts sociales : Cour d'appel, 6 avril 2011, *J.T.L.*, 2012, p. 58 ; *Pas.*, 35, p. 618.

[1041] Cass. fr. (ch. mixte), 9 juillet 2004, n° 02-16302.

[1042] Cour d'appel, 12 mars 2008, *Pas.*, 34, p. 270.

[1043] Cour d'appel, 6 avril 2011, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

annulée, le vendeur est toujours resté propriétaire de la chose et que l'acheteur ne l'a jamais été. En conséquence, tous les actes que l'acheteur a pu passer, en tant que propriétaire, sur le bien vendu, devraient être eux-mêmes annulés (revente, constitution d'hypothèque ou de gage, bail, etc.). La rétroactivité produit cependant de telles conséquences négatives à l'égard des tiers qu'elle est assortie de nombreuses limites.

B) *Limites*

464. L'impossible et l'inopportun. Le caractère rétroactif connaît de multiples exceptions, qui sont justifiées par deux types de considérations. Dans certains contrats, il semble impossible de revenir sur le passé, et on se résoudra à un anéantissement seulement pour l'avenir. Mais dans la plupart des cas, ce sont des raisons d'opportunité qui justifient la mise à l'écart de la rétroactivité, ce qui montre bien que celle-ci ne relève pas de la « nature des choses ». Ces deux séries de considérations jouent, tant dans les rapports entre les parties (1) qu'à l'égard des tiers (2).

1) *Limites dans les rapports entre les parties*

a. *Contrats à exécution successive*

465. Impossibilité de restituer en nature. Le principe de rétroactivité ne peut pas s'appliquer avec toute sa rigueur dans les contrats dits « à exécution successive », dans lesquelles les parties s'échangent, au fil du temps, des prestations qui se succèdent et qui se renouvellent. Dans un contrat de travail, par exemple, si on peut concevoir, en cas d'annulation, que le salarié rende son salaire, il paraît impossible que l'employeur lui rende en contrepartie le travail fourni, de même que, dans un contrat de bail, le locataire ne peut pas rendre la jouissance des lieux loués. Pour éviter que l'un des contractants ne s'enrichisse sans cause au détriment de l'autre, on peut raisonner de deux manières différentes. On peut d'abord faire jouer la rétroactivité à travers une restitution en valeur, comme on le fait habituellement dans les cas où l'objet du contrat ne peut pas être restitué en nature : si le locataire, par exemple, ne peut pas restituer l'occupation des lieux, il peut restituer en revanche une somme correspondant à cette occupation, qui viendra se compenser en tout ou en partie avec l'obligation de restituer les loyers qui pèsera sur le bailleur. Dans ce raisonnement, la somme que

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

devra restituer le locataire ne sera pas nécessairement équivalente aux loyers qu'il recevra en retour, car la valeur locative, telle qu'elle devra être évaluée par expert, peut s'avérer supérieure ou inférieure à celle qui a servi de base à la détermination du montant des loyers. Cette solution apparaît du coup très difficile à mettre en œuvre et elle peut aboutir à mettre une des parties dans une situation difficile (le locataire qui devrait payer une somme supplémentaire parce que son loyer est finalement jugé trop faible, ou le salarié qui devrait restituer une partie de ses salaires passés, jugés trop élevés par rapport au travail fourni !). Pour simplifier, certains auteurs proposent de déroger ici au caractère rétroactif de la nullité, et d'admettre, comme on le fait en matière de résolution, que l'anéantissement du contrat ne vaut que pour l'avenir – le bailleur conservant les loyers perçus, et le salarié les salaires correspondant au travail passé[1044]. La question reste très discutée en Belgique[1045], et elle a donné lieu, en France, à une jurisprudence contradictoire, qui semble plutôt aujourd'hui pencher en faveur de la rétroactivité de l'annulation des contrats à exécution successive corrigée par un jeu de restitutions en valeur[1046]. Le nouvel article 1178 du Code civil français, qui ne dit rien de la nullité des contrats à exécution successive et qui renvoie d'une manière générale aux règles relatives aux restitutions, semble également aller dans ce sens. Il en va de même de l'article 5.62 du Code civil belge. La jurisprudence luxembourgeoise est divisée sur cette question. Dans une décision déjà ancienne, le tribunal de Luxembourg avait écarté le caractère rétroactif de la nullité du contrat de travail[1047], mais dans d'autres décisions relatives au même type de contrat, où la question n'était pas directement posée, la Cour d'appel semble considérer comme allant de soi que le salarié doit restituer les salaires à lui versés[1048]. Dans une décision de 2010, rendue en matière de bail, le tribunal de Luxembourg, après avoir livré une analyse doctrinale détaillée de la question, déclare s'en tenir « à la théorie classique des effets rétroactifs de la nullité avec,

[1044] FLOUR, AUBERT, SAVAUX 2014, n° 366 ; MALINVAUD, MEKKI, SEUBE, *Droit des obligations*, *op. cit.*, n° 438.

[1045] WÉRY, n° 350.

[1046] Voy. ainsi en matière de bail : Cass. (3e civ.), 18 mai 2011, n° 10-11721 ; pour un contrat de travail : Cass. (soc.), 20 mars 2019, n° 18-12.582 P.

[1047] Trib. Luxembourg, 7 décembre 1966, *Pas.*, 20, p. 291 (à propos d'une concession d'un droit de chasse, donnant lieu au paiement de redevances périodiques : le chasseur, qui a pu chasser avant l'annulation du contrat, ne peut obtenir la restitution des redevances).

[1048] Cour d'appel, 9 mars 2017, n° 41873 du rôle (la Cour rejette la demande en annulation et en conséquence la demande de remboursement des salaires).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

comme corollaire, une rétribution indemnitaire pour les obligations non susceptibles de restitution en nature »[1049]. Mais dans une décision récente, rendue à propos d'un contrat d'études annulé pour dol, le même tribunal pose en principe que les contrats à exécution successive ne sont pas annulés rétroactivement ; et refuse en conséquence à l'élève le remboursement des frais de sa formation pendant le temps où le contrat a été exécuté[1050].

Le législateur peut lui-même décider d'écarter la rétroactivité de la nullité lorsque celle-ci apparaît trop complexe à mettre en œuvre, et que l'exécution du contrat peut être divisée dans le temps. C'est ainsi que l'article 100-19 de la loi du 10 août 2015 sur les sociétés commerciales prévoit que la nullité d'une société dotée de la personnalité morale produit ses effets à compter de la décision qui la prononce.

b. *Contrats passé par les incapables*

466. Article 1312 du Code civil. L'article 1312 du Code civil pose une dérogation remarquable au principe de rétroactivité de l'annulation des contrats. Aux termes de ce texte « Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aura été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, ou l'interdiction ne peut en être exigé à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit ». Cela signifie que, si un incapable passe un contrat, et qu'il reçoit des prestations en exécution de celui-ci (par exemple, le prix d'un bien qu'il a vendu), l'annulation de ce contrat pour incapacité ne l'obligera à rendre ce qu'il a reçu que dans la mesure où il l'aura conservé, alors qu'il pourra obtenir, de son côté, la restitution de ce qu'il a versé au cocontractant. Cette solution est aujourd'hui consacrée par l'article 5.124 du nouveau Code civil belge, et par l'article 1352-4 du Code civil français. Elle renforce considérablement la protection de l'incapable, qui sera d'autant plus incité à demander la nullité des contrats qu'il a passés qu'il n'en subira aucun inconvénient. Elle peut aussi apparaître comme un moyen de dissuader les tiers de traiter avec les incapables – et à se renseigner soigneusement sur l'incapacité éventuelle de

[1049] Trib. Luxembourg, 2 février 2010, n° 122413.

[1050] Trib. Luxembourg, 25 octobre 2023, n^{os} TAL-2023-00370 et TAL-2023-01983. Le tribunal cite dans le même sens Cour d'appel, 18 novembre 2004, n° 28235.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

leur cocontractant. C'est également un souci de prévention qui est traditionnellement avancé pour justifier la règle *Nemo auditur* dont nous allons maintenant parler.

c. Nemo auditur

467. Sources. D'origine incertaine, mais sanctifié par le temps, l'adage « *Nemo auditur propriam turpitudinem allegans* » (nul n'est entendu lorsqu'il allègue sa propre turpitude) pose ce qu'il est convenu d'appeler « l'exception d'indignité ». Cet adage, qui trouve une expression textuelle dans les codes civils de plusieurs pays européens[1051], est traditionnellement reçu, en tant que tel et en l'absence de consécration législative, dans la jurisprudence des trois pays du Code civil. Il a été consacré par l'article 5.123 du nouveau Code civil belge selon lequel « [l]e juge peut refuser, en tout ou en partie, la restitution due à la partie coupable d'une violation intentionnelle de l'ordre public lors de la conclusion du contrat ». La réforme française de 2016, en revanche, a passé la règle sous silence. Au Luxembourg[1052], l'adage occupe une place relativement importante, si on tient compte de la faiblesse quantitative de la production jurisprudentielle[1053]. Cet adage est doublé d'un autre « *In pari causa turpitudinis cessat repetitio* » (à égalité d'indignité, la répétition est exclue), dont on ne le distingue pas habituellement en France[1054], ni au Luxembourg[1055]. En Belgique, en revanche, la doctrine dominante attribue des significations différentes aux deux adages, mais la différence apparaît plus de terminologie que de fond : c'est à l'adage « *In pari causa* » qu'on donne le sens qu'en France et au Luxembourg, on attribue à « *Nemo auditur* »[1056].

468. Signification. Contrairement à ce que l'expression pourrait faire croire, l'adage *Nemo auditur* ne fait pas obstacle, d'une manière générale, à toute prétention judiciaire d'une partie qui

[1051] Voy. p. ex. : art. 66 du Code des obligations suisse, § 817 du BGB, § 1174 de l'ABGB autrichien, article 1305 du Codigo civil espagnol.

[1052] Voy. A. MOREL et E. OMES, « *Nemo auditur propriam turpitudinem allegans* », *J.T.L.*, 2009, p. 86 ; POELMANS, n° 120 ; Cour d'appel, 9 novembre 2011 et 28 mars 2012, *Pas.*, 35, p. 700, note P. ANCEL.

[1053] La base de données de la jurisprudence luxembourgeoise permet de recenser 82 décisions (dont 34 de la Cour d'appel) où « *Nemo auditur* » est venu en discussion.

[1054] Sauf à soutenir que le sens véritable de l'adage serait celui de « *In pari causa* » : dans ce sens Ph. LE TOURNEAU, *L'adage Nemo auditur…*, préf. P. RAYNAUD, Paris, LGDJ, 1970.

[1055] Voy. Cour d'appel, 28 mars 2012, préc., qui traite, globalement, des deux adages « *nemo auditur propriam turpitudinem allegans* » et « *in pari causa turpitudinis cessat repetitio* ».

[1056] WÉRY, n°s 316 et 349 ; VAN OMMESLAGHE, n°s 231 et 232.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

aurait eu un comportement indigne à l'origine de cette prétention. Bien qu'il soit souvent invoqué pour tenter de bloquer une prétention quelconque, et que certaines décisions semblent lui donner une portée très large[1057], on lui attribue habituellement, au Luxembourg comme en France, un sens beaucoup plus précis : la règle ne joue que dans le cas de nullité pour cause immorale (ainsi que, dans une conception plus large, pour cause illicite, voire, dans certaines décisions pour illicéité ou immoralité de l'objet), et dans ce cas, elle n'interdit pas à la partie qui est à l'origine de cette immoralité ou de cette illicéité de demander la nullité, elle lui interdit seulement de demander la répétition des prestations qu'elle a versées en exécution du contrat annulé[1058]. Un arrêt récent de la Cour d'appel est très nettement dans ce sens. Pour la Cour, « cet adage, repris en français sous la forme de "nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" est réduit à une action en restitution consécutive à la nullité d'un contrat pour cause immorale ou illégale. Il n'est pas souhaitable que la turpitude c'est-à-dire la conduite ignominieuse, honteuse, immorale d'une partie empêche de prononcer la nullité de l'acte ; car elle conduirait à maintenir des contrats contraires à la loi. Seulement, cette partie ne pourra pas invoquer la nullité du contrat immoral ou illégal auquel elle a concouru, afin d'obtenir la restitution de ce qu'elle a versé »[1059]. L'adage apparaît donc comme une exception à la rétroactivité de l'annulation. Il est censé avoir une fonction préventive : celui qui, consciemment, passe un contrat immoral (voire illicite), risque de voir son cocontractant, s'il est innocent, demander la nullité du contrat ; il devra alors restituer ce qu'il a versé, sans pouvoir, en raison de l'adage, obtenir la restitution de ce qu'il a lui-même versé. La crainte d'un tel déséquilibre serait de nature à dissuader de passer des contrats contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou du moins de les exécuter. On peut néanmoins fortement douter de l'efficacité de cette fonction de prévention, qui supposerait que les contractants « indignes » aient tous une claire conscience de l'existence et de la portée de la règle.

[1057] V. par exemple Trib. Luxembourg 7 février 2024, Numéro TAL-2020-01496 du rôlequi, sans faire application de la règle, affirme que « les adages invoqués sont des règles non écrites qui expriment, en droit positif, la déchéance frappant le contractant qui prétendrait faire de sa propre indignité un titre pour agir en justice. Une partie ne peut ainsi pas solliciter en justice l'exécution d'un contrat contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ce qui n'est pas le cas des contrats litigieux.

[1058] Voy. p. ex. : Flour, Aubert, Savaux 2022, n° 585 s. ; Terré, Simler, Lequette, Chenede 2023, n° 580. En Belgique, c'est le sens qu'on attribue à « *In pari causa* », Wéry, n° 316 ; Van Ommeslaghe, n° 232.

[1059] Cour d'appel, 15 novembre 2023, Arrêt N° 128/23 – VII – CIV.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

On peut plutôt penser que l'adage a une vertu répressive, en ce qu'il permet au juge de sanctionner durement les contractants qui ont consciemment violé l'ordre public et les bonnes mœurs.

469. Domaine. Le domaine d'application de l'adage est très incertain en doctrine et en jurisprudence. L'adage est parfois présenté comme spécifique à la nullité pour cause illicite et immorale, tandis que d'autres auteurs en réservent l'application aux seuls cas d'immoralité, que ce soit de la cause ou de l'objet, à l'exclusion des cas où le contrat serait « simplement » illicite, et la jurisprudence française semble être en ce sens[1060], tandis que le nouveau texte belge prévoit d'une manière générale l'application de l'exception d'indignité en cas de « violation intentionnelle de l'ordre public ». On soutient encore que l'adage « *Nemo auditur* » serait un moyen pour le juge de mettre en balance le comportement respectif des parties au contrat et qu'il n'aurait vocation à jouer qu'en cas d'indignité égale des deux parties, ce que traduirait mieux la formulation alternative « *in pari causa turpitudinis cessat repetitio* »[1061]. Aucune de ces distinctions, cependant, ne rend compte exactement de l'état de la jurisprudence en la matière, dont il est bien difficile de donner les lignes directrices. Deux arrêts rendus à quelques mois d'intervalle par la Cour d'appel du Luxembourg sur la question sont significatifs de cette confusion. Dans le premier, la Cour fait jouer l'adage pour refuser, à des propriétaires qui avaient fait travailler « au noir » une personne non autorisée, la restitution des acomptes versés à cette personne qui avait mal fait le travail : pour les juges, « lorsque la nullité découle de l'immoralité ou de l'illicéité du contrat […] la répétition est paralysée en vertu de l'exception d'indignité ».[1062] Dans la seconde affaire, il s'agissait d'une vente d'immeuble dont une partie du prix avait été dissimulée pour frauder le fisc. Pour éviter de payer le supplément de prix, l'acheteur avait invoqué la nullité de l'opération, et réclamé la restitution de ce qu'elle avait déjà versé. Le vendeur invoquait à l'encontre de cette demande les adages *Nemo auditur* et *In pari causa*. La Cour d'appel ordonne la restitution. Elle juge que les adages « ne peuvent pas être invoqués pour s'opposer aux restitutions suite à la nullité de contrats contraires à l'ordre public. En effet, lorsque l'ordre public a été violé, la nullité doit faire produire les effets les plus complets possibles ».

[1060] Cass (1re civ.), 26 septembre 2018, n° 16-25.184 P.

[1061] Pour le détail de ces différentes théories, voy. P. ANCEL, note préc.

[1062] Cour d'appel, 9 novembre 2011, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Ainsi, la violation de l'ordre public qui, dans le premier arrêt, justifie l'application de « *nemo auditur* » est la raison même, pour le second, d'écarter cet adage ! Dans un arrêt de 2019, la Cour d'appel restreint le domaine d'application de l'adage à la seule nullité pour cause immorale[1063], mais, dans l'arrêt de 2023 précédemment cité, la Cour estime que l'adage doit jouer en cas de nullité d'un contrat « pour cause immorale ou illégale », ce qui va donc au-delà de la seule immoralité, mais qui semble exclure l'application de *Nemo auditur* lorsque c'est l'objet même du contrat qui est immoral ou illicite[1064].

En réalité, on peut penser que les tribunaux appliquent ou n'appliquent pas l'adage au cas par cas, sans se laisser dicter la solution par un critère préétabli, en fonction de ce qui leur apparaît le plus opportun pour sanctionner des comportements particulièrement répréhensibles[1065]. C'est sans doute ce qui a amené la Cour de cassation belge à reconnaître dès 1966 le caractère facultatif pour le juge de l'application des adages[1066]. Dans un arrêt ultérieur, la Haute juridiction belge a, plus nettement encore, affirmé que « le juge a certes, la faculté de rejeter la répétition, soit parce qu'il considère que l'avantage ainsi reconnu à l'un des contractants compromettrait le rôle préventif de la sanction de nullité absolue prévue à l'article 1131 du Code civil, soit parce qu'il estime que l'ordre social exige que l'un des contractants soit plus sévèrement frappé ; qu'il n'est toutefois pas tenu de le faire, parce que l'adage *"in pari causa turpitudinis cessat repetitio"* n'est pas une norme obligatoire »[1067]. Ce caractère facultatif est clairement consacré par l'article 5.123 du Code civil belge. On peut souhaiter que cette approche pragmatique et réaliste inspire les juges luxembourgeois plus que le formalisme apparent de la jurisprudence française.

2) *Limites vis-à-vis des tiers*

470. Sécurité des tiers. La rétroactivité de l'annulation est particulièrement nuisible à la sécurité des tiers qui ont traité avec une des parties à contrat ultérieurement annulé. Le problème se pose tout particulièrement pour les contrats translatifs de propriété d'un bien : comme on l'a vu, en cas de nullité d'un tel contrat, l'acheteur (ou le donataire) est censé n'avoir jamais été propriétaire, ce qui entraîne la nullité

[1063] Cour d'appel, 6 mars 2019, n°s 44942 et 45014.

[1064] Cour d'appel, 15 novembre 2023, arrêt n° 128/23 – VII – CIV.

[1065] Dans ce sens Fabre-Magnan (2024), n°s 733 et s.

[1066] Cass. be., 8 décembre 1966, *Pas.*, 1967, I, p. 434, avec les conclusions de l'avocat général Hayoit de Termicourt.

[1067] Cass. be., 24 septembre 1976, *Pas.*, 1977, I, p. 101 ; *J.T.*, 1977, p. 471.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

subséquente de tous les contrats que celui-ci a pu passer sur le bien avec un tiers. Il devrait en résulter systématiquement l'éviction du tiers. Le droit prévoit cependant un certain nombre de correctifs.

En premier lieu, la jurisprudence française reconnaît que l'annulation rétroactive ne fait pas disparaître les actes d'administration que l'acheteur a pu passer sur le bien entre la conclusion du contrat et son annulation. Un locataire qui a conclu avec l'acquéreur évincé serait donc protégé en cas d'annulation, le vendeur retrouvant la propriété de son bien devrait respecter le contrat de bail[1068].

Pour les actes de disposition, en revanche, la protection des tiers n'est assurée qu'en matière mobilière, par le jeu de l'article 2279 du Code civil : « En fait de meubles, la possession vaut titre ». Celui qui achète de bonne foi une chose mobilière et qui est mis en possession par son vendeur acquiert la propriété de ce bien même si son vendeur n'en est pas propriétaire – et donc, pour ce qui nous intéresse ici, son vendeur, propriétaire au moment de la vente, s'en voit ultérieurement privé rétroactivement par l'effet de l'annulation du contrat en vertu duquel il avait lui-même acquis la propriété. En matière immobilière, l'acquéreur ne bénéficie pas de la même protection, car les règles de la publicité foncière, dans les pays du Code civil, ne permettent que de régler que les conflits entre deux acquéreurs successifs qui tiennent leur droit du même vendeur : si j'achète un immeuble d'une personne qui l'a déjà vendu à un tiers n'ayant pas encore publié son droit, je l'emporterai sur ce tiers si je publie avant lui ; en revanche, si j'acquiert un immeuble d'une personne qui apparaît bien sur les registres de la Conservation des hypothèques comme en étant propriétaire, mais que le droit de cette personne se trouve ultérieurement anéanti par l'effet de l'annulation du contrat passé avec son propre vendeur, je devrai en principe restituer l'immeuble. Le sous-acquéreur, dans un tel cas, ne sera protégé qu'au bout d'un certain temps, si, avant que le premier vendeur ne revendique le bien, il devient propriétaire par le jeu de la prescription acquisitive. Dans certains cas, cependant, lorsque la cause de nullité était absolument indécelable, la jurisprudence française a admis que le sous-acquéreur pouvait devenir propriétaire par le jeu de la théorie de l'apparence[1069]. Enfin, le sous-acquéreur est protégé lorsque c'est son propre vendeur qui demande la nullité du contrat par lequel il est devenu propriétaire : tenu à garantie envers son acquéreur, il ne pourra l'évincer de la propriété qu'il lui a transmise.

§ 2. Étendue de la nullité quant au contrat

471. Tout le contrat, rien que le contrat ? Après la question de l'étendue de la nullité dans le temps se pose celle de son étendue, en quelque sorte, dans l'espace, c'est-à-dire du ou des actes qui sont touchés par l'annulation. Cette question se pose principalement lorsque la cause de nullité n'affecte, au départ, qu'une clause du contrat : il faut alors se demander si la nullité de cette clause est limitée à celle-ci, ou si elle s'étend à tout le contrat (A). Mais, même lorsque la nullité touche tout le contrat – soit directement,

[1068] La solution est discutée en Belgique : WÉRY, n° 354.

[1069] Cass. fr. (1re civ.), 3 avril 1963, *D.*, 1964, p. 306, note J. CALAIS-AULOY.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

soit par répercussion – la question se pose en sens inverse de savoir si elle se répercute sur toutes ses parties, et, éventuellement, sur d'autres actes (**B**).

A) *Incidence de la nullité d'une clause sur le contrat*

472. Nullité totale ou nullité partielle ? Il est fréquent que la cause de nullité ne concerne, au départ, qu'une ou plusieurs clauses particulières du contrat. C'est le cas en particulier lorsqu'une des clauses du contrat est contraire à l'ordre public (ou plus largement à une réglementation impérative), alors que l'opération contractuelle, dans son ensemble, a un objet et une cause licites. On se demande alors si cette nullité doit rester cantonnée à cette clause – on parle alors de nullité partielle, ou si elle doit s'étendre à l'ensemble du contrat qui serait alors affecté d'une nullité totale. Il faut surtout prendre garde à ne pas confondre cette distinction avec celle des nullités absolues et des nullités relatives, qui ne concerne que le régime de l'action en nullité. La question de l'étendue de la nullité se pose, dans la plupart des cas, pour des clauses atteintes d'une nullité absolue (pour violation de l'ordre public), mais elle peut aussi se poser pour des nullités relatives, sanctionnant la violation d'un ordre public de protection (les clauses abusives par exemple) ou l'absence de cause d'une clause particulière. La plupart des causes de nullité relative, cependant, affectent par principe tout le contrat (vices du consentement, incapacités, lésion, etc.). Il n'y a de toute façon pas de rapport entre les deux distinctions.

473. Critère subjectif. Le Code civil contient, sur la question, deux textes qui consacrent une solution différente selon que le contrat est à titre gratuit ou à titre onéreux[1070]. D'un côté, l'article 900 du Code civil, relatif aux libéralités, dispose que « Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites » – ce qui revient à dire que le testament ou la donation doit subsister en dépit de l'annulation de la clause illicite. D'un autre côté, l'article 1172 du Code civil, relatif d'une manière générale aux conditions (clauses qui font dépendre le contrat d'un événement futur et incertain)[1071], dispose que « Toute condition d'une chose impossible ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi,

[1070] Sur cette distinction, voy. *supra*, n° 81.
[1071] Voy. *infra*, n°s 588 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ». Depuis longtemps, cependant, la jurisprudence a dépassé cette distinction, et les tribunaux s'attachent à l'importance que la clause annulée avait dans la volonté des parties de conclure le contrat ou de passer l'acte, qu'il soit à titre onéreux ou gratuit. Dès le début du XXe siècle, la Cour d'appel du Luxembourg, reprenant une manière de raisonner de la jurisprudence française, posait que « L'insertion d'une clause illicite dans une convention à titre onéreux ne rend le contrat nul qu'au cas où il s'agit d'une stipulation essentielle se rattachant intimement aux autres dispositions de la convention, de sorte que, dans leur ensemble, elles forment un tout indivisible et que l'une est la condition de l'autre ; il en est autrement lorsque la clause illicite est tout à fait accessoire et indépendante des autres stipulations, et que son élimination n'aurait pas empêché les parties de contracter aux mêmes conditions »[1072]. De même, dans un contrat à titre gratuit, si la condition illicite doit en principe être réputée non écrite, il en va « autrement au cas où la condition illicite était reconnue en fait avoir été la cause déterminante et le but de la donation ou du legs, alors que l'absence d'une cause licite ôterait alors tout effet à l'obligation conformément à l'article 1131 du Code civil »[1073]. Il faut donc, au cas par cas, rechercher quelle a été la volonté des parties, pour savoir si pour elles, ou au moins pour l'une d'elles, la clause était la « cause impulsive et déterminante de leur engagement », ou si ce n'était qu'une clause accessoire, en l'absence de laquelle elles auraient tout de même contracté. Dans le premier cas, il faudra faire tomber le contrat tout entier, dans le second, la nullité ne sera que partielle. Ce critère subjectif est aujourd'hui consacré par le nouvel article 1184 du Code civil français.

Ce critère subjectif, tout à fait conforme à la vision volontariste du contrat, est évidemment d'application très délicate, et la recherche de la volonté des parties par rapport à la clause considérée est souvent divinatoire. Le pouvoir d'appréciation des juges à cet égard est évidemment très important, et la question relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

474. Correctifs. On peut cependant se demander si, dans certains cas la recherche de la volonté des parties n'est pas un faux-semblant dissimulant des considérations de politique juridique fondées sur

[1072] Cour d'appel, 20 avril 1904, *Pas.*, 6, p. 477 ; Cour d'appel, 4 décembre 1908, *Pas.*, 7, p. 535 ; Cour d'appel, 2 décembre 1910, *Pas.*, 8, p. 407.

[1073] Trib. Luxembourg, 3 janvier 1956, *Pas.*, 16, p. 457.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la finalité de la règle violée et sur l'efficacité de la sanction. Il faut remarquer, en effet, que l'étendue plus ou moins grande de la nullité peut avoir une incidence sur la mise en œuvre effective de cette nullité. Dans de nombreux cas, le contractant qui veut se débarrasser d'une clause contractuelle veut néanmoins garder le bénéfice du contrat dans son ensemble : s'il craint, en faisant tomber la clause, de perdre le bénéfice du contrat tout entier, il peut être dissuadé de demander la nullité. Le souci d'assurer l'effectivité de la sanction peut amener les tribunaux à cantonner la nullité à la seule clause illicite sans se demander quelle importance cette clause a pu avoir dans l'intention des parties ou de la partie qui l'a imposée. Le nouvel article 1184 du Code civil français consacre expressément cette idée en posant que le contrat doit être maintenu « lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien ». Plus nettement encore, l'article 5.63 du nouveau Code civil belge met sur le même plan le critère subjectif de la volonté des parties et le critère objectif du but de la règle violée. Ce second critère aboutit parfois à mettre de côté les clauses par lesquelles les parties ont indiqué que, pour elles, telle ou telle clause était déterminante, ou déclarant que toutes les clauses forment un ensemble indivisible, de sorte que la nullité de l'une entraînerait celle du contrat tout entier. Dans une approche fondée sur la volonté des parties, une telle clause devrait déterminer le sort du contrat. Mais, si le juge a l'impression que la clause a en réalité pour but de dissuader une partie de demander la nullité, il pourra la neutraliser, et rechercher quelle a été l'importance véritable de la clause annulée dans l'économie de l'opération[1074]. Le juge luxembourgeois peut d'autant plus facilement écarter une telle clause que, à la différence des juges français, il est entièrement libre de l'interprétation qu'il donne du contrat, et n'a pas à craindre le contrôle de la dénaturation des clauses claires et précises[1075].

475. Détermination légale de l'étendue de la nullité : les clauses réputées non écrites. Ce sont également des considérations de politique juridique indépendantes de l'intention des parties qui amènent

[1074] Voy. à propos d'une libéralité, où l'effet de dissuasion est particulièrement à craindre si le bénéficiaire en contestant la clause perd la libéralité : Trib. Luxembourg, 3 janvier 1956, préc., qui considère sans importance le fait que le testateur ait expressément déclaré subordonner l'effet de la donation ou du legs à l'accomplissement de cette condition. Comp. les hésitations de la jurisprudence française à propos des clauses d'indivisibilité : Cass. fr. (3e civ.), 6 juin 1972, *D.*, 1973, J, p. 151, note Malaurie ; Cass. fr. (comm.), 27 mars 1990, n° 88-15092.

[1075] Voy. *infra*, n° 530.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

le législateur, dans des cas de plus en plus nombreux, à préciser lui-même l'étendue de la nullité affectant une clause contractuelle. Dans certains cas, le législateur impose une nullité totale : ainsi lorsque l'article 1174 du Code civil dispose que « Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige » – ce qui implique que la nullité de la condition potestative affecte tout le contrat[1076]. Mais, dans la législation moderne, dans l'immense majorité des cas, le législateur édicte une nullité limitée aux clauses qu'il prohibe, notamment dans le domaine de l'ordre public de protection, pour permettre aux contractants protégés de conserver le bénéfice du contrat sans avoir à souffrir des clauses interdites. Très souvent, cette solution est posée en utilisant la vieille formule de l'article 900 du Code civil : la clause prohibée est « réputée non écrite ». Jusqu'à une période récente, on considérait que cette formule signifiait simplement que la nullité était limitée à la clause, le contrat subsistant pour le surplus – et c'était du reste le sens qu'on donnait traditionnellement à l'article 900. C'est encore cette signification qui apparaît dans le nouvel article 1184 du Code civil français[1077], comme dans l'article 5.63 du nouveau Code civil belge[1078]. Mais, depuis quelques années, s'est développé en France un courant doctrinal[1079] – qui n'est pas resté sans influence en Belgique[1080] – soutenant que les clauses « réputées non écrites » étaient autre chose que des clauses nulles – que ces clauses devaient être considérées comme absentes du contrat, par l'effet d'une déclaration de la loi, sans que le juge ait à intervenir pour les déclarer nulles. Cette analyse a plusieurs conséquences, qui ont déjà été rencontrées : un juge saisi du contrat contenant une clause de ce type pourra déclarer son illicéité à tout moment, sans même qu'elle soit demandée par une partie, sans que cette sanction puisse être atteinte par la prescription, et sans qu'aucune confirmation ne soit possible. Cette analyse – dans laquelle, comme on l'a déjà dit, on peut voir une résurgence de la vieille théorie de l'inexistence – a été clairement consacrée par la Cour de cassation française[1081], et on en trouve un écho dans un arrêt de la Cour de

[1076] Voy. *infra*, n° 593.

[1077] « Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite… »

[1078] « La clause réputée non écrite par la loi, une fois annulée, laisse subsister le reste du contrat. »

[1079] Voy. not. : S. GAUDEMET, *La clause réputée non écrite*, préf. Y. LEQUETTE, Paris, Economica, 2006.

[1080] WÉRY, n°s 336 et s. (avec des nuances) et les auteurs cités.

[1081] Cass. fr. (civ. 3e), 9 mars 1988, n° 86-17869 ; Cass. fr. (civ. 3e), 26 avril 1989, n° 87-18384 ; Cass. fr. (civ. 3e), 30 juin 2021, n° 19-23.038 B ; Cass. fr. (civ. 3e), 8 février 2024, n° 22-16.422B.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

cassation belge[1082], mais les nouveaux textes français et belge n'en font aucune mention On trouve mention de la solution jurisprudentielle française dans un jugement récent du tribunal de Luxembourg, mais dans une affaire où la demande en annulation d'une clause était fondée sur le Code de la consommation français[1083]. Pour le reste, la solution française ne semble pas jusqu'à présent avoir pénétré au Luxembourg. Elle devrait cependant y être consacrée à propos des clauses abusives dans les contrats de consommation. Comme on l'a déjà vu[1084], la directive de 1993 prévoit que les clauses abusives « ne lient pas » le consommateur. Cette formule, qui a été choisie pour tenir compte de la diversité des droits nationaux en matière d'invalidité des actes juridiques, a été interprétée par la CJUE en ce sens qu'elle permettait au juge de soulever d'office à tout moment le caractère abusif d'une clause – ce qui correspond aux conséquences qui sont attachées au « réputé non écrit » si on veut le distinguer de la nullité. En dehors de ce cas, cependant, l'opportunité de concevoir un régime de sanction distinct de celui de la nullité paraît douteuse[1085].

B) *Incidence de la nullité totale du contrat*

476. Cas de nullité totale. La nullité peut affecter l'ensemble du contrat lorsque, par application des règles précédentes, on lui étend la nullité d'une clause particulière. Mais la nullité totale peut aussi être directe, lorsque la cause de nullité affecte, au départ, le contrat lui-même considéré dans sa globalité : les vices du consentement, l'incapacité d'une partie, l'absence ou l'indétermination de l'objet, la cause illicite ou immorale de l'opération, etc. sont, par principe, des causes de nullité qui affectent le contrat tout entier. Se pose alors la question de savoir si cette nullité totale s'étend, sans distinction, à toutes les clauses du contrat, mais aussi celle de savoir s'il ne convient pas de l'étendre à d'autres contrats qui sont liés au contrat annulé.

477. Incidence de la nullité du contrat sur ses clauses. La réponse de principe à la première question ne fait aucun doute : la nullité du contrat s'étend à toutes ses clauses, qui n'ont de sens que par rapport à l'ensemble qu'elles forment entre elles. Il en va ainsi sans distinguer selon l'importance que les clauses considérées ont par rapport au contrat : si on peut admettre qu'un contrat subsiste en en retranchant certaines clauses accessoires, aucune clause, même accessoire, ne peut subsister sans le contrat. Par

1082 Cass. be., 27 avril 2003, *RGDC*, 2005, p. 42, note P. Wéry.

1083 Trib. Luxembourg, 9 février 2024, n° TAL-2019-03855.

1084 Voy. *supra*, n° 415.

1085 Dans ce sens : Malaurie, Aynes, Stoffel-Munck, n° 721.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

exemple, si un contrat de travail contient une clause de non-concurrence à la charge du salarié après le moment où son travail aura pris fin, la nullité du contrat (qu'elle soit ou non rétroactive) libérera le salarié de son obligation de non-concurrence. Ce principe, cependant, n'est pas absolu. Il convient de faire exception pour les clauses dites « de différend », qui déterminent la manière dont doivent être réglés les litiges éventuels entre les parties : clauses compromissoires (qui prévoient le recours à l'arbitrage), clauses attributives de compétence territoriale, clauses prévoyant un recours à la médiation, etc. Il paraît raisonnable que ces clauses ne soient pas anéanties par suite de l'annulation du contrat. La nullité d'un contrat, en effet, ne sera prononcée qu'à l'issue du procès, donc à un moment où la clause en question aura déjà joué : le litige aura été porté par exemple devant un tribunal arbitral, qui statuera sur le contrat ; si, à l'issue du procès, il juge que le contrat est nul, et que cette nullité entraîne la nullité de la clause d'arbitrage, cela revient à dire que l'arbitre scie la branche sur laquelle il était assis, et qu'il faut donc recommencer le procès depuis le début devant une juridiction étatique. Ou alors, il faudrait considérer que le seul fait pour une partie d'invoquer, au début du procès, la nullité du contrat, paralyse ce type de clauses, ce qui en réduirait considérablement l'efficacité. C'est pourquoi la jurisprudence française, depuis longtemps, admet l'autonomie des clauses compromissoires[1086], avant que celle-ci ne soit consacrée dans le Code de procédure civile. Au Luxembourg, l'autonomie de la clause compromissoire, déjà admise par certaines décisions jurisprudentielles[1087], est désormais reconnue par l'article 1227-2 du Nouveau Code de procédure civile, issu de la loi du 19 avril 2023 sur l'arbitrage. Selon ce texte, « [u]ne clause compromissoire faisant partie d'un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. Elle n'est pas affectée par la nullité, la caducité ou la résolution de celui-ci ». Ces solutions devraient être étendue aux clauses attributives de compétence territoriale[1088]. On peut justifier ces solutions en considérant que ces « clauses » figurant dans un *instrumentum* contractuel sont en réalité des conventions distinctes, ayant un objet spécifique, et qui n'ont pas nécessairement à suivre le sort du contrat auquel elles se rattachent. En matière de contrats internationaux, le Règlement (CE) n° 1215/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale[1089] (ci-après « règlement Bruxelles I *bis* ») raisonne de la même manière, lorsqu'il pose dans son article 25 qu'« une convention attributive de juridiction faisant partie d'un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat » et que « la validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n'est pas valable ».

478. Extension de la nullité à d'autres contrats. La nullité d'un contrat peut parfois s'étendre à d'autres contrats qui lui sont liés. Cela est bien admis depuis longtemps pour des contrats qui sont considérés comme accessoires à un contrat principal : ainsi, il résulte de l'article 2012 du Code civil qu'un contrat de cautionnement doit être annulé si le contrat faisant naître l'obligation garantie par la caution

[1086] Cass. fr. (1re civ.), 7 mai 1963, *JCP G*, 1963, II, p. 13405, note GOLDMAN (pour l'arbitrage international) ; Cass. fr. (comm.), 9 avril 2002, n° 98-16829 (pour l'arbitrage interne).

[1087] Voy. d'ailleurs Cour d'appel, 26 juillet 2005, *Pas.*, 33, p. 117 qui, pour considérer qu'une clause compromissoire peut être soumise à une loi différente de celle applicable au contrat, pose qu'une clause compromissoire est « une partie distincte » du contrat.

[1088] Voy. pour la France Cass. fr. (1re civ.), 8 juillet 2010, n° 07-17788.

[1089] *J.O.U.E.*, L. 351/1, 20 décembre 2012.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

est lui-même frappé de nullité. Mais, en dehors de cette hypothèse, la jurisprudence française admet que lorsque des contrats sont « interdépendants » ou forment un « ensemble indivisible », la nullité de l'un doit s'étendre aux autres, et cette solution est aujourd'hui consacrée par l'article 1186 du Code civil français, selon lequel « [l]orsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie ». Par exemple, dans une opération de *leasing* (crédit-bail en droit français) où une personne se procure la jouissance immédiate d'un bien en le louant à l'établissement de crédit qui l'a acheté, la nullité de la vente entraînerait celle du contrat de location. D'une manière plus générale, la Cour de cassation française a consacré cette notion d'interdépendance contractuelle pour tous les contrats de location financière d'un matériel nécessaire à l'exécution d'une autre convention : l'anéantissement de cette convention entraîne nécessairement l'annulation du contrat de location financière, et sont réputées non écrites les clauses de divisibilité contractuelle inconciliables avec cette interdépendance[1090]. La Cour d'appel du Luxembourg a consacré la même solution à propos d'un contrat de vente d'un terrain et d'un contrat d'entreprise ayant pour objet la construction d'un immeuble sur ce terrain : la Cour a considéré qu'en raison des liens étroits entre les deux contrats (signés avec deux sociétés différentes, mais représentées par la même personne physique), la disparition du premier (par suite de la défaillance d'une condition suspensive) entraînait la caducité du second[1091]. Plus récemment, la Cour d'appel a repris très explicitement les solutions de la jurisprudence française en matière de location financière[1092]. Ces différents arrêts sont relatifs à des affaires où l'un des contrats interdépendants avait été résolu, mais leur motivation indique que la solution vaudrait pour toute cause d'anéantissement, donc en particulier pour le cas où l'un des contrats serait annulé. Nous retrouverons ces solutions en étudiant d'une manière générale la question de la caducité du contrat, dans le cadre des développements relatifs à la durée des contrats[1093].

[1090] Cass. fr. (ch. mixte), 17 mai 2013, n°s 11-22.768 et 11-22.927.

[1091] Cour d'appel, 5 mai 2010, *Pas.*, 35, p. 187. La Cour d'appel avait déjà utilisé, dans un autre contexte, la notion d'ensemble contractuel (Cour d'appel, 13 juin 2007, *Pas.*, 33, p. 558 à propos d'un dépôt-vente).

[1092] Cour d'appel, 10 mars 2021, n° CAL-2019-00458.

[1093] Voy. *infra*, n° 557.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La nullité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 527-571
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Chapitre II
Les autres sanctions

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les autres sanctions, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 573-577
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les autres sanctions, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 573-577
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

479. En plus ou à la place. – – La nullité du contrat n'est pas toujours suffisante pour sanctionner la violation des règles de validité du contrat : seuls des dommages et intérêts peuvent permettre de réparer le préjudice éventuellement subi par une partie suite à l'annulation (**Section 1**). À l'inverse, la nullité n'apparaît pas toujours nécessaire ou opportune : dans certains cas, très limités, elle pourra être remplacée par une modification du contrat irrégulier (**Section 2**).

SECTION 1. LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

480. Responsabilité délictuelle. Le contractant victime d'un préjudice en raison de l'annulation d'un contrat peut obtenir de l'autre des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle[1094]. Cette possibilité est aujourd'hui expressément prévue par l'article 1178 du Code civil français. Par hypothèse, le contrat est considéré comme n'ayant fait naître aucune obligation, il ne saurait donc être question de faire jouer une responsabilité contractuelle, qui répare les préjudices causés du fait de l'inexécution des obligations contractuelles. Par ailleurs, dans le système du Code civil, la responsabilité délictuelle est admise de manière suffisamment large pour qu'il ne soit pas utile de faire appel à la théorie de la *culpa in contrahendo* développée par Ihering dans le contexte très différent du droit allemand[1095]. Dans tous les cas, celui qui agit en responsabilité devra prouver la faute du contractant. Dans l'immense majorité des cas, c'est le contractant qui demandera la nullité qui agira en dommages et intérêts contre l'autre, la faute consistant alors à avoir été à l'origine de la conclusion du contrat annulé (violence, dol, exploitation abusive de sa situation de force, mobiles illicites ou immoraux, etc.). Mais il peut arriver aussi que ce soit le défendeur à l'action en nullité qui demande des dommages et intérêts à l'autre, lorsque celui-ci invoque une nullité qui est due à sa propre faute : par exemple, on peut concevoir qu'un incapable qui demande la nullité d'un contrat qu'il a passé soit condamné à des dommages et intérêts pour avoir faussement déclaré à son cocontractant qu'il était capable. Les dommages et intérêts obtenus peuvent permettre de compenser les frais que le contractant a engagés pour la conclusion du contrat annulé, ainsi

[1094] Voy. p. ex. : Cour d'appel, 19 octobre 2016, n° 40580 ; Cour d'appel, 22 janvier 2020, n° 44017 ; Cour d'appel, 6 mars 2024, n° CAL-2023-00251.

[1095] Voy. *supra*, n° 178.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les autres sanctions, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 573-577
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

que la perte d'une chance d'avoir pu passer d'autres contrats, mais non pas les bénéfices attendus du contrat annulé lui-même, parce que cela reviendrait à lui donner effet[1096].

Les dommages et intérêts peuvent se cumuler avec l'annulation du contrat, mais ils peuvent aussi être demandés à la place de l'annulation. Un arrêt récent de la Cour d'appel relève ainsi que « [l]a victime d'un dol peut à son choix faire réparer le préjudice que lui ont causé les manœuvres de son cocontractant par l'annulation de la convention et, s'il y a lieu, par l'attribution de dommages et intérêts, ou simplement par une indemnisation pécuniaire »[1097]. Il en va ainsi notamment en cas de dol incident (cas où le contractant victime du dol aurait de toute façon passé le contrat, mais à des conditions plus avantageuses pour lui) : les dommages et intérêts viendront alors en compensation de la partie du prix payée en trop. On n'est pas loin d'une autre solution, consistant à faire modifier le contrat.

SECTION 2. LA MODIFICATION DU CONTRAT

481. Rééquilibrage d'un contrat déséquilibré. Dans les cas où c'est un déséquilibre entre les prestations contractuelles qui vicie le contrat, il est parfois possible, au lieu d'accorder la nullité du contrat, de le réviser pour rétablir l'équilibre. Cette solution est expressément prévue en cas de lésion des 7/12e dans la vente d'immeuble par l'article 1681 du Code civil (où l'acquéreur peut préférer payer le supplément de prix plutôt que de rendre l'immeuble acheté à bas prix). Cette solution est également prévue par l'article 1118, alinéa 2 du Code civil en cas de lésion qualifiée, mais cette fois à la demande de celui qui a payé un prix excessif, et qui peut préférer la réduction. On pourrait songer à l'appliquer dans d'autres hypothèses, notamment en cas d'erreur, de dol ou de violence, si la victime du vice préfère garder le contrat, en obtenant une modification du prix payé. La Cour de cassation française l'avait admis en matière de dol[1098], et le projet de réforme français prévoyait en cas d'erreur la possibilité pour la victime du vice d'opter pour le maintien du contrat rectifié, mais cette solution n'a pas été retenue dans le texte définitif. C'est que cette solution, si elle paraît raisonnable, n'est cependant guère dans la tradition des pays du Code civil, où on considère que, si le

[1096] FLOUR, AUBERT, SAVAUX 2022, n° 593.
[1097] Cour d'appel, 6 mars 2024, préc.
[1098] Cass. (3e civ.), 6 juin 2012, n° 11-15973, *R.D.C.*, 2012, p. 1180, note GENICON.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les autres sanctions, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 573-577
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

contrat n'a pas été vraiment voulu, il faut l'anéantir[1099], et où la possibilité pour le juge de modifier un contrat n'est reconnue qu'avec parcimonie[1100]. On a tendance – sans doute trop – à raisonner de manière binaire : ou le contrat n'est pas valable, et il doit tomber, ou bien il répond à toutes les conditions de validité posées par la loi, et il a alors pleine force obligatoire.

482. Modification d 'une clause illicite. Le problème se pose également pour certaines clauses du contrat, qui fixent un montant ou une durée illicites – par exemple une clause qui fixe un taux d'intérêt usuraire, qui laisse à un contractant une durée trop courte pour agir contre l'autre, ou qui, à l'inverse lui impose une obligation de non-concurrence pendant une durée trop longue. On pourrait être tenté de dire que la sanction la plus raisonnable serait de corriger le montant ou la durée fixée pour rendre la clause conforme à la loi. Cependant une telle sanction n'a pas que des avantages, en ce qu'elle est moins dissuasive que la nullité : un contractant en situation de force sera d'autant plus tenté d'introduire dans le contrat une clause illicite qu'il sait qu'il risque seulement une correction de la clause. C'est cette considération qui a poussé la CJUE à dire, en matière de clauses abusives, que les juges nationaux n'ont pas le pouvoir de réviser les clauses abusives, ils ne peuvent que les annuler[1101]. Dans un arrêt faisant expressément référence à cette décision, la Cour d'appel du Luxembourg a jugé que cette solution devait être étendue à toutes les clauses illicites, même stipulées entre professionnels[1102]. Pour la Cour, « une annulation partielle de la clause litigieuse risque d'encourager la partie profitant du maintien de la clause amputée à "pratiquer l'illicite" […] une telle solution n'encourage pas que la clause soit volontairement rectifiée par son rédacteur qui reste assuré qu'en cas de contestation de la régularité de la clause, seule la partie irrégulière est supprimée. La Cour conclut de ce qui précède que, hormis le cas où le législateur autorise expressément le juge à remodeler ou adapter les clauses contractuelles qui, aux termes de l'article 1134 du Code civil, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, il ne lui appartient ni de refaire le contrat, ni de dépecer une clause contractuelle pour en extraire ce qui est valable ».

[1099] Dans ce sens T. GÉNICON, *R.D.C.*, 2012, p. 380.

[1100] Voy. aussi *infra*, n° 796 à propos de la réfaction (réduction du prix suite à une inexécution partielle du contrat) qui a bien du mal à faire sa place à côté de la résolution (anéantissement total du contrat inexécuté).

[1101] C.J.U.E., 14 juin 2012, arrêt 618/10, *Banco Espanol de Credito*.

[1102] Cour d'appel, 20 avril 2021, n° CAL-2019-00837.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les autres sanctions, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 573-577
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

483. Article 1134 du Code civil. Dans tous les systèmes juridiques, le contrat, dès lors qu'il est valable, crée, pour les parties, un lien sanctionné par le droit. Ce lien peut être plus ou moins fort, on peut admettre que les parties puissent s'en défaire dans certaines conditions, on peut permettre au juge, dans certains cas, d'y mettre fin ou de le modifier, les sanctions qui frappent les parties qui prétendent se soustraire au contrat qu'elles ont passé ou qui n'exécutent pas les obligations qu'il met à leur charge peuvent être plus ou moins énergiques, etc. Mais, au-delà de ces infinies variations, il y a un minimum sans quoi le contrat ne serait pas un contrat : à partir du moment où on a passé un contrat, on ne peut pas faire comme s'il n'avait pas été passé, on ne peut pas s'en dégager unilatéralement dans n'importe quelle condition, ni refuser sans raison de l'exécuter. C'est un principe fondamental de tout ordre social qui reconnaît le contrat comme un des modes de régulation des relations interindividuelles. Que serait la société si un vendeur pouvait, après la vente, décider que le bien vendu lui appartient toujours ? Si la personne qui avait emprunté de l'argent pouvait librement décider de ne pas le rendre ? Si un locataire décidait brusquement et sans raison de ne plus payer ses loyers ou si son bailleur pouvait, à tout moment et sans motif, mettre fin au bail et expulser son locataire ? La sécurité des relations sociales, la prévisibilité des actions des individus, ne peuvent être assurée que si les contrats passés se voient reconnaître un minimum de force sanctionnée par le droit.

Tous les systèmes juridiques donc, admettent cela, qui est de l'essence du contrat. Mais il n'est sans doute pas de droit où ce principe est affirmé avec plus de force que dans le Code civil. Dans un texte célèbre, hérité de Domat, l'article 1134, alinéa 1er du Code civil affirme que : « *Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites* ». Ce texte est aujourd'hui repris en France par l'article 1103 (sous la seule réserve du remplacement du mot « convention » par celui de « contrat »), ainsi que par l'article 5.69 du nouveau Code civil belge (où la formule est mise au singulier).

Ce texte pose ce que, en France et au Luxembourg, on appelle le principe de la *force obligatoire du contrat*. En Belgique, on préfère parler, pour bien rendre compte de l'assimilation que l'article 1134 du Code civil fait du contrat à la loi, du principe de la *convention-loi* – formule aujourd'hui reprise dans l'intitulé de l'article 5.69 du Code civil belge.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 581-582
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

484. Portée. Une lecture attentive du texte fait apparaître une double restriction à la portée de ce principe. D'une part, comme on l'a souligné depuis le début, les contrats n'ont force obligatoire que s'ils sont « légalement formés »[1103], c'est-à-dire si les conditions de validité posées par la loi (et accessoirement par la jurisprudence) ont été respectées lors de sa formation. Pour échapper à l'exécution du contrat, éviter qu'on lui applique les sanctions de son inexécution, ou obtenir la restitution des prestations qu'elle aurait versées en exécution de ce contrat, une partie peut donc toujours essayer de démontrer que le contrat passé n'a pas été valablement formé – dans la mesure où elle a qualité pour soulever cette nullité. D'autre part, l'article 1134 du Code civil introduit, implicitement, une distinction entre les personnes qui sont concernées par cette force obligatoire : si les conventions tiennent lieu de loi « à ceux qui les ont faites », aux parties, le texte ne dit rien des effets qu'elles produisent à l'égard des autres personnes, des tiers. Nous verrons qu'il ne faut pas en déduire que le contrat n'a aucun effet à l'égard des tiers, mais il est certain que la force obligatoire du contrat n'a pas la même portée pour les parties (**Titre I**) et pour les tiers (**Titre II**).

[1103] Dans l'article 5.69 du Code civil belge, « légalement » est remplacé par « valablement ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 581-582
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

485. Force obligatoire et contenu obligationnel. Parce que le contrat, *stricto sensu*, crée des obligations pour les parties[1104] – c'est-à-dire qu'il rend une ou chaque partie créancière de l'autre – on ramène souvent la force obligatoire du contrat à cette création d'obligations. Cette présentation nous apparaît exagérément réductrice de ce qui se passe entre les parties – mais aussi à l'égard des tiers – lorsqu'un contrat est conclu. D'une part, le contrat n'a pas pour seul effet possible de créer des obligations : il peut aussi créer ou transférer un droit réel (par exemple, une vente qui transfère la propriété), modifier ou éteindre une obligation existante, créer une nouvelle personne (le contrat constitutif d'une société), attribuer compétence à une juridiction, etc. Or, tous ces effets que peut avoir un contrat sont tout aussi obligatoires pour les parties que la création d'obligations : par exemple, le vendeur qui a transféré la propriété de son bien ne peut pas, ensuite, changer d'avis et reprendre le bien. Du reste, l'article 1134 du Code civil proclame la force obligatoire, non pas pour les seuls contrats, mais d'une manière plus générale pour toutes les « conventions », dont certaines peuvent n'avoir aucunement pour objet la création d'obligations : par exemple, lorsqu'un créancier fait remise de sa dette à son débiteur, cette convention, régie par les articles 1282 et suivants du Code civil, ne crée aucune obligation nouvelle, tout au contraire elle éteint une obligation préexistante ; elle n'en a pas moins force obligatoire en ce que le créancier ne peut plus, ensuite, faire comme si il n'avait pas fait la remise, et réclamer à son ex-débiteur le paiement de sa dette. Tous ces exemples montrent que la force obligatoire, entre les parties, est quelque chose de différent, et en quelque sorte de plus profond, des effets que produit l'éventuel contenu obligationnel de la convention. Il est vrai que dans la nouvelle rédaction des textes remplaçant l'article 1134 en France et en Belgique, le mot « convention » a été remplacé par le mot « contrat », mais cela n'est que la conséquence de l'élargissement de la définition du contrat, qui n'est plus seulement, en France, un accord créant des obligations, mais aussi un accord modifiant ou éteignant une obligation, et, en Belgique, plus largement encore un accord tendant à « faire naître des effets de droit »[1105]. Quel que soit son contenu spécifique – qu'il fasse naître ou non des obligations – le contrat crée de toute façon une norme nouvelle – une petite loi, pour reprendre la formulation

[1104] Sur la définition du contrat comme convention créatrice d'obligations, voy. *supra*, n°s 47 et s.
[1105] Sur cette évolution de la définition du contrat en France et en Belgique, voy. *supra*, n° 56.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 585-586
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

même de l'article 1134 du Code civil – qui s'impose aux parties, qui les lie, qui les engage, comme la loi générale lie tout sujet de droit. Cet effet fondamental du contrat s'observe même, du reste, lorsque le contrat crée des obligations : on peut voir par exemple que ce n'est pas seulement le débiteur contractuel qui est engagé par le contrat (ce qui, pour lui, signifie qu'il doit exécuter son obligation), le créancier contractuel (qui n'est, lui, tenu d'aucune obligation) l'est également en ce qu'il ne peut pas méconnaître les termes du contrat qui définissent le contenu et les modalités de l'obligation de son débiteur (par exemple, il ne peut pas lui réclamer avant le terme fixé, il ne peut pas lui appliquer en cas d'inexécution une indemnité plus forte que celle qui a été prévue, etc.)[1106].

Nombre des effets que le contrat – ou, d'une manière générale, toute convention – produit entre les parties peuvent ainsi s'expliquer autour de cette idée d'une norme génératrice d'un lien obligatoire (**Sous-titre I**). Cela ne doit pas conduire à négliger, cependant, les effets spécifiques liés à la naissance des obligations contractuelles (**Sous-titre II**).

[1106] Pour un développement de cette présentation, voy. P. ANCEL, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », *RTD civ.*, 1999, p. 771.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 585-586
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

486. Questions. La signification exacte de la force obligatoire doit être précisée à travers la réponse à trois questions : quelle est la force du lien qui engage les parties ? (**Chapitre I**) quelle en est la teneur ? (**Chapitre II**) et pendant combien de temps les parties sont-elles liées ? (**Chapitre III**).

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 589
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Chapitre I
La force du lien obligatoire

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

487. Une « loi » moins forte que la loi. Si la comparaison que fait l'article 1134 du Code civil entre le contrat et la loi traduit bien l'idée que le contrat crée une norme, réglant la situation juridique entre les parties comme la loi de l'État le fait d'une manière générale pour tous les sujets de droit, la portée de cette comparaison ne doit pas être exagérée. La loi contractuelle est une loi subordonnée, qui tire sa force de la loi de l'État, et qui n'est reconnue par celle-ci que dans la mesure où elle est nécessaire pour assurer un équilibre entre l'intérêt social et les intérêts individuels. Si, comme on l'a dit d'emblée, il est indispensable, pour assurer la sécurité des relations juridiques et la prévisibilité des actions, de reconnaître une certaine force à la loi contractuelle, cette force n'a pas nécessairement à être absolue. Diverses considérations tenant à l'intérêt général ou aux intérêts des parties, peuvent conduire à la limiter, tant pour les parties elles-mêmes (**Section 1**), que pour le juge (**Section 2**) et, bien sûr, vis-à-vis du législateur lui-même (**Section 3**).

SECTION 1. LA FORCE DU LIEN OBLIGATOIRE POUR LES PARTIES

488. Article 1134, alinéas 2 et 3 du Code civil. Le caractère très frappant de l'article 1134, alinéa 1er du Code civil a souvent tendance à faire oublier que le texte comporte deux autres alinéas : le second tire la conséquence directe de la force obligatoire en posant l'irrévocabilité du contrat (**§ 1**), le troisième tempère cette force en posant l'exigence de la bonne foi dans l'exécution du contrat (**§ 2**).

§1. L'irrévocabilité du contrat

A) *Principe*

489. Interdiction d'une révocation unilatérale. Les conventions, déclare l'article 1134, alinéa 2 du Code civil, « ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ». C'est là la conséquence première de la force obligatoire : un contractant ne peut plus, une fois que le contrat est signé, revenir sur son engagement, et faire comme s'il ne l'avait pas passé. Seul un accord mutuel des parties peut les délier. Si vous avez commandé une marchandise, et que cet achat vous semble déraisonnable, tant pis pour vous : vous devrez quand-même en prendre livraison ou à défaut payer des dommages et intérêts. Si vous avez vendu votre maison et que vous regrettez la vente, tant

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pis pour vous : vous ne pouvez pas dire à votre acheteur que vous avez changé d'avis et lui demander qu'il vous rende la maison. Si vous avez prêté de l'argent à un de vos amis qui doit vous le rendre l'année prochaine, et que, le lendemain, vous avez un besoin urgent de cet argent, tant pis pour vous : vous ne pouvez pas demander à l'emprunteur de vous rendre l'argent tout de suite. Cette irrévocabilité doit s'entendre comme comprenant l'immutabilité du contrat : pas plus qu'elle ne peut s'affranchir complètement du contrat, une partie ne peut prétendre en changer unilatéralement les conditions. Dans l'exemple du prêt, le prêteur qui aurait prêté sans intérêt ne peut pas changer d'avis et dire à son emprunteur que finalement il lui demandera des intérêts au taux de 5 % l'an.

490. Sanction de la révocation interdite. Que va-t-il se passer si une partie, après avoir passé un contrat, prétend le révoquer ou le modifier ? La sanction ne sera pas toujours la même. Dans de nombreux cas, la volonté – illicite – de se dégager du contrat se traduira par le refus pour le débiteur contractuel d'exécuter les obligations mises à sa charge : le vendeur refusera de livrer la chose, l'acheteur refusera de payer le prix, l'entrepreneur refusera de faire le travail promis, le salarié tenu par une clause de non-concurrence se fera réembaucher par un employeur concurrent, etc. Dans ces hypothèses, la sanction de la révocation se confondra avec les conséquences de l'inexécution des obligations contractuelles : le contractant qui refuse d'exécuter sera condamné à des dommages et intérêts, parfois il pourra être contraint d'exécuter son engagement, le cocontractant victime de l'inexécution pourra se dégager du contrat en en demandant la résolution, etc.[1107] Mais, dans d'autres cas, la révocation ne se traduira pas à proprement parler par une inexécution, et ces sanctions n'auront aucun sens. La réaction de l'ordre juridique sera simplement dans l'inefficacité de la volonté révocatoire. Si par exemple un contractant, qui a accepté dans son contrat une clause attribuant compétence à un tribunal arbitral (clause compromissoire), prétend revenir sur cette clause, et saisit le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour régler son litige avec son cocontractant, ce tribunal, appliquant le contrat, se contentera de se déclarer incompétent. Si le prêteur, qui a accordé un délai d'un an pour rembourser, prétend changer d'avis et demande à son emprunteur le remboursement au bout de 6 mois, le tribunal

[1107] Voy. *infra*, n°s 753 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

le déboutera purement et simplement de sa demande. On aurait tort, à notre avis, de présenter ces solutions comme des formes d'exécution forcée des obligations contractuelles, alors qu'il s'agit d'applications directes par le juge de la norme contractuelle liant les parties.

491. Licéité des révocations mutuellement consenties. Si une partie ne peut unilatéralement se retirer du contrat, il va de soi que les deux parties peuvent se mettre d'accord pour s'en délier mutuellement. Ainsi, comme il a été dit, vous ne pouvez pas en principe refuser de prendre livraison ni de payer une marchandise que vous avez commandée ; mais vous pouvez toujours essayer de vous mettre d'accord avec votre vendeur pour qu'il renonce au contrat. Cet accord mutuel, appelé traditionnellement *mutuus dissensus* (dissentiment mutuel), doit, pour être valable, être passé dans les mêmes formes que celles qui étaient exigées pour la validité du contrat qu'il présent anéantir. Si le premier contrat devait être passé par acte authentique, il ne pourra être détruit que par un autre acte authentique.

Le *mutuus dissensus* doit être distingué d'un contrat que les parties passeraient en sens inverse du premier : ainsi, dans le cas d'une vente, si, après que le contrat a produit son plein effet, que la propriété a été transférée et la chose livrée, si le vendeur acceptait de racheter la chose. Ici il s'agit d'un contrat – ou plus exactement d'une convention – par laquelle les parties conviennent d'anéantir le premier contrat. La différence est importante surtout pour les contrats translatifs de propriété, notamment pour des raisons fiscales : un *mutuus dissensus* n'opère pas un second transfert de propriété en sens inverse, qui pourrait donner lieu au paiement de nouveaux droits de mutation.

492. Irrévocabilité des actes unilatéraux. D'une manière générale, les actes unilatéraux produiront les mêmes effets qu'un contrat. Fondamentalement, ils ont, tout comme les contrats, force obligatoire, ils « tiennent lieu de loi » à ceux qui les ont faits, selon la formule que l'article 1134 du Code civil utilise pour les conventions. Cela signifie, lorsqu'on est en présence d'un acte unilatéral générateur d'obligation – un engagement unilatéral de volonté – que l'auteur de l'acte est tenu d'exécuter ce qu'il a promis. Mais, tout comme pour les contrats, la force obligatoire des actes unilatéraux ne se limite pas à cela : elle signifie, plus fondamentalement, que celui qui a fait l'acte ne peut pas faire comme s'il n'avait pas été émis, et cela vaut tout aussi bien pour les actes juridiques qui ne sont pas créateurs d'obligations. Un locataire qui a donné congé, par exemple, ne peut pas revenir dessus et prétendre se maintenir

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

dans les lieux. Cette irrévocabilité paraît même plus forte que celle des contrats, qui peuvent toujours être révoqués du consentement mutuel des deux parties, alors que le propre d'un acte unilatéral est de ne pas pouvoir être anéanti par la personne qui l'a fait[1108]. Il n'en va autrement que dans les cas où la loi permet cette révocation (ainsi pour le testament, dont la force obligatoire est différée jusqu'au décès du testateur), ou, par analogie avec les contrats, lorsqu'il s'agit d'engagements à durée indéterminée[1109] (ainsi, un employeur qui s'est engagé à payer une prime de fin d'année à ses salariés sans limitation de durée peut à tout moment y mettre fin, sachant que cette révocation ne vaudra que pour l'avenir).

B) *Limites*

493. Limites légales. L'article 1134, alinéa 2 du Code civil, tout en posant que les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel, ajoute « ou pour les causes que la loi autorise ». Ces cas où la loi permet à un contractant de revenir sur son engagement sont extrêmement divers, et répondent à des préoccupations elles-mêmes diverses. Le cas le plus important en pratique est celui de la résolution pour inexécution, prévue par l'article 1184 du Code civil, qui permet à la partie d'un contrat synallagmatique de faire tomber le contrat – et donc de se libérer de ses propres obligations – si l'autre contractant n'exécute pas les siennes. Ce mécanisme, dont nous ferons plus loin l'étude détaillée, répond à la fois au souci de sanctionner le débiteur contractuel auteur de l'inexécution, et de sauvegarder les droits du créancier qui en est victime. La résolution pour inexécution est cependant strictement encadrée : nous verrons qu'en principe, le créancier doit la demander en justice et ne peut pas s'affranchir du contrat par une déclaration unilatérale, et que, même lorsqu'elle est permise, une telle résolution unilatérale ne peut s'opérer que sous le contrôle du juge[1110]. Beaucoup plus nettement dérogatoires à la force obligatoire du contrat sont les dispositions légales qui permettent à un contractant, que la loi veut spécialement protéger, de changer d'avis et de revenir sur son engagement sans avoir à justifier

[1108] Pour anéantir le congé, il faut le consentement du bailleur et du locataire ; conformément au principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent décider d'un commun accord de tenir pour non avenu le congé donné par l'une d'elles : (C. civ., art. 1134), Cass. be., 23 novembre 2009, n° C.08.0263.F.

[1109] Voy. *infra*, n°s 546 et s.

[1110] Voy. *infra*, n° 782.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de motifs particuliers. Le texte le plus caractéristique concerne le contrat de mandat, pour lequel l'article 2004 du Code civil dispose que « le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble » : cette révocation dite traditionnellement « *ad nutum* »[1111] est justifiée par l'idée que le mandat ne peut pas se poursuivre si le mandant n'a plus confiance dans le mandataire. En matière de mandat, l'article 2007 du Code civil prévoit aussi que le mandataire peut à tout moment renoncer au mandat. On citera encore l'article 1944 du Code civil qui prévoit que « le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors-même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution » et l'article 1794 du Code civil qui ouvre au maître de l'ouvrage dans un marché à forfait la faculté de résilier le contrat « par sa seule volonté » même si les travaux ont déjà commencé[1112]. Ces exceptions sont parfois cependant atténuées par l'obligation qui est faite à celui qui résilie avant terme d'indemniser son cocontractant (C. civ., art. 2007 et 1794), ou par la limite de l'abus de droit[1113].

À ces exceptions traditionnelles, il faut ajouter, dans le droit contemporain, les divers droits de rétractation qui sont ouverts au profit du consommateur. Ces droits ont été étudiés à propos du processus de formation du contrat dans lequel ils s'inscrivent[1114]. Mais, techniquement, ils s'analysent comme de véritables dérogations au principe de l'irrévocabilité du contrat, et donc de la force obligatoire. Ils le sont d'autant plus qu'il s'agit de facultés discrétionnaires, qui, non seulement n'ont pas à être justifiées par des motifs particuliers, mais qui ne sont pas susceptibles d'être limitées par la notion d'abus de droit.

On ne traitera pas en revanche comme une exception au principe d'irrévocabilité le droit de résiliation unilatérale dont dispose en principe tout contractant qui s'est engagé dans un contrat à exécution successive et à durée indéterminée (par exemple, un contrat de travail ou un contrat de bail). Dans de tels contrats, en effet, on ne peut pas considérer que les contractants s'engagent pour leur vie entière, et la possibilité

[1111] L'expression vient du latin, et signifie que la révocation peut intervenir sur un simple signe de tête, sans aucun motif.

[1112] On cite aussi parfois l'article 1889 du Code civil, qui permet à celui qui a prêté une chose de la reprendre même avant le terme convenu s'il lui survient « un besoin pressant et imprévu de la chose », mais ici la résiliation suppose un motif contrôlé par le juge.

[1113] Cette limite est parfois appliquée en cas de révocation du mandat. La Cour d'appel a même jugé que, en présence d'un mandat est rémunéré donné pour une durée déterminée, c'était au mandant de prouver que la révocation n'avait pas un caractère abusif en justifiant des motifs de sa décision (Cour d'appel, 9 mars 2011, n° 87256, *BIJ*, 2005, p. 12).

[1114] Voy. *supra*, n°s 167 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de mettre fin au contrat, qui n'opère du reste que pour l'avenir, est implicitement incluse dans le contenu même de l'engagement. Nous retrouverons ce mécanisme essentiel en étudiant la durée des contrats[1115].

494. Limites conventionnelles. Peut-on, par une clause du contrat, accorder à l'une des deux parties le droit de se retirer unilatéralement de celui-ci ? La réponse n'est pas évidente, car, de prime abord, une telle clause anéantit le principe même de la force obligatoire, et semble donc incompatible avec la notion même de contrat. C'est pourquoi du reste l'article 1174 du Code civil prohibe les « conditions purement potestatives », qui font dépendre une obligation contractuelle de la seule volonté de son débiteur : dire « je m'engage à cela si je veux », ou « je m'engage, mais je pourrai changer d'avis », ce n'est pas en réalité s'engager. Cependant, une clause de ce type devient possible si le droit de se retirer du contrat n'est pas complètement libre (par exemple, je vous achète ce terrain, mais je pourrai dénoncer la vente si je n'obtiens pas l'autorisation de construire dessus)[1116] ou s'il est assorti d'une contrepartie. C'est ce qui se passe dans la clause de dédit, qui est très répandue dans la pratique contractuelle, et qui est consacrée par la loi en matière de vente (C. civ., art. 1590) : un contrat – de vente, de services, de location d'une maison de vacances, etc. – est passé, mais chaque partie conserve le droit de changer d'avis dans un certain délai, en payant à l'autre une certaine somme. Dans la plupart des cas, un des contractants verse à l'autre, au départ, la somme correspondante, sous forme d'arrhes : si c'est ce contractant qui se dédit, il perdra les arrhes, si c'est l'autre, il devra restituer deux fois le montant des arrhes versés.

Les arrhes ne doivent pas être confondus avec l'acompte qu'un contractant verse à l'autre dans l'attente de l'exécution d'un contrat (par exemple, à un peintre avant qu'il ne commence les travaux de peinture). Un tel acompte ne donne à aucune partie le droit de se retirer du contrat, c'est au contraire une concrétisation immédiate de la force obligatoire. En conséquence, si celui qui a versé l'acompte change ensuite d'avis et s'oppose à l'exécution du contrat, on est en présence d'une inexécution contractuelle qui ouvre droit aux sanctions de l'inexécution du contrat (exécution forcée, dommages et intérêts qui ne seront pas nécessairement égaux au montant de l'acompte versé). Dans la pratique, il n'est cependant pas toujours facile de savoir si on est en présence d'arrhes ou d'acompte. En droit français, l'article L. 114-1 du Code de la consommation présume que la somme versée par un consommateur constitue des arrhes, mais cette présomption n'est pas consacrée au Luxembourg, où il faudra dans chaque cas rechercher l'intention des parties, au-delà des termes employés.

[1115] Voy. *infra*, n°s 546 et s.

[1116] On est alors en présence d'une condition parfaitement licite.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§2. L'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat

495. Exigence générale du droit des contrats. Venant après l'affirmation de l'irrévocabilité du contrat, l'article 1134, alinéa 3 du Code civil pose que les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ». On a vu dans les développements introductifs comment cette notion de bonne foi issue du droit romain, était devenue, en changeant de sens, une exigence centrale du droit des contrats modernes, reconnue à peu près partout en Europe (à l'exception notable des pays de *common law*)[1117]. On a vu aussi que la notion de bonne foi, en matière contractuelle, désigne le comportement loyal attendu des contractants ; dans ce sens, elle se distingue de la notion surtout utilisée en droit des biens, où la bonne foi désigne la croyance légitime qu'une personne a dans une situation qui se révèle ensuite être fausse[1118]. Nous avons vu aussi que la jurisprudence, dépassant la lettre de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil, fait jouer un rôle à la bonne foi dans toutes les phases de la vie du contrat, et que cette vision extensive a été consacrée par l'article 1104 du Code civil français. Nous en avons déjà vu diverses applications au stade des négociations précontractuelles[1119], notamment avec l'obligation d'information qui pèse sur certains contractants[1120]. Il s'agit ici de développer le rôle particulier que joue l'exigence de bonne foi au stade de l'exécution du contrat – le seul qui soit, du reste, explicitement prévu par l'article 1134, alinéa 3 du Code civil, repris et développé par l'article 5.73 du nouveau Code civil belge.

496. Différentes fonctions au stade de l'exécution du contrat. Si on se limite ici au rôle de la bonne foi dans l'exécution du contrat, on peut discerner plusieurs fonctions différentes de la notion. Dans les pays du Code civil, ces fonctions ont fait l'objet d'une systématisation beaucoup plus rigoureuse dans la doctrine belge que dans la doctrine française. Les auteurs belges distinguent habituellement trois fonctions de la bonne foi[1121] : une fonction interprétative, une fonction complétive et une fonction modératrice – certains prônant, sans grand succès jusqu'à présent, une quatrième fonction, adaptatrice. Cette présentation trouve un écho dans certains exposés

[1117] Pour la présentation générale de la bonne foi, voy. *supra*, n°s 114 et s.
[1118] Voy. *supra*, n° 117.
[1119] Voy. *supra*, n°s 177 et 178.
[1120] Voy. *supra*, n°s 197 et s.
[1121] Voy. p. ex. : P. Wéry, n°s 112 et s. ; P. Van Ommeslaghe, n°s 98 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

comparatifs : J. Smits présente ainsi les fonctions de la bonne foi dans les pays de droit civil autour de trois mots « *supplementation* », « *interpretation* » et « *restriction* »[1122]. Ces trois fonctions peuvent sans doute être ramenées à deux, car les fonctions complétive et interprétative interviennent toutes deux lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu du contrat (**A**). Toute autre est la fonction modératrice ou restrictive, qui permet de bloquer l'exercice d'une prérogative contractuelle (**B**). Ces deux fonctions se retrouvent très explicitement dans l'article 5.73 du nouveau Code civil belge.

A) *La bonne foi, instrument de détermination du contenu contractuel*

497. Interprétation. Lorsque la rédaction du contrat est obscure ou imprécise, et que les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la signification de telle ou telle clause, il appartient au juge d'interpréter le contrat. Nous verrons plus loin que cette interprétation doit se faire en principe en fonction de la volonté des parties, mais que les articles 1156 et suivants du Code civil, qui réglementent la question, font également référence à certains éléments objectifs. Parmi ceux-ci, la bonne foi, bien qu'elle ne soit pas expressément visée par ces articles, peut certainement jouer un rôle. Lorsqu'on peut hésiter sur le sens d'une clause, et à défaut d'éléments indiquant la volonté des parties, le juge peut retenir une interprétation conforme à la bonne foi. Le lien avec le comportement des parties est double. L'interprétation conforme à la bonne foi est d'abord celle que les parties, si elles s'étaient comportées loyalement l'une envers l'autre, auraient retenue. Mais c'est aussi celle qui conduit à imposer à chaque contractant un comportement loyal.

498. Création d'obligations. Nous verrons plus loin que le juge peut adjoindre aux obligations expressément voulues par les parties des obligations complémentaires, qui permettront de sanctionner sur le fondement de la responsabilité contractuelle certains comportements ayant causé un préjudice à l'autre partie. L'article 1134, alinéa 3 du Code civil est un des instruments permettant la création de telles obligations. Dans certains cas, le juge fera dériver de l'exigence générale de bonne foi ou de loyauté des obligations à contenu plus précis. Nous avons vu ainsi que, au stade de la formation du contrat,

[1122] SMITS, pp. 138 et s.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

c'est aujourd'hui le devoir général de bonne foi qui est utilisé pour justifier les obligations d'information mises à la charge de certaines parties. De même, au stade de l'exécution du contrat, la jurisprudence française – ou, parfois, ses interprètes – rattache à la bonne foi l'obligation pesant sur un employeur de reclasser ses salariés, ou d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi[1123], ou encore, dans le cadre des relations commerciales, l'obligation plus générale de coopération ou de collaboration. Mais, dans un certain nombre de cas, la bonne foi n'apparaît pas seulement comme un principe ou une exigence générale d'où on fait dériver des obligations à objet plus spécifique, elle apparaît elle-même comme objet d'obligation, généralement sous la terminologie d'« obligation de loyauté ». Une telle « obligation » apparaît de manière particulièrement fréquente dans la jurisprudence de la Cour de cassation française ; elle a notamment été consacrée par la Chambre commerciale, qui affirme par exemple que « les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat »[1124]. L'article 5.73 du Code civil belge dispose de son côté que « chacune des parties doit, dans l'exécution du contrat, se comporter comme le ferait une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances ». On trouve de plus en plus souvent dans la jurisprudence luxembourgeoise une telle formule générale : ainsi dans un arrêt de la Cour d'appel de 2003 qui affirme que le débiteur obligé sous condition est tenu d'une « obligation de loyauté » lui imposant « de faire tout son possible pour que l'opération aboutisse »[1125]. Ce type d'utilisation de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil pour faire peser sur un contractant des obligations non expressément prévues rejoint un autre mécanisme que nous étudierons plus loin, celui de l'article 1135 du Code civil selon lequel « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature »[1126]. En théorie les deux textes ont des fonctions différentes : l'article 1135 du Code civil permet au juge de

[1123] Voy. p. ex. : Cass. fr. (soc.), 25 février 1992, n° 89-41634 « L'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ».

[1124] Cass. fr. (comm.), 24 novembre 1998, n° 96-18537. Voy. aussi Cass. fr. (1re civ.), 16 mars 2004, n° 01-15804, qui parle d'une « obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi ».

[1125] Cour d'appel, 12 novembre 2003, *Pas.*, 32, p. 426-Voy. plus récemment : Cour d'appel, 2 juillet 2020, n° CAL-2019-00550, *Pas.*, 40, p. 59 ; Cour d'appel, 25 novembre 2021, n° CAL-2019-00311.

[1126] Voy. *infra*, nos 534 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

créer des obligations non prévues, alors que l'article 1134, alinéa 3 du Code civil lui donne le pouvoir de contrôler la manière dont un contractant exécute ses obligations[1127]. Mais, dans la jurisprudence, les deux textes se recoupent aujourd'hui très largement, et certains projets européens consacrent explicitement la fonction complétive de la bonne foi[1128].

Dans cette fonction, le manquement à la bonne foi conduit logiquement à la mise en jeu des sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles. Dans la mesure où l'exécution en nature de ces obligations de loyauté paraît difficilement envisageable, la sanction sera, en général, la responsabilité contractuelle du contractant fautif. Les textes européens envisagent cependant parfois une autre sanction, consistant à « empêcher la partie défaillante d'exercer ou d'invoquer un droit, un moyen d'action ou de défense dont elle disposerait autrement » (DCEV, art. 32). Dans le DCFR, c'est même la seule sanction prévue[1129]. En réalité, on bascule alors vers une tout autre fonction, beaucoup plus originale, de la bonne foi contractuelle, celle qui consiste à contrôler l'exercice de prérogatives contractuelles.

B) *La bonne foi, instrument de contrôle de l'exercice de prérogatives contractuelles*

499. Principe. Dans les pays du Code civil, la sanction du manquement à la bonne foi ne passe pas toujours par une approche en termes d'obligations, qui conduit à l'application des sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles. On peut relever, dans les jurisprudences française et belge, un certain nombre de décisions où la sanction du comportement contraire à la bonne foi consiste tout simplement dans la neutralisation, dans l'inefficacité de ce comportement au regard des conséquences qui lui sont normalement attachées par le contrat. Ces décisions sont rendues en réaction à la prétention d'un contractant – généralement en position de créancier – qui prétend faire usage de certaines prérogatives que lui confère le contrat (demande d'exécution de sa créance, mise en œuvre de sanctions contre l'autre contractant, exercice d'une

1127 P. JACQUES, *Regards sur l'article 1135 du Code civil*, *op. cit.*, n°s 157 et s., spéc. n°s 167 et s.

1128 Voy. p. ex. l'article 32 du Code Gandolfi.

1129 « Breach of the duty does not give rise directly to the remedies for non-performance of an obligation but may preclude the person in breach from exercising or relying on a right, remedy or defence which that person would otherwise have » (art. III-1 : 103).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

option, etc.)[1130]. L'article 1134, aliéna 3 du Code civil va permettre au juge de contrôler la manière dont ces prérogatives sont mises en œuvre, non pas seulement en condamnant à des dommages et intérêts celui qui les exerce de manière déloyale, mais en rejetant la prétention fondée sur cet exercice déloyal. Un exemple caractéristique est celui de la jurisprudence française relative aux clauses résolutoires, qui a constitué, à partir des années 1970, une des premières manifestation de la (re)découverte de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil dans le droit français des contrats. Le créancier, victime de l'inexécution, qui invoque la clause de mauvaise foi (par exemple, après avoir toléré pendant de longues années une inexécution qu'il prétend ensuite faire sanctionner par un revirement brutal, ou encore en profitant d'une période où il sait que le débiteur ne peut être joint, pour envoyer la mise en demeure) se verra refuser la résolution alors pourtant que les conditions posées par la clause pour l'obtenir semblent réunies[1131]. Dans le même ordre d'idées, un arrêt de 1976 approuvait les juges du fond d'avoir considéré qu'un dédit exercé de mauvaise foi « ne pouvait produire aucun effet juridique »[1132]. Un raisonnement similaire a pu être tenu, plus récemment, à l'égard d'un crédirentier qui, dans le seul but d'obtenir la résolution du contrat, se prévalait d'une clause lui permettant d'exiger « à n'importe quel moment et sur son seul souhait, pour quelque motif que ce soit la conversion de la rente en une obligation de soins », à un moment où le débirentier, en raison d'un accident l'ayant handicapé, était dans l'impossibilité d'exécuter cette obligation de soins : cette attitude a conduit au rejet de la demande en résolution[1133]. On trouve l'équivalent de ces solutions en Belgique, où elles illustrent ce que les auteurs belges appellent la fonction dite « limitative » ou « modératrice » de la bonne foi. La Cour de cassation s'en est notamment servie pour procéder à la réduction des clauses pénales d'un montant excessif[1134], avant que le législateur belge n'intervienne sur cette question[1135]. Elle a également admis, sur le même fondement, que le juge pouvait imposer la résolution du contrat à un

[1130] Sur cette notion, voy. L. Molina, *La prérogative contractuelle*, préf. L. Aynes, Paris, LGDJ, 2022.

[1131] Cass. fr. (3e civ.), 16 octobre 1973, n° 72-11956 ; Cass. (3e civ.), 8 avril 1987, n° 85-17596 ; Cass. (3e civ.), 31 janvier 1995, n° 92-20654 ; *D.*, 1995, p 389, note C. Jamin ; Cass. (1re civ.), 16 février 1999, n° 96-21997, *Defrénois*, 2000, p. 248, obs. D. Mazeaud.

[1132] Cass. (3e civ.), 11 mai 1976, n° 75-10854.

[1133] Cass. (1re civ.), 7 février 2006, n° 03-15394.

[1134] Cass., 18 février 1988, *Pas.*, 1988, I, p. 728.

[1135] Voy. *infra*, nos 881 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

créancier qui réclame l'exécution forcée de la convention de manière abusive[1136]. Plus récemment, répondant aux vœux d'une partie de la doctrine[1137], la haute juridiction belge a accepté de contrôler sur ce fondement l'exercice d'une clause résolutoire expresse[1138].

Ces solutions jurisprudentielles peuvent être rapprochées de certaines dispositions légales qui, même si elles ne s'y réfèrent pas explicitement, sont souvent considérées comme des applications particulières de l'exigence de bonne foi contractuelle. On songe ainsi à l'article 1178 du Code civil, qui interdit à celui qui a empêché l'accomplissement d'une condition suspensive de se prévaloir de sa défaillance pour être libéré du contrat[1139], ou encore à l'article 1150 du Code civil qui neutralise les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité contractuelle en cas de dol ou de faute lourde du débiteur.

Cette utilisation de la bonne foi comme moyen de blocage des prérogatives contractuelles peut être rapprochée d'un mécanisme procédural typique de la *common law*, celui de l'*estoppel,* qui s'est récemment introduit dans les droits des pays civilistes. Ce mécanisme permet à un juge de bloquer (« stopper ») une prétention incompatible avec un comportement antérieur d'un plaideur, lorsque le défendeur avait pu se fier à ce comportement antérieur, et qu'il en avait tenu compte dans sa propre conduite. Dans les droits d'Europe continentale, et en particulier dans les pays du Code civil, le mécanisme de l'estoppel, ou le principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, qui est son équivalent fonctionnel, sont habituellement présentés comme une des applications de l'exigence de bonne foi. On trouve du reste des décisions jurisprudentielles, en droit français, qui font application de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil pour s'opposer à la prétention d'un contractant en contradiction avec son comportement antérieur[1140]. La jurisprudence luxembourgeoise, depuis quelques années, fait également le lien entre l'estoppel et l'exigence de bonne foi[1141], même si elle cantonne le rôle de l'estoppel à la sanction de comportements incohérents dans le cadre procédural[1142].

500. Lien avec l'interdiction de l'abus de droit : différences d'approches en France et en Belgique. Sur ce rôle de blocage au nom de la bonne foi de l'exercice de prérogatives contractuelles, l'approche belge et l'approche française apparaissent sensiblement différentes.

1136 Cass. be., 16 janvier 1986, *Pas. be*., 1986, I, p. 602.

1137 P. WÉRY, « Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles », in *Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil*, Bruxelles, La charte, 2004, pp. 287 et s., n° 49.

1138 Cass. be., 9 mars 2009, *TBBR*., 2010/3, pp. 130-136, note J.-F. GERMAIN, « Le contrôle de la gravité du manquement en présence d'une clause résolutoire expresse ».

1139 Voy. *infra*, n° 608.

1140 Cass. fr. (comm.), 8 mars 2005, n° 02-15783, *RLDC*, 2005, obs. D. Houtcieff, « Quelle sanction pour la contradiction ? ».

1141 Voy. p. ex. : Cour d'appel, 4 juillet 2018, n° 44893 ; Trib. Luxembourg, 2 juin 2023, n° TAL-2020-06456.

1142 Cass., 6 mai 2021, n° CAS-2020-00087 ; Trib. Luxembourg, 2 juin 2023, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

En Belgique, la fonction limitative de la bonne foi est identifiée avec l'interdiction de l'abus de droit : le créancier, ou plus largement le titulaire d'une prérogative contractuelle sera considéré comme ayant manqué à la bonne foi lorsqu'il aura abusé de son droit. Faite pour la première fois par un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 1983[1143], constamment reprise dans les arrêts postérieurs, et largement admise en doctrine[1144], cette identification est aujourd'hui consacrée par l'article 5.73 du nouveau Code civil belge, qui présente explicitement comme une application du principe de bonne foi la règle selon laquelle « nul ne peut abuser des droits qu'il tire du contrat ». Il n'en va pas de même en droit français, où la doctrine s'efforce, de manière plus ou moins convaincante, de distinguer l'abus de droit du manquement à la bonne foi en matière contractuelle[1145]. La jurisprudence, quant à elle, pour sanctionner les comportements déloyaux d'un titulaire de prérogatives contractuelles, se réfère tantôt à l'une, tantôt à l'autre[1146] des notions, sans qu'on puisse toujours savoir exactement pourquoi[1147]. Cette attitude s'explique parce que, dans la tradition française, la problématique de l'abus de droit s'est principalement développée dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle, et que la sanction normale de l'abus est toujours la condamnation du titulaire du droit à des dommages et intérêts, plus que le blocage de l'exercice abusif de la prérogative (comme c'est aujourd'hui le cas en Belgique), à tel point que les manuels français de droit des obligations ne consacrent en général aucun développement à l'abus de droit dans la partie relative aux contrats[1148].

[1143] Cass. be., 19 septembre 1983, *Pas. be.*, 1984, I, p. 55 ; *J.T.*, 1985, p. 56, note Dufrêne ; *R.C.J.B.*, 1986, p. 282, note J.L. Fagnart ; *R.D.C.*, 1984, p. 276, note Rauws.

[1144] Voy. : J.-F. Romain, « Le principe de la convention-loi (portée et limites) : réflexions au sujet d'un nouveau paradigme contractuel », in *Les obligations contractuelles*, Bruxelles, Éd. jeune barreau, 2000, n° 390-3.

[1145] Voy. p. ex. : Fabre-Magnan, 2024, n° 689.

[1146] Pour le recours à la notion de manquement à la bonne foi : Cass. fr. (3e civ.), 8 avril 1987, n° 85-17596 ; Cass. (3e civ.), 31 janvier 1995, n° 92-20654 ; Cass. (1re civ.), 16 février 1999, n° 96-21997 (clause résolutoire invoquée de mauvaise foi) ; Cass. (3e civ.), 11 mai 1976, n° 75-10854 (clause de dédit) ; Cass. fr. (comm.), 8 mars 2005, n° 02-15783 (comportement contradictoire d'un banquier).

[1147] Voy. p. ex., pour l'utilisation de l'abus de droit : Cass. fr. (soc.), 5 mai 2004, n° 02-41224 (abus du droit de rompre un contrat de travail en période d'essai) ; Cass. fr. (ass. plén.), 1er décembre 1995, 5 arrêts, *D.*, 1996, p. 13, concl. M. Jéol et note L. Aynès ; *JCP*, 1996, II. p. 22565, concl. M. Jéol et note J. Ghestin, (abus du droit de fixer unilatéralement le prix dans un contrat-cadre) ; Cass. (soc.), 14 octobre 2008, n° 07-43071 (abus dans l'usage par un employeur d'une clause de mobilité).

[1148] Pour une comparaison plus complète de l'abus de droit en France et en Belgique, voy. P. Ancel, « L'abus de droit en droit français et en droit belge », in E. Van den Haute (dir.), *Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge*, *op. cit.*, pp. 77 à 103.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

501. Lien avec l'interdiction de l'abus de droit : jurisprudence luxembourgeoise. Sur ce point, la jurisprudence luxembourgeoise récente s'inscrit assez nettement dans l'optique du droit belge, en assimilant la fonction limitative de la bonne foi avec l'interdiction de l'abus de droit. Dans un arrêt de 2022, la Cour d'appel, après avoir rappelé que le principe de bonne foi engendre pour chaque partie une obligation de loyauté, pose ainsi que « [l]e principe d'exécution de bonne foi des conventions interdit à une personne d'abuser des droits que lui confère le contrat »[1149]. Le même arrêt, se référant explicitement à la position de la Cour de cassation belge, juge que'« il y a abus lorsque le titulaire, usant dans son seul intérêt d'un droit qu'il puise dans la convention, en retire un avantage disproportionné à la charge corrélative de l'autre partie », et se propose de rechercher si, en l'espèce « s'il y a violation de l'exécution de bonne foi, respectivement un abus de droit ». Cette assimilation, qui se retrouve dans diverses autres décisions[1150], paraît logique en droit luxembourgeois. En effet, l'introduction de la notion d'abus de droit dans l'article 6-1 du Code civil par une loi du 2 juillet 1987, sur le modèle du Code civil suisse, marque une certaine rupture avec la tradition française. L'article 6-1 du Code civil dispose en effet que « Tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l'intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l'exercice normal d'un droit, n'est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l'abus ». La formule « n'est pas protégé par la loi » marque clairement que la première sanction de l'exercice abusif d'un droit doit être le refus par le juge de déclarer fondée la prétention du titulaire du droit. La fonction limitative de la bonne foi contractuelle, qui permet de bloquer la prétention de celui qui exerce de manière déloyale une prérogative déloyale, s'inscrit donc assez naturellement dans le cadre de ce texte.

502. Limites : jurisprudences française et belge. Les jurisprudences belge et française ont posé des limites aux pouvoirs dont le juge dispose pour bloquer l'usage d'une prérogative contractuelle exercée contrairement à la bonne foi (c'est-à-dire de manière abusive). Dès 1982, la Cour de cassation belge a posé que « la

[1149] Cour d'appel, 8 mars 2022, n° CAL-2020-01079.

[1150] Voy. p. ex. : Trib. Luxembourg, 16 novembre 2021, n° TAL-2020-04497 ; Trib. Luxembourg, 6 juin 2023, n° TAL-2021-04178 ; Trib. Luxembourg, 23 janvier 2024, n° TAL-2023-06022.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

sanction d'un tel abus n'est pas la déchéance totale de ce droit, mais seulement la réduction de ce droit à son usage normal »[1151], et cette formule a été réitérée à maintes reprises dans la jurisprudence postérieure[1152]. Cela signifie en particulier, en cas d'abus dans la mise en œuvre d'une clause contractuelle, qu'il n'appartient pas au juge de « réviser la convention et de déclarer ladite partie totalement déchue du droit qu'elle déduit du contrat »[1153]. L'abus permet ainsi au juge de paralyser momentanément l'usage d'une clause, parce qu'elle est mise en œuvre de manière abusive, mais cette clause, dès lors qu'elle est licite, n'est pas rayée définitivement du contrat, elle pourra être invoquée ultérieurement, conformément à la bonne foi cette fois, si l'occasion s'en présente. Cette limite se retrouve dans un arrêt très remarqué de la Chambre commerciale de la Cour de cassation française du 10 juillet 2007, même si cette limite est ici exprimée sur le terrain de la bonne foi. Selon cet arrêt, rendu au visa de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil, « si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties »[1154]. On retrouve bien la même idée que la sanction judiciaire ne peut pas aller jusqu'à priver le créancier contractuel de son droit. Aussi bien en France qu'en Belgique, cependant, cette distinction entre le blocage de l'exercice du droit et sa suppression, apparaît comme très relative, notamment dans les cas où la clause invoquée abusivement n'est appelée à jouer qu'une seule fois[1155]. En toute hypothèse, la jurisprudence belge semble reconnaître au juge un pouvoir plus étendu, puisqu'elle l'autorise à réduire le droit du créancier contractuel, alors que la Cour de cassation française prohibe de manière générale toute atteinte à la substance des droits contractuels.

[1151] Cass. be., 16 décembre 1982, *Pas. be.*, 1983, I, p. 472.

[1152] Cass. be., 18 février 1988, *Pas. be.*, I, p. 728 ; *R.D.C.*, 1988, note E. Dirix ; Cass. be., 11 juin 1992, *Pas. be.*, I, p. 898 ; Cass. be., 8 février 2001, *Pas. be.*, 2001, I, p. 244.

[1153] Cass. be., 7 février 1994, *Pas. be.*, 1994, I, p. 150.

[1154] Cass. fr. (comm.), 10 juillet 2007, n° 06-14768. Voy., outre de multiples commentaires les observations de Y. Lequette, in *Grands arrêts de la jurisprudence civile*, t 2, 12e éd., Paris, Dalloz, 2008 n° 164. La formule a été reprise notamment par Cass. fr. (3e civ.), 26 mars 2013, n° 12-14870. Sur cet arrêt voy. le commentaire de Y.-M. Laithier, *R.D.C.*, 2013, p. 888.

[1155] Voy. à ce sujet les remarques de Wéry, n° 488 ; Van Ommeslaghe, n° 37. Voy. aussi *infra*, nos 508 et s., à propos de l'imprévision, le rejet d'une demande en exécution d'un contrat dont l'équilibre a été bouleversé par l'évolution économique.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

503. Limites : jurisprudence luxembourgeoise. Ici encore, la jurisprudence luxembourgeoise semble plus proche des solutions belges que de la position française. Dans toute une série de décisions rendues en matière de bail commercial au sujet des incidences de la pandémie de Covid-19, le tribunal de Luxembourg s'est fondé sur l'exigence de bonne foi – expressément assimilée à l'interdiction de l'abus de droit – pour réduire le montant des loyers dus par le commerçant pendant la période où il avait été interdit d'exercer son activité[1156]. Suivant une jurisprudence française des années 1980, le tribunal commence par poser que l'exigence de bonne foi oblige le bailleur à venir en aide à son locataire en difficulté, en acceptant de négocier une diminution temporaire du montant des loyers, mais, au lieu de se borner, comme l'avait fait la Cour de cassation française, il procède directement à la réduction du montant des loyers pour sanctionner le comportement du bailleur qui, en ayant obstinément refusé toute négociation, a abusé de son droit d'exiger l'exécution du contrat. Cette démarche, qui aboutit indirectement à une sorte de révision du contrat pour imprévision, paraît directement inspirée de l'approche belge. Saisie d'un pourvoi contre une de ces décisions, la Cour de cassation, sans reprendre directement à son compte la motivation du tribunal, a estimé qu'elle était justifiée[1157]. La réduction de loyer pendant les périodes d'inactivité n'est cependant pas de droit, et plusieurs décisions rejettent les demandes de réduction en jugeant que le bailleur a eu une attitude suffisamment conciliante et n'a pas manqué à la bonne foi[1158]. Toutes les décisions soulignent que, en principe, l'article 1134, alinéa 3 ne permet pas au juge de modifier les stipulations du contrat, et que ce n'est que de manière exceptionnelle que le manquement à la bonne foi permet de porter atteinte à ce principe dont il convient maintenant de faire l'étude.

[1156] Voy. not. Trib. Luxembourg, 28 juin 2021, n^os^ TAL-2021-02457 et TAL-2021-02480 ; Trib. Luxembourg, 12 juillet 2021, n^os^ TAL-2021-02935 et TAL-2021-03029, *Pas.*, 40, p. 562, note P. ANCEL et A. PRÜM ; Trib. Luxembourg, 13 juillet 2021, n° TAL-2021-01938. Voy. en dernier lieu Trib. Luxembourg, 10 octobre 2023, n° TAL-2021-07267, à la motivation particulièrement explicite. Sur cette jurisprudence, voy. A. WAISSE, « Bail commercial et covid-19 : la réduction du loyer au nom du solidarisme contractuel », *JN Obligations*, 2021, n° 4, pp. 119-1243. Sur l'ensemble de la question, voy. I. CORBISIER, « An II de la pandémie de Covid-19 – Un point comparatif sur les tribulations du paiement du loyer dans le cadre d'un bail commercial (Luxembourg, Belgique et France) : cacophonie, solidarisme ou pragmatisme ? », *JYL*, 2021/2, pp. 33-43, et *J.T.L.*, 2021/3, pp. 69-78.

[1157] Cass., 27 octobre 2022, n° CAS-2021-00108, rejetant le pourvoi contre Trib. Luxembourg, 12 juillet 2021, n^os^ TAL-2021-02935 et TAL-2021-03029.

[1158] Voy. p. ex. : Trib. Luxembourg, 12 juillet 2021, n° TAL-2021-04656 (pourvoi rejeté par Cass., 22 décembre 2022, n° CAS-2021-00114) ; Trib. arr. Luxembourg, 22 décembre 2021, n° TAL-2021-06976 ; Trib. arr. Luxembourg, 22 décembre 2021, n° TAL-2021-04661 ; Trib. Luxembourg, 22 décembre 2022, n° TAL-2022-03827.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

SECTION 2. LA FORCE DU LIEN OBLIGATOIRE POUR LE JUGE

504. Le contrat, norme de référence pour le juge. La force obligatoire, qui signifie au premier chef que le contrat lie, engage les parties, s'impose au juge chargé de régler les litiges entre elles. L'analogie avec la loi que fait l'article 1134 du Code civil est ici particulièrement parlante : lorsque le juge doit régler un litige contractuel, la règle de droit dont il doit, d'abord, faire application, est la norme que les parties elles-mêmes se sont données, c'est-à-dire la norme contractuelle. Sans doute, les normes légales sont toujours très présentes à l'arrière-plan, avec une force supérieure à celle du contrat lui-même : d'une part, le juge ne devra pas faire application du contrat si celui-ci n'a pas été conclu conformément à la loi et il devra en écarter les clauses illicites, d'autre part, si le contrat est incomplet, il sera amené à combler ses lacunes en faisant appel, notamment, aux règles légales prévues pour s'appliquer en l'absence de volonté exprimée des parties[1159]. Mais, pour tout ce qui est prévu dans le contrat, et qui n'est pas contraire à la loi (ou plus généralement aux règles posées par l'ordre juridique pour la validité des accords privés), le juge n'aura pas en principe le choix : c'est le contrat qu'il devra appliquer, même si la solution choisie par les parties lui paraît injuste ou économiquement insatisfaisante. Il en résulte l'interdiction de principe pour le juge de modifier le contrat. Ce principe est cependant loin d'être absolu (§ 1) et il est particulièrement mis à l'épreuve dans le cas de l'imprévision, lorsque l'équilibre contractuel voulu par les parties se trouve bouleversé par un changement imprévu de circonstances (§ 2).

§1. L'interdiction pour le juge de modifier le contrat

505. Principe. Par principe, le juge ne peut pas modifier une stipulation contractuelle ou refuser de l'appliquer : il ne peut pas, par exemple, diminuer le prix que les parties ont convenu pour rémunérer une prestation, refuser d'appliquer une limitation de responsabilité au motif que le dommage résultant de l'inexécution du contrat lui paraît trop grave, porter de 6 mois à un an le délai que le contrat laisse à une partie pour exercer telle ou telle prérogative, etc. Toute décision qui se permettrait de procéder à ce type de modification du contenu contractuel devrait être censurée par la Cour de cassation sur le fondement de l'article 1134 du Code civil.

[1159] Voy. *infra*, n° 533.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Il convient de mettre à part les modifications qui peuvent résulter de l'illicéité d'un contrat ou d'une stipulation contractuelle. D'une part, dans certains cas exceptionnels, le juge est autorisé à « rectifier » le contrat ou la clause pour le rendre licite : ainsi lorsqu'un prix est lésionnaire, le juge est autorisé à le réviser pour rééquilibrer le contrat[1160]. D'autre part, plus généralement, lorsque le juge prononce la nullité d'une seule clause, en laissant subsister le contrat pour le surplus, il en résulte, inévitablement une modification du contrat. Dans ces hypothèses, cependant, le juge ne méconnaît pas la force obligatoire de la clause ou du contrat puisque de toute façon ce qui a été convenu entre les parties était contraire à la loi et n'avait pas force obligatoire : la révision du contrat n'est ici qu'un diminutif de l'annulation.

506. Exceptions légales. Quelle que soit son importance pour l'ordre social, le principe de la force obligatoire ne doit pas être conçu comme un dogme absolu, et on peut concevoir que le législateur lui apporte des exceptions justifiées par diverses considérations, éventuellement sous le contrôle de la juridiction constitutionnelle[1161]. Le législateur peut donc autoriser les juges, dans certains cas strictement délimités, à apporter des modifications à des contrats pourtant parfaitement valables, et donc dotés de force obligatoire. Sans prétendre en donner un catalogue exhaustif, on signalera ici quelques dispositions remarquables, dont l'étude plus approfondie sera faite ultérieurement à propos des stipulations contractuelles auxquelles elles se rapportent. Dans de nombreux cas, la faculté laissée au juge de modifier un contrat est liée au souci d'aider un débiteur contractuel en difficulté. Le Code civil contient à cet égard une disposition tout à fait générale, l'article 1244, qui permet au juge « en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ». Ce délai de grâce de droit commun est aujourd'hui doublé par diverses dispositions spéciales à certains débiteurs, notamment dans le cadre des procédures visant à traiter les difficultés financières des entreprises[1162], ou, plus récemment, les situations de surendettement des particuliers[1163]. La récente loi du 7 août 2023 sur les faillites

[1160] *Cf.* C. civ., art. 1118, si la partie lésée demande l'exécution du contrat après réduction des obligations lésionnaires.

[1161] En France, le Conseil constitutionnel a érigé la force obligatoire du contrat en un principe constitutionnel : C. const., 10 juin 1998, n° 98-401 DC, *J.O.*, 14 juin 1998, p. 9033 ; *RTD civ.*, 1998, p. 796, obs. N. MOLFESSIS « le législateur ne saurait porter à l'économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » (à propos de l'application aux contrats en cours d'une loi nouvelle).

[1162] Voy. les articles 593 et suivants du Code de Commerce (Arr. g. d du 4 octobre 1934) sur le sursis de paiement aux commerçants en difficulté.

[1163] Voy. L. du 8 janvier 2013 concernant le surendettement.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

va même, sur le modèle français, jusqu'à instaurer une possibilité d'effacement des dettes des faillis personnes physiques lorsque la procédure est clôturée pour insuffisance d'actif[1164]. Il convient cependant d'observer que ces diverses mesures ne sont pas spécifiques aux obligations contractuelles, et qu'elles peuvent s'appliquer aux dettes de toute nature quelle qu'en soit la source. Il n'en va pas de même d'autres dispositions, spécifiques au droit des contrats, qui sont plutôt fondées sur le souci d'assurer ou de restaurer un certain équilibre contractuel, indépendamment de la situation personnelle du contractant désavantagé : le pouvoir de révision des clauses pénales, intégré dans les articles 1152 et 1231 du Code civil, sur le modèle français, par la loi du 15 mai 1987, en constitue l'exemple le plus caractéristique. Lorsqu'une clause contractuelle fixe par avance le montant des dommages et intérêts dus en cas d'inexécution du contrat, le juge peut réduire ou augmenter cette « peine », si elle est « manifestement excessive ou dérisoire »[1165]. Ce type de dispositions constitue une atteinte beaucoup plus directe à la force obligatoire du contrat que les mesures d'aide aux débiteurs en difficulté.

507. Exception jurisprudentielle. Il est très rare que les tribunaux, en dehors de toute disposition légale les y autorisant, se reconnaissent eux-mêmes le droit de modifier le contenu d'un contrat. Cependant, la jurisprudence luxembourgeoise reconnaît depuis longtemps, tout comme en France et en Belgique, la possibilité pour un juge de réduire les honoraires des mandataires. Un jugement du Tribunal de Luxembourg de 1955 pose ainsi que « bien que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, il est admis que les honoraires d'un agent d'affaires, eussent-ils été stipulés à forfait, peuvent être réduits par les tribunaux, s'ils sont hors de proportion avec les soins effectivement donnés ou avec le service effectivement rendu »[1166]. La Cour d'appel en a fait application pour contrôler la fixation des honoraires d'un avocat, alors même que la loi de 1991 confie ce contrôle au Conseil de l'Ordre[1167]. La jurisprudence est constante sur ce point, les tribunaux considérant que le Conseil de l'ordre ne donne qu'un avis qui ne lie pas le juge[1168].

1164 C. comm., art. 536-3.

1165 Voy. *infra*, n°s 881 et s.

1166 Trib. Luxembourg, 29 juin 1955, *Pas.*, 16, p. 412.

1167 Cour d'appel, 30 janvier 2002, *Pas.*, 32, p. 159

1168 Pour des applications récentes, voy. : Trib. Luxembourg, 26 novembre 2013, n° 152701 ; Cour d'appel, 20 décembre 2023, n° CAL-2023-00152 ; Trib. Paix Esch, 7 janvier 2024, n° 22/2024 E-CIV 229/22 ; Trib. Paix Diekirch, 8 juillet 2024, n° 805/24.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Cette solution, qui remonte au droit romain, est parfois justifiée par l'idée que le mandat est normalement un contrat gratuit[1169] ; elle est également liée au fait qu'il est souvent difficile d'apprécier par avance l'importance exacte de la mission d'un mandataire. Aussi bien n'est-ce que dans ce cas où la rémunération a été fixée par avance que le pouvoir de révision judiciaire se justifie, il n'a pas lieu d'être lorsque la rémunération a été a été confirmée après l'exécution du mandat[1170].

§2. Le problème de l'imprévision

508. Notion. Le problème de la possibilité pour le juge de modifier le contrat se pose avec une acuité particulière dans les cas dits d'imprévision. L'hypothèse est que les circonstances qui ont présidé à la conclusion du contrat, et qui ont déterminé les conditions acceptées par les parties, ont fondamentalement changé depuis cette conclusion, sans que les parties l'aient prévu, de sorte que l'équilibre du contrat, tel qu'il a été voulu par les parties, s'en trouve complètement bouleversé. Bien que la question soit beaucoup plus large, on songe aujourd'hui principalement, lorsqu'on évoque l'imprévision, à un changement des circonstances économiques, qui aboutit à rendre l'exécution du contrat beaucoup plus onéreuse pour l'une des parties. Par exemple, un contrat a été passé pour la fabrication d'un matériel incorporant parmi ses éléments un certain métal, et le prix du matériel a été fixé en fonction du cours de ce métal. Entre la conclusion du contrat et la livraison du matériel, le cours du métal augmente dans des proportions énormes par suite de circonstances exceptionnelles que les parties n'avaient pas envisagées lors de leurs négociations (par exemple, une guerre ou un tremblement de terre dans le pays où le minerai est extrait). Le coût de fabrication du matériel s'en trouve considérablement augmenté, de sorte que le fabricant, s'il doit livrer au prix fixé, subira des pertes considérables. La question se pose alors, dans de telles circonstances, de savoir si la partie ainsi désavantagée peut se dégager du contrat ou si – et c'est sous cet angle que nous examinons ici le problème – elle peut demander au juge de modifier le contrat pour le rééquilibrer (dans l'exemple donné, en augmentant le prix fixé). Ce problème ne se pose évidemment pas dans les contrats à

[1169] POELMANS, n° 135.

[1170] Trib. Luxembourg, 29 juin 1955, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

exécution instantanée, qui sont exécutés immédiatement après leur conclusion ; il se pose dans les contrats où il existe un décalage de temps important entre la conclusion et l'exécution, et surtout dans les contrats dont l'exécution est échelonnée sur une longue période de temps.

Les situations qui tombent sous le coup de cette problématique de l'imprévision doivent être soigneusement distinguées de deux autres situations. D'une part, il faut distinguer l'imprévision de la lésion : dans les deux cas, on est en présence d'un déséquilibre contractuel, mais, alors que dans l'hypothèse de la lésion, ce déséquilibre existait dès le départ, parce que l'une des parties a accepté (plus ou moins librement) des conditions très désavantageuses pour elle, l'imprévision concerne un déséquilibre non voulu (non prévu) au départ, et apparu postérieurement à la conclusion du contrat. D'autre part, l'imprévision doit être distinguée du cas où l'exécution du contrat, par suite du changement des circonstances, est devenue impossible (ainsi, dans l'exemple donné, si en raison des événements survenus dans le pays d'extraction du minerai, il est désormais impossible de se procurer le métal en question, de sorte que le matériel ne peut plus, momentanément au moins, être fabriqué) : si tel était le cas, on serait en présence d'un cas de force majeure, qui pourrait entraîner la résolution (ou au moins la suspension du contrat) et qui dégagerait de toute responsabilité le contractant incapable d'exécuter[1171]. Dans les hypothèses ici examinées, l'exécution du contrat n'est pas devenue impossible, elle est simplement devenue plus onéreuse pour l'une des parties. La distinction entre force majeure et imprévision n'est cependant pas aussi claire dans tous les systèmes juridiques. En particulier, dans le droits de common law, les deux situations peuvent relever de la même qualification de « frustration of contratct ».

509. Le débat. De prime abord, dans les hypothèses considérées, le juge ne devrait pas pouvoir intervenir, ni pour mettre fin au contrat, ni pour le réviser. Le principe de la force obligatoire semble s'y opposer : le déséquilibre qui résulte du changement de circonstances n'est, après tout, que l'effet du contrat tel que les parties l'ont voulu. Celles-ci auraient pu, si elles l'avaient voulu, introduire dans le contrat toutes sortes de clauses qui auraient pu faire varier l'équilibre contractuel en fonction de l'évolution des circonstances (ainsi, dans

[1171] Sur les effets de la force majeure, voy. *infra*, n[os] 766 et s. et 838 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'exemple donné, en indexant le prix sur le cours du métal servant à la fabrication du matériel commandé) ; si elles ne l'ont pas fait, c'est, de prime abord, parce qu'elles ont estimé que le prix du matériel devait rester fixe, chaque partie devant supporter les risques du changement des circonstances. Ce maintien des conditions initiales du contrat quelle qu'ait été l'évolution des circonstances semble être commandé par ailleurs par un impératif de sécurité juridique – que le principe de la force obligatoire vise à garantir : chaque partie doit pouvoir compter, dès le départ sur les conditions fixées. L'intérêt d'un contrat est, précisément, d'être un acte de prévision qui doit garantir les contractants contre les incertitudes de l'avenir. Depuis très longtemps, cependant, on se demande si ces principes ne doivent pas céder dans certaines hypothèses exceptionnelles, où le changement de circonstances affecte l'équilibre contractuel à un point tel qu'il apparaît déraisonnable de maintenir l'exécution du contrat aux conditions initiales.

Les remèdes à de telles situations ont pu, au cours des siècles, et peuvent encore être recherchés selon deux approches assez différentes. Une première approche cherche à concilier la remise en cause des conditions initiales du contrat avec la force obligatoire, en se fondant sur le contrat lui-même et sur la volonté supposée des parties. Tel est le sens de la doctrine de la « *clausula rebus sic stantibus* », qui s'est développée dans la doctrine des juristes du Moyen-Âge : dans cette doctrine, tout contrat contiendrait implicitement une clause selon laquelle les conditions fixées par les parties ne vaudraient que tant que les choses resteraient les mêmes (*rebus sic stantibus*). Si le contrat pouvait être défait ou révisé par suite du changement de circonstances, ce serait donc par l'effet même de la volonté des parties. Cette approche a été beaucoup critiquée, car elle se fonde sur une interprétation complètement divinatoire de la volonté des parties, alors que précisément, celles-ci n'ont, à aucun moment, envisagé le changement de circonstances. C'est pourquoi, aujourd'hui, on préfère souvent une seconde approche, qui se place, non au moment où le contrat a été conclu, mais au moment présent, en considérant l'importance du déséquilibre créé par le changement de circonstances et le caractère insupportable qu'il présente pour une des parties. On peut alors estimer que l'attitude du cocontractant qui exige l'exécution stricte du contrat aux conditions initiales sans tenir compte des changements intervenus est injuste, déloyale, en d'autres termes contraire à la bonne foi contractuelle – ce qui, on

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'a vu, peut amener le juge à intervenir. Dans les droits modernes, ces deux approches du problème de l'imprévision – celle qui se fonde sur le contrat initial, et celle qui se fonde sur la situation présente – sont souvent combinées : les systèmes juridiques qui admettent l'imprévision considèrent prioritairement l'importance du déséquilibre contractuel et les perturbations apportées à l'exécution normale du contrat, mais ils regardent aussi avec attention si le changement était ou non prévisible, et si les parties n'avaient pas choisi délibérément de l'ignorer pour mettre les risques du contrat à la charge de la partie qui pourrait en souffrir. En toute hypothèse, l'opinion générale est que la révision pour imprévision ne peut être admise que dans des circonstances exceptionnelles pour ne pas compromettre la sécurité que doit présenter le contrat.

510. Solutions en droit comparé. Alors qu'au XIXe siècle, le principe de la force obligatoire s'opposait partout à la prise en considération des situations d'imprévision, il existe aujourd'hui une tendance très nette, dans les droits européens, à tenir compte de ces situations pour permettre au juge d'intervenir dans le contrat. Cette tendance trouve ses origines dans l'évolution qu'a connue, au début du XXe siècle, le droit allemand. Au lendemain de la première guerre mondiale, le pays a connu une période de très forte dépréciation monétaire, de sorte que les prix fixés dans des contrats de vente passés antérieurement, ne représentaient plus, lors de leur versement postérieur, que des valeurs dérisoires. Saisi à propos de l'un de ces contrats, le *Reichsgericht* consacra, en 1922, la théorie doctrinale de la disparition du fondement contractuel (*Wegfall der Geschäftsgrundlage*)[1172] : si le changement de circonstances est tel qu'on peut considérer que le fondement du contrat a disparu, il s'impose, conformément à l'exigence de bonne foi (*Treu und Glauben*) du § 242 du BGB de modifier les conditions initialement fixées. Cette jurisprudence, qui a connu, depuis, d'importants développements en Allemagne, a été consacrée par le législateur lors de la réforme du BGB en 2000. Le § 313 du BGB prévoit désormais qu'une adaptation du contrat peut être demandée « lorsque les circonstances constituant le fondement du contrat ont radicalement changé après la conclusion de celui-ci, de sorte que les parties n'auraient pas conclu le contrat ou du moins ne l'auraient pas conclu dans les mêmes conditions si elles avaient agi en connaissance de cause et que, eu

[1172] RG, 3 février 1922, *RGZ*, 103, 128.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

égard à toutes les circonstances de l'espèce et plus spécialement à la répartition contractuelle ou légale des risques, l'exécution du contrat initial ne peut pas être imposée à l'une des parties ». Par la suite, de nombreux droits nationaux ont accepté, par la voie légale ou par la voie jurisprudentielle, de prendre en compte les situations d'imprévision, soit pour permettre l'adaptation du contrat par le juge soit au moins pour libérer la partie victime du changement[1173]. La révision du contrat en cas de changement de circonstances est également admise par les Principes Unidroit, ainsi que par plusieurs projets européens de droit des contrats[1174]. Les droits de *common law* ont, eux, en la matière, une position assez nuancée. Très attachés à l'idée de sécurité de l'engagement contractuel, les juges anglais sont, traditionnellement, rebelles à l'idée de révision du contrat. Sans doute, en droit anglais, on admet qu'un changement radical des circonstances qui ont justifié la conclusion du contrat peut constituer un cas de *frustation* (équivalent de la force majeure) excluant son exécution s'il lui retire toute raison d'être[1175] ; mais cela n'a jamais été admis en cas de changement économique entraînant une modification du coût du contrat[1176], et, en toute hypothèse, cela ne pourrait pas conduire à la modification du contrat par le juge, mais seulement à son anéantissement.

511. Solutions dans les pays du Code civil. Face à cette tendance générale en droit comparé et européen, les pays du Code civil étaient jusqu'à une période récente assez isolés. Ils refusaient en effet par principe non seulement toute prise en compte du changement de circonstances, non seulement pour permettre une révision du contrat, mais encore pour libérer de ses obligations le contractant victime du déséquilibre. Cependant, cette solution traditionnelle, toujours applicable au Luxembourg (**A**), vient d'être remise en cause lors des récentes réformes en France et en Belgique, ce qui ouvre de nouvelles perspectives au Luxembourg (**B**).

[1173] Voy. p. ex. : Pays-Bas (BWB, art. 6 : 258), Grèce (C. civ., art. 388), Italie (Codice civile, art. 1467).

[1174] Principes Unidroit, art. 6.2.2 ; PDEC, art. 6 : 111 ; DCFR, III art. 1 : 110 ; DCEV, art. 89.

[1175] P. ex., dans une affaire célèbre (Coronation case) il a été jugé que n'avait pas à être exécuté le contrat de location d'un appartement conclu pour 2 jours dans le but de permettre au locataire d'assister au couronnement du roi Edouard VII, dès lors que le couronnement avait été reporté pour cause de maladie du roi (Krell V. Henry, [1903] 2 KB 740).

[1176] Voy. CARTWRIGHT, pp. 260 et s., spéc. p. 266. Voy. *Davis contractors ltd v. Farham UDC* (1956), AC 696 (HL), 728-29.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

A) *La solution traditionnelle dans les pays du Code civil : le refus de la révision pour imprévision*

512. L'arrêt « Canal de Craponne » et ses suites. Le Code civil ne contenait aucune disposition spéciale sur la question du changement de circonstances, ni dans l'article 1134, ni dans les textes suivants, et ce silence a pu être interprété comme le rejet de la doctrine de la *clausula rebus sic stantibus*. Au XIXe siècle, il était évident que le juge ne pouvait pas réviser le contrat en cas de changement de circonstances, et la question n'est même pas abordée par les auteurs. En 1876, la Cour de cassation rendit un arrêt très célèbre, qui est aujourd'hui présenté comme la décision emblématique du refus de la révision pour imprévision. Dans cette affaire, des contrats, conclus au XVIe siècle, fixaient le montant des redevances que les paysans riverains d'un canal d'irrigation du sud de la France – le canal de Craponne – devaient payer au propriétaire du canal pour pouvoir en utiliser l'eau. Au XIXe siècle, le propriétaire du canal saisit la justice pour obtenir une augmentation de cette redevance, qui n'avait jamais été modifiée au cours des siècles, et qu'il estimait insuffisante pour couvrir les frais d'entretien du canal. Prenant en compte le déséquilibre du contrat, la Cour d'appel d'Aix en Provence accepta d'élever le prix fixé. Cet arrêt fut cassé au visa de l'article 1134 du Code civil. Pour la Cour de cassation française, « dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse apparaître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants »[1177]. Cette solution, inspirée par une conception rigide de la force obligatoire du contrat, a été réitérée au lendemain de la première guerre mondiale[1178], dans une période où de nombreux contrats s'étaient trouvés déséquilibrés par suite du bouleversement du niveau des prix des biens et des services, et à un moment où, comme on l'a vu, le *Reichsgericht* allemand introduisait dans sa jurisprudence, au nom de la bonne foi, la théorie de la « disparition du fondement contractuel ». Et la solution s'est constamment maintenue depuis dans la jurisprudence des juridictions judiciaires, même si les applications en sont de plus en plus

[1177] Cass. fr. (civ.), 6 mars 1876, GAJC, 12e éd., n° 165. Il faut observer que cet arrêt, aujourd'hui présenté comme fondateur, ne concernait pas vraiment une hypothèse d'imprévision, le déséquilibre contractuel résultant en l'espèce d'une longue évolution parfaitement prévisible.

[1178] Cass. fr. (civ.), 6 juin 1921, *D.*, 1921, 1, p. 73.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

rares[1179], sans doute à cause de la multiplication, dans les contrats des clauses d'adaptation. La révision pour imprévision n'était pas pour autant inconnue du droit français. D'une part, les juridictions administratives avaient adopté une position différente de celle de la Cour de cassation, en permettant notamment au concessionnaire d'un service public d'obtenir une indemnité si l'exécution du contrat a été rendue plus onéreuse pour eux par le changement des circonstances économiques[1180] : cette solution, qui est soumise à la condition d'un bouleversement de l'économie du contrat, est justifiée par le souci d'assurer la continuité des services publics quelles que soient les circonstances économiques. D'autre part, de nombreux textes légaux prévoyaient la possibilité pour le juge de modifier certains contrats déséquilibrés par suite des circonstances économiques[1181].

513. Réception de la solution en Belgique et au Luxembourg. La solution de l'arrêt de 1876 avait été reprise dès 1921 par la Cour de cassation belge, et, comme en France, elle s'y était constamment maintenue, en dépit du développement d'un fort courant doctrinal favorable à la révision pour imprévision. Comme en France, cependant, un certain nombre de textes spéciaux prenaient en compte le changement des circonstances pour permettre une adaptation du contrat par le juge[1182]. Il est plus délicat de dire quelle est la position traditionnelle de la jurisprudence luxembourgeoise, faute de pouvoir citer, jusqu'à la période récente, aucune décision ayant eu à se prononcer sur la question. Cependant la doctrine qui s'est exprimée sur le sujet semble considérer comme allant de soi que la jurisprudence Canal de Craponne a cours au Luxembourg[1183]. Et, dans ses conclusions devant la Cour de cassation saisie du problème en 2013, le Parquet Général se référait encore à l'arrêt français de 1876 pour conclure au rejet de la demande de révision formée par un contractant. Cependant, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 octobre 2013 à la suite de ces conclusions[1184] ne reprend pas

[1179] Voy. implicitement Cass. (3e civ.), 10 décembre 2003, n° 02-14.990.

[1180] C.E., 30 mars 1916 (Gaz de Bordeaux), *D.*, 1916, 3, p. 25 ; *S.*, 1916, 3, p. 17, note HAURIOU.

[1181] Pour un recensement de ces mesures voy., p. ex., FLOUR, AUBERT, SAVAUX 2022, nos 836 et s. et, sur l'ensemble de la question : L. GRYNBAUM, *Le contrat contingent – L'adaptation du contrat par le juge sur habilitation du législateur*, Paris, LGDJ, 2004.

[1182] Voy. les textes cités par WÉRY, n° 582.

[1183] D. SPIELMANN et H. DUPONG, « Quelques réflexions sur la théorie de l'imprévision », in *Le bicentenaire du Code civil : une contribution luxembourgeoise*, Luxembourg, Éd. Portalis, 2008, pp. 150 et s.

[1184] Cass., 24 octobre 2013, n° 64/13, *Pas.*, 36, p. 393, note P. ANCEL.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

exactement cette motivation, et s'inscrit par-là dans un mouvement général de recul par rapport à la position traditionnelle dans les trois pays du Code civil, que les réformes récentes en France et en Belgique confirment de manière éclatante.

B) *Évolutions et perspectives*

514. Évolution des idées. Pendant longtemps, dans les pays du Code civil, la doctrine, à quelques exceptions près, approuvait massivement la jurisprudence Canal de Craponne, au nom du dogme de la force obligatoire et de l'impératif de sécurité juridique. Depuis quelques années, cependant, un fort courant doctrinal s'est développé dans les trois pays, en faveur de la remise en cause de ce principe et de l'admission de la théorie de l'imprévision. Ce courant – remarquablement illustré au Luxembourg par un substantiel article de D. Spielmann et H. Dupong[1185] – met tout particulièrement en évidence l'isolement du droit des pays du Code civil dans le concert européen, où, comme on l'a vu, la majorité des droits nationaux ainsi que les projets d'harmonisation européenne admettent la révision pour imprévision. Or l'expérience des pays qui connaissent un tel mécanisme, parfois depuis longtemps, montre que les craintes d'une insécurité juridique, qui motivaient traditionnellement le rejet de la théorie, sont sans doute excessives, pourvu que le mécanisme de la révision soit strictement encadré. En France et en Belgique, la jurisprudence n'était pas restée insensible à ce courant, même si c'était par le biais de succédanés à une admission franche de la théorie, avant que celle-ci ne soit consacrée législativement dans les deux pays à l'occasion des récentes réformes. Face à ces évolutions importantes, les solutions du droit luxembourgeois doivent être scrutées avec attention.

515. Droit français. Sans avoir jamais été directement remise en cause, la jurisprudence Canal de Craponne avait été, depuis une cinquantaine d'années, battue en brèche par diverses décisions remarquées de la Cour de cassation française qui avaient utilisé des notions générales du droit des contrats pour prendre en compte le changement de circonstances. Au début des années 1990, plusieurs décisions avaient ainsi mobilisé la notion de bonne foi, alors en pleine expansion, pour condamner à des dommages et intérêts le contractant qui, dans un contexte de bouleversement de l'équilibre contractuel provoqué par l'évolution économique, continuait à exiger de son cocontractant désavantagé l'exécution stricte du contrat, alors qu'il aurait pu (ou dû) le renégocier[1186]. Même si ces décisions, rendues dans des circonstances

[1185] D. Spielmann et H. Dupong, *Quelques réflexions sur la théorie de l'imprévision*, précité.
[1186] Voy. not. t Cass. fr. (comm.), 3 novembre 1992, Bull. 92, IV, n° 338.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

particulières, ne conduisaient pas à permettre une révision du contrat par le juge, l'octroi de dommages et intérêts au contractant victime du déséquilibre aboutissait, de fait, à une solution assez proche. Plus récemment, un arrêt non publié de la chambre commerciale de 2010[1187] avait eu recours à la notion de cause à propos d'un contrat rendu plus onéreux pour l'une des parties par l'augmentation du coût des matières premières nécessaires à sa prestation : pour la Cour, le juge, avant d'ordonner l'exécution du contrat, aurait dû rechercher si cette augmentation « n'avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance […] de déséquilibrer l'économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature et de priver de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit » par le débiteur de la prestation. Mais là encore, cette utilisation de la notion de cause – ultérieurement abandonnée[1188] – pour appréhender un changement de circonstances bouleversant l'économie du contrat ne pouvait pas aboutir à la révision du contrat par le juge : privé de cause, le contrat devrait logiquement être anéanti.

Ces solutions jurisprudentielles – dont certaines ont pu influencer la jurisprudence luxembourgeoise récente – sont aujourd'hui dépassées depuis que le législateur français, dans le cadre de la réforme de 2016, a institué un véritable pouvoir de révision judiciaire en cas d'imprévision dans le nouvel article 1195 du Code civil. Ce texte, dont la version définitive est le fruit de nombreuses hésitations, vise le cas où « un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque ». Cette situation permet au contractant qui en est victime d'exiger la renégociation du contrat, tout en continuant à exécuter ses obligations. En cas d'échec, si les parties ne se mettent pas d'accord pour mettre fin au contrat ou pour demander au juge de procéder à son adaptation, « le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe ». Il semble que, jusqu'à présent, ce pouvoir de révision judiciaire, qui constitue une petite révolution en droit français, n'ait connu que de très rares applications. L'une des raisons en est que le texte est généralement considéré comme supplétif, et que les clauses de renonciation se sont multipliées dans la pratique.

516. **Droit belge.** En Belgique, on a songé comme en France à faire appel à la notion de bonne foi pour nuancer la solution traditionnelle du refus de la révision pour imprévision. Certains auteurs avaient soutenu que la bonne foi pourrait avoir en la matière une fonction adaptatrice, qui autoriserait le juge à adapter le contrat dont l'économie est bouleversée[1189]. Mais cette opinion, qui suscite des résistances dans la doctrine, avait été repoussée avec vigueur par la Cour de cassation. Dans un arrêt de 2006, la Cour avait rappelé que « le juge ne peut modifier le contenu d'une convention pour des considérations d'équité. La règle de l'exécution de bonne foi n'implique pas que, si des circonstances nouvelles et non prévues par les parties lors de la conclusion de la convention rende son exécution plus difficile pour le débiteur, le créancier ne puisse demander le paiement de sa créance »[1190]. Cependant, ce refus d'une fonction adaptatrice de la bonne foi, n'excluait pas le jeu de sa fonction

[1187] Cass. fr. (comm.), 29 juin 2010, n° 09-67369, inédit. Sur cet arrêt voy. *supra*, n° 359.

[1188] Cass. fr. (comm.), 18 mars 2014, n° 12-29453, inédit.

[1189] D. PHILIPPE, *Changement de circonstances et bouleversement de l'économie contractuelle*, Bruxelles, Bruylant, 1986 ; D. PHILIPPE, « L'imprévision », *J.T.*, 2007, p. 738 ; M. FONTAINE, « Portée et limites du principe de la convention-loi », in *Les obligations contractuelles*, Bruxelles, Édition du jeune barreau, 1984, p. 190.

[1190] Cass. be., 20 avril 2006, n° C030084N.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

modératrice à travers la sanction de l'abus de droit qui en est, en droit belge, l'expression, et qui est, on l'a vu, reconnu par la jurisprudence luxembourgeoise[1191]. Dans un arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de cassation belge n'avait pas hésité à faire appel à cette dernière notion pour repousser l'action d'un contractant qui continuait d'exiger de manière anormale une exécution devenue disproportionnée par rapport à l'évolution de la situation économique des deux parties qui avait justifié l'accord initial. Contrairement à la jurisprudence française des années 1990, l'arrêt n'aboutit pas à une condamnation à dommages et intérêts sanctionnant le manquement à la bonne foi. Il conclut au rejet pur et simple de l'action en exécution considérée comme abusive – ce qui paraît assez curieux compte tenu de la sanction habituelle de l'abus de droit en droit belge[1192]. Mais en toute hypothèse, pas plus qu'en droit français, ce n'est pas à la révision du contrat qu'on aboutissait ici.

Comme en France, la réforme du droit des obligations en Belgique a été l'occasion d'introduire explicitement dans le Code civil un pouvoir de révision judiciaire pour imprévision. L'article 5.74 du nouveau Code civil après avoir rappelé qu'en principe « chaque partie doit exécuter ses obligations quand bien même l'exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l'exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué » permet au débiteur, dans le cas où « un changement de circonstances rend excessivement onéreuse l'exécution du contrat de sorte qu'on ne puisse raisonnablement l'exiger », de demander au créancier la renégociation du contrat, et, en cas de refus ou d'échec, de demander au juge d'« adapter le contrat afin de le mettre en conformité avec ce que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de la conclusion du contrat si elles avaient tenu compte du changement de circonstances », ou d'y mettre fin en tout ou en partie. Sans qu'il soit possible de se livrer ici à une comparaison détaillée des deux textes, on notera que le texte belge définit les conditions de ce pouvoir de révision d'une manière plus précise que l'article 1195 français, mais que la procédure pouvant conduire à la révision du contrat (conduite en la forme du référé) est plus rapide que celle prévue en France. Le texte précise explicitement qu'il est supplétif.

517. Jurisprudence luxembourgeoise : absence de consécration directe de la révision pour imprévision. Dans un arrêt récent, le seul qu'elle ait jamais eu à rendre sur la question, la Cour de cassation a semblé prendre une certaine distance avec la solution classique[1193]. Dans cette espèce, il s'agissait d'un compromis de vente portant sur un terrain à bâtir, qui avait été passé en 1995, mais dont l'acheteur n'avait demandé l'exécution que 15 ans plus tard, à un moment où, bien sûr, le prix fixé en 1995 ne correspondait plus du tout à la valeur du terrain. Pour échapper à son engagement, le vendeur invoquait, entre autres arguments, la théorie de l'imprévision. La Cour d'appel ayant répondu que « les conditions minimales à l'application de la théorie de l'imprévision ne sont pas remplies », le vendeur avait formé un pourvoi en soutenant que

[1191] Voy. *supra*, n° 500.

[1192] Voy. *supra*, n° 500.

[1193] Cass., 24 octobre 2013, n° 64/13, *Pas.*, 36, p. 393, note P. Ancel.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'exécution du contrat au prix de 1995 « entraîne un déséquilibre entre les prestations réciproques des parties et a pour effet de priver l'engagement des demanderesses en cassation de toute contrepartie réelle » – formule visiblement puisée dans l'arrêt français de 2010 précédemment évoqué. Bien qu'il y ait eu toutes sortes de bonnes raisons de rejeter le pourvoi, le Parquet général, dans ses conclusions devant la Cour de cassation, avait choisi de se placer sur le terrain des principes, en rappelant l'opposition de la jurisprudence française, et en soulignant que les arrêts des années 1990 précédemment rapportés n'avaient pas remis en cause la solution traditionnelle du refus de l'imprévision. La Cour de cassation aurait donc pu suivre sur ce terrain, et rejeter le pourvoi en rappelant le principe selon lequel le changement de circonstances n'affecte pas la force obligatoire du contrat. Elle a choisi, très différemment, de motiver sa décision en observant que les conditions de la « théorie de l'imprévision » n'étaient pas réunies en l'espèce. Elle juge en effet que « les juges du fond, interprétant souverainement les clauses de l'acte du 21 février 1995, ont pu retenir qu'il continue à lier les parties, justifiant à suffisance le rejet de la théorie de l'imprévision par la constatation que l'augmentation dans le temps du prix d'un terrain à bâtir est tout à fait prévisible ». Même s'il est toujours très difficile d'interpréter un arrêt *a contrario*, lorsqu'on ignore absolument tout du contenu des débats qui ont pu avoir lieu au sein de la juridiction, on pourrait être tenté de déduire de la formule de la Cour que, si les conditions de l'imprévision avaient été réunies, la révision aurait pu être admise. À tout le moins, si on ne peut pas affirmer avec certitude que la Cour a voulu consacrer la théorie de l'imprévision, on peut en revanche noter avec intérêt qu'elle n'a pas saisi l'occasion de réaffirmer son rejet, ce qui marque une certaine ouverture par rapport à la jurisprudence traditionnelle. Plusieurs décisions récentes du tribunal de Luxembourg s'inscrivent dans la même démarche : ils déclarent ne pas prendre parti sur la réception en droit luxembourgeois de la théorie de l'imprévision, mais rejettent la demande en révision au motif que de toute façon les conditions n'en étaient pas réunies[1194]. On relèvera notamment un jugement du 2 mai 2024, qui, en s'appuyant sur diverses références doctrinales, relève d'abord que la solution du droit luxembourgeois est incertaine. Les juges rejettent ensuite la demande en révision

[1194] Trib. Luxembourg, 28 juin 2021, n^os^ TAL-2021-02457 et TAL-2021-02480 ; Trib. Luxembourg, 30 novembre 2021, n° TAL-2021-013.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

formée par un contractant, non parce qu'une telle révision serait par principe impossible, mais parce que les conditions d'une telle révision ne sont de toute façon pas réunies en l'espèce s'agissant non d'un bouleversement imprévisible de la situation économique *a posteriori* de la signature du Contrat, mais d'une situation qui aurait déjà existé au moment de la signature du Contrat, mais dont le contractant n'aurait pas été informée[1195].

518. Jurisprudence luxembourgeoise : consécration indirecte à travers le rôle de la bonne foi. Même si elle n'a pas jusque-là consacré directement la théorie de l'imprévision, on constate que la jurisprudence luxembourgeoise récente aboutit à des résultats sensiblement équivalents en utilisant l'instrument de la bonne foi. On a vu en effet que, dans les nombreuses décisions rendues en matière de bail à loyer relativement aux incidences des mesures d'interdiction d'activité prises pendant la période de la Covid-19, le tribunal de Luxembourg n'a pas hésité à réduire, dans des proportions variables, le montant des loyers dus par les locataires commerçants pendant les périodes où ils ont été empêchés d'exercer leur activité dans les lieux loués. Cette révision judiciaire des contrats de bail, intervenant dans des situations fort proches de celles qui relèvent habituellement de la théorie de l'imprévision, repose sur une une combinaison remarquable – quoique pas nécessairement consciente de la part des juges – des solutions jurisprudentielles françaises et belges antérieures aux réformes. L'idée générale de toutes ces décisions est que, en principe, le bailleur ne manque pas à la bonne foi en exigeant l'intégralité du montant du loyer même lorsque la situation du locataire est devenue difficile, mais que, dans certaines circonstances, il doit faire preuve de modération et offrir au locataire une marge de négociation. S'appuyant sur le célèbre arrêt *Huard* rendu en 1992 par la Cour de cassation française[1196], le tribunal pose qu'« une partie qui refuse obstinément de réviser un contrat devenu déséquilibré manque à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat ». Mais en même temps, se référant cette fois à la jurisprudence belge, le tribunal assimile ce manquement à la bonne foi à un abus de droit, et le sanctionne, non pas comme le faisaient les arrêts français des années 1990, par l'allocation de dommages et intérêts, mais par le rejet partiel de la prétention du bailleur, donc par la réduction du montant demandé pendant

[1195] Trib. Luxembourg, 2 mai 2024, n° TAL-2019-10459.
[1196] Cass. fr. (comm.), 3 novembre 1992, Bull. 92, IV, n° 338.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la période de fermeture administrative – ce à quoi les juridictions françaises se refusent toujours lorsque l'article 1195 du Code civil français n'est pas applicable[1197]. Comme on le voit, le schéma n'est pas si éloigné de celui mis en place par les nouveaux articles 1195 du Code civil français et 5.74 du Code civil belge : nous sommes dans des cas où il n'apparaît pas normal, compte tenu des circonstances nouvelles, d'exiger l'exécution sans changement du contrat devenu déséquilibré, le créancier est alors tenu de renégocier les conditions du contrat, et, s'il ne le fait pas, le juge peut se substituer à lui et procéder lui-même à l'adaptation du contrat. Une décision de 2023 apparaît à cet égard particulièrement caractéristique. Après avoir suivi le raisonnement habituel fondé sur la bonne foi, le tribunal relève qu'« [i]l ressort ainsi de l'analyse tant du comportement du créancier que de celui du débiteur, en poursuivant l'exécution du contrat tel que conclu initialement – et ce malgré le bouleversement de son économie contractuelle à la suite de circonstances nouvelles imprévisibles – que le bailleur recherche un avantage hors de proportion avec la charge corrélative de l'autre partie. En d'autres termes, en continuant à imposer l'exécution d'un contrat dont l'économie est radicalement déséquilibrée et qui préjudicie grandement le locataire, il y a un déséquilibre manifeste : à cause du comportement du bailleur, un déséquilibre se crée qui procure un avantage pour le bailleur de percevoir le loyer au désavantage pour la société appelante de le payer »[1198]. Le rapprochement avec la théorie de l'imprévision est ici particulièrement net. On peut cependant observer quelques différences. Il n'est pas absolument certain que, dans les affaires citées, les nouveaux textes français et belge auraient permis la révision judiciaire, dans la msure où l'exécution du contrat par le locataire n'est pas, à proprement parler, devenue « excessivement onéreuse », le montant du loyer n'ayant pas augmenté. On peut néanmoins soutenir que le fait que le locataire doive payer des loyers sans pouvoir en retour tirer des bénéfices du bien loué équivaut pour lui à un coût plus élevé du contrat. Mais par ailleurs, il n'est pas certain que le processus de révision pour imprévision puisse s'appliquer de manière rétroactive pour remettre en cause le montant de prestations contractuelles dues dans le passé. On relèvera encore que la révision judiciaire pour imprévision est fondée en premier lieu sur la situation objective créée par le changement de

[1197] Voy. en dernier lieu Trib. Jud. Paris 17 juillet 2024, RG n° 21/11584

[1198] Trib. Luxembourg, 10 octobre 2023, n° TAL-2021-07267.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

circonstances, alors que la révision sur le fondement de la bonne foi et sur l'obligation de négocier le contrat déséquilibré met au premier plan l'appréciation du comportement des parties avant la saisine du juge. Enfin on doit noter que l'exigence de bonne foi dans le droit des contrats est un principe d'ordre public, alors que, en France comme en Belgique, le processus de révision pour imprévision mis en place est susceptible d'être écarté par la convention des parties. Compte tenu de ces différences, il appartiendra au législateur luxembourgeois de choisir sa voie dans le cadre de la réforme du droit des contrats actuellement envisagée entre la consécration d'un mécanisme de révision judiciaire pour imprévision sur le modèle français ou belge, très encadré et au domaine d'application finalement assez limité, ou le maintien d'une possibilité exceptionnelle de révision fondée sur l'exigence de bonne foi, plus souple et plus centrée sur le comportement des contractants.

SECTION 3. LA FORCE DU LIEN OBLIGATOIRE POUR LE LÉGISLATEUR

519. Le contrat plus fort que la loi ? Comme on l'a déjà dit maintes fois dans cet ouvrage, la norme créée par le contrat est une norme inférieure aux règles juridiques (légales ou jurisprudentielles) émanant de l'État lui-même. Il en résulte que, selon la lettre même de l'article 1134 du Code civil, la force obligatoire n'est reconnue qu'aux conventions « légalement formées ». Cependant, une fois qu'un contrat est légalement formé, le législateur lui-même doit en principe le respecter.

D'une part, une loi nouvelle qui édicterait des conditions de validité plus sévères que celles qui existaient auparavant (par exemple, en imposant pour la conclusion d'un contrat une forme écrite non exigée avant) ne peut pas remettre en cause la validité d'un contrat qui a été passé antérieurement. Ce n'est là que l'application du principe général de non-rétroactivité des lois nouvelles inscrit à l'article 2 du Code civil, et qui s'applique à toutes situations juridiques, contractuelles ou non contractuelles. Le même principe impose normalement qu'une loi nouvelle ne remette pas en cause les effets d'un contrat, dès lors qu'ils se sont produits antérieurement. La Cour d'appel a eu l'occasion de faire application de ce principe dans une affaire concernant un contrat d'assurance : ce contrat avait été passé avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 1993, et, avant cette entrée en vigueur, il avait été résilié par l'assureur selon

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

les règles alors en vigueur. Moins de 30 jours après la réception par l'assuré de la lettre de résiliation, l'assuré avait été victime d'un sinistre, que l'assureur prétendait ne pas couvrir. Or, entre temps, était entrée en vigueur la loi de 1993, qui impose à l'assureur d'observer un délai minimum de 30 jours après la mise en demeure avant de résilier le contrat. L'assuré prétendait que cette loi s'appliquait immédiatement à son contrat, et que, en conséquence il était encore couvert. La Cour d'appel rétorque justement que selon le principe de non-rétroactivité « le droit lui-même est régi par la loi du jour où a été passé l'acte créateur de ce droit. Tous les effets juridiques produits par la situation envisagée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle feront partie du domaine de la loi ancienne et on ne saurait les lui arracher sans rétroactivité »[1199].

Mais d'autre part, à côté de ce principe général de non-rétroactivité, il existe une règle de droit transitoire qui est spécifique aux contrats, et qui semble révéler une certaine supériorité de la norme contractuelle, une fois formée, sur la loi elle-même. En principe, en dehors du droit des contrats, une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques : si, par exemple, dans un système juridique qui admettait jusque-là que les enfants nés hors mariage n'avaient pas de droits successoraux, une loi nouvelle intervient pour dire que désormais les enfants naturels et les enfants légitimes ont les mêmes droits, cette loi va s'appliquer même aux enfants qui sont nés avant son entrée en vigueur. Or en matière contractuelle, on écarte en principe cette règle d'application immédiate, et on admet la survie de la loi ancienne, qui continue de s'appliquer même aux effets futurs du contrat, qui se produisent après son entrée en vigueur. Ce principe est bien admis en droit luxembourgeois[1200], et on le retrouve exprimé dans un arrêt récent de la Cour de cassation[1201]. On explique habituellement cette règle par l'idée que les parties ont construit leur relation contractuelle, et en ont déterminé les effets, en fonction de l'état du droit existant au moment de leur accord, et qu'il n'est pas souhaitable de remettre en cause leurs prévisions. « Il ne serait, dit ainsi la Cour d'appel, pas juste de modifier l'aménagement des contrats que les parties ont volontairement choisi en leur faisant application des

[1199] Cour d'appel, 5 avril 2000, *Pas.*, 32, p. 331.

[1200] Cour d'appel, 5 avril 2000, préc. ; Cour d'appel, 26 avril 2017, n° 42073 ; Cour d'appel, 29 avril 2020, n° CAL-2019-00963.

[1201] Cass., 9 mars 2023, n° CAS-2022-00083 avec les conclusions du Parquet Général.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

lois nouvelles. »[1202] Si par exemple, un contrat de prêt avec un taux d'intérêt de 20 %, a été conclu à un moment où un tel taux était licite, une loi nouvelle, limitant le taux maximum autorisé à 15 %, non seulement ne remettra pas en cause les intérêts perçus avant son entrée en vigueur, mais n'empêchera pas en principe le prêteur – qui a calculé la rentabilité de l'opération en fonction du taux permis au moment de la formation du contrat – de percevoir les intérêts à 20 % jusqu'à la fin du contrat. Ce principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle s'applique non seulement pour les lois supplétives – sur les points que les parties n'auraient pas expressément réglés – mais aussi, normalement, aux lois impératives – qui laissent en principe subsister les effets que les parties auraient réglés en conformité avec la loi antérieure[1203].

520. La loi plus forte que le contrat. Comme tout ce qui se rapporte à la force obligatoire, les principes ici exposés n'ont pas de valeur absolue. Le respect des prévisions des parties, la sécurité juridique que doit procurer le contrat, sont des impératifs puissants, mais ils entrent souvent en conflit avec d'autres considérations qui peuvent amener le législateur à rendre les lois nouvelles immédiatement applicables aux contrats en cours.

Une loi nouvelle, d'abord, peut se déclarer immédiatement applicable aux effets futurs des contrats en cours – ce qui revient à écarter le principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle – dès lors que les objectifs poursuivis par la loi semblent imposer cette application immédiate. Dans l'exemple cité précédemment d'une réduction des taux d'intérêt, le législateur peut parfaitement considérer que cette réduction, justifiée par le souci de protéger les emprunteurs en difficulté, ou de juguler l'inflation, doit, pour atteindre ces objectifs, entraîner une réduction immédiate des intérêts perçus par les prêteurs. Cette possibilité est admise implicitement par la Cour de cassation dans l'arrêt précité, qui rejette le pourvoi contre un arrêt d'appel ayant admis qu'une disposition transitoire « ne portait pas exception au principe de l'application de la loi ancienne aux situations contractuelles en cours »[1204]. La jurisprudence française admet même que, en l'absence de dispo-

[1202] Cour d'appel, 5 avril 2000, préc.

[1203] Dans ce sens Cour d'appel, 5 avril 2000, préc., Cour d'appel, 29 avril 2020, préc. Pour une application de ce principe dans la jurisprudence française voy. not. Cass. fr. (1re civ.), 4 décembre 2001, n° 98-18411.

[1204] Cass., 9 mars 2023, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

sition expresse, une loi nouvelle peut s'appliquer aux effets futurs des contrats en cours si « des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses » le justifient[1205]. Cette formule, dont on ne trouve pour l'instant aucun équivalent dans la jurisprudence luxembourgeoise, suscite de grandes difficultés d'interprétation, dès lors que, comme il a été dit, il ne suffit pas, pour justifier l'application immédiate, d'établir que la loi nouvelle est impérative, il faut qu'elle appartienne en quelque sorte au « noyau dur » de l'ordre public[1206]. Pour prendre un exemple tiré d'une modification récente du droit luxembourgeois, on peut s'interroger sur l'application dans le temps de la loi du 8 janvier 2013 relative au surendettement, qui impose désormais aux créanciers professionnels ayant fait souscrire un cautionnement à une personne physique, d'informer annuellement la caution sur la consistance de la dette garantie (C. civ., art. 2016). En l'absence de toute disposition dans la loi prévoyant son application aux cautionnements donnés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, doit-on considérer que le souci de protéger les cautions, qui est l'objectif de la loi, est une considération suffisamment impérieuse pour justifier son application immédiate ? La Cour d'appel ne l'a pas admis[1207].

Le législateur peut même aller plus loin, et déclarer que la loi nouvelle sera expressément rétroactive, et qu'elle pourra donc remettre en cause la validité ou les effets antérieurs des contrats passés avant son entrée en vigueur. Une telle rétroactivité ne peut cependant résulter, cette fois, que d'une disposition expresse de la loi[1208], et, dans la mesure où elle porte gravement atteinte à la sécurité juridique, la liberté du législateur n'est pas ici sans limite. Si, en dehors de la matière pénale, le principe de non-rétroactivité des lois n'a pas en lui-même valeur constitutionnelle[1209], certaines lois civiles rétroactives pourraient être considérées comme non conformes au principe de prééminence du droit et à la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de

[1205] Cass. fr. (comm.), 3 mars 2009, n° 07-16527 (à propos d'une loi de 2001 prévoyant que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats).

[1206] Sur les différents cercles de l'ordre public voy. *supra*, n° 400.

[1207] Cour d'appel, 29 avril 2020, préc. À propos d'une disposition similaire, la jurisprudence française avait jugé que la loi nouvelle s'appliquait aux cautionnements en cours : Cass. fr. (comm.), 18 février 1992, n° 89-21.187.

[1208] Cour d'appel, 5 avril 2000, préc.

[1209] Trib. Luxembourg, 30 novembre 1979, *Pas.*, 25, p. 69. Voy. en France : C. const., 7 novembre 1997, n° 97-391 DC.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'homme. La Cour eur. D.H. considère que la rétroactivité n'est permise, au regard de ces principes, que si l'intervention législative est « justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général »[1210]. De même la CJUE estime que le principe de non-rétroactivité ne peut être écarté qu'exceptionnellement dans un but d'intérêt général et dans le respect du principe de confiance légitime[1211]. Ces limites, cependant, ne sont pas spécifiques à la matière contractuelle et ne sont pas liées à une quelconque prééminence du contrat sur la loi.

[1210] Cour eur. D.H., 28 octobre 1999, *Zielinski et Pradal c/France*, http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-62948.

[1211] C.J.C.E., 26 avril 2005, *Goed Wonen*, C-376/02, *Rec.* I-3445.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La force du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 591-629
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Chapitre II
La teneur du lien obligatoire

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

521. Au-delà de la volonté des parties. Lorsqu'on cherche à savoir quel est le contenu exact de l'engagement contractuel, la réponse semble devoir être recherchée dans la volonté des parties : le contrat étant un accord volontaire, les parties sont tenues de ce qu'elles ont voulu. Cette réponse – évidente – s'avère cependant très souvent insuffisante, d'abord parce que, même lorsqu'elles règlent explicitement leurs relations, les parties ne le font pas toujours de manière suffisamment claire et précise, ensuite parce que les parties n'ont pas toujours (et même pas souvent) exprimé une volonté sur tous les aspects de leur relation. Dans le premier cas, il appartiendra alors au juge, saisi d'un litige portant sur un point obscur ou imprécis du contrat, de l'interpréter (**Section 1**). Dans le second, le contenu explicite devra être complété par la loi ou par le juge (**Section 2**).

SECTION 1. L'INTERPRÉTATION DU CONTRAT

522. Interprétation subjective et interprétation objective. Lorsqu'il s'agit de savoir, en présence de termes obscurs ou imprécis, ce qu'ont voulu les parties, quelle a été leur intention, deux approches différentes peuvent adoptées. La première – subjective – consiste à rechercher, sans s'attacher nécessairement à la signification littérale des mots employés, quelle a été la « véritable intention » des parties, en s'appuyant sur toutes sortes d'éléments internes au contrat (la confrontation de la clause obscure avec d'autres, l'exposé des motifs fait par les parties elles-mêmes, etc.) mais aussi externes au contrat (les relations habituelles entre les parties, ce qu'elles ont pu dire à des tiers avant ou après le contrat, etc.). Une telle approche est de prime abord celle qui est privilégiée dans les pays de droit civil, et elle trouve sa plus parfaite expression dans l'article 1156 du Code civil, selon lequel « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ». Cette formule est aujourd'hui reprise presque textuellement tant par l'article 1188 du Code civil français que par l'article 5.64 du nouveau Code civil belge. La difficulté d'une telle approche est que cette recherche de la « vraie » volonté des parties est souvent très aléatoire, soit parce que les éléments manquent pour la trouver, soit parce que les parties n'ont pas elles-mêmes eu de volonté claire sur tel ou tel point du contrat, soit encore parce qu'elles n'avaient pas en réalité

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de volonté commune et ne comprenaient pas la même chose des termes employés. C'est pourquoi, dans les pays de *common law*, on adopte plus par principe une approche objective, qui fait passer les termes employés avant une recherche divinatoire de l'intention des parties. Une des expressions les plus représentatives de cette interprétation objective se trouve dans une décision américaine de 1911, où le juge Learned Hand affirme que « un contrat n'a, à proprement parler, rien à faire avec la volonté personnelle ou individuelle des parties. Un contrat est une obligation attachée par la simple force de la loi à certains actes des parties, habituellement des mots, qui accompagnent et représentent ordinairement une certaine intention. Si, cependant, il était prouvé par vingt évêques que l'une des parties, quand elle a utilisé les mots comprenait autre chose que la signification usuelle que le droit leur attribue, alors cela pourrait être pris en considération »[1212]. Cette approche correspond à une conception du contrat où ce qui compte, c'est moins ce qui a été réellement voulu que ce que chaque partie a pu comprendre des intentions de l'autre à travers les termes employés.

En réalité, l'opposition est moins marquée qu'on ne pourrait le croire, parce que tous les systèmes juridiques – en *common law* comme dans les pays de droit civil – sont amenés à combiner les deux approches dans les méthodes qu'adoptent les juges pour interpréter le contrat (**§ 1**). L'opposition se révèle peut-être plus sensible si on se demande à quels juges est attribué le pouvoir d'interprétation (**§ 2**).

§1. Les méthodes d'interprétation

523. Conseils donnés aux juges. Les rédacteurs du Code civil ont édicté, dans les articles 1156 à 1164, toute une série de règles expliquant comment il faut interpréter un contrat. Qualifiées ironiquement de « guide-âne » par Carbonnier[1213], ces textes n'ont qu'une importance pratique limitée. Suivant la position prise par ses homologues française[1214] et, jusqu'à une période récente, belge[1215],

[1212] *Hotchkiss v. National City Bank of New York* (1911) cité par J. SMITS, *Contract law. A comparative introduction*, *op. cit.*, p. 123.

[1213] J. CARBONNIER, *Droit civil*, *op. cit.*, n° 1062, p. 2175.

[1214] Cass. fr. (req.) 18 mars 1807, *S.*, 1807, 1, p. 361 ; Cass. fr. (req.), 24 février 1868, *DP*, 1868, I, p. 308. Voy. encore récemment : Cass. fr. (1re civ.), 19 décembre 1995.

[1215] Cass. be., 22 mai 1868, *Pas. be.*, 1868, I, p. 380 ; Cass. be., 9 octobre 1964, *Pas. be.*, 1965, I, p. 132.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la Cour de cassation du Luxembourg a affirmé très tôt que ces dispositions « constituent des conseils adressés aux juges, et non pas des règles impératives dont l'inobservation entraînerait la nullité de la décision »[1216]. Si la formule a légèrement évolué depuis, mais sur le fond la solution est restée constante : un arrêt récent réaffirme ainsi que « l'article 1156 du Code civil n'a pas un caractère impératif, ses dispositions constituant des conseils donnés aux juges par le législateur pour l'interprétation des conventions et non des règles absolues dont la méconnaissance donne ouverture à cassation »[1217]. Il convient cependant de signaler que la Cour de cassation belge avait, avant la réforme, rompu avec cette position traditionnelle, et qu'elle considérait que les articles 1156 et suivants du Code civil sont de véritables règles de droit auxquelles les juges du fond doivent se conformer[1218]. L'exemple est à méditer au Luxembourg, car, même si on considère que l'interprétation concrète des contrats relève du pouvoir souverain des juges du fond[1219], on ne voit pas pourquoi le juge ne devrait pas respecter les règles posées par la loi pour effectuer cette interprétation. En toute hypothèse, l'examen de ces textes est important en ce qu'ils montrent comment, dans la pensée des rédacteurs du Code, le principe d'interprétation subjective (**A**) est nuancé par la prise en considération de nombreux éléments objectifs (**B**).

A) *Le principe de l'interprétation subjective*

524. Article 1156 du Code civil. Comme on l'a dit, l'article 1156 qui ouvre dans le Code civil la section consacrée à l'interprétation des contrats, s'inscrit nettement dans une approche subjective, elle-même liée à une conception volontariste du contrat. Ce qui compte, c'est ce que les parties ont voulu, leur « commune intention », plutôt que ce qu'elles ont dit ou écrit « le sens littéral des termes ». Le juge peut bien sûr tenir compte des termes employés, qui sont très souvent révélateurs de l'intention des parties, mais, si les termes sont ambigus, imprécis ou contradictoires, il peut aller chercher d'autres éléments susceptibles de découvrir ce que les parties

[1216] Cass., 24 décembre 1896, *Pas.*, 4, p. 230. Solution réaffirmée plus récemment par Cass., 18 juin 1987, *Pas.*, 27, p. 117.

[1217] Cass., 12 octobre 2023, n° CAS-2022-00127.

[1218] Cass. be., 24 mars 1988, *Pas. be.*, 1988, I, p. 894 et 10 janvier 1994, *Pas. be.*, 1994, I, p. 12 (à propos de l'article 1156 du Code civil) ; Cass. be., 22 mars 1979, *Pas. be.*, 1979, I, p. 863 (à propos de l'article 1162 du Code civil).

[1219] Voy. *infra*, n° 529.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ont voulu, soit dans le contrat lui-même (confrontation avec d'autres clauses, objectifs exprimés dans le préambule du contrat, etc.), soit dans des éléments extérieurs (audition des parties, témoignages relatant les négociations). Dans ce dernier cas, cependant, le juge doit respecter les règles de preuve de l'article 1341 du Code civil, qui lui interdit de retenir des témoignages ou présomptions à l'encontre de ce qui est écrit dans le contrat[1220] : ce n'est donc que si l'examen du contrat lui-même ne permet pas de découvrir l'intention des parties que le recours à des éléments extérieurs est possible.

525. Autres textes. D'autres articles de la section s'inscrivent nettement dans la même optique de recherche de la volonté des parties. Il en va ainsi de l'article 1163 du Code civil, selon lequel « Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter ». De même, l'article 1164 du Code civil, selon lequel « Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par-là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés », ce qui paraît être une application particulière de l'article 1156 du Code civil. On peut encore rattacher à cette démarche subjective l'article 1157 du Code civil, selon lequel « Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle pourrait avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun » – parce que, en principe, on doit supposer que, si les parties ont inséré une clause dans le contrat, c'est parce qu'elles voulaient que cette clause ait un sens. L'article 1161 du Code civil, selon lequel « Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier », peut être lu dans le même esprit, parce qu'on doit supposer que les parties n'ont pas voulu se contredire. L'article 5.65 du nouveau Code civil belge reprend ces différents éléments en les présentant explicitement comme des moyens de déterminer la volonté réelle des parties. Cependant, on peut aussi voir dans ce texte, au-delà de ce qu'ont vraiment voulu les parties – qui n'ont pas nécessairement eu conscience de la contradiction – l'expression d'un principe de cohérence[1221], qui tirerait plutôt le texte du côté de considérations objectives, nettement présentes dans d'autres articles.

[1220] Voy. *supra*, n° 421.

[1221] Sur ce « principe », voy. D. HOUTCIEFF, *Le principe de cohérence en matière contractuelle*, préf. H. MUIR WATT, Paris, LGDJ, 2001.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

B) *La prise en considération d'éléments objectifs*

526. La matière du contrat. – L'article 1158 du Code civil pose que « les termes qui sont susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat ». Bien que l'article 5.65 reprenne cette formule au titre des directives visant à déterminer la volonté réelle des contractants, cette référence à la « matière » du contrat n'est pas directement liée à ce que les parties ont réellement voulu, mais plutôt au sens que des contractants abstraits pourraient donner, dans le type de contrat considéré, aux termes employés. Par exemple, si dans un contrat ayant pour objet la construction d'une maison on trouve une clause intitulée « Terme » disant que « le présent contrat prendra fin à telle date », il faut normalement comprendre que le terme est un terme suspensif, indiquant que l'entrepreneur doit achever la maison avant cette date sous peine de sanctions, et non un terme extinctif qui libérerait l'entrepreneur de son obligation[1222] – ceci n'excluant pas la preuve d'une volonté contraire. On peut trouver un prolongement de l'article 1158 du Code civil dans les règles spéciales posées par la loi pour l'interprétation de certains contrats : ainsi lorsque, à propos du mandat, l'article 1988 du Code civil prévoit que « le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration », cette règle ne tient aucun compte de ce que les parties ont réellement voulu, elle impose une interprétation restrictive des termes employés en considération de la « matière » spécifique du contrat de mandat, qui crée des dangers particuliers pour le mandant.

527. L'usage. Deux articles se réfèrent à l'usage comme élément d'interprétation du contrat. L'article 1159 du Code civil commande d'interpréter ce qui est ambigu « par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé ». Comme plusieurs autres articles de la section relative à l'interprétation, ce texte est susceptible de deux lectures : une lecture subjective (que consacre l'article 5.65 du Code civil belge), dans laquelle on suppose que les parties ont donné aux termes de leurs contrats la même signification que celle qu'on leur donne habituellement dans la pratique locale, une lecture objective, partant de l'idée que les contractants n'ont pas nécessairement connaissance de cette pratique, et qui s'y réfère faute de pouvoir déterminer avec certitude ce que les parties ont voulu. On peut faire la même double lecture de l'article 1160 du Code civil, selon lequel

[1222] Sur la distinction du terme extinctif et du terme suspensif, voy. *infra*, n° 570.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

« On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles ne soient pas exprimées » – est-ce parce qu'on suppose que les parties ont voulu « faire comme tout le monde », ou parce que ces clauses apparaissent normales compte tenu des pratiques habituelles ? L'article 1160 du Code civil est du reste un texte à la frontière de la question de l'interprétation et de celle du comblement des lacunes du contrat, qui, nous le verrons, se fait très souvent sans référence à la volonté des parties, et même contre celle-ci.

528. La faveur pour un contractant. Le Code civil contient dans son article 1162 une règle d'interprétation qui exprime la faveur faite à un contractant : « Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ». Dans le langage des rédacteurs du Code civil, celui qui a stipulé désignait le créancier[1223], et celui qui a contracté l'obligation était le débiteur[1224] : c'était ce dernier que, en cas de doute, on voulait favoriser, pour compenser en quelque sorte sa situation plus dure dans le contrat[1225]. Mais, par suite d'un glissement sémantique, on comprend souvent aujourd'hui « stipuler » dans le sens de « rédiger », et on se sert de l'article 1162 du Code civil pour justifier une interprétation des contrats d'adhésion en faveur de l'adhérent, et en défaveur du rédacteur des conditions générales. Ce glissement, présent depuis longtemps dans les jurisprudences française[1226] et belge[1227], est désormais consacré par les textes issus des réformes française (C. civ. fr., art. 1190) et belge (C. civ. be., art. 5.66) Le même glissement s'observe dans la jurisprudence récente des juges du fond luxembourgeois, où il est fréquemment explicité[1228]. Un tel

[1223] On retrouve ce sens dans la « stipulation pour autrui » de l'article 1121 du Code civil, voy. *infra*, n°s 1082 et s.

[1224] Ce sens primitif se retrouve dans la nouvelle rédaction du texte dans l'art. 1190 du projet français : « Dans le doute, une obligation s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ».

[1225] Pour des applications du texte dans cette signification originaire : J.d.P. Luxembourg, 11 novembre 1974, *Pas.*, 23, p. 250 ; Trib. Luxembourg, 14 octobre 1970, *Pas.*, 21, p. 519 ; Comp. Cour d'appel, 3 août 1882, *Pas.*, 2, p. 151 qui déclare l'article 1162 inapplicable dans un contrat de société où tous les associés sont à la fois « stipulants et promettants » (c'est-à-dire débiteurs et créanciers).

[1226] Cass. fr. (civ.), 11 mai 1948, *Gaz. Pal.*, 1948, 2, p. 41 ; Aix, 6 avril 1960, *D.*, 1960, p. 343.

[1227] Voy. WÉRY, n° 423 et les arrêts cités. Il semble que la jurisprudence belge tende plutôt à interpréter contre celui qui est le bénéficiaire de la clause, même s'il n'est pas le débiteur (p. ex. : interprétation restrictive des clauses exclusives ou limitatives de garantie) ; mais, dans la plupart des cas, ces clauses ont été insérées par le rédacteur de l'acte).

[1228] Cour d'appel, 13 février 2002, n° 24910 ; Trib. Luxembourg, 31 janvier 2003, n° 73548 ; Trib. Luxembourg, 20 décembre 2022, n° TAL-2021-10025 ; Cour d'appel, 31 mai 2023, n° CAL-2020-00126 ; Trib. Luxembourg, 2 mai 2024, n° TAL-2019-10459.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

principe d'interprétation « *contra proferentem* » (contre le rédacteur), qui est une des manifestations de la protection de la partie faible dans les contrats d'adhésion, a été explicitement consacré en matière de contrats de consommation par l'article L. 211-2 (2) du Code de la consommation luxembourgeois[1229], reprenant textuellement l'article 5 de la directive de 1993 « Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut ». Cependant, au Luxembourg cette règle d'interprétation a un domaine d'application plus large que dans le texte européen puisque (comme toute la réglementation des clauses abusives) elle ne s'applique pas seulement aux clauses prérédigées sous forme de conditions générales, mais à toutes les clauses des contrats de consommation[1230]. Il faut souligner que la règle d'interprétation ici posée, à la différence de ce qu'on admet traditionnellement pour les articles 1156 et suivants du Code civil, a une portée impérative, ce qui a une influence sur les pouvoirs du juge qui interprète.

§2. Le pouvoir d'interprétation

529. Principe : le pouvoir souverain des juges du fond. La question est ici de savoir qui a le pouvoir d'interpréter le contrat. Le juge, sans doute, lorsqu'il est saisi d'un litige relatif au contrat, et que les parties sont en désaccord sur le sens du contrat ou de l'une de ses clauses. Mais quel juge exactement ? La question se pose dans les pays de droit civil où, à la différence des pays de *common law*, on fait habituellement, au niveau des pouvoirs juridictionnels, une séparation nette entre le droit et le fait : dans les trois pays du Code civil, en particulier, la Cour de cassation, n'est en principe compétente que pour juger du droit, la connaissance et la découverte des faits étant réservée aux juges du fond. Même si ce n'est là qu'une présentation approximative d'une distinction artificielle et d'une réalité autrement plus complexe, la question se pose de savoir où on situe l'interprétation du contrat par rapport à cette distinction du fait et du droit.

[1229] Pour éviter que cette règle d'interprétation ne se retourne contre les consommateurs, le texte précise qu'elle ne s'applique pas dans le cadre d'une action en cessation formée contre le professionnel. Il s'agit d'éviter que le professionnel ne cherche à éviter l'éviction de la clause en faisant état d'une interprétation favorable au consommateur.

[1230] Voy. *supra*, n° 412 le domaine d'application de la réglementation des clauses abusives.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

D'un côté, on peut considérer – en prenant à la lettre l'article 1134 – que tout contrat pose, à sa petite échelle, une norme juridique en ce qu'il dit, comme une loi, ce que des sujets de droit doivent ou peuvent faire ou ne pas faire, et en ce qu'il constitue la référence première pour le juge chargé de régler un litige entre les parties. Mais d'un autre côté, c'est une norme qui n'a pas de portée générale, et dont, on vient de le voir, l'interprétation repose en principe sur la volonté des parties, laquelle ne peut qu'être recherchée qu'au cas par cas, sans pouvoir donner lieu à l'édiction d'interprétations générales qui seraient valables pour tous les contrats d'un même type. C'est pourquoi la Cour de cassation, au Luxembourg comme en France et en Belgique, a toujours considéré que l'interprétation des contrats était une question relevant du pouvoir souverain des juges du fond, et ne pouvant pas donner lieu en principe à ouverture à cassation[1231]. C'est là un des principes les mieux établis du droit des contrats, ayant donné lieu, au fil du temps, à un grand nombre d'arrêts d'irrecevabilité de la part de la Cour de cassation, dont la jurisprudence en matière contractuelle est par ailleurs peu fournie. De ce point de vue, l'interprétation des contrats se distingue radicalement de celle de la loi, qui constitue le cœur de l'activité régulatrice de la Cour de cassation. Au Luxembourg, cependant, la solution n'est pas rattachée à l'idée qu'il s'agit d'une question de fait, mais à l'absence de caractère impératif des articles 1156 et suivants du Code civil.

Dans des pays comme la France et la Belgique, le refus par la Cour de cassation de contrôler l'interprétation des contrats se justifie aussi par le fait qu'il est normalement inutile d'assurer sur l'ensemble du territoire une unité d'interprétation de contrats qui sont tous différents. Cet argument ne vaut pas au Luxembourg, où il n'existe de toute façon qu'une cour d'appel et où la Cour de cassation n'a pas été instituée pour assurer l'unité d'interprétation de la loi[1232]. Pour cette même raison, le pouvoir souverain des juges du fond en la matière ne présente pas au Luxembourg les mêmes inconvénients qu'ailleurs lorsqu'on est en présence de contrats d'adhésion, passés certes avec des parties différentes, mais rédigés en des termes tout à fait identiques, et qu'il peut être choquant d'interpréter différemment à Lyon et à Marseille ou à Mons et à Liège. Pour cette raison, la Cour de cassation française a parfois accepté de contrôler directement ou indirectement l'interprétation des contrats-types ou de clauses d'utilisation générale. Le problème ne se pose pas au Luxembourg puisque l'unité d'interprétation est suffisamment assurée par l'unique cour d'appel. Il paraît donc amplement justifié que la Cour de cassation renvoie à cette cour l'interprétation

[1231] Jurisprudence constante depuis Cass., 20 juillet 1876, *Pas.*, 1, p. 215 ; Voy. récemment : Cass., 3 décembre 2020, n CAS-2019-00169 ; Cass., 25 mai 2023, n° CAS-2022-00062.

[1232] Sur le rôle de la Cour de cassation au Luxembourg voy. le remarquable article de P. KINSCH et M. PIERRAT, « La mission de la Cour de cassation : point de vue luxembourgeois », *Ann. dr. lux.*, 2009, vol. 19, pp. 83-108.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

des contrats. On peut seulement regretter que, comme on l'a vu, on déduise de ce pouvoir souverain l'absence de contrôle de l'application des articles 1156 et suivants du Code civil : on peut tout à la fois dire que les juges sont souverains pour découvrir le sens de tel ou tel contrat, et en même temps leur imposer, pour faire ce travail, d'appliquer les méthodes d'interprétation que la loi leur dicte.

530. Dénaturation des clauses claires et précises. En France, il est admis depuis le XIX[e] siècle que le pouvoir d'interprétation reconnu aux juges du fond cesse lorsque la clause en discussion est « claire et précise »[1233]. Si le juge fait dire à cette clause autre chose que le sens découlant de ses termes, on est en présence d'une « dénaturation » qui est censurée au visa de l'article 1134 du Code civil. On peut en effet considérer que, dans un tel cas, le juge refuse d'appliquer le contrat, ou qu'il en modifie les termes, ce qui est une violation de l'article 1134 du Code civil, règle de droit étatique dont l'application est contrôlée par la Cour de cassation, juge du droit. La solution est aujourd'hui reprise par le nouvel article 1192 du Code civil selon lequel « [o]n ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ». Une solution voisine est admise en Belgique, mais en d'autres termes : les juges du fond sont tenus par « le respect de la foi due aux actes », imposé par les articles 1319, 1320 et 1332 du Code civil en matière de preuve, et ils ne doivent pas adopter une interprétation inconciliable avec les termes du contrat[1234]. Dans un premier temps, la Cour de cassation luxembourgeoise avait suivi la jurisprudence française, un arrêt de 1905 ayant affirmé que le pouvoir souverain des juges du fond trouvait sa limite dans le cas « où le juge du fait, au lieu d'interpréter un acte obscur, dénature la portée d'une clause absolument claire et précise qui ne comporte pas d'interprétation et substitue ainsi une convention nouvelle à celle qui avait été conclue par les parties »[1235]. Cependant, la distinction entre la mauvaise interprétation et la dénaturation est assez artificielle, en ce que le concept de « clause absolument claire et précise » qui ouvre droit au contrôle de la dénaturation est lui-même un concept très imprécis. L'expérience en France montre que, assez souvent, il y a bien un doute sur le sens de la clause et que la censure, au visa de l'article 1134 du Code civil, est un moyen pour la Cour de cassation de donner sa propre interprétation, contraire à celle des juges du fond. C'est cette constatation qui avait amené assez vite

[1233] En France : jurisprudence constante depuis Cass. fr. (civ.), 15 avril 1872, *GAJC*, t. 2, n° 161.

[1234] Ce qui, selon la majorité des auteurs belges, n'interdit pas d'interpréter un acte prétendument clair. Sur la jurisprudence belge voy. Van Ommeslaghe, n[os] 392 et s.

[1235] Cass., 5 mai 1905, *Pas.*, 7, p. 139.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la Cour de cassation luxembourgeoise à abandonner la notion de dénaturation en matière contractuelle, au motif que la distinction entre les clauses claires et obscures est purement arbitraire ; pour la Cour, savoir si une clause est claire et précise ou non est déjà une question de fait qui relève de l'interprétation souveraine des juges du fond[1236]. Un arrêt du 31 octobre 2019, qui censure au visa de l'article 1134 du Code civil un arrêt d'appel ayant méconnu une stipulation non équivoque d'un contrat, semble cependant marquer un tournant dans cette attitude traditionnelle[1237].

531. Limite : le contrôle de la qualification. Il ne faut pas confondre l'interprétation – qui consiste à découvrir la signification d'un contrat ou d'une clause obscurs ou imprécis, avec le processus de qualification, qui consiste à faire rentrer le contrat dans une catégorie juridique nommée (une vente, un bail, un mandat, etc.). Le nouveau Code civil belge consacre à la qualification une sous-section distincte de celle relative à l'interprétation (art. 5.67 et 5.68). Ce processus est normalement préalable à l'interprétation – la qualification pouvant alors commander l'interprétation à retenir en fonction de la « matière » du contrat. Par exemple, le fait de qualifier un contrat de « mandat » entraînera l'application de l'article 1988 du Code civil prévoyant que « le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration ». Mais parfois, à l'inverse, l'interprétation du contrat peut déterminer la qualification du contrat : si par exemple, dans un contrat par lequel une personne remet une chose à une autre, il n'est pas clair que cette dernière peut ou non se servir de la chose, le choix de l'une ou l'autre interprétation commandera la qualification de prêt ou de dépôt. Or, si l'interprétation du contrat relève du pouvoir souverain des juges du fond, la qualification, qui consiste à faire rentrer une situation de fait dans les présupposés d'une règle de droit, procède de l'application et de l'interprétation de cette règle, et elle ne peut s'opérer que sous le contrôle de la Cour de cassation. La Cour de cassation luxembourgeoise distingue depuis longtemps les deux opérations : dès 1876, elle affirmait que si en principe, « le juge du fond a un pouvoir souverain pour fixer le sens d'une convention par interprétation de l'intention

[1236] Cass., 15 décembre 1925, *Pas.*, 11, p. 225 ; Cass., 27 juillet 1939, *Pas.*, 15, p. 1 ; Cass., 25 juin 1959, *Pas.*, 17, p. 559 ; Cass., 30 juin 2011, *Pas.*, 37, p. 815 ; Cass., 28 février 2013, n° 3102.

[1237] Cass., 31 octobre 2019, n° 138/2019, n° CAS-2018-00097, pp. 39-40. Sur cet arrêt, voy. P. KINSCH, *Le contrôle de la dénaturation des écrits existe-t-il devant la Cour de cassation luxembourgeoise ?*, *op. cit.*, pp. 40-41. Voy. très récemment : Cass., 23 janvier 2025, n° 11/2025, n° CAS-2024-00069.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

des parties contractantes », pourrait en revanche être censurée une décision qui « méconnaîtrait le caractère légal de la convention et les conséquences qu'elle doit produire »[1238]. Plus récemment, elle a réaffirmé son « droit de censure sur la qualification donnée au contrat, en recherchant en droit si les faits constatés en réunissent les caractères légaux »[1239]. Dans l'exemple précédemment donné, le juge du fond est libre de déterminer si la personne à qui la chose a été remise peut ou non s'en servir pour son usage personnel (c'est de l'interprétation) ; mais s'il estime qu'il ne pouvait pas s'en servir, alors il doit qualifier le contrat de dépôt (C. civ., art. 1917 et s.) et non de prêt (C. civ., art. 1875 et s.). Cette opération de qualification est absolument essentielle : outre que, comme on l'a vu, elle peut avoir une incidence sur l'interprétation du contrat, elle commande les règles applicables tant à la validité du contrat, qu'à ses effets. Elle peut, en particulier, jouer un rôle déterminant lorsqu'il faudra compléter le contenu explicite du contrat par un contenu implicite.

SECTION 2. LE COMPLÉTEMENT DU CONTRAT

532. Contrat incomplet. Il est rare que les parties à un contrat aient envisagé dans leur accord tous les aspects de leur relation, et qu'elles aient prévu la solution de toutes les difficultés qui pourraient surgir entre elles[1240]. Si un problème surgit qui n'a pas été réglé expressément dans le contrat, les parties peuvent bien sûr essayer de se mettre d'accord sur la manière de le résoudre en complétant elles-mêmes leur contrat. À défaut, la loi donne directement un certain nombre de solutions, et elle permet au juge, même en l'absence de texte, de compléter le contrat par référence à certains éléments qui lui sont extérieurs. Le contenu explicite du contrat, tel qu'il a été déterminé par les parties, va alors s'enrichir d'un contenu implicite. Cette idée trouve une assise légale dans un texte qui vient immédiatement après l'article 1134 du Code civil, et qui en est le complément nécessaire – dont on trouve du reste l'équivalent dans de nombreux ordres juridiques. Ce texte, l'article 1135 du Code

[1238] Cass., 20 juillet 1876, *Pas.*, 1, p. 215.

[1239] Cass., 22 octobre 1970, *Pas.*, 21, p. 346.

[1240] La notion de contrat incomplet a fait l'objet de très nombreuses études d'économistes, notamment aux États-Unis. Cependant elle n'a pas exactement le même sens pour les économistes et pour les juristes. Pour une présentation des différences de notions. Voy. E. Putman, « L'introuvable contrat complet », in *R.R.J.*, 2008-5, n° spécial consacré à L'analyse économique du droit. Autour D'ejan Mackaay, p. 2479.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

civil, prévoit que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». Il se retrouve, avec quelques modifications, à l'article 1194 du Code civil français et à l'article 5.71 du nouveau Code civil belge. Pour comprendre la portée exacte de ce texte[1241], il paraît nécessaire d'introduire certaines distinctions, d'abord quant aux différents types d'incomplétude auxquels il permet de remédier (**§ 1**), ensuite quant aux méthodes qu'il prévoit pour compléter le contrat (**§ 2**).

§1. Les types d'incomplétude

533. Lacunes du contrat. L'article 1135 du Code civil est souvent présenté comme un texte indiquant au juge comment il doit combler les « lacunes » du contrat, quand les parties n'ont pas réglé une question nécessaire à la solution de leur litige[1242]. On peut effectivement parler de lacune lorsqu'il est absolument nécessaire de trouver une réponse à la question pour que le contrat puisse produire ses effets. Supposons par exemple un contrat de vente, dans lequel il est prévu que les marchandises vendues devront être délivrées à telle date, mais sans qu'il soit précisé où elles doivent l'être. Est-ce alors au vendeur d'aller livrer les marchandises chez l'acheteur, ou est-ce à l'acheteur d'aller les chercher chez le vendeur (en organisant lui-même le transport) ? La réponse à cette question est absolument indispensable pour que le contrat puisse prendre effet si rien ne se passe à la date fixée, et si les parties ne sont pas d'accord sur le lieu de livraison : l'acheteur pourrait-il alors agir contre le vendeur pour le contraindre à livrer, ou au moins demander des dommages et intérêts au vendeur qui ne lui a pas livré à la date prévue ? Ou bien est-ce au contraire le vendeur qui peut se plaindre de ce que l'acheteur lui laisse les marchandises « sur les bras » ? Dans un tel cas, si l'affaire vient devant un tribunal, c'est dans la loi que celui-ci trouvera la réponse, plus précisément dans l'article 1609 du Code civil selon lequel « la délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en était l'objet,

[1241] Voy. en droit français (mais parfaitement transposables au Luxembourg) les deux réflexions complémentaires, et en partie contradictoires, de P. JACQUES, *Regards sur l'article 1135 du Code civil*, préf. F. CHABAS, Paris, Dalloz, 2005 et de C. MOULY, *Retour sur l'article 1135 du Code civil – Une nouvelle source du contenu contractuel*, préf. D. FERRIER, Paris, LGDJ, 2006.

[1242] Voy. p. ex. en France BÉNABENT (2016), n° 288 ; en Belgique WÉRY, n° 387 ; pour une approche comparative : SMITS, pp. 130 et s. (« *gap filling* »).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

s'il n'en a pas été autrement convenu ». En l'espèce, dans le silence des parties, il devra donc être jugé que c'est à l'acheteur de venir chercher les marchandises chez le vendeur. Il est indispensable que le droit contienne des réponses pour combler ce type de lacunes, car autrement le contrat resterait lettre morte. Aussi bien, si la réponse ne se trouve pas dans la loi, l'article 1135 du Code civil permet-il au juge de chercher la réponse dans les usages ou dans l'équité, comme nous le verrons plus loin.

Il faut cependant bien voir que ce ne sont pas toutes les lacunes du contrat qui pourront être ainsi comblées. Certaines lacunes sont trop importantes pour que le juge ou le législateur puisse suppléer la volonté absente des parties : ce sont les lacunes qui affectent un élément essentiel du contrat, sans lequel celui-ci ne peut se former valablement. Si par exemple, dans une vente, le prix n'est pas déterminé ni déterminable, le juge ne peut pas le fixer à la place des parties, et le contrat est nul, peut-être même inexistant. L'article 1135 du Code civil permet seulement au juge de déterminer les « suites » d'un contrat qui, au départ, est suffisamment complet pour avoir force obligatoire. Il ne lui permet pas de déterminer à la place des parties les éléments nécessaires pour que ce contrat soit valable.

534. Obligations non prévues. L'article 1135 du Code civil n'est pas seulement un instrument permettant au juge de combler ce qu'on pourrait appeler les « lacunes techniques » du contrat, en allant chercher dans la loi ou en créant lui-même les solutions nécessaires pour que le contrat puisse s'exécuter. Il est également utilisé pour ajouter dans le contrat certaines obligations qui ne sont pas indispensables à son fonctionnement, mais que, pour des raisons d'opportunité, le législateur ou la jurisprudence choisissent d'intégrer dans le contrat. Sans doute, certaines obligations sont nécessairement impliquées par le type de contrat considéré : c'est ce que Pothier appelait les « *essentialia* », « les choses qui sont de l'essence du contrat […] sans lesquelles ce contrat ne peut subsister »[1243]. Par exemple, on ne conçoit pas qu'un contrat de vente puisse ne pas obliger le vendeur à la délivrance de la chose : si les parties n'en ont rien dit, on est en présence d'une véritable lacune, et le juge trouvera dans la loi les règles nécessaires pour la combler (délai, lieu, frais de la délivrance). Mais dans d'autres cas, on est en présence d'une obligation qui n'est pas indispensable pour que le contrat

[1243] Pothier, *Traité des obligations*, n° 6.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

s'exécute : tel est le cas par exemple de l'obligation de garantie du vendeur (qui permet à l'acheteur de demander la résolution de la vente ou la diminution du prix, avec éventuellement des dommages et intérêts, si la chose présente des défauts qui n'étaient pas apparents lors de la vente). Si les parties à une vente n'ont rien dit d'une telle obligation, on ne peut pas dire à proprement parler qu'il y a une lacune dans le contrat, car celui-ci peut parfaitement s'exécuter sans une telle obligation[1244]. Si la chose vendue s'avère défectueuse, il faudra bien sûr se demander si le vendeur doit ou non indemniser l'acheteur, mais on pourrait considérer que le silence gardé par les parties est en soi une solution au problème, en indiquant que le vendeur n'est tenu à aucune garantie. Cependant, la loi décide, dans l'article 1641 du Code civil, qu'une telle obligation est une « suite » normale du contrat de vente, elle fait partie de ce que Pothier appelait les « *naturalia* », les choses « qui sont seulement de la nature du contrat […] qui, sans être de l'essence du contrat, font partie de ce contrat, quoique les parties ne s'en soient point expliquées, étant de la nature du contrat que ces choses y soient renfermées et sous-entendues »[1245]. Sur le fondement de l'article 1135 du Code civil, le juge peut lui aussi ajouter dans le contrat des obligations que les parties n'avaient pas expressément prévues, et qui seront considérées comme des « suites » tenant à la « nature » de ce contrat. L'exemple le plus célèbre d'une telle adjonction se trouve dans la jurisprudence française qui, à partir de 1911, a fait peser sur le transporteur de personnes une obligation de sécurité (c'est-à-dire l'obligation d'assurer la sécurité des passagers, et donc de l'indemniser contractuellement en cas d'accident)[1246], alors qu'auparavant on considérait que les accidents de transport relevaient de la responsabilité délictuelle[1247]. Au Luxembourg, cette jurisprudence n'a pas eu l'occasion de se développer, car la solution avait déjà été prévue par une loi du 8 février 1908 ayant modifié l'article 103 du Code de commerce. Mais la jurisprudence luxembourgeoise a reconnu une telle obligation de sécurité dans de nombreux autres contrats[1248]. Cette adjonction va bien au-delà d'un

[1244] Qui d'ailleurs peut être expressément écartée du contrat, du moins dans les ventes entre professionnels.

[1245] POTHIER, *Traité des obligations*, *op. cit.* et *loc. cit.*

[1246] Cass. fr. (civ.), 21 novembre 1911, *S.*, 1912, 1, p. 73, note LYON-CAEN ; *GAJC*, n° 262.

[1247] Sur les intérêts de cette jurisprudence, voy. *infra*, n° 810.

[1248] Voy. p. ex. pour l'obligation du restaurateur d'assurer la sécurité de ses clients dans les locaux du restaurant : Cour d'appel, 2 février 2022, n° CAL-2020-00730. Sur le domaine des obligations de sécurité en droit luxembourgeois, voy. RAVARANI, n°s 508 et s.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

comblement des lacunes à proprement parler[1249] : sans l'obligation de sécurité, le contrat de transport peut parfaitement fonctionner, et remplir sa fonction économique (transporter les passagers d'un point à un autre), et d'ailleurs il fonctionnait très bien comme cela en France jusqu'en 1911 ; on ne peut donc pas dire que le juge, en faisant peser sur le transporteur une obligation de sécurité, répare un « oubli » des parties, le silence gardé à cet égard pouvant simplement signifier que le transporteur n'avait jamais entendu assumer une telle obligation. L'intervention du juge qui « crée » de toutes pièces une obligation supplémentaire à la charge d'une partie pourrait donc tout aussi bien être considérée comme une modification du contenu du contrat. C'est pourquoi, du reste, pour caractériser ce gonflement du contenu obligationnel du contrat, un auteur français de la première moitié du XXe siècle, Josserand, a parlé de « forçage » du contrat[1250]. Souvent reprise depuis, la formule, à connotation clairement négative, peut cependant être critiquée, dans la mesure où elle présuppose que le contrat doit être uniquement l'œuvre de la volonté des parties. Or cette approche volontariste est clairement démentie par l'examen des méthodes de complétement du contrat que permet l'article 1135 du Code civil.

§2. Les méthodes de complétement du contrat

535. Complétement concret et complétement abstrait. Le droit comparé amène à distinguer deux types d'opérations permettant de compléter le contenu du contrat. Dans son ouvrage de droit comparé des contrats, J. Smits distingue ainsi ce qu'il appelle le « *ad hoc gap filling* » et le « *gap filling by default rules* »[1251] – ce qu'on peut essayer de traduire par comblement concret et comblement abstrait des lacunes du contrat.

Dans le premier cas, le juge complète le contrat (qu'il s'agisse de combler des lacunes à proprement parler ou d'ajouter des obligations non prévues) par la recherche de solutions propres au contrat

[1249] C'est pourquoi, dans les présents développements, on a préféré utilisé le terme « complètement », peu usuel quoique correct, plutôt que de parler de « comblement », ce qui évoque l'idée d'une lacune.

[1250] L. Josserand, « L'essor moderne du concept contractuel », in *Recueil d'études des sources du droit en l'honneur de François Geny*, t. II, *Sources générales des systèmes juridiques actuels*, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1934, pp. 333 et s., spéc. p. 340. Voy. aussi L. Leveneur, « Le forçage du contrat », in *Que reste-t-il de l'intangibilité du contrat ? Dr. et patrimoine*, 1998, p. 69.

[1251] Smits, pp. 130 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

considéré, en fonction de ce que les parties à ce contrat auraient probablement voulu si elles avaient pensé au problème. La solution posée ne vaut que pour le contrat considéré, elle résulte d'une appréciation concrète, au cas par cas, qui, logiquement ne devrait pas être contrôlée par le juge du droit. La démarche du juge est ici dans le prolongement direct de son activité d'interprétation. Elle s'en distingue cependant parce que, par hypothèse, les parties n'ont pas pensé au problème, et qu'il est vain de rechercher ce qu'elles ont voulu. On doit donc se contenter d'une volonté probable, hypothétique. Ce type d'opérations correspond à ce que, en droit allemand, on appelle l'interprétation complétive (*ergänzende Vertragsauslegung*), visant à découvrir ce que « à la lumière de l'objectif poursuivi par le contrat, ce qu'elles auraient dit si elles avaient réglé le point en question »[1252]. En *common law*, la recherche des « *implied terms in fact* » correspond à la même logique : ce que le juge doit trouver, c'est, selon une décision célèbre de 1939, ce qu'une personne ayant assisté à la conclusion du contrat (*an officious bystander*) aurait pu souffler aux parties, et que celles-ci auraient alors inséré dans leur contrat en disant simplement « Oh bien sûr ! »[1253]. On retrouve la même idée dans l'article II-9:101 du DCFR qui autorise le juge à régler des points que les parties n'auraient pas prévu, en essayant, si possible, de « donner effet à ce que les parties, si elles avaient réglé la question, auraient probablement décidé ».

Mais dans d'autres cas, le comblement des lacunes s'opère selon une tout autre logique, qui consiste à poser une règle générale et abstraite, applicable, par principe, à tous les contrats du même type (*default rule*). Cette règle peut bien sûr être inspirée par ce qu'on suppose être la volonté raisonnable de la majorité des contractants dans le type de contrat considéré, mais elle n'a rien à voir avec la volonté réelle ou supposée des parties à tel ou tel contrat particulier. On n'est plus dans le domaine du cas par cas, la solution est trouvée dans une règle de droit posée par la loi ou par le juge du droit, et dont l'application par les juges du fond est contrôlée par ce dernier. Telle est la logique de ce que, en *common law*, on appelle les *implied terms in law*, effets d'un contrat qui découlent de la nature de celui-ci, qui en sont des suites nécessaires, indépendamment

[1252] J. SMITS, *Contract law. A comparative introduction*, *op. cit.*, p. 131.

[1253] Opinion du juge McKinnon LJ dans *Shirlaw v. Southern Foundries* [1939], 2 KB 206, Court of Appeal.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de ce que les parties peuvent ou non vouloir[1254]. L'adjonction par la Cour de cassation française de l'obligation de sécurité dans le contrat de transport de personnes en est une bonne illustration : cette obligation est édictée d'une manière générale comme une règle de droit applicable à tous les contrats de transport. Du reste, du point de vue du fond du droit, il n'y a aucune différence entre le droit français, où la règle posée est jurisprudentielle, et le droit luxembourgeois où, comme on l'a dit, la solution est édictée dans un texte de loi (C. comm., art. 103).

Pour rationnelle que puisse paraître cette distinction, elle n'est que très rarement systématisée dans les pays du Code civil. Cela tient à ce que l'article 1135 du Code civil peut servir aussi bien de support à l'une qu'à l'autre démarche, même si les conséquences en sont très différentes. Si le complètement par la loi (**A**) relève nécessairement d'un comblement abstrait, les deux autres éléments de référence visés par le texte – l'usage (**B**) et l'équité (**C**) – peuvent, selon les cas, servir tantôt à compléter concrètement un contrat particulier, tantôt à poser des règles générales.

A) *Le complètement par la loi*

536. Lois supplétives et impératives. Même si la référence à la loi n'apparaît qu'en dernier dans l'article 1135 du Code civil[1255], les lois jouent un rôle essentiel dans le comblement des lacunes des contrats. Comme on le sait déjà, il existe même, dans le Code civil et dans d'autres lois, une multitude de textes dont le rôle est, précisément de « suppléer » à la volonté des parties quand elle ne s'est pas exprimée. C'est à toutes ces lois supplétives que renvoie principalement l'article 1135 du Code civil. Pendant longtemps, on présentait ces lois comme reflétant la volonté probable des parties : si les parties avaient pensé au problème, disait-on, elles l'auraient probablement réglé de cette manière. C'est pourquoi on disait parfois que ces lois étaient « interprétatives de volonté ». Cette explication, très artificielle, correspondait à une approche exclusivement volontariste du contrat, dans laquelle on n'imaginait pas que les effets du contrat puissent provenir d'autre chose que de la

[1254] Voy. l'exposé de cette logique dans : *Liverpool City Council v. Irwin* [1976], 2 W.L.R. 562, cité par Smits, p. 133.

[1255] Cette place a été maintenue dans le nouvel article 1194 du Code civil français. Dans l'article 5.71 du nouveau Code civil belge, en revanche, la loi vient en premier parmi les sources de complètement du contrat.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

volonté des parties. Cette présentation est aujourd'hui généralement abandonnée, et on préfère voir dans les lois supplétives des règles qui correspondent à la conception que le législateur lui-même (et non les contractants) se fait de l'organisation sociale fondée sur le contrat, et de l'équilibre normal des droits et des obligations entre les parties. Ce sont, en ce sens, des solutions normales, des « modèles », présentés aux contractants, même si ceux-ci peuvent les écarter. L'explication fondée sur la volonté supposée des parties est en tout cas totalement inopérante lorsque les lois qui vont s'appliquer au contrat sont des lois impératives, puisque ces lois s'appliqueraient de la même manière si les parties avaient exprimé une volonté contraire. Dans un cas comme dans l'autre, que les lois en matière contractuelle soient supplétives ou impératives, elles s'inscrivent dans le modèle d'un comblement abstrait des lacunes du contrat : les solutions posées par la loi valent pour tous les contrats d'un même type, d'une même « nature ». Ce sont tous les vendeurs qui sont tenus d'une obligation de garantie des vices cachés (C. civ., art. 1641)[1256], c'est dans tous les contrats de bail que le bailleur est tenu de faire les réparations autres que locatives (C. civ., art. 172), c'est dans tous les contrats de dépôt que le déposant ne peut, sauf permission expresse, se servir de la chose déposée (C. civ., art. 1930), et ce sont tous les contrats de transport qui contiennent une obligation de sécurité (C. comm., art. 103). Et, lorsqu'un juge saisi d'un litige relativement à un de ces contrats, fait application, à défaut de volonté contraire des parties, de telle ou telle de ces règles, il ne règle évidemment pas une question de fait ; il applique une règle de droit, dont l'interprétation peut être contrôlée par la Cour de cassation.

537. **Incorporation des obligations légales dans le contrat.** De prime abord, le renvoi que l'article 1135 du Code civil fait à « la loi » pour compléter le contenu du contrat peut paraître inutile. Le juge qui doit appliquer une loi pour combler une lacune du contrat le fera directement, sans passer par le détour de l'article 1135 du Code civil : pour reprendre un exemple précédemment donné, si le vendeur et l'acheteur n'ont pas précisé le lieu de livraison, le tribunal, en cas de litige, ira chercher directement la solution dans l'article 1609 du Code civil, règle supplétive. Cependant, la référence à la loi dans l'article 1135 du Code civil peut être comprise comme réalisant l'incorporation de la règle légale dans le contrat : ce n'est pas l'article 1609 du Code civil qui obligera le vendeur à livrer au lieu où était la chose au jour de la vente, c'est le contrat. Si c'est la loi qui prévoit la solution, c'est le contrat passé entre telle et telle personne qui oblige les parties dans les termes prévus. En conséquence la responsabilité pour manquement à une obligation prévue par la

[1256] Selon la personnalité des contractants, cette obligation est tantôt supplétive tantôt impérative.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

loi doit être considérée comme une responsabilité contractuelle. Si certains auteurs ont autrefois soutenu le contraire, c'est toujours sur le fondement d'une approche volontariste du contrat : les effets du contrat prévus par la loi (et donc non voulus directement par les parties) ne pouvaient donc pas être considérés comme des effets proprement contractuels. Dans les approches modernes du contrat, on peut voir à l'inverse dans l'article 1135 du Code civil une des manifestations de ce que, selon la formule de Durkheim « tout n'est pas contractuel (c'est-à-dire volontaire) dans le contrat »[1257].

B) *Le complètement par l'usage*

538. Usages de droit et usages conventionnels. Ce n'est pas seulement aux lois qu'il faut se référer pour déterminer le contenu du contrat, c'est aussi, selon l'article 1135 du Code civil, à « l'usage ». Ce texte trouve un écho dans l'article 1160 du Code civil, déjà rencontré, selon lequel « on doit suppléer dans les conventions les clauses qui y sont d'usage quoiqu'elles ne soient pas exprimées », et qui, bien que placé dans la section relative à l'interprétation, concerne plutôt le comblement des lacunes du contrat. Le sens exact de ce renvoi à l'usage est particulièrement difficile à déterminer. Selon une terminologie empruntée à Gény, qui l'avait lui-même importée d'Allemagne, on distingue souvent les usages de droit – qui ne sont autres que les coutumes, normes générales extérieures aux parties et résultant d'un comportement reconnu comme obligatoire dans un groupe social déterminé – et les usages conventionnels – pratiques habituellement suivies par les contractants. La distinction est en réalité fort obscure, et il n'est pas étonnant que, selon les auteurs, l'article 1135 du Code civil soit compris comme visant l'une ou l'autre forme d'usage[1258]. Il convient sans doute de distinguer deux types d'utilisations de l'usage, qui correspondent aux deux types de comblement des lacunes précédemment distingués.

Dans l'immense majorité des cas, les usages qui vont servir à combler les lacunes d'un contrat (par exemple, en y introduisant des clauses que les parties n'y ont pas mises elles-mêmes) sont des usages « de droit », c'est-à-dire des pratiques habituellement suivies et reconnues comme étant « la norme » dans le groupe social auquel appartiennent les contractants. C'est en ce sens que la Cour d'appel définit l'usage comme « les pratiques qui,

[1257] Sur cette formule, voy. *supra*, n° 43.

[1258] Voy. p. ex. la totale différence de présentation entre Poelmans, qui considère que l'article 1135 du Code civil vise les « usages conventionnels » (Poelmans, p. 137) et Wéry pour qui le texte vise les « usages de droit » (Wéry, n°s 391 et s.)

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales dans le secteur d'activité considéré »[1259]. Le fait que ces pratiques soient des pratiques relatives aux effets de tel ou tel contrat n'en fait pas pour autant des « usages conventionnels ». C'est ainsi que, par exemple, depuis le XIX[e] siècle, la jurisprudence, dans les trois pays du Code civil, considère que la solidarité se présume en matière commerciale[1260] : l'usage entre commerçants est de stipuler la solidarité des débiteurs, et c'est pourquoi, si par exception, on ne trouve pas une telle clause dans un contrat, on fera comme si elle y était. C'est aussi sur le fondement de pratiques habituelles du monde bancaire que la jurisprudence, au XIX[e] siècle, a élaboré les règles générales relatives aux contrats de compte-courant. D'une manière générale, les usages jouent un rôle important en matière bancaire, et le Luxembourg en est un territoire privilégié d'application : par exemple, on va considérer qu'il est d'usage, dans les contrats bancaires, que le défaut de protestation du client à la réception de son relevé de compte vaille approbation des opérations qui y sont enregistrées ; même si ce n'est pas dit dans le contrat, la jurisprudence considérera que la solution s'applique[1261]. Dans tous ces cas, les usages opèrent exactement comme les lois supplétives, donc comme des règles de droit applicables dans tous les contrats du type considéré (dans le dernier exemple, dans tous les contrats de compte-bancaire), et leur existence et leur portée est une question de droit qui peut être contrôlée par la Cour de cassation[1262].

Dans d'autres cas, cependant, ce qui est pris en considération, ce ne sont pas les usages sociaux dans un secteur considéré, mais les pratiques habituelles des parties ou de l'une d'elles – ce qu'on peut appeler les « usages conventionnels ». Ces usages n'ont pas, en eux-mêmes, valeur de norme, mais dans certaines circonstances, les juges peuvent s'y référer pour combler une lacune d'un contrat particulier passé entre les parties. Par exemple, dans une entreprise, si l'habitude a été prise de donner des primes aux salariés, on peut considérer que le paiement devient obligatoire en vertu

[1259] Cour d'appel, 1[er] juillet 2021, n° CAL-2020-00529.

[1260] Voy. *infra*, n° 621.

[1261] Cour d'appel, 9 février 1994, *Pas.*, *29*, p. 315 ; Cour d'appel, 18 juin 2004, n° 27044, *BIJ*, 2004, p. 207 (qui estime cependant que cet usage ne couvre pas les fautes commises par la banque et n'empêche pas le client d'agir en responsabilité contre celle-ci).

[1262] Voy. p. ex. Cass. fr. (comm.), 26 février 1979, n° 77-13701.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

d'un usage constant de l'entreprise, valant engagement tacite de l'employeur[1263]. Mais dans ce cas, l'obligation au paiement de la prime ne devient pas une règle générale applicable à tout contrat de travail : c'est une solution retenue *ad hoc* pour les contrats passés au sein d'une entreprise déterminée, et son existence relève de l'appréciation souveraine des juges du fond[1264]. Dans les deux cas, cependant, on trouve un point commun : l'usage, qu'il soit une norme générale extérieure ou une habitude propre à un contractant, n'est jamais impératif, il ne s'appliquera que si les parties ne l'ont pas écarté expressément[1265].

C) *Le complètement par l'équité*

539. Équité et bonne foi. L'article 1135 est un des très rares textes du Code civil qui fait référence à la notion vague d'équité. Cette référence, très étonnante dans un système légaliste, est généralement regardée avec beaucoup de méfiance par la doctrine des pays du Code civil, et, d'une manière générale, les juges se gardent bien d'y faire expressément référence lorsqu'ils complètent le contenu d'un contrat[1266]. Cependant, c'est bien cette notion qui peut expliquer que, en dehors de tout texte et de tout usage, la jurisprudence se permette d'intégrer dans un contrat des obligations non prévues par les parties : si la Cour de cassation française a décidé, en 1911, de faire peser sur les transporteurs de personnes une obligation de sécurité, c'est parce qu'il lui paraissait « équitable » que le transporteur assume par principe la charge des accidents survenus aux passagers, sans que ceux-ci aient à prouver sa faute. Et on peut rattacher à la même considération les multiples obligations d'information, de conseil, de surveillance que la jurisprudence fait peser sur certains professionnels. Un arrêt de la Cour d'appel voit ainsi « une suite naturelle et implicite que l'usage et l'équité donnent à l'obligation du restaurateur » dans l'obligation qu'elle fait peser sur celui-ci de surveiller les vêtements du client[1267]. L'article 1135 du Code civil permet ainsi aux

[1263] Cour d'appel, 14 avril 2005, n° 29395, *BIJ*, 2005, p. 181.

[1264] Cass., 26 mai 2005, n° 2072.

[1265] Voy. p. ex. Cour d'appel, 14 avril 2005, préc. i, qui juge que l'employeur ayant constamment rappelé que la prime versée était exceptionnelle, le salarié n'avait aucun droit acquis à son maintien.

[1266] Voy. cependant Cour d'appel, 6 mars 1934, *Pas.*, 13, p. 213 ; Cour d'appel, 27 janvier 1982, *Pas.*, 25, p. 299.

[1267] Cour d'appel, 27 janvier 1982, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

juges de faire passer dans le contrat une certaine dose de justice contractuelle, d'introduire, au-delà ou même à l'encontre de ce qu'ont pu vouloir les parties, un certain équilibre entre les droits et les obligations. De ce point de vue, la référence à l'équité dans l'article 1135 du Code civil rejoint largement un autre instrument qui, dans la jurisprudence contemporaine, permet de compléter le contenu du contrat par la création de nouvelles obligations, à savoir la bonne foi de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil[1268]. Il est vrai que, comme certains auteurs ont pu le faire remarquer, les deux textes ont théoriquement une fonction différente : l'article 1134, alinéa 3 du Code civil donne au juge le pouvoir de contrôler la manière dont un contractant exécute ses obligations, alors que l'article 1135 du Code civil lui permet de créer des obligations non prévues[1269]. Mais, dans la jurisprudence, ils se recoupent aujourd'hui très largement. Du reste, dans le nouveau Code civil belge, les auteurs de la réforme ont choisi de remplacer purement et simplement la référence à l'équité par la notion de bonne foi dans l'article 5.71, qui constitue la version remodelée de l'article 1135.

Tout comme la référence aux usages, le recours (implicite) à l'équité pour compléter le contenu du contrat et celui (généralement explicite) à la bonne foi dans sa fonction complétive, peuvent relever soit de l'« *ad hoc gap filling* », soit du « *gap filling by default rules* ». Dans certains cas, c'est en fonction de particularités propres au contrat qui lui est soumis que le juge (du fond) décidera que tel contractant est tenu à l'égard de l'autre d'une obligation d'information, de surveillance, de coopération, etc. Mais, beaucoup plus souvent, la présence dans tel ou tel type de contrat de telle ou telle obligation est affirmée de manière générale, comme une règle applicable à tous les contrats de ce type : l'obligation de sécurité pèse ainsi sur tout transporteur de personnes, sur tout exploitant de jeux forains, sur tout restaurateur, etc. La règle posée par la jurisprudence fonctionne alors, pour le complétement du contrat, de la même manière que la loi, et elle peut être comme elle, supplétive ou (plus souvent) impérative. Cela exclut de considérer que cette création d'obligations procéderait d'une recherche de la volonté probable des parties. Même si, dans une conception libérale de la société, certains peuvent trouver que la jurisprudence (comme

[1268] Sur cette fonction complétive de la bonne foi contractuelle voy. *supra*, n° 496.

[1269] P. JACQUES, *Regards sur l'article 1135 du Code civil*, *op. cit.*, n°s 157 et s., spéc. n°s 167 et s.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

le législateur) vont trop loin dans ce « forçage » du contrat, on ne peut pas se contenter de le critiquer en notant que les obligations créées ne correspondent pas à ce que les parties ont voulu, alors que l'ensemble du mécanisme complétif de l'article 1135 du Code civil montre que le contrat a, aussi, un contenu objectif indépendant de cette volonté.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La teneur du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 631-655
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Chapitre III
La durée du lien obligatoire

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

540. La distinction des contrats à exécution instantanée et des contrats à exécution successive. Pendant combien de temps un contrat a-t-il force obligatoire ? Cette question, essentielle en pratique, n'est abordée dans le Code civil qu'à propos de certains contrats spéciaux (le bail, le prêt, le contrat de travail, etc.). C'est que le problème ne se pose pas de la même manière dans tous les contrats, car le rapport au temps des obligations des parties est très différent d'un contrat à l'autre. La doctrine a introduit à cet égard une distinction entre les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive. Les premiers s'exécutent (ou du moins peuvent s'exécuter) en un instant, de sorte que la question de leur durée ne se pose normalement pas : c'est le cas de la vente. Les seconds – dont les exemples les plus caractéristiques sont le contrat de bail et le contrat de travail – s'exécutent par une série de prestations qui s'échelonnent dans le temps, pendant une durée plus ou moins longue. La distinction – reprise par le nouvel article 1111-1 du Code civil français – est très malencontreuse – et très trompeuse – sur le plan terminologique, parce que de nombreux contrats dits « à exécution instantanée » voient leur exécution différée ou même échelonnée dans le temps. La vente, par exemple, qui est le type même du contrat dit « à exécution instantanée », donne très souvent lieu à un paiement différé ou échelonné de la part de l'acheteur, et il peut être prévu que le vendeur livrera la chose en plusieurs fois. De même, à la surprise habituelle des étudiants, on traite parfois comme un contrat « à exécution instantanée » le contrat d'entreprise (ou, selon la terminologie du Code civil, de louage d'ouvrage) par lequel une personne s'engage à effectuer une prestation envers une autre à titre indépendant[1270], alors pourtant que la réalisation de la prestation promise (la construction d'une maison, le nettoyage d'un vêtement, le transport de marchandises ou d'une personne, etc.) suppose presque toujours un certain temps. Mais, même s'il serait souhaitable de trouver une terminologie plus adaptée, la distinction, souvent critiquée, mérite à notre sens d'être conservée. En effet, l'exécution différée, fractionnée ou étalée dans le temps, d'un contrat comme la vente ou le contrat d'entreprise, n'a pas le même sens que

[1270] Ce qui distingue ce contrat du contrat de travail (appelé, dans le Code, contrat de louage de services) où le salarié effectue son travail à titre subordonné, en obéissant aux instructions de son employeur. Ce n'est cependant pas pour cette raison que le contrat de travail est, lui, considéré comme le type même du contrat à exécution successive !

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'étalement dans le temps des prestations nées d'un contrat de travail, ou des rapports qui naissent d'un contrat de bail. Dans le premier cas, même si leur exécution est étalée dans le temps, les différentes actions attendues de l'acheteur, du vendeur ou de l'entrepreneur sont conçues comme formant un tout indivisible, une prestation unique dont les différents paiements, les différentes livraisons ou étapes de réalisation du travail ne sont que des fractions : tant que l'acheteur n'aura pas payé le prix, le vendeur livré tous les éléments de la chose, ou l'entrepreneur fini la maison, le contrat ne sera pas complètement exécuté. La durée n'est ici qu'une modalité d'exécution de la prestation, elle ne fait pas partie de l'objet du contrat : l'acheteur, par exemple, ne s'oblige pas « à payer le prix pendant un certain temps », il s'oblige « à payer le prix » (tout de suite, plus tard, ou par mensualités). Il n'en va pas de même dans un contrat de bail ou de travail, où les obligations des parties s'exécutent par une série de prestations qui se renouvellent dans le temps, ou par une prestation continue, de sorte qu'on peut concevoir que les parties, à un moment donné, cessent de fournir la ou les prestations sans qu'il y ait pour autant inexécution : si, à un moment donné, le salarié quitte son emploi, ou le bailleur donne congé à son locataire, on dira simplement que le contrat prend fin et non pas que le salarié ou le bailleur n'ont pas exécuté complètement leurs obligations. Ici, la durée est un élément essentiel de l'objet du contrat : on ne peut pas se contenter de dire, par exemple, que « le locataire s'oblige à payer les loyers de l'appartement qui lui est loué », il ne s'oblige à le faire que « tant que le bail durera » (cette durée pouvant être ou non déterminée à l'avance). La durée n'est pas, comme dans les contrats dits « à exécution instantanée » une modalité d'exécution des prestations prévues par le contrat, elle est le temps pendant lequel les prestations sont dues. Cette idée apparaît dans le nouvel article 1229 du Code civil français, relatif aux effets de la résolution pour inexécution : pour déterminer si l'anéantissement du contrat qui en résulte est ou non rétroactif, le texte distingue selon que « les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu » ou que « les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat ». Pour traduire l'opposition, on pourrait parler de « contrats de prestations » dans le premier cas, et de

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

contrats de durée dans le second[1271]. Les termes d'« exécution instantanée » et d'« exécution successive », légitimés par la force de la tradition, ne sont utilisés ici que moyennant ces précisions essentielles.

541. Relativité de la distinction. Même si elle est ainsi débarrassée de son ambiguïté terminologique, il faut avoir conscience que la distinction est affectée d'une certaine relativité. Selon les circonstances et la volonté des parties, un même contrat peut relever de l'une ou l'autre logique. Ainsi, le contrat de travail, qui semble être le contrat à exécution successive par excellence, peut devenir un contrat « à exécution instantanée » si le salarié s'engage, non à travailler « pendant un certain temps », mais « pour une entreprise déterminée » selon l'expression de l'article 1780 du Code civil (nettoyer un grenier, abattre un arbre dans mon jardin, etc.). Le contrat ne prendra fin que lorsque le travail sera effectué, et le salarié manquera à son obligation s'il démissionne au milieu[1272]. À l'inverse, un contrat ayant habituellement pour objet une prestation unitaire peut devenir un contrat « à exécution successive ». Par exemple, un commerçant détaillant et un grossiste, au lieu de passer au coup par coup des contrats de vente, peuvent conclure, une fois pour toutes, un contrat de fourniture prévoyant la livraison régulière de marchandises moyennant, à chaque fois, paiement de leur prix, pendant un certain temps ou sans limitation de durée. Le cautionnement est traditionnellement un contrat « à exécution instantanée », où la caution est obligée de payer la dette du débiteur principal si celui-ci ne la paye pas lui-même ; il devient très souvent, dans la pratique, un contrat à exécution successive, lorsque la caution s'engage à garantir toutes les dettes du débiteur principal envers le créancier (avec ou sans limitation de durée). Par ailleurs, un même contrat peut, selon les systèmes et selon les époques, être analysé comme un contrat « à exécution instantanée » ou comme un contrat « à exécution successive », ce qui aura des conséquences importantes sur son régime juridique. L'exemple de la jurisprudence française relative au contrat de prêt à usage (prêt d'un livre, d'un appartement, etc.) est à cet égard caractéristique. Traditionnellement, parce que ce contrat est un contrat réel qui se forme par la remise de la chose à l'emprunteur, on le considérait comme un contrat unilatéral, où la seule obligation était l'obligation de l'emprunteur de restituer la chose. Cette obligation est par hypothèse affectée d'un terme, et il était admis que, si ce terme n'avait pas été fixé par les parties, il appartenait au juge de combler cette lacune et de fixer lui-même la date de restitution. Mais on peut aussi, très différemment, par analogie avec le contrat de bail[1273], centrer l'analyse sur l'obligation du prêteur de laisser la chose à disposition de l'emprunteur pendant un certain temps : le prêt apparaît alors comme un contrat de durée, qui, en cas de non-fixation du terme,

[1271] Pour une présentation renouvelée de la durée dans le contrat, voy. A. Etienney, *La durée de la prestation*, préf. T. Revet, Paris, LGDJ, 2008.

[1272] La logique est alors la même que celle du contrat d'entreprise ou de prestation de services (ayant pour objet p. ex. la construction d'une maison, le nettoyage d'un vêtement, les soins apportés à un malade, le conseil juridique etc.) réglementé dans le Code civil sous l'appellation de « louage d'ouvrage » par opposition au « louage de services aujourd'hui appelé contrat de travail. La différence entre les deux contrats tient à ce que le salarié, dans le contrat de travail, est subordonné à son employeur, alors que l'entrepreneur agit en toute indépendance.

[1273] La différence entre le prêt à usage et le bail est que le premier est nécessairement gratuit (donc unilatéral) alors que le bail est un contrat synallagmatique à titre onéreux.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pourra prendre fin à tout moment par la volonté unilatérale d'une partie[1274]. Telle est la position actuelle de la Cour de cassation française[1275], qui révèle un glissement dans l'analyse du contrat de prêt.

En dépit de ces incertitudes, la problématique de la durée des contrats est fondamentalement différente selon qu'on est en présence d'un contrat « à exécution instantanée » (**Section 1**) ou à « exécution successive » (**Section 2**). Cependant, les règles relatives à la caducité des contrats sont largement communes aux deux catégories (**Section 3**).

SECTION 1. LA DURÉE DES CONTRATS À « EXÉCUTION INSTANTANÉE »

542. Durée liée à l'exécution des obligations. Lorsque les prestations attendues des parties sont conçues comme formant un tout dont on attend une exécution intégrale, la durée du contrat se calque nécessairement sur celle de cette exécution. Le contrat ne prendra pas fin, il aura force obligatoire, tant que les parties n'auront pas toutes exécuté leurs obligations, ou que celles-ci se seront éteintes pour une autre cause que l'exécution. Il importe peu à cet égard que l'exécution ait été différée ou fractionnée : le terme (ou les termes successifs fixés pour l'exécution) ne mettra évidemment pas fin au contrat, il ne fera que rendre exigible l'obligation qui en est assortie. Par exemple, dans une vente où le paiement du prix est payable en quatre versements trimestriels, l'acheteur ne sera pas automatiquement délié au bout d'un an, il ne sera libéré du contrat que lorsqu'il aura payé l'intégralité du prix. Il en va de même dans un contrat comme le prêt d'argent, où l'emprunteur doit rembourser l'intégralité de la somme qui lui a été versée (assortie éventuellement d'intérêts). De tels contrats ne peuvent prendre fin avant leur exécution complète que si les obligations qu'ils ont fait naître s'éteignent pour une autre cause : par exemple si la dette de l'emprunteur se trouve atteinte par la prescription, ou si l'une des parties bénéficie d'une remise de dette, soit de la part de l'autre partie, soit par l'effet d'une décision judiciaire (par exemple, dans le cadre d'une procédure de traitement du surendettement). Dans tous les cas, la fin du contrat n'est que la conséquence de l'extinction des obligations qu'il a produite.

[1274] Voy. *infra*, n°s 546 et s.

[1275] Cass. fr. (1re civ.), 3 février 2004, n° 01-00004 ; Cass. fr. (1re civ.), 30 septembre 2015, n° 14-25709.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

543. Prolongement dans le temps des effets d'un contrat. Un contrat peut continuer d'avoir force obligatoire très longtemps après que ses obligations principales auront été exécutées. D'abord, certains de ses effets non obligationnels qui se sont produits une fois pour toutes au moment de la formation ou de l'exécution du contrat, peuvent être pérennes : il en va ainsi du transfert de propriété dans la vente, qui ne sera jamais remis en cause tant que le bien existera. Ensuite, le contrat peut faire naître des obligations accessoires qui survivent à l'exécution des obligations principales. Ainsi dans une vente, même après que la chose a été livrée et le prix payé, le vendeur demeure tenu d'une obligation de garantie contre les vices cachés ou le défaut de conformité de la chose. Tant que cette obligation n'est pas éteinte, l'acheteur d'une chose viciée peut agir contre le vendeur en se fondant sur le contrat (dont toutes les clauses relatives au règlement des litiges, au montant de la réparation, aux causes d'exonération, etc. demeurent applicables). L'après-contrat reste régi par le contrat tant que toutes les obligations que celui-ci a fait naître ne sont pas épuisées. Il en va de même, du reste, pour les contrats dits « à exécution successive ».

SECTION 2. LA DURÉE DES CONTRATS À « EXÉCUTION SUCCESSIVE »

544. Principe et distinction. Les contrats qu'on appelle traditionnellement « contrats à exécution successive » se caractérisent par un renouvellement dans le temps, pour une période déterminée ou non, des prestations à effectuer par les parties (ou par la partie débitrice si le contrat est unilatéral). Les deux exemples les plus caractéristiques sont le contrat de bail et le contrat de travail : chaque mois, le locataire s'engage à payer un loyer en contrepartie de l'obligation qui pèse sur le bailleur de lui procurer la jouissance paisible des lieux loués, chaque mois l'employeur doit payer le salarié en contrepartie du travail qu'il a pu fournir pendant la période considérée. On peut y assimiler des contrats qui font naître une prestation qui s'exécute de manière continue, et qui peut durer plus ou moins longtemps selon la volonté des parties : ainsi le contrat de dépôt ou le contrat de mandat. Dans ces hypothèses, on ne peut pas dire qu'un tel contrat dure jusqu'à ce qu'il soit complètement exécuté. À tout moment au cours du contrat, on peut concevoir soit que le contrat continue (de nouvelles prestations seront exécutées par la suite), soit qu'il s'arrête sans que cela apparaisse nécessairement comme une inexécution partielle des obligations contractuelles. Par exemple, un salarié est obligé d'effectuer chaque jour travaillé un certain nombre de prestations pour son employeur ; si, à un moment donné, il décide de démissionner, il ne sera plus tenu de travailler à partir de la prise d'effet de sa démission, et le fait de ne pas venir au travail ensuite ne sera évidemment pas considéré comme une inexécution

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de ses obligations ! Dans ces hypothèses, la durée du contrat va dépendre de la volonté des parties, qui peuvent vouloir que les prestations se renouvellent plus ou moins longtemps. Il faut alors distinguer selon que les parties ont ou non, dès le départ, déterminé la durée de leur contrat[1276].

A) *Les contrats à exécution successive et à durée indéterminée*

545. Principe et limites. Lorsque les parties n'ont pas elles-mêmes fixé de terme à leur engagement, il est posé en principe, dans les trois pays du Code civil, que chaque partie dispose d'un droit de résiliation unilatérale, c'est-à-dire de la faculté d'y mettre fin à tout moment. Ce principe est aujourd'hui posé explicitement par les articles 1211 du Code civil français et 5.75 du nouveau Code civil belge. Au Luxembourg, il a été nettement affirmé par la Cour de cassation, au visa de l'article 1134, alinéa 2 du Code civil : « Attendu qu'il résulte de cette disposition que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du même texte, offerte aux deux parties »[1277]. Cependant, tout en posant le principe (**1**), la Cour en laisse entrevoir les limites (**2**).

1) *Le principe du droit de résiliation unilatérale*

546. Fondement. Consacré explicitement par certains textes, ce droit est reconnu par la jurisprudence d'une manière générale dans tous les contrats à exécution successive et indéterminée, comme une conséquence d'une interprétation extensive de l'article 1780 du Code civil. Ce texte, écrit à l'origine pour le seul contrat de travail[1278], dispose, dans le but de protéger la liberté du salarié, que « on ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée ». Mais il est admis que cette règle n'est que

[1276] On pourrait songer à un dépassement de la distinction pour ce que certains auteurs appellent les « contrats d'existence » (Life time contracts), définis comme des relations sociales à long terme par lesquelles les individus se fournissent des biens ou des services, accèdent à un travail ou à une source de revenus. Ces contrats, qui vont du bail d'habitation au crédit à la consommation en passant par le contrat de travail, suscitent des difficultés particulières qui pourraient justifier l'élaboration d'un régime juridique spécifique protecteur de la personne engagée ; voy. L. NOGLER et U. REIFNER (dir.), *Life time contracts*, Eleven international publishing, 2014 ; D. HIEZ, « À propos des Life time contracts », *RTD civ.*, 2014, pp. 817 et s. : L. RATTI (dir.), *Embedding the Principles of Life Time Contracts. A Research Agenda for Contract Law*, La Haye, Eleven international Publishing, 2018

[1277] Cass., 13 juillet 1995, *Pas.*, 29, p. 433. Pour un rappel récent de la solution, voy. Cour d'appel, 15 décembre 2022, n° CAL-2021-00972.

[1278] Le Code civil connaît ce contrat sous le nom de « contrat de louage de services ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'expression d'un principe général de prohibition des engagements perpétuels, du moins dans les contrats « à exécution successive » dont la durée pour la vie des parties (et peut-être même au-delà, si les héritiers étaient tenus de continuer le contrat) porterait une grave atteinte à leur liberté[1279]. On serait en présence d'un tel engagement perpétuel si les parties à un tel contrat passé sans limitation de durée, la fourniture renouvelée de biens ou de services, n'avaient pas la possibilité de s'en retirer sans l'accord de l'autre. Il faut donc, pour « sauver » ces contrats, ouvrir à chaque partie la faculté de s'en retirer unilatéralement. Ce droit paraît tellement important au regard de la liberté individuelle que le Conseil constitutionnel français, lui a reconnu une valeur constitutionnelle : « si le contrat est la loi commune des parties, la liberté qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 justifie qu'un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l'un ou l'autre des contractants »[1280]. On peut de même penser qu'en droit luxembourgeois, le législateur ne pourrait organiser un contrat à exécution successive sans prévoir un droit de résiliation unilatérale.

547. Portée. Le droit de résiliation unilatérale n'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, nullement contraire au principe de la force obligatoire, et de l'irrévocabilité qui en découle. Ce principe ne vaut que dans la limite des engagements assumés par les parties. Or, si aucune durée n'a été fixée, cela ne veut pas dire « les parties sont engagées jusqu'à leur mort » – puisque cette interprétation aboutirait à condamner le contrat – mais seulement « les parties sont engagées jusqu'à ce que l'une d'elles veuille sortir du contrat ». Par ailleurs, il faut bien voir que le droit de résiliation unilatérale n'a pas pour effet, dans le type de contrats où il est reconnu, de détruire complètement le contrat, et de permettre à celui qui l'exerce de revenir sur son engagement. La résiliation n'opère que pour l'avenir : les parties n'ont plus à accomplir, pour l'avenir, de nouvelles prestations, mais elles restent tenues de toutes les obligations nées avant la résiliation, et qui n'étaient pas encore exécutées[1281]. Un locataire qui résilie son bail n'aura plus, à compter de la date de

[1279] Pour l'énoncé de cette justification, voy. Cour d'appel, 15 décembre 2022, préc.

[1280] C. const., 9 novembre 1999, n° 99-419 DC (décision rendue à propos de la loi créant le pacte civil de solidarité – équivalent du partenariat du droit luxembourgeois –, et précisant que chaque partenaire doit pouvoir rompre unilatéralement un tel pacte, assimilé à un contrat).

[1281] Comp. Zenati-Castaing, Revet, n° 209, qui expliquent la solution par l'idée que la résiliation affecte les obligations contractuelles, mais non le contrat lui-même.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

prise d'effet de cette résiliation, à payer de loyers (et il ne pourra plus occuper les lieux), mais il ne sera pas libéré des loyers correspondant à son occupation antérieure et qu'il n'aurait pas encore payés.

548. Domaine. Il faut répéter que le droit de résiliation unilatérale n'a de sens que dans les contrats qu'on appelle traditionnellement « à exécution successive », c'est-à-dire ceux qui prévoient une série de prestations ayant vocation à se renouveler dans le temps. Il n'existe aucune possibilité de ce type pour les contrats qui ont pour objet une prestation unitaire, serait-elle étalée ou échelonnée dans le temps (un acheteur à crédit, par exemple, ne peut pas résilier le contrat avant d'avoir tout payé). Le droit de résiliation unilatérale n'existe pas davantage, en principe, dans les contrats à exécution successive dès lors qu'une durée a été fixée[1282]. En revanche, le droit de résiliation unilatérale est reconnu par principe dans tous les contrats à durée indéterminée, quel qu'en soit l'objet : contrat de travail (C. trav., art. L. 124-1), contrat de bail (C. civ., art. 1736), ouverture de crédit faite par une banque à un client[1283], contrat de compte-joint[1284], cautionnement donné sans limitation de durée pour la garantie des dettes futures et indéterminées d'un débiteur, contrat d'abonnement à une revue, contrat d'entretien d'un matériel, contrat de concession exclusive[1285], etc. On remarquera qu'on ne distingue pas selon que les contrats considérés portent sur des prestations à caractère personnel, ou qu'ils ont un objet purement patrimonial, alors même que dans ce cas l' atteinte à la liberté individuelle des parties est moins évidente. De même, dans tous ces contrats, le droit de résiliation est reconnu en principe au profit de chaque partie, même si elle n'est pas tenue de prestations à caractère personnel : par exemple, dans le bail à durée indéterminée, le droit de résiliation est reconnu non seulement au locataire (qui ne peut pas être obligé d'habiter toujours au même endroit), mais aussi au bailleur (dont c'est plutôt la propriété que la liberté qui est ici protégée). Nous verrons cependant qu'il est davantage encadré pour le bailleur que pour le locataire.

[1282] Voy. *infra*, n° 553.

[1283] Solution rappelée par CSSF, *Rapport d'activité 2004*, pp. 142 et 143.

[1284] Cass., 13 juillet 1995, *Pas.*, 29, p. 433.

[1285] Cour d'appel, 11 juillet 1972, *Pas.*, 22, p. 194 ; Cour d'appel, 18 novembre 1998, *Pas.*, 31, p. 67 ; Cour d'appel, 10 mars 2005, *D.A.O.R.*, 2007, n° 84, note POELMANS ; Cour d'appel, 6 juillet 2011, n° 35365, *BIJ*, 2012, p. 141.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

En dehors du domaine qui vient d'être délimité, il peut être mis fin unilatéralement par une partie à un contrat pour des raisons particulières. L'une d'elles, qui a déjà été évoquée, réside dans l'inexécution de ses obligations par l'autre partie qui permet à l'autre, dans des conditions qui seront ultérieurement précisées, de demander ou parfois de procéder unilatéralement à la résolution du contrat. Lorsque cette résolution pour inexécution concerne un contrat à exécution successive, on l'appelle traditionnellement résiliation, car, comme la résiliation unilatérale dont il est ici question, elle n'opère que pour l'avenir[1286]. Cependant, il ne faut surtout pas confondre cette résiliation pour inexécution – qui est applicable dans tous les contrats successifs, même à durée limitée – avec le droit de résiliation unilatérale, spécifique aux contrats à durée indéterminée.

2) *Les limites au droit de résiliation unilatérale*

549. Liberté versus sécurité. Le droit de résiliation unilatérale, déduit indirectement de l'article 1780 du Code civil, a été conçu, on l'a dit, pour protéger la liberté individuelle des contractants – et, dans le cas particulier du contrat de louage de services, pour éviter le retour du servage. Cependant, au fil du temps, on s'est aperçu que la reconnaissance d'un tel droit pouvait produire des effets pervers, du moins dans certains contrats qui procurent à une des parties des prestations essentielles à sa vie ou à son activité. Permettre à un bailleur de mettre fin librement et à tout moment au bail, cela revient à priver le locataire du jour au lendemain de son lieu d'habitation ; reconnaître à l'employeur le droit de résilier le contrat de travail, c'est priver brutalement le salarié de sa source de revenus ; permettre à un banquier de couper les crédits qu'il avait ouverts sans limitation de durée à une entreprise, c'est compromettre la survie de cette entreprise qui comptait sur les crédits accordés ; laisser à l'organisateur d'un réseau de distribution la liberté de rompre, c'est empêcher le concessionnaire ou le franchisé de poursuivre son activité. Le souci d'assurer la stabilité de certains rapports contractuels, et d'assurer une certaine sécurité au cocontractant, a amené le législateur (pas seulement au Luxembourg), à encadrer le droit de résiliation unilatérale dans de nombreux contrats. En dehors de ces textes, des limites peuvent être cherchées dans les concepts généraux du droit des contrats.

550. Encadrement législatif du droit de résiliation unilatérale dans certains contrats. Il est hors de question de recenser ici tous les textes qui, pour protéger une partie, limitent la liberté de rompre reconnue à l'autre. Les textes les plus caractéristiques sont relatifs

[1286] Voy. *infra*, n° 794.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

au contrat de travail et au contrat de bail, mais on peut également citer la réglementation du contrat d'agent commercial[1287], ou celle des contrats relatifs aux services de paiement bancaire[1288]. L'encadrement législatif peut prendre différentes formes, qui sont souvent combinées.

Une première limite au droit de résiliation unilatérale consiste à en subordonner l'exercice au respect d'un certain délai de préavis, permettant au cocontractant de « se retourner ». Un tel délai de préavis est ainsi imposé aux deux parties en matière de bail d'habitation. Le Code civil prévoyait déjà un délai fixé par « l'usage des lieux ». Dans le droit moderne, le locataire comme le propriétaire doivent respecter un délai minimum de trois mois[1289] ; ce délai est de six mois dans les baux commerciaux et les baux mixtes (C. civ., art. 1736 red. L. 21 septembre 2006). En matière de contrat de travail, les articles 124-3 à 124-5 du Code du travail définissent la durée du préavis, plus longue lorsque la résiliation émane de l'employeur (de 3 à 6 mois selon l'ancienneté du salarié) que lorsque c'est le salarié qui démissionne (la moitié des délais précédents). Dans les contrats de consommation, une loi du 27 août 2024 vient d'ajouter dans l'article L211-3 du Code de la consommation à la liste des clauses présumées abusives de manière irréfragable « [l]es clauses autorisant le professionnel à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ».

Une seconde limite, beaucoup plus importante, consiste à subordonner la résiliation à certains motifs. Cette exigence est au cœur de la réglementation du licenciement en droit du travail : selon l'article L. 124-11 du Code du travail « Est abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal, le licenciement qui est contraire à la loi ou qui n'est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l'aptitude ou à la conduite du salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ». En l'absence de tels motifs, le salarié aura droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause son licenciement. On retrouve cette exigence de justes motifs dans le cadre du bail : ainsi, en matière de bail d'habitation, le bailleur ne peut mettre fin au bail que s'il veut reprendre les lieux loués pour les

[1287] L. du 3 juin 1994.

[1288] L. du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, art. 74.

[1289] Ce délai est porté à 6 mois pour le bailleur s'il met fin au bail pour habiter [L. 21 septembre 2006, art. 12 (3)].

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

occuper, si le locataire n'exécute pas ses obligations ou si « il existe d'autres motifs graves et légitimes » [L. 21 septembre 2006, art. 12 (2)]. En matière de baux commerciaux, de même, le bailleur ne peut évincer le commerçant locataire que dans des conditions et pour des raisons énumérées par l'article 1762-4 du Code civil. On citera encore l'article L. 224-14 du Code de la consommation, qui prévoit que le prêteur peut mettre fin à tout moment à un contrat de crédit à durée indéterminée « pour des raisons objectivement justifiées ».

Enfin, même motivée, la résiliation peut être accompagnée du versement au contractant évincé d'une indemnité compensatrice, du moins en l'absence d'une faute grave : tel est le système retenu en droit du travail (C. trav., art. L. 124-7) ou dans la loi de 1994 relative aux agents commerciaux (art. 19). Ce ne sont là que des exemples, qui sont développés dans le cadre de l'étude des matières correspondantes, et qui visent simplement à montrer ici les différentes manières dont le droit de résiliation unilatérale peut être encadré par la loi. Ces exemples montrent aussi que cet encadrement peut être (et est le plus souvent) très inégalitaire, les conditions imposées à l'un des contractants pour mettre fin au contrat pouvant être plus strictes que celles qui sont imposées à l'autre, que la réglementation a pour but premier de protéger.

551. Limites de droit commun. Soucieuse de protéger chaque partie contre un changement brutal de la situation contractuelle, la jurisprudence, au Luxembourg comme dans les autres pays du Code civil, exige dans tous les cas, même lorsque cela n'est pas prévu dans la loi, que le contractant qui met fin au contrat respecte un délai de préavis, que les juges fixent au cas par cas en fonction des usages et des circonstances de l'espèce. En France et en Belgique, l'exigence d'un préavis pour la résiliation unilatérale est aujourd'hui généralisée par les textes issus des réformes (C. civ. fr., art. 1211 ; C. civ. be., art. 5.75). Dès 1926, la Cour d'appel tout en admettant qu'un contrat de concession exclusive à durée indéterminée pouvait être résilié unilatéralement, avait réservé le cas où la dénonciation avait été faite « intempestivement »[1290]. De manière plus précise, un arrêt de 1972, relatif au même type de contrat, tire de l'article 1135 du Code civil que en cas de résiliation du contrat par le concédant, « le concessionnaire a droit à des dommages et intérêts, même en l'absence de toute convention lorsque cette résiliation a eu lieu sans

[1290] Cour d'appel, 9 juillet 1926, *Pas.*, 11, p. 246.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

préavis suffisant et en l'absence de motifs graves la justifiant »[1291]. Le même arrêt précise que « le préavis doit être d'une durée telle que le concessionnaire dispose du temps nécessaire pour retrouver, compte tenu des circonstances de fait particulières à l'espèce, une situation équivalente à celle que lui donnait le contrat de concession de vente exclusive résilié ». La solution est constante en jurisprudence[1292]. L'exigence de préavis peut cependant céder (comme c'est d'ailleurs le cas en matière de licenciement) en présence d'une faute grave du contractant.

D'une manière plus générale, l'interdiction de l'abus de droit – qui, comme on l'a vu, est, en matière contractuelle, un aspect particulier de l'exigence de bonne foi – peut également limiter l'exercice du droit de résiliation unilatérale : l'arrêt de la Cour de cassation de 1995 qui affirme ce droit fait expressément réserve de « l'abus sanctionné par l'article 1134 alinéa 3 »[1293]. C'est du reste sur le fondement de l'abus de droit que, au Luxembourg comme en France et en Belgique, la jurisprudence sanctionnait les ruptures sans motif d'un contrat de travail avant que la réglementation du licenciement ne vienne rendre inutile ce recours au droit commun. Même s'il n'a plus qu'un intérêt historique, un arrêt rendu par la Cour d'appel en 1982, à connotation particulièrement sociale, mérite encore d'être signalé à ce propos : la Cour y affirme que « l'exercice par le patron du droit de résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée porte atteinte à l'une des raisons d'être de l'entreprise qui est d'assurer la stabilité de l'emploi. Cet exercice ne peut se justifier qu'en raison de l'intérêt économique de l'entreprise, de sorte que, lorsque le droit de rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est exercé par l'employeur à une autre fin et notamment dans son seul intérêt, il est entaché d'abus »[1294]. En dehors du droit du travail, on peut considérer que c'est la limite de l'abus qui fonde l'interdiction des ruptures brutales et l'exigence d'un préavis[1295]. Au-delà, la jurisprudence luxembourgeoise ne va pas jusqu'à en déduire que la résiliation doit être spécialement motivée : en l'absence de texte, la résiliation unilatérale reste, par principe, une résiliation « *ad nutum* », qui n'est pas en elle-même

[1291] Cour d'appel, 11 juillet 1972, *Pas.*, 22, p. 194.

[1292] Voy. récemment Cour d'appel, 15 décembre 2022, n° CAL-2021-00972 (qui présente l'absence d'un délai raisonnable de préavis comme un cas particulier d'abus de droit.

[1293] Cass., 13 juillet 1995, *Pas.*, 29, p. 433.

[1294] Cour d'appel, 8 janvier 1982, *Pas.*, 25, p. 273.

[1295] Cour d'appel, 15 décembre 2022, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

fautive[1296]. Un arrêt récent de la Cour d'appel rappelle que « la rupture des relations contractuelles peut intervenir sans motivation ou justification de son bien-fondé, hormis les cas où la loi l'exige, comme par exemple en matière de licenciement, sous réserve de l'abus du droit de résilier »[1297]. Mais elle peut devenir abusive par les modalités de sa mise en œuvre (par exemple, si les termes de la lettre de résiliation sont vexatoires ou mensongers). La Cour d'appel a en outre précisé que, en l'absence de motifs particuliers, « la mise en œuvre de cette décision doit s'accompagner du souci de réduire le préjudice causé au partenaire. La méconnaissance de cette modalité expose au paiement de dommages et intérêts »[1298].

B) *Les contrats à exécution successive et à durée déterminée*

552. Terme extinctif. Les parties peuvent, dans les limites fixées par la loi[1299], assigner d'avance une durée à leur relation contractuelle. Le contrat sera conclu pour un certain temps, ou jusqu'à une certaine date. Ce terme dit extinctif est, dans son principe, très différent du terme dit suspensif qui peut être fixé pour l'exécution d'une obligation (par exemple, le délai laissé à un acheteur pour payer le prix de vente)[1300]. Son effet n'est pas de rendre exigible une obligation, mais de mettre fin au contrat, lequel, à l'avenir, n'obligera plus les parties à de nouvelles prestations. Un tel terme extinctif, il faut le remarquer, n'a aucun sens pour les contrats à exécution instantanée, différée ou fractionnée, qui, comme on l'a dit, n'ont pas d'autre fin que le moment de l'extinction des obligations qu'ils font naître. On peut dire qu'un contrat de travail, ou de bail, est conclu pour une durée déterminée. On ne peut pas dire qu'un contrat de vente, même si l'acheteur a 1 an pour payer le prix, qu'il est conclu « pour une durée d'un an ».

[1296] Cour d'appel, 18 novembre 1998, *Pas.*, 31, p. 67.

[1297] Cour d'appel, 15 décembre 2022, préc.

[1298] Cour d'appel, 18 novembre 1998, préc.

[1299] La loi peut, pour assurer la stabilité de certaines relations contractuelles, réglementer la fixation du terme dans certains contrats : ainsi l'article L. 122-1 du Code du travail limite les cas où il est possible de recourir à un contrat de travail à durée déterminée. Un tel contrat « peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et non durable ; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ».

[1300] Sur le terme suspensif comme modalité d'une obligation, voy. *infra*, n[os] 570 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

1) *Situation avant l'arrivée du terme*

553. Situation avant l'arrivée du terme. Les parties sont tenues d'effectuer régulièrement leurs prestations, selon les modalités convenues, jusqu'au terme prévu. Jusqu'à ce terme, le principe de l'irrévocabilité du contrat s'applique pleinement, ce qui veut dire qu'en principe aucune des parties n'a le droit de mettre fin unilatéralement au contrat[1301] : une rupture anticipée serait contraire à la force obligatoire. Le contractant qui met fin au contrat avant le terme encourra alors les sanctions normales de l'inexécution contractuelle[1302]. Il n'en va autrement, comme dans les contrats à exécution instantanée, que si l'une des parties n'exécute pas ses obligations (par exemple, le locataire ne paye pas ses loyers ou dégrade les lieux loués, le salarié fait mal son travail). On trouve application de ces principes pour le contrat de travail : l'article L. 122-13 du Code du travail dispose qu'en principe « le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié avant l'échéance du terme », sauf dans le cas prévu par l'article L. 124-10 du Code du travail d'un « fait ou d'une faute » d'une partie qui « rend définitivement impossible le maintien du contrat de travail », et la rupture anticipée ouvre droit en principe à des dommages et intérêts au profit du salarié comme au profit de l'employeur.

Par exception, la loi peut prévoir la résiliation anticipée d'un contrat qui a été passé pour une durée déterminée. Il s'agit en général de contrats qui reposent sur une relation de confiance particulière entre les contractants. L'application la plus caractéristique concerne le contrat de mandat, pour lequel l'article 2004 du Code civil dispose que « le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble », tandis que l'article 2007 du Code civil permet au mandataire de renoncer au mandat, aucun de ces textes ne distinguant selon que le contrat a été passé à durée déterminée ou indéterminée. De même, l'article 1944 du Code civil prévoit que « le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors-même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ». Ces solutions ont déjà été évoquées au titre du principe d'irrévocabilité du contrat car, à la différence du droit de résiliation

[1301] Pour un rappel de cette solution constante, voy. p. ex. Trib. Luxembourg, 22 juin 2023, n° TAL-2021-09737.

[1302] Il faut cependant observer que les contrats à exécution successive les plus courants (contrat de travail, contrat de bail) se prêtent très mal à une exécution forcée. La partie qui rompt avant le terme sera dès lors généralement condamnée à des dommages et intérêts.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

unilatérale dans les contrats à durée indéterminée, il s'agit de véritables exceptions au principe de la force obligatoire. Ces exceptions sont parfois cependant atténuées par l'obligation qui est faite à celui qui résilie avant terme d'indemniser son cocontractant[1303], ou par la limite de l'abus de droit[1304].

Une clause du contrat peut également permettre à une partie de résilier avant le terme[1305]. Cette clause n'est cependant pas licite dans les contrats de consommation, si c'est au professionnel que la faculté de résiliation est reconnue [C. consomm., art. L. 211-3 (4)].

2) *Situation à l'arrivée du terme*

554. Fin du contrat. En principe, le contrat prend fin automatiquement au terme prévu, sans que les parties aient à exprimer une volonté quelconque[1306]. Cela signifie que, à l'avenir, les parties ne seront plus tenues d'accomplir les prestations objet du contrat : le salarié ne travaillera plus et ne sera plus payé, le locataire quittera les lieux et n'aura plus à payer les loyers, l'abonné ne recevra plus son journal chaque matin ou ne pourra plus téléphoner sur son portable mais il n'aura plus à payer le prix, etc. Cependant, cette « fin » du contrat ne signifie pas nécessairement l'extinction de toutes les obligations qui sont nées du contrat. D'une part, si les prestations qui étaient dues avant le terme n'ont pas toutes été exécutées avant le terme, leur exécution pourra bien sûr encore être exigée après : le locataire qui est en retard dans le paiement des loyers, l'employeur dans le paiement des salaires, restent débiteurs après la fin du contrat des sommes impayées. Le terme extinctif opère ici de la même manière que la résiliation du contrat à durée indéterminée. D'autre part, comme pour les contrats « à exécution instantanée », même si toutes les obligations principales ont été exécutées, le contrat a pu faire naître des obligations accessoires

[1303] Voy. p. ex. l'article 2007 du Code civil en cas de renonciation du mandataire, ou l'article 1794 du Code civil qui permet au maître de l'ouvrage de résilier un marché à forfait, sauf à indemniser l'entrepreneur.

[1304] Voy. ainsi en matière de révocation du mandat Cour d'appel, 9 mars 2011, n° 87256, *BIJ*, 2005, p. 128 qui estime même, à propos d'un mandat rémunéré, que l'abus est présumé, et que c'est au mandant d'établir les motifs légitimes de la révocation. Sur l'ensemble du problème en matière de mandat : P. Santer et P. Gloden, « L'irrévocabilité du mandat, mythe ou réalité », in *Le bicentenaire du Code civil, une contribution luxembourgeoise*, Luxembourg, éd. Portalis, 2008, pp. 391 et s.

[1305] Trib. Luxembourg, 22 juin 2023 ; n° TAL-2021-09737.

[1306] Dans ce sens, p. ex., à propos d'un contrat de location d'un bien mobilier : Cour d'appel, 7 décembre 2011, 35, p. 730.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

qui peuvent subsister bien après la fin du contrat – et qui même, parfois, sont justement prévues pour s'exécuter dans la période précontractuelle : il est fréquent, par exemple, qu'un salarié contracte une obligation de non-concurrence (ou de non rétablissement) qui lui interdit, pendant une certaine période après la fin de son contrat de travail, de se faire réembaucher dans un certain cercle spatial par un employeur concurrent. C'est dire que, si le contrat ne peut plus générer de nouvelles obligations après le terme, il conserve toute sa force obligatoire pour les obligations qui sont nées avant le terme.

555. Prolongation de la durée du contrat. Il arrive fréquemment qu'une relation contractuelle, conçue à l'origine pour durer une certaine période se prolonge au-delà du terme fixé. Cette prolongation peut prendre différentes formes, qui sont distinguées dans les nouveaux textes français et belge. Il se peut d'abord que les parties conviennent de repousser le terme prévu à l'origine. C'est ce que le nouvel article 1213 du Code civil français et l'article 5.77 du nouveau Code civil belge appellent la « prorogation » du contrat. On reste alors dans le cadre du contrat initial, dont seul le terme extinctif est modifié. Les articles 1214 du Code civil français et 5.78 du Code civil belge distinguent cette situation du renouvellement du contrat, prévu par la loi ou décidé par les parties, qui consiste dans la conclusion d'un nouveau contrat, identique au précédent, mais à durée indéterminée. Le plus souvent, ce renouvellement ne sera pas décidé expressément par les parties, il résultera du fait qu'elles continuent d'exécuter les prestations contractuelles après le terme[1307]. C'est ce qu'on appelle la tacite reconduction du contrat (C. civ. fr., art. 1215). Cette tacite reconduction est parfois expressément prévue par la loi. Ainsi, en matière de bail non commercial d'un bien immobilier, l'article 1738 du Code civil dispose que, si « à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit »[1308]. Très souvent, la reconduction automatique est prévue par le contrat lui-même, qui définira alors à quelles conditions le contrat se poursuivra au-delà du terme, notamment en précisant comment et combien de temps avant le terme la partie qui désire mettre fin au contrat devra manifester sa volonté.

[1307] Trib. Luxembourg, 18 novembre 2016, *Pas.*, 38, pp. 445 et s.

[1308] Le bail ne prendra fin que si le locataire décide de partir, ou que si le bailleur veut mettre fin au bail, ce qu'il ne peut faire que dans des cas très limités [L. du 21 septembre 2006 sur le contrat de bail d'habitation, art. 12(1)]. À défaut, selon ce texte, le bail est prorogé.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Qu'elle soit d'origine légale ou conventionnelle, la nature et les effets de la tacite reconduction suscitent de nombreuses difficultés. La question présente de nombreux intérêts, notamment quant au point de savoir si les garanties qui assortissaient le contrat initial sont maintenues, ou si la prescription de l'action en nullité repart à zéro. La Cour de cassation française avait décidé que la tacite reconduction n'était pas une prorogation du contrat primitif mais qu'elle donnait naissance à un nouveau contrat en principe à durée indéterminée[1309], et cette solution a été consacrée par le nouvel article 1215 du Code civil français ainsi que par l'article 5.78 du Code civil belge. Telle est aussi la solution suivie par la jurisprudence luxembourgeoise[1310]. C'est la solution que prévoit expressément l'article 1738 du Code civil pour le bail d'immeuble, mais les parties peuvent cependant prévoir une reconduction pour la durée du contrat initial[1311]. Lorsque la reconduction est prévue par une clause, celle-ci prévoit en général si le contrat se poursuit sans limitation de durée[1312] ou s'il est reconduit pour la même durée que la précédente.

Ces clauses de tacite reconduction peuvent être dangereuses car très souvent un contractant laissera passer sans s'en rendre compte le délai assigné pour mettre fin au contrat, et se trouvera engagé sans l'avoir voulu pour une nouvelle période. C'est pourquoi le Code de la consommation interdit, au titre de la protection contre les clauses abusives, les clauses d'un contrat de consommation « selon lesquelles le contrat est prorogé pour une durée supérieure à un an si le consommateur ne le dénonce pas à une date déterminée » [C. consomm., art. L. 211-3 (9)]. La directive de 1993 sur les clauses abusives prévoit quant à elle, mais sans en faire une obligation pour les états, que peut être déclarée abusive une clause ayant pour objet ou pour effet « de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur »[1313]. Le droit français impose quant à lui aux professionnels prestataires de services d'informer le consommateur au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le

[1309] Voy. p. ex. Cass. fr. (1re civ.), 17 juillet 1980, n° 79-11869.

[1310] Trib. Luxembourg, 18 novembre 2016, *Pas.*, 38, pp. 445 et s. Trib. Luxembourg, 12 juillet 2017, n° 178153 ; Trib. Luxembourg, 3 juillet 2019, n° TAL-2018-06543 ; Trib. Luxembourg, 25 janvier 2021, n° TAL-2020-07954.

[1311] Cour d'appel, 7 décembre 2011, préc., qui transpose la solution à la location d'un bien meuble, tout en précisant que les parties peuvent stipuler une reconduction pour une durée déterminée.

[1312] C'est en particulier la pratique des opérateurs de téléphonie mobile : une fois écoulée la période d'abonnement, le contrat se poursuit sans limitation de durée, ce qui permet alors à l'utilisateur de mettre fin à son abonnement à tout moment.

[1313] Dir. n° 93/13 du 5 avril 1993 modifiée par directive 2011/83 du 25 octobre 2011, Annexe point h.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite (C. consomm. fr., art. L. 136-1).

556. Absence de reconduction. La reconduction ou le renouvellement du contrat n'est pas en principe un droit pour les contractants : en l'absence de clause prévoyant la reconduction tacite, le contrat prend fin automatiquement si une des parties refuse de continuer le contrat ; et, même si la reconduction tacite est prévue, chaque partie peut en principe manifester sa volonté contraire, et s'opposer au renouvellement, en respectant le délai de préavis prévu par la loi ou par la clause. Imposer le renouvellement du contrat à la fin de la période prévue reviendrait à enfermer les parties dans une relation contractuelle perpétuelle, ce qui, on l'a vu, n'est pas possible. Cependant, les mêmes raisons qui ont poussé le législateur à encadrer dans de nombreux contrats le droit de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée, l'ont amené à poser des limites au droit de refuser le renouvellement de certains contrats à durée déterminée, lorsque ceux-ci présentent une importance particulière pour la vie d'un des contractants. C'est le cas notamment du contrat de bail : en matière de bail d'habitation, l'article 12 de la loi du 21 septembre 2006 prévoit que tout contrat de bail (y compris les baux à durée déterminée) qui « vient à cesser pour n'importe quelle cause » (donc en particulier par l'arrivée du terme) est « prorogé à durée indéterminée »[1314] en dehors des cas limités où la loi permet au bailleur d'y mettre fin ; en matière de baux commerciaux, le commerçant a en principe droit au renouvellement de son bail pendant 15 ans (C. civ., art. 1762-4).

En dehors de ces cas prévus par les textes, la jurisprudence française admet que, dans les contrats de distribution et de concession commerciale, le refus de renouvellement peut constituer un abus de droit, ce qui confine parfois à un contrôle des motifs de la rupture de la relation. Cette jurisprudence trouve un prolongement dans l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce français qui sanctionne le fait de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie », ce qui peut viser en particulier le fait de refuser de renouveler un contrat. Ces solutions, cependant, ne trouvent pour l'instant aucun équivalent au Luxembourg.

[1314] La précision « à durée indéterminée » a été ajoutée par une loi du 23 juillet 2024.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

SECTION 3. LA CADUCITE DU CONTRAT

557. Notion de caducité. On parle de caducité pour désigner la fin d'un contrat, valable à l'origine, par suite de la disparition ultérieure d'un des éléments essentiels. Un exemple typique est fourni par l'article 1722 du Code civil, qui, même s'il n'emploie pas le terme, prévoit que « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ». La notion de caducité se distingue de la nullité du contrat, en ce qu'elle atteint un contrat qui était supposé valable au moment de sa formation[1315]. Elle se distingue également de la résolution du contrat, qui sanctionne l'inexécution par une des parties de ses obligations ; la caducité atteint le contrat indépendamment de toute inexécution[1316]. Pour la même raison, et bien que l'article 1722 pris comme illustration de départ utilise ce terme, la caducité ne se confond pas avec la résiliation du contrat : ce terme en effet désigne soit un cas particulier de résolution pour inexécution (lorsque le contrat est à exécution successive), soit la décision unilatérale d'une partie de mettre fin à un contrat (ce qui, on l'a vu, est un droit lorsque le contrat est à exécution successive et à durée indéterminée). Or la caducité, qui n'est liée ni à une inexécution du contrat, ni à la volonté d'un contractant, ne correspond ni à l'une ni à l'autre hypothèse. La caducité semble se rapprocher davantage de la force majeure, qui, nous le verrons, entraîne la résolution ou la résiliation du contrat dont elle rend l'exécution impossible. Cependant, si elles se recoupent parfois, la caducité a un domaine d'application plus large que la force majeure : elle ne suppose pas que l'événement à l'origine de la disparition de l'élément essentiel ait été imprévisible et irrésistible (caractéristiques de la force majeure), ni, surtout, que cette disparition rende l'exécution du contrat techniquement impossible. Dans certains cas, la caducité sera admise parce que le contrat a perdu sa raison d'être. Bien que la notion n'ait été présente dans le Code civil de 1804 que dans quelques textes spéciaux[1317], elle a été assez tôt utilisée en jurisprudence en dehors de ces hypothèses, et, dans la période récente, elle a fait l'objet de systématisations doctrinales en France et en Belgique. Elle a été introduite en 2016 dans le Code civil français, qui lui consacre deux articles, les articles 1186 et 1187 (curieusement placés après les textes sur la nullité, au sein

[1315] Cour d'appel, 22 février 2024, n° CAL-2021-00898.

[1316] Trib. Luxembourg, 19 avril 2024, n° TAL-2023-07066.

[1317] Voy. les articles 1039, 1040, 142 et 1043 du Code civil sur la caducité des testaments.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

du chapitre relatif à la formation du contrat). On la retrouve dans le nouveau Code civil belge, aux articles 5.113 et 5.265, qui ne la consacrent cependant que dans le cas de disparition de l'objet du contrat. La notion est également connue de la jurisprudence luxembourgeoise, dont les solutions révèlent de nombreuses incertitudes tant quant aux causes de caducité (**§ 1**) que quant à ses effets (**§ 2**).

§ 1. Causes de caducité

558. Distinction. Les décisions luxembourgeoises utilisent la notion de caducité dans deux séries d'hypothèses. Dans certains cas, la caducité est liée à un élément interne au contrat considéré (**A**), dans d'autres elle est la conséquence de l'anéantissement d'un autre contrat avec lequel le contrat considéré est en situation d'interdépendance (**B**). Cette distinction correspond aux deux cas de caducité aujourd'hui visés par l'article 1186 du Code civil français.

A) *Caducité liée à un élément interne au contrat*

559. Disparition d'un élément essentiel. C'est l'hypothèse visée par le premier alinéa du nouvel article 1186 du Code civil français. Elle vise en tout premier lieu le cas où l'objet de la convention disparaît en cours d'exécution du contrat, de sorte que le contrat ne peut plus être exécuté. C'est le seul cas envisagé par le nouveau Code civil belge, aux articles 5.265 et 5.113. Outre le cas déjà cité de l'article 1722 du Code civil, on rencontre quelques applications de cette caducité par disparition de l'objet dans la jurisprudence luxembourgeoise : ainsi, devient caduque par suite de la disparition de son objet une donation au conjoint survivant faite par contrat de mariage de l'usufruit de toutes les propriétés immobilières du prémourant, dès lors qu'au jour du décès, il n'existait plus dans le patrimoine du défunt aucune propriété immobilière[1318]. On remarquera cependant que cette hypothèse se recoupe largement avec d'autres mécanismes d'anéantissement du contrat : la résolution pour inexécution si la disparition de l'objet est due à la faute d'un contractant, la force majeure si elle en est indépendante. C'est pourquoi du reste le nouveau Code civil belge ne traite ce cas que comme une cause d'extinction de l'obligation ayant cet objet, l'article 5.113 disposant que cette caducité n'entraîne la disparition du contrat lui-même que si on se trouve dans un des cas généraux d'extinction du contrat (dont, précisément

[1318] Trib. Diekirch, 16 juin 2024, n° TAD-2021-01280.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la force majeure ou la résolution pour inexécution). La notion de caducité paraît avoir davantage de consistance dans d'autres cas. On peut ainsi parler de caducité lorsqu'un contrat *intuitu personae* prend fin par suite du décès d'une des parties contractantes – ainsi dans le cas prévu par l'article 2003 du Code civil qui prévoit que « le mandat finit » par la mort du mandant ou du mandataire. La question la plus délicate est de savoir si on peut envisager des cas de caducité du contrat par suite de la disparition de sa cause. *A priori* la réponse paraît devoir être négative, dans la mesure où, comme le rappellent fréquemment les tribunaux luxembourgeois, l'existence ou l'absence de la cause s'apprécient au moment de la conclusion du contrat[1319]. S'agissant de la cause objective, si la contrepartie attendue n'est pas fournie le contrat pourra être anéanti par le mécanisme de la résolution du contrat. Et, s'agissant de la cause subjective, il faut rappeler que le principe est que l'erreur sur les motifs n'est pas une cause de nullité du contrat, *a fortiori* ne devrait-elle pas être une cause de caducité si les éléments ayant motivé la conclusion du contrat disparaissent *a posteriori*. Cependant, en matière de libéralités, la jurisprudence française a parfois admis la caducité d'une disposition à titre gratuit lorsque la situation ou l'état de fait qui a déterminé la volonté du disposant disparaît postérieurement à la date de l'acte[1320] et cette position a pu être relayée dans la jurisprudence luxembourgeoise[1321]. On pourrait songer à étendre cette solution aux actes à titre onéreux lorsque les raisons qui ont justifié la conclusion du contrat sont entrés dans le champ contractuel et que l'événement postérieur fait, au regard de ces raisons, perdre tout intérêt au contrat. C'est l'hypothèse déjà évoquée de la location d'appartement pour assister à un événement ultérieurement annulé (« *coronation case* »). Ce type de situation, que la notion allemande de « disparition du fondement contractuel » (*Wegfall der Geschäftsgrundlage*) permet de prendre en compte, pourrait avantageusement être traité, en droit luxembourgeois, par l'utilisation de la notion de caducité[1322].

[1319] Cour d'appel, 9 juillet 2003, n° 27411 ; Trib. Luxembourg, 19 avril 2024, n° TAL-2023-07066.

[1320] Cass. fr. (1re civ.), 30 octobre 2008, n° 07-17.64 (caducité d'une reconnaissance de dette prévoyant le paiement par l'ex-époux à son ex-épouse de la pension alimentaire destinée à assurer l'éducation et l'entretien de leur fils disparaît à partir du moment où l'enfant est à la charge exclusive de son père).

[1321] Cour d'appel, 1er décembre 2004, n° 28616, qui s'appuie aussi sur des citations de la doctrine belge. La décision écarte cependant la solution pour le testament au motif qu'il incombe en principe au testateur de veiller lui-même à la révocation de son testament.

[1322] On pourrait aussi traiter ce type de situations sur le terrain de l'imprévision, voy. *supra*, nos 508 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

560. Défaillance d'une condition suspensive. Dans la jurisprudence luxembourgeoise, c'est surtout à propos des cas de défaillance d'une condition suspensive que la notion de caducité est régulièrement utilisée. Dans un arrêt de 2020, la Cour de cassation a ainsi jugé que la caducité d'un compromis de vente conclu entre deux parties par l'effet de la défaillance de la condition suspensive qui s'impose aux parties et aux tiers a pour conséquence que les obligations prévues au compromis de vente, dont fait partie le paiement d'une commission à l'agent immobilier par l'acquéreur initial, sont censées n'avoir jamais pris naissance[1323]. Cette référence à la caducité se retrouve dans de nombreuses décisions[1324]. Cette utilisation de la notion de caducité est cependant aujourd'hui critiquée dans la doctrine française, au motif qu'elle ne correspond pas à la disparition d'un élément essentiel du contrat[1325]. On voit cependant assez mal quelle autre qualification pourrait convenir à une telle situation. La formule utilisée par le nouvel article 1304-6 du Code civil français selon lequel « [e]n cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé », ne semble pas incompatible avec la qualification de caducité.

B) *Caducité liée à une situation d'interdépendance contractuelle*

561. Groupes de contrats, ensembles contractuels, interdépendance contractuelle. Dans le nouveau droit français des obligations, le deuxième alinéa de l'article 1186 du Code civil traite d'un cas particulier de caducité. Selon ce texte : « Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. » Ce texte apparaît comme l'aboutissement d'une construction doctrinale et jurisprudentielle développée en France depuis les années 1970, et qui avait été reçue par la jurisprudence luxembourgeoise. Dans un article souvent cité de 1978, un auteur français remarquait que « la théorie classique a traité le contrat comme un continent superbement isolé alors qu'il

[1323] Cass., 11 juin 2020, n° 84/20200.

[1324] Voy. p. ex. Cour d'appel, 26 septembre 2019, n° 44976 ; Cour d'appel, 3 juillet 2024, n° CAL-2023-00439. Cour d'appel, 26 juin 2024, n° CAL. 2023-00122, *JN Obligations*, 2024, n° 3, pp. 191-193, note H. WESTENDORF.

[1325] D. HOUTCIEFF, *Droit des contrats*, 8e éd., Bruxelles, Bruylant, n° 594-2.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

peut n'être que l'île d'un archipel animé d'une vie collective »[1326]. Cet article faisait écho à la thèse soutenue quelques années plus tôt par Bernard Teyssié sur « les groupes de contrats[1327], qui mettait en évidence les différents types de liens pouvant exister entre des contrats. On peut, sans souci d'exhaustivité, et en reprenant sommairement certaines classifications proposées par cet auteur, distinguer des groupes « verticaux » et des groupes « horizontaux ». Les premiers sont constitués de contrats qui se succèdent pour la réalisation d'une opération économique : qu'il s'agisse de contrats successifs qui permettent la circulation d'une chose (ventes successives d'un bien par le producteur au grossiste, par le grossiste au distributeur qui le revend au consommateur final, vente d'un produit à un entrepreneur qui l'incorpore ensuite dans un ouvrage qu'il est chargé de réaliser, vente d'un matériel à une société financière qui le loue ensuite en leasing à un utilisateur, etc.) ou de contrats par lesquels une personne chargée de l'exécution d'un travail (entrepreneur, mandataire, etc.) en confie à son tour l'exécution à un tiers (sous-traitance). Mais les contrats peuvent aussi constituer un ensemble horizontal, lorsque plusieurs contrats sont passés avec des prestataires différents pour la réalisation d'une même opération (contrats passés avec différentes entreprises pour la construction d'un immeuble, par exemple) ou lorsque, pour assurer l'exécution d'un contrat principal, on lui adjoint un contrat accessoire (constitution d'une sûreté, cautionnement, contrat d'entretien ou de service après-vente passé en complément de l'acquisition d'un bien, etc.).

Les effets que le droit positif peut attribuer aux contrats liés à l'intérieur de ces groupes ou ensembles contractuels se déploient sur différents terrains assez différents. Dans les années 1970, la théorie des groupes de contrats a été surtout utilisée pour tenter de justifier certaines atteintes au principe de l'effet relatif des contrats notamment l'extension de certaines clauses figurant dans un des contrats aux autres contrats du même ensemble[1328], et surtout la reconnaissance d'actions directes contractuelles entre les différentes parties aux contrats concernés : alors que, en principe, un

[1326] M. Cabrillac, « Remarques sur la théorie générale des contrats et les créations récentes de la pratique commerciale », in *Mélanges dédiés à Gabriel Marty*, Toulouse, Université des sciences sociales, 1978, pp. 235 à 254, p. 248.

[1327] B. Teyssié, *Les groupes de contrats*, Paris, LGDJ, 1975, p. 328. Pour le droit belge, voy. P.-A. Foriers, *Groupes de contrats et ensembles contractuels : Quelques observations en droit positif*, Bruxelles et Paris, De Boeck, Larcier et LGDJ, 2006, p. 189.

[1328] Voy. p. ex. pour une clause compromissoire : Cass. fr. (1re civ.), 30 mars 2004, nº 01-14.311.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

contrat ne fait naître de droits et d'obligations qu'entre les parties, il y aurait lieu, dans le cadre des groupes de contrats, d'étendre aux parties à un des contrats du groupe les droits et obligations nés de ces autres contrats, comme si les parties à chaque contrat du groupe étaient, dans une certaine mesure, parties à l'ensemble. Cela justifierait en particulier que l'action en réparation des dommages subis par une de ces parties du fait de l'inexécution d'un autre contrat du groupe soit traitée comme une action en responsabilité contractuelle, et non délictuelle comme le principe de l'effet relatif le commanderait[1329]. Cette utilisation de la notion de groupes de contrats est aujourd'hui abandonnée en France, mais la notion a ressurgi sur un autre terrain, qui nous intéresse directement ici, et dans lequel s'inscrit le nouvel article 1186 français. Il s'agit ici de répercuter sur les différents contrats du groupe les incidences des événements qui affectent un de ses éléments : si l'un des contrats du groupe est anéanti (par l'effet d'une annulation ou d'une résolution), cela peut priver de tout intérêt les autres contrats qui lui sont liés, qui en dépendent, et, par une sorte d'« effet domino », entraîner leur anéantissement. Cet anéantissement « réflexe » prend alors la forme d'une caducité. Dès avant la réforme de 2016, et la consécration de cette idée dans le nouvel article 1186, ce type de solutions avait été largement consacré par la jurisprudence française, et les tribunaux luxembourgeois avaient suivi. Pour justifier ce type de solutions, on avait parfois eu recours, avant 2016, à des notions classiques du droit des obligations. On considérait notamment que chacun des contrats était la cause de l'autre ou des autres, par une des utilisations extensives de la notion de cause dont le droit français était coutumier avant que cette notion ne soit effacée du code. On utilisait aussi la notion d'indivisibilité entre les contrats, en lui donnant un autre sens que celui visé à l'article 1217 (aujourd'hui en France 1320 et suivants) à propos de l'indivisibilité des obligations[1330]. Ces solutions ont par ailleurs constitué un des éléments de la théorie des groupes de contrats, mais aujourd'hui on en rend plutôt compte à travers la notion d'interdépendance contractuelle, pour marquer que, dans un groupe, les différents contrats peuvent dépendre les uns des autres. Ces différents fondements se retrouvent dans la jurisprudence luxembourgeoise.

[1329] Sur cette problématique, voy. *infra*, n°s 1111 et s.

[1330] Sur l'indivisibilité, voy. *infra*, n°s 631 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

562. Conditions de la caducité liée à l'interdépendance. Il ne suffit pas de constater que plusieurs contrats font partie d'un même groupe ou ensemble pour en déduire que l'anéantissement de l'un se répercute sur les autres. La caducité liée à l'interdépendance contractuelle suppose la réunion de conditions bien précises. Un jugement du Tribunal de Luxembourg de 2017, longuement motivé et largement appuyé sur la doctrine et la jurisprudence françaises, fait état de ces conditions[1331]. Le tribunal pose au départ que « [l]'interdépendance contractuelle est la caractéristique d'un ensemble de contrats dont l'imbrication des prestations donne naissance à l'opération globale voulue par les parties, de telle sorte que l'opération globale ne peut pas se réaliser si un seul des contrats fait défaut et que, réciproquement, chaque contrat perd sa raison d'être en cas d'échec de l'opération globale. Les groupes de contrats correspondent à la situation dans laquelle deux ou plusieurs contrats sont consciemment liés entre eux de telle sorte que les événements affectant l'un sont susceptibles d'avoir un effet sur les autres. Le plus souvent le groupe de contrats est composé de contrats conclus entre différentes personnes lesquelles concourent à la réalisation d'une finalité économique commune : il s'agit alors d'un ensemble de contrats soudés par une identité de cause dont témoignent les ventes avec prêt ou le crédit-bail ». Le tribunal introduit ensuite une distinction – également reprise de la doctrine et de la jurisprudence française entre l'indivisibilité subjective des différents contrats (liée à la volonté des parties de considérer les contrats comme un tout indissociable), et l'indivisibilité objective (lorsque les prestations des différents contrats ne pourraient se concevoir séparément). Le tribunal estime que « pour justifier des conséquences aussi importantes que l'anéantissement en cascade de contrats, la poursuite d'un objectif économique commun, même si elle constitue l'indice de leur éventuelle association dans l'esprit des parties, n'est pas suffisante », et que « la notion de cause ne peut, sous le qualificatif de cause globale du contrat ou d'un groupe de contrats, servir de fondement à l'anéantissement en cascade des contrats de ce groupe. Seule la prise en considération de la volonté commune des parties en ce sens peut justifier une telle solution », cette volonté étant appréciée souverainement par les juges du fond[1332]. On reconnaît dans cette décision les

[1331] Trib. Luxembourg, 16 mai 2017, n° 177100.

[1332] Voy. déjà Trib. Luxembourg, 17 mars 2015, n[os] 141.076, 150.669, 150.670, 151.551 et 151.552.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

différentes notions mises en avant en France pour rendre compte des solutions (interdépendance, groupes de contrats, indivisibilité, cause…).

Cette position, qui met en avant la recherche de la volonté des parties, connaît cependant une exception, toujours décalquée de la jurisprudence française. Dans la période récente, la Cour de cassation avait en effet posé une règle spécifique pour les contrats s'inscrivant dans le cadre d'une opération incluant une location financière : ces contrats sont considérés de droit comme interdépendants, de sorte que l'anéantissement de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité des autres[1333]. Par exemple, une personne se procure un bien auprès d'un fournisseur, qui s'engage à en assurer la maintenance. Mais au lieu d'acheter elle-même ce bien, elle le prend en location de longue durée auprès d'un établissement de crédit qui l'achète au fournisseur à cette fin. Si un problème survient dans les relations entre le fournisseur et l'utilisateur, et que le contrat passé avec celui-ci est résolu ou résilié, cela fera tomber nécessairement le contrat de location. Il en va ainsi sans que la volonté des parties soit prise en compte, toute clause prévoyant le maintien des contrats autres que celui qui a été anéanti étant, selon la Cour de cassation, réputée non écrite. Cette position a été fidèlement suivie tant par le tribunal de Luxembourg que par la Cour d'appel[1334]. Dans un arrêt de 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre un arrêt qui avait suivi ce raisonnement, en estimant que l'interdépendance contractuelle était vérifiée tant sur base du concept de l'indivisibilité subjective que sur celui de l'indivisibilité objective[1335].

On peut se demander si cette jurisprudence, élaborée en décalque de la jurisprudence française antérieure à la réforme, subsistera au regard du nouveau texte français. Dans celui-ci, en effet, dès lors que l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, la caducité se produit dans deux cas, d'une part pour « les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition » (critère purement objectif), d'autre part pour « ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu

[1333] Cass. fr. (ch. mixte) 17 mai 2013, n°s 11-22.768 et 11-22.927 ; Cass. fr., (2e civ.), 2 juillet 2020, n° 17-12.611 P.

[1334] Trib. Luxembourg, 16 mai 2017, préc. Cour d'appel, 10 mars 2021, n° CAL-2019-00458.

[1335] Cass., 10 juillet 2018, n° 79/2018, n° 3986, *JN Obligations*, 2020, n° 1-2, pp. 85-92, note O. POELMANS.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

était une condition déterminante du consentement d'une partie ». Dans ce deuxième cas, il importe peu que les conventions soient matériellement exécutables indépendamment les unes des autres, dès lors que la commune intention des parties est de les rendre interdépendantes. Cependant, dans tous les cas, selon l'article 1186, la caducité ne peut intervenir « que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ».

§ 2. Effets de la caducité

563. Mise en œuvre. Une première question est de savoir si la caducité est automatique ou doit être prononcée par le juge. Discutée en France[1336], la solution n'est pas très claire dans la jurisprudence luxembourgeoise. Dans un arrêt de 2020, la Cour d'appel a jugé que, tout comme la nullité, « la caducité n'est pas un état de l'acte qui se déclenche automatiquement, dès lors que ses conditions sont remplies. La partie intéressée pourra seulement se prévaloir d'une caducité qui sera, ou non, admise par le juge »[1337]. Mais, à l'inverse, une décision de 2024 juge, à propos de la caducité résultant de la défaillance d'une condition suspensive que « le contrat devient caduc sans qu'il soit nécessaire que les parties constatent cette caducité. La défaillance de la condition suspensive entraîne en effet de plein droit l'effacement du contrat et ce indépendamment de la volonté des parties »[1338]. Les formules du nouvel article 1186 du Code civil français semblent plutôt plaider en faveur du caractère extrajudiciaire de la caducité, laquelle peut de toute façon être contestée en justice par celui qui veut que le contrat soit maintenu. En toute hypothèse, dans le cas particulier (mais le plus important en pratique) de la caducité liée à l'interdépendance contractuelle, l'intervention préalable du juge est en principe nécessaire au préalable pour prononcer la nullité ou la résolution du premier contrat dont l'anéantissement entraîne la caducité de l'autre. Suivant en cela la position de la jurisprudence française, la Cour d'appel a posé que « pour que la location financière soit caduque, encore faut-il que la résolution du contrat principal, en l'occurrence le contrat de

[1336] Voy. Houtcieff, n° 596.
[1337] Cour d'appel, 2 juillet 2020, n° CAL-2019-00550.
[1338] Cour d'appel, 3 juillet 2024, n° CAL-2023-00439.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

fourniture du matériel soit acquise, sa seule inexécution n'étant pas suffisante pour obtenir la caducité par ricochet du contrat qui lui est lié »[1339].

564. Caractère rétroactif ou non. La notion de caducité évoque traditionnellement une disparition du contrat seulement pour l'avenir[1340], et la formule du nouvel article 1187 du Code civil français, « [l]a caducité met fin au contrat » semble aller dans ce sens. En réalité, tout dépend du type de contrat auquel on a affaire et il paraît opportun de transposer les solutions admises pour la résolution du contrat. Si on est en présence d'un contrat « à exécution successive », dans lequel les prestations peuvent être divisées dans le temps, la caducité mettra fin au contrat seulement pour l'avenir (comme s'il y avait résiliation). En revanche, la caducité devrait avoir un effet rétroactif pour les contrats « à exécution instantanée », dans lequel les prestations sont indivisibles dans le temps.

[1339] Cour d'appel, 10 mars 2021, préc., citant Cass. fr. (comm), 4 novembre 2014, n° 13-24.270 P. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation française a cependant précisé qu'une résiliation unilatérale du contrat de fourniture était suffisant pour entraîner la caducité du crédit-bail (Cass. fr. (comm.), 5 février 2025, n° 23-14.318).

[1340] Dans ce sens : Cour d'appel, 2 juillet 2020, n° CAL-2019-00550.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La durée du lien obligatoire, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 657-686
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

565. Diversité des obligations contractuelles. Tout contrat, au sens strict, fait naître des obligations. Même si on admet que cette naissance d'obligations ne s'identifie pas à la force obligatoire du contrat – qui s'applique aussi à tous les effets non obligationnels du contrat – l'étude des obligations contractuelles est indissociable de celle du contrat, dont elles constituent le contenu le plus caractéristique. Ces obligations qui peuvent naître d'un contrat sont extrêmement diverses : au-delà de la classification sommaire – et très contestable – qu'en fait l'article 1101 du Code civil en obligations de faire, de ne pas faire, et de donner[1341], il est impossible de rendre compte ici de l'immense variété des prestations et des abstentions dont un contractant peut assumer la charge envers un autre. Pour n'en donner qu'une toute petite idée, cela va de l'obligation de livrer une chose à celle de ne pas faire concurrence à l'autre, en passant pas l'obligation de délivrer certains renseignements, de construire une maison, de veiller à la conservation d'une chose dont on a la garde, de restituer une somme qu'on vous a prêtée, de tenter de concilier deux parties en litige, de payer une somme à la place d'un débiteur défaillant, de gérer un patrimoine, etc. L'étude du contenu, de l'étendue, des sanctions spécifiques de ces différentes obligations ne peut être faite que dans le cadre de l'étude des règles spéciales aux différents contrats, habituellement faite dans les cours et ouvrages dits de « contrats spéciaux » ou relatifs à tel ou tel contrat en particulier (la vente, le bail, le mandat, etc.). Tel n'est pas, il faut le rappeler, l'objet du présent ouvrage.

566. Règles générales applicables aux obligations contractuelles. Dans le cadre d'un ouvrage consacré au droit commun des contrats, il ne peut être question que de faire l'étude des règles générales applicables à toutes les obligations contractuelles, quel qu'en soit l'objet. Ces règles ont elles-mêmes un domaine d'application plus ou moins général. Certaines sont spécifiques aux obligations nées d'un contrat, et trouvent naturellement leur place dans un ouvrage de droit des contrats : tel est le cas des règles relatives aux sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles qui, soit par les conditions de leur mise en œuvre, soit par leurs effets, sont directement dans le prolongement de la force obligatoire du contrat. Mais d'autres règles ont un domaine d'application plus général, en ce qu'elles ont vocation à s'appliquer à toutes les obligations,

[1341] Voy. *supra*, n°s 52 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
[Introduction], Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 689-691
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

quelle qu'en soit leur source – qu'elles soient nées d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un fait générateur de responsabilité extra-contractuelle, etc. Telles sont par exemple les règles relatives à l'exécution ou aux modes d'extinction des obligations. Bien que les rédacteurs du Code civil les aient mêlées aux règles spécifiques au contrat, cette présentation est souvent regardée comme une faute de logique, et l'habitude s'est prise, dans les pays du code civil, de les étudier de manière séparée, au sein de cours ou de manuels consacrés au « régime général de l'obligation »[1342]. Cette tradition académique a été reprise dans les nouveaux textes du droit des obligations en France et en Belgique, qui traitent séparément des sources des obligations » (dont le contrat), et du « régime général de l'obligation ». Comme on l'a déjà dit, le choix a été fait, dans le présent manuel, de ne pas se limiter aux règles spécifiques aux obligations contractuelles, et d'intégrer, au sein de cette partie relative aux effets du contrat, les règles du « régime général »[1343]. La raison en est que, dans la pratique, ces règles s'appliquent beaucoup plus souvent aux obligations contractuelles qu'à celles qui dérivent d'une autre source, et que, en retour, certains aspects de la problématique spécifique aux contrats sont difficilement compréhensibles sans une connaissance des règles du régime général. Certaines questions sont en outre intimement mêlées, de sorte qu'il s'avère difficile de les séparer : par exemple, la question de savoir si on peut contraindre un débiteur à exécuter en nature son obligation, qui se pose en théorie pour toutes les obligations, est tout à fait centrale lorsqu'on traite des sanctions de l'inexécution du contrat. Du reste, la comparaison des deux réformes récentes en France et en Belgique montre que la répartition des deux types de règles n'a pas été opérée de la même manière dans les deux pays, le droit belge ayant, d'une manière générale, renvoyé davantage de questions à la partie « régime général » (ce qui dénote une certaine

[1342] En France cette tradition est suivie par tous les auteurs de manuels récents à l'exception de Fabre-Magnan qui incorpore les règles du régime général au sein des règles spécifiques aux contrats. En Belgique, la tradition est la même, au moins chez les auteurs de langue française : P. Wéry ne traite que des obligations contractuelles (le régime général de l'obligation devant faire l'objet d'un autre volume ; P. Van Ommeslaghe consacre deux volumes séparés séparés au contrat et au régime général. La répartition des questions dans l'une ou l'autre catégorie n'est cependant pas la même chez tous les auteurs : en France, J. Flour, J.L. Aubert, E. Savaux traitaient traditionnellement dans le cadre du régime général de nombreuses questions spécifiques aux obligations contractuelles (résolution, responsabilité contractuelle, etc.), mais cette présentation a été abandonnée dans les dernières éditions.

[1343] C'est aussi la présentation suivie en France par M. Fabre-Magnan, et, au Luxembourg, par O. Poelmans.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
[Introduction], Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 689-691
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

influence de la pensée juridique allemande). L'étude conjointe des deux séries de règles permet donc de donner une vue plus réaliste du mécanisme contractuel – même si les dimensions réduites assignées à cet ouvrage ne permettront de donner des règles du régime général qu'une vue plus superficielle.

567. Plan suivi. Les obligations contractuelles seront d'abord envisagées dans leur aspect statique, à travers leurs modalités (**Chapitre I**). On verra ensuite la manière dont elles s'exécutent (**Chapitre II**), puis les sanctions de leur inexécution (**Chapitre III**). Enfin, on examinera leurs différentes causes d'extinction (**Chapitre IV**)[1344]. Seul le chapitre III relatif aux sanctions de l'inexécution est (en grande partie) spécifique aux obligations contractuelles ; les autres chapitres valent, sous réserve d'indications contraires sur tel ou tel point, pour toutes les obligations quelles qu'en soient les sources[1345].

[1344] Les règles relatives à la transmission des obligations (et plus généralement au changement de créancier ou de débiteur dans le rapport d'obligation, seront étudiées dans le Titre II relatif aux effets du contrat à l'égard des tiers).

[1345] Les étudiants de l'Université du Luxembourg, où on suit la tradition de la séparation entre le droit des contrats et le régime général de l'obligation, peuvent donc, dans le cadre du premier cours, passer directement au chapitre III.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
[Introduction], Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 689-691
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Chapitre I
Les modalités des obligations contractuelles

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

568. Notion de modalités. Ce qui est essentiel au rapport d'obligation, c'est un créancier, un débiteur, et un objet à exécuter (faire ou ne pas faire, donner). Au-delà de cette structure de base, diverses variantes – traditionnellement appelées modalités – peuvent affecter l'obligation. Toutes ces modalités – qui ne sont pas spécifiques aux obligations contractuelles – font l'objet des articles 1168 et suivants du Code civil (Chapitre IV du Titre III : des diverses espèces d'obligations). Ces modalités peuvent tenir au lien de l'obligation avec le temps, à la pluralité d'objets ou de sujets de l'obligation[1346].

SECTION 1. LES MODALITÉS TEMPORELLES

569. Distinction du terme et de la condition. Dans le cas le plus simple, l'obligation est destinée à s'exécuter aussitôt qu'elle naît. Mais, dans la plupart des cas, le rapport d'obligation va s'inscrire dans un temps plus ou moins long. Deux modalités peuvent alors affecter l'obligation : le terme et la condition.

Alors que le terme suspend l'exécution de l'obligation jusqu'à l'arrivée d'un événement certain, la condition lie l'existence même de l'obligation à la survenance d'un événement incertain.

SOUS-SECTION 1. LE TERME

570. Définition et caractéristiques. De très nombreuses obligations ne sont pas susceptibles d'être exécutées immédiatement, dès leur naissance. Elles sont affectées d'un terme. Par exemple, l'emprunteur, tenu d'une obligation de rembourser la somme prêtée, ne sera tenu d'opérer ce remboursement qu'à une certaine date ou au bout d'une certaine durée, de même que le vendeur d'une chose n'est pas toujours tenu de la livrer immédiatement, ou que le contribuable n'est tenu de payer ses impôts qu'à une date fixée par l'administration.

Dans ces différents cas, le terme apparaît comme un événement futur, et certain, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'il arrivera un jour. Ce peut être une date précise (le 5 novembre 2026), l'expiration d'une certaine durée (dans 6 mois), mais aussi un événement dont la date exacte n'est pas connue, même s'il est certain qu'il se produira (à

[1346] Le Code présente également au titre des modalités de l'obligation les obligations avec clauses pénales. Celles-ci, qui constituent un mécanisme spécifiquement contractuel, seront étudiées avec les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, voy. *infra*, n°s 924 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

mon décès)[1347]. Dans un tel cas, on parle parfois de terme incertain. Il n'est cependant pas toujours facile de déterminer si l'événement auquel les parties lient l'exécution de l'obligation est certain ou incertain. Le tribunal de Luxembourg a jugé que les parties pouvaient tenir pour certain un événement objectivement incertain, marquant ainsi par là leur ferme volonté que l'obligation soit exécutée[1348].

L'autre grande caractéristique du terme est que l'événement attendu affecte seulement l'exécution de l'obligation, non son existence : l'obligation affectée d'un terme existe dès qu'elle a été stipulée, ou dès l'événement qui lui a donné naissance, c'est seulement son exécution qui est retardée (C. civ., art. 1185). Si j'ai emprunté 100 000 €, que je dois rembourser le 5 novembre 2016, je suis, dès maintenant, débiteur de cette somme, alors même qu'on ne peut pas encore me contraindre à la payer.

Ces deux caractéristiques distinguent le terme de l'autre modalité temporelle de l'obligation, la condition. Celle-ci en effet est également un événement futur, mais incertain ; et, à la différence du terme, elle affecte l'existence même de l'obligation.

571. Distinction du terme suspensif et du terme extinctif. Il faut bien distinguer ici deux sens du mot terme : le terme dont nous parlons ici est celui qui retarde l'exécution d'une obligation, et qui est réglementé par les articles 1185 et suivants du Code civil. On l'appelle parfois, de manière ambiguë, le terme suspensif, parce qu'il « suspend » l'exécution. Mais on a vu précédemment que le mot terme est aussi utilisé, dans un autre sens, pour désigner le moment où un contrat à exécution successive prendra fin, lorsque ce contrat est stipulé à durée déterminée (contrat de travail, bail, etc.) : il s'agit alors du terme extinctif. Dans ce cas, les obligations ne sont affectées, tant que dure le contrat, d'aucune modalité ; ce sont des obligations pures et simples ; mais elles prendront fin au terme stipulé. Les deux types de terme obéissent pour l'essentiel aux mêmes règles en ce qui concerne leur fixation (**§ 1**), mais ils n'ont pas du tout les mêmes effets (**§ 2**).

[1347] Cour d'appel, 15 novembre 2007, *Pas.*, 34, p. 61 (qui considère que la stipulation selon laquelle l'obligation ne deviendra exigible qu'au décès d'une personne ne constitue pas un pacte sur succession future, prohibé par l'article 1130 du Code civil.

[1348] Trib. Luxembourg, 14 janvier 2021, n° TAL-2020-03790 (à propos d'une clause d'un contrat de prêt en prévoyant le remboursement au moment « que l'emprunteuse reçoive une indemnité du tribunal pour une affaire qui est en cours ». La clause a été considérée comme fixant un terme.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

La distinction entre les deux catégories de termes n'est cependant pas toujours évidente. On peut s'en rendre compte par la comparaison de deux contrats très proches, le bail (mise à disposition d'un bien moyennant paiement de loyers), et le prêt à usage (mise à disposition d'un bien à titre gratuit). Dans le bail, le terme fixé (le bail court jusqu'au 1er juillet 2016) est un terme extinctif, qui marque la fin du contrat de bail, et des obligations qu'il fait naître. Dans le prêt à usage, on considère traditionnellement que la date de restitution (je vous prête mon appartement jusqu'au 1er juillet 2016) est un terme suspensif (c'est la date à laquelle l'emprunteur pourra être contraint de restituer). Ce n'est qu'une question d'angle de vue.

Les projets européens traitent distinctement de la problématique de la durée des obligations contractuelles (à partir de quand prennent-elles effet et jusqu'à quand ?) et de la question du moment d'exécution du contrat (qui correspond à celle du terme suspensif dans le Code civil). Il en va de même des nouveaux textes belges et français, qui consacrent des développements spécifiques à la durée des contrats, distincts de ceux relatifs au terme comme modalité des obligations.

§ 1. La fixation du terme

572. Terme explicite. Si l'obligation n'est pas d'origine contractuelle, le terme peut être fixé par la loi ou par le juge : par exemple, c'est la loi qui détermine le moment où les contribuables doivent payer leurs impôts, c'est le juge qui, condamnant une personne à payer une pension alimentaire, dit à quelles échéances elle devra être payée. Si l'obligation est contractuelle, le terme peut être déterminé expressément par les parties dans leur contrat, soit par une date ou une période fixe, soit par référence à un événement dont la date n'est pas encore précisément connue. Selon les cas, il peut s'agir d'un terme unique auquel l'obligation devra être exécutée en totalité (vous me rembourserez le 1er mars 2026), ou d'une série de termes échelonnés déterminant une exécution fractionnée (vous me rembourserez sur un an, à raison de tant chaque 1er du mois).

Lorsque le terme est fixé de manière imprécise ou par référence à un événement dont la date n'est pas connue, la détermination de cette date peut susciter des difficultés, qui seront résolues par le juge conformément aux règles générales de l'interprétation des contrats. Au Luxembourg, la Cour d'appel a eu l'occasion de se prononcer sur le sens de la clause « remboursable à première demande » : pour elle, une telle clause « tend précisément à écarter l'idée du terme et à souligner le caractère d'exigibilité immédiate de la somme prêtée »[1349]. Un cas particulier est celui où le moment a été fixé par référence aux besoins du débiteur (quand vous le pourrez, quand vous serez en état de rembourser). Cette situation est spécialement envisagée par l'article 1901 à propos du prêt : il ne faut pas que l'emprunteur puisse différer

[1349] Cour d'appel, 30 septembre 1953, *Pas.*, 16, p. 77.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

indéfiniment le remboursement, sinon cela transformerait le terme en une condition potestative interdite[1350]. C'est pourquoi le texte renvoie à l'appréciation du juge, qui fixera un terme au débiteur « suivant les circonstances »[1351]. On se rapproche alors du cas où les parties n'ont pas fixé de terme du tout.

573. Terme non fixé. Si aucun terme n'a été fixé ni par la loi, ni par le juge, ni par les parties, c'est en principe qu'il n'y en a pas, et que l'obligation est immédiatement exigible. Par exemple, si je vous vends un bien, sans qu'aucun terme ne soit fixé pour le paiement du prix, le prix est alors payable comptant, dès que la chose est livrée (C. civ., art. 1651).

Il en va autrement cependant dans certains contrats où le terme est de l'essence de l'opération. C'est le cas du contrat de prêt : si je vous prête une chose ou une somme, ce n'est pas pour que vous me la rendiez au moment même où je vous la prête, sinon le prêt ne sert évidemment à rien. Or il arrive très souvent que, dans ce type de contrat, le terme de l'obligation de restitution ne soit pas fixé. Pour résoudre ce genre de difficultés, les articles 1888 et suivants du Code civil ont fixé des règles qui, ces dernières années, ont suscité, en droit français, un abondant contentieux. Lorsqu'il s'agit d'un prêt d'argent, l'article 1900 confie au juge le soin d'« accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances », ce qui signifie une fixation judiciaire du terme[1352]. Selon une jurisprudence constante, la solution est cependant différente dans le cas des avances en compte-courant d'associé, qui sont considérées comme des prêts à durée indéterminée résiliables à tout moment par le prêteur[1353]. Lorsqu'il s'agit du prêt d'une chose (prêt à usage), l'article 1888 du Code civil prévoit que le prêteur peut reprendre la chose lorsqu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été prêtée. Mais, s'il s'agit d'une chose à usage permanent, la Cour de cassation française, en l'absence de texte, raisonne comme pour un contrat à durée indéterminée et permet au prêteur de résilier le contrat à tout moment[1354]. Cette solution semble

[1350] Voy. *infra*, n° 593.

[1351] Pour une application voy. Trib. Luxembourg, 17 octobre 2008, n° 116446.

[1352] Pour des applications récentes voy. Cour d'appel, 31 mai 2017, n° 43199 ; Cour d'appel, 21 mars 2024, n^{os} CAL-2023-00527 et CAL-2023-00699 ; Trib. Luxembourg, 22 janvier 2024, n° TAL-2021-06537 ; Trib. Luxembourg, 19 avril 2024, n° TAL-2021-06536.

[1353] Voy. récemment Cour d'appel, 15 novembre 2022, n° CAL-2020-01068 ; Cour d'appel, 28 février 2023, n° CAL-2022-00334.

[1354] Cass. fr. (1re civ.), 3 février 2004, n° 01-00004 ; Cass. fr. (1re civ.), 30 septembre 2015, n° 14-25709.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

reçue au Luxembourg[1355]. Ces solutions illustrent la difficulté de distinguer dans certains cas le terme extinctif du contrat et le terme suspensif de l'obligations.

§2. Les effets du terme

574. Avant et après l'échéance. Lorsque survient la date ou l'événement choisi comme terme, on dit que la dette est échue ou arrive à échéance. Les règles spécifiques découlant de la stipulation d'un terme suspensif peuvent être étudiées en distinguant la situation avant l'échéance du terme et la situation à l'échéance.

A) *La situation avant l'échéance du terme*

575. Distinction de l'existence et de l'exigibilité. Les effets du terme s'articulent autour de la notion d'exigibilité, qui désigne le moment où le créancier peut exiger du débiteur l'exécution de son obligation. Tant que le terme n'est pas échu, l'obligation n'est pas exigible, mais elle n'en existe pas moins[1356].

1) *L'obligation n'est pas exigible*

a. *Principe*

576. Conséquences du défaut d'exigibilité. Le défaut d'exigibilité, avant le terme, s'entend de l'impossibilité pour le créancier d'exiger l'exécution de la part du débiteur. Plus précisément, cela signifie que, tant que le terme n'est pas échu, le créancier ne peut pas agir en exécution forcée contre le débiteur. Celui-ci, de son côté, ne peut encourir aucune sanction s'il n'exécute pas – ni la résolution du contrat, ni la condamnation à des dommages et intérêts. On ne peut même pas, dans ce cas, parler d'inexécution. Et, parce qu'il ne peut pas contraindre le débiteur à payer, le créancier ne peut pas davantage invoquer contre lui la compensation – qui est, nous le verrons, une sorte de paiement forcé[1357] : si *Primus* est créancier de *Secundus* pour 5 000 € à terme du 1er janvier 2026, et que *Secundus* est créancier de *Primus* d'une somme payable immédiatement, Primus devra payer ce qu'il doit, et attendre le 1er janvier 2026 pour réclamer ce que lui doit Secundus – sinon cela

[1355] J.P. Luxembourg, 20 décembre 2023, rép. n° 3349/23.
[1356] Comp. en droit belge : Van Ommeslaghe, n° 1196 ; en droit français : Bénabent (2016), n° 317.
[1357] Voy. *infra*, n° 891.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

reviendrait à priver *Secundus* du bénéfice du terme. Enfin, parce que le créancier ne peut pas demander l'exécution à son débiteur, la prescription ne court pas contre lui (C. civ., art. 2257, al. dernier)[1358].

b. *Limites : la déchéance du terme*

577. Notion. Certains événements peuvent, dès avant le terme stipulé, autoriser le créancier à réclamer son dû : on dit qu'il y a déchéance du terme. Si la dette était à exécution échelonnée (un prêt remboursable mensuellement pendant 5 ans), la déchéance aura pour effet de rendre immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues. Cette déchéance du terme peut être légale ou conventionnelle.

578. Déchéance légale. L'article 1188 du Code civil prévoit deux cas de déchéance du terme : la faillite, et la perte des sûretés.

Le premier cas (qui a disparu en droit français, mais qui subsiste en droit luxembourgeois comme en droit belge) est repris à l'article 450 du Code de commerce, selon lequel « Le jugement déclaratif de la faillite rend exigible, à l'égard du failli, les dettes passives non échues ». Cette déchéance du terme permet d'admettre immédiatement toutes les créances au passif de la procédure et d'en poursuivre le règlement collectif[1359]. Pour les créanciers eux-mêmes, cette déchéance n'a qu'un effet pratique limité, dans la mesure où, de toute façon, ils ne pourront pas agir immédiatement contre le débiteur, la faillite ayant aussi pour effet d'arrêter les poursuites individuelles. L'intérêt de la déchéance du terme se révèle surtout lorsque la dette non exigible est assortie d'une sûreté personnelle : cela va permettre au créancier de mettre en œuvre immédiatement sa sûreté (par exemple, d'agir immédiatement contre la caution). À la faillite proprement dite, il faut aujourd'hui assimiler l'ouverture d'une procédure de traitement du surendettement, telle qu'elle est organisée par la loi du 8 janvier 2013[1360] : l'article 5 de cette loi prévoit que l'ouverture de la procédure a le double effet de rendre exigible les dettes non échues et de suspendre les voies d'exécution.

[1358] Voy. *infra*, n° 944.

[1359] En droit français, les procédures de règlement des difficultés des entreprises n'ont plus pour but premier d'assurer le paiement des créanciers en liquidant les biens de l'entreprise, mais d'assurer autant que possible le redressement de celui-ci. C'est pourquoi, depuis 1985, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'entraîne plus la déchéance du terme. Seule l'ouverture d'une liquidation judiciaire (équivalent de la faillite du droit luxembourgeois) conserve cet effet traditionnel (C. comm. fr., art. L. 643-1).

[1360] Sur ces procédures en général, voy. *infra*, n°s 585 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Avant la mise en place des procédures de traitement du surendettement, l'insolvabilité d'un particulier non commerçant ne donnait pas lieu à une organisation spécifique, et tous les créanciers pouvaient saisir les biens du débiteur en ordre dispersé. On disait que le débiteur était en « déconfiture ». On se demandait alors si l'état de déconfiture pouvait être assimilé à la faillite au sens de l'article 1188 du Code civil, et entraîner la déchéance du terme. La jurisprudence l'avait admis, à la condition que la déconfiture ait été déclarée par une décision judiciaire[1361]. Cela permettait à tous les créanciers de procéder ou de participer aux saisies. Cette solution n'a plus qu'un intérêt pratique très limité, car, dans ces hypothèses, le débiteur demandera en général à bénéficier d'une procédure de traitement du surendettement.

Le deuxième cas visé par l'article 1188 du Code civil est celui où, par son fait, le débiteur a diminué les sûretés qu'il avait données à son créancier. La déchéance du terme est ici à la fois une sanction pour le débiteur, et une mesure de sauvegarde pour le créancier, qui comptait sur des garanties de paiement et qui s'en trouve privé du fait du débiteur. La solution s'applique de manière extensive à toutes les garanties constituées au profit du créancier, quelle qu'en soit la nature[1362], mais, selon la lettre même du texte, les sûretés visées à l'article 1188 du Code civil ne sont que les sûretés contractuelles, non celles que le créancier tient de la loi[1363].

579. Déchéance conventionnelle. Très souvent le contrat qui fait naître l'obligation à terme – le contrat de crédit – contient une clause de déchéance du terme pour le cas où le débiteur n'exécuterait pas telle ou telle de ses obligations. En particulier dans les contrats de crédit où le remboursement est fractionné, il est habituellement prévu que le non-paiement d'une échéance entraînera la déchéance du terme : l'emprunteur devra alors payer immédiatement la totalité des sommes restant dues. Bien sûr il sera rarement en mesure de le faire, mais l'avantage de cette clause pour le créancier est qu'il pourra procéder immédiatement aux mesures d'exécution forcée pour la totalité des sommes restant dues. Ces clauses de déchéance du terme constituent aussi un moyen de pression sur le débiteur, qui, dans la crainte d'avoir tout à rembourser tout de suite, sera peut-être plus diligent dans le respect des échéances. Cependant, la Cour d'appel a récemment rappelé que, en l'absence d'une telle clause, le défaut de paiement d'une échéance d'une dette n'entraîne pas de plein droit la déchéance du terme pour la totalité de

[1361] Trib. Diekirch, 17 mars 1904, *Pas.*, 6, p. 548 ; Cour d'appel, 25 mars 1904, *Pas.*, 6, p. 505.
[1362] Cour d'appel, 24 mars 1895, *Pas.*, 7, p. 111.
[1363] Trib. Luxembourg, 18 octobre 1899, *Pas.*, 5, p. 223.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

cette dette, le juge n'a pas le droit de prononcer la déchéance du terme en dehors des cas prévus par la loi ou par la convention des parties[1364].

2) *L'obligation existe*

580. Qui a terme doit déjà. Un proverbe ancien dit « qui a terme ne doit rien ». Cette formulation est trompeuse : cela veut simplement dire qu'on ne peut pas exiger de lui qu'il paye. Mais la dette, si elle n'est pas encore exigible, existe bien : le créancier à terme est déjà créancier, et le débiteur déjà débiteur. Cela a de multiples conséquences : d'abord cela permet le paiement avant terme, ensuite, le créancier à terme a certains droits dès avant le terme.

581. Paiement avant terme. Le fait que la dette existe déjà, dès la conclusion du contrat qui l'a fait naître, implique que son paiement, avant le terme, ne constitue pas un paiement indu : le débiteur qui a payé, même par erreur, ne peut pas obtenir la restitution des sommes versées, contrairement à celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas du tout.

Cela ne veut pas dire, cependant, que le créancier soit obligé d'accepter le paiement avant le terme. Il faut savoir en faveur de quel contractant le terme a été stipulé. En principe, selon l'article 1187 du Code civil, le terme est « présumé stipulé en faveur du débiteur »[1365], pour lui donner un délai d'exécution : cela veut dire que le débiteur, s'il veut se libérer par anticipation, peut le faire librement sans que le créancier puisse s'y opposer. Cette solution va de soi lorsqu'il est prévu dans le contrat que le débiteur doit s'exécuter « avant telle date » ou « au plus tard à telle date » : lorsque par exemple, un entrepreneur s'engage à faire des travaux avant telle date, le maître de l'ouvrage serait mal venu à refuser que les travaux soient faits plus tôt. Mais, selon le texte, il en va autrement s'il résulte de la stipulation, ou des circonstances, que le terme a été aussi convenu en faveur du créancier : dans ce cas, le créancier peut refuser le paiement avant terme. C'est la situation la plus fréquente aujourd'hui : si en effet le crédit consenti est assorti d'une stipulation d'intérêts, le créancier subit un manque à gagner si le débiteur lui rembourse avant terme (s'il avait su, il aurait placé son

[1364] Cour d'appel, 29 juin 2017, *Pas.*, 38, pp. 620 et s.

[1365] La solution est reprise par l'article 1305-3 du Code civil français et par l'article 5.153 du nouveau Code civil belge.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

argent ailleurs) et il peut donc refuser un tel remboursement[1366]. Le plus souvent, les contrats de crédit réglementent explicitement le paiement par anticipation, en exigeant du débiteur qui se libère ainsi par avance le paiement d'une indemnité compensatrice. Ces clauses sont réglementées dans le cadre du crédit à la consommation (C. consomm., art. L. 224-17).

582. Droits du créancier avant l'arrivée du terme. Le créancier titulaire d'une créance à terme peut d'ores et déjà se comporter comme un « propriétaire » de cet élément d'actif : il peut céder sa créance ou la donner en gage. C'est même surtout pour les créances à terme que ces opérations sont utiles, car elles permettent au créancier d'obtenir immédiatement des liquidités qu'il ne pourrait pas contraindre son débiteur à lui verser immédiatement. En retour, la créance à terme, parce qu'elle fait déjà partie du patrimoine de son titulaire, peut également être saisie par ses propres créanciers. Par ailleurs, le créancier à terme a également la possibilité de pratiquer des mesures conservatoires pour protéger sa créance[1367].

B) *La situation à l'échéance du terme*

583. Renversement de la situation. L'arrivée du terme marque un renversement de la situation : en principe, l'obligation devient exigible (**1**), à moins que le débiteur n'obtienne un report ou des délais de paiement (**2**).

1) *Principe : l'obligation devient exigible*

584. Conséquences de l'exigibilité. La principale conséquence est que l'obligation devient susceptible d'exécution forcée : le créancier peut, s'il a déjà un titre exécutoire (acte notarié), mettre immédiatement en œuvre les procédures d'exécution, et, s'il n'a pas encore de titre exécutoire, obtenir la condamnation du débiteur à payer. La compensation devient également possible dès l'arrivée du terme.

Cependant, le débiteur qui n'exécute pas immédiatement lors de l'échéance n'encourt pas nécessairement tout de suite les différentes sanctions qui assortissent l'inexécution des obligations. En principe, dans le système du Code civil, le créancier doit, avant d'obtenir des dommages et intérêts sanctionnant le retard dans

[1366] *Contra* : Trib. Luxembourg, 20 décembre 2006, n° 86063, critiqué à juste titre par O. Poelmans, n° 296.

[1367] Sur ces mesures, voy. *infra*, n°s 722 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'exécution, rappeler solennellement au débiteur qu'il doit exécuter. C'est ce qu'on appelle la mise en demeure (C. civ., art. 1146 et s.). Au Luxembourg, cependant, l'article 1146 du Code civil, dans la rédaction que lui a donné la loi du 15 mai 1987, dispense le créancier de mise en demeure dès lors qu'un terme a été fixé d'un commun accord entre les parties. Nous retrouverons en détail le rôle et le régime de la mise en demeure lorsque nous ferons l'étude des sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles[1368].

2) *Limites : délais de paiement*

585. Délais conventionnels. On peut d'abord concevoir que ce soit le créancier lui-même qui accorde des délais à son débiteur. Il s'agit alors d'une prorogation de terme, qui est une modification de la clause de terme initialement fixée. On se retrouve alors dans la situation étudiée précédemment avant l'échéance du terme : pas d'exécution forcée, pas de compensation, pas de dommages et intérêts pour retard.

Ces délais conventionnels peuvent être accordés dans le cadre d'une négociation individuelle entre le débiteur et son créancier. Mais ils peuvent aussi être octroyés dans le cadre d'une négociation collective, sous l'égide d'une institution judiciaire ou parajudiciaire. C'est le cas, si le débiteur est un particulier non commerçant, des délais qui peuvent être accordés par les créanciers dans le cadre des procédures de traitement du surendettement actuellement réglementées par la loi du 8 janvier 2013 : cette loi met en effet en place une procédure de règlement conventionnel qui se déroule devant une commission de médiation ; cette commission propose au débiteur et au créancier un plan de règlement conventionnel qui peut comporter notamment « des mesures de report ou de rééchelonnement de paiement des dettes » (L. 8 janvier 2013, art. 7).

586. Délais judiciaires : délai de grâce. Ces délais, octroyés par un juge pour venir au secours d'un débiteur en difficulté, sont appelés habituellement délais de grâce.

La possibilité pour le juge d'octroyer des délais de grâce avait été reconnue par le Code civil de 1804, dans l'article 1244 qui fixe toujours le droit commun de délais de grâce. Ce texte s'applique en principe à toutes les obligations, quelle qu'en soit l'objet et

[1368] Voy. *infra*, n°s 685 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la source[1369], sous réserve de cas où l'octroi de délais de grâce est interdit par la loi[1370]. À la différence de la France[1371] et de la Belgique[1372], le Luxembourg a conservé le texte originaire, très restrictif dans sa formulation « Les juges peuvent, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état ». Cependant, il faut remarquer que l'article 1244 du Code civil ne fixe pas de durée maximum pour l'octroi des délais (dont on dit simplement qu'ils doivent être modérés), et n'assortit cet octroi que de conditions assez vagues, qui sont laissées à l'appréciation des juges du fond. Il semble que les tribunaux luxembourgeois se montrent assez rigoureux dans l'appréciation de ces conditions. La Cour d'appel juge ainsi que « il se dégage de la lecture de cet article (1244) que les délais de paiement sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d'octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l'obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties »[1373]. Elle ajoute que « [l]e délai de grâce prévu à l'article 1244 du Code civil n'est à accorder que s'il apparaît comme vraisemblable qu'à l'expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s'acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu'il soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l'évolution future de sa situation financière et en fonction de cette projection indique

[1369] La Cour de cassation belge a cependant jugé que l'article 1244 du Code civil ne s'appliquait qu'aux obligations conventionnelles, la possibilité pour le juge d'octroyer un délai pour l'exécution d'autres obligations étant cependant permise sur le fondement d'un principe général de droit fondé sur l'équité (Cass. be., 13 septembre 1977, *Pas. be.*, 1978, I, p. 41, note F.D.).

[1370] Il en va ainsi notamment pour les dettes résultant de la signature d'un effet de commerce (Cour d'appel, 19 octobre 2006, *Pas.*, 33, p. 204) ou pour les dettes d'aliment, dont le paiement ponctuel est nécessaire à la satisfaction des besoins du créancier.

[1371] En droit français, l'article 1244 du Code civil a été modifié à maintes reprises, toujours dans le sens d'une extension des pouvoirs du juge. Dans le dernier état, datant de la réforme de 2016, le délai de grâce est réglementé dans l'article 1342-5 du Code civil français.

[1372] En Belgique, la formulation originaire avait été modifiée en 1967, mais dans un sens plutôt plus restrictif, commandant au juge de tenir compte dans l'octroi des délais de ceux qui ont déjà été accordés au débiteur. Cette restriction a été reprise dans l'article 5.201 du nouveau code.

[1373] Cour d'appel, 20 décembre 2023, n° CAL-2023-00928. Voy. les exemples cités par Poelmans, n° 298, dont il est cependant difficile de déduire une attitude générale des tribunaux, que seule une recherche empirique permettrait de connaître.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la durée requise du terme de grâce sollicité »[1374]. Le délai de grâce n'a par ailleurs que des effets limités, ce n'est pas une véritable prorogation de terme qui modifierait les termes du contrat, c'est, dans la conception traditionnelle, un simple sursis à l'exécution de la condamnation du débiteur, qui empêche le créancier de recourir aux mesures d'exécution forcée[1375]. C'est du reste la présentation que donne du délai de grâce l'article 232 du NCPC. Le débiteur qui obtient le bénéfice d'un délai de grâce est donc, à proprement parler, toujours en retard, et il doit donc payer au créancier des intérêts de retard. C'est en ce sens qu'on peut comprendre la formule de l'article 1244 du Code civil « toutes choses demeurant en l'état ». Pour la même raison, parce que la dette est toujours exigible, le délai de grâce n'empêche pas le jeu de la compensation (C. civ., art. 1292) : le créancier à qui un délai de grâce est imposé par le juge peut donc invoquer la compensation pour refuser de payer ce qu'il devrait de son côté à son débiteur.

587. Délais judiciaires : textes spéciaux. À côté du délai de grâce de droit commun, il existe certains délais spéciaux obéissant à des règles particulières.

Ces textes spéciaux ont parfois un effet plus radical que le délai de l'article 1244. Une telle réglementation spéciale existe en matière commerciale depuis un arrêté grand-ducal de 1934 qui permet d'accorder un sursis de paiement « au commerçant qui par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffisants pour satisfaire tous ses créanciers en principal et intérêts » (C. comm., art. 593 et s.). On en trouve aujourd'hui un équivalent beaucoup plus développé au profit des particuliers, avec la loi sur le surendettement du 8 janvier 2013 : si la procédure précédemment évoquée de règlement conventionnel échoue, une procédure de redressement judiciaire peut être engagée par le débiteur devant le juge de paix du domicile du débiteur ; le juge rend un jugement dans lequel il arrête un plan de redressement judiciaire qui peut comporter, entre autres mesures, « le sursis au paiement de tout ou partie des dettes ». L'octroi de tels délais, empêche évidemment les différents créanciers d'exercer des procédures d'exécution contre le débiteur. À la différence du

[1374] Cour d'appel, 4 juin 2024, n° CAL-2023-00635 ; Cour d'appel, 20 décembre 2023, préc.
[1375] Dans ce sens : Cour d'appel, 22 mars 1901, *Pas.*, 05, p. 576.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

délai de grâce de droit commun, il est expressément prévu que ces délais bénéficient également aux cautions ayant garanti l'engagement du débiteur surendetté ainsi qu'à ses codébiteurs du débiteur surendetté, ce qui semble indiquer qu'on est bien ici en présence d'un véritable report d'exigibilité de la dette. On évitera cependant de dire de ces mesures, justifiées par des situations de crise et par le souci de garantir au débiteur « ainsi qu'à sa communauté domestique, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine » (L. 2013, art. 1er), qu'elles confèrent au débiteur un « droit de ne pas payer ses dettes » – méchante formule naguère utilisée par Ripert pour stigmatiser l'extension du délai de grâce par le législateur français[1376].

SOUS-SECTION 2. LA CONDITION

588. Notion. Le contrat est, d'une manière générale, un acte de prévision. Mais, au moment où elles passent leur contrat, les parties ne sont pas toujours en mesure de prévoir avec certitude les événements en considération desquels le contrat est passé. En principe, il appartient à chaque partie de supporter les risques que cette incertitude de l'avenir fait peser sur l'utilité que le contrat présente pour elle. Si, par exemple, j'achète un appartement à Luxembourg, parce que je pense que mon contrat de professeur à l'Université sera renouvelé après ma retraite, et que, finalement, je n'obtiens pas ce renouvellement, tant pis pour moi : je ne pourrai pas dire que le contrat n'a plus de sens pour moi, et en demander l'annulation ; on est en présence ici d'une erreur sur les motifs qui n'est pas, on le sait, une cause de nullité du contrat[1377]. Il en va bien sûr de même, en sens inverse, pour mon vendeur qui m'aurait vendu son appartement que dans l'espérance, finalement déçue, qu'il obtiendrait un poste à l'étranger. Cependant les parties peuvent vouloir intégrer cette incertitude dans le contrat, en en faisant supporter la charge par la partie à qui elle n'incomberait pas normalement. C'est en insérant une condition dans le contrat qu'elles vont pouvoir le faire : pour reprendre l'exemple précédent, je peux convenir avec mon vendeur que je n'achète son appartement que sous la condition que mon contrat soit renouvelé. Le contrat tombera si cette condition ne se réalise pas, et c'est alors mon vendeur, non moi, qui supporterai le risque.

[1376] G. Ripert, « Le droit de ne pas payer ses dettes », *DH*, 1936, chron., p. 57.
[1377] Voy. *supra*, n° 231.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Tous les systèmes juridiques connaissent ce type de mécanisme, dont l'utilité pratique est considérable. Dans le Code civil, il est défini à l'article 1168 selon lequel « L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas ». Cette définition fait d'emblée apparaître une distinction entre deux types de conditions : celle qui suspend la naissance de l'obligation à la réalisation de l'événement (vous ne serez tenu de me livrer l'appartement, et je ne serai tenu de vous le payer que si je suis renouvelé), et celle qui, à l'inverse, prévoit que l'obligation tombera en cas de survenance ou de non-survenance d'un événement (je vous achète, mais la vente sera résolue si je n'obtiens pas mon renouvellement, vous devrez alors me rembourser ce que je vous aurai payer, et je vous rendrai l'appartement). Dans le premier cas, on parle d'une *condition suspensive*, dans le second d'une *condition résolutoire*. Les textes sur la condition ont été repris, avec diverses modifications, aux articles 1304 et suivants du Code civil français et 5.139 et suivants du nouveau Code civil belge.

589. Éléments essentiels. Qu'elle soit suspensive ou résolutoire, l'article 1168 du Code civil pose les deux éléments fondamentaux de la condition, qui permettent de la distinguer du terme suspensif précédemment étudié : un élément futur et incertain, et une incidence sur l'existence même de l'obligation.

Pour qu'on soit en présence d'une condition, il faut d'abord, selon la lettre du texte, qu'on soit en présence d'un événement futur et incertain – alors que le terme, on l'a vu, est un événement certain (même si la date de réalisation en est, elle, incertaine). En réalité, l'élément essentiel est dans l'incertitude de l'événement, non dans son caractère futur : sans doute, dans l'immense majorité des cas, ce sont les événements futurs qui sont incertains, mais il peut arriver aussi qu'un événement se soit déjà produit, alors que les parties n'en savent rien, et qu'elles l'insèrent comme condition dans leur contrat (le cas est explicitement prévu par l'article 1181 du Code civil). On observe au passage que la notion d'incertitude s'apprécie, non pas objectivement, mais par rapport à la manière dont les parties considèrent l'événement.

Cet événement va affecter l'existence même de l'obligation, et c'est là encore une différence essentielle avec le terme qui, selon l'article 1188 du Code civil, « ne suspend point l'engagement dont

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

il retarde seulement l'exécution ». L'obligation conditionnelle, selon l'article 1168 du Code civil (ainsi que par le nouvel article 1304 du Code civil français), « dépend » de l'événement : elle est, selon les cas, suspendue tant que l'événement n'est pas arrivé (condition suspensive), ou « résiliée » si l'événement arrive ou n'arrive pas (condition résolutoire). L'article 5.139 du nouveau Code civil belge, qui dispose que « L[l]obligation est conditionnelle lorsque son exigibilité ou son extinction dépend d'un événement futur et incertain » est cependant beaucoup moins net.

Ces deux éléments sont étroitement liés : c'est parce que l'événement est incertain qu'on peut en faire dépendre l'existence même de l'obligation. Si l'événement auquel on lie l'obligation est certain, l'engagement pris est nécessairement ferme, et ce n'est que le moment d'exécution qui peut se trouver retardé.

590. Source des conditions. En théorie, une condition, comme un terme, peut avoir pour origine soit une clause contractuelle, soit une disposition légale, et elle peut s'appliquer à toute obligation qu'elle qu'en soit la source. L'étude des conditions fait donc partie, comme celle du terme du « régime général de l'obligation ». C'est sous cet angle qu'elle est abordée par le code français après la réforme et par le nouveau Code civil belge. En pratique cependant, dans l'immense majorité des cas, les conditions affectent des obligations contractuelles, et résultent d'une clause du contrat (ou d'un acte juridique unilatéral). Aussi bien les conditions de validité des conditions (**§ 1**), comme leurs effets (**§ 2**), ne peuvent guère être envisagés sans une référence constante au contrat dans lequel elles sont insérées.

§1. Les conditions de validité des conditions

591. Des clauses contractuelles spécifiques. Les articles 1169 et suivants du Code civil, qui définissent les conditions de validité des conditions, ont été visiblement écrits pour les conditions posées par des clauses contractuelles. On y trouve, à côté d'exigences générales à toutes les clauses contractuelles – les conditions doivent être licites et possibles – (**A**) une exigence spécifique – elles ne doivent pas être purement potestatives de la part de celui qui s'oblige (**B**).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

A) *Exigences communes à toutes les clauses contractuelles*

592. Prohibition des clauses illicites ou impossibles. Selon l'article 1172 du Code civil, « toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ». Les exemples de conditions impossibles sont les plus souvent des hypothèses d'école[1378]. En revanche, l'interdiction des conditions illicites ou immorales donne lieu à certaines applications en jurisprudence. Un exemple typique est celui des clauses insérées dans une donation ou dans un testament qui prétendent limiter la liberté de la vie privée du bénéficiaire de la libéralité : on prévoit par exemple que le légataire sera privé du bénéfice du testament s'il se remarie après le décès du testateur, ou s'il adopte telle religion, ou s'il vit avec une personne du même sexe, etc. Il ne nous paraît pas utile de développer ici les divers cas d'illicéité, dès lors que le texte n'est qu'une application particulière de l'article 6 du Code civil.

Ce qui est surtout remarquable, dans l'article 1172 du Code civil, c'est l'étendue de la sanction : la nullité de la condition n'affecte pas seulement celle-ci, mais l'ensemble de la convention[1379]. Textuellement la règle ainsi posée ne vaut que pour les actes à titre onéreux : pour les libéralités, l'article 900 du Code civil prévoit la solution inverse (la condition réputée non écrite). On sait cependant que la jurisprudence, dépassant l'opposition des textes, a abouti à un régime identique pour les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux. Ce qui compte, c'est le caractère accessoire ou essentiel de la clause illicite ou immorale dans l'intention des parties. Le débat dépasse d'ailleurs largement le seul cas des conditions, car les articles 1172 et 900 du Code civil ont été interprétés comme s'appliquant sans distinction à toutes les clauses des contrats. C'est pourquoi la question a été étudiée d'une manière générale à propos de la nullité du contrat[1380].

[1378] Voy. cependant Cour d'appel, 14 mars 2024, n° CAL-2023-00175, considérant comme une condition « impossible, illicite et contraire aux bonnes mœurs » la clause soumettant un compromis de vente à la condition suspensive que l'acquéreur obtienne les « pré-autorisations nécessaires » à la démolition d'un immeuble, alors qu'aucun texte ne prévoit une telle pré-autorisation.

[1379] Solution reprise par l'article 1304-1 du projet français.

[1380] Voy. *supra*, n°s 472 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

B) *Exigence spécifique aux conditions : la nullité des conditions purement potestatives*

593. Principe. Les articles 1169 à 1171 du Code civil distinguent trois catégories de conditions, selon le rôle qu'y joue la volonté des parties. On distingue ainsi la condition casuelle, qui ne dépendent en aucune manière de la volonté de l'une ou l'autre des parties (C. civ., art. 1169. Par exemple : si je décède avant vous), la condition potestative « qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher » (C. civ., art. 1170. Par exemple : si je démissionne) et la condition mixte « qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers » (C. civ., art. 1172. Par exemple : si je me marie). Ces trois types de conditions sont en principe valables, mais sous réserve d'une importante limite posée par l'article 1174 du Code civil, selon lequel « toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part du débiteur ».

Cette prohibition, reprise par l'article 1304-2 du Code civil français et l'article 5.141 du nouveau Code civil belge, et dont on trouve l'équivalent dans différents droits étrangers[1381], est traditionnellement justifiée par le fait qu'il est impossible de s'obliger en se rendant maître de la faculté de faire tomber l'obligation. Dire : je m'oblige à telle chose, si je veux (condition suspensive) ou si je ne change pas d'avis (condition résolutoire), c'est ne pas s'obliger du tout. C'est pourquoi le nouveau Code civil belge présente la prohibition comme une application de l'idée selon laquelle la condition doit être extérieure au contrat, c'est-à-dire ne pas porter sur un élément dont dépend la validité du contrat (dans ce cas le consentement de la partie). Mais cette justification ne vaut que pour les conditions du type « si je veux », qui sont très exceptionnelles en pratique, et qui sont en réalité des cas d'inexistence de l'obligation plus que de nullité. Le plus souvent, les conditions potestatives sont des conditions qui dépendent non pas directement de la volonté du débiteur, mais d'un événement sur lequel la volonté du débiteur a prise (par exemple : je ne vous rembourserai pas si je quitte mon emploi). La prohibition de ce type de condition est alors plutôt qu'on veut éviter qu'un contractant ne soit à la merci de l'autre. Cette idée

[1381] Voy. p. ex. : Codice civile italien (art. 1355), Codigo civil espagnol (art. 1115), Code civile québecois (art. 1500).

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

inspire certaines solutions en dehors même du strict domaine des conditions : ainsi on a souvent rapproché de l'article 1174 du Code civil les solutions jurisprudentielles relatives à la détermination du prix, qui (en France jusqu'en 1995) annulaient le contrat lorsque cette détermination était laissée à l'arbitraire d'une partie[1382]. On peut rattacher à la même idée la solution selon laquelle les clauses de non-responsabilité ne jouent pas en cas de dol (inexécution volontaire) de la part du débiteur[1383].

Dans le strict domaine des conditions, l'article 1174 du Code civil est un texte fréquemment invoqué dans les hypothèses les plus diverses. Il convient de préciser les conditions et les effets de la nullité.

1) *Conditions de la nullité des conditions potestatives*

594. Potestative pour qui ? Le texte n'interdit que les conditions potestatives de la part du débiteur. Il n'y a en effet rien de choquant à ce que le débiteur soit obligé sous une condition dépendant de la volonté exclusive du créancier : par exemple, si le prêteur déclare qu'il se réserve la possibilité de ne pas demander le remboursement à son emprunteur : après tout, le créancier est toujours maître de demander ou de ne pas demander l'exécution au débiteur ; il peut le préciser d'emblée dans le contrat[1384].

On en déduisait traditionnellement que les conditions potestatives sont valables dans les contrats synallagmatiques, puisque chaque contractant est à la fois créancier et débiteur de l'autre : il peut en effet paraître admissible qu'un des contractants se réserve le droit de ne pas exécuter son obligation, sachant qu'alors l'autre contractant sera également libéré de sa propre obligation. Certains exemples de telles conditions sont d'ailleurs prévus par les textes : il en va ainsi de la vente à l'essai (par exemple : j'achète une encyclopédie avec la faculté de la retourner dans un certain délai si elle ne me plaît pas), analysée par l'article 1588 du Code civil comme une vente sous condition suspensive, ou de la vente avec faculté de rachat (dite aussi traditionnellement vente à réméré) permettant au vendeur de reprendre la chose vendue au bout d'un certain temps (C. civ.,

[1382] Voy. *supra*, n°s 325 et s.

[1383] Voy. *infra*, n° 862.

[1384] Pour une application, voy. Cour d'appel, 14 décembre 2016, n° 40643 du rôle (fixation unilatérale par un banquier du moment où il décide de recourir à un appel de marge dans un « crédit lombard »).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

art. 1659 et s.). Cependant, si on réfléchit bien, on s'aperçoit qu'il est faux d'affirmer d'une manière générale que les conditions potestatives sont valables dans les contrats synallagmatiques : dès lors qu'une des parties a le pouvoir d'exécuter ou de ne pas exécuter, même si cela la prive du même coup du pouvoir d'exiger l'obligation de l'autre, cela a pour effet de priver son cocontractant du bénéfice du contrat. C'est pourquoi la doctrine et la jurisprudence contemporaine n'hésitent pas à appliquer l'article 1174 du Code civil même dans le cadre des contrats synallagmatiques[1385]. La Cour d'appel a posé très clairement cette solution[1386].

En toute hypothèse, la nullité des conditions potestatives ne devrait avoir vocation à s'appliquer que lorsqu'on est en présence d'un rapport d'obligation, entre un débiteur et un créancier. La jurisprudence fait cependant parfois jouer la notion de potestativité à propos de clauses qui ne font naître à proprement parler aucune obligation, pour sanctionner un déséquilibre entre les droits reconnus à chaque partie. On peut le voir notamment dans un arrêt de la Cour de cassation française, relatif à une affaire touchant une pratique contractuelle luxembourgeoise : cet arrêt annule pour potestativité une clause (courante dans les contrats passés par les banques luxembourgeoises avec leurs clients) attribuant compétence aux tribunaux luxembourgeois, mais laissant à la banque la faculté de saisir un autre tribunal[1387]. Confrontés au même type de clauses, les tribunaux luxembourgeois n'ont pas suivi cette jurisprudence[1388].

595. Potestative jusqu'où ? Encore faut-il préciser ce qu'on entend par condition potestative. De ce point de vue, on fait traditionnellement la distinction entre les conditions simplement et les conditions purement potestatives[1389]. Les secondes sont celles qui dépendent exclusivement de la volonté du débiteur. Les conditions simplement potestatives dépendent à la fois de la volonté du débiteur et d'un événement extérieur : celui-ci peut être en particulier la volonté d'un tiers, ce qui correspond aux conditions mixtes de l'article 1171 du Code civil (« si je me marie », ce qui suppose que je trouve quelqu'un qui accepte de m'épouser ; « si j'obtiens un crédit », ce qui suppose, non seulement que je demande le crédit, mais encore que mon banquier me l'accorde). Cette distinction ne semble pas très rationnelle au regard de l'objectif poursuivi par l'article 1174 du Code civil,

1385 Voy. en France : Cass. fr., 23 septembre 1982, n° 81-10131.

1386 Cour d'appel, 16 janvier 2001, *Pas.*, 32, p. 187.

1387 Cass. fr. (1re civ.), 26 septembre 2012, *J.T.L.*, 2013, p. 7, note P. Ancel et G. Cuniberti – Pour une appréciation critique de cette solution dans la doctrine française, voy. M.-E. Ancel, I. Marion et L. Wynaendt, *Banque et droit*, mars-avril 2013, n° 148, p. 8 ; Fages, n° 121.

1388 Trib. Luxembourg, 29 janvier 2014, nos 153636, 155943, 156026 et 157028.

1389 Pour l'exposé de cette distinction, voy. p. ex. en droit belge Van Ommeslaghe, n° 1216 ; en droit français Flour, Aubert, Savaux vol. 3 2015, n° 314.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

qui est de protéger un contractant contre l'arbitraire de l'autre, dès lors que, même si la condition est simplement potestative, la volonté du débiteur jouera toujours un rôle déterminant sans sa réalisation. C'est pourquoi la jurisprudence contemporaine, au Luxembourg comme en France, ne s'arrête plus à la distinction des conditions purement et simplement potestative. Les tribunaux recherchent au cas par cas si, même dans les conditions simplement potestatives, dépendant à la fois de la volonté du débiteur et d'un tiers ou d'un événement extérieur, le débiteur est ou non « maître du jeu », s'il a ou non la libre appréciation des circonstances déterminant sa décision[1390].

Un arrêt de la Cour d'appel en date du 16 janvier 2001 est très représentatif de cette manière de juger. Il s'agissait d'un contrat de vente d'une voiture par un garage à un particulier, dans lequel il était prévu que le contrat n'engageait le vendeur qu'après contresignature par le gérant ou le fondé de pouvoir. De prime abord, on était en présence d'une condition « purement potestative » dans la mesure où le gérant était absolument libre de contresigner ou non le contrat[1391]. Il n'en est pas ainsi en revanche si la décision que le débiteur doit prendre pour échapper à sa dette lui impose un sacrifice ou si l'appréciation de l'opportunité de l'acte à accomplir par le débiteur pour échapper à sa dette est susceptible d'un contrôle judiciaire à partir de données objectives ». La Cour considère qu'en l'espèce la décision du gérant de la société n'était pas complètement libre, car elle était liée à des considérations objectives tenant à la rentabilité de l'opération, compte tenu des conditions de reprise de l'ancien véhicule proposées à l'acheteur. « Le but de la clause n'est dès lors pas d'instaurer un déséquilibre des forces économiques en présence, et l'opportunité de l'éventuel refus de contre-signature à fournir par la société exploitant le garage est susceptible de vérification, notamment par voie d'expertise, et d'un

1390 Dans ce sens pour la France FLOUR, AUBERT, SAVAUX vol. 3 2015, n° 315 s. et les arrêts cités.

1391 L'analyse en termes de vente sous condition peut cependant être contestée : plutôt que de voir dans l'acte signé par le client et par l'employé du garage un contrat conclu sous condition de sa ratification par le garage, il était possible de dire que, l'employé n'ayant pas le pouvoir de signer le contrat définitif et d'engager le garage, il ne s'agissait que d'un projet de contrat, dans lequel le client faisait une offre (achat d'un véhicule à tel prix avec reprise de mon ancien véhicule pour tel montant), le garage étant ou non libre d'accepter cette offre. C'est cette analyse, déjà consacrée dans un arrêt ancien (Cour d'appel, 2 octobre 1931, *Pas.*, 12, p. 290), qui a servi ultérieurement à la Cour à valider l'opération dans une affaire identique à celle de 2001 et concernant le même garage : Cour d'appel, 27 avril 2005, *Pas.*, 33, p. 70 (Voy. *supra*, n° 135).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

contrôle judiciaire »[1392]. Dans un arrêt plus récent, la Cour d'appel, en se référant à la doctrine française, relève que « pour apprécier la régularité d'une clause au regard des articles 1170 et 1174 du Code civil, il convient d'analyser si elle ouvre la faculté à la partie en faveur de laquelle elle a été stipulée de mettre fin au contrat par une décision unilatérale et arbitraire, n'entraînant aucun préjudice pour elle et ne s'appuyant pas sur des motifs réels et sérieux. Si tel n'est pas le cas, la clause ne saurait être considérée comme purement potestative, partant ne saurait être soumise à la sanction de l'article 1174 du Code civil »[1393].

Ce type de raisonnement, qui réduit considérablement les cas de nullité a priori des conditions potestatives, n'est admissible que parce que le juge dispose, *a posteriori*, d'un instrument de contrôle de la manière dont le débiteur a usé du pouvoir d'appréciation que lui laisse la clause. Nous verrons en effet que, selon l'article 1178 du Code civil, si c'est le débiteur, obligé sous condition, qui a empêché l'accomplissement de celle-ci, il sera néanmoins tenu comme si la condition s'était réalisée. Lorsque la volonté du débiteur n'est pas complètement libre, mais qu'elle dépend de circonstances objectives, d'un événement extérieur ou de la décision d'un tiers, il est donc possible, sur le fondement de ce texte, de vérifier que ce sont bien ces circonstances ou éléments extérieurs – et non une volonté arbitraire – qui ont justifié le dégagement du contrat. C'est du reste ce que laisse entendre la Cour d'appel pour valider le contrat passé par le garage : le client à qui le garage refuserait finalement le contrat pourrait montrer, à l'aide d'une expertise, que la valeur de reprise de son véhicule était correcte et que c'est de manière injustifiée que le garage a rejeté la vente. De même, celui qui achète un bien sous condition de l'obtention d'un crédit sera tenu, même s'il n'obtient pas de crédit, dès lors que c'est de son fait qu'il ne l'a pas obtenu (parce qu'il ne l'a pas demandé, parce qu'il n'a pas donné suite aux propositions que lui a fait la banque, etc.). La nullité fondée sur l'article 1174 du Code civil ne s'impose donc que si la volonté du débiteur apparaît d'emblée comme totalement arbitraire et insusceptible de contrôle a posteriori. S'agissant de cas très exceptionnels où on pourrait conclure à l'inexistence de la volonté contractuelle, on peut se demander si l'article 1174 du Code civil est un texte bien utile, et si l'article 1178 du Code civil ne suffit pas à assurer la protection du créancier contre l'arbitraire[1394]. C'est sans doute pourquoi certains projets européens ont renoncé à la prohibition traditionnelle des conditions potestatives, au profit d'une règle générale sanctionnant l'immixtion du débiteur dans le jeu de la condition[1395]. Telle était également en France la position du projet Terré, mais la réforme a maintenu la solution de l'article 1174 du Code

[1392] Cour d'appel, 16 janvier 2001, *Pas.*, 32, p. 187. Voir récemment, reprenant la même formule : Trib. Luxembourg, 23 décembre 2014, n° 128.685.

[1393] Cour d'appel, 24 octobre 2018, n° 44561.

[1394] Contra : J. Flour, J.-L. Aubert, Y. Flour et E. Savaux, *Droit civil – Les obligations*, t. 3, *Le rapport d'obligation*, 5e éd., Paris, Sirey, 2007, n° 297 qui estimaient que l'article 1178 du Code civil ne peut pas jouer dans le cas d'une condition potestative, dans la mesure où le débiteur n'est engagé à rien dans cette hypothèse.

[1395] PDEC, art. 16 : 103, DCFR, art. III 1 : 106 – La prohibition des conditions potestatives est en revanche maintenue dans le Code Gandolfi (art. 54).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

civil, tout en la limitant aux cas où « condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur » (ce qui correspond à la notion traditionnelle de condition « purement potestative »).

596. Applications. L'article 1174 du Code civil fait l'objet, au Luxembourg, d'une jurisprudence abondante. On se bornera à citer ici quelques applications caractéristiques. La Cour de cassation a ainsi jugé qu'était potestative la clause d'un contrat de cession de droits de propriété intellectuelle qui subordonnait l'obligation de rémunération des inventions objet de la cession à la condition de l'exploitation effective en série de ces inventions par la société cessionnaire ou par une entité contrôlée par celle-ci. Pour la Cour, « cette condition est une condition potestative, dès lors qu'elle permet à la société d'empêcher, discrétionnairement et sans inconvénient, cette exploitation en vendant ses droits sur les inventions à une tierce personne, de sorte que l'exploitation par elle-même ou par une entité contrôlée par elle ne peut plus se faire »[1396]. En revanche n'a pas été considérée comme potestative la condition d'obtention d'un crédit bancaire « pour autant que nécessaire », parce qu'elle « dépend à la fois de la volonté de l'acheteur (qui doit entreprendre les démarches pour solliciter le prêt) et de celle d'un tiers (l'institut financier) »[1397]. De même, toujours en matière de crédit bancaire, la Cour d'appel a jugé que la clause de résiliation unilatérale d'une ouverture de crédit n'était pas une condition potestative, parce que la mise en œuvre d'une telle clause n'était pas sans conséquence pour la banque, qui, en dénonçant le contrat d'ouverture de la ligne de crédit, renonçait aux avantages pécuniaires qu'il lui procurait et notamment aux intérêts débiteurs, de sorte que cette dénonciation devait répondre à une logique économique dont les juges vérifient en l'espèce qu'elle a été respectée[1398]. Cependant, dans un arrêt plus récent, la Cour d'appel a jugé qu'était potestative une telle clause, précisant que « la banque pourra faire cesser le crédit de plein droit et exiger le remboursement immédiat des sommes dues […] en cas de diminution, dont l'appréciation appartient à la seule banque, de la valeur des garanties généralement quelconques fournies à la banque, notamment celle des immeubles hypothéqués ». La Cour estime en effet que l'appréciation de la diminution de valeur

[1396] Cass., 6 juin 2019, n° CAS-2018-00069. Voy. dans la même affaire Cass., 30 mars 2023, n° CAS-2022-00080, sur l'étendue de la nullité du contrat résultant de l'annulation de la caluse de rémunération.

[1397] Cass., 22 février 2018, n° 3863, rejetant le pourvoi contre Cour d'appel, 1er mars 2017, n° 42648.

[1398] Cour d'appel, 24 octobre 2018, préc.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

des garanties offertes était une « appréciation subjective et discrétionnaire du prêteur ne pouvant être ni contrôlée, ni contestée, de sorte que l'emprunteur reste à la merci de la volonté de son débiteur »[1399]. On voit bien à travers ces exemples l'importance, pour la qualification ou non de potestativité, du critère de la possibilité pour le juge de contrôler la décision du débiteur de se dégager du contrat.

2) *Effets de la nullité des conditions potestatives*

597. Nullité de l'obligation. Tout comme l'article 1172 du Code civil, l'article 1174 dudit Code prévoit que ce n'est pas seulement la condition potestative qui est nulle, mais l'obligation tout entière qui en dépend. Par suite, sauf lorsque l'obligation affectée de la condition peut être séparée du contrat, c'est celui-ci tout entier qui sera annulé. Cette solution, fondée sur l'idée que celui qui s'est ainsi obligé ne s'est pas vraiment obligé, est rappelée régulièrement en jurisprudence, et elle est reprise par l'article 1304-2 du Code civil français. Elle est pourtant paradoxale : le prononcé de la nullité aboutit à la même conséquence que si le débiteur avait fait jouer la condition. L'intérêt de la solution apparaît cependant lorsque c'est l'autre partie qui invoque la nullité de la condition ; cette partie va pouvoir ainsi se débarrasser du contrat, même si du reste le débiteur, lui, voudrait s'y tenir. Cela peut paraître injuste[1400], mais cette menace d'annulation peut avoir un effet dissuasif pour celui qui serait tenté de s'obliger de manière potestative. Du reste, pour supprimer la nocivité de la règle, il suffirait de dire que la nullité pour potestativité est une nullité relative, édictée pour protéger le créancier de l'obligation ainsi soumise au bon vouloir du débiteur, et qui ne peut en conséquence être invoquée que par celui-ci. L'article 1304-2 du Code civil français semble aller dans ce sens en disposant que la nullité ne peut pas être invoquée si l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. Une autre voie, peut-être préférable serait de considérer, à l'inverse, que la condition potestative est simplement réputée non écrite, ni le débiteur ni le créancier ne pouvant alors en tirer argument pour se dégager du contrat.

[1399] Cour d'appel, 15 juin 2023, n[os] CAL-2019-00973 et CAL-2019-01037.

[1400] Dans l'affaire de la vente de la voiture, le garage avait contresigné le contrat, et prétendant livrer la voiture au client. C'était celui-ci qui, pour se dégager de la vente qu'il regrettait d'avoir passé, tirait argument de la prétendue potestativité de la condition pour le garage.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§ 2. Les effets des conditions

598. Distinction. Les effets d'une condition sont fondamentalement différents selon que la condition est suspensive (**A**) ou résolutoire (**B**). Mais il existe aussi des règles communes (**C**).

A) *Effets propres à la condition suspensive*

599. Principe. On rappellera que la condition suspensive est celle qui suspend, qui subordonne l'existence de l'obligation à la survenance de l'événement incertain : tant que l'événement ne se réalise pas, l'obligation (ou les obligations) ne prend pas naissance. Si on est en présence d'une condition insérée dans un contrat, le contrat ne fait naître, pour l'instant, aucune obligation ; ce n'est que si l'événement se réalise, que les parties se trouveront obligées. Il convient donc de distinguer la situation pendant la période d'incertitude (**1**) et lors de la levée de l'incertitude (**2**).

1) *Situation pendant la période d'incertitude*

600. Obligations en suspension dans un contrat obligatoire. Selon une expression traditionnelle, la condition est pendante (*pendente conditionne*) : on ne sait pas encore si elle se réalisera, ou si elle défaillira.

L'obligation est alors en suspens, elle est conditionnelle – et le droit du créancier l'est en conséquence. Cette obligation ne saurait en conséquence faire l'objet d'aucune exécution, ni volontaire, ni forcée. Ce n'est pas à dire qu'elle soit dans le néant juridique : elle a vocation à naître. En conséquence, le créancier peut dès ce moment prendre des mesures conservatoires. Par ailleurs, le droit conditionnel constitue déjà un élément du patrimoine du créancier qui peut le céder, et qui peut être saisi par un tiers : la transmission et la saisie sont cependant affectées de la même condition que le droit lui-même.

Ce n'est pas dire que le contrat, lui, n'existe pas lorsqu'il est passé sous condition : il a même force obligatoire, et c'est cette force obligatoire qui explique le jeu de la condition ; mais la condition commande la naissance des obligations, et éventuellement des effets réels du contrat. Raisonnons sur l'exemple, très important en pratique, d'une vente d'immeuble contractée sous la condition

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

suspensive de l'octroi d'un crédit à l'acheteur[1401] : tant que le crédit n'est pas obtenu, l'acheteur n'est pas propriétaire, il n'est pas tenu de payer le prix et le vendeur n'est pas tenu de remettre les clés ; mais il serait faux de dire que la vente n'est pas formée. La vente a d'ores et déjà force obligatoire (y compris bien sûr en ce qu'elle suspend les obligations), et, en cas de litige entre les parties au sujet de la réalisation de la condition, ce litige devra être résolu par application des clauses contractuelles (par exemple, il faudra appliquer une éventuelle clause attributive de compétence contenue dans le contrat). Par ailleurs, la convention contenant une condition doit être exécutée de bonne foi par les parties : l'article 1178 du Code civil, qui sanctionne par la réalisation de la condition le comportement du débiteur qui a empêché l'accomplissement de l'événement choisi comme condition[1402], est interprété par la jurisprudence luxembourgeoise comme faisant naître une obligation de loyauté à la charge du débiteur[1403]. Cette solution, également consacrée par la Cour de cassation belge[1404], nous paraît particulièrement révélatrice de la distinction précédemment exposée entre la force obligatoire du contrat et son contenu obligationnel[1405].

2) *Situation lors de la levée de l'incertitude*

601. Défaillance de la condition – Si la condition ne se réalise pas, la ou les obligations suspendues ne prennent pas naissance. S'il s'agit d'obligations contractuelles, le contrat n'a plus de raison d'être : il devient caduc[1406]. Dans tous les cas, les actes que le créancier a pu passer sur son droit conditionnel vont se trouver rétroactivement anéantis. Il faut cependant noter que, lorsque la condition est édictée dans le seul intérêt d'une partie qu'elle a pour but de protéger, seul ce contractant bénéficiaire peut se prévaloir de la défaillance de cette condition, et son cocontractant ne peut pas l'invoquer pour échapper aux poursuites en exécution du contrat[1407]. La solution est analogue à celle qui s'applique en cas de nullité relative du contrat.

[1401] En droit français, cette condition est présumée par la loi lorsque l'acquéreur est un consommateur, même si le vendeur n'est pas un professionnel (C. Consomm. fr., art. L. 312-16).

[1402] Voy. *infra*, n° 608.

[1403] Voy. les arrêts cités *infra*, n° 608.

[1404] Cass. be., 5 juin 1981, *Pas. be.*, I, p. 1149.

[1405] P. ANCEL, n° 43.

[1406] Cour d'appel, 2 juillet 2020, *Pas.*, 40, pp. 69 et s. ; Cour d'appel, 3 juillet 2024, n° CAL-2023-00439.

[1407] Cour d'appel, 9 novembre 2016, *Pas.*, 38, pp. 295 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Comme on vient de le voir, la Cour de cassation belge a cependant, à juste titre, décidé que, si le contrat ne pouvait plus, pour l'avenir, faire naître d'obligations à la charge des parties, il avait cependant existé pendant la période antérieure[1408], et il avait pu générer des obligations autres que celles affectées par la condition, et notamment des obligations déduites de l'exigence générale de bonne foi. En conséquence, les comportements déloyaux d'une partie envers l'autre pendant la période d'attente peuvent être sanctionnés par des dommages et intérêts contractuels, indépendamment de la sanction spécifique prévue par l'article 1178 du Code civil à l'encontre du débiteur qui a empêché l'accomplissement de la condition[1409].

602. Réalisation de la condition. La réalisation de la condition suspensive, au contraire, fait naître l'obligation, transforme le droit conditionnel en un droit actuel produisant son plein effet. Si on est en présence d'un contrat translatif de propriété, le transfert, jusque-là suspendu, devient effectif. La question importante est alors de savoir à quel moment se produisent ces effets : au moment où la condition se réalise, ou, rétroactivement, dès le moment où le contrat contenant la condition a été conclu ? L'article 1179 du Code civil – texte qui vaut pour les deux types de conditions – édicte la seconde solution : l'obligation est censée être née depuis le jour où « l'engagement a été contracté ». Cette rétroactivité, qui est souvent considérée comme une fiction légale, n'est pas d'ordre public : elle peut être écartée par la convention des parties. Elle produit un certain nombre de conséquences, mais comporte aussi d'importantes limites.

La rétroactivité de l'accomplissement de la condition a pour principale conséquence la validation des actes accomplis par le créancier *pendente conditionne* : c'est ainsi que si le débiteur a payé la dette alors que la condition n'était pas encore accomplie, ce paiement qui était indu au jour où il a été fait, sera rétroactivement validé et ne pourra pas donner lieu à répétition ; c'est ainsi surtout que si le titulaire du droit conditionnel a aliéné son droit, cette aliénation va se trouver validée (c'est le cas en particulier pour un acheteur conditionnel qui aurait vendu la chose avant la réalisation de la condition). C'est d'ailleurs l'intérêt principal de la

[1408] Cass. be., 5 juin 1981, préc.

[1409] Voy. égal. : Cass. be., 15 mai 1986, *Pas. be.*, 1986, I, p. 1123 ; Cass. be., 4 avril 1993, *Pas. be.*, 1993, I, p. 353.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

rétroactivité, qui permet de conforter la situation fragile du titulaire de droit conditionnel. À l'inverse, les actes passés par l'autre partie sont en principe annulés.

Cette rétroactivité, cependant, ne saurait être poussée jusqu'au bout. Elle connaît de nombreuses limites dans les contrats translatifs de droits réels (la vente notamment). D'une part, la rétroactivité est inapplicable pour résoudre la question des risques de perte ou de la détérioration de la chose vendue : normalement si la chose périt ou est détériorée *pendente conditionne*, et que la condition se réalise ultérieurement, l'acheteur, censé propriétaire depuis la conclusion du contrat, devrait en supporter les risques. Il devrait donc payer la chose, alors même que celle-ci a été détruite. L'article 1182 du Code civil écarte cette solution : la chose demeure aux risques du débiteur (le vendeur), et le contrat se trouve résolu. D'autre part, la rétroactivité, favorable au titulaire du droit conditionnel, présente de multiples inconvénients pour l'autre partie, titulaire, lui, d'un droit sous condition résolutoire : logiquement, les actes qu'il a passés *pendente conditionne* devraient être anéantis. C'est vrai pour les actes de disposition – sauf à ce que cette nullité ne préjudicie pas aux tiers qui ignoraient l'existence de la condition[1410] – mais non pour les actes d'administration (par exemple, un bail de courte durée consenti par le vendeur d'un immeuble pendant la période d'incertitude). Par ailleurs, il est admis que le vendeur peut conserver les fruits perçus avant la réalisation de la condition[1411].

La solution du Code civil, suivie par plusieurs droits qui en sont inspirés a l'avantage principal est de consolider les actes que le créancier contractuel a pu faire sur son droit incertain entre le jour du contrat et le jour de la réalisation de la condition. Mais elle est également génératrice d'une certaine complexité dans le règlement des comptes entre les deux parties, et c'est pourquoi certains codes modernes l'ont écartée, ainsi que les différents projets européens[1412]. Cet abandon est désormais effectif en Belgique (C. civ. be., art. 5.147), ainsi qu'en France, sauf convention contraire des parties (C. civ. fr., art. 1304-5). Le nouveau droit français maintient en revanche la rétroactivité pour la condition résolutoire.

[1410] En matière mobilière, les tiers peuvent être protégés par l'article 2279 du Code civil.

[1411] Sur toutes ces limites, voy., en droit français, Flour, Aubert, Savaux, vol. 3 2015, n° 309 ; en droit belge : Van Ommeslaghe, n° 1219.

[1412] Code Gandolfi, art. 49 ; PDEC, art. 16 : 103 ; DCFR, art. III. 1 : 106.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

B) *Effets propres à la condition résolutoire*

603. Principe. Selon l'article 1183 du Code civil, la condition résolutoire est « celle qui lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation et remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé ». On peut raisonner sur l'exemple d'une donation qui a été faite par une personne actuellement sans descendants, mais qui prévoit que, pour le cas où le donataire aurait des enfants dans un certain délai, elle serait résolue et le donataire devrait restituer les biens donnés. Les rédacteurs du Code civil ont également fondé sur une condition résolutoire tacite le mécanisme de la résolution pour inexécution : selon l'article 1184 du Code civil, tout contrat synallagmatique est censé conclu sous la condition résolutoire de l'inexécution des engagements de chaque partie. Cette explication est très artificielle mais nous verrons que les effets de la résolution pour inexécution sont largement calqués sur ceux du jeu d'une condition résolutoire. Comme pour la condition suspensive, mais exactement en sens inverse, ces effets sont différents selon qu'on est dans la période d'incertitude ou à la levée de l'incertitude.

1) *Situation pendant la période d'incertitude*

604. Rien à signaler. L'obligation contractée sous condition résolutoire est déjà née : le contrat produit exactement ses effets comme s'il n'y avait pas de condition. Simplement, cette obligation (et le droit corrélatif du créancier) est affectée d'une fragilité particulière : elle est résoluble. Mais cela ne change rien, dans l'immédiat, à son régime juridique.

2) *Situation lors de la levée de l'incertitude*

605. Distinction. La *défaillance de la condition* n'a pas d'effet particulier : l'obligation, et donc le contrat, se trouve définitivement consolidés. Tous les effets sont concentrés dans le cas de la *survenance de la condition*. L'obligation s'éteint, le contrat est détruit par le jeu de ce qu'on appelle, précisément, une « résolution ». Selon l'article 1183 du Code civil, on « remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé ». C'est dire que, là encore, la condition opère de manière rétroactive. On en déduit habituellement que l'acte affecté de la condition est censé n'avoir jamais été passé, avec toutes les conséquences qui s'en infèrent pour les parties (restitutions des prestations versées) et pour les tiers (anéantissement des actes passés par le créancier conditionnel). Tout se passe comme

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

si le contrat était annulé, même si la cause de cet anéantissement rétroactif est complètement différente. Cependant cette rétroactivité connaît un certain nombre de limites. On retrouve d'abord les mêmes limites que celles qui ont été évoquées précédemment à propos de la condition suspensive : dans le cas d'une vente, on peut raisonner pour l'acheteur évincé par suite de la réalisation d'une condition résolutoire exactement de la même manière que pour un vendeur ayant vendu sous une condition suspensive qui s'est réalisée (validation des actes d'administration, conservation des fruits, etc.). Il faut y ajouter une limite spécifique : la rétroactivité de la résolution ne joue pas en principe dans les contrats à exécution successive, qui ne sont anéantis que pour l'avenir. Nous retrouverons la même solution lorsque nous étudierons la résolution pour inexécution.

L'opportunité du maintien de la solution traditionnelle est davantage discutée pour la condition résolutoire que pour la condition suspensive. C'est que, lorsqu'une condition résolutoire se réalise, le contrat a le plus souvent été exécuté, et il faudra de toute façon revenir sur ces effets passés en réglant les restitutions entre les parties. La rétroactivité est une manière traditionnelle (même si ce n'est pas la seule) de justifier cette remise en état. C'est pourquoi les projets européens sont ici partagés. Le nouveau droit français, s'il abandonne la rétroactivité pour la condition suspensive, la maintient pour la condition résolutoire, sauf à l'écarter « si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat » (C. civ. fr., art. 1304-7). L'article 5.147 du nouveau Code civil belge, quant à lui, dispose que « [l]a réalisation de la condition résolutoire donne lieu à restitution de la prestation fournie conformément aux articles 5.115 à 5.122. Toutefois, les prestations de faire et de ne pas faire, ainsi que leur contrepartie, ne sont pas restituées ».

C) *Règles communes aux deux types de conditions*

606. Problèmes généraux d'interprétation. Comme toutes les autres clauses contractuelles, les conditions ne sont pas toujours rédigées de manière suffisamment précise, de telle sorte qu'on peut parfois hésiter sur le point de savoir si la condition est ou non réalisée. L'article 1175 du Code civil pose à cet égard une règle très générale, qui n'est que la reprise, à propos des conditions, du principe d'interprétation des conventions posé à l'article 1156 du Code civil « Toute condition doit être accomplie de la manière

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût ». Bien entendu, les juges du fond ont sur ce point un pouvoir souverain.

Mais les articles 1176 et suivants du Code civil posent ensuite certaines règles plus précises, d'abord quant à l'incidence du temps, ensuite quant à l'incidence du comportement des parties.

1) *L'incidence du temps*

607. **Différents cas.** La question de l'incidence du temps est envisagée par les articles 1176 et 1177 du Code civil en fonction de deux facteurs : la nature (positive ou négative) de l'événement choisi comme condition et l'existence ou l'absence d'une durée stipulée par les parties pour sa réalisation.

1°. L'article 1176 du Code civil est relatif au cas où les parties ont choisi comme condition la survenance (positive) d'un événement. Exemple : si je me marie, si je suis au chômage, etc.

Dans ce cas, le texte fait une nouvelle distinction :

– si les parties ont fixé un terme fixe pour la réalisation de cet événement (si je me marie avant le 1er janvier 2006), la condition sera censée défaillie si ce terme arrive sans que l'événement se soit produit. C'est une évidence !

– si, en revanche, aucun terme n'a été fixé (si je me marie un jour, si je réussis à vendre ma maison, si j'obtiens un prêt, etc.), la condition ne sera censée défaillie que lorsqu'il sera devenu certain que l'événement n'arrivera pas. Jusque-là le contrat sera soumis à l'incertitude, soit qu'on ne sache pas encore s'il prendra effet ou non, soit qu'on puisse toujours craindre qu'il soit résolu. Lorsque la condition est une condition suspensive, on pourrait songer à dire qu'il y a là un engagement perpétuel, mais la cour de cassation française s'y est refusée[1413]. Le créancier se trouve alors dans une situation très inconfortable. C'est pourquoi il est admis que lorsque les parties n'ont fixé aucun délai, la condition sera réputée défaillie à l'expiration d'un délai raisonnable à compter d'une mise en demeure infructueuse du débiteur[1414]. Par ailleurs, dans certains cas, le juge pourra, par interprétation de la volonté des parties, estimer qu'il y a eu limitation implicite dans le temps de la période d'accomplissement de la condition[1415]. Les juges luxembourgeois estiment que « l'absence de terme à la réalisation des conditions n'impose pas ipso facto de maintenir le contrat pendant une durée illimitée » et reconnaissent « l'existence d'un terme implicite, en considérant que les parties ne peuvent demeurer liées indéfiniment et que, selon leur intention, elles ont dû admettre que les conditions devaient se réaliser dans un délai normal et suffisant, au-delà duquel la réalisation des conditions doit être considérée comme impossible »[1416].

[1413] Cass. fr. (1re civ.), 4 juin 1991, n° 90-11295.

[1414] Cour d'appel, 25 novembre 2021, n° CAL-2019-00311.

[1415] Cass. fr. (3e civ.), 3 février 1982, n° 80-15794 ; Cour d'appel, 22 novembre 2023, n° CAL-2022-00626.

[1416] Trib. Luxembourg, 14 novembre 2023, n° TAL-2021-02514 ; Trib. Luxembourg, 21 février 2024, n° TAL-2022-06158.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

2°. L'article 1177 du Code civil concerne le cas où les parties ont subordonné leur contrat à la non-survenance d'un événement : je vous prête de l'argent sous la condition que je ne me marie pas, le contrat sera résolu si je n'obtiens pas mon prêt, etc. Dans ce cas, « cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas ».

On retrouve des règles similaires dans l'article 5. 143 du nouveau Code civil belge. Les articles 1176 et 1177 ne sont en revanche pas repris dans le Code civil français après la réforme. Ce sont donc les règles générales d'interprétation des conventions qui s'appliqueront.

2) *L'incidence du comportement du débiteur*

608. Article 1178 du Code civil. Beaucoup plus important que les articles précédents est l'article 1178 du Code civil qui prend en compte le comportement du débiteur obligé conditionnellement : « la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ». Le texte peut aisément se comprendre à l'aide de quelques exemples : si j'ai acheté une maison sous la condition que je vende l'ancienne, et si je ne mets pas ma maison en vente, ou que je refuse sans raison tous les acquéreurs, on va faire comme si la maison avait été vendue, et je serai lié par mon achat ; si j'ai acheté une maison sous condition suspensive de l'obtention d'un crédit bancaire, et que je ne demande pas ce crédit, ou que je refuse systématiquement toutes les offres qui me sont faites par les banquiers, il serait anormal que je puisse ainsi me libérer de mon acquisition : l'article 1178 du Code civil permet de faire comme si j'avais obtenu mon prêt.

L'article 1178 du Code civil, dont on retrouve l'équivalent dans les différents projets européens[1417], est traditionnellement fondé sur la même idée que l'article 1174 du Code civil : il vise à éviter que le débiteur ne tienne le créancier à sa merci, que l'exécution de l'obligation dépende de la décision arbitraire de celui qui s'est engagé. Le texte permet alors de neutraliser l'effet de cette volonté du débiteur. Dans une approche plus moderne, on peut aussi le fonder sur l'exigence de bonne foi contractuelle : quand on s'est obligé sous condition, il est contraire à la bonne foi d'empêcher le jeu de la condition. Cette idée, qu'on trouve exprimée dans certains projets

[1417] Code Gandolfi, art. 52 (2) ; PDEC, art. 16 : 102 ; DCFR, art. III-1 : 106 (4).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

européens[1418], est également très présente dans la jurisprudence luxembourgeoise[1419]. Elle suppose qu'on considère que la condition n'affecte pas le contrat lui-même, mais seulement les obligations qu'il fait naître. Elle conduit à aller plus loin que la sanction du comportement du débiteur qui a « empêché l'accomplissement de la condition », et à faire peser sur le débiteur une obligation positive de faire tout son possible pour que la condition se réalise. La Cour de cassation a nettement consacré cette idée, en affirmant que, dans la mesure où la réalisation dépend de la volonté du débiteur, « celui-ci est tenu à certaines obligations », et en approuvant les juges d'appel d'avoir jugé « que l'article 1178 du Code civil impose à charge du débiteur qui s'engage sous une condition suspensive une véritable obligation de coopérer loyalement afin que la condition puisse se réaliser, que le débiteur doit dès lors entreprendre tout son possible pour que l'opération puisse aboutir et qu'il lui appartient d'établir qu'il a accompli les diligences nécessaires »[1420]. La même idée, qui conduit à un véritable renversement de la charge de la preuve (c'est au débiteur de prouver qu'il a accompli les diligences nécessaires), amène à élargir le domaine d'application du texte : l'exigence de bonne foi ne vaut pas seulement pour le débiteur, mais aussi pour le créancier, et on doit sanctionner de la même manière le créancier qui empêche l'accomplissement de la condition s'il y a intérêt (par exemple, un vendeur, qui, regrettant d'avoir vendu, ferait tout pour que son acheteur n'obtienne pas son crédit). La règle – qui a été écrite pour la condition suspensive – est par ailleurs bilatéralisable : de même qu'il faut réputer réalisée la condition suspensive dont le débiteur a empêché l'accomplissement, de même il y a lieu de réputer défaillie la condition résolutoire dont le débiteur a provoqué la réalisation. Les nouveaux textes français (C. civ. fr., art. 1304-3) et belges (C. civ. be., art. 5.144) prévoient expressément cette application à la condition résolutoire. Dans les deux pays, la règle est par ailleurs doublée par une règle plus générale qui met à la charge du débiteur l'obligation de ne pas compromettre les droits de l'autre partie (C. civ. fr., art. 1304-5, C. civ. be., art. 5.146).

[1418] Cette référence à la bonne foi est expressément retenue par l'article 16 : 102 des PDEC ainsi que par l'article III-1 : 106 du DCFR. Voy. aussi Principes UNIDROIT art. 5.3.3.

[1419] Cass., 14 juillet 2009, *Pas.*, 34, p. 413 ; Cour d'appel, 28 juin 2000, *Pas.*, 31, p. 395 (qui sanctionne les « manœuvres déloyales » d'un « tricheur ») ;

[1420] Cass., 14 juillet 2009, *Pas.*, 34, p. 413 ; Voy. récemment Cour d'appel, 20 juillet 2024, n° CAL-2023-00122.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

La jurisprudence luxembourgeoise récente connaît de nombreuses applications de l'article 1178 du Code civil. La plupart concernent l'hypothèse de l'acheteur qui cherche à échapper à son acquisition en ne déployant aucun effort pour obtenir son crédit[1421]. Mais on peut aussi citer le cas d'un lotisseur qui a acquis un terrain, en stipulant que le prix ne serait payable que le jour où toutes les autorisations nécessaires au lotissement auront été obtenues, et qui omet de faire les diligences nécessaires afin d'obtenir un vote favorable de la part du conseil communal et en faisant même obstruction aux démarches des vendeurs auprès de ce conseil : pour la Cour d'appel, il commet, par négligence et manque de loyauté, une faute empêchant l'accomplissement de la condition stipulée, et il faut en conclure que la condition suspensive prévue au contrat de vente est réputée accomplie[1422].

SECTION 2. LES OBLIGATIONS PLURALES

609. Pluralité d'objets et de sujets. Un rapport d'obligation simple a un seul objet, et lie un seul créancier à un seul débiteur. Très souvent, cependant, l'obligation porte sur plusieurs objets (**Sous-section 1**) ou a plusieurs sujets actifs ou passifs (**Sous-section 2**). Une présentation pédagogique aussi artificielle que traditionnelle regroupe ces différentes situations, très différentes les unes des autres, sous le nom d'obligations plurales.

SOUS-SECTION 1. LA PLURALITÉ D'OBJETS DE L'OBLIGATION

610. Obligations conjonctives. Lorsqu'un débiteur s'oblige à plusieurs choses envers le créancier, ces différents objets peuvent être d'abord être cumulatifs : le vendeur d'une cuisine, par exemple, s'oblige à la fois à livrer et à installer les différents éléments du mobilier. On parle ici d'obligations conjonctives. Ou, selon la terminologie du nouvel article 1306 français, d'obligations cumulatives. Dans un tel cas, le débiteur ne sera libéré que s'il a effectué les différentes prestations. Il est difficile – et sans grand intérêt pratique – de distinguer ce cas de celui où le contrat fait naître plusieurs obligations distinctes.

611. Obligations alternatives. Plus rarement, le débiteur s'oblige, de manière alternative, à effectuer une prestation ou une autre. Dans ce cas, prévu par le Code civil sous le nom d'obligation alternative, le débiteur « est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation » (C. civ., art. 1189). Comme le relève le tribunal de Luxembourg dans une décision récente, ce type d'obligation doit être distingué d'une obligation sous condition potestative : le débiteur est bien obligé, mais il choisit la manière d'exécuter son obligation[1423]. Par exemple, il peut être prévu dans un contrat de prêt que l'emprunteur pourra rembourser, soit en espèces, soit en transférant au créancier la propriété de titres, ou encore qu'il pourra choisir la monnaie dans laquelle il remboursera. En principe le choix appartient au

[1421] Cass., 14 juillet 2009 ; Cour d'appel, 28 juin 2000, préc. ; Cour d'appel, 7 février 2024, n° CAL-2022-00723.

[1422] Cour d'appel, 12 novembre 2003, *Pas.*, 32, p. 426.

[1423] Pour une application récente, voy. Trib. Luxembourg, 6 juillet 2023, n° TAL-2023-01344.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

débiteur, mais les parties peuvent convenir que c'est le créancier qui choisira (C. civ., art. 1190). Dans un tel cas, si l'un des deux objets de l'obligation vient à disparaître, l'obligation devient pure et simple, et le débiteur doit fournir l'autre (C. civ., art. 1192). Le tribunal de Luxembourg a eu l'occasion de préciser, dans la période récente, que la perte de valeur d'un des deux objets n'équivalait pas à sa disparition ; le débiteur peut alors se libérer en fournissant la chose qui a le moins de valeur, le créancier supportant le risque de cette alternative[1424]. Les règles relatives aux obligations alternatives sont aujourd'hui reprises dans les articles 1307 à 1307-5 du Code civil français, et par l'article 5.157 du Code civil belge.

612. Obligations facultatives. Il arrive que le débiteur s'oblige, à titre principal, à fournir un certain objet, mais qu'il puisse choisir, à titre subsidiaire, d'en fournir un autre (généralement à certaines conditions que le contrat précisera). Dans ce cas, rare en pratique et non prévu par le Code civil, la doctrine parle d'obligation facultative. La catégorie est explicitement consacrée par l'article 1308 nouveau du Code civil français et par l'article 5.158 du nouveau Code civil belge sous le nom d'obligation à prestation subsidiaire. La différence avec les obligations alternatives tient aux incidences de la force majeure qui rend impossible la fourniture de l'objet principal : alors que, dans les obligations alternatives, où les deux objets sont sur le même plan, cette disparition ne libère pas le débiteur, si l'obligation est facultative, la disparition de l'objet principal entraînera l'extinction de l'obligation.

SOUS-SECTION 2. LA PLURALITÉ DE PARTIES

613. Problématique. Une obligation peut avoir plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers. Il suffit de penser, par exemple, à un emprunt qui a été contracté par deux personnes vivant en couple, ou, à l'inverse à un prêt que ces deux personnes font ensemble à un de leurs amis. La question est alors de savoir, dans le premier cas, si chaque débiteur peut être tenu de payer la totalité au créancier, ou, dans le second, si chaque créancier peut demander paiement de la totalité de la somme prêtée au débiteur. La réponse à ces questions a pu varier historiquement, et elle n'est pas nécessairement la même dans tous les pays, car elle dépend de considérations de politique juridique : quelle partie au rapport d'obligation veut-on favoriser ?

C'est particulièrement évident en cas de pluralité de débiteurs. Si on pose que le créancier ne peut demander à chaque débiteur que sa part, cela signifie que ce dernier va devoir multiplier les poursuites pour se faire payer, et, surtout, qu'il supportera le risque de l'insolvabilité de l'un des codébiteurs. À l'inverse, si chaque codébiteur est tenu pour le tout vis-à-vis du créancier (sauf ensuite son recours

[1424] Trib. Luxembourg, 27 janvier 2005, n° 79059, cité par POELMANS, n° 329 (dans une hypothèse où une banque émettrice d'obligations pouvait rembourser les prêteurs soit en espèces soit en actions d'une société. Selon le tribunal, le fait que la société ait été mise en faillite, et que les actions aient perdu toute valeur réelle, n'interdisait pas à la banque de se libérer avec ces titres).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

contre le ou les autres), le créancier pourra obtenir son entier paiement même si l'un des débiteurs est insolvable, et c'est celui qui a payé qui, ne pouvant récupérer ce qui excède sa part, supportera cette insolvabilité. Cette seconde solution est donc beaucoup plus favorable au crédit que la première, mais elle est évidemment beaucoup plus dure pour les débiteurs.

On doit faire le même choix – bien qu'avec de moindres enjeux – lorsqu'il existe plusieurs créanciers : il paraît *a priori* plutôt normal que chaque créancier ne puisse demander que sa part, mais si on raisonne sur l'exemple du couple qui a prêté à un ami, cela va obliger chaque conjoint à demander remboursement de son côté, ce qui peut coûter en temps et en argent. Mais la solution inverse, à première vue plus commode, peut s'avérer dangereuse pour le créancier qui n'a pas obtenu le paiement, car il aura peut-être du mal à récupérer sa part.

614. Principe de division de l'obligation. Le Code civil distingue d'une manière générale, les obligations qui sont divisibles de celles qui ne le sont pas (C. civ., art. 1217 et s.). Par nature, certaines obligations ne sont susceptibles d'être exécutées qu'en totalité, de sorte que, même si elles ont plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, chaque créancier ne peut qu'en demander l'exécution, et chaque débiteur doit cette exécution totale : il en va ainsi, par exemple, de l'obligation de livrer une chose elle-même non susceptible d'être divisée (un animal, une voiture) ; si deux personnes vivant en couple, par exemple, ont vendu ensemble une telle chose, il va de soi que l'acheteur peut demander à chaque conjoint de lui remettre la chose entière. On ne conçoit pas que le mari dise : moi, je ne vous donne que la moitié de la voiture, demandez à ma femme de vous livrer l'autre moitié ! Mais, pour toutes les autres obligations, qui n'ont pas pour objet une chose ou une prestation indivisible – et notamment pour les plus importantes d'entre elles, les obligations de somme d'argent – le principe est que, à défaut d'une loi ou d'une stipulation contraire, l'exécution de ces obligations se divise, tant entre les différents créanciers qu'entre les différents débiteurs. S'il existe plusieurs créanciers, chaque créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que sa part au débiteur. Et à l'inverse, lorsqu'une obligation divisible a plusieurs débiteurs, chacun des codébiteurs n'est tenu en principe envers le créancier que d'une partie de la dette. Ce principe n'est pas posé d'une manière générale par le Code civil, qui n'en énonce qu'une application particulière à l'égard des héritiers du

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

débiteur ou du créancier : ceux-ci, nous dit l'article 1220 du Code civil, « ne peuvent demander la dette ou ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur »[1425]. Mais le principe vaut aussi bien lorsque, dès le départ, l'obligation est née au profit de plusieurs créanciers ou à la charge de plusieurs débiteurs : chacun ne peut demander ou n'est tenu que d'une partie de sa dette. On traduit habituellement cette règle, régulièrement rappelée en jurisprudence[1426], en disant que l'obligation est conjointe, ou simplement conjointe – expressions particulièrement malheureuses parce qu'elles laissent croire que les débiteurs sont engagés ensemble, alors que précisément ils sont tenus séparément. Il vaudrait mieux parler, comme le fait la version francophone des PDEC, d'obligations « disjointes » [PDEC, art. 10 :101 (2)]. Ce principe de divisibilité de l'obligation, tant du côté actif que du côté passif, est aujourd'hui posé de manière générale par l'article 5.159 du nouveau Code civil belge et par l'article 1309 du Code civil français.

Ce principe, cependant, est loin d'être absolu, et il ne s'appliquera qu'assez rarement en pratique. Dans de très nombreux cas, en effet, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention passée entre les parties au rapport d'obligation, cette division est écartée, surtout entre les débiteurs, plus rarement entre les créanciers d'une dette normalement divisible. Deux mécanismes, d'inégale importance, permettent d'arriver à ce résultat, celui de la *solidarité* (**§ 1**) et celui de *l'indivisibilité* de la dette (**§ 2**).

Ce système, qui pose la division de l'obligation en solution de principe, est loin d'être admis de manière unanime en droit comparé. Si la division du côté des créanciers – qui présente plus d'avantages que d'inconvénients – est à peu près partout admise, il n'en va pas de même du côté des débiteurs. Plusieurs droits étrangers posent en principe, à l'inverse, que, en cas de pluralité de débiteurs, chacun est tenu de toute la dette – sauf texte ou stipulation contraire[1427], et cette solution, plus favorable au crédit et plus en accord avec la pratique contractuelle courante, est reprise par tous les projets européens.[1428]La différence avec le système du Code civil est cependant fortement atténuée par le fait que, dans les trois pays du Code, la jurisprudence admet que la solidarité se présume en matière commerciale.

[1425] La solution est reprise, pour le paiement des dettes de la personne décédée, par les articles 870 et 873 du Code civil.

[1426] Voy. p. ex. Cour d'appel, 1er avril 2009, *Pas.*, 34, p. 512.

[1427] Voy. p. ex. : Codice civile italien, art. 1294 ; BGB, § 497 (pour les dettes contractuelles seulement).

[1428] Code Gandolfi, art. 88 ; PDEC, art. 10 : 101 ; DCFR, art. III-4 : 103. Voy. aussi Principes Unidroit, art. 11.1.2.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§ 1. La solidarité

615. Distinction. Les obligations solidaires sont régies par les articles 1197 et suivants du Code civil, qui distinguent la solidarité entre les créanciers (active) et la solidarité entre les débiteurs (passive).

A) *La solidarité active*

616. Principe et applications. La solidarité entre les créanciers (ou solidarité active) est une modalité d'une obligation qui comporte plusieurs créanciers : elle permet à chaque créancier de demander au débiteur l'intégralité du paiement (sauf naturellement à reverser ensuite aux autres ce qui excède sa part). C'est un mécanisme dangereux pour les créanciers, car le créancier qui n'a rien reçu peut craindre que l'autre ne lui reverse pas sa part. Pour cette raison, c'est un mécanisme rare en pratique, qui suppose que règne une confiance mutuelle entre les différents créanciers. Une telle confiance doit régner en particulier entre les cotitulaires d'un compte joint, qui constitue la principale application pratique de la solidarité active[1429] : le principe d'un tel compte est en effet que chaque cotitulaire peut retirer de l'argent du compte, et même demander au banquier de lui verser l'intégralité du solde créditeur, sans avoir besoin de l'accord de l'autre[1430].

L'article 1197 du Code civil dispose que « l'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance », ce qui signifie que cette solidarité ne peut reposer que sur une convention entre les créanciers et le débiteur. Si plusieurs personnes ouvrent ensemble un compte bancaire sans préciser qu'il s'agit d'un compte joint, ce compte fonctionnera sous la signature commune des cotitulaires[1431]. Les effets de cette solidarité sont réglés très sommairement par les articles 1198 et 1199 du Code civil. On peut, d'une manière générale, transposer les règles beaucoup plus détaillées établies pour la solidarité passive.

[1429] Cour d'appel, 1er août 2012, n° 37183 ; Cour d'appel, 6 juin 2018, n° 44627.

[1430] Cour d'appel, 11 juillet 1997, *Pas.*, 30, p. 405. Un tel compte entraîne en même temps solidarité passive, en ce que, si le solde est débiteur, chaque titulaire en est tenu pour le tout vis-à-vis de la banque.

[1431] Voy. dans ce sens : Cass. fr. (1re civ.), 16 juin 1992, n° 90-18209.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

B) *La solidarité passive*

617. Principe. L'hypothèse est que le créancier a plusieurs débiteurs, et il peut demander à chacun la totalité de la dette (C. civ., art. 1200). La solidarité constitue donc, pour le créancier, une garantie contre l'insolvabilité de ses codébiteurs, et c'est, à ce titre, une institution très importante en droit du crédit. On en étudiera successivement les conditions (**1**) et les effets (**2**).

1) *Les conditions de la solidarité*

618. Sources. Aux termes de l'article 1202 du Code civil : « La solidarité ne se présume pas ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition expresse de la loi ».

Il résulte de ce texte que la solidarité peut avoir deux sources : elle peut être soit conventionnelle (**a**), soit légale (**b**). Cependant, allant à l'encontre de la lettre de ce texte, la jurisprudence admet traditionnellement des cas de solidarité non prévus par la loi (**c**).

a. *La solidarité conventionnelle*

619. Clause expresse. Lorsque la dette est civile, et en dehors des cas où elle est prévue par la loi, la solidarité suppose une stipulation expresse du contrat liant le créancier aux codébiteurs[1432]. Cette stipulation ne suppose cependant pas l'emploi d'une formule sacramentelle : il suffit qu'il soit clairement indiqué dans l'acte que chaque codébiteur sera tenu de la totalité de la dette vis à vis du créancier.

b. *La solidarité légale*

620. Fondements divers. De nombreux textes, dans le Code civil ou dans des lois séparées, prévoient que deux ou plusieurs débiteurs engagés dans certaines circonstances sont tenus solidairement envers le créancier. Sans pouvoir donner ici une énumération exhaustive de ces textes, on se contentera, à partir de quelques exemples, de souligner les différents fondements qui peuvent justifier une telle solidarité. La plupart du temps, c'est l'idée de communauté d'intérêts entre les débiteurs qui est à la base de ces textes. On citera ici en premier lieu l'article 220 du Code civil qui édicte la solidarité

[1432] Pour une application : Cour d'appel, 19 juillet 2013, n° 38552.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

entre époux pour les dettes liées à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants. De même, selon l'article 14 de la loi de 1915 sur les sociétés, les associés d'une société en nom collectif sont solidairement (et indéfiniment) responsables des dettes sociales. On peut encore signaler la solidarité entre les co-mandants (C. civ., art. 2002 – mais non entre les co-mandataires : C. civ., art. 1995) ou entre les co-emprunteurs dans le prêt à usage (C. civ., art. 1887)[1433]. Dans d'autres cas, c'est plutôt la faveur que le législateur manifeste à l'égard du créancier qui justifie la solidarité : c'est ainsi que, pour assurer une protection particulière des victimes d'infractions contre l'insolvabilité fréquente des délinquants, l'article 50 du Code pénal prévoit que « tous les individus condamnés pour une même infraction, sont tenus solidairement des restitutions et des dommages et intérêts ». Le texte ne s'applique pas aux dommages et intérêts résultant d'un délit civil, mais il est alors relayé par le mécanisme jurisprudentiel de l'obligation *in solidum*.[1434]

c. *Extensions jurisprudentielles*

621. Solidarité en matière commerciale. Bien que l'article 1202 du Code civil exige, pour qu'il y ait solidarité, soit une stipulation conventionnelle expresse, soit une disposition expresse de la loi, la jurisprudence, dans les trois pays du Code civil, admet depuis longtemps que la solidarité se présume en matière commerciale. En France, la solution remonte à un arrêt de 1920, elle a été reprise par la Cour de cassation belge en 1952. Au Luxembourg, où il est difficile de retrouver sa première consécration, elle est régulièrement réaffirmée dans la jurisprudence récente[1435]. Cette règle est traditionnellement présentée comme étant d'origine coutumière, et elle apparaît comme l'exemple type d'une consécration jurisprudentielle d'une coutume *contra legem*. Un jugement récent du tribunal de Luxembourg en explique les raisons « le but de cet usage est de renforcer le crédit des codébiteurs et d'inciter le créancier à contracter,

[1433] Précision importante : le prêt à usage (ou commodat) s'entend du prêt d'une chose non fongible, que l'emprunteur doit restituer en nature après s'en être servi (prêt d'une voiture, d'un appartement, etc.). Il ne faut pas le confondre avec le prêt de consommation, qui porte sur des choses fongibles dont l'emprunteur rendra l'équivalent après les avoir consommées (prêt d'argent notamment). L'article 1887 du Code civil ne s'applique pas au prêt de consommation, pour lequel la solidarité ne peut résulter que d'une stipulation expresse.

[1434] Voy. *infra*, n° 622.

[1435] Cour d'appel, 1er juillet 1992, n° 11552 ; 10 juillet 2013, n° 38314 ; Trib. Luxembourg, 14 juillet 2001, n° 47983 ; 9 décembre 2014, n° 154-410, citant abondamment des sources doctrinales françaises ; Cour d'appel, 12 juin 2024, n° CAL-2022-00860.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ce qui est essentiel à la promotion des transactions commerciales et au bon développement du commerce »[1436]. La portée exacte de la règle est cependant discutée : alors qu'en France la jurisprudence applique la solution à toutes les obligations commerciales[1437], la Cour de cassation belge ne l'applique qu'aux obligations contractuelles à l'exclusion d'autres sources d'obligations[1438]. Le caractère exceptionnel de la règle nous semble commander cette interprétation restrictive. L'article 5.160 du nouveau Code civil belge définit de manière précise le champ de cette solidarité commerciale : « Elle existe de plein droit entre des entreprises, au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique, qui sont tenues à une même obligation contractuelle. Cette règle ne s'applique toutefois pas lorsque l'entreprise est une personne physique et que son obligation contractuelle est manifestement étrangère à l'entreprise. »

622. Obligation *in solidum*. On a vu précédemment que, dans le cas où une infraction a été commise par plusieurs personnes, le Code pénal prévoit expressément la solidarité de ces co-auteurs pour le paiement des dommages et intérêts. Au-delà de ce cas particulier, la jurisprudence française a admis, depuis le XIXe siècle, que la victime d'un dommage causé par plusieurs personnes peut demander l'intégralité de la réparation à chacun des co-auteurs de ce dommage. Cette solution a été suivie en Belgique (non sans quelques réticences) et au Luxembourg, où elle apparaît en jurisprudence dès la fin du XIXe siècle[1439]. On considère depuis longtemps, cependant, qu'il ne s'agit pas là d'un véritable cas de solidarité passive : on a d'abord parlé en doctrine de « solidarité imparfaite »[1440], avant que ne s'impose, dans les trois pays du Code civil, l'expression « obligation *in solidum* ». Cette différence de terminologie traduit, dans l'opinion majoritaire, une différence de nature avec le mécanisme de la solidarité : on explique habituellement que, si chaque co-auteur est tenu de réparer l'intégralité du dommage, ce n'est pas en tant que garant des autres, mais parce qu'il est censé (dans une logique d'équivalence des conditions) avoir causé en entier ce dommage, dès lors que, sans son intervention, ce dommage ne se serait pas

1436 Trib. Luxembourg, 9 décembre 2014, préc.

1437 Sur le domaine de la solidarité commerciale en droit français, voy. M. MIGNOT, *JCl Civil*, art. 1197 à 1216 fasc. 20, nos 129 et s.

1438 Cass. be., 1er octobre 1981, *Pas. be.*, 1982, I, p. 171.

1439 Cour d'appel, 24 janvier 1874, *Pas.*, 1, p. 403. La solution est constante depuis ; Voy. récemment : Trib. Luxembourg, 6 mars 2024, n° TAL-2022-03134.

1440 Expression encore utilisée par Cass. fr., 17 juillet 1968, no 64-14264.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

produit. À la différence des codébiteurs solidaires, qui ne sont, fondamentalement, débiteurs que d'une partie de la dette commune, les coresponsables d'un même dommage sont, chacun, débiteurs de l'entière réparation[1441]. Cette analyse, cependant, permet assez mal d'expliquer, sinon par une vague considération d'équité, que le coresponsable qui a réparé l'entier dommage ait un recours contre les autres responsables, alors pourtant qu'il n'a fait que payer sa dette. C'est pourquoi, en France, dans les années 1960-1970, un certain courant doctrinal a contesté l'analyse traditionnel, en partant de l'idée que chaque coauteur n'est responsable que d'une partie du dommage, et n'est donc débiteur que d'une partie de la réparation ; l'obligation *in solidum* ne se justifierait que par faveur pour la victime, et apparaîtrait comme une simple garantie de paiement tout à fait analogue à la solidarité. Cette analyse a été admise un temps par la jurisprudence, qui en déduisait que l'obligation *in solidum* ne jouait pas lorsque l'un des co-auteurs, pour des raisons de fait ou de droit, n'était pas responsable envers la victime, le ou les autres, n'ayant pas de recours contre lui, ne devant alors payer que des dommages et intérêts correspondant à la part du dommage qu'ils avaient causé. Mais cette solution, très défavorable aux victimes, a été ensuite abandonnée et on est revenu à l'explication classique fondée sur l'idée d'une obligation au tout de chaque co-auteur. C'est cette explication qui a été très nettement consacrée par la Cour de cassation du Luxembourg dans un arrêt de 1975, pour lequel « chacun des responsables d'un dommage ayant concouru à le causer en entier est tenu d'en assurer la réparation intégrale, même si un recours de la victime envers l'un des coauteurs s'avère impossible pour une raison de fait ou de droit, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un éventuel partage des responsabilités prononcé par les juges du fond entre divers coauteurs, ce partage n'affectant que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée n'ayant pas commis de faute »[1442].

Une étude plus précise du domaine, des conditions, et des effets de l'obligation *in solidum* relève d'un ouvrage consacré à la responsabilité civile[1443]. Notre propos ici était seulement de montrer en quoi cette obligation se différencie d'une obligation solidaire *stricto sensu*. Cette différence se traduit en particulier quant aux effets des deux mécanismes.

[1441] Voy. p. ex. pour cette analyse dans la jurisprudence luxembourgeoise : Trib. Luxembourg, 27 mars 1954, *Pas.*, 16, p. 181 ; Cour d'appel, 25 octobre 1961, *Pas.*, 18, p. 387.

[1442] Cass. (crim.), 26 juin 1975, *Pas.*, 23, p. 116. Cour d'appel, 10 juillet 2013, n° 38194.

[1443] Voy. Ravarani, n°s 1016 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

2) *Les effets de la solidarité*

623. Dissociation des rapports juridiques. Quand on se demande de quoi exactement sont tenus les codébiteurs solidaires, la question peut viser deux types de rapports. Une chose est de savoir combien le créancier peut demander à chaque codébiteur et à quelles conditions il peut le faire – c'est ce qu'on appeler l'obligation à la dette – une autre chose est de savoir quelle part de la dette chaque codébiteur doit définitivement supporter, comment la dette va se partager entre les différents codébiteurs – ce qu'on peut nommer la contribution à la dette. La solidarité se traduit par un décalage entre ces deux aspects. Cette terminologie souvent employée en matière de régimes matrimoniaux lorsqu'on se demande quelle part chaque époux doit prendre dans les dettes communes peut être transposée ici : la solidarité n'affecte que l'obligation à la dette (**a**), elle ne modifie pas la part contributive de chaque codébiteur dans ses rapports avec les autres (**b**).

a. *Les rapports du créancier avec les codébiteurs : l'obligation à la dette*

624. Effets principaux et secondaires. Selon une terminologie traditionnelle – reprise par le nouveau droit belge – on distingue les effets principaux de la solidarité, qui touchent en quelque sorte à la substance de l'obligation (1°) de que ce qu'il est convenu d'appeler ses effets secondaires, qui concernent sa mise en œuvre (2°).

1°. *Les effets principaux*

625. Unité d'objet, pluralité de liens. On résume souvent les effets de la solidarité à travers une formule doctrinale : unité d'objet, pluralité de liens obligatoires[1444]. Unité d'objet en ce que chaque débiteur est tenu à la même chose envers le créancier ; pluralité de liens obligatoires en ce que chaque dette peut conserver un certain particularisme, chaque codébiteur peut être tenu de manière différente. Il en résulte que, si chaque débiteur est tenu au tout envers le créancier, cela n'empêche pas chaque codébiteur de faire valoir des moyens de défense, des exceptions, qui lui sont propres.

626. Obligation au tout de chaque codébiteur. Le créancier peut demander l'entier paiement à l'un des codébiteurs, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division (C. civ., art. 1203, C. civ. fr.,

[1444] Voy. p. ex. VAN OMMESLAGHE, n°s 1249 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

art. 1313, C. civ. be., art. 5.161)), c'est à dire lui demander de diviser ses poursuites. Il peut agir à la fois contre tous les codébiteurs, ou, tant qu'il n'est pas payé, successivement contre l'un puis contre l'autre : les poursuites faites contre l'un n'empêchent pas de poursuivre ensuite les autres (C. civ., art. 1204), et, selon la jurisprudence, il n'est même pas tenu, lorsqu'il poursuit un codébiteur, de mettre en cause les autres[1445]. Ces règles sont doublement intéressantes pour le créancier. D'abord, il n'a pas à diviser ses poursuites ; il peut se contenter d'agir contre un seul des codébiteurs, d'où un gain de temps et d'argent. Ensuite, si un des débiteurs est insolvable, le créancier peut tout de même espérer être payé puisqu'il peut demander la totalité aux autres.

Il faut cependant relever que cette obligation au tout ne vaut que contre les codébiteurs eux-mêmes, tant qu'ils sont vivants. Si l'un des codébiteurs solidaires décède, la solidarité ne cesse pas, mais la dette globale dont était tenu le débiteur décédé se divise entre ses cohéritiers : le créancier ne peut donc demander à chaque cohéritier qu'une fraction de ce qu'il pouvait demander à l'auteur décédé. Il n'en va autrement que dans le cas où la dette est indivisible (C. civ., art. 1219 et 1220, C. civ. be., art. 5.165, C. civ. fr., art. 1309).

627. Exceptions opposables par les codébiteurs solidaires. Chaque codébiteur peut invoquer un certain nombre d'exceptions[1446], de moyens de défense vis à vis du créancier. L'article 1208 du Code civil introduit à ce sujet une distinction d'application délicate entre différents types d'exceptions.

Chaque codébiteur peut opposer toutes les exceptions qui lui sont personnelles (par exemple : son incapacité, un vice du consentement), ainsi que les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs (par exemple : tous les débiteurs ont été victimes du même vice du consentement) ou qui résultent de la nature de l'obligation (par exemple : la nullité du contrat pour atteinte à l'ordre public). En revanche, il ne peut pas faire valoir les exceptions qui sont purement personnelles à l'un de ses codébiteurs : par exemple, il ne peut soulever l'incapacité de l'un de ses codébiteurs ou le vice du consentement dont il a été victime (ce qui n'est qu'une conséquence du caractère relatif de la nullité pour ces causes). Des

[1445] Trib. Luxembourg, 4 janvier 1893, *Pas.*, 3, p. 78.

[1446] Le Code utilise fréquemment ce terme d'exceptions pour désigner les moyens de défense opposables par un débiteur à un créancier (Voy. *infra*, n° 1015 à propos de la cession de créance).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

solutions particulières existent pour différentes causes d'extinction de l'obligation : confusion (C. civ., art. 1209), novation (C. civ., art. 1281), remise de dette (C. civ., art. 1285), compensation (C. civ., art. 1294). Le nouvel article 1315 du Code civil français, de même que l'article 5.162 du nouveau Code civil belge reprennent, en l'assortissant d'exemples, la distinction entre exceptions personnelles et exceptions communes.

Dans les hypothèses où le codébiteur solidaire à qui le paiement est demandé n'est pas admis à soulever les exceptions purement personnelles à un de ces codébiteurs, un problème délicat peut surgir lors du recours, si l'exception est de nature à entraîner la nullité, l'extinction ou la diminution de la dette du débiteur qui peut l'invoquer. En effet, le codébiteur solidaire qui aura payé pourra, lors de son recours, se voir opposer par l'autre l'extinction ou la diminution de sa dette, de sorte que la charge de la dette se trouve alors alourdie pour les débiteurs qui restent tenus. Pour éviter cela, le nouvel article 1315 du Code civil français prévoit que le codébiteur solidaire peut se prévaloir de l'exception pour faire diminuer sa part

2°. *Effets secondaires*

628. Effets procéduraux. La solidarité produit aussi ce qu'on appelle des effets secondaires, d'ordre procédural. L'idée générale est que les actes de procédure faits par ou contre un des codébiteurs solidaires doivent produire des effets à l'égard des autres. Il s'agit de renforcer l'efficacité de la solidarité, en dispensant le créancier de mettre en cause tous les débiteurs. Ces effets secondaires ne jouent pas dans le cadre particulier de l'obligation *in solidum*[1447].

Certains de ces effets secondaires ont été prévus par le Code civil. Ainsi, les actes de poursuite faits par le créancier contre l'un seul des codébiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard des autres (C. civ., art. 1206). La mise en demeure de l'un fait courir les intérêts pour les autres (C. civ., art. 1207) ou, en cas d'obligation de livrer une chose, met cette chose aux risques de tous les codébiteurs (C. civ., art. 1205).

Partant de ces solutions particulières, la doctrine française, au XIXe siècle, a posé en règle générale que les codébiteurs solidaires se représentent mutuellement dans leurs rapports avec le créancier. Cette théorie de la représentation mutuelle, qui a inspiré diverses solutions jurisprudentielles en France, n'a pas été reçue en Belgique, où on estime que la solidarité ne peut pas produire d'autres effets que ceux qui sont

[1447] Cour d'appel, 20 février 2001, n° 23798.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

prévus par la loi[1448]. La jurisprudence luxembourgeoise, en revanche, n'a pas hésité à aller au-delà des textes légaux, et on y trouve mention du principe de représentation mutuelle[1449]. Ainsi il est admis que la chose jugée dans les rapports entre le créancier et un codébiteur solidaire vaut à l'égard des autres[1450], ou que l'appel formé par un des codébiteurs profite aux autres, qui n'auront pas besoin de faire un appel incident[1451].

La théorie de la représentation mutuelle a cependant été corrigée par l'idée que la représentation ne pouvait jouer que dans un sens favorable aux codébiteurs, mais qu'elle ne pouvait pas aboutir à aggraver leur situation. Ainsi, si un codébiteur transige avec le créancier, cette transaction peut profiter aux autres débiteurs, mais non pas leur nuire[1452]. Cette règle ne s'applique pas cependant en ce qui concerne la chose jugée : ce qui a été jugé dans les rapports entre le créancier et un codébiteur solidaire vaut à l'égard des autres, que le jugement ait été défavorable ou favorable[1453], car le jugement, déclaratif d'une situation antérieure, ne saurait être considéré comme aggravant cette situation.

Les nouveaux textes belges et français n'ont pas consacré d'une manière générale cette théorie. Il n'en ont consacré que certains aspects, soit dans le cadre des textes sur la solidarité (C. civ. fr., art. 1314, C. civ. be., art. 5.163), soit à propos des différents mécanismes concernés (confusion, remise de dette, prescription…)

b. *Les rapports des codébiteurs entre eux : la contribution à la dette*

629. Détermination de la part de chaque codébiteur. La solidarité n'affecte que l'obligation à la dette envers le créancier ; elle ne modifie pas la part contributive de chaque codébiteur, qui pourra donc, s'il a payé plus que cette part, se retourner contre les autres. C'est ce que pose clairement l'article 1213 du Code civil, selon lequel « L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ». Encore faut-il déterminer quelle est la « part et portion de chacun ». En principe, la répartition de la charge de la dette se fait de manière égalitaire en fonction du nombre de débiteurs[1454], mais d'autres bases de répartition peuvent avoir été convenues entre les intéressés ou résulter des circonstances. C'est alors, dit la jurisprudence à celui qui soutient

[1448] VAN OMMESLAGHE, n° 1253.

[1449] Cass., 28 avril 2022, n° CAS-2021-00052 ; Cour d'appel, 16 janvier 2002, n°s 24052 et 24175.

[1450] Cour d'appel, 12 janvier 2006, *Pas.*, 33, p. 130.

[1451] Cour d'appel, 5 avril 2000, *Pas.*, 31, p. 321.

[1452] Cour d'appel, 16 janvier 2002, préc. Comp. en droit français : Cass. fr. (comm.), 28 mars 2006, n° 04-12197.

[1453] Cour d'appel, 12 janvier 2006, préc.

[1454] On parle traditionnellement d'une répartition par « parts viriles », mais cette expression, marquée par une représentation masculine du monde, est aujourd'hui désuète.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

que la répartition doit se faire de manière inégale de prouver « soit l'existence d'une convention, soit que les parties avaient des intérêts inégaux dans l'affaire »[1455].

L'article 1216 du Code civil prévoit même le cas à première vue curieux où la dette ne concernait que l'un des coobligés solidaires ; en ce cas, si c'est un autre codébiteur (non intéressé à la dette) qui a payé, il aura un recours pour la totalité, comme dans le cas de cautionnement. Ce texte (dont le principe se retrouve dans le nouvel article 1318 du Code civil français et dans l'article 5.164 du nouveau Code civil belge) semble permettre l'utilisation de la solidarité dans le cas où, au départ, il n'y a qu'un seul débiteur, comme substitut du cautionnement. Cette utilisation est plus fréquente qu'on ne le pense. On peut penser à deux conjoints qui empruntent solidairement de l'argent destiné exclusivement à financer l'activité professionnelle de l'un des deux. La Cour d'appel a eu à connaître d'une application de l'article 1216 du Code civil dans un cas où une brasserie avait fait un prêt à une société exploitant une discothèque, les deux gérants de la société s'étant engagés solidairement au remboursement du prêt[1456]. Si, compte tenu des termes de l'article 1216 du Code civil, la validité de ce type d'engagement ne peut pas être discutée, son régime juridique suscite diverses difficultés. Il s'agit en particulier de savoir si on doit appliquer à l'engagement du codébiteur solidaire non intéressé à la dette les règles protectrices posées par la loi ou élaborées par la jurisprudence au profit des cautions[1457].

630. Recours du codébiteur *solvens*. Le codébiteur qui a payé le créancier (le « *solvens* ») a un recours contre le ou les autres codébiteurs pour ce qui excède sa part. L'article 1214 du Code civil précise cependant que, lorsqu'il exerce ce recours, le codébiteur ne bénéficie plus lui-même de la solidarité entre ses codébiteurs : il doit diviser son recours entre eux, et ne peut demander à chacun que sa part. Cependant, pour éviter que celui qui a payé ne supporte seul la charge de l'insolvabilité de l'un des autres, le texte ajoute que « si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement ». Par exemple, si la dette était de 30 000 €, et qu'il y a trois codébiteurs (A, B, C), chacun tenu pour 10 000, le codébiteur A qui a payé le tout, peut normalement récupérer 10 000 de B, et 10 000 de C. Mais, si C est insolvable, A pourra récupérer 15 000 de B.

Le recours entre codébiteurs solidaires, expressément prévu par l'article 1214 du Code civil, peut être fondé sur la notion de la subrogation personnelle : lorsqu'on est obligé de payer la dette d'autrui – ce qui est le cas d'un codébiteur solidaire pour tout ce qui excède sa part – on devient, par l'effet de ce paiement, créancier à la place

[1455] Cour d'appel, 22 mars 2006, *Pas.*, 33, p 244.

[1456] Cour d'appel, 9 mai 2007, n° 31619, BIJ 2007, n° 107 ; adde récemment : Trib. Luxembourg, 22 février 2023, n° TAL-2022-08661.

[1457] *Cf.* not. Cass. fr., 17 novembre 1999, n° 97-16335.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

du créancier qu'on a désintéressé (C. civ., art. 1231)[1458]. Le subrogé recueille alors la créance telle qu'elle était dans le patrimoine du créancier originaire : cela lui permet de bénéficier de toutes les sûretés qui, éventuellement, assortissaient la dette payée ; mais, en contrepartie, le subrogé pourra se voir opposer par le débiteur contre qui il agit toutes les exceptions que celui-ci auraient ou opposer au créancier originaire. Si, donc, le codébiteur contre qui le recours est exercé disposait d'exceptions purement personnelles, que le solvens n'a pas pu opposer au créancier, il pourra les faire valoir à l'encontre de son codébiteur exerçant le recours. Pour éviter cet inconvénient, la Cour de cassation belge reconnaît aussi au codébiteur qui a payé un recours fondé sur l'enrichissement sans cause du codébiteur n'ayant pas payé, qu'il ne serait pas juste de libérer de la charge de la dette[1459].

C'est aussi par l'idée de justice ou d'équité qu'on peut expliquer que le recours soit reconnu, non pas seulement au codébiteur solidaire *stricto sensu*, mais aussi au coobligé *in solidum*, alors même que celui-ci, étant censé avoir causé l'entier dommage, n'a, au fond, payé que ce qu'il devait en assumant la charge de la réparation intégrale. Mais, dans un tel cas, il serait injuste que le choix fait par la victime de demander paiement à tel ou tel aboutisse à libérer les autres qui sont, eux aussi, censés être responsables de l'entier dommage.

§ 2. L'indivisibilité

631. Il y a « Indivisibilité » et « indivisibilité ». Le terme d'indivisibilité est utilisé dans le langage juridique avec de multiples sens, pour désigner de situations où on ne peut pas séparer, dissocier l'un de l'autre deux actes ou deux faits juridiques, de sorte qu'il paraît opportun de les traiter ensemble. C'est en ce sens qu'on parle de l'indivisibilité d'un litige, lorsque deux demandes en justice sont tellement liées qu'il s'impose d'y répondre ensemble dans une même décision[1460]. De même, en matière contractuelle, pour expliquer que la nullité d'une clause d'un contrat entraîne celle du contrat tout entier, on dira parfois que les différentes clauses du contrat forment un tout indivisible, ou, de même, que deux contrats liés forment un ensemble indivisible, pour décider que les incidents qui affectent l'un de nullité ou résolution auront des répercussions sur l'autre[1461]. L'indivisibilité du compte courant, qui est une importante règle jurisprudentielle en matière bancaire, repose sur la même idée : les différentes opérations qui se succèdent les unes ou autres sur un compte bancaire forment des éléments d'un ensemble global de sorte que ce n'est qu'à la fin du fonctionnement du compte qu'on saura qui est créditeur et qui est débiteur.

[1458] Voy. *infra*, n°s 1020 et s.

[1459] Cass. be., 21 octobre 1965, *Pas. be.*, 1966, I, p. 240.

[1460] T. Hoscheit, « L'indivisibilité procédurale », *J.T.L.*, 2010, p. 54.

[1461] Voy. *supra*, n° 478 à propos de la nullité et *infra*, n° 797 à propos de la résolution. On parle plutôt aujourd'hui de contrats interdépendants.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Les articles 1222 à 1225 du Code civil envisagent l'indivisibilité de l'obligation dans un sens technique très différent : il s'agit de cas où une obligation doit être exécutée en entier, sans pouvoir se diviser entre les différents créanciers ou les différents débiteurs. C'est alors un mécanisme voisin de la solidarité, qui s'en distingue cependant à la fois par ses sources (**A**) et, surtout, par ses effets (**B**). On l'utilise souvent pour doubler la solidarité et en renforcer l'efficacité.

A) *Sources de l'indivisibilité*

632. Indivisibilité naturelle ou conventionnelle. Comme on l'a exposé précédemment, l'indivisibilité va de soi pour certaines obligations, qui ne peuvent être exécutées qu'en entier : l'obligation de livrer un corps certain, par exemple, ou d'accomplir un service qui ne peut pas être divisé. Cette indivisibilité de droit ne résulte pas seulement de la nature matérielle de l'objet de l'obligation (indivisibilité naturelle : par exemple : la livraison d'un animal), elle peut aussi résulter de l'esprit dans lequel l'obligation a été conçue : on parle alors d'indivisibilité intellectuelle (C. civ., art. 1217 et 1218). Ainsi, la construction d'une maison, même si elle est matériellement divisible, est habituellement conçue comme ne pouvant être exécutée qu'en entier, parce qu'il ne sert à rien de n'avoir que les murs. De manière moins évidente, le paiement du prix d'une chambre d'hôtel a pu être considéré comme indivisible pour ses deux occupants[1462].

Cependant, en dehors de ces cas, les parties à un contrat peuvent stipuler expressément qu'une obligation, par sa nature parfaitement divisible (par exemple, une obligation de somme d'argent), sera exécutée comme si elle était indivisible. Cette indivisibilité conventionnelle produit des effets proches de ceux de la solidarité.

B) *Effets de l'indivisibilité*

633. Indivisibilité à double sens. À la différence de la solidarité, qui peut être stipulée distinctement vis-à-vis des seuls débiteurs ou des seuls créanciers, l'indivisibilité produit nécessairement effet à la fois à l'égard des uns et des autres.

Envisagée vis-à-vis des créanciers, elle produit pour l'essentiel les mêmes effets que la solidarité active : chaque créancier peut réclamer au débiteur la totalité de l'obligation, sauf à répercuter ensuite ce qui excède sa part sur les autres (C. civ., art. 1225).

[1462] Trib. Luxembourg, 20 janvier 2011, n° JUDOC : 99866433.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Envisagée maintenant du côté des débiteurs, l'effet essentiel est le même que celui de la solidarité : chaque débiteur de la dette indivisible est tenu, vis-à-vis du créancier, de l'exécuter en entier, sauf ensuite son recours contre les autres débiteurs. Deux différences cependant doivent être signalées. D'une part, on ne retrouve pas ici les effets secondaires de la solidarité : les actes de procédure faits contre un seul ou par un seul des codébiteurs ne produiront donc pas d'effets contre ou au profit des autres. D'autre part, à l'inverse, l'indivisibilité présente pour le créancier l'avantage de se continuer entre les cohéritiers après le décès de chaque codébiteur : on pourra donc, ici, demander à chaque cohéritier la totalité de la dette (C. civ., art. 1223), et pas seulement, comme dans le cas de solidarité, une fraction de celle-ci. La solution est reprise par le nouvel article 1320 du Code civil français et par l'article 5.167 du nouveau Code civil belge. Pour cumuler cet avantage avec ceux de la solidarité, on stipule souvent que les codébiteurs s'engagent de manière solidaire et indivisible.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les modalités des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 693-743
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Chapitre II
L'exécution des obligations contractuelles

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

634. Différents modes d'exécution. Un contrat est fait pour être exécuté. Il appartient donc à chaque partie de faire ce qu'elle avait promis, ou de ne pas faire ce dont elle devant s'abstenir. Si tout se passe bien, cette exécution est volontaire, mais, si ce n'est pas le cas, le débiteur peut, à certaines conditions, être contraint à exécuter. Il est par ailleurs des cas où l'exécution se produira de manière automatique, sans que l'une ou l'autre des parties intervienne : ni le débiteur pour accomplir volontairement la prestation, ni le créancier pour l'y contraindre. C'est ce qui se passe lorsque les deux parties au contrat sont réciproquement créancière et débitrice l'une de l'autre de sommes d'argent, de sorte que les deux dettes vont s'éteindre par compensation. C'est ce qui se passe aussi lorsque le créancier et le débiteur deviennent une seule et même personne (notamment parce que l'un hérite de l'autre) : la dette s'éteindra alors par confusion.

Il ne s'agit ici que d'étudier l'exécution volontaire des obligations – qu'on appelle, techniquement, le paiement. Il est plus opérationnel d'étudier l'exécution forcée au titre des sanctions de l'inexécution contractuelle, ce qui permet d'en examiner l'articulation avec les autres sanctions[1463]. Quant aux modes de paiement automatiques que sont la compensation et la confusion, leur étude trouve plus naturellement place au sein des développements consacrés à l'extinction des obligations[1464].

635. L'exécution volontaire : le paiement. Il sera donc question ici du paiement. Dans le langage courant, le terme désigne seulement la remise d'une somme d'argent par le débiteur à son créancier. Dans le langage juridique francophone, le terme est utilisé, d'une manière beaucoup plus générale, pour désigner toute exécution volontaire d'une obligation, quel qu'en soit l'objet : l'emprunteur qui rembourse son prêteur, l'acheteur qui verse le prix entre les mains du vendeur, etc. mais aussi le vendeur qui livre la chose, l'entrepreneur qui construit la maison qui lui a été commandée, etc. payent leur dette. C'est en ce sens très général que le Code civil utilise le terme de paiement. Le paiement est d'abord présenté, dans l'article 1234 du Code civil, comme le premier des modes d'extinction de l'obligation. Il est ensuite réglementé, dans les articles 1235 à 1270 du Code civil, sans distinguer par principe selon que l'obligation porte

[1463] Voy. *infra*, n°s 718 et s.
[1464] Voy. *infra*, n°s 890 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

sur une obligation monétaire ou non monétaire. Cependant, certains articles concernent spécifiquement des obligations non monétaires (C. civ., art. 1237, 1238 al. 1er et 1243), et de nombreux autres ont été pensés en fonction de la figure habituelle du paiement d'une somme d'argent. Aussi bien, dans les développements qui vont suivre, nous serons amenés à très souvent distinguer selon l'objet de l'obligation à exécuter.

Les règles relatives au paiement sont également, à de rares exceptions près, communes à toutes les obligations, quelle qu'en soit la source. Elles font donc partie du régime général de l'obligation, et ne sont pas spécifiques aux obligations contractuelles. C'est pourquoi, fort logiquement, dans les nouveaux droits français et belge, le paiement est réglementé dans la partie relative au régime général de l'obligation, aux articles 1342 et suivants du Code civil français, 5.194 et suivants du Code civil belge. Dans le Code civil de 1804, du reste, ces règles n'ont pas été pensées au regard de la problématique de l'exécution du contrat, mais au regard de celle, beaucoup plus générale, de l'extinction des obligations. C'est une présentation logique, mais qui a l'inconvénient de couper la matière du droit des contrats, dont elle est pourtant un élément essentiel : dans le Code civil, il n'y a aucune règle spécifiquement consacrée à l'exécution des contrats, on passe directement du principe de la force obligatoire aux règles relatives aux sanctions de l'inexécution, ce qui fait un peu oublier que le contrat est d'abord fait pour être exécuté. La présentation du Code tranche avec celles des textes internationaux et projets européens où les règles ici étudiées sont abordées, de manière plus concrète, sous l'angle de l'exécution des contrats[1465]. Dans les développements qui vont suivre, sans abandonner l'angle habituel de présentation, nous essaierons de garder présent à l'esprit que le paiement, avant d'être une cause d'extinction des obligations, est, d'abord, leur mode normal d'exécution.

636. Nature juridique du paiement. En France comme en Belgique, on a beaucoup débattu de la nature juridique du paiement[1466]. La question n'est pas purement théorique, car elle a un certain nombre d'incidences concrètes, notamment sur les conditions

[1465] Code Gandolfi, art. 75 et s. ; PDEC, art. 7 : 101 ets. ; DCFR, art. 2 : 101 et s ; Principes Unidroit, art. 6.1.1 et s.

[1466] Pour une excellente présentation comparative de la question, voy. VAN OMMESLAGHE, vol. 3, nos 1390 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de validité du paiement. La thèse traditionnelle, en France, est que le paiement, dans la mesure où il est volontaire, est une convention entre le créancier et le débiteur, par lequel les deux parties s'accordent sur l'exécution de l'obligation : le débiteur propose au créancier telle ou telle prestation, que le créancier accepte comme satisfactoire. Dans cette thèse, l'accord du créancier est toujours nécessaire pour que le paiement puisse valablement s'opérer. Cette thèse a cependant été remise en cause par un auteur[1467] qui a fait observer, à juste titre, que, si l'accord du créancier était parfois requis pour la réalisation effective du paiement (par exemple, la livraison d'une chose par un vendeur ne peut pas s'exécuter si l'acheteur refuse de recevoir la chose), cet accord n'était jamais requis pour que le paiement produise son effet essentiel, à savoir l'extinction de l'obligation : cet effet doit se produire dès lors que l'exécution proposée par le débiteur correspond effectivement au contenu de son engagement. À partir de là, il conviendrait plutôt d'analyser le paiement, en général[1468], comme un fait juridique, supposant certes pour sa réalisation un acte volontaire du débiteur, et parfois une volonté du créancier, mais qui produirait ses effets indépendamment de ces volontés[1469]. Cette analyse est reprise au Luxembourg par O. Poelmans[1470], et, dans un arrêt de 2012, la Cour d'appel, pour admettre la preuve du paiement par tous moyens, a posé que le paiement était un fait[1471] La doctrine belge, de son côté, analyse majoritairement le paiement comme un acte juridique unilatéral, supposant toujours la volonté du débiteur – ce qui semble être l'explication également retenue en Allemagne et en Italie[1472]. Cette analyse, qui est reprise dans la définition du paiement à l'article 5.194 du nouveau Code civil belge, et qui est significative de l'accueil plus favorable généralement réservé à l'acte unilatéral en Belgique qu'en France, fonctionne assez bien pour l'exécution des obligations de faire (monétaires ou non monétaires), mais beaucoup plus mal pour l'exécution des obligations de ne pas faire, qui repose seulement sur une abstention pas toujours volontaire ni même consciente de la

[1467] N. Catala, *La nature juridique du paiement*, préf. J. Carbonnier, Paris, 1961.

[1468] L'auteur met à part le paiement des « obligations de donner », c'est-à-dire l'acte de transfert de propriété d'un bien. Mais on peut contester cette vision du transfert de propriété comme l'exécution d'une « obligation ». Voy. *supra*, n° 52.

[1469] Dans le même sens, J. Ghestin, M. Billiau et G. Loiseau, *Traité de droit civil – Le régime des créances et des dettes*, Paris, LGDJ, 2005, n°s 530 et s.

[1470] Poelmans, n° 487.

[1471] Cour d'appel, 4 juillet 2012, n° 37596.

[1472] Van Ommeslaghe, vol. 3, n°s 1394 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

part du débiteur. L'article 1342 du Code civil français ne prend pas parti, en se contentant d'affirmer que « [l]e paiement est l'exécution volontaire de la prestation due ».

L'étude du droit positif – textes et jurisprudence – révèle qu'il est bien difficile de trancher entre ces différentes analyses, et le paiement est sans doute un des mécanismes du droit civil qui est le plus rebelle à la systématisation. Beaucoup d'auteurs, aujourd'hui, se contentent de dire que le paiement est « un acte complexe, participant de la convention et du fait juridique »[1473], ou « un acte juridique d'une nature particulière »[1474]. Selon les questions à résoudre, et la nature de l'obligation, le droit attache plus ou moins d'importance à la volonté des parties, à la fois pour ce qui concerne la réalisation du paiement (**Section 1**), ses effets (**Section 2**) et sa preuve (**Section 3**).

SECTION 1. LA RÉALISATION DU PAIEMENT

637. Différentes questions. Il s'agit ici à la fois de décrire ce qui se passe (qui paye ? à qui ? quoi ? comment ? quand ? où ?) lors de l'opération de paiement et, à propos de chaque étape de ce processus de définir les conditions requises pour que le paiement effectué ait un caractère libératoire. On s'interrogera successivement sur les parties au paiement (**§ 1**), sur l'objet du paiement (**§ 2**), et sur ses modalités (**§ 3**).

§1. Les parties au paiement

638. Qui doit payer à qui ? De prime abord, le paiement intervient entre le débiteur et le créancier. Mais en réalité ce n'est pas toujours le cas, car le paiement est parfois fait par une autre personne que le débiteur et/ou à une autre personne que le créancier. C'est pourquoi, traditionnellement, et bien que ces termes ne figurent pas dans le Code civil, on désigne celui qui paye comme étant le *solvens* (on peut traduire : le payeur) et celui qui reçoit le paiement comme étant l'*accipiens* (le payé). Le paiement n'est libératoire pour le débiteur que si certaines conditions sont remplies chez l'une et chez l'autre de ces personnes.

[1473] MALAURIE, AYNES, STOFFEL-MUNCK, n° 1075.
[1474] FLOUR, AUBERT SAVAUX, vol. 3 2015., n° 107.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

A) *Le solvens*

639. Acteur essentiel du paiement. Quelle que soit l'analyse qu'on donne du paiement – acte ou fait juridique – le *solvens* en est l'acteur essentiel. Un acte, ou du moins un comportement volontaire de sa part est toujours requis. Les textes posent certaines règles concernant l'identité du *solvens* (1), et sa capacité (2).

1) *Identité du solvens*

640. Paiement par le débiteur ou par un tiers. En principe, le paiement est effectué par le débiteur lui-même. Mais il peut être effectué par un tiers (soit par erreur, soit parce qu'il y est obligé par la loi ou par convention, soit volontairement, par intention libérale ou avec intention de se faire ensuite rembourser). Dans ces différentes situations, deux questions très différentes se posent : d'une part il faut se demander si un tel paiement est valable, donc libératoire pour le débiteur ; d'autre part, il faut voir quelles sont les conséquences d'un tel paiement, en ce qui concerne les droits du *solvens* non débiteur.

641. Validité du paiement par un tiers. Le paiement fait par un tiers est en principe valable. L'article 1236 du Code civil pose à cet égard que « une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution » : le terme « intéressé » vise des cas où le tiers qui paye est obligé de le faire, soit parce qu'il a cautionné la dette du débiteur, soit parce qu'étant tenue solidairement, elle doit payer globalement la dette dont elle n'est débitrice qu'en partie. Mais le texte ajoute que « l'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ». Il s'agit ici de cas où le *solvens* n'est pas obligé de payer. Son paiement peut alors s'expliquer de diverses manières. Le *solvens* peut, d'abord, être un représentant du débiteur, qui paye en son nom (un mandataire, le tuteur qui paye les dettes d'un incapable). Mais il peut payer en son nom propre : ce paiement peut alors s'expliquer par une intention libérale, mais, beaucoup plus souvent, il s'agira d'une simple avance que le tiers fait, avec l'intention de se faire ensuite rembourser par le débiteur. Il devra alors se faire subroger dans les droits du créancier[1475].

[1475] Sur la subrogation voy. *infra*, n°s 1018 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

L'article 1236 du Code civil semble mettre ce cas à part ; en réalité, un tel paiement avec subrogation est parfaitement valable, simplement il n'aura pas pour effet d'éteindre la dette, le débiteur initial devant rembourser le subrogé.

Ces règles ne valent cependant que pour les obligations de somme d'argent. Si le contrat fait naître une obligation de faire, l'article 1237 du Code civil pose que cette obligation ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même ». Ce cas coïncide avec celui des contrats *intuitu personae* : si j'ai choisi tel architecte pour faire les plans de ma maison, je peux refuser que les plans soient faits par quelqu'un d'autre ; en revanche, si j'ai acheté du matériel fabriqué en série dans tel magasin, qui est en rupture de stock, je ne peux refuser la livraison du même matériel par un autre magasin que le premier se serait substitué. L'article 5.196 du nouveau code civil belge reprend ces diverses solutions en précisant les raisons qui peuvent amener le créancier à refuser le paiement fait par un tiers. Beaucoup plus sobrement, le nouvel article 342-1 du Code civil français concentre toutes ces règles en un seul article, posant que « [l]e paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier ».

642. Conséquences du paiement fait par un tiers. Il faut ici distinguer selon les raisons qui ont amené le tiers à payer. On doit d'abord mettre à part le cas où le paiement a été fait à tort par quelqu'un qui se croyait débiteur (alors que la dette n'existait pas ou plus – elle avait déjà été remboursée et le *solvens* ne le savait pas – ou alors que la dette était due par quelqu'un d'autre. On est alors en présence d'un des cas de paiement de l'indu, qui est traité par le Code civil au titre des quasi-contrats. Plus précisément, on est dans le cas prévu par l'article 1377 du Code civil qui ouvre au *solvens* un droit à « répétition », c'est-à-dire à restitution contre l'*accipiens*.

Il en va autrement dans tous les autres cas, où le *solvens* n'a pas payé par erreur. Soit il a agi comme mandataire : il a alors un recours personnel contre le débiteur. Soit il a agi en son nom propre : il n'aura pas de recours contre le débiteur s'il a agi avec l'intention de faire une libéralité à ce dernier ; en l'absence d'intention libérale, il pourra avoir un recours, soit sur le fondement de la gestion d'affaires, soit sur le fondement de la subrogation.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

2) *Capacité du solvens*

643. Distinctions. Dans la plupart des cas, le paiement repose sur une manifestation de volonté du *solvens* – et c'est pourquoi la majorité de la doctrine y voit un acte juridique. L'article 1238 du Code civil (repris en substance par l'article 5.197 du nouveau Code civil belge, mais non dans les nouveaux textes français) semble confirmer cette analyse, en posant une exigence de capacité chez le *solvens*. Le texte, cependant, distingue selon l'objet du paiement. S'il s'agit d'un corps certain (par exemple, un immeuble, une œuvre d'art), le paiement n'est valable que si le *solvens* est « propriétaire de la chose donnée en paiement et capable de l'aliéner ». Cette exigence aura rarement l'occasion de jouer, dans la mesure où, on le sait, les contrats translatifs de propriété opèrent en principe ce transfert immédiatement, par le seul effet du contrat : la capacité de « payer » se confond alors avec celle de passer le contrat. Si le paiement porte sur des choses fongibles (et notamment sur de l'argent), il faut également que le *solvens* soit propriétaire des choses ou de l'argent et capable de les aliéner, mais si ce n'était pas le cas, l'*accipiens* pourrait conserver les choses ou l'argent dès lors qu'il était de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ignorait l'incapacité ou le défaut de propriété du *solvens*.

B) *L'accipiens*

644. Rôle de l'accipiens. L'*accipiens* a, de prime abord, dans l'opération de paiement, un rôle moins actif que le *solvens*. Ce n'est pas lui qui a, en principe, la maîtrise du déclenchement de l'opération, et il se contente de recevoir la chose ou la prestation qui lui est offerte par le *solvens*. Il faut néanmoins, pour que le paiement soit valable, que l'*accipiens* présente certaines qualités (1). Par ailleurs, même s'il n'est pas, en droit, une condition de validité du paiement, son consentement est souvent, en fait, requis (2).

1) *Les qualités de l'accipiens*

645. L'accipiens doit être le créancier. En principe, le paiement doit être fait au créancier ou à son mandataire, et non à un tiers. Le paiement fait à un non-créancier n'est pas valable. Cependant les conséquences d'un tel paiement ne sont pas toujours les mêmes selon les situations.

Soit la somme n'était due à personne (par exemple, un organisme social verse par erreur une prestation à quelqu'un qui ne remplissait pas les conditions pour y avoir droit), dans ce cas, il y a paiement de l'indu ouvrant au *solvens* un droit à répétition. Plus précisément, on est ici en présence de ce qu'on appelle un indu objectif, relevant de l'article 1376 du Code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». La différence avec le cas de l'article 1377 du

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Code civil, évoqué plus haut, est que l'action en répétition n'est pas ici subordonnée à la preuve d'une erreur, ni de la part du *solvens* ni de la part de l'*accipiens*.

La seconde situation est celle où la somme était due, mais à un autre que l'*accipiens* (par exemple, on fait un paiement à une personne dont on croit qu'elle est mandataire du créancier et qui ne l'est pas, ou à une personne que l'on croit héritier, ou à son créancier alors que celui-ci a cédé sa créance). Dans ce cas, le paiement n'est pas en principe libératoire, et le débiteur devra ensuite acquitter sa dette entre les mains du véritable créancier : qui paie mal paie deux fois ! Il aura alors un recours contre celui qu'il a payé à tort, sur le fondement du paiement de l'indu (C. civ., art. 1376). Cependant, l'article 1240 du Code civil (dont la solution est reprise par l'article 1342-3 du Code civil français et par l'article 5.198 du nouveau Code civil belge) apporte une exception importante à ce principe : le paiement est valable s'il a été effectué de bonne foi à une personne qui était « en possession de la créance », c'est-à-dire qui se comportait comme si elle était créancière (les nouveaux textes belges et français parlent du créancier apparent). Une application particulière se rencontre dans le cas d'une créance cédée lorsque la cession n'a pas été notifiée au débiteur cédé, qui paye alors de bonne foi son créancier originaire (C. civ., art. 1691)[1476]. Dans ce cas, c'est le véritable créancier, qui n'aura pas pu obtenir son paiement, qui aura un recours contre le « possesseur de la créance ». Ce recours peut être fondé sur l'enrichissement sans cause.

646. L'*accipiens* **doit être capable.** Comme le *solvens*, l'*accipiens* doit être capable de recevoir : selon l'article 1241 du Code civil, « le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir ». Par exemple, si le créancier est mineur, le débiteur ne peut payer qu'à son représentant légal ; s'il paye directement au mineur, ce paiement est nul, et le débiteur peut être amené à payer une deuxième fois. Le texte atténue cependant la rigueur de cette règle, pour le cas où le paiement a « tourné au profit du créancier » – c'est-à-dire que les sommes payées ont été conservées, placées ou ont servi à l'acquisition d'un bien resté dans le patrimoine du créancier. On retrouve l'équivalent de ces règles dans les nouveaux textes français et belges.

Du cas où le créancier est incapable de recevoir, on peut rapprocher celui où il n'a pas le pouvoir de le faire. C'est le cas lorsqu'un tiers, créancier de ce créancier, cherche à se faire payer en appréhendant la créance de son débiteur (qui fait partie des biens de celui-ci, et qui, comme tous ses autres biens, peut servir à payer les créanciers en cas de non-paiement). Il peut le faire en pratiquant une saisie-arrêt entre les mains du débiteur (NCPC, art. 693 et s.). Cette saisie – appelée aussi opposition – a pour

[1476] Voy. *infra*, n° 1009.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

effet, dans un premier temps, d'interdire au débiteur de se libérer entre les mains de son créancier (avant que, dans un deuxième temps, le saisissant ne se voie attribuer la propriété de la créance). Si le titulaire de la créance saisie se faisait néanmoins payer sa créance par son débiteur, ce paiement serait nul.

2) *Le consentement de l'accipiens*

647. Différentes situations. Dans l'analyse traditionnelle, qui voit dans le paiement une véritable convention entre le débiteur et son créancier tendant à l'extinction de la dette, le paiement est subordonné au consentement de l'*accipiens*. Cependant cette analyse ne correspond pas à la réalité : dans certains cas, en effet, le paiement peut se réaliser sans aucune intervention du créancier, et sans qu'il ait la possibilité de le refuser. Il en va ainsi pour les obligations de ne pas faire, dans lesquelles l'exécution consiste en une abstention du débiteur, sur laquelle le créancier n'a aucune prise – sauf à assigner son débiteur en justice s'il estime que l'obligation est mal exécutée. Pour les obligations de faire, en revanche, qu'elles soient ou non monétaires, le créancier a, en fait, la possibilité de refuser le paiement (en ne prenant pas la livraison du bien commandé, en refusant de laisser entrer l'entrepreneur qui veut faire les travaux, en refusant de recevoir la somme due, en demandant à sa banque de rejeter un virement, etc.). Le consentement du créancier est, en fait, nécessaire pour la réalisation du paiement. Mais est-il pour autant nécessaire en droit ? Cela dépend du point de savoir si le paiement effectué est ou non régulier. Il est un certain nombre de cas où le créancier a tout à fait le droit de refuser l'exécution : ainsi si le paiement est fait par un incapable, ou par un tiers dans le cas de l'article 1237 du Code civil, ou si le débiteur offre autre chose que ce qui a été promis, ou s'il n'offre qu'un paiement partiel que le créancier peut toujours refuser[1477]. Mais, dans les autres cas, si le débiteur capable offre un paiement correspondant en tous points à l'obligation promise, le créancier n'a aucun droit de refuser cette exécution de l'obligation : il n'y a aucune raison, par exemple, d'obliger un vendeur à garder la chose vendue plus longtemps chez lui, ou de refuser à un emprunteur (qui paye des intérêts) de se libérer au terme. La difficulté est cependant que, dans certains cas, on ne sait pas au départ si on est ou non dans une situation où le créancier a le droit de refuser le paiement, c'est précisément l'objet d'un litige entre les parties. Par exemple, le débiteur veut payer 10 000, alors

[1477] Voy. *infra*, n° 657.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

que le créancier, lui, prétend que la somme due est de 20 000. Il ne veut pas accepter un paiement partiel, de peur qu'on y voie ensuite une renonciation à demander le paiement intégral. D'un autre côté, le débiteur veut payer tout de suite, car il ne veut pas supporter des intérêts de retard. Il faut donc trouver un moyen, sans attendre l'intervention du juge, de sauvegarder à la fois les intérêts de l'un et de l'autre. C'est dans ce but que les rédacteurs du Code civil ont mis en place la procédure très complexe des offres réelles et de la consignation.

648. Offres réelles et consignation. On n'entrera pas ici dans les détails de cette procédure, longuement réglementée par les articles 1257 à 1264 du Code civil et par les articles 949 à 955 du Nouveau Code de procédure civile, mais dont l'importance pratique est limitée, en raison de son caractère exagérément formaliste. L'idée générale de cette procédure est la suivante : le débiteur à qui son créancier refuse le paiement peut, si les conditions prévues par l'article 1258 du Code civil sont réunies (capacité du créancier et du débiteur, paiement offert de la totalité de la somme, terme échu et condition éventuelle réalisée, etc.), offrir le paiement, par l'intermédiaire d'un huissier. Si le créancier refuse cette offre, le débiteur peut, après sommation, procéder à la consignation (c'est-à-dire au dépôt) des sommes ou choses à payer auprès d'un établissement agréé (qui est, au Luxembourg, la Trésorerie de l'État). Si le créancier refuse toujours, le débiteur peut saisir le tribunal, qui jugera du bien-fondé des offres du débiteur. Si ces offres sont jugées valables, le débiteur sera libéré, nonobstant l'absence de consentement du créancier.

On trouve des équivalents de cette procédure, en beaucoup moins formaliste, dans certains projets européens[1478]. D'autres projets mettent en place une procédure de « mise en demeure » du créancier (*mora creditoris*)[1479], connue de divers droits étrangers[1480]. C'est cette voie qu'ont suivie les nouveaux textes français (C. civ., art. 1345 à 1345-3) et belges (art. 5.211 à 5.216) : le débiteur à qui son créancier refuse le paiement peut mettre en demeure son créancier de l'accepter ; à elle seule, cette mise en demeure (comme celle que le créancier peut adresser en sens inverse au débiteur qui n'exécute pas ses obligations[1481]) arrête le cours des intérêts de retard, et met la chose dont la livraison est refusée aux risques du créancier. À défaut pour le créancier de satisfaire à cette mise en demeure, le débiteur peut consigner la somme ou, s'il s'agit d'une chose à livrer, la remettre entre les mains d'un gardien

[1478] Voy. p. ex. PDEC, art. 7 : 110 et 7 : 111.

[1479] Code Gandolfi, art. 103 et s.

[1480] Voy. p. ex. en droit suisse les articles 91-96 du CO.

[1481] Sur laquelle, voy. *infra*, n[os] 685 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

professionnel. Si l'obligation porte sur un service, pour lequel toute consignation est évidemment impossible, le débiteur sera, en droit français, purement et simplement libéré si le créancier n'a pas satisfait à la mise en demeure dans un délai de deux mois. Il serait sans doute intéressant de transposer cette procédure au Luxembourg.

§ 2. L'objet du paiement

649. Que doit-on payer ? Il y a évidemment un lien étroit entre le paiement et l'obligation que le paiement a pour objet d'exécuter et d'éteindre. D'abord, l'article 1235, qui ouvre la section du Code civil sur le paiement, dispose que « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ». Ce paiement de l'indu est réglé plus en détail par les articles 1376 et 1377 du Code civil au titre des quasi-contrats[1482]. Ensuite, dans le cas normal où la dette existe, l'objet à payer est calqué sur l'objet de l'obligation : on doit payer ce qu'on doit (**A**), tout ce qu'on doit (**B**). Ces deux principes, qui connaissent diverses exceptions, suscitent en outre des difficultés spécifiques dans le cas où le paiement a pour objet une somme d'argent.

A) *Identité de la chose remise en paiement et de l'objet de l'obligation*

1) *Règles générales*

650. Principe. Le principe est posé par l'article 1243 du Code civil (repris par l'article 5.200 du Code belge, et, de manière implicite, par l'article 1342-4 du Code français) : « le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande ». Le principe joue aussi bien pour les obligations de somme d'argent que pour les obligations non monétaires. Si j'ai promis de payer une certaine somme, je ne peux pas me libérer en transférant à mon créancier la propriété d'un bien, même s'il est supposé être de valeur supérieure à la somme due : mon créancier n'a peut-être que faire d'un tel bien, et ne veut pas nécessairement courir le risque de sa revente[1483]. À l'inverse, si je suis redevable de la livraison d'une chose ou d'une prestation de services, je ne peux pas me libérer en offrant à mon créancier de lui payer une somme

[1482] Sur les différents cas de paiement de l'indu, voy. *supra*, n°s 642 et s.

[1483] Pour un rappel de la règle : Cour d'appel, 16 janvier 2002, n° 25003 (refus d'une banque de recevoir en remboursement d'un prêt une créance née d'une police d'assurance).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

d'argent. Dans la conception des pays du Code civil, si je n'exécute pas, mon créancier pourra m'assigner en justice pour obtenir l'exécution en nature de mon engagement – ce qui est un antidote à la possibilité de l'*efficient breach of contract*, prônée par certains juristes de *common law*, qui permettrait à un débiteur contractuel de se libérer du contrat devenu trop onéreux pour lui en payant l'équivalent en argent de la prestation promise. Il en va ainsi même si le contrat contient une clause pénale fixant le montant des dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution[1484] : le débiteur ne peut pas se libérer en payant le montant prévu, et le créancier peut toujours l'assigner pour obtenir l'exécution en nature. Il n'en va autrement que si le contrat a fait naître une obligation alternative, offrant au débiteur le choix entre deux prestations. Mais, dans ce cas, la liberté de choisir l'objet du paiement tient précisément à la dualité d'objets de l'obligation elle-même.

Ce principe de l'identité de l'objet du paiement et de l'objet de l'obligation connaît cependant une exception, avec la dation en paiement. Il suscite part ailleurs diverses difficultés spécifiques dans le cas des obligations de somme d'argent.

651. Exception : la dation en paiement. Si, selon l'article 1243, le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, il peut toujours accepter, et le paiement ainsi effectué est tout à fait valable. Par exemple, le créancier d'une somme d'argent peut accepter de recevoir à la place un immeuble, une œuvre d'art, ou des instruments financiers. L'acheteur d'une voiture de telle couleur peut très bien accepter, pour éviter des délais de livraison trop longs, de recevoir à la place un véhicule d'une autre couleur. On est alors en présence de ce qu'on appelle une dation en paiement. Non réglée par le Code civil (mais aujourd'hui prévue expressément par l'article 5.200 du nouveau Code civil belge et par l'article 1342-4 du Code civil français), cette opération peut être définie comme un accord pour substituer à l'objet initial de l'obligation un autre objet lors du paiement.

La dation en paiement peut être analysée de deux manières. Tantôt – c'est l'analyse classique – on y voit la combinaison d'une vente et d'un paiement (par compensation) : celui qui accepte un immeuble en guise de paiement d'une somme d'argent achèterait cet immeuble, mais le prix qu'il aurait à payer viendrait en

[1484] Voy. *infra*, n°s 924 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

compensation de ce que lui doit son débiteur-vendeur. Tantôt on y voit un cas particulier de novation[1485] : les parties conviendraient de remplacer l'obligation initiale (ayant par exemple pour objet une somme d'argent) par une nouvelle obligation (ayant par exemple l'immeuble pour objet) ; cette novation aurait alors pour effet d'éteindre l'obligation initiale. Une analyse plus moderne y voit simplement une convention modificative de l'obligation initiale[1486]. Le régime juridique de l'opération, très complexe, combine ces différentes analyses, de sorte qu'il est sans doute un peu vain de vouloir rattacher la dation en paiement à une autre notion juridique[1487].

En l'absence de jurisprudence luxembourgeoise accessible, on peut se référer aux solutions retenues en France et en Belgique. Du point de vue de ses conditions de validité, la dation en paiement suppose un accord du créancier, qui peut être simplement tacite. Pour le reste, on doit combiner les conditions générales relatives au paiement, avec les conditions propres à l'acte par le moyen duquel la dation se réalise : ainsi, s'il s'agit du transfert de propriété d'un bien, on appliquera, au moins par analogie, les règles relatives à la vente du bien considéré (capacité d'aliéner, possibilité de demander la rescision pour lésion si l'immeuble remis en paiement est d'une valeur bien supérieure à la dette acquittée[1488]). Il en va de même des effets, pour lesquels on doit tenir compte des effets spécifiques à l'acte servant à réaliser le paiement : par exemple, on appliquera la garantie des vices cachés prévue en matière de vente si le bien remis en paiement est défectueux. Pour le reste, la dation en paiement produit les effets ordinaires d'un paiement, en ce qu'elle entraîne l'extinction de la dette. Cette extinction ne se produit normalement que par l'exécution de l'opération servant à effectuer le paiement, et non dès le moment où les parties s'accordent sur le mode de paiement : ainsi, si l'opération échoue (parce que le bien devant être remis en paiement n'est pas livré ou est défectueux), on en reviendra à l'obligation initiale, et le créancier pourra exiger le paiement de ce qui était prévu au départ – ce qui, de prime abord, semble distinguer la dation en paiement d'une novation. Cependant, l'article 2058 du Code civil prévoit que, dans un tel cas, la caution de la dette initiale est définitivement libérée – comme s'il y avait eu extinction définitive de la dette.

Enfin, il faut signaler que la dation en paiement est considérée par l'article 445 du Code de commerce comme un des moyens anormaux de paiement que le commerçant ne peut plus utiliser pour payer ses créanciers lorsqu'il est en état de cessation des paiements. Un tel paiement est nul[1489]. C'est sous cet angle que la dation en paiement vient le plus fréquemment devant les tribunaux luxembourgeois[1490].

[1485] Sur cette opération, voy. *infra*, n°s 919 et s.

[1486] D. HIEZ, « La nature juridique de la dation en paiement », *RTD civ.*, 2004, pp. 1999 et s.

[1487] Dans ce sens, VAN OMMESLAGHE, vol. 3, n° 1454.

[1488] Cass. fr. (3e civ.), 13 décembre 1968, *Bull. civ.*, III, n° 552.

[1489] Sur ces nullités de la période suspecte, voy. *infra*, n° 729.

[1490] Voy. p. ex. : Trib. Luxembourg, 11 novembre 1933 ; Cour d'appel, 18 juillet 1934, *Pas.*, 13, p. 235 ; Cour d'appel, 24 avril 1985, *Pas.*, 26, p. 345 ; Cour d'appel, 10 novembre 2010, n° 34814.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

2) *Règles spécifiques aux différents objets d'obligations*

a. *Obligations non monétaires*

652. **Corps certains et choses de genre.** Lorsque le contrat a pour objet la remise d'une chose autre que de l'argent, la question se pose souvent de savoir à partir de quand on considérera que la chose remise correspond bien à celle qui était promise. Le Code civil règle la question en distinguant selon que la chose promise était un corps certain ou une chose de genre. Dans le premier cas, l'article 1245 du Code civil dispose que « le débiteur est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure ». C'est là une application du principe déjà rencontré selon lequel le transfert de propriété d'une chose se produit dès le jour du contrat (vente ou donation) ; dès lors les risques sont à la charge du créancier : si la chose est détériorée par suite d'un cas de force majeure entre le jour de la vente et celui de la livraison, l'acheteur devra se contenter de la chose dans l'état où elle se trouve lors de la livraison. Il n'en va pas de même pour les choses de genre, pour lesquelles le transfert de propriété ne s'opère qu'au jour de la livraison. L'article 1246 du Code civil dispose alors que « le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise ». Il faut et il suffit donc, pour que le contrat soit considéré comme exécuté, que le vendeur livre une chose de qualité moyenne. Naturellement cela ne vaut qu'en l'absence de spécifications particulières dans le contrat : tout est ici une question d'interprétation du contrat.

b. *Obligations monétaires*

653. **Spécificité.** Le paiement des dettes de somme d'argent – de loin le plus important en pratique – présente une grande spécificité quant à la question de l'identité entre ce qu'il faut remettre et l'objet de l'obligation. Une première difficulté tient aux fluctuations de valeur de la monnaie dans laquelle le paiement doit être effectué. Une autre, qui surgit surtout dans les contrats internationaux, tient à la détermination de la monnaie qui peut être utilisée pour réaliser le paiement.

654. **Incidence des fluctuations de la valeur de la monnaie ; principe.** La monnaie – dans sa version moderne détachée de toute référence à un métal précieux – est un bien qui n'a pas de valeur en soi. Sa seule valeur est celle de sa puissance d'échange avec d'autres biens ou services. Or cette valeur d'échange peut considérablement fluctuer au fil du temps, et la question est de savoir s'il faut en tenir compte pour calculer la somme que le débiteur doit payer pour se libérer. Par exemple, si je vous ai emprunté 300 000 il y a dix ans (ce qui, à l'époque m'a permis d'acheter un appartement de 4 pièces à Luxembourg), est ce que, aujourd'hui, je dois vous rendre la somme nominale de 300 000 (alors même que cela ne me permet plus d'acheter qu'un studio), ou une somme permettant d'acheter

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

un appartement de 4 pièces aujourd'hui (700 000) ? La réponse de principe à cette question est certainement négative. Le principe, énoncé par l'article 1895 du Code civil pour le cas particulier du prêt d'argent, mais qui vaut d'une manière générale pour toutes les obligations de somme d'argent, est celui du *nominalisme monétaire* : « L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat ». Cela signifie que c'est au créancier de supporter le risque de la perte de valeur de la monnaie (ou de l'augmentation du coût de la vie). Celui qui m'a prêté 300 000 il y a dix ans, ne récupérera aujourd'hui que 300 000, quelle que soit la perte de valeur d'échange de cette somme pendant les dix ans. Il en va ainsi même si cette perte de valeur a été brutale et imprévisible, dès lors qu'on n'admet pas, comme on l'a vu, la révision du contrat pour imprévision.

655. Exceptions. Le principe du nominalisme monétaire n'est pas d'ordre public. Conventionnellement, les parties peuvent convenir de faire varier la somme à rembourser en fonction de certains indices extérieurs (le coût de la construction, la valeur du blé, etc.). Cette possibilité est aujourd'hui expressément prévue par l'article 1343 du Code civil français. C'est ce qu'on appelle une *clause d'indexation ou d'échelle mobile*. Dans certains droits étrangers – et notamment en France – ces clauses font l'objet d'une réglementation destinée à éviter leur effet inflationniste. Une telle réglementation n'existe pas de manière générale au Luxembourg. La loi n'y interdit les clauses que dans certains contrats, où l'indexation risque d'alourdir de manière trop forte la charge financière du contrat pour une partie : il en va ainsi en matière de bail d'habitation, où l'article 5 (5) de la loi du 21 septembre 2006 prohibe les clauses qui dérogeraient aux dispositions impératives relatives à la fixation et à la modification du loyer[1491]. En dehors de ces cas, la loi prévoit parfois elle-même une indexation automatique d'une prestation monétaire : il en va ainsi, tout particulièrement, de l'indexation des salaires prévue par l'article L. 223-1 du Code du travail, et qui est un des points forts de la réglementation du travail au Luxembourg.

Le principe du nominalisme monétaire est également écarté pour certaines obligations, qu'on appelle dettes ou obligations de valeur[1492]. Il s'agit d'obligations monétaires que la loi (ou parfois la

[1491] Pour d'autres cas, voy. Poelmans, n° 501.

[1492] Pour la France, voy. p. ex. : Terré, Simler, Lequette, Chenede 2023, n°s 1458 et s. ; pour la Belgique : Van Ommeslaghe, n°s 1451 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

jurisprudence) fait varier en fonction de la valeur des choses qu'elles représentent. Le débiteur va alors se libérer, non par le montant fixé au jour de la naissance de la dette, mais par celui qui est déterminé au jour de sa liquidation. La notion, doctrinale à l'origine, a été expressément consacrée par l'article 1343 du Code civil français et par l'article 5.205 du nouveau Code civil belge. Mais elle est également connue de la jurisprudence luxembourgeoise. Mais cette figure se rencontre essentiellement en dehors du droit des contrats, notamment en droit des successions et dans le droit des obligations extracontractuelles. Est par exemple une dette de valeur l'indemnité d'occupation que doit payer en cas de divorce un époux qui a occupé seul le domicile conjugal depuis que l'autre l'a quitté[1493], ou la récompense de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil que doit payer un époux à l'autre dont le patrimoine a contribué à enrichir la communauté[1494].

656. Détermination de la monnaie de paiement. La monnaie stipulée dans un contrat peut avoir un double rôle : celle d'une unité de valeur et celle d'un moyen de paiement. Ces deux rôles peuvent être dissociés : on peut calculer le montant d'une prestation en dollars et prévoir que le paiement effectif se fera en euros, en fonction du cours du change au jour du paiement. Cette dissociation, qui équivaut à une clause d'indexation sur une monnaie étrangère, est licite. L'article 1153-1 du Code civil, inséré par une loi du 12 juillet 1980, en règle les conséquences pour le cas où le débiteur est en retard pour payer, et que la monnaie dans laquelle la somme est due subit une dépréciation entre l'échéance et le jour du paiement effectif. Dans ce cas, le débiteur est tenu « à un versement d'un montant additionnel correspondant à la différence entre les taux de change au jour de l'échéance et au jour du paiement effectif ». Il n'en va autrement que si le débiteur s'est trouvé empêché de s'acquitter par le fait du créancier ou par suite de force majeure, ou si la dépréciation n'a pas entraîné de dommage pour le créancier.

S'agissant de la monnaie dans laquelle il faut s'acquitter du paiement, le principe est que, à défaut de clause particulière dans le contrat, elle est déterminée par le lieu du paiement : les paiements effectués au Luxembourg s'effectuent donc en principe en monnaie

[1493] Cour d'appel, 16 mai 2018, *Pas.*, 38, p. 908 ; Cour d'appel, 26 avril 2023, n° CAL-2021-00992.
[1494] Cour d'appel, 18 mars 2015, n° 36537.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

nationale (l'euro). Cependant, il est licite de stipuler un paiement en monnaie étrangère, sauf réglementations particulières qui pourraient intervenir sur le contrôle des changes[1495].

B) *Indivisibilité du paiement*

1) *Principe*

657. Article 1244 du Code civil. Selon l'article 1244, alinéa 1er du Code civil (repris par l'article 1342-4 du Code civil français et par l'article 5.200 du nouveau Code civil belge), « le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible » (ce qui est le cas en particulier des dettes de somme d'argent). Cela signifie que, si le débiteur offre de ne payer qu'une partie de la somme, le créancier peut refuser et les intérêts de retard courront sur la totalité. Le débiteur, qui n'offre qu'un paiement partiel, n'a pas la possibilité de recourir dans ce cas à la procédure des offres réelles, qui présuppose un paiement intégral.

Ce principe, cependant, ne vaut que dans la mesure où les parties au contrat n'ont pas elles-mêmes prévu l'étalement dans le temps de l'exécution de l'obligation, ce qui est extrêmement fréquent, notamment dans le cadre des prêts bancaires. Le principe d'indivisibilité ne jouera alors que par rapport à la somme due à chaque échéance.

2) *Limites*

658. Délais de paiement (renvoi). L'article 1244 du Code civil présente comme une exception au principe de l'indivisibilité du paiement la possibilité pour le juge d'accorder au débiteur un délai de grâce. C'est une présentation curieuse, car le délai de grâce peut très bien porter sur la totalité de la dette, auquel cas le débiteur, autorisé à payer plus tard, devra s'acquitter de l'intégralité de la dette. Il n'y a atteinte au principe d'indivisibilité que si le délai ne porte que sur une partie de la dette, le débiteur devant alors en payer une partie immédiatement – sans que, alors, le créancier ne puisse refuser ce paiement partiel. Il en va de même pour tous les délais spéciaux que le législateur moderne permet au juge d'accorder, soit aux commerçants en difficulté, soit aux particuliers surendettés. Ces différents dispositifs ont déjà été examinés dans le cadre de l'étude du terme, et il est inutile d'y revenir ici[1496].

659. Pluralité de débiteurs (renvoi). Il faut rappeler que s'il existe plusieurs débiteurs, le créancier doit en principe diviser ses poursuites contre les différents débiteurs. Il n'en va autrement que s'il y a solidarité entre les débiteurs, ou si la dette est indivisible, par nature ou par convention[1497].

[1495] Comp. les règles posées par l'article 7 : 108 des PDEC.
[1496] Voy. *supra*, nos 585 et 586.
[1497] Voy. *supra*, nos 615 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§ 3. Les modalités du paiement

660. Volonté des parties. La manière dont, concrètement, doit s'opérer le paiement – donc l'exécution du contrat – relève avant tout de la volonté des parties. Si les articles 1247 et suivants du Code civil posent à cet égard un certain nombre de règles générales quant au lieu, au moment et aux frais du paiement, ce ne sont que des règles supplétives, qui sont très souvent écartées par des clauses contraires (**A**). De même, dans le cas où l'obligation à exécuter est une obligation de somme d'argent, c'est aux parties qu'il revient en principe de déterminer avec quels instruments s'effectuera le paiement (**B**).

A) *Règles générales*

661. Lieu du paiement. Il ne faut pas croire que la question du lieu du paiement est une question anecdotique. La question est de savoir si le paiement est quérable (c'est au créancier de venir chercher son paiement chez le débiteur) ou portable (c'est au débiteur d'aller porter le paiement chez le créancier – ou de lui envoyer). Pour les obligations de somme d'argent, compte tenu des moyens modernes de paiement, qui n'impliquent plus aucun déplacement matériel des parties, la question n'est plus vraiment celle du lieu, mais celle de savoir qui doit prendre l'initiative du paiement : en d'autres termes, peut-on reprocher au débiteur de n'avoir pas payé, et lui faire payer des intérêts de retard, si le créancier n'a pas pris l'initiative de lui demander ce paiement ? Pour les obligations non monétaires, la question a une importance pratique encore plus grande : il s'agit, par exemple, de savoir si c'est au vendeur d'aller livrer la chose chez l'acheteur, ou si c'est à l'acheteur de venir chercher cette chose chez le vendeur. Et, derrière cette question, se dissimulent des enjeux fondamentaux : qui doit se charger de l'organisation du transport ? Qui doit, en conséquence, payer le transporteur ? Et qui doit supporter les risques si la chose périt en cours de transport ? Donc qui doit s'assurer contre ces risques ?

L'article 1247 du Code civil répond à la question du lieu du paiement par une série de distinctions. En principe, « le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention ». Mais, si les parties n'ont rien dit à ce sujet, « le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet », c'est-à-dire, en général, chez le débiteur. Si rien n'est prévu, c'est donc en général à l'acheteur d'aller chercher la chose chez le vendeur (ou au lieu d'entreposage de la chose), non l'inverse. Le paiement est ici quérable. Il en va de même en principe dans tous les autres cas où « le paiement doit être fait au domicile du débiteur ». Ces solutions sont reprises par l'article 1342-6 nouveau du Code civil français et par l'article 5.203 du Code civil belge. Mais, en droit français, il en va autrement si le paiement porte sur une somme d'argent : le paiement est alors portable. Le nouveau droit français reprend ici la distinction faite par les PDEC (art. 7:101). Mais il faut insister : il ne s'agit là que de règles supplétives, et en pratique, ce point sera presque toujours réglé par les parties. En matière de vente internationale, il peut l'être notamment par référence aux Incoterms élaborés par la Chambre de commerce internationale, qui définissent les différentes formules de vente en fonction des moyens de transport utilisés [par exemple : FOB, *free on board*, s'il est prévu que l'acheteur vienne chercher la marchandise à bord du navire qui l'a transporté, DAT : *Delivered At Terminal*, marchandises (déchargées) livrées sur quai, dans un terminal maritime, fluvial, aérien, routier ou ferroviaire désigné, etc.]

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

662. **Moment du paiement.** Le rôle de la volonté des parties est également prépondérant pour déterminer le moment du paiement, qui n'est rien d'autre que l'échéance du terme suspensif prévu pour l'exécution du contrat. Si rien n'est prévu, le paiement doit intervenir immédiatement – ou du moins, comme le disent les PDEC « dans un délai raisonnable à partir de l'exécution du contrat ».

663. **Frais du paiement.** Les frais du paiement sont, selon l'article 1248 du Code civil, à la charge du débiteur. Cette règle, reprise par l'article 1342-6 du Code civil français et 5.204 du Code civil belge, n'est guère en accord avec le principe selon lequel le paiement est normalement quérable : c'est au créancier de venir chercher son paiement chez le débiteur, mais aux frais de celui-ci. En pratique, les parties lieront le plus souvent les deux questions : c'est à la partie qui doit prendre l'initiative et/ou qui doit venir chercher la chose à tel ou tel endroit qu'incomberont normalement les frais (de virement, d'envoi postal, de déplacement, de transport, etc.) correspondants.

B) *Règles spécifiques aux obligations de sommes d'argent*

664. **Instruments de paiement.** – On se contentera d'évoquer ici les différents instruments de paiement des obligations monétaires, dont l'étude détaillée relève du droit bancaire. Autrefois les paiements s'effectuaient en espèces (ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire), mais ce mode de paiement n'est plus utilisé que pour les petites transactions. Aujourd'hui, la plupart des paiements s'effectuent en monnaie dite scripturale, parce qu'ils résultent d'un jeu d'écritures (aujourd'hui informatisée) qui fait passer l'argent du compte du *solvens* au compte de l'*accipiens* : remise d'un chèque (rare au Luxembourg), virement, ordre permanent pour les créances périodiques, ordre donné au moyen d'une carte de paiement ou de crédit. Les règles applicables à ces divers instruments peuvent interférer avec le droit des obligations, notamment en ce qui concerne la question du moment du paiement. Par exemple, il est important de déterminer si un paiement effectué par virement est considéré comme acquis au moment même où le débiteur émet l'ordre, ou seulement au moment où le compte du créancier est crédité. Le principe est que le transfert de monnaie s'effectue seulement au moment où le compte du créancier est crédité[1498], mais le fait de donner l'ordre de virement, s'il existe une provision suffisante, peut néanmoins être considéré comme un acte d'exécution, empêchant le créancier, au nom de l'exigence de bonne foi, de mettre en œuvre immédiatement les sanctions de l'inexécution[1499].

SECTION 2. LES EFFETS DU PAIEMENT

665. **Exécution et extinction.** Lorsqu'il porte sur une obligation contractuelle – ce qui est le contexte dans lequel on l'étudie ici – le paiement constitue d'abord une exécution du contrat. Sous cet angle, son effet sera d'interdire au créancier de mettre en œuvre les sanctions de l'inexécution contractuelle : exécution forcée, résolution, dommages et intérêts, etc. En particulier, pour les obligations

[1498] Trib. Luxembourg, 29 octobre 2008, *D.A.O.R.*, 2009, n° 90.
[1499] Cass., 27 mai 1971, *Pas.*, 21, p. 462, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de somme d'argent, le débiteur, une fois qu'il aura payé, n'aura plus à payer des intérêts de retard – et c'est le plus souvent sous cet angle qu'on discute du moment exact auquel le paiement se produit. Ce n'est cependant pas sous cet angle que les rédacteurs du Code civil ont envisagé le paiement, dans lequel ils ont vu, d'abord, un mode d'extinction de l'obligation. Cet effet extinctif (§ 1) est cependant écarté dans un cas très important, où le paiement, effectué par un tiers, n'a qu'un effet translatif (§ 2).

§1. Principe : l'effet extinctif

666. Principe. Dès lors que l'obligation est payée, elle est éteinte. Il en résulte diverses conséquences. Non seulement le créancier ne peut plus en demander l'exécution, mais cette créance sort de son patrimoine : il ne peut plus la céder, ni la mettre en gage, ses créanciers ne peuvent plus la saisir. Si cette créance était assortie de sûretés, ces sûretés n'ont plus de raison d'être, elles sont éteintes par l'effet du paiement : par exemple, la caution qui a garanti le paiement est libérée. Il va de soi que, si le paiement n'est que partiel, la dette ne sera que réduite, et non éteinte, dans la limite du paiement effectué. Peuvent alors se poser des problèmes d'imputation des paiements.

667. Imputation des paiements. La question de l'imputation des paiements se pose dans deux séries de cas. La première situation est celle où le débiteur n'a payé qu'en partie une dette qui comprend différentes parties présentant des caractéristiques différentes : par exemple, une partie en capital et une partie en intérêts. Si on décide que le paiement effectué diminue d'abord les intérêts, cela signifie que le montant du capital reste intact, et que ce capital va continuer à produire des intérêts comme si la dette n'avait pas commencé à être remboursée. Si en revanche, c'est le capital qui est amputé, les intérêts produits seront moins importants. De même, si la dette a été cautionnée pour une partie seulement, doit-on considérer que les paiements s'imputent d'abord sur la partie cautionnée (auquel cas la caution verra sa charge diminuée, et peut même se voir libérée), ou sur la partie non cautionnée, la caution restant alors toujours tenue de la même somme ? Une seconde situation est celle où le débiteur a envers le créancier plusieurs dettes ayant des caractéristiques différentes (l'une porte intérêt à 5 % et l'autre à 10 %, l'une est

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

garantie par une hypothèque et l'autre pas, etc.), de sorte que le fait d'imputer sur l'une ou l'autre de ces dettes ne produira pas le même résultat. D'une manière générale, l'imputation dépend de la volonté des parties, mais en cas de désaccord ou d'absence de volonté exprimée, les articles 1253 à 1256 du Code civil posent des règles supplétives. En principe, c'est au débiteur, lorsqu'il paye, de déclarer sur quelle dette (ou sur quelle partie de la dette) il entend imputer son paiement (C. civ., art. 1253), mais il n'a pas le choix lorsque la dette porte intérêts : l'imputation se fera alors d'abord sur les intérêts (ce qui est en faveur du créancier) (C. civ., art. 1254). Si le débiteur n'a rien dit, le créancier peut, dans la quittance qu'il adresse au débiteur (et qui fait preuve du paiement), choisir sur quelle dette il impute, et le débiteur ne peut aller contre ce choix (C. civ., art. 1255). Si personne n'a rien dit, alors l'article 1256 du Code civil fait diverses distinctions : soit une dette est échue et pas l'autre, alors le paiement sera imputé d'abord sur celle qui est échue ; soit les deux dettes sont toutes deux échues, et alors le paiement s'imputera sur la dette « que le débiteur avait le plus d'intérêts d'acquitter » (par exemple, celle qui porte intérêt au taux le plus élevé, celle qui est garantie par une sûreté qui grève le patrimoine du débiteur, etc.). Si on ne peut pas faire la différence, alors l'imputation se fait sur la dette la plus ancienne, et si elles sont de même date, on impute proportionnellement (C. civ., art. 1256). Les règles retenues par les projets européens ne sont pas substantiellement très différentes[1500]. On retrouve en particulier la règle importante selon laquelle, si une dette portée intérêts, le paiement s'impute d'abord sur les intérêts, avant de diminuer le capital. En France, la matière est désormais réglée, sans grand changement par l'article 1342-10 du Code civil, en Belgique par les articles 5.208 à 5.210 du nouveau code.

§2. Limite : le paiement à effet translatif (la subrogation)

668. Renvoi. Lorsque le paiement est effectué par un tiers, et qu'il n'est pas commandé par une intention libérale, ce paiement peut donner lieu à subrogation, soit en vertu de la loi, soit par l'effet d'une convention entre les parties. Cela signifie que le tiers *solvens* devient créancier à la place du créancier originaire, qu'il a désintéressé, la créance payée lui est transférée. Le paiement n'a donc pas

[1500] Voy. l'article 7 : 109 des PDEC, l'article 2 : 110 du DCFR, l'article 84 du Code Gandolfi.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ici d'effet extinctif, mais un effet translatif. L'étude détaillée de ce mécanisme sera faite en parallèle avec celle des autres moyens de transfert des créances, ce qui en fera mieux comprendre l'intérêt[1501].

SECTION 3. LA PREUVE DU PAIEMENT

669. Qui et comment ? Il arrive fréquemment qu'un contentieux s'élève entre le créancier et le débiteur au sujet de la réalité du paiement, le débiteur prétendant s'être libéré, le créancier prétend que l'obligation n'a pas été exécutée. Comme toujours en matière de preuve se posent deux questions : celle de la charge de la preuve (qui doit prouver ?) (**§ 1**) et celle des moyens de preuve (comment la preuve peut-elle être apportée ?) (**§ 2**).

§1. La charge de la preuve

670. Article 1315 du Code civil. En principe, c'est au débiteur qui se prétend libéré d'apporter la preuve du paiement : c'est une des règles de base du droit de la preuve. Cependant les articles 1282 à 1284 du Code civil, bizarrement placés dans la section relative à la remise de dette, posent certaines présomptions de paiement en cas de remise au débiteur du titre qui constate l'obligation : le créancier est présumé avoir reçu son paiement lorsqu'il remet au débiteur, soit l'original de l'acte sous seing privé, soit la grosse de l'acte authentique (c'est-à-dire la copie comportant la formule exécutoire). Il ne s'agit cependant que d'une présomption simple, le créancier pouvant toujours essayer de prouver qu'il n'a pas été payé. Le nouvel article 1342-9 du Code civil français reprend ces solutions. De même, les articles 2271 à 2273 du Code civil édictent des prescriptions courtes fondées sur l'idée de présomption de paiement, la preuve contraire ne pouvant alors être apportée que par l'aveu du débiteur ou le serment[1502].

La question de la charge de la preuve se pose de manière particulière pour les obligations de faire non monétaires. Si le créancier contractuel prétend que l'obligation a été mal exécutée, il lui appartient de le prouver. Mais cette preuve ne sera pas toujours suffisante : dans certains cas, il faudra aussi que le créancier prouve que le débiteur n'a pas accompli les diligences nécessaires pour obtenir le résultat, alors que dans d'autres cas, il lui suffira de prouver la non-obtention du résultat. Cette différence a été formalisée sous la forme de la distinction entre les obligations de

[1501] Voy. *infra*, n°s 1018 et s.
[1502] Voy. *infra*, n° 941.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

moyens et les obligations de résultat, qui est souvent présentée comme une différence quant à la charge de la preuve. Nous verrons cependant plus loin qu'en réalité, la distinction ne se situe pas du tout sur le terrain de la preuve : dans tous les cas, en effet, le créancier doit prouver que l'obligation n'a pas été exécutée, mais cette preuve est plus ou moins exigeante selon le degré de l'obligation.

§2. Moyens de preuve

671. Obligations non monétaires. Il ne fait aucun doute que l'exécution d'une obligation de faire ou de ne pas faire peut se prouver par tous moyens. Même si on estime que le paiement est un acte juridique, il apparaît absurde d'exiger une preuve par écrit pour des faits matériels (la construction d'une maison, la délivrance d'une chose, etc.), *a fortiori* pour des abstentions. Bien entendu, rien n'empêche le débiteur de tenter de se ménager une preuve écrite de son exécution (la réception des travaux, le bon de livraison signé par le créancier, etc.), mais, dans la mesure où l'établissement de cet écrit dépend de la bonne volonté du créancier, on ne peut pas pénaliser le débiteur qui ne peut le fournir. La preuve pourra donc se faire par tous moyens.

672. Obligations de somme d'argent. On considérait traditionnellement, en revanche, que le paiement d'une somme d'argent, en tant qu'acte juridique, devait se prouver par écrit[1503]. La quittance, acte remis au débiteur qui a payé, est le moyen habituel de faire cette preuve.

Cependant cette position, clairement consacrée par la Cour de cassation belge[1504] semble abandonnée en France où plusieurs arrêts français ont posé que « la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens »[1505] et cette solution est reprise par le nouvel article 1342-8 du Code civil français qui affirme, de manière générale, que « le paiement se prouve par tous moyens ». Depuis quelques années, la Cour d'appel du Luxembourg se prononce également dans ce sens[1506].

[1503] Dans ce sens Trib. Luxembourg, 11 décembre 2003, n°s 75251 et 77614.

[1504] Cass. be., 6 décembre 2002, *Pas. be.*, 2002, p. 2349.

[1505] Cass. fr. (1re civ.), 6 juillet 2004, n° 01-14.618 ; Cass. fr. (3e civ.), 27 février 2008, n° 07-10.222, *Bull.*, 2008, III, n° 35 (cassation partielle).

[1506] Cour d'appel, 25 novembre 2009, *Pas.*, 35, pp. 40 et s., spéc. pp. 45 et 47 ; Cour d'appel, 4 juillet 2012, n° 37596 ; Cour d'appel, 11 juillet 2018, n° 43277.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'exécution des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 745-769
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

673. Un problème central du droit des contrats. Que peut faire le créancier d'une obligation contractuelle si son débiteur n'exécute pas son obligation ? Par exemple, j'ai prêté de l'argent et mon emprunteur ne me le rend pas en temps voulu, j'ai acheté du matériel nécessaire à la bonne marche de mon entreprise, et le vendeur ne me le livre pas, j'ai fait construire une maison, et la maison qui m'est livrée n'est pas conforme aux plans, etc. Il apparaît évident, dans ces hypothèses, que le débiteur doit être sanctionné, et que le créancier doit disposer de certains moyens d'action pour obtenir la satisfaction attendue ou du moins un certain équivalent. Sans quoi la force obligatoire serait un vain mot, et il serait inutile de passer des contrats. Mais, d'un autre côté, le débiteur avait peut-être de bonnes raisons de ne pas exécuter, il en a peut-être été empêché, il faut peut-être lui laisser un peu de temps pour se rattraper, il n'est peut-être pas raisonnable de le contraindre à exécuter, peut-être que c'est à tort que le créancier se plaint d'une mauvaise exécution, etc. Comme toujours, il ne faut pas voir les choses d'un seul côté, et, sur cette question comme sur d'autres, il y a un équilibre à trouver entre les intérêts des parties en cause, entre la sécurité que doit procurer le contrat et la protection nécessaire du débiteur. Faut-il, en particulier, laisser le créancier libre juge des moyens qu'il met en œuvre en réaction à l'inexécution, ou faut-il lui imposer une gradation dans la riposte en fonction de la gravité de cette inexécution ou du préjudice qu'il subit ? Faut-il lui imposer, pour mettre en œuvre ces moyens, de passer par un tribunal, qui jugera a priori du bien-fondé et de la mesure de la sanction, ou peut-on se contenter d'un contrôle judiciaire *a posteriori* des mesures que le créancier aurait prises unilatéralement ? La manière dont le système juridique répond à ces questions est un aspect central du droit des contrats, parce que la grande majorité des litiges contractuels naissent lorsque l'une des parties se plaint de ce que l'autre n'a pas exécuté ses obligations. C'est généralement à ce propos que viennent devant le juge toutes les discussions précédemment rencontrées sur l'existence du contrat, sur sa validité, sur son interprétation, sur le changement de circonstances, etc. de sorte qu'un exposé pragmatique du droit des contrats pourrait être tout entier organisé à partir des problèmes d'inexécution.

Cependant, avant de voir comment le droit luxembourgeois traite de cette problématique si importante, il faut poser un certain nombre de repères sur la notion même d'inexécution, sur les

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 773-786
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

différentes formes qu'elle peut prendre et sur la nature des règles qui permettent d'y remédier. Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons commencer l'étude des solutions du Code civil.

674. Inexécution du contrat ou inexécution des obligations ? Dans le langage courant, on parle habituellement de l'inexécution du contrat, mais ce n'est là qu'une facilité de langage. Il est plus exact de parler de l'inexécution des obligations contractuelles. Le contrat lui-même, en tant qu'acte normatif doté de force obligatoire, n'est pas susceptible d'être exécuté ou inexécuté : on ne peut pas dire par exemple que le prêteur qui prétendrait obtenir son remboursement avant le terme, le contractant qui contesterait la compétence d'un tribunal valablement désigné par une clause d'un contrat, « n'exécute » pas le contrat, mais seulement qu'il ne le « respecte pas », ou qu'il « viole » la force obligatoire, et dans ces hypothèses, la sanction sera simplement que la prétention contraire au contrat sera repoussée par le juge. Il n'est nul besoin de donner au cocontractant des moyens d'action spécifiques en réaction à cette négation de la force obligatoire. On est en présence d'une inexécution, en revanche, lorsqu'un contractant est débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire quelque chose[1507], et qu'il ne fait pas ce qu'il devait faire ou qu'il fait ce qu'il ne devait pas faire. Dans ce cas, la simple application du contrat par le juge n'est pas suffisante pour satisfaire le créancier : il ne suffit pas que le juge dise au débiteur « vous êtes en tort de ne pas exécuter » pour que la somme due soit payée, que le bien non livré parvienne entre les mains de l'acheteur ou que la maison mal construite soit refaite, il faudra trouver des moyens concrets permettant de donner au créancier l'avantage qu'il n'a pas eu (soit en contraignant le débiteur à exécuter, soit en procurant un équivalent au créancier).

Il est d'autant moins fondé de parler de l'inexécution du contrat que la question de l'inexécution n'est pas spécifique aux obligations contractuelles : elle se pose d'une manière générale pour toute obligation quelle qu'en soit la source. Le créancier d'une pension alimentaire octroyée par un juge, par exemple, doit lui aussi disposer

[1507] Certains ajouteront « ou de donner » une chose, c'est-à-dire d'en transférer la propriété (Voy. *supra*, n° 52). Mais dans la mesure où le transfert de propriété, dans le système du Code civil, est toujours automatique, la prétendue « obligation » de donner est en quelque sorte auto-exécutable. S'il peut y avoir inexécution, c'est seulement de l'obligation de faire certains actes qui sont nécessaires au déclenchement du transfert (p. ex., en matière immobilière, la passation de l'acte authentique). On retombe alors dans le cas de l'inexécution d'une obligation de faire.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 773-786
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de certains moyens d'action si son débiteur ne le paye pas, de même que l'administration fiscale si le contribuable ne paie pas ses impôts. Cependant, la question de l'inexécution présente une spécificité marquée lorsque l'obligation est née d'un contrat, ce qui justifie qu'on en fasse habituellement l'étude dans les cours et manuels de droit des contrats, plutôt que dans ceux consacrés au « régime général des obligations ». D'une part, certaines conséquences de l'inexécution, qui touchent le contrat lui-même, n'ont de sens que pour les obligations contractuelles (exception d'inexécution, résolution pour inexécution). D'autre part, le système juridique peut choisir de donner un régime spécial à des sanctions à vocation générale : c'est ainsi que, en droit luxembourgeois, les dommages et intérêts qui sanctionnent l'inexécution d'une obligation contractuelle relèvent du régime spécial de la responsabilité contractuelle, distincte dans ses conditions et dans ses effets, de la responsabilité qui sanctionne l'inexécution d'une obligation d'une autre source. Cette ambivalence des règles relatives aux sanctions de l'inexécution est très sensible si on compare la manière dont ces règles sont traitées dans les textes issus des réformes du droit des obligations en France et en Belgique : alors que le droit français, fidèle à l'approche traditionnelle, traite de l'ensemble de ces questions dans le cadre du droit des contrats (à la seule exception de la mise en demeure), le nouveau code belge n'en traite dans ce cadre que de manière très partielle, et concentre l'essentiel des règles dans la partie relative au régime général de l'obligation. Dans le cadre de cet ouvrage consacré au droit des contrats, nous traiterons ici de l'ensemble des questions, sauf à signaler, dans les développements qui vont suivre, les règles qui valent pour toutes les obligations, et celles qui sont spécifiques aux obligations contractuelles.

675. Inexécution ou inexécutions ? L'inexécution d'une obligation (contractuelle ou non) peut prendre différentes formes. Il peut s'agir d'un simple retard dans l'exécution : par exemple, l'emprunteur devait restituer la chose ou la somme prêtée tel jour, l'entrepreneur devait avoir fini la maison avant telle date, et la date est dépassée – mais il peut encore exécuter (un jour, un mois, un an plus tard). Mais il peut aussi s'agir d'une inexécution définitive : soit parce qu'on sait que le débiteur n'exécutera jamais (il l'a dit, il est insolvable, il ne peut plus se procurer la chose qu'il devait livrer, etc.), soit parce qu'il est de toute façon trop tard pour exécuter (le traiteur n'a pas livré le repas de mariage le jour de

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 773-786
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

la cérémonie !). On peut encore parler d'inexécution lorsque la prestation promise a été accomplie, mais qu'elle ne l'a pas été de manière conforme à ce qui avait été convenu ou à ce qui pouvait être attendu : le traiteur a bien livré au jour dit le repas de mariage, mais un des mets était avarié, et les convives ont été intoxiqués, la maison a été construite à temps, mais elle n'est pas conforme aux plans, l'avocat s'est occupé du dossier de son client, mais il a laissé passer un délai pour agir de sorte que l'affaire a été perdue, etc. Une autre distinction peut être faite quant aux causes de l'inexécution : si le débiteur n'a pas exécuté, ce peut être parce qu'il a été négligent, ou même parce qu'il a volontairement refusé de tenir son engagement, mais cela peut être aussi parce que l'exécution est devenue impossible par suite de circonstances extérieures (force majeure). De prime abord, il est clair que la réaction du droit ne peut pas être la même dans toutes ces hypothèses : on ne peut pas envisager les mêmes moyens d'action contre le débiteur s'il est simplement en retard, ou s'il est de toute façon trop tard pour exécuter, de même qu'on n'imagine pas que le débiteur qui n'a pas pu exécuter par suite d'un cas de force majeure soit sanctionné de la même manière que celui qui a été négligent. Dans une approche qui se veut pragmatique, certains droits organisent les conséquences de l'inexécution de manière différenciée selon les cas d'inexécution : en cas de retard, le créancier a tel ou tel moyen à sa disposition, en cas d'inexécution définitive, il peut faire telle chose, etc. C'était le cas du droit allemand avant la réforme du droit des obligations de 2000. Le Code civil, en revanche, ne distingue pas de manière générale les différents cas d'inexécution et la doctrine a toujours adopté une conception globale de l'inexécution, englobant toutes les hypothèses précédentes, sauf à admettre ensuite des différences de détail selon les hypothèses. Cette présentation est aujourd'hui généralement suivie par la plupart des systèmes juridiques, et elle se retrouve dans les différents projets européens.

676. Imputabilité ou non-imputabilité de l'inexécution : la force majeure. Dans certains cas, alors même que le contrat n'a pas été ou a été mal exécuté, le débiteur contractuel échappera en tout ou partie aux conséquences de l'inexécution, s'il apparaît que cette inexécution a été provoquée par un événement extérieur qui a rendu l'exécution impossible. Commune à tous les systèmes juridiques, et se retrouvant dans tous les textes internationaux et projets européens,

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 773-786
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

cette situation apparaît, dans le Code civil du Luxembourg, sous des vocables différents : « cause étrangère » dans l'article 1147, « force majeure et cas fortuit » dans l'article 1148, « cas fortuit ou force majeure » dans l'article 1348. C'est la formule « force majeure » qui l'a emporté, et on peut la considérer comme synonyme de toutes les autres (cause étrangère libératoire de l'article 1147 du Code civil, ou cas fortuit).

La notion de force majeure, qui a des incidences tant en matière contractuelle qu'en matière de responsabilité délictuelle, est une notion ambiguë. On l'utilise parfois pour désigner des événements naturels qui ont rendu inévitable la survenance du dommage (par exemple, un cataclysme qui, coupant les moyens de transport, a empêché la livraison d'un bien en temps utile). L'expression, cependant, a un sens plus général : elle vise tout événement extérieur ayant été la véritable cause du dommage, ou, en matière contractuelle, de l'impossibilité d'exécution du contrat. Cet événement peut être tout aussi bien une décision de l'État (parfois appelée fait du prince), le fait d'un tiers, ou le comportement de la victime elle-même. Peu importe la nature de l'événement, pourvu qu'il présente certains caractères, qui peuvent le faire considérer comme la cause unique du dommage ou de l'impossibilité d'exécution.

677. Éléments constitutifs de la force majeure : évolution en France et en Belgique. Traditionnellement, en droit français, la notion de force majeure était définie de la même manière en matière contractuelle et en matière de responsabilité délictuelle. On exigeait, pour qu'un événement puisse être qualifié de force majeure, la réunion de trois éléments : il fallait que cet événement ait été extérieur à l'auteur du dommage, imprévisible et irrésistible pour lui, et c'est cette présentation, assez différente de celle qui s'est développée en Belgique[1508] qui est toujours reçue au Luxembourg[1509]. La doctrine et la jurisprudence françaises avaient cependant tendance, depuis quelques

[1508] Pour la Cour de cassation belge, un événement est constitutif de force majeure s'il rend l'exécution de l'obligation impossible et s'il est exempt de toute faute du débiteur : Cass. be., 12 juin 1947, *Pas. be.*, 1947, I, p. 264 ; Cass. be., 9 décembre 1976, *Pas. be.*, 1967, I, p. 408. Sur le droit belge en la matière, voy P.-A. Foriers et C. De Leval, « Force majeure et contrat », in P. Wéry (dir.), *Le droit des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code civil*, Bruxelles, La Charte, 2004, pp. 498 et s. La différence semble cependant être plus de présentation que de fond.

[1509] Ravarani, n°s 1068 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 773-786
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

décennies, à remettre en cause cette trilogie traditionnelle[1510], et ce courant n'est pas resté sans influence sur la jurisprudence luxembourgeoise[1511]. Cette évolution affecte d'abord l'exigence d'extériorité. Celle-ci reste sans doute, en principe, une condition de base de la force majeure : elle implique notamment qu'un contractant ne puisse invoquer comme cause d'exonération les fautes ou les empêchements de ses préposés puisque précisément il doit en répondre. Mais cette condition est aujourd'hui appréciée avec moins de rigueur qu'autrefois. Par exemple, on admettra qu'une grève de salariés, qui empêche l'entreprise de satisfaire ses clients dans les délais contractuellement stipulés, peut être extérieure à l'entreprise si elle n'a pas été provoquée par des désaccords internes, mais par un mot d'ordre syndical national[1512]. Surtout, certaines décisions ont admis que la maladie du débiteur contractuel, qui provient de causes internes, pouvait constituer un cas de force majeure l'exonérant de toute responsabilité si elle a été par ailleurs imprévisible et irrésistible[1513]. L'évolution affecte ensuite l'imprévisibilité : sans aller jusqu'à renoncer complètement à cette exigence, comme l'ont fait certaines décisions françaises, il est parfois soutenu que, ce qui compte d'abord, c'est l'irrésistibilité de l'événement, c'est-à-dire, en matière contractuelle, le fait que cet événement rende l'exécution absolument impossible. Dans ce sens, la Cour de cassation française a jugé, dans une décision, que, « l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement dommageable »[1514]. L'imprévisibilité ne serait exigée de surcroît que si la prévision de l'événement aurait pu permettre de prendre des précautions suffisantes pour l'éviter ou le neutraliser. On traduit parfois cette idée en remplaçant la notion d'imprévisibilité par celle d'inévitabilité[1515]. Cependant, l'Assemblée plénière

[1510] Pour une vision renouvelée de la force majeure en droit français, voy. P.-H. ANTONMATTEI, *Contribution à l'étude de la force majeure*, coll. Bibliothèque de droit privé, Paris, LGDJ, 1992.

[1511] Voy. p. ex. Trib. Luxembourg, 23 octobre 2007, n° 224/07 VIII, cité par RAVARANI, n° 1075.

[1512] RAVARANI, n° 1069.

[1513] En France : Cass. fr. (1re civ.), 10 février 1998, n° 96-13.316 ; Cass. fr. (ass. plén.), 14 avril 2006, n° 02-11.168. Au Luxembourg, cette position a été suivie par Trib. Luxembourg, 7 juillet 2009, n° 163/09 XI ; Cour d'appel, 28 avril 2010, n° 34304. Voy. les critiques de RAVARANI, n° 1070.

[1514] Cass. fr. (1re civ.), 9 mars 1994, nos 91-17459 et 91-17464.

[1515] P.-H. ANTONMATTEI, *Contribution à l'étude de la force majeure*, *op. cit.* et « Ouragan sur la force majeure », *JCP*, 1996, I, p. 3907.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 773-786
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de la Cour de cassation française a réaffirmé en 2006 l'exigence cumulative des deux critères d'irrésistibilité et d'imprévisibilité[1516], et cette position est généralement suivie.

Les réformes récentes, tant en France qu'en Belgique, ont été l'occasion d'une importante nouveauté, consistant à donner des définitions différentes de la force majeure en matière contractuelle et en matière de responsabilité extracontractuelle. En France, en matière extracontractuelle, en l'absence pour l'instant d'une réforme récente de la responsabilité, la jurisprudence semble vouloir s'en tenir à la trilogie traditionnelle (extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité)[1517]. En matière contractuelle, en revanche, la force majeure est désormais définie de manière plus souple par le nouvel article 1218 du Code civil, placé en tête des articles relatives aux sanctions de l'inexécution du contrat. Le texte se contente d'un « événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». L'assouplissement est encore beaucoup plus net en Belgique. En matière délictuelle, selon l'article 6.7 du nouveau Code civil, « il y a force majeure lorsqu'il est impossible de respecter la règle de conduite applicable », tandis que, en matière contractuelle, « il y a force majeure en cas d'impossibilité pour le débiteur, qui ne lui est pas imputable, d'exécuter son obligation ». Dans les deux cas, le texte précise qu'« il est tenu compte du caractère imprévisible et inévitable » de l'obstacle à l'exécution ou, en matière délictuelle, du fait qui empêche de respecter la règle de conduite. On remarque que l'extériorité a disparu, et que l'imprévisibilité et l'inévitabilité ne sont plus à proprement parler des conditions de la force majeure, mais des éléments d'appréciation à prendre en compte par le juge. En France et en Belgique, cependant, un point commun demeure en matière contractuelle : l'impossibilité d'exécution de l'obligation doit être bien distinguée de la simple difficulté d'exécution ou de l'onérosité excessive générée par un changement de circonstances (constitutif d'imprévision)[1518]. Cela exclut en principe que la force majeure puisse exonérer un débiteur de son obligation de payer une somme d'argent.

[1516] Cass. fr. (ass. plén.), 14 avril 2006, n° 02-11.168.

[1517] Voy. en dernier lieu Cass. fr., (2e civ.), 19 septembre 2024, n° 23-10.638 B.

[1518] Voy. *supra*, nos 508 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 773-786
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

En France, ces dernières années, un débat a surgi sur le point de savoir si un contractant pouvait invoquer la force majeure lorsqu'il était placé, non dans l'impossibilité d'exécuter sa propre obligation (généralement une obligation de somme d'argent), mais dans l'impossibilité de recevoir la prestation dont il était créancier – par exemple dans l'hypothèse où, à raison d'un problème de santé imprévisible et irrésistible, le contractant ne peut suivre une formation auquel il s'était inscrit, ou profiter d'un séjour dans un appartement de vacances. Après avoir semblé l'admettre en 1998[1519], la Cour de cassation a nettement pris parti contre cette extension de la notion de force majeure. Pour elle, « le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure »[1520].

678. Éléments constitutifs de la force majeure : jurisprudence luxembourgeoise. Au Luxembourg, pour l'instant, on s'en tiendra à une définition unique en matière contractuelle et en matière délictuelle, axée sur la trilogie traditionnelle extériorité/imprévisibilité/irrésistibilité[1521]. C'était le cas avant la crise sanitaire[1522], et c'est encore le cas dans les décisions rendues depuis 2020 dans le contexte de COVID-19[1523]. La force majeure est ainsi définie comme « un événement survenu postérieurement à la conclusion du contrat et qui a pour effet de rendre impossible l'exécution de son obligation de donner, de faire ou de ne pas faire, indépendamment d'une faute du débiteur dans la genèse, la survenance et les conséquences de l'événement »[1524].

[1519] Cass. fr., (1re civ.), 10 février 1998, n° 96-13.316.

[1520] Cass. fr., (1re civ.), 25 novembre 2020, n° 19-21.060 P ; Cass. fr., (3e civ.), 30 juin 2022, n° 21-20.190 B.

[1521] Merci à Julien Risser et à Zohra Mchirgui pour leur recherche approfondie de la jurisprudence luxembourgeoise récente sur le sujet.

[1522] Trib. Luxembourg, 5 novembre 2010, n° 196/10 ; Cour d'appel, 12 janvier 2011, n° 35324 ; Cour d'appel, 27 novembre 2014, nos 38586, 39073 et 39075 ; Trib. Luxembourg, 19 décembre 2017, n° 253/2017 , n° 186539 ; Trib. Luxembourg, 23 janvier 2018, n° 16/2018 ; Trib. Luxembourg, 7 mai 2019, n° TAL-2018-07762. O. POELMANS, « Causes étrangères et force majeure, note sous – Cour d'appel, 29 mars 2018, n° 38424 et Cour d'appel, 31 octobre 2018, n° 43712 », *JN Obligations*, 2020, n° 3-4, pp. 93-100.

[1523] Voy. décisions ci-après.

[1524] Trib. Luxembourg, 28 juin 2021, n° TAL-2021-00994 ; Trib. Luxembourg, 12 juillet 2021, nos TAL-2021-02935 et TAL-2021-03029 ; Trib. Luxembourg, 8 décembre 2021, n° TAL-2021-03756 ; Trib. Luxembourg, 22 décembre 2021, n° TAL-2021-04661 ; Trib. Luxembourg, 23 décembre 2021, n° TAL-2021-04661 ; Trib. Luxembourg, 13 juillet 2022, n° TAL-2022-03402.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 773-786
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Il est vrai que la condition d'extériorité a pu, dans une espèce[1525], être de mise de côté afin de retenir qu'une « maladie irrésistible peut constituer un événement de force majeure au sens des articles 1147 et 1148 du Code civil exonérant le débiteur des dommages et intérêts normalement dus »[1526] en se référant à une jurisprudence isolée de la Cour de cassation française[1527]. Mais la condition d'extériorité a bien été réaffirmée par la suite, cette condition signifiant, selon le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, « que le défendeur ne peut invoquer, pour échapper à sa responsabilité, ni son propre fait, ni celui dont une règle juridique quelconque lui impose précisément de garantir les conséquences dommageables pour les tiers »[1528]. S'agissant de la condition d'imprévisibilité, elle « consiste pour l'agent, à ne pas avoir pu prévoir un événement irrésistible. Cela signifie que l'imprévisibilité exigée n'est pas une imprévisibilité absolue. Une telle condition ne serait d'ailleurs presque jamais remplie, car tout événement est en soi prévisible. L'imprévisibilité requise est donc seulement l'absence raisonnable de prévisibilité, l'absence de prévisibilité pour l'homme normal »[1529]. L'irrésistibilité, quant à elle, « prend généralement la forme de l'impossibilité d'exécution en matière contractuelle. Celle-ci doit être totale et définitive, l'impossibilité temporaire ou partielle ne constituant pas un cas de force majeure »[1530]. Il est par ailleurs précisé que ce critère « fait l'objet d'une appréciation in abstracto, par rapport à l'inexécution d'un débiteur normalement raisonnable et diligent placé dans les mêmes circonstances »[1531].

[1525] Voy. aussi Trib. Luxembourg, 22 avril 2015, n° 82/15, qui retient une définition de la force majeure dépourvue de la condition d'extériorité : « Le cas de la force majeure vise un évènement imprévisible et irrésistible, non imputable au bailleur ».

[1526] Cour d'appel, 28 avril 2010, n° 34304.

[1527] Cass., (1re civ.), 10 février 1998, préc. (cité expressément par l'arrêt luxembourgeois).

[1528] Trib. Luxembourg, 5 novembre 2010, n° 196/10 ; rappr. Trib. Luxembourg, 19 décembre 2017, n° 253/2017, n° 186539 ; Trib. Luxembourg, 23 janvier 2018, n° 16/2018 ; Trib. Luxembourg, 7 mai 2019, n° TAL-2018-07762 ; Trib. Luxembourg, 8 décembre 2020, n° TAL-2020-03617 ; Trib. Luxembourg, 11 mai 2021, n° TAL-2020-00361.

[1529] Trib. Luxembourg, 22 avril 2015, n° 82/15 ; rappr. Trib. Luxembourg, 19 décembre 2017, n° 253/2017 ; n° 186539 ; Trib. Luxembourg, 23 janvier 2018, n° 16/2018 ; Trib. Luxembourg, 7 mai 2019, n° TAL-2018-07762 ; Trib. Luxembourg, 8 décembre 2020, n° TAL-2020-03617 ; Trib. Luxembourg, 11 mai 2021, n° TAL-2020-00361.

[1530] Trib. Luxembourg, 5 novembre 2010, n° 196/10 ; Trib. Luxembourg, 8 décembre 2020, n° TAL-2020-03617 ; Trib. Luxembourg, 11 mai 2021, n° TAL-2020-00361.

[1531] Trib. Luxembourg, 8 décembre 2020, n° TAL-2020-03617 ; Trib. Luxembourg, 11 mai 2021, n° TAL-2020-00361.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 773-786
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Comme en France et en Belgique, les tribunaux luxembourgeois mettent l'accent sur le caractère insurmontable de l'obstacle empêchant l'exécution du contrat : par conséquent, il ne suffit pas que l'exécution ait été rendue plus difficile ou plus onéreuse[1532]. L'empêchement qui résulte de la force majeure « doit être radical dans le chef de celui qui invoque la force majeure pour pouvoir valoir force majeure dans le chef de ce dernier ». Ainsi est-il jugé, en contexte de la Covid-19, qu'« une impossibilité temporaire ou partielle dans le chef du locataire se caractérisant par une difficulté accrue dans l'exécution de ses obligations de paiement des loyers pendant la période limitée du confinement ne saurait constituer un cas de force majeure dans son chef, le critère de l'irrésistibilité n'étant pas donné dans une telle situation »[1533]. Cela semble exclure de manière générale que la force majeure puisse être invoquée pour se soustraire à une obligation de somme d'argent.

Enfin, sur la question de savoir si la force majeure peut être invoquée lorsque l'impossibilité a été, non celle du débiteur d'exécuter son obligation, mais celle de recevoir la prestation dont il est créancier, on peut relever deux décisions luxembourgeoises qui l'ont admis, dans des hypothèses où, pourtant, il n'y avait pas impossibilité radicale, mais simplement perte d'intérêt du contrat pour le contractant empêché[1534]. Mais ces décisions, qui se fondent sur l'arrêt français de 1998, sont antérieures à la position prise par la Cour de cassation française en 2020 et 2022, il n'est pas certain que les juridictions luxembourgeoises consacreraient la même décision aujourd'hui.

679. Effets de la force majeure en matière contractuelle (renvoi). En matière contractuelle, la force majeure a plusieurs effets, qui se situent sur des terrains différents. Elle peut jouer un rôle en matière de preuve, en ce qu'elle constitue un des cas d'impossibilité de prouver par écrit (C. civ., art. 1348)[1535]. Lorsqu'elle intervient au stade de l'exécution du contrat, elle a d'abord pour conséquence, en principe, soit de suspendre l'exécution de l'obligation du débiteur si l'empêchement est temporaire et si l'obligation peut encore être exécutée, soit, si l'empêchement est définitif, de libérer le débiteur de son

[1532] Trib. Luxembourg, 12 juillet 2021, préc.

[1533] Trib. Luxembourg, 8 décembre 2020, n° TAL-2020-03617 ; Trib. Luxembourg, 11 mai 2021, n° TAL-2020-00361.

[1534] Cour d'appel, 28 avril 2010, n° 34304, préc. ; Trib. Luxembourg, 7 juillet 2009, n°s 114440 et 120356 (jonction).

[1535] Voy. *supra*, n° 427.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 773-786
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

obligation. En conséquence, le débiteur empêché par suite d'un cas de force majeure ne peut être responsable du préjudice causé à son cocontractant du fait de l'inexécution ou du retard d'exécution. C'est là un effet de la force majeure commun à la responsabilité contractuelle et à la responsabilité délictuelle. De manière plus spécifique à la matière contractuelle, la force majeure peut avoir pour effet d'entraîner la résolution du contrat, et donc de libérer le créancier de l'obligation inexécutée. C'est le principe, qui cède cependant dans les contrats translatifs de propriété, où le transfert immédiat de la propriété de la chose aboutit à faire supporter au créancier de l'obligation de livrer les risques de la disparition de la chose par suite d'un cas de force majeure. Nous retrouverons tous ces effets avec les différentes sanctions de l'inexécution auxquels ils se rapportent.

680. Sanctions ou remèdes ? L'habitude, dans les pays du Code civil, est de parler de « sanctions » de l'inexécution pour désigner les différentes conséquences attachées par le droit à l'inexécution d'une obligation contractuelle. Cette terminologie est aujourd'hui contestée. Même si le terme de sanction peut être entendu de manière large comme désignant toute conséquence juridique attachée à une règle de droit, il est le plus souvent compris, de manière plus étroite, comme désignant le « mal » qui frappe une personne qui ne s'est pas comportée de manière conforme au droit. Or d'une part, dans ce sens étroit, le terme s'applique assez mal à ce qui, dans les pays du Code civil, est considéré comme la première conséquence de l'inexécution, à savoir l'exécution forcée de l'obligation – qui semble être moins une « sanction » que l'application directe du rapport d'obligation. D'autre part, le terme de sanction, qui correspond à une conception morale du contrat, fondée sur le respect de la parole donnée, s'accorde assez mal avec une approche plus moderne, fortement teintée de considérations d'efficacité économique, où l'important est moins, en cas d'inexécution, de « faire mal » au débiteur, que de permettre au créancier d'obtenir satisfaction dans les moins mauvaises conditions possibles. C'est pourquoi, à la lumière du droit comparé et des projets européens, certains auteurs voudraient privilégier une approche dite « remédiale »[1536] des conséquences de l'inexécution contractuelle. L'idée est, comme le résume parfaitement un auteur français, que « le contrat n'est pas seulement un échange de promesses sanctionnées par la force

[1536] « Remèdes » se veut la traduction de l'anglais « *remedies* ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 773-786
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

obligatoire que lui donne la loi ; c'est aussi un marché qui fait naître chez les parties des anticipations qu'il faut faire respecter autant qu'il est raisonnable en offrant aux parties, plutôt que des « sanctions » de cette faute civile qu'est l'inexécution, des "remèdes" à l'inexécution »[1537]. Cette approche – assez nettement inspirée de l'esprit de la *common law* – domine assez nettement les différents projets européens, qui évitent d'utiliser le terme « sanctions », et qui parlent de « *remedies* » (DCFR), de « moyens d'action » (DCEV) ou de « moyens » (PDEC) en cas d'inexécution. On la retrouvait dans le projet français de 2015, qui utilisait explicitement le terme de « remèdes » dans son article 1217, mais dans le texte final, on est revenu à l'approche traditionnelle, et le terme de « remèdes » a été remplacé par celui de « sanctions ». De même, dans l'article 5.83 qui lui correspond dans le nouveau Code civil belge, il est question de l'« énumération des sanctions ». Indépendamment des termes employés, cependant, on peut penser que l'approche « remédiale » a déjà largement pénétré les droits des pays du Code civil, y compris le droit luxembourgeois, notamment en ce qu'elle implique une certaine déjudiciarisation des moyens d'action offerts au créancier.

681. Les conséquences de l'inexécution dans le Code civil. La question des sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles a été particulièrement mal traitée par les rédacteurs du Code civil. Les articles qui y sont relatifs sont lacunaires, et, surtout, ils sont éparpillés dans différentes sections du Code. Certaines questions (mise en demeure, exécution en nature des obligations) sont abordées à propos de la distinction des obligations de donner et des obligations de faire ou de ne pas faire (C. civ., art. 1139, et 1142 à 1145). Puis le Code consacre une section aux dommages et intérêts (C. civ., art. 1146 à 1155), avant de traiter, beaucoup plus loin, de la résolution pour inexécution (C. civ., art. 1184, à propos des conditions) et des clauses pénales (C. civ., art. 1226 à 1233). C'est la doctrine, en France et en Belgique, qui s'est efforcée de donner de la matière une vision plus ordonnée.

La présentation du Code civil, critiquée à juste titre par les comparatistes[1538], a été heureusement abandonnée à l'occasion des réformes en France et en Belgique. Le nouveau droit français regroupe en une seule section les différents moyens d'action du créancier en cas d'inexécution du contrat. Les différents moyens sont globalement

[1537] Ph. REMY, « L'inexécution du contrat », in F. TERRÉ (dir.), *Pour une réforme du droit des contrats*, Paris, Dalloz, 2009, p. 254.

[1538] Voy. not. D. TALLON, « L'inexécution du contrat : pour une autre présentation », *RTD civ.*, 1994, p. 223.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 773-786
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

exposés dans un article d'annonce, l'article 1217 du Code civil, qui précise en même temps la possibilité de les cumuler, puis chacun des remèdes est détaillé dans les articles suivants : exception d'inexécution, exécution forcée en nature, réduction du prix, résolution, réparation du préjudice causé par l'inexécution. Seule la question de la mise en demeure est restée en dehors de cette présentation d'ensemble, qui inspire assez largement le plan d'exposition qui sera ici suivi. Il en va de même en Belgique, sauf à ce que, comme nous l'avons dit, pour un certain nombre de sanctions, le code procède par renvoi à la partie relative au régime général de l'obligations.

682. Plan suivi. Les conséquences de l'inexécution des obligations contractuelles peuvent se répartir en deux grandes catégories.

Certaines affectent le sort du contrat inexécuté : le créancier peut ici vouloir s'en tenir au contrat en essayant d'obtenir l'exécution contre le gré du débiteur (exécution forcée), ou, à l'inverse à s'en débarrasser pour être libéré de ses propres obligations (résolution ou résiliation). Ces deux solutions sont en principe alternatives.

Par ailleurs, le créancier subit généralement un préjudice du fait de l'inexécution. Pour réparer ce préjudice, il pourra demander des dommages et intérêts, dans le cadre de ce qu'on appelle habituellement la responsabilité contractuelle. Selon les cas, ces dommages et intérêts peuvent venir, soit à la place des autres sanctions, soit se cumuler avec l'exécution forcée ou la résolution.

Cependant, avant d'en venir à ces différentes solutions, qui supposent le plus souvent une intervention judiciaire, le créancier peut – et parfois doit – mettre en œuvre certaines solutions d'attente visant à la fois à préserver ses droits et à faire pression sur le débiteur pour qu'il s'exécute.

Nous commencerons par l'exposé de ces solutions d'attente (**Section 1**), avant d'étudier l'option du créancier quant au sort du contrat (**Section 2**), puis les dommages et intérêts (**Section 3**).

Ce plan, qui se veut pragmatique, n'est qu'une des multiples manières de présenter la matière. Nous n'avons pas ici fait de distinction entre les sanctions communes à toutes les obligations contractuelles, et celles qui sont propres aux contrats synallagmatiques (résolution et exception d'inexécution), que certains auteurs de manuels traitent de manière séparée. Il nous apparaissait en effet important de mettre au cœur des développements la question de l'option entre l'exécution et la résolution (même si cette question ne se pose que pour les contrats synallagmatiques, de toute façon les plus nombreux). De même, le souci de donner une vision d'ensemble des sanctions de l'inexécution nous amené à traiter ici de l'exécution forcée, dont la place serait plutôt, logiquement, au sein du régime général de l'obligation (ce qui est le choix du nouveau Code civil belge). Surtout, nous avons fait le choix de traiter des dommages et intérêts sous l'angle de la « responsabilité contractuelle », c'est-à-dire d'une réparation du préjudice qui peut, selon les cas, se substituer ou s'ajouter aux

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 773-786
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

autres sanctions. De ce point de vue, nous nous séparons nettement des auteurs qui voient dans les dommages et intérêts une forme d'exécution par équivalent du contrat, présentée alors comme une alternative à l'exécution en nature[1539].

683. Conséquences de l'inexécution des actes unilatéraux. Les développements qui vont suivre concernent à titre principal l'inexécution des obligations nées d'un contrat. La question de l'inexécution se pose également cependant lorsqu'une personne a assumé une obligation en vertu d'un acte unilatéral. On peut, d'une manière générale, transposer les solutions qui seront ci-après exposées, sous réserve de quelques adaptations. Comme la personne qui n'exécute pas un engagement contractuel, celui qui n'exécute pas l'obligation qu'il a assumée unilatéralement pourra être condamné à des dommages et intérêts : c'est même l'intérêt principal qu'il y a à reconnaître l'existence des engagements unilatéraux de volonté[1540]. La difficulté vient de ce que, dans le système du Code civil, il existe deux sources de dommages et intérêts : la responsabilité contractuelle, liée à l'inexécution d'un contrat (régie par les articles 1142 et suivants du Code civil), et la responsabilité délictuelle ou extracontractuelle résultant d'un fait ou d'un comportement illicite en dehors de tout contrat (régie par les articles 1382 et suivants). Parce qu'ils sont liés à l'inexécution d'un engagement, les dommages et intérêts dus par celui qui viole sa promesse unilatérale sont beaucoup plus proches de la responsabilité contractuelle (même si on n'est pas en présence d'un contrat) et ils doivent obéir au régime de celle-ci. De même, il faut admettre que celui qui ne respecte pas son engagement unilatéral peut être condamné à exécuter, dans les mêmes limites que celles qui sont admises pour les contrats. En revanche, il n'est pas possible de transposer aux engagements unilatéraux la résolution pour inexécution, qui consiste dans l'anéantissement du contrat inexécuté : cette sanction, en effet, est liée à la réciprocité des obligations nées du contrat, qui ne peut pas se concevoir pour un engagement unilatéral. Le bénéficiaire d'un tel engagement, qui ne s'est lui-même engagé à rien, n'a aucun intérêt à obtenir l'anéantissement de l'engagement de son débiteur.

[1539] Sur ce débat, voy. *infra*, n° 801.

[1540] Voy., p. ex., à propos de l'engagement pris par l'auteur d'une reconnaissance mensongère de subvenir aux besoins de l'enfant : Cass. fr. (1re civ.), 21 juillet 1987, n° 85-16887 ; Cass. fr. (1re civ.), 10 juillet 1990, n° 88-15105.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 773-786
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

SECTION 1. LES SOLUTIONS D'ATTENTE

684. Mesures extrajudiciaires. Avant d'opter pour telle ou telle solution définitive – ce qui, le plus souvent, supposera une intervention d'un tribunal – le créancier peut – et parfois doit, selon ce qu'il veut obtenir ensuite – prendre certaines mesures destinées à sauvegarder ses droits et à faire pression sur le débiteur pour qu'il s'exécute si c'est encore possible. Deux mécanismes très différents, qui ne sont pas incompatibles l'un avec l'autre, sont prévus à cet effet dans le Code civil du Luxembourg : il s'agit d'une part de la mise en demeure – mesure commune à toutes les obligations contractuelles ou non – et d'autre part de l'exception d'inexécution, mécanisme spécifique aux contrats synallagmatiques.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

SOUS-SECTION 1. LA MISE EN DEMEURE

685. Notion. On désigne sous ce terme un avertissement solennel délivré au débiteur qui n'a pas exécuté : le créancier rappelle au débiteur qu'il est en retard pour exécuter et lui demande solennellement de le faire. La mise en demeure fait l'objet, dans le Code civil, d'une réglementation très éclatée, et très difficile à systématiser, aux articles 1139, 1146 et 1146-1, et 1153. L'état actuel de ces textes remonte à la loi du 15 mai 1987, qui a apporté de très importantes modifications par rapport au droit antérieur. Par ailleurs, la mise en demeure est visée par de très nombreux textes spéciaux concernant des obligations ou des contrats particuliers. La législation récente traduit une évolution sensible des fonctions de la mise en demeure (**§ 1**) en même temps qu'elle en assouplit considérablement les formes (**§ 2**).

§1. Fonctions de la mise en demeure

686. Dualité des conceptions. L'idée d'un avertissement solennel que le créancier peut (et parfois doit) délivrer au débiteur défaillant avant de mettre en œuvre les sanctions de l'inexécution est connue de nombreux systèmes juridiques, mais cet avertissement (qui n'est pas toujours appelé mise en demeure) n'a pas toujours la même signification, ni les mêmes fonctions. On peut opposer ici deux conceptions très différentes, qui se combinent parfois. Dans une première conception, qui correspond à l'étymologie (demeure vient du latin *mora*, retard), la mise en demeure est une *constatation (ou, mieux, une constitution) officielle du retard du débiteur*. Le créancier, qui jusque-là avait fait preuve de patience, fait savoir au débiteur que, désormais, il le considère comme étant en retard et qu'il a bien l'intention de mettre en œuvre immédiatement les sanctions de l'inexécution. Dans cette conception – qui est la conception traditionnelle du Code civil – l'effet principal de la mise en demeure est de permettre au créancier de demander des dommages et intérêts liés au retard (en particulier des intérêts de retard sur le paiement d'une somme d'argent). Rien n'empêche par ailleurs le créancier, dès le jour de la mise en demeure, ou même sans avoir mis préalablement le débiteur en demeure, de demander l'exécution forcée à son débiteur ou d'agir en résolution du contrat : l'assignation en justice nécessaire pour obtenir ces sanctions vaudra alors mise en demeure. Mais dans une autre conception, l'avertissement délivré au débiteur (qui n'est

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

pas alors, techniquement, une « mise en demeure ») vise très différemment *à donner à celui-ci une ultime chance de s'exécuter* : le créancier ne dit pas au débiteur « désormais vous êtes en retard » (il l'est de toute façon depuis l'échéance), mais « si vous n'exécutez pas bientôt, j'exercerai mes droits contre vous ». Dans cette conception, l'acte délivré au débiteur est censé fixer un délai supplémentaire pour qu'il s'exécute – et, s'il n'en fixe pas, la loi ou le juge fixeront eux-mêmes un tel délai. Tant que ce délai ne sera pas expiré, le créancier ne pourra pas prétendre à l'exécution forcée ni demander la résolution du contrat (alors même que les dommages et intérêts liés au retard auront pu, eux, courir depuis le terme fixé par le contrat). Cette conception, héritée de la tradition germanique, domine les projets européens de droit des contrats, qui ne connaissent pas la mise en demeure au sens du Code civil (les intérêts de retard y courent de plein droit), mais qui mettent en place la possibilité pour le créancier d'accorder par notification un délai supplémentaire au débiteur, en subordonnant en principe à cette notification le droit d'obtenir la résolution du contrat. Tel est par exemple le système du DCFR (art III-3:103), des Principes Lando (art. 8:106) ou des Principes Unidroit (art. 7.1.5). On peut naturellement concevoir que les deux fonctions soient combinées au sein d'un même système et, d'une manière générale, il y a une forte tendance des droits contemporains, y compris dans les pays du Code civil, à mettre en valeur la fonction de « seconde chance » accordée au débiteur[1541], en liaison avec le souci de sauver les contrats non exécutés mais aussi avec la montée de l'exigence de bonne foi ainsi qu'avec la déjudiciarisation des sanctions de l'inexécution. Cette évolution est particulièrement sensible en droit belge, où l'article 5.231 du nouveau Code civil définit la mise en demeure comme « l'acte juridique unilatéral par lequel le créancier notifie au débiteur, de manière claire et non équivoque, sa volonté d'exiger l'exécution de son obligation », et qui exige d'une manière générale que les sanctions de l'inexécution soient précédées d'une mise en demeure, en précisant que « la loi, le contrat ou la bonne foi peuvent exiger que le créancier accorde au débiteur un délai afin qu'il exécute l'obligation en souffrance ». L'évolution est moins nette en droit français, même si la conception de « seconde chance » se manifeste dans le cadre de la réglementation des sanctions de l'inexécution, et notamment de la résolution.

[1541] Pour la mise en évidence de cette fonction en droit français, voy. not. X. LAGARDE, « Remarques sur l'actualité de la mise en demeure », *JCP*, 1996, doct. I, n° 3974 ; en droit belge : WÉRY, n° 447.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Bien que non encore réformé, le droit luxembourgeois apparaît aujourd'hui, lui aussi, comme un système mixte. Si la mise en demeure reste, principalement, dans la lignée de la conception traditionnelle du Code civil, un moyen de constituer juridiquement le débiteur en retard (**A**), elle devient parfois aussi un préalable obligé à la mise en œuvre des sanctions de l'inexécution (**B**).

A) *Constitution officielle du retard*

687. Principe et exceptions. Dans le système du Code civil, la mise en demeure est en principe nécessaire pour que le débiteur soit considéré comme étant juridiquement en retard. Cependant ce principe, s'il est théoriquement maintenu en droit luxembourgeois (**1**) se trouve aujourd'hui pratiquement vidé de sa substance en raison des exceptions qui lui sont apportées (**2**).

1) *Principe*

688. Nécessité de la mise en demeure pour constituer le débiteur en retard. Dans l'Ancien droit français, on appliquait en principe la règle « *dies interpellat pro homine* » (textuellement : le jour vaut interpellation de l'homme). Cela voulait dire que la seule arrivée du terme suffisait pour qu'on considère que le débiteur était en retard, sans que le créancier n'ait rien à faire ni à dire. Les rédacteurs du Code civil ont consacré implicitement le principe inverse, en exigeant, pour que le créancier puisse réclamer des dommages et intérêts pour retard, une « mise en demeure ». On considère que le créancier qui ne demande pas officiellement à son débiteur d'exécuter lui accorde implicitement un délai. Cette conception se retrouve, en dehors de la sphère du Code civil, dans de nombreux droits européens, qui exigent également une mise en demeure pour faire courir les intérêts de retard : ainsi en droit allemand (BGB, § 286), en droit suisse (CO, art. 102), en droit italien (Codice civile, art. 1219-3), même si les exceptions qui sont apportées ont souvent tendance (comme au Luxembourg d'ailleurs) à vider le principe de sa portée. Mais d'autres droits considèrent que le débiteur qui doit exécuter son obligation dans un délai déterminé n'a pas besoin d'être mis en demeure pour être tenu de payer des dommages et intérêts liés au retard : il en va ainsi des droits de *common law*, et cette solution est aujourd'hui reprise par les textes internationaux et par les différents projets européens.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

689. Effets de la mise en demeure. Le principe posé explique les deux effets principaux qui sont attachés à la mise en demeure dans le Code civil.

D'une part, c'est seulement à compter de la mise en demeure, et non directement à partir du jour de l'échéance, que le débiteur devra payer des dommages et intérêts réparant le préjudice causé au créancier par son retard. C'est ce que dispose l'article 1146 du Code civil « les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation […] ». La règle trouve une application particulière – la plus importante en pratique – lorsque l'obligation inexécutée est une obligation de somme d'argent. Dans ce cas, les dommages et intérêts prennent la forme d'intérêts de retard destinés à compenser la perte financière subie par le créancier qui n'a pas pu tirer profit de l'argent non reçu (notamment en le plaçant). Or, conformément au principe qui vient d'être exposé, ces intérêts ne vont courir qu'à compter du jour où le débiteur aura été mis en demeure : c'est ce que dispose l'article 1153, alinéa 3 du Code civil.

D'autre part, la mise en demeure a une incidence importante sur le transfert des risques de perte ou de détérioration de la chose lorsque l'obligation inexécutée est une obligation de livrer une chose dont la propriété a été préalablement transférée. En principe, comme on l'a déjà expliqué, dans le système du Code civil, les contrats translatifs de propriété (comme la vente) emportent immédiatement ce transfert, indépendamment du moment de la livraison. Dans ce système, il est logique que l'acquéreur supporte financièrement les conséquences de la perte ou de la détérioration de la chose, même si elle ne lui a pas encore été livrée, dès lors que cette perte n'est pas due au fait du vendeur – ce qui signifie qu'il devra quand même payer le prix de « sa » chose[1542]. Cela, cependant, ne devrait plus être le cas si le débiteur est en retard pour livrer – car à partir de ce moment, la perte ou la détérioration devrait lui être imputable. Mais, là encore, c'est en principe seulement à compter de la mise en demeure – et non du seul fait de l'arrivée du terme – que la chose repassera aux risques du vendeur : c'est la solution posée par l'article 1138, alinéa 2 du Code civil[1543].

[1542] Pour une présentation plus complète de la solution, voy. *infra*, n° 766 à propos des effets de la force majeure sur le contrat (théorie des risques).

[1543] Ce principe connaît des applications dans d'autres articles du Code civil relatifs à des situations particulières ou à des contrats spéciaux (C. civ., art. 1195, 1205, 1788, 1790, 1929).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

690. Domaine de la mise en demeure. Bien qu'elle soit posée – comme toutes les règles relatives au régime des obligations – à propos des seules obligations conventionnelles, l'exigence de la mise en demeure pour constituer le débiteur en retard, et en particulier pour obtenir des intérêts de retard, vaut d'une manière générale pour toutes les obligations quelle qu'en soit la source. Le tribunal de Luxembourg a cependant, dans plusieurs décisions anciennes, jugé que le texte ne s'appliquait qu'aux obligations contractuelles[1544]. Mais c'était en réalité seulement pour en exclure l'application au domaine de la responsabilité délictuelle, pour lequel il existe des règles particulières. D'une part, il est certain qu'on ne peut exiger de la victime d'un dommage qu'elle mette en demeure son auteur avant de lui demander des dommages et intérêts : le montant de ceux-ci ne peut en aucune manière dépendre du fait que la victime a ou non mis en demeure le responsable avant de l'assigner. D'autre part, quant à la question (qui est celle réglée par l'article 1146 du Code civil) de savoir à partir de quand courent les intérêts de retard sur les dommages et intérêts[1545], elle est liée, en matière délictuelle, à un important débat sur la date de naissance de la créance de dommages et intérêts, que nous ne pouvons traiter ici[1546].

2) *Exceptions*

691. Particularisme du droit luxembourgeois. Dans le Code civil originaire, la nécessité de la mise en demeure pour produire les deux effets précédents, était écartée dans deux cas – qui ont été maintenus dans le code actuel (**a**). Mais, au Luxembourg, la loi du 15 mai 1987 a ajouté une troisième exception, qui vide très largement le principe de la mise en demeure de sa substance (**b**). S'y ajoutent encore les règles d'origine européenne relatives aux délais de paiement (**c**).

[1544] Trib. Luxembourg, 27 mars 1954, *Pas.*, 16, p. 181 ; Trib. Luxembourg, 11 novembre 1960, *Pas.*, 18, p. 288.

[1545] Qui est, en droit luxembourgeois, la date du jugement, sans qu'il soit nécessaire que le créancier les ait demandés : Ravarani, n° 1248.

[1546] Sur ce débat en France, parmi une très abondante littérature, on pourra consulter les deux thèses récentes de P.-E. Audit, *La « naissance » des créances, approche critique du conceptualisme juridique*, préf. D. Mazeaud et R. Noirot, Paris, Dalloz, 2015, et *Les dates de naissance des créances*, à paraître. Sur la date de naissance de la créance de dommages et intérêts, voy. plus spécialement, P. Jourdain, « La date de naissance de la créance d'indemnisation », in *La date de naissance des créances*, Colloque CEDAG du 25 mars 2004, *LPA*, 9 novembre 2004, pp. 49 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

a. *Exceptions prévues par le Code civil originaire*

692. Dépassement irrémédiable du délai. Selon l'article 1146 du Code civil, les dommages et intérêts ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure « excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain délai qu'il a laissé passer ». Il s'agit de l'hypothèse où l'exécution n'a plus d'intérêt après la date fixée. L'article 5.233 du nouveau Code civil belge exprime cela en disant que « la mise en demeure n'est pas requise lorsqu'elle ne présente plus d'utilité ». L'exemple type est celui, précédemment donné, du traiteur qui ne livre pas le repas de mariage le jour de la cérémonie : même si je n'ai pas mis en demeure le traiteur de me livrer, je pourrai lui demander des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il m'a causé en me privant du repas le jour magique de mon mariage ! Mais, à vrai dire, dans un tel cas, les dommages et intérêts que je pourrai demander ne sont pas des dommages et intérêts pour retard, car le préjudice subi est lié à une inexécution définitive du contrat : on parlera alors de dommages et intérêts compensatoires. Et on peut du reste tirer argument de l'article 1146, alinéa 1er du Code civil pour justifier que, d'une manière générale, la mise en demeure ne soit pas nécessaire chaque fois que le créancier demande des dommages et intérêts compensatoires, qu'ils soient la conséquence d'un retard irrémédiable, d'une absence définitive d'exécution ou d'une mauvaise exécution (par exemple, en cas de livraison d'une chose défectueuse)[1547].

Une application particulière de cette idée se trouve dans l'article 1145 du Code civil, selon lequel « Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention ». Dans l'interprétation traditionnelle qui est donnée de ce texte, le créancier d'une obligation de ne pas faire est dispensé de mettre en demeure celui qui a violé cette obligation[1548] : la solution s'explique aisément si on considère que, en soi, un seul acte contraire à une obligation de ce type constitue une violation définitive et irrémédiable, pour laquelle le créancier doit pouvoir obtenir des dommages et intérêts compensatoires[1549].

[1547] Voy. *infra*, n° 699.

[1548] Cass. fr. (1re civ.), 26 février 2002, n° 99-19053. Sur une autre interprétation désormais donnée de l'article 1145 du Code civil par la jurisprudence française, voy. *infra*, n° 828.

[1549] Sur cette explication : DE PAGE, *Traité*, t. III, 1967, p. 102, n° 75.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

La solution n'a cependant de sens que si on considère la fonction traditionnelle de la mise en demeure, visant à constituer le débiteur en retard[1550].

693. Dispense conventionnelle de mise en demeure. Aux termes de l'article 1139 du Code civil « le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou un autre acte équivalent, *soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure* ». C'est dire que le contrat peut écarter la nécessité d'une mise en demeure pour constituer le débiteur en retard. Ces clauses sont extrêmement fréquentes en pratique. Cependant, leur licéité est parfois remise en cause par certains textes spéciaux, dans le souci d'assurer une protection minimale à certaines catégories de contractants. D'une manière plus générale, la dispense de mise en demeure peut tomber sous le coup de l'article L. 211-2 du code de la consommation relative aux clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs : a ainsi été considérée comme abusive la clause prévoyant que les intérêts sur la somme due à un entrepreneur par un consommateur courraient de plein droit à compter de la facture au taux légal majoré de 4 %[1551].

b. *Exception spécifique au Luxembourg : l'article 1146 alinéa 2*

694. Jour de l'exécution déterminé. L'article 1146, alinéa 2 a été introduit dans le Code civil par la loi du 15 mai 1987. On n'en trouve l'équivalent ni en France ni en Belgique. Le texte – repris d'un article du Code des obligations suisse – écarte l'exigence de la mise en demeure « lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier ». Il s'agit donc d'un texte spécifique aux obligations contractuelles. Dans ce cadre, le seul fait qu'un terme précis ait été fixé par les parties (ou par l'une d'elles qui en a reçu le droit) suffit à dispenser le créancier de la mise en demeure[1552] : les intérêts de retard courront de plein droit et le vendeur en retard pour livrer supportera les

[1550] Wéry, n° 464.

[1551] Trib. Luxembourg (réf.), 18 février 2011, n° 199/11.

[1552] Voy. avant ce texte : Cour d'appel, 29 novembre 1971, *Pas.*, 22, p. 87 qui avait jugé que « Le fait qu'un terme a été stipulé dans le contrat ne suffit donc pas à entraîner dispense de la mise en demeure, mais il faut avant tout un accord des parties décidant que l'arrivée du terme produira les effets d'une mise en demeure. Cet accord peut être exprès ou même tacite, à condition toutefois que la volonté des parties soit certaine ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

risques à compter de ce jour. Or il faut bien voir que, en matière contractuelle, le jour d'exécution est fixé dans l'immense majorité des cas. Par exemple, un arrêt de la Cour d'appel a jugé que dans un contrat de location à long terme d'un véhicule qui dispose que les mensualités dues en vertu de ce contrat sont à payer d'avance, le premier jour ouvrable de chaque mois, le propriétaire n'a pas besoin de mettre spécialement le locataire en demeure de payer les loyers échus et restés impayés[1553]. L'exigence de principe de la mise en demeure n'a donc plus aujourd'hui, en droit luxembourgeois, qu'une portée extrêmement réduite, du moins pour les obligations contractuelles : elle ne vaut que si aucun terme n'a été fixé pour l'exécution (auquel cas, de toute façon, il faut bien que le créancier prenne une initiative pour déclencher l'exécution) ou (mais cela peut se discuter) si le terme fixé est incertain (par exemple : au jour du décès d'un contractant). Au fond, le droit luxembourgeois est revenu au vieux principe « *dies interpellat* » puisque c'est seulement lorsqu'un « jour » avait été fixé que ce principe pouvait s'appliquer. La solution posée au Luxembourg rejoint ici celle de plusieurs droits européens, qu'on présente habituellement comme exigeant la mise en demeure, mais qui font également exception dans le cas du terme déterminé[1554]. La jurisprudence luxembourgeoise fait régulièrement application de ce texte, notamment en matière de construction lorsque les parties ont fixé un délai pour l'achèvement des travaux[1555]. La Cour d'appel a jugé qu'il n'était pas nécessaire que la date soit fixée de manière précise, pourvu qu'elle soit déterminable,[1556] On ne doit donc pas s'arrêter à certaines décisions qui ont cru devoir limiter la portée du texte. Ainsi, un jugement du Juge de Paix de Luxembourg a considéré que la dispense de mise en demeure résultant de l'article 1146, alinéa 2 du Code civil ne valait que si le délai fixé était impératif, et que, en l'absence d'indication claire, il fallait considérer qu'il s'agissait seulement d'un délai indicatif[1557]. Le texte commande la solution contraire : si les parties ont fixé un délai pour l'exécution, ce délai doit être considéré comme

[1553] Cour d'appel, 9 novembre 1993, 29, p. 293.

[1554] Voy., p. ex., le § 286 du BGB ou (avec des nuances) l'article 1219-3 du Codice civile.

[1555] Voy. en dernier lieu : Cour d'appel, 25 janvier 2024, n° CAL-2021-01041.

[1556] Cour d'appel, 17 mai 2006, n° 30 483 (délai de 6 à 8 semaines à compter de la commande).

[1557] J.P. Luxembourg, 21 décembre 2007, n° 4993/07, *BIJ*, 2008, p. 65. La distinction du délai impératif (ou de rigueur) et du délai indicatif est tirée de la doctrine et de la jurisprudence française.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

étant de rigueur, à moins qu'il ne résulte des termes du contrat ou des circonstances que les parties n'ont entendu lui donner qu'un caractère indicatif.

c. *Exception tirée du droit européen*

695. Règles particulières aux obligations de paiement résultant de transactions commerciales. Pour lutter contre les retards de paiement qui grèvent lourdement la trésorerie des entreprises, et qui nuisent à leur compétitivité, la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales[1558] a imposé aux états membres de l'Union européenne d'introduire dans leur droit des règles relatives aux délais de paiement consentis par les entreprises, soit à d'autres entreprises, soit aux pouvoirs publics, soit à des particuliers. Les dispositions essentielles de cette directive prévoient que les intérêts de retard courent de plein droit – donc sans mise en demeure – à partir d'un certain délai variable selon la personnalité du débiteur. Cette directive a été transposée au Luxembourg par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard[1559]. Les solutions adoptées en 2000 n'ayant pas résolu le problème, une nouvelle directive a été prise en 2011[1560], transposée par la loi du 29 mars 2013. Désormais, pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de service entre entreprises, ou par une entreprise à un pouvoir public, si la date du paiement a été fixée dans le contrat, ces intérêts courent de plein droit à compter du lendemain de ce jour [L. 18 avril 2004, art. 3 (3) (a)] – ce qui rejoint la règle de l'article 1146, alinéa 2 du Code civil. Si aucune date ou aucun délai n'a été fixé[1561], les intérêts courront de plein droit, selon les cas, dans les 30 jours de la facture, de la réception des marchandises ou de leur vérification par l'acheteur. Si le débiteur est un consommateur, l'article 12 de la loi de 2004 prévoit que « les créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur sont de plein droit productives d'intérêts au taux légal à partir

1558 *J.O.C.E.*, L. 200/35, 8 août 2000.

1559 Voy. M. Thewes, « Les nouvelles règles en matière de délais de paiement », *Ann. dr. lux.*, 2004, n° 14, pp. 147 et s.

1560 Dir. 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte).

1561 La loi fixe par ailleurs un délai de paiement maximum, qui est de 60 jours pour les entreprises et de 30 jours pour les pouvoirs publics.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de l'expiration du troisième mois qui suit la réception des marchandises, l'achèvement des travaux ou la prestation de services ». L'article 13 de la loi de 2004 subordonne cependant l'application de ce texte à l'envoi de la facture au consommateur dans le délai d'un mois, avec la mention expresse que le professionnel entend se prévaloir de l'article 12 de la loi du 2004 ; à défaut la mise en demeure redevient nécessaire.

696. Que reste-t-il du principe ? En dehors du cas de l'article 13 de la loi de 2004, la mise en demeure n'est plus nécessaire pour faire courir les intérêts de retard sur le paiement des sommes d'argent dans le cadre des transactions commerciales, qu'elles soient entre entreprises ou entre une entreprise et un consommateur. Cette exigence est donc aujourd'hui limitée aux obligations nées de contrats entre particuliers, et encore à condition qu'aucune date précise n'ait été fixée dans le contrat pour l'exécution. La mise en demeure conserve cependant toute son utilité, quelles que soient les parties au contrat, en cas de retard dans l'exécution d'une obligation non monétaire (retard dans la livraison ou dans l'exécution d'une prestation de services), notamment pour mettre les risques à la charge du débiteur. Par ailleurs, dans de nombreux cas, la mise en demeure est aujourd'hui un préalable obligé à la mise en œuvre des sanctions de l'inexécution.

B) *Préalable obligé à la mise en œuvre des sanctions de l'inexécution ?*

697. Évolution. Si on se tient aux articles 1139, 1146 et 1153 du Code civil, la mise en demeure, nécessaire en principe pour faire courir les intérêts de retard, n'est pas exigée pour la mise en œuvre des autres sanctions de l'inexécution. Cette conception est cependant depuis longtemps dépassée en droit belge, où la doctrine et la jurisprudence ont, sous l'influence de De Page, développé une conception beaucoup plus extensive du mécanisme[1562]. En 1976, la Cour de cassation de Belgique a posé que l'article 1146 du Code civil n'était qu'une application d'un principe général imposant la mise en demeure comme un préalable à toutes sanctions de l'inexécution,

[1562] DE PAGE, *Traité*, t. III, n° 73, p. 98 : « Le principe (de la mise en demeure) vaut de manière générale […] Il faut se rappeler le but de la mise en demeure. Ce but est de permettre au débiteur de s'exécuter, s'il en est temps encore. Par l'interpellation la volonté du créancier se fixe, se précise et le débiteur, laissé jusque-là dans l'incertitude, sait ce qu'il doit faire et peut dès lors s'exécuter […] ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

et notamment de l'exécution forcée des obligations[1563]. Désormais, comme on l'a dit, l'article 5.231 du nouveau Code civil belge exige d'une manière générale que les sanctions de l'inexécution soient précédées d'une mise en demeure. Au Luxembourg, comme en France, l'évolution est moins nette, même si l'idée de préalable obligé à la mise en œuvre des diverses sanctions de l'inexécution gagne du terrain, au moment même où, comme on l'a vu précédemment, la fonction traditionnelle de la mise en demeure, visant à faire courir les intérêts de retard, est en net recul. Encore peu sensible en droit commun (**1**), l'évolution apparaît nettement dans différents textes spéciaux (**2**).

1) *Préalable à l'octroi de dommages et intérêts compensatoires ?*

698. Différentes sanctions. La question se pose de manière différente au regard des différentes sanctions de l'inexécution que sont les dommages et intérêts compensatoires (**a**), la résolution du contrat (**b**) et son exécution forcée (**c**).

a. *Préalable à l'octroi de dommages et intérêts compensatoires ?*

699. Principe. Le créancier peut-il prétendre obtenir des dommages et intérêts sans avoir mis son débiteur en demeure ? Comme on l'a vu, la réponse est claire pour les dommages et intérêts moratoires (ceux qui réparent le préjudice lié au retard) puisque c'est précisément la fonction traditionnelle de la mise en demeure que d'en déclencher le cours. Mais la question est beaucoup plus compliquée pour les dommages et intérêts compensatoires, qui réparent le préjudice résultant de l'inexécution définitive du contrat (absence totale d'exécution ou mauvaise exécution). De prime abord, l'article 1146 du Code civil, qui dispose que « les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure », ne distingue pas, et la jurisprudence française exigeait traditionnellement une mise en demeure même pour l'obtention de dommages et intérêts compensatoires[1564]. La Cour de cassation belge a pris position dans le même sens d'une manière particulièrement nette dans un arrêt de 1975[1565]. Il faut cependant bien préciser la portée de la question.

[1563] Cass. be., 9 avril 1976, *Pas.*, 1976, I, p. 887.
[1564] Voy. p. ex. Cass. fr. (civ.), 13 avril 1923, *S.*, 1926, 1, p. 17.
[1565] Cass. be., 4 septembre 1975, *Pas.*, 1976, I, p. 16.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Normalement, pour obtenir des dommages et intérêts, le créancier victime de l'inexécution doit passer par le juge. Or nous verrons que, dans les pays du Code civil, la citation en justice est traditionnellement considérée comme valant mise en demeure. Au moment où le juge statuera sur les dommages et intérêts, le débiteur aura donc de toute façon été mis en demeure par l'assignation, de sorte que l'exigence d'une mise en demeure ne semble avoir aucune portée pratique. La question est cependant de savoir si on peut refuser des dommages et intérêts au créancier au motif qu'avant d'agir en justice il n'avait pas procédé à une mise en demeure préalable. Dans un système où la mise en demeure est conçue comme un avertissement préalable destiné à donner au débiteur une dernière chance de s'exécuter, on pourrait concevoir de répondre positivement : le créancier ne pourrait pas directement passer à la phase judiciaire. Dans le système traditionnel du Code civil, où la mise en demeure est seulement destinée à constituer le débiteur en retard, la logique conduit en revanche à accorder des dommages et intérêts sans exiger une mise en demeure préalable à l'assignation : certes, le créancier qui n'a pas mis en demeure plus tôt ne pourra pas obtenir d'intérêts de retard sur la période antérieure à l'assignation, mais celle-ci suffira à lui permettre d'obtenir des dommages et intérêts compensatoires, dès lors que ceux-ci compensent un préjudice indépendant du retard et lié à une inexécution définitive ou à une mauvaise exécution. Tel est le sens qu'il convient à notre avis de donner à un arrêt de chambre mixte de la Cour de cassation française du 6 juillet 2007[1566], selon lequel les dommages et intérêts sont dus même en l'absence de mise en demeure dès lors que l'inexécution est caractérisée et a causé un préjudice au créancier. La Cour d'appel du Luxembourg a de même jugé que la mise en demeure n'était pas nécessaire pour obtenir des dommages et intérêts sanctionnant l'inexécution définitive du contrat (en l'espèce le non-achèvement d'une construction), dès lors du moins que l'inexécution était suffisamment caractérisée[1567].

Se pose cependant la question de savoir si, en l'absence de mise en demeure préalable à l'assignation, le créancier peut réclamer des dommages et intérêts compensatoires en réparation d'un préjudice qu'il a subi avant l'assignation. Si les jurisprudences française et luxembourgeoise n'ont semble-t-il pas eu l'occasion de se prononcer sur cette question, la Cour de cassation belge a quant à elle posé que « Les dommages et intérêts compensatoires sont dus à dater du jour où l'inexécution de

[1566] Cass. fr. (ch. mixte), 6 juillet 2007, n° 06-13823.
[1567] Cour d'appel, 27 juin 2012, n° 37309.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'obligation contractuelle est acquise, peu importe la date de la mise en demeure »[1568]. L'arrêt permet ainsi à un garagiste, qui avait retenu une voiture de son client jusqu'à paiement de la réparation, d'obtenir le remboursement des frais de gardiennage qu'il avait engagés avant de mettre en demeure son client de payer la facture. En conséquence, l'absence de mise en demeure préalable à l'assignation n'aura pas d'incidence, non seulement sur le principe, mais encore sur le montant des dommages et intérêts compensatoires. Ces solutions pourraient cependant évoluer si on intégrait davantage l'idée d'avertissement préalable et de seconde chance laissée au débiteur.

700. Limites. Dans certains cas, une mise en demeure distincte de l'assignation peut s'imposer. Il en va ainsi tout d'abord lorsque le montant des dommages et intérêts a été fixé par avance par une clause pénale : dans ce cas, le créancier, qui peut obtenir réparation sans avoir à assigner son débiteur doit, sauf clause contraire, le mettre en demeure sous une autre forme. L'exigence de la mise en demeure est expressément prévue par l'article 1230 du Code civil, qui ne distingue pas entre les dommages et intérêts moratoires et compensatoires[1569]. Cependant, dans un arrêt postérieur à la loi de 1987, la Cour d'appel a jugé que l'article 1146, alinéa 2, du Code civil, qui dispense de la mise en demeure lorsque le jour de l'exécution a été fixé d'un commun accord, s'appliquait aussi dans ce cas, alors même que l'article 1230 prévoit expressément que la mise en demeure est nécessaire y compris lorsqu'un terme a été fixe pour l'exécution[1570]. Une mise en demeure préalable à l'assignation peut par ailleurs être nécessaire pour caractériser l'inexécution. Cette formule, utilisée par certains projets français de réforme du droit des contrats[1571], vise principalement le cas où l'exécution de l'obligation du débiteur suppose le concours ou du moins une initiative du créancier. Un arrêt de la Cour de cassation française de 1996[1572] illustre bien la situation : dans cette affaire, une société fournissant des produits à un grand magasin parisien s'était engagée à mettre à sa disposition des démonstrateurs des produits. Ceux-ci ne s'étaient jamais présentés, mais de son côté, le grand magasin n'avait jamais pris contact avec son cocontractant pour fixer les modalités de la venue des démonstrateurs. La Cour de cassation a considéré que, faute de mise en demeure, le grand magasin ne pouvait pas se plaindre de l'inexécution du contrat sur ce point. Dans le même ordre d'idées, il a été jugé au Luxembourg qu'un locataire ne saurait reprocher à son bailleur de ne pas avoir fait des travaux nécessaires pour assurer la jouissance paisible des lieux loués s'il ne l'a pas averti de leur nécessité[1573]. Mais dans un tel cas, ce qui sera exigé, ce sera moins une mise en demeure formelle qu'un avertissement délivré au cocontractant, et le refus de réparation sera moins justifié par l'absence de mise en demeure que par l'absence de faute du débiteur non averti, ou par la faute du créancier qui a été la véritable cause de la production du dommage qu'il impute à l'autre[1574].

[1568] Cass. be., 31 mars 2006, *Pas.*, 2006, p. 733.
[1569] Pour une application ancienne : Cour d'appel, 13 juillet 1899, *Pas.*, 5, p. 136.
[1570] Cour d'appel, 5 mai 2014, BIJ 2004, p. 122.
[1571] Projet Terré, art. 122 al 3 ; Projet Catala, art. 1365.
[1572] Cass. fr., 28 mai 1996, n° 94-17076.
[1573] J.P. Luxembourg, 27 mai 2005, n° 93800, non publié.
[1574] Voy. la jurisprudence française citée par Terré, Simler, Lequette 2013, p. 1042, notes 2 et 4.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

b. *Préalable à la résolution ?*

701. Résolution judiciaire. Mesure propre aux contrats synallagmatiques, la résolution du contrat permet au créancier contractuel de faire tomber le contrat inexécuté, et ainsi de se libérer de ses propres obligations[1575]. Dans la plupart des droits nationaux, ainsi que dans la plupart des textes internationaux et des projets européens de droit des contrats, la résolution procède d'une déclaration unilatérale du créancier. Il paraît dès lors normal que le créancier, avant de procéder à la résolution, prévienne le débiteur, en lui laissant une dernière chance de s'exécuter. Ce type d'avertissement préalable – qui ne porte pas en général le nom de mise en demeure – n'avait traditionnellement guère de sens dans les pays du Code civil. Nous verrons en effet que, selon l'article 1184 du Code civil (toujours en vigueur au Luxembourg), la résolution doit être demandée en justice : dès lors, le débiteur aura encore le temps de se retourner et de proposer l'exécution après avoir été assigné ; l'assignation vaudra mise en demeure, et, si le débiteur n'a pas exécuté entre-temps, le juge pourra prononcer la résolution même si, avant l'assignation, le débiteur n'avait reçu aucun avertissement[1576]. Cependant, le problème de la mise en demeure se pose dans les cas où le créancier peut procéder à la résolution sans agir en justice.

702. Résolution non judiciaire. Il en va ainsi lorsque le contrat contient une clause résolutoire expresse permettant au créancier de résoudre le contrat sans intervention judiciaire : dans un tel cas, la jurisprudence exige en général une mise en demeure préalable. La Cour d'appel a ainsi, dans un arrêt du 19 octobre 2011, posé que « si la clause résolutoire conventionnelle dispense ainsi le créancier de devoir s'adresser à un juge pour être libéré de ses engagements, il n'en doit cependant pas moins, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, mettre le débiteur en demeure d'exécuter ses engagements restés en souffrance », en soulignant que « cette mise en demeure, nécessaire à la mise en œuvre de la clause résolutoire, est destinée à avertir le débiteur de la sanction de la résolution de plein droit qu'il encourt, s'il persiste à ne pas exécuter ses obligations échues »[1577]. Cependant, le problème se

[1575] Voy. *infra*, n°s 753 et s.

[1576] Sous réserve des cas, précédemment évoqués, où cet avertissement était nécessaire pour que le débiteur sache ce qu'il avait à faire.

[1577] Cour d'appel, 19 octobre 2011, *J.T.L.*, 2012, p. 114 ; *BIJ*, 2012, p. 104.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pose rarement en pratique car la plupart des clauses résolutoires, soit prévoient expressément que la résolution interviendra dans un certain délai suivant la mise en demeure, soit, à l'inverse, excluent toute mise en demeure (ce qui, comme le rappelle au passage la Cour d'appel, est en principe licite). Le problème se posera plus souvent à l'avenir parce que la jurisprudence actuelle admet que, même en l'absence de clause, le créancier peut déclarer unilatéralement la résolution dans certaines circonstances[1578]. Dans ces hypothèses, il serait opportun de subordonner en principe la résolution unilatérale à un avertissement préalable du débiteur, assorti d'un délai supplémentaire pour s'exécuter, sur le modèle des droits étrangers et des textes internationaux et européens. Telle est la solution désormais consacrée par les droits belge et français, qui admettent maintenant la possibilité d'une résolution unilatérale comme alternative à la résolution judiciaire : tant l'article 5.83 du Code civil belge que l'article 1226 du Code civil français exigent dans ce cas que le créancier mette préalablement le débiteur en demeure de s'exécuter en lui laissant un délai pour le faire – ce qui est typique de la fonction de « dernière chance » jouée par la mise en demeure. Cependant, dans le droit actuel, certains textes spéciaux excluent la mise en demeure tout en permettant la résolution unilatérale : ainsi en matière de vente, l'article 1657 du Code civil (toujours applicable en France et en Belgique), prévoit la résolution de plein droit et « sans sommation » si l'acheteur ne prend pas livraison au jour prévu.

c. *Préalable à l'exécution forcée ?*

703. Principe. Nous verrons que, en droit luxembourgeois, le créancier a en principe le droit de demander l'exécution en nature de l'obligation. Pour cela, il devra de toute façon s'adresser à un tribunal, et, comme pour la résolution ou les dommages et intérêts compensatoires, l'assignation vaudra mise en demeure. La jurisprudence n'exige pas que, avant d'agir en justice, le créancier ait délivré une mise en demeure préalable. Il n'en va autrement que lorsque le créancier demande sur le fondement de l'article 1144 l'autorisation de faire exécuter l'obligation par un tiers aux frais du débiteur : dans ce cas, la Cour d'appel exige une mise en demeure préalable pour laisser au débiteur une chance de s'exécuter lui-même[1579]. La question se pose différemment pour les obligations de somme d'argent,

[1578] Voy. *infra*, n° 782.

[1579] Cour d'appel, 26 mars 2015, n° 39317 du rôle.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

si le créancier dispose, avant toute condamnation judiciaire, d'un titre exécutoire lui permettant de procéder immédiatement à la saisie des biens du débiteur (acte notarié, jugement fixant une pension alimentaire). Même dans ces cas, cependant, le créancier n'est pas tenu de délivrer une mise en demeure avant de procéder à la saisie. Mais les textes relatifs aux saisies exigent généralement la signification au débiteur, peu de temps avant la saisie, d'un commandement de payer qui vaut comme dernier avertissement[1580]. Le nouvel article 1221 du Code civil français subordonne dans tous les cas l'exécution forcée en nature à une mise en demeure préalable, et il en va de même de l'article 5.83 du Code civil belge.

2) *Textes spéciaux*

704. **Exemples.** Divers textes spéciaux exigent une mise en demeure préalable à certaines sanctions de l'inexécution contractuelle, en faisant courir un certain délai entre la mise en demeure et la sanction. Dans la plupart des cas, le but est de protéger un contractant contre le risque d'une rupture brutale de la relation contractuelle, surtout lorsque cette rupture pourrait procéder d'une décision unilatérale du créancier. Par exemple, la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance prévoit, dans ses articles 21 et 22, que, en cas de non-paiement des primes par l'assuré, l'assureur peut suspendre l'exécution du contrat, mais seulement à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'envoi à l'assuré d'une lettre recommandée comportant mise en demeure de payer la prime échue ; l'assureur n'aura le droit de résilier définitivement le contrat que 10 jours après l'expiration de ce délai. On trouve un autre exemple du même type à l'article 116 du Code de commerce (dans la rédaction que lui a donnée une loi du 21 décembre 1994) à propos des modes de réalisation du gage commercial : ce texte prévoit que le créancier à qui son débiteur a remis un bien en gage peut, s'il n'est pas remboursé, procéder à la vente publique du bien, mais il ne peut le faire qu'à l'issue d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée[1581]. On voit que, dans ces hypothèses, la mise en demeure obéit à une logique complètement différente de celle du Code civil dans les articles 1139 et suivants : il ne s'agit pas du tout de constituer le débiteur en retard, mais plutôt de le prévenir que, s'il n'exécute pas très vite, il sera sanctionné. La mise en demeure apparaît alors comme une sorte de préavis avant sanctions.

§ 2. Formes de la mise en demeure

705. **Évolution.** L'article 1139 du Code civil dispose que « le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation, soit par un autre acte équivalent ». Le terme « sommation » désigne ici un acte d'huissier par lequel le créancier demande solennellement à son

[1580] Voy. p. ex. les articles 719 (saisie-exécution), 762 (saisie des récoltes), 809 (saisie immobilière) du Nouveau Code de procédure civile.

[1581] Cette mise en demeure est cependant écartée lorsque le gage porte sur des instruments financiers (ce qui est sa principale application au Luxembourg) : L. 5 août 2005, art. 11.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

débiteur de s'exécuter. Quant à l'acte équivalent, il a toujours été admis que cela visait l'assignation en justice visant à faire sanctionner l'inexécution[1582], mais on refusait en principe d'aller au-delà[1583]. On n'admettait pas, en matière civile, qu'une simple lettre puisse valoir mise en demeure. Cette rigueur était cependant depuis longtemps écartée en matière commerciale, où il était admis que « toute déclaration formelle de la volonté du créancier d'exiger l'exécution de l'obligation, que cette volonté soit exprimée dans une assignation en justice, dans une sommation extraordinaire ou dans un télégramme »[1584], mais non dans une simple interpellation orale[1585].

La loi du 15 mai 1987 a considérablement assoupli les formes de la mise en demeure. Sans modifier l'article 1139 du Code civil, cette loi a ajouté dans le Code un article 1146-1 prévoyant que « lorsqu'il n'en a pas été convenu autrement, la mise en demeure se fait par acte d'huissier ou par lettre recommandée à la poste ». Le législateur luxembourgeois a ici précédé le législateur français, qui était cependant allé plus loin dans l'assouplissement : une loi française de 1991 avait modifié l'article 1139 du Code civil pour préciser que la mise en demeure pouvait se faire soit par sommation, soit par un autre acte équivalent « telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante », et cette solution a été reprise par le nouvel article 1344 du Code civil. En France, donc, une lettre simple suffit, alors qu'au Luxembourg, la mise en demeure suppose une lettre recommandée. Les solutions antérieures, qui admettaient n'importe quelle forme écrite pour la mise en demeure en matière commerciale doivent cependant perdurer[1586]. En Belgique, les textes originaires du Code civil n'avaient jamais été modifiés, mais la jurisprudence avait admis que n'importe quel acte écrit indiquant clairement la volonté du créancier de voir exécuter l'obligation par le débiteur pouvait valoir mise en demeure[1587], et cette solution a été consacrée par

[1582] Voir déjà Trib. Luxembourg, 25 janvier 1893, *Pas.*, 3, 53.

[1583] Cour d'appel, 10 mars 1911, *Pas.*, 8, p. 65.

[1584] Trib. Luxembourg, 3 juin 1905, *Pas.*, 7, p. 76.

[1585] Cour d'appel, 10 mars 1911, *Pas.*, 8, p. 65 ; Trib. Luxembourg, 17 juillet 1926, 12, p. 412.

[1586] J.P. Luxembourg, 21 décembre 2007, n° 4993/07, *BIJ*, 2008, p. 65, selon lequel « un téléfax suffit dès lors qu'il en ressort une interpellation suffisante ». Cette formule, ainsi que les références doctrinales et jurisprudentielles citées dans la décision montrent que le juge applique en réalité la solution française.

[1587] Cass. be., 28 mars 1994, *Pas.*, 1994, I, p. 317 ; en matière commerciale la Cour de cassation belge va encore plus loin, puisqu'elle n'exige même pas un acte écrit : Cass. be., 20 novembre 2008, n° C06.0293.F, www.cass.be.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

le nouvel article 5.231 du nouveau Code civil selon lequel « la mise en demeure est l'acte juridique unilatéral par lequel le créancier notifie au débiteur, de manière claire et non équivoque, sa volonté d'exiger l'exécution de son obligation ».

SOUS-SECTION 2. L'EXCEPTION D'INEXÉCUTION

706. Moyen propre aux contrats synallagmatiques. Lorsque l'obligation inexécutée est née d'un contrat synallagmatique, le créancier dispose, à certaines conditions, d'un moyen d'action spécifique, qu'il peut mettre en œuvre immédiatement, sans avoir à solliciter l'intervention d'un juge : d'une part, il peut refuser d'exécuter ses propres obligations tant que son cocontractant n'a pas exécuté la sienne. C'est ce qu'on appelle l'exception d'inexécution, ou, en utilisant une terminologie latine qui marque l'ancienneté du mécanisme, l'exception *non adimpleti contractus*. Même si cette solution ne règle pas définitivement le problème, et qu'elle n'est, au plein sens du terme, qu'une solution d'attente, elle présente un grand intérêt pour le contractant qui l'exerce : il peut ainsi espérer faire pression sur son cocontractant (qui a intérêt à exécuter au plus vite pour recevoir la prestation qu'il attend) ; d'autre part, même si cette pression se révèle inefficace, l'exception lui permet de préserver ses droits (en évitant d'avoir à exécuter une prestation qu'il ne serait pas sûr de pouvoir récupérer en cas d'inexécution définitive).

707. Consécration législative. Dans sa rédaction d'origine, le Code civil ne prévoyait pas d'une manière générale l'exception d'inexécution, dont il ne connaissait que quelques applications particulières. Par exemple, l'article 1612 du Code civil prévoyait (et prévoit toujours) que le vendeur au comptant peut refuser de livrer la chose tant qu'il n'est pas payé, et l'article 1704 du Code civil consacre la même solution en matière d'échange. Mais, dès le XIX[e] siècle, la jurisprudence, suivant les enseignements de Pothier, a généralisé ces solutions, tant en France[1588] qu'en Belgique[1589], et au Luxembourg[1590] et a reconnu l'exception d'inexécution d'une manière générale dans tous les contrats synallagmatiques. La Cour de cassation belge en a même fait un principe général du

[1588] Cass. fr., 11 février 1889, *DP*, 1890, 1, p. 121.
[1589] Cass. be., 14 février 1843, *Pas. be.*, 1843, I, p. 61.
[1590] Cour d'appel, 10 juillet 1903, *Pas.*, 06, p. 366.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

droit[1591]. Cette extension n'allait pas de soi, car le mécanisme, qui est mis en œuvre sans intervention du juge, apparaît comme un moyen de justice privée à l'égard duquel on aurait pu être réticent. Cependant, ce moyen, qui permet de préserver un certain équilibre des rapports entre contractants, est apparu admissible en ce qu'il ne produit que des effets limités, conservatoires, et qu'il est toujours susceptible d'être contrôlé *a posteriori* par le juge. On y voit parfois une traduction de la notion de cause au stade de l'exécution du contrat : chaque obligation trouvant sa cause dans l'obligation corrélative de l'autre partie, il est normal que chaque partie puisse refuser d'exécuter tant qu'elle n'a pas reçu la contrepartie. Cette explication paraît quelque peu superflue surtout si on considère que le mécanisme est connu de nombreux systèmes juridiques qui ne connaissent pas la notion de cause. En dehors des pays du Code civil, l'exception a été de même admise par la jurisprudence, et elle a été très souvent consacrée par les codes nationaux. Elle est prévue aujourd'hui par tous les textes internationaux et projets européens.

Au Luxembourg, la loi du 15 mai 1987 a intégré l'exception d'inexécution dans le Code civil, aux articles 1134-1 et 1134-2, comme une suite de la force obligatoire – ou peut-être de l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat. Les réformes du droit des obligations en France et en Belgique ont été l'occasion d'intégrer également l'exception d'inexécution dans le Code civil de ces deux pays (C. civ. fr., art. 1219 et 1220, C. civ. be., art. 5.98 et 5.239). Ces textes sont cependant assez elliptiques, tant en ce qui concerne les conditions (**§ 1**) que les effets (**§ 2**) de l'exception.

§1. Conditions

708. Contrôle *a posteriori*. Comme on l'a souligné d'emblée, l'exception d'inexécution est une mesure extra-judiciaire. Le créancier qui s'estime victime d'une inexécution décide seul, unilatéralement, de ne pas exécuter ses propres obligations, sans avoir à demander l'autorisation du juge, et même, en dehors de textes

[1591] Voy. avant la réforme : Cass. be., 24 septembre 2009, n° C.08.0346N ; sur l'exception d'inexécution en droit belge, voy. B. Dubuisson et J.-M. Trigaux, « L'exception d'inexécution en droit belge », in M. Fontaine et G. Viney (dir.), *Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles. Études de droit comparé*, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 57 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

spéciaux[1592], sans avoir à mettre préalablement le débiteur en demeure. Bien sûr, à ce stade, on ne peut pas savoir s'il a tort ou s'il a raison de se comporter ainsi. Si l'autre contractant estime que l'exception d'inexécution est injustifiée – par exemple parce qu'il prétend, lui, avoir correctement exécuté ses obligations – c'est à lui qu'il appartiendra de saisir le juge pour contraindre l'autre à exécuter, ou pour faire sanctionner ce qu'il estime être un refus injustifié d'exécution. Ou alors, c'est celui qui a d'abord fait jouer l'exception qui, ne voyant pas la situation bouger, se décide à saisir le juge pour obtenir des sanctions définitives, et c'est à ce moment-là que son adversaire contestera le bien-fondé de l'exception. Dans les deux cas, le juge sera amené, *a posteriori*, à décider si les conditions auxquelles est subordonnée la mise en œuvre de l'exception étaient bien remplies. Ces conditions apparaissent être au nombre de trois : des obligations réciproques, l'inexécution d'une obligation exigible, un exercice conforme à la bonne foi. Certaines de ces conditions peuvent cependant être modifiées par une clause contractuelle.

709. Obligations réciproques. Liée, sinon à la notion de cause, du moins à la réciprocité des obligations, l'exception ne peut, selon l'article 1134-2 du Code civil, être exercée que pour « suspendre l'exécution de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l'autre partie n'exécute pas ». Cette exigence est traditionnelle : une jurisprudence constante dénie ainsi à un locataire le droit de refuser de payer ses loyers au motif que le bailleur n'accomplit pas les réparations auxquelles il est tenu ; c'est que l'obligation de payer les loyers trouve sa contrepartie dans l'obligation qui pèse sur le bailleur de faire jouir le locataire de la chose ; le locataire ne serait donc fondé à refuser de payer les loyers que si le défaut de réparation rendait impossible l'occupation des lieux (par exemple si, en raison du toit non réparé, l'appartement était régulièrement inondé)[1593]. On peut cependant se demander si, nonobstant la formulation très restrictive de l'article 1134-2 du Code civil (contrepartie directe), il ne serait pas possible de faire jouer l'exception lorsque l'obligation inexécutée, sans constituer à proprement parler la contrepartie,

[1592] Par exemple l'article 21 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance qui impose à l'assureur, en cas de non-paiement des primes, de mettre en demeure l'assuré avant de procéder à la suspension de la garantie.

[1593] Trib. Luxembourg, 3 juin 2005, n° 94465, *BIJ*, 2005, p. 167 ; Trib. Luxembourg, 27 juin 2008, n° 115138, *BIJ*, 2008, p. 131.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

empêche la réalisation du but contractuel : si j'ai acheté une cuisine (pour un prix déterminé), que le vendeur a promis de me l'installer (pour un prix également fixé), et que le vendeur me livre la cuisine sans me l'installer, ne serais-je pas fondé à refuser de payer aussi le prix du mobilier tant que celui-ci n'est pas installé ? En toute hypothèse, cependant, cela ne serait envisageable que si la vente et l'installation étaient l'objet du même contrat : la formule de l'article 1134-2 du Code civil semble exclure que, comme l'a admis la Cour de cassation belge[1594] et comme le suggère parfois la doctrine française, on puisse faire jouer l'exception entre des obligations nées de deux contrats distincts, même interdépendants. En Belgique, cette extension du domaine de l'exception d'inexécution est désormais certaine. L'article 5.98, qui consacre l'exception d'inexécution en matière contractuelle, est en effet doublé par un article 5.239, inséré dans la partie relative au régime général de l'obligation, qui admet d'une manière générale le jeu de l'exception dans tout « rapport synallagmatique », ce qui peut viser des obligations nées de deux contrats distincts, ou même en dehors de tout contrat.

On doit cependant noter que la jurisprudence permet parfois à un créancier contractuel, par un mécanisme voisin de l'exception d'inexécution, de refuser de restituer une chose appartenant à son débiteur, alors même qu'il n'existe aucune réciprocité entre l'obligation de restituer qui pèse sur lui et l'obligation inexécutée du débiteur. C'est ainsi qu'un garagiste à qui son client ne paye pas la facture de réparation de la voiture peut refuser de la lui rendre, de même qu'un avocat non payé de ses prestations peut refuser de rendre à son client les pièces du dossier. Pourtant, l'obligation de payer qui pèse sur le client trouve sa contrepartie, non dans l'obligation de rendre la voiture ou le dossier, mais dans l'obligation de réparer la voiture ou de défendre le client (qui a déjà été exécutée). C'est que, ici, on n'est pas en présence de l'exception d'inexécution, mais du mécanisme du droit de rétention, qui suppose un simple lien de connexité entre les deux obligations. Ce mécanisme est traditionnellement étudié dans le cadre du droit des sûretés.

710. Inexécution d'une obligation exigible. On ne peut refuser d'exécuter sa propre prestation que si l'obligation inexécutée par l'autre était exigible. L'article 1134-2 du Code civil exclut expressément l'exception si « la convention a prévu en faveur de cette partie une exécution différée ». La solution semble aller de soi : on ne peut pas à la fois accorder à l'autre un délai pour exécuter et refuser d'exécuter sa propre obligation tant qu'elle ne l'a pas fait. Si je permets à mon acheteur de me payer seulement dans 3 mois, je ne peux pas différer du même coup la livraison de la chose. Du reste, si l'obligation de l'autre n'est pas encore exigible, on ne peut pas parler d'une inexécution.

[1594] Cass. be., 8 septembre 1995, *Pas. be.*, 1995, I, p. 785

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

La solution n'est cependant pas aussi évidente. Certains droits étrangers, et la plupart des textes internationaux et projets européens permettent d'exercer l'exception d'inexécution de manière préventive, lorsqu'il est d'ores et déjà certain que le débiteur, alors même qu'il bénéficie d'un délai pour exécuter, ne le fera pas, ou même, dans certains textes lorsque le contractant « croit raisonnablement » que l'autre n'exécutera pas[1595]. Ce mécanisme d"exception d'inexécution anticipée a été repris par le nouvel article 1220 du Code civil français qui prévoit qu'« une partie peut suspendre l'exécution de sa propre prestation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle ». On trouve une disposition similaire dans l'article 5.239 du nouveau Code civil belge. Une telle solution n'est pas actuellement reconnue en droit luxembourgeois, sauf dans le cas particulier d'un acheteur menacé d'éviction, qui peut, selon l'article 1653 du Code civil, « suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble ». Elle pourrait sans grand inconvénient être généralisée dès lors qu'elle permet au créancier de réagir rapidement, sans affecter définitivement la situation du débiteur.

En dehors de ce contexte particulier, le jeu de l'exception d'inexécution peut présenter des difficultés lorsque les deux obligations sont exigibles au même moment, ce qui est le cas normal dans toutes les opérations au comptant. Lorsque les deux parties ne sont pas en présence l'une de l'autre (comme c'est le cas dans un magasin où le paiement de l'acheteur et la remise de la chose peuvent être véritablement simultanées), il faut bien tout de même que l'un s'exécute avant l'autre, et il n'est pas toujours facile de savoir lequel : est-ce au vendeur d'expédier d'abord la marchandise pour recevoir ensuite son paiement, ou à l'acheteur de payer pour recevoir la marchandise ? L'article 1134-1 du Code civil, qui pose que « La convention qui donne naissance à des obligations réciproques oblige, sauf intention ou usage contraires, chaque partie à exécuter son obligation de façon à ce qu'elle coïncide avec l'obligation corrélative de l'autre partie », ne règle pas vraiment la difficulté, qui ne reçoit de solution qu'au cas par cas, en fonction des termes du contrat et des usages[1596].

[1595] CVIM, art. 71 ; Unidroit, art. 7.3.4 ; PDEC, art. 9 : 201 ; DCFR, art. II-3 : 401 ; DCEV, art. 113.

[1596] Voy. p. ex., à propos d'une cession d'actions : Cour d'appel, 21 juin 2006, n° 29783 (à propos d'une cession d'actions : la Cour juge que c'est d'abord au vendeur de livrer les actions avant d'être payé).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

711. Cause de l'inexécution. Faut-il, pour qu'un contractant puisse invoquer l'exception d'inexécution, que l'inexécution soit imputable à l'autre partie ? Ou peut-on admettre que le mécanisme joue aussi en cas de force majeure ? De prime abord, rien ne l'exclut : l'article 1134-2 du Code civil exige seulement qu'il y ait eu un « défaut d'exécution » sans en préciser la cause. En droit français, la doctrine considère de manière quasiment unanime que l'exception d'inexécution peut être invoquée quelle que soit la cause de l'inexécution, y compris après la saisine du juge pour s'opposer à une demande en exécution[1597]. En réalité, dans un tel cas, la possibilité pour le créancier de suspendre l'exécution de son obligation n'est qu'une application de la théorie des risques, et c'est ainsi que la question est présentée en droit belge[1598]. Les nouveaux textes belges distinguent du reste clairement le mécanisme de l'exception proprement dit (art. 5.98 et 5.239) des conséquences de l'impossibilité d'exécution : si celle-ci est temporaire, « l'exécution de l'obligation corrélative du cocontractant est suspendue » (C. civ. be., art. 5.102, si elle est définitive le contrat est « dissous de plein droit » (art. 5.100). Mais, quelle que soit la présentation qu'on en donne, l'inexécution due à un cas de force majeure permet bien au cocontractant de refuser lui-même d'exécuter. Cependant, dans les récentes décisions rendues au sujet des effets des mesures prises en période de Covid sur les obligations du locataire en matière de bail à loyer, le tribunal de Luxembourg a considéré dans de nombreuses décisions que le fait que l'impossibilité d'exploiter les lieux ne soit pas imputable au bailleur excluait le jeu de l'exception d'inexécution. Pour le tribunal, « l'impossibilité temporaire pour le preneur-exploitant d'exercer son activité dans les lieux loués à cause de la fermeture ordonnée n'est pas la conséquence d'un manquement du bailleur à cette triple obligation de garantie d'assurer la jouissance paisible, mais bien d'une décision des autorités qui s'impose à lui… Par conséquent, le bailleur n'ayant pas manqué à son obligation de faire jouir le preneur, le moyen tiré de l'exception d'inexécution est à rejeter »[1599]. Cette argumentation nous paraît assez critiquable, dans la mesure où, qu'on y voie un cas particulier d'exception d'inexécution ou

[1597] Voy. p. ex. J. Ghestin, Ch. Jamin et M. Billau, « Les effets du contrat », in *Traité de droit civil*, 3e éd., 2001, Paris, L.G.D.J., n° 83 ; Terré, Simler, Lequette, Chénedé 2023, n° 770 ; M. Fabre-Magnan, *Droit des obligations, I. Contrat et engagement unilatéral*, 5e éd., Thémis, 2019, n° 995.

[1598] Dans ce sens Wéry, nos 775 et 577.

[1599] Trib. Luxembourg, 12 juillet 2021, nos TAL-2021-02935 et TAL-2021-03029, *Pas.*, 40, p. 532, note P. Ancel et A. Prüm.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

– sans doute plus justement – une application de la théorie des risques, il paraît anormal, dans un contrat synallagmatique, d'obliger le débiteur à exécuter son obligation alors qu'il ne reçoit pas la prestation réciproque, même si cela n'est pas dû au fait de son cocontractant. Dans les affaires liées à la Covid, si la solution paraît néanmoins justifiée, c'est pour une autre raison. C'est que, dans ces affaires, il n'y a pas à proprement parler inexécution de l'obligation de délivrance de la part du bailleur : le locataire, s'il ne peut plus exercer son activité pendant une certaine période, conserve la jouissance des locaux, dont le bailleur ne peut plus disposer. La situation semble donc plutôt commander une réduction du montant du loyer (à laquelle, on l'a vu, le tribunal parvient par un autre moyen[1600]) plutôt que la suspension totale de l'obligation du locataire, à laquelle conduit normalement le jeu de l'exception d'inexécution. C'est ce qui explique que, dans ses arrêts de 2022 relatifs à la même problématique, la Cour de cassation française ait également écarté le jeu de l'exception d'inexécution, par des motifs assez proches de ceux avancés par le tribunal de Luxembourg[1601], alors pourtant qu'en droit français, il est habituellement admis que l'exception peut jouer même en cas de force majeure.

712. Exercice conforme à la bonne foi. L'exigence générale de bonne foi de l'article 1134 alinéa 3 interdit d'abord qu'on puisse invoquer l'exception d'inexécution si on est soi-même à l'origine de l'inexécution de l'autre partie[1602]. Elle impose ensuite que l'exception joue de manière proportionnée par rapport à la gravité de l'inexécution. On ne concevrait guère, par exemple, que l'acheteur d'une voiture refuse d'en payer le prix au motif que l'allume-cigare ne fonctionne pas ! En droit comparé et européen, les différents textes reflètent cette exigence de manière diverse : ainsi les PDEC permettent au créancier de suspendre l'exécution « ainsi qu'il est raisonnable eu égard aux circonstances », le DCEV pose que « L'éventuelle suspension de l'exécution […] est totale ou partielle, dans la mesure justifiée par l'inexécution ». L'article 5.239 du nouveau Code civil belge prévoit explicitement que « La suspension doit être appliquée de bonne foi ». Ces formules sont plus souples que celle de l'article 1219 du Code civil français, qui subordonne le jeu de

[1600] Voy. *supra*, n° 518.

[1601] Cass. fr., (3e civ.), 30 juin 2022, FS-B, n° 21-20.127 (1re espèce) ; n° 21-20.190 (2e espèce), n° 21-19.889 (3e espèce).

[1602] Dans ce sens : POELMANS, n° 207-1.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'exception à une inexécution « suffisamment grave ». Il vaut mieux admettre que même une inexécution mineure, partielle, peut justifier le jeu de l'exception, mais le cocontractant ne pourra alors lui-même que refuser partiellement d'exécuter (par exemple, en retenant une partie du prix jusqu'à ce que l'autre ait totalement exécuté)[1603]. Il n'en irait autrement que dans le cas précédemment examiné où l'inexécution partielle empêcherait d'atteindre l'objectif du contrat.

713. Clauses relatives à l'exception d'inexécution. Il est certainement possible, en droit commun, d'élargir les conditions de mise en œuvre de l'exception, par exemple en ouvrant la possibilité d'une exception d'inexécution anticipée, en prévoyant que l'inexécution d'une quelconque obligation d'une partie autorisera l'autre à suspendre l'exécution de toutes ses autres obligations, même de celles qui n'en seraient pas la « contrepartie directe », ou en permettant de refuser totalement l'exécution même en cas d'inexécution partielle. Admises en matière de résolution, ces clauses doivent l'être *a fortiori* pour l'exception d'inexécution, qui produit des effets moins graves. La solution est moins claire pour les clauses qui, à l'inverse, prétendraient interdire à un contractant le droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution, ou en restreindraient les conditions : la doctrine belge les admet sans hésitation[1604], la doctrine française est plus hésitante[1605]. De prime abord, il ne nous semble pas y avoir de raison d'interdire de manière générale de telles clauses, sous les mêmes conditions que celles qui excluent le jeu de la résolution ou le droit aux dommages et intérêts en cas d'inexécution[1606]. Cependant, l'article L. 211-3 (3) du Code de la consommation déclare abusives « les clauses interdisant au consommateur de suspendre en tout ou en partie le versement des sommes dues si le professionnel ne remplit pas ses obligations ».

§2. Effets de l'exception d'inexécution

714. Suspension des obligations. Du point de vue de ses effets, l'exception apparaît comme un mécanisme d'attente, qui n'affecte pas définitivement le sort du contrat. Celui qui l'invoque peut se

[1603] Dans ce sens en droit belge : Wéry, n° 779.

[1604] Wéry, n° 772 ; C. Goux, « Les clauses relatives à l'exception d'inexécution », in P. Wéry (dir.) *Les clauses applicables en cas d'inexécution des obligations contractuelles*, Bruxelles, La Charte, 2001, pp. 159 et s.

[1605] Voy. par ex. FLOUR AUBERT SAVAUX 2022, n° 752.

[1606] Voy. *infra*, n°s 773 et 853 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

refuser à exécuter, mais il n'est pas libéré du contrat. Par exemple, un vendeur impayé peut refuser de livrer, mais il ne peut pas vendre le bien à quelqu'un d'autre. On est en présence d'une simple suspension de l'exécution – et c'est d'ailleurs sous cette appellation qu'elle est désignée dans divers projets européens, et le terme se retrouve dans les nouveaux textes français et belges[1607].

Cette suspension qui affecte au premier chef la ou les obligations que le contractant qui invoque l'exception a des incidences variables sur le contrat lui-même. Dans certains cas, sans doute, l'exception ne fait que retarder l'exécution, et, lorsque celle-ci reprendra, le contrat sortira en quelque sorte indemne : il en va ainsi lorsque le vendeur retarde la livraison jusqu'à ce qu'il soit payé. Mais, dans d'autres cas, la suspension se traduit par une véritable « mise entre parenthèses » du contrat, qui pourra reprendre plus tard, mais sans que l'on puisse effacer la période où il n'a pas été exécuté. Ainsi, dans un contrat de bail, si le locataire est privé momentanément de la jouissance des lieux loués, il sera libéré du paiement des loyers pendant toute la période où il a dû aller vivre ailleurs. De même, si l'assureur suspend le contrat d'assurance parce que l'assuré ne paye pas les primes, et qu'un accident survient pendant cette période, l'assuré ne sera pas couvert, même si, ultérieurement, il reprend ses paiements. La suspension opère donc ici comme une sorte de résiliation momentanée du contrat.

715. Suspension temporaire ou définitive. On enseigne généralement que l'exception n'est qu'un remède temporaire, une solution d'attente. C'est vrai dans la mesure où le jeu de l'exception ne suffit jamais à régler définitivement le sort du contrat. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Si, finalement, le cocontractant s'exécute, l'exception ne peut plus jouer et le contractant qui l'avait exercée doit lui-même s'exécuter. Si, à l'inverse, l'inexécution persiste, le cocontractant devra, pour tirer les conséquences définitives de l'inexécution, saisir la justice soit pour obtenir l'exécution, soit pour obtenir la résolution, soit pour obtenir (à la place ou en plus) des dommages et intérêts[1608]. En pratique, cependant, dans de nombreux cas, on assiste à un « pourrissement » de la situation : si le créancier n'a pas un intérêt suffisant à la situation, il ne fera rien, et le contrat restera inexécuté des deux côtés. Du reste,

[1607] PDEC, art. 9:201 ; DCEV, art. 113 ; DCFR, art. III-3:401 (« *right to withhold performance* »).

[1608] Cour d'appel, 27 avril 2011, n° 36005, *BIJ*, 2012, p. 117. Cour d'appel, 10 novembre 2022, *Pas.*, 41, p. 394.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'exception peut être invoquée, et continuer de jouer, alors qu'on sait dès le départ que le cocontractant n'exécutera jamais ses obligations – par exemple parce qu'il est en faillite. Ce n'est que s'il a déjà exécuté en partie, s'il a besoin d'être dégagé du contrat pour pouvoir contracter ailleurs, ou s'il veut obtenir la prestation qui lui a été promise que le créancier devra saisir la justice pour qu'il soit statué sur le sort définitif du contrat.

Ce caractère temporaire est conçu de manière assez stricte par la jurisprudence luxembourgeoise, qui en tire argument pour refuser à un contractant débiteur d'invoquer l'exception d'inexécution de manière purement défensive, pour résister à une demande en exécution formée par son cocontractant, sans chercher par ailleurs à faire sanctionner l'inexécution dont il se prévaut. Pour les juridictions luxembourgeoises, l'exception ne peut être invoquée qu'avant la saisine du juge. L'*excipiens*, assigné en exécution par son cocontractant, ne peut pas se contenter de dire en défense qu'il refuse d'exécuter tant que ce dernier n'a pas lui-même exécuté, il doit former une demande reconventionnelle en dommages et intérêts ou en résolution du contrat[1609]. Cette solution, qui s'appuie sur des écrits doctrinaux belges et français anciens, semble spécifiquement luxembourgeoise. On ne trouve pas trace de cette solution dans les jurisprudences des deux pays voisins.

[1609] Cou d'appel, 28 juin 2017, n° 43688 ; Cour d'appel, 19 janvier 2018, n° 35244 ; Trib. Luxembourg, 20 mars 2024, n° TAL-2023-06898.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les solutions d'attente, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 786-813
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

SECTION 2. LE SORT DU CONTRAT INEXÉCUTÉ

716. Différentes solutions envisageables. De prime abord, le contractant victime de l'inexécution d'une ou plusieurs obligations de son cocontractant, peut envisager deux solutions qui vont affecter très différemment le contrat. Soit il veut absolument obtenir la prestation qui lui a été promise et il cherchera alors à contraindre le débiteur à exécuter son obligation, en « s'accrochant » en quelque sorte à la force obligatoire du contrat : tu t'es engagé à me payer (ou à me rembourser) telle somme, tu as promis de me livrer tel bien, de me construire ma maison, etc. tu dois tenir ton engagement, et je vais saisir le juge pour qu'il t'y contraigne ! Soit, à l'inverse, le contrat qui n'a pas été exécuté ne l'intéresse plus, et le créancier va chercher à s'en débarrasser, à la fois pour pouvoir récupérer ce qu'il a lui-même versé en exécution de ce contrat et pour pouvoir, éventuellement, passer avec quelqu'un d'autre un contrat similaire.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Je t'ai vendu mon appartement et tu ne me le payes pas : je veux sortir de ce contrat, pour pouvoir vendre l'appartement à quelqu'un d'autre. Je t'ai acheté du matériel, que tu ne me livres pas, alors que je t'en ai déjà payé une partie : je veux pouvoir récupérer ce que je t'ai déjà payé, et j'achèterai ailleurs le matériel dont j'ai besoin ! C'est le choix entre ces deux grandes solutions qu'offre, en droit luxembourgeois, l'article 1184 du Code civil, qui permet au créancier de demander soit l'exécution du contrat, soit sa résolution (c'est-à-dire son anéantissement) : « La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ».

Les choses ne sont cependant pas si simples. Les deux solutions ci-dessus envisagées ne sont pas toujours possibles l'une et l'autre, et parfois elles ne sont pas possibles – ou ne présentent d'intérêt – ni l'une ni l'autre.

L'exécution forcée, d'abord, n'est pas toujours envisageable. Elle ne l'est pas, en fait, lorsque l'inexécution du contrat est définitive, sans qu'on puisse revenir dessus : si, au cours de l'exécution d'un contrat de transport, un accident est survenu, et que le passager est décédé, cela n'a évidemment aucun sens d'essayer de contraindre le transporteur à l'exécution de son obligation de sécurité ! Même lorsque l'inexécution n'est pas définitive, l'exécution forcée peut s'avérer en fait très difficile, voire impossible à obtenir, si elle suppose le concours du débiteur et que celui-ci refuse absolument de s'y soumettre : essayez donc de contraindre un maçon de construire un mur ! Surtout, on peut concevoir que le droit, pour des considérations de politique juridique, se refuse par principe à ordonner l'exécution forcée, même lorsqu'elle est possible, ou ne l'admette que de manière exceptionnelle : nous verrons ainsi que c'est la position de principe des droits de *common law*, dont c'est, en droit des contrats, un des principaux traits distinctifs par rapport aux droits d'Europe continentale, qui considèrent, eux, l'exécution forcée comme une solution normale (même s'ils peuvent, eux-aussi, interdire qu'on y recoure dans certaines circonstances).

Quant à la résolution – l'anéantissement du contrat inexécuté – elle n'a, de prime abord, d'utilité que dans les contrats synallagmatiques, où le créancier peut avoir intérêt à se débarrasser du contrat pour être libéré lui-même de ses propres obligations ou pour récupérer ce qu'il a déjà versé : si le contrat ne fait naître

LARCIER INTERSENTIA
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

d'obligations que pour le cocontractant, la seule chose que peut rechercher le créancier, c'est d'en obtenir l'exécution ou, à défaut, des dommages et intérêts. Pourquoi par exemple, un banquier qui a obtenu un cautionnement pour garantir un prêt, voudrait-il se libérer d'un contrat qui ne lui confère que des avantages ? Ce qu'il veut, c'est que la caution paye, donc faire exécuter le contrat[1610]. Mais, même si le contrat est synallagmatique, la résolution n'est pas toujours possible, parce qu'il est souvent impossible de revenir sur le passé. C'est le cas dans la plupart des contrats ayant pour objet une prestation de services : si mon avocat, par exemple, a laissé passer un délai de prescription, et m'a fait perdre mon procès, il est impossible de revenir dessus ; tout ce que je peux espérer et tout ce que je veux, c'est obtenir la réparation de mon préjudice. Et puis, là encore, la possibilité d'obtenir la résolution peut être plus ou moins largement admise selon les systèmes juridiques : on peut concevoir, par exemple, que le droit refuse d'admettre qu'un contrat puisse être anéanti pour une inexécution mineure.

Dans un certain nombre de cas, une troisième solution est envisageable : lorsque le contrat aura été exécuté de manière incomplète ou imparfaite, le créancier pourra vouloir rester dans les liens du contrat, mais en obtenant une diminution du prix convenu pour la prestation. Cette réduction du prix, qui équivaut à une modification du contrat mal exécuté, n'a pas été envisagée d'une manière générale dans le Code civil de 1804, et, aujourd'hui encore, au Luxembourg, elle n'est possible que dans certains cas particuliers. Les nouveaux droits français et belge lui ont en revanche fait une place générale au sein des sanctions de l'inexécution. Ce remède n'a cependant qu'un domaine d'application limité.

Il y a donc toute une série de cas où, en fait ou en droit, le contractant victime de l'inexécution n'aura à sa disposition que l'un de ces moyens d'action qui mettent en jeu le sort du contrat – exécution forcée, résolution, réduction du prix – voire, on le dit moins souvent, aucun de ces moyens. Dans ces hypothèses, le seul remède à l'inexécution sera l'obtention de dommages et intérêts, qui joueront alors le rôle d'un substitut à l'exécution. Dans d'autres cas, ils viendront se combiner avec l'un ou l'autre des autres moyens d'action.

[1610] Voy. cependant *infra*, n° 757 la possibilité de faire jouer la résolution dans certains contrats unilatéraux.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

717. Combinaison des moyens d'action. Une question très importante est celle de savoir si les différentes solutions ouvertes au créancier victime de l'inexécution peuvent se cumuler, ou si elles lui sont offertes de manière alternative. Dans la plupart des projets européens, on pose en principe le cumul des moyens d'action, dans la mesure où ils sont compatibles[1611]. Ce principe, qu'on retrouve dans le nouveau droit français (art. 1217), comme dans l'article 5.83 du nouveau Code civil belge, vaut aussi en droit luxembourgeois, mais il n'a de sens que pour les dommages et intérêts qui peuvent toujours être demandés en plus de la résolution (C. civ., art. 1184) ou de l'exécution forcée, pour réparer le préjudice subi par le créancier. En revanche, le cumul paraît de prime abord exclu entre les deux principales solutions qui s'offrent au créancier par rapport au contrat lui-même, l'exécution forcée ou la résolution, qui sont, par nature, incompatibles : si le créancier demande l'exécution, c'est qu'il veut se tenir au contrat, s'il demande la résolution, c'est qu'il veut son anéantissement.

L'affirmation doit cependant être nuancée. Il est certain qu'on ne peut pas demander en même temps à un tribunal de condamner le débiteur à exécuter et de prononcer la résolution du contrat. Mais, d'abord, on peut les demander successivement, y compris par voie d'une demande subsidiaire à l'autre : si le créancier a d'abord demandé la condamnation à l'exécution, et que celle-ci ne peut pas être obtenue, il peut se rabattre sur la résolution du contrat ; à l'inverse, s'il n'obtient pas la résolution, par exemple parce que l'inexécution est jugée trop peu grave, il peut ensuite chercher à faire exécuter. Selon la Cour d'appel, le créancier peut même changer de voie au cours du procès, et substituer en appel une demande en résolution à la demande en exécution qu'il avait formée en première instance[1612]. Ensuite, si la résolution est obtenue, elle peut déboucher sur des obligations de restitution, et être accompagnée d'une condamnation à des dommages et intérêts. Or ces obligations, si le débiteur ne les exécute pas volontairement, peuvent faire l'objet d'une demande d'exécution forcée, ce remède n'étant pas spécifique aux obligations nées d'un contrat, mais valant pour toute obligation quelle qu'en soit la source.

C'est sous le bénéfice de ces observations préliminaires qu'on peut étudier les deux voies qui s'offrent au créancier victime de l'inexécution : l'exécution forcée (**Sous-section 1**) et la résolution

[1611] PDEC, art. 8 : 102 ; DCFR, art. II-3 : 102 ; DCEV, art. 106 (6).
[1612] Cour d'appel, 1er mars 2000, *Pas.*, 31, p. 368.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pour inexécution (**Sous-section 2**). On dira ensuite quelques mots de la troisième voie que constitue la réduction du prix, même si, actuellement elle n'est ouverte que dans des hypothèses limitées (**Sous-section 3**)

SOUS-SECTION 1. L'EXÉCUTION FORCÉE

718. Distinction. Est-il toujours possible ou licite, d'abord, de contraindre le débiteur à l'exécution ? Et comment peut-on le faire ? Si c'est possible et licite, le créancier a-t-il un véritable droit à obtenir la condamnation de son débiteur à l'exécution ? Ces questions reçoivent des réponses très différentes selon les systèmes. En droit luxembourgeois, comme dans les deux autres pays du Code civil, il faut distinguer selon la nature de l'obligation inexécutée : si l'exécution forcée est de droit pour les obligations de somme d'argent (**§ 1**), elle suscite davantage de difficultés pour les obligations non monétaires (**§ 2**).

§1. L'exécution forcée des obligations de somme d'argent

719. Exécution forcée sur les biens. Si l'obligation est une obligation de payer une somme d'argent, le créancier a la possibilité de se payer sur les biens de son débiteur, qui seront vendus contre le gré de celui-ci, et dont le prix sera distribué entre ses différents créanciers. Cette manière de contraindre le débiteur à payer ses dettes, que connaissent aujourd'hui tous les systèmes juridiques européens est le résultat d'une longue évolution historique, qui a conduit de l'exécution sur la personne même du débiteur à l'exécution sur les biens. Dans les droits primitifs, le créancier avait la possibilité de mettre à mort le débiteur qui n'exécutait pas, ou de le réduire en esclavage (ce qui était sans doute plus efficace). Ces modalités d'exécution primitives se sont peu à peu adoucies, et la mise en œuvre de l'exécution sur la personne du débiteur a été progressivement soustraite à la justice privée du créancier pour être confiée à l'État. Mais, jusqu'au XIXe siècle, le créancier impayé avait toujours la possibilité de faire mettre en prison le débiteur. Cependant cette « contrainte par corps », qui n'avait qu'une efficacité limitée, n'existe plus aujourd'hui que pour le paiement des amendes pénales. Désormais, la seule possibilité ouverte au créancier est de se faire payer sur les biens de son débiteur. Cette possibilité est affirmée, de manière très générale, par l'article 2092 du Code civil, qui consacre

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ce qu'il est convenu d'appeler *le droit de gage général du créancier sur le patrimoine du débiteur*[1613] : « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir »[1614]. Ce texte est, dans les pays du Code civil, un des points d'ancrage de la théorie du patrimoine, qui traduit le lien entre l'actif et le passif de toute personne.

Bien que le texte, pris à la lettre, ne vise que le débiteur qui « s'est engagé personnellement » – donc par contrat – le principe posé, ainsi que toutes les règles qui s'y rattachent et qui vont être exposées dans les développements qui vont suivre, concerne en réalité toutes les obligations, contractuelles ou non contractuelles[1615]. On exposera d'abord rapidement les prérogatives conférées par le droit de gage général (A), avant de voir comment le droit en assure la protection (B).

A) *Les prérogatives du droit de gage général*

720. Modes de réalisation. Comment, concrètement, un créancier que son débiteur ne paye pas volontairement peut-il se faire payer sur les biens de son débiteur ? En droit luxembourgeois, cela dépend de la qualité du débiteur.

Si le débiteur n'est pas commerçant, le créancier ne peut en principe se faire payer qu'en pratiquant une saisie des biens du débiteur, c'est-à-dire en faisant vendre ces biens à son profit, ou, s'il s'agit de créances, en s'en faisant payer le montant par le débiteur de son débiteur. Les procédures de saisie, qui sont réglementées par le Nouveau Code de procédure civile, sont des *procédures individuelles*, en ce sens qu'il appartient à chaque créancier de diligenter une procédure de saisie, ou de se joindre à une saisie commencée par un autre créancier. Pour cela, il devra être titulaire d'une créance certaine, liquide (c'est-à-dire dont le montant est évalué) et exigible, et avoir un titre exécutoire (un acte notarié, ou un jugement de condamnation du débiteur) (NCPC, art. 689). Ce sont par ailleurs des *procédures partielles*, en ce sens qu'un créancier ne peut pas, par une seule saisie, appréhender l'ensemble des biens du débiteur : il existe des procédures différentes selon la nature des biens à saisir (saisie-exécution pour les biens

[1613] L'expression est trompeuse : il ne faut surtout pas confondre ce « droit de gage général » avec le gage, qui est une sûreté particulière sur les biens mobiliers.

[1614] Ce texte se retrouve à l'identique en droit français et en droit belge, mais avec une autre numérotation : en Belgique l'article 2092 est devenu l'article 7 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ; en France, c'est depuis 2006 l'article 2294 du Code civil.

[1615] Le texte belge a d'ailleurs été corrigé en ce sens : l'article 7 de la loi hypothécaire dispose désormais « quiconque est obligé personnellement ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

mobiliers corporels, saisie immobilière, saisie-arrêt pour les créances, saisie des rémunérations du travail, etc.). Dans tous les cas, la saisie fait intervenir un huissier et se déroule sous le contrôle de la justice.

Si le débiteur est un commerçant, il est toujours possible de pratiquer une saisie tant que le débiteur n'est pas en état de cessation des paiements, c'est-à-dire dans l'impossibilité de répondre de toutes ses dettes avec son actif disponible. Dans ce cas, le commerçant sera mis en faillite, et c'est dans le cadre de cette procédure, réglée par le Code de commerce (C. comm., art. 437 et s), que les créanciers se feront payer. À la différence des saisies, la faillite est une *procédure globale*, c'est-à-dire qu'elle permet d'appréhender et de vendre tous les biens du débiteur. C'est en outre une *procédure collective* : tous les créanciers sont appelés à déclarer leur créance, et sont rassemblés dans une « masse », et le prix des biens est distribué entre tous les créanciers.

La différence (traditionnelle) entre les deux types de procédures est aujourd'hui atténuée avec la mise en place au Luxembourg sur le modèle français de procédures de traitement du surendettement des particuliers : ces procédures ont pour but premier d'accorder au débiteur surendetté des délais[1616] ou des remises de dette ; mais, dans le dernier état du droit (L. 8 janvier 2013), si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise de sorte que délais et remises ne peuvent aboutir à son redressement, le juge peut ouvrir une procédure de « rétablissement personnel » qui vise à vendre les biens du débiteur, et à payer ses créanciers, le débiteur étant libéré pour le surplus si le produit de la vente s'avère insuffisant. On est alors très proche de ce qui se passe dans la faillite commerciale.

Il n'est évidemment pas question, dans le cadre d'un ouvrage de droit des contrats, d'entrer dans le détail de ces différentes procédures (qui relèvent du droit judiciaire privé, du droit commercial ou du droit de la consommation). Il est en revanche nécessaire de s'interroger sur l'efficacité du droit de gage général pour assurer le paiement effectif du créancier.

721. Efficacité du droit de gage général. En dépit – ou peut-être à cause – de son caractère « général », le droit qui appartient à tout créancier de se payer sur les biens du débiteur ne lui assure qu'une protection illusoire contre l'inexécution des obligations de son débiteur.

[1616] Voy. *supra*, n°s 585 et 586.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

La première raison est justement que ce droit appartient à tous les créanciers. Or il n'est évidemment pas certain que les biens du débiteur seront suffisants pour pouvoir désintéresser tous ses créanciers. Si ce n'est pas le cas, *le droit de gage général ne confère à ses titulaires aucun droit de préférence* : on partagera en principe le prix entre tous les créanciers venant à la distribution en proportion du montant de leurs créances respectives (C. civ., art. 2093) : on dit, traditionnellement, que le partage s'opère « au marc le franc ». Si, par exemple, le débiteur a un actif de 90 000, et un passif de 120 000 ainsi réparti : A est créancier de 40 000, B de 60 000, C de 20 000. A (1/3 du passif) recevra 1/3 de l'actif soit 33 000, B recevra ½ soit 45 000, C 1/6 soit 15 000. Dans cet exemple, aucun des créanciers ne recevra un paiement intégral.

Cette règle reçoit cependant une application différenciée selon le mode d'exécution. Elle ne joue vraiment que dans les procédures collectives (faillite) où tous les biens sont vendus collectivement au profit de tous les créanciers, ce qui garantit une égalité entre les créanciers chirographaires. Dans les procédures individuelles (saisies), chaque créancier agit individuellement, quand il veut, et quand il peut (si sa créance est certaine, liquide et exigible), en saisissant tel ou tel bien du débiteur. Si d'autres créanciers ont déjà, avant lui, saisi un bien et se sont fait attribuer le prix, il se peut que celui qui vient ensuite n'ait plus rien : on dit que le paiement est le prix de la course.

Par ailleurs, il faut voir que l'assiette du droit de gage général – les biens sur lesquels chaque créancier peut se payer – est très fragile. Les créanciers peuvent certes saisir, selon l'article 2092 du Code civil, « tous les biens mobiliers et immobiliers » (sous réserve de ceux que la loi déclare insaisissables[1617]), « présents et à venir », c'est-à-dire non seulement qui étaient présents dans le patrimoine du débiteur au moment où la créance est née, mais aussi ceux dont il devient propriétaire par la suite. Mais c'est à la condition que ces biens soient encore présents dans le patrimoine au moment où le créancier exerce son droit (c'est-à-dire au moment où il saisit ou au moment où s'ouvre la procédure de faillite). Si le débiteur a, entre le moment où il est devenu débiteur et le moment où le créancier le poursuit, vendu ou donné certains biens, ceux-ci, sortis du patrimoine, ne pourront plus être appréhendés par le créancier. Titulaire d'un simple droit personnel, le créancier n'a pas de droit sur tel ou tel bien particulier du débiteur, il n'a que le droit – en quelque sorte virtuel – de se payer sur les biens qui

[1617] Voy. p. ex. : NCPC, art. 728 (insaisissabilité des biens nécessaires à la vie et au travail du saisi), C. trav., art. L. 224-2 (insaisissabilité d'une fraction du salaire), NCPC, art. 717 (possibilité de stipuler une insaisissabilité dans une donation ou un testament).

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

sont dans le patrimoine au moment de l'ouverture des procédures d'exécution. On dit que *le droit de gage général ne confère aucun droit de suite.*

Le droit offre certes aux créanciers qui veulent accroître leurs chances d'être payés en cas d'insolvabilité de leur débiteur de prendre des garanties particulières, qu'on appelle des sûretés. Le contractant qui fait crédit à son cocontractant peut, par exemple, demander à un tiers de s'engager à payer la dette du débiteur si celui-ci ne la paie pas : tel est l'objet du contrat de cautionnement, déjà rencontré. Le créancier peut aussi se faire accorder par le débiteur un droit réel sur tel ou tel de ses biens, qui lui donnera le droit de se faire payer sur ce bien par préférence aux autres créanciers, et qui, dans certains cas, lui donnera aussi le droit de suivre le bien et de se payer dessus même s'il sort du patrimoine du débiteur. C'est ce que donne notamment une hypothèque sur un immeuble du débiteur. Même en l'absence d'une telle convention entre le créancier et le débiteur, la loi donne à certains créanciers, qu'on veut favoriser (les salariés pour le paiement de leur salaire, le fisc pour le paiement des impôts, etc.) un droit de préférence sur tout ou partie des biens du débiteur. Mais ces sûretés (dont une étude détaillée s'impose dans le cadre d'autres enseignements)[1618] réduisent d'autant les chances d'obtenir le paiement pour les autres créanciers, ceux qui n'ont pas de sûreté, et qu'on appelle les créanciers chirographaires – qui n'ont, eux, ni droit de préférence ni droit de suite.

Le droit offre cependant, à la marge, certains moyens de protection à ces créanciers en leur permettant de sauvegarder la consistance de l'assiette du droit de gage général.

B) *Les moyens de sauvegarde du droit de gage général*

722. Mesures conservatoires et actions de reconstitution de l'actif. Les créanciers, même s'ils n'ont pas de sûretés, peuvent d'abord intervenir de manière préventive, pour empêcher une diminution de l'actif du débiteur : tel est l'effet des saisies conservatoires, qui permettent de rendre indisponibles certains biens du débiteur avant même que les conditions requises pour pratiquer une saisie aux

[1618] Sur les sûretés en droit luxembourgeois, voy. A.-R. Cuny de la Verrryère, *Sûretés et garanties au Grand-Duché de Luxembourg*, Bruxelles, Larcier, 2014 ; H. Westendorf, *Les sûretés et garanties du crédit en droit luxembourgeois*, t. 1, *Les principales garanties mobilières conventionnelles*, coll. Faculté de droit, d'économie et de Finance de l'Universite du Luxembourg 2e éd, Bruxelles, Larcier 2020 ; t. 2, *Les garanties personnelles*, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2023.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

fins d'exécution soient réunies : l'article 550 du Nouveau Code de procédure civile permet ainsi au Président du Tribunal d'arrondissement d'ordonner une saisie des effets mobiliers « dans les cas qui requerront célérité ». Mais, à côté de ces règles dont l'étude relève du droit judiciaire, le Code civil ouvre aux créanciers deux actions spécifiques leur permettant de préserver ou de reconstituer l'assiette de leur droit de gage général. Il s'agit de l'action oblique (**1**) et de l'action paulienne (**2**). Dans le code actuel, non modifié sur ce point depuis 1804, ces deux actions sont présentées dans les articles 1166 et 1167 comme des exceptions au principe de l'effet relatif des contrats posé à l'article 1165[1619]. Cette présentation, très contestable, a été abandonnée dans les nouveaux textes français et belges, qui en traitent au sein du régime général de l'obligation (C. civ. fr., art. 1341 à 1241-3, C. civ. be., art. 5.242 et 5.243).

1) *L'action oblique (C. civ., art. 1166)*

723. Principe. L'article 1166 du Code civil prévoit que « les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ». Ce texte permet aux créanciers d'exercer, au nom et à la place du débiteur les droits et actions que celui-ci a contre les tiers, et qu'il n'exerce pas alors que cela pourrait lui permettre de récupérer des éléments d'actif. C'est un moyen de lutte contre la négligence du débiteur qui n'est sans doute pas très pressé d'exercer des actions dont le résultat profiterait à son créancier. Par exemple, le débiteur a vendu un immeuble à un prix trop bas, et il pourrait faire annuler la vente ou réviser le prix en exerçant une action en rescision pour lésion[1620]. S'il n'exerce pas cette action, son créancier peut le faire à sa place pour ensuite saisir l'immeuble récupéré ou le supplément de prix versé. Ou encore, le débiteur a été victime d'un fait dommageable, et il pourrait demander des dommages et intérêts. Le créancier peut demander ces dommages et intérêts à sa place si le débiteur ne le fait pas lui-même. L'appellation « action oblique » pour désigner ce droit d'agir au nom du débiteur reconnu par l'article 1166 du Code civil s'explique précisément parce que le créancier n'agit pas en son nom personnel, il ne se voit personnellement reconnaître aucun droit direct contre le débiteur de son débiteur. Il vaudrait du reste mieux dire qu'il exerce l'action du débiteur « par la voie oblique ».

[1619] Sur lequel voy. *infra*, n°s 953 et s.
[1620] Voy. *supra*, n°s 259 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

L'action oblique apparaît comme un mécanisme doublement exceptionnel. D'une part, elle se traduit par une immixtion du créancier dans les affaires du débiteur, dont la liberté d'action se trouve ainsi restreinte. D'autre part, d'un point de vue plus technique, elle apparaît, lorsque les droits exercés sont d'origine contractuelle, comme une dérogation (au moins apparente) au principe de l'effet relatif du contrat posé à l'article 1165 du Code civil, et c'est ainsi que les rédacteurs du Code l'ont présentée : ce principe, nous le verrons, signifie que le contrat ne fait naître de droits et d'obligations que pour les seules parties ; or le créancier qui exerce l'action oblique se comporte comme si c'était lui le titulaire des droits et actions de son débiteur. Cette dérogation est cependant purement apparente, car le créancier se voit ici investi d'un pouvoir de représentation, et, nous le verrons, les effets de son action se produisent exclusivement dans le patrimoine du débiteur. Ce caractère dérogatoire de l'action oblique a amené la loi et la jurisprudence à la soumettre à des conditions restrictives (**a**), et à ne lui faire produire que des effets limités (**b**).

a. *Conditions de l'action oblique*

724. Conditions relatives aux droits pouvant être exercés par la voie oblique. Le texte adopte une formulation très générale, visant à la fois les « droits » et les « actions ». Les exemples précédemment donnés (action en rescision pour lésion, action en dommages et intérêts) visent des actions en justice, mais le créancier peut aussi, sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, exercer des droits qui ne supposent pas l'intervention d'un tribunal : par exemple le droit de faire jouer une clause résolutoire permettant de récupérer une chose, le droit de mettre fin à un contrat de bail, de demander la restitution d'une chose prêtée, etc. Peu importe par ailleurs la source des droits et actions : il peut s'agir de droits d'origine contractuelle, mais aussi d'une action en dommages et intérêts extra-contractuels, d'une action en répétition de l'indû, etc.

Encore faut-il, cependant, que les droits et actions ne soient pas « exclusivement attachés à la personne » du débiteur. Le créancier ne peut jamais se substituer au débiteur pour exercer une action ou pour prendre une décision qui suppose une appréciation trop personnelle, que seul le débiteur peut prendre. C'est ainsi que le créancier ne peut certainement pas exercer à la place de son

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

débiteur des actions extrapatrimoniales, alors même qu'elles pourraient procurer au débiteur un avantage pécuniaire : par exemple, une action en désaveu de paternité permettant d'éviter de payer une pension alimentaire, ou à l'inverse une action en recherche de paternité naturelle permettant d'espérer un bel héritage, etc. Mais la notion s'applique aussi à des actions patrimoniales, mais à caractère personnel trop marqué : c'est ainsi par exemple que, si le créancier peut en principe agir à la place de son débiteur pour obtenir le paiement de dommages et intérêts, il en va autrement lorsque le préjudice subi est un préjudice moral (la mort d'une personne proche, la souffrance physique, une atteinte à la vie privée) dont seule la victime peut apprécier l'opportunité de demander la réparation[1621]. De même, le créancier ne peut pas agir en révocation d'une donation consentie par le débiteur à un tiers[1622], ni demander à la place de celui-ci la réduction ou la suppression d'une pension alimentaire dont il est tenu. Le caractère strictement personnel explique également qu'un créancier ne puisse pas intervenir dans la gestion des biens de son débiteur en exerçant à sa place des facultés qu'on est toujours libre d'exercer ou non[1623] : si le débiteur, par exemple, laisse un de ses immeubles inoccupés, le créancier ne peut pas décider de le louer à sa place. La notion de « droits et actions exclusivement attachés à la personne » – textuellement reprise par l'article 1341 du Code civil français et par l'article 5.242 du Code civil belge, est cependant d'application délicate, car il faut trouver le juste équilibre entre la nécessaire liberté d'action et de décision du débiteur, et le souci de protéger le créancier, dont l'abstention compromet le paiement. Faute de pouvoir trouver beaucoup de précédents dans la jurisprudence nationale, les tribunaux luxembourgeois peuvent ici s'inspirer des jurisprudences française et belge, du reste très proches sur cette question[1624].

725. Conditions relatives aux créanciers pouvant exercer l'action oblique. Tous les créanciers peuvent exercer l'action oblique, quelle que soit la source – contractuelle ou non – de leur créance.

[1621] Liège, 28 juin 1991, cité par WÉRY, n° 853.

[1622] Cass. fr. (1re civ.), 19 avril 1988, n° 86-18028.

[1623] Sur la distinction entre les droits et les simples facultés, voy. Cour d'appel, 20 janvier 2022, n° CAL-2018-00834.

[1624] Comp. pour la France : FLOUR, AUBERT, SAVAUX, ANDREU, FORTI 2022, nos 10 et s. ; pour la Belgique : WÉRY, n° 853 ; VAN OMMESLAGHE, n° 1523.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

L'action en revanche n'est pas ouverte aux associés d'une société, qui, n'étant pas créanciers de celle-ci, ne peuvent pas exercer ses droits contre un tiers[1625].

L'action oblique n'étant pas en elle-même une mesure d'exécution, mais un préalable permettant de faire rentrer un bien ou une valeur dans le patrimoine, où le créancier pourra ensuite le saisir, il est admis qu'il n'est pas nécessaire que le créancier ait déjà un titre exécutoire. Mais c'est plus qu'une mesure conservatoire, et c'est pourquoi le créancier doit avoir une créance, non seulement certaine, mais aussi déjà exigible. En droit français, la Cour de cassation exige en plus que la créance soit liquide, déjà évaluée en argent[1626], alors que l'opinion dominante, en Belgique, est en faveur de la solution contraire[1627], en s'appuyant sur un seul arrêt de cour d'appel. De toute façon la fixation du montant sera nécessaire pour pouvoir saisir, et c'est seulement cette perspective qui justifie l'exercice de l'action oblique.

726. Conditions relatives au débiteur. L'action oblique ne peut être exercée que si le débiteur est inactif : s'il a agi en justice, le créancier ne peut pas se joindre au procès, et, si le débiteur décide d'agir alors que l'action est commencée, le créancier perd toute qualité pour agir. Mais peu importe la raison de l'inaction : il peut s'agir d'une simple négligence ou d'une volonté de nuire au créancier, voire d'une impossibilité personnelle dans laquelle le débiteur s'est trouvé d'agir.

Cette carence du débiteur doit compromettre les intérêts du créancier. D'une manière générale, cela suppose que le débiteur est insolvable, ou du moins menacé d'insolvabilité[1628]. Comme toute action, en effet, l'action oblique suppose un intérêt à agir. Or, si le débiteur a d'autres biens sur lesquels le créancier peut se payer, il faut considérer que ce dernier n'a pas un intérêt suffisant à agir pour faire rentrer d'autres biens dans le patrimoine. Cette condition doit cependant être appréciée avec souplesse. Même si le débiteur n'est pas complètement insolvable, l'action oblique peut être recevable si l'inaction du débiteur rend plus difficile le recouvrement de la créance. Le Tribunal de Luxembourg, se référant à la jurisprudence

[1625] Cour d'appel, 26 février 2020, n° CAL-2018-00209, se référant à la jurisprudence française.
[1626] Cass. fr. (1re civ.), 4 janvier 1983, n° 81-15865.
[1627] Wéry, n° 850, Van Ommeslaghe, n° 1524.
[1628] Cour d'appel, 2 mai 2007, n° 30577.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

française, a ainsi jugé que le droit pour un indivisaire de provoquer le partage pour pouvoir ensuite saisir la part divise d'un coindivisaire, reconnu par l'article 815-17 du Code civil et présenté comme une application particulière de l'article 1166, ne supposait pas que soit rapportée la preuve de l'insolvabilité du débiteur dès lors que son inaction du débiteur cause un préjudice au créancier en mettant sa créance en péril[1629].

La condition d'insolvabilité n'a par ailleurs aucun sens dans les hypothèses où l'action oblique est exercée pour assurer la sauvegarde d'un droit déterminé et non pour permettre au créancier de recouvrer sa créance : ainsi dans l'hypothèse, tirée de la jurisprudence française, où un syndicat de copropriétaires agit, à la place d'un des propriétaires pour résilier le bail contre un locataire troublant la tranquillité des autres propriétaires[1630]. Il s'agit là d'une utilisation complètement différente du mécanisme de l'article 1166 du Code civil.

b. *Effets de l'action oblique*

727. Fiction de représentation. Les effets de l'action oblique sont liés à l'idée que le créancier n'agit pas en son propre nom contre le débiteur de son débiteur. Il exerce les « droits et actions » de celui-ci. Tout se passe comme si le créancier avait reçu de son débiteur le pouvoir de le représenter. C'est cette fiction qui permet de concilier le mécanisme de l'action oblique avec le principe de l'effet relatif des contrats, puisque le créancier, tiers au contrat, agit au nom d'une partie. Ce fondement a d'importantes conséquences.

D'une part, le créancier agissant par la voie de l'action oblique doit respecter les mêmes règles que celles qui auraient été applicables si c'était le débiteur qui avait agi[1631], et il pourra se voir opposer les mêmes exceptions que celles qui auraient pu être opposées au débiteur. D'autre part, et surtout, les effets de l'action vont se produire dans le patrimoine du débiteur, et non du créancier agissant. Celui-ci pourra ensuite, bien entendu, saisir dans ce patrimoine les éléments d'actif récupérés, mais il ne sera pas nécessairement le seul. Les autres créanciers pourront également se payer sur cet actif récupéré, et ils vont entrer en concours avec le créancier qui a agi, sans que celui-ci, qui aura en quelque sorte « tiré les marrons du feu » au profit des autres, se voie reconnaître un droit de préférence.

[1629] Trib. Luxembourg, 19 avril 2024, n^os^ TAL-2020-09506 et TAL-2023-00076.

[1630] Cass. fr., 14 novembre 1985, n° 84-15577.

[1631] Trib. Luxembourg, 7 juillet 1965, *Pas.*, 19, p. 596.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Cet effet peu attractif de l'action oblique explique qu'elle ne soit qu'assez rarement exercée en pratique – et du coup on peut comprendre la rareté de la jurisprudence luxembourgeoise en la matière.

728. Distinction avec les actions directes. Les effets qui viennent d'être exposés permettent de distinguer l'action oblique – qui appartient, par principe, à tout créancier – des actions dites « directes » que la loi, et parfois la jurisprudence, reconnaissent à certains créanciers seulement. Ces actions permettent aux créanciers qui en bénéficient d'agir en leur nom propre contre un débiteur de leur débiteur. Le bénéfice de ces actions tombe alors dans le patrimoine du créancier agissant, qui n'entre pas en concours avec les autres[1632]. L'exemple le plus caractéristique est celui de l'action directe reconnue à la victime d'un accident contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage : la créance d'indemnité, due en théorie au responsable, profite exclusivement à la victime. Avec ces actions directes, on est en présence de véritables exceptions au principe de l'effet relatif des contrats, et c'est à ce titre que nous en ferons ultérieurement l'étude[1633].

2) *L'action paulienne (C. civ, art. 1167)*

729. Principe. Aux termes de l'article 1167 du Code civil « ils [les créanciers] peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ». Cette règle est reprise en substance par l'article 1341-2 du Code civil français et de manière beaucoup plus détaillée par l'article 5.243 du nouveau Code civil belge. Appelée traditionnellement « paulienne », en référence au jurisconsulte romain qui l'aurait inventée, cette action ne se comprend que si on sait, au départ, que les contrats, alors même qu'ils ne font naître de droits et d'obligations que pour les parties, sont néanmoins opposables aux tiers – en ce sens que les tiers ne peuvent pas faire comme si le contrat n'avait pas été passé, ils doivent en subir les conséquences[1634]. Cela vaut en particulier pour les créanciers des contractants : si mon débiteur vend un de ses biens, ce bien sort de son patrimoine, donc de mon droit de gage général, je ne peux plus me payer dessus. L'article 1167 du Code civil fait cependant exception à ce principe lorsque l'acte fait par le débiteur est frauduleux,

[1632] Trib. Luxembourg, 4 mars 2010, n°s 121585, 125280 et 125656.
[1633] Voy. *infra*, n°s 1104 et s.
[1634] Voy. *infra*, n° 983.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

c'est-à-dire a été passé dans le but ou avec l'intention ou du moins la conscience de nuire à son créancier en soustrayant le bien à ses poursuites. Dans un tel cas, le créancier lésé pourra, par l'action paulienne de l'article 1167 du Code civil, faire déclarer que l'acte ne lui est inopposable. Cette action est une application particulière d'un principe général, selon lequel « la fraude corrompt tout », exprimé généralement sous sa forme latine : *fraus omnia corrumpit*. C'est de manière tout à fait inexacte que les rédacteurs du Code civil ont présenté l'action paulienne, à l'article 1167 du Code civil, comme une exception au principe de l'effet relatif inscrit à l'article 1165 du Code civil. Loin de faire produire au contrat frauduleux des effets exceptionnels à l'égard du créancier agissant, l'action paulienne permet au contraire d'écarter ses effets normaux liés à son opposabilité.

L'article 1167 du Code civil est doublé, en droit commercial, par des textes spéciaux sanctionnant la fraude commise par un commerçant qui, se sachant proche de la faillite, cherche à faire échapper des biens aux poursuites de ses créanciers ou à en favoriser certains au détriment d'autres. L'article 445 du Code de commerce prévoit ainsi la nullité de certains actes passés par le commerçant pendant la période – dite, significativement, « période suspecte » – qui s'est écoulée entre le moment où il a cessé ses paiements et celui où le jugement d'ouverture de la faillite a été prononcé. Il en va ainsi notamment des « actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit, ainsi que (des) actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en retour ». Si les conditions posées par ce texte et les effets produits diffèrent sensiblement de ceux de l'article 1167 du Code civil, en revanche l'article 448 du Code de commerce, qui prévoit que « Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont nuls, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu » peut être considéré comme une application pure et simple de l'action paulienne[1635].

730. Distinction de l'action paulienne et des mécanismes voisins. L'action paulienne diffère sensiblement de l'action oblique : alors que celle-ci permet aux créanciers d'agir au nom du débiteur, pour exercer des droits que celui-ci n'exerce pas lui-même, l'action paulienne permet aux créanciers d'agir, en leur nom personnel, pour faire tomber des actes que le débiteur a passés. Et, alors que l'action oblique profite à tous les créanciers, l'action paulienne, nous le verrons, ne bénéficie qu'à celui qui l'a exercée.

Il faut également distinguer l'action paulienne de *l'action en déclaration de simulation*, fondée sur l'article 1321 du Code civil, qui permet aux tiers de faire déclarer qu'un acte passé par un contractant

[1635] Dans ce sens : Cour d'appel, 17 décembre 2008, *Pas.*, 34, p 363 ; Cour d'appel, 26 avril 2022, n° CAL-2020-00977.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ne correspond pas à la réalité. Cette action – qui est une autre exception au principe d'opposabilité du contrat aux tiers[1636] – permet par exemple à un créancier de faire déclarer qu'un acte de vente passé par son débiteur est purement apparent, et que le « vendeur » a secrètement convenu avec son « acheteur » qu'il resterait propriétaire. Ici encore, il s'agit de lutter contre la fraude, car la vente apparente est très probablement destinée à soustraire le bien vendu aux poursuites des créanciers en faisant croire qu'il est sorti du patrimoine. Mais, alors que l'action en déclaration de simulation vise à faire tomber une apparence d'acte, l'action paulienne s'attaque à un acte réel : on ne prétend pas que la vente faite par le débiteur est fictive, mais qu'elle a été passée dans le but de nuire aux créanciers. Il peut arriver que le créancier ait le choix entre les deux actions : face à une vente consentie par son débiteur, sans raison apparente, à un tiers, le créancier peut essayer de prouver, soit que cette vente est fictive, soit que, bien que réelle, elle est frauduleuse. Les conditions (**a**) et les effets (**b**) de l'action paulienne sont cependant différentes de celles de l'action en déclaration de simulation.

a. *Conditions de l'action paulienne*

731. Conditions tenant à l'acte attaqué. Tous actes passés par le débiteur peuvent en principe être attaqués par la voie de l'action paulienne, dès lors – selon une formule qu'on trouve dans plusieurs arrêts de la Cour d'appel – qu'ils se sont traduits par un appauvrissement du débiteur, et qu'ils ont été inspirés par la fraude[1637]. La jurisprudence luxembourgeoise suit ici très fidèlement les solutions développées en France et en Belgique, elles-mêmes très proches.

La première condition, *l'appauvrissement du débiteur*, doit être entendue de manière très souple. Il faut entendre par là les actes qui diminuent les chances pour le créancier de se faire payer[1638]. Cela vise au premier chef les actes d'appauvrissement au sens strict, qui diminuent la valeur du patrimoine. Le type même de l'acte d'appauvrissement, susceptible d'être attaqué, est la donation : le débiteur fait sortir de son patrimoine un bien sans recevoir de contrepartie. On peut y assimiler une renonciation à succession, un changement de régime matrimonial permettant de faire passer

[1636] Voy. *infra*, n°s 975 et s.

[1637] Cour d'appel, 17 décembre 2008, préc. ; Cour d'appel, 23 novembre 2022, n° CAL-2020-01039.

[1638] Cour d'appel, 17 décembre 2008, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

des biens du patrimoine d'un époux à celui de l'autre[1639], etc. Mais les actes à titre onéreux peuvent aussi se traduire par un appauvrissement, dès lors qu'ils sont déséquilibrés au détriment du débiteur (vente d'un bien à bas prix, échange déséquilibré) ou lorsqu'ils ont pour effet de diminuer la valeur du bien (bail de longue durée sur un immeuble, constitution d'une hypothèque, etc.). Cependant, même s'il n'y a pas appauvrissement au sens strict, un acte peut être attaqué par la voie de l'action paulienne s'il est susceptible de de causer un préjudice aux créanciers. La Cour de cassation belge estime justement à cet égard que l'acte peut être attaqué dès lors qu'il constitue une « entrave […] des droits de recours des créanciers »[1640]. Comme le relève P. Van Ommeslaghe, « il ne faut pas établir un bilan comptable théorique du patrimoine du débiteur, mais tenir compte des possibilités réelles d'exécution du créancier »[1641]. Ainsi, la vente d'un immeuble, même à prix normal, peut donner prise à l'action paulienne dès lors qu'elle permet de soustraite aux poursuites des créanciers des biens faciles à saisir, en les remplaçant par de l'argent facile à dissimuler[1642], de même qu'un apport de biens en société en échange d'actions ou de parts plus difficiles à réaliser par les créanciers. Un arrêt de la Cour d'appel admet ainsi la recevabilité d'une action paulienne dirigée contre la vente d'un bien immobilier au motif que cet acte « nuit (au créancier) dès lors qu'il a pour conséquence de faire disparaître du patrimoine du débiteur un bien immobilier facilement saisissable et d'amoindrir les chances de recouvrement du créancier »[1643]. Pour cette même raison, la solution traditionnelle selon laquelle les paiements faits par le débiteur ne sont pas susceptibles d'être attaquées par une action paulienne n'a pas une portée absolue : certes, en payant une dette, le débiteur ne s'appauvrit pas, mais, dans certaines conditions, il peut apparaître que le paiement a été fait pour favoriser certains créanciers au détriment d'autres (paiement d'une dette non échue, dation en paiement, etc.) et alors le paiement peut être attaqué par l'action paulienne. Parmi les actes qui, directement ou indirectement, se traduisent par un appauvrissement du débiteur, l'article 1167 du Code civil met seulement à part les partages, alors même qu'ils seraient déséquilibrés : l'article 882 du Code civil organise en effet

[1639] Cour d'appel, 15 décembre 2021, n° CAL-2021-00140.
[1640] Cass. be., 5 janvier 2006, n° C.04.0607.N, *Pas.* be., 2006, p. 40.
[1641] P. VAN OMMESLAGHE, n° 1536.
[1642] Cass. be., 5 janvier 2006, préc.
[1643] Cour d'appel, 12 juillet 2012, n° 36846.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

une procédure préventive d'opposition, qui permet aux créanciers d'intervenir aux partages mettant en cause leur débiteur pour veiller à ce qu'ils soient équilibrés ; dès lors, ils ne peuvent attaquer par l'action paulienne un partage consommé que si malgré l'opposition le partage s'est déroulé sans eux.

La seconde condition pour que l'action paulienne puisse être exercée est celle qui justifie l'institution, à savoir *la fraude* commise par le débiteur. Cette notion de fraude est entendue largement : tant la jurisprudence belge que la jurisprudence française admettent qu'il n'est pas nécessaire que l'acte ait été passé dans l'intention de nuire aux créanciers ; il suffit que le débiteur ait eu conscience de causer le préjudice à ses créanciers en compromettant leur chance de se faire payer, même si l'acte a été passé principalement à d'autres fins. La Cour de cassation belge pose ainsi que « il suffit de prouver que l'acte ou le payement avait un caractère anormal et que le débiteur a agi en sachant que ses créanciers seraient préjudiciés »[1644]. La Cour de cassation française, elle, se contente de « la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité »[1645]. Cette interprétation est reproduite par la doctrine au Luxembourg[1646]. Par exemple, si je fais une donation à mes enfants, c'est sans doute, à titre principal, pour les mettre à l'abri du besoin ou pour leur permettre de s'installer dans la vie, et pas pour nuire à mes créanciers, mais, si je fais cette donation à un moment où je suis criblé de dettes, je sais très bien que cela va empêcher mes créanciers de se payer, et la donation sera considérée comme frauduleuse. Le caractère anormal, donc frauduleux de l'acte attaqué, s'apprécie en fonction des circonstances (caractère plus ou moins déséquilibré de l'acte, moment où il a été fait, personnes avec qui le contrat a été passé, etc.).

La fraude doit, au minimum, émaner du débiteur lui-même. Mais faut-il aussi que le tiers avec qui l'acte a été passé ait eu conscience de la fraude ? Selon une jurisprudence constante, il faut ici distinguer selon que l'acte est à titre gratuit ou onéreux[1647]. Dans le premier cas, l'acte pourra être attaqué même si le donataire était de bonne foi, car, n'ayant pas versé de contrepartie, l'anéantissement de l'acte

[1644] Cass. be., 15 mars 1985, *Pas.*, 1985, I, p. 875.
[1645] Cass. fr., 14 février 1995, n° 92-18886.
[1646] Poelmans, n° 238.
[1647] Cour d'appel, 17 décembre 2008, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ne sera pas trop dommageable pour lui. Dans le second, on exigera que l'acquéreur ait été complice de la fraude, car l'anéantissement de l'acte le privera d'un bien pour lequel il aura versé une contrepartie qu'il aura sans doute beaucoup de mal à récupérer. Il en ira de même si ce tiers a revendu le bien à un sous-acquéreur : pour récupérer le bien, le créancier devra prouver aussi que le sous-acquéreur a été complice de la fraude[1648]. Le nouveau texte belge précise à cet égard que l'action « ne peut pas porter atteinte à la protection du tiers acquéreur ».

732. Conditions relatives au débiteur. L'exigence générale d'un intérêt à agir chez le créancier, donc d'un préjudice à lui causé par l'acte attaqué, impose que l'action paulienne (tout comme d'ailleurs en principe l'action oblique) ne puisse être exercée que si le débiteur est insolvable : si le débiteur a d'autres biens sur lesquels le créancier peut se payer, il est inutile de faire tomber les actes qui ont fait sortir des biens du patrimoine[1649]. Cette condition d'insolvabilité s'apprécie au moment où l'action est exercée : peu importe que, au moment où l'acte a été passé, le débiteur ait été insolvable, et qu'il n'ait passé l'acte que pour cette raison, dès lors qu'ensuite il est revenu à meilleure fortune.

Cette exigence d'insolvabilité n'est cependant pas requise lorsque, comme l'admet la jurisprudence française, le créancier utilise l'action paulienne pour sauvegarder, non pas son droit de gage général, mais un droit particulier qu'il a sur tel ou tel bien du débiteur : il en va ainsi par exemple du débiteur qui, ayant conféré une hypothèque sur un de ses immeubles, passe un acte qui réduit considérablement la valeur de cet immeuble en le donnant à bail pour une longue durée[1650]. Même si le débiteur a d'autres biens par ailleurs, l'acte porte atteinte au droit spécial du créancier hypothécaire. Il s'agit là d'une utilisation particulière de l'action paulienne, que la formule très générale de l'article 1167 du Code civil permet[1651], et que la jurisprudence luxembourgeoise admet également[1652]

733. Conditions relatives au créancier. Il est admis de manière constante en jurisprudence que seuls peuvent exercer l'action paulienne les créanciers qui avaient déjà une créance au moment où le débiteur a passé l'acte suspecté de fraude[1653]. Cette exigence s'explique aisément : le débiteur n'a pu vouloir frauder que les droits

[1648] Cour d'appel, 4 juillet 2007, *Pas.*, 33, p 573.

[1649] Trib. Luxembourg, 13 mai 2002, n° 68119, *BIJ*, 2002, p. 2.

[1650] Cass. fr. (1re civ.), 18 juillet 1995, n° 93-13681.

[1651] Dans ce sens FLOUR, AUBERT, SAVAUX, ANDREU, FORTI 2022, n° 24.

[1652] Trib. Luxembourg, 13 novembre 2020, n° TAL-2018-07485.

[1653] Cass. fr. (comm.), 14 mai 1952, *D.*, 1953, p. 625 ; Cass. be., 23 mars 1956, *Pas. be.*, 1956, I, p. 783.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

des créanciers dont il était déjà débiteur, il ne pouvait pas avoir l'intention ou la conscience de porter atteinte aux droits de personnes à qui il ne devait rien encore. Cette explication dicte cependant la portée de la règle : aux créances existantes au moment de l'acte, il faut assimiler celles qui n'existaient pas encore, mais dont le débiteur savait qu'il allait être tenu. Par exemple si, ayant accepté de cautionner envers une banque toutes les dettes de ma société, et sachant que cette société est en grandes difficultés, de sorte que c'est probablement à moi que la banque va demander le paiement dans les mois qui vont suivre, je me dépêche de « mettre à l'abri » ma maison en la donnant à un proche, la banque pourra attaquer cette donation par l'action paulienne. Il faut seulement que le créancier puisse établir, selon la Cour de cassation française, qu'il avait, avant l'acte contesté, une « créance certaine dans son principe »[1654], ou, selon la Cour de cassation belge « que le fondement de la créance existe au moment où l'acte critiqué est posé »[1655]. *A fortiori* n'est-il pas nécessaire, que, au moment de l'acte, le créancier ait eu une créance liquide et exigible. Là encore, la jurisprudence luxembourgeoise suit fidèlement ces solutions[1656].

Ces conditions deviennent en revanche nécessaires au moment où le créancier exerce l'action paulienne[1657]. Si la créance n'est pas encore exigible, le créancier ne peut pas en effet justifier d'un préjudice, car il n'est pas exclu que le débiteur redevienne solvable à ce moment-là. Comme pour l'action oblique, la solution est plus discutée en ce qui concerne la liquidité de la créance. Il est certain en tout cas que le créancier n'a pas besoin d'avoir un titre exécutoire, dès lors que l'action paulienne n'est pas une mesure d'exécution[1658].

b. *Effets de l'action paulienne*

734. Inopposabilité de l'acte attaqué. En dépit d'un certain flottement dans la terminologie des arrêts, il est aujourd'hui bien admis, dans les trois pays du Code civil, que l'action paulienne n'est pas une action en nullité de l'acte, mais simplement en inopposabilité. La Cour de cassation française le rappelle clairement dans un arrêt

[1654] Voy. p. ex. : Cass. fr. (comm.), 12 juillet 1994, n° 92-14483.
[1655] Cass. be., 20 mars 2008, n° F.07.0027.N, *Pas. be.*, 2008, p. 776.
[1656] Cour d'appel, 15 mars 2012, n°s 36552 et 36576.
[1657] Cour d'appel, 3 octobre 2018, n° 44580 ; Trib. Luxembourg, 24 octobre 2023, n° TAL-2022-05123.
[1658] Flour, Aubert, Savaux, Andreu, Forti 2022, n° 25 ; Van Ommeslaghe, n° 1535.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

récent : « l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin de restaurer son droit de gage général sur l'objet de cette aliénation, en l'autorisant à le saisir entre les mains du tiers »[1659]. Cette qualification a des conséquences importantes. D'une part, l'acte attaqué reste valable entre les parties : le tiers évincé de la propriété du bien qui lui a été transmis frauduleusement peut donc agir contre son cocontractant sur le fondement de la responsabilité contractuelle. D'autre part, et surtout, à la différence de l'action oblique, l'action paulienne ne profite qu'à celui qui l'exerce : si l'acte lui est inopposable, il reste opposable aux autres, qui ne pourront donc pas saisir le bien objet de l'acte attaqué. Le créancier exerçant l'action paulienne se trouve donc placé par rapport à ce bien dans une situation qui lui est exceptionnellement favorable.

Le fondement de cette inopposabilité est discuté. En Belgique, la Cour de cassation, suivant l'opinion de De Page, a jugé que l'action paulienne constitue une variété particulière d'action en responsabilité civile, l'inopposabilité étant une réparation en nature du préjudice subi par le créancier[1660]. Il en résulte que l'action est soumise à la prescription particulière des actions en responsabilité civile. La question n'a pas d'intérêt au Luxembourg où une telle règle spécifique de prescription n'existe pas. Mais on peut noter que, à l'occasion, l'action paulienne devient franchement une action en responsabilité : si le tiers complice de la fraude a détruit ou revendu le bien qui lui a été transmis par l'acte attaqué, et que la mauvaise foi du sous-acquéreur ne peut être prouvée, le créancier ne peut alors demander à l'acquéreur que des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il subit[1661].

§ 2. L'exécution forcée des obligations non monétaires

735. Problématique. Lorsque l'obligation qui n'est pas exécutée n'a pas pour objet le paiement d'une somme d'argent, son exécution contre le gré du débiteur paraît, d'emblée, plus difficile que lorsque c'est une somme qui n'a pas été payée. Les moyens mis

[1659] Cass. fr. (1re civ.), 9 avril 2014, n° 12-23022 – En droit belge, voy. p. ex. : Cass. be., 9 février 2006, n° C.02.0074.N.

[1660] Cass. be., 26 avril 2012, n° C.11.0142.N.

[1661] Cour d'appel, 4 juillet 2007, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

en œuvre pour obtenir le paiement d'une somme – la vente forcée des biens du débiteur et la distribution de leur prix aux créanciers – sont évidemment sans intérêt lorsqu'il s'agit d'obtenir la livraison d'une chose, la construction d'une maison, la réparation d'une voiture ou la cessation d'activités concurrentes. À l'évidence, il n'est pas toujours possible de contraindre le débiteur à exécuter de telles obligations, et, même lorsque c'est possible, ce n'est pas nécessairement souhaitable.

Qu'une telle exécution forcée ne soit pas toujours possible, de nombreux exemples permettent de le montrer. Certes, on peut imaginer que, si le vendeur ne livre pas un bien à l'acheteur, on envoie un huissier, et éventuellement les représentants de la force publique chez ce vendeur pour lui prendre de force la chose et la remettre à l'acheteur : ce n'est pas au fond si différent de ce qui se passe lorsqu'on procède à la saisie des meubles d'un débiteur de somme d'argent, et qu'on les enlève de chez lui pour les faire vendre. Mais, dans de nombreux cas, l'exécution des obligations non monétaires suppose la participation personnelle du débiteur, et dans de tels cas, aucune contrainte directe ne peut s'envisager : on ne peut guère concevoir, par exemple, qu'un entrepreneur qui ne fait pas les travaux qu'il a promis soit amené par des policiers armés sur le chantier, et qu'il soit contraint de les faire avec une arme dans le dos. À vrai dire, ce n'est pas techniquement impossible – et ce type de contrainte peut exister à l'encontre de coupables d'infraction pénale – mais, dans nos conceptions modernes, il est difficile d'admettre une telle atteinte à la liberté dans le cadre d'engagements purement privés. Du reste, d'un point de vue plus utilitaire, on pourrait craindre qu'une telle exécution sous la contrainte ne soit guère efficace, et que la prestation accomplie sous la contrainte ne soit bâclée ou mal faite. Tout ce qui paraît possible, dans ces hypothèses, c'est qu'on puisse condamner l'entrepreneur à exécuter les travaux, sous la menace de sanctions pécuniaires s'il ne les fait pas en temps utile. Mais, si cette contrainte indirecte échoue, il n'y aura pas d'autres solutions que de condamner le débiteur au paiement de dommages et intérêts, l'obligation étant alors en quelque sorte convertie en obligation monétaire, qui, elle, pourra donner lieu à une exécution forcée selon les modes précédemment étudiés.

Mais, même si elle est toujours possible, une telle contrainte indirecte n'apparaît pas nécessairement souhaitable, au regard des valeurs véhiculées par le système juridique. Dans les droits de

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

common law, où le contrat apparaît d'abord comme un marché, un échange économique, on n'essaiera même pas, en principe, de condamner le débiteur à exécuter. L'octroi de dommages et intérêts, dans cette logique économique, apparaît comme la sanction normale de l'inexécution, et la *specific performance* (exécution en nature) est regardée comme un remède exceptionnel. L'essentiel paraît être que le créancier, s'il n'obtient pas la prestation attendue, puisse en obtenir l'équivalent monétaire (grâce auquel, dans la majorité des cas, il pourra se procurer ailleurs le bien ou le service attendu). Du côté du débiteur, en outre, dans une certaine conception d'économie du droit, il paraît acceptable qu'un contractant se refuse d'exécuter en nature s'il est plus avantageux pour lui de payer des dommages et intérêts que de tenir son engagement – c'est ce qu'on nomme *l'efficient breach of contract.* Les droits d'Europe continentale, spécialement dans les pays du Code civil, ont traditionnellement une conception radicalement différente du contrat, qui est vu, non comme un marché, mais comme un échange de promesses fondé sur des libres volontés. Dans cette conception, chaque contractant doit tenir sa promesse, quoi qu'il lui en coûte et quel que soit l'intérêt que cette exécution présente pour l'autre, et l'idée de tolérer ou d'encourager *l'efficient breach of contract* parait inacceptable. En cas d'inexécution, la condamnation à l'exécution en nature paraît être la solution normale, une conséquence en quelque sorte naturelle de la force obligatoire du contrat, et elle ne sera écartée que de manière exceptionnelle.

Face à cette différence de conception – qui constitue un des traits les plus marquants de la différence entre les droits de *common law* et de *civil law* en matière contractuelle, les textes internationaux et les projets européens ont adopté des solutions intermédiaires. S'ils affirment en principe le droit à l'exécution en nature des obligations, qu'elles aient un objet monétaire ou non monétaire, ces textes posent des limites importantes à ce droit, lorsque les difficultés ou le coût de l'exécution en nature pour le débiteur apparaissent hors de proportion par rapport à l'avantage qu'en tirerait le créancier. Ce type de limites, où on reconnaît une certaine influence du *common law* et de sa logique d'efficacité économique, pénètrent progressivement les droits d'Europe continentale et en particulier des pays du Code civil.

736. Solutions dans les pays du Code civil. De prime abord, la lecture du Code civil pourrait laisser croire que les rédacteurs du Code se sont inscrits dans la logique de *common law* de refus de la

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

specific performance. L'article 1142 du Code civil – texte issu de la rédaction de 1804 – pose en effet que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ». Le texte semble donc indiquer que, pour ces obligations, l'exécution forcée en nature est exclue, et que seule l'exécution par équivalent est possible. En réalité il n'en est rien. Ce texte, cependant, est un véritable trompe-l'œil, et son interprétation par la doctrine et par la jurisprudence est sans doute l'exemple le plus caractéristique du décalage (fâcheux) qui existait jusqu'à une période récente dans les pays du Code civil, et qui existe encore au Luxembourg, entre le droit écrit et le droit effectivement applicable. La jurisprudence, dans les trois pays, a en effet complètement renversé le principe de l'article 1142 du Code civil, en permettant, par principe, au créancier d'exiger l'exécution de son obligation par le débiteur et cette solution est aujourd'hui consacrée dans le code en France et en Belgique (**A**). Par ailleurs, le Code lui-même a assorti le principe de l'article 1142 du Code civil d'exceptions dans les cas où l'exécution peut être obtenue d'un tiers (**B**).

A) *L'exécution par le débiteur*

737. Article 1142 du Code civil versus article 1184 du Code civil. Dans le Code civil luxembourgeois, l'article 1142 semble entrer en contradiction avec un autre texte, déjà rencontré, l'article 1184. En effet, alors que l'article 1142 du Code civil semble exclure l'exécution forcée en nature pour les obligations de faire ou de ne pas faire, l'article 1184 du Code civil, relatif à la résolution, permet, lui, au contractant victime de l'inexécution dans un contrat synallagmatique, au lieu de demander la résolution de « forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ». On aurait pu, à vrai dire, concilier ces deux textes à partir de la formule « lorsqu'elle est possible », en disant que, justement, l'exécution en nature n'est pas possible chaque fois que l'obligation est de faire ou de ne pas faire – ce qui aurait largement vidé de sa substance l'article 1184 du Code civil, l'option n'étant alors ouverte que pour les seules obligations monétaires. Telle n'est pas l'interprétation qui a été retenue. Tout au contraire, la jurisprudence, dans les trois pays du Code civil, a fait prévaloir l'article 1184 du Code civil pour affirmer un véritable droit à l'exécution en nature, même pour les obligations de faire ou de ne pas faire, ce qui a abouti à neutraliser l'article 1142 du Code

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

civil, ou du moins à en réduire considérablement le domaine d'application. Pour comprendre l'état du droit luxembourgeois – qui suit ici complètement les solutions françaises et belges antérieures aux reformes – il nous apparaît utile de nous inspirer de la présentation faite en droit belge par P. Wery, qui est aujourd'hui consacrée par l'article 5.234 du nouveau Code civil belge. Cet auteur distingue, très justement à notre sens, deux questions, qui correspondent à deux stades du litige entre le créancier et le débiteur. Dans un premier temps, qui correspond au procès sur le fond, il faut se demander si le créancier peut demander en justice la condamnation de son débiteur à l'exécution en nature : la réponse est en principe positive, l'article 1184 du Code civil primant alors sur l'article 1142 du Code civil (**1**). Mais, dans un deuxième temps, il faudra se demander comment cette condamnation à l'exécution pourra elle-même être mise à exécution, comment on pourra effectivement contraindre le débiteur à faire ce qu'il ne veut pas faire ou à ne pas faire ce qu'il veut faire : c'est à ce stade que l'article 1142 du Code civil retrouvera son empire (**2**)[1662].

1) *La condamnation à l'exécution*

738. Renversement du principe. Victime de l'inexécution, le créancier agit contre son débiteur pour le faire condamner à exécuter. Le tribunal va-t-il lui répondre par un refus, en lui disant : selon l'article 1142 du Code civil, vous n'avez droit qu'à des dommages et intérêts ? Certainement pas : en principe, à l'opposé de ce que dit le texte, le juge peut, et même doit, faire droit à cette demande d'exécution. Ce renversement du principe, bien acquis depuis longtemps dans les jurisprudences française et belge, s'observe aussi au Luxembourg où la Cour d'appel a posé que « l'article 1142 du Code civil, qui dit que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur, doit s'interpréter dans le sens que le créancier d'une telle obligation a en principe toujours le droit de réclamer l'exécution en nature chaque fois du moins qu'il y a possibilité de l'imposer et qu'il ne doit pas se contenter de dommages et intérêts, c'est-à-dire

[1662] Cette distinction a été élaborée par P. Wéry dans sa thèse consacrée à l'exécution forcée : P. WÉRY, *L'exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires. Une relecture des articles 1142 à 1144 du Code civil*, préf. I. MOREAU-MARGREVE, Bruxelles, Kluwer, 1993. On la retrouve dans le manuel de droit des obligations de l'auteur : WÉRY, n°s 497 et s. On ne partagera pas nécessairement l'opinion de l'auteur en ce qu'il estime que cette distinction traduit la pensée des rédacteurs du code. Mais elle nous paraît rendre parfaitement compte de l'état du droit positif dans les pays du Code civil.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

d'une satisfaction par équivalent, que lorsqu'une exécution en nature est impossible à lui procurer »[1663]. Cette primauté de l'exécution en nature est aujourd'hui consacrée, avec certaines limites, dans les nouveaux textes belges et français. L'article 1221 du Code civil français dispose que « [l]e créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier », tandis que, selon l'article 5.234 du nouveau Code civil belge : « Le créancier a le droit de demander en justice l'exécution de la prestation due, sauf si cela s'avère impossible ou abusif. » Ce principe, dont il faut bien mesurer la portée (**a**), connaît cependant, comme les nouveaux textes français et belge le montrent, certaines limites (**b**).

a. *Principe de la primauté de l'exécution en nature*

739. Fondements. Dans la rédaction originaire des textes du Code civil (toujours en vigueur au Luxembourg), cette primauté de l'exécution en nature peut s'appuyer sur l'article 1184 du Code civil, qui permet au créancier de forcer le débiteur à l'exécution et c'est d'ailleurs sur ce texte que se fondent nombre de décisions[1664]. Plus fondamentalement, on y voit habituellement, dans les pays du Code civil, une conséquence directe du principe de la force obligatoire (ou en Belgique de la convention-loi). « La primauté de l'exécution en nature, écrit ainsi P. Wery, consacre de manière éclatante un principe fondamental du droit des contrats, celui de la convention-loi »[1665]. Cela n'est vrai, cependant, que dans une certaine conception, en quelque sorte morale, de ce principe, qui met en avant le respect de la parole donnée. Mais, comme l'a fait remarquer en France l'auteur d'une thèse comparative consacrée aux sanctions de l'inexécution, ce n'est qu'une conception parmi d'autres[1666]. En *common law*, où on considère que l'exécution en nature ne doit être prononcée qu'à titre exceptionnel, le contrat n'est pas moins obligatoire qu'en France ou au Luxembourg, mais la préférence pour une sanction pécuniaire (exécution par équivalent) s'explique par le fait que cette force obligatoire est fondée sur des considérations plus

[1663] Cour d'appel, 11 janvier 1984, *Pas.*, 26, p. 139.

[1664] Voy. ainsi récemment Cour d'appel, 7 mai 2014, n° 39248.

[1665] WÉRY, n° 504.

[1666] Y.-M. LAITHIER, *Étude comparative des sanctions de l'inexécution du contrat*, préf. H. MUIR-WATT, Paris, LGDJ, 2004.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

économiques que morales. Même si on n'a pas forcément envie d'importer cette conception, il est toujours bon de se rappeler que les solutions qui nous semblent les plus « naturelles » peuvent être très relatives. Quoi qu'il en soit, cette primauté, typique des droits civilistes, se manifeste de deux manières complémentaires, à travers le pouvoir du juge d'ordonner l'exécution en nature, et le droit pour le créancier de l'exiger.

740. Pouvoir du juge d'ordonner l'exécution en nature. La reconnaissance du pouvoir pour le juge de condamner le débiteur à exécuter peut se recommander de l'autorité de Pothier, qui, traitant de l'obligation de faire ou de ne pas faire, écrivait déjà que le créancier devait demander en justice que le débiteur soit condamné à faire ce qu'il a promis, et que « le juge, sur cette demande, prescrit un certain temps dans lequel le débiteur sera tenu de faire ce qu'il a promis »[1667]. Ce pouvoir est devenu tout à fait certain lorsque la jurisprudence, au XIXe siècle en France, a inventé le procédé de l'astreinte – condamnation à une somme d'argent augmentant en fonction du temps que met le débiteur à exécuter[1668]. L'application de ce procédé aux obligations de faire ou de ne pas faire d'origine contractuelle présuppose que le juge peut condamner le débiteur à l'exécution de telles obligations.

Il faut observer que le pouvoir du juge ne lui permet pas seulement d'ordonner au débiteur ce qu'il n'a pas fait, ou de cesser de faire ce qu'il n'a pas le droit de faire. Il peut aussi, dans la mesure où c'est possible, lui ordonner de refaire de manière correcte ce qu'il a mal fait (remettre en état une voiture mal réparée, reprendre des travaux dans une maison mal construite, réparer une chose vendue défectueuse).

Ce pouvoir du juge d'ordonner l'exécution en nature est reconnu par ailleurs même à l'encontre des souhaits du créancier : si le débiteur, mis en demeure, offre d'exécuter en nature, le créancier ne peut pas refuser cette offre et demander des dommages et intérêts[1669]. Ce n'est que si l'offre n'est pas sérieuse, ou si le créancier a légitimement perdu confiance dans la compétence de son contractant, qu'il peut refuser l'exécution en nature[1670].

[1667] R.-J. POTHIER, *Traité*, n° 146.

[1668] Voy. *infra*, n° 746.

[1669] Cass. fr. (3e civ.), 27 mars 2013, n° 12-13734 ; Cour d'appel, 18 décembre 2013, n° 39545.

[1670] Cour d'appel, 12 mars 2003, n° 26828 ; Cour d'appel, 11 juillet 2012, n° 31206 ; Cour d'appel, 18 décembre 2013, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

741. Droit pour le créancier d'exiger l'exécution en nature. En principe, le juge n'a pas seulement la possibilité, il a l'obligation d'ordonner l'exécution dès lors qu'elle lui est demandée. Progressivement, en effet, la jurisprudence en est venue, dans les trois pays, à reconnaître au créancier un véritable droit à l'exécution en nature. En Belgique, la Cour de cassation avait ainsi posé que « l'exécution en nature constitue le mode normal d'exécution forcée tant des obligations de faire que de celles de ne pas faire »[1671]. En France, où il avait été parfois soutenu que le juge avait le choix entre l'exécution en nature et l'exécution par équivalent[1672], la Cour de cassation affirmait de la manière la plus nette que « la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est possible »[1673], et elle n'hésitait pas à casser des décisions qui avaient condamné le débiteur à des dommages et intérêts alors que le créancier demandait l'exécution[1674]. Et c'est bien en termes de « droit à l'exécution » que sont rédigés les nouveaux textes français et belge. Il faut souligner que ce droit de demander l'exécution n'est pas subordonné à l'exigence d'un préjudice subi par le créancier : celui-ci ne demande pas réparation du mal qui lui a été fait, il ne fait qu'exiger ce à quoi il a droit.

La formule précédemment citée de la Cour d'appel du Luxembourg, selon laquelle le créancier « a en principe toujours le droit de réclamer l'exécution en nature chaque fois du moins qu'il y a possibilité de l'imposer et qu'il n'a à se contenter de dommages et intérêts, c'est-à-dire d'une satisfaction par équivalent, que lorsqu'une exécution en nature est impossible à lui procurer »[1675], s'inscrit parfaitement dans cette logique. Dans un jugemeny plus récent, cependant, le Tribunal de Luxembourg, tout en relevant que « la jurisprudence a pu retenir que le créancier d'une obligation de faire a le droit de réclamer l'exécution en nature chaque fois qu'il a la possibilité de l'imposer, sans devoir se contenter de dommages et intérêts, c'est-à-dire une satisfaction par équivalent lorsque l'exécution en nature est impossible »,

[1671] Cass. be., 14 avril 1994, *Pas.*, 1994, I, p. 370. Voy. les très nombreux arrêts cités par WÉRY, n° 504.

[1672] D. TALLON, « Dommages et intérêts et exécution en nature. Quelques observations comparatives entre la *common law* et le droit français », *J.T.*, 1985, p. 602.

[1673] Cass. fr. (1re civ.), 16 janvier 2007, n° 06-13983.

[1674] Cass. fr.(3e civ.), 11 mai 2005, n° 03-21136.

[1675] Cour d'appel, 11 janvier 1984, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pose que « cette solution est contraire au texte de l'article 1142 du Code civil aux termes duquel, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution ». Cette motivation n'est cependant qu'un détour pour juger que l'exécution en nature est « inadaptée en l'espèce », ce qui n'est donc pas une remise en cause de principe du droit à l'exécution en nature[1676].

b. *Limite*

742. Exécution impossible. Il va de soi que la condamnation à l'exécution ne peut être obtenue que si l'exécution est encore matériellement possible. Cette limite figure expressément dans l'article 1184 du Code civil. Elle est reprise, sous sa forme négative, tant par le nouvel article 1221 du Code civil français que par l'article 5. 234 du Code civil belge. Il faut préciser que l'impossibilité qui exclut l'exécution en nature est une notion plus large que la force majeure, qui désigne le cas particulier où l'impossibilité est due un événement imprévisible et irrésistible. La force majeure exclut bien entendu toute exécution en nature, mais celle-ci est pareillement exclue si l'impossibilité est imputable au débiteur (par exemple lorsque, de son fait, l'inexécution est définitivement consommée – sauf à noter que, dans ce cas, le débiteur pourra être condamné à des dommages et intérêts.

743. Obligations strictement personnelles. Ensuite, il est traditionnellement admis que le juge ne peut pas condamner (notamment sous astreinte) le débiteur à exécuter une obligation strictement personnelle. Cette expression est très ambiguë : on comprend parfois par-là les obligations dont l'exécution suppose une participation personnelle du débiteur, mais cela reviendrait à exclure la condamnation à l'exécution pour la grande majorité des obligations de faire. Une telle participation personnelle du débiteur est certes de nature à exclure qu'on puisse contraindre directement le débiteur à exécuter le jugement de condamnation, mais non qu'on puisse, au départ, le condamner à exécuter. Aussi bien la notion ne vise-t-elle que les obligations dont l'exécution met en jeu des aspects intimes de la personnalité de sorte que même une contrainte indirecte (comme la menace d'avoir à payer une astreinte) paraît exclue. La formule du DCFR nous apparaît excellente à cet égard : ce texte exclut l'exécution en nature si « *performance would be of such a personal character that it would be unreasonable to enforce it* ». C'est ainsi

[1676] Trib. Luxembourg, 12 mai 2015, n° 162029.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

que, au début du XXe siècle la Cour de cassation française a refusé, au nom de ce qu'on appelle maintenant le « droit moral de l'auteur sur son œuvre » de condamner le peintre Whistler à achever et à livrer le portrait d'une aristocrate britannique[1677]. Mais la solution ne vaudrait évidemment pas pour un peintre en bâtiment. Cette limite n'est pas reprise par les nouveaux textes en France et en Belgique, mais on peut considérer qu'elle est incluse dans la notion d'impossibilité visée par ces textes. L'article 5.234 du Code civil belge vise le cas où l'exécution « est contraire à la dignité humaine », mais, curieusement le texte ne semble exclure dans ce cas que l'exécution de la condamnation. En réalité, dans ce cas, on n'imagine pas que le juge puisse condamner le débiteur à une telle exécution !

La même idée d'obligation strictement personnelle était parfois avancée pour justifier la jurisprudence française (très contestée) qui, depuis 1993, refusait d'ordonner l'exécution forcée d'une promesse unilatérale de vente[1678] : le promettant, qui se rétractait ne pouvait être condamné qu'à des dommages et intérêts, car, selon certains auteurs, la liberté de contracter ou de ne pas contracter était trop fondamentale pour qu'on puisse obliger quelqu'un, même indirectement, à « consentir » à un acte dont il ne veut pas. Cette solution a trouvé un écho au Grand-Duché dans une jurisprudence – contestée – du tribunal de Luxembourg qui a refusé d'ordonner l'exécution en nature d'un pacte d'actionnaires à l'encontre d'un actionnaire qui avait voté de manière non conforme au pacte[1679]. Il faut bien noter que, dans ces hypothèses, l'exclusion de l'exécution forcée intervient, dès le stade de la décision de condamnation. Ce qui est exclu, ce n'est pas seulement qu'une telle décision puisse être portée à exécution (ce qui, dans le cas de la promesse de vente, pourrait du reste se faire très facilement sans recours à aucune contrainte physique, par le jeu d'une condamnation valant transfert de propriété), c'est ab initio qu'on puisse condamner le débiteur à faire ce qu'il ne veut plus faire. Le problème, cependant, ne se pose plus en droit français, dans la mesure, où, comme on l'a vu, le nouvel article 1124 du Code civil prévoit désormais que « [l]a révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis »[1680].

[1677] Cass. fr. (civ.), 14 mars 1900, *DP*, 1900, 1, 497.
[1678] Voy. *supra*, n° 185.
[1679] Trib. Luxembourg, 5 mars 2009, n°s 114096, 1184701. Voy. les critiques de Poelmans, n° 528.
[1680] Voy. *supra*, n° 186.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

744. Abus ou caractère disproportionné. Même lorsque l'exécution est possible, le droit d'en demander l'exécution devrait, comme tout droit subjectif, céder en cas d'abus de la part du créancier[1681]. Sauf à avoir de la force obligatoire du contrat une conception quasi-mystique, il n'y a en effet pas de raison de considérer, comme la doctrine le pensait au XIX[e] siècle, que le droit à l'exécution en nature est un droit discrétionnaire. Il pourrait notamment y avoir abus si le créancier, après avoir fait croire au débiteur qu'il ne demanderait pas l'exécution, et qu'il se contenterait d'un dédommagement, changeait brutalement d'avis. Surtout, l'abus pourrait être caractérisé, pour reprendre une formule de la Cour de cassation belge « lorsque le titulaire, usant dans son seul intérêt d'un droit qu'elle puise dans la convention […] en retire un avantage disproportionné à la charge corrélative de l'autre partie »[1682]. Cette formule permettrait de repousser la demande d'exécution forcée lorsque le créancier demande une exécution en nature très coûteuse pour le débiteur, alors qu'il n'a subi qu'un préjudice très faible qui pourrait être réparé par l'allocation de dommages et intérêts – même s'il faut noter que, en soi, l'exigence d'un préjudice n'est pas une condition de l'exécution en nature. Les différents projets européens, sans recourir à la notion d'abus de droit, excluent l'exécution en nature des obligations non monétaires si cette exécution « comporte pour le débiteur des efforts ou des dépenses déraisonnables »[1683] ou « si la charge ou les dépenses induites par l'exécution seraient disproportionnées par rapport au bénéfice » que le créancier en retirerait[1684] – formule qui fait directement écho à la définition de l'abus de droit en droit belge. Avant la réforme, cependant, la Cour de cassation française semblait considérer que le droit à l'exécution en nature était un droit absolu. Un exemple caractéristique de cette approche est fourni dans une affaire où un couple avait fait construire une maison qui lui avait été livrée avec une différence de niveau de 33 cm par rapport aux plans ; les époux ne demandaient rien d'autre que la démolition de la maison et sa reconstruction conformément aux plans, ou, à défaut, des dommages et intérêts permettant d'obtenir ce résultat ! La Cour d'appel avait cru pouvoir rejeter cette demande et se contenter d'octroyer des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi. L'arrêt

[1681] Dans ce sens POELMANS, n° 527.
[1682] Cass. be., 19 septembre 1983, *Pas. be.*, 1984, I, p. 55.
[1683] PDEC, art. 9 : 102.
[1684] DCEV, art. 110.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

est cassé au visa de l'article 1184 du Code civil, au motif que le créancier a le droit de demander l'exécution chaque fois qu'elle est possible.[1685]. Il est vrai que, dans cette affaire, le débiteur n'avait pas porté sa défense sur le terrain de l'abus de droit, et on ne sait pas s'il aurait eu gain de cause s'il l'avait fait. La limite de l'abus de droit avait été en tout cas admise en Belgique, où la Cour de cassation avait permis à un juge d'imposer la résolution du contrat à un créancier qui réclamait l'exécution forcée de la convention de manière abusive[1686]. Et cette solution a été consacrée dans l'article 5.234 du nouveau Code civil belge, aux termes duquel « [l]e créancier a le droit de demander en justice l'exécution de la prestation due, sauf si cela s'avère impossible ou abusif ». Rompant avec la jurisprudence antérieure, le nouvel article 1221 du Code civil français exclut quant à lui l'exécution en nature « s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier » – formule dans laquelle certains ont vu la traduction d'une influence pernicieuse de la *common law*, alors qu'on peut y voir simplement une application particulière de la notion d'abus de droit[1687].

La position de la jurisprudence luxembourgeoise sur ce point n'est pas facile à déterminer. Dans un jugement de 2015, à la motivation contestable, le Tribunal de Luxembourg a jugé que l'exécution en nature était « inadaptée » à l'espèce, dans une affaire où le défendeur invoquait le caractère disproportionné de cette exécution (le remplacement d'une plaque non conforme) par rapport au trouble constaté, mais sans faire directement le lien du refus avec cette disproportion[1688]. Plus récemment, la Cour d'appel du Luxembourg a exclu par principe le recours à la notion d'abus de droit pour s'opposer à la destruction d'ouvrages irrégulièrement construits dans une copropriété, dans une affaire où le copropriétaire assigné soutenait que la démolition était demandée « dans la seule intention de nuire, le coût des travaux à entreprendre étant disproportionné par rapport à l'empiétement commis qui ne serait que de quelques 2,5 m² et non de 3,5 m² »[1689]. Cependant l'arrêt n'est peut-être pas caractéristique, dans la mesure où la solution est fondée sur la disposition spécifique de l'article 1143 ainsi que sur les règles applicables en

[1685] Cass. fr. (3e civ.), 11 mai 2005, préc.
[1686] Cass. be., 16 janvier 1986, *Pas. be.*, 1986, I, p. 602.
[1687] Dans ce sens Fages 2023, n° 298.
[1688] Trib. Luxembourg, 12 mai 2015, n° 162029.
[1689] Cour d'appel, 6 mars 2019, n° 44576.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

matière de copropriété. C'est plus ici le caractère discrétionnaire du droit de refuser l'empiètement que celui du droit à l'exécution forcée qui est en cause. En dehors d'hypothèses particulières, on ne voit pas pourquoi le droit d'exiger l'exécution serait insusceptible d'abus, dans un système juridique où l'abus de droit est sanctionné par un texte spécial du Code civil. Le tribunal de Luxembourg a du reste admis que, pour une obligation monétaire, le droit de poursuivre l'exécution plutôt que demander la résolution du contrat est susceptible d'abus[1690], ce qui manifeste une volonté des juges d'exercer un contrôle sur la manière dont le créancier met en œuvre les sanctions de l'inexécution.

On notera d'ailleurs que cette idée apparaît en législation, à travers la hiérarchisation des remèdes en cas de non-conformité d'un bien vendu à un consommateur : l'article L. 212-5 du Code de la consommation, issu de la transposition de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation[1691], permet à l'acheteur d'un bien défectueux ou non conforme de demander la réparation ou le remplacement de ce bien (ce qu'on peut considérer comme une forme d'exécution en nature) ; mais cette option ne lui est ouverte que « sauf impossibilité ou disproportion » et « à moins que l'une de ces solutions ne constitue par rapport à l'autre une charge excessive pour le professionnel. Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s'il impose au professionnel des coûts qui, par rapport à l'autre mode, sont déraisonnables compte tenu : – de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas défaut de conformité, – de l'importance du défaut de conformité et – de la question de savoir si l'autre mode de dédommagement peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur ».

2) *L'exécution de la condamnation*

745. ***Nemo precise cogi ad factum.*** Ce n'est pas tout pour le créancier d'avoir obtenu la condamnation de son débiteur à exécuter. Encore faut-il savoir si et comment le débiteur pourra être contraint à exécuter ce à quoi il a été condamné. C'est à ce stade que l'article 1142 du Code civil prend tout son sens dans le droit moderne : d'une manière générale, en effet, le débiteur ne pourra être contraint directement à exécuter, dès lors que cela supposerait une contrainte physique sur sa personne. Or, comme le dit un ancien adage dont l'article 1142 du Code civil paraît être une traduction : *Nemo precise cogi ad factum* (on ne peut forcer quelqu'un à faire quelque chose). L'article 5.234 du nouveau Code

[1690] Trib. Luxembourg, 8 mai 2012, n° 142959, qui relève que le choix d'un bailleur d'exiger le paiement des loyers jusqu'au terme du bail plutôt que d'en demander la résolution « procurerait au bailleur un avantage disproportionné par rapport aux inconvénients que subit son locataire ».

[1691] *J.O.C.E.*, L. 171, 7 juillet 1999.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

civil belge marque bien que, même si le créancier a le droit de demander l'exécution en nature, « une condamnation qui ne tend pas au paiement d'une somme d'argent ne peut être exécutée lorsqu'elle requiert nécessairement le recours à la contrainte sur la personne du débiteur ». On ne peut donc, ici recourir qu'à une contrainte indirecte, à des moyens de pression, et s'ils échouent, alors, par la force des choses, l'obligation de faire ou de ne pas faire se « résoudra en dommages et intérêts » (**a**). Dans certains cas, cependant, il est possible de recourir à une contrainte directe, soit parce que cela peut se faire sans contrainte physique, soit parce que la loi l'autorise (**b**).

a. *Principe : contrainte indirecte*

746. Astreinte. Pour tenter de contraindre le débiteur condamné à satisfaire effectivement à sa condamnation, la jurisprudence, au XIXe siècle, a inventé le mécanisme de l'astreinte : dans son jugement de condamnation, le tribunal prévoit que le débiteur devra payer une certaine somme d'argent qui augmentera régulièrement en fonction du temps qu'il mettra à exécuter. Selon la nature de l'obligation, la difficulté plus ou moins grande qu'il y a à l'exécuter, l'urgence que cette exécution présente pour le créancier, la périodicité d'augmentation peut être plus ou moins rapprochée : par heure, par jour, par semaine, par mois de retard. Cette technique, dont on trouve trace dans la jurisprudence luxembourgeoise au moins dès le début du XXe siècle[1692], a été introduite dans le Code civil du Luxembourg, aux articles 2059 à 2066, par un acte Benelux de 1976. Il s'agit donc d'une réglementation commune au Luxembourg, à la Belgique et aux Pays-Bas, qui s'éloigne sur plusieurs points du droit français. Son interprétation relève certes au premier chef des juridictions nationales de chaque pays, mais elle doit, en cas de doute, être soumise par la voie d'une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux.

Un arrêt de la Cour d'appel précise parfaitement la nature du mécanisme de l'astreinte : « L'astreinte est définie comme un moyen de coercition, imposé par le juge à la partie condamnée pour l'inciter à exécuter la condamnation principale ; l'astreinte est un procédé indirect permettant de contraindre à la prestation due qui peut consister en une obligation de faire, de ne pas faire

[1692] J.P. Redange, 30 mars 1911, *Pas.*, 08, p. 228.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ou de donner. L'astreinte n'a aucun caractère indemnitaire ni dans son principe ni dans son montant. Elle n'est pas une condamnation à une indemnité, mais une mesure de contrainte. Étant prononcée "sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu" (article 2059, alinéa 1er), elle est cumulable avec des dommages et intérêts ».

Cet attendu souligne le caractère essentiel de l'astreinte : c'est un moyen de pression, qui n'a aucun caractère indemnitaire. Il ne faut surtout pas la confondre avec les dommages et intérêts auxquels le débiteur sera éventuellement condamné pour réparer le préjudice causé au créancier par son retard ou, s'il n'exécute pas, par son inexécution définitive. Pour cette raison, la somme que devra payer le débiteur au titre de l'astreinte pourra se cumuler avec les dommages et intérêts.

Si l'étude détaillée de l'astreinte relève du droit judiciaire privé, il faut signaler ici les principaux éléments de son régime[1693]. L'astreinte n'est pas une mesure spécifique du droit des contrats, elle peut assortir l'exécution de n'importe quelle obligation, contractuelle ou non, ayant donné lieu à une condamnation par décision de justice : par exemple, un commerçant qui ouvre un magasin en contravention avec la réglementation des heures d'ouverture des commerces peut être condamné, sous astreinte, à le fermer sous peine de x € par jour de contravention. La seule limite, posée par l'article 2059 du Code civil, est que l'astreinte ne peut pas assortir une condamnation au paiement d'une somme d'argent, pour laquelle elle n'aurait du reste guère d'intérêt. L'astreinte peut être prononcée par toutes les juridictions civiles et commerciales, y compris, selon l'article 940 du Nouveau Code de procédure civile, par le juge des référés. Cette condamnation peut avoir deux issues, soit que le débiteur exécute, soit qu'il refuse de céder, et que le créancier, lassé d'attendre se décide à se contenter de dommages et intérêts. Dans les deux cas, il faudra liquider l'astreinte, c'est-à-dire calculer le montant que devra payer le débiteur en fonction du temps qu'il aura mis à exécuter. Contrairement à ce qui est prévu en France, où on distingue les astreintes provisoires et définitives, le juge n'a aucun moyen, à ce moment, de modérer le montant de l'astreinte, et le débiteur devra payer l'intégralité des sommes dues : toute

[1693] Pour une étude plus détaillée, voy. M. THEWES, « L'astreinte en droit luxembourgeois », *Ann. dr. lux.*, 1999, pp. 119 et s.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

astreinte, au Benelux, est définitive (C. civ., art. 2062). Le juge n'a le pouvoir de modifier le montant initialement fixé que si le débiteur se trouve placé momentanément ou définitivement dans l'impossibilité d'exécuter : il peut alors suspendre le paiement ou y mettre fin.

Selon que le débiteur se décide ou non finalement à exécuter, le créancier aura droit, en plus de l'astreinte liquidée, à des dommages et intérêts, mais qui n'ont pas la même fonction dans l'un et l'autre cas.

747. Dommages et intérêts de substitution. Si le débiteur condamné à exécuter en nature se décide finalement à le faire, le créancier pourra obtenir, en plus de l'astreinte liquidée, des dommages et intérêts compensant le préjudice que lui a causé le retard dans l'exécution. C'est là le jeu normal de la responsabilité contractuelle. Si, en revanche, aucune exécution n'intervient, le créancier devra bien se résoudre, à un moment donné, à demander à la place des dommages et intérêts. Il est d'ailleurs fréquent qu'il les demande dès le départ, pour le cas où le débiteur ne satisferait pas à son engagement : la décision de condamnation à l'exécution peut alors fixer un certain délai au débiteur pour s'exécuter (généralement sous astreinte) et prévoir du même coup le montant des dommages et intérêts qui seront dus en cas d'inexécution définitive. Si ce n'est pas le cas, le créancier lassé d'attendre l'exécution, devra ressaisir le juge à la fois pour liquider l'astreinte et pour obtenir des dommages et intérêts de substitution. C'est là où on voit jouer l'article 1142 du Code civil : l'obligation de faire ou de ne pas faire inexécutée se « résout » en dommages et intérêts. Ces dommages et intérêts de l'article 1142 du Code civil ne s'inscrivent pas dans le jeu habituel de la responsabilité contractuelle : ils ne visent pas à réparer un préjudice subi par le créancier, ils visent seulement à procurer au créancier l'équivalent de la prestation qu'il attendait du contrat. Ils sont du reste calculés en fonction de cet objectif : ainsi dans l'affaire déjà citée de la maison non conforme aux plans, les maîtres de l'ouvrage demandaient que l'entrepreneur soit condamné à démolir et à reconstruire, ou, à défaut, à ce qu'il leur verse une somme d'argent leur permettant de financer cette démolition et cette reconstruction. On est ici en présence, non pas d'une réparation – fonction normale de la responsabilité civile – mais d'une forme d'exécution par équivalent qui, pas plus

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

que l'exécution en nature n'est subordonnée à la preuve d'un préjudice particulier subi par le créancier, mais elle devrait connaître la même limite de l'abus[1694].

C'est à partir de l'article 1142 du Code civil, du reste, qu'un important courant doctrinal français a soutenu que, d'une manière générale, les dommages et intérêts contractuels ne reposaient pas sur une véritable responsabilité du débiteur défaillant, mais qu'ils étaient une forme d'exécution du contrat. Cette conception correspond bien à ce qui se produit dans les hypothèses examinées, où le débiteur, condamné à exécuter en nature, se refuse à le faire alors que l'exécution est encore possible : il devra alors exécuter par équivalent. Mais dans tous les autres cas, les dommages et intérêts semblent bien plutôt avoir une fonction de réparation du préjudice : qu'il s'agisse de réparer le préjudice causé par le retard, par l'inexécution d'une prestation devenue définitivement impossible, ou par la mauvaise exécution d'une prestation. Ces dommages et intérêts s'inscrivent alors dans la même logique que celle de la responsabilité civile extracontractuelle.

b. *Limites : cas de contrainte directe*

748. Cas où la contrainte physique est autorisée. Le mécanisme d'exécution par équivalent de l'article 1142 du Code civil s'explique par l'impossibilité de recourir à la contrainte physique pour amener le débiteur à exécuter contre son gré. Exceptionnellement, cependant, la loi peut autoriser un tel recours à la contrainte sur la personne. Il en va ainsi en matière d'expulsion, où, après la résiliation du bail, la loi du 21 septembre 2006 [art. 12 (3)], permet au juge d'ordonner le « déguerpissement forcé » du locataire. Cette expulsion s'opère au besoin avec le concours de la force publique. Cependant, il n'y a pas vraiment de contrainte corporelle : l'expulsion consiste essentiellement à sortir les meubles du locataire, rendant impossible l'occupation des lieux[1695].

749. Cas où la contrainte physique est inutile. L'exécution par équivalent n'a pas lieu d'être non plus lorsqu'on peut arriver au résultat recherché sans avoir besoin de faire intervenir personnellement le débiteur. Il en va ainsi lorsqu'un contractant se refuse à passer un acte authentique nécessaire à l'accomplissement de sa promesse – notamment lorsque, à la suite d'une promesse synallagmatique de vente (compromis de vente), l'un des deux contractants refuse

[1694] Comp. en droit français, Cass fr. (3e civ.), 6 juillet 2023, n° 22-10.884, qui juge que le contrôle de proportionnalité prévu par l'article 1221 C. civ. fr. doit s'appliquer aussi lorsque le créancier, au lieu de demander l'exécution en nature, demande directement des dommages et intérêts lui permettant d'en financer le coût.

[1695] Sur la gestion des meubles du locataire expulsé, voy. L. 21 septembre 2006, art. 29 et 30.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

de passer le contrat de vente authentique qui opérera transfert de propriété. Dans un tel cas, il est admis que le jugement de condamnation peut valoir acte authentique et opérer transfert de propriété. La solution est souvent rattachée au fait que, dans un tel cas, l'obligation à exécuter n'est pas une obligation de faire, mais une obligation de donner, laquelle n'est précisément pas visée par l'article 1142 du Code civil, et les partisans du maintien dans le droit moderne de ce type d'obligations utilisent très souvent cet argument pour en montrer l'utilité. Cette explication est contestable. D'une part, l'obligation dont le jugement vaudra exécution n'est pas, directement, celle de transférer la propriété, c'est l'obligation de passer l'acte authentique à laquelle les parties ont attaché l'effet translatif de propriété, donc une simple obligation de faire. D'autre part et surtout, le mécanisme décrit ne vaut pas seulement lorsque c'est le vendeur, tenu de la prétendue « obligation de donner » qui est défaillant, mais aussi lorsque c'est l'acheteur qui se refuse à passer l'acte ; or cet acheteur ne peut évidemment être regardé comme un débiteur de l'obligation de donner, dont il est, au contraire, créancier.

C'est aussi l'inutilité d'une contrainte sur la personne du débiteur qui explique les exceptions que le Code civil apporte à l'article 1142 lorsque l'exécution peut être accomplie, non par le débiteur lui-même, mais par le créancier lui-même ou par un tiers.

B) *L'exécution par un tiers ou par le créancier*

750. Principe. Dans certains cas, le créancier pourra obtenir satisfaction en faisant lui-même ce qu'il attendait du débiteur ou en faisant intervenir un tiers qui effectuera la prestation à la place du débiteur. Il sera alors inutile de passer par la procédure précédente (condamnation du débiteur à exécuter, assortie d'une astreinte, débouchant éventuellement sur des dommages et intérêts de substitution). Cette exécution par un tiers est prévue par le Code civil aux articles 1143 et 1144, qui sont présentés comme des exceptions au principe de l'article 1142 du Code civil, mais qui, dès lors que le principe posé par ce texte a été renversé, apparaissent aujourd'hui comme des applications particulières du droit à l'exécution en nature.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

1) *L'article 1143 du Code civil*

751. Destruction de ce qui a été fait. L'article 1143 du Code civil s'applique lorsque l'obligation inexécutée était une obligation de ne pas faire, notamment l'obligation de ne pas réaliser un ouvrage (construction, excavation, clôture, etc.). Il peut s'agir d'une obligation contractuelle, mais, beaucoup plus souvent, il s'agira d'une obligation légale (par exemple, une interdiction de construire sur tel terrain, ou en dépassant une certaine hauteur). L'article 1143 du Code civil permet alors au créancier de demander que cet ouvrage soit démoli contre le gré du débiteur. C'est le créancier, ou un tiers, qui effectuera les travaux de démolition, sans qu'il soit nécessaire d'exercer une contrainte sur la personne du débiteur. Celui-ci pourra être condamné au paiement des frais de la destruction – obligation de somme d'argent susceptible d'exécution forcée. Le principe de ce texte est aujourd'hui repris par l'article 1222 nouveau du Code civil français et par l'article 5.235 du nouveau Code civil belge. Ces textes prévoient que le juge peut condamner par avance le débiteur à avancer les frais de la destruction.

Il convient de relever que l'action tendant à la destruction des ouvrages est une action en exécution de l'obligation, non une action en réparation du préjudice que l'ouvrage illicite cause au demandeur. Il n'est donc pas nécessaire, pour obtenir satisfaction, que le créancier prouve qu'il a subi un préjudice[1696] – sauf à ce que, dans certains cas, s'il ne subit aucun préjudice, sa demande en démolition puisse apparaître abusive. Si le créancier a subi un préjudice, il peut demander, en plus de la remise en état, la condamnation du débiteur à des dommages et intérêts, mais il ne s'agit pas alors de l'exécution par équivalent de l'article 1142 du Code civil, il s'agit du jeu normal de la responsabilité contractuelle. Dans l'état actuel, et compte tenu de la conception couramment admise qui reconnaît au créancier un véritable droit à l'exécution en nature, il semble que le juge soit tenu d'ordonner la destruction dès lors qu'elle est demandée[1697] – sauf, là encore, abus de droit[1698]. Mais, dans une perspective d'harmonisation européenne, il serait souhaitable que le juge puisse écarter la demande – comme d'une manière générale,

[1696] Cass. fr. (3e civ.), 13 novembre 1997, n° 95-21311.

[1697] Dans ce sens Trib. Luxembourg, 21 mars 1956, *Pas.*, 16, p. 539 ; Cour d'appel, 6 mars 2019, n° 44576.

[1698] *Contra*, en matière de copropriété dans une affaire où la construction constituait un empiètement irrégulier : Cour d'appel, 6 mars 2019, préc. Sur cet arrêt, voy. *supra*, n° 744.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

toute demande de condamnation à l'exécution en nature – si la mesure demandée apparaît manifestement déraisonnable ou disproportionnée par rapport à l'avantage qu'en tirerait le créancier. Dans ce sens, le nouvel article 1222 du Code civil français précise que la destruction doit être demandée « dans un délai et à un coût raisonnable », ce qui laisse entendre que le juge devrait refuser son autorisation si la destruction était demandée trop tardivement ou si son coût apparaissait excessif. Dans le nouveau texte belge, la solution est subordonnée à la condition que « la prestation s'y prête », ce qui laisse également supposer un pouvoir d'appréciation du juge.

2) *L'article 1144 du Code civil*

752. Faculté de remplacement. L'article 1144 du Code civil prévoit que « le créancier, peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même la prestation aux dépens du débiteur ». Il faut supposer ici que le contrat n'a pas été conclu en considération exclusive de la personne du débiteur, et que la prestation peut aussi bien être accomplie par un tiers. Il peut s'agir, par exemple, de la livraison d'un bien qu'on peut trouver ailleurs sur le marché ou d'une prestation de services que peut assurer de multiples entreprises de la place. Plutôt que de faire condamner son cocontractant à exécuter (ce qui va prendre du temps et ne débouchera peut-être que sur le versement de dommages et intérêts), le créancier peut préférer me procurer le bien ailleurs ou faire faire le travail par quelqu'un d'autre. Selon l'article 1144 du Code civil, il ne peut pas en principe décider unilatéralement d'exécuter lui-même ou de faire exécuter l'obligation par quelqu'un d'autre : il doit d'abord demander une autorisation en justice[1699]. Il est cependant admis qu'en cas d'urgence, le créancier peut se dispenser d'une telle autorisation et procéder immédiatement au remplacement[1700]. En principe, même dans ce cas, le créancier doit d'abord mettre son débiteur en demeure d'exécuter[1701], mais l'urgence peut être telle qu'elle peut même dispenser le créancier de cette formalité[1702]. Le créancier qui a procédé au remplacement de manière régulière pourra ensuite présenter la facture à son cocontractant (même si elle est plus élevée que le prix que le contractant défaillant avait demandé).

[1699] Voy. cependant *infra*, n° 788, sur la possibilité de se dispenser d'un recours du juge en se plaçant sur le terrain de la résolution.

[1700] Cour d'appel, 9 novembre 2005, n° 27581 ; Cour d'appel, 23 novembre 2023, n° CAL-2022-00560.

[1701] Cour d'appel, 27 février 2020, n° CAL-2018-00866 ; Cour d'appel, 23 novembre 2023, préc.

[1702] Cour d'appel, 21 février 2001, *Pas.*, 32, p. 30.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Ici encore, on est dans une logique d'exécution[1703] : pour obtenir l'autorisation de justice ou pour justifier *a posteriori* du bien-fondé du remplacement, le créancier devra prouver que le débiteur a manqué à son obligation[1704], mais il n'aura pas besoin de prouver un préjudice, nécessaire seulement pour obtenir des dommages et intérêts complémentaires. Cependant, la Cour d'appel estime que le juge saisi d'une telle demande d'autorisation apprécie son opportunité, notamment en fonction du coût du remplacement[1705]. La faculté de remplacement prévue par l'article 1144 a été reprise par l'article 1222 du Code civil français et par l'article 5.235 du nouveau Code civil belge, sous les mêmes limites que la destruction de l'ouvrage contraire à une obligation de ne pas faire (« à dans un délai et à un coût raisonnables » dans le texte français, « si la prestation s'y prête » dans le texte belge). Cependant, le texte français contient une nouveauté importante : le remplacement, à la différence de la destruction n'est plus subordonné à l'autorisation du juge, le créancier peut donc y procéder de sa propre initiative. L'autorisation judiciaire n'est utile que si le créancier veut que le débiteur soit condamné à faire l'avance des frais.

L'article 1144 du Code civil apparaît comme une formule intermédiaire entre l'exécution par équivalent du contrat et sa résolution. On n'est pas loin de la situation où le créancier qui ne peut pas obtenir l'exécution de son cocontractant choisit, au lieu de tenter de l'y forcer, de faire tomber le contrat, pour pouvoir ensuite contracter avec quelqu'un d'autre. Les deux mécanismes doivent cependant être distingués, car, dans le cas du remplacement, on reste dans le cadre du contrat originaire, alors que, s'il y a résolution, le créancier peut négocier avec un remplaçant un contrat à d'autres conditions que le contrat résolu.

SOUS-SECTION 2. LA RÉSOLUTION DU CONTRAT

753. Notion et intérêt. Au lieu d'essayer d'en obtenir l'exécution contre le gré du débiteur, le créancier de l'obligation inexécutée peut souhaiter se libérer du contrat : c'est ce que permet, la résolution pour inexécution, prévue par l'article 1184 du Code civil. Cette solution – connue de tous les systèmes juridiques européens – présente d'abord l'avantage de dispenser définitivement le créancier d'exécuter ses propres obligations : le vendeur impayé, par exemple, n'aura pas à livrer la chose. Contrairement à ce que

[1703] Ce qu'a dit clairement la Cour de cassation belge : Cass. be., 6 mars 1919, *Pas. be.*, 1919, I, p. 80.

[1704] Cour d'appel, 20 février 2024, n° CAL-2023-00230.

[1705] Cour d'appel, 26 mars 2015, n° 39317 du rôle.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

permet l'exception d'inexécution, la libération du créancier est ici définitive : le vendeur pourra donc, dans cet exemple, revendre la chose à quelqu'un d'autre, en espérant percevoir le prix plus tôt, et de manière plus sûre que n'aurait pu le permettre l'exercice des voies d'exécution contre le premier acheteur ; de même, un concessionnaire tenu par un contrat d'exclusivité pourra, grâce à la résolution, reprendre sa liberté et se procurer ailleurs les biens destinés à sa clientèle, etc. Si le créancier a déjà exécuté, il pourra se faire restituer, dans la mesure du possible, les prestations qu'il a déjà faites : le vendeur ayant déjà livré aura le droit d'obtenir la restitution du bien, l'acheteur ayant déjà payé et n'ayant pas reçu le bien ou ayant reçu un bien défectueux pourra réclamer le remboursement du prix, le bailleur à qui le locataire ne paye pas les loyers pourra faire expulser ce locataire, etc. La résolution du contrat est particulièrement avantageuse dans les contrats qui emportent transfert de propriété d'une chose, car elle permettra au créancier impayé de redevenir propriétaire : si le vendeur impayé choisit l'exécution forcée, il risque, si l'acheteur est insolvable, d'entrer en concours avec les autres créanciers de l'acheteur, y compris sur le bien vendu (dans la mesure où, en principe, le transfert de propriété dans la vente s'opère immédiatement, indépendamment du paiement du prix) ; en revanche, s'il opte pour la résolution, il redeviendra propriétaire du bien, qui, sorti du patrimoine de l'acheteur, échappera à ses autres créanciers. La résolution pour inexécution est en revanche sans intérêt dans les contrats qui ont déjà été exécutés et pour lesquels il est impossible de revenir sur l'exécution passée : ainsi, dans les contrats de prestation de service, si le prestataire de service a mal fait le travail (le teinturier a détérioré votre vêtement, le maçon a construit le mur de travers, le garagiste a oublié de remettre de l'huile dans votre voiture et le moteur a été endommagé, etc.), il est vain pour le client de demander la résolution, et, faute de pouvoir obtenir une exécution désormais impossible, la solution la plus adaptée sera le plus souvent de demander des dommages et intérêts.

754. Articulation avec les autres sanctions. L'intérêt que présente la résolution pour le créancier dépend dans une large mesure de la manière dont cette sanction s'articule avec les autres sanctions de la résolution. Les choses sont simples en ce qui concerne l'articulation entre *la résolution et l'exécution forcée*, car il paraît exclu que les deux sanctions puissent se cumuler : le créancier ne peut à la fois demander que l'autre exécute ses propres obligations,

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

et vouloir se dispenser d'exécuter les siennes, il ne peut vouloir à la fois le maintien du contrat et sa disparition. C'est pourquoi l'article 1184 du Code civil présente la résolution comme une des branches d'une option ouverte au créancier : « la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté *a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution* de la convention lorsqu'elle est possible *ou d'en demander la résolution* avec dommages et intérêts ». Il convient simplement de signaler que, si la résolution est incompatible avec l'exécution forcée des obligations nées du contrat, elle peut déboucher sur des obligations de restitution susceptibles, elles, de donner lieu à exécution forcée. Les choses sont moins évidentes en ce qui concerne l'articulation *de la résolution avec des dommages et intérêts*. Si on conçoit les dommages et intérêts comme une réparation du préjudice directement causé par l'inexécution, on peut estimer que la résolution, qui remet les choses en l'état, tient lieu d'une telle réparation et exclut l'attribution de dommages et intérêts complémentaires. De même, si on voit dans les dommages et intérêts contractuels, comme certains auteurs français, une forme d'exécution par équivalent de l'obligation inexécutée[1706], on peut avoir du mal à justifier que le créancier demande à la fois une telle « exécution » et l'anéantissement du contrat. Aussi bien, peut-on concevoir que certains systèmes juridiques interdissent le cumul de la résolution avec les dommages et intérêts : il en allait ainsi notamment en droit allemand avant la réforme du droit des obligations de 2001. Le Code civil n'a jamais admis cette solution : la formule précitée de l'article 1184 du Code civil indique explicitement que le créancier peut demander la résolution « avec dommages et intérêts ». Cette solution paraît bien préférable. Il faut bien voir en effet que, même si elle lui permet de se retrouver en l'état antérieur à la conclusion du contrat, la résolution laisse subsister les préjudices liés au retard subi par le créancier dans l'allocation de ses ressources (même s'il revend la marchandise, il le fait avec retard), aux occasions manquées de contracter avec autrui, et aux frais engagés pour faire valoir ses droits. C'est pourquoi le cumul de la résolution et des dommages et intérêts, admis en Allemagne depuis la réforme de 2001, est aujourd'hui consacré par la plupart des droits nationaux en Europe, ainsi que par les différents textes et projets internationaux et européens. Nous verrons cependant que ces dommages et

[1706] Voy. *infra*, n° 801.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

intérêts liés à la résolution ne seront pas nécessairement pas appréciés de la même manière que ceux qu'obtiendraient le créancier si le contrat était maintenu.

755. Conception d'ensemble du mécanisme de la résolution. Tous les droits modernes, en Europe tout au moins, connaissent un mécanisme de résolution permettant au créancier de se libérer du contrat non exécuté. Cependant la conception d'ensemble de ce mécanisme peut être très différente d'un système juridique à l'autre, et cela peut avoir des incidences importantes sur le domaine, les conditions et les effets de la résolution. On peut voir dans la résolution une forme de réparation en nature du préjudice subi par le créancier, replacé dans la situation où il était avant la conclusion du contrat inexécuté. On peut aussi y voir une conséquence de l'interdépendance des obligations dans les contrats synallagmatiques : dans un contrat de ce type, chaque partie ne s'engage que pour recevoir quelque chose en échange ; il est logique qu'elle puisse se libérer si l'autre n'accomplit pas la prestation promise. C'est en ce sens que certains auteurs, dans la lignée de la thèse soutenue par H. Capitant, voient dans la résolution une application particulière de la notion de cause[1707]. Les rédacteurs du Code civil, quant à eux, ont choisi de rattacher la résolution pour inexécution à la technique de la condition résolutoire, et c'est pourquoi ils l'ont réglementée à l'article 1184, au sein des textes consacrés à la condition. Le texte pose que chaque partie à un contrat synallagmatique ne s'engage que sous la condition résolutoire implicite de l'inexécution par l'autre de ses propres obligations. Cette présentation est aujourd'hui très critiquée, à la fois parce qu'elle repose sur une analyse divinatoire de la volonté des parties au moment où elles s'engagent (elles n'ont pas toujours en tête la perspective d'une inexécution potentielle), et surtout parce que le fondement indiqué ne correspond guère au régime juridique de la résolution, tant en ce qui concerne les conditions (**§ 1**), la procédure (**§ 2**) ou les effets (**§ 3**) de la résolution. Aussi bien les nouveaux textes relatifs à la résolution en France et en Belgique (C. civ. fr., art 1224 et s., C. civ. be., art. 5.90 et s.) ont-ils complètement détaché le mécanisme de la technique de la condition. Ces textes contiennent par ailleurs d'importantes nouveautés par rapport à l'approche traditionnelle de la résolution pour inexécution.

[1707] H. CAPITANT, *De la cause des obligations*, Paris, Dalloz, 1923, spéc. pp. 309 et s. (ouvrage accessible sur la base de données Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5726708t).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§ 1. Les conditions de la résolution

756. Différentes questions. À quelles conditions un créancier contractuel peut-il obtenir la résolution du contrat ? Il faut, bien sûr qu'il y ait inexécution du contrat. Mais pas de n'importe quel contrat (**A**) et pas n'importe quelle inexécution (**B**).

A) *Le contrat inexécuté*

757. Pas seulement les contrats synallagmatiques. On enseigne traditionnellement que la résolution ne s'applique qu'aux contrats synallagmatiques, et c'est effectivement uniquement dans ce cadre qu'elle est prévue par l'article 1184 du Code civil. C'est pourquoi on a pu voir dans la résolution une conséquence de la réciprocité des obligations, telle qu'elle s'exprime dans le Code civil dans la notion de cause : si un contractant n'exécute pas ses obligations, l'autre n'a plus de raison d'exécuter les siennes, et il peut demander à être libéré du contrat. En réalité, la résolution est une sanction de l'inexécution qui peut aussi bien se concevoir dans certains contrats unilatéraux. La restriction habituelle de son domaine aux seuls contrats synallagmatiques (qui a disparu des nouveaux textes français, mais non de l'article 5.90 du nouveau Code civil belge) s'explique parce que, dans l'immense majorité des cas, c'est dans ce type de contrats que le contractant victime de l'inexécution a intérêt à se dégager du contrat. Dans un contrat unilatéral, pour celui qui n'est que créancier, et qui ne doit rien à l'autre, la seule sanction intéressante est en général l'exécution, lorsqu'elle est possible, ou à défaut des dommages et intérêts. Dans un contrat de cautionnement, par exemple, on ne voit pas bien ce que le créancier aurait à gagner à la résolution, qui ferait précisément tomber l'obligation de la caution, sans libérer le créancier d'obligations dont il n'est pas débiteur. Mais il n'y a aucune raison d'exclure par principe la résolution dans un contrat unilatéral lorsque le créancier a intérêt à l'obtenir : dès 1905, la Cour d'appel affirmait que « l'article 1184 du Code civil, qui dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, n'est pas spécial à ceux-ci, mais est applicable aussi aux contrats unilatéraux »[1708]. Il en va ainsi tout d'abord dans les contrats unilatéraux dans lesquels le créancier est tenu d'obligations accessoires : ainsi, dans une donation qui comporte des charges pour le donataire (héberger le donateur, entretenir un de ses proches, etc.), l'article 953 du Code

[1708] Cour d'appel, 24 mars 1905, *Pas.*, 07, p. 111.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

civil prévoit la possibilité pour le donateur de révoquer la donation en cas d'inexécution des charges, et on considère que cette révocation est une simple application de la résolution pour inexécution[1709]. Il en va ainsi, surtout, dans les contrats unilatéraux qui, comme le prêt, font naître pour le débiteur une obligation de restitution : si l'emprunteur d'une chose n'entretient pas correctement la chose prêtée, si l'emprunteur d'une somme ne rembourse pas une des mensualités à l'échéance, ou refuse de fournir les garanties promises[1710], le prêteur a intérêt à récupérer au plus vite la chose ou la somme prêtée, et la résolution (qui se traduira ici en une déchéance du terme initialement stipulé) est un moyen de le faire.

758. **Pas tous les contrats synallagmatiques.** À l'inverse, la résolution est parfois exclue, pour des raisons diverses, dans certains contrats synallagmatiques. C'est ainsi que l'article 1978 du Code civil prévoit que, dans un contrat de vente contre rente viagère, « le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur ». Cette solution, qu'on explique parfois de manière peu convaincante par le caractère aléatoire de l'opération, cède cependant en présence d'une clause prévoyant expressément la résolution[1711]. Il en va de même dans le cas du partage, dans lequel on estime que l'effet déclaratif s'oppose à ce que le non-paiement de la soulte due par un des copartageants à l'autre soit sanctionné par la résolution du partage, à moins que les parties n'aient stipulé une clause résolutoire expresse[1712].

B) *L'inexécution*

759. **Caractères de l'inexécution.** La résolution ne peut être en principe obtenue que si on est en présence d'une inexécution effective (**1**) et présentant une certaine gravité (**2**). Peu importe en revanche la cause de cette inexécution (**3**).

1) *Effectivité de l'inexécution*

760. **Rejet de la résolution anticipée.** De prime abord, la résolution peut s'appliquer à tout type d'inexécution : simple retard, inexécution définitivement consommée, ou mauvaise exécution. Mais il est nécessaire que cette inexécution soit déjà effective, ce qui suppose que l'obligation du débiteur soit déjà exigible. Le créancier

[1709] Cour d'appel, 27 janvier 1893, *Pas.*, 03, p. 60 ; Cour d'appel, 19 janvier 2005, n° 28705 et 29033, *BIJ*, 2006, p. 39.

[1710] Cour d'appel, 24 mars 1905, préc.

[1711] Cour d'appel, 16 mai 2001, *Pas.*, 32, p. 121 ; Cour d'appel, 19 avril 2012, n° 36783 ; Cour d'appel, 27 novembre 2019, n° CAL-2018-00331.

[1712] Cour d'appel, 6 juillet 2005, *Pas.*, 33, p. 111.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

n'est pas fondé à demander (ou à déclarer) la résolution au seul motif qu'il craint que le débiteur n'exécute pas à l'échéance. Une telle résolution anticipée est cependant aujourd'hui admise dans la plupart des textes internationaux et projets européens, pour permettre au créancier de se débarrasser sans attendre d'un contrat dont l'inexécution est, sinon certaine, du moins très probable. Cet « *anticipatory breach of contract* » est notamment consacrée par les Principes Unidroit « si, avant l'échéance, il est manifeste qu'il y aura inexécution essentielle de la part de l'autre partie » (art. 7.3.3, formule reprise presque textuellement par les Principes Lando), par le DCFR « *if the debtor has declared that there will be a non-performance of the obligation, or it is otherwise clear that there will be such a non-performance, and if the non-performance would have been fundamental* », ou encore par le DCEV « si le vendeur a déclaré qu'il ne s'exécuterait pas ou s'il est par ailleurs manifeste qu'il ne s'exécutera pas ». Le nouveau Code civil belge a suivi ce mouvement : l'article 5.90, alinéa 2 dispose que « [l]e contrat peut aussi être résolu, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est manifeste que le débiteur, après avoir été mis en demeure de donner, dans un délai raisonnable, des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations, ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour le créancier ». Le nouveau droit français, en revanche, tout en consacrant la possibilité d'une exception d'inexécution anticipée, n'a pas admis la même solution pour la résolution. Jusqu'ici, le droit luxembourgeois ne semble pas avoir encore suivi la logique d'efficacité économique qui sous-tend la résolution anticipée, et qui n'est pas sans dangers pour le débiteur. Les juges luxembourgeois peuvent cependant connaître d'un tel mécanisme lorsqu'ils ont à appliquer à une vente internationale la Convention de Vienne dont l'article 72 dispose que « si, avant la date de l'exécution du contrat, il est manifeste qu'une partie commettra une contravention essentielle au contrat, l'autre partie peut déclarer celui-ci résolu ».

2) *Gravité de l'inexécution*

761. Une exigence relative. On enseigne généralement que, pour ouvrir droit à la résolution du contrat, l'inexécution doit être suffisamment grave. En réalité, le degré de gravité exigé dépend de la procédure d'obtention de la résolution. Nous allons voir que, dans le système du Code civil, la résolution doit en principe être demandée

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

en justice : dans un tel contexte, le juge a un pouvoir d'appréciation, il n'est pas obligé d'accorder la résolution du seul fait qu'il y a inexécution. Il peut non seulement, comme le prévoit expressément l'article 1184, alinéa 3 du Code civil, accorder un délai au débiteur pour s'exécuter, mais encore refuser purement et simplement la résolution s'il lui, apparaît que l'inexécution n'est pas suffisamment grave et que de simples dommages et intérêts suffisent à satisfaire le créancier. Par exemple, il est très probable qu'un juge refuserait d'accorder la résolution d'une vente de voiture pour la simple raison que la couleur du parechoc n'est pas exactement la même que sur le descriptif, ou la résolution d'un bail au seul motif que le locataire a été en retard une ou deux fois en un an pour payer son loyer.

Mais nous verrons aussi que le droit luxembourgeois permet parfois au créancier d'obtenir la résolution sans intervention préalable du juge, et la situation est alors différente. Ainsi, lorsqu'il y a dans le contrat une clause résolutoire expresse, cette clause fixera elle-même le degré de gravité exigé pour ouvrir droit à la résolution – soit en énumérant les causes de résolution, soit par une formule générale plus ou moins rigoureuse (tout retard d'exécution ou tout retard de plus de x jours après mise en demeure/tout manquement à telle obligation ou toute inexécution quelle qu'en soit la nature, la cause ou la gravité, etc.). Le juge, saisi *a posteriori* d'une contestation sur le bien-fondé de la résolution devra alors apprécier la gravité de l'inexécution en fonction de ce qui est prévu par la clause. À l'inverse, la jurisprudence actuelle qui autorise en l'absence de clause résolutoire la résolution par déclaration unilatérale du créancier subordonne la licéité de cette déclaration à une inexécution d'un degré plus grave que celui qui pourrait justifier une résolution judiciaire. Ces distinctions se retrouvent dans les nouveaux textes français et belges qui, nous le verrons, consacrent ces trois modes de mise en œuvre de la résolution : l'exigence de gravité de l'inexécution y est posée pour la résolution judiciaire et pour la résolution par déclaration unilatérale, mais pas lorsque la résolution est prévue par une clause résolutoire (C. civ. fr., art. 1224, C. civ. be., art. 5.90, al. 1).

762. Critères d'appréciation de la gravité. Dans certains droits étrangers, l'appréciation de la gravité de l'inexécution se fait en fonction de la nature de l'obligation inexécutée. Il en va ainsi en droit anglais où la résolution (*termination for breach of contract*) est admise s'il y a non-respect d'une « *condition* », c'est-à-dire d'une

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

clause que les parties ont regardée comme essentielle pour donner à la partie innocente le droit de mettre fin au contrat, quelle que soit la gravité que cette inexécution présente en elle-même[1713]. Cette logique se retrouve dans le Code Gandolfi (art. 107), qui subordonne la résolution à une « inexécution d'importance notable », définie comme celle qui « concerne une des obligations principales [et non secondaires] du contrat », les obligations secondaires étant celles « dont l'exécution est d'une importance minime eu égard à l'économie du rapport contractuel et à l'intérêt du créancier ». Cette logique n'est pas, d'une manière générale, celle de la jurisprudence dans les pays du Code civil. L'inexécution par un locataire de son obligation d'entretien de la chose louée dans le bail, par exemple, qui n'est qu'une obligation secondaire par rapport à celle de payer les loyers, pourra être suffisante pour justifier la résolution du contrat de bail. L'importance de l'obligation inexécutée par rapport à l'objectif poursuivi par les parties est un élément certes important dans l'appréciation de la gravité de l'inexécution, mais ce n'est qu'un élément parmi d'autres, à côté du préjudice plus ou moins grand subi par le créancier, de la bonne ou de la mauvaise foi du débiteur, du caractère plus ou moins répété des manquements. L'appréciation de la gravité de l'inexécution est une question de fait qui relève du pouvoir souverain des juges du fond[1714]. Pour prendre quelques exemples tirés de la jurisprudence[1715], ont été considérés comme des inexécutions suffisamment graves : le fait pour un vendeur d'immeuble de vendre le bien à un tiers au mépris d'un compromis de vente, le fait pour l'acheteur de ne pas payer le prix, le retard habituel dans le paiement des loyers d'un bail ou d'une rente viagère[1716], le fait pour un locataire d'héberger des proches bruyants et agressifs à l'égard des voisins, etc. À l'inverse, la Cour d'appel n'a pas considéré comme un manquement suffisamment grave le fait pour des donataires de n'avoir pas payé les frais de notaire que l'acte avait mis à leur charge, alors qu'ils avaient respecté toutes leurs autres obligations[1717]. De même, il a été jugé, dans un contrat de

[1713] CARTWRIGHT, pp. 281 et s. Mais le droit anglais admet aussi la résolution en cas de « *fundamental breach of contract* », même si l'obligation violée n'est pas une « condition ».

[1714] Cass., 27 avril 2017, n° 3781.

[1715] La plupart de ces exemples sont cités et détaillés par POELMANS, n° 215, avec les références des décisions.

[1716] Cour d'appel, 19 avril 2012, n° 36783.

[1717] Cour d'appel, 19 janvier 2005, n° 28705 et 29033, *BIJ*, 2006, p. 39.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

construction, que des malfaçons n'étaient pas d'une gravité telle à équivaloir à une inexécution, alors que les travaux avaient été réalisés en grande partie[1718].

763. **Textes spéciaux.** De nombreux textes spéciaux qui prévoient la résolution d'un contrat précisent le type et la gravité de l'inexécution nécessaires à la mise en œuvre de cette sanction. Par exemple, en cas de vice caché d'une chose vendue, l'action en garantie des vices cachés – qui peut déboucher entre autres sur la résolution de la vente, n'est ouverte par l'article 1641 du Code civil que si les défauts rendent la chose « impropre à l'usage auquel on la destine ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Dans un tout autre domaine, l'article 22 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance subordonne la résiliation du contrat par l'assureur au défaut de paiement 10 jours après mise en demeure de l'assuré.

3) *Causes de l'inexécution*

764. **Distinction.** La résolution peut intervenir dans deux cas très différents, selon que l'inexécution est imputable au débiteur ou est due à un cas de force majeure. Mais elle n'intervient pas tout à fait dans les mêmes conditions dans les deux cas.

a. *L'inexécution imputable au débiteur*

765. **Inexécution fautive ou non fautive.** C'est le cas normal : le débiteur n'a pas exécuté, ou a mal exécuté, alors qu'il aurait pu le faire. La résolution est toujours envisageable dans un tel cas. Il convient cependant de bien préciser que par « inexécution imputable au débiteur », il ne faut pas nécessairement comprendre une inexécution fautive. Tout dépend de l'objet de l'obligation qui n'a pas été exécutée. On fait, dans les pays du Code civil, une distinction (sur laquelle nous reviendrons) entre les obligations de moyens et les obligations de résultat, qui est surtout utilisée pour déterminer les conditions de la responsabilité contractuelle[1719], mais qui a également son intérêt quant à la résolution du contrat. Certaines obligations sont dites de résultat, car elles obligent le débiteur à atteindre un certain résultat, alors que d'autres obligent seulement le débiteur à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour y parvenir (ce sont les obligations de moyens). Dans le premier cas, la responsabilité du débiteur sera engagée du seul fait qu'il n'aura pas atteint le résultat promis, sans qu'il y ait à juger de son comportement, c'est-à-dire sans qu'il y ait à se demander s'il a commis

[1718] Trib. Luxembourg, 29 juin 2023, n° TAL-2022-09719.
[1719] Voy. *infra*, n°s 822 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

une faute. De la même manière, en cas d'inexécution d'une telle obligation, dès lors qu'elle sera jugée suffisamment grave, la résolution du contrat ne sera pas subordonnée à l'existence d'une faute. Par exemple, si le débiteur d'une somme d'argent ne paye pas à l'échéance, ou si celui qui doit livrer une marchandise ne le fait pas, ou livre une chose non conforme, le créancier pourra demander la résolution sans avoir à prouver la faute, et le débiteur ne pourra pas se défendre en alléguant que l'inexécution n'est pas de sa faute. L'absence de faute peut simplement amener le juge à accorder des délais au débiteur. En revanche, si l'obligation est de moyens, la résolution du contrat, tout comme l'octroi de dommages et intérêts au créancier, sont subordonnés à la preuve que le débiteur n'a pas mis tous les moyens en œuvre pour atteindre le résultat – donc à la preuve d'une faute. En pratique, les obligations de moyens se rencontrent surtout dans les contrats de service (contrat passé avec un médecin, un prestataire de services de conseils, un réparateur, etc.) pour lesquels la résolution est rarement un remède adéquat. Dans la plupart des cas, la résolution pourra donc être obtenue sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute du cocontractant.

b. *L'inexécution due à un cas de force majeure*

766. Théorie des risques. La résolution peut aussi intervenir dans des cas où l'inexécution n'est pas imputable au débiteur, parce qu'elle n'est que la conséquence d'un cas de force majeure, qui a empêché le débiteur d'accomplir ce qu'il a promis. On définit habituellement la force majeure comme un événement extérieur au débiteur, imprévisible, et irrésistible. La principale conséquence de la force majeure est d'exonérer le débiteur de sa responsabilité contractuelle, et nous ferons à ce propos l'étude détaillée de ces différents éléments[1720]. Mais, dans les contrats synallagmatiques, se pose aussi la question de savoir quelle est l'incidence de la force majeure sur le contrat : le contrat impossible à exécuter est-il maintenu, de telle sorte que l'autre partie doit, elle, exécuter sa propre prestation, ou est-il résolu, de telle sorte que l'autre partie est libérée ? Les solutions apportées par le droit à cette question sont habituellement regroupées sous le nom de « théorie des risques », parce qu'il s'agit de savoir lequel des contractants supporte les conséquences de la force majeure : le débiteur qui ne peut pas exécuter (et qui, si le contrat est résolu, ne recevra pas sa rémunération),

[1720] Voy. *infra*, n°s 838 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ou le créancier de l'obligation inexécutée (lequel, si le contrat est maintenu, devra quand même exécuter sa propre prestation) ? Dans le Code civil, cette question reçoit une réponse différenciée selon la nature du contrat affecté par la force majeure.

767. Principe : résolution du contrat impossible à exécute. En droit civil luxembourgeois, comme dans la plupart des systèmes juridiques, c'est la première solution qui est en principe retenue : le contrat impossible à exécuter sera résolu, de sorte que le créancier de la prestation impossible à exécuter sera libéré du contrat et n'aura pas à exécuter sa propre prestation. On dit alors que les risques sont à la charge du débiteur : *res perit debitori*. Prenons un exemple : si vous avez passé un contrat avec une agence de voyages pour aller passer un séjour de rêve dans une île paradisiaque de l'autre bout du monde, et que, la veille de votre départ, un typhon détruit toutes les installations touristiques de cette île, vous ne pourrez pas demander des dommages et intérêts à l'agence (c'est l'effet exonératoire de la force majeure), mais, d'un autre côté, vous n'aurez pas à payer le voyage (et vous pourrez vous faire rembourser ce que vous avez payé). L'agence, débitrice de l'obligation rendue impossible à exécuter, qui a déjà engagé des frais pour l'organisation de votre voyage, va donc *in fine* supporter le risque de la situation. La solution, bien que non expressément prévue par les textes, peut être déduite de l'article 1184 du Code civil, qui ne distingue pas selon la cause de l'inexécution. Elle est aujourd'hui expressément prévue par l'article 1218 du Code civil français ainsi que par l'article 5.100 du nouveau Code civil belge. Cependant, il n'y a lieu à résolution que lorsque l'impossibilité résultant du cas de force majeure est totale et définitive. En cas d'impossibilité temporaire, la solution est une suspension des obligations contractuelles – laquelle, s'apparentant à l'exception d'inexécution, ne suppose pas la saisine du juge. En revanche, lorsqu'il y a lieu à résolution, on se demande si l'intervention du juge est nécessaire pour la prononcer. Nous retrouverons la question plus loin[1721].

768. Exception : *res perit domino*. Le principe connaît cependant, dans les pays du Code civil, une exception remarquable qui concerne les contrats translatifs de propriété, dans lesquels l'impossibilité de livrer la chose par suite d'un cas de force majeure n'entraîne pas la résolution du contrat. Comme on le sait déjà, dans le système

[1721] Voy. *infra*, n°s 771 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

du Code civil, le transfert de propriété s'opère en principe *solo consensu*, c'est-à-dire par le seul échange des consentements, sans attendre la livraison de la chose[1722]. Il en résulte que, si la chose périt par suite d'un cas de force majeure avant d'être livrée, l'acheteur, en tant que propriétaire, doit en supporter les conséquences : *res perit domino* (la perte de la chose est à la charge du propriétaire). Non seulement il ne pourra pas demander de dommages et intérêts au vendeur (qui n'est pas responsable de la situation), mais il n'est pas libéré de l'obligation de le payer. C'est donc lui, créancier de l'obligation de livrer inexécutée, qui supporte le risque de la force majeure. La solution est prévue, de manière peu claire, par l'article 1138 du Code civil, et elle est reprise par le nouvel article 1196 du Code civil français, ainsi que (de manière plus ambiguë) par les articles 5.79 et 5.80 du nouveau Code civil belge[1723]. Le texte fait cependant exception dans le cas où le vendeur était en retard pour livrer et qu'il a été mis en demeure de le faire. Par ailleurs, cette solution est très souvent écartée par une clause du contrat qui déplace le transfert des risques au moment où la chose est livrée. La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises et le projet de règlement européen sur la vente ont suivi cette pratique et prévu que le transfert des risques s'opère en principe au moment de la délivrance de la chose, selon les cas à l'acheteur ou au transporteur (CVIM, art. 66 et s. ; DCEV, art. 140 et s.). La vente sera donc résolue, et l'acheteur libéré de son obligation de payer le prix, si la chose périt alors qu'elle est encore entre les mains du vendeur, même s'il n'est pour rien dans cette perte.

§ 2. La procédure de la résolution

769. Différents systèmes. Selon les systèmes juridiques, la procédure d'obtention de la résolution peut être plus ou moins formaliste, et faire intervenir ou non le juge. Deux grands modèles se rencontrent, qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Dans le Code civil de 1804, tel qu'il est toujours en vigueur sur ce point au Luxembourg, la résolution apparaît comme une sanction judiciaire : l'article 1184 du Code civil indique clairement que « le contrat n'est point résolu de plein droit » lorsque le débiteur n'a pas satisfait à son engagement, et que « la résolution doit être demandée en justice ». Le juge contrôle

[1722] Voy. *supra*, n° 52.
[1723] Voy. *supra*, n° 52.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

a priori si les conditions de la résolution sont réunies, et il a un pouvoir d'appréciation pour accorder ou non la résolution selon la gravité de l'inexécution. Ce système est principalement inspiré par une conception rigoureuse de la force obligatoire du contrat : le créancier victime de l'inexécution ne doit pas pouvoir se libérer tant que le juge ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de la résolution. L'intervention du juge est aussi une protection importante offerte au débiteur, qui n'a pas à craindre que le créancier ne se débarrasse trop facilement du contrat sous le prétexte d'une inexécution ou d'une mauvaise exécution peut-être imaginaires. Mais, en contrepartie, cette procédure apparaît comme très handicapante pour le créancier qui ne pourra se libérer du contrat, et éventuellement contracter avec quelqu'un d'autre, qu'à la fin d'une procédure qui peut durer longtemps. Pendant ce temps, l'insolvabilité du débiteur peut s'aggraver, le bien vendu peut être détruit ou détérioré, aux risques d'un créancier qui n'est pour rien dans la situation. C'est pourquoi des droits plus soucieux d'efficacité économique ont opté pour un autre système, où le créancier qui se prétend victime de l'inexécution peut déclarer unilatéralement la résolution du contrat, sauf à ce que, dans une phase ultérieure, le débiteur puisse contester devant le juge le bien-fondé de la résolution. Tel est le système admis depuis longtemps dans les pays de *common law*, où la résolution (*termination*) est considérée comme une simple acceptation de la rupture (*repudiation*) émanant de celui qui n'a pas exécuté le contrat : il faut alors et il suffit que la victime notifie à son cocontractant son intention de mettre fin au contrat[1724]. De même, en droit allemand, le § 323 du BGB (*Rücktritt*) permet au créancier de se « retirer » du contrat si le débiteur n'a pas exécuté. Ce système est incomparablement plus favorable au créancier, à qui il permet de réallouer sans attendre ses ressources (revendre la marchandise impayée, placer le prix de la marchandise non livrée), même si l'avantage est surtout sensible si le contrat n'a pas encore été exécuté par le créancier. L'efficacité de cette résolution unilatérale est encore renforcée si le droit permet au créancier, comme on l'a vu, de se libérer de manière anticipée. Mais ce système est évidemment dangereux pour le débiteur, qui est à la merci d'un créancier de mauvaise foi, et qui ne réussira que très difficilement à retrouver le bénéfice du contrat même si, *a posteriori*, le juge estime que la résolution était infondée. D'une manière générale, cependant, c'est ce second modèle qui est aujourd'hui le plus répandu

[1724] Cartwright, p. 273 ; W. Anson et J. Beaton, *Anson's Law of Contract*, OUP, 27 th edition, 1998, pp. 535 à 539.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

en Europe, et c'est lui qu'on retrouve dans tous les textes internationaux et projets européens (Principes Unidroit, PDEC, Convention de Vienne, DCEV, etc.). Aussi bien ce modèle tend-il à gagner même des pays qui étaient à l'origine favorables à la résolution judiciaire, et qui, soit se rangent purement et simplement au système de la déclaration unilatérale, soit permettent au créancier d'opter entre les deux voies[1725]. Telle est la position qui a été récemment adoptée en France et en Belgique à l'occasion des réformes : dans les deux pays, les nouveaux textes, tout en maintenant la possibilité de demander la résolution en justice, permettent au créancier de résoudre le contrat par une déclaration unilatérale, sous réserve d'un contrôle judiciaire *a posteriori*.

770. Évolution du droit luxembourgeois. Dans l'attente d'une réforme, le Luxembourg a conservé, par principe, le système de la résolution judiciaire prévu à l'article 1184, alinéa 3 du Code civil. Mais la portée de ce principe est aujourd'hui considérablement atténuée, dans la mesure où les créanciers peuvent, dans de nombreux cas, procéder à la résolution sans intervention préalable du juge, soit par l'effet d'une clause du contrat, soit même, dans la jurisprudence récente, en l'absence de clause. Le cas où l'inexécution est causée par un cas de force majeure doit par ailleurs être mis à part.

A) *La résolution judiciaire*

771. Principe. Le texte de l'article 1184 du Code civil est tout à fait clair « la résolution doit être demandée en justice ». Ce principe est régulièrement rappelé en jurisprudence. Deux décisions du tribunal de Luxembourg, rendues à presque 60 ans de distance, l'illustrent bien. En 1957, le tribunal notait que « la seule expiration du délai dans lequel un engagement transactionnel devait être exécuté ne suffit pas pour entraîner au profit de la partie lésée par l'inexécution de cet engagement la résolution de la transaction, mais une résolution judiciaire de la transaction est, à défaut de tout pacte commissoire[1726], nécessaire pour faire renaître au profit de la partie lésée les droits que la transaction avait éteints »[1727]. Dans une récente décision, rendue début 2015, il rappelle que « à défaut d'accord entre parties et en l'absence

[1725] En Italie, le principe est celui de la résolution judiciaire (Codice civile, art. 1453), mais la loi prévoit elle-même de larges exceptions (Codice civile, art. 1454). Pour un aperçu plus large des droits nationaux européens, *cf.* les notes sous l'article III. – 3 : 507 du DCFR (*Draft Common Frame of Reference*, *Full Edition*, vol. I, 2009-2010, spéc. pp. 879-880).

[1726] Sur cette notion, voy. *infra*, n° 774.

[1727] Trib. Luxembourg, 21 novembre 1957, *Pas.*, 17, p. 207.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de clause résolutoire expresse, le recours au juge est obligatoire pour obtenir la résolution du contrat, de sorte que la partie saisissante, en qualité de créancier de l'obligation de livraison des panneaux solaires, ne pouvait pas résoudre unilatéralement le contrat par courrier »[1728].

772. Mise en œuvre. Le créancier qui veut faire tomber le contrat inexécuté doit donc saisir le tribunal. En principe, c'est le tribunal compétent au fond qui doit être saisi, mais, dans les cas d'urgence, et s'il n'y a aucune contestation sérieuse sur l'inexécution, la résolution peut être demandée au juge des référés (Nouveau Code de procédure civile, art. 15 et 932). Il n'est normalement pas nécessaire que le débiteur ait été préalablement en demeure, dès lors que l'assignation en justice vaut, traditionnellement, mise en demeure[1729]. On peut cependant penser que, si l'inexécution consiste dans un simple retard dans l'exécution, le créancier obtiendra d'autant plus facilement du juge la résolution qu'il aura, avant le procès, tenté en vain d'obtenir l'exécution. En effet, il faut rappeler que, dans un tel contexte de résolution judiciaire, le juge n'est pas tenu d'accorder la résolution qui lui est demandée : il peut, selon la lettre même de l'article 1184 du Code civil, accorder un délai au débiteur s'il lui semble possible qu'il exécute encore, il peut aussi refuser la résolution si l'inexécution ne lui paraît pas suffisamment grave et se contenter d'octroyer au créancier des dommages et intérêts. Cela présente évidemment beaucoup d'inconvénients pour le créancier, et c'est ce qui explique le développement en pratique de clauses résolutoires expresses qui dispensent du recours au juge. Dans les nouveaux droits français et belge, le mécanisme de la résolution judiciaire perdure : si elle n'est plus obligatoire, cette résolution fonctionne largement comme dans le droit antérieur. L'article 1227 du Code civil dispose que « [l]a résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice », sans mentionner l'exigence d'une mise en demeure préalable à l'assignation), et l'article 1228 pose que « [l]e juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts », ce qui reprend largement l'article 1184. En droit belge, il en va de même dans l'article 5.91 du nouveau Code, mais à la différence du droit français, l'article 5.83 exige une mise en demeure préalable sans distinguer entre les différents types de résolution.

[1728] Trib. Luxembourg, 13 janvier 2015, n° 155.351.

[1729] *Contra* : Poelmans, n° 212 (mais l'arrêt cité concerne la mise en jeu d'une clause résolutoire).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

773. Clauses excluant le droit de demander la résolution. L'article 1184 du Code civil, fondé sur l'idée d'une « condition résolutoire sous-entendue » n'est pas considéré traditionnellement comme étant d'ordre public. Aussi est-il admis que, dans un contrat, les parties peuvent prévoir que, en cas d'inexécution de ses obligations par un contractant, l'autre ne pourra pas demander la résolution[1730]. Cependant, ces clauses, qui se rapprochent des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité peuvent apparaître comme un moyen pour un contractant en situation de force de s'exonérer de ses obligations. C'est pourquoi la loi en prévoit parfois la nullité, notamment en droit de la consommation (C. consomm., art. L. 211-3.5 et L. 211-3.12).

B) *La résolution fondée sur une clause résolutoire expresse*

774. Notion. De très nombreux contrats contiennent une clause résolutoire expresse (autrefois appelée aussi pacte commissoire[1731]), prévoyant qu'à défaut d'exécution le contrat sera résolu de plein droit, sans que le créancier ait à demander au juge de prononcer la résolution.

Ces clauses, qui permettent au créancier d'éviter les lenteurs et les incertitudes de la résolution judiciaire, sont extrêmement dangereuses pour le débiteur, qui peut être confronté à l'arbitraire de son créancier, et perdre le bénéfice du contrat alors même qu'il a correctement exécuté celui-ci. Sans doute, le juge pourra contrôler *a posteriori* le bien-fondé de la mise en œuvre de la clause, mais ce contrôle sera assez limité, et, même s'il est finalement jugé que le créancier était dans son tort en déclarant la résolution du contrat, il sera souvent difficile de faire revivre le contrat résolu. C'est pourquoi le droit pose des limites à la validité des clauses résolutoires expresses, et en limite les effets.

1. *Validité des clauses*

775. Principe. Depuis longtemps, dans les trois pays du Code civil, il est admis que l'exigence d'un recours au juge, dans l'article 1184 du Code civil, n'est pas d'ordre public. Au Luxembourg,

[1730] Cour d'appel, 18 janvier 2006, n° 30981, *BIJ*, 2006, p. 39 (à propos du droit de révocation d'une donation pour inexécution des charges, considéré par la jurisprudence comme une application de l'article 1184 du Code civil).

[1731] Cette expression, qu'on trouve dans les arrêts anciens, est aujourd'hui plutôt utilisée pour désigner, de manière plus spécifique, la clause (en principe interdite) d'un contrat de gage par laquelle le créancier stipule que, à défaut de remboursement de la dette, il deviendra automatiquement propriétaire de la chose gagée.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la validité de ce type des clauses résolutoires a été admise très nettement par un arrêt de la Cour de cassation de 1905[1732], pour lequel « le pacte commissoire stipulant qu'à défaut d'exécution de l'obligation dans un délai déterminé, le contrat sera résolu, constitue une condition résolutoire d'une espèce particulière ». La solution s'inscrit dans la continuité de l'article 1184 du Code civil : dès lors que celui-ci est fondé sur une condition résolutoire sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, les parties peuvent insérer dans leur contrat une condition expresse. Cependant, comme le précise déjà l'arrêt de 1905, cette condition résolutoire expresse ne dispensera pas toujours du recours au juge : il n'en ira ainsi que si les parties ont clairement précisé que la résolution aurait lieu de plein droit en cas d'inexécution. À défaut, la clause ne serait considérée que comme un rappel de l'article 1184 du Code civil : « au cas où le pacte commissoire ne reproduit que la condition résolutoire tacite enfermée dans tout contrat synallagmatique aux termes de l'article 1184 du Code civil, sans rien y ajouter, la résolution n'a lieu que dans les limites tracées par cet article » – c'est-à-dire par décision judiciaire. L'intérêt d'une telle clause n'apparaît que dans les cas où la résolution pour inexécution est en principe exclue – en particulier dans le cas d'une vente contre rente viagère, où elle apparaît comme une dérogation à l'article 1978 du Code civil[1733].

776. Limites. La validité des clauses résolutoires est parfois écartée ou limitée par la loi, dans le but de protéger certains contractants faibles. C'est ainsi que l'article L. 211-3.4 du Code de la consommation condamne comme abusives « les clauses, selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier ou de rompre unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat »[1734]. De même, en matière de bail d'habitation, l'article 1762-2 du Code civil prévoit que « la clause résolutoire expresse reste soumise à l'appréciation du juge compétent », ce qui interdit à un bailleur de mettre fin au bail par simple lettre. Dans d'autres cas, la loi, sans remettre en cause la validité des clauses, limite simplement leurs effets.

[1732] Cass., 5 mai 1905, *Pas.*, 07, p. 125.

[1733] Voy. p. ex. Cour d'appel, 19 avril 2012, n° 36783 ; Cour d'appel, 22 septembre 2019, n° CAL-2018-00331.

[1734] Le texte n'interdit donc pas par principe les clauses résolutoires expresses : il interdit seulement celles qui seraient stipulées pour un motif d'ordre général, du type 'en cas d'inexécution par le consommateur d'une quelconque de ses obligations.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

2. *Effets des clauses*

a. *Mise en oeuvre*

777. Décision du créancier. Quand on dit que la clause résolutoire expresse opère « de plein droit », il faut s'entendre sur le sens de cette expression. Cela ne signifie pas que la résolution joue automatiquement, sans aucune intervention humaine : en réalité, il appartient toujours au créancier de décider s'il entend ou non faire jouer la clause. S'il ne réagit pas en cas d'inexécution, ou s'il laisse un délai au débiteur, la clause ne jouera pas. Le créancier peut même renoncer au bénéfice de la clause : ce sera le cas, par exemple s'il demande judiciairement l'exécution du contrat[1735]. Le nouveau droit belge exige que le créancier qui veut mettre la clause en œuvre le fasse par une notification écrite au débiteur avec indication des manquements qui lui sont reprochés (C. civ. be., art. 5.83)

778. Mise en demeure. Si le créancier décide de faire jouer la clause, il doit en principe, selon une jurisprudence constante, mettre en demeure le débiteur en lui précisant que, s'il n'exécute pas dans un certain délai, le contrat sera résolu[1736]. Dans la mesure où la résolution ne passe pas ici par une demande en justice, et où le débiteur ne pourra pas obtenir de délai de la part du juge, il est normal que le débiteur ne soit pas pris par surprise, et qu'il ait en quelque sorte le temps de « se retourner ». La Cour d'appel note ainsi que « cette mise en demeure, nécessaire à la mise en œuvre de la clause résolutoire, est destinée à avertir le débiteur de la sanction de la résolution de plein droit qu'il encourt, s'il persiste à ne pas exécuter ses obligations échues »[1737]. Il s'agit donc d'une mise en demeure « avertissement », très différente de la mise en demeure traditionnelle qui vise seulement à constituer le retard. Aussi bien faut-il considérer qu'il faut l'exiger même dans le cas où un délai précis a été fixé pour l'exécution, la dispense de mise en demeure prévue dans ce cas par l'article 1146, alinéa 2, ne concernant que celle requise pour l'obtention de dommages et intérêts[1738]. Cette

[1735] Cour d'appel, 25 avril 1967 ; Cass., 30 mai 1968, *Pas.*, 21, p. 65 (on ne peut cependant déduire une telle renonciation du fait que le créancier d'un crédit-bail demande le paiement des loyers arriérés, alors que le contrat prévoyait la possibilité de conserver ces arriérés à titre de clause pénale en cas de résolution du contrat).

[1736] Cass., 5 mai 1905, préc. ; Cour d'appel, 20 octobre 2011, *J.T.L.*, 2012, p. 114 ; *BIJ*, 2012, p. 104.

[1737] Cour d'appel, 20 octobre 2011, préc. ; Voy. aussi Cour d'appel, 3 novembre 2020, n° CAL-2018-00186.

[1738] Voy. *supra*, n° 691.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

exigence de mise en demeure préalable à la mise en œuvre de la clause résolutoire est aujourd'hui posée en principe par le nouvel article 1225 du Code civil français, ainsi que par l'article 5.83 du nouveau Code civil belge. Le texte français exige que la mise en demeure mentionne expressément la clause résolutoire, ce qui est aussi la position actuelle de la jurisprudence luxembourgeoise[1739].

En principe, cette exigence de mise en demeure avec délai n'est pas elle-même d'ordre public : le contrat peut dispenser le créancier de toute mise en demeure, ou prévoir que la résolution se produira au moment même de la notification faite au débiteur[1740]. L'article 1225 du Code civil français dispense ainsi le créancier de mise en demeure s'il a été « convenu que celle-ci résulterait du seul faut de l'inexécution » et la même solution résulte en droit belge de l'article 5.233 du nouveau Code civil. Cependant, toujours dans le but de protéger certains contractants, certains textes spéciaux peuvent exiger la mise en demeure de manière impérative. Il en va ainsi, en droit luxembourgeois, des articles 21 et 22 de la loi du 27 juillet 1997 sur l'assurance : en cas de non-paiement des primes, l'assureur doit d'abord envoyer une lettre recommandée à l'assuré, comportant mise en demeure de payer, et lui indiquant que le contrat sera suspendu en cas de non-paiement à l'expiration d'un délai d'au moins trente jours ; l'assureur aura ensuite le droit de résilier le contrat, mais seulement à l'expiration d'un nouveau délai de 10 jours. Il s'agit d'éviter que l'assuré négligent ne se retrouve brutalement privé de la couverture de l'assurance, ce qui pourrait avoir pour lui des conséquences catastrophiques.

b. *Contrôle du juge*

779. Contrôle a posteriori limité. Même si elles jouent de manière unilatérale, sans intervention initiale du juge, les clauses résolutoires n'échappent pas complètement au contrôle du juge. Si le débiteur à qui le créancier a notifié la résolution conteste celle-ci, il pourra toujours saisir le juge. Cependant ce contrôle *a posteriori* est normalement assez limité : le juge pourra simplement vérifier que la clause est valable, et que le créancier l'a fait jouer dans les conditions qu'elle a prévues, et en respectant les formalités qu'elle a posées. Il n'aura pas en principe la possibilité de refuser la résolution s'il estime que l'inexécution n'est pas assez grave, ni d'accorder un délai au débiteur pour s'exécuter.

780. Extension du contrôle. Les dangers des clauses résolutoires ont cependant amené la jurisprudence à chercher des moyens d'étendre ce contrôle. D'une part, la jurisprudence pose

[1739] Cour d'appel, 3 novembre 2020, préc.

[1740] Cour d'appel, 20 octobre 2011, préc., qui précise que « Dans cette hypothèse, cependant, les parties doivent prévoir dans leur clause résolutoire, non une "sommation de payer" les mensualités échues, mais une déclaration notifiée au débiteur, l'informant de la résolution du contrat par le jeu de la clause résolutoire de plein droit ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

un principe d'interprétation restrictive : comme le relève un arrêt de la Cour d'appel, remarquablement motivé à cet égard, « l'interprétation, compte tenu de ce que les clauses résolutoires constituent des actes de justice privée, dépourvus des garanties attachées aux sanctions judiciaires, est, aux fins de protéger les intérêts du débiteur, à effectuer de manière restrictive. Une clause résolutoire ambiguë est par conséquent à interpréter en faveur de celui qui contracte l'obligation, soit en l'espèce l'emprunteur »[1741]. Les juges peuvent ainsi considérer qu'une clause insuffisamment précise n'entraîne pas une résolution de plein droit, et ne fait que rappeler la possibilité de demander la résolution judiciaire[1742]. D'autre part et surtout, les juges peuvent ici faire jouer l'exigence générale de bonne foi pour contrôler, non pas le contenu de la clause, mais la manière dont elle a été mise en œuvre par le créancier[1743]. La Cour de cassation a fait application de cette exigence dans une hypothèse où un bailleur avait cru pouvoir résilier le bail au motif qu'il n'avait pas été payé à temps, alors que le locataire avait donné l'ordre de virement à sa banque dès qu'il avait reçu le rappel, et que c'était seulement par suite d'un retard de la banque dans l'exécution du virement que le compte du bailleur n'avait été crédité que quelques jours plus tard[1744]. Dans un tel cas, les juges du fond sont autorisés à considérer que le contrat n'a pas été résolu. Il y a là une application typique du jeu de la bonne foi (qu'on peut assimiler dans ce contexte à la prohibition de l'abus de droit) comme moyen de bloquer l'exercice d'une prérogative que le contrat donne au créancier[1745]. La clause résolutoire n'est pas annulée, elle pourra jouer ultérieurement dans d'autres situations d'inexécution, mais le contractant ne peut pas s'en prévaloir dans l'espèce particulière soumise au juge.

781. Sanctions de la résolution irrégulière ou abusive Si la clause est annulée ou neutralisée, la question se pose de savoir quelle peut être la sanction du comportement du créancier qui a rompu illicitement ou abusivement le contrat. Au minimum, il devra payer des dommages et intérêts à son cocontractant qu'il a privé

[1741] Cour d'appel, 20 octobre 2011, préc.
[1742] Cour d'appel, 19 avril 2012, n° 36783.
[1743] Cour d'appel, 17 juin 2009, n° 32762.
[1744] Cass., 27 mai 1971, *Pas.*, 21, p. 462.
[1745] Voy. *supra*, n° 500.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

indûment du bénéfice du contrat. Mais peut-on imaginer que le juge puisse alors faire comme si le contrat n'avait pas été résolu et en ordonner l'exécution ? En droit, cela semble possible : même si la résolution s'est produite au moment où la clause a été invoquée, le fait que le juge annule la clause ou interdise au créancier de s'en prévaloir aboutit logiquement à faire revivre le contrat. L'article 5.94 du nouveau Code civil belge prévoit dans ce sens que « [l]a notification par laquelle le créancier résout le contrat est inefficace si les conditions de la résolution ne sont pas remplies ou si elle est abusive ». Mais en fait cela sera souvent très difficile, car le créancier qui s'est débarrassé du contrat aura souvent contracté ailleurs, et la seule sanction sera souvent l'octroi de dommages et intérêts. C'est pour éviter cet inconvénient que le nouveau droit français (C. civ. fr., art. 1226, al. 4) prévoit que, à tout moment, le débiteur à qui on notifie la décision de résolution unilatérale peut saisir le juge pour contester cette résolution, donc avant même qu'elle soit effective. La solution est prévue pour la résolution par déclaration unilatérale en l'absence de clause, mais elle pourrait être transposée à la clause résolutoire.

C) *La résolution par déclaration unilatérale*

782. Expansion. Jusqu'à une période récente, le droit luxembourgeois ne permettait à un créancier de se retirer unilatéralement du contrat que dans certains cas particuliers prévus par la loi, et qui ne doivent du reste pas tous être mis sur le même plan (**a**). Mais, suivant les évolutions des droits belge et français, la jurisprudence reconnaît aujourd'hui, en droit commun, une telle faculté de résolution unilatérale dont le régime est encore en gestation (**b**).

a. *Cas prévus par la loi*

783. Code civil et lois spéciales. Les rédacteurs du Code civil n'ont admis la résolution sans autorisation de justice que dans un seul cas, celui de l'article 1657 du Code civil, qui concerne exclusivement la vente de « denrées et effets mobiliers », c'est-à-dire de marchandises : ce texte prévoit que si l'acheteur ne prend pas livraison de la chose au terme convenu « la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur ». Le texte est justifié principalement par l'urgence, s'agissant de biens qui peuvent se détériorer ou se déprécier si on les garde trop longtemps.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

En dehors du Code, un certain nombre de textes plus récents ont mis en place des mécanismes de résolution extrajudiciaires du contrat. Le cas le plus important en pratique est celui du contrat de travail. On sait que, lorsque ce contrat est à durée indéterminée, l'employeur peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter un préavis et de justifier d'un motif réel et sérieux. Il ne s'agit pas là, cependant, d'une résolution pour inexécution analogue au mécanisme de l'article 1184 du Code civil, car le licenciement n'est pas nécessairement fondé sur une inexécution de ses obligations par le salarié, ni même sur un motif lié à celui-ci : c'est seulement l'expression du droit de résiliation unilatérale dans les contrats à exécution successive et à durée indéterminée[1746]. On retrouve en revanche la logique de la résolution pour inexécution dans le cas de l'article L. 124-10 du Code du travail qui permet à chaque partie de « résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l'expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l'autre partie ». Cette résiliation, qui peut intervenir même dans un contrat de travail à durée déterminée, s'opère sans recours au préalable au juge, elle suppose seulement une notification par lettre recommandée. On en rapprochera l'article 18 (1) de la loi du 3 juin 1994 relative au statut des agents commerciaux selon lequel « chacune des parties peut, sous réserve de tous dommages et intérêts résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le commettant et l'agent commercial ou en raison d'un manquement grave de l'autre partie à ses obligations ». Ici encore, il s'agit d'une résiliation extrajudiciaire dont le bien-fondé ne sera apprécié qu'*a posteriori* par le juge.

b. *Droit commun*

784. Résolution liée à l'urgence. Il est admis depuis longtemps, dans la lignée de l'article 1657 du Code civil, qu'un contractant peut mettre fin unilatéralement au contrat en cas d'urgence, lorsque les circonstances imposent une rupture immédiate sans qu'il soit possible d'attendre l'intervention d'un juge, même en référé. Par exemple, personne n'a jamais contesté que l'organisateur d'un spectacle peut expulser de la salle un spectateur qui trouble la

[1746] Sur lequel voy. *supra*, n°s 545 et s.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

représentation par son comportement bruyant ou déviant. On peut aussi rattacher à la même idée la possibilité pour le créancier d'une obligation de faire, reconnue depuis longtemps en jurisprudence, de faire exécuter la prestation par un tiers prévue par l'article 1144 du Code civil en se dispensant, s'il y a urgence, de l'autorisation judiciaire normalement nécessaire[1747]. En même temps qu'elle est un mode d'exécution en nature de l'obligation, cette faculté de remplacement se rapproche d' une forme de résolution du contrat initial. Un arrêt de la Cour d'appel de 1998 marque bien le lien entre les deux mécanismes, en posant que « bien que l'article 1184 du Code civil porte que la résolution d'une convention doit être demandée en justice, une partie liée par un contrat synallagmatique et qui se plaint de l'inexécution de l'obligation de son cocontractant peut, dans certaines conditions, rompre unilatéralement le contrat et faire usage de la faculté de remplacement »[1748]. On peut, il est vrai, contester que l'exercice de la faculté de remplacement se traduise techniquement par une rupture du contrat initial, et l'assimilation faite par l'arrêt entre remplacement et résolution est un peu approximative. L'arrêt illustre cependant l'ouverture de la jurisprudence luxembourgeoise vers une admission plus large de la résolution par déclaration unilatérale, en dehors du cas d'urgence.

785. Résolution unilatérale en dehors du cas d'urgence : solutions françaises et belges. Dès avant les réformes du droit des obligations, la jurisprudence, en France et en Belgique, avait admis que, même en l'absence d'urgence, un contractant pouvait mettre fin au contrat sans recourir au juge. En France, la Cour de cassation avait admis, dès 1998, que « la gravité du comportement d'une partie peut autoriser l'autre partie à mettre fin au contrat à ses risques et périls »[1749]. La solution était un peu moins claire en Belgique, où la Cour de cassation avait considéré en 2002 et en 2009 que l'article 1184 du Code civil « ne fait pas obstacle à ce qu'une partie à un tel contrat décide de sa propre initiative et à ses propres risques de ne pas exécuter ses obligations et notifie à son cocontractant qu'elle considère que le contrat a pris fin »[1750]. L'arrêt ne semblait pas considérer que cette notification opérait vraiment résolution

[1747] Voy. *supra*, n° 752.

[1748] Cour d'appel, 16 juin 1998, *Pas.*, 30, p. 493.

[1749] Cass. fr. (1re civ.), 13 octobre 1998, n° 96-21485. Voy. notamment depuis cet arrêt : Cass. fr. (1re civ.), 20 février 2001, n° 99-15170 ; Cass. fr. (3e civ.), 1er décembre 2010, n° 09-16516.

[1750] Cass. be., 2 mai 2002, nos C.99.0277.N et C.01.0185.N, *Pas. be.*, 2002, p. 1051 et Cass. be., 16 février 2009, n° C.08.0043.N, *J.T.*, 2010, p. 352.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

du contrat, celle-ci ne pouvant semble-t-il résulter que de la décision judiciaire qui, *a posteriori*, appréciera si la décision unilatérale du créancier était ou non justifiée. On était ici en présence d'une formule intermédiaire entre la résolution judiciaire traditionnelle et la résolution par déclaration unilatérale. Cependant, dans un arrêt plus récent, la Cour de cassation belge avait nettement consacré le principe de la résolution unilatérale en cas d'inexécution grave, en admettant que l'acte unilatéral produisait effet tant qu'il n'avait pas été déclaré inefficace par le juge[1751]. Ces solutions, qui étaient des exemples remarquables d'une interprétation jurisprudentielle allant contre la lettre de la loi, s'inscrivaient dans un courant européen, déjà signalé, qui tend à déjudiciariser la résolution. Dans les deux pays, la réforme du droit des obligations a prolongé ces solutions jurisprudentielles en donnant au créancier victime de l'inexécution, même en l'absence d'une clause résolutoire, une option entre la résolution judiciaire traditionnelle, et une résolution par voie de déclaration unilatérale adressée au créancier (C. civ. fr., art. 12224, C. civ. be., art. 5.90). Contrairement à la jurisprudence antérieure, où la résolution par déclaration unilatérale était présentée comme une solution exceptionnelle, les deux voies – judiciaire et extrajudiciaire – sont aujourd'hui mises sur le même plan et soumises aux mêmes conditions.

786. Résolution unilatérale en dehors du cas d'urgence : droit luxembourgeois. Déjà présente dans l'arrêt précité de 1998, la faculté de rupture unilatérale du contrat, même en dehors du cas d'urgence, est aujourd'hui bien implantée dans la jurisprudence luxembourgeoise. On la trouve ainsi énoncée dans un arrêt de 2001[1752], et encore dans un arrêt de 2011 selon lequel « un créancier peut exceptionnellement et à ses risques et périls procéder à une résolution unilatérale d'un contrat » si cette rupture « se justifie, entre autres, au vu d'une inexécution ou d'un comportement graves dans le chef des débiteurs »[1753]. Les derniers arrêts rendus en la matière manifestent un alignement total sur la jurisprudence française antérieure à la réforme. Dans un arrêt de 2023, la Cour de cassation, reprenant textuellement la formule française, pose que

[1751] Cass. be., 23 mai 2019, R.G.D.C., 2019 (476), n° 13. Sur cette évolution jurisprudentielle en Belgique, voy. WÉRY, n°s 789 à 799.

[1752] Cour d'appel, 10 juillet 2001, n°s 23107, 23145, 23250, *JurisNews – Regard sur le droit de la construction et immobilier*, 2007, n° 2, p. 7.

[1753] Cour d'appel, 20 octobre 2011, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

« la gravité du comportement d'une partie peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls »… La formule « à ses risques et périls »[1754] signifie que le créancier doit s'attendre à ce que le juge contrôle *a posteriori* le bien-fondé de la rupture et qu'il puisse, éventuellement, la déclarer infondée.

787. Conditions de la résolution par déclaration unilatérale. Dans quels cas est-il possible au créancier de déclarer unilatéralement la résolution ? Pour comprendre la question, il faut poser au départ que, par hypothèse, ces conditions ne seront pas appréciées *a priori* par le juge. Le juge ne pourra intervenir qu'*a posteriori*, généralement à la demande du débiteur à l'encontre de qui le créancier aura décidé unilatéralement de considérer le contrat comme résolu. Et la question est de savoir dans quels cas le juge estimera que la décision du créancier était fondée. Suffit-il pour cela que le juge estime que l'inexécution était suffisamment grave pour que lui-même, si on lui avait demandé, ait accepté de prononcer la résolution ? Ou faut-il un degré supplémentaire de gravité ou d'urgence qui puisse justifier que le créancier ait pu décider de se passer de l'intervention du juge ? Jusqu'à la réforme, la jurisprudence française semblait se montrer plus exigeante pour admettre la résolution unilatérale que pour permettre au juge de prononcer la résolution : une rupture unilatérale sans contrôle préalable du juge ne pouvait être justifiée que par la « gravité du comportement du débiteur », ce qui semblait aller au-delà d'une « inexécution grave ». Là-dessus, la jurisprudence luxembourgeoise précitée a été pendant un temps assez imprécise. L'arrêt de 1998 se contentait de dire que le créancier qui se plaint de l'inexécution de son cocontractant peut rompre unilatéralement le contrat « dans certaines conditions », sans préciser lesquelles. L'arrêt de 2001, beaucoup plus disert, posait que la résolution unilatérale est possible « dès lors que le contrat implique, également en cours d'exécution l'existence d'une relation de confiance entre parties et que l'une d'elles manque gravement à ses obligations, si bien que l'autre partie risque de subir un grave préjudice et ne peut de ce fait limiter sa riposte à l'exception d'inexécution. Ce n'est pas seulement la gravité de la faute du cocontractant qui peut justifier la résolution unilatérale ; se sont aussi les conséquences qui résulteraient d'une attente du prononcé par les juges de l'anéantissement du contrat. L'urgence justifie une résolution immédiate lorsque le préjudice du

[1754] Cass., 12 janvier 2023, *Pas.*, 41, p. 355. Voy. aussi Cour d'appel, 7 juillet 2022, n° CAL-2021-00945 ; Cour d'appel, 22 février 2024, n° CAL-2021-00898.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

créancier s'aggraverait constamment s'il devait attendre une décision judiciaire ». L'arrêt mêlait deux critères, dont on ne savait pas bien s'ils sont cumulatifs ou alternatifs : d'une part la « gravité de la faute », en violation de la confiance, d'autre part le critère plus traditionnel de l'urgence à faire tomber le contrat. Quant à l'arrêt de 2011, il estimait que cette rupture « se justifiait, entre autres, au vu d'une inexécution ou d'un comportement graves dans le chef des débiteurs » – ce qui mêlait le critère objectif de la gravité de l'inexécution et celui, subjectif, de la gravité du comportement, et qui, par l'emploi de l'expression « entre autres », laissait la porte ouverte à d'autres justifications. Mais, comme on l'a dit, les arrêts les plus récents semblent s'être ralliés purement et simplement au critère posé par la jurisprudence française antérieure à la réforme, en subordonnant la résolution par déclaration unilatérale à la « gravité du comportement du débiteur ». Cette exigence supplémentaire semble se justifier si on considère que, dans le droit luxembourgeois actuel, la résolution par déclaration unilatérale apparaît comme une exception au principe de la résolution judiciaire clairement posé par l'article 1184. On peut cependant se demander s'il est bien praticable de subordonner la résolution par déclaration unilatérale à des conditions spécifiques distinctes de celles qui sont normalement requises pour la résolution judiciaire, et si la distinction entre l'inexécution grave – objective – et le comportement grave du débiteur – subjectif – est tenable. C'est pourquoi on peut penser que l'évolution – jurisprudentielle ou législative – tendra à aligner purement et simplement les conditions de la résolution par déclaration unilatérale sur celles de la résolution judiciaire, et à laisser au créancier le choix entre les deux voies, comme l'ont fait les législateurs en France et en Belgique.

788. Formes de la résolution par déclaration unilatérale. Ce qui est sûr, en tout cas, est que la résolution unilatérale, si on l'admet, doit être subordonnée à un certain formalisme destiné à protéger le débiteur. Comme pour la mise en œuvre d'une clause résolutoire, et pour les mêmes raisons, il est indispensable que le créancier qui a l'intention de mettre fin au contrat mette en demeure le débiteur d'exécuter, et, si l'exécution est encore possible, lui laisse un certain délai pour y procéder – même dans le cas où un délai précis a été fixé pour l'exécution, où, selon l'article 1146, alinéa 2, la mise en demeure n'est pas nécessaire pour obtenir des dommages et intérêts. L'arrêt de 1998 pose très clairement ces

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

exigences : statuant dans une affaire où un maître de l'ouvrage, mécontent du travail fait par l'entrepreneur, avait spontanément fait appel à un autre entrepreneur, sans même prévenir le premier, il juge que « pour pouvoir agir de la sorte, il faut que le créancier ait mis le débiteur en demeure et lui ait laissé un temps raisonnable pour qu'il puisse exécuter son obligation. Il faut ensuite que le remplacement ait lieu aussitôt après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure infructueuse. Il faut ensuite que le cocontractant qui a failli à son obligation soit averti du remplacement, de manière qu'il ne prenne plus ses dispositions pour tenter encore d'exécuter le contrat »[1755]. On peut cependant penser que l'octroi d'un délai supplémentaire n'est pas nécessaire si l'exécution est devenue définitivement impossible, ou si l'urgence est telle qu'il n'est pas possible d'attendre plus longtemps. Dans de tels cas, la résolution sera simplement subordonnée à une notification au débiteur. L'exigence d'une mise en demeure pour la mise en œuvre de la résolution par déclaration unilatérale est aujourd'hui clairement posée par l'article 5.80 du nouveau Code civil belge (avec les limites applicables à toute mise en demeure), et par l'article 1226 du Code civil français. Le formalisme de cette résolution par déclaration est particulièrement accusé en droit français : la mise en demeure doit, sauf urgence, laisser au débiteur un délai raisonnable pour s'exécuter, elle doit « mentionner expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat », et la notification de résolution que le créancier doit adresser au débiteur si l'inexécution persiste doit préciser les raisons qui motivent cette résolution (c'est aussi le cas en droit belge). Ce formalisme manifeste une certaine réticence des auteurs de la réforme française par rapport à cette forme de résolution.

Les textes internationaux et la plupart des projets européens consacrent un système un peu différent, très inspiré du droit allemand, qui repose sur une gradation dans la gravité de l'inexécution. La résolution peut être déclarée sans délai si on est en présence d'une « inexécution essentielle » du contrat (Unidroit, art. 7.3.1 ; PDEC, art. 9 : 301 ; DCEV, art. 87), d'une « contravention essentielle » (CVIM, art. 72) ou d'une « fundamental non-performance » (DCFR, art. III-3 : 502). En revanche, si le débiteur est simplement en retard pour exécuter et que ce retard n'est pas une inexécution essentielle, la résolution peut quand même être obtenue, mais seulement après que le créancier ait fixé au débiteur un délai supplémentaire pour s'exécuter (Unidroit, art. 7.3.1, PDEC ; art. 9 : 301 ; DCFR, art. III-3 : 502 ; DCEV, art. 87). Les nouveaux textes français et belges ne reprennent pas cette distinction.

[1755] Cour d'appel, 16 juin 1998, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

789. Effets de la résolution par déclaration unilatérale. La déclaration unilatérale, tout comme la mise en jeu d'une clause résolutoire, se déroule sous le contrôle *a posteriori* du juge. Celui-ci peut être saisi soit par le débiteur – qui conteste la résolution que lui impose le créancier – soit par le créancier lui-même, s'il ne parvient pas à obtenir concrètement les résultats de la résolution (par exemple, si le débiteur refuse de lui restituer les prestations déjà exécutées). Le juge va alors vérifier si les conditions de fond de la rupture unilatérale étaient réunies et si les formes ont été respectées. Son pouvoir de contrôle est plus important ici que dans le cas du jeu d'une clause résolutoire, car il va pouvoir apprécier si l'inexécution était suffisamment grave pour justifier la décision du créancier. Si ce n'est pas le cas, le créancier pourra, au minimum, être condamné à des dommages et intérêts. C'est en ce sens que la Cour de cassation française disait que la résolution unilatérale a lieu « aux risques et périls » du créancier, formule reprise par la Cour d'appel du Luxembourg dans ses arrêts les plus récents, ainsi que par les nouveaux textes français et belges. Si le créancier n'est pas sûr de son fait, il peut avoir intérêt à saisir le juge pour faire prononcer une résolution judiciaire.

Si la décision unilatérale de résolution est jugée fondée, le juge déclarera la résolution (il ne la prononcera pas, puisqu'elle se sera produite avant). La résolution produira alors les mêmes effets que si elle avait été prononcée, mais à compter du jour de la notification.

Si en revanche le juge estime la résolution mal fondée, la question se pose de savoir s'il peut faire revivre le contrat et en ordonner l'exécution. Le problème est exactement le même que dans le cas de l'invocation illicite ou abusive d'une clause résolutoire. Comme on l' a vu, dans les deux cas, l'article 5.94 du nouveau Code civil belge dispose que « la notification par laquelle le créancier résout le contrat est inefficace si les conditions de la résolution ne sont pas remplies ou si elle est abusive », ce qui signifie que le juge pourra ordonner l'exécution du contrat irrégulièrement résolu si elle est encore possible. Cette solution semble avoir été consacrée par un arrêt de la Cour d'appel du Luxembourg en date du 11 janvier 2022[1756]. Le Code civil français ne contient pas la même disposition, mais il offre au débiteur, prévenu par la mise en demeure, de saisir à tout moment le juge pour contester la résolution, le créancier

[1756] N° CAL-2020-00481, *JN Obligations*, 2022, n° 4, pp. 127-128, note H. WESTENDORF.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

devant alors prouver la gravité de l'inexécution (C. civ. fr., art. 1226, al. 4). Cette disposition devrait permettre d'éviter, dans la plupart des cas, que la résolution ne soit jugée illicite qu'*a posteriori*.

D) *La résolution en cas de force majeure*

790. Résolution de plein droit ?. Comme on l'a dit précédemment, la force majeure, lorsqu'elle rend définitivement impossible l'exécution du contrat par un contractant, entraîne en principe la résolution de ce contrat, ce qui libère en principe le cocontractant de ses obligations, sauf dans le cas des contrats translatifs de propriété[1757]. La question se pose alors de savoir si le contractant qui souhaite être libéré – qu'il s'agisse du contractant empêché ou de son cocontractant, doit agir en justice conformément au principe posé par l'article 1184 du Code civil. En droit français, avant la réforme, la Cour de cassation avait posé le principe selon lequel l'article 1184 du Code civil était applicable quelle que soit la cause de l'inexécution, ce qui imposait au contractant qui se prévalait de l'inexécution pour force majeure d'agir en justice pour obtenir la résolution[1758]. Dans les années récentes, la question était très discutée, et certains auteurs plaidaient pour la reconnaissance, en cas de force majeure, d'une résolution de plein droit – solution du reste prévue par l'article 1722 en matière de bail dans le cas de la perte totale de la chose louée. Consacrant cette opinion, le nouvel article 1218 du Code civil français a condamné la jurisprudence antérieure en posant que, si l'empêchement résultant de la force majeure est définitif, « le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations ». La formule « de plein droit » signifie que celui qui se prévaut de la résolution n'a même pas besoin d'adresser une notification à l'autre partie. Si celle-ci agit en justice pour demander l'exécution, ou faire sanctionner l'inexécution, le juge appréciera *a posteriori* si on était bien dans une situation de force majeure. La même solution est prévue par l'article 5.100 du nouveau Code civil belge, selon lequel « lorsque l'impossibilité d'exécuter une obligation principale est totale et définitive sans être imputable au débiteur, le contrat est dissous de plein droit en sa totalité ». La position actuelle des tribunaux luxembourgeois

[1757] Voy. *supra*, n° 767 et 768.

[1758] Jurisprudence constante depuis Cass. fr. (civ.), 14 avril 1891, n° 000044 ; *GAJC*, 11e éd., n° 176 ; *DP*, 1891, 1, 329, note PLANIOL ; Cass. fr. (1re civ., 2 juin 1982, n° 81-10.158: *Bull. civ.*, I, n° 205 ; Cass. fr. (1re civ.), 12 mars 1985, *Bull. civ.*, I, n° 94 ; *RTD civ.*, 1986, 345, obs. MESTRE.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

n'est pas facile à connaître sur ce sujet. En dehors des nombreuses décisions qui font application du mécanisme de résolution de plein droit de l'article 1722 du Code civil, on ne peut guère citer qu'un jugement de 2009 du tribunal de Luxembourg qui déclare suivre la position de la jurisprudence française[1759]. En réalité, il faut bien distinguer deux questions. La première est celle des effets de la force majeure sur l'obligation du débiteur empêché : s'il est définitif, l'empêchement libère le débiteur, et cette extinction opère de plein droit, sans qu'il soit nécessaire ni même pertinent de passer par le mécanisme de la résolution. C'est dire que le débiteur peut se contenter d'invoquer la force majeure en défense si le créancier lui demande l'exécution de son obligation ou des dommages et intérêts, sans qu'on puisse lui reprocher de n'avoir pas demandé antérieurement la résolution[1760]. Tout autre est la question de savoir quel est le sort du contrat suite à cette libération du débiteur. C'est une question qui intéresse le créancier du débiteur empêché : dès lors qu'on n'est pas dans le cas d'un contrat translatif de propriété, le créancier se trouve dans la situation de n'importe quel créancier victime de l'inexécution quelle qu'en soit la cause, et, s'il veut être libéré il doit demander la résolution sur le fondement de l'article 1184. Il doit donc demander la résolution en justice, le juge appréciant alors si l'inexécution ou le retard d'exécution est suffisamment grave pour la justifier.

§ 3. Les effets de la résolution

791. Distinction selon le type de contrat. La résolution se traduit, d'une manière générale, par l'anéantissement du contrat et par la libération des deux parties. On enseigne traditionnellement que cet anéantissement est en principe rétroactif (**A**) et total (**B**), mais les deux affirmations méritent d'être nuancées.

A) *Anéantissement rétroactif ?*

792. Distinction. Parce qu'elle est présentée, dans le Code civil, comme la conséquence du jeu d'une condition résolutoire sous-entendue, la résolution produit traditionnellement, dans les pays du Code, un effet rétroactif, le même que celui que l'article 1183 du

[1759] Trib. Luxembourg, 7 juillet 2009, n°s 114440 et 120356 (jonction).

[1760] Dans ce sens en France dès avant la réforme : Cass. fr. (comm.), 28 avril 1982: *Bull. civ.*, IV, n° 145 ; *RTD civ.*, 1983, 340, obs. CHABAS.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Code civil pour la condition résolutoire en général[1761] : elle « remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé ». Ce principe, cependant, ne joue pas de la même manière dans les contrats dits « à exécution instantanée » et ceux qui sont « à exécution successive ».

1) *Contrats à exécution instantanée*

793. Principe de rétroactivité. On rappellera d'abord que nous entendons ici par contrats à exécution instantanée non seulement ceux qui sont exécutés en un seul trait de temps (une vente au comptant, par exemple), mais encore ceux dont l'exécution s'étale ou s'échelonne dans le temps, dès lors que les différents actes d'exécution sont considérés comme formant un tout indivisible (vente avec paiement échelonné du prix, prestations de services en vue d'un résultat déterminé, etc.)[1762]. Dans ce type de contrats, la résolution va globalement produire les mêmes effets que la nullité (ce qui explique que les deux mécanismes soient souvent confondus) : non seulement chacun des contractants est libéré pour l'avenir, mais les effets produits dans le passé sont remis en cause. Chaque contractant doit restituer ce qu'il a reçu en exécution du contrat ; si le contrat avait transféré la propriété d'un bien (vente), on va considérer que l'acquéreur n'a jamais été propriétaire. Du coup, les actes qu'il avait pu passer sur le bien dont la propriété lui avait été transférée doivent eux-aussi être annulés. Toutes les difficultés que nous avons étudiées en matière de nullité se retrouvent ici : quant au calcul des restitutions, quant aux conséquences de l'impossibilité de restituer, quant à la protection des tiers de bonne foi, etc.[1763].

Parce qu'elle est liée à une analyse elle-même très contestable du mécanisme de la résolution, cette rétroactivité est depuis quelque temps contestée dans la doctrine des pays du Code civil. Si on peut comprendre que la nullité – qui repose sur une absence initiale des conditions de validité du contrat – opère de manière rétroactive, on ne comprend pas pourquoi la résolution, fondée sur une mauvaise exécution d'un contrat valable *ab initio*, doit se traduire par un anéantissement rétroactif, source de multiples inconvénients. L'essentiel, pour assurer l'efficacité de la sanction que constitue la résolution, c'est que le créancier soit libéré à l'avenir, et qu'il puisse récupérer ce qu'il a déjà versé en exécution du contrat annulé, ainsi que la propriété des biens qui aurait été transférée par le contrat. Mais il n'est sans doute pas utile, pour

[1761] Voy. *supra*, n° 603.

[1762] Voy. *supra*, n°s 542 et 543.

[1763] Voy. *supra*, n°s 458 et s. Sur les effets de la résolution, voy. O. Poelmans, note sous Cour d'appel, 10 janvier 2018, n° 44077, *JN Obligations*, 2018, n° 4, pp. 61-64.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

aboutir à ces résultats, de passer par l'affirmation de la rétroactivité de la résolution. C'est pourquoi, dans de nombreux droits étrangers, on considère que la résolution met seulement fin au contrat pour l'avenir, et les projets européens vont tous dans le même sens[1764]. Le nouveau droit français (art. 1229) abandonne lui aussi la rétroactivité de la résolution, en posant simplement que « La résolution met fin au contrat », cet effet se produisant, selon les cas, « soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ». Cet abandon de la rétroactivité ne fait cependant pas obstacle aux restitutions des prestations échangées, du moins lorsque ces prestations « ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu » – ce qui vise ce qu'on appelle traditionnellement les contrats à exécution instantanée. La différence avec l'approche traditionnelle apparaît surtout en ce qui concerne les tiers, dont les droits ne seront pas par principe affectés par la résolution. Le droit belge maintient quant à lui dans l'article 5.95 le principe de la rétroactivité, mais en l'écartant à l'égard des tiers de bonne foi.

2) *Contrats à exécution successive*

794. Résiliation. Il s'agit ici des contrats dont l'exécution est échelonnée dans le temps, sans que l'addition des différentes prestations constitue un tout indivisible. On enseigne traditionnellement que la résolution de ces contrats n'opère pas de manière rétroactive, les contractants étant seulement libérés pour l'avenir. On parle alors, non pas de résolution, mais de résiliation. L'affirmation se vérifie dans la plupart des cas : ainsi, dans un contrat de bail, si le locataire cesse de payer ses loyers, le bail ne sera résilié que pour l'avenir, le bailleur n'ayant pas à restituer les loyers pour la période passée. On croit souvent que la solution tient à l'impossibilité de restituer les prestations passées (ici l'impossibilité pour le locataire de restituer la jouissance des lieux pendant la période antérieure à la résiliation). Mais ce n'est pas la bonne explication : la résiliation n'aurait pas davantage de caractère rétroactif si les prestations qui ont été fournies étaient parfaitement restituables (par exemple, un contrat d'abonnement à une revue, que l'abonné cesserait de payer). La raison d'être de la solution est plutôt qu'il n'y a aucune raison d'ordonner des restitutions pour la période pendant laquelle le contrat a été correctement exécuté. Mais cette justification dicte les limites de la solution : si le contrat à exécution successive n'a jamais été correctement exécuté (par exemple, le bailleur n'a jamais assuré la jouissance paisible du locataire), alors la résolution doit jouer, comme dans un contrat à exécution instantanée, de manière

[1764] Voy. R. WINTGEN, « La retroactivité de l'anéantissement en droit comparé », *R.D.C.*, 2008/1, p. 73.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

rétroactive, et il doit y avoir restitution de toutes les prestations versées. C'est donc au fond la même règle qui s'applique dans les contrats à exécution successive et dans les contrats à exécution instantanée : la résolution est ou non rétroactive, selon l'économie du contrat et le moment où a commencé l'inexécution. La formule de l'article 5.95 du nouveau Code civil belge est clairement en ce sens : tout en maintenant, comme on l'a dit, le principe de l'anéantissement du contrat résolu depuis le jour de sa conclusion, le texte ajoute que « [t]outefois, elle ne rétroagit qu'à la date du manquement qui y a donné lieu pour autant que le contrat soit divisible dans l'intention des parties, eu égard à sa nature et à sa portée ». En droit français, où le principe de rétroactivité est formellement abandonné, l'article 1229 précise que « [l]orsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». On remarquera que, dans les deux pays, le critère traditionnel de la distinction entre résolution et résiliation, lié à la distinction entre contrats à exécution instantanée et à exécution successive, a été remplacé par un critère plus concret (la divisibilité dans le temps en droit belge, l'utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque en droit français).

Attention à ne pas confondre cette « résiliation-sanction » – qui n'est qu'une variété non rétroactive de résolution pour inexécution – et la résiliation unilatérale des contrats à exécution successive et à durée indéterminée, qui est un droit pour les contractants, qui s'exerce sans recours préalable au juge et qui n'est pas subordonnée à la preuve d'une inexécution des obligations du cocontractant.

B) *Anéantissement total ?*

795. Principe. À la différence de la nullité, la résolution ne concerne, en principe, que le contrat tout entier. On ne conçoit pas de résolution partielle au sens où on connaît une nullité partielle n'affectant que certaines clauses du contrat[1765]. De deux choses l'une en effet, si une clause particulière fait naître une obligation spécifique qui n'est pas exécutée (par exemple, la clause interdisant à un locataire d'exercer telle ou telle activité dans les lieux loués) : ou bien on considère que l'inexécution de cette obligation est suffisamment grave pour faire tomber le contrat tout entier, ou bien on estime que ce n'est pas le cas et alors cela n'a aucun sens

[1765] Voy. *supra*, n° 472.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de faire tomber la clause sans le contrat. On peut cependant envisager une résolution partielle dans le cas où l'inexécution ne concerne qu'une partie du contrat, pouvant être séparée des autres parties. Le contractant victime peut alors vouloir conserver le contrat pour sa partie exécutée, et obtenir sa résolution pour l'autre partie : si j'ai acheté du matériel avec une clause obligeant mon vendeur à en assurer l'entretien, que le matériel m'est livré, mais que l'entretien n'est pas assuré, je peux demander la résolution pour la partie « entretien » – ce qui me permettra de ne pas payer le prix de cette partie et de passer un contrat d'entretien avec un autre prestataire – tout en gardant le matériel et en en payant le prix. L'inexécution partielle se traduira donc par une résolution partielle[1766].

On rapproche parfois de la résolution partielle le cas où la chose n'étant pas intégralement livrée, ou non conforme, ou le service n'étant pas intégralement rendu, le créancier choisit de s'en contenter, sauf à payer un prix moindre. Cette analyse est sans doute artificielle : celui qui demande la réduction du prix ne veut pas, par hypothèse, être débarrassé du contrat, il souhaite au contraire le garder à des conditions plus avantageuses. Nous verrons plus loin que la réduction du prix, qui est une forme de réfaction du contrat, est aujourd'hui traitée comme une sanction à part entière, distincte de la résolution.

796. Portée de l'anéantissement du contrat résolu. L'anéantissement du contrat résolu n'a pas la même portée que celui d'un contrat annulé. Ici, ce n'est pas, comme dans le cas de nullité, la norme contractuelle elle-même qui est anéantie, et qui prive le contrat de force obligatoire, ce sont seulement les effets – obligationnels et réels – du contrat qui sont remis en cause. La différence la plus sensible avec la nullité tient à ce que le contractant qui, par hypothèse, n'a pas exécuté les obligations dont il était tenu, devra, en plus de perdre le bénéfice du contrat, payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'autre. Or cette responsabilité, bien que fondée sur un contrat résolu, sera considérée – même si l'anéantissement est rétroactif – comme une responsabilité contractuelle, parce que résultant de l'inexécution d'obligations contractuelles. Et, si le contrat contenait une clause pénale – fixant le montant des dommages et intérêts dus en cas d'inexécution[1767] – cette clause restera

[1766] Voy. C. RIGALLE, *La résolution partielle du contrat,* pref. C. JAMIN, Paris, Dalloz, 2003.
[1767] Voy. *infra*, n°s 866 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

applicable nonobstant la résolution. Il devrait en aller de même de toutes les clauses relatives à la responsabilité[1768], ainsi que des clauses diverses destinées à organiser le traitement des différends entre les parties (clause de conciliation, clause compromissoire, clause attributive de compétence juridictionnelle, etc.) ou de celles qui servent à organiser la période post-contractuelle (clauses de non-concurrence). Toutes ces clauses ont en effet la même raison de jouer en cas de résolution que si le contrat prend fin pour une autre cause. Le nouvel article 1230 du Code civil français dispose en ce sens que « la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence ».

797. Extension de l'anéantissement. Comme en matière de nullité, le contrat résolu peut entraîner dans sa chute d'autres contrats qui lui sont liés[1769]. C'est ainsi que, dans une opération de *leasing* (crédit-bail dans la terminologie française). Si le bien loué est défectueux, le locataire peut demander la résolution de la vente de ce bien par le fournisseur à l'établissement de crédit bailleur ; cette résolution entraînera la résiliation du contrat de bail, libérant le locataire du paiement des loyers pour l'avenir. On retrouve ici la théorie des ensembles contractuels étudiée à propos de la caducité du contrat[1770].

[1768] *Contra*, en droit français, une décision aberrante de Cass. fr. (comm.), 5 octobre 2010, n° 08-11630, qui juge que les clauses limitatives de responsabilité prévues dans le contrat ne jouent pas en cas de résolution.

[1769] Voy. *supra*, n° 478.

[1770] Voy. not. en droit français S. Amrani-Mekki, Indivisibilité et ensembles contractuels : l'anéantissement en cacade des contrats, Defrénois, 2002, p. 355.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le sort du contrat inexécuté, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 813-889
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

SECTION 3. LA RÉDUCTION DU PRIX

798. Absence de principe général. La possibilité pour le créancier d'obtenir, en cas d'exécution imparfaite de l'obligation du débiteur, une réduction du prix – appelée souvent réfaction du contrat – est admise par un certain nombre de textes spéciaux. On en connaît, dans le Code civil, une application très importante avec l'action estimatoire qui permet à l'acheteur victime d'un vice caché de la chose de demander, au lieu de la résolution de la vente (action rédhibitoire), la diminution du prix (C. civ., art. 1644), et on retrouve cette possibilité dans la réglementation spéciale de la garantie des biens de consommation (C. consomm., art. L. 212-5).

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réduction du prix, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 889-891
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

À côté de ces textes, qui nourrissent l'essentiel du contentieux en la matière devant les juridictions luxembourgeoises, on peut citer l'article 1617 du Code civil selon lequel, si le vendeur ne délivre pas la contenance prévue au contrat, l'acheteur peut demander une réduction du prix. Le Code civil prévoit également des cas de réduction des loyers en matière de bail (C. civ., art. 1722, 1769, 1770). Par ailleurs, en matière de ventes commerciales, la jurisprudence, dans les trois pays du Code civil, admet traditionnellement, à titre d'usage, la possibilité pour le juge, en cas de petits défauts de conformité des marchandises livrées, de refuser la résolution et de procéder à une réduction du prix[1771]. Cependant, on considère généralement que, en dehors de ces cas particuliers, la réduction du prix n'est pas un remède général à l'inexécution des contrats, ce qui s'explique par la réticence traditionnelle de la doctrine à reconnaître au juge un pouvoir de modification du contenu du contrat. Cette position n'a cependant qu'une portée pratique très limitée. D'une part, il est très fréquent que le contractant mécontent se contente d'adresser un paiement partiel à son cocontractant. Si ce dernier agit en justice pour obtenir un paiement total, et que le juge reconnaît le bien-fondé de la contestation, il est peu probable qu'il condamne néanmoins le débiteur à des dommages et intérêts pour avoir procédé de lui-même, sans en avoir le droit, à une réduction du prix. D'autre part, même s'il n'a pas droit à obtenir directement une réduction du prix, le contractant insatisfait peut obtenir un résultat équivalent en se contentant, au lieu de demander la résolution, de demander des dommages et intérêts compensant le préjudice résultant de la mauvaise exécution. En pratique, dans les décisions luxembourgeoises, on voit souvent le contractant demander la réduction du prix et, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts[1772]. Aussi bien la consécration récente, en France et en Belgique, de la réduction du prix comme un remède général à l'inexécution des contrats, ne devrait avoir qu'une portée limitée.

799. Reconnaissance en France et en Belgique. La plupart des textes internationaux et des projets européens reconnaissent la réduction du prix comme une des sanctions possibles de l'inexécution. Les réformes française et belge se sont inscrites dans ce

[1771] Voy. déjà : Cour d'appel, 30 avril 1926, *Pas.*, 11, p. 249.
[1772] Voy. p. ex. Cour d'appel, 26 juin 2024, n° CAL-2022-00206.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réduction du prix, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 889-891
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

courant[1773]. Dans les nouveaux textes, la réduction du prix apparaît dans la liste générale des sanctions de l'inexécution (C. civ. fr., art. 1217, C. civ. be., art. 5.83, 4°). Mais elle fait ensuite l'objet d'une réglementation assez différente dans les deux pays. En France, l'article 1223 du Code civil reconnaît au créancier, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, de notifier au débiteur après mise en demeure, sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. Cependant cette réduction extrajudiciaire – qui apparaît comme un pendant de la résolution par déclaration unilatérale – ne produit effet que si elle est acceptée par écrit par le cocontractant. À défaut, le débiteur du prix est censé demander la réduction du prix en justice, il ne peut pas se contenter d'adresser un paiement partiel. Il en va de même s'il a déjà payé. L'apport principal du texte est de reconnaître de manière générale au juge un pouvoir de réduction du prix, car on ne voit pas bien l'intérêt du système de réduction extrajudiciaire dès lors qu'il suppose l'accord du cocontractant (ce qui était de toute façon possible dans le droit antérieur, et qui l'est certainement en droit luxembourgeois). Le système belge paraît plus satisfaisant : comme en matière de résolution, l'article 5.97 du nouveau Code civil donne au créancier de l'exécution imparfaite, lorsque l'inexécution n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution, le choix entre demander la réduction du prix en justice, et adresser à son cocontractant une notification écrite indiquant la cause de la résolution – le juge étant supposé apprécier *a posteriori* le bien-fondé de cette réduction unilatérale. Le texte précise que le créancier qui obtient la réduction du prix ne peut exiger de réparation pour compenser cette différence de valeur, mais qu'il peut réclamer des dommages et intérêts pour tout autre dommage.

[1773] CVIM, art. 50 (texte en vigueur au Luxembourg) ; PDEC, art. 9 : 401 ; DCFR, art. III.3 : 601.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réduction du prix, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 889-891
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

SECTION 4. LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE CAUSÉ PAR L'INEXÉCUTION[1774]

800. Dommages et intérêts contractuels. En plus ou à la place des autres sanctions précédemment étudiées, le contractant victime de l'inexécution peut obtenir la condamnation de son débiteur défaillant à des dommages et intérêts. Il le peut *en plus des*

[1774] Pour une étude détaillée de la question, avec toute la jurisprudence récente, voy. RAVARANI, n°s 477 à 774.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

autres sanctions, chaque fois qu'ayant demandé l'exécution, il obtient celle-ci avec retard, ou que, le contrat ayant été résolu, il se trouve privé des avantages qu'il attendait du contrat. Il le peut *à la place des autres sanctions*, si le débiteur s'est finalement refusé à exécuter en nature ou si l'inexécution ou la mauvaise exécution est définitivement consommée. Dans le Code civil, ces dommages et intérêts sont prévus par divers textes. L'article 1142 du Code civil, déjà rencontré, prévoit que toute obligation de faire ou de ne pas faire inexécutée « se résout en dommages et intérêts[1775]. Puis le Code consacre une section entière, de l'article 1146 à l'article 1155, aux « dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation ». On retrouve ensuite mention de ces dommages et intérêts à l'article 1184 du Code civil, qui, comme on le sait, donne au créancier une option entre l'exécution forcée et la résolution, « avec dommages et intérêts », puis à l'article 1229 du Code civil relatif à la clause pénale, « compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution » etc. sans parler des nombreux textes relatifs aux sanctions de l'inexécution des contrats spéciaux. Si la réforme française de 2016 a modifié quelques-uns de ces textes (l'article 1142, les textes relatifs aux clauses), les articles 1146 à 1155, qui concentrent l'essentiel de la matière ont simplement été renumérotés (ils sont devenus les articles 1231-1 à 1231-7) et n'ont subi que de légères retouches sur le fond, dans l'attente d'une réforme d'ensemble de la responsabilité civile. En Belgique, en revanche, les textes sur les dommages et intérêts contractuels ont été revus, bien que sans changement majeur, dans le cadre de la réforme du droit des obligations de 2023. La matière est aujourd'hui réglée aux articles 5.86 à 5.89 du nouveau Code civil belge.

801. Responsabilité ou exécution ? Les juristes des pays du Code civil considèrent aujourd'hui majoritairement ces dommages et intérêts liés à l'inexécution du contrat comme une forme de responsabilité civile, qu'ils mettent sur le même plan que la responsabilité délictuelle prévue par les articles 1382 et suivants du Code. Dans les deux cas, les dommages et intérêts ont pour but de réparer un préjudice subi, la différence étant que, dans le cas de la responsabilité

[1775] Dans le Code civil, il est question des « dommages et intérêts ». Dans le langage juridique moderne, on parle plutôt des « dommages et intérêts ». On peut employer l'un ou l'autre terme.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

délictuelle, le fait dommageable s'est produit en dehors de toute relation contractuelle préexistante entre la victime et l'auteur du dommage[1776], alors que dans le cas de la responsabilité contractuelle, le dommage est lié à l'inexécution d'une obligation contractuelle.

Depuis une vingtaine d'années, cette vision a été contestée en France par un important courant doctrinal, qui a prétendu montrer la « fausseté » du concept de responsabilité contractuelle[1777]. Pour les auteurs appartenant à ce courant, les dommages et intérêts contractuels ne seraient pas une forme de réparation du préjudice subi par le créancier, mais, très différemment, un mode d'exécution du contrat, se substituant à l'exécution en nature que le créancier n'a pas pu obtenir ou n'a obtenu que tardivement, en d'autres termes une exécution par équivalent. La vision moderne, qui ne semble être apparue que tardivement, au début du XXe siècle, serait le fruit d'une mauvaise lecture des articles du Code. Cette nouvelle conception (présentée comme un retour à la vérité ancienne) a toutes sortes de conséquences, notamment quant aux conditions de l'octroi des dommages et intérêts (qui ne supposerait pas la preuve d'un préjudice) et à leur évaluation. Elle conduit par ailleurs à un rétrécissement du champ de la « responsabilité contractuelle », qui ne devrait concerner que les cas de non-accomplissement de la prestation prévue au contrat (dommages et intérêts intrinsèques), à l'exclusion de tous les dommages périphériques, extrinsèques (dommages à la personne ou aux biens consécutifs à la mauvaise exécution) justiciables des seuls articles 1382 et suivants du Code civil.

Cette conception, qui a influencé quelques décisions de la jurisprudence française, et qui marque profondément un des projets doctrinaux de réforme du droit des obligations[1778], semble cependant difficile à concilier avec les solutions généralement reçues dans les pays du Code civil, et en particulier au Luxembourg[1779]. Il

[1776] D'une manière générale, dans ces développements, nous prendrons les deux termes de « dommage » et de « préjudice » comme synonymes. Sur la différence qu'on pourrait établir, voy. *infra*, n° 830.

[1777] C'est l'intitulé d'un article très marquant de Ph. REMY, « La "responsabilité contractuelle" : histoire d'un faux concept », *RTD civ.*, 1997 pp. 323 et s. Avant lui, l'idée avait déjà été développée par : D. TALLON, « L'inexécution du contrat : pour une autre présentation », *RTD civ.*, 1994, p. 223 ; Ph. LE TOURNEAU, *Droit de la responsabilité et des contrats*, 8e éd., coll. Dalloz Action, Paris, Dalloz, 2010, n°s 802 et s.

[1778] Il s'agit du projet Terré dont Ph. Remy est un des auteurs.

[1779] RAVARANI, n° 21.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

est vrai que, dans un cas particulier, les dommages et intérêts ont bien cette fonction d'exécution par équivalent : c'est le cas, prévu par l'article 1142 du Code civil, où le créancier, ne pouvant obtenir l'exécution en nature, doit se contenter de l'octroi d'une somme d'argent qui lui permettra d'obtenir par ailleurs cette exécution (par exemple, à défaut de pouvoir obtenir que l'entrepreneur démolisse et reconstruise une maison non conforme aux plans, l'octroi d'une somme permettant de financer cette démolition et cette reconstruction). Cette fonction est essentielle dans les droits de *common law*, où, on l'a vu, la *specific performance* ne peut normalement pas être obtenue, et il n'est pas étonnant que la conception des dommages et intérêts comme exécution par équivalent ait été en particulier remise au goût du jour en France par un comparatiste spécialiste de *common law*[1780]. Mais, dans les pays du Code civil, où l'exécution en nature est aujourd'hui le principe, les dommages et intérêts ont vocation, dans l'immense majorité des cas, non pas à se substituer à l'exécution, mais bien à réparer le préjudice subi du fait de l'inexécution ou du retard dans l'exécution. Il est bien difficile de voir une forme d'exécution, en particulier, dans les dommages et intérêts qui s'ajoutent à la résolution du contrat, alors que celle-ci, on l'a vu, est précisément une solution alternative à l'exécution. C'est également clairement de réparation, et non d'exécution, qu'il est question lorsque la victime d'un accident survenu dans le cadre de l'exécution d'un contrat se plaint d'un manquement de son cocontractant à l'obligation de sécurité qui pesait sur lui. Il est vrai que les auteurs partisans de l'idée d'exécution par équivalent voudraient sortir ces obligations de sécurité du domaine de la responsabilité contractuelle, mais cette position, qui repose sur une conception très volontariste du contrat, reviendrait à remettre en cause une évolution jurisprudentielle plus que centenaire[1781]. C'est néanmoins ce que fait, en France, le projet ministériel de réforme de la responsabilité civile de 2017, qui prévoit que la réparation des dommages à la personne relève par principe de la responsabilité extracontractuelle, dans la lignée directe du projet Terré – alors même que ce projet ministériel, par ailleurs, consacre nettement la fonction de réparation des dommages et intérêts contractuels.

[1780] D. TALLON, « L'inexécution du contrat : pour une autre présentation », *op. cit.*

[1781] Voy. dans ce sens, en Belgique, où le débat français ne semble pas avoir eu une grande répercussion : WÉRY, n° 533 ; B. DUBUISSON, « Questions choisies en droit de la responsabilité contractuelle », in *La théorie générale des obligations*, 1998, p. 101.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

802. Unité ou dualité des responsabilités délictuelle et contractuelle[1782]**.** Le Code civil réglemente de manière complètement séparée la réparation des dommages selon qu'elle est causée en dehors ou dans le cadre d'un contrat : articles 1382 et suivants du Code civil dans le premier cas, articles 1147 et suivants du Code civil (principalement) dans le second. Au-delà d'un certain nombre de constantes, ces règles, nous le verrons, sont en partie différentes, même si, au fil du temps, ces différences ont eu tendance à s'atténuer dans la jurisprudence. Les deux types de responsabilité, cependant, visent des hypothèses qui peuvent être très proches : par exemple, si le passager d'un taxi est blessé lors du transport, il demandera réparation à la compagnie de taxis sur le fondement de la responsabilité contractuelle (puisque le dommage résulte, en droit luxembourgeois, de la violation par le transporteur de son obligation de sécurité) ; mais, s'il est tué dans l'accident, ses proches, eux, devront demander réparation sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, parce qu'ils sont tiers au contrat, et ne sont donc pas personnellement créanciers de cette obligation de sécurité. De même, si le médecin, auprès de qui je suis allé volontairement consulter (donc avec qui j'ai passé un contrat), fait une erreur de diagnostic ou de traitement entraînant l'aggravation de mon mal, j'agirai contre lui en responsabilité contractuelle ; mais si, appelé pour me soigner alors que, victime d'un accident, je gis inconscient sur le bord de la route, il commet le même type d'erreur entraînant les mêmes conséquences fâcheuses, alors sa responsabilité sera délictuelle, puisque, inconscient, je n'ai pas pu passer de contrat avec lui. Face à ces situations, un certain courant doctrinal plaide depuis longtemps en France, sinon pour l'unification des deux régimes de responsabilité, contractuelle et délictuelle, du moins pour le rapprochement de leurs régimes[1783]. Ce courant avait trouvé son expression dans l'un des projets français de réforme du droit des obligations, l'avant-projet Catala, qui traitait dans un même corps de règles des deux types de responsabilité civile, sauf à poser, à la marge, quelques règles particulières pour l'une et l'autre. À l'opposé, les auteurs qui

[1782] Sur la question, voy. P. Jourdain, « La distinction des responsabilités délictuelle et contractuelle : état du droit français », in *Le droit français de la responsabilité civile confronté aux projets européens d'harmonisation*, Travaux du GRERCA, Paris, IRJS Éditions, 2012, p. 67.

[1783] Dans ce sens p. ex. A. Tunc, *La responsabilité civile*, Paris, 1989, pp. 44 et s. ; G. Viney, « Introduction à la responsabilité », in J. Ghestin (dir.), *Traité de droit civil*, 3e éd., 2008, nos 232 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

défendent l'idée que les dommages et intérêts contractuels ne sont pas une vraie forme de responsabilité, sont totalement hostiles à ce rapprochement, et plaident à l'inverse pour un renforcement de la spécificité des règles de la « responsabilité contractuelle ». Pour eux, les artifices de la distinction seraient supprimés si on sortait de cette « responsabilité contractuelle » la réparation des dommages à la personne qui devrait relever de la seule responsabilité délictuelle. Ce courant s'exprime dans l'autre grand projet doctrinal français du droit des obligations, celui réalisé sous la direction de F. Terré. La réforme française de 2016 ne s'inscrit pas dans ce sens, puisque les articles 1231 et suivants du Code civil figurent sous le titre « La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat » et que ces textes doivent ultérieurement intégrés dans le titre relatif à la responsabilité civile. Le projet ministériel de réforme de cette matière met sur le même plan la responsabilité extracontractuelle et la responsabilité contractuelle, sauf à poser quelques règles spécifiques à cette dernière. Il en va de même dans le nouveau droit belge : même si les dommages et intérêts contractuels sont traités dans le cadre du droit des contrats, ils sont clairement présentés comme une forme de réparation du dommage causé par l'inexécution (C. civ. be., art. 5.86 et s., art. 5.234 et s.)[1784] et l'article 5.237, alinéa 2, du nouveau Code civil dispose que « les articles 1382 à 1386*bis* de l'ancien Code civil (c'est-à-dire les règles relatives à la responsabilité délictuelle[1785]) sont d'application conforme à moins que leur nature et leur portée ne soient incompatibles avec une telle application ».

Même si on ne partage pas les conceptions fondamentales des auteurs qui nient l'existence même d'une « responsabilité contractuelle », il nous semble qu'il est bien difficile de se passer d'une différenciation des deux régimes de responsabilité[1786]. Le fait qu'un dommage soit causé dans le cadre d'une relation préexistante faisant naître des obligations à la charge d'une partie, et des attentes chez l'autre, ne peut rester sans incidence sur les règles qui régissent la réparation de ce dommage, notamment quant au fait générateur de la responsabilité, l'évaluation des dommages et intérêts ou la possibilité d'aménager conventionnellement la réparation. L'examen des solutions du droit comparé montre qu'il n'existe que très peu de

[1784] Dans les nouveaux textes du livre 5, il n'est du reste pas question des « dommages et intérêts », mais seulement de la « réparation du dommage causé par l'inexécution ».

[1785] Ces textes sont remplacés depuis le 1er janvier 2025 par le nouveau livre VI du Code civil.

[1786] Voy. dans ce sens : P. JOURDAIN, « La distinction des responsabilités délictuelle et contractuelle : état du droit français », précité.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

systèmes juridiques qui connaissent un régime unitaire de réparation des dommages causés hors contrat et dans le cadre d'un contrat, et que cette unité n'y est le plus souvent qu'un faux-semblant. L'harmonisation européenne semble par ailleurs aujourd'hui rendre cette unification impossible. Les actuels règlements européens relatifs à la détermination de la loi applicable ou à la compétence juridictionnelle distinguent en effet par principe selon que le litige naît dans le cadre d'un contrat (Rome I, Bruxelles I) ou à la suite d'un délit (Rome II, Bruxelles II). Quant aux multiples projets européens, doctrinaux ou institutionnels relatifs au droit des contrats, ils ne traitent des dommages et intérêts que dans ce cadre, sans envisager les liens entre ces dommages et intérêts et la responsabilité délictuelle. En même temps, cependant, on voit se développer en droit européen des régimes mixtes de responsabilité, qui échappent à la distinction traditionnelle, et qui obéissent aux mêmes règles sans distinguer selon que le dommage a été causé dans le cadre d'un contrat ou en dehors : c'est le cas de la responsabilité du fait des produits défectueux fondée sur la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (ci-après, « directive du 25 juillet 1985 »)[1787][1788]. En droit français, de même, échappent complètement à la distinction le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, et la responsabilité médicale.

803. Domaine et régime de la responsabilité contractuelle. Souvent confondues lorsqu'on s'interroge sur les conditions de la responsabilité contractuelle, deux questions, à notre sens très différentes, se posent successivement lorsqu'on cherche à connaître les règles relatives à la responsabilité contractuelle. La première – qui est en quelque sorte une question préalable – est celle du domaine d'application de ces règles : un dommage ayant été causé par une personne à une autre, qui demande des dommages et intérêts, il faut se demander si ces dommages et intérêts relèvent des règles de la responsabilité contractuelle (principalement les articles 1147 et suivants du Code civil) ou des règles de la responsabilité délictuelle (C. civ., art. 1382 et s.). Ce n'est qu'ensuite, si on est dans le domaine de la responsabilité contractuelle (**sous-section 1**), qu'il faudra déterminer le contenu de ces règles, en tant qu'elles définissent

[1787] *J.O.C.E.*, L. 210, 7 août 1995.
[1788] Voy. *infra*, n° 813.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

un régime de responsabilité différent de celui de la responsabilité délictuelle (**sous-section 2**), pouvant être aménagé par diverses conventions (**sous-section 3**).

SOUS-SECTION 1. LE DOMAINE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

804. Problématique. Un dommage a été causé, la victime s'en plaint et demande des dommages et intérêts à la personne qui en est, selon elle, responsable. La première question qui se pose est : sur quel fondement ? Cette responsabilité doit-elle être recherchée sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, ou 1147 et suivants du Code civil ? Il faut bien comprendre que la réponse à cette question ne préjuge pas de la réponse qui sera donnée à la question de savoir si la victime obtiendra ou non réparation. À supposer qu'on ait déterminé que la responsabilité doit être recherchée sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code civil, il faudra appliquer ces règles, et elles amèneront peut-être à conclure que l'auteur du dommage n'est pas responsable, qu'il ne doit pas payer de dommages et intérêts. Mais on ne pourra le savoir que lorsqu'on aura déterminé, au départ, si la responsabilité est contractuelle ou délictuelle. La réponse à cette question est d'autant plus importante que, en droit luxembourgeois (comme en droit français), si la responsabilité est de nature contractuelle, la victime ne pourra se fonder que sur les articles 1147 et suivants du Code civil, et elle ne pourra pas se prévaloir des articles 1382 et suivants du Code civil, même si ceux-ci lui sont plus favorables que les règles de la responsabilité contractuelle. La délimitation des domaines des deux responsabilités (**§ 1**) précédera donc l'étude de leur combinaison (**§ 2**).

§1. La délimitation du domaine de la responsabilité contractuelle

805. Domaine fermé. En principe, lorsqu'un dommage est causé, sa réparation relève des règles de la responsabilité délictuelle. Ce n'est que si certaines conditions sont réunies que la responsabilité sera considérée comme étant de nature contractuelle, à défaut ce sont les règles de la responsabilité délictuelle qui s'appliqueront. En droit luxembourgeois, comme dans les deux autres droits fondés sur le Code civil, on peut ramener ces conditions à trois : il faut d'abord qu'il existe un contrat avec lequel le fait dommageable ait

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

un lien (**A**) ; il faut ensuite que le fait dommageable se rattache à une obligation née du contrat (**B**) ; il faut enfin, en principe, que le contrat ait été passé entre la victime et l'auteur du dommage (**C**). Ces trois conditions se retrouvent peu ou prou dans tous les systèmes juridiques, mais elles n'y ont pas toujours, loin de là, la même signification.

A) *Un lien contractuel*

806. Existence d'un contrat. À l'évidence, il ne peut pas avoir de responsabilité contractuelle s'il n'y a pas de contrat. Mais, comme on l'a vu dès les premiers développements de ce manuel, il n'est pas toujours facile de savoir si un contrat existe ou non : il faut en effet rappeler que, en dehors des cas où les parties ont explicitement et consciemment passé un contrat, la loi ou même le juge peuvent découvrir dans les relations des parties un accord contractuel dont celles-ci n'avaient pas nécessairement conscience. Le cas le plus caractéristique est celui des relations bénévoles (transport gratuit d'une personne, assistance bénévole) que les juges vont parfois qualifier de contrat, précisément dans le but de retenir le caractère contractuel de la responsabilité de l'une des parties[1789].

807. Existence d'un contrat au moment du fait dommageable. Même si un contrat existe, la responsabilité ne sera contractuelle que si le fait dommageable s'est produit après la conclusion de ce contrat. C'est pourquoi les cas déjà examinés de rupture de pourparlers précontractuels relèvent en droit luxembourgeois de la responsabilité délictuelle, de même que la violation d'une obligation d'information pesant sur une partie au cours de la période précontractuelle[1790]. Ce n'est cependant pas toujours aussi clair en jurisprudence, car, si un contrat est passé par la suite, celui-ci produit une sorte d'effet de halo, qui amène parfois à sanctionner sur le fondement contractuel des préjudices causés par un manquement antérieur à la formation du contrat[1791].

[1789] Pour des exemples d'arrêts ayant retenu une convention d'assistance bénévole : Cour d'appel, 15 janvier 1997, n°s 16643 et 16484 ; Cour d'appel, 7 mars 2007, n° 29170, cités par Ravarani, n° 493.

[1790] Ravarani, n° 483. Il en va de même en droit européen au regard des règles de compétence juridictionnelle posées par le règlement de Bruxelles II (C.J.C.E., 17 septembre 2002, C-334/000).

[1791] Voy. p. ex. en droit français : Cass. fr. (comm.), 3 mai 2006, n° 04-19 315 ; Cass. fr. (comm.), 13 septembre 2011, n° 10-18323.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

La situation est encore moins claire au cours de la période post-contractuelle. Il est certain que, si un dommage a été causé pendant l'exécution du contrat, on pourra encore en demander réparation après sur le fondement contractuel – y compris, on l'a vu, si on a obtenu la résolution de ce contrat pour inexécution. Mais, en outre, même si un dommage survient après la fin des relations contractuelles, il peut encore relever de la responsabilité contractuelle s'il se rattache à la violation d'une obligation contractuelle qui se prolonge après la fin du contrat : il suffit de songer à la violation d'une obligation de non-concurrence, ou à la réparation des dommages causés par une défectuosité de la chose vendue, qui sont liés à l'obligation de garantie dont le vendeur peut être tenu longtemps après le transfert de propriété et la livraison de la chose.

808. Existence d'un contrat valable. Au cas où le contrat n'existe pas, ou pas encore, il faut assimiler celui où le contrat qui a été passé a été annulé. Un contrat nul étant censé n'avoir jamais fait naître d'obligations entre les parties, la responsabilité qui peut être encourue à raison d'un fait dommageable survenu entre le moment de la conclusion du contrat et celui de son annulation ne peut être que délictuelle[1792]. C'est du reste très souvent pour échapper à sa responsabilité contractuelle qu'un contractant, qui n'a pas fourni la prestation promise, essaiera de faire annuler le contrat.

B) *Le rattachement du dommage à une obligation contractuelle*

809. Principe. Tout ce qui se passe entre les parties à un contrat, même valable, et qui est générateur de dommages, ne relève pas nécessairement de la responsabilité contractuelle. Pour que celle-ci soit applicable, encore faut-il que le dommage causé puisse être rattaché à la violation d'une obligation née de ce contrat. Prenons l'exemple d'un contrat de déménagement au cours duquel le déménageur, pris de boisson, se prend de querelle avec le client, l'agresse et le blesse : dans un tel cas on considérera généralement que la responsabilité est délictuelle, car de prime abord le dommage ne se rattache pas à une obligation née du contrat de déménagement. Il en irait tout autrement, évidemment, si le déménageur avait, au cours des opérations, cassé un vase appartenant au client ! Cette question de savoir si le dommage se rattache à une

[1792] Voy. *supra*, n° 480.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

obligation contractuelle – qui permet de déterminer de quel corps de règles relève la responsabilité – doit être distinguée de celle, qui se pose ensuite, de savoir si l'obligation a été effectivement violée : dans l'exemple du déménageur, c'est une chose de dire que sa responsabilité est contractuelle s'il casse un vase, c'est autre chose de savoir si le seul fait de casser un vase doit être considéré comme une inexécution de son obligation, même par exemple si le vase, excessivement fragile, s'est cassé tout seul entre ses mains. La réponse à cette question dépend, nous le verrons, du point de savoir si l'obligation du déménageur est une obligation de moyens ou de résultat. Cette distinction n'a cependant lieu de s'appliquer que si, au départ, on a identifié une obligation contractuelle à la charge du cocontractant qui a causé le dommage.

810. Obligations implicites. Toute la difficulté, pour répondre à cette première question, vient de ce que, comme on l'a vu précédemment, les obligations nées d'un contrat ne sont pas seulement celles que les parties y ont mises : le contrat peut aussi faire naître des obligations que les parties n'ont pas voulues ou pas envisagées et que la loi ou le juge décide d'y intégrer, sur le fondement de l'article 1135 du Code civil. La création, en France, de l'obligation de sécurité dans le contrat de transport[1793] est l'exemple le plus caractéristique de cette création judiciaire d'obligations contractuelles, dont l'effet est (et dont le but était précisément à l'origine) d'étendre le champ de la responsabilité contractuelle au détriment de celui des articles 1382 et suivants du Code civil. Sur ce modèle, la jurisprudence luxembourgeoise a reconnu de même des obligations de sécurité de la personne ou des biens du client dans les contrats les plus divers[1794] : contrat de travail[1795], contrats passés avec un exploitant de jeux forains, un établissement thermal, un club de fitness, une station de lavage de voitures, le tenancier d'une station-service[1796], l'exploitant d'une discothèque[1797], etc. mais non avec l'exploitant d'un magasin pendant les achats[1798] ni avec celui

[1793] Cass. fr. (civ.), 21 novembre 1911 (Cie générale transatlantique), accessible sur http://www.legifrance.gouv.fr. On rappellera qu'au Luxembourg, cette obligation de sécurité avait été reconnue par le législateur dès 1908 et intégrée dans l'article 103 du Code de commerce.

[1794] Voy. le recensement fait par Ravarani, n° 508.

[1795] Voy. en dernier lieu Cour d'appel, 27 juin 2024, n° CAL-2023-00116.

[1796] Cour d'appel, 31 mai 2023, arrêt n° 77/23 – VII – CIV.

[1797] Cour d'appel, 24 avril 2024, n° CAL-2022-00856.

[1798] Cour d'appel, 17 janvier 1997, *Pas.*, 20, 232.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

d'un parking[1799]. Les obligations de conseil et de renseignement que les tribunaux mettent à la charge de différents professionnels et en particulier des établissements financiers dans le cadre des différents contrats de crédit ou de fourniture de services financiers, s'inscrivent dans la même logique[1800]. Il n'est évidemment pas question dans le cadre limité de ce manuel d'entrer dans le détail de ces différentes obligations, il faut simplement insister sur l'extension considérable du champ de la responsabilité contractuelle qu'elles réalisent.

811. **Décontractualisation ?** Cette extension du domaine de la responsabilité contractuelle a été, dès ses origines, souvent critiquée en doctrine, comme en témoigne l'expression, à connotation très négative, de « forçage » du contrat, due à Josserand[1801]. Ces critiques se sont accentuées dans la période récente, notamment de la part des auteurs qui voient dans la responsabilité contractuelle une forme d'exécution par équivalent des obligations contractuelles. Cette analyse s'accorde évidemment très mal avec le jeu des obligations de sécurité, que ce courant doctrinal propose en conséquence de « décontractualiser », pour ramener le contrat à l'essentiel, c'est-à-dire aux obligations voulues par les parties ou correspondant à son objectif économique principal. Les prétendues « obligations de sécurité » nées de tel ou tel contrat ne seraient en réalité que des devoirs généraux de la vie sociale dont toute personne est tenue vis-à-vis de toute autre, et pas seulement vis-à-vis des personnes avec qui elle a contracté. Leur violation ne devrait donc être sanctionnée que sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil. Le projet ministériel français de réforme de la responsabilité civile de 2017 consacre cette position. Le très récent texte belge sur la responsabilité extracontractuelle ne va pas aussi loin, mais, dans le cas des dommages résultant d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, il permet sans limite à la victime de choisir d'agir sur un fondement extracontractuel plutôt que sur le fondement contractuel (C. civ. be., art. 6.3).

La décontractualisation totale des obligations de sécurité (telle qu'elle est admise par le projet français) nous paraît très contestable. Outre qu'elle repose sur une conception volontariste du contrat qui nous semble quelque peu dépassée (le contrat, ce serait seulement ce que les parties ont voulu expressément ou implicitement, non ce que le juge y met), elle méconnaît le fait que les « devoirs généraux de la vie sociale » prennent un contenu particulier lorsqu'ils sont intégrés dans un contrat : s'il est vrai que je dois veiller à ce que mon comportement ne cause aucun dommage à la vie ou à l'intégrité corporelle d'autrui, ce devoir n'est plus tout à fait le même si je suis chauffeur de taxi et que je m'engage, moyennant une rémunération, à transporter mes passagers d'un point à un autre ; on peut alors bien concevoir que ce qui n'est, hors contrat, qu'un devoir général de prudence et de diligence, devienne, dans le cadre du contrat de transport, une véritable obligation de conduire sains et saufs mes passagers à destination. On observera par ailleurs que le droit européen ne distingue pas, pour délimiter le domaine de la responsabilité contractuelle, entre les dommages résultant de la violation d'obligations principales du contrat et ceux qui se rattachent à ces devoirs généraux de la vie sociale. L'article 1er du règlement Rome I n'exclut nullement les obligations de sécurité des obligations contractuelles,

1799 Trib. Luxembourg, 2 décembre 1983, n° 1165/83 ; Trib. Luxembourg, 10 janvier 2012, n° 110494.

1800 RAVARANI, nos 510 et s.

1801 Voy. *supra*, nos 45 et 534.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

pas plus que les différents projets d'harmonisation du droit des contrats, dont certains envisagent même expressément au titre de la responsabilité contractuelle les dommages corporels subis par un contractant[1802].

On peut néanmoins se montrer favorable à la décontractualisation des obligations qui pèsent sur certains professionnels, en raison même de leur profession, et qui ont un contenu identique à l'égard de toutes les personnes destinataires de leur activité, que celle-ci s'exerce ou non dans le cadre d'un contrat. C'est ainsi que la jurisprudence luxembourgeoise admet depuis longtemps, sur le modèle français, que la responsabilité des notaires pour violation de leur devoir de conseil est une responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du Code civil[1803]. Plus récemment la Cour de Cassation française a fait sortir du champ de la responsabilité contractuelle la violation par un médecin de son obligation d'information puis de son obligation de soins, qui étaient jusque-là rattachés au contrat[1804]. On peut du reste se demander si, dans ce domaine, il ne faudrait pas, d'une manière générale, abandonner la solution traditionnelle, remontant à un arrêt français de 1936[1805], rattachant au contrat médical l'obligation pesant sur le médecin de donner au patient « des soins consciencieux, attentifs et, conformes aux données acquises de la science »[1806]. Le médecin, en réalité, a exactement la même obligation à l'égard de toute personne qu'il soigne, même s'il n'a pas passé de contrat avec elle. Dans un tel cas, cependant, le fondement contractuel ou délictuel de l'action n'a que des incidences très limitées sur le régime de l'action.

C) *Dommage causé à une partie au contrat par une autre partie*

812. Effet relatif du contrat. En principe, si le dommage causé à l'occasion de l'inexécution d'une obligation contractuelle n'est pas subi par le cocontractant, mais par un tiers, la responsabilité doit relever des articles 1382 et suivants du Code civil. La raison en est dans une règle fondamentale du droit des contrats, que nous étudierons plus loin, et qui est la règle de l'effet relatif du contrat[1807] : selon cette règle posée par l'article 1165 du Code civil, le contrat ne fait naître d'obligations qu'entre les parties contractantes, il ne peut rendre les tiers ni débiteurs ni créanciers. En conséquence, si un tiers subi un dommage du fait de l'inexécution d'un contrat auquel il n'est pas partie, ce tiers ne peut pas être traité comme un créancier contractuel. Pour engager la responsabilité de l'auteur du dommage, il devra agir sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil : c'est

[1802] Code Gandolfi, art. 164 ; DCEV, art. 84 (qui considère comme abusives toute clause « ayant pour objet ou pour effet d'exclure ou de limiter la responsabilité du professionnel en cas de décès ou de préjudice corporel subi par le consommateur »).

[1803] RAVARANI, n° 677.

[1804] Cass. fr. (1re civ.), 3 juin 2010, n° 09-13591, Cass. fr. (1er civ.), 14 octobre 2010, n° 09-69195.

[1805] Cass. fr. (civ.), 20 mai 1936, *D.*, 1936, 1, p. 88, concl. MATTER, rapp. JOSSERAND.

[1806] Pour la reprise de cette jurisprudence au Luxembourg, voy. p. ex. Cour d'appel, 5 décembre 2001, nos 24506 et 24516.

[1807] Voy. *infra*, nos 953 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

le cas, notamment, pour les dommages subis par les proches d'une victime décédée à la suite de la mauvaise exécution d'un contrat (contrat de transport de personnes, contrat médical). Nous verrons cependant que ce principe connaît en jurisprudence de nombreuses limites. C'est ainsi que, depuis longtemps, dans les trois pays du Code civil, la jurisprudence admet que, dans le cas d'une chaîne de ventes portant sur un même bien, le dernier acquéreur, victime d'un défaut de la chose, peut agir en responsabilité contractuelle contre le premier vendeur alors même qu'il n'a pas de lien contractuel avec lui[1808]. Par ailleurs, dans la jurisprudence récente, en France et au Luxembourg, il a été admis que le tiers victime de l'inexécution d'un contrat, s'il doit agir contre le débiteur contractuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, peut, sur ce fondement, se contenter, pour établir la faute de l'auteur du dommage, de prouver la violation de l'obligation contractuelle[1809] – ce qui vide très largement de sa substance le principe énoncé. Ces différentes solutions – et surtout la dernière, qui n'est pas consacrée en Belgique – contribuent à un certain isolement des droits français et luxembourgeois par rapport aux autres droits européens dans le domaine de la responsabilité civile.

813. **Responsabilité du fait des produits défectueux.** Le régime spécifique de la responsabilité du fait des produits défectueux, consacré au Luxembourg par la loi du 21 avril 1989 et tiré de la transposition de la directive du 25 juillet 1985, échappe à cette distinction entre les parties et les tiers. Le fabricant ou l'importateur qui met sur le marché des produits défectueux est responsable de plein droit des dommages causés à la personne ou aux biens d'autrui, sans qu'il y ait à distinguer selon que la victime a acheté directement la chose au fabricant (donc a passé un contrat avec lui) ou à un revendeur, ou même n'a pas passé de contrat du tout (un voisin en visite chez l'acquéreur, un passant victime de l'explosion du produit, etc.). On peut analyser cette solution, soit comme le résultat d'une décontractualisation de l'obligation du fabricant de mettre sur le marché des produits sûrs, soit comme l'instauration d'un régime de responsabilité du troisième type, qui ne serait ni contractuel ni délictuel.

§ 2. La combinaison de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle : la règle du non-cumul

814. **Problématique.** À supposer qu'on se trouve dans le domaine de la responsabilité contractuelle, tel qu'il vient d'être délimité, se pose la question de savoir si la victime peut, au lieu de fonder sa demande en réparation sur les règles contractuelles, invoquer les articles 1382 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité

[1808] Sur ces chaînes de contrats, voy. *infra*, n°s 1111 et s.

[1809] Voy. *infra*, n°s 986 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

délictuelle. Posée habituellement en termes de « cumul » ou de « non-cumul » des responsabilités, la question est en réalité celle de l'option : il n'est évidemment pas question que la victime obtienne réparation deux fois, sur les deux fondements, ni même qu'elle puisse combiner les règles qui lui sont les plus favorables sur les deux terrains. Il s'agit seulement de savoir si la victime peut choisir entre les deux fondements. La question se pose parce que, dans un certain nombre de cas, les règles de la responsabilité délictuelle se révèlent plus favorables à la victime que celles fondées sur le contrat. Il en va ainsi, en particulier, lorsque le contrat contient une clause qui limite ou exclut la responsabilité, ou lorsque la responsabilité contractuelle impose de prouver la faute de l'auteur du dommage, alors que, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la victime pourrait bénéficier d'une responsabilité sans faute[1810]. En faveur d'une option reconnue à la victime, on peut faire valoir que, derrière les obligations spécifiques nées du contrat, il y a toujours les devoirs généraux de la vie sociale, sanctionnés par la responsabilité délictuelle, et que la convention des parties ne peut écarter. Mais en sens inverse, on observe que si la loi pose des règles particulières à la réparation des dommages subis à la suite de l'inexécution du contrat, ce n'est pas pour que ces règles soient écartées chaque fois que le dommage tombe aussi sous le coup des règles de la responsabilité délictuelle.

Le problème se pose en réalité très différemment selon les systèmes juridiques. Dans certains droits, la responsabilité délictuelle est enfermée dans des limites assez strictes, elle ne peut réparer que certains dommages (qui ne sont pas, en général, ceux que répare la responsabilité contractuelle) et suppose presque toujours la preuve d'une faute. Dans ces systèmes, dont le droit allemand est sans doute le meilleur exemple, on aura tendance à admettre largement l'option de la victime entre les deux régimes, dès lors qu'en réalité ils se chevaucheront assez rarement. Il n'en va pas de même dans les pays du Code civil, où, au contraire, la responsabilité délictuelle est un système de réparation très ouvert, qui permet de réparer n'importe quel type de dommage et, dans de nombreux cas, sans avoir à prouver la faute de l'auteur du dommage. Dans un tel contexte, presque tous les cas d'inexécution d'un contrat peuvent,

[1810] C'est le cas lorsque le contrat fait naître une simple obligation de moyens (Voy. *infra*, n° 823), alors que le dommage ayant été causé par une chose, la victime pourrait bénéficier de la responsabilité sans faute fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

en même temps, constituer des faits générateurs de responsabilité délictuelle (faute ou fait de la chose). Dès lors, si la victime pouvait choisir la voie délictuelle chaque fois que la réparation est fermée sur le fondement contractuel, les conditions mises par la loi ou par le contrat lui-même à l'obtention de dommages et intérêts contractuels pourraient être systématiquement tournées, et ce serait la force obligatoire du contrat lui-même qui en serait affectée. C'est pourquoi, dans les trois pays du Code civil, on pose en principe la règle dite du « non-cumul des responsabilités », qu'il vaudrait mieux appeler (pour les raisons indiquées plus haut) la règle de la « non-option » : en principe, la victime d'un dommage relevant des règles de la responsabilité contractuelle ne peut pas demander réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La portée exacte de ce principe – qui est conçu de manière plus souple en Belgique qu'en France ou au Luxembourg – doit cependant être précisée. Cela amène à distinguer selon que le problème se pose dans les rapports entre les parties au contrat (**A**), ou dans les rapports avec les tiers (**B**).

A) *La règle du non-cumul dans les rapports entre les parties au contrat*

815. Règle de fond. Dès la fin du XIXe siècle, la Cour de cassation française a posé en principe que la responsabilité délictuelle ne peut pas être utilisée pour réparer les dommages causés par la faute commise dans le cadre de l'exécution d'un contrat[1811], et la jurisprudence luxembourgeoise a régulièrement suivi[1812]. Les tribunaux luxembourgeois justifient cette position par le fait que le choix laissé à la victime « aurait pour résultat de supprimer toutes les dispositions spéciales édictées par le législateur en matière contractuelle, notamment celles par lesquelles il a entendu particulariser la responsabilité de telle ou telle catégorie de contrats »[1813]. Cette position est aujourd'hui critiquée en droit français par certains auteurs, qui estiment qu'il vaudrait mieux, en suivant l'exemple allemand, réduire le champ de la responsabilité délictuelle et permettre le

[1811] Cass. fr. (Req.), 21 juillet 1890, *DP*, 1891, 1, p. 380 ; Cass. fr. (civ.), 11 janvier 1922, *DP*, 1922, I, p. 16, note R. DEMOGUE ; Grands arrêts, n° 177.

[1812] Voy. p. ex. : Cass., 20 avril 1972, *Pas.*, 22, p. 153 ; Cour d'appel, 17 janvier 1967, *Pas.*, 20, p. 232 – *adde*. les nombreuses décisions citées par RAVARANI, n° 1375. Voy. en dernier lieu Cour d'appel, 5 mars 2024, n° CAL-2023-00595.

[1813] Cour d'appel, 17 janvier 1967, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

cumul des deux responsabilités[1814]. C'est un choix possible de politique juridique, mais, dans l'état actuel du droit de la responsabilité extracontractuelle, au Luxembourg comme en France, il paraît difficilement imaginable d'abandonner la règle du non-cumul.

816. **Règles procédurales.** Au Luxembourg, comme en France, le principe du non-cumul n'est pas considéré comme relevant de l'ordre public, au sens procédural du terme. Dès lors, si le contractant victime agit sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, il n'appartient pas au juge de rejeter d'office l'action si le défendeur ne soulève pas l'erreur de fondement.[1815]. Même si cette erreur de qualification est soulevée par le défendeur, le juge peut rectifier et examiner l'action sur le fondement contractuel, ce qui réduit largement la portée de la règle du non cumul[1816]. Rien n'empêche par ailleurs le contractant victime, qui hésite sur le fondement de son action (pas toujours facile à déterminer si on considère les incertitudes des domaines respectifs des deux responsabilités) d'agir à titre principal sur le fondement contractuel, et à titre subsidiaire sur la base de la responsabilité délictuelle[1817].

817. **Particularisme du droit belge.** De prime abord, la position tranchée des juridictions françaises et luxembourgeoises contraste avec celle du droit belge. La Cour de cassation belge, après de multiples hésitations, avait affirmé en 2006 que la responsabilité quasi-délictuelle d'un contractant « ne peut être admise que si la faute qui lui est imputée constitue un manquement non seulement à l'obligation contractuelle mais aussi au devoir général de prudence qui lui incombe et si cette faute a causé un dommage autre que celui qui est dû à la mauvaise exécution du contrat »[1818]. La haute juridiction belge semblait donc admettre des hypothèses de « cumul », où la victime aurait le choix entre les deux responsabilités, mais on pouvait se demander si l'opposition n'était pas plus apparente que réelle : l'exigence, pour admettre l'action délictuelle, d'un dommage distinct de celui qui est dû à la mauvaise exécution du contrat, réduisait en effet considérablement les hypothèses de cumul. L'article 6.3 du nouveau Code civil belge semble aller beaucoup plus loin puisqu'il dispose que « [s]auf si la loi ou le contrat en dispose autrement, les dispositions légales en matière de responsabilité extracontractuelle sont applicables entre cocontractants ». Cette disposition semble signer l'arrêt de mort de la règle du non-cumul. Cependant, les alinéas suivants du texte en tempèrent considérablement la portée. Si, en effet, le contractant victime choisit d'exercer son action en réparation sur le fondement extracontractuel, son cocontractant peut « invoquer les moyens de défense découlant du contrat qu'il a conclu avec la partie lésée, de la législation en matière de contrats spéciaux et des règles particulières de prescription applicables

1814 J.-S. BORGHETTI, « La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps », *RTD civ.*, 2010, pp. 1 et s., spéc. n°s 26 et s.

1815 RAVARANI, n°s 1375 et 1376.

1816 RAVARANI, n° 1380.

1817 Cass., 10 juillet 2018, n° 81/2018, n° 3994, *J.T.L.*, 2019/3, n° 63, pp. 70-72. Comp. en droit français : Cass. fr. (comm.), 13 juillet 2010, n° 09-14985.

1818 Cass. be., 29 septembre 2006, n° C.03.0502.N/1. Sur la portée de cet arrêt, très controversée, et sur la question des rapports entre les deux responsabilités en droit belge, voy. not. WÉRY, n°s 621 et s. Adde : O. GOUT, « Le cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle en droit belge et en droit français : de la genèse des règles aux perspectives d'évolution », in *Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge*, préc., pp. 123 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

au contrat ». Cette disposition (dont on trouve l'équivalent pour la réparation des dommages causés par un auxiliaire du cocontractant) neutralise en pratique les effets du principe du « cumul » (ou plutôt de l'option). Ce n'est que pour les dommages « résultant d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique ou d'une faute commise avec l'intention de causer un dommage » que le principe de l'option entre les deux responsabilités s'applique sans restriction.

B) *La règle du non-cumul dans les rapports avec les tiers au contrat*

818. **Dommage causé par un tiers au contrat.** En principe, lorsque le dommage a été causé par un tiers au contrat, la responsabilité contractuelle n'a pas vocation à s'appliquer. La victime n'a, contre le tiers, qu'une action délictuelle. Ce principe s'applique en particulier dans le cas, très fréquent, où l'inexécution du contrat est due, non à l'action du cocontractant lui-même, mais à celle d'un de ses préposés. Pour reprendre l'exemple du déménageur, dans l'immense majorité des cas, le déménageur qui casse le vase est un employé de l'entreprise de déménagement avec qui le client a passé le contrat. Dans un tel cas, c'est contre l'entreprise, et non contre l'employé, que le client a une action en responsabilité contractuelle[1819]. Traditionnellement, il était admis que cette action en responsabilité contractuelle n'excluait pas que la victime puisse, en outre, agir contre le préposé en raison de sa faute personnelle, cette fois sur le fondement délictuel[1820] : il y avait donc là un cas d'un véritable cumul entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, mais contre deux défendeurs différents. Cette jurisprudence est peut-être cependant remise en cause à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation française qui a posé le principe de l'immunité du préposé ayant agi dans le cadre de ses fonctions[1821]. Certains arrêts de la Cour d'appel ont emboîté le pas de cette jurisprudence, alors que d'autres ont refusé de la suivre, maintenant le principe d'un cumul entre la responsabilité du commettant et celle du préposé[1822]. Le nouveau droit belge de la responsabilité extracontractuelle consacre ici la même solution que dans les rapports entre contractants : la victime peut invoquer contre l'auxiliaire de son cocontractant les règles de la responsabilité extracontractuelle, sauf à l'auxiliaire à opposer à la victime les exceptions tirées du droit des contrats que son donneur d'ordre pourrait opposer (C. civ. be., art. 6.3, § 2).

819. **Dommage causé à un tiers au contrat.** Lorsque l'inexécution du contrat a causé un dommage à un tiers au contrat, le problème du cumul ne devrait pas se poser, puisque, nous l'avons vu, ce tiers victime n'a en principe contre le contractant qu'une action en responsabilité délictuelle. Mais il en va parfois autrement, notamment dans les chaînes de contrats, où la jurisprudence admet que le sous-acquéreur d'un bien défectueux a, contre le premier vendeur ou le fabricant du bien, une action de nature contractuelle. La règle du non-cumul s'applique alors, et elle conduit à des conséquences particulièrement injustes : nous verrons en effet que ce sous-acquéreur, lorsqu'il agit par la voie contractuelle, est censé exercer l'action qui appartenait au premier acquéreur, et il peut en conséquence se voir opposer toutes les exceptions que le premier vendeur aurait pu opposer au premier acheteur de la chaîne,

[1819] RAVARANI, n° 988.
[1820] Cour d'appel, 13 juin 1990, *Pas.*, 28, p. 45.
[1821] Cass. fr. (ass. plén.), 25 février 2000 (Costedoat), n° 94-15846.
[1822] Cour d'appel, 24 février 2010, *Pas.*, 35, p. 161.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

notamment l'existence de clauses limitatives de responsabilité contenues dans le premier contrat[1823]. En raison de la règle du non-cumul, le sous-acquéreur ne pourra pas échapper à ces clauses, qu'il n'a pourtant pas acceptées, en fondant son action sur la responsabilité délictuelle. Il serait souhaitable, dans ce cas, d'écarter le principe du non-cumul.

SOUS-SECTION 2. LE RÉGIME LÉGAL DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

820. Prolongement du contrat. La structure de la responsabilité contractuelle, dans la conception dominante, est fondamentalement la même que celle de la responsabilité délictuelle : le débiteur contractuel est condamné à réparer le dommage que, par son fait illicite, il a causé à son créancier, de même que toute personne qui a causé un dommage à autrui par un fait que la loi considère comme générateur de responsabilité. Cependant, parce que la responsabilité contractuelle se situe dans le prolongement du contrat qui lie (ou liait) la victime et l'auteur du dommage, elle est marquée d'un certain particularisme, tant en ce qui concerne ses conditions (**§ 1**) que ses effets (**§ 2**).

§1. Conditions de la responsabilité contractuelle

821. Comparaison avec la responsabilité extracontractuelle. Lorsqu'un dommage est causé en dehors de toute relation contractuelle préexistante entre la victime et l'auteur du dommage, la responsabilité, régie en principe par les articles 1382 et suivants du Code civil, suppose la réunion de trois conditions : un dommage, bien sûr, mais aussi, du côté de celui à qui la réparation est demandée, un fait générateur de responsabilité, et, entre les deux, un lien de causalité. On retrouve ces trois conditions en matière contractuelle, mais elles sont toutes teintées d'un certain particularisme.

A) *Le fait générateur de responsabilité*

822. Responsabilité pour faute ou sans faute ? Un rappel essentiel s'impose avant de commencer : ce n'est pas parce qu'on a causé un dommage qu'on en est nécessairement responsable. Si j'ouvre un nouveau restaurant, et que, en raison des qualités exceptionnelles de ma cuisine, j'attire toute la clientèle qui

[1823] Voy. *infra*, n°s 1111 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

fréquentait les autres restaurants du quartier, acculant peut-être certains d'entre eux à la faillite, mes concurrents malheureux ne seront certainement pas fondés à me demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice que je leur ai causé. Pour que la responsabilité soit admise, il faut que le fait qui a été à l'origine du dommage présente certaines caractéristiques qui justifient qu'on en fasse peser la charge sur son auteur. Dans l'exemple précédent, ma responsabilité ne sera admise que si je me suis livré, pour attirer la clientèle, à des actes que la jurisprudence qualifie de « concurrence déloyale ». Cet exemple ne doit pas faire croire, cependant, que la responsabilité d'une personne ne peut être engagée que si elle a commis une faute. La faute – comportement anormal, non conforme à la conduite normalement attendue d'un homme prudent et diligent – est sans doute, dans tous les systèmes juridiques, le fait générateur de responsabilité par excellence. Mais, dans les sociétés modernes, il est très généralement admis qu'on peut engager sa responsabilité même si on n'a pas commis de faute, pas pour n'importe quel fait, mais pour des faits qui, socialement, apparaissent justifier un déplacement de la charge du dommage de celui qui en a été victime vers celui qui en a été l'auteur. En droit luxembourgeois, comme dans les deux autres pays du Code civil, ces cas de responsabilité sans faute sont très largement admis – beaucoup plus largement que dans la plupart des autres droits européens. En matière extracontractuelle, on opère une distinction entre trois catégories de faits : si le dommage a été causé par le fait personnel de l'auteur du dommage – comme dans l'exemple du restaurant – il faut en principe une faute pour engager sa responsabilité (C. civ., art. 1382) ; il ne sera en revanche pas nécessaire de prouver une faute si le dommage est dû au fait d'une chose que l'auteur du dommage avait sous sa garde (C. civ., art. 1384, al. 1er), ni s'il a été causé par le fait d'une des personnes dont, selon la loi, on doit répondre (ses enfants mineurs, ses préposés, ses apprentis) (C. civ., art. 1384, al. 2 à 4). Les cas où il n'est pas nécessaire de prouver la faute sont eux-mêmes de deux types, selon que l'auteur du dommage peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a commis aucune faute (parents, artisans), ou que cette exonération est impossible (fait des choses, fait des préposés), auquel cas on est en présence d'une responsabilité purement objective, sans faute.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Qu'en est-il maintenant en matière contractuelle ? La responsabilité contractuelle est-elle une responsabilité pour faute prouvée, pour faute présumée, ou sans faute ? Cela dépend, comme nous allons le voir, du point de savoir si l'obligation inexécutée est qualifiée d'obligation de moyens ou d'obligation de résultat.

823. Distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat : principe. En matière contractuelle, il n'y a pas lieu de distinguer, comme en matière délictuelle, selon la nature du fait qui a causé le dommage (fait personnel, fait d'une chose, fait d'autrui). Encore qu'on ait voulu, à une certaine époque, en France, construire une responsabilité contractuelle du fait des choses ou du fait d'autrui, ces distinctions ne nous semblent pas avoir de sens en matière contractuelle. Lorsqu'un dommage est causé par un contractant à un autre, même lorsque ce contractant se servait d'une chose pour exécuter le contrat, ou même s'il avait confié cette exécution à un de ses préposés, la seule question qui se pose est : ce contractant a-t-il ou non exécuté son obligation contractuelle ? *Le fait générateur est donc toujours l'inexécution de l'obligation*. C'est ce qu'affirme l'article 1147 du Code civil selon lequel « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Mais encore faut-il savoir à partir de quand il y a inexécution. Tout dépend du contenu exact des obligations du débiteur. Pour savoir s'il y a lieu ou non à responsabilité, il faut se demander à quoi le débiteur était tenu, et comparer ce contenu avec ce qu'il a fait ou n'a pas fait. L'examen des dispositions spéciales du Code civil relatives aux différents contrats montre que, selon les cas, on se montre plus ou moins exigeant à l'égard du débiteur contractuel. Par exemple, l'article 1927 du Code civil relatif au dépôt dispose que « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ». Pour engager la responsabilité du dépositaire, il faudra donc prouver qu'il n'a pas été assez soigneux, ce qui revient à prouver sa faute. Mais lorsque l'article 1611 du Code civil, relatif à la vente, dispose que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

délivrance au terme convenu », on voit que la responsabilité du vendeur qui ne livre pas à temps n'est aucunement subordonnée à la preuve d'une faute.

Pour essayer de mettre de l'ordre dans la diversité des obligations contractuelles, un auteur français de la première moitié du XXe siècle, Demogue, a introduit, en s'inspirant de la doctrine italienne, une distinction entre deux catégories d'obligations, nommées par lui obligations de moyens et obligations de résultat[1824]. Le principe de cette distinction est le suivant. Dans certains cas (obligations de moyens), le débiteur est seulement tenu de mettre en œuvre tous les moyens qui sont en son pouvoir pour parvenir au résultat attendu du contrat : il sera alors responsable si, et seulement si, il n'a pas mis tous les moyens en œuvre, donc s'il a commis une faute, il ne suffira pas de prouver qu'il n'a pas atteint le résultat attendu. L'article 1967 du Code civil sur le dépôt donne l'exemple d'une telle obligation. Dans d'autres cas (obligations de résultat), le débiteur est obligé à fournir le résultat promis, et il sera responsable dès lors que ce résultat n'aura pas été atteint, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il a commis une faute, qu'il n'a pas été assez diligent ou soigneux : ainsi du vendeur qui, selon l'article 1611 du Code civil, doit payer des dommages et intérêts dès lors qu'il n'a pas livré à temps.

Cette distinction devait connaître par la suite une fortune considérable dans les trois pays du Code civil, et dans certains pays étrangers. Elle a même été consacrée par l'article 5.4 des Principes Unidroit. Bien qu'elle ne figure pas dans le Code, elle constitue aujourd'hui la base du droit de la responsabilité contractuelle, au Luxembourg comme en France et en Belgique. De manière assez surprenante, la distinction est complètement absente du nouveau droit français des obligations, et elle n'est pas davantage reprise par le projet ministériel de 2017 sur la responsabilité civile. En revanche, on trouve cette distinction exprimée dans l'article 5.72 du nouveau Code civil belge. Il faut cependant bien en comprendre la portée, et en déterminer le critère, avant de s'interroger sur son bien-fondé.

824. Distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat : portée. La distinction est parfois présentée sur le terrain probatoire, comme commandant la charge de la preuve de la faute : alors que, en présence d'une obligation de moyens, le créancier devrait

[1824] R. DEMOGUE, *Traité des obligations*, t. V, Paris, Rousseau, 1925, pp. 538 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

prouver la faute, il n'aurait plus à faire cette preuve si l'obligation est de résultat[1825]. Cette présentation, bien que commune, et dont on trouve trace dans l'article 5.72 du nouveau Code civil belge, nous semble assez contestable, car la distinction opère sur le terrain du fond du droit. Lorsque l'obligation et de résultat, la non-obtention du résultat promis constitue, en soi, l'inexécution du contrat, et le débiteur ne peut pas s'exonérer des dommages et intérêts en prouvant qu'il n'a commis aucune faute[1826]. Conformément à l'article 1147 du Code civil, il ne peut échapper à la condamnation à dommages et intérêts qu'en prouvant que cette inexécution n'est pas de son fait, qu'elle est due à une cause étrangère constitutive de force majeure. C'est du reste ce que dit l'article 5.72 du Code civil belge, ce qui contredit quelque peu l'affirmation que, pour les obligations de résultat, « si le résultat n'est pas atteint, la faute du débiteur est présumée ». L' exonération par la preuve de la force majeure se situe alors sur le terrain du lien de causalité, elle n'est pas liée à la manière dont le débiteur s'est comporté – bien ou mal – même si la distinction n'est pas toujours aisée en pratique. S'il y a ici une présomption, c'est une présomption de causalité, et non une présomption de faute. Par exemple, le vendeur qui n'a pas livré à temps peut certainement s'exonérer s'il n'a pas pu se procurer le bien qu'il devait livrer parce que son importation a été bloquée par suite d'une interruption du trafic aérien entre le pays de fabrication et le Luxembourg : dans ce cas il n'est pour rien dans le défaut de livraison. Il ne pourra en revanche pas échapper au paiement de dommages et intérêts en alléguant que son employé, qui devait livrer le bien, est tombé malade et est actuellement en arrêt de travail : même si on ne peut pas dire que le vendeur a commis une faute, c'est de son fait (du fait de son entreprise) si le bien n'a pas été livré à temps. Lorsque l'obligation est de résultat, la responsabilité contractuelle apparaît donc comme une responsabilité objective, sans faute, analogue à celle qui existe en matière délictuelle sur le fondement de l'article 1384 du Code civil. En revanche, elle est une responsabilité pour faute lorsque l'obligation est seulement de moyens.

La distinction est cependant en partie brouillée par le fait de situations intermédiaires, où le créancier contractuel n'a pas à prouver la faute, mais où le débiteur peut s'exonérer de sa responsabilité en

[1825] Ravarani, n° 518 (mais l'auteur reconnaît lui-même plus loin qu'il ne s'agit pas d'une présomption de faute).

[1826] Cour d'appel, 2 avril 2003, *Pas.*, 32, p. 524.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

démontrant qu'il n'a pas commis de faute. C'est ce qu'on appelle parfois des obligations de moyens renforcées, ou des obligations de résultat atténuées. La jurisprudence admet ainsi que le dépositaire, qui ne restitue pas la chose déposée, est présumé responsable sauf à prouver qu'il n'a commis aucune faute dans la conservation de la chose, et que, si elle a péri ou disparu, ce n'est pas en raison d'un manque de soins ou de surveillance de sa part[1827]. On est alors en présence d'une responsabilité contractuelle pour faute présumée.

825. Distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat : critères. En dehors des cas où la loi le prévoit, et si les parties n'ont pas exprimé d'intention claire à cet égard, il n'est pas toujours facile en effet de savoir si telle obligation est de moyens ou de résultat. S'il est acquis que les obligations de payer une somme d'argent, celles de livrer ou de restituer une chose, ainsi que les obligations de ne pas faire sont toujours des obligations de résultat[1828], les solutions sont extrêmement variées pour la plupart des obligations de faire non monétaires, et tout spécialement pour les obligations de sécurité. Aucun des critères suggérés en doctrine (qualité des parties professionnelles ou profanes, aléa plus ou moins grand dans l'obtention du résultat, rôle plus ou moins actif du créancier dans l'exécution de la prestation, etc.) ne permet de rendre compte de l'intégralité des solutions jurisprudentielles. Les juges combinent ces différents critères pour aboutir à la qualification qui leur semble la plus opportune, compte tenu de l'équilibre qu'ils veulent établir entre les intérêts des parties. Il en résulte des solutions extrêmement nuancées dont on ne peut donner ici que quelques exemples[1829]. Ont été ainsi considérées comme des obligations de résultat : celle du professionnel chargé de réparer une chose, celle du comptable d'établir un bilan, celle du fournisseur d'un système d'alarme quant au déclenchement de l'alarme en cas d'intrusion, celle de l'organisateur de spectacles quant au respect du programme, les obligations de sécurité du transporteur, du fabricant de bouteille de gaz, l'obligation de présence du salarié sur son lieu de travail[1830], l'obligation du promoteur-vendeur de réaliser des travaux exempts

[1827] Cour d'appel, 13 juin 2007, *Pas.*, 33 p. 58 (à propos de la responsabilité d'un garagiste à qui une voiture de luxe avait été confiée en dépôt-vente et qui avait été volée).

[1828] RAVARANI, n° 519.

[1829] La plupart des exemples sont tirés de RAVARANI, n°s 509, 528 et 529. On y a seulement ajouté quelques décisions très récentes.

[1830] Cour d'appel, 11 juillet 2024, n° CAL-2022-01044.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

de vices[1831], etc. Ont été en revanche considérés comme étant de moyens les obligations du mandataire ou du commissionnaire quant à l'accomplissement des missions dont ils sont chargés[1832], l'obligation d'un agent immobilier[1833], les obligations de sécurité de l'exploitant d'un établissement de bains, d'un manège d'équitation, d'un parc zoologique, d'une discothèque[1834], etc. On peut observer qu'à l'intérieur d'un même contrat, l'obligation d'un contractant peut être qualifiée tantôt de moyens tantôt de résultat selon les circonstances. Par exemple, le médecin n'est en principe tenu que d'une obligation de moyens. C'est même à son propos que la jurisprudence française a, pour la première fois en 1936, consacré la distinction des obligations de moyens et de résultat, en posant que le médecin était tenu « non bien évidemment, de guérir le malade, […] du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science »[1835]. Mais l'évolution des techniques médicales et des idées a amené la jurisprudence, dans certains cas, à faire peser sur le médecin une véritable obligation de résultat à la charge du médecin ou de l'établissement de soins. Il en va ainsi pour ce qu'on appelle les « obligations accessoires de sécurité », dans les cas où le dommage n'est pas dû à un diagnostic erroné ou à des soins inefficaces, mais à des éléments extérieurs à l'activité médicale elle-même (par exemple : le malade chute de la table d'examen parce que celle-ci est défectueuse). Dans le prolongement, la Cour de cassation du Luxembourg a récemment consacré (en suivant le modèle français) une obligation de résultat des établissements de soins pour les infections nosocomiales contractées par le malade lors de son séjour dans l'établissement[1836]. Parfois, le caractère de l'obligation varie en fonction des diverses phases d'exécution du contrat : ainsi, l'obligation du transporteur ferroviaire, qui est de résultat pendant le déroulement du transport, n'est que de moyens tant que le voyageur attend sur le quai[1837].

[1831] Cour d'appel, 27 juin 2024, n°s 44149 et 44301.

[1832] Cour d'appel, 28 mars 2024, n° CAL-2021-01139.

[1833] Cour d'appel, 7 mars 2024, n° CAL-2022-00618.

[1834] Cour d'appel, 4 avril 2024, n° CAL-2022-00856.

[1835] Cass. fr. (civ.), 20 mai 1936 (*Mercier*), préc.

[1836] Cass. lux., 31 janvier 2013, n° 8/13, *Pas.*, 36, p. 373 note, P. Ancel. Voy. récemment Trib. Luxembourg, 21 juin 2023, n^{os} TAL-2020-00112, TAL-2020-01720, TAL-2020-04526 et TAL-2021-10159 (Jonction).

[1837] Cass., 1er juillet 1971, *Pas.*, 21, 464 ; Cour d'appel, 20 avril 2012, *Pas.*, 22, 153 ; Cour d'appel, 22 mars 2018, n° 43904.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

826. Bien-fondé de la distinction. La distinction des obligations de moyens et de résultat n'est qu'une construction doctrinale et jurisprudentielle, qui n'est pas connue de tous les systèmes juridiques, et qui est aujourd'hui, à l'intérieur même des pays du Code civil, souvent critiquée par la doctrine. On lui reproche d'abord la grande incertitude de ses critères, d'où résulte une certaine imprévisibilité des solutions jurisprudentielles quant à la qualification d'obligations de moyens ou de résultat. Mais cette incertitude ne serait pas moins grande si, comme le suggèrent certains auteurs, on s'interrogeait de manière concrète sur le contenu de chaque obligation particulière de chaque contrat sans passer par la phase préalable de qualification dans une des deux catégories. Il est vrai en revanche que la distinction est beaucoup trop rigide : si la notion d'obligation de résultat présente une incontestable unité, il n'en va pas de même pour l'obligation de moyens, car selon les contrats, on sera plus ou moins exigeant quant aux moyens que le débiteur doit mettre en œuvre pour atteindre le résultat. Par exemple, l'obligation qui pèse sur le dépositaire d'apporter dans la garde « les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent » (C. civ., art. 1927) doit être, selon l'article suivant appréciée « avec plus ou moins de rigueur » selon que le dépositaire a ou non offert spontanément ses services selon qu'il est rémunéré ou non, selon qu'il a été fait ou non dans son intérêt, etc. (C. civ., art. 1928), et elle n'est peut-être pas identique à l'obligation, qui résulte d'autres textes, de se comporter « en bon père de famille ». La qualification d'obligations de moyens n'est donc pas, en elle-même suffisante pour établir le degré de diligence requis du contractant. En dépit de ces limites, la distinction conserve un intérêt pédagogique et elle reste un élément incontournable du droit de la responsabilité contractuelle dans les pays du Code civil.

827. Responsabilité contractuelle du fait des choses ou du fait d'autrui ? On a parfois tenté, en France, de transposer à la responsabilité contractuelle les notions de responsabilité du fait des choses et du fait d'autrui qui sont consacrées, en matière délictuelle, par l'article 1384 du Code civil. Cette transposition, qui a inspiré quelques décisions françaises, est cependant généralement critiquée, et elle n'a jusque-là jamais été retenue par la jurisprudence luxembourgeoise[1838]. Dans tous les cas, la responsabilité contractuelle est une responsabilité du fait personnel, résultant du manquement à une obligation par le débiteur contractuel. Si le dommage est causé lors de l'exécution du contrat par le maniement d'une chose, la seule question est de savoir si le comportement du débiteur dans l'utilisation de cette chose est ou non un manquement à son obligation, et la réponse dépend grandement du point

[1838] RAVARANI, n°s 844 et 988.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

de savoir si l'obligation était de moyens ou de résultat. De même, dans le cas extrêmement fréquent où le débiteur contractuel a chargé un tiers (notamment un de ses préposés) de l'exécution de son obligation, on recherchera bien la responsabilité contractuelle de l'employeur ; cependant ce ne sera pas en tant que commettant sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil, mais en tant que débiteur direct et là encore la seule question sera de savoir si le fait du préposé constitue une violation de l'obligation du débiteur. Dans l'exemple déjà pris du déménageur qui casse un vase du client, c'est bien sûr la responsabilité de l'entreprise que le client recherchera en premier lieu, parce que c'est avec l'entreprise qu'il a contracté – non avec l'employé – et c'est l'entreprise qui doit (par l'intermédiaire de ses employés), exécuter les obligations nées du contrat. Comme le dit excellemment la Cour d'appel « la mise en œuvre de cette responsabilité s'effectue dans les mêmes conditions que la responsabilité pour le fait personnel du contractant. Si le débiteur est tenu d'une obligation de résultat, le seul fait de l'inexécution suffit. S'il s'agit d'une obligation de moyens, la victime doit prouver la faute de la personne dont le débiteur répond »[1839].

B) *Le préjudice*

828. Nécessité d'un préjudice. Le préjudice peut être défini, d'une manière générale, comme une atteinte aux intérêts d'une personne. L'existence d'un préjudice est une condition de base de toute responsabilité civile, dès lors que le but de cette responsabilité est de réparer le mal qui a été causé à une personne. Cependant, dans la conception doctrinale qui voit dans les dommages et intérêts contractuels, non pas une véritable responsabilité, mais une forme d'exécution par équivalent du contrat, il a été soutenu que l'existence d'un préjudice n'était pas une condition d'obtention des dommages et intérêts : le créancier contractuel a droit à l'exécution, et, dès lors qu'il ne l'obtient pas, il doit pouvoir obtenir une compensation pécuniaire même s'il n'a subi aucun préjudice particulier. La jurisprudence française a parfois suivi cette idée : ainsi, il a été jugé qu'un locataire, qui n'avait pas exécuté son obligation d'entretien du local loué devait payer des dommages et intérêts à son bailleur alors même que le local loué était voué à la destruction, de sorte qu'il importait peu au bailleur de récupérer ce local en mauvais état[1840]. Cette solution a été très vite abandonnée, mais, d'une manière plus générale, la Cour de cassation française admet aujourd'hui que la preuve d'un préjudice subi n'est jamais nécessaire lorsque l'obligation violée est une obligation de ne pas faire (par exemple, une obligation de non-concurrence). Cette solution était, avant la réforme, fondée sur l'article 1145 du

[1839] Cour d'appel, 15 janvier 1997, n°s 16643 et 16684, cité par RAVARANI, n° 988.
[1840] Cass. fr. (3e civ.), 30 janvier 2002, n° 00-15784.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Code civil, selon lequel « Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention »[1841].

La jurisprudence luxembourgeoise, pas plus d'ailleurs que la jurisprudence belge, ne semble jamais avoir suivi cette position, du reste controversée en France. D'une manière générale, au Luxembourg, l'octroi de dommages et intérêts est toujours subordonné à la preuve d'un préjudice, dont l'importance servira de mesure à l'évaluation des dommages et intérêts. Dans le cas particulier de l'article 1145 du Code civil, il faut sans doute s'en tenir à l'interprétation traditionnelle qui y voyait seulement une dispense de mise en demeure[1842].

Sans doute conviendrait-il de mettre à part le cas où les dommages et intérêts ne sont pas demandés à titre de réparation, mais pour procurer au créancier contractuel l'équivalent de l'exécution en nature que le créancier n'a pas réussi à obtenir : ainsi dans le cas où la prestation fournie n'est pas conforme à celle qui avait été promise, et où la somme demandée vise à permettre au créancier d'obtenir le résultat initialement convenu[1843]. Dans ce cas, on ne se situe pas sur le terrain de la responsabilité mais sur celui de l'exécution, et les dommages et intérêts n'ont pas à être calculés en fonction de l'importance du préjudice subi, mais uniquement en fonction de ce qui est nécessaire pour obtenir la prestation promise. Il n'en reste pas moins que, même dans ces hypothèses, si le créancier ne subit absolument aucun préjudice du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution, on peut penser qu'il n'a aucun intérêt à agir et sa demande en dommages et intérêts devrait être déclarée irrecevable : la force obligatoire du contrat n'est pas un but en soi, elle n'est faite que pour servir les intérêts des parties ; si l'obligation contractuelle a perdu tout intérêt pour le créancier (comme dans le cas du local mal entretenu promis à la démolition ou de l'obligation de non-concurrence ayant perdu toute utilité pour le créancier), on ne voit pas pourquoi le créancier pourrait en obtenir encore l'exécution, ni obtenir des dommages et intérêts à la place de l'inexécution.

829. Spécificité du préjudice contractuel ? Dans de nombreux systèmes juridiques étrangers, le préjudice lié à l'inexécution du contrat est appréhendé de manière différente des préjudices réparables en matière délictuelle : ce ne sont pas les mêmes préjudices qui sont réparés en cas d'inexécution d'un contrat et en cas de violation d'un devoir général de la vie sociale. Il est probable que

[1841] Cass. fr. (1re civ.), 10 mai 2005, n° 02-15910 ; Cass. fr. (1re civ.), 31 mai 2007, n° 05-19978 ; Cass. fr., 29 octobre 2010, n° 09-69928. La solution permet notamment à un contractant d'obtenir des dommages et intérêts en cas de violation d'une obligation de non-concurrence alors que lui-même, ne pouvant exercer l'activité interdite à son cocontractant, ne subit aucun préjudice de cette violation.

[1842] C'était l'interprétation traditionnellement retenue en France : Cass. fr. (1re civ.), 26 février 2002, n° 99-19053 ; Voy. *supra*, n° 692.

[1843] Ainsi dans l'exemple précédemment cité du maître de l'ouvrage qui demande des dommages et intérêts pour faire rehausser le niveau de sa maison non conforme aux plans : Voy. *supra*, n° 744.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

les rédacteurs du Code civil avaient de même pensé de manière spécifique la notion de préjudice contractuel, défini dans l'article 1149 du Code civil, d'une manière très économique, comme couvrant la perte faite par le créancier et le gain dont il a été privé. Au fil du temps, cependant, la tendance majoritaire au rapprochement des deux types de responsabilité s'est traduite par une perte de cette spécificité, tant en ce qui concerne les différents types de préjudices réparables sur le fondement de la responsabilité contractuelle (1) que les conditions auxquelles ces préjudices sont réparables (2).

1) *Différents types de préjudices contractuels*

830. Classifications communes à la responsabilité contractuelle et à la responsabilité extracontractuelle. Dans la mesure où elle est aujourd'hui, majoritairement, conçue comme ayant pour fonction la réparation du préjudice subi par le créancier victime de l'inexécution, la responsabilité contractuelle permet, dans les pays du Code civil, de réparer les préjudices les plus divers, qu'on peut classer de la même manière que dans le cadre de la responsabilité délictuelle. Ces classifications sont rendues plus lisibles si on accepte de distinguer, comme le propose aujourd'hui une partie de la doctrine française, entre la notion de préjudice et la notion de dommage – généralement employées l'une pour l'autre. Dans cette conception, la notion de dommage pour désigner l'événement malheureux advenu à la victime (la mort, les blessures, la destruction d'un bien, etc.), le préjudice désignant plutôt l'atteinte aux intérêts qui peut résulter de ces différents événements[1844]. Dans cette terminologie, on dira que la responsabilité contractuelle permet, tout comme la responsabilité délictuelle, de réparer les conséquences aussi bien des dommages corporels que des dommages matériels résultant de la mauvaise exécution du contrat. Quant aux préjudices, ils peuvent eux-mêmes être soit des atteintes aux intérêts patrimoniaux (une perte de revenus, une perte de clientèle, les dépenses de réparation d'un bien, etc.) soit des atteintes aux intérêts extrapatrimoniaux – ce qu'on appelle habituellement le préjudice moral (des souffrances endurées à la suite d'un accident, la douleur causée par la perte d'un être cher, l'atteinte à sa vie privée, etc.). Les deux notions ne se situent pas sur le même plan : un dommage corporel peut causer

[1844] Le projet ministériel français consacre cette terminologie. Le nouveau droit belge de la responsabilité civile (Livre 6 du nouveau Code civil) fait à peu près la même distinction, mais avec une terminologie différente, en définissant le « dommage » comme les conséquences économiques ou non économiques » d'une atteinte à un intérêt.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

à la fois un préjudice patrimonial (perte de revenus) et un préjudice moral (douleur, souffrance causée par les dégâts esthétiques). Alors que l'article 1149 du Code civil semble ne viser que des préjudices patrimoniaux, il est aujourd'hui admis que les dommages et intérêts contractuels couvrent toutes ces sortes de dommages et de préjudices, dont la diversité n'a d'égal que celle des contrats eux-mêmes. Pour ne prendre que quelques exemples, on peut faire jouer la responsabilité contractuelle aussi bien pour obtenir la réparation des préjudices pécuniaires et moraux qu'on a subi à la suite d'un accident de transport, pour couvrir la perte financière que subit un prêteur du fait qu'il est remboursé en retard par son emprunteur, pour réparer le préjudice à la fois pécuniaire et moral lié au fait que le voyage qu'on a « acheté » a été mal organisé et qu'on a été privé de la visite de certains sites, pour compenser la perte de clientèle qu'on a subie parce que le matériel acheté pour rénover son entreprise vous a été livré en retard ou était défectueux, etc.

Le courant doctrinal français qui ramène la responsabilité contractuelle à une forme d'exécution par équivalent du contrat prône un resserrement de la responsabilité contractuelle sur certains types de préjudices liés à la fonction économique du contrat. Le projet Terré, très inspiré de ce courant, propose notamment de sortit purement et simplement de la responsabilité contractuelle la réparation des atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle d'un contractant, et cette position a été suivie par le projet ministériel français de 2017.

831. Classifications propres à la responsabilité contractuelle. Présentée par les rédacteurs du Code civil comme spécifique aux dommages et intérêts contractuels, la distinction de l'article 1149 du Code civil entre la perte subie (*damnum emergens*) et le manque à gagner (*lucrum cessans*) est aujourd'hui utilisée d'une manière générale dans les deux types de responsabilité civile. La victime d'un accident corporel, par exemple, pourra obtenir aussi bien la compensation des frais médicaux qu'elle a dû exposer pour se faire soigner (perte subie) que celle de la perte de salaire qu'elle subit du fait de son incapacité temporaire ou définitive de travail (manque à gagner), et ceci sans qu'il y ait à distinguer selon que l'accident est un accident de la circulation relevant de la responsabilité délictuelle ou un accident de transport relevant des articles 1147 et suivants du Code civil. Une autre distinction, en revanche, est propre à la responsabilité contractuelle, car elle repose sur le type de préjudice que peut causer la non-obtention

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

d'une prestation promise – ce qui est une situation typiquement contractuelle. Il faut ici distinguer entre le préjudice lié au retard dans l'accomplissement de la prestation (par exemple : le retard dans le paiement d'une somme d'argent qui vous prive des bénéfices que vous auriez ou tirer du placement de cette somme) et le préjudice lié à l'inexécution définitive ou à la mauvaise exécution de la prestation attendue (le fait de recevoir une chose défectueuse, l'absence du traiteur le jour du repas de mariage, la violation de son obligation de non-concurrence qui détourne ainsi à son profit une partie de votre clientèle, etc.). Ces deux types de préjudice sont réparés par des dommages et intérêts qui, sur certains points, n'obéissent pas aux mêmes règles : moratoires dans le premier cas, compensatoires dans le second. On l'a déjà vu à propos de la mise en demeure, on le verra plus loin en ce qui concerne les modes d'évaluation.

2) *Conditions pour que le préjudice contractuel soit réparable*

832. Conditions communes aux deux types de responsabilités. D'une manière générale, le préjudice contractuel, pour être réparable, doit répondre aux mêmes conditions que dans le cadre de la responsabilité délictuelle. On se contentera donc de les rappeler ici brièvement en renvoyant pour plus de détails aux ouvrages généraux du droit de la responsabilité civile[1845]. Le préjudice doit d'abord être certain, exigence considérablement atténuée par l'admission, dans les pays du Code civil, de la notion de perte d'une chance. Le préjudice doit en outre consister dans la lésion d'un intérêt licite (ou légitime) : utilisée naguère pour cantonner la réparation aux préjudices résultant de l'atteinte à un droit subjectif, cette condition permet aujourd'hui à la jurisprudence de refuser l'action en réparation à certaines victimes qui se trouvaient dans une situation illicite qui a été à l'origine de leur dommage. En matière contractuelle, cette idée trouve spécialement application en cas de « travail au noir », à la fois pour refuser au travailleur au noir le paiement des rémunérations qui lui ont été promises et à l'employeur le paiement d'indemnités en réparation du travail mal fait[1846]. On ajoute généralement que le dommage doit être direct, mais cette condition relève plutôt de l'exigence du lien de causalité que du préjudice lui-même.

[1845] Pour le Luxembourg : Ravarani, n°s 1096 et s.

[1846] Cour d'appel, 9 novembre 2011, *Pas.*, 35, p. 700, note P. Ancel (au motif très contestable de la règle Nemo auditur).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

833. Condition spécifique à la responsabilité contractuelle : prévisibilité du préjudice. L'article 1150 du Code civil (repris presque textuellement par l'article 1231-3 du Code civil français) dispose que le débiteur « n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ». Ce texte, qui consacre implicitement la validité des clauses limitatives de responsabilité en matière contractuelle[1847], pose aussi, plus directement, une condition spécifique à la réparation du préjudice contractuel : « qu'on ait pu prévoir » les dommages et intérêts, donc le préjudice à réparer. Cette exigence, dont on retrouve l'équivalent dans certains textes internationaux et projets européens, est révélatrice du lien qui existe entre l'obligation de réparation et le contrat inexécuté : lors de la conclusion du contrat, le débiteur a dû mesurer la portée de son engagement (et éventuellement le montant de la contrepartie demandée à son cocontractant) en fonction de ce qu'il pouvait imaginer d'avoir à payer en cas de mauvaise exécution. Pour raisonner sur un exemple classique, si vous confiez un colis à un transporteur sans lui dire qu'il y a dedans un tableau précieux qui vaut plusieurs millions d'euros, il ne peut pas s'attendre à débourser une telle somme si le colis est détérioré. Un préjudice d'une telle importance est imprévisible et le client ne devrait pas pouvoir en obtenir réparation. Encore faut-il déterminer ce qui doit être prévisible : s'agit-il seulement du type de dommage susceptible d'être subi, ou de son étendue ? L'exigence de prévisibilité concerne certainement, au minimum, la nature du dommage : par exemple, la Cour de cassation française a estimé (de manière très rigoureuse) que la SNCF (compagnie française des chemins de fer), responsable du retard dans le transport ferroviaire, n'avait pas à réparer le dommage subi par le client qui, à la suite de ce retard, avait manqué sa correspondance en avion[1848]. Mais faut-il aller au-delà, et considérer que l'exigence de l'article 1150 du Code civil touche également l'étendue du dommage ? Ainsi, dans l'exemple précité, si le client avait, en prenant son billet, déclaré qu'il avait un avion en correspondance, mais sans dire qu'il s'agissait d'un voyage en classe affaires, suivi d'un séjour en hôtel de luxe, la SNCF aurait-elle dû indemniser son client pour l'intégralité de la perte financière subie ? Là-dessus, la jurisprudence n'adopte pas exactement la même position dans les trois pays du Code

[1847] Voy. *infra*, n°s 853 et s.

[1848] Cass. fr. (1re civ.), 28 avril 2011, n° 10 – 15 056.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

civil. Pour la Cour de cassation belge, la prévisibilité ne concerne que la cause du dommage ; en conséquence « pour que le débiteur puisse être condamné, du chef d'inexécution, à réparer le dommage qui était prévu ou qui était prévisible lors du contrat, il n'est pas requis que l'étendue du dommage soit déjà prévue ou puisse être prévue »[1849]. Il en résulte, par exemple, selon certains auteurs, que le transporteur du colis devrait réparer l'intégralité du dommage causé par la perte du colis, y compris la perte des objets précieux non déclarés[1850]. Cette position semble consacrée par l'article 5.87 du nouveau Code civil belge selon lequel « seul le dommage dont les parties pouvaient raisonnablement prévoir le principe à la conclusion du contrat doit être réparé ». La Cour de cassation française a une position moins tranchée : elle pose certes que « les dispositions de l'article 1150 concernent seulement la prévision ou la prévisibilité des éléments constitutifs du dommage et non l'équivalent monétaire destiné à les réparer »[1851], mais la notion d'éléments constitutifs du dommage permet d'englober des éléments qui ne seraient pas pris en compte en Belgique (nature des biens transportés dans le colis remis au transporteur, nature du vol pris en correspondance et catégorie de l'hôtel, etc.)[1852]. C'est seulement l'évaluation monétaire de ces éléments qui échappe à l'exigence. La jurisprudence luxembourgeoise, quant à elle, a évolué sur la question. Après avoir exigé la prévisibilité non seulement de la consistance, mais de la valeur du bien objet du contrat[1853], elle estime aujourd'hui que la prévisibilité ne porte pas sur l'étendue du dommage mais seulement sur sa consistance, ce qui implique que le responsable doit supporter les augmentations même imprévisibles de la valeur du bien[1854]. Cette interprétation réduit considérablement la portée de l'article 1150 du Code civil, et contribue à rapprocher la responsabilité contractuelle de la responsabilité délictuelle.

[1849] Cass. be., 11 avril 1986, *R.C.J.B.*, 1990, p. 79, note Cornélis ; Cass. be., 4 février 2010, *R.D.C.*, 2010, p. 498.

[1850] Dans ce sens, Wéry, n° 560.

[1851] Cass. fr. (comm.), 4 mars 1965, *JCP*, 1965, II, p. 14219, note Rodiere.

[1852] Voy. p. ex. Cass. fr. (1re civ.), 3 juin 1998, n° 95-16 887 (où la recherche de la prévisibilité porte sur la nature des objets emportés par les voyageurs dans leurs bagages).

[1853] Cour d'appel, 6 juin 1984, n° 7374.

[1854] Cour d'appel, 4 juillet 2012, n° 36967 (à propos d'une œuvre d'art confiée à un musée et valant 5 fois plus que la valeur déclarée). Voy. cependant Trib. Luxembourg, 28 janvier 2022, n° TAL-2020-05668 (qui, tout en admettant le caractère prévisible du dommage – nécessité de remplacer un parquet – réduit le montant de l'indemnisation en tenant compte du prix initial du parquet).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Dans tous les cas, l'exigence de prévisibilité tombe si l'inexécution est due à un « dol » du débiteur, c'est-à-dire à sa faute intentionnelle[1855]. Nous retrouverons cette limite à propos des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité.

C) *Le lien de causalité*

834. Condition commune aux deux responsabilités. Comme le préjudice, l'exigence d'un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité (ici la violation d'une obligation contractuelle) et le dommage subi est une condition commune à la responsabilité contractuelle et à la responsabilité délictuelle, et il ne s'agit ici que de signaler les particularités (limitées) que cette condition présente en matière contractuelle, renvoyant pour le reste aux ouvrages de droit de la responsabilité civile[1856]. En matière contractuelle comme en matière délictuelle, la causalité joue un double rôle : elle apparaît comme une condition positive de la responsabilité (**1**), mais elle apparaît également négativement, en creux, à travers les causes d'exonération de la responsabilité (**2**). C'est surtout sur ce second terrain qu'on peut noter un certain particularisme de la responsabilité contractuelle.

1) *La causalité, condition positive de la responsabilité contractuelle*

835. Différentes conceptions du lien de causalité (renvoi). La causalité est sans doute la condition de la responsabilité civile qui a fait couler le plus d'encre. La doctrine et la jurisprudence se partagent entre deux conceptions. Dans la conception dite de « l'équivalence des conditions », tout événement qui a été, de quelque manière que ce soit, à l'origine du dommage, sans lequel le dommage ne serait pas produit, est considéré comme étant juridiquement une de ses causes. La théorie dite de la « causalité adéquate », à l'opposé, amène à sélectionner les événements qui apparaissent comme les plus déterminants, comme ceux qui étaient les plus susceptibles de causer le dommage. On en trouve une traduction remarquable dans l'article 6.18 du nouveau Code civil belge, qui, tout en posant en principe qu'un fait est une cause

[1855] Cour d'appel, 23 mars 2006, *Pas.*, 33, p. 175.

[1856] En tout premier lieu pour le Luxembourg à RAVARANI, n°s 989 et s. qui utilise très largement le droit français. Pour la Belgique, voy. tout particulièrement VAN OMMESLAGHE, vol. 2, n°s 1091 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

du dommage si, sans ce fait, le dommage ne se serait pas produit, pose ensuite que « toutefois, il n'y a pas de responsabilité si le lien entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est à ce point distendu qu'il serait manifestement déraisonnable d'imputer ce dommage à la personne dont la responsabilité est invoquée. Dans cette appréciation, il est tenu compte, en particulier, du caractère improbable du dommage au regard des conséquences normales du fait générateur de responsabilité et de la circonstance que ce fait n'a pas contribué de manière significative à la survenance du dommage ». C'est plutôt cette seconde théorie qui inspire en général les solutions de la jurisprudence luxembourgeoise[1857], aussi bien en matière contractuelle qu'en matière délictuelle.

836. Exigence particulière à la responsabilité contractuelle : l'article 1151 du Code civil. L'article 1151 du Code civil semble poser, quant au lien de causalité, une exigence spécifique à la responsabilité contractuelle. Selon ce texte, les dommages et intérêts ne doivent comprendre « à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ». Il faudrait donc une proximité particulière entre l'inexécution de l'obligation contractuelle et le dommage subi. Ce texte trouve son origine dans un passage célèbre de Pothier, qui envisage les différents dommages en chaîne qui peuvent se produire à la suite de la vente d'une vache atteinte d'une maladie contagieuse[1858]. Le vendeur est certainement tenu de compenser la perte de la vache, mais aussi la perte du troupeau contaminé qui s'en est suivie. Mais sera-t-il également tenu de réparer le dommage subi du fait que l'acheteur, privé de ses bœufs, n'a pu labourer ses terres, ce qui l'a conduit à ne pas pouvoir payer ses créanciers, qui ont fait saisir et vendre à vil prix les biens du paysan ? Pour Pothier, la réponse est négative : « le marchand ne sera pas tenu des dommages que j'ai souffert par la saisie réelle de mes biens ; ce dommage n'est qu'une suite très éloignée et indirecte de son dol ; et il n'y a pas une relation nécessaire : car quoique la perte de mes bestiaux, que son dol m'a causée, ait influé dans le dérangement de ma fortune, ce dérangement peut avoir eu d'autres causes ». Cependant l'article 1151 du Code civil n'apparaît aujourd'hui que comme une expression de l'exigence de causalité,

[1857] Ravarani, n°s 1001, 1994 et s.
[1858] Pothier, n° 167.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

et la question des dommages en chaîne est aujourd'hui réglée par application de la théorie de la causalité adéquate, sans que l'on distingue selon que le fait générateur initial constitue un délit civil ou l'inexécution d'un contrat.

Il est certain en tout cas que cette exigence d'un dommage direct n'empêche pas, en matière contractuelle comme en matière délictuelle, la réparation des préjudices dits « par ricochet », qui sont subis, non par la victime directe du dommage, mais par d'autres personnes qui subissent eux-mêmes un préjudice consécutif. Le cas typique est celui des proches d'une personne décédée dans un accident, qui souffrent à la fois moralement et financièrement à la suite de ce décès. Il faut néanmoins signaler que, si l'accident est le résultat de la mauvaise exécution d'un contrat (par exemple, un accident de transport, un accident médical), ces victimes par ricochet, qui sont tiers au contrat, ne pourront en principe agir en réparation contre le débiteur contractuel que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en raison du principe de l'effet relatif du contrat[1859].

2) *Les causes étrangères, facteurs d'exonération de responsabilité*

837. Causes étrangères. Dans tous les cas, en matière contractuelle, il appartient au créancier qui se prétend victime de l'inexécution de prouver que cette inexécution y a été pour quelque chose dans la production du dommage. La jurisprudence française avait, pendant une certaine période, posé une solution contraire dans le cadre des obligations de résultat, dans lesquelles elle voyait une présomption de causalité[1860], mais cette jurisprudence est aujourd'hui abandonnée[1861]. Qu'on soit en présence d'une obligation de moyens ou de résultat, la victime doit prouver que le comportement du débiteur contractuel est, d'une manière ou d'une autre, intervenu dans la survenance du dommage. Cela, cependant, n'empêche pas le débiteur contractuel de prouver l'existence d'autres événements qui doivent être considérées, soit comme des causes concurrentes à son propre fait, soit même comme la seule et véritable cause du dommage. Ces causes étrangères aboutiront, selon les cas, soit à

[1859] Voy. *infra*, n°s 986 et s.

[1860] Cass. fr. (1re civ.), 16 février 1988, n° 86-14918 (il s'agissait de dispenser le client d'un garagiste, victime d'une panne, de prouver que cette panne était due à l'intervention du garagiste).

[1861] Cass. fr., 28 mars 2008, n° 06-18350.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

une exonération totale si l'événement extérieur est la cause exclusive du dommage (**a**), soit à une exonération partielle dans le cas contraire (**b**).

a. *La cause étrangère exclusive : l'exonération totale*

838. Force majeure. Dans certains cas, alors même que le contrat n'a pas été ou a été mal exécuté, le débiteur contractuel échappera à toute responsabilité, s'il apparaît que cette inexécution a été provoquée par un événement extérieur qui a rendu l'exécution impossible. On considérera alors que cet événement a été la cause exclusive du dommage, ce qui, en quelque sorte, coupe le lien de causalité apparent entre l'inexécution et le dommage. C'est ce qu'on appelle la force majeure. La notion de force majeure a été étudiée en tête des développements sur l'inexécution des obligations contractuelles[1862], et on a déjà vu ses effets sur différentes sanctions, notamment sur la résolution du contrat[1863]. Mais ce qui nous intéresse ici , c'est que la force majeure, parce qu'elle suspend l'exécution de son obligation par le débiteur (si l'empêchement est temporaire) ou parce qu'elle le libère de son obligation (si l'empêchement est définitif) a aussi et d'abord pour effet, comme en matière délictuelle, d'exonérer le débiteur de l'obligation inexécutée (ou exécutée avec retard) de toute responsabilité. C'est ce que prévoit, en matière contractuelle, l'article 1147 du Code civil selon lequel « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, *toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée*, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». En théorie, cet effet exonératoire peut se produire dans tous les cas de responsabilité contractuelle. Cependant, si le débiteur est tenu d'une obligation de moyens, le débat sur la force majeure n'apparaît que rarement au titre des causes d'exonération, il se fond habituellement dans la discussion sur la faute du débiteur : le créancier contractuel essaiera de prouver que le débiteur a commis une faute, et celui-ci se défendra en essayant de montrer qu'il a été empêché de mettre tous les moyens en œuvre par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. En pratique, la force majeure n'apparaîtra donc comme une cause d'exonération autonome que dans le cadre des responsabilités sans

[1862] Voy. *supra*, n°s 676 et s.
[1863] Voy. *supra*, n°s 766 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

faute, où, précisément, le seul moyen pour l'auteur du dommage d'échapper à sa responsabilité est de démontrer que son fait n'a pas été la véritable cause du dommage. En matière contractuelle, la force majeure ne joue donc un rôle spécifique que dans le cadre des obligations de résultat.

b. *Les causes étrangères concurrentes : l'exonération partielle*

839. Fait de la victime et fait du tiers. Le débiteur contractuel, qui n'a pas exécuté son obligation, peut essayer de démontrer que cette inexécution n'est pas la seule cause du dommage subi, et qu'elle est liée, aussi, à d'autres causes qui lui sont extérieures. Si ces autres causes ne présentent pas les caractères de la force majeure, elles pourront néanmoins, dans certains cas, entraîner une exonération partielle de responsabilité. Les solutions ne sont pas ici différentes en matière contractuelle et en matière délictuelle.

Il en va ainsi, tout d'abord, lorsque le dommage subi par le créancier trouve son origine, en partie dans le comportement du débiteur contractuel, en partie dans le comportement du créancier lui-même : par exemple, le vendeur, qui détériore la chose vendue lors de la livraison, reproche à son acheteur de ne pas l'avoir averti des difficultés d'accès particulières de sa maison, qui ont joué un rôle dans l'accident ; l'emprunteur, qui ne peut pas rembourser l'intégralité de son prêt, vient reprocher au prêteur professionnel de lui avoir prêté imprudemment, alors que sa situation financière laissait présager les difficultés de remboursement ; le transporteur de personnes, responsable d'un accident de transport, reproche au passager de n'avoir pas respecté les consignes de prudence pendant le transport, etc. Cette situation correspond, en matière délictuelle, à l'exonération partielle par le fait de la victime. En droit français, au terme d'une évolution complexe, comme en droit belge, cette exonération partielle n'est admise que si le fait de la victime est fautif[1864]. Et en France, même, la jurisprudence avait un temps refusé tout effet exonératoire à la faute de la victime non constitutive de force majeure en cas de manquement à une obligation de sécurité de résultat[1865]. Au Luxembourg, la jurisprudence ne fait pas

[1864] France : Cass. fr. (1re civ.), 17 janvier 2008, n° 06-20107 ; Belgique : Cass. be., 9 octobre 2009, *Pas. be.*, 2009, p. 2195.

[1865] Cass. fr. (1re civ.), 13 mars 2008, n° 05-12551 (cette solution, élaborée à propos de l'obligation de sécurité du transporteur de personnes, ne s'applique plus en matière de transport ferroviaire, désormais régi par le Règlement européen du 23 octobre 2007 : Cass. fr. (1re civ), 11 décembre 2019, n° 18-13.840 P).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

ces distinctions et elle admet l'exonération partielle même en cas de fait non fautif de la victime, si ce fait a eu un rôle causal déterminant dans la production du dommage[1866]. En pratique, cependant, la différence n'a que des conséquences limitées, surtout en matière contractuelle, où le fait du créancier, lorsqu'il a joué un rôle causal, est le plus souvent un fait fautif[1867]. Selon les cas, le partage de responsabilité se fera soit en fonction de la gravité des fautes, soit en fonction du rôle causal de chacun des faits ayant concouru à la production du dommage.

Lorsque le dommage est dû à la fois au fait du défendeur et au fait d'un tiers, en revanche, ce fait n'a aucun effet exonératoire : dans ce cas, en effet, les deux coresponsables sont tenus chacun *in solidum*, c'est-à-dire de la totalité de la réparation[1868]. Le partage de responsabilité ne se produira que dans les rapports des coresponsables entre eux, au stade des recours. Le fait d'un tiers n'est une cause d'exonération que s'il est constitutif de force majeure : l'exonération sera alors totale. Il en va de même en cas de concours entre le fait du débiteur contractuel et un événement naturel, qui n'est exonératoire que s'il présente les caractères de la force majeure.

840. Mitigation ? On peut rattacher à la problématique de la faute de la victime la question de l'obligation pour la victime de modérer son dommage, connue habituellement sous la terminologie anglophone de « *mitigation* ». La question est de savoir si la victime d'un dommage ne doit pas prendre les mesures nécessaires pour limiter (*mitigate*) l'importance de ce dommage lorsque cela est possible – à défaut de quoi elle ne pourrait pas obtenir la réparation intégrale. La question peut se poser en matière contractuelle comme en matière délictuelle, pour la réparation des dommages corporels : la victime d'un accident, devenue handicapée, peut-elle obtenir la réparation intégrale de son préjudice alors que, en acceptant de subir un traitement médical approprié, elle aurait pu limiter les conséquences de ce handicap ? En matière contractuelle, la question peut aussi concerner des dommages économiques : si par exemple l'acheteur de marchandises ne vient pas en prendre livraison, le vendeur a, selon l'article 1657 du Code civil, la faculté de déclarer la résolution

[1866] Cour d'appel, 29 juin 1983, *Pas.*, 26, p. 54 ; Cour d'appel, 29 juin 1983, *Pas.*, 26, p. 54. Voy. plus récemment : Trib. Luxembourg, 29 octobre 2019, n° TAL-2018-05139 ; Cour d'appel, 13 juillet 2023, n^{os} CAL-2021-00847 et CAL-2021-00908.

[1867] Dans ce sens Ravarani, n° 1044.

[1868] Voy. *supra*, n° 622.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de la vente, pour pouvoir vendre ailleurs les marchandises ; s'il ne le fait pas, et qu'il laisse les marchandises se détériorer, pourra-t-il néanmoins demander à l'acheteur de lui en rembourser le prix intégral, alors que son comportement est pour quelque chose dans cette détérioration ?

De très nombreux droits étrangers font peser sur la victime – et en particulier pour le créancier contractuel victime de l'inexécution – une telle obligation de modérer le dommage. En *common law*, en particulier, le « *duty to mitigate the damage* » s'inscrit dans la logique économique qui domine tout le droit des contrats. Les textes internationaux et projets européens admettent de même que « Le débiteur ne répond pas du préjudice dans la mesure où le créancier aurait pu l'atténuer par des moyens raisonnables »[1869]. Au sein des pays du Code civil, la jurisprudence belge s'est clairement rangée à cette approche, sur le fondement de l'exigence de bonne foi de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil : dans un arrêt de 2001, la Cour de cassation a admis que « si cette règle n'impose pas au créancier de restreindre son dommage dans toute la mesure du possible, elle lui commande de prendre, avec loyauté, les mesures raisonnables qui permettent de modérer ou de limiter son préjudice »[1870]. Cette solution est aujourd'hui consacrée, en matière contractuelle, par l'article 5.238 du nouveau Code civil belge, selon lequel « [l]e créancier doit prendre les mesures raisonnables pour limiter et prévenir les conséquences dommageables de l'inexécution […] Si le créancier ne prend pas ces mesures, le dommage qui en découle est alors à sa charge ». La Cour de cassation française, en revanche, refuse obstinément de consacrer une telle obligation : pour elle « l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable »[1871]. Mais le projet ministériel français de 2017 consacre une telle obligation de limiter le dommage, sauf en matière de dommages corporels. Au Luxembourg, en dépit de certaines solutions en sens contraire[1872], la jurisprudence semble majoritairement favorable à l'obligation pour la victime de modérer son dommage, du moins

[1869] Formule tirée des Principes Unidroit, art. 7.4.8. Voy. des formules approchantes dans : CVIM, art. 77 ; PDEC, art. 9 : 505 ; DCFR, art. 3 : 705.

[1870] Cass. be., 17 mai 2001, *J.T.*, 2002, p. 467. Sur le droit belge, voy. D. PHILIPPE, « L'obligation pour la victime de limiter son propre dommage », *J.L.M.B.*, 1994, p. 48.

[1871] Cass. fr., 19 juin 2003 (2 arrêts), n°s 01-13289 et 00-22302.

[1872] Trib. Luxembourg, 2 juin 2010, n° 164/10 XVII ; Trib. Luxembourg, 9 mars 2011, n° 88/11 XVII.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

en matière contractuelle[1873]. Cette position semble d'autant plus facile à admettre que, comme on l'a vu, la jurisprudence luxembourgeoise admet l'exonération partielle du responsable en cas de fait même non fautif de la victime : si celle-ci ne prend pas les mesures permettant de réduire son dommage, elle contribue à celui-ci et il est logique qu'elle en supporte la partie qu'elle aurait pu éviter. Encore faut-il cependant, que ces mesures apparaissent comme raisonnables, ce qu'il appartient au responsable de prouver[1874]. Il faut aussi qu'elles soient possibles. En matière contractuelle, l'un des moyens qui permet le plus souvent de réduire l'étendue du préjudice est de mettre fin au contrat au plus vite pour vendre ailleurs les biens qui en sont l'objet ou pour faire accomplir par un tiers le service attendu du contractant défaillant. Cela explique que l'obligation de mitigation se soit tout particulièrement développée dans des systèmes juridiques qui admettent la possibilité pour le créancier de se dégager du contrat par déclaration unilatérale : on peut d'autant plus facilement lui reprocher de ne pas avoir usé de cette possibilité. Dans les pays du Code civil, le champ de la mitigation se trouvait jusque-là réduit du fait que le créancier devait en principe recourir au juge pour obtenir la résolution du contrat ou le remplacement du débiteur. La déjudiciarisation des sanctions de l'inexécution qui est actuellement à l'œuvre dans les pays du Code civil paraît de nature à donner une expansion plus grande à l'obligation de modérer le dommage en matière contractuelle.

§2. Effets de la responsabilité contractuelle

841. Réparation. Le propre de la responsabilité civile est de faire naître une obligation de réparer le dommage subi, et c'est l'effet qu'on accorde généralement à la responsabilité contractuelle – sauf si on y voit une forme d'exécution par équivalent de l'obligation inexécutée. Cependant cette obligation de réparer présente une certaine spécificité en matière contractuelle, tant en ce qui concerne les modes de réparation (**A**) que la mise en œuvre du droit à réparation (**B**).

[1873] Voy. les nombreuses décisions citées par Ravarani, n° 1213, et not. : Cour d'appel, 26 février 1997, *Pas.*, 30, p. 207 ; Cour d'appel, 4 mars 2009, *Pas.*, 34, p. 620. Plus récemment, à propos d'un salarié licencié abusivement : Cour d'appel, 23 juillet 2020, n^os^ CAL-2019-00322 et CAL-2019-00657.

[1874] Le problème se pose en particulier pour les traitements médicaux, de la proportionnalité entre les risques qu'ils présentent et les chances d'amélioration qu'ils offrent à la victime, voy. p. ex. Trib. Luxembourg, 26 mai 2010, n° 157/10 XVII.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

A) *Modes de réparation*

842. **Réparation *versus* exécution.** On oppose souvent réparation en nature et réparation par équivalent. Cette distinction, déjà très ambigüe en matière de responsabilité délictuelle[1875], n'apparaît guère pertinente dans le cadre de la responsabilité contractuelle. En matière contractuelle, la distinction essentielle est entre l'exécution forcée du contrat, et la réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution, qui est nécessairement un équivalent de ce que le créancier contractuel a perdu ou n'a pas pu obtenir. Si j'obtiens du juge que mon débiteur soit condamné, sous astreinte, à faire ce qu'il m'avait promis, il n'est pas question de réparation, mais d'exécution forcée. La réparation, elle, vise à compenser, par la fourniture d'un équivalent, le préjudice que le créancier subit du fait du retard dans l'exécution ou de l'absence d'exécution. Il n'en reste pas moins que cet équivalent peut lui-même prendre la forme de prestations en nature venant à la place de la prestation non fournie, et on peut, dans ce cas, parler de réparation en nature (1). Dans l'immense majorité des cas, cependant, l'équivalent prendra la forme monétaire de dommages et intérêts (2).

1) *Réparation en nature*

843. **Notion.** Si j'ai contracté avec un journal pour la publication d'un reportage sur ma vie, et que le journal, violant le contrat, révèle des éléments que je lui avais expressément interdit de révéler, je peux demander, en réparation de cette atteinte à ma vie privée, qu'il soit condamné à publier la décision qui reconnaît sa faute. Si l'architecte qui a fait les plans de ma maison a commis une erreur, de sorte que ma maison est inhabitable, je peux demander à ce qu'il soit condamné à financer sa reconstruction. Ce sont deux exemples de réparation en nature en matière contractuelle. Dans ces cas, je n'obtiens pas l'exécution de ce qui était promis, mais une compensation sous une forme non financière. La distinction avec l'exécution en nature se révèle cependant souvent assez délicate : si j'achète un bien qui se révèle défectueux, et que je demande à ce que mon vendeur soit condamné à me fournir un bien de remplacement, s'agit-il d'exécution ou de réparation ? La distinction est théoriquement importante, parce que, s'il s'agit d'exécution, le créancier y a droit sans avoir à prouver de préjudice, alors qu'il doit faire cette preuve si on est en présence d'une réparation. Par ailleurs, alors que le juge, dans la conception qu'on se fait de la force obligatoire du contrat dans les pays du Code civil, est en principe tenu d'ordonner l'exécution en nature si elle lui est demandée, le choix du mode de réparation lui appartient, et il peut refuser d'ordonner une réparation en nature si elle ne lui paraît pas adéquate. Un arrêt de la Cour d'appel de 1987, d'inspiration très doctrinale[1876], fait clairement la distinction. Après avoir noté que « lorsque le créan-

[1875] P. BRUN, *Responsabilité civile extracontractuelle*, 5e éd., Paris, LexisNexis, 2018, nos 606-607.

[1876] L'arrêt cite G. VINEY et P. JOURDAIN, *Traité de droit civil – Les effets de la responsabilité*, éd., 2001, p. 34, no 16-2.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

cier demande l'exécution en nature et que celle-ci ne se heurte pas à la prohibition fondée sur le caractère dit personnel de l'obligation, le juge est tenu de l'ordonner » et que ce « droit à l'exécution proprement dite du contrat n'est pas subordonné à la preuve des conditions de la responsabilité contractuelle », les juges notent que « lorsque le stade de l'exécution est révolu, la question à résoudre est celle de la réparation du préjudice causé au cocontractant [...] dans ce cas de figure, en droit positif, la réparation en nature est facultative pour le juge »[1877]. Il n'est pas sûr que la jurisprudence, au Luxembourg comme dans les autres pays du Code civil, fasse toujours aussi clairement la distinction.

2) *Réparation pécuniaire : les dommages et intérêts*

844. Différents types de dommages et intérêts contractuels. Dans l'immense majorité des cas, la réparation du préjudice sera faite par l'allocation de dommages et intérêts au créancier victime de l'inexécution. Ces dommages et intérêts peuvent prendre différentes formes, selon la nature de l'obligation inexécutée, et avoir différentes fonctions selon la manière dont ils s'articulent avec les autres sanctions de l'inexécution. On peut d'abord concevoir que le créancier ait demandé, et obtenu, l'exécution en nature du contrat : dans ce cas, les dommages et intérêts viseront à réparer le préjudice subi du fait du retard dans l'exécution, on parle habituellement de dommages et intérêts moratoires. Lorsque l'obligation inexécutée est une obligation de somme d'argent, ces dommages et intérêts prendront la forme d'intérêts de retard (moratoires) dont le montant est fixé par l'article 1153 du Code civil. Si en revanche le créancier n'obtient pas l'exécution du contrat, les dommages et intérêts seront dits compensatoires, car ils visent à compenser le préjudice résultant de cette absence d'exécution. Ces dommages et intérêts n'ont cependant pas la même fonction – et ne devraient pas être évalués de la même manière – selon que le contrat est ou non résolu : dans le cas de résolution, l'article 1184 du Code civil permet au créancier d'obtenir des dommages et intérêts, mais ceux-ci n'ont pas pour but de fournir un équivalent de la prestation non obtenue, puisque le contrat est anéanti et que le créancier est libéré de l'obligation de fournir une contrepartie ou qu'il récupère celle qu'il a déjà fournie. Ces dommages et intérêts ne doivent alors permettre au créancier que de compenser, à titre complémentaire, le préjudice qu'il subit du fait qu'il a été privé du bien pendant un certain temps, ou qu'il n'a pas pu contracter ailleurs[1878].

[1877] Cour d'appel, 6 juillet 2011, n° 35410, cité par RAVARANI, n° 1224.
[1878] Cour d'appel, 1er mars 2000, *Pas.*, 31, p. 367.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

845. Règles d'évaluation des dommages et intérêts. Contrairement à de nombreux droits étrangers, le Luxembourg, pas plus que les autres pays du Code civil, n'a développé des règles très précises d'évaluation des dommages et intérêts, pas plus en matière contractuelle qu'en matière délictuelle. On s'en tient à un principe très général de réparation intégrale, qui laisse un très large pouvoir d'appréciation aux juges (**a**). Cependant, en matière contractuelle, ce principe de réparation intégrale connaît un certain nombre de limites (**b**).

a. *Principe de réparation intégrale*

846. Tout le préjudice, rien que le préjudice. Le principe de réparation intégrale signifie que la réparation accordée doit replacer la victime, autant qu'il est possible, dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas été causé. Commun aux deux types de responsabilité civile, ce principe pose certaines contraintes au juge dans la manière dont il évalue les dommages et intérêts.

Tout d'abord, le juge ne peut pas accorder à la victime moins que ce qu'il estime être la valeur du préjudice subi pour des motifs étrangers à la consistance de ce préjudice. Contrairement à certains droits étrangers, le droit luxembourgeois (pas plus que les droits français ou belge) ne permet pas au juge de modérer le montant des dommages et intérêts en fonction de la plus ou moins grande gravité de la faute[1879], ni en fonction des situations financières respective de la victime et du responsable : un responsable pauvre devra payer autant qu'un responsable riche, et ceci même si la victime est, elle, parfaitement à l'aise financièrement.

Ensuite, à l'inverse, le juge ne peut pas accorder à la victime plus que la valeur de son préjudice, en particulier parce que la faute commise par l'auteur du dommage serait particulièrement grave. À la différence, là encore, de certains droits étrangers, et notamment des droits de *common law*, les droits des pays du Code civil ne connaissent pas, pour l'instant, le mécanisme des *dommages et intérêts punitifs*, qui permettent de sanctionner par une somme très élevée les fautes particulièrement graves, et notamment intentionnelles. Au Luxembourg, comme en France et en Belgique, les

[1879] En droit belge, l'article 1386*bis* du Code civil apportait une exception remarquable à ce principe en permettant au juge de modérer le montant des dommages et intérêts dus par un malade mental. Les articles 6.10 et 6.11 du nouveau code consacrent ce pouvoir de modération pour les mineurs de plus de 12 ans et pour les malades mentaux.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

dommages et intérêts sont faits pour réparer un préjudice, non pas pour punir le responsable, cette fonction étant dévolue au seul droit pénal[1880]. Il n'est pas sûr cependant que cet état de droit subsistera longtemps, l'influence croissante des droits de common law et, avec elle, la prise en considération de l'efficacité économique de la sanction, pouvant conduire à une importation du mécanisme des dommages et intérêts punitifs. Une certaine évolution se dessine déjà en ce sens en droit français, notamment à travers certains projets de réforme[1881].

Enfin le principe de réparation intégrale interdit normalement au juge de fixer le montant des dommages et intérêts de manière forfaitaire, notamment en accordant, expressément du moins, une somme « symbolique », ou en se référant à des barèmes[1882].

847. Liberté d'appréciation du juge. Toutes ces contraintes sont assez théoriques, et n'affectent en réalité que la motivation des jugements. Sur le fond, en effet, le juge est libre d'apprécier la valeur du préjudice *in concreto*, et il n'est pas tenu de justifier le montant des dommages et intérêts qu'il accorde. Dans les pays du Code civil, à la différence de la plupart des pays environnants, l'évaluation des dommages et intérêts est en effet considérée comme une question de fait, relevant de *l'appréciation souveraine des juges du fond*, et ne donnant lieu à aucun contrôle de la part de la Cour de cassation[1883]. La seule limite – complètement formelle – est que la motivation de la décision ne doit pas être en porte à faux avec le principe de réparation intégrale : ainsi, le juge est libre de tenir compte de la gravité de la faute commise, pourvu qu'il ne le dise pas, il peut bien utiliser des barèmes, pourvu que ceux-ci n'apparaissent pas dans sa décision comme obligatoires, etc. Cette liberté d'appréciation, qui aboutit à de fâcheuses disparités entre les juridictions et entre les victimes, est cependant de plus en

[1880] Ravarani, n° 1216. Dans la jurisprudence récente, on trouve plusieurs affaires où on débat sur le point de savoir si l'octroi de tels dommages et intérêts par une juridiction étrangère est contraire à l'ordre public international. Le problème n'a pas été tranché (Voy. Cour d'appel, 13 janvier 2020, n^{os} CAL-2020-00584 et CAL-2020-00632.

[1881] Les dommages et intérêts punitifs étaient admis par le projet Catala (art. 1371) et par l'article 54 du projet Terré (en matière délictuelle). Le projet ministériel de 2017 consacre une solution analogue, sous le nom d'amende civile.

[1882] Sur tous ces points, voy. Ravarani, n°s 1206 et s.

[1883] Cass., 17 février 2000, n° 4/00 ; 19 février 2009, n° 11/09 ; 2 avril 2015, n° 28/15 ; Comp. en Belgique : Cass. be., 16 décembre 2004, *Pas. be.*, 2004, p. 2014. En France : Cass. fr.(civ.), 23 mai 1911, *DP*, 1912, 1, p. 421. Voy. encore récemment : Cass. fr. (2e civ.), 21 décembre 2006, n° 04-13567.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

plus critiquée[1884], et il n'est pas exclu qu'à la longue on introduise dans le système des critères précis d'évaluation des dommages et intérêts[1885].

848. Moment d'évaluation des dommages et intérêts. On a beaucoup discuté, notamment en France, de la date de naissance de la créance de réparation. L'opinion commune est que la victime devient créancière de l'indemnité dès le jour de la survenance du dommage – c'est-à-dire, en matière contractuelle, dès le jour de l'inexécution. Mais on est ici en présence d'une dette de valeur[1886], dont le montant ne sera connu qu'au moment où le juge, dans sa décision, fixera le montant de l'indemnité. Il est constant, au Luxembourg, que c'est à ce moment-là que le juge devra se placer pour évaluer les dommages et intérêts. Il devra donc tenir compte des aggravations ou des diminutions de la consistance du dommage qui ont pu se produire entre le jour de l'événement dommageable (l'inexécution) et le jour de sa décision – ce qui a surtout des conséquences en matière de dommage corporel. Il devra aussi tenir compte des changements du pouvoir d'achat de la monnaie entre ces deux moments : par exemple, si le dommage a consisté dans la destruction d'un bien qui valait 100 au jour du dommage, mais que, au jour de la condamnation, il faut 150 pour acquérir un bien équivalent, la victime recevra 150.

b. *Limites légales*

849. Article 1150 du Code civil (renvoi). On traite souvent comme une limite à la réparation intégrale du préjudice l'article 1150 du Code civil, déjà évoqué, selon lequel les dommages et intérêts sont seulement ceux qu'on a prévus ou pu prévoir lors du contrat. Cependant, la manière dont cet article est interprété en fait plutôt une règle de limitation des chefs de dommage réparables, qu'une règle limitant la réparation du préjudice : pour reprendre l'exemple classique, si le transporteur n'a pas pu prévoir que son client lui confiait des objets précieux, il ne sera pas tenu d'en réparer la perte, mais, dès lors qu'il en est tenu, les dommages et intérêts seront de la totalité de la valeur des objets, même si elle était imprévisible. C'est pourquoi nous avons étudié la question avec les conditions tenant au préjudice réparable[1887].

850. Article 1153 du Code civil. L'article 1153 du Code civil constitue la limitation la plus la plus générale au principe de la réparation intégrale. Ce texte concerne la réparation du dommage que subit

[1884] RAVARANI, n° 1206.
[1885] Le projet ministériel français sur la responsabilité contient diverses règles à ce sujet.
[1886] Voy. *supra*, n° 654.
[1887] Voy. *supra*, n° 833.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

le créancier d'une somme d'argent (que cette créance soit d'origine contractuelle ou non) lorsque cette somme lui est payée avec retard. Le montant des dommages et intérêts est alors fixé par la loi de manière forfaitaire : ils « ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ». Longtemps fixé pour de longues périodes par la loi elle-même, le taux de l'intérêt légal est désormais fixé chaque année par règlement grand-ducal sur la base de la loi modifiée du 18 avril 2004, en fonction du taux moyen des prêts civils et commerciaux pratiqués par les banques. À titre de simple information, on indiquera que le taux pour 2024 est de 4,5 % pour les contrats entre particuliers, et pour les contrats entre professionnels et consommateurs. Pour les transactions commerciales, il existe un taux spécial, fixé conformément à une directive européenne, qui est basé sur le taux marginal de référence publié séparément au mémorial B au début de chaque semestre, majoré de 8 points de pourcentage. Pour le premier semestre 2024 il est fixé à 12,50 %.[1888]. Les intérêts calculés à ce taux ne courent en principe, selon l'article 1153, alinéa 2 du Code civil, qu'à compter de la mise en demeure du débiteur, mais on sait que cette exigence connaît aujourd'hui des exceptions de plus en plus nombreuses.

Les intérêts ainsi calculés constituent un forfait qui s'impose au juge. Ils sont dus quelle que soit l'importance du préjudice réel subi par le créancier, et même, selon l'article 1153, alinéa 2 du Code civil, sans que le créancier ait à justifier d'aucune perte. À l'inverse, le juge n'a pas la possibilité de fixer un taux supérieur en fonction des circonstances spécifiques de la cause (par exemple, pour tenir compte d'un placement particulièrement avantageux que le créancier aurait pu faire s'il avait eu l'argent en temps utile). Il ne peut qu'appliquer le taux légal. Ce caractère forfaitaire, cependant, ne vaut que pour le préjudice né du retard lui-même (qui consiste normalement dans la perte des revenus que l'argent encaissé à temps aurait pu procurer au créancier). En revanche, si le créancier a subi un préjudice indépendant du retard, il peut, selon l'article 1153, alinéa 4 du Code civil, obtenir des dommages et intérêts complémentaires, qui sont, eux, compensatoires : on peut imaginer par exemple la perte qu'aurait subi une entreprise qui, n'ayant pas été payée à

[1888] Ce taux résulte de la loi du 18 avril 2004 telle que modifiée par la loi du 29 mars 2013 [transposant la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte) ayant abrogé la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000]. Il est défini par rapport au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à certaines opérations.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

temps, n'a pas pu se procurer les matières premières nécessaires à sa production, et a dû elle-même indemniser ses clients pour le retard dans ses livraisons. Ces dommages et intérêts complémentaires ne sont dus que si le débiteur était en faute, mais, contrairement au droit français et au droit belge, l'article 1153 du Code civil n'exige pas la mauvaise foi du débiteur[1889].

Le dispositif d'évaluation forfaitaire de l'article 1153 du Code civil est complété par l'article 1154 du Code civil qui réglemente l'anatocisme, c'est-à-dire la capitalisation des intérêts. La règle est qu'en principe, les intérêts ne portent pas eux-mêmes intérêt (ce qui pourrait aboutir à une augmentation très rapide de la dette du débiteur). Cependant, cette capitalisation peut être prévue expressément par la convention, elle ne peut alors s'opérer qu'année par année, et porter seulement sur des intérêts échus[1890].

La condamnation à payer des intérêts s'applique d'abord au débiteur qui, dès avant le jugement de condamnation, était tenu d'une obligation monétaire qu'il n'a pas exécutée. Mais des intérêts peuvent aussi courir sur les dommages et intérêts auxquels est condamné un débiteur contractuel ayant manqué à ses engagements (ou tout autre responsable de dommage). En principe, ces intérêts courent, au taux légal, à partir du jour de la condamnation si le débiteur condamné tarde à exécuter. Il s'agit alors d'intérêts moratoires relevant de l'article 1153 du Code civil. Mais les juges peuvent aussi faire courir des intérêts sur la période antérieure à la condamnation, à un moment où le débiteur, n'étant pas encore condamné, ne pouvait pas encore exécuter. Bien que ces intérêts visent aussi à réparer un préjudice directement lié à l'écoulement du temps entre le fait dommageable (soit, en matière contractuelle l'inexécution du contrat) et le prononcé de la décision, on les qualifie habituellement, au Luxembourg comme en Belgique, *d'intérêts compensatoires*, dont le juge peut librement fixer le taux d'intérêt et le point de départ, sans être tenu par l'article 1153 du Code civil[1891]. Elaborée naguère par la jurisprudence française pour permettre au juge d'accorder des intérêts courant sur des dommages et intérêts avant le prononcé du jugement, alors que le débiteur n'avait pas été mis en demeure, la notion a perdu de son intérêt depuis une loi de 1985 ayant inséré dans le Code civil français un article 1153-1 – sans équivalent au Luxembourg – prévoyant que les intérêts sur une décision de condamnation courent de plein droit à partir de la décision, mais que le juge a la faculté de les faire courir à partir d'une date antérieure. La Cour de cassation française, après quelques hésitations, a finalement admis que ces intérêts antérieurs avaient nécessairement un caractère moratoire[1892].

851. **Autres textes.** De nombreux textes spéciaux dérogent au principe de la réparation intégrale en matière contractuelle. Certains de ces textes – issus parfois de conventions internationales – fixent des plafonds d'indemnisation : le créancier

[1889] Cour d'appel, 26 janvier 2012, n° 34796.

[1890] Pour plus de détails, voy. RAVARANI, n° 1250.

[1891] Cour d'appel, 20 mars 2008, n°s 30902, 30589, 31491. Sur ces intérêts compensatoires, voy. RAVARANI, n° 1251. Comp. pour la Belgique, VAN OMMESLAGHE, vol. 2, n° 1149.

[1892] Cass. fr. (1re civ.), 28 avril 1998, n°.96-14762

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

victime de l'inexécution ne peut pas obtenir plus que le montant fixé, mais, si son dommage est inférieur, il obtiendra moins. Il en va ainsi, par exemple, en matière postale, en cas de perte ou de détérioration d'un envoi[1893], ou en matière de transport aérien[1894]. D'autres textes fixent, à l'inverse des minima d'indemnisation : ainsi en matière de bail d'habitation, le locataire dont le bail a été résilié a droit à des dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à une année de loyers si le motif de résiliation s'avère dolosif.

B) *Mise en œuvre du droit à réparation*

852. **Compétence et prescription.** En droit luxembourgeois, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle se distingue assez peu de celle de la responsabilité contractuelle, parce que les règles relatives à la compétence juridictionnelle, et à la prescription de l'action sont en principe les mêmes. Néanmoins, s'agissant de la prescription, il faut noter que le point de départ du délai pour agir – qui est en principe, dans les deux cas, de trente ans ou de dix ans entre commerçants – n'est pas le même en matière délictuelle (où c'est le jour de la naissance du dommage) et en matière contractuelle (où c'est la date d'exigibilité de l'obligation inexécutée)[1895]. Par ailleurs, il faut tenir compte de nombreux délais spéciaux en matière contractuelle : par exemple, le délai de l'action en responsabilité contre un architecte ou entrepreneur de construction est de dix ans (C. civ., art. 1792), et celui pour agir contre le vendeur d'une chose défectueuse n'est que d'un an à compter de la dénonciation du défaut, qui doit lui-même intervenir dans un bref délai suivant la constatation de celui-ci (C. civ., art. 1648). Du point de vue de la compétence juridictionnelle, s'il n'existe pas de différence lorsque la responsabilité est purement interne au Luxembourg, il en va autrement lorsque la relation entre l'auteur du dommage et la victime présente un élément international. Alors qu'en matière délictuelle, la victime peut choisir entre les tribunaux du pays du domicile du responsable et du pays de survenance du dommage, le choix en matière contractuelle est entre le tribunal du domicile du défendeur et celui du lieu d'exécution du contrat[1896]

SOUS-SECTION 3. LES CONVENTIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

853. **Spécificité de la responsabilité contractuelle.** Il n'est pas exclu, en fait, que des personnes qui savent qu'elles sont susceptibles de se causer un dommage en dehors de tout contrat – donc relevant de la responsabilité délictuelle – cherchent par avance à régler conventionnellement les conséquences de ce dommage, notamment en limitant leur responsabilité réciproque, voire en s'en

[1893] L. du 28 décembre 1990 portant approbation de la Convention postale universelle de 1989.

[1894] Les limitations d'indemnisation trouvent leur origine dans la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, remplacée par la Convention de Montréal du 28 mai 1999 (non encore en vigueur au Luxembourg).

[1895] Cour d'appel, 23 novembre 2005, n° 29355.

[1896] Règlement (UE), n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 12 décembre 2012 (refonte, dit Bruxelles I *bis*), art. 7 (1) et (2).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

exonérant. On peut concevoir, par exemple, que de telles conventions interviennent entre deux voisins pour les troubles qu'ils pourraient se causer, ou entre deux entreprises concurrentes susceptibles d'empiéter sur le champ d'activité de l'autre et de détourner une partie de sa clientèle. Cependant de telles conventions, rares en pratique, sont, au Luxembourg[1897] comme en France[1898], considérées comme nulles – alors qu'elles sont valables en Belgique[1899]. Les règles relatives à la responsabilité délictuelle sont considérées comme étant d'ordre public, et il est seulement possible de passer des conventions sur le droit à réparation après la survenance du dommage – notamment sous la forme d'une transaction entre l'auteur du dommage et la victime. Il n'en va pas de même en matière contractuelle où les clauses relatives à la responsabilité que les contractants peuvent encourir l'un envers l'autre sont extrêmement fréquentes en pratique, et (sous réserve de nombreuses exceptions) considérées comme valables. La spécificité de la responsabilité contractuelle apparaît bien sur ce terrain : dans la mesure où cette responsabilité se situe dans le prolongement du contrat, œuvre de la volonté des parties, celles-ci peuvent par avance, en fait, convenir de la manière dont les dommages qu'elles peuvent se causer dans le cadre de l'exécution de ce contrat seront réparés, et cet aménagement conventionnel peut être regardé comme un des aspects de la répartition de la charge des risques entre les parties qui préside à toute relation contractuelle.

854. Diversité des clauses. Les clauses relatives à la responsabilité contractuelle sont, en pratique, extrêmement variées. On peut proposer différentes classifications, en fonction de la structure de la clause, et en fonction de l'effet que cette clause produit sur la charge du débiteur.

Du point de vue de la structure, il faut d'abord distinguer les véritables clauses relatives à la responsabilité de celles qui concernent les obligations dont l'inexécution peut donner lieu à responsabilité. Si je suis l'exploitant d'un parking public, et que je veux

[1897] Dans ce sens, implicitement RAVARANI, n° 738.

[1898] Voy. p. ex. Cass. fr. (2e civ.), 15 juin 1994, n° 92-18048 – Pour la critique de la solution P. BRUN, *Responsabilité civile extracontractuelle*, *op. cit.*, n° 98. Le projet ministériel français de 2017 permet, dans certaines limites, les conventions sur la responsabilité délictuelle.

[1899] Solution constante depuis Cass. be., 21 février 1907, *Pas. be.*, 1907, I, p. 135. Voy. en dernier lieu : Cass. be., 29 mai 1984, *Pas. be.*, 1984, I, p. 1175. L'article 6.1 du nouveau Code civil consacre par principe le caractère supplétif des règles de la responsabilité civile extracontractuelle.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ne pas être tenu des dommages que les automobilistes qui se garent dans ce parking du fait de la détérioration de leur véhicule ou du vol de leurs effets personnels, je peux imaginer deux types de clauses : la première consiste à dire que je n'assure pas la surveillance des véhicules (ce qui revient à limiter le contenu obligationnel du contrat), la seconde consiste à dire que « je ne réponds pas des dommages causés aux véhicules », ce qui, sans toucher aux obligations nées du contrat, exclut ma responsabilité si une voiture est dégradée. Parmi les clauses qui touchent à la responsabilité, on peut ensuite distinguer celles qui touchent au principe même de la responsabilité, et celles qui ne concernent que son étendue. Les premières agissent sur les conditions du droit à réparation : tel est le cas, par exemple, d'une clause qui, dans un contrat contenant normalement une obligation de résultat, prévoit que le débiteur ne sera responsable que de sa faute, ou même seulement d'une faute lourde ; tel est le cas aussi d'une clause qui prévoit que le débiteur sera responsable même si l'inexécution est due à un cas de force majeure, ou qui donne de la force majeure une définition différente de celle qu'elle a normalement (plus extensive ou plus restrictive). On peut aussi prévoir que le débiteur ne sera responsable que de certains dommages et pas d'autres. Enfin, une autre manière, plus radicale, d'agir sur le principe même de la responsabilité, est de prévoir que le débiteur ne sera pas du tout responsable en cas d'inexécution. D'autres clauses, sans toucher au principe même de la responsabilité ni à ses conditions, agissent seulement sur l'étendue de la réparation, soit en en plafonnant le montant, soit en prévoyant un minimum, soit en fixant un forfait d'indemnisation.

Ici apparaît une autre distinction, qui se superpose à la précédente. Cette distinction qui repose sur l'effet que la clause produit sur la charge du débiteur qui n'a pas exécuté, joue un rôle plus important quant à la détermination du régime des clauses, et c'est celle qui sera suivie pour structurer notre exposé. On peut ici distinguer les clauses qui allègent cette charge (soit en subordonnant le droit à réparation à des conditions plus restrictives que celles qui s'appliqueraient normalement, soit en limitant le montant de la réparation, soit en excluant purement ou simplement la responsabilité) (**§ 1**), les clauses qui aggravent à l'inverse la charge du débiteur (soit en ouvrant le droit à réparation plus largement, par exemple, en cas de force majeure, soit en fixant un minimum

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

d'indemnisation) (§ 2), et les clauses, dites clauses pénales, qui, fixant un forfait d'indemnisation, peuvent jouer dans un sens ou dans l'autre (§ 3).

§1. Les clauses allégeant la responsabilité du débiteur

855. Limitation ou exclusion de responsabilité. Comme on l'a vu précédemment, les clauses qui allègent la charge du débiteur en cas de survenance d'un dommage au créancier contractuel peuvent prendre différentes formes, qu'on a l'habitude de traiter ensemble parce qu'elles produisent le même résultat économique favorable au débiteur et défavorable au créancier. Peu importe que ce résultat soit obtenu par une restriction de l'étendue des obligations normalement mises à la charge du débiteur, par une délimitation des conditions de la responsabilité (le débiteur ne sera responsable que de sa faute, de sa faute lourde, que de tel ou tel dommage, voire il ne sera pas responsable du tout) ou par une limitation de l'étendue de la réparation (le débiteur en cas de dommage ne pourra pas être condamné à payer plus que tant d'euros). La problématique est globalement la même dans ces différents cas.

De prime abord, on pourrait être choqué par ces clauses qui aboutissent à limiter la réparation du préjudice subi par le créancier, voire à le laisser sans réparation. Les réticences qu'on peut avoir sont particulièrement fortes pour les clauses qui ont pour effet d'exclure totalement la réparation : il paraît à première vue inadmissible qu'un contractant qui s'engage à quelque chose stipule en même temps qu'il ne sera pas responsable s'il ne remplit pas son engagement. Cela ne revient-il pas à anéantir l'engagement lui-même, et cela ne constitue-t-il pas une condition purement potestative prohibée par l'article 1174 du Code civil ? D'une manière plus générale, on peut craindre que les clauses qui allègent la responsabilité (même en limitant seulement la réparation) n'incitent le débiteur à se montrer négligent dans l'accomplissement de ses obligations : pourquoi ferait-il des efforts alors qu'il ne risque rien ou pas grand-chose s'il accomplit sa prestation d'une manière incorrecte ? Les réticences s'accroissent encore si on sait que ces clauses exclusives ou limitatives de responsabilité sont le plus souvent imposées à un contractant par un autre en situation de force. Toutes ces considérations font

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

que les clauses limitatives, et plus encore exclusives, sont *a priori* parmi les plus suspectes dans les contrats, spécialement dans les contrats d'adhésion.

D'un autre côté, cependant, on peut penser qu'il est normal que, dans un contrat, les parties répartissent comme elles l'entendent la charge des risques que chacune accepte d'assumer, en fonction de la contrepartie qu'elle reçoit. Les clauses peuvent présenter, de ce point de vue, une certaine utilité économique Le contractant bénéficiaire d'une telle clause, parce qu'il risque moins en cas d'inexécution, peut proposer à son cocontractant une prestation moins chère, voire lui laisser le choix entre une formule avec pleine responsabilité, à prix fort, et une formule avec responsabilité limitée, moins coûteuse.

Les différents systèmes juridiques s'efforcent de trouver un équilibre entre ces considérations opposées. En droit luxembourgeois, comme dans les autres pays du Code civil, cet équilibre est trouvé à la fois sur le terrain de la validité des clauses (A) et sur celui de leurs effets (B).

A) *Validité des clauses*

1) *Principe de validité*

856. Solution constante. Au Luxembourg, comme en France ou en Belgique, les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité sont en principe valables[1900]. Pour les clauses limitatives, cette validité peut être fondée sur l'article 1150 du Code civil, qui limite la réparation, non seulement aux dommages et intérêts prévisibles, mais aussi, et d'abord, à ceux « qu'on a prévus » – ce qui peut s'appliquer, en particulier, à ceux qui ont été par avance prévus par une clause du contrat. Cet argument textuel, cependant, ne vaut que pour les clauses qui plafonnent le montant des dommages et intérêts, mais non pour celles qui modifient les conditions de la responsabilité (par exemple, en la subordonnant à la preuve d'une faute lourde), qui sont pourtant tout aussi valables. Plus fondamentalement, c'est le principe de liberté contractuelle qui semble justifier la validité des clauses limitatives.

On peut davantage hésiter à reconnaître la validité des clauses totalement exclusives de responsabilité, qui ne sont pas visées par l'article 1150 du Code civil, et qui semblent se heurter à l'obstacle

[1900] Ravarani, n° 741. En jurisprudence, voy. p. ex. : Cour d'appel, 13 décembre 1984, *Pas.*, 26, p. 238 ; 9 février 1994, *Pas.*, 29, p. 315.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de la potestativité[1901]. Cette validité est cependant généralement admise, tant en France[1902] qu'en Belgique[1903], et la solution semble également admise au Luxembourg[1904]. Un arrêt de la Cour d'appel de 2021 admet ainsi la validité d'une clause excluant dans une location financière toute responsabilité du loueur pour une atteinte à la jouissance de la chose[1905]. Cette validité peut se défendre dans la mesure où, nous le verrons, ces clauses ne couvrent de toute façon pas les fautes intentionnelles du débiteur, ce qui écarte le grief de potestativité. Par ailleurs, nous verrons qu'elles ne peuvent concerner que des obligations accessoires du contrat, dont le débiteur pourrait directement s'affranchir.

La validité des clauses limitatives et exclusives de responsabilité est également admise largement en droit comparé, ainsi que dans les différents projets européens. Par exemple, les PDEC disposent de manière générale que « Les moyens accordés en cas d'inexécution peuvent être exclus ou limités à moins que ce ne soit contraire aux exigences de la bonne foi d'invoquer l'exclusion ou la limitation » (art. 8 : 109). De même, le Code Gandolfi, en énumérant dans son article 106 toute une série d'exceptions à la validité des clauses, en présuppose une validité de principe.

857. Condition d'intégration dans le contrat (rappel). Même lorsqu'elles sont valables, les clauses exclusives ou limitatives de responsabilité ne sont applicables, comme toutes les clauses contractuelles, que si elles ont été acceptées par le créancier. Lorsqu'elles sont intégrées dans un contrat d'adhésion, ce qui est particulièrement fréquent, on leur appliquera l'article 1135-1 du Code civil relatif à l'intégration des conditions générales dans le contrat[1906]. Même si la règle n'a rien de spécifique aux clauses limitant ou excluant la responsabilité, c'est sans doute à propos de telles clauses qu'on discutera le plus souvent en pratique du point de savoir si la partie à qui on les oppose « a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées ». On rappellera du reste que, dans sa version d'origine, l'article 1135-1 du Code civil contenait un second alinéa exigeant une acceptation spéciale par écrit pour un certain nombre de clauses, dont, précisément « les

1901 Voy. *supra*, n°s 593 et s.

1902 Voy. p. ex. : TERRÉ, SIMLER, LEQUETTE, CHENEDE 2023, n°s 879 et s. ; FAGES 2023, n° 333.

1903 WÉRY, n° 764 ; VAN OMMESLAGHE, n° 1156 ; B. DUBUISSON, « Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ou de garantie en droit belge », in P. WÉRY (dir.), *Les clauses applicables en cas d'inexécution des obligations contractuelles*, Bruxelles, La Charte, 2001, pp. 33 et s. La validité des clauses exonératoires est expressément admise par l'article 5.89 du nouveau Code civil belge.

1904 RAVARANI, n° 741.

1905 Cour d'appel, 30 novembre 2021, n° CAL-2019-00718. En l'espèce, on est plutôt en présence d'une clause aggravant la responsabilité du débiteur. Voy. *infra*, n° 865.

1906 Voy. *supra*, n° 170.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

clauses qui prévoient en faveur de celui qui a établi les conditions générales des limitations de responsabilité ». Même si ce texte a été abrogé en 2004, on peut souhaiter que les juges se montrent particulièrement exigeants quand il s'agit d'admettre l'intégration dans le contrat de ce type de clause, en particulier lorsque la limitation ou l'exclusion de responsabilité a été portée à la connaissance du créancier par voie d'affichage.

2) *Limites à la validité*

a. *Limites résultant de textes spéciaux*

858. Clauses abusives. La validité des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité trouve aujourd'hui une exception considérable dans le domaine des contrats conclus entre professionnels et consommateurs, avec la législation sur les clauses abusives. D'une part, certaines de ces clauses figurent dans la liste des clauses expressément interdites de l'article L. 211-3 du Code de la consommation : il en va ainsi, notamment, des « clauses excluant ou limitant la garantie légale en cas de vice caché de la chose vendue » (C. consomm., art. L. 211-3, point 1), des clauses excluant l'obligation pour un professionnel chargé d'un travail sur une chose de veiller à la conservation de cette chose (C. consomm., art. L. 211-3, point 18), des clauses interdisant au consommateur de faire jouer la garantie due par le réparateur d'une chose (C. consomm., art. L. 211-3, point 19), des clauses excluant la responsabilité du professionnel en cas de mort ou de dommages corporels subis par le consommateur (C. consomm., art. L. 211-3, point 21). Mais, au-delà, on peut se demander si les clauses limitatives ou exclusives de la responsabilité du professionnel ne tombent pas sous le coup de la formule générale de l'article L. 211-2 du Code de la consommation qui définit comme abusive toute clause entraînant un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur, du moins chaque fois que l'exonération ou la limitation a été stipulée sans contrepartie appréciable pour le consommateur (notamment une diminution du prix)[1907]. Dans les relations de consommation, il conviendrait sans doute de ne sauver que les clauses donnant au consommateur le choix entre deux prix différents de la prestation, selon l'étendue de la responsabilité du professionnel. En toute hypothèse, dans le cadre de cette réglementation des clauses abusives, il n'y a pas lieu de faire la différence entre les clauses qui excluent la

[1907] Dans ce sens RAVARANI, n° 741-2.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

responsabilité pour manquement à une obligation, et celles qui excluent directement une obligation relevant normalement du contrat considéré[1908].

859. Autres textes. En dehors de la législation sur les clauses abusives, dont la portée est très générale, il existe de nombreux autres textes qui excluent la validité des clauses limitatives ou exclusives (ou de certaines d'entre elles) dans certains contrats. Sans souci d'exhaustivité, on citera les articles 1792 et 2270 du Code civil relatifs à la garantie due par les constructeurs, l'article L. 212-7, alinéa 1er du Code de la consommation relatif à la garantie de conformité due par les vendeurs dans les contrats de consommation, l'article 103 du Code de commerce (repris par l'article 1784 du Code civil), issu d'une loi de 1908, qui annule les clauses excluant la responsabilité du « voiturier » (transporteur) pour les accidents survenus aux voyageurs[1909], l'article 1954-2 du Code civil (datant d'une loi de 1979) déclarant nulles et sans effet les clauses tendant à écarter ou à limiter la responsabilité des hôteliers pour la perte ou la détérioration des effets déposés dans leur établissement, etc. Sur tous ces points, il faut noter qu'il peut exister des différences sensibles entre la législation luxembourgeoise et les droits français et belge.

b. *Limites générales*

860. Clauses portant atteinte à une obligation essentielle du contrat. En dehors de tout texte spécial, une jurisprudence largement convergente en France, en Belgique et au Luxembourg, admet la nullité des clauses limitatives – et *a fortiori* exclusives – de responsabilité lorsqu'elles aboutissent à vider le contrat d'une de ses obligations essentielles. L'idée de base de cette jurisprudence est que les clauses ne doivent pas aboutir à vider le contrat de sa substance, à lui retirer sa raison d'être. On ne peut pas concevoir, par exemple, qu'un vendeur s'exonère de toute responsabilité s'il ne livre pas, qu'un dépositaire puisse dire qu'il ne sera jamais responsable s'il ne rend pas la chose déposée, qu'un transporteur de marchandises se dégage de toute responsabilité en cas de non-acheminement des marchandises, etc. En Belgique, cette jurisprudence est relativement

[1908] Voy. p. ex. pour l'obligation d'assurer la conservation et la restitution des choses confiées à un professionnel l'article L. 211-3, point 18.

[1909] En droit français, le Code de commerce contient également une disposition, datant de 1905, qui annule les clauses exclusives de responsabilité (mais non les clauses limitatives) dans les contrats de transport de marchandises. Mais cette solution ne se retrouve pas en droit luxembourgeois.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ancienne, puisque la Cour de cassation a affirmé dès 1959 qu'une clause exonératoire ou limitative est nulle si elle a pour effet « d'anéantir l'obligation contractée par le débiteur »[1910]. Bien que la formule, très générale, vise *a priori* toutes sortes d'obligations, la doctrine s'accorde à considérer que l'interdiction ne s'applique en réalité qu'aux obligations essentielles du contrat[1911]. Désormais, la solution trouve une assise légale dans l'article 5.89 du nouveau Code civil, qui répute non écrite « la clause qui vide le contrat de sa substance ». En France, l'interdiction des clauses portant atteinte aux obligations essentielles remonte au célèbre arrêt Chronopost de 1993[1912], dans lequel la Cour de cassation, en se fondant sur la notion de cause, annule la clause d'un contrat de transport rapide de courrier, qui, en cas de non délivrance du pli dans le délai prévu, limitait la responsabilité de la société au remboursement du prix payé : la Cour retient que la société « spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service […] s'était engagée à livrer les plis de la société B. dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite ». Depuis cet arrêt, la question a fait l'objet en France d'une évolution jurisprudentielle chaotique, concernant souvent le contrat de transport, et a suscité un torrent d'écrits doctrinaux[1913]. Après avoir, un temps, considéré que le seul fait que le débiteur ait manqué à une obligation essentielle suffisait à entraîner l'inefficacité de la clause[1914], la Cour de cassation a, en 2010 (arrêt *Faurecia 2*), réaffirmé la validité de principe des clauses, même touchant à une obligation essentielle : « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur »[1915]. Une telle formule implique sans doute la nullité des clauses qui excluent

[1910] Cass. be., 25 septembre 1959, *Pas. be.*, 1960, I, p. 113. Voy. plus récemment : Cass. be., 26 mars 2004, *Pas. be.*, 2004, p. 513 qui déclare sans effet une clause qui « anéantit l'objet même de l'obligation ».

[1911] WÉRY, n° 768.

[1912] Cass. fr. (comm.), 22 octobre 1996, n° 93-18 632. Voy. *supra*, n° 357.

[1913] Voy. p. ex., au sein d'une littérature très abondante : D. MAZEAUD, « Clauses limitatives de réparation : les quatre saisons », *D.*, 2008., p. 1776.

[1914] Cass. fr. (ch. mixte), 22 avril 2005, n° 03-14.112 ; Cass. fr. (comm.), 13 février 2007, n° 05-17407 (dit arrêt Faurecia I), *Defrénois*, 2007, p. 1042, obs. R. LIBCHABER ; *JCP G*, 2007, I, p. 10063, obs. Y.-M. SERINET ; *R.D.C.*, 2007, p. 707, obs. D. MAZEAUD ; *RTD civ.*, 2007, p. 567, obs. B. FAGES.

[1915] Cass. fr. (comm.), 29 juin 2010, n° 09-11841 (dit Faurecia II), *D.*, 2011, p. 42, note O. GOUT ; sur cet arrêt, voy. D. MAZEAUD, « Clauses limitatives de réparation : la fin de la saga ? », *D.*, 2010, p. 2142.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

toute responsabilité en cas de manquement à une obligation essentielle – et, *a fortiori*, des clauses qui excluraient à la source cette obligation elle-même. S'agissant des clauses limitatives, en revanche, elles ne devraient être annulées que si la limitation n'était assortie d'aucune contrepartie, ou seulement d'une contrepartie dérisoire pour le créancier[1916]. Cette jurisprudence s'inscrit clairement dans une vision économique des clauses limitatives de responsabilité, qui sont justifiées dès lors qu'elles permettent de réduire le coût de la prestation. La formule jurisprudentielle a fait l'objet, lors de la réforme, d'une généralisation dans le nouvel article 1170 du Code civil français, selon lequel « [t]oute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Un arrêt de la Cour d'appel du 16 février 2021, dans une affaire qui n'est pas sans rappeler l'affaire *Chronopost*, juge ainsi, pour déclarer inopposable une clause figurant dans un contrat de transport de marchandises excluant toute responsabilité du transporteur en cas de non-délivrance du colis, que « la jurisprudence n'admet pas qu'un transporteur qui manque à son obligation essentielle du contrat, puisse s'exonérer de sa responsabilité sur le fondement d'une clause stipulée au contrat. Il est admis qu'en l'absence presque totale d'aléa dans l'acheminement du courrier respectivement de colis, l'utilisateur paraît dans le droit le plus strict de compter sur l'obtention d'un résultat. Or, la clause 14.1 contredit la portée de l'engagement pris par B au titre de l'obligation essentielle du contrat »[1917]. Plusieurs jugements du Tribunal de Luxembourg reproduisent également les développements tirés de l'ouvrage de G. Ravarani, selon lequel les clauses exclusives ou limitatives de responsabilité, licites en principe en raison du principe de la liberté contractuelle sont « inapplicables en cas de dol, de faute lourde ou encore lorsqu'elles portent à atteinte à une obligation essentielle du contrat […] L'aménagement conventionnel des obligations ne peut pas vider le contrat de sa substance, en faisant porter la clause sur l'obligation essentielle ou fondamentale du contrat, sous peine de priver ce dernier de sa

[1916] L'arrêt de 2010 relève à cet égard que, si la société a manqué à une obligation essentielle du contrat, « le montant de l'indemnisation négocié aux termes d'une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n'était pas dérisoire, que la société O. a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société F. sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit O. pour le secteur automobile », ce qui pouvait permettre de dire que « la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de la société O. ».

[1917] Cour d'appel, 16 février 2021, n° CAL-2020-00169.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

cause »[1918]. Cependant, dans une affaire récente soumise à la Cour de cassation, le Ministère public, après avoir analysé longuement la jurisprudence française, note que « [l]e critère ne réside pas dans la nature de l'obligation dont elle aménage la sanction de l'inexécution mais dans l'effet que produit la clause sur la portée de l'engagement contractuel du débiteur. En d'autres termes lorsque l'effet de la clause consiste à désactiver l'engagement souscrit, à neutraliser le caractère contraignant de l'obligation essentielle, à enlever sa force à l'obligation en privant de sanction son inexécution, elle doit être réputée non écrite parce qu'elle permet au débiteur de ne pas exécuter son obligation essentielle »[1919].

861. Clauses concernant les dommages à la personne. Il est très souvent soutenu, en France, que sont nulles les clauses qui prétendraient limiter, ou *a fortiori* exclure, la responsabilité du débiteur contractuel pour des dommages causés à la vie ou à l'intégrité corporelle du créancier. La raison invoquée est dans la règle de l'indisponibilité de la personne humaine, mais aussi, plus concrètement, dans l'idée qu'il ne faut pas, par de telles clauses, risquer d'inciter le contractant à la moindre négligence sur une matière aussi essentielle. Cette position, si elle n'a jamais été clairement consacrée par la Cour de cassation française, a inspiré certaines décisions de cours d'appel, et le projet ministériel français de réforme de la responsabilité civile la consacre nettement. En Belgique, en dépit de quelques auteurs qui allaient dans le même sens, c'était plutôt l'opinion contraire, favorable à la licéité des clauses même dans ce domaine, qui prévalait[1920], mais l'article 5.89 du nouveau Code civil belge issu de la réforme répute désormais non écrites les clauses qui exonèrent le débiteur « de sa faute ou de celle d'une personne dont il répond, lorsque cette faute cause une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne ». Au Luxembourg, la doctrine semble plutôt en faveur de la validité de principe des clauses[1921]. Sans doute faudrait-il, en la matière, distinguer les clauses exclusives de toute responsabilité, qui devraient être nulles par principe, et les

[1918] Trib. Luxembourg, 10 juin 2022, n° TAL-2019-00847 ; Trib. Luxembourg, 23 novembre 2023, n° TAL-2020-05107.

[1919] Conclusions du Parquet général sur Cass., 14 décembre 2023, n° CAS-2023-00022.

[1920] Van Ommeslaghe, vol 2, n° 1158 et les auteurs cités.

[1921] Ravarani, n° 741-2 ; *contra* C. Hoffmann, in *La réparation intégrale en Europe*, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 251 qui estime que « les clauses excluant l'indemnisation en cas de préjudice corporel devraient être déclarées nulles en raison du principe d'ordre du disponibilité du corps humain ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

clauses limitatives qui pourraient être admises – sur le modèle de certains plafonnements légaux (notamment en matière de transport aérien). Le débat n'a cependant qu'un intérêt pratique limité, dans la mesure où, on l'a vu, les clauses sont de toute façon interdites dans les contrats de consommation[1922], ainsi que d'une manière générale dans les contrats de transport de personnes[1923].

B) *Effets des clauses exclusives ou limitatives*

862. Inapplication des clauses aux fautes dolosives. Les clauses exclusives ou limitatives ne couvrent pas n'importe quel cas d'inexécution. Selon une jurisprudence constante, et commune aux trois pays du Code civil, elles ne couvrent pas les conséquences de la faute dolosive du débiteur. Cette solution peut être rattachée à l'article 1150 du Code civil, qui ne limite la réparation aux dommages et intérêts prévus ou prévisibles que si ce n'est point par le « dol » du débiteur que l'obligation n'a pas été exécutée. La notion de dol ici visée est très différente du dol lors de la formation du contrat, qui est un des vices du consentement : ici, elle désigne la faute intentionnelle du débiteur qui, volontairement, n'exécute pas son engagement. Admettre que les clauses couvrent même cette inexécution volontaire signifierait que le débiteur pourrait, à sa guise, se libérer de l'engagement qu'il a pris. La solution est donc dans la droite ligne de la prohibition des conditions purement potestatives. On peut y voir aussi une manifestation de l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat : celui qui, ayant exclu ou limité sa responsabilité, manque volontairement à ses obligations, se comporte de manière déloyale. La notion de faute dolosive ou intentionnelle est entendue assez largement par la jurisprudence : il n'est pas nécessaire que le débiteur ait agi dans l'intention de nuire à son créancier, il faut et il suffit qu'il ait violé son engagement de manière délibérée et consciente (même s'il a pensé que cela ne portait pas préjudice à son cocontractant).

Contrairement à une présentation répandue, que reprennent certains projets européens[1924], on ne peut pas dire que, en cas de dol, la clause est nulle. La nullité d'une clause s'apprécie *ab initio*, en tenant compte des éléments connus au moment de la formation du

[1922] C. consomm., art. L. 211-3, point 21.

[1923] C. civ., art. 1784 et C. comm., art. 103.

[1924] Code Gandolfi, art. 106 (1) ; DCFR, art. III-3 : 105.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

contrat. Or ce n'est qu'au moment de l'inexécution qu'on saura si le débiteur a commis une faute dolosive. Il vaut donc mieux parler d'inefficacité plutôt que de nullité[1925].

863. Assimilation de la faute lourde à la faute dolosive. Traditionnellement, en France et au Luxembourg, on assimile à la faute dolosive la faute lourde, c'est-à-dire celle qui consiste dans une négligence grossière du débiteur – celle qui, selon l'expression de Carbonnier, est tellement grave qu'on croirait que le débiteur l'a fait exprès[1926]. Cette assimilation, qui se retrouve en droit comparé[1927] et dans certains projets européens[1928], est en revanche rejetée en Belgique[1929]. L'article 5.89 du nouveau Code civil belge admet expressément la validité des clauses exonérant le débiteur de sa faute lourde, même si cette exonération ne se présume pas. En revanche, en France, l'article 1231-3 du Code civil, qui reprend en substance l'article 1150, précise désormais que la limitation de responsabilité ne joue pas « lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». Il est extrêmement difficile de définir ce qu'on entend par « faute lourde ». En France, dans le cours de la « saga » jurisprudentielle relative aux clauses limitatives de responsabilité, il avait été admis un temps que constituait par principe une faute lourde tout manquement à une obligation essentielle[1930] – ce qui était une autre manière de paralyser les clauses ayant trait à une obligation de ce type. Mais cette solution a été abandonnée en 2010 par l'arrêt qui réaffirme la validité des clauses même lorsqu'elles touchent à une obligation essentielle[1931] : selon cet arrêt « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ». Il appartient au juge d'apprécier au cas par cas si cette gravité est suffisante pour faire échec au jeu de la clause. Cette jurisprudence a été suivie au Luxembourg[1932].

[1925] En ce sens très justement Ravarani, n°s 743 et s.

[1926] J. Carbonnier, n° 1072, p. 2192.

[1927] Pour le droit allemand, voy. les auteurs cités par Ravarani, n° 743 et note 1.

[1928] Code Gandolfi, art. 106 (1) ; DCFR, art. III-3 : 105 (1) qui parle de « *gross negligence* ».

[1929] Van ommeslaghe, vol. 2, n° 1161 ; WERY, n° 767 (jurisprudence acquise depuis 1958).

[1930] Cass. fr. (1re civ.), 2 décembre 1997, n° 95-21907 ; Cass. fr. (comm.), 14 mars 2000, n° 97-16299.

[1931] Cass. fr. (comm.), 29 juin 2010, n° 09-11841 (Faurecia 2, préc.).

[1932] Cour d'appel, 11 février 2015, n° 39543 ; Cour d'appel, 21 novembre 2019, n° 36715. Voy. aussi les conclusions du Ministère public sur Cass., 14 décembre 2023, n° CAS-2023-00022.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

864. **Interprétation restrictive des clauses.** Les effets des clauses limitatives ou exclusives sont également atténués par les règles qui président à l'interprétation de ces clauses. D'une manière générale, l'article 1162 du Code civil, qui commande d'interpréter la convention « contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation », permet de retenir une interprétation restrictive de la limitation ou des conditions de l'exonération, soit qu'on considère que le débiteur qui s'exonère est le « créancier » de la clause, soit que, dans une lecture plus moderne du texte, on considère que « celui qui a stipulé » c'est le rédacteur de la clause, notamment dans les contrats d'adhésion[1933]. Cette interprétation en faveur du créancier victime de l'inexécution s'impose a fortiori dans les contrats entre consommateurs et professionnels, en raison de l'article L. 211-2 (2) du Code de la consommation, à supposer toutefois que les clauses limitant la responsabilité du professionnel soient encore valables, ce qui est douteux[1934].

§ 2. Les clauses aggravant la responsabilité du débiteur

865. **Validité sous réserve d'exceptions.** Les clauses qui aggravent la responsabilité du débiteur en cas d'inexécution (par exemple, en lui imposant une indemnité minimum, ou en lui faisant supporter les conséquences de la force majeure, ou en transformant une obligation de moyens en obligation de résultat, etc.) n'ont pas retenu l'attention de la doctrine autant que les clauses limitatives ou exclusives. À première vue, dans une optique de protection du créancier contractuel, ces clauses ne suscitent aucune critique, et leur validité est généralement admise, pour peu que le problème soit abordé[1935]. L'arrêt de la Cour d'appel déjà cité qui admet la validité de principe des clauses exonératoires de responsabilité, faisant supporter dans une location financière l'intégralité des risques de perte de la chose quelle qu'en soit la cause, concerne en réalité une clause de ce type. Cette affirmation doit cependant être nuancée : lorsqu'elles sont imposées à un débiteur contractuel en situation de faiblesse, ces clauses peuvent s'avérer aussi pénalisantes que les clauses qui, en sens inverse, limitent la responsabilité d'un contractant en situation de force. On peut songer, par exemple, à la clause qui fait supporter au locataire d'une voiture la charge de tous les dommages qui peuvent lui advenir, y compris ceux qui résulteraient d'un cas de force majeure, n'engageant pas normalement la responsabilité du débiteur contractuel. Aussi bien peut-on se demander si certaines de ces clauses ne pourraient pas tomber sous le coup de la législation sur les clauses abusives. En l'absence de texte spécial en droit

[1933] Sur ce glissement de sens dans la lecture de l'article 1162 du code civil, voy. *supra*, n° 528.
[1934] Voy. Cour d'appel, 30 novembre 2021, n° CAL-2019-00718.
[1935] Voy. p. ex. en droit belge VAN OMMESLAGHE, vol. 2, n° 1156.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

luxembourgeois, il faut considérer, au cas par cas, si ces clauses d'aggravation ont une contrepartie suffisante pour le consommateur, s'il a le choix entre plusieurs formules lui permettant de couvrir plus ou moins sa responsabilité (ce qui est notamment le cas dans les contrats de location de voiture, où le client a le choix entre plusieurs formules d'assurance des risques du véhicule, avec ou sans franchise d'indemnisation).

Le plus souvent cependant, l'aggravation de responsabilité résultera, indirectement, de la fixation dans le contrat d'une indemnité forfaitaire qui, si elle est très élevée, obligera le débiteur à payer une somme supérieure au préjudice subi par le créancier. On est alors en présence d'une clause pénale, soumise à un régime très spécifique.

§ 3. Les clauses fixant un forfait d'indemnisation : les clauses pénales

866. Notion et fonctions. Au lieu de plafonner, par une clause limitative de responsabilité, les dommages et intérêts dus en cas d'inexécution, ou, à l'inverse, de fixer un minimum d'indemnisation (rare en pratique) les parties peuvent fixer de manière forfaitaire, par une clause particulière, le montant de la somme que le débiteur aura à payer au créancier s'il n'exécute pas ses obligations. C'est ce type de clause qu'on appelle, dans les droits issus du Code civil, une clause pénale (C. civ., art. 1226 et s.). La somme stipulée dans la clause peut avoir, dans l'esprit des parties, plusieurs significations, plusieurs fonctions, qui peuvent du reste être mêlées dans des proportions variables. Elle peut être conçue comme la fixation forfaitaire des dommages et intérêts réparant le préjudice causé au créancier par l'inexécution : la clause a, alors, une *fonction indemnitaire*. Elle présente le grand avantage, pour le créancier, de le dispenser d'avoir à saisir le juge pour faire fixer les dommages et intérêts, ce qui lui économisera les frais et les coûts d'un procès ainsi que les incertitudes de l'évaluation judiciaire[1936]. Elle peut aussi, si le montant fixé est plus faible que le préjudice prévisible, servir, en fait, de clause limitative de responsabilité. Le seul fait d'étudier la clause pénale à cette place, au sein des développements consacrés à la responsabilité contractuelle, semble ravaler ce type de clauses à cette seule fonction indemnitaire. Mais cette approche est réductrice car, le plus

[1936] Surtout dans les pays où, comme au Luxembourg, cette évaluation relève de l'appréciation souveraine du juge et n'est pas encadrée par des normes précises.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

souvent, la clause est imposée par un créancier en situation de force, et la somme fixée est généralement beaucoup plus élevée que le préjudice normalement attendu. La clause vise alors, non pas seulement à réparer ce préjudice, mais aussi à sanctionner le débiteur n'ayant pas exécuté, et, préventivement, à faire pression sur lui pour qu'il s'exécute. C'est cette *fonction comminatoire*, très fréquente en pratique, qui a justifié l'appellation « clause pénale », car la somme stipulée apparaît alors comme une sorte de pénalité, de peine civile frappant le débiteur. Lorsque cette fonction comminatoire domine, ou est exclusive[1937], la clause apparaît alors comme particulièrement dangereuse pour le débiteur qui risque d'être amené à payer des sommes considérables, sans rapport avec le préjudice effectivement subi par le créancier. Ces clauses soulèvent en outre une question de principe : la liberté contractuelle peut-elle aller jusqu'à permettre à un contractant d'édicter une « peine » à la charge de l'autre, en allant au-delà de la fonction de réparation, de rééquilibrage des patrimoines, à laquelle semble devoir se borner le droit civil ?

867. Différentes conceptions. Face à ce type de clauses, le droit peut avoir différentes attitudes. La question principale, qui domine toute la matière, est de savoir s'il faut mettre « dans le même sac » et soumettre au même régime juridique les clauses ayant pour but d'évaluer conventionnellement le montant des dommages et intérêts et celles dont le but est principalement comminatoire. Dans certains systèmes juridiques, on fait nettement la distinction : ainsi, en *common law*, on distingue entre les clauses ayant pour objet de pénaliser le débiteur en cas d'inexécution (*penalty*), qui sont nulles, et celles qui visent à évaluer raisonnablement le préjudice (*liquidated damages*), qui sont valables[1938]. Dans d'autres, en revanche, on assimilera en principe les deux types de clauses, qu'on validera donc *a priori* sans tenir compte du montant stipulé, sauf à tempérer la rigueur des clauses pour l'une ou l'autre des parties en permettant au juge de réviser le montant stipulé lorsqu'il apparaîtra comme disproportionné par rapport au préjudice. Nous verrons que c'est le cas

[1937] Il en va ainsi des clauses d'astreinte, par lesquelles on prévoit le versement à titre de menace d'une certaine somme par jour (ou par toute autre période) de retard.

[1938] Voy. pour une traduction écrite de cette distinction le § 2-718 de l'*Uniform commercial code* aux États-Unis : « (1) *Damages for breach by either party may be liquidated in the agreement but only at an amount which is reasonable in the light of the anticipated or actual harm caused by the breach, the difficulties of proof of loss and the inconvenience or non feasibility of otherwise obtaining an adequate remedy. A term fixing unreasonably large liquidated damages is void as a penalty* ».

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

en France, à la suite d'une importante évolution législative. D'une manière remarquable, le droit belge, bien qu'ayant été construit à l'origine à partir des mêmes textes qu'en France et au Luxembourg, a évolué vers une conception intermédiaire, proche de la *common law* par sa logique, qui repose sur l'idée que seules les clauses indemnitaires sont admissibles, même si, dans son dernier état, et plus encore dans le nouveau texte légal issu de la réforme de 2023, cette position n'apparaît pas si différente dans ses résultats de la position française[1939]. Comme souvent, le Luxembourg est resté dans l'orbite de la France, tant en ce qui concerne la qualification de clause pénale (**A**) que son régime juridique (**B**).

A) *La qualification de clause pénale*

868. Enjeux de la question. La question est ici de savoir à partir de quand, et selon quels critères une clause contractuelle peut être qualifiée de clause pénale. Cette question a fait l'objet, dans la période récente, d'un important contentieux, du moins en France et en Belgique, et a suscité, dans ces deux pays, d'importants développements doctrinaux. L'importance de la question est liée, en partie, à la consécration, par les législateurs des trois pays du Code civil, d'un pouvoir judiciaire de révision du montant des clauses pénales (en France en 1975, au Luxembourg en 1987, en Belgique en 1998)[1940] : il faut alors déterminer avec précision quelles sont les clauses qui sont soumises à ce pouvoir de révision. Le droit luxembourgeois ne distingue pas entre les clauses indemnitaires et celles qui sont comminatoires (**1**). Il distingue en revanche les clauses pénales s'autres clauses mettant une somme à la charge du débiteur (**2**).

[1939] La matière de la clause pénale est une de celles où s'observe le mieux, en droit des obligations, l'autonomisation du droit belge Dans les développements particulièrement fouillés que P. Wéry consacre à la clause pénale (Droit des obligations, n° 694 à 748) on ne trouve, sur 40 pages et 211 notes de bas de page, que 4 références à la doctrine française. On ne trouve en particulier aucune référence à la thèse de D. MAZEAUD, *La notion de clause pénale*, Paris, LGDJ, 1992, pref. F. CHABAS, incontournable pour les juristes français. À l'inverse ce dernier ne fait dans sa thèse qu'une rapide référence à la position de la jurisprudence belge, qu'il juge « réductrice et erronée » (*op. cit.*, n° 268).

[1940] Voy. *infra*, n° 881.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

1) *L'absence de distinction entre les clauses indemnitaires et les clauses comminatoires*

869. Dualité des fonctions dans le Code civil. Dans le Code civil, la clause pénale n'est pas réglementée dans la partie relative à la responsabilité contractuelle, mais au sein du chapitre consacré aux « diverses espèces d'obligations », aux articles 1226 et suivants du Code civil consacrés aux « obligations avec clause pénale ». Dans sa version d'origine, l'article 1226 du Code civil définissait (et définit toujours au Luxembourg) la clause pénale comme « celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ». Cette définition fait nettement ressortir la fonction comminatoire de la clause pénale : le « quelque chose » – qui est, dans l'immense majorité des cas, une somme d'argent – est supposé suffisamment important pour faire pression sur le débiteur, pour l'inciter à exécuter. Dans les articles 1226 et suivants, les rédacteurs du Code civil ont utilisé constamment le mot « peine » pour désigner la somme stipulée. Cependant, un peu plus loin dans la section consacrée à ces clauses pénales, l'article 1229 du Code civil précise que « La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale ». Et ici apparaît la fonction indemnitaire de la clause pénale : si la menace a échoué, et que le débiteur n'a pas exécuté, la peine stipulée vaudra comme réparation du préjudice subi par le créancier. Cette seconde fonction a conduit depuis longtemps la doctrine et la jurisprudence à opérer une assimilation entre la clause pénale définie à l'article 1226 du Code civil et la clause visée, dans la section relative aux dommages et intérêts contractuels, à l'article 1152 du Code civil[1941], selon lequel « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre »[1942]. Cette assimilation pose cependant problème lorsqu'on est en présence d'une clause où l'une des fonctions l'emporte nettement sur l'autre, voire est exclusive de l'autre. Ainsi, lorsque le montant stipulé est très faible, la

[1941] L'article 1152 n'est plus en vigueur en Belgique depuis 1998.

[1942] Cette assimilation est acquise dès le début du XIXe siècle chez les premiers commentateurs du Code (Voy. p. ex. : TOULLIER, *Le Droit civil français suivant l'ordre du code*, t. 6, 1814, n° 275 ; DURANTON, *Cours de droit civil français*, t. 11, 4e éd., 1844, n° 322). On la retrouve en Belgique chez F. LAURENT, *Principes de droit civil*, t. 17, n° 424.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

clause n'a aucune valeur comminatoire et ne paraît relever que de l'article 1152 du Code civil, non de l'article 1226 du Code civil. À l'inverse, l'article 1152 du Code civil ne semble guère applicable aux clauses dont le montant très élevé, sans rapport avec le préjudice attendu, vise uniquement à faire pression, pas plus qu'aux clauses d'astreinte, par lesquelles on prévoit le versement à titre de menace d'une certaine somme par jour (ou par toute autre période) de retard. Se pose alors la question de savoir comment on va qualifier les clauses qui relèvent seulement de l'une des deux logiques.

870. Position du droit français. En droit français, la fonction indemnitaire semble de prime abord l'avoir emporté sur la fonction comminatoire : dans tous les manuels modernes, c'est d'abord sous l'angle d'une clause relative à la responsabilité contractuelle, à propos de l'article 1152 du Code civil, que la clause pénale est étudiée, sauf à préciser que, lorsque ce montant forfaitaire est très élevé, la clause a aussi un aspect comminatoire. Et la Cour de cassation française a quant à elle, dans certains de ses arrêts, donné une définition des clauses pénales qui met l'accent sur la fonction indemnitaire, et qui est beaucoup plus proche de celle de l'article 1152 du Code civil que de celle de l'article 1226 du Code civil : « constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée »[1943]. Cependant, dans un arrêt de 1985, elle a posé que « la peine stipulée peut se concevoir aussi bien comme un moyen de contraindre les parties à l'exécution que comme une évaluation conventionnelle anticipée du préjudice futur »[1944]. Pour certains auteurs, du reste, les seules véritables clauses pénales seraient celles visées à l'article 1226 du Code civil, à savoir les clauses visant à faire pression sur le débiteur pour qu'il s'exécute[1945]. Pour ces auteurs, les clauses fixant forfaitairement les dommages et intérêts, visées à l'article 1152 du Code civil ne seraient donc des clauses pénales que si leur montant était suffisamment élevé pour avoir cette fonction comminatoire.

[1943] Cass. (1re civ.), 10 octobre 1995, nº 93-16869.

[1944] Cass. (1re civ.), 3 janvier 1985, nº 83-15291.

[1945] Dans ce sens J. Mestre, « De la notion de clause pénale et de ses limites », *RTD civ.*, 1985, p. 372. L'idée a été reprise et développée par D. Mazeaud, *La notion de clause pénale*, *op. cit.*, nos 265 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Ces débats, s'ils conservent leur intérêt en droit luxembourgeois, sont aujourd'hui dépassés en France, dans la mesure où, lors de la réforme de 2016, les différents textes relatifs aux clauses pénales ont été fusionnés en un seul article, l'article 1231-5, qui prend la place de l'ancien article 1152. Ce nouveau texte met en avant la fonction indemnitaire, puisqu'il est relatif à la clause qui « stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts », mais par la suite, cette clause est qualifiée de « pénalité ». On retrouve donc ici la combinaison traditionnelle des fonctions indemnitaires et comminatoire. De toute façon, depuis la loi de 1985, qui a ouvert le pouvoir de révision judiciaire des clauses, ce pouvoir de révision est applicable à toutes les clauses qui prévoient le paiement d'une somme d'argent en cas d'inexécution du contrat par le débiteur, qu'il s'agisse de clauses purement indemnitaires sans effet comminatoire (dans la mesure où la loi permet au juge de réviser une clause « manifestement dérisoire »), de clauses fixant un montant de dommages et intérêts « manifestement excessif » (ayant donc à la fois une fonction indemnitaire et comminatoire), voire, semble-t-il, de clauses n'ayant pas pour but d'évaluer des dommages et intérêts, mais uniquement de contraindre le débiteur à exécuter[1946].

871. Position du droit belge. L'approche est sensiblement différente en *droit belge* qui, à partir des années 1970, a nettement mis en avant la fonction indemnitaire de la clause pénale, en gommant complètement le caractère comminatoire, et en faisant totalement abstraction de l'article 1226 du Code civil (dans sa rédaction d'origine). Cette évolution s'est d'abord produite en jurisprudence, à une époque où, en Belgique comme en France, on cherchait à lutter contre des clauses fixant des indemnités excessives par rapport au dommage[1947]. Dans un important arrêt du 17 avril 1970[1948], la Cour de cassation de Belgique, faisant prévaloir les articles 1229 et 1152 du Code civil sur l'article 1226 du Code civil, avait jugé que, lorsque la somme stipulée était trop importante pour pouvoir s'analyser comme la réparation du dommage susceptible d'être subi par le créancier du fait de l'inexécution, la clause ne pouvait pas s'analyser comme une clause pénale, et que, en conséquence, l'ar-

[1946] Voy. p. ex. : Cass. (soc.), 3 mai 1989, n° 86-41634, *Bull.*, V, n° 325, p. 197.

[1947] Ce qui a, finalement, dans les trois pays, justifié la mise en place d'un pouvoir judiciaire de révision des clauses, voy. *infra*, n°s 881 et s.

[1948] Cass. be., 17 avril 1970, *Pas. be.*, 1970, I, p. 711 ; *J.T.*, 1970, p. 545.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ticle 1152 du Code civil affirmant à l'époque (dans les Codes des trois pays) l'intangibilité de la clause fixant forfaitairement le montant des dommages et intérêts ne pouvait pas s'y appliquer. La Cour de cassation belge avait alors estimé qu'une telle clause purement comminatoire était nulle comme contraire à l'ordre public sur le fondement de l'article 6 du Code civil, rejoignant ainsi la distinction faite en *common law* entre les *penalties* nulles et les *liquidated damages*, valables[1949]. Bien qu'elle ait été critiquée par différents auteurs, comme contraire aux dispositions du Code civil, cette solution a été par la suite constamment réitérée en jurisprudence. Lorsqu'on a voulu, en 1998, introduire dans le Code un pouvoir de révision des clauses pénales, en s'inspirant des lois antérieures votées en France et au Luxembourg, on a, après quelques hésitations, suivi la même logique – qui est, on le remarquera, exactement à l'opposé de celle suivie en France par les auteurs voulant réserver la qualification de clause pénale aux seules clauses comminatoires.

La loi belge du 23 novembre 1998 a en effet fait disparaître la distorsion existant entre l'article 1226 et l'article 1152 du Code civil, en abrogeant ce dernier, et en décalquant la définition qu'il donnait dans l'article 1226 du Code civil, alors ainsi rédigé : « La clause pénale est celle par laquelle une personne s'engage à payer, en cas d'inexécution de la convention, une compensation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite de ladite inexécution ». Cette nouvelle définition met donc en avant la seule fonction indemnitaire, et éclipse la fonction comminatoire[1950]. Il faut cependant d'ores et déjà signaler que, contrairement à l'ancienne jurisprudence, les clauses qui ne correspondent pas à cette fonction indemnitaire (c'est-à-dire les clauses stipulant un montant sans rapport avec dommage prévisible) n'étaient plus frappées de nullité, elles étaient simplement révisables par le juge. Cette évolution s'est prolongée avec la réforme de 2023. Le nouvel article 5.88 qui, comme en droit français, fusionne l'ensemble des textes relatifs à la « clause pénale » porte l'intitulé « clause indemnitaire », et il vise la clause qui « stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts ». Mais, si le montant stipulé est

[1949] Voy. *supra*, n° 867. Ce qui est considéré, en droit belge comme une clause pénale valable correspond aux *liquidated damages* du droit anglais.

[1950] D'une manière peu rationnelle, le législateur belge a cependant maintenu la réglementation de la clause pénale aux articles 1226 et suivants (alors qu'il eût été plus logique de maintenir l'article 1152 et de faire figurer à sa suite la réglementation de la clause). Il a de même conservé le terme « peine » qui figure dans plusieurs articles du code relatifs à la clause pénale.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

« manifestement déraisonnable », la clause n'est pas nulle, mais le juge peut la réduire. La solution n'est dès lors, aujourd'hui, pas si éloignée de la solution française, même si celle-ci repose sur une logique différente. Mais nous verrons qu'il en résulte d'importantes différences quant aux conditions de la révision judiciaire.

872. Position luxembourgeoise. Au Luxembourg, la Cour d'appel, dans un arrêt du 14 juillet 2004, a, tout en visant l'article 1226 du Code civil, défini la clause pénale comme « l'évaluation conventionnelle forfaitaire faite d'avance, des dommages et intérêts auxquels pourra donner lieu l'inexécution ou le retard dans l'exécution » – ce qui est une définition très proche de celle de l'article 1152 du Code civil, et met donc en avant la fonction indemnitaire. Dans les années 1980, cette conception avait amené certaines juridictions du fond luxembourgeoises à annuler comme contraires à l'ordre public certaines clauses pénales dont le montant était disproportionné au dommage subi si cette disproportion était le résultat d'une exploitation de l'infériorité de la partie faible au contrat[1951] – ce qui rejoignait par certains côtés la solution belge. Mais cette solution avait été fermement condamnée par la Cour de cassation, qui avait jugé « qu'une clause pénale, stipulée dans une convention légalement formée fait la loi des parties et s'impose au juge en l'absence de toute fraude à la loi et nonobstant une disproportion – fût-elle flagrante – entre le préjudice et l'avantage que le créancier tire de l'inexécution des obligations de son cocontractant » et que « les parties sont libres de déterminer les moyens de contrainte destinés à assurer, même à défaut de préjudice, l'exécution de leurs conventions »[1952]. C'était donc admettre que la clause pénale pouvait, aussi, avoir un caractère purement comminatoire. Et lorsque le législateur luxembourgeois a, quelques années plus tard, introduit le pouvoir de révision judiciaire des clauses, il l'a fait en recopiant quasi-textuellement le texte français de 1975. On peut donc considérer que le droit luxembourgeois, comme le droit français, considère comme des clauses pénales soumises au pouvoir de révision toutes les clauses fixant forfaitairement une somme due par le débiteur en cas d'inexécution, sans distinguer selon que cette somme a une finalité indemnitaire, comminatoire ou (ce qui est le cas le plus fréquent) combine les deux. La différence entre les droits des trois pays est donc essentiellement, aujourd'hui, une question de présentation, et il faudra sans doute se demander,

[1951] Voy. les décisions citées par RAVARANI, n° 750.

[1952] Cass., 19 janvier 1984, *Tines c/Eurosett-Paulick*, cité par RAVARANI, n° 750.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

dans le cadre de la réforme envisagée, s'il ne serait pas opportun, comme en droit français et en droit belge, de fusionner les différents textes relatifs à la caluse pénale.

2) *La distinction de la clause pénale et des clauses voisines*

873. Caractères distinctifs. Au-delà de certaines différences de conception, les trois droits basés sur le Code civil retiennent des éléments communs pour la qualification de clause pénale, qui amènent, de manière similaire, à distinguer ce type de clause de notions voisines (et, en conséquence, d'exclure le pouvoir de révision). Sur ces différents points, même si la question ne s'est pas encore posée au Luxembourg, on peut se référer sans hésiter aux solutions françaises et belges, elles-mêmes tout à fait similaires. En premier lieu, la clause pénale a nécessairement une nature *contractuelle* : cela amène à exclure la qualification de clause pénale (et le pouvoir de révision) pour les indemnités qui sont fixées par la loi, même lorsqu'elles sont reprises textuellement dans le contrat[1953]. En second lieu, qu'elle soit indemnitaire ou comminatoire (ou les deux), la clause pénale suppose que l'indemnité (ou la peine) stipulée sanctionne (ou cherche à éviter) *l'inexécution d'une obligation*. Cela amène à exclure la qualification de clause pénale pour toute une série de sommes qui, loin de sanctionner une inexécution contractuelle, apparaissent comme la contrepartie du droit reconnu à une des deux parties de mettre fin unilatéralement du contrat. Il en va ainsi, par exemple, de la clause de dédit qui permet à une des parties de se retirer du contrat en versant une certaine somme à son cocontractant (ou, le plus souvent, en perdant les arrhes qu'elle a versés à l'autre lors de la conclusion du contrat)[1954]. De même, la clause d'une promesse unilatérale de vente par laquelle le bénéficiaire verse au promettant une indemnité d'immobilisation qu'il perdra s'il décide de ne pas passer le contrat définitif n'est pas une clause pénale : le bénéficiaire a en effet un droit discrétionnaire de passer ou non le contrat définitif[1955] et la perte de l'indemnité ne peut en aucune manière être considérée comme une sanction d'une inexécution. La Cour de

[1953] Voy. p. ex. en droit français pour les pénalités de retard dues par un employeur qui ne verse pas à temps les cotisations à une caisse de retraite : Cass. fr. (soc.), 10 novembre 1981, *Bull. civ.*, V, n° 891 ; 2 juin 1994, n° 91-11.493.

[1954] France : Cass. fr. (comm.), 2 avril 1996, n° 94-13.433 ; Cass. fr. (3e civ.), 15 février 2006, n° 04-17.595. Belgique : Cass., 22 octobre 1999, *R.C.J.B.*, 2001, p. 103, note I. MOREAU-MARGREVE.

[1955] Voy. *supra*, n° 183.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

cassation française analyse très justement cette indemnité comme le prix de l'avantage consenti au bénéficiaire, et non comme une clause pénale[1956]. De même encore, l'indemnité devant être versée à un salarié en contrepartie d'un engagement de non-concurrence ne s'analyse pas en une clause pénale, car elle ne sanctionne l'inexécution d'aucune obligation[1957]. L'exercice de qualification, dans ces hypothèses, n'est cependant pas toujours aussi aisé qu'on pourrait le croire, car il est parfois difficile de déterminer si la rupture d'un contrat est l'exercice d'un droit ou une inexécution justifiant l'allocation de dommages et intérêts[1958]. En troisième lieu, enfin, la clause pénale se distingue par son *caractère forfaitaire*. On n'est donc pas en présence d'une clause pénale si les parties ont confié au juge (ou à un tiers) le pouvoir d'évaluer les dommages et intérêts. De même si les parties ont simplement entendu fixer un plafond à l'indemnisation, sans exclure que la somme allouée puisse être inférieure au montant fixé si le préjudice est moindre : on est alors en présence, non d'une clause pénale, mais d'une clause limitative de responsabilité relevant, non de l'article 1152 du Code civil, mais de l'article 1150 du Code civil. Le juge peut certes faire « sauter » le plafond conventionnel d'indemnisation en cas de dol ou de faute lourde du débiteur, mais en dehors de ces cas il ne peut pas réviser la clause[1959]. À l'inverse, lorsque les parties ont fixé un montant d'indemnisation de manière forfaitaire, cette clause sera qualifiée de clause pénale, même si son montant est très faible, et, en droit luxembourgeois comme en droit français, elle sera soumise au pouvoir de révision si le montant est « manifestement dérisoire ». On peut cependant se demander si, en dehors de ce cas, le juge ne pourrait pas requalifier la clause en clause limitative, ce qui permettrait de l'écarter en cas de dol ou de faute lourde[1960]. Telle est la solution retenue par l'article 5.88 du nouveau Code civil belge, qui, dans le cas où « la clause indemnitaire porte sur un montant ou une prestation déraisonnablement faible », prévoit de la traiter comme une clause limitative de responsabilité.

[1956] Cass. fr. (3e civ.), 29 juin 1994, n° 92-19.645 ; Cass. fr. (3e civ.), 30 avril 2002, n° 00-16.422.

[1957] Cass. fr. (soc.), 4 juillet 1983, *Bull. civ.*, V, n° 380 ; 26 mai 1988, *Bull. civ.*, V, n° 318.

[1958] Le choix de qualification est parfois influencé par des considérations de politique juridique qui amènent à s'écarter du critère posé. Ainsi, en France, la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que les indemnités conventionnelles à verser à un salarié en cas de licenciement même régulier sont susceptibles de révision, alors pourtant que le licenciement régulier, exercice d'un droit pour l'employeur, ne constitue pas une inexécution du contrat de travail : Cass. fr. (soc.), 5 juin 2008, n° 06-45.316, *R.D.C.*, 2008, p. 1158, obs. J.-S. BORGHETTI.

[1959] France : Cass. fr. (comm.), 18 décembre 2007, n° 04-16.069, *JCP*, 2008, I, p. 125, nos 13 et s., obs. Ph. STOFFLE-MUNCK.

[1960] Dans ce sens en Belgique : WÉRY, n° 702.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

B) *Le régime de la clause pénale*

874. Évolution. Les rédacteurs du Code civil ont réglementé de manière assez détaillée le régime juridique de la clause pénale dans les articles 1226 et suivants. Une partie de cette réglementation, centrée sur les effets de la clause, et visant à déterminer dans quelles conditions le créancier peut la mettre en œuvre, est restée inchangée jusqu'à une période récente dans les trois pays du Code civil. Cependant, dans la période contemporaine, les législateurs des trois pays ont apporté d'importants aménagements au régime juridique de la clause pénale. Ces aménagements, qui trouvent leur équivalent dans la plupart des droits européens modernes, sont justifiés par les dangers particuliers de la clause pénale, dont l'aspect comminatoire vient fréquemment heurter la fonction d'évaluation des dommages et intérêts. Pour corriger les excès de la liberté contractuelle en ce domaine, le législateur moderne, au Luxembourg comme ailleurs, a été amené à exclure dans certains cas la validité de la clause pénale (**1**), mais surtout à tempérer la rigueur de ses effets par l'instauration d'un pouvoir de révision judiciaire (**2**).

1) *La validité de la clause*

875. Principe. En droit commun, la clause pénale est en principe parfaitement valable. Si, comme on l'a vu, une certaine jurisprudence des juges du fond avait un temps (sur le modèle belge alors en vigueur) admis la nullité des clauses pénales disproportionnées, cette jurisprudence, condamnée par la Cour de cassation, est aujourd'hui rendue inutile par le pouvoir de révision reconnu au juge. Une clause excessive peut être révisée, mais elle n'est pas nulle *a priori*.

La validité de la clause pénale suppose cependant que le contrat dans lequel elle est insérée soit lui-même valable. Même si, dans la doctrine française, on a pu soutenir que la clause pénale constituait une convention à part entière, distincte du contrat dont elle vise à assurer l'exécution[1961], elle n'en reste pas moins accessoire à l'obligation principale, et elle n'a plus de raison d'être si le contrat vient à être annulé, puisqu'alors son inexécution ne peut plus être sanctionnée. C'est ce qu'indique l'article 1227 du Code civil, qui précise qu'à l'inverse, la nullité de la clause pénale n'entraîne pas celle du contrat dans lequel elle est insérée. Le texte vient ici déroger au principe selon lequel c'est le juge qui apprécie l'étendue de la nullité en fonction de l'importance que la clause avait dans l'esprit des parties[1962].

[1961] D. MAZEAUD, *La notion de clause pénale*, *op. cit.*
[1962] Voy. *supra*, n° 472.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

876. Limites. En France et en Belgique, il existe plusieurs dispositions spécifiques qui prévoient la nullité des clauses pénales dans certains contrats, notamment en matière de crédit bancaire aux particuliers[1963]. Au Luxembourg, on ne trouve aucune disposition de ce type, mais la question se pose de savoir si les clauses pénales ne peuvent pas tomber sous le coup de la *législation sur les clauses abusives* lorsqu'elles sont stipulées dans un contrat passé entre un consommateur et un professionnel[1964]. La question a été expressément réglée en Belgique, où la loi de protection des consommateurs prohibe comme abusives les clauses contenues dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui ont pour objet de « fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations du consommateur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise »[1965]. De même en France, l'article R. 132-2, 3° du Code de la consommation dispose depuis 2009 que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives […] sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet […] d'imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ». En l'absence jusqu'à une période récente d'une telle disposition au Luxembourg, on se demandait si une telle clause ne pourrait pas être annulée, au titre de la définition générale des clauses abusives, si elle créait « un déséquilibre des droits et les obligations au préjudice du consommateur »[1966]. La question avait été discutée en France avant la réforme de 2009 qui a introduit un texte spécial sur la question : si certains auteurs admettaient l'application du texte général[1967], d'autres la contestaient en estimant que cela viderait de son sens l'article 1152 du Code civil qui, comme nous allons le voir, permet au juge, dans tous les contrats, de réviser le montant des clauses abusives excessives ou dérisoires[1968]. Dans un très intéressant arrêt du 10 novembre 2010, la Cour d'appel du

[1963] Voy. en France, les articles L. 312-21, L. 312-29 et L. 331-31 du Code de la consommation. En Belgique, voy. l'article 90 de la loi du 12 juin 1991.

[1964] Sur cette législation, voy. *supra*, n°s 411 et s.

[1965] L. 6 avril 2010, art. 74, 24.

[1966] C'est la définition des clauses abusives dans l'article L. 211-2 du Code de la consommation du Luxembourg.

[1967] G. PAISANT, « Clauses pénales et clauses abusives après la loi n° 95-96 du 1er février 1995 », *D.*, 1995. chron., p. 223.

[1968] Dans ce sens, p. ex., MALAURIE, AYNES, STOFFEL-MUNCK, *Les obligations*, *op. cit.*, n° 992.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Luxembourg avait jugé, dans le même sens, que le régime particulier des articles 1152 et 1231 du Code civil excluait par principe, l'application de la législation sur les clauses abusives. Certes, la Cour d'appel remarque qu'il est impossible de trancher la question par application du principe « *lex specialis generalibus derogant* », car il est ici difficile de déterminer si la loi spéciale est la législation sur les clauses abusives (qui dérogerait aux dispositions de droit commun du Code civil) ou les articles 1152 et 1231 du Code civil (textes eux-mêmes profondément dérogatoires au droit commun des contrats). Mais, en s'appuyant sur les travaux préparatoires de la loi de 1987 qui a instauré le pouvoir de révision judiciaire, la Cour observe que les rédacteurs de la loi avaient parfaitement conscience que les clauses pénales sont particulièrement dangereuses dans les contrats de consommation, et que c'est principalement en pensant à ces contrats qu'ils avaient introduit ce mécanisme de révision. Or, selon la Cour, le législateur « n'a pas jugé utile de mentionner les clauses pénales abusives dans la liste indicative, mais non exhaustive, des clauses considérées comme abusives de l'article 2 de la loi du 25 août 1983[1969], mais a, au contraire, préféré légiférer en la matière par une disposition spécifique aux clauses pénales, applicable à tous les contractants, quelle que soit leur qualité. Il faut en induire que le législateur a voulu soustraire la clause pénale du régime des clauses abusives introduit par la loi du 25 août 1983 et la soumettre aux articles 1152 et 1231 du Code civil ». La Cour d'appel réserve seulement le cas où l'abus résulterait du cumul de la clause avec d'autres dispositions contractuelles. Cette position a été réitérée à plusieurs reprises depuis[1970]. On pouvait cependant se demander si elle était compatible avec le droit européen : la directive de 1993 définit en effet celles-ci de manière tout à fait générale, et ne paraît pas laisser aux États membres la possibilité d'exclure par principe telle ou telle catégorie de clauses au motif qu'elle ferait l'objet par ailleurs d'une réglementation spécifique. Par ailleurs, un arrêt récent de la CJUE pose très nettement que, lorsqu'un juge national constate le caractère abusif d'une clause pénale dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, il ne peut pas se limiter, comme l'y autorise le droit national, à modérer le montant de la pénalité mise par cette clause à la charge de ce consommateur, mais il doit (au besoin d'office) écarter purement et simplement l'application de

[1969] Il s'agit désormais de l'article L. 211-13 du Code de la consommation.

[1970] Trib. Luxembourg, 5 juillet 2016, n° 170/2016 ; Trib. Luxembourg, 25 octobre 2023, n° TAL-2023-00152.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la clause à l'égard du consommateur[1971]. Ce débat est aujourd'hui obsolète, car la loi du 27 août 2024 vient d'ajouter dans la liste des clauses présumées abusives de manière irréfragable de l'article L211-3 du Code de la consommation : « les clauses imposant au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé. » Les clauses pénales peuvent donc désormais être annulées sur le fondement de la législation des clauses abusives.

2) *Les effets de la clause pénale*

877. Forfait révisable. Dans le Code civil, les effets de la clause pénale tournent autour de l'idée, exprimée par l'article 1231, que cette clause vaut évaluation forfaitaire des dommages et intérêts. Cette idée commande à la fois les conditions du droit du créancier au paiement de la somme stipulée (a), le montant de la somme qu'il peut obtenir (b), et la manière dont la clause peut se combiner avec les autres sanctions de l'inexécution (c). Si le premier et le troisième point demeurent largement inchangés depuis le XIXe siècle, la question centrale du montant que peut obtenir le créancier a été complètement transformée par l'instauration récente du pouvoir judiciaire de révision des clauses.

a. *Les conditions du droit du créancier au paiement de la somme stipulée*

878. Conditions de la responsabilité contractuelle. Parce que la clause pénale est une évaluation anticipée des dommages et intérêts, les conditions d'obtention de la somme stipulée sont en principe celles qui commandent la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. Comme le dit la Cour d'appel du Luxembourg « Cette somme n'est exigible que dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que les dommages et intérêts ordinaires »[1972]. C'est ainsi, tout d'abord, que le créancier ne peut prétendre obtenir son paiement que s'il prouve l'inexécution de la part du débiteur (ce qui, selon que l'obligation est de moyens ou de résultat, suppose ou non de prouver la faute du débiteur). Les articles 1232 et 1233 du Code civil règlent à cet égard les difficultés particulières qui surgissent lorsque l'obligation est due par plusieurs héritiers du débiteur, et qu'un seul des héritiers

[1971] C.J.U.E., 30 mai 2013, *Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito*, aff. C-488/11, *Europe*, 2013, comm. 321, obs. A. BOUVERESSE ; *RTD eur.*, 2013 n° 3 p. 560, obs. C. AUBERT DE VINCELLES.

[1972] Cour d'appel, 29 novembre 1971, *Pas.*, 22, p. 87.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

contrevient à la convention. C'est ainsi ensuite que, selon l'article 1230 du Code civil, le créancier doit, pour obtenir son paiement, mettre en demeure le débiteur d'exécuter – exigence reprise par le nouvel article 1231-5 du Code civil français. Cependant, comme le précise la Cour d'appel, cette exigence ne vaut que sous réserve des exceptions que comporte en général la nécessité de la mise en demeure[1973] : la mise en demeure ne sera donc pas nécessaire si l'inexécution est définitive, ou, selon l'article 1146, alinéa 2 du Code civil, lorsqu'un terme a été fixé par accord entre les deux parties. Sur ce point, la loi de 1987 qui a introduit au Luxembourg cette exception à la mise en demeure a fait naître une contradiction avec l'article 1230 qui, lui, dispose que la mise en demeure pour l'obtention de la peine est nécessaire que l'obligation ait été stipulée avec ou sans terme. La Cour d'appel a clairement fait prévaloir l'article 1146, alinéa 2, sur l'article 1230[1974].

879. Dispense de preuve du préjudice. Il existe cependant une différence essentielle entre la mise en œuvre de la clause pénale et celle de la responsabilité contractuelle en l'absence d'une telle clause. C'est que, la clause pénale valant évaluation forfaitaire des dommages et intérêts, le créancier n'a pas à prouver l'étendue de son préjudice pour obtenir réparation. Selon la jurisprudence luxembourgeoise – semblable en cela à la jurisprudence française – il n'a même pas à prouver qu'il a subi un préjudice[1975]. On voit là l'intérêt principal de la clause pour le créancier qui, du coup, n'a plus besoin de passer par le juge pour faire fixer le montant des dommages et intérêts. Le recours au juge ne sera nécessaire que si le créancier a besoin d'un titre exécutoire pour obtenir l'exécution forcée de sa créance, ou que si le débiteur conteste la validité de la clause ou le fait de l'inexécution. Cependant, depuis la loi de 1987 qui a permis la révision judiciaire du montant des clauses, les hypothèses de contestation par le débiteur sont devenues plus nombreuses.

b. *Le montant dû par le débiteur*

880. Caractère forfaitaire. Parce que la clause pénale a un caractère forfaitaire, le créancier a normalement droit au montant exact stipulé. C'est ce qu'affirme avec force l'article 1152, alinéa 1er du

[1973] Cour d'appel, 29 novembre 1971, préc. ; Cour d'appel, 9 novembre 1993, *Pas.*, 29, p. 293 ; Cour d'appel, 19 octobre 2023, n° CAL-2021-00974.

[1974] Cour d'appel, 5 mai 2014, *BIJ*, 2004, p. 122.

[1975] Cour d'appel, 29 novembre 1971, préc. ; Trib. Luxembourg, 31 mai 2023, n° TAL-2020-07752 ; Trib. Luxembourg, 5 juillet 2023, n° TAL-2022-02028.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Code civil, selon lequel « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ». La formule est textuellement reprise par le nouvel article 1231-5 du Code civil français, et on en retrouve la substance dans l'article 5.88 du nouveau Code civil belge. Il se peut bien entendu que la somme stipulée ne corresponde pas au préjudice subi – soit qu'elle soit trop faible pour compenser ce préjudice, soit, plus souvent, qu'elle lui soit à l'inverse supérieure. Mais dans un tel cas, la partie désavantagée ne peut pas normalement demander au juge de modifier la peine pour la ramener au montant effectif du préjudice. Ce *principe d'intangibilité* ne connaissait d'exception, dans le Code civil de 1804, que dans le cas prévu par l'article 1231 : le juge pouvait réduire la peine si celle-ci avait été prévue pour une inexécution totale et que le débiteur avait exécuté partiellement son obligation. Mais en dehors de cette exception qui pouvait se justifier par la volonté des parties, le principe était, comme le disait notamment la Cour de cassation du Luxembourg, que « la clause pénale, stipulée dans une convention légalement formée fait la loi des parties et s'impose au juge »[1976]. La formule montre que le principe de l'article 1152 du Code civil n'était qu'une application de la force obligatoire des conventions : le juge n'a pas le pouvoir de modifier les « conventions légalement formées ». Cependant, ce principe se trouve aujourd'hui largement remis en cause, au Luxembourg comme dans beaucoup d'autres droits, par la consécration en 1987 d'un pouvoir judiciaire de révision des clauses pénales, qui est sans doute l'aspect le plus caractéristique de la matière.

881. Révision judiciaire des clauses pénales : historique et droit comparé. Si les rédacteurs du Code civil avaient pris la peine d'affirmer spécialement ce principe d'intangibilité de la clause pénale dans l'article 1152, c'est parce qu'ils entendaient rompre avec une certaine pratique judiciaire de l'Ancien droit qui, appuyée sur Dumoulin et Pothier, permettait au juge, pour des raisons d'équité, de modifier le montant des peines conventionnelles lorsque ce montant paraissait excessif. Cela montre que, depuis longtemps, les juristes étaient conscients des dangers particuliers de cette clause,

[1976] Pour une application de ce principe, voy. au Luxembourg avant la loi de 1987 : Cass., 19 janvier 1984, 26, p. 41. « En l'absence de toute fraude à la loi, les parties sont libres de déterminer les moyens de contrainte destinés à assurer, même à défaut de préjudice, l'exécution de leurs conventions ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

qui paraissaient justifier une entorse aussi remarquable à la force du contrat. Et il est remarquable que, postérieurement au Code civil, la plupart des droits européens ont admis, plus ou moins tôt, un pouvoir de révision judiciaire des clauses pénales excessives[1977]. Le *Bürgerliches Gesetzbuch* avait, dès 1900, consacré un tel pouvoir pour les peines conventionnelles d'un montant disproportionné dans le § 343 (1)[1978], et on le retrouve, très sobrement exprimé, dans l'article 163 du Code des obligations suisse, selon lequel « le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives », ou encore dans le Codice civile italien de 1942 (art. 1384)[1979]. Tous les codes

[1977] En *common law*, la révision des clauses fixant forfaitairement les dommages et intérêts n'est pas admise, mais ces clauses (liquidated damages) ne sont valables que si l'évaluation est raisonnable et que si le montant stipulé n'a pas pour but de pénaliser le débiteur.

[1978] *Herabsetzung der Strafe*, § 343.

(1) Ist eine verwirkte Strafe unverhältnismäßig hoch, so kann sie auf Antrag des Schuldners durch Urteil auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Bei der Beurteilung der Angemessenheit ist jedes berechtigte Interesse des Gläubigers, nicht bloß das Vermögensinteresse, in Betracht zu ziehen. Nach der Entrichtung der Strafe ist die Herabsetzung ausgeschlossen.

[1979] *La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.*

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

récents contiennent des dispositions similaires[1980], de même que les Principes Unidroit[1981], ainsi que les différents projets d'harmonisation européenne du droit des contrats[1982].

D'un point de vue de politique juridique, l'admission d'un pouvoir judiciaire de révision des clauses pénales suppose la recherche d'un équilibre entre des intérêts opposés. D'un côté, la pratique contractuelle révèle depuis longtemps les abus de certains contractants qui profitent de leur situation de force pour stipuler des pénalités en cas d'inexécution qui se révèlent sans rapport avec le préjudice subi, le plus souvent parce qu'elles sont excessives. Indépendamment même de tels abus, il faut avoir conscience que le montant de la clause est par hypothèse fixé *ab initio*, lors de la conclusion du contrat, à un moment où on a du mal à évaluer l'exact préjudice que pourra entraîner l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat. L'abus, ou l'erreur d'évaluation n'apparaîtront qu'après l'inexécution, à un moment où on connaîtra l'étendue exacte du préjudice subi. Il apparaîtra alors souvent injuste de condamner le débiteur au paiement de cette somme, tant en raison de l'énormité qu'elle peut représenter pour lui, que de l'enrichissement anormal

[1980] Voy. p. ex. le nouveau *Codul civil* roumain, art. 1541 ; le *Nieuw Burgerlijk Wetboek néerlandais*, art. 6 : 94 : Article 6 : 94 *A reduction or increase of the contractual penalty.*

1. the court may, upon the request of the debtor, reduce the contractual penalty if this is obliviously required by standards of reasonableness and fairness, on the understanding that it cannot grant the creditor less than the applying compensation for damages that would have been due by virtue of law (statutory provisions) :
2. *the court may, upon the request of the creditor, grant a compensation for additional damages in addition to a contractual penalty which has replaced the compensation for damages that would have been due by virtue of law (statutory provisions), if this is obliviously required by standards of reasonableness and fairness :*
3. *every contractual provision in derogation from paragraph 1 is null and void.*

Adde le Code civil du Québec, art. 1623 « […] le montant de la peine stipulée peut être réduit si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive ».

[1981] Article 7.4.13 dans la version 2010.

[1982] Voy. p. ex. le DCFR, art. III – 3 : 710. III. – 3 : 710 : *Stipulated payment for non-performance*

(1) where the terms regulating an obligation provide that a debtor who fails to perform the obligation is to pay a specified sum to the creditor for such non-performance, the creditor is entitled to that sum irrespective of the actual loss :

(2) however, despite any provision to the contrary, the sum so specified in a contract or other juridical act may be reduced to a reasonable amount where it is grossly excessive in relation to the loss resulting from the non-performance and the other circumstances.

Adde l'article 170 du Code européen des contrats : Article 170 (4) La peine peut être diminuée équitablement par le juge, si le débiteur a effectué, et que le créditeur ne l'a pas refusée, une exécution partielle, ou si le montant de la peine est manifestement excessif, eu égard, dans tous les cas, à l'intérêt que le créancier avait à l'exécution.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

qu'elle semble procurer au créancier[1983]. De puissantes considérations d'équité semblent alors conduire à reconnaître au juge un pouvoir de réviser la clause (et notamment de la modérer lorsqu'elle est excessive). Mais d'un autre côté, ce pouvoir de révision ne doit pas complètement anéantir les avantages, et l'utilité économique, que présente la clause. Si on reconnaît trop largement le pouvoir de révision, la clause risque de perdre sa fonction comminatoire (qui postule que le montant stipulé puisse être suffisamment élevé pour inciter le débiteur à exécuter, et que le débiteur ne puisse pas compter trop facilement sur le pouvoir modérateur du juge). La fonction de la clause comme mode d'évaluation des dommages et intérêts, qui doit normalement dispenser du recours au juge et dissuader le débiteur qui n'a pas exécuté de contester son obligation, peut elle-même être remise en cause s'il est trop facile de faire réviser la clause.

882. Révision judiciaire des clauses pénales : évolution dans les trois pays du Code civil. Les trois pays du Code civil, après être restés longtemps prisonniers de la formule rigide de l'article 1152, ont, eux aussi, fini par consacrer un tel pouvoir de révision dans la période récente, s'inscrivant ainsi dans un mouvement général des droits européens. Mais ils l'ont fait de manière différenciée.

Le problème de la révision judiciaire des clauses pénales, longtemps occulté, s'est posé en France à la fin des années 1960, en liaison avec le développement des contrats de crédit-bail (ou *leasing*). Dans de tels contrats, il était fréquent à l'époque que le crédit-bailleur stipule qu'à défaut de paiement d'un seul loyer, le contrat serait résilié et que le locataire devrait payer, à titre de clause pénale, l'intégralité (ou une fraction importante) des loyers restant à courir jusqu'à la fin du bail. Le locataire devait alors à la fois restituer le bien, et continuer, en fait, à le payer. De nombreux locataires avaient alors tenté d'obtenir l'annulation ou la réduction de ces clauses, en se fondant sur différents arguments (absence de cause de l'obligation de payer les loyers restant dus, enrichissement sans cause du créancier, etc.), mais ils s'étaient heurtés à l'inflexibilité de la Cour de cassation, qui s'abritait derrière la force obligatoire du contrat et l'intangibilité de la clause pénale affirmée par l'article 1152

[1983] Il ne s'agit cependant pas, techniquement, d'un enrichissement sans cause, dans la mesure où il trouve sa justification juridique dans le contrat.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

du Code civil. Finalement, le législateur s'est décidé à intervenir, par une loi du 9 juillet 1975, ajoutant un second alinéa à l'article 1152 du Code civil aux termes duquel « Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». La loi de 1975 a en outre modifié l'article 1231 du Code civil, qui prévoyait déjà un pouvoir de révision en cas d'exécution partielle du contrat, pour préciser que ce pouvoir devait s'exercer « à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152 ». Le texte précise encore que le pouvoir de révision, tant sur le fondement de l'article 1152 du Code civil que sur celui de l'article 1231 du Code civil est d'ordre public, toute stipulation contraire est dès lors réputée non écrite. À l'époque, la réforme avait suscité de vives critiques de la part de certains auteurs qui craignaient une remise en cause du principe de la force obligatoire du contrat – critiques qui, avec le recul, peuvent paraître bien surprenantes si on considère l'admission générale (et déjà ancienne) de la solution dans les droits européens. La loi de 1975 fut ultérieurement complétée par une loi du 11 octobre 1985 permettant au juge de procéder d'office à la révision. Les solutions sont désormais reprises, sans changement sur le fond, par l'article 1231-5 du Code civil français.

Le *législateur belge*, pour sa part, n'a introduit le pouvoir de révision des clauses pénales que beaucoup plus récemment, par une loi du 23 novembre 1998. Cependant, en Belgique, dès avant cette loi, la Cour de cassation belge ne s'était pas montrée sourde aux arguments des débiteurs confrontés à des pénalités énormes, et cela a sans doute contribué à retarder dans ce pays l'intervention du législateur. D'une part, comme nous l'avons déjà vu, dès 1970, la Cour de cassation avait affirmé la nullité des clauses fixant un montant disproportionné, en adoptant une définition restrictive, et strictement indemnitaire des clauses pénales : toute clause qui n'apparaissait pas comme ayant une fonction indemnitaire était alors considérée comme contraire à l'ordre public[1984]. D'autre part, même pour des clauses qui n'apparaissaient pas, au moment de leur formation, comme disproportionnées par rapport au préjudice prévisible dans le contrat considéré, la Cour de cassation belge avait accepté de faire jouer le correctif de l'abus de droit dans des cas où le créancier faisait jouer la clause d'un montant élevé alors qu'il n'avait en réalité subi qu'un préjudice limité[1985]. Dans un tel cas, le débiteur pouvait (et du reste peut toujours) obtenir la réduction de la clause, voire faire interdire en justice au créancier de s'en prévaloir[1986]. Néanmoins ces solutions, qui faisaient peser de grosses incertitudes sur l'efficacité des clauses apparaissaient peu satisfaisantes, et on avait même pu parler en Belgique de « crise

[1984] Ce qui, on le rappelle, est la solution du droit anglais, même si la terminologie est opposée, puisque les clauses nulles sont qualifiées de « *penalties* ».

[1985] Cass. be., 18 février 1988, *Pas. be.*, I, p. 178.

[1986] Cass., 8 février 2001, *Pas.*, 2001, p. 244.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

de la clause pénale ». C'est pourquoi le législateur belge s'était finalement décidé à intervenir par une loi du 23 novembre 1998, en substituant un pouvoir de révision judiciaire à la sanction rigoureuse de la nullité admise par la jurisprudence pour les clauses à caractère exclusivement comminatoire. Ce pouvoir de révision avait été intégré dans l'article 1231, § 1er du Code civil, selon lequel « Le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention ». Comme en France et au Luxembourg, le législateur belge avait par ailleurs conservé, dans l'article 1231, § 2 du Code civil, la pouvoir de révision des clauses en cas d'exécution partielle. Ces solutions se retrouvent dans l'article 5.88 du nouveau Code civil, mais avec des formulations assez différentes. Le texte prévoit que « la clause indemnitaire est manifestement déraisonnable, le juge la réduit, d'office ou à la demande du débiteur, compte tenu du dommage et de toutes les autres circonstances, en particulier des intérêts légitimes du créancier ». La sanction de la nullité n'est conservée que lorsqu'un arrêté a fixé un montant maximal pour les clauses indemnitaires figurant dans les conditions générales d'un contrat d'adhésion. Les clauses contraires sont réputées non écrites dans la mesure où elles dépassent le maximum autorisé.

Le législateur luxembourgeois, quant à lui, avait décidé de suivre l'exemple français dès 1987. La loi du 15 mai 1987, d'une part, a introduit dans l'article 1152 du Code civil un alinéa 2 qui est le recopiage intégral de la formule française de 1975 (sans toutefois reprendre la formule de 1985 permettant au juge de réviser d'office), et d'autre part a modifié l'article 1231 du Code civil toujours en recopiant la loi française. On peut donc, d'une manière générale, s'inspirer au Luxembourg des solutions jurisprudentielles françaises quant à l'interprétation de ces textes, tant en ce qui concerne l'article 1152 que l'article 1231 du Code civil.

883. Pouvoir de révision de l'article 1152 du Code civil : conditions. Selon l'article 1152 du Code civil, « le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». On rappellera d'abord que celle-ci n'est ouverte que si on est en présence d'une véritable clause pénale, au sens des articles 1152 et 1226 du Code civil – ce qui exclut notamment toutes les clauses qui fixent une « indemnité » ne sanctionnant pas l'inexécution d'une obligation. Il faut ensuite que le montant de cette clause soit en décalage important, « manifeste » dit le texte, avec le préjudice subi. En droit luxembourgeois, comme en droit français, la révision judiciaire est ouverte aussi bien lorsque le montant stipulé est trop faible (« manifestement dérisoire ») que lorsqu'il est trop élevé (« manifestement excessif »)[2], tandis qu'en droit belge, il ne l'est que si le montant est trop élevé. Dans les deux cas, la question se pose de savoir par rapport à quel préjudice s'apprécie

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la disproportion : s'agit-il du préjudice effectivement subi par le créancier ou du préjudice attendu, prévisible pour le type de contrat considéré, au moment où le contrat a été conclu ? La Cour de cassation française a nettement pris parti pour la première solution[1987], l'excès (ou l'insuffisance manifeste) s'appréciant au moment où la décision est rendue[1988]. La Cour d'appel du Luxembourg a adopté la même position : « le caractère manifestement excessif ou non de la clause incriminée, qui doit être objectivement apprécié et ce à la date où le juge statue, ne saurait résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi par le créancier et le montant de l'indemnité prévue »[1989]. Cette solution (qui est, nous le verrons, différente de celle du droit belge) correspond à la logique de la révision judiciaire qui est, en droit français et luxembourgeois, clairement distincte d'un contrôle de validité de la clause. Ce qui est contrôlé – et éventuellement corrigé – c'est le résultat concret produit par la clause au moment où elle joue. Comme on l'a déjà signalé, depuis la loi de 1985, en France, le juge peut soulever d'office le caractère excessif, alors qu'au Luxembourg, il faut que la révision soit demandée par une partie. Dans tous les cas, c'est aux juges du fond qu'il appartient de décider souverainement si la clause est ou non manifestement excessive ou dérisoire. La Cour de cassation française va même jusqu'à leur reconnaître un pouvoir discrétionnaire de refuser la révision, ce qui veut dire que les juges n'ont pas à motiver leur refus, puisqu'alors, selon la Cour, ils ne font qu'une « application pure et simple de la convention »[1990]. En revanche, ils doivent motiver la décision de réviser, et la Cour de cassation française contrôle alors les motifs avancés[1991]. Cette position a été suivie par la Cour d'appel du Luxembourg dans un arrêt de 1993, selon lequel « Si le juge refuse la modification demandée de la clause, il n'a pas à donner un motif à sa décision, car ce faisant il applique purement et simplement la convention des parties. En revanche, lorsque le juge décide de réajuster la clause manifestement excessive ou dérisoire, il devra motiver sa décision, c'est-à-dire indiquer en quoi la clause est

1987 Cass. fr. (comm.), 11 février 1997, *Bull. civ.*, IV, n° 47.

1988 Cass. fr. (1re civ.), 19 mars 1980, *Bull. civ.*, I, n° 95.

1989 Cour d'appel, 9 novembre 1993, 29, p. 293 ; Cour d'appel, 10 novembre 2010, *J.T.L.*, 2011, p. 107 ; *Pas.*, 35, p. 277 ; Cour d'appel, 22 octobre 2014, n° 38636 ; Cour d'appel, 6 décembre 2023, n° CAL-2022-00961.

1990 Cass. (comm.), 19 novembre 1991, *Bull. civ.*, IV, n° 91.

1991 Cass. (comm.), 11 février 1997, *Bull. civ.*, IV, n° 47.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

manifestement excessive ou dérisoire »[1992]. La solution est fondée sur l'idée que « en matière de pénalités conventionnelles le maintien de la peine convenue est la règle et la modification de cette peine est l'exception »[1993]. Il ne suffit pas, dès lors, pour justifier la révision, de constater que le montant fixé est supérieur (ou inférieur) au préjudice subi, il faut un décalage énorme, anormal[1994].

Sur la question des conditions de la révision judiciaire, le *droit belge* se différenciait jusque là assez nettement du modèle français repris au Luxembourg, ce qui marquait bien la différence de logique entre les deux systèmes. Comme on l'a vu, la révision, en droit belge, apparaît comme un substitut de la nullité admise antérieurement par la jurisprudence pour des clauses pour lesquelles, en raison de l'importance excessive de la somme stipulée, l'aspect indemnitaire était éclipsé par la finalité comminatoire. En révisant la clause, le juge lui redonne en quelque sorte sa fonction indemnitaire qui, en droit belge, conditionne sa qualification comme « clause pénale » et sa validité. Il en résulte – et c'est toujours vrai après la réforme – que la révision n'est permise que dans un sens, pour réduire le montant des peines excessives, et non pour réévaluer le montant des indemnités trop faibles. Ces dernières en effet ne sont pas critiquables au regard de la définition de la clause pénale posée à l'article 1226 du Code civil (sauf à tomber sous le coup des règles relatives aux clauses limitatives de responsabilité). Il en résultait ensuite, jusqu'à la réforme, que le caractère excessif de l'indemnité ne s'appréciait pas, comme en France et au Luxembourg, par rapport au dommage effectivement subi par le créancier, mais, selon l'ancien article 1231, § 1er du Code civil, par rapport au « montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention », c'est-à-dire au préjudice qui pouvait être prévu au moment de la conclusion du contrat. On voyait bien ici que la réduction permise par le texte n'était qu'un diminutif de l'annulation antérieurement fulminée par la jurisprudence : c'était en quelque sorte une annulation partielle, qui visait à ramener le montant à ce qui était légalement admissible dans l'évaluation conventionnelle des dommages et intérêts. Le caractère excessif s'appréciait donc, non au moment où le juge statuait, mais au moment où les parties avaient conclu le contrat, en tenant compte du caractère forfaitaire que présente nécessairement l'évaluation anticipée du préjudice. Le seul fait que la clause soit très excessive par rapport au dommage effectivement subi ne justifiait pas la réduction, dès lors que le montant stipulé n'était pas déraisonnable par rapport au dommage potentiel que les parties pouvaient imaginer : ainsi, dans le cas d'un bail, une clause pénale pour départ anticipé du locataire (ou défaut de paiement ayant entraîné la résiliation du bail) ne pouvait pas être réduite du seul fait que le bailleur avait trouvé immédiatement à relouer le local. La réforme du droit des obligations a nettement infléchi cette logique. L'article 5.88 du nouveau Code civil dispose que « si la clause indemnitaire est manifestement déraisonnable, le juge la réduit, d'office ou à la demande du débiteur, compte tenu du dommage et de toutes les autres circonstances, en particulier des intérêts légitimes du créancier ». On voit que désormais, même si ce n'est qu'une des circonstances permettant d'apprécier

[1992] Cour d'appel, 9 novembre 1993, 29, p. 293 ; Cour d'appel, 22 octobre 2014, n° 38636 ; Cour d'appel, 6 décembre 2023, préc.

[1993] Cour d'appel, 9 novembre 1993, préc.

[1994] Voy. les exemples donnés par Ravarani, n° 753.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

le caractère « manifestement déraisonnable » du montant stipulé, la comparaison avec le dommage effectivement subi apparaît comme le premier élément à prendre en compte – ce qui rapproche le droit belge du droit des deux autres pays.

884. Pouvoir de révision de l'article 1152 du Code civil : étendue. Les juges du fond sont souverains pour déterminer l'étendue de la révision, mais dans certaines limites. La Cour de cassation française pose que, en cas de clause manifestement excessive, les juges ne peuvent descendre en dessous du préjudice effectivement subi par le créancier[1995]. La solution était expressément prévue en droit belge par l'article 1231 § 1er du Code civil selon lequel « En cas de révision, le juge ne peut condamner le débiteur à payer une somme inférieure à celle qui aurait été due en l'absence de clause pénale », mais désormais l'article 5.88 du nouveau Code civil dispose, d'une manière un peu différente qu'il « ne peut condamner le débiteur à une réparation inférieure à un montant raisonnable ou à une prestation raisonnable ». La Cour d'appel du Luxembourg juge quant à elle que « En cas de reconnaissance du caractère manifestement excessif de la peine stipulée, il incombe au juge de la réduire dans une limite située entre le préjudice effectivement souffert et le seuil au-delà duquel elle aurait un caractère manifestement excessif »[1996]. Cette formule indique bien que le juge, lorsqu'il constate le caractère excessif d'une pénalité, n'est pas tenu d'en réduire le montant à la valeur du préjudice effectivement subi[1997] : le juge peut en effet souhaiter conserver à la clause son caractère « pénal », et on peut même penser que cela devrait être la règle, si on veut que le pouvoir de révision ne fasse pas perdre aux clauses pénales leur caractère coercitif[1998]. De même, en cas de peine manifestement dérisoire, le juge apprécie souverainement le montant de la réévaluation, et n'est pas tenu de fixer le montant à la valeur estimée du préjudice[1999]. Il faut cependant rappeler que, si la clause pénale fixant un montant excessif est insérée dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le juge devrait, pour se conformer

[1995] Cass. (1re civ.), 24 juillet 1978, *Bull. civ.*, I, n° 280.

[1996] Cour d'appel, 9 novembre 1993, 29, p. 293. Voy. encore récemment la reprise de la même formule par Cour d'appel, 29 février 2024, n° CAL-2021-00932.

[1997] Voy. aussi dans ce sens en France : Cass. (comm.), 23 janvier 1979, *Bull. civ.*, IV, n° 30 ; comp. en Belgique : Cass., 22 octobre 2004, *J.T.*, 2005, p. 679 selon lequel « le juge est tenu de réduire le montant de la clause pénale au montant du dommage potentiel, sans pouvoir descendre en dessous du préjudice subi ».

[1998] L'article 1541 du nouveau Code civil roumain prévoit expressément que « la pénalité réduite doit demeurer néanmoins supérieure à l'obligation principale ».

[1999] Cass. fr. (soc.), 5 juin 1996, *Bull. civ.*, V, n° 226.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

au droit européen, l'écarter purement et simplement au titre de la législation sur les clauses abusives, ce qui revient à dire qu'il lui incomberait alors de fixer le montant des éventuels dommages et intérêts en fonction du préjudice effectivement subi. Tel n'était pas jusque là la position de la jurisprudence luxembourgeoise, mais elle est désormais imposée par le nouvel article L211-3 du Code de la consommation[2000].

885. Pouvoir de révision de l'article 1231 du Code civil. La révision sur le fondement de l'article 1231 du Code civil, qui était déjà prévue dans le Code civil de 1804, obéit à un régime juridique particulier. Il faut supposer que le contrat a été partiellement exécuté par le débiteur, mais que la peine stipulée est d'un montant fixe, qui ne tient pas compte de cette exécution partielle[2001]. Si, par exemple, dans un contrat de *leasing*, il a été prévu que le locataire devrait, en cas de défaillance, restituer la chose et payer à titre de clause pénale les 4/5e des loyers restant à courir, l'article 1231 du Code civil est sans application, car le montant de la clause varie en fonction de l'importance de l'inexécution : dans un tel cas, le locataire peut simplement espérer une réduction sur le fondement de l'article 1152 du Code civil. L'article 1231 du Code civil jouerait en revanche si la clause pénale était de 10 000 €, sans tenir compte du nombre de loyers déjà payés. Dans ce cas, le juge peut réduire la peine « à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ». Dans l'exemple cité, il peut, si le locataire a déjà payé 8 loyers sur 10, ramener la peine à 2 000 €. Cette réduction peut se cumuler avec celle de l'article 1152 du Code civil.

Le cas de révision de l'article 1231 du Code civil se retrouve à l'identique en Belgique. Mais il existait en Belgique un autre cas spécifique de révision, rajouté par la loi de 1998 dans l'article 1153, alinéa 4 du Code civil, pour le cas où la clause pénale visait à fixer les dommages et intérêts de retard dans le paiement d'une somme d'argent. La différence avec le cas général – difficilement explicable et critiquée en doctrine – était que le caractère excessif de la clause se mesurait par rapport au préjudice effectivement subi, et non par rapport au dommage potentiel. La différence a disparu dans le nouveau droit, l'article 5.88 du nouveau Code civil disposant explicitement que le pouvoir de révision institué pour les clauses pénales joue de la même manière lorsqu'un intérêt est stipulé pour le retard de paiement d'une somme d'argent,

[2000] Voy. *supra*, n° 876.

[2001] Cour d'appel, 14 janvier 2015, n° 39608 ; Cour d'appel, 2 février 2017, n° 42162.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

c. *La combinaison de la clause pénale avec les autres sanctions de l'inexécution du contrat*

886. Combinaison avec l'exécution en nature. Le Code civil prévoit expressément la manière dont la clause pénale peut se combiner avec l'exécution en nature de la convention. Là encore, on observe que la clause suit le même régime que les dommages et intérêts. Le principe posé par l'article 1229 du Code civil est que le créancier « ne peut pas demander à la fois le principal (c'est-à-dire l'exécution de la convention) et la peine » – de même qu'il ne pourrait pas à la fois demander des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi du fait de l'inexécution et essayer d'obtenir l'exécution en nature. Il pourrait en revanche, dans un tel cas, demander des dommages et intérêts moratoires, pour compenser le préjudice subi du retard dans l'exécution. De la même manière, l'article 1229 du Code civil permet de faire jouer la clause pénale tout en demandant l'exécution si la clause a été stipulée pour sanctionner le retard.

887. Combinaison avec la résolution. Le Code en revanche ne dit rien de la manière dont la clause pénale se combine avec la résolution du contrat. La difficulté vient ici de ce que la résolution entraîne l'anéantissement rétroactif de la convention, ce qui, de prime abord, devrait également faire tomber la clause pénale (comme dans le cas d'annulation du contrat visé par l'article 1227 du Code civil). Cependant, comme nous l'avons vu, l'anéantissement du contrat résultant de la résolution n'a pas exactement la même portée que celui qui découle de la nullité[2002]. En particulier, il n'est pas contesté que le créancier qui demande la résolution puisse en même temps obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle – ce qui montre que la résolution ne fait pas complètement disparaître le contrat. De la même manière, même s'il est difficile d'en trouver une explication logique parfaitement convaincante, il est admis dans la jurisprudence française que le créancier puisse à la fois faire jouer la résolution et la clause pénale, dès lors que celle-ci se présente comme devant compenser le préjudice lié à cette résolution. En pratique, du reste, il est fréquent que le contrat contienne à la fois une clause résolutoire et une clause pénale, qui se présentent comme devant jouer ensemble.

[2002] Voy. *supra*, n° 745.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La réparation du préjudice causé par l'inexécution, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 891-97...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Chapitre IV
L'extinction des obligations contractuelles

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

888. Différentes causes d'extinction. À la différence de certains droits réels, comme la propriété, qui ont une vocation à la perpétuité, les droits personnels – expression active d'un rapport d'obligation entre un créancier et un débiteur – ne sont pas faits pour durer éternellement, ils peuvent – et même doivent normalement – s'éteindre par l'effet de divers événements. L'article 1234, qui ouvre le chapitre du Code civil consacré à l'extinction des obligations énumère les causes d'extinction dans un certain désordre. On mettra d'emblée à part, dans cette liste, la nullité ou la rescision du contrat[2003], qui aboutit effectivement à faire disparaître les rapports d'obligation nés du contrat, mais en raison de l'inaptitude du contrat à faire naître légalement des obligations : dans la conception du Code civil, la nullité n'est donc pas à proprement parler une cause d'extinction, mais plutôt d'inexistence (fictive) des obligations. Elle ne se retrouve pas, du reste, dans la liste des causes d'extinction qui figure à l'article 5.244 du nouveau Code civil belge, ni dans les causes d'extinction traitées aux nouveaux articles 1342 et suivants du Code civil français. Si, donc, on met à part la nullité, on peut, pour la clarté de l'exposé, distinguer deux catégories parmi les causes d'extinction énumérées à l'article 1234. Dans certains cas, d'abord, l'obligation va s'éteindre tout simplement parce qu'elle n'a plus de raison d'être, le créancier ayant obtenu ce qu'il attendait. À ces causes d'extinction en quelque sorte « normales », correspondant à la finalité même de l'obligation (**Section 1**), on peut opposer des causes d'extinction plus accidentelles, qui font disparaître l'obligation alors même que le créancier n'a pas été satisfait (**Section 2**).

Toutes les règles ici exposées relèvent de ce qu'il est convenu d'appeler le « régime général de l'obligation ». Elles ne s'appliquent pas seulement aux obligations contractuelles, mais aussi bien aux obligations nées d'un quasi-contrat, d'un fait générateur de responsabilité délictuelle, ou directement de la loi.

SECTION 1. L'EXTINCTION PAR SATISFACTION DU CRÉANCIER

889. Extinction avec ou sans exécution. La manière la plus normale d'obtenir satisfaction, pour le créancier, c'est que le débiteur exécute volontairement son obligation : le paiement apparaît ainsi, dans l'article 1234 du Code civil, comme la première cause d'extinction.

[2003] On rappellera que les deux termes sont synonymes.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Et on sait que, si le débiteur ne paye pas, le créancier peut, au moins pour les obligations de somme d'argent, recourir à l'exécution forcée : la dette sera éteinte, comme si elle avait été payée, dès lors que, à la suite d'une condamnation à exécuter, par le résultat des saisies pratiquées sur les biens du débiteur, ou dans le cadre d'une procédure de traitement de l'insolvabilité, le créancier aura obtenu son dû. Nous ne reviendrons pas sur ces causes d'extinction, étudiées au titre de l'exécution de l'obligation ou des sanctions de son inexécution[2004]. Mais la satisfaction du créancier peut aussi être obtenue automatiquement sans qu'il y ait, à proprement parler, exécution, ni volontaire ni forcée, de l'obligation par l'effet de certaines situations. Tel est l'effet d'abord de la compensation, qui se produit si le créancier est par ailleurs lui-même débiteur de son débiteur (**Sous-section 1**), et, plus rarement, dans le cas de la confusion sur une même tête des qualités de débiteur et de créancier (**Sous-section 2**).

SOUS-SECTION 1. LA COMPENSATION

890. Notion. La compensation, régie par les articles 1289 et suivants du Code civil, est un mécanisme d'extinction d'une obligation qui se produit lorsque deux personnes sont réciproquement créancière et débitrice l'une de l'autre : si *Primus* doit 1 000 à *Secundus* et que de son côté, *Secundus* doit également 1 000 (hypothèse d'école), on peut concevoir qu'au lieu que *Primus* paye 1 000, et que *Secundus* lui rende tout aussitôt pour acquitter sa propre dette, on considère qu'aucun paiement n'aura lieu et que les deux dettes seront éteintes. Naturellement, si l'une des dettes était d'un montant supérieur à l'autre, la compensation ne se produirait qu'à concurrence de la plus faible. La solution paraît relever de l'évidence, et du simple bon sens : pourquoi aller payer d'un côté ce qu'on doit recevoir de l'autre ? Mais, en droit, il faut se méfier de l'évidence et du bon sens, car, si, pour autant qu'on puisse le savoir, tous les systèmes juridiques modernes connaissent la compensation, ils n'en ont pas tous la même conception, et ne la soumettent pas aux mêmes conditions et ne lui donnent pas les mêmes effets.

891. Double fonction. Quelle que soit la manière dont elle est organisée, la compensation a une double nature, ou plus exactement une double fonction : c'est à la fois un mécanisme de règlement

[2004] Voy. *supra*, n[os] 635 et s., 718 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

des dettes réciproques, et un instrument de garantie au profit de chaque créancier. Et cette double fonction explique l'importance du mécanisme dans la pratique des affaires contemporaine[2005]. D'abord, c'est *un mécanisme de règlement simplifié* : la compensation va permettre d'éteindre en une seule fois deux obligations. C'est une forme de paiement (on parle souvent de paiement par compensation), intermédiaire entre le paiement volontaire (parce que comme celui-ci, l'extinction des dettes compensables s'opère sans qu'aucun des créanciers n'ait à mettre en œuvre des mesures d'exécution) et l'exécution forcée (parce que ce paiement va s'opérer, sans intervention de chaque débiteur, et même parfois contre leur gré). En tout cas, c'est un paiement simplifié : si la compensation n'existait pas, *Primus* devrait payer sa dette, en transférant des liquidités à *Secundus*, et *Secundus* devrait lui aussi payer, en transférant des liquidités à *Primus*. Ce double transfert est évité, et cela est avantageux pour les deux débiteurs : le débiteur qui n'a pas actuellement de liquidités, et qui, pour s'en procurer, devrait peut-être vendre un de ses biens, mobiliser son capital, va s'en sortir commodément. Il est dispensé de sortir des fonds : il paye, sans douleur, avec un de ses biens, qui n'est autre que la créance qu'il a sur l'autre.

Ensuite, la compensation apparaît comme un extraordinaire *instrument de garantie* pour chacun des créanciers. Là encore, supposons que la compensation n'existe pas : *Primus* devrait payer *Secundus*, et demander son paiement à *Secundus* ; si celui-ci était insolvable, *Primus*, pour obtenir son paiement, devrait exercer des voies d'exécution (ou concourir à une procédure de faillite). Il trouverait peut-être, dans l'actif de *Secundus*, les 1 000 € qu'il lui aurait payés, ou un bien que ces 1 000 € auraient servis à acheter, mais il ne serait pas le seul à pouvoir le faire : ces 1 000 € (à supposer qu'on les retrouve), profiteraient à tous les créanciers de *Secundus*. En définitive, *Primus*, ayant versé 1 000 €, ne récupérerait peut-être que 100 ou 500. Grâce à la compensation, *Primus* échappera au concours avec les créanciers de *Secundus* : n'ayant rien à débourser lui-même, tout se passera comme s'il avait été intégralement payé par *Secundus*. En quelque sorte, *Primus* se paye à titre exclusif sur un élément d'actif de *Secundus*, qui n'est autre que la créance réciproque que *Secundus* a sur lui. Cette fonction de garantie explique

[2005] Sur cette double fonction de la compensation, voy. VAN OMMESLAGHE, vol. 3, n° 1557.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

que la compensation est souvent invoquée lorsque l'une des parties est en situation financière difficile, et notamment soumise à une procédure de faillite[2006] (même si, alors, elle se heurte à des obstacles).

892. Différentes conceptions de la compensation. Les différents systèmes juridiques n'ont pas la même conception de la compensation. On peut ici opposer une conception substantielle et une conception processuelle de la compensation. Dans la conception substantielle, reçue en général dans les pays de droit civil, la compensation ne procède pas d'une décision du juge, mais opère comme un mode d'extinction de la créance à partir du moment où certaines conditions tenant aux deux créances sont remplies. Il existe cependant, entre les différents pays de droit civil, une différence entre ceux où, comme en France (mais aussi en Belgique et au Luxembourg), la compensation opère de plein droit[2007], et ceux, qui semblent plus nombreux, où elle suppose une déclaration unilatérale de celui qui l'invoque. Il en va ainsi notamment en Allemagne[2008], en Suisse[2009], et c'est ce système qui est repris par les textes internationaux et projets européens[2010]. La différence est cependant plus nette avec les droits qui ont une conception procédurale de la compensation : dans ce cas, conformément aux origines romaines du mécanisme[2011], l'extinction de la créance repose sur une décision du juge à qui on va demander de tenir compte dans sa décision de la balance des comptes entre les parties, et qui, en fonction des circonstances, a le choix de l'accorder ou de ne pas l'accorder. C'est sur cette idée que repose, dans les systèmes de *common law,* la compensation « *at law* » (ou *independant set-off*), où les deux dettes, faisant l'objet de deux demandes croisées (*claim and cross-claim*), continuent d'exister pendant tout le procès. Mais le droit anglais connaît aussi une compensation en *equity* (*equitable*

2006 P. HURT, « La compensation comme garantie d'une créance sur un débiteur en faillite », *J.T.L.*, 2010, n° 7, p. 30.

2007 Ce système est également celui de l'Espagne (Codigo civil, art. 1202) et de l'Italie (Codice civile, art. 1242).

2008 BGB, § 388 : « *Die Aufrechnung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teil* » (« La compensation se produit par une déclaration faite à l'autre partie »).

2009 CO, art. 124 : « 1. La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l'invoquer ».

2010 Unidroit, art. 8.3 ; PDEC, art. 13 : 104 ; DCFR, art. III-6 : 104.

2011 Il semble que la compensation trouve son origine dans l'*exceptio doli*, moyen de défense procédural permettant de sanctionner la mauvaise foi du demandeur, et qui pouvait notamment être invoquée lorsque le créancier demandeur refusait de tenir compte, dans sa réclamation, d'une créance que son débiteur avait contre lui. L'*exceptio doli* est également à la source de la construction de l'abus de droit dans les droits germaniques.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ou *transaction set-off*), qui opère comme un moyen de défense substantiel, et qui ne peut jouer qu'entre des dettes présentant un certain lien entre elles.

893. Différents types de compensation en droit luxembourgeois. Le droit luxembourgeois, à l'image du droit français et du droit belge, adopte en principe une conception substantielle de la compensation : la compensation est un effet direct de la loi qui se produit dès lors que certaines conditions sont réunies (**§ 1**). Mais il connaît aussi une compensation judiciaire, qui n'est pas sans rapport avec le *set-off at law* des droits de *common law*, dans la mesure où c'est le juge qui prononce la compensation en réponse à deux demandes croisées de paiement de dettes (**§ 2**). Il faut aussi faire une place à la compensation conventionnelle qui se produit par accord entre les parties, alors même que les conditions légales n'en sont pas remplies (**§ 3**). Dans ces différents cas, le droit luxembourgeois ne s'éloigne pas sensiblement des droits français et belge, eux-mêmes très proches.

§ 1. La compensation légale

894. Principe. La compensation légale est celle qui se produit de plein droit lorsque certaines conditions sont réunies : les deux dettes réciproques s'éteignent automatiquement au moment même où elles sont certaines, liquides et exigibles. Il faut d'abord préciser cet effet extinctif (**A**), pour mieux comprendre les conditions de cette compensation légale (**B**).

A) *Les effets de la compensation légale*

895. Effets automatiques mais facultatifs. On n'a pas tout dit lorsqu'on a posé – ce qui est la base du mécanisme – que la compensation provoque l'extinction des deux dettes, à concurrence de la plus faible d'entre elles. Encore faut-il savoir comment et à quel moment se produit cet effet. De ce point de vue, le droit des pays du Code civil semble reposer sur une contradiction : d'une part, l'article 1290 du Code civil (repris en substance par le nouvel article 1347, alinéa 2, du Code civil français et par l'article 5.255 du nouveau Code civil belge) pose que la compensation se produit de plein droit « par la seule force de la loi » ; mais d'autre part, il est admis que c'est un mécanisme facultatif, qui ne joue que si une des parties l'invoque. Ces deux propositions peuvent cependant être conciliées.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

1) *La compensation est facultative*

896. Mécanisme d'intérêt privé. La compensation est un mécanisme reconnu dans l'intérêt exclusif des parties. Par conséquent, il dépend de celles-ci de la faire jouer ou non. Ce principe a plusieurs conséquences. D'une part, la compensation peut être écartée par les parties. Une partie peut renoncer à invoquer la compensation[2012] : lorsque l'autre lui demandera de payer, elle sera alors obligée de le faire. Mais, bien entendu, cela n'exclut pas que l'autre, elle, se prévale de la compensation. Surtout, une partie qui pourrait invoquer la compensation pour se soustraire au paiement, peut très bien payer sa dette, sauf ensuite à réclamer à l'autre ce qui lui est dû. Ce paiement est parfaitement valable, et ne saurait donner lieu à restitution. Il en va ainsi même si le paiement a été fait dans l'ignorance de la dette à compenser. Cette décision de ne pas faire jouer la compensation peut être nuisible aux tiers, car le créancier va venir en concours sur d'autres biens. Cela explique la règle de l'article 1299 du Code civil : si le paiement est fait en connaissance de cause, le *solvens* ne peut plus, ensuite, pour le recouvrement de sa créance, se prévaloir des sûretés qui y étaient attachées. Cette règle est reprise par l'article 5.262 du nouveau code belge, qui réserve le cas où celui qui a payé avait un juste motif d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

D'autre part, la compensation ne joue que si elle est invoquée. La solution, traditionnellement admise, est aujourd'hui expressément posée par l'article 1347 du Code civil français. Supposons qu'une des parties entre qui existent des dettes compensables agit contre l'autre ; le défendeur n'invoque pas la compensation. Dans ce cas, le juge ne peut pas soulever ce moyen d'office : il condamnera le défendeur à payer. Mais la compensation peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Elle ne saurait en revanche être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, puisqu'on ne saurait reprocher aux juges du fond de ne pas avoir fait jouer une compensation qui n'était pas invoquée.

En principe, c'est le débiteur assigné en paiement qui va opposer la compensation de ce que lui doit le créancier. Mais l'article 1294 du Code civil permet aussi à la caution d'opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal : c'est une conséquence du caractère accessoire du cautionnement. En revanche, un codébiteur solidaire, qui n'est pas un débiteur accessoire, ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à un autre codébiteur : c'est une manifestation

[2012] Cour d'appel, 1er octobre 1963, *Pas.*, 19, p. 209 ; Trib. Luxembourg, 10 février 2012, n° 134812.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

claire de ce que le paiement par compensation ne se produit pas automatiquement. Mais, si le débiteur solidaire qui en avait la possibilité a invoqué la compensation, cela vaudra paiement, et cela libérera à due concurrence les autres codébiteurs.

2) *La compensation se produit de plein droit*

897. Portée limitée. Le principe, énoncé à l'article 1290 du Code civil, selon lequel la compensation se produit de plein droit par la seule force de la loi, distingue le système du Code civil de celui des pays (comme l'Allemagne ou la Suisse) où la compensation ne se produit qu'à la suite d'une déclaration de l'une des parties. Cependant, ce principe n'a qu'une portée limitée. Il ne joue, comme nous venons de le voir, que si l'une des parties invoque la compensation. Il signifie alors deux choses. D'abord il implique que le juge doit prononcer (ou, plus exactement déclarer) la compensation si les conditions en sont réunies, il n'a pas de pouvoir d'appréciation. Ensuite et surtout, la compensation, si elle est invoquée, est censée s'être produite dès le moment où les conditions en étaient réunies : l'article 1290 du Code civil dispose que « les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois » (dans le nouveau texte français, « à la date où ses conditions se trouvent réunies »[2013]. Par conséquent, tous les événements qui ont pu se produire ultérieurement et qui sont de nature à empêcher la compensation sont sans incidence. Dans un tel système, il est donc très important de déterminer à quel moment exactement les conditions de la compensation légale sont réunies. C'est de ce point de vue que le système de la compensation dans le Code civil devrait se distinguer le plus nettement de celui des droits où la compensation procède d'une déclaration unilatérale d'une des parties : logiquement, dans ces droits, la compensation devrait se produire au moment de la notification[2014]. Cependant, cette opposition de principe doit être nuancée car certains droits où une déclaration unilatérale est exigée prévoient que, une fois déclarée, la compensation opère son effet extinctif dès le jour où les deux créances pouvaient être compensées[2015].

[2013] Comp. l'article 1242 du Codice civile italien : « *La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio* ».

[2014] Telle est la solution retenue par les PDEC (art. 13 : 106), les principes Unidroit (art. 8.5), le DCFR (art. III-6 : 107), le Code Gandolfi [art. 132 (3)].

[2015] CO suisse, art. 124 : « 2. Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées » ; BGB, § 388 : Effet de la compensation : « *Die Aufrechnung bewirkt, dass die Forderungen, soweit sie sich decken, als in dem Zeitpunkt erloschen gelten, in welchem sie zur Aufrechnung geeignet einander gegenübergetreten* » (« La compensation a pour effet que les créances, dans la mesure où elles se recouvrent, sont considérées comme éteintes à partir du moment où elles étaient propres à se compenser l'une avec l'autre »).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

B) *Les conditions de la compensation légale*

898. Parties et tiers. On peut ranger les conditions de la compensation légale en deux catégories, car elles n'ont pas la même portée : conditions tenant aux rapports entre les parties (**1**), et conditions tenant aux droits des tiers (**2**).

1) *Conditions tenant aux rapports entre les parties*

899. Double rapport d'obligation. La compensation suppose entre les deux parties un double rapport d'obligation, ce qui en rend les conditions particulièrement complexes. Elle n'est possible que si les deux créances présentent certaines conditions l'une par rapport à l'autre (**a**) mais aussi si chacune des créances remplit certaines conditions (**b**).

a. *Conditions que doivent remplir les deux créances l'une par rapport à l'autre*

900. Réciprocité. Aux termes de l'article 1289 du Code civil, la compensation ne peut se produire qu'entre deux personnes qui sont réciproquement créancière et débitrice l'une de l'autre. La règle semble évidente : si *Primus* est créancier de *Secundus*, et débiteur de *Tertius*, il n'y a aucune raison que la compensation se produise entre les deux dettes.

La règle qui semble aller de soi connaît cependant de multiples difficultés d'application parce que les situations juridiques peuvent être complexes, et qu'il n'est pas toujours facile de déterminer s'il y a deux ou trois personnes en présence, ou qui est créancier ou débiteur de qui. D'abord il y a des cas où on se demande si la personne intermédiaire a bien un patrimoine distinct de l'un des débiteurs-créanciers. Il en va ainsi notamment dans le contexte des groupes de sociétés : *Primus* a une créance envers une société *Secundus* ; il est débiteur d'une autre société du même groupe *Tertius*, qui est une filiale à 100 % de *Secundus*. Economiquement, il y a identité entre *Secundus* et *Tertius*. Cependant, en principe, les différentes sociétés d'un même groupe constituent des personnes juridiques distinctes, ce qui exclut la compensation. Il peut en aller autrement si la société *Tertius* apparaît comme fictive, et si son patrimoine est entièrement confondu avec celui de la société *Secundus* : la compensation deviendra alors possible. Il en va autrement également pour les créances d'une succursale, qui n'a pas une personnalité morale distincte de celle de la société : ces créances peuvent dès lors se compenser avec les créances qu'un tiers a contre la société[2016]. Par ailleurs, il faut bien distinguer société et indivision : l'indivision entre deux personnes ne constitue pas un patrimoine distinct : si un frère est débiteur de l'indivision (parce que, par exemple, il a utilisé à son profit des valeurs qui y figurait), et par ailleurs créancier de son frère pour des dépenses qu'il a faites sur le bien indivis, la compensation pourra s'opérer.

[2016] Cour d'appel, 1er octobre 1963, *Pas.*, 19, p. 209.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Ensuite, il y a des cas où on se demande de qui une personne est créancière : selon la réponse, la compensation sera ou non permise. Par exemple, *Primus* est un assureur de responsabilité. Son assuré, *Secundus*, ne lui a pas payé des primes. Il cause un accident à *Tertius*, qui, par la voie de l'action directe, demande le paiement de l'indemnité à *Primus*. L'assureur peut-il lui opposer la compensation avec les primes impayées ? L'analyse du mécanisme de l'action directe permet de dire que l'assureur est débiteur envers la seule victime *Tertius*, et non envers son assuré : il ne peut donc pas opposer la compensation[2017].

901. Fongibilité. L'article 1291 du Code civil pose une règle qui va de soi : la compensation ne peut se produire que si les deux créances ont des objets interchangeables – on dit qu'elles doivent être fongibles entre elles. Cela exclut d'emblée la compensation pour les corps certains : si *Primus* doit livrer une voiture à *Secundus* qui doit lui remettre un cheval de course, la compensation est évidemment impossible. Aucun des deux n'aurait satisfaction si les deux dettes se compensaient.

On ne peut pas davantage imaginer de compensation entre une obligation de somme d'argent et une obligation de faire[2018]. Tout ce que peut faire le débiteur d'une de ces deux créances, c'est invoquer contre l'autre l'exception d'inexécution, pour se dispenser d'exécuter sa propre obligation si l'autre n'exécute pas la sienne. Mais on sait que celle-ci n'éteint pas les obligations, elle ne fait qu'en suspendre l'exécution. L'extinction des obligations ne pourra résulter que de la résolution du contrat, qui doit en principe être demandée en justice.

La compensation n'a donc de sens que si les deux obligations ont pour objet des choses de genre, à condition qu'elles soient de même espèce (on ne peut pas compenser l'obligation de livrer du blé avec celle de livrer du pétrole). Le domaine d'élection de la compensation est donc celui des dettes de somme d'argent. Un problème particulier, important dans la pratique luxembourgeoise, se pose dans l'hypothèse où les deux dettes ne sont pas libellées dans la même monnaie : après avoir naguère décidé que cela empêchait la compensation, la monnaie étrangère apparaissant comme une « marchandise »[2019], la Cour d'appel juge désormais que cette différence de monnaie n'interdit pas la compensation[2020].

2017 Sur le mécanisme de l'action directe, voy. *infra*, n° 1104.

2018 Cour d'appel, 11 janvier 1984, 26, p. 139.

2019 Cour d'appel, 2 mars 1923, *Pas.*, 11, p. 134.

2020 Cour d'appel, 1er octobre 1963, préc. ; Les textes internationaux et projets européens prévoient également la possibilité d'une telle compensation, du moins si les deux monnaies sont librement convertibles : Principes Unidroit, art. 8.2 ; PDEC, art. 13 : 103 ; DCFR, art. III-6 : 104. Voy. aussi dans le même sens le projet de réforme français, art. 1325-1, al. 2.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

902. Connexité ? D'une manière générale il importe peu que les deux créances proviennent ou non de la même cause, qu'elles soient liées par un même rapport de droit. Une dette de paiement d'un prix de vente née d'un contrat peut se compenser avec une dette d'indemnité née d'un accident de la circulation. Certes, nous verrons que lorsque les deux créances sont liées, notamment lorsqu'elles proviennent d'un même contrat (on dit qu'elles sont connexes), la compensation sera plus facile ; mais la connexité n'est en aucune manière une condition légale de la compensation.

b. *Conditions que doit remplir chaque créance*

903. Origine indifférente. L'origine des créances est en principe indifférente (C. civ., art. 1293). Peu importe la cause contractuelle, délictuelle (dommages et intérêts), quasi-contractuelle, légale (par exemple : des dettes fiscales) des créances.

Cependant la loi exclut de la compensation, pour des raisons diverses, un certain nombre de créances :

- la créance de restitution d'un propriétaire injustement dépouillé (volé, escroqué) ne peut se compenser avec une créance qu'aurait le voleur (C. civ., art. 1293-1°) : il s'agit autant de sanctionner le créancier indélicat que des protéger les autres créanciers contre celui qui se serait mis malhonnêtement en situation d'exclusivité :
- la créance de restitution d'un dépôt ou d'un prêt à usage (C. civ., art. 1293-2°) est insusceptible de compensation. La règle, qui vise à protéger la propriété du déposant ou du prêteur est d'un très faible intérêt pratique car il est très rare que les choses prêtées à usage ou déposées soient des choses fongibles susceptibles de se compenser :
- la créance d'aliments ne peut se compenser dans la mesure où elle est insaisissable (C. civ., art. 1293, – 3°) ; il s'agit ici d'éviter que le créancier d'une pension alimentaire, qui doit lui-même de l'argent au débiteur, se voie priver de sa pension, alors que, par hypothèse, celle-ci est nécessaire à la satisfaction de ses besoins[2021]. La règle, cependant, n'est qu'une application d'une règle plus générale qui exclut la compensation lorsque l'une des créances est insaisissable[2022]. C'est donc moins en raison de l'origine de la créance que de son caractère insaisissable que la créance d'aliments est insusceptible de compensation :
- enfin et surtout, selon l'article L. 224-3 du Code du travail, l'employeur ne peut procéder à une retenue sur les salaires qu'il doit à son salarié que dans des cas déterminés. C'est dire qu'en dehors de ces cas, il ne peut procéder à la compensation avec les sommes que le salarié pourrait lui devoir.

[2021] La compensation redevient cependant possible si les deux créances réciproques sont toutes deux des créances alimentaires : Cour d'appel, 6 avril 1993, *Pas.*, 29, p. 238.

[2022] Voy. *infra*, n° 905.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

904. Créances certaines, liquides et exigibles. La compensation opère comme un paiement forcé, reposant sur l'appréhension exclusive, par chaque partie, de la créance réciproque. À partir de là, la compensation ne peut s'opérer que si chaque dette est susceptible de faire l'objet d'une demande en exécution forcée. On ne peut invoquer la compensation contre son débiteur que si on aurait pu le contraindre à payer à dette. On peut expliquer ainsi que les deux dettes doivent être certaines, liquides et exigibles (C. civ., art. 1291)[2023] : la compensation légale ne se produira entre elles qu'au moment où ces conditions seront remplies pour les deux créances.

Une créance est liquide, selon la Cour d'appel, « lorsqu'elle est certaine et que le montant est déterminé. Il faut qu'elle soit certaine dans son existence et dans son montant »[2024]. Si la dette de mon débiteur est incertaine, je ne peux faire jouer la compensation contre lui, parce que je ne pourrais pas l'obliger à me payer tant qu'un juge n'aurait pas établi l'existence de la dette. Ce n'est qu'à ce moment que la compensation pourra s'exercer. Mais il ne suffirait pas que mon débiteur conteste sa dette pour échapper à la compensation : si en effet le juge établit *a posteriori* que la contestation n'était manifestement pas fondée, la compensation remontera au jour où les autres conditions en auront été réunies[2025]. Le défaut de liquidité empêche également la compensation, parce que la dette non liquide n'est pas susceptible de paiement forcé, ni d'ailleurs volontaire. La compensation ne s'opérera que lorsque le montant sera évalué : par exemple, si *Primus* doit 1 000 € à *Secundus* et que *Secundus* lui a causé un dommage, la compensation ne pourra s'opérer que lorsque les dommages et intérêts seront évalués (et d'ici là, *Primus* sera peut-être obligé de payer si sa propre dette est exigible, d'où l'intérêt pour lui de solliciter la compensation judiciaire[2026]) *infra*).

[2023] Ces exigences sont généralement reprises par les textes internationaux et les projets européens : Les PDEC exigent ainsi que les deux dettes soient exigibles (art. 13 : 101) et qu'elles soient certaines dans leur existence et dans leur montant. Voy. aussi Principes Unidroit, art. 8.1 ; DCFR, art. III-6 : 102 et 103 ; Code Gandolfi, art. 132 (2).

[2024] Cour d'appel, 18 janvier 2018, n° 42989 (créance d'indemnité de retard non liquide car contestée dans son principe même par le débiteur).

[2025] Cour d'appel, 5 mai 2004, *D.A.O.R.*, 2005, n° 74, p. 126, note A. DÉOME et O. POELMANS (dans une hypothèse où le jugement statuant sur la contestation était intervenu seulement après la faillite du débiteur, qui rend normalement impossible la compensation. Dans la mesure où la contestation n'était pas sérieuse, la créance a pu être considérée comme certaine dès avant la faillite).

[2026] Voy. *infra*, n°s 911 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

La compensation est également impossible si l'une des dettes n'est pas exigible[2027]. Faire jouer la compensation aboutirait en effet à priver le débiteur de cette dette du bénéfice du terme. Il est clair cependant que, si c'est ce débiteur qui invoque la compensation contre l'autre, dont la dette est exigible, la compensation pourra jouer puisqu'en principe le débiteur peut renoncer au bénéfice du terme : mais la compensation sera alors assimilée à un paiement d'une dette non échue, ce qui pourra avoir certaines conséquences (paiement de pénalités, nullités de la période suspecte). L'article 1292 du Code civil (repris tant par le nouvel article 1347-3 du Code civil français que par l'article 5.257 du nouveau Code civil belge) précise cependant que le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation, ce qui est logique puisque le délai de grâce n'est pas, en dépit de l'expression du texte, un véritable terme, il ne repousse pas l'exigibilité[2028]. Certes, il empêche l'exécution forcée, mais cet effet ne s'explique que parce que le débiteur n'est pas en état de payer : or, s'il est créancier de son débiteur, il a précisément le moyen de payer celui-ci avec cette créance.

905. Créances saisissables. On ne peut faire jouer la compensation contre son débiteur que si la créance qu'il a sur vous est susceptible d'être appréhendée au titre de l'exécution forcée. Cette idée explique que la compensation soit exclue si l'une des créances est insaisissable. Il convient ici de généraliser la solution prévue par l'article 1293-3° du Code civil pour les créances alimentaires. L'interdiction de la compensation vaut aussi, par exemple, pour la fraction insaisissable de la créance de salaire (même dans les cas où une retenue sur salaires serait permise par application de l'article L. 224-3 du Code du travail), pour les rentes d'accidents du travail, etc.

Il faut cependant signaler que la compensation n'est interdite qu'à sens unique : le titulaire de la créance insaisissable (le salarié, le créancier d'aliments) peut en effet, lui, pour se dispenser de payer ce qu'il doit, invoquer la compensation (par exemple, le salarié assigné par l'employeur en remboursement d'un crédit peut invoquer la compensation même avec la fraction insaisissable du

[2027] Pour une application en matière de compte courant : Cour d'appel, 17 mars 1999, *Pas.*, 31, p. 129 (le solde d'un compte courant ne devient exigible au jour de la clôture : en conséquence, ce n'est qu'à cette date qu'une banque peut compenser le solde débiteur d'un compte du client avec le solde créditeur d'un autre).

[2028] Voy. *supra*, n° 586.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

salaire : solution logique puisqu'il pourrait, pour payer, prélever sur son compte des sommes provenant de cette fraction.). De même, la Cour d'appel a jugé que, en raison de l'insaisissabilité des biens publics, le créancier d'une collectivité publique ne peut pas opposer la compensation à cette collectivité, alors que celle-ci, elle, pourrait opposer la compensation à une personne privée[2029].

2) *La compensation et les droits des tiers*

906. Article 1298 du Code civil. Aux termes de l'article 1298, la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à des tiers. Cette règle est reprise par le nouvel article 1347-7 du Code civil français et par l'article 5.261 du nouveau Code civil belge. Il faut ici se souvenir de ce que la compensation permet à chaque créancier de se payer à titre exclusif sur une créance appartenant à l'autre. Elle doit par conséquent être exclue si l'une des créances a déjà été appréhendée par un ou plusieurs tiers, ou si un tiers a déjà acquis sur cette créance un droit qui empêche toute appréhension exclusive par un créancier. Cette solution de principe, qui a de multiples conséquences (**a**) connaît cependant une exception remarquable lorsque les deux dettes sont connexes (**b**).

a. *Le principe*

907. Différentes situations. La règle de l'article 1298 du Code civil fait obstacle à la compensation aussi bien lorsque l'une des créances a déjà été transmise à un tiers que lorsque cette créance est simplement bloquée, rendue indisponible au profit d'un ou de plusieurs tiers. Si l'une des créances a été transmise à un tiers (par cession ou subrogation[2030]), le débiteur ne devrait pouvoir opposer la compensation au nouveau titulaire de la créance (cessionnaire ou subrogé) que si les conditions en étaient réunies avant cette transmission. Cependant, en matière de cession de créance, l'article 1295 du Code civil (modifié en 1994) édicte une règle différente : la compensation est opposable au cessionnaire dès lors que la créance du cédé était née antérieurement à la notification de la cession, et qu'elle est devenue exigible avant la créance cédée ou simultanément. La compensation est exclue dans les cas où la créance de l'un des débiteurs a déjà été appréhendée par un autre créancier dans le cadre d'une mesure d'exécution, alors même que la mesure

[2029] Cour d'appel, 19 juin 2019, n° 37005.

[2030] Sur ces mécanismes, voy. *infra*, n°s 996 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pratiquée a seulement eu pour effet de bloquer la créance au profit du tiers saisissant : c'est le cas si, avant que les conditions de la compensation ne soient remplies, une des créances a fait l'objet d'une saisie-arrêt. Cette hypothèse est d'ailleurs expressément prévue par l'article 1298 du Code civil.

Surtout, il faut relever ici l'interdiction de la compensation lorsque l'une des parties est mise en faillite[2031]. Cette solution est constante dans les trois pays du Code civil. Dans un tel cas, en effet, tous les éléments d'actif du débiteur sont rendus indisponibles, et aucun créancier ne peut plus exercer de voies d'exécution. Aucun créancier ne doit pouvoir soustraire un élément d'actif à son profit exclusif. Ce blocage est d'ailleurs renforcé par l'interdiction faite au débiteur de payer tel ou tel de ses créanciers après l'ouverture de la procédure. Pour ces deux raisons (blocage de l'actif et interdiction des paiements), la compensation est normalement interdite après l'ouverture de la procédure. Il faut comprendre qu'elle ne peut pas jouer si les conditions s'en sont trouvées seulement réunies après le jugement d'ouverture : si en revanche les deux dettes réciproques étaient certaines, liquides et exigibles avant ce jugement, la compensation peut encore être invoquée après, puisque, en vertu de l'article 1290 du Code civil, elle opère de plein droit au jour où les conditions en étaient réunies[2032]. En revanche si l'une des deux dettes a été liquidée ou est devenue exigible après le jugement déclaratif, la compensation ne peut plus s'opérer. Cependant la solution – comme toutes celles qui tiennent aux droits des tiers – connaît une exception remarquable si les deux dettes sont connexes.

b. *Exception en cas de dettes connexes*

908. Idée générale. En règle générale, nous l'avons dit, la compensation peut jouer entre deux dettes qui n'ont pas la même origine, qui ne trouvent pas leur source dans un même rapport de droit, qui n'ont pas de lien entre elles. Mais, s'il existe un tel lien, s'il y a connexité entre les deux dettes, la jurisprudence (et, en France, le législateur) facilite le jeu de la compensation : on pourra se passer de certaines des conditions qui viennent d'être énumérées, ou lever certains obstacles au jeu normal de la compensation légale. En d'autres termes, si la connexité n'est pas une condition nécessaire

[2031] Solution indiscutée au moins depuis Cour d'appel, 2 mars 1923, *Pas.*, 11, p. 134. Voy. récemment Cour d'appel, 11 juillet 2018, *Pas.*, 39, p. 85.

[2032] Cour d'appel, 5 mai 2004, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de la compensation, c'est une condition de substitution, une sorte de joker. Encore faut-il préciser de quelles conditions la connexité permet ainsi de se passer, puis ce qu'on entend par connexité.

909. Effets de la connexité. Dans le cadre de la compensation légale, la connexité permet de passer outre aux cas où la compensation est interdite dans l'intérêt des tiers, c'est à dire aux divers cas que l'on peut rattacher à l'article 1298 du Code civil. L'idée est en effet que, lorsque les deux dettes sont connexes, chacune des créances est *a priori* réservée au paiement de l'autre partie, il y a une sorte d'affectation qui permet de faire jouer la compensation alors même que l'une des créances a été appréhendée par un ou plusieurs autres créanciers[2033]. C'est ainsi surtout que, selon une jurisprudence traditionnelle, si les dettes étaient connexes, la compensation demeure possible, même après l'ouverture d'une procédure collective, alors même que les conditions de la compensation n'ont été remplies qu'après le jugement d'ouverture, à un moment où aucun paiement n'était plus permis[2034]. Cette solution, également admise en Belgique[2035], a été consacrée en France par la loi du 10 juin 1994 : elle figure désormais à l'article L. 622-7 du Code de commerce comme une exception à la règle de l'interdiction des paiements.

Mais, selon la jurisprudence française, la connexité permet aussi de passer outre à la transmission de l'une des créances à un tiers, soit par la voie d'une cession, soit par la voie d'une subrogation[2036] : la connexité permet de faire remonter la compensation à une date antérieure à la cession ou à la subrogation. L'idée est clairement que la créance connexe était réservée au paiement du créancier-débiteur, sa transmission à un tiers est donc sans effet ; le créancier originaire n'a transmis que du vent. Ces solutions n'étaient pas admises par la jurisprudence belge[2037], mais le nouveau texte belge prévoit désormais de manière générale que la règle selon laquelle la compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis par un tiers reçoit exception en cas de dettes connexes.

2033 POELMANS, n° 544.

2034 Voy. p. ex. Cour d'appel, 11 juillet 1984, n° 7145 ; Cour d'appel, 16 juin 2004, n° 27652 ; Cour d'appel, 4 juillet 2007, n° 31521 ; Cour d'appel, 11 juillet 2018, *Pas.*, 39, p. 85.

2035 Cass. be., 7 décembre 1961, *Pas. be.*, 1962, I, p. 440 ; Cass. be., 4 février 2011, n° C10.0443N.

2036 Cass. fr. (3e civ.), 12 juillet 1995, n° 93-18182.

2037 Cass. be., 26 juin 2003, n° C01.0528.F.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Cependant, la connexité ne permet pas de passer outre toutes les conditions normalement requises pour la compensation. Se référant à la jurisprudence française, un arrêt de 2024 de la Cour d'appel juge, à juste titre, que l'exigence de certitude de la créance ne se prête pas au palliatif, parce que, « faute de certitude de l'une des créances réciproques prétendues, il manquerait un élément essentiel au jeu de la compensation ». De même, pour la Cour, la connexité paraît impuissante à suppléer la fongibilité requise des créances. En conséquence, conclut l'arrêt, « seules demeurent substituables par la connexité la liquidité et l'exigibilité ; elle peut d'ailleurs les remplacer cumulativement »[2038].

910. Notion de connexité. Encore faut-il voir ce qu'on entend par connexité. Cette question est souvent discutée dans le cadre des procédures de faillite. Au minimum on admettra qu'il y a connexité lorsque les deux dettes sont nées d'un même contrat[2039]. Par exemple, dans un contrat d'entreprise, le client doit payer le prix des travaux ; mais de son côté, l'entrepreneur doit des dommages et intérêts pour mauvaise exécution des travaux. L'entrepreneur est mis en redressement judiciaire avant que les dommages et intérêts ne soient liquidés : le client peut opposer la compensation pour se dispenser de payer le prix. C'est apparemment ce seul cas de connexité qui est reconnu par la jurisprudence luxembourgeoise : dans l'arrêt précité de 2024, la Cour d'appel juge que « le caractère connexe présuppose que les dettes compensables soient issues d'une seule et même situation synallagmatique et donc, en matière contractuelle, d'un seul et même contrat »[2040]. Dans un tel cas, du reste, la compensation se rapproche de l'exception d'inexécution. Mais la jurisprudence française va parfois plus loin. Elle admet la connexité si les deux créances se rattachent à des contrats distincts, mais faisant partie d'un même ensemble contractuel[2041]. En revanche, il n'y a pas connexité si les créances, bien que nées à l'occasion d'un même contrat, procèdent de fondements différents[2042]. Certaines décisions du tribunal de Luxembourg semblent sensibles à cette idée de connexité élargie[2043].

2038 Cour d'appel, 22 mai 2024, n° CAL-2022-00280.

2039 Trib. Luxembourg, 15 février 2008, *BIJ*, 2008, p. 190.

2040 Cour d'appel, 22 mai 2024, préc.

2041 Cass. fr., 9 mai 1995, n° 93-11724. Mais il ne suffit pas que les dettes soient nées de relations commerciales régulières entre les parties : Cass. fr. (comm.), 5 avril 1994, n° 92-13989.

2042 Cass. fr. (comm.) 18 décembre 2012, n° 11-17872 (pas de compensation entre une dette contractuelle et une dette née d'une faute délictuelle commise à l'occasion du contrat).

2043 Trib. Luxembourg, 15 novembre 2016, n° 171668 ; Trib. Luxembourg, 11 janvier 2024, n° TAL-2018-06980 (à propos de la connexité entre deux demandes).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

La connexité produit également des effets dans le cadre de la compensation judiciaire.

§2. La compensation judiciaire

911. Principe. L'hypothèse est qu'un créancier agit en justice contre son débiteur pour le voir condamner au paiement. Le débiteur assigné prétend disposer d'une créance contre le demandeur, mais les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies : il ne peut donc pas se contenter d'invoquer la compensation en défense. Il va alors demander au tribunal de provoquer la compensation par le biais d'une demande reconventionnelle visant à la condamnation du demandeur principal à payer la dette en sens inverse. Par exemple, vous m'assignez en paiement d'une dette contractuelle de 10 000 € ; mais par ailleurs je prétends que vous me devez des dommages et intérêts dont le montant n'est pas encore fixé (et qui ne sont donc pas encore liquides ni exigibles) ; je vais demander au juge de statuer en même temps sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle, c'est à dire de fixer les dommages et intérêts et de vous condamner à me les payer ; la compensation pourra alors s'opérer entre les deux dettes. Elle ne s'opérera que lorsque le jugement sera rendu, ce qui distingue fondamentalement le mécanisme de la compensation légale, qui est censée se produire à un moment antérieur à celui où elle est invoquée. Ici le défendeur ne se contente pas d'opposer une compensation qui s'est déjà produite, il demande qu'elle se produise. Cependant, d'un autre côté, on peut dire que le juge à qui on demande cette compensation, ne fait que faire en sorte que les conditions légales de la compensation soient réunies. Admise au départ sans texte par la jurisprudence dans les trois pays du Code civil[2044], la compensation judiciaire est aujourd'hui consacrée par les nouveaux textes français (C. civ. fr., art. 1348) et belges (C. civ. be., art. 5.264). Elle obéit à des conditions spécifiques.

912. Conditions. La compensation judiciaire n'est possible que si les conditions défaillantes sont de celles sur lesquelles le juge peut avoir une influence. Il est certain que le juge ne saurait passer outre aux conditions de réciprocité et de fongibilité des créances entre

[2044] Au Luxembourg : Cour d'appel, 29 janvier 1980, *Pas.*, 25, p. 17.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

elles, sans lesquelles aucune compensation ne saurait intervenir. Il ne devrait pas davantage pouvoir ordonner la compensation si la créance du demandeur à l'action principale est insaisissable : si on me demande le paiement d'une pension alimentaire, je ne devrais pas pouvoir résister en demandant au juge de condamner mon créancier à des dommages et intérêts en raison d'un préjudice qu'il m'a causé[2045]. La compensation judiciaire pourra en revanche être ordonnée si l'une des créances n'est pas liquide : c'est le cas typique de la compensation avec une créance de dommages et intérêts non encore liquidée, dont le juge devra fixer le montant. Les solutions sont plus incertaines pour les autres conditions de la compensation. On considère généralement que la compensation judiciaire n'est pas possible si la créance invoquée dans la demande reconventionnelle n'est pas certaine[2046]. Cette opinion mérite d'être nuancée : il ne suffit pas que le débiteur assigné en paiement par la voie de la demande reconventionnelle conteste l'existence de sa dette pour échapper à la compensation. Il faut simplement, comme le dit un arrêt de la Cour d'appel que la créance puisse « être constatée et liquidée sans difficultés et sans retard préjudiciables à l'autre partie »[2047]. Si le débat est trop important, le débiteur assigné en paiement à titre principal devra payer sa dette, et il lui appartiendra ensuite de provoquer un nouveau procès pour obtenir le paiement de ce qu'il prétend lui être dû. Reste le cas où la créance invoquée en compensation n'est pas exigible : logiquement, le juge ne devrait pouvoir prononcer la compensation dans ce cas que s'il a le pouvoir de prononcer la déchéance du terme. Cette condition, prévue en France par le projet Catala, n'a cependant pas été retenue par l'ordonnance de 2016, qui a prévu que « la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations n'est pas encore liquide ou exigible » (C. civ. fr., art. 1348). En revanche, dans le nouveau droit belge, l'article 5.264 du Code civil prévoit que « même si les obligations ne sont pas encore certaines ou liquides, la compensation peut être prononcée par le juge », ce qui semble exclure le défaut d'exigibilité.

[2045] La Cour de cassation française a cependant considéré que la compensation judiciaire pouvait jouer même pour les créances exclues de la compensation par l'article 1293. Voy. pour une créance insaisissable Cass. fr. (2e civ.), 10 mars 1965, *D.*, 1965, p. 350. *Contra* pour la Belgique : VAN OMMESLAGHE, vol. 3, n° 1590.

[2046] TERRÉ, SIMLER, LEQUETTE, CHENEDE 2023, n° 1702.

[2047] Cour d'appel, 29 janvier 1980, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

913. Rôle de la connexité. Il n'est pas nécessaire, pour que le juge prononce la compensation judiciaire, que les deux dettes soient connexes[2048]. Mais la connexité facilite le jeu de la compensation judiciaire : dès lors que la dette à liquider est connexe à la dette faisant l'objet de la demande principale, le juge, qui a normalement un pouvoir d'appréciation, devra faire droit à la demande reconventionnelle et prononcer la compensation[2049]. Telle est la solution retenue par le nouvel article 1348-1 du Code civil français, selon lequel « le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible ». Le texte précise que, dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles, et qu'elle pourra être opposée même à l'encontre des droits des tiers.

§ 3. La compensation conventionnelle

914. Principe. L'accord des deux parties peut aboutir à faire jouer la compensation lorsque les conditions légales n'en sont pas réunies. C'est ce qu'on appelle la compensation conventionnelle. Les deux parties se mettent d'accord pour que leurs dettes réciproques se compensent alors même que l'une des deux n'est pas exigible (auquel cas l'une renonce au bénéfice du terme), ou pas liquide (auquel cas elles en fixent le montant). La compensation se produit au moment de l'accord des parties. L'opération peut s'analyser comme une dation en paiement réciproque, chacun des créanciers acceptant d'être payé avec la créance de l'autre sur lui-même. Une application caractéristique, en droit bancaire, réside dans les conventions d'unicité de compte que peuvent passer une banque et son client, prévoyant que les différents comptes du client forment un tout indivisible, de sorte que le solde débiteur de l'un ou de plusieurs d'entre eux pourra se compenser, au profit de la banque, avec le solde débiteur d'un ou plusieurs autres, même si les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies (notamment parce que l'un des comptes n'a pas été clôturé)[2050]. La possibilité d'une telle compensation conventionnelle est aujourd'hui expressément consacrée par le nouvel article 1348-2 du Code civil français et par l'article 5.263 du nouveau Code civil belge.

[2048] Cass. fr. (1re civ.), 30 juin 1993, n° 91-16162.
[2049] Cass. fr. (3e civ.), 20 novembre 2002, n° 00-14423.
[2050] Sur la licéité de cette convention : Cour d'appel, 17 mars 1999, *Pas.*, 31, p. 129.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

915. Validité. La compensation conventionnelle est en elle-même parfaitement licite : la Cour d'appel a clairement affirmé que « lorsque l'une des dettes ne réunit pas les conditions exigées par la loi pour que la compensation s'opère de plein droit, cette compensation peut cependant s'opérer par la volonté des parties, librement consentie, dont les conditions sont réglées entre elles »[2051]. Cette validité trouve cependant une limite dans la nécessité de respecter les droits des tiers. La compensation va en effet avoir pour effet de soustraire la créance de chaque débiteur au droit de gage de ses créanciers pour l'affecter exclusivement au paiement de l'autre. Si cette opération est effectuée dans une période où l'un des débiteurs est en état de cessation des paiements – donc pendant la période dite suspecte[2052] – elle sera considérée comme un moyen de paiement anormal prohibé par l'article 445 du Code de commerce, à moins que cette compensation conventionnelle n'ait été convenue de bonne foi avant cette période[2053]. Il en irait de même d'une convention par laquelle, pendant cette période, un créancier du débiteur en difficulté se rendrait débiteur de celui-ci dans le seul but de pouvoir ensuite invoquer la compensation[2054].

Il convient cependant de mettre à part, au regard des procédures de faillite, les conventions dites de *netting*, qui constituent une application particulière de la compensation conventionnelle. Il s'agit de conventions passées entre opérateurs financiers qui ont pour objet d'assurer le règlement de créances et de dettes résultant de transactions sur instruments financiers. Ces opérations prennent techniquement la forme de clauses de compensation avec déchéance du terme des créances et dettes réciproques des parties. Dans le but d'assurer la sécurité du système financier, ces opérations sont mises à l'abri des incidences des procédures de traitement de l'insolvabilité. La loi du 5 août 2005 qui transpose la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière[2055] dispose à cet égard en son article 18 que « les compensations entre avoirs, opérées en cas de mesures d'assainissement, de procédure de liquidation ou de toute autre situation de concours, sont valables et opposables aux tiers, aux commissaires, aux curateurs et aux liquidateurs ou autres organes similaires, quels que soient les dates d'exigibilité, leurs objets ou les monnaies dans lesquelles elles sont libellées, à condition qu'elles résultent d'opérations qui font l'objet de conventions ou de clauses de compensation bilatérales

2051 Cour d'appel, 16 octobre 1956, *Pas.*, 17, p. 21.

2052 Voy. *supra*, n° 729.

2053 Trib. Luxembourg, 15 juin 1966, *Pas.*, 20, p. 212 (à propos d'une convention passée entre un avocat et son client prévoyant que l'avocat retiendrait ses frais et honoraires sur les sommes recouvrées par lui au nom de son client. Dès lors qu'elle est convenue avant la période suspecte, cette convention s'applique même aux honoraires correspondant à l'activité de l'avocat pendant cette période).

2054 Cour d'appel, 25 mai 2011, *Pas.*, 35, p. 642.

2055 *J.O.C.E.*, L. 168, 27 juin 2002.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ou multilatérales entre deux ou plusieurs parties ». L'article 19 de la même loi pose également le principe de validité et d'opposabilité aux organes de la faillite des clauses de compensation avec déchéance du terme « nonobstant l'engagement ou la poursuite d'une mesure d'assainissement d'une procédure de liquidation indépendamment du moment où ces clauses, y compris de compensation, ont été convenues ou exécutées, et (b) nonobstant toute saisie civile, pénale ou judiciaire ou confiscation pénale ainsi que toute cession ou autre aliénation alléguée des droits concernés ou concernant lesdits droits ». On est donc ici en présence d'une dérogation générale à l'article 1298 du Code civil, selon lequel la compensation ne peut jouer au préjudice des droits des tiers.

SOUS-SECTION 2. LA CONFUSION

916. Notion – On appelle confusion la réunion sur une seule tête des qualités de créancier et de débiteur (C. civ., art. 1300) : un enfant hérite de son père dont il était le créancier, deux sociétés, dont l'une était créancière de l'autre, fusionnent, un locataire achète l'immeuble qui lui était loué, un débiteur se fait céder la créance dont il est débiteur (notamment dans le cadre du retrait litigieux de l'article 1699 du Code civil[2056]). Dans tous ces cas, le débiteur devient en quelque sorte débiteur de lui-même. Cette confusion éteint le rapport d'obligation.

917. Effet extinctif. Le Code civil présente la confusion comme une cause d'extinction de l'obligation. L'extinction de l'obligation a pour conséquence la perte des sûretés qui assortissaient la créance. En particulier, si la créance était cautionnée, la caution se trouve libérée (C. civ., art. 1301). Cette extinction peut n'être que partielle si la confusion ne s'opère que pour une partie de la dette : ainsi lorsqu'une personne, créancière d'un de ses enfants, décède en laissant plusieurs héritiers ; l'enfant débiteur n'est libéré que pour sa part successorale, pour le reste, il devient débiteur de ses frères et sœurs. Il en va de même lorsqu'un codébiteur solidaire devient titulaire de la créance : l'article 1301 du Code civil précise qu'il peut alors réclamer ce qui excède sa part à ses codébiteurs.

Cet effet extinctif trouve cependant certaines limites. Le créancier devenu son propre débiteur peut en effet continuer à opposer son droit aux tiers. La Cour de cassation belge a ainsi jugé que la victime d'un accident devenue l'héritière du responsable pouvait néanmoins demander à l'assureur de celui-ci le paiement de

[2056] Voy. *infra*, n° 1001.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'indemnité d'assurance[2057]. De même, il a été admis en France que le locataire ayant acheté l'immeuble loué peut continuer à opposer à son vendeur la diminution de la valeur de l'immeuble résultant du bail pour faire échec à une action en rescision pour lésion[2058]. La doctrine s'appuie parfois sur ces solutions pour dire que la confusion n'éteint pas vraiment le rapport d'obligation, mais paralyse seulement son exécution[2059]. L'article 5.269 du nouveau Code civil belge semble aller dans ce sens, puisqu'il prévoit que l'effet premier de la confusion est de suspendre l'exigibilité de l'obligation. Ce n'est que si l'obstacle à l'exigibilité est définitif que l'obligation est éteinte.

Cet effet extinctif (ou cette paralysie d'exécution) peut prendre fin si la réunion des qualités de débiteur et de créancier vient elle-même à cesser. Il en va ainsi, en tout cas, si cette cessation est rétroactive : ainsi, si la vente au locataire de l'immeuble loué vient à être annulée ou résolue, l'acquéreur redevient locataire[2060]. La cour d'appel du Luxembourg a naguère décidé le contraire[2061], mais la solution est très contestable.

L'article 1301 règle la question des effets de la confusion qui se produit dans la personne d'un débiteur sur ses cautions ou sur ses codébiteurs solidaires. Dans le même ordre d'idées, un arrêt de la Cour d'appel s'est prononcé sur les effets de la confusion produite dans la personne d'un locataire devenu propriétaire indivis du bien loué. Se référant à la jurisprudence française, la Cour décide que la confusion s'opère partiellement entre la qualité de propriétaire et celle de locataire à concurrence de ses droits indivis, mais n'entraîne pas l'extinction, même partielle, du bail[2062].

SECTION 2. L'EXTINCTION SANS SATISFACTION DU CRÉANCIER

918. Causes diverses. Même dans l'hypothèse où il n'a pas reçu satisfaction, le créancier peut consentir à l'extinction du rapport d'obligation, soit pour le remplacer par un autre – c'est la novation

[2057] Cass. be., 26 octobre 1962, *Pas. be.*, 1963, I, p. 259. Comp : Cass. fr.

[2058] Cass. (1re civ.), 16 novembre 1959, *JCP*, 1960, II, p. 11837.

[2059] Voy. not. en Belgique VAN OMMESLAGHE, vol. 3, n° 1555 ; en France, avec des nuances TERRÉ, SIMLER, LEQUETTE, CHENEDE 2023, n° 1707.

[2060] Cass. fr. (3e civ.), 22 juin 2005, n° 03-18.624 P.

[2061] Cour d'appel, 16 juillet 1935, *Pas.*, 13, p. 526.

[2062] Cour d'appel, 20 décembre 2020, n° CAL-2019-00653.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

(**Section 1**) – soit en faisant purement et simplement remise de sa dette au débiteur (**Section 2**). Mais l'obligation peut aussi s'éteindre sans la volonté du créancier, par le seul fait de l'écoulement du temps – c'est la prescription (**Section 3**).

SOUS-SECTION 1. LA NOVATION

919. Notion. Il arrive fréquemment que les parties à un rapport d'obligation – et tout particulièrement à un rapport contractuel – décident, alors que cette obligation n'a pas encore été exécutée, de lui apporter des modifications. Par exemple, si un emprunteur a des difficultés de remboursement, il peut essayer de s'entendre avec son banquier pour que celui-ci lui consente un rééchelonnement de sa dette, avec éventuellement une modification du taux d'intérêt. Dans certains cas, si les modifications sont très importantes, on considérera que le contrat n'est plus le même, qu'une nouvelle obligation s'est substituée à l'ancienne, qui, elle, sera considérée comme éteinte. C'est ce que, dans le Code civil, on appelle novation. Le Code civil français réformé la définit, de manière plus précise que dans le code actuel, comme « un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée » (art. 1329). La nouvelle définition belge est sensiblement la même (C. civ. be., art. 5.245).

920. Différents types. La novation, réglementée dans le Code civil aux articles 1271 à 1275, peut, selon l'article 1271, s'opérer de trois manières – qui se retrouvent dans les nouveaux textes belges et français. La première, qui correspond à ce qui a été décrit, s'opère « lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte » : c'est ici le contenu de l'obligation qui est changé, les parties restant les mêmes. Dans les deux autres cas prévus par le texte, le changement affecte une partie au rapport d'obligation : soit que « un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier » (C. civ., art. 1291-2°), soit que, à l'inverse « par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien » (C. civ., art. 1291-3°). Dans ces deux dernières utilisations, la novation permet d'assurer la « circulation » du rapport d'obligation, en transférant à une personne le bénéfice d'une créance, ou à l'inverse en lui faisant assumer la charge d'une dette née à l'origine sur la tête d'une autre, et nous la retrouverons à ce propos[2063]. C'est ce qui

[2063] Voy. *infra*, n° 1052.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

explique que, dans le nouveau droit français, la novation ne soit plus traitée au titre des causes d'extinction de l'obligation (ce qu'elle est pourtant), mais au sein des différentes « opérations sur créances », en parallèle avec la cession de créance, la cession de dette, et la délégation. Dans cette fonction, la novation, surtout en ce qu'elle permet de réaliser un changement de créancier, est aujourd'hui fortement concurrencée par ces autres mécanismes juridiques, et on peut s'interroger sur l'utilité de son maintien dans le droit civil moderne. La novation objective, seule examinée ici, qui opère un changement de dette entre les mêmes parties, paraît plus utile, et elle correspond à des situations fréquentes en pratique. Néanmoins, on peut se demander s'il est vraiment utile de la conserver comme un concept autonome, alors que l'article 1134 du Code civil suffirait peut-être à justifier l'effet extinctif des conventions par lesquelles les parties remplacent une obligation par une autre[2064]. Il est notable que de nombreux Codes modernes ont abandonné la novation, de même que la plupart des textes internationaux et projets européens à la seule exception du Code Gandolfi[2065].

On examinera successivement les conditions (**§ 1**) et les effets (**§ 2**) de la novation objective.

§ 1. Conditions

921. Modification de l'obligation. Il va de soi qu'on ne peut parler de novation que si les parties introduisent dans leur rapport un élément nouveau, traditionnellement désigné sous la forme latine « *aliquid novi* ». Mais toute modification du rapport d'obligation n'est pas une novation. Selon une jurisprudence constante, on ne peut parler de novation que si la modification touche un élément essentiel du contrat. C'est, par principe, le cas lorsqu'il y a changement de débiteur ou de créancier. C'est beaucoup moins évident en cas de modification du contenu de l'obligation. On pourra considérer qu'il y a novation, par exemple, si la modification affecte la cause de l'obligation (un vendeur et un acheteur conviennent que le prix de vente sera conservé momentanément par l'acheteur à titre de prêt), ou son objet (les parties conviennent que le bien à livrer sera remplacé par un bien de nature différente). En revanche, on considère, de manière générale, que la modification des modalités de paiement du prix,

[2064] Dans ce sens VAN OMMESLAGHE, vol. 3, n° 1592.
[2065] Article 130, qui ne concerne que la novation « objective ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la réduction de son montant, la simple augmentation du montant d'une ligne de crédit[2066], la prorogation du terme[2067], l'adjonction d'une clause d'indexation, la stipulation d'une nouvelle sûreté au profit du créancier[2068], etc. pour ne prendre que quelques exemples, ne sont pas des modifications suffisantes pour opérer une novation, du moins à défaut d'une volonté contraire explicite[2069]. Il faut, dit la Cour d'appel, que « la modification apportée à l'obligation affecte sa structure fondamentale. En cas de changement mineur, il n'y a pas de novation »[2070]. Il est impossible de donner un critère rigide permettant de tracer à coup sûr la frontière entre la novation et les modifications non novatoires, car les juges vont apprécier au cas par cas, en combinant des éléments objectifs (l'importance des modifications) et un élément subjectif (la volonté des parties).

922. Volonté de nover. La volonté de nover, appelée traditionnellement « *animus novandi* », est sans doute l'élément central de la novation. Dans le cas d'une novation par changement de créancier ou de débiteur, il faudra un accord tripartite, car cette opération, qui modifie le sort du débiteur ou du créancier originaires, ne peut s'opérer sans leur concours[2071]. La novation par changement de dette, ne suppose, elle, que le consentement des deux parties. L'article 1273 du Code civil (repris quasi-textuellement par le nouvel article 1330 du Code civil français et en substance par l'article 5.245 du Code civil belge) se contente ici d'affirmer que « la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ». Cette formule ne signifie pas que la volonté de nover doit être expresse. Elle sera même le plus souvent tacite[2072]. En fait, il est assez rare que les parties, au moment où elles procèdent à la modification de leur contrat, aient une claire conscience qu'elles procèdent à une novation, et encore plus rare qu'elles disent expressément qu'elles le font. C'est le plus souvent *a posteriori*, que l'une des parties ou un tiers, pour échapper aux conséquences de l'obligation initiale, viendra dire qu'il y a eu novation. Il appartiendra alors au juge, en fonction de l'importance des changements apportés, de

2066 Cour d'appel, 8 juin 2022, n° CAL-2018-00848.

2067 Même arrêt.

2068 Cour d'appel, 19 juin 1934, *Pas.*, 13, p. 572.

2069 Pour un état détaillé de la jurisprudence française sur la question : TERRÉ, SIMLER, LEQUETTE 2013, n°s 1428 et s.

2070 Cour d'appel, 24 janvier 2023, n° CAL-2022-00198.

2071 Voy. *infra*, n°s 1041 et 1052.

2072 Cour d'appel, 24 janvier 2023, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

dire s'il y avait ou non intention de nover. Le Code Gandolfi – le seul projet européen qui réglemente le mécanisme – présume la volonté de nover chaque fois qu'il y a « incompatibilité objective du premier contrat par rapport au second » ; ce n'est qu'à défaut qu'il faut une volonté non équivoque, sachant qu'en cas de doute, on considérera qu'il n'y a pas eu novation [art. 131 (3) et (4)]. La même idée se trouve développée dans un arrêt récent de la Cour d'appel, qui développe de longues et intéressantes considérations sur la volonté de nover. Pour la Cour, « le seul constat de modifications importantes n'autorise pas à conclure à l'existence d'une novation, en l'absence de manifestation d'une intention novatoire », de sorte que « en cas de doute sur l'intention des parties, la novation doit être refoulée au profit d'une simple modification ou même d'une addition des engagements successifs ». Et si « une attitude purement passive, une simple abstention, en particulier, sera, en principe, jugée impuissante à caractériser l'intention de nover, car équivoque… », cette intention peut être déduite de multiples indices et notamment d'une « d'une incompatibilité de la seconde obligation avec la première »[2073].

923. Validité des obligations. Bien que la loi soit muette sur ce point, on considère traditionnellement que la novation ne peut s'opérer que si les deux obligations – l'ancienne, qui est éteinte, et la nouvelle, qui s'y substitue – sont l'une et l'autre valables. Cette exigence est affirmée clairement par le nouvel article 1331 français : « La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables » Si l'obligation ancienne est nulle, la novation peut être considérée comme dépourvue de cause : il n'y a rien à éteindre[2074]. Le nouveau texte français réserve cependant le cas où la novation a eu « pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice ». La novation apparaît ici comme une des techniques de régularisation de l'acte nul. Si, en revanche, c'est l'obligation nouvelle qui est nulle cette nullité fait disparaître la raison d'être de la novation, et fait revivre l'obligation ancienne[2075].

[2073] Cour d'appel, 24 janvier 2023, préc.
[2074] Cass. fr. (1re civ.), 7 novembre 1995, n° 92-16695.
[2075] Cass. fr. (comm.), 4 février 1992, n° 90-12609.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§2. Effets

924. Extinction de l'obligation. La novation a pour effet de faire disparaître, pour l'avenir, l'obligation ancienne, par la création d'une obligation nouvelle qui ne présente pas nécessairement les mêmes caractères. Il en résulte, d'abord, que le débiteur de l'obligation nouvelle ne peut plus opposer les exceptions, les moyens de défense qu'il aurait pu tirer de l'ancienne obligation (sauf bien sûr la nullité du contrat originaire, qui, on vient de le voir, fait en principe tomber la novation elle-même). Cette conséquence est surtout importante dans les novations par changement de créancier ou de débiteur, qui se distinguent à cet égard fondamentalement des mécanismes de transmission des obligations[2076]. Ensuite, l'effet extinctif a pour conséquence, très importante en pratique, la disparition des accessoires de la dette principale, et notamment des sûretés qui l'assortissaient[2077]. Cette extinction joue en particulier lorsque la dette est garantie par un cautionnement : la caution est libérée par l'effet de la novation. En pratique, du reste, c'est très souvent la caution qui cherchera à faire juger qu'il y a eu novation entre le créancier et le débiteur principal pour échapper à son engagement[2078]. Cependant, les parties à la novation peuvent convenir expressément de reporter sur la nouvelle dette les sûretés qui assortissaient l'ancienne (C. civ., art. 1278, C. civ. fr., art. 1334, C. civ. be., art. 5.247). Si la dette est garantie par l'engagement d'un tiers (caution ou codébiteur solidaire), le consentement de celui-ci est requis.

925. Novation du contrat ? Présentée par les rédacteurs du Code civil comme une cause d'extinction de « l'obligation », la novation opère bien comme cela lorsqu'elle résulte d'un changement de débiteur ou de créancier. En revanche, lorsqu'elle s'opère entre les parties par une modification substantielle du contenu de l'obligation, il semble que, lorsque l'obligation est d'origine contractuelle, elle affecte, de manière plus globale, le contrat lui-même. Comme l'observe justement P. Van Ommeslaghe, « en pratique, on parle souvent d'une novation alors qu'un contrat est substitué à un autre »[2079]. C'est même, semble-t-il ce qui se passe dans l'immense majorité des cas : lorsque la novation par changement d'objet est reconnue, c'est parce que la modification apportée est suffisamment importante (par exemple, un changement de prix, le remplacement de la chose à livrer par une autre, etc.) ; or, si tel est le cas, c'est l'économie du contrat qui se trouve bouleversée. De même, si on prend l'exemple caractéristique de la novation par changement de cause – l'acquéreur qui conserve le prix à titre d'emprunteur – on voit bien qu'il s'agit là du remplacement d'un contrat

[2076] Voy. *infra*, n°s 995 et s.
[2077] Trib. Luxembourg, 31 mars 1928, *Pas.*, 12, p. 438.
[2078] Voy. p. ex. Cour d'appel, 8 juin 2022, préc.
[2079] VAN OMMESLAGHE, vol. 3, n° 1591.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

par un autre, auquel on va appliquer des règles substantiellement différentes de celles du contrat originaire. Sans doute serait-il plus logique, si on veut vraiment maintenir la novation dans le Code civil, d'en reconsidérer fondamentalement le régime, en distinguant nettement la novation objective – qui n'est, selon nous, qu'une forme de modification du contrat lui-même – des novations par changement de débiteur et de créancier, qu'il conviendrait – comme le fait désormais le Code civil français – de rapprocher des autres formes de circulation des obligations (cession de créance, subrogation, reprise de dette).

SOUS-SECTION 2. LA REMISE DE DETTE

926. Remise volontaire ou imposée. Il arrive que le créancier, pour des raisons variables, accepte de décharger son débiteur de tout ou partie de sa dette (**§ 1**). Mais, dans le droit contemporain, on rencontre aussi certains cas de remise de dette imposée (**§ 2**).

§1. Remise de dette volontaire

927. Convention ou acte unilatéral ? La remise de dette peut être conçue de deux manières, soit comme un acte unilatéral de renonciation du créancier à sa créance, soit comme une convention entre le créancier et son débiteur. C'est cette seconde conception qui a prévalu dans le Code civil, qui n'envisage, à l'article 1287, que « la remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur », et, aujourd'hui encore, dans la doctrine française, il est couramment admis que seul un accord entre le créancier et le débiteur peut décharger ce dernier, au motif que l'obligation est un lien entre deux personnes[2080]. Le nouvel article 1350 du Code civil français maintient ce point de vue, en définissant la remise de dette comme « le contrat[2081] par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation ». La doctrine belge, plus ouverte que la doctrine française aux actes unilatéraux, admettait plus facilement avant la réforme qu'on puisse renoncer unilatéralement à un droit de créance[2082], et cette opinion s'est traduite dans le nouveau code belge : même si l'article 5. 250 donne de la remise de dette la même définition qu'en France, l'article 5. 253 admet, en parallèle, que « Le créancier peut, par sa seule volonté, renoncer à son droit de créance ».

[2080] FLOUR, AUBERT, SAVAUX, vol. 3, n° 473.

[2081] Sur le plan terminologique, dans le droit actuel, si on veut être parfaitement rigoureux, il vaut mieux dire que la remise de dette est une convention, plutôt qu'un contrat, puisqu'elle ne fait pas naître d'obligations, tout au contraire (sur la distinction, voy. *supra*, n° 55). Mais dans le nouveau droit français, la remise de dette est bien un contrat puisqu'elle a pour effet d'éteindre une obligation.

[2082] VAN OMMESLAGHE, vol. 3, n°s 1601 et 1613.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Cette opinion a migré au Luxembourg[2083]. Un jugement du tribunal de Luxembourg considère ainsi que la renonciation d'une partie à demander à son débiteur les accessoires de la dette, formulée dans ses conclusions, vaut remise de dette au sens de l'article 1282[2084]. Le débat, riche en arrière-plans théoriques[2085], n'a cependant qu'un intérêt pratique limité, car, même si on admet que la remise de dette est une convention, l'acceptation du débiteur peut être tacite, et même résulter de son simple silence, dès lors que la remise est faite dans son intérêt exclusif.

928. Conditions. Du point de vue de ses conditions, la remise de dette obéit aux conditions générales de validité des contrats. Lorsqu'elle est consentie par intention libérale envers le débiteur, elle obéit en outre aux conditions de fond des donations (notamment, quant à la capacité de disposer), et elle en produira d'ailleurs les effets (notamment, du point de vue du rapport et de la réduction des libéralités). Mais, curieusement, on a toujours considéré qu'elle n'était pas soumise aux conditions de forme des donations, ce qui supposerait la passation d'un acte authentique[2086]. Une jurisprudence luxembourgeoise ancienne mais jamais démentie est en ce sens[2087].

929. Effets. Du point de vue de ses effets, la remise de dette a un effet extinctif, qui se traduit notamment par la disparition des sûretés qui assortissaient la dette. En particulier, selon l'article 1285, elle entraîne la libération des codébiteurs solidaires. Il n'en va autrement que si le créancier a réservé ses droits contre ceux-ci, auquel cas ils ne sont tenus que déduction faite de la part de celui qui la remise a été faite[2088] – cette dernière solution devenant le principe dans le nouveau droit français (C. civ. fr., art. 1350-1). La remise de dette accordée au débiteur principal libère également les cautions qui garantissaient la dette (C. civ., art. 1287, C. civ. fr., art. 1350-2, C. Civ. be., art. 5.251). On s'est demandé si cette libération des coobligés s'appliquait aussi lorsque le créancier n'avait consenti à la remise de dette que de manière plus ou moins contrainte,

2083 POELMANS, n° 540.

2084 Trib. Luxembourg, 28 octobre 2022, n° 183291.

2085 Voy. l'exposé du débat par VAN OMMESLAGHE, vol. 3, n° 1613.

2086 Voy. en ce sens pour la France : FLOUR, AUBERT, SAVAUX, vol. 3 2015, n° 494 ; pour la Belgique : VAN OMMESLAGHE, vol. 3, n° 1603.

2087 Trib. Diekirch, 10 novembre 1881, *Pas.*, 2, p. 306.

2088 Pour une application, voy. Cour d'appel, 2 avril 2003, n° 24175.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

dans le cadre d'un plan de règlement des difficultés du débiteur (concordat en cas de faillite, plan conventionnel de traitement du surendettement). Cette question, qui a suscité ces dernières années en France une évolution jurisprudentielle et législative chaotique, avait donné lieu au Luxembourg en 1971 à un arrêt très net de la Cour d'appel, pour qui « D'après l'article 1287 du Code civil, la remise de dette, consentie par le créancier au débiteur principal, libère les cautions ; si même une telle remise n'est consentie que sous la pression des circonstances, elle conserve en droit le caractère d'une remise volontaire et libère, en même temps que le débiteur principal, les cautions de celui-ci. Il n'en serait autrement que si la caution avait concouru à la remise accordée par le créancier au débiteur principal et consenti à rester engagée en vertu de son cautionnement »[2089]. La solution a été depuis expressément consacrée en matière de surendettement des particuliers par l'article 41 de la loi du 8 janvier 2013, selon lequel « les remises de dettes sur le principal ou sur les accessoires, les mesures de rééchelonnement du crédit, la réduction du taux d'intérêt consenties dans le cadre d'un plan ou accordées par un jugement dans le cadre de la présente loi au profit du débiteur surendetté bénéficient également aux cautions ayant garanti l'engagement du débiteur surendetté ainsi qu'aux coobligés et codébiteurs du débiteur surendetté ».

930. Preuve de la remise de dette. C'est au débiteur qui prétend avoir été libéré par son créancier de prouver que celui-ci lui a fait remise de sa dette. Cette preuve peut se faire par tous moyens. Cependant, un des moyens de preuve privilégiés sera le fait que le créancier a remis à son débiteur le titre représentatif de la créance. Bien que cette remise de titre puisse s'expliquer par une autre raison que la remise de dette, et notamment – le plus souvent – par le paiement effectué par le débiteur, les rédacteurs du Code civil en ont réglementé les effets à propos de la remise de dette. Les articles 1282 et 1283 du Code civil établissent à cet égard une présomption de libération du débiteur liée à la remise du titre, qu'il s'agisse de l'original de l'acte sous seing privé (C. civ., art. 1282) ou de la grosse de l'acte authentique (C. civ., art. 1283). La présomption est irréfragable dans le premier cas, simple dans le second. Ces présomptions ont disparu en France et en Belgique.

[2089] Cour d'appel, 27 octobre 1971, *Pas.*, 22, p. 49.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§2. Remise de dette imposée

931. Plans de traitement des difficultés du débiteur. Des remises (partielles) de dette sont souvent consenties volontairement par les créanciers pour permettre à leur débiteur de faire face à des difficultés financières. Dans le même contexte, il arrive que des remises de dette soient imposées aux créanciers. C'est le cas, depuis la loi du 8 janvier 2013, dans le contexte des procédures de traitement du surendettement des particuliers. Dans le cadre de ces procédures, en cas d'échec du plan conventionnel de redressement, le juge rend un jugement dans lequel il arrête un plan de redressement judiciaire qui peut comporter, outre le sursis au paiement de tout ou partie des dettes, la réduction du taux d'intérêt, mais aussi la remise de la dette sur les accessoires. Surtout, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, il peut bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, qui, après saisie et vente de ses biens, peut déboucher sur un effacement de toutes ses dettes non professionnelles. Cet effacement, tout comme les remises volontaires, bénéficie aux cautions du débiteur et à ses codébiteurs solidaires, puisque l'article 41 (2) de la loi vise aussi bien les mesures « accordées par jugement » que celles qui ont été « consenties ». Un tel effacement des dettes est également possible, depuis la loi du 7 août 2023, dans le cadre des procédures de faillite : aux termes de l'article 536-3 du Code de commerce, « le failli personne physique peut être déchargé par le tribunal du solde des créances nées antérieurement au jugement déclaratif de faillite… à l'exception des créances visées par l'article 2101, paragraphe 1er, point 4°, du Code civil » (créances de salaires). Cependant, à la différence de ce qui se passe dans le cadre d'une procédure de traitement du surendettement des particuliers, cet effacement ne profite ni aux codébiteurs ni aux constituants de sûretés personnelles, qui peuvent cependant demander une décharge personnelle si leur obligation est manifestement disproportionnée à ses facultés de remboursement (C. comm., art. 536-4).

SOUS-SECTION 3. LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE (ÉTUDE SOMMAIRE)

932. Notion. Dans tous les droits, l'écoulement du temps produit des effets sur les situations juridiques. Le temps qui passe peut faire acquérir des droits : ainsi, au Luxembourg, celui qui a, pendant trente ans, eu la possession d'un bien immobilier peut en devenir

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

propriétaire. C'est ce qu'on appelle la prescription acquisitive (ou usucapion). À l'inverse, celui qui, pendant trente ans, n'exerce pas un droit dont il est titulaire – et, en particulier, un droit de créance – cessera de pouvoir l'exercer, comme s'il était éteint : c'est ce qu'on appelle la prescription extinctive, dont il est question ici, au titre des causes d'extinction des obligations. Le mécanisme de la prescription n'est pas spécifique aux obligations conventionnelles, ni même aux obligations, car il s'applique en principe d'une manière générale à tous les droits subjectifs quelle qu'en soit l'objet et la nature. Son étude détaillée dépasse de très loin le cadre d'un manuel de droit des contrats, et c'est pourquoi nous n'en ferons ici qu'une étude sommaire[2090].

La prescription extinctive n'est pas le seul mécanisme qui a pour effet de bloquer l'exercice des prérogatives du titulaire d'un droit. Les délais de prescription doivent, d'abord, être distingués des *délais de procédure*, qui déterminent à quel moment doivent être accomplis les actes de procédure au cours d'un procès (délai pour déposer des conclusions, délai pour opérer une notification, délai pour exercer une voie de recours). Ces délais n'ont pas pour conséquence l'extinction du droit du créancier, leur non-respect peut simplement avoir pour effet d'empêcher la continuation du procès, qui pourra éventuellement être recommencé (sauf si ce non-respect a fait acquérir autorité de chose jugée à une décision). Il est plus difficile de distinguer les délais de prescription proprement dits des *délais de forclusion* (ou de déchéance), qui font, comme la prescription, perdre un droit non exercé dans un certain temps, mais de manière plus radicale que la prescription : en particulier ces délais, généralement très courts, courent sans pouvoir être interrompus ou suspendus par les événements qui arrêtent le cours de la prescription[2091] – ce pourquoi on les appelle aussi délais préfix. Il n'existe pas de critère décisif de distinction des deux catégories de délais, et la distinction ne peut se faire qu'au cas par cas[2092]. On peut s'interroger sur l'intérêt de maintenir cette distinction.

933. Fondement. Pourquoi les droits s'éteignent-ils par prescription ? De prime abord, rien ne paraît plus injuste : en quoi le fait que trente ans se soient écoulés depuis qu'une personne est devenue débitrice justifie-t-il qu'elle soit libérée de sa dette ? Cela peut paraître choquant, surtout dans le cadre des obligations nées d'un contrat, où la prescription paraît contraire au principe de la force obligatoire et au respect de la parole donnée qui, dans les pays du Code civil,

2090 Sur l'ensemble de la matière, voy. *Annales du droit luxembourgeois*, 2024, vol. 32 – 2022 pp. 13-188. Voy. aussi S. MENÉTREY, « La nature de la prescription », *Annales du droit luxembourgeois*, 2020, vol. 29 – 2019, pp. 45 et s. et T. HOSCHEIT, « Point de départ et computation de la prescription », *Annales du droit luxembourgeois*, 2020, vol. 29 – 2019, pp. 81 et s.

2091 Voy. *infra*, n°s 947 et s.

2092 Voy. p. ex. la qualification de délai de forclusion retenue pour le délai de deux ans suivant la naissance de l'enfant pour agir en recherche de paternité : Cour d'appel, 5 juillet 2006, *Pas.*, 33, p. 274.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

en constitue le fondement moral le plus évident. Cependant, si tous les systèmes juridiques connaissent la prescription, c'est sans doute que cette institution répond à de puissantes considérations d'organisation sociale. Plusieurs explications sont généralement avancées, et, si aucune n'est à elle seule déterminante, elles se combinent pour justifier le mécanisme. Du point de vue de la relation individuelle entre le créancier et le débiteur (ou, d'une manière plus générale, entre le titulaire du droit prescrit et ceux à qui il est opposable), on peut d'abord considérer que, dans un certain nombre de cas, si le créancier n'a pas exercé son droit pendant une longue période, c'est parce qu'il y a renoncé. Même si ce n'est pas le cas, on peut vouloir sanctionner le créancier négligent, qui n'a pas correctement géré ses affaires, alors surtout que, du côté du débiteur, l'exercice tardif du droit présente de sérieux inconvénients : le débiteur que son créancier a « laissé tranquille » pendant très longtemps, a pu se croire déchargé, et il a pu dépenser l'argent nécessaire à l'acquittement de son obligation. La demande d'exécution tardive risque de le placer dans une situation financière difficile, surtout lorsque la dette était une dette périodique (le paiement de loyers, par exemple) qui s'est accumulée au cours du temps. Dans un certain nombre de cas, en outre, le fait que le créancier n'ait pas réclamé son dû pendant une longue période s'explique tout simplement parce qu'il a déjà été payé : la prescription reposera alors sur une présomption de paiement. À ces considérations tirées de la relation individuelle entre les parties, s'ajoutent de puissantes considérations d'intérêt général, qui valent du reste pour toutes sortes de prescriptions (y compris en matière pénale), et pas seulement pour la prescription extinctive du droit privé. L'objectif premier de la prescription, ou du moins de certaines d'entre elles, est de « ne pas réveiller le chat qui dort » – ou, selon une formule latine « *quieta non movere* » : au bout d'un certain temps, lorsque les choses se sont calmées, lorsqu'aucune discussion n'a eu lieu sur une question, il y aurait plus de trouble social à revenir dessus, à faire un procès, qu'à laisser la question irrésolue, et, peut-être, à laisser un droit sans sanction. Au fond, la prescription montre que, comme Goethe, le système juridique aime mieux l'injustice que le désordre[2093]. Du reste, il n'est pas sûr que revenir longtemps après sur une affaire ancienne soit le meilleur moyen de parvenir à une solution juste : lorsque trop de temps s'est écoulé, il y a un risque de dépérissement des preuves

[2093] « Je suis ainsi fait, j'aime mieux commettre une injustice que de souffrir le désordre » (GOETHE, « Siège de Mayence », in *Annales*, 1822).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

(les papiers ont été perdus, les témoins sont morts, les protagonistes ne se souviennent plus exactement eux-mêmes) qui rendront très difficile la recherche de la vérité.

Ces différentes considérations s'entremêlent pour justifier la prescription, elles sont les unes et les autres plus ou moins puissantes selon les différents cas de prescription. Ce sont les considérations sociales qui justifient tout particulièrement les longues prescriptions, tandis que le souci de protection du débiteur justifie une prescription raccourcie pour les dettes périodiques, et que certaines prescriptions très courtes s'expliquent principalement par des présomptions de paiement.

934. Nature de la prescription. On peut avoir deux conceptions de la prescription, du point de vue de la manière dont le mécanisme agit sur le droit du créancier. Dans une première conception, dite substantielle, la prescription agit sur le droit lui-même, dont elle provoque l'extinction. Dans une seconde conception, dite procédurale, le droit prescrit n'est pas éteint, mais c'est seulement l'exercice de l'action qui permet de le défendre ou d'en demander l'exécution qui est dénié au créancier : le créancier est toujours créancier, mais il ne peut plus agir en justice pour le faire reconnaître. Les différents systèmes juridiques se partagent entre ces deux conceptions, entre lesquelles les rédacteurs du Code civil ne semblent pas avoir tranché. D'un côté, la prescription est présentée explicitement comme une cause d'extinction des obligations tant par l'article 1234 du Code civil (qui la fait figurer dans la liste des causes par lesquelles les obligations s'éteignent) que par l'article 2219 du Code civil qui la définit comme un moyen « de se libérer par un certain laps de temps ». Mais d'un autre côté, certaines solutions semblent mieux s'expliquer par l'approche procédurale de l'institution : ainsi la solution traditionnelle selon laquelle le paiement d'une dette prescrite n'est pas un paiement indu, ou la règle, déjà rencontrée en matière de nullités, selon laquelle, même lorsque l'action en nullité est prescrite, le contractant peut toujours soulever la nullité par voie d'exception.

935. Sources. Mécanisme d'application générale, qui dépasse très largement le droit des obligations, la prescription n'est pas régie dans le Code civil au sein du Titre III du Livre III relatif aux obligations conventionnelles. Elle fait l'objet d'un titre distinct, qui constitue le dernier du Code (Titre XX du Livre III), intitulé De la prescription et de la possession (C. civ., art. 2219 à 2281). Ce titre est

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

commun à la prescription extinctive et à la prescription acquisitive, qui sont certes des mécanismes très différents, mais qui présentent un certain nombre d'éléments communs.

Ces textes sont, pour leur plus grande part, les textes d'origine du Code, qui n'ont été que très peu modifiés. De ce point de vue, le Luxembourg se distingue des deux autres pays du Code civil qui ont, dans la période récente, réformé leur droit de la prescription, dans le cadre d'un mouvement assez général en Europe : la France a opéré une réforme d'ensemble en 2008, la Belgique a fait des réformes partielles en 1976 puis en 1998, en attendant une nouvelle réforme dans le cadre de la refonte générale du Code civil. La prescription est donc, aujourd'hui, un des aspects du droit des obligations où le droit luxembourgeois est le plus en décalage avec les droits français et belge. Tout comme le droit des contrats, le droit luxembourgeois de la prescription fait actuellement l'objet d'un processus de réforme dans le cadre d'un partenariat entre le Ministère de la justice et l'Université du Luxembourg. L'avant-projet élaboré par le groupe de travail a été transmis à la Ministre en septembre 2024. En attendant les résultats de ce processus, la doctrine et la jurisprudence françaises demeurent cependant, dans une certaine mesure, utilisables comme modèles au Luxembourg, parce que les structures de base et les concepts généraux de la matière restent les mêmes.

Le Code civil n'est par ailleurs pas la seule source de la matière. Il est complété par de très nombreux textes spéciaux qui édictent des prescriptions particulières pour tel ou tel contrat, pour telle ou telle action. La multiplication des délais est du reste une des grandes sources de complexité de la matière.

On étudiera successivement les conditions (**§ 1**) et les effets (**§ 2**) de la prescription.

§1. Les conditions de la prescription

936. Questions. Pour savoir si la prescription est acquise, il faut d'abord rechercher, dans la loi ou dans la convention des parties, quelle était la durée de la prescription (**A**). Il faut ensuite se demander si cette durée s'est bien écoulée (**B**).

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

A) *La durée de la prescription*

937. Durée fixée par la loi. C'est la loi qui fixe en principe, pour les différentes catégories de créances, le délai de prescription. Il arrive cependant fréquemment que les parties fixent elles-mêmes dans leur convention une durée différente. Dans le droit actuel, ces clauses sont nulles si elles prétendent allonger la durée prévue par la loi : l'article 2220 du Code civil dispose en effet que « on ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise ». La règle marque bien les considérations d'ordre public qui s'attachent à la prescription. Rien n'interdit en revanche, par principe, de stipuler un délai de prescription plus court que celui prévu par la loi. Cependant ces clauses, lorsqu'elles touchent le droit de mettre en œuvre une sanction de l'inexécution contractuelle, agissent à la manière d'une clause limitative de responsabilité. Elles devraient donc être soumises au régime général de ces clauses[2094], et, en particulier, tomber sous le coup de la législation sur les clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs. En toute hypothèse, ces clauses, selon la Cour de cassation, ne sont valables que si elles ne privent pas en fait le créancier de toute possibilité d'agir utilement[2095]. Lors de la réforme française de 2008, on a abandonné la distinction entre les clauses qui allongent et les clauses qui raccourcissent le délai. L'article 2254 du Code civil français dispose désormais que « [l]a durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans » (dans un système où le délai de droit commun de la prescription est désormais de cinq ans).

En l'absence de clause, il existe un délai de droit commun (**1**), mais aussi de très nombreux délais spéciaux (**2**).

1) *Droit commun*

938. Distinction entre le droit civil et le droit commercial. Au Luxembourg, le délai de prescription extinctive de droit commun est toujours de trente ans en matière civile (C. civ., art. 2262), et de dix ans en matière commerciale (C. comm., art. 189). Ces délais sont exceptionnellement longs si on les compare à ceux qui sont admis dans les pays voisins, où les réformes récentes se sont toutes

[2094] Voy. *supra*, n[os] 853 et s.
[2095] Cass., 17 décembre 2009, *Pas.*, 35, p. 123.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

traduites par un raccourcissement considérable des délais de prescription : ainsi, le délai de prescription en matière civile est désormais de dix ans en Belgique (C. civ. be, art. 2262*bis*), de cinq ans en France (C. civ. fr, art. 2224), et seulement de trois ans en Allemagne ! On peut penser que le raccourcissement du délai de droit commun sera un des points principaux de la réforme actuellement entreprise.

Le délai de dix ans de la prescription commerciale ne s'applique pas seulement aux obligations entre commerçants, mais aussi, selon l'article 189 du Code de commerce, aux obligations entre commerçants et non-commerçants – c'est-à-dire aux actes mixtes – peu important que l'obligation elle-même ait ou non la nature commerciale, et peu important la source (contractuelle ou non) de cette obligation. Dans les relations entre commerçants et non-commerçants, le délai de dix ans joue tout aussi bien pour faire obstacle à l'action du non-commerçant contre le commerçant que l'inverse[2096].

2) *Prescriptions particulières*

939. Durées variables. Il existe en droit luxembourgeois une multitude de délais spéciaux, de durée très variable, dont on ne peut donner ici que quelques exemples. Ainsi se prescrivent par dix ans les actions en responsabilité contre les architectes et entrepreneurs et certains vendeurs d'immeubles à construire pour les dommages touchant les gros ouvrages (C. civ., art. 2270)[2097] ; par cinq ans l'action en nullité relative d'un contrat (C. civ., art. 1304), l'action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les actions des mineurs contre le tuteur relativement aux faits de tutelle (C. civ., art. 475) ; par trois ans l'action en paiement des salaires (C. civ., art. 2277, al. 1er), l'action en réparation d'un dommage causé par un produit défectueux (L. 21 avril 1989, art. 7), les actions dérivant d'un contrat d'assurance (L. 21 juillet 1997, art. 44) ; par deux ans l'action en rescision pour lésion de l'article 1674 du Code civil et par un an celle de l'article 1118 du Code civil ; par un an encore l'action en garantie des vices cachés (C. civ., art. 1648), etc.

2096 Cour d'appel, 29 avril 2009, *Pas.*, 34, p. 468.

2097 La règle ne fait pas double emploi avec la prescription de dix ans des actions contre le commerçant, car le délai de dix ans de l'article 2270 est à la fois un délai de prescription, et une durée maximum de l'obligation de garantie de l'entrepreneur (garantie décennale) : ce délai court donc à compter de la réception des travaux, et non, comme c'est la règle en matière de prescription, à compter du jour où le créancier, s'étant aperçu des défauts, a eu la possibilité d'agir en justice.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Au sein de ce fatras, on mettra simplement à part deux types de prescriptions qui répondent à une logique particulière : la prescription quinquennale des créances périodiques, et les courtes prescriptions des articles 2271 à 2273 du Code civil.

940. Prescription des créances périodiques. L'article 2277 du Code civil soumet à une prescription de cinq ans un certain nombre d'actions en paiement de créances dont le point commun est d'être payables par échéances périodiques. Le texte donne une énumération de certaines de ces créances (les arrérages de rentes, les pensions alimentaires, les loyers et fermages, les intérêts des sommes prêtées). Mais cette énumération n'est pas limitative, car le texte s'applique plus généralement « à tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ». À l'origine, la prescription quinquennale visait aussi les salaires, mais la loi du 24 mai 1989 a ramené à trois ans la prescription en ce domaine (art. 2277, al. 1). Le délai de cinq ans pour les créances périodiques, qui est d'une importance pratique considérable, s'explique principalement par des considérations de protection du débiteur : il s'agit d'éviter l'accumulation d'arriérés qui, s'ils devaient être payés en une seule fois au-delà de cinq ans, représenteraient une charge considérable, alors que, payés de manière périodique, ils peuvent l'être avec les revenus réguliers du débiteur. Pour reprendre une formule ancienne de la Cour d'appel, l'article 2277 du Code civil « repose non seulement sur une présomption de négligence du créancier, mais encore, et principalement, sur un motif d'humanité, celui-ci touchant à l'ordre public et consistant dans la préoccupation du législateur d'empêcher la ruine des débiteurs gênés »[2098] La règle se retrouve en droit belge ; elle n'a plus de sens en droit français où désormais le délai de prescription de droit commun est de cinq ans, mais le particularisme des dettes périodiques continue d'apparaître à travers l'interdiction qui est faite, pour ces dettes, de prévoir un délai de prescription plus court.

L'article 2277 du Code civil a, au Luxembourg comme en France et en Belgique, suscité une jurisprudence abondante, notamment en ce qui concerne son domaine d'application. Il est acquis que la notion de dettes périodiques ne vise que « les dettes qui, ayant pour objet les produits ou revenus périodiques et s'augmentant d'elles-mêmes par l'effet du temps, sont susceptibles, par leur propre accumulation, de ruiner le débiteur » ; en conséquence, l'article 2277 du Code civil est « inapplicable à des annuités qui ne sont pas des prestations périodiques, mais autant de fractions

[2098] Cour d'appel, 25 juillet 1913, *Pas.*, 9, p. 167.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

d'un prix global, auquel avaient été assignés autant de termes »[2099]. La Cour d'appel semble par ailleurs considérer que la notion de périodicité implique que les sommes dues soient fixes, et prévues d'avance[2100] : ne sont donc pas soumises à la prescription quinquennale les sommes payables périodiquement, mais dont le montant est variable (les factures d'électricité, d'eau, de gaz, etc.). Il est également acquis que la règle ne s'applique pas aux dettes périodiques qui ont été capitalisées, par exemple aux intérêts ayant fait l'objet d'une capitalisation par le jeu de l'anatocisme, ou aux sommes dues périodiquement qui, à un moment, ont fait l'objet d'une reconnaissance de dette globale[2101]. Pour cette raison, l'article 2277 du Code civil est inapplicable aux intérêts du solde débiteur du compte courant, qui s'incorporent dans le solde à chaque arrêté de compte, de sorte qu'il devient impossible de distinguer les intérêts du capital[2102]. De même, si des dettes périodiques ont fait l'objet d'un paiement indu, qui a permis au créancier de les capitaliser, l'action en répétition de l'indu ouverte au débiteur se prescrit par trente ans et non par cinq ans[2103].

941. Courtes prescriptions des articles 2271 à 2273 du Code civil. Les articles 2271 à 2273 du Code civil édictent un certain nombre de prescriptions très courtes à l'encontre d'un certain nombre de fournisseurs de biens ou de services : six mois pour les « maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois » (l'étudiant qui donne des cours de rattrapage, le professeur de piano, etc.), ainsi que pour les « hôteliers et traiteurs » (entendez aussi restaurateurs) pour le logement et la nourriture, un an pour les huissiers pour le paiement de leurs actes, pour les « marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands »[2104], pour les « maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves ; et autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage », deux ans pour les « avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires »[2105]. Ces courtes prescriptions, qui doivent

[2099] Cour d'appel, 25 juillet 1913, préc.

[2100] Cour d'appel, 10 juin 1998, *Pas.*, 30, p. 487 ; Voy. plus récemment : Cour d'appel, 21 octobre 2021, n° CAL-2019-00332.

[2101] Cour d'appel, 17 octobre 1979, *Pas.*, 24, p. 402.

[2102] Cour d'appel, 11 juillet 2007, *BIJ*, 2007, p. 148 ; Cour d'appel, 22 juillet 2020, n° CAL-2018-00735 (la solution est généralement présentée comme une application de l'effet dit novatoire de l'entrée en compte des créances).

[2103] Cour d'appel, 6 janvier 1969, *Pas.*, 21, p. 92 ; Cour d'appel, 27 mai 2004, *Pas.*, 32, p. 544 ; Cour d'appel, 26 octobre 2023, n° CAL-2021-00812 (à propos de la prescription triennale des créances de salaire).

[2104] Le réparateur d'automobiles n'est pas un marchand au sens de l'article 2272 du Code civil, mais un entrepreneur, même lorsqu'il a fait accessoirement des fournitures de pièces de rechange (J.P. Luxembourg, 27 septembre 1979, *Pas.*, 24, p. 451). De même la courte prescription de l'article 2272 ne s'applique pas au paiement des fournitures faites par un entrepreneur dans le cadre de travaux de réparation, d'entretien ou d'aménagement : Cour d'appel, 30 novembre 2022, n° CAL-2022-00438.

[2105] Ce qui ne couvre pas le paiement des honoraires de consultation et de plaidoirie : Cour d'appel, 5 avril 2006, n° 30110 du rôle ; Cour d'appel, 2 mars 2023, n° CAL-2022-00425 ; Trib. Diekirch, 14 mai 2024, n° TAD-2020-00137.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

être interprétées de manière restrictive, reposent sur l'idée que ces professionnels, habituellement, demandent un paiement immédiat de leurs prestations. Dès lors, si au bout de six mois, un an ou deux ans (selon les cas), ils n'ont pas introduit d'action pour se faire payer, c'est probablement parce qu'ils l'ont déjà été. Cette idée de présomption de paiement[2106] explique le régime très particulier de ces courtes prescriptions. D'une part, selon l'article 2275 du Code civil, les professionnels à qui on oppose ces prescriptions peuvent tenter de prouver qu'ils n'ont pas été payés, en déférant le serment à leur client. La prescription abrégée ne joue pas davantage si le client avoue qu'il n'a pas payé, directement ou indirectement en niant la dette[2107]. D'autre part, si le professionnel agit en justice pendant le délai, ou si le débiteur reconnaît sa dette, ces actes – comme d'une manière générale pour toute prescription – ont pour effet d'interrompre la prescription, qui repart alors de zéro. Mais, dans le cas des courtes prescriptions des articles 2271 à 2273 du Code civil, il est traditionnellement admis que le délai qui repart n'est pas le court délai prévu par ces textes, mais le délai de droit commun : les actes accomplis font en effet tomber la présomption de paiement qui constitue la raison d'être de ces prescriptions, et il n'y a plus de raison de les faire jouer[2108]. C'est ce qu'on nomme l'interversion de la prescription[2109]. Ce mécanisme est propre aux courtes prescriptions présomptives allant de 5 mois à 5 ans, dont celles des articles 2271 et suivants du Code civil, il ne s'applique pas à la prescription quinquennale de l'article 2277 qui ne repose pas sur une présomption de paiement[2110].

B) *L'écoulement de la prescription*

942. Questions. Pour savoir si une créance est prescrite, il ne suffit pas de connaître la durée de la prescription qui lui est applicable. Il faut encore savoir si le créancier a ou non dépassé cette durée. Or ce n'est pas toujours si évident qu'on pourrait le croire, d'une part

2106 Cour d'appel, 16 mars 2011, *BIJ*, 2011, p. 13.

2107 Cour d'appel, 10 juin 1998, *Pas.*, 30, p. 402 ; Cass., 25 février 2016, n° 21/16 ; Cour d'appel, 2 mars 2023, n° CAL-2022-00425. Voy. déjà dans ce sens des décisions anciennes : Trib. Luxembourg, 5 janvier 1894, *Pas.*, 3, p. 250 ; Trib. Luxembourg, 5 mars 1902, *Pas.*, 4, p. 314.

2108 Cour d'appel, 17 octobre 1979, *Pas.*, 24, p. 402 ; Trib. Luxembourg, 14 décembre 2023, n° TAL-2023-00082.

2109 Ce mécanisme a été supprimé en droit français (C. civ. fr., art. 2231).

2110 Cass., 9 novembre 2006, n° 53/06 ; Trib. Luxembourg, 10 novembre 2022, n^{os} TAL-2021-03482 et TAL-2021-10242.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

parce qu'il faut savoir comment on compte le temps (1), à partir de quand (2) et parce qu'il faut tenir compte de certains événements qui affectent l'écoulement de la prescription (3).

1) *Le mode de calcul du délai*

943. ***Dies a quo* et *dies ad quem*.** Les articles 2260 et 2261 du Code civil posent deux règles de base pour la computation des délais, qui valent, d'une manière générale, pour toutes les prescriptions (acquisitives comme extinctives) et même, au-delà pour tous les délais. Le premier texte précise que le délai se compte par jour et non par heure. Il en résulte que les fractions de jours ne comptent pas, donc que le jour du point de départ (le *dies a quo*) n'est pas pris en compte : une prescription qui a commencé à courir à 17 heures un jour sera donc considérée comme ayant couru seulement à compter de 0 h le lendemain. Le second article pose que la prescription « n'est acquise que lorsque le dernier jour du terme est accompli » : ce dernier jour, le « *dies ad quem* » est donc compris dans la prescription. Le créancier gagne ainsi deux jours ! Si, par exemple, une dette de loyers est devenue exigible le 22 juin 2015, la prescription quinquennale ne commencera à courir que le 23 juin à 0 h ; le créancier aura alors jusqu'au 23 juin 2020 à minuit pour en demander le paiement.

2) *Le point de départ du délai*

944. **Naissance du droit ou naissance de l'action ?** D'une manière générale, les délais de prescription ne courent contre le créancier qu'à compter du jour où il peut agir contre son débiteur. C'est l'expression d'un principe ancien exprimé sous sa forme latine « *Contra non valentem agere non currit praescriptio* » (la prescription ne court pas contre celui qui ne peut pas valablement agir). On a déjà vu des applications de ce principe à propos de l'action en nullité : le délai de prescription d'une action en nullité relative pour vice du consentement, par exemple, ne court qu'à compter du jour où le contractant s'est aperçu de son erreur ou a cessé d'être sous l'emprise de la violence. S'agissant de l'exercice d'un droit de créance, cela signifie qu'en principe le délai de prescription ne court pas contre le créancier à compter du jour de la naissance de son droit (souvent difficile à déterminer du reste), mais seulement à compter de l'échéance du terme, moment où il peut demander l'exécution (C. civ., art. 2257)[2111]. De même, selon le même texte, si la créance est conditionnelle, la prescription ne peut pas courir avant la survenance de la condition. Mais la règle a une portée plus générale : par exemple la victime d'un dommage ne peut pas agir tant qu'elle ignore l'existence de ce dommage ; une personne victime d'une

[2111] Cour d'appel, 17 mai 2018, *Pas.*, 38, p. 915 ; Cour d'appel, 14 juin 2017, n° 43151 ; Cass., 16 décembre 2021, n° CAS-2020-00151.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

exposition à l'amiante ne peut agir en responsabilité qu'à compter du moment où elle saura qu'elle a été contaminée, et ce n'est donc qu'à compter de ce jour que la prescription pourra courir contre elle. Le nouvel article 2224 du Code civil français, issu de la réforme de 2008, dispose de manière générale que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », ce qui est une bonne manière de poser le principe. Les projets européens reprennent également la même idée[2112]. Ce point de départ « glissant » – qui est une contrepartie de la réduction du délai de prescription – suscite cependant des difficultés pratiques quant à sa mise en œuvre.

945. Exceptions. Dans un certain nombre de cas, la loi prévoit expressément qu'un délai de prescription d'une action contractuelle va courir à compter du jour du contrat, alors même que, dès ce jour, le contractant n'avait pas nécessairement la possibilité d'agir. Cela peut s'expliquer parce que le délai fixé a une double nature : il n'est pas seulement un délai de prescription, qui détermine le temps pendant lequel le créancier peut exercer son droit, il est aussi une règle de fond qui fixe l'étendue temporelle d'une obligation ou d'une responsabilité. C'est le cas, par exemple, du délai de garantie décennale des architectes et entrepreneurs de l'article 2270 du Code civil, qui est, d'abord, le temps pendant lequel l'entrepreneur est responsable des dommages affectant l'ouvrage, ou encore du délai de deux ans pendant lequel les biens de consommation sont garantis par les vendeurs (C. consomm., art. L. 212-6)[2113]. Dans d'autres cas, le point de départ au jour du contrat – et non au jour où le créancier a la possibilité d'agir – s'explique parce que le législateur a voulu enfermer dans un délai très bref une action de nature exceptionnelle. On est alors en présence, non d'un véritable délai de prescription, mais d'un délai de forclusion, ou préfix, indépendant de la possibilité effective d'agir. Tel est le cas des délais d'un an et deux ans posés par les articles 1118 et 1676 du Code civil en matière de rescision pour lésion.

[2112] Voy. p. ex. Code Gandolfi, art. 134 (2) ; PDEC, art. 14:203 et 14:301.

[2113] Ce délai est très différent du délai de droit commun de la garantie des vices cachés (C. civ., art. 1648), qui est également de deux ans, mais qui court à compter du moment où l'acheteur a dénoncé le vice à son vendeur. Le vendeur, en droit commun, est responsable sans limite de durée, mais l'acheteur a deux ans pour agir à compter de la révélation du vice. Dans le système de la garantie des biens de consommation, le vendeur n'est responsable que si le dommage se révèle dans les deux ans.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Dans le cadre des réformes récentes du droit de la prescription en droit comparé, les législateurs ont souvent complété le délai de prescription, qui court comme indiqué à compter du jour où le titulaire du droit a la possibilité d'agir, par un second délai qui court à compter de la naissance du droit. Il s'agit d'éviter que, par le jeu du report du point de départ du délai, ou par l'effet des événements qui allongent la durée de la prescription, l'extinction liée à la prescription ne soit indéfiniment retardée. On rencontre ainsi un tel délai-butoir en droit français où l'article 2232 du Code civil dispose que « le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ». Un tel système n'est pas connu de manière générale en droit luxembourgeois, mais on en connaît déjà une application particulière dans la législation (d'origine européenne) sur la responsabilité du fait des produits défectueux : l'article 7 de la loi du 21 avril 1989 dispose que « l´action en réparation prévue par la présente loi se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l´identité du producteur, sans préjudice des dispositions de droit commun réglementant la suspension ou l´interruption de la prescription » (c'est le délai de prescription), mais que, en outre « le droit à réparation conféré à la victime en application de la présente loi s´éteint à l´expiration d´un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit défectueux qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n´ait engagé une procédure judiciaire contre le producteur » (c'est le délai-butoir). D'une manière plus générale, on peut se demander si le délai de prescription de droit commun ne constitue pas un délai-butoir à l'égard des actions relevant de prescriptions plus courtes, mais qui ne seraient pas acquises par suite du report de leur point de départ ou d'interruptions ou de suspensions[2114]. On peut par exemple imaginer qu'une action en nullité relative, qui se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice n'ait pas encore été exercée trente ans après la conclusion du contrat parce que le dol n'aurait été découvert qu'après ce délai. Il serait alors raisonnable de la déclarer prescrite par application du délai de droit commun[2115].

3) *Les événements affectant l'écoulement du délai*

946. Distinction. Une prescription qui a commencé de courir peut s'arrêter par l'effet de certains événements. Il faut ici bien distinguer les événements qui provoquent l'interruption du cours de la prescription – c'est-à-dire qui font repartir le délai de zéro – et ceux qui entraînent seulement la suspension de ce délai – dont le cours reprendra, ensuite, au moment où il s'est arrêté.

D'une manière générale, ces événements n'ont aucun effet sur les délais dits de forclusion, qui courent, inéluctablement, jusqu'à leur terme sans pouvoir être interrompus ni suspendus.

[2114] Dans ce sens POELMANS, n° 565.

[2115] La Cour de cassation française en avait cependant décidé autrement dans un cas de nullité pour dol, à une époque où le délai-butoir de vingt ans n'existait pas encore : Cass. fr. (1re civ.), 11 septembre 2013, n° 12-20816, dans une hypothèse où le dol avait été découvert par les héritiers du contractants 28 ans après la conclusion du contrat.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

a. *L'interruption de la prescription*

947. Causes d'interruption. L'interruption de la prescription extinctive résulte de deux types d'événements très différents, qui, selon une formule de la Cour d'appel, « s'analysent en une situation qui contredit les fondements mêmes de la prescription, soit qu'il y ait réveil du titulaire jusque-là inactif, soit qu'il y ait de la part de celui qui avait commencé à prescrire reconnaissance des droits du titulaire »[2116].

La première cause d'interruption est due au créancier, qui prend l'initiative de poursuivre son débiteur, montrant ainsi qu'il n'est pas négligent, et qu'il a bien l'intention d'obtenir l'exécution. N'importe quel acte du créancier contre son débiteur n'a pas cet effet : il faut, plus précisément, une « citation en justice » (C. civ., art. 2244). Il ne suffirait pas, par exemple, que le créancier mette son débiteur en demeure pour que la prescription soit interrompue[2117]. Mais n'importe quelle citation en justice produit cet effet : l'article 2245 du Code civil précise qu'il peut s'agir d'une simple citation en conciliation devant le juge de paix (pourvu qu'elle soit suivie d'une assignation au fond dans les délais) et la jurisprudence a précisé qu'une assignation en référé tendant à obtenir une provision pouvait également suffire[2118], sauf à ce que, si la demande est rejetée, l'interruption soit considérée comme non avenue[2119] Pour la Cour d'appel « devant la diversification des modes d'introduction de l'instance, ce n'est pas seulement la citation en justice qui interrompt la prescription, mais tout acte signifié renfermant une prétention incompatible avec la prescription commencée »[2120]. La citation produit son effet interruptif même si elle est délivrée devant un tribunal qui se déclare ensuite incompétent (C. civ., art. 2246) ; en revanche, si l'assignation est annulée par suite d'un vice de forme, ou si la demande est rejetée, cette nullité ou ce rejet feront disparaître cet effet (C. civ., art. 2247).

L'autre événement qui entraîne l'interruption de la prescription est la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier : cela détruit un des fondements de la prescription, qui est la présomption

[2116] Cour d'appel, 7 octobre 2015, n° 41124.

[2117] Il n'en va plus de même en Belgique où, depuis une loi de 2013, la mise en demeure a, sous certaines conditions, un effet interruptif limité (C. civ. be., art. 2244, § 2).

[2118] Cour d'appel, 11 mars 1998, *Pas.*, 30, p. 449 ; Cour d'appel, 7 octobre 2015, préc.

[2119] Cour d'appel, 6 juin 2024, n° CAL-2023-00615.

[2120] Cour d'appel, 28 septembre 2006, *Pas.*, 33, p. 281.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

que le débiteur a déjà exécuté. Des discussions surgissent fréquemment devant les tribunaux pour savoir si le débiteur a véritablement reconnu son droit. Pour la Cour d'appel, « pour qu'un acte soit interruptif de la prescription, il doit clairement établir la volonté de son auteur, qui doit être particulièrement nette ». Ainsi, une correspondance imprécise ne peut fonder aucune interruption[2121], pas plus que le silence gardé par le prétendu débiteur à la réception d'un courriel[2122].

Des difficultés particulières surgissent lorsque l'obligation a plusieurs débiteurs solidaires, ou un débiteur et une caution. Les articles 2249 et 2250 du Code civil règlent les conséquences de l'assignation délivrée contre, ou de la reconnaissance faite par, l'un de ces codébiteurs (elle a effet contre les autres) ou le débiteur principal (elle produit son effet interruptif contre la caution).

948. Effets de l'interruption. L'interruption a pour effet, en quelque sorte, d'effacer le temps passé : le délai repart de zéro. En principe, le nouveau délai est de la même durée que l'ancien. Supposons, par exemple, une prescription de dix ans, qui a commencé à courir le 14 mai 2005. Elle aurait dû prendre fin le 15 mai 2015 à minuit. Mais le créancier avait, le 10 janvier 2015, assigné son débiteur en référé. Cette assignation a fait courir, à compter du 11 janvier à 0 h, un nouveau délai de dix ans. Le créancier a désormais jusqu'au 11 janvier 2025 pour assigner au fond. Cet allongement considérable trouve cependant une limite dans les droits qui admettent un délai butoir (et notamment en droit français, où les interruptions du délai ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée de prescription au-delà de vingt ans suivant la naissance de la dette).

Pour les courts délais des articles 2271 à 2273 du Code civil, le délai qui repart après l'interruption est le délai de droit commun. Cet effet d'interversion de la prescription se produit également lorsque, à la suite de la demande en justice, le créancier obtient la condamnation de son débiteur : sans que cela soit très facile à justifier, on considère que la créance constatée par le jugement se prescrit par trente ans à compter du prononcé de la décision[2123].

[2121] Cour d'appel, 6 décembre 2018, n° CAL-2018-00139.
[2122] Cour d'appel, 25 avril 2023, n° CAL-2022-00360.
[2123] Cour d'appel, 21 avril 2004, *BIJ*, 2004, p. 152.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

b. *La suspension de la prescription*

949. Notion. Il y a suspension lorsque surviennent, pendant le cours de la prescription, des événements qui empêchent le créancier d'agir contre son débiteur. Ces événements arrêtent temporairement le cours de la prescription : lorsque la situation qui a justifié la suspension prendra fin, la prescription recommencera à courir pour la durée qui restait au jour de la survenance de l'empêchement (sous réserve, là encore, de l'existence d'un délai-butoir). Il se peut que la situation qui justifie la suspension ait existé dès avant que la prescription ait commencé de courir : dans ce cas, la situation se traduira par un report du point de départ de la prescription. Les articles 2251 à 2259 du Code civil, qui règlent la question, mettent sur le même plan suspension et report du point de départ.

950. Causes de suspension. La loi énumère aux articles 2252 à 2259 du Code civil un certain nombre de cas dans lesquels le créancier est, en droit ou en fait, dans l'impossibilité d'agir contre son débiteur : c'est le cas lorsque le créancier est un incapable (mineur ou majeur protégé), ou lorsqu'un époux est débiteur de l'autre (ce qui, en fait, rend l'action en justice très difficile), ou lorsque le débiteur est décédé et que l'héritier a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire (de sorte qu'on ne sait pas s'il répondra ou non des dettes). Ces cas ont été conçus à l'origine comme limitatifs : l'article 2251 du Code civil, en disposant que « la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi » semble exclure toute suspension pour une autre cause non prévue. Les rédacteurs du Code civil, pour qui la prescription répondait à des considérations d'ordre public, voulaient empêcher que le jeu de la prescription ne soit trop facilement remis en cause par l'application de la maxime « *Contra non valentem agere* ». Cependant, ce principe général a ressurgi dans la jurisprudence des trois pays du Code civil. Cet appel à la notion de force majeure, qui donne au juge un large pouvoir d'appréciation pour relever un créancier de la prescription, est désormais consacré en droit français par l'article 2234 du Code civil, selon lequel « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». On retrouve la même idée dans certains projets européens[2124]. Au

[2124] Voy. p. ex. PDEC, art. 14:303 (suspension en cas d'empêchement échappant au créancier) ; DCFR, art. III-7:303.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Luxembourg, la Cour d'appel a posé en 1963, à propos de l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale, que « la prescription de l'action civile est suspendue au profit de la partie civile toutes les fois que l'exercice de l'action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure »[2125]. Et, dans un arrêt récent, la Cour de cassation vise explicitement le « principe général de droit *contra non valentem…* » pour casser un arrêt qui avait refusé d'admettre la suspension de la prescription d'une dette fiscale malgré le fait que le préposé du bureau d'imposition compétent avait accordé aux débiteurs un sursis à exécution des bulletins d'imposition ce qui constituait pour le receveur compétent un obstacle légal à toute mesure de recouvrement[2126]. En pratique, cependant, les cas où les tribunaux admettent effectivement qu'il y a eu impossibilité d'agir sont assez rares[2127]. Par ailleurs, l'impossibilité d'agir n'opère pas exactement de la même manière que les causes de suspension visées par la loi : la Cour d'appel juge que « la règle ne joue pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où l'empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription […] la prorogation accordée en raison de l'obstacle de force majeure n'ayant pas pour effet d'assurer au créancier un délai pour agir, dont la durée est nécessairement égale à celle qui restait à courir lorsque l'empêchement a surgi, mais de ne lui octroyer que le temps nécessaire et suffisant pour agir »[2128].

§ 2. Les effets de la prescription

951. Effet extinctif. Selon l'article 1234 du Code civil, la prescription est une des causes d'extinction des obligations. Cependant la portée de cet effet extinctif est très discutée. La question est à rattacher au débat précédemment évoqué sur la nature substantielle ou procédurale de la prescription : est-ce le droit substantiel qui est éteint, ou seulement l'action en justice permettant de le faire reconnaître et sanctionner ? Les solutions du droit positif luxembourgeois participent d'un mélange des deux conceptions, et les juridictions luxembourgeoises parlent tantôt d'une extinction du droit ou d'une libération de la dette[2129] tantôt de l'extinction de la faculté de

[2125] Cour d'appel, 19 février 1964, *Pas.*, 19, p. 274.
[2126] Cass., 3 février 2022, n° CAS-2020-00163.
[2127] POELMANS, n° 561 et les arrêts cités.
[2128] Cour d'appel, 2 mai 2018, n° 43863.
[2129] Cour d'appel, 16 mars 2011, *BIJ*, 2011, p. 13.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

faire sanctionner le droit en justice[2130]. Ce qui est sûr, c'est que le créancier ne peut plus contraindre son débiteur au paiement d'une dette prescrite – et cette solution s'impose aussi bien dans l'une et dans l'autre conception. Mais certaines solutions ne semblent pouvoir s'expliquer que comme une conséquence de l'extinction du droit lui-même : ainsi, la prescription empêche tout aussi bien l'extinction de la dette par compensation (alors que celle-ci, on l'a vu, ne suppose aucune action en justice) ; par ailleurs les sûretés qui garantissaient la dette s'éteignent. En particulier, la caution est libérée.

D'autres solutions, cependant, montrent que, même après la prescription, quelque chose subsiste du droit éteint. La solution la plus importante est que, si le débiteur paye volontairement la dette prescrite, ce paiement n'est pas considéré comme un paiement de l'indu – ce que les tenants de la conception substantielle de la prescription justifient par le recours à la notion d'obligation naturelle visée à l'article 1235 du Code civil. Par ailleurs, il faut rappeler, dans le cas particulier du droit d'invoquer la nullité d'un acte, que ce droit, lorsqu'il est prescrit, peut encore être invoqué par voie d'exception à l'action en exécution de l'autre partie[2131].

952. Effet non automatique. Bien qu'elle soit fondée, en partie, sur des considérations d'intérêt général, la prescription apparaît largement, dans le système du Code civil, comme un mécanisme d'intérêt privé. Cela se voit surtout à travers la règle posée par l'article 2223 du Code civil selon lequel le juge ne peut pas soulever d'office la prescription : elle ne jouera que si elle est invoquée par le débiteur (y compris pour la première fois en appel : C. civ., art. 2224)[2132]. La jurisprudence luxembourgeoise en a déduit que le juge ne peut davantage soulever d'office une prescription courte, si le débiteur s'est contenté de soulever une prescription longue[2133]. Mais à l'inverse, la Cour d'appel a admis que le juge n'était pas tenu de soulever d'office, au secours du créancier cette fois, le

2130 Voy. p. ex. Trib. Luxembourg, 22 mars 2009, *J.T.L.*, 2009, p. 152.

2131 Voy. *supra*, n° 453.

2132 Cass., 8 juin 2023, n° CAS-2022-00098.

2133 Conseil d'état (Comité du contentieux), 21 novembre 1984, *Pas.*, 26, p. 174 (mais l'arrêt précise qu'à l'inverse, le juge peut soulever d'office une prescription longue si le débiteur a, à tort, soulevé une prescription plus courte, car il a ainsi marqué sa volonté de se prévaloir de la prescription).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

moyen tiré de la suspension de la prescription[2134]. Il n'en va pas de même des délais de forclusion, qui sont considérés comme d'ordre public[2135].

Le caractère d'intérêt privé de la prescription apparaît également à travers la possibilité reconnue au débiteur par l'article 2220 du Code civil de renoncer à la prescription une fois qu'elle est acquise. Cette renonciation peut être expresse ou tacite, mais dans ce cas elle doit résulter de circonstances qui indiquent nécessairement et sans équivoque, la volonté du renonçant, en pleine connaissance de cause, de ne pas se prévaloir de la prescription[2136]. En particulier, il a été jugé que la renonciation à la prescription accomplie ne saurait s'induire du seul fait que le moyen de la prescription n'a pas été soulevé en première instance, une telle conclusion aboutissant à enlever tout effet à l'article 2224 du Code civil (qui permet de soulever pour la première fois la prescription en cause d'appel)[2137]. En toute hypothèse, la renonciation ne peut pas intervenir avant que la prescription ne soit acquise – ce qui, on l'a vu, condamne les clauses visant à allonger le cours de la prescription. On est en présence ici d'un mécanisme d'ordre public de protection[2138].

[2134] Cour d'appel, 10 juin 1968, *Pas.*, 20, p. 418.

[2135] Trib. Diekirch, 7 novembre 2023, n° TAD-2020-00426 (à propos du délai de forclusion de l'article L.212-6 du Code de la consommation).

[2136] Cour d'appel, 12 juillet 2018, n° 38954.

[2137] Cour d'appel, 10 juin 1968, préc.

[2138] Sur cette notion, voy. *supra*, n°s 407 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extinction des obligations contractuelles, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 979-1029
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

953. Effet relatif du contrat. Le contrat, qui produit naturellement son plein effet entre ceux qui l'ont conclu – les parties – peut-il également atteindre ceux qui lui sont extérieurs – les tiers ? Dans quelle mesure ceux-ci peuvent-ils acquérir des droits par l'effet du contrat, être tenus d'obligations qu'il a fait naître, ou, au moins, peuvent-ils ou doivent-ils en tenir compte dans leur comportement ? De prime abord, la réponse à ces questions paraît devoir être négative : parce qu'il est le produit d'un accord privé entre deux ou plusieurs personnes, le contrat ne devrait pas pouvoir lier les tiers, qui n'ont pas participé à cet accord. À la différence de la loi de l'État, qui s'impose à tous, la « loi contractuelle » ne peut, semble-t-il, avoir pour sujets que les contractants eux-mêmes. C'est ce que traduit, dans le Code civil, l'article 1165, qui pose le principe dit de l'effet relatif « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Elles ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent que dans le cas prévu à l'article 1121 ».

Cet article semble être la traduction de la règle romaine « *Res inter alios acta, aliis nec nocet nec prodest* »[2139], ce qui témoigne de l'ancienneté du principe. Il est aujourd'hui commun à tous les systèmes juridiques même s'il n'y est pas toujours exprimé de manière aussi ferme que dans l'article 1165 du Code civil[2140]. On le retrouve même en droit international public où l'article 34 de la Convention de Vienne sur le droit des traités pose que « Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement ».

En réalité, ce principe n'a qu'une portée limitée, qui se révèle très variable d'un droit à l'autre, et qui, à l'intérieur des droits des pays du Code civil, a considérablement évolué (**Sous-titre I**). Il est par ailleurs assorti de diverses exceptions (**Sous-titre II**).

[2139] Traduction littérale : « la chose convenue entre les parties ne peut ni nuire ni bénéficier aux tiers ». La règle est souvent citée sous sa forme abrégée « *res inter alios* ».

[2140] Pour une présentation comparative : R. CABRILLAC, *Droit européen comparé des contrats*, *op. cit.*, pp. 189-205.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1033
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

954. Un principe en trompe-l'œil. Lorsqu'on cherche à dégager la signification exacte du principe posé par l'article 1165 du Code civil, on débouche rapidement sur des règles d'une extrême complexité. Cette complexité tient à l'ambiguïté des termes de l'article 1165 du Code civil. Le contrat n'a d'effet qu'entre les parties, et pas à l'égard des tiers. Certes. Mais que faut-il entendre par « effets du contrat » ? Et que faut-il entendre par « parties » et par « tiers » ? Sur ces deux points, on est amené à faire toutes sortes de distinctions, qui réduisent considérablement la portée du texte, et, indépendamment des exceptions qui peuvent lui être apportées, en réduisent considérablement la portée, et en font, d'une certaine manière, un principe en trompe-l'œil.

Sur le premier point, on a vu, déjà, que le contrat produit, entre les parties, toutes sortes d'effets qui vont bien au-delà, comme une présentation simpliste le laisse croire, de la seule création d'obligations. Et cette diversité se retrouve dans les effets que le contrat a à l'égard des tiers. Si on peut facilement comprendre que, par principe, un contrat ne puisse pas créer d'obligations – au sens strict du terme – pour ceux qui ne l'ont pas passé, il est également assez clair que la force obligatoire du contrat n'aurait aucun sens si les tiers pouvaient faire comme si le contrat n'existait pas : même si je ne suis pas partie au contrat de vente que vous avez passé sur votre immeuble, je ne peux pas continuer à vous considérer comme propriétaire, et à nier le droit de propriété de votre acheteur. De ce point de vue, on distingue traditionnellement la question de l'effet relatif du contrat et celle de son opposabilité aux tiers ou par les tiers. C'est ce que nous verrons dans un premier temps (**Chapitre I**).

Sur le second point, il faut d'emblée souligner l'extrême subtilité de la distinction des parties et des tiers. Sans doute, dans une première approche, on peut dire que les parties sont ceux qui ont passé le contrat, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant, et que les tiers sont tous les autres. Mais, outre que cette catégorie de tiers est très hétérogène, il faut avoir immédiatement conscience que les qualités de partie et de tiers sont très évolutives : il suffit de songer au cas où une partie décède, elle sera alors remplacée par ses héritiers, ou au cas d'un commerçant qui exerçant son commerce dans un immeuble dont il est simplement locataire, et désirant cesser son activité, cède son bail à son successeur. Dans ces deux cas, une personne qui était à l'origine tiers au contrat en devient ensuite une partie. Il faut également penser que la qualité

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1037-1038
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de partie au contrat peut être définie de manière plus ou moins extensive, lorsque la relation contractuelle s'inscrit dans un ensemble de contrats interdépendants : lorsque vous passez un contrat avec un entrepreneur pour construire votre maison, et que l'entrepreneur, avec votre accord, sous-traite les travaux d'électricité à une entreprise spécialisée, peut-on considérer que cette dernière est complètement étrangère au contrat que vous avez passé ? Autant de points que nous retrouverons dans un deuxième temps en approfondissant la distinction des parties et des tiers (**Chapitre II**).

LARCIER INTERSENTIA
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1037-1038
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Chapitre I
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

955. Première approche. Pris à la lettre, le principe posé par l'article 1165 du Code civil est visiblement trop absolu. Il est évidemment impossible de dire qu'un contrat ne peut pas nuire aux tiers : si, étant à la recherche d'une maison, j'en ai repéré une qui me plaît, et que, téléphonant au vendeur, j'apprends qu'il vient de la vendre à quelqu'un d'autre, il est clair que ce contrat, auquel je suis parfaitement étranger me « nuit ». Et, en sens inverse, on voit bien qu'un contrat peut profiter à quelqu'un qui n'y est pas partie : si je vis avec vous, et que vous achetez (avec votre seul argent) une maison au bord de la mer, je pourrai en profiter lors de nos vacances communes. Au-delà de ces exemples un peu caricaturaux, la jurisprudence, dans les trois pays du Code civil, a admis dans de nombreux cas qu'un tiers pouvait se prévaloir de la situation juridique nouvelle créée par un contrat, ou, à l'inverse, être obligé d'en tenir compte dans son propre comportement. La doctrine, en France et en Belgique, a cherché à concilier ces cas avec la lettre de l'article 1165 du Code civil, en distinguant l'effet relatif proprement dit – qui signifie seulement que les tiers ne peuvent pas devenir titulaires des droits ni débiteurs des obligations créés par le contrat – et l'opposabilité du contrat – qui signifie que les tiers doivent et peuvent tenir compte de la situation juridique créée par le contrat. Pour traduire cette distinction, la doctrine belge oppose traditionnellement les effets internes du contrat (la création de droits et d'obligations), qui ne s'appliquent qu'aux parties – c'est l'article 1165 du Code civil – et ses effets externes – la modification de la situation juridique qui en résulte et qui est opposable aux tiers[2141]. Pour reprendre le premier exemple donné ci-dessus : si la maison que je convoitais est vendue à autrui, moi, qui suis tiers à cette convention, je ne pourrai en prendre possession et je n'aurai pas à la payer (effets internes du contrat, qui ne valent qu'entre les parties) ; mais je ne pourrai pas faire comme si la maison n'avait pas été vendue, par exemple en offrant au vendeur un prix supérieur pour qu'il rompe le premier contrat et me donne la préférence (effets externes du contrat, qui me sont opposables). Cette distinction a été reprise à l'occasion des réformes tant en France qu'en Belgique. Elle apparaît

[2141] Sur cette terminologie spécifiquement belge, voy. not. M. Fontaine, « Les "effets internes" et les "effets externes" du contrat », in M. Fontaine et J. Ghestin (dir.), *Les effets du contrat à l'égard des tiers, Comparaison franco-belge*, Paris, LGDJ, 1992, pp. 40 et s. ; cette terminologie servait de base à la présentation de la question dans les manuels belges avant la réforme : Wéry (2011), pp. 789 et s. ; Van Ommeslaghe, pp. 645 et s. ; elle est reprise en droit luxembourgeois par Poelmans, p. 215. Elle n'a pas été reprise par le nouveau Code civil belge.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

désormais en droit français à travers les articles 1999 et 1200 du Code civil, et en Belgique dans l'article 5.103 du nouveau Code civil, intitulé « relativité et opposabilité » (abandonnant au passage la formulation doctrinale effets internes/effets externes). Bien qu'elle soit parfois difficile à manier, et que les frontières entre les deux types d'effets soient parfois difficiles à tracer, cette distinction permet assez bien de rendre compte de l'état du droit luxembourgeois en la matière.

SECTION 1. L'EFFET RELATIF DU CONTRAT

956. De l'article 1165 à l'article 1119 du Code civil. Le principe de l'effet relatif, tel qu'il est actuellement entendu à partir de la distinction précédente, paraît beaucoup mieux exprimé, dans le Code civil de 1804, par l'article 1119 du Code civil que par l'article 1165 du Code civil. Aux termes de ce texte, que nous avons déjà rencontré, « On ne peut en général s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même ». La place de ce texte dans le Code civil, au sein des règles de validité du contrat, et plus spécialement dans la section relative au consentement, peut sembler étrange : c'est que, pour les rédacteurs du Code, il s'agissait d'abord d'une règle de protection du consentement, visant à éviter qu'une personne ne se trouve liée par un contrat sans l'avoir voulu. C'est à ce titre que nous avons déjà traité de ce texte[2142]. Mais aujourd'hui, l'article 1119 du Code civil est surtout vu comme une règle relative aux effets du contrat, signifiant qu'un contrat ne peut avoir pour effet de rendre un tiers ni créancier ni débiteur[2143].

957. Signification. Un jugement du tribunal de Luxembourg exprime parfaitement la signification du principe de l'effet relatif du contrat, tel qu'on l'entend aujourd'hui : « Le principe de l'effet relatif du contrat signifie que celui-ci ne saurait faire naître un droit au profit ou à l'encontre d'un tiers. Seules les parties au contrat peuvent devenir créanciers ou débiteurs par l'effet de celui-ci »[2144]. Le principe concerne donc essentiellement ce qu'on peut appeler le « contenu obligationnel » du contrat : un tiers au contrat ne peut pas être

[2142] Voy. *supra*, n° 299.

[2143] Rappelons que, pour les rédacteurs du Code, « stipuler » c'est se rendre créancier, et « s'engager », c'est se rendre débiteur.

[2144] Trib. Luxembourg, 17 février 2015, n° 159.910, reprenant la formule de Trib. Luxembourg, 20 juin 2006, n° 95.999.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

tenu, par ce contrat lui-même, de payer les sommes ou de faire quelque chose qui a été mis à la charge d'un contractant ; il ne peut pas davantage, en principe, demander à un contractant l'exécution d'une obligation qui a été stipulée en faveur de l'autre. C'est du reste ainsi que maintenant le nouvel article 1199 du Code civil français pose la règle : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter ». Très proche, le texte belge dispose que « le contrat ne fait naître des obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent demander l'exécution d'une obligation contractuelle que si la loi le prévoit et dans le cas prévu à l'article 5.107 » (art. 5.103, al. 1). On peut cependant trouver ces formulations, bien préférables à celle de l'article 1165, un peu trop étroites, dans la mesure où le principe de l'effet relatif concerne aussi les effets réels du contrat, et plus généralement ses effets non obligationnels : un contrat translatif de droits réels (comme une vente) ne peut transférer la propriété qu'à l'acquéreur, et ne peut priver de son droit que le vendeur, une clause attributive de compétence stipulée entre deux contractants ne lie pas les tiers intéressés à la solution du litige entre ces contractants. Par ailleurs, la formule retenue ne doit pas être interprétée comme limitant l'effet relatif à l'exécution du contrat, elle a également des conséquences en ce qui concerne les sanctions de son inexécution.

958. Applications : effet relatif et exécution du contrat. La jurisprudence luxembourgeoise récente donne à voir quelques exemples d'application du principe entendu comme excluant qu'un tiers puisse demander l'exécution du contrat ou qu'on puisse la lui demander. Une application caractéristique se rencontre en matière bancaire : lorsque, en application de la législation de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, un compte bancaire a été ouvert par une personne avec désignation d'un tiers qui en est le « bénéficiaire économique » ; celui-ci, bien qu'inscrit comme tel dans les registres de la banque, est un tiers au contrat de compte et la banque peut s'opposer à ce qu'il fasse des opérations sur le compte[2145]. De même, lorsque, dans un contrat de vente entre deux particuliers, l'acquéreur s'engage à construire sur le terrain avec une société désignée mais non présente à l'acte, celle-ci ne peut pas agir en exécution du contrat[2146]. Dans l'affaire qui a donné lieu au

[2145] Cour d'appel, 9 juillet 2004, *D.A.O.R.*, 2005, n° 74.
[2146] Cour d'appel, 23 février 2005, n° 28829.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

jugement précité de 2015, il s'agissait d'un avocat qui avait passé avec un promoteur un contrat de conseil en vue d'assurer la domiciliation d'une société au Luxembourg ; dans ce contrat, le promoteur s'était engagé personnellement envers l'avocat à payer les sommes dues par la société à ce titre. Une autre avocate (que l'on suppose être du même cabinet) était intervenue dans le dossier et avait facturé ses prestations à la société ; celle-ci n'ayant pas payé, elle s'était retournée contre le promoteur. Elle est déboutée, car elle était tiers au contrat passé par son confrère avec celui-ci[2147].

959. Applications : effet relatif et sanctions de l'inexécution du contrat. Pas plus qu'il ne peut se voir imposer l'exécution du contrat ni en exiger l'exécution à son profit, un tiers ne peut ni se voir appliquer ni mettre en œuvre directement les sanctions de l'inexécution du contrat. C'est ainsi, d'abord que, si un tiers concourt avec une partie à l'inexécution du contrat, il peut sans doute engager sa responsabilité à l'égard de l'autre partie, mais seulement sur le fondement de la responsabilité délictuelle[2148]. De même, à l'inverse, si un tiers est victime de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, il ne peut réclamer réparation de son préjudice que sur le fondement de la responsabilité délictuelle[2149]. Nous verrons ultérieurement que ce principe connaît une exception remarquable lorsque le tiers victime est lié au contractant auteur du dommage par une chaîne de contrats translatifs de propriété[2150], mais en dehors de ce cas, parce que le tiers n'est pas créancier d'une obligation née du contrat inexécuté, il ne peut pas agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il en va ainsi notamment en matière de sous-traitance : suivant la position de la Cour de cassation française[2151], la jurisprudence luxembourgeoise affirme de manière constante que l'action du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant en réparation des dommages causés par celui-ci est une action délictuelle[2152]. Cependant, nous verrons que le caractère délictuel de l'action du tiers est aujourd'hui largement vidé de sa substance dans la mesure où la jurisprudence, au Luxembourg comme en France, admet que le tiers peut, sur ce fondement, se prévaloir du

2147 Trib. Luxembourg, 17 février 2015, préc.

2148 Voy. *infra*, n° 970.

2149 Cour d'appel, 1er juillet 1998, n° 20546 ; Cour d'appel, 13 février 2019, n° 43390.

2150 Voy. *infra*, n° 986.

2151 Cass. fr. (ass. plén.), 12 juillet 1991, n° 90-13602 (arrêt *Besse*).

2152 Trib. Luxembourg, 30 juin 2000, n° 48733 ; Cour d'appel, 1er juillet 1998, n° 20546 ; Cour d'appel, 9 octobre 2008, *Pas.*, 34, p. 281 ; Cour d'appel, 25 octobre 2017, n° 40026.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

manquement au contrat pour établir la faute délictuelle – solution parfois présentée comme une conséquence de l'opposabilité du contrat aux tiers[2153].

SECTION 2. L'OPPOSABILITÉ DU CONTRAT

960. Illustrations. Même si, en principe, un tiers ne peut pas devenir créancier ni, encore moins, débiteur par l'effet d'un contrat, il paraît évident que la situation juridique nouvelle qui résulte de la conclusion du contrat peut modifier, positivement ou négativement, la situation des tiers, et que ceux-ci peuvent s'en prévaloir ou doivent en tenir compte. Quelques exemples peuvent aisément en convaincre. Supposons que vous soyez un(e) de mes ami(e)s et que je vous autorise habituellement à venir vous promener dans mon jardin ; un jour, vous vous présentez à la porte et vous trouvez un gros chien que vous ne connaissez pas et qui vous barre le passage. Vous découvrez alors que j'ai vendu (sans vous en avertir) ma maison et mon jardin. Il est bien évident que vous ne pourrez pas imposer au nouveau propriétaire de vous recevoir, en invoquant l'article 1165 du Code civil, et en prétendant que la vente de la maison, à laquelle vous êtes étranger(e), ne peut produire aucun effet à votre égard ! Si vous n'êtes nullement obligé(e) par ce contrat, vous ne pouvez pas en méconnaître les effets. Supposons maintenant que vous soyez un de mes créanciers : avant la vente, vous pouviez saisir la maison au titre de votre droit de gage général, après la vente, elle vous échappera en principe, tandis que, à l'inverse, les créanciers de mon acheteur pourront, eux, saisir la maison dont il est devenu propriétaire. Supposons encore que vous ayez eu en tête de m'embaucher comme votre salarié : mais un autre employeur m'a proposé un salaire plus important, et c'est avec lui que j'ai passé le contrat de travail. Vous comprenez bien que, du coup, vous ne pouvez plus m'embaucher, tant que mon contrat avec mon employeur actuel n'a pas pris fin[2154]. Dans tous ces cas, on voit que les tiers ne peuvent pas faire comme si le contrat n'existait pas, ils doivent, d'une certaine manière, le respecter. Et, à l'inverse, si le contrat produit des effets positifs à leur égard, ils peuvent s'en prévaloir.

[2153] Voy. *infra*, n° 987.

[2154] Sur le point de savoir si vous pouvez m'inciter à quitter mon travail actuel pour pouvoir m'embaucher, voy. *infra*, n°s 970 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

On rencontre dans tous les systèmes juridiques ce type d'effets à l'égard des tiers, mais ceux-ci sont admis de manière plus ou moins générale, et donnent lieu à une conceptualisation plus ou moins poussée.

961. Conceptualisation. Dans les pays du Code civil, les solutions qui viennent d'être exposées sont présentées de manière systématique, avec d'autres, comme des applications d'un principe général d'opposabilité des effets du contrat aux tiers ou par les tiers. C'est semble-t-il en Belgique que cette construction doctrinale a été élaborée en premier lieu, à partir d'un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1909[2155] selon lequel « Si les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, ce principe ne règle que les droits et obligations qui découlent des contrats, il ne met pas obstacle à ce que ceux qui y sont demeurés étrangers, constatent l'existence de conventions avouées ou légalement prouvées et tirent argument du fait de leur existence, non pour réclamer à leur profit l'exécution des obligations qu'elles stipulent, mais pour en déduire eu égard aux liens et aux droits qui en découlent, les conséquences favorables ou défavorables pour les parties, que les événements ou agissements des tiers ont entraîné pour elles ». C'est l'opposition faite par cet arrêt entre « les droits et obligations des parties » qui seules relèvent de l'article 1165 du code civil, et les conséquences que peut produire pour les tiers le « fait de l'existence du contrat », qui a servi de base au développement dans la doctrine belge de la distinction entre les effets internes du contrat, qui ne valent qu'entre les parties, et ses « effets externes », qui sont opposables aux tiers ou par les tiers. Cette opposabilité, réaffirmée depuis 1909 par de nombreux arrêts, est aujourd'hui présentée par la doctrine comme un principe général du droit des contrats[2156]. Elle figure désormais à l'article 5.103, alinéa 2, du nouveau Code civil belge selon lequel « [l]es tiers doivent reconnaître l'existence d'un contrat en tant que fait, tout comme ils peuvent en invoquer l'existence à leur avantage ».

En France, où l'arrêt de 1909 est passé curieusement inaperçu, la distinction entre l'effet relatif du contrat et son opposabilité n'a été opérée par la doctrine que plus tard, dans les années 1930. Si la doctrine française n'utilise pas la distinction entre « effets internes » et « effets externes » du contrat, l'idée est exactement la même : la

[2155] *Pas. be.*, 1909, I, p. 272, concl. Av. gén. TERUDEN.
[2156] VAN OMMESLAGHE, n° 659 et les auteurs cités.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

règle de l'article 1165 du Code civil de 1804 selon laquelle le contrat ne « peut nuire aux tiers ni leur profiter » signifie seulement qu'il ne peut en principe rendre un tiers créancier ou débiteur (effet relatif), mais les tiers n'en doivent pas moins tenir compte de la situation juridique créée par le contrat, de même qu'ils peuvent s'en prévaloir si elle leur est favorable. La distinction a été, de manière relativement récente, consacrée de manière générale par la Cour de cassation française, qui posait que « l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par ceux auxquels ils n'ont pas été parties »[2157]. Elle a été consacrée en 2016 à l'article 1200 du Code civil, qui, venant après l'affirmation de l'effet relatif à l'article 1199, pose que « l'article 1201 du Code civil, venant après l'affirmation que « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties contractantes », pose que « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait ».

En l'absence de tout écrit doctrinal sur le sujet au Luxembourg, il est difficile de dire si les juridictions de ce pays ont plutôt importé l'idée de Belgique ou de France. Ce qui est sûr, c'est qu'elles consacrent, dans diverses situations, la même distinction. C'est ainsi que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 29 octobre 1998, posé que « Si un contrat n'a pas d'effet obligatoire envers le tiers, il lui est par contre opposable, en ce sens qu'il constitue pour lui une situation de fait, dont il ne peut, sans commettre de faute, entraver l'accomplissement »[2158]. On doit cependant observer que, dans certaines décisions, la terminologie est assez flottante : ainsi, un arrêt de la Cour d'appel approuve le tribunal d'avoir jugé « qu'en vertu de l'effet relatif des conventions découlant de l'article 1165 du Code civil, une société, dès lors qu'elle n'est pas signataire d'un pacte conclu entre certains de ses associés, doit être considérée comme un tiers aux pactes extrastatutaires et qu'il en résulte comme conséquence immédiate, l'inopposabilité de ces pactes à la société »[2159]. En réalité, dans cette affaire, il s'agissait bien de l'effet relatif au sens strict, permettant de repousser l'action d'un associé demandant à la société de lui verser un boni de liquidation calculé d'après les règles arrêtées entre les seuls actionnaires.

[2157] Cass. fr. (comm.), 1er avril 1965, n° 61-12 952 ; Voy. aussi : Cass. fr. (comm.), 22 octobre 1991, n° 89-20490.

[2158] *Pas.*, 31, p. 7.

[2159] Cour d'appel, 26 février 2020, n° CAL-2018-00209. Voy. dans la même affaire Trib. Luxembourg, 20 décembre 2017, n° 160333.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

962. Explication. Il est difficile d'expliquer de manière convaincante cette opposabilité du contrat aux tiers ou par les tiers. On la rattache souvent à l'idée que le contrat n'est pas qu'un acte créateur de droits et d'obligations, que c'est aussi un fait social qui s'impose à tous. Cette idée apparaît déjà dans l'arrêt belge de 1909, et on la retrouve de manière explicite dans la jurisprudence française et luxembourgeoise récente, ainsi que dans la formulation de l'article 5.103 du Code civil belge. Cette présentation est assez contestable : ce qui est opposé aux tiers ou par les tiers, ce n'est pas un fait brut, mais bien, comme le formule d'ailleurs exactement l'article 1200 du Code civil français, la « situation juridique » nouvelle résultant de l'accord des parties, telle qu'elle est configurée par lui. Si, par exemple, l'acheteur et le vendeur ont convenu que le bien vendu ne deviendrait la propriété de l'acheteur qu'à telle date, c'est seulement à partir de cette date que les créanciers du vendeur ne pourront plus saisir le bien dans son patrimoine, et que ceux de l'acheteur pourront l'appréhender dans l'actif de ce dernier. Il est difficile de voir là du « fait ». Pour cette raison, il vaut mieux dire, à notre avis, que, ce qui est opposable, c'est la norme contractuelle qui a, d'une certaine manière, force obligatoire autant à l'égard des tiers qu'à l'égard des parties – même si, bien sûr, elle ne crée de droits et d'obligations que pour les parties[2160]. Dès lors que le système juridique permet aux personnes privées de passer des conventions qui ont « force de loi », il apparaît normal que les tiers doivent respecter cette loi contractuelle qui n'aurait, autrement, pas de valeur : que vaudrait un contrat de vente si tous les tiers pouvaient considérer que le vendeur est resté propriétaire ? On peut aussi raisonner en termes de droits subjectifs : puisqu'on permet aux personnes privées de créer (de transférer, de modifier) des droits par contrat, il apparaît logique que les tiers doivent respecter ces droits[2161].

Cela n'implique pas du reste que l'opposabilité soit un principe absolu. Il appartient au système juridique, de même qu'il détermine l'étendue de la force obligatoire entre les parties, de dire quelles conséquences, et à quelles conditions, la loi contractuelle doit produire vis-à-vis des tiers, dans la mesure où cela lui apparaît nécessaire à assurer l'efficacité du contrat tout en sauvegardant l'intérêt des tiers qui n'ont pas eu leur mot à dire lors de son élaboration. Une étude de droit comparé, basée sur la comparaison du droit allemand et du droit français, a montré que l'opposabilité n'avait pas nécessairement à être conçue comme un principe général d'où découleraient toutes sortes de conséquences automatiques[2162]. À cet égard, on peut penser que le droit français, suivi par la jurisprudence luxembourgeoise, va parfois trop loin dans les conséquences qu'il tire de l'opposabilité, qui ne sont du reste pas toujours les mêmes qu'en droit belge.

963. Double sens de l'opposabilité. Bien qu'on mette souvent en avant l'opposabilité du contrat aux tiers, à laquelle s'attachent un grand nombre de conséquences pratiques (**Sous-section 1**), l'opposabilité joue aussi, dans l'autre sens, lorsque le contrat est opposé par les tiers aux parties (**Sous-section 2**).

[2160] Pour le développement de cette présentation, voy. P. ANCEL, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », *op. cit.*, n°s 48 et s.

[2161] *Cf.* FLOUR, AUBERT, SAVAUX, n° 435.

[2162] R. WINTGEN, *Étude critique de la notion d'opposabilité – Les effets du contrat à l'égard des tiers en droit français et allemand*, préf. J GHESTIN, Paris, LGDJ, 2004.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

SOUS-SECTION 1. L'OPPOSABILITÉ DU CONTRAT AUX TIERS

964. Principe et limites. Contrairement à ce qu'affirme de manière un peu maladroite l'article 1165 du Code civil, un contrat peut « nuire » aux tiers, en créant pour eux une situation juridique désavantageuse qu'ils ne pourront pas méconnaître. Ce principe, dont il existe de très nombreuses manifestations (§ 1), n'est cependant pas absolu, des limites importantes étant édictées dans l'intérêt des tiers (§ 2).

§1. Les manifestations de l'opposabilité

965. Distinction entre les effets réels et les effets personnels du contrat. Du point de vue de la règle ici étudiée, il est habituel de distinguer deux types d'effets qui peuvent être produits par le contrat. L'opposabilité est particulièrement visible lorsque le contrat produit des effets réels – c'est-à-dire lorsqu'il crée ou transfère un droit réel sur un bien (A). Mais elle produit aussi certaines conséquences, plus difficiles à cerner, s'agissant des effets simplement personnels – c'est-à-dire des droits de créance et des obligations (B). Ce ne sont pas seulement les conséquences de l'opposabilité qui ne sont pas les mêmes dans les deux cas, mais aussi ses conditions.

A) *Opposabilité des effets réels du contrat*

1) *Principe d'opposabilité*

966. Solutions. Les illustrations qui ont été précédemment données de l'opposabilité concernaient presque toutes des contrats translatifs de droits réels (spécialement la vente). Il paraît assez évident que ces contrats, en tant qu'ils affectent directement le statut des biens, doivent avoir des incidences sur la situation juridique des tiers. D'une manière générale, lorsqu'un bien est transmis, les tiers doivent tenir compte du transfert. Toute personne doit respecter le droit réel de l'acquéreur ou du donataire, et ne peut user du bien transmis qu'avec l'autorisation du nouveau propriétaire. Plus particulièrement, les créanciers du vendeur ou du donateur ne peuvent plus saisir le bien dans son patrimoine, puisque leur droit de gage général ne vise que les biens dont leur débiteur est propriétaire. Et, si on veut acheter le bien, il faut l'acheter au nouveau propriétaire et non à l'ancien, qui n'a plus de droit sur le bien, et donc plus de pouvoir de le vendre. Il en va de même des contrats

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

qui constituent un nouveau droit réel : si un débiteur, en garantie de sa dette, constitue une hypothèque sur un de ses immeubles au profit de son créancier, les autres créanciers ne pourront se payer sur l'immeuble qu'après le créancier hypothécaire et la personne qui achèterait l'immeuble ne deviendrait titulaire que d'un droit de propriété grevé de l'hypothèque.

Toutes ces solutions sont connues depuis longtemps, et elles font partie des règles de base de tout système juridique. Au Luxembourg, un jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg en 1911 témoigne de ce que cette opposabilité des contrats translatifs de droits réels était déjà, à cette époque, parfaitement admise. Pour établir leur droit de passage sur le terrain de leur voisin, des époux s'appuyaient sur l'acte de vente de leur maison qui avait été passé avec leurs vendeurs, et qui comprenait ce droit de passage. Les défendeurs ayant allégué que cet acte, auquel ils n'étaient pas parties, ne leur était pas opposable en raison de l'article 1165 du Code civil, le tribunal juge que « une doctrine et jurisprudence constantes décident que l'article 1165 ne serait opposable au demandeur qu'en tant qu'il s'agirait d'établir une obligation à la charge d'un tiers en vertu d'un acte qui lui serait étranger ; mais que, lorsque l'une des parties se borne à justifier par un titre régulier de la transmission de la propriété en sa faveur, l'autre ne saurait être recevable à récuser de plano l'autorité de ce titre ; qu'elle ne peut le combattre qu'en lui opposant, soit un autre titre, soit la prescription ; qu'il s'en suit que la règle que les conventions ne sont opposables qu'aux parties contractantes est inapplicable aux actes translatifs de propriété, lesquels sont opposables à tout le monde »[2163].

967. Opposabilité du contrat ou opposabilité du droit ? Ces diverses solutions étaient admises bien avant que ne se développe en doctrine la théorie de l'opposabilité du contrat aux tiers[2164]. On considérait en effet qu'elles n'étaient que des manifestations de l'opposabilité des droits réels, qu'on présentait traditionnellement comme une caractéristique spécifique de cette catégorie de droits. Alors que, expliquait-on, les droits personnels ne relient que le créancier et le débiteur, les droits réels s'imposent à tous, *erga omnes*. Si on est propriétaire d'un bien, on l'est au regard de tout le monde ; si on a une hypothèque sur un immeuble, on ne l'a pas seulement dans les rapports avec son débiteur, on l'a vis-à-vis de tous les autres créanciers et de tous les acquéreurs potentiels de l'immeuble. Cependant, même si

[2163] Trib. Luxembourg, 26 juillet 1911, *Pas.*, 09, p. 277.

[2164] Dans le jugement luxembourgeois de 1911, le terme d'opposabilité n'est pas employé dans son sens moderne : la formule selon laquelle « les conventions ne sont opposables qu'aux parties contractantes » n'est qu'une manière d'exprimer l'effet relatif.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

cela est vrai, cela ne suffit pas à expliquer que l'acquéreur d'un bien puisse opposer son droit de propriété à tous : opposer son droit, c'est nécessairement se prévaloir du fait ou de l'acte qui vous l'a conféré, donc cela suppose que ce fait ou cet acte soit lui-même opposable aux tiers. Si je suis devenu propriétaire par succession, c'est la loi qui m'a conféré le droit, et cette loi s'impose évidemment à tous. Si je suis devenu propriétaire par contrat, il faut, pour que je puisse opposer mon droit, que le contrat (de vente, de donation) s'impose également à tous. L'opposabilité du droit se ramène donc nécessairement à l'opposabilité du contrat.

2) *Conditions de l'opposabilité*

968. Règles de publicité. L'opposabilité des contrats translatifs ou constitutifs de droits réels produit des conséquences si importantes que, dans un certain nombre de cas, la loi subordonne cette opposabilité à l'accomplissement de formalités de publicité destinées à faire connaître le contrat aux tiers. Cela n'a rien de systématique : par exemple, pour vous refuser l'accès à son jardin, l'acquéreur de ma maison n'aura nul besoin d'avoir publié l'acte de vente ; si un litige surgit entre lui et vous (parce que, par exemple, vous avez pénétré sur le terrain sans son autorisation), il lui suffira, pour vous faire condamner, de faire la preuve de son droit en produisant son titre de propriété – peu important que ce titre ait été ou non publié. Mais il n'en va pas de même si, par exemple, vous voulez m'acheter la maison que vous pensez toujours être ma propriété : si, sans vous dire que je l'ai déjà vendue, je vous la vends à nouveau, il va en résulter un litige avec le nouveau propriétaire. Dans ce cas, l'acquéreur ne pourra vous opposer son droit – et en conséquence faire tomber la vente qui vous a été consentie – que s'il a, préalablement, publié la vente qui lui a été consentie.

D'une manière générale, comme il a déjà été vu[2165], les contrats translatifs (vente, donation) ou constitutifs (hypothèque, usufruit, etc.) de droits réels portant sur des immeubles doivent être publiés pour être opposables aux acquéreurs tenant leur droit du vendeur ou du constituant, ainsi qu'aux créanciers ayant acquis du débiteur un droit réel sur l'immeuble (créanciers hypothécaires). Au Luxembourg, cette publication s'effectue auprès d'une administration spéciale dénommée « conservation des hypothèques »[2166]. Pour les biens mobiliers, en revanche, aucune publication n'est en principe exigée : c'est la mise en possession de l'acquéreur ou du donataire, ou du créancier gagiste, qui rendra la vente, la donation ou le gage opposables aux

[2165] Voy. *supra*, n° 428.
[2166] L. 25 septembre 1905, art. 1er.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

tiers, par le jeu de l'article 2279 du Code civil : si j'achète un meuble à une personne qui l'a en sa possession, et que j'en prends livraison, je ne pourrai me voir opposer la vente de ce même bien, qui aurait été consentie plus tôt par mon vendeur à un autre acquéreur qui, lui, n'aurait pas été mis en possession.

B) *Opposabilité des effets personnels du contrat*

1) *Principe général*

969. Les droits personnels comme restrictions à la liberté d'agir des tiers. L'idée que les contrats sont opposables aux tiers est beaucoup moins évidente lorsque la situation juridique créée par le contrat est un simple rapport personnel, entre un créancier et un débiteur, qui n'affecte pas directement le statut d'une chose. À première vue, si les tiers sont nécessairement concernés lorsqu'une chose change de propriétaire ou est grevée d'un droit spécifique au profit d'une personne, ils le sont beaucoup moins lorsque deux personnes conviennent que l'une devra faire (ou ne pas faire) quelque chose envers l'autre. Cependant, il est aisé de voir que même une relation de ce type peut affecter la situation des tiers. C'est assez évident lorsque le droit personnel concerne l'usage d'un bien : si je loue l'appartement dont je suis propriétaire – ce qui confère au locataire seulement le droit personnel d'obtenir de moi que je le laisse jouir de l'appartement – il est certain que vous ne pouvez plus, même si je vous en donne l'autorisation, pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans l'appartement sans l'accord du locataire. Mais, même lorsque la relation entre le créancier et le débiteur ne touche pas un bien particulier, elle peut concerner les tiers, chaque fois que l'obligation du débiteur lui interdit de passer des contrats avec d'autres personnes. Même si les tiers ne sont pas, à proprement parler, débiteurs de cette obligation, le système juridique peut leur imposer, pour assurer l'efficacité du contrat, d'en tenir compte et d'adopter un comportement qui ne conduise pas à permettre ou à favoriser sa violation par le débiteur. C'est dans cette optique que le droit luxembourgeois, comme beaucoup d'autres droits, admet la responsabilité du tiers qui se rend complice de la violation d'une obligation contractuelle.

LARCIER INTERSENTIA
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

2) *Application : la responsabilité du tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle*

970. Illustrations. Pour bien comprendre le problème, on peut partir d'un certain nombre d'exemples. Le premier a déjà été donné : c'est celui du salarié qui a déjà passé un contrat de travail avec un employeur. Si un autre employeur veut, à son tour, embaucher à temps plein ce salarié, il doit certainement attendre que le premier contrat de travail ait pris fin. Et déjà, on voit là une manifestation de l'opposabilité du contrat aux tiers. Mais jusqu'où va cette opposabilité ? Le second employeur peut-il inciter le salarié, dont il veut s'assurer les services au plus tôt, à quitter son emploi sans préavis (par exemple, en lui promettant de payer l'indemnité de résiliation qui pourrait être mise à sa charge) ? En restant dans le domaine du contrat de travail, on peut raisonner sur le cas où le salarié a accepté une clause de non-concurrence : il ne peut pas, après la fin de son contrat, se faire réembaucher pendant un certain temps par un employeur du même secteur d'activité. Concrètement, cela signifie que ce salarié, s'il respecte la clause, ne sera pas sur le marché du travail pendant un certain temps et dans une certaine zone géographique, et cela limite en fait la liberté des autres employeurs de pouvoir profiter de ses services et de ses compétences. Mais que va-t-il se passer si le salarié ne respecte pas la clause et se fait réembaucher par un autre employeur ? Il est certain que dans ce cas le salarié engagera sa responsabilité contractuelle, et qu'il pourra même être contraint de cesser le travail, au besoin sous astreinte. Mais l'employeur qui l'a embauché pourrait-il lui aussi être sanctionné ? Certes, il n'était pas partie au premier contrat de travail, et il n'est pas personnellement obligé par la clause. Mais d'un autre côté, s'il connaissait cette clause, ne devait-il pas en tenir compte dans son comportement, et s'abstenir de réembaucher ce salarié dont il savait qu'il n'était pas libre ? On retrouve la même problématique dans le cadre des contrats de distribution, qui obligent un détaillant à s'approvisionner exclusivement auprès de son fournisseur. Si ce détaillant viole cette obligation d'exclusivité et achète ailleurs, celui qui lui vend les produits objet de la clause ne pourrait-il pas engager sa responsabilité envers le fournisseur ? Ou, variante : un fabricant de produits veut réserver la vente de ceux-ci à un réseau de distributeurs agréés (par exemple, un fabricant de parfums, qui veut éviter que ses produits ne soient dévalorisés en étant vendus dans tous les supermarchés) ; dans ce but, il impose

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

à ses distributeurs de ne pas revendre les produits à d'autres distributeurs non agréés. Si un de ces distributeurs viole le contrat et revend à un tiers, il engagera sa responsabilité contractuelle et pourra sans doute être exclu du réseau ; mais ne peut-on également reprocher au tiers (qui n'ignorait sans doute pas l'existence du réseau de distribution exclusif) de n'en avoir pas tenu compte, et d'avoir consciemment vendu des produits dont le fabricant voulait organiser une distribution sélective ? Dernier exemple, dans un domaine très différent : *Primus* a consenti à *Secundus* une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble. Cette promesse fait naître, à la charge du promettant, une obligation de ne pas vendre à quelqu'un d'autre tant que la promesse est en vigueur. Si *Primus* vend néanmoins son immeuble à *Tertius*, au mépris de la promesse, il engagera certainement sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de *Secundus*. Mais celui-ci pourra-t-il aussi engager la responsabilité de *Tertius* (et éventuellement lui demander de restituer le bien) s'il était au courant de la promesse, et qu'il a, consciemment, porté atteinte au droit de *Secundus* ? Dans tous ces cas, il est clair que le tiers n'est pas tenu personnellement de l'obligation créée par le contrat, il n'en est pas débiteur. Mais d'un autre côté, on peut penser que, s'il connaît ce contrat et cette obligation, son comportement, qui porte consciemment atteinte au droit du créancier, est fautif. Les solutions jurisprudentielles sur ces situations sont plus nuancées que celles que nous avons rencontrées pour les contrats faisant naître des droits réels, car il faut trouver un équilibre entre le souci de préserver la liberté d'action des tiers, que le contrat prétend limiter, et celui d'assurer une efficacité minimum au contrat.

971. Principe de la responsabilité du tiers complice. En France[2167] et en Belgique[2168], la jurisprudence a admis depuis longtemps que le tiers qui, consciemment, participait à la violation d'une obligation contractuelle pouvait engager sa responsabilité envers le créancier de cette obligation. En France, cette responsabilité a été admise et a suscité d'importants débats doctrinaux avant même que soit théorisée la notion d'opposabilité du contrat aux tiers, dont elle est aujourd'hui présentée comme une des principales applications. Depuis, dans les deux pays, on peut en recenser de multiples applications jurisprudentielles, notamment dans les

[2167] Cass. fr. (civ.), 27 mai 1908, *D.*, 1908, 1, p. 459 (débauchage d'un salarié).

[2168] Cass. be., 24 novembre 1932, *Pas. be.*, 1933, I, p. 23, concl. Proc. gén. LECLERCQ (à propos de l'achat à un tiers de marchandises au mépris d'une clause d'exclusivité).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

situations précédemment évoquées[2169]. Au Luxembourg, on en trouve déjà trace dans un jugement du Tribunal de Diekirch de 1931 qui retient la responsabilité délictuelle à l'égard d'un bailleur d'un tiers qui avait « méchamment » aidé le locataire à faire disparaître les meubles garnissant les lieux, et sur lesquels le bailleur disposait d'un privilège[2170]. Plus récemment, c'est à propos d'un réseau de distribution que la Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer de la manière la plus nette le principe de l'opposabilité du contrat aux tiers[2171]. Il s'agissait de la vente par Auchan Luxembourg de parfums de marque dont les producteurs avaient contractuellement réservé la distribution à des distributeurs agréés. Cependant, la Cour de cassation, tout comme la Cour d'appel[2172], consacrent en la matière une solution très nuancée : la revente par un distributeur hors réseau n'est pas, en soi, interdite ; elle ne l'est que si ce distributeur s'est approvisionné auprès d'un distributeur du réseau, en violation directe des obligations contractuelles de celui-ci ; en revanche, il est licite pour quiconque de s'approvisionner hors du réseau, s'il trouve des revendeurs dans un pays non couvert par le réseau. Le principe de la liberté du commerce et du libre jeu de la concurrence l'emporte alors sur l'opposabilité aux tiers des contrats passés entre le producteur et ses distributeurs[2173]. Cette solution, dont on trouve l'équivalent dans les jurisprudences française[2174] et belge[2175], montre clairement que l'opposabilité du contrat aux tiers n'est pas un principe absolu, une sorte de nécessité technique

[2169] Quelques exemples : condamnation de l'acheteur qui achète un bien qu'il sait être l'objet d'une promesse de vente (Cass. fr., 10 avril 1948, *D.*, 1948, p. 421 ; Cass. be., 30 janvier 1965, *Pas. be.*, 1965, I, p. 538) ; condamnation d'un grossiste qui vend des marchandises à un détaillant au mépris d'une clause d'exclusivité liant ce détaillant à son fournisseur (Cass. fr. (comm.), 21 février 1978, n° 76-12716) ; condamnation d'une personne qui achète une voiture alors que la banque qui avait financé l'acquisition par le vendeur avait interdit à celui-ci de la revendre tant que le prêt ne serait pas remboursé et s'en était réservé la propriété (Cass. be., 22 avril 1983, n° F-19830422-21).

[2170] Trib. Diekirch, 9 décembre 1931, *Pas.*, 13, p. 141.

[2171] Cass., 29 octobre 1998, 31, p. 7, préc.

[2172] Cour d'appel, 22 octobre 1997, *Pas.*, 30, p. 273 ; Cour d'appel, 29 octobre 2003, *Pas.*, 32, p. 597.

[2173] Selon la jurisprudence luxembourgeoise, c'est au tiers non agréé de prouver qu'il s'est approvisionné de manière licite, auprès de personnes extérieures au réseau de distribution.

[2174] Dans l'affaire *Auchan*, la Cour d'appel se réfère explicitement à : Cass. fr. (comm.), 13 décembre 1988, n° 87-15521 ; Cass. fr. (comm.), 4 décembre 1990, n° 89-12193 ; Cass. (comm.), 27 octobre 1992, n° 90-15831 – Pour une étude approfondie de la question en droit français, voy. N. Ferrier et L. Sautonie-Laguioonie, « La distribution parallèle à l'épreuve de l'opposabilité du réseau », *RTD civ.*, 2011, pp. 225 et s.

[2175] Cass. be., 17 juin 1960, *Pas. be.*, 1960, I, p. 1191.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

qui imposerait, de manière automatique, aux tiers de tenir compte des contrats passés en dehors de lui. C'est un choix de politique juridique, qui peut conduire à des solutions très nuancées. On peut encore citer un jugement du tribunal de Luxembourg qui, à propos de la violation d'une clause de non-concurrence, rappelle que « s'il est vrai que les contrats n'ont pas d'effet obligatoire envers les tiers, ils leurs sont néanmoins opposables, en ce sens qu'ils constituent pour les tiers une situation de fait dont ils ne peuvent, sans commettre de faute, entraver l'accomplissement. Ainsi, le tiers à un contrat qui, en connaissance de cause, s'est associé à la méconnaissance par une partie, des obligations créées par le contrat, est constitué en faute et commet un acte contraire aux usages »[2176].

972. Conditions de la responsabilité du tiers complice. Dans tous les cas, la condition minimum pour qu'on puisse retenir la responsabilité du tiers est qu'il ait eu connaissance du contrat à la violation duquel il a participé[2177]. Contrairement à ce qui a été observé pour les contrats constitutifs ou générateurs de droits réels, il n'existe pas, ici, de système de publicité qui commanderait, automatiquement, l'opposabilité du contrat. Il appartient au contractant qui veut engager la responsabilité du tiers de prouver, par tous moyens, que celui-ci connaissait le contrat ou la clause qui interdisait au débiteur de l'obligation de contracter avec ce tiers. Dans certains cas, cette preuve sera relativement facile à apporter, compte tenu des pratiques qui existent et qui sont notoires dans tel ou tel secteur économique : il est difficile à un grand distributeur exploitant une chaîne d'hypermarchés, par exemple, d'ignorer que les parfums de marque sont revendus à l'intérieur d'un réseau de distribution sélectif. Plus largement, aux cas où le tiers a eu effectivement connaissance du contrat au moment où il a lui-même contracté, on assimilera ceux où il aurait dû le connaître s'il avait pris un minimum de renseignements[2178].

La simple connaissance est-elle suffisante ? Dans un premier temps, la Cour de cassation belge exigeait une fraude « qualifiée » au droit du cocontractant, une intention de nuire[2179], mais elle se contente aujourd'hui d'une « fraude simple », déduite de « la connaissance qu'il (le tiers) avait ou devait avoir de la situation existante » et de « la collaboration qu'il a néanmoins apportée à la violation des obligations contrac-

[2176] Trib. Luxembourg, 22 novembre 2007, n[os] 64004, 64393, 67538 et 91908.

[2177] Trib. Luxembourg, 22 novembre 2007, préc.

[2178] Voy. p. ex. dans la jurisprudence belge : Cass. be., 28 novembre 2002, n° C.01.0532.F.

[2179] Cass. be., 24 novembre 1932, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

tuelles »[2180]. On ne trouve pas l'équivalent d'une telle formule dans la jurisprudence française ni dans la jurisprudence luxembourgeoise, mais la nécessité d'une collaboration à la violation des obligations contractuelles pourrait expliquer les solutions en matière de réseaux de distribution sélective : seul peut être sanctionné le tiers qui se procure les produits auprès d'un membre du réseau violant ses propres obligations contractuelles, non celui qui se procure les produits à l'étranger auprès de distributeurs qui ne sont pas eux-mêmes tenus à l'exclusivité.

973. Nature et effets de la responsabilité du tiers complice. Encore que cela ait été autrefois discuté, il est bien admis aujourd'hui que la responsabilité du tiers complice de la violation d'une obligation contractuelle est une responsabilité délictuelle (extracontractuelle) fondée sur l'article 1382 du Code civil[2181] : le tiers est condamné, non parce qu'il a manqué à une *obligation* contractuelle – dont il n'est pas personnellement débiteur – mais parce qu'il a violé une norme générale de comportement qui impose à toute personne le *devoir* de ne pas participer consciemment à la violation des contrats passés par autrui, ce qui constitue une faute au regard de l'article 1382 du Code civil. Le caractère délictuel de la responsabilité concilie ainsi cette responsabilité avec le principe de l'effet relatif.

Cette responsabilité se traduit normalement par l'octroi de dommages et intérêts au contractant victime de l'inexécution (l'employeur victime de la violation de la clause de non-concurrence, le fabricant victime de la distribution hors réseau, le bénéficiaire de la promesse de vente frustré du bien qu'il comptait acquérir, etc.). On se demande si on peut aller jusqu'à une réparation en nature, permettant au contractant victime d'obtenir l'annulation du contrat passé en violation de son droit. Le problème se pose tout particulièrement en cas de promesse de vente : la jurisprudence belge antérieure à 2023 admettait la nullité du contrat passé en violation d'une promesse de vente[2182], à la différence de la jurisprudence française qui estimait, avant la réforme, que cette violation ne pouvait être sanctionnée que par des dommages et intérêts, même à la charge du promettant[2183]. On a vu en revanche que la Cour de cassation française avait admis qu'une vente conclue avec un tiers au mépris d'un pacte de préférence pouvait être sanctionnée, non seulement par la nullité de la vente, mais par la substitution du bénéficiaire au tiers acquéreur, si celui-ci connaissait l'existence du pacte

[2180] Cass. be., 22 avril 1983, préc.
[2181] Trib. Diekirch, 9 décembre 1931, préc.
[2182] Cass. be., 30 janvier 1965, *Pas. be.*, 1965, I, p. 538.
[2183] Voy. *supra*, n° 185.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir[2184]. Cette solution a été consacrée par le nouvel article 1123 du Code civil français, mais l'article 1124, brisant la jurisprudence antérieure, consacre désormais une solution proche pour la promesse unilatérale : « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul », sans aller toutefois jusqu'à la possibilité de substitution du bénéficiaire dans les droits du tiers. Le nouveau droit belge, lui, consacre à la fois pour le pacte de préférence et pour le contrat d'option (promesse unilatérale) à la fois la possibilité de faire annuler le contrat passé avec le tiers et de lui substituer le bénéficiaire (C. civ. be., art. 5.26). Dans les cas où la violation de l'obligation contractuelle se traduit par une activité continue du tiers (par exemple, la vente de parfums en supermarché), il semble acquis que le tiers puisse se voir interdire, au besoin sous astreinte, de continuer son activité illicite.

§ 2. Les limites de l'opposabilité

974. Intérêt des tiers. Dans un certain nombre de cas, la loi permet aux tiers d'écarter l'application à leur égard d'un acte qui leur serait normalement opposable. Il en va ainsi en cas de simulation (**A**) ou en cas de fraude, par la voie déjà exposée de l'action paulienne (**B**).

A) *La simulation*

975. Notion. Pour différentes raisons – qui ne sont pas toujours très honnêtes – les parties à un contrat peuvent choisir de dissimuler l'existence, la nature ou les conditions de leur contrat aux yeux des tiers. Elles vont alors passer un acte apparent, qui dissimulera leur véritable intention, exprimée dans un acte secret appelé contre-lettre. La simulation peut porter sur l'existence même du contrat : par exemple, pour échapper à mes créanciers, je fais semblant de vendre un tableau de valeur dont je suis propriétaire (acte apparent) ; mais, secrètement, je conviens avec mon acheteur qu'il n'y a aucune vente (acte secret ou contre-lettre). La simulation peut consister aussi dans un déguisement de la nature de l'acte : pour échapper aux droits d'enregistrement importants en cas de donation d'un bien, ou pour éviter d'exciter la jalousie d'autres personnes, le donateur fait semblant, par l'acte apparent, de vendre un bien au

[2184] Voy. *supra*, n° 193.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

donataire ; mais par une contre-lettre, il est convenu que le prétendu acheteur ne paiera par le prix. C'est ce qu'on appelle une donation déguisée. Dans la même optique, mais en sens inverse, pour éviter à un acheteur de payer des droits de mutation importants, les parties à un contrat de vente conviennent parfois de dissimuler au fisc une partie du prix : le prix indiqué dans l'acte de vente sera par exemple de 500 000 €, mais il est convenu que l'acheteur paiera en plus « sous la table » 100 000 €. Ici la simulation porte sur les conditions du contrat. On connaît enfin des cas de simulation qui portent sur la personne d'un des contractants : pour éviter de faire savoir aux tiers qu'on est devenu propriétaire de tel ou tel bien, ou parce qu'on n'a pas le pouvoir d'en devenir acquéreur[2185], on convient que le bien sera, en apparence, vendu à un tiers (prête-nom) ; celui-ci, en secret, rétrocédera le bien à son véritable acheteur. On parle ici d'interposition de personne[2186].

976. Analyse. La simulation est un mécanisme délicat à analyser. On le présente souvent comme la juxtaposition de deux contrats : un contrat apparent, ostensible, et un contrat occulte. En réalité, au moins dans l'hypothèse où la simulation ne fait pas intervenir un tiers interposé, on devrait plutôt considérer qu'il n'y a entre les parties qu'un seul contrat, au sens de *negotium*, ce qui est convenu entre les parties : les parties conviennent de l'acte réel (une donation, une vente à un certain prix) et, dans leur convention, elles prévoient la dissimulation de sa nature ou de ses conditions réelles (la donation sera présentée comme une vente, une partie du prix sera dissimulée). S'il y a dualité d'actes, c'est seulement sur le plan des actes instrumentaires : l'acte mensonger dressé pour constater la convention sera doublé, éventuellement, par un acte secret (qui, parfois, sera seulement une convention orale entre les parties). Parfois, dans le cas du contrat purement fictif, la convention entre les parties n'aura pas pour effet de créer des droits et des obligations, mais seulement de prévoir la rédaction d'un acte mensonger faisant croire à la conclusion d'un contrat qui n'est pas passé en réalité. Ce n'est que dans le cas d'interposition de personne qu'il y aura effectivement deux contrats : un contrat passé entre les deux vraies parties à l'acte, et un contrat passé entre

[2185] P. ex. parce qu'on travaille dans un établissement pour personnes âgées, et qu'on veut acheter la maison d'un des pensionnaires de l'établissement, ce qu'interdit l'article 1125-1 du Code civil.

[2186] Cour d'appel, 12 novembre 2003, *Pas.*, 32, p. 451.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

celles-ci (ou l'une d'elles) et la personne qui servira de prête-nom. L'*instrumentum* mensonger lui, sera dressé entre le prête-nom et l'une des parties[2187].

977. Régime juridique. On peut hésiter quant à la manière dont le système juridique doit traiter la simulation. D'un côté, c'est un mensonge, une tromperie, qui est souvent inspirée par des mobiles illicites ou immoraux, et qui crée dans tous les cas une apparence trompeuse pour les tiers. Mais d'un autre côté, la simulation n'est pas toujours un instrument de fraude : certaines simulations peuvent simplement avoir pour but de préserver la paix des familles ou de ne pas révéler une opération à des concurrents. Et, dans ces hypothèses, il paraît logique, dans un système consensualiste, de s'attacher à ce que les parties ont réellement voulu, qu'elles aient exprimé leur volonté d'une manière ostensible ou non, sauf à ce que les tiers ne souffrent pas de cette dissimulation. Le Code civil tranche la difficulté de manière équilibrée, en prévoyant, à l'article 1321, que « les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers ». Il faut donc distinguer les effets de la simulation entre les parties (**1**) et à l'égard des tiers (**2**).

1) *Les effets de la simulation entre les parties*

978. Principe : validité de la convention de simulation. Dans une optique consensualiste, qui permet aux parties d'exprimer leur volonté de n'importe quelle manière, on estime traditionnellement que la simulation n'est pas, en soi, interdite : les parties sont libres d'exprimer leur volonté de manière ostensible ou de la cacher aux yeux des tiers – sauf à ce que, comme nous le verrons plus loin les tiers ne puissent pas se voir opposer l'accord tenu secret. Il en résulte que la simulation n'est pas, en elle-même, une cause de nullité de l'accord des parties, tel qu'il résulte de la contre-lettre anéantissant ou corrigeant l'acte apparent. C'est ce qu'exprime implicitement la première partie de l'article 1321 du code civil (Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes). Le nouvel article 1201 du Code civil français pose de même que « Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre,

[2187] Cour d'appel, 11 février 2015, n° 39648 ; Cour d'appel, 17 février 2016, n°s 40439 (à propos d'ouvertures de comptes bancaires par un prête-nom).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

produit effet entre les parties »[2188]. De même, l'article 5.39 du nouveau Code civil belge prévoit sobrement que « [l]a contre-lettre prévaut entre les parties ».

979. Conséquences Il résulte de la validité de principe de la simulation que, si une des parties prétendait à l'application de l'acte apparent, l'autre pourrait s'y opposer en révélant la contre-lettre. Par exemple, le bénéficiaire d'une donation déguisée en vente pourrait s'opposer au paiement du prix que lui réclamerait le pseudo-vendeur en faisant état de l'acte secret prévoyant qu'aucun prix ne serait payé. En principe, cependant, entre parties, la preuve de la contre-lettre ne peut pas être faite par tous moyens : dès lors que l'acte ostensible aura été établi par écrit, la preuve de l'acte secret devra être elle-même apportée par écrit, conformément à l'article 1341 du Code civil selon lequel « il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes »[2189].

Même lorsqu'elle est en elle-même licite, la simulation ne saurait faire échapper l'acte aux conditions de validité du contrat que les parties ont voulu passer. Il conviendra alors d'appliquer, entre les parties, les conditions propres à l'acte requalifié conformément à la contre-lettre : si par exemple, les parties ont déguisé une donation sous une vente, il faudra, pour savoir si l'acte est valable, appliquer les règles de capacité et de pouvoir propres aux donations, généralement plus exigeantes que celles requises en matière de vente. Le contrat pourra être annulé, par exemple, si la donation déguisée a été faite par une personne qui était frappée d'une incapacité de disposer à titre gratuit ou à l'inverse à une personne qui était incapable de recevoir à titre gratuit. La simulation permet seulement dans ce cas d'écarter le formalisme spécifique des donations, en évitant la rédaction d'un acte authentique. Il en va de même dans les cas d'interposition de personnes : si la loi interdit à telle ou telle personne de passer tel ou tel contrat, le contrat passé par une personne qui agit de manière occulte pour le compte de la personne frappée de l'interdiction sera tout aussi nul. L'article 911 du Code civil édicte ici clairement que « toute disposition au profit d'un incapable est nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées ». Les textes facilitent ici la preuve de la simulation en édictant des présomptions d'interposition de personne[2190]. Il faut bien noter que ces solutions ne sont pas des exceptions à la validité de la simulation : la nullité ne provient pas ici de ce que l'acte a été simulé, mais du non-respect des conditions de validité posées pour cet acte[2191].

980. Exceptions : les simulations frauduleuses. Très différents sont les cas où c'est le fait de dissimuler qui, parce que la dissimulation est inspirée par un souci de fraude, entraîne la nullité d'un acte qui serait parfaitement valable s'il avait été

[2188] Comp. PDEC, art. 6:103 « Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule leur véritable accord, c'est l'accord caché qui prévaut entre elles ».

[2189] Voy. *supra*, n° 421.

[2190] C. civ., art. 911, al. 2, et art. 1125-1, al. 2.

[2191] Dans ce sens : Flour, Aubert, Savaux 2022, n° 609.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

passé de manière ostensible. L'exemple typique est celui du « dessous de table », c'est-à-dire de la dissimulation d'une partie du prix d'une vente dans le but de faire échapper l'une ou l'autre partie au paiement de droits fiscaux afférents à la totalité du prix. Le droit commun des contrats conduirait à la nullité absolue de la convention de simulation, sur le fondement de l'article 1131 du code civil relatif à la cause illicite, mais, au Luxembourg (comme d'ailleurs en France et en Belgique), ce type de pratiques est appréhendé par une loi spéciale, la loi du 28 janvier 1948, aux termes de laquelle « Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d´une vente d´immeubles et tout ou partie de la soulte d´un échange ou d´un partage comprenant des biens immeubles ». Cette nullité est une nullité absolue[2192]. Le texte est interprété comme entraînant seulement la nullité de la contre-lettre, ce qui est une sanction beaucoup plus efficace que celle qui consisterait à faire tomber l'ensemble de la vente. Les parties sont alors tenues par l'acte apparent, ce qui signifie que le vendeur devra se contenter du prix minoré fixé dans cet acte, et devra éventuellement restituer le dessous de table qu'il aurait déjà perçu[2193]. Les deux parties seront en outre condamnées solidairement à une amende fiscale égale au montant dissimulé. Pour renforcer l'efficacité de la sanction, le texte prévoit que la preuve de la simulation peut être rapportée par tous moyens, par dérogation à l'article 1341 du Code civil.

2) *Les effets de la simulation à l'égard des tiers*

981. Option des tiers. En posant que les contre-lettres « n'ont point d'effet contre les tiers », l'article 1321 du Code civil indique explicitement que l'acte secret, alors même que c'est lui qui exprime la volonté des parties, est inopposable aux tiers. Ceux-ci peuvent, s'ils y ont intérêt, s'en tenir à l'acte apparent. Par exemple, si un bien a fait l'objet d'une vente fictive, les créanciers de l'acheteur peuvent saisir ce bien dans le patrimoine de celui-ci, sans qu'on puisse leur opposer qu'en réalité, le bien n'a jamais été vendu et est resté dans le patrimoine du prétendu vendeur[2194]. Mais en même temps, le texte n'interdit nullement aux tiers qui y auraient intérêt de se prévaloir de l'acte secret. Ainsi, dans le même exemple, les créanciers du prétendu vendeur, qui voudraient saisir le bien, peuvent intenter une *action en déclaration de simulation* pour faire tomber l'acte apparent, et démontrer qu'en réalité le bien est resté dans le patrimoine de leur débiteur. Contrairement à ce qui a été relevé dans les relations entre les parties, cette démonstration peut être faite par tous moyens, l'exigence de preuve par écrit ne s'imposant pas aux tiers, qui sont dans l'impossibilité de produire un écrit établi

[2192] Cour d'appel, 19 décembre 2000, n° 23.823.

[2193] Cour d'appel, 28 mars 2012, *Pas.*, 35, p. 704, note P. ANCEL. L'arrêt juge par ailleurs que la demande en restitution du prix ne peut pas être paralysée par la règle « *Nemo auditur* » ; Trib. Luxembourg, 8 novembre 2023, n° TAL-2019-07078.

[2194] Voy. ainsi dans le contexte d'une faillite de l'acheteur apparent : Cour d'appel, 27 juin 1933, *Pas.*, 13, p. 87.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

en dehors d'eux[2195]. De même, les héritiers d'un prétendu vendeur peuvent démontrer par tous moyens que la vente dissimule une donation, pour faire rapporter la valeur du bien donné à la succession, et, éventuellement, pour faire réduire la donation si elle porte atteinte à leur réserve[2196]. Les solutions de l'article 1321 sont reprises par le nouvel article 1201 du Code civil français, ainsi que par l'article 5.39 du nouveau Code civil belge, qui réserve cependant le choix aux tiers de bonne foi.

En raison de cette option reconnue aux tiers, on peut assister à un conflit entre un tiers qui se prévaut de l'acte apparent et un tiers qui se prévaut de la contre-lettre – par exemple le créancier d'un faux acheteur et le créancier d'un faux vendeur qui veulent tous deux saisir le bien prétendument vendu. Dans une telle hypothèse, la jurisprudence française a donné la préférence au tiers qui se prévaut de l'acte apparent – le créancier de l'acheteur dans l'exemple donné – et contre qui, selon la lettre de l'article 1321 du Code civil, la contre-lettre ne saurait avoir d'effet[2197].

B) *L'action paulienne*

982. **Renvoi.** Une autre limite importante à l'opposabilité du contrat aux tiers est constituée par le mécanisme déjà étudié de l'action paulienne[2198]. L'hypothèse est qu'un débiteur a passé un acte qui l'appauvrit (vente ou donation) dans le but de faire échapper un bien aux poursuites de ses créanciers ou de l'un d'eux. Ceux-ci peuvent alors sur le fondement de l'article 1167 du Code civil, attaquer l'acte frauduleux. Comme on l'a vu, l'action paulienne n'aboutit pas à l'annulation de l'acte,

[2195] Assez curieusement, la Cour d'appel a considéré comme tiers l'acquéreur réel d'un bien qui avait été acquis en apparence par une autre personne qui avait servi de prête-nom (Cour d'appel, 12 novembre 2003, 32, p. 451). Pourtant la contre-lettre avait été passée entre l'acquéreur fictif et l'acquéreur réel, ce qui faisait de celui-ci une partie à l'acte.

[2196] Lorsqu'une donation est faite à un héritier potentiel, elle est considérée par principe comme étant faite « en avancement d'hoirie », c'est-à-dire comme une avance sur la part de succession à laquelle l'héritier aura droit au moment du décès du donateur. À ce moment, il faudra « rapporter » le bien donné, ou du moins sa valeur, dans l'actif de la succession, pour déterminer quelle doit être la part de chacun, et la valeur du bien donné s'imputera sur la part du donataire. Si le bien est donné à un tiers ou à un héritier mais dans le but de l'avantager (donc par une donation non rapportable), il faudra vérifier, au moment de l'ouverture de la succession, que cette donation ne porte pas atteinte à la réserve, c'est-à-dire à la part minimum de la succession à laquelle ont droit certains héritiers proches (notamment les enfants). Si c'était le cas, la donation serait « réduite », c'est-à-dire que son bénéficiaire devrait reverser à la succession de la valeur du bien donné. Bien que d'une manière générale, les héritiers soient considérés comme des parties aux contrats passés par la personne à qui ils succèdent, ils sont, lorsqu'ils demandent le rapport ou la réduction, traités comme des tiers, parce qu'ils agissent en vertu d'un droit qui leur est personnel. Ils peuvent donc prouver la simulation par tous moyens.

[2197] Cass. fr. (1re civ.), 22 février 1983, nº 81-16061.

[2198] Voy. *supra*, nos 729 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

elle rend simplement l'acte inopposable au(x) créancier(s) qui l'exerce(nt). C'est donc bien une limite à l'opposabilité des contrats passés par le débiteur, et certainement pas, comme la place de l'article 1167 du Code civil le laisse croire, une limite à l'effet relatif des contrats.

L'action paulienne doit être distinguée de l'action en déclaration de simulation qui vient d'être exposée. Le créancier qui exerce l'action paulienne ne cherche pas à montrer que l'acte passé par son débiteur est fictif ou mensonger, il allègue simplement qu'il a été fait dans le but de porter atteinte à ses droits. Parfois cependant, le créancier peut avoir le choix entre les deux actions : en présence d'une donation faite par le débiteur à ses enfants, le créancier pourrait démontrer que cette donation est fictive, le donateur ayant en réalité conservé la propriété du bien, ou que, en la considérant comme réelle, elle avait pour seul but de faire échapper le bien donné aux poursuites de ses créanciers.

SOUS-SECTION 2. L'OPPOSABILITÉ DU CONTRAT PAR LES TIERS

983. Principe. Il est fréquent qu'un tiers ait intérêt à se prévaloir d'un contrat qui a été passé en dehors de lui, parce que ce contrat constitue un élément au soutien d'une prétention qu'il forme contre un des contractants, ou d'une défense contre une prétention de celui-ci. Cette idée fait l'objet, depuis longtemps, de multiples applications qui ne suscitent guère de difficultés (**§ 1**). Mais, dans la jurisprudence récente, en France et au Luxembourg, elle a également été utilisée, de manière très contestable, pour fonder la responsabilité d'un contractant à l'égard d'un tiers victime de l'inexécution d'un contrat (**§ 2**).

§1. Applications traditionnelles

984. Diversité. Les applications traditionnelles de l'idée d'opposabilité du contrat par les tiers sont extrêmement diverses et sont rebelles à toute tentative de classification[2199]. Le premier arrêt rendu en Belgique sur la question, celui qui a servi de base à la théorie de l'opposabilité des effets externes d'un contrat, concernait précisément une hypothèse de ce type : un médecin, qui avait soigné un accidenté, et qui ne parvenait pas à se faire payer par son client, avait agi en enrichissement sans cause contre la compagnie d'assurance qui couvrait les dommages corporels de celui-ci ; il prétendait que, s'il n'avait pas prodigué les soins à l'accidenté, la compagnie d'assurance aurait eu à verser une indemnité plus importante à celui-ci. Le médecin se prévalait donc du contrat passé entre l'assureur et son client pour fonder sa prétention. La Cour de cassation admet qu'il

[2199] Voy. M. FONTAINE, *Effets internes et effets externes du contrat, op. cit.*

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

puisse le faire, au nom précisément de ce qu'on nommera plus tard en doctrine « l'opposabilité du contrat ». La même idée se retrouve dans de très nombreuses situations. Par exemple, l'article 1384, alinéa 5 du Code civil fait peser sur le « commettant » la responsabilité des dommages causés par son « préposé » ; pour engager la responsabilité d'une personne à ce titre, il faut établir l'existence d'un lien de préposition entre cette personne et l'auteur du dommage et pour cela, la victime peut s'appuyer sur les stipulations du contrat entre eux, alors même qu'elle n'y est pas partie. À l'inverse une personne responsable d'un dommage, pour limiter le montant de l'indemnisation qu'on lui demande au titre de l'incapacité de travail de la victime, pourra évidemment invoquer les dispositions du contrat de travail passé par cette victime avec son employeur pour établir le montant de la rémunération de cette victime, donc l'étendue exacte de son préjudice[2200]. De même, lorsqu'un fonds de commerce a été cédé à un prix tenant compte d'une indemnité compensant le préjudice résultant de troubles de voisinage affectant l'exploitation du fonds, le juge peut tenir compte de cette fixation du prix pour évaluer l'indemnité due par l'auteur des troubles, alors même que celui-ci est étranger au contrat de vente[2201].

985. Constantes. Au-delà de la diversité des espèces, on peut mettre en évidence deux règles communes. La première est que, pour pouvoir invoquer le contrat auquel il est étranger, le tiers devra en faire la preuve. Contrairement au cas inverse où c'est un des contractants qui se prévaut du contrat, cette preuve pourra se faire par tous moyens, sans respecter l'exigence de l'écrit posée par l'article 1341 du Code civil. C'est que le tiers, par hypothèse, n'avait pas la possibilité de se préconstituer la preuve écrite d'un contrat auquel il était étranger. Très souvent cependant le tiers aura besoin d'établir le contenu exact du contrat qu'il invoque ; il devra alors faire appel au juge pour qu'il enjoigne au contractant défendeur de produire l'écrit contractuel. La seconde règle est que, lorsque le tiers invoque un contrat auquel il est étranger, il doit le prendre tel qu'il est, dans les limites de ce qui a été convenu entre les parties, et il peut donc se voir opposer tous les moyens de défense que le contractant contre qui il agit pourrait opposer à son cocontractant. On voit là une nouvelle preuve de ce que l'opposabilité du contrat n'est pas celle d'un simple « fait », mais bien de la norme contractuelle

[2200] Cass. be., 23 mai 1960, *Pas. be.*, 1960, I, p. 1094.
[2201] Cass. be., 27 janvier 1994, n° C930057F.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

elle-même, telle qu'elle a été convenue entre les parties. On en a une parfaite illustration avec l'arrêt belge de 1909, où la Cour de cassation, tout en estimant par principe que le médecin pouvait invoquer le contrat d'assurance souscrit par son client, juge en l'espèce la prétention du médecin infondée, parce que le contrat d'assurance ne couvrait précisément pas le paiement des frais médicaux. Il en va cependant autrement dans le cadre de l'application très contestable que la jurisprudence luxembourgeoise fait aujourd'hui, sur le modèle français, de l'idée d'opposabilité du contrat par les tiers, sur la question de la responsabilité d'un contractant à l'égard des tiers.

§ 2. Une application contestable : la responsabilité d'un contractant à l'égard des tiers

986. Effet relatif versus opposabilité. L'hypothèse est inverse de celle qui a été précédemment examinée, au sujet de la responsabilité du tiers qui se rend complice de la violation d'une obligation contractuelle : ici c'est une partie à un contrat qui n'a pas exécuté son obligation vis-à-vis de son cocontractant, et qui, ce faisant, a causé un dommage à un tiers. Ce tiers peut-il obtenir réparation de la part de celui qui a manqué à ses obligations ? Oui, sans doute, mais normalement, par application du principe de l'effet relatif, il ne le peut que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, puisque le contractant n'était pa obligé envers lui[2202]. Se pose alors la question de savoir si, pour obtenir réparation sur ce fondement, il doit prouver une faute délictuelle en quelque sorte détachable du contrat – c'est-à-dire, au-delà de la seule inexécution du contrat, un manquement à un devoir de prudence qui s'impose à l'égard de toute personne – ou s'il peut, en se prévalant du contrat, se contenter de prouver le manquement contractuel. Quelques exemples permettront de comprendre le problème. Une personne décède dans un accident de transport. Le transporteur avait, on le sait, à l'égard de cette personne, une obligation de sécurité de résultat, dont le passager aurait pu se prévaloir s'il avait été simplement blessé. Mais, comme il est décédé, ce sont ses proches qui, en tant que victimes par ricochet, subissent le préjudice. Ce sont des tiers au contrat. Peuvent-ils alors demander réparation au transporteur en se prévalant du manquement à l'obligation de résultat de celui-ci, ce qui les dispenserait de prouver sa faute ? À première vue, cela semble impossible, car les

[2202] Sur ce principe, voy. *supra*, n° 959.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

proches, n'étant pas parties au contrat, ne sont pas créanciers de l'obligation de sécurité. S'ils peuvent agir contre le transporteur, c'est, semble-t-il, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ce qui suppose de prouver une faute du transporteur. C'est ce que semble dicter le principe de l'effet relatif. Mais la solution semble bien peu opportune : est-il normal que le transporteur soit mieux traité lorsque son passager décède que lorsqu'il est simplement blessé ? Un autre exemple est celui d'un vendeur qui manque à son obligation de délivrer l'immeuble vendu dans les délais fixés. Cet immeuble devait être loué par l'acheteur à une entreprise. Celle-ci ne peut pas s'installer à temps, et subit un grave préjudice commercial. L'entreprise peut-elle demander réparation au vendeur en invoquant le retard dans la livraison ? Certes, elle n'est pas personnellement créancière de l'obligation de délivrance au moment prévu, et il semble qu'elle ne pourrait obtenir réparation que si elle prouvait que le manquement contractuel du vendeur est objectivement fautif (principe de l'effet relatif). Mais d'un autre côté, cet entrepreneur, étant directement intéressé à la bonne exécution du contrat passé par l'acheteur, ne pourrait-il, en invoquant la notion d'opposabilité, se prévaloir de ce manquement pour obtenir plus facilement réparation ? Ou encore : un bailleur d'un immeuble à usage commercial n'entretient pas l'immeuble comme il devrait le faire ; ce faisant, il cause un dommage, non à son locataire qui a loué le fonds de commerce, mais au locataire du fonds qui se trouve empêché d'accéder normalement aux locaux où le commerce est exploité. Ce locataire peut-il, pour obtenir des dommages et intérêts de la part du bailleur – avec lequel il n'a aucun lien contractuel – se prévaloir du manquement par le bailleur à ses obligations contractuelles envers son locataire[2203] ?

987. Solutions en France et en Belgique. Le problème se pose depuis longtemps en France, et la jurisprudence française a considérablement évolué. Jusqu'à une période récente, la Cour de cassation estimait que le tiers ne pouvait pas se prévaloir du seul manquement au contrat, dans la mesure où ce n'était pas envers lui que l'obligation a été souscrite[2204]. Le tiers ne pouvait obtenir

[2203] C'étaient les faits qui avaient donné lieu à l'arrêt d'Assemblée plénière de 2006 qui a fixé la jurisprudence française. Voy. *infra*, n° 987.

[2204] Il n'en allait autrement que dans les cas où on pouvait considérer que le tiers avait été associé au contrat par le biais d'une stipulation pour autrui tacite : il avait alors la possibilité, en acceptant cette stipulation, d'agir contre le contractant ayant manqué à son obligation sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Telle était, on le verra, l'astuce utilisée au profit des victimes par ricochet des accidents de transport. Voy. *infra*, n° 1089.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

réparation que s'il prouvait que le comportement du tiers était en même temps, et indépendamment de l'inexécution contractuelle, une faute délictuelle[2205], ou, dans une période plus récente, un manquement au devoir général de ne pas nuire à autrui[2206]. Telle est toujours la position de la Cour de cassation belge, qui juge régulièrement que « celui qui commet une faute contractuelle à l'égard d'un tiers peut être extracontractuellement responsable lorsque son manquement à ses obligations contractuelles constitue, simultanément et indépendamment du contrat, une violation de l'obligation générale de prudence s'imposant à tous »[2207]. Mais en France, après une longue période d'incertitudes et de divergences entre les chambres de la Cour de cassation, l'Assemblée plénière a finalement affirmé en 2006 que « un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage »[2208]. Cela revient à dire que la seule inexécution d'une obligation contractuelle constitue une faute délictuelle à l'égard des tiers. Bien qu'elle ait fait l'objet de nombreuses critiques, cette solution a été réitérée par un nouvel arrêt d'Assemblée plénière de 2020, qui se fonde curieusement sur le principe, tiré de l'ancien article 1165 du Code civil, selon lequel le contrat ne peut pas nuire aux tiers, de sorte qu'il importe de ne pas entraver l'indemnisation des dommages subis par un tiers du fait d'un manquement contractuel. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement[2209].

Cette assimilation du manquement contractuel à une faute délictuelle, qu'on a parfois tenté de justifier au nom de l'opposabilité du contrat par les tiers, a été très généralement critiquée par la doctrine française. Il est en effet très difficile de voir dans cette assimilation une simple manifestation de l'opposabilité du contrat. Le tiers ne se contente pas ici de se prévaloir de ce que l'auteur du dommage

[2205] Voy. p. ex. : Cass. fr. (1re civ.), 9 octobre 1962, *Bull. civ.*, I, n° 405 ; Cass. fr. (1re civ.), 23 mai 1978, n° 76-11663.

[2206] Voy. p. ex. Cass. (comm.), 8 octobre 2002, n° 98-22858, *JCP*, 2003, I, p. 152, n° 3, obs. G. VINEY.

[2207] Voy. en dernier lieu Cass. be., 25 octobre 2012, n° C.120079.F.

[2208] Cass. fr. (ass. plén.), 6 octobre 2006, n° 05-13255. Parmi les innombrables commentaires suscités par cet arrêt, on pourra se référer à ceux qui sont parus dans le numéro spécial que la *Revue des contrats* a consacré à la question (2007/2) pp. 537 et s.

[2209] Cass. fr. (ass. plén.), 13 janvier 2020, n° 17-19.963 P.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

est tenu d'une obligation à l'égard de son cocontractant, il prétend que cette obligation à l'égard du cocontractant est également un devoir envers lui. Il se présente donc, d'une certaine manière, comme créancier de l'obligation contractuelle, ce qui paraît être une méconnaissance flagrante du principe de l'effet relatif.

988. Solutions luxembourgeoises. En dépit de ces critiques, la jurisprudence luxembourgeoise a très vite emprunté le pas de la Cour de cassation française, en reprenant textuellement la formule de l'arrêt de 2006. Dans un arrêt du 2 juillet 2008, la Cour d'appel admet ainsi qu'un agent immobilier peut obtenir des dommages et intérêts de la part de l'acquéreur d'un immeuble, qui, ayant manqué à ses obligations envers le vendeur, avait été à l'origine de la résolution amiable du contrat, et ainsi privé l'agent de sa commission[2210]. Peu de temps après, elle a jugé que le liquidateur d'une entreprise de construction, condamné à indemniser le maître de l'ouvrage pour avoir trop rapidement clôturé la liquidation, pouvait se retourner contre le sous-traitant de l'entrepreneur qui avait mal exécuté les travaux qui lui avaient été confiés et qui avait été à l'origine de la faillite de l'entrepreneur[2211]. Dans ces deux cas on voit bien un tiers (l'agent immobilier, le liquidateur) agir en responsabilité contre une partie à un contrat auquel il est étranger (l'acheteur, le sous-traitant) pour obtenir des dommages et intérêts en invoquant le fait que cette partie a manqué à ses obligations envers son cocontractant. Tout comme la solution française dont elle s'inspire, cette position de la Cour d'appel a suscité une certaine réticence dans la doctrine luxembourgeoise[2212]. Ces critiques ont peut-être amené la Cour à nuancer sa position. Dans un arrêt de 2015, tout en prétendant s'appuyer sur une évolution de la jurisprudence française, elle juge en effet, tout en maintenant « qu'une faute contractuelle puisse également constituer une faute délictuelle à l'égard d'un tiers au contrat », qu'il faut « distinguer à cet égard entre l'inexécution d'une obligation qui se limite au cercle des contractants et celle d'une obligation qui par son objet même intéresse les tiers ». En se fondant sur cette distinction, elle rejette l'action en réparation d'une société qui se prétendait victime du manquement par une banque à son obligation d'information dans le cadre d'investissements réalisés par son fondateur et gérant et qui s'étaient

[2210] Cour d'appel, 2 juillet 2008, *BIJ*, 2008, p. 152.
[2211] Cour d'appel, 9 octobre 2008, *Pas.*, 34, p. 281.
[2212] Poelmans, p. 214 ; Ravarani, n° 500.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

révélés complètement ruineux pour celui-ci, et pour la société à qui les titres acquis avaient été transférés. Dès lors que le contrat avait été passé entre la banque et la personne physique, la société était un tiers et, pour la Cour d'appel, elle ne pouvait se prévaloir d'une prétendue violation par la banque de son devoir d'information à l'égard du cocontractant. Il lui appartenait « d'établir que la faute reprochée à l'intimée constitue, indépendamment du contrat, soit un manquement à une règle légale ou réglementaire, soit une imprudence ou négligence abstraction faite de la convention. La faute invoquée par le tiers à l'appui de son action en responsabilité délictuelle doit se distinguer de l'inexécution proprement dite du contrat et être détachable ou indépendante de celui-ci »[2213]. Ainsi, sans remettre en cause le principe d'une assimilation possible entre le manquement contractuel et la faute délictuelle, l'arrêt en limite singulièrement le champ d'application aux obligations qui « par leur objet même intéressent les tiers » – notion qu'il faudrait évidemment préciser. Bien que réitérée à deux reprises depuis dans des affaires similaires[2214], cette position semble cependant minoritaire au sein de la Cour d'appel, car de nombreux arrêts récents ont réaffirmé la position originaire, calquée sur celle de la jurisprudence française, en assimilant sans nuance le manquement contractuel à une faute délictuelle[2215].

989. Régime de l'action en réparation du tiers. De prime abord, parce que le tiers demande réparation de son dommage sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il ne peut pas se voir opposer les limitations de responsabilité qui résultent du contrat vis-à-vis du cocontractant[2216]. Par exemple, si le contrat contenait une clause limitative de responsabilité, cette clause, en vertu de l'effet relatif, n'est pas applicable au tiers victime. Du coup, l'assimilation du manquement contractuel à la faute délictuelle, déjà critiquable en elle-même, conduit à des résultats parfaitement contestables, qui ne correspondent en aucun cas à ceux qui sont habituellement admis sur le terrain de l'opposabilité. Le tiers, en effet, dans la mesure où il peut invoquer le manquement contractuel à l'appui de sa prétention, bénéficie de tous les avantages que procure la

[2213] Cour d'appel, 27 mai 2015, n° 40384, *JN Obligations*, 2016, n° 3, pp. 13-15, note O. POELMANS.
[2214] Cour d'appel, 17 février 2016, n° 40439 ; Cour d'appel, 9 janvier 2019, n° 44685.
[2215] Cour d'appel, 25 octobre 2017, n° 40026 ; Cour d'appel, 10 juillet 2019, n° CAL-2018-00332 ; Cour d'appel, 31 mai 2022, n° CAL-2021-00407 ; Cour d'appel, 11 octobre 2023, n° CAL-2022-00850.
[2216] POELMANS, p. 214.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

responsabilité contractuelle (et notamment la dispense de prouver la faute si l'obligation contractuelle était de résultat). Mais en même temps, parce que l'action est fondée sur l'article 1382 du Code civil, il n'en supporte aucun des inconvénients. Il a, en quelque sorte, à la fois « le beurre et l'argent du beurre ». Sensible à ces inconvénients, la chambre commerciale de la Cour de cassation française a, dans un arrêt récent, jugé que « [p]our ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ». La Cour casse en conséquence l'arrêt d'appel qui avait déclaré inopposable au tiers victime la clause limitative de responsabilité contenue dans le contrat inexécuté[2217]. Cette position paraît raisonnable, mais elle paraît difficile à concilier avec la jurisprudence de l'Assemblée plénière – que l'arrêt ne remet pas en cause – qui affirme le caractère délictuel de l'action du tiers victime.

990. Évolution souhaitée. On peut penser que, si on veut étendre aux tiers – ou du moins à certains tiers – le bénéfice d'obligations contractuelles stipulées au départ au profit d'un cocontractant particulier, il vaudrait mieux utiliser franchement la voie contractuelle. C'est ce que faisait la jurisprudence française au temps où elle faisait bénéficier les proches des passagers décédés dans un accident de transport d'une stipulation pour autrui tacite leur permettant de profiter de l'obligation de sécurité dont le passager était le premier créancier[2218]. Le projet Catala avait proposé de généraliser cette solution, en ouvrant systématiquement au tiers victime de l'inexécution contractuelle une option entre la responsabilité délictuelle (à condition de prouver une faute indépendante du manquement contractuel, comme c'est le cas en Belgique) et la responsabilité contractuelle (sauf alors à se voir opposer toutes les conditions et toutes les limitations de responsabilité stipulées au contrat). La solution – reprise en substance par le projet ministériel français de réforme de la responsabilité civile de 2017 – était bonne dans son

[2217] Cass. fr. (comm.), 3 juillet 2024, n° 21-14.947 B.
[2218] Voy. *infra*, n° 1089.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

principe, mais il serait sans doute sage d'en limiter l'application à certains contrats, et à certains tiers spécialement intéressés par le contrat (on pense en particulier aux victimes par ricochet). C'est ce que fait la jurisprudence allemande qui admet que, dans certains cas restrictivement définis, un contrat peut avoir un « effet protecteur pour les tiers » (*Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte*), ce qui permet aux tiers victimes de son inexécution d'agir contre le contractant qui a manqué à ses obligations sur le fondement de la responsabilité contractuelle[2219]. L'arrêt de la Cour d'appel de 2015, qui limitait l'assimilation des fautes aux cas où l'obligation contractuelle, « par son objet même intéresse les tiers »[2220] invitait à aller dans ce sens : plutôt que de dire que, dans un tel cas, l'inexécution de l'obligation contractuelle équivaut à une faute délictuelle, ne vaudrait-il pas mieux dire que le tiers apparaît comme un bénéficiaire de cette obligation contractuelle, assimilé en cas de manquement à cette obligation, à une partie au contrat ?

[2219] Pour une discussion plus approfondie, voy. P. ANCEL, « Le fondement contractuel ou délictuel de l'action », in N. FERRIER et A. PELISSIER (dir.), *L'entreprise face aux évolutions de la responsabilité civile*, Paris, Economica, 2012, pp. 75 et s., spéc. n°s 17 et s.

[2220] Cour d'appel, 27 mai 2015, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction entre l'effet relatif et l'opposabilité du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourg...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Chapitre II
La distinction des parties et des tiers

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

991. Complexité. Rien ne semble plus simple à première vue que de distinguer les parties au contrat – ceux qui l'ont conclu – des tiers. Les parties, ce sont les personnes qui ont conclu le contrat ou celles qui ont été représentées lors de cette conclusion. Les tiers, ce sont tous ceux qui n'ont été ni parties, ni représentés. Rien n'est plus complexe en réalité, et il ne faut pas s'étonner si cette question a fait l'objet, en particulier dans la doctrine française, de débats passionnés : on aborde ici un des aspects les plus confus et les plus évolutifs du droit des contrats. Cette complexité tient principalement à ce que la distinction, relativement simple au moment de la conclusion du contrat, n'est pas figée une fois pour toutes à ce moment et que de nombreuses personnes, tiers à l'origine, peuvent par la suite s'intégrer de manière plus ou moins complète dans le contrat.

992. Distinction au moment de la conclusion du contrat. Au moment où le contrat est conclu, la situation est relativement simple : les parties, ce sont les personnes qui concluent le contrat, et les tiers, ce sont tous les autres. Le seul élément de complexité tient à la technique de la représentation[2221] : les parties qui ont conclu le contrat ne sont pas nécessairement celles qui étaient présentes lors de cette conclusion, et qui ont exprimé leur volonté oralement ou par écrit à ce moment ; ce peut être aussi des personnes non présentes, mais qui ont été représentées par un mandataire ou un représentant légal – celui-ci, qui n'a fait qu'exprimer la volonté du représenté, étant en revanche un tiers[2222].

La doctrine des pays du Code civil fait souvent des distinctions entre différentes catégories de tiers au contrat. On oppose souvent les tiers absolus, *penitus extranei*[2223], à des personnes qui occuperaient une situation intermédiaire entre les parties et les tiers. Ce serait le cas des créanciers des parties, et de leurs ayants-cause – c'est-à-dire des personnes qui tiendraient des droits d'une des parties, soit par l'effet d'une transmission universelle du patrimoine de celle-ci (les héritiers), soit par l'effet d'un acte particulier de transmission d'un bien particulier (la personne qui achète un bien à une

[2221] Sur la représentation, voy. *supra*, n°s 302 et s.

[2222] Du moins dans la représentation dite parfaite, où la personne du représentant s'efface complètement une fois le contrat conclu. Dans la représentation imparfaite (commission, prête-nom), le contrat est d'abord conclu avec le représentant, qui en répercutera ensuite les effets sur la personne pour le compte de qui le contrat a été passé. Sur cette distinction, voy. *supra*, n°s 307 et 308.

[2223] En latin, ceux qui sont complètement étrangers au contrat.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

des parties). Cette présentation nous paraît compliquer inutilement les choses, si du moins on se place au moment de la conclusion du contrat. Il est vrai que les créanciers d'une des parties peuvent être particulièrement intéressés par les contrats que passe leur débiteur – surtout quand il s'agit de contrats qui modifient la substance du patrimoine de celui-ci, donc l'assiette de leur droit de gage général. Ils n'en sont pas moins des tiers véritables, à qui le contrat, comme à n'importe quel tiers, est simplement opposable – sous réserve des possibilités spécifiques qui peuvent leur être reconnues pour écarter cette opposabilité – et qui, comme n'importe quel tiers, peuvent se prévaloir du contrat. Simplement, en pratique, on peut observer que le concept d'opposabilité jouera plus souvent à leur égard qu'à l'égard de tiers qui n'ont aucun lien avec les parties. Quant aux ayants-cause, c'est une catégorie qui n'existe que de manière potentielle au moment de la conclusion du contrat : certes, au moment du décès d'un contractant, ses héritiers recueilleront par principe l'intégralité de ses droits et de ses obligations, et pourront devenir parties aux contrats qu'il a passés, et nous verrons que ce peut être aussi le cas de certains ayants-cause à titre particulier. Il n'en reste pas moins que, au moment où le contrat est passé, ces héritiers ou acquéreurs potentiels ne sont que des tiers ordinaires, et, même s'ils sont particulièrement intéressés aux contrats que peuvent passer la personne dont ils pensent acquérir ultérieurement tout ou partie des droits, à ce stade, ces contrats leur sont simplement opposables comme à tout autre tiers.

993. Évolution de la distinction au cours de la vie du contrat. La situation des ayants-cause, qui vient d'être évoquée, montre déjà que la distinction entre parties et tiers n'est pas figée une fois pour toutes au moment de la conclusion du contrat. Des personnes, qui étaient à l'origine étrangères au contrat, peuvent s'y intégrer par la suite par l'effet d'événements très divers. Ces événements peuvent être ou non volontaires. Ainsi, lorsqu'une partie décède, ce sont ses héritiers qui vont prendre sa place dans le contrat[2224], sans qu'aucune manifestation de volonté ne soit requise à cet effet. Mais l'intégration d'un tiers dans le contrat peut aussi être le résultat d'un acte de volonté : par exemple, lorsqu'une partie cède à un tiers la créance qu'elle a sur l'autre partie[2225]. Cette distinction quant à l'origine du changement est cependant peu opérationnelle pour

[2224] Voy. *infra*, n°s 1036 et s.
[2225] Voy. *infra*, n°s 996 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

présenter la matière, car certains mécanismes peuvent être, selon les cas, soit conventionnels, soit purement légaux[2226], ou découler d'une fiction de volonté admise par la jurisprudence[2227]. Plus importante nous semble être une autre distinction, qui servira ici de base à l'organisation des développements, et qui est liée à la distinction du contrat et de l'obligation qui a été antérieurement présentée[2228]. Dans certains cas, le tiers qui est substitué ou adjoint à une partie au contrat pour l'exécution de celui-ci ne l'est qu'en qualité de partie à un rapport d'obligation né du contrat : il devient créancier d'une créance contractuelle (**Section 1**) ou débiteur d'une dette contractuelle (**Section 2**), mais sans devenir, à proprement parler, partie au contrat. Dans d'autres cas, en revanche, c'est la qualité de partie au contrat qui se trouve modifiée : le tiers devient véritablement partie au rapport contractuel né à l'origine en dehors de lui (**Section 3**).

SECTION 1. LES TIERS PRENANT LA QUALITÉ DE CRÉANCIER CONTRACTUEL

994. Mécanismes translatifs et non translatifs. Le Code civil, tout comme beaucoup d'autres systèmes juridiques, connaît et réglemente deux types de mécanismes permettant à une personne de devenir créancière à la place d'une autre d'un rapport d'obligation auquel elle était à l'origine étrangère. Dans un premier type de mécanismes, qu'on peut appeler translatifs, le tiers va devenir créancier parce qu'il va acquérir la créance même dont était titulaire le premier créancier. Il va se la voir transmettre (par convention ou par l'effet de la loi) comme il pourrait se voir transmettre la propriété d'un bien corporel (une maison, une voiture, etc.). La conséquence principale est que le créancier nouveau acquiert la créance telle qu'elle est, avec tout ce qu'elle a de bon (les accessoires, notamment les sûretés qui la garantissent) et tout ce qu'elle a de mauvais (les vices, les moyens de défense qui pouvaient être opposés au créancier originaire). Il en résulte également que le débiteur de la créance transmise, dont la situation n'est pas juridiquement changée par l'opération, n'a pas à y intervenir ni à y consentir. La cession de créance et la subrogation appartiennent à cette première catégorie. Dans d'autres mécanismes, en revanche, il y a remplacement

[2226] Voy. ainsi pour la subrogation, *infra*, n°s 1018 et s.

[2227] Voy. *infra*, n°s 1038 et s. la question de la transmission des créances aux ayants-cause à titre particulier.

[2228] Voy. *supra*, n°s 483 et s.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

sans transfert d'une créance par une autre : le nouveau créancier va prendre la place de l'ancien par l'effet d'un nouvel engagement que le débiteur va prendre envers lui, à la place de celui qu'il avait envers son créancier originaire. Dans ce type de mécanismes, qu'on peut dire non translatifs, l'intervention du débiteur est toujours nécessaire, car il peut se trouver tenu envers le nouveau créancier d'une manière différente de son engagement primitif. Il ne pourra pas nécessairement invoquer à l'égard du nouveau créancier les mêmes moyens de défense qu'il aurait pu opposer à l'ancien. C'est le cas dans la novation par changement de créancier et dans la délégation.

La superposition, dans le droit moderne, de ces deux types de mécanismes, qui remplissent globalement les mêmes fonctions économiques, tient à l'histoire. Il n'a pas toujours été admis, historiquement, qu'un débiteur, qui s'est engagé envers un créancier déterminé, se retrouve par la suite, sans l'avoir voulu, lié à un autre créancier par l'effet d'une cession de son droit par le premier créancier. Il est cependant assez vite apparu qu'une créance n'est pas seulement un lien entre deux personnes, elle est aussi un élément d'actif, une valeur économique, un bien, dans le patrimoine du créancier. Celui-ci peut avoir intérêt à transmettre ce bien, notamment parce qu'il veut s'éviter la charge de son recouvrement, ou parce qu'il veut se procurer immédiatement des liquidités que sa créance, si elle est à terme, ne pourrait pas lui permettre d'obtenir immédiatement. C'est pourquoi, déjà en droit romain, on a cherché à développer des substituts à la transmission des créances, en permettant au débiteur de prendre un nouvel engagement envers un tiers. Par la suite, ces mécanismes non translatifs se sont maintenus, alors même qu'étaient admis plus franchement des modes directs de transmission des créances. Si elle est une source de complexité, cette diversité des mécanismes offre en même temps une grande richesse de ressources aux acteurs économiques, qui peuvent choisir la formule la plus adaptée à leurs besoins.

Nous examinerons d'abord les mécanismes translatifs, qui permettent de transférer une créance à un tiers (**Sous-section 1**), puis ceux qui aboutissent au remplacement sans transmission d'un créancier par un autre (**Sous-section 2**). Notons que ces différents mécanismes peuvent s'appliquer aussi bien à des créances non contractuelles qu'à des créances nées d'un contrat.

SOUS-SECTION 1. LA TRANSMISSION DES CRÉANCES À DES TIERS

995. Différents mécanismes. Le Code civil réglemente deux mécanismes opérant transfert d'une créance, la cession de créance (**§ 1**) et la subrogation personnelle (**§ 2**). La transmission de certaines créances peut également s'opérer automatiquement au profit des ayants-cause du créancier (**§ 3**).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§ 1. La cession de créance

996. Notion. La cession de créance est un contrat par lequel un créancier (cédant) transfère à une autre personne (le cessionnaire) la créance qu'il a sur son débiteur (le cédé). Le plus souvent, cette cession est faite à titre onéreux, moyennant le paiement d'un prix par le cessionnaire : la cession apparaît alors comme une variété particulière de vente, ce qui explique que les rédacteurs du Code civil l'aient réglementée dans le titre sur la vente, aux articles 1689 et suivants, sous l'intitulé vieilli de « transport des créances »[2229]. Cette approche est cependant quelque peu restrictive, car la cession de créance peut tout aussi bien servir à réaliser une donation, voire être insérée dans un testament. Les règles qui lui sont applicables relèvent donc plutôt du droit commun des contrats, voire du régime général des obligations[2230]. Ces textes, qui étaient restés inchangés en France jusqu'à la réforme de 2016, ont connu d'importantes modifications au Luxembourg par une loi du 21 décembre 1994, elle-même inspirée d'une loi belge de la même année. Il faut donc éviter de transposer systématiquement en la matière les solutions françaises antérieures à la réforme.

À côté des règles de droit commun, il existe certaines réglementations particulières, notamment pour la cession des droits résultant d'un contrat d'assurance-vie[2231], pour la cession des salaires[2232], ainsi que pour la cession des parts de certaines sociétés[2233]. En matière financière, des textes spéciaux organisent la titrisation (cession d'un portefeuille de créances à un organisme qui émet en contrepartie des instruments financiers)[2234] ainsi que la cession de créances à titre de garantie de créances et d'instruments financiers[2235].

On s'en tiendra ici à la cession de droit commun dont on étudiera les conditions (**A**) et les effets (**B**).

[2229] Ce terme n'a évidemment rien à voir avec le contrat de transport au sens moderne. Il signifie simplement transfert.

[2230] C'est la place qu'elles occupent dans le nouveau droit français des obligations, aux articles 1321 à 1326, au sein d'un chapitre consacré aux opérations sur obligations (qui a cependant laissé subsister au sein des règles sur la vente des règles spéciales à la cession de créance à titre onéreux). En droit belge, la cession est désormais réglementée dans le sous-titre consacré à la transmission des obligations, aux articles 5.174 à 5.186 du nouveau Code civil.

[2231] L. 27 juillet 1977, art. 118 et 119.

[2232] L. 11 novembre 1970.

[2233] Sociétés civiles : C. civ., art. 1861 ; sociétés anonymes : L. 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, art. 430-4 ; sociétés à responsabilité limitée : L. 10 août 1915, art. 710-13.

[2234] L. 22 mars 2004. Voy. A. Prüm *et alii*, *La titrisation*, Limal, Anthemis, 2008.

[2235] L. 5 août 2005, art. 13 et 14.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

A) *Les conditions de la cession de créance*

997. Contrat entre le cédant et le cessionnaire. La cession de créance est un contrat entre le cédant (le créancier initial) et le cessionnaire (le nouveau créancier). Le débiteur n'est pas partie à la cession, et il n'a pas à y intervenir. Cela s'explique parce que, juridiquement du moins, la cession ne modifiera pas la situation du débiteur, qui aura exactement les mêmes moyens de défense à l'égard du cessionnaire que ceux qu'il avait à l'égard du cédant.

Du point de vue de sa validité, ce contrat obéit à des conditions relativement souples (**1**). Mais la loi exige certaines formalités pour l'opposabilité de la cession de créance aux tiers (**2**).

998. Cession légale. Dans le Code civil, la cession de créance ne peut résulter que d'un contrat. Le droit luxembourgeois connaît cependant un cas de cession légale de créance : selon une jurisprudence constante, le recours de l'organisme de sécurité sociale qui doit verser des prestations à un de ses affiliés victime d'un accident contre le responsable de cet accident repose sur une cession légale de la créance de réparation de la victime au profit de l'organisme[2236]. Il s'agit d'une particularité du droit luxembourgeois par rapport au droit français et au droit belge, où ce recours est fondé sur la subrogation[2237]. Cependant, la distinction semble surtout être terminologique, car les conséquences pratiques de la distinction sont aujourd'hui bien atténuées[2238].

1) *Conditions de validité*

a. *Conditions de fond*

999. Article 1108 du Code civil. La cession de créance obéit aux conditions générales de validité des contrats, énumérées par l'article 1108 du Code civil. Le consentement et la capacité ne présentent aucune particularité en la matière. L'objet et la cause de la cession méritent en revanche qu'on s'y attarde.

1000. Objet de la cession : créances pouvant être cédées. Du point de vue de *son objet*, la cession peut porter sur toute créance, quelle qu'en soit la nature (créances de sommes d'argent, droit à une prestation en nature, bénéfice d'une obligation de ne pas faire, etc.) et quelle qu'en soit l'origine (créance contractuelle, créance de dommages et intérêts résultant d'un fait générateur de responsabilité délictuelle, etc.). Certaines créances cependant

[2236] Jurisprudence constante au moins depuis Cass., 9 juillet 1959, *Pas.*, 18, p. 5. Voy. encore récemment : Cour d'appel, 14 janvier 2009, *Pas.*, 34, p. 562.

[2237] Voy. *infra*, n°s 1020 et s.

[2238] Voy. RAVARANI, n°s 1336 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ne peuvent pas être cédées car elles sont indisponibles. Cette indisponibilité peut résulter de la loi (par exemple : les créances alimentaires, les créances de salaire dans la limite du montant insaisissable), mais elle peut aussi avoir été stipulée dans la convention qui a fait naître la créance. Cependant une telle indisponibilité conventionnelle ne peut pas être opposée au cessionnaire qui n'en a pas eu connaissance[2239]. La jurisprudence française jugeait même, de manière contestable, que la clause d'indisponibilité convenue entre le cédant et le cédé n'est opposable au cessionnaire que s'il l'a acceptée[2240]. Le nouvel article 1321 du Code civil français ne consacre pas ces solutions, mais exige que, dans un tel cas, le cédé consente à la cession. Plus nuancé, l'article 5.174 du Code civil belge dispose à cet égard que « [l]a cession d'une créance contraire à une interdiction de cession contractuelle n'est pas opposable au débiteur cédé lorsque le cessionnaire est tiers complice de la violation de cette interdiction ».

La créance cédée peut être affectée d'une modalité : dans l'immense majorité des cas, il s'agit de créances à terme (dont le cédant peut ainsi obtenir immédiatement la valeur), mais on pourrait aussi bien céder une créance conditionnelle. On admet même la possibilité de céder des créances futures, par exemple, provenant d'un contrat non encore passé : ce qui permet notamment de se servir de ces créances en garantie du remboursement d'un crédit.

1001. Cause de la cession. La cession de créance peut servir à réaliser des opérations très diverses, donc avoir des causes variées. Si elle est faite à titre gratuit, sa cause est celle d'une donation (ou d'un testament), à savoir l'intention libérale. Lorsqu'elle est faite à titre onéreux, elle trouve sa cause, comme tous les contrats de vente, dans l'échange effectué entre la chose (le bien) et le prix. Il faut observer que, dans ce cas, le prix ne correspond pas nécessairement au montant nominal de la créance. La cession est habituellement utilisée comme un moyen de crédit : le créancier, qui a une créance à terme, et qui a besoin immédiatement de liquidités, cède sa créance dont il peut immédiatement tirer un certain prix. Dans ce cas, celui qui achète la créance (souvent une banque) la paiera moins cher que son montant, la différence représentant la rémunération du crédit qu'il consent. Le prix sera d'autant moins élevé que la créance est douteuse, c'est-à-dire que son recouvrement paraît présenter des difficultés : dans ce cas, la cession de

[2239] Voy. dans ce sens l'article 11 : 301 des PDEC.
[2240] Cass. fr. (comm.), 21 novembre 2000, n° 97-16874.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

créance cesse d'être une opération de crédit, elle devient une opération spéculative. Le cessionnaire achète pour une bouchée de pain une créance d'un montant nominal élevé, en espérant parvenir à la recouvrer.

On peut aussi utiliser la cession de créance pour garantir le remboursement d'un crédit octroyé par le cessionnaire : la cession est alors faite sans paiement d'un prix ; si le cédant ne rembourse pas le crédit que lui a fait le cessionnaire, celui-ci conservera la créance et pourra la recouvrer contre le débiteur cédé, dans le cas contraire, le cédant récupérera la créance et c'est lui qui l'encaissera. Cette utilisation a été consacrée expressément par le législateur français dans le cadre de la cession de créances professionnelles (cession de créances faite par une entreprise à une banque, relevant d'une réglementation spéciale dans le Code monétaire et financier), mais non pour la cession de créances de droit commun. Au Luxembourg, en revanche, la loi du 5 août 2005 sur les garanties financières admet explicitement la possibilité de céder une créance à titre de garantie. Cette cession est alors soumise à des conditions particulières, plus souples qu'en droit commun[2241].

1002. Retrait litigieux. Les rédacteurs du Code civil ont envisagé spécialement cette utilisation spéculative lorsque la créance cédée est litigieuse, c'est-à-dire qu'elle fait l'objet d'une contestation (sur son existence ou sur son montant) entre le cédant et le cédé. Le débiteur de la créance litigieuse pourra, dans le but d'éviter le procès avec le cessionnaire, lui rembourser le prix de la cession, et il sera alors libéré. C'est ce qu'on appelle le *retrait litigieux* (C. civ., art. 1699 à 1701). Ces textes, spécifiques à la cession intervenue en tant que vente, sont restés inchangés en France lors de la réforme de 2016 et ont été repris sans changement important par l'article 5.178 du nouveau Code civil belge. Le but de ce mécanisme est de protéger le débiteur contre un cessionnaire qui, ayant acheté la créance, risque d'être prêt à tout pour gagner le procès contre le cédé. On peut y voir une forme de transaction forcée (le cédé oblige le cessionnaire à renoncer au procès en renonçant de son côté à se défendre), mais aussi une sorte d'expropriation (le cessionnaire est contraint d'abandonner la créance qu'il a acquise). C'est pourquoi le domaine du retrait litigieux est exceptionnel, et la Cour de cassation française a précisé que les textes en la matière devaient

[2241] Voy. les articles 13 et 14 de la loi.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

faire l'objet d'une interprétation stricte[2242]. C'est ainsi que le mécanisme ne s'applique qu'aux créances litigieuses en droit, et non aux créances douteuses en fait (en raison de l'insolvabilité du débiteur). L'article 1700 du Code civil précise à cet égard que la créance est litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. Pour la jurisprudence luxembourgeoise, qui suit la position de la Cour de cassation française, la faculté de retrait n'est ouverte que si le litige relatif à la créance existait avant la cession, elle n'existe pas lorsque le droit est devenu litigieux dans la suite par une contestation subséquente à la cession[2243]. Dans une décision récente, le juge de paix de Luxembourg a jugé que cette contestation doit mettre en question le droit lui-même et non pas seulement les modalités de son exercice, son exécution ou des difficultés procédurales[2244]. Par ailleurs, la Cour d'appel du Luxembourg a naguère décidé que la faculté de retrait n'était pas applicable lorsque la créance cédée n'était que l'accessoire d'une convention principale, qui n'en forme qu'une faible partie (ainsi pour une créance cédée dans le cadre du rachat global de l'actif d'une société par une autre)[2245]. La jurisprudence française actuelle consacre la solution contraire : le seul fait que la cession intervenue ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application de l'article 1699, sauf à ce que le juge puisse déterminer le prix spécial de la créance litigieuse[2246]. On peut remarquer que le retrait litigieux fait actuellement l'objet d'une jurisprudence très abondante en France, dont la jurisprudence luxembourgeoise, plutôt rare, pourrait sans doute s'inspirer.

b. *Conditions de forme*

1003. Consensualisme. La cession de créance n'est pas soumise, par elle-même, à des formes particulières pour sa validité. L'article 1689 du Code civil exigeait naguère la remise du titre au cessionnaire, mais cette forme n'était qu'un acte d'exécution de la cession (l'exécution par le cédant de son obligation de délivrance). Le texte a été réformé en 1994 (sur le modèle d'une loi belge de la même année) et désormais il est indiqué clairement que la cession

2242 Cass. fr. (1re civ.), 20 janvier 2004, n° 00-20.086 P.

2243 Cour d'appel, 4 janvier 1913, *Pas.*, 9, p. 100 ; Cour d'appel, 4 mars 1932, *Pas.*, 12, p. 460 ; Trib. Luxembourg, 17 novembre 2021, n° TAL-2021-03769.

2244 Trib. Paix Luxembourg, 28 juin 2023, Cass. (1re civ.), 20 janvier 2004, préc.

2245 Cour d'appel, 30 mars 1939, *Pas.*, 14, p. 200.

2246 Cass. fr. (1re civ.), 4 juin 2007, n° 06-16.746 ; Cass. fr. (comm.), 27 mai 2008, n° 07-11.428 P.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

s'opère par l'échange des consentements. À l'inverse, le nouvel article 1322 du Code civil français dispose que la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité. En droit luxembourgeois, il convient cependant de faire exception au caractère consensuel de la cession lorsque la cession est effectuée à titre de libéralité : dans ce cas, il faudra respecter les formes spécifiques requises pour la donation ou pour le testament. En dehors de ce cas, il faudra aussi respecter les règles de preuve du droit commun, civil ou commercial, ce qui peut conduire à dresser un écrit. Surtout, comme on va le voir, il faudra respecter les formalités exigées par l'article 1690 du Code civil, pour assurer l'opposabilité de la cession aux tiers.

2) *Conditions d'opposabilité aux tiers*

1004. Intérêt. La cession de créance n'est véritablement efficace que si elle est opposable aux tiers. Sinon, ceux-ci pourraient faire comme si la créance faisait encore partie du patrimoine du cédant et cela aurait des conséquences fâcheuses pour le cessionnaire. Le problème se pose à l'égard de trois catégories de personnes, dont la situation est directement affectée par la cession.

Le tiers le plus directement intéressé est le *débiteur cédé*. S'il n'était pas au courant de la cession, il pourrait payer au cédant, son créancier originaire, et ce paiement, fait de bonne foi, serait valable. Le cessionnaire ne pourrait plus, dès lors, obtenir son paiement du cédé.

La cession doit également être opposable aux *autres créanciers du cédant*, sinon ils pourraient saisir la créance cédée dans le patrimoine du cédant, empêchant, là encore, le paiement du cessionnaire.

Enfin, la cession n'est efficace que si elle est opposable aux *ayants cause du cédant*, c'est-à-dire à des personnes qui voudraient, à leur tour, acquérir la créance. Imaginons en effet que pour mobiliser un crédit que j'ai accordé, je cède ma créance à un banquier ; si je suis malhonnête, je peux essayer de me procurer à nouveau des fonds auprès d'un autre banquier en lui cédant une nouvelle fois la créance. La question est alors de savoir qui doit l'emporter, du premier ou du second cessionnaire. Le problème est d'ailleurs le même que pour la vente d'un immeuble ou d'un meuble corporel.

1005. Exigences légales. La cession de créance fait partie des contrats dont l'opposabilité aux tiers est subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités, sans doute à cause du nombre

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

des tiers directement concernés, et du caractère totalement invisible de la cession aux yeux de ceux-ci. Dans le Code civil de 1804, ces formalités de publicité, requises par l'article 1690 du Code civil, étaient particulièrement lourdes, et constituaient un obstacle sérieux à l'utilisation pratique de la cession de créance. Ces formalités, qui n'avaient pas été modifiées en France avant la réforme du droit des obligations[2247], ont été considérablement assouplies au Luxembourg, sur le modèle belge (**a**), et la sanction de leur inobservation est moins automatique, du moins à l'égard du débiteur cédé (**b**).

a. *Formalités nécessaires*

1006. Principe. La publicité consiste dans l'information du débiteur cédé : celui-ci est averti directement par le cessionnaire (ou éventuellement par le cédant), de sorte qu'il pourra ensuite renseigner les tiers sur l'existence de la cession. Le premier soin de celui qui veut acquérir une créance ou la saisir doit être de se renseigner auprès du débiteur de cette créance pour savoir si elle fait toujours partie du patrimoine du créancier originaire.

1007. Modalités. Traditionnellement, cette information du débiteur cédé pouvait se faire, selon l'article 1690 du Code civil, de deux manières. La plus simple consistait dans la signification, par acte d'huissier, de la cession au débiteur cédé. Mais le cessionnaire pouvait aussi faire accepter la cession par le cédé dans un acte authentique. Cette forme était rarement choisie car elle était beaucoup plus lourde et onéreuse que la signification. Dans les deux cas, un acte authentique était nécessaire (acte d'huissier ou acte notarié), ce qui était justifié par le souci de donner à l'opération une date certaine. On voulait éviter que le cessionnaire, pour s'opposer à la prétention d'un autre cessionnaire ou d'un créancier, n'antidate l'acte de cession.

Au Luxembourg, la loi de 1994 déjà évoquée a considérablement simplifié le formalisme de l'article 1690 du Code civil. L'opposabilité de la cession peut désormais être assurée soit par une simple notification, soit par une acceptation, ces deux formalités n'étant pas

[2247] Le droit français avait cependant mis en place, en dehors du Code civil, des formes particulières de cession de créance soumises à un formalisme beaucoup moins rigide que celui de l'article 1690. La plus importante est la cession de créances professionnelles à des établissements de crédit, réglementée par une loi de 1981, désormais intégrée dans le Code monétaire et financier aux articles L. 313-23 et suivants.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

cumulatives[2248]. La différence avec la formule originaire est que ces actes peuvent intervenir par acte sous seing privé, un acte authentique n'est plus nécessaire. La notification, dit la Cour d'appel, « s'entend de tout acte contenant les éléments essentiels à une exacte information du débiteur quant au transfert de créance et peut revêtir la forme d'un courrier recommandé »[2249]. Mais elle peut tout aussi bien être faite par acte sous seing privé[2250]. Quant à l'acceptation, qui n'est soumise à aucune forme, elle n'implique pas que le débiteur doive être consulté sur la cession et y donner son consentement, elle doit, dit la Cour d'appel « être entendue simplement comme l'aveu, par le débiteur, de la connaissance de la cession effectuée »[2251]. Peut alors se poser un problème de date de la notification ou de l'acceptation : si la date est contestée, il appartient au cessionnaire de rapporter la preuve que la date est exacte, et cette preuve peut être rapportée par tous moyens.

La loi belge de 2006 était allée encore plus loin : depuis cette loi, la cession est opposable aux créanciers du cédant et aux autres cessionnaires dès le jour où elle a été conclue (sous réserve, là encore, du problème de preuve si la date est contestée). La notification n'est plus requise que dans les rapports avec le débiteur. Ce système a été repris lors de la réforme par l'article 5.179 du nouveau Code civil. Lors de la réforme de 2016, le législateur français s'est aligné sur ce mécanisme dans les nouveaux articles 1323 et 1324 du Code civil. Cet assouplissement des formalités de la cession se retrouve dans les différents projets d'harmonisation européenne[2252]. Le droit luxembourgeois, qui exige toujours une notification ou une acceptation, se trouve donc désormais en retrait par rapport aux droits des deux autres pays du Code civil. Cependant, le système de l'opposabilité de la cession dès la date de sa conclusion se retrouve pour la cession de créances à titre de garantie dans le cadre de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.

b. *Sanctions du défaut des formalités*

1008. Vis-à-vis des tiers autres que le débiteur cédé. Tant que la cession n'a pas été notifiée au débiteur, elle est inopposable aux créanciers et aux ayants-cause du cédant. Les créanciers du cédant peuvent considérer que la créance fait toujours partie de l'actif de leur débiteur, et donc l'appréhender par la voie de la saisie-arrêt[2253] ; si le cédant est mis en faillite avant la notification, la créance fera

[2248] Cour d'appel, 27 avril 2017, n° 42653.

[2249] Cour d'appel, 27 avril 2017, n° 42653, *Pas.*, 38, p. 516 ; Cour d'appel, 2 mars 2023, n° CAL-2022-00425.

[2250] Cour d'appel, 12 juillet 2018, n° 40655.

[2251] Cour d'appel, 19 juin 2019, n° 44562.

[2252] Voy. p. ex. PDEC, art. 11 : 202 et 11 : 303.

[2253] Cour d'appel, 4 janvier 2017, n° 41093.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

partie de l'actif de la procédure. Quant aux ayants cause du cédant (les autres cessionnaires), ils peuvent considérer que le cédant est toujours titulaire : le second cessionnaire sera donc préféré au premier s'il accomplit avant lui les formalités de l'article 1690 du Code civil. On comprend l'importance de la détermination de la date et les risques de fraude aux droits des tiers qu'un assouplissement excessif du formalisme fait courir.

Peu importe en revanche, entre deux cessionnaires, que le premier n'ait procédé qu'à une notification ou ait fait accepter la cession par acte sous seing privé, alors que le second a, lui, recouru à une signification par voie d'huissier. Dans le système résultant de la loi de 1994, les deux formalités ont exactement la même valeur. C'est le premier qui a notifié qui doit de toute façon l'emporter[2254].

1009. Vis-à-vis du débiteur cédé. La situation est plus complexe en ce qui concerne le débiteur cédé. Le défaut d'accomplissement des formalités n'a pas, à son égard, un effet aussi absolu. Deux questions différentes se posent. La première est de savoir jusqu'à quand le débiteur peut valablement payer son créancier originaire. En principe, ce paiement est valable tant que le cédé n'a pas reçu notification (C. civ., art. 1691), mais le texte réserve le cas où il est prouvé que le cédé avait connaissance de la cession au moment où il a payé le cédant[2255]. Dans ce cas, il devra payer une deuxième fois le cessionnaire. Le droit luxembourgeois, tout comme le droit belge, s'est ici radicalement séparé de la jurisprudence française, qui estimait, avant la réforme, que la simple connaissance par le cédé de l'existence de la cession ne suffisait pas à la lui rendre opposable[2256]. Et cette solution est maintenue par le nouvel article 1324 du Code civil français selon lequel la cession « ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il l'a acceptée ».

Toute autre est la question de savoir si le défaut de notification empêche le cessionnaire de demander le paiement au cédé. La Cour de cassation française a jugé que ce défaut « ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession »[2257]. Le cessionnaire peut donc demander le paiement au cédé tant que celui-ci n'a pas payé le cédant, et que la créance n'a pas été appréhendée par un tiers (créancier ou autre cessionnaire). Cette solution

[2254] Cass., 22 mai 2014, n° 52/14, *Pas.*, 36, p. 745, note P. Ancel.

[2255] La solution était déjà admise avant la réforme de 1994 : Cass., 12 juillet 1990, *Pas.*, 28, p. 41.

[2256] Cass. fr. (1re civ.), 22 mars 2012, n° 11-15151. Seule l'acceptation non équivoque de la cession par le cédé l'empêche de se prévaloir du défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 (Cass. fr. (1re civ.), 19 septembre 2007, n° 06-11814, Cass. fr. (1re civ.), 22 mars 2012, préc.).

[2257] Voy. en dernier lieu Cass. fr. (comm.) 28 septembre 2004, n° 03-12023.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

doit sans aucun doute être transposée au Luxembourg, ne serait-ce que parce que la demande de paiement du cessionnaire fait connaître la cession au cédé, et l'empêche de toute façon de payer son créancier originaire. Il n'a donc aucune raison de refuser de payer le cessionnaire.

B) *Les effets de la cession de créance*

1010. Effets translatif et obligationnel. La cession a, comme toute vente ou donation un effet translatif : le cessionnaire devient titulaire de la créance cédée (1). La cession fait aussi naître, pour les deux parties, un certain nombre d'obligations (2).

1) *Transfert de la propriété de la créance*

1011. Principe. Comme dans une vente, le cessionnaire devient titulaire de la créance cédée. Il faut se demander à quel moment se produit ce transfert (a) et quelles en sont les conséquences (b).

a. *Moment du transfert*

1012. Accord des parties ou notification. Entre les parties, le transfert de la créance se produit dès le moment de l'accord de cession, sans attendre l'accomplissement des formalités de publicité. En revanche, à l'égard des tiers, c'est la notification qui fait sortir la créance du patrimoine du cédant et la fait entrer dans le patrimoine du cessionnaire. C'est donc seulement à partir de ce moment que les créanciers du cédant ne peuvent plus appréhender la créance cédée ; en particulier si le cédant est mis en faillite après ce moment, la créance ne fait plus partie du patrimoine du cédant et échappe à ses créanciers. De même, après ce moment, le cessionnaire ne risque plus d'entrer en conflit avec d'autres cessionnaires éventuels.

Il en va autrement, cependant, lorsque la créance cédée est une créance future. De prime abord, le transfert d'une telle créance ne pourra alors s'opérer que le jour où la créance vient à exister : telle était la solution retenue par l'article 1323 du Code civil français après la réforme de 2016, mais le texte a été modifié en 2021 et précise désormais que le transfert s'opère à la date de l'acte aussi bien pour les créances futures que présentes. Cette solution, destinée à harmoniser la solution du droit commun avec celle retenue pour la cession de créances professionnelles, met fin du coup à la difficulté particulière qui surgissait en présence d'un contrat à exécution successive qui fait naître des créances à échéances périodiques (contrat de bail ou contrat de travail, par exemple). Fallait-il alors considérer que ces créances naissaient en une seule fois, au moment de la conclusion du contrat, et que seule leur exigibilité est échelonnée dans le temps – auquel cas le cessionnaire de telles créances les appréhendait globalement dès ce moment, sans pouvoir entrer en concours avec d'autres créanciers du cédant – ou au contraire que leur naissance s'opérait au fur et

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

à mesure des échéances, auquel cas la cession ne produit son effet translatif qu'au fur et à mesure de l'exécution du contrat ? Cette question – qui a bien d'autres enjeux – avait suscité de vifs débats dans la doctrine française[2258]. Finalement, la Cour de cassation française, après une période de divergences entre les chambres, avait décidé que les créances naissaient globalement en une seule fois au moment de la conclusion du contrat[2259]. La Cour de cassation du Luxembourg a suivi cette position à propos d'une cession de salaire : dès le moment de la cession, le cessionnaire devient créancier de l'ensemble des salaires devant être versés au cédant (dans la limite du montant stipulé à l'acte), sans que son droit soit affecté par l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre le cédant[2260].

b. *Conséquences du transfert*

1013. Identité de la créance. La créance que le cessionnaire recueille dans son patrimoine est exactement la même que celle qui existait dans le patrimoine du cédant, avec ses aspects positifs mais aussi négatifs. Il en résulte que la créance est transmise avec *tous ses accessoires* mais aussi que le cédé peut opposer au cessionnaire *toutes les exceptions* qu'il aurait pu opposer au cédant.

1014. Transmission des accessoires. Aux termes de l'article 1692 du Code civil, « la vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ». Cette solution (reprise par le nouvel article 1321 du Code civil français et par l'article 5.177 du nouveau Code civil belge) est une conséquence du caractère translatif de la cession de créance. Cependant, la Cour d'appel a jugé que les parties pouvaient renoncer à cette transmission, en excluant par exemple de la cession l'hypothèque garantissant le paiement de la créance[2261]. Encore faut-il savoir ce qu'on entend par accessoires de la créance. Le texte donne comme exemple les sûretés qui assortissent la créance transmise : si, par exemple, le cédant avait pris une caution pour se protéger contre l'insolvabilité du débiteur, cette caution va se retrouver engagée vis-à-vis du cessionnaire[2262]. De même l'acquéreur d'un immeuble, cessionnaire de la créance de loyers contre

[2258] Voy. récemment sur cette question les deux thèses opposées et soutenues à quelques jours d'intervalle de : P.-E. Audit, *La « naissance » des créances*, préf. D. Mazeaud, Paris, Dalloz, 2015 ; R. Noirot, *Les dates de naissance des créances*, disponible sur http://www.theses.fr/2013PA05D016.

[2259] Cass. fr. (ch. mixte), 22 novembre 2002, n° 99-13935.

[2260] Cass., 20 juin 2013, n° 48/13.

[2261] Cour d'appel, 27 avril 2017, n° 42653.

[2262] Il en va ainsi même si la cession n'a pas été notifiée au débiteur cédé, la caution n'étant pas un tiers au sens de l'article 1690 du Code civil : Cass. fr. (1re civ.), 4 mars 2003, n° 01-01375.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

le locataire, devient titulaire de la garantie bancaire déposée pour le paiement de ces loyers[2263]. En conséquence, en cas de vente d'un immeuble loué assortie d'une cession des loyers à l'acquéreur, celui-ci devient titulaire de la garantie bancaire qui a été constituée par le locataire par dépôt sur le compte du bailleur, lequel doit en reverser le montant à son acquéreur.

Mais il faut entendre ce texte plus largement, comme visant non seulement les sûretés citées par le texte, mais aussi toutes les garanties dont disposait le créancier originaire : serait ainsi transmise au cessionnaire le bénéfice d'une clause de réserve de propriété garantissant la créance de prix d'un vendeur[2264]. La notion d'accessoire est entendue plus largement encore par la jurisprudence française. On considère ainsi que le cessionnaire peut exercer toutes les actions en justice sanctionnant l'inexécution de son obligation par le cédé : par exemple, si la créance cédée était une créance contractuelle, le cessionnaire peut exercer contre le cédé une action en responsabilité contractuelle[2265], ou une action en résolution du contrat. La Cour de cassation française admet même la transmission au cessionnaire d'une action en responsabilité délictuelle contre un tiers qui a compromis le recouvrement de la créance cédée[2266]. Toujours sur le fondement de l'article 1692 du Code civil, on admet que les clauses du contrat générateur de la créance cédée s'appliquent également dans les rapports entre le cédé et le cessionnaire : si, par exemple, le contrat contenait une clause d'arbitrage, le litige entre le cédé et le cessionnaire relatif à la créance contractuelle cédée devra être porté devant un tribunal arbitral[2267]. Le Tribunal de Luxembourg en a ainsi jugé pour une clause attributive de juridiction[2268]. Il faut observer que ces clauses peuvent jouer dans les deux sens : non seulement le cessionnaire peut s'en prévaloir, mais le cédé peut aussi les invoquer contre lui. C'est pourquoi la notion d'accessoire – qui évoque les avantages que la créance peut présenter pour le cessionnaire – est sans doute un peu trop étroite pour rendre compte de ces solutions. Il vaut mieux dire que la créance cédée

[2263] Cour d'appel, 5 avril 2017, n° 42545 ; Trib. Luxembourg, 5 mars 2024, n° TAL-2023-04758.

[2264] Comp. à propos de la subrogation, qui produit le même effet translatif : Cass. fr. (comm.), 11 juillet 1988, n° 86-17643 ; Cour d'appel, 8 novembre 2007, BIJ 2008, p. 223.

[2265] Cass. fr. (1re civ.), 19 juin 2007, n° 05-21678.

[2266] Cass. (1re civ.), 24 octobre 2006, n° 04-10231 ; Cass. (2e civ.), 17 décembre 2009, n° 09-11612.

[2267] Cass. fr. (1re civ.), 5 janvier 1999, n° 96-20202 ; Cass. fr. (2e civ.), 20 décembre 2001, n° 00-10806.

[2268] Trib. Luxembourg, 14 juillet 2004, n° 81530.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

est configurée – positivement et négativement – par le contrat qui l'a fait naître, et que c'est avec cette configuration qu'elle passe dans le patrimoine du cessionnaire.

Cela, cependant, ne fait pas à proprement parler du cessionnaire une partie au contrat qui a fait naître la créance cédée, et en cela la cession de créance se différencie fondamentalement d'une cession de contrat. Si, par exemple, cette créance est la créance de prix d'une vente, le cessionnaire, s'il acquiert une créance contractuelle, n'en devient pas pour autant vendeur à la place du cédant. C'est toujours ce dernier qui devra livrer la chose vendue, et qui devra en assurer la garantie – sauf du reste à ce que l'inexécution de ces obligations par le vendeur originaire puisse être opposée par le cédé au cessionnaire.

1015. Opposabilité des exceptions. On applique ici la règle selon laquelle nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a lui-même : *Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*. En conséquence, si le débiteur cédé avait un moyen de refuser le paiement, en tout ou en partie, à son créancier originaire, il pourra également refuser de payer le cessionnaire. On dit que le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. Supposons, par exemple, que la créance cédée représente le prix de vente d'une marchandise ; si la marchandise vendue est avariée, l'acheteur peut refuser de payer au cessionnaire comme il aurait pu le faire à son créancier, le vendeur (par le jeu de l'exception d'inexécution)[2269]. De même le débiteur peut opposer au cessionnaire la nullité ou la résolution pour inexécution du contrat qu'il a passé avec le cédant. Il n'en irait autrement que si le débiteur cédé avait pris envers le cessionnaire l'engagement personnel de payer la dette[2270].

On enseigne traditionnellement que seules peuvent être opposées au cessionnaire les exceptions nées antérieurement au moment où la cession est devenue opposable au cédé – c'est-à-dire celles que le cédé aurait pu, avant ce moment, faire valoir à l'encontre du cédant[2271]. Tout dépend en réalité de la nature des exceptions. Il est certain que le cédé ne peut pas opposer au cessionnaire les exceptions tirées d'accords personnels qu'il aurait passés avec le cédant après la notification de la cession (remise de dette, modification des conditions de remboursement, etc.), le cédant n'ayant plus, à partir de la cession, aucun pouvoir de modifier la créance. En revanche, le cédé devrait toujours pouvoir opposer au cessionnaire les causes de nullité du contrat, même si elles ne se sont révélées qu'après la cession, ainsi que les moyens de défense tirés de l'inexécution par le cédant de ses obligations contractuelles, même si cette inexécution est postérieure à la cession. La Cour de cassation française en avait jugé ainsi à propos de l'exception d'inexécution, en posant un principe général, selon lequel « le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire

[2269] Voy. p. ex. Trib. Luxembourg, 20 juillet 2001, n° 49020.

[2270] Cour d'appel, 24 octobre 2007, n° 31069.

[2271] Dans ce sens p. ex. Poelmans, p. 366.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession »[2272]. Cette distinction, assortie de divers exemples, a été reprise par le nouvel article 1324 du Code civil français selon lequel « le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes ».

Des règles particulières existent dès aujourd'hui dans le code luxembourgeois pour l'exception de compensation. Selon l'article 1295 du Code civil, modifié par la loi de 1994, le cédé peut opposer au cessionnaire la compensation de ce que le cédant lui doit dès lors que sa créance contre le cédant est née avant la notification de la cession, et qu'elle devient exigible avant ou au même moment que la créance cédée. Cette règle permet donc d'opposer une compensation qui ne se réalise que postérieurement à la notification, ce qui est substantiellement différent de la solution traditionnellement reçue en France et en Belgique où la compensation est inopposable si les conditions en ont été remplies seulement après la notification. Dans les trois pays, cependant, la compensation peut toujours être invoquée, quel que soit le moment où elle s'est produite, dès lors que les dettes à compenser étaient connexes[2273]. On retrouve cette distinction dans le nouvel article 1324 français et dans l'article 5.182 du nouveau Code civil belge.

2) *Obligations des parties*

1016. Obligations du cessionnaire. Le cessionnaire n'est tenu d'aucune obligation particulière si la cession est faite à titre gratuit, ou à titre de garantie d'un crédit distinct. Il a l'obligation de payer le prix, si la cession a lieu à titre onéreux. L'inexécution de cette obligation, cependant, ou un paiement seulement partiel, n'affecte pas l'effet translatif de la cession – sauf au cédant impayé à demander la résolution. De ce point de vue, la cession de créance se distingue fondamentalement de la subrogation, qui ne produit son effet translatif que si un paiement est effectué[2274].

1017. Obligations du cédant. Le cédant a d'abord une *obligation de délivrance* qui va s'opérer, en droit commun, par la remise du titre constatant la créance. Bien que, en droit luxembourgeois, cette remise du titre ne soit plus prévue par l'article 1689 du Code civil, elle reste en principe nécessaire. Le titre est en effet utile au cessionnaire comme instrument de preuve et, éventuellement, comme instrument de recouvrement. L'article 5.184 du Code civil belge dispose à cet égard que « [l]e cédant est tenu de remettre au cessionnaire tous

[2272] Cass. fr. (comm.), 12 janvier 2010, n° 08-22000.
[2273] Sur cette notion, voy. *supra*, n°s 908 et s.
[2274] Voy. *infra*, n° 1018.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

les actes et éléments de preuve nécessaires en sa possession qui concernent la créance et ses droits accessoires ». Dans de nombreux cas, cependant, la mise à disposition de la créance s'opérera d'une autre manière : ainsi pour la transmission d'instruments financiers dématérialisés, on procédera par inscription des titres au compte du cessionnaire[2275].

Le cédant a également, si la cession est faite à titre onéreux, une *obligation de garantie* (C. civ., art. 1692). En principe, le cédant, tout comme un vendeur ordinaire garantit l'acheteur contre les vices cachés, garantit *l'absence de vices de la créance* (C. civ., art. 1693). C'est dire que si le débiteur oppose au cessionnaire une exception qu'il avait contre le cédant, le cessionnaire peut se retourner contre le cédant pour obtenir le remboursement de ce qu'il lui a payé. Cette garantie ne porte que sur l'existence de la créance au moment du transport : elle ne joue pas bien entendu si c'est le cessionnaire qui a laissé perdre la créance, par exemple, en la laissant prescrire. Cette garantie peut être (comme en principe la garantie des vices dans la vente), écartée par une clause du contrat de cession. En revanche, le cédant ne garantit pas, en principe, le cessionnaire contre *l'insolvabilité du débiteur cédé* (C. civ., art. 1694). Si le débiteur est insolvable et que, pour cette raison, le cessionnaire ne peut obtenir son paiement, il n'a pas de recours contre le cédant. Une clause contraire est cependant possible dans le contrat de cession : les articles 1694 et 1695 du Code civil en précisent la portée. Le nouvel article 1326 du Code civil français et l'article 5.186 du nouveau Code civil belge reprennent en substance ces différentes dispositions.

§2. La subrogation personnelle

1018. Notion. Le terme subrogation signifie remplacement. Il faut distinguer deux types de subrogation. La *subrogation réelle* est le remplacement d'une chose par une autre dans un patrimoine. On peut prendre comme exemples le remplacement d'un bien détruit par l'indemnité d'assurance, qui permettra aux créanciers qui avaient un droit sur le bien de voir ce droit se reporter sur l'indemnité, ou encore, en matière de régimes matrimoniaux, le mécanisme du remploi qui permet de donner le statut de bien propre à un bien acheté pendant le mariage dans le régime de communauté lorsque

[2275] Voy. pour le transfert d'instruments financiers à titre de garantie : L. 5 août 2005, art. 14 (2).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ce bien est acquis à l'aide d'argent provenant de la vente d'un bien lui-même propre (C. civ., art. 1434)]. L'étude de ce mécanisme est faite en droit des biens, ou dans le cadre des parties du droit civil qui y font appel (droit des sûretés, droit des régimes matrimoniaux). Très différente, la *subrogation personnelle* est le remplacement d'une personne titulaire d'un droit de créance par une autre personne qui a payé le créancier. C'est de cette subrogation qu'il est question ici.

La subrogation personnelle est toujours liée à un paiement, et c'est ce qui explique la place où elle est réglementée dans le Code civil, aux articles 1250 et suivants, dans la section relative au paiement. Cette place a été conservée après les réformes en France et en Belgique (C. civ. fr., art. 1346 et s. ; C. civ. be., art. 5.217 et s.). Il faut supposer que le paiement est fait par un autre que le débiteur ; dans certaines conditions, un tel paiement n'aura pas un effet extinctif, mais translatif : celui qui a payé va être subrogé dans les droits du créancier, c'est-à-dire qu'il pourra exercer contre le débiteur les droits du créancier qu'il a désintéressé. Par exemple, vous devez 10 000 € à un établissement de crédit ; pour vous rendre service, je paie à votre place ; mais je n'entends pas vous faire cadeau des 10 000 € ; je vais alors exiger que l'établissement de crédit me subroge dans ses droits et je pourrai, ensuite, vous demander le remboursement de ce que j'ai payé.

Comme on le voit, la subrogation est un *mode de transfert d'une créance* : tout se passe comme si le créancier subrogeant avait cédé sa créance au tiers subrogé[2276]. Mais la subrogation est étroitement liée au paiement, ce qui explique d'importantes différences avec la cession de créance, tant du point de vue des conditions (**A**) que des effets (**B**).

A) *Les conditions de la subrogation*

1019. Subrogation légale ou conventionnelle. Comme on l'a dit, la subrogation suppose toujours un paiement pour autrui. Mais tout paiement pour autrui n'entraîne pas subrogation : la loi attache cet effet à certains paiements (subrogation légale) ; en dehors de ces cas, il faut un accord de volontés spécial (subrogation conventionnelle). Il y a là une première distinction avec la cession de créance qui est

[2276] C'est pourquoi l'avant-projet de réforme français de 2005 avait opéré un regroupement de ce mécanisme avec la cession de créances, mais cette présentation n'a pas été maintenue dans le texte définitif.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

toujours conventionnelle[2277]. Pour la Cour d'appel du Luxembourg, la subrogation légale n'est que subsidiaire par rapport à la subrogation conventionnelle : s'il y a eu subrogation conventionnelle, le subrogé n'a pas à démontrer que les conditions de la subrogation légale sont remplies[2278].

1) *La subrogation légale*

1020. Quatre cas. L'article 1251 du Code civil prévoit quatre cas où la subrogation a lieu de plein droit. Des quatre cas prévus par l'article 1251, celui du 3° est de loin le plus important, parce qu'il a une portée générale (**a**). Les autres cas ne mériteront qu'une rapide mention (**b**).

a. *L'article 1251-3° du Code civil*

1021. *Solvens* tenu pour d'autres ou avec d'autres. Ce texte prévoit la subrogation au profit de « celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ». C'est, dit la Cour d'appel, « l'éventualité où la subrogation s'impose avec le plus d'évidence, celle où l'équité la requiert le plus impérieusement »[2279]. Depuis longtemps, la jurisprudence estime que les deux conditions posées par ce texte (être tenu au paiement et avoir intérêt à l'acquitter) sont confondues. Il faut et il suffit que celui qui a payé la dette d'autrui ait été obligé de le faire – ce qu'exprime maladroitement le texte en disant qu'il avait intérêt de l'acquitter. Le texte vise spécialement deux hypothèses. La première est celle où celui qui a payé était tenu *avec* d'autres : cela vise le cas du *codébiteur solidaire* qui a payé la totalité de la dette ; il peut se retourner contre l'autre pour tout ce qui excède sa part contributive (C. civ., art. 1214), et bénéficie pour ce recours de tous les droits qui appartenaient au créancier désintéressé. L'autre hypothèse est celle où le *solvens* était tenu *pour* d'autres : cela vise tout spécialement la caution qui est obligée de payer la dette du débiteur principal. Ayant payé, elle a un recours contre le débiteur principal en exerçant les droits du créancier (C. civ., art. 2029). Les conditions nécessaires pour que le *solvens* bénéficie de la subrogation légale,

[2277] Sous réserve, en droit luxembourgeois, de la cession légale de la créance d'indemnité des victimes d'accidents aux organismes de sécurité sociale. Mais cette « cession légale » est très proche d'une subrogation.

[2278] Cour d'appel, 13 juin 2018, *Pas.*, 39, p. 54.

[2279] Cour d'appel, 6 juillet 2023, n° 45205.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

sont, d'abord, qu'il ait effectivement payé[2280], et ensuite, qu'il ait été obligé de le faire. Celui qui, spontanément et sans y être tenu, décide de payer la dette d'autrui doit s'il veut avoir un recours, demander à être subrogé conventionnellement[2281].

1022. Extensions. Pris à la lettre, l'article 1251-3° du Code civil ne devrait pas justifier la subrogation dans les cas où le *solvens* a payé une dette qui lui est propre. Raisonnons par exemple sur le cas de l'assureur de dommages qui a indemnisé son assuré à la suite du vol ou de la destruction par un tiers d'un de ses biens : l'assureur était bien tenu de payer, mais il ne l'était pas « pour un autre », il n'a pas payé la dette de l'auteur du dommage, il n'a fait que payer sa propre dette, fondée sur le contrat d'assurance qui le lie à son assuré et trouvant sa cause dans le paiement des primes. Il ne devrait donc pas pouvoir récupérer auprès de l'auteur du dommage, sur le fondement de la subrogation, les sommes qu'il a versées. Cependant la solution apparaît injuste, car elle aboutit à libérer sans raison l'auteur du dommage de son obligation de réparation. C'est pourquoi, dans les trois pays du Code civil, le législateur a édicté des textes spéciaux pour ouvrir un recours subrogatoire dans de telles hypothèses. En France, le recours subrogatoire de l'assureur de dommages a été reconnu par une loi de 1930, aujourd'hui intégrée dans le Code des assurances[2282]. Au Luxembourg, la loi du 27 juillet 1997, dans son article 52, admet de même que « l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage ». Sur le même modèle, des textes spéciaux ont reconnu un recours subrogatoire à l'employeur qui, sur le fondement de l'article L. 121-6 du Code du travail, verse son salaire à un salarié victime d'un accident contre le responsable de celui-ci[2283], ou au Fonds pour l'emploi qui a versé des indemnités de chômage à un salarié en cas de faillite de l'employeur dans les droits et privilèges du salarié contre cet employeur[2284]. Partant de la même

[2280] Cour d'appel, 5 juin 2013, n°s 38205 et 38524.

[2281] Trib. Luxembourg, 22 juin 2011, *Pas.*, 35, p. 755 ; Cour d'appel, 15 juillet 2020, n° CAL-2019-00192.

[2282] C. ass. fr., art. L. 121-12. En droit français, le mécanisme de la subrogation fonde également le recours des organismes de sécurité sociale contre les auteurs d'accidents entraînant le versement de prestations aux assurés. On rappelle qu'en droit luxembourgeois, ce recours est fondé sur une cession de créance légale.

[2283] C. trav., art. 121-6 (6).

[2284] C. trav., art. L. 126-1 (8).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

idée, la Cour de cassation française avait admis, au-delà des textes spéciaux qui la consacrent, que « celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette »[2285]. Par exemple : un créancier charge un mandataire (ou un notaire) d'accomplir des formalités de conservation d'une sûreté ; le mandataire manque à son obligation, la sûreté est perdue ; en conséquence, il est condamné à indemniser son client en lui payant le montant de la créance. Ce faisant, il paye sa propre dette, mais la Cour de cassation française ne lui reconnaît pas moins un recours contre le débiteur (qu'il ne serait pas juste de libérer). Cette jurisprudence, qui étend considérablement le champ d'application de l'article 1251-3° du Code civil a été suivie au Luxembourg. Déjà en 1992, la Cour de cassation avait admis qu'un maître de l'ouvrage ayant vendu un immeuble affecté de malfaçons et tenu d'effectuer des dépenses en raison de son obligation légale de garantie à l'égard de l'acquéreur peut conserver un intérêt à agir contre les personnes responsables des vices en application des articles 1792 et 2270 du Code civil[2286]. La Cour d'appel du Luxembourg a par la suite repris la formule de la Cour de cassation française. Ainsi dans un arrêt de 2011, cette Cour admet que l'État, qui indemnise un salarié pour la perte de salaire qu'il subit à la suite d'un licenciement abusif, sur le fondement d'un règlement grand-ducal relatif à l'aide au réemploi, peut invoquer l'article 1251-3° du Code civil pour obtenir le remboursement de ces indemnités de l'employeur, responsable de la perte d'emploi. Sans doute l'État n'avait fait ici qu'exécuter une obligation légale qui lui incombait et qui était tout à fait distincte de l'obligation de réparation pesant sur l'employeur, mais, pour la Cour, la subrogation définie à l'article 1251-3 du Code civil « s'applique au débiteur qui, bien que tenu d'une dette personnelle, fondée par une cause qui lui est propre, libère, en acquittant sa dette, un autre débiteur, tenu à un autre titre »[2287].

La jurisprudence française, ainsi suivie au Luxembourg, a été explicitement consacrée en 2016 dans le nouvel article 1346 du Code civil français qui dispose : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. ». Très proche, l'article 5.220

[2285] Cass. fr. (1re civ.), 7 novembre 1995, n° 93-16148 ; Cass. fr. (1re civ.), 27 mars 2001, n° 98-16723.
[2286] Cass., 26 novembre 1992, *Pas.*, 29, p. 204.
[2287] Cour d'appel, 26 mai 2011, n° 35485, *BIJ*, 2011, p. 154.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

du nouveau Code civil belge dispose que la subrogation a lieu de plein droit : « au profit de celui qui s'acquitte d'une dette, s'il a, par son paiement, libéré, à l'égard de leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».

b. *Les autres cas de subrogation légale*

1023. ***Solvens* ayant payé sans y être obligé.** À la différence de l'article 1251-3° du Code civil, les trois autres cas de l'article 1251 du Code civil visent des cas où une personne a payé la dette d'autrui sans y être obligé.

- l'article 1251-1° du Code civil prévoit la subrogation au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye (volontairement) un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges et hypothèques. Ce texte permet à un créancier d'éviter qu'un créancier de rang préférable au sien ne choisisse un mauvais moment pour saisir et faire vendre le bien grevé de sûreté.
- l'article 1251-2° du Code civil prévoit la subrogation au profit de l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué qui paye les créanciers hypothécaires avec le prix de vente : si le prix n'est pas suffisant pour désintéresser tous les créanciers du vendeur, cette subrogation permettra à l'acquéreur, en cas de saisie de l'immeuble, de primer les créanciers impayés.
- l'article 1251-4° du Code civil fait profiter de la subrogation l'héritier bénéficiaire qui accepte de désintéresser avec ses deniers personnels les créanciers de la succession.

Ces cas, très liés au droit des sûretés, ou au droit des successions, et qui n'ont qu'un intérêt pratique assez limité, ne méritent pas d'être examinés plus avant dans un manuel de droit des contrats. Ils ont été maintenus dans le nouveau texte belge, qui ajoute que la subrogation a lieu « dans tous les autres cas où la loi le prévoit ». En revanche, les trois cas spéciaux prévus par l'actuel article 1251 ont disparu du Code civil français, parce qu'on a considéré qu'ils étaient absorbés dans le cas général.

2) *La subrogation conventionnelle*

1024. Distinction. Même si celui qui a payé n'était pas tenu de le faire, et n'entrait pas dans un des cas prévus par les textes, il peut se faire subroger dans les droits du créancier (C. civ., art. 1250). La subrogation peut résulter soit d'un accord de volontés entre le créancier (subrogeant) et le tiers *solvens* qui va être subrogé (**a**), soit, plus rarement, d'un accord de volontés ente le débiteur et le tiers subrogé (**b**).

a. *La subrogation par le créancier (ex parte creditoris)*

1025. Principe. Une personne paye volontairement la dette d'une autre, avec l'intention de se faire rembourser par cette dernière. Elle doit alors, pour se ménager un recours subrogatoire contre le débiteur, demander au créancier de la subroger dans ses droits. Cette subrogation par le créancier, dite parfois *ex parte creditoris*, est

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

prévue par l'article 1250 1° du Code civil. Elle ressemble beaucoup à une cession de créance à titre onéreux : le créancier originaire (subrogeant) se fait payer immédiatement le montant de sa créance, et, en contrepartie, transfère la créance à celui qui le paye. Elle est cependant soumise à des conditions différentes : plus rigoureuses quant à la validité de l'opération, plus souples quant à son opposabilité aux tiers. Et, comme nous le verrons plus loin, elle ne produit pas tout à fait les mêmes effets.

1026. Conditions de fond. Les conditions sont en général les mêmes que pour la cession de créance. Il faut le consentement des parties – c'est-à-dire du créancier subrogeant et du tiers payeur, le débiteur restant, comme dans la cession de créance, étranger à l'opération. Cela s'explique parce que la subrogation ayant, comme la cession, un effet translatif, la situation juridique du débiteur ne s'en trouve pas aggravée.

Une différence importante avec la cession de créance est cependant que la subrogation, du point de vue de sa cause, est nécessairement une opération à titre onéreux, puisqu'elle est liée au paiement de la créance. Le créancier ne peut pas subroger quelqu'un qui ne le paie pas. Par ailleurs, la subrogation n'est possible que pour des créances existantes : on ne peut pas payer en effet une créance qui n'existe pas encore.

1027. Conditions de forme. L'article 1250 du Code civil pose deux exigences :

- d'une part, la *subrogation doit être expresse* : aucune mention sacramentelle n'est exigée, mais il faut que le créancier exprime nettement sa volonté de transférer sa créance à celui qui le paye :
- d'autre part, *la subrogation doit être faite en même temps que le paiement*[2288]. Généralement l'accord de subrogation résulte d'une mention dans la quittance remise par le créancier lors du paiement, qu'on appelle quittance subrogatoire ou subrogative. Cette exigence de concomitance interdit certainement une subrogation consentie *a posteriori*, car le paiement fait sans mention de la subrogation, aura produit son effet extinctif et on ne peut plus faire revivre la créance. Mais, selon la jurisprudence française – confirmée sur ce point par le nouvel

[2288] Cour d'appel, 13 juillet 2017, n° 42515.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

article 1346-1, alinéa 3, du Code civil français – cela n'interdit pas la subrogation par anticipation : les parties peuvent convenir par avance que, chaque fois que le tiers paiera le créancier, celui-ci le subrogera dans ses droits[2289]. Cette jurisprudence est suivie au Luxembourg[2290]. C'est ce qui se produit notamment dans la pratique de l'affacturage, qui constitue l'utilisation la plus fréquente aujourd'hui de la subrogation conventionnelle : un établissement de crédit (*factor*) accepte de payer les factures émises par une entreprise, moyennant subrogation dans les droits de celle-ci contre les débiteurs des factures[2291]. Cela permet à l'entreprise d'obtenir un paiement immédiat des créances qu'elle a contre ses clients, et de s'épargner les soucis du recouvrement.

1028. Absence de formalités d'opposabilité. À la différence de la cession de créance, la subrogation est opposable aux tiers sans qu'il soit nécessaire de la notifier formellement au débiteur de la créance ainsi transmise : les formalités de l'article 1690 du Code civil ne sont pas applicables ici[2292]. Certes, il sera prudent pour le subrogé d'avertir le débiteur de la créance transmise de la subrogation. À défaut, celui-ci pourrait payer de bonne foi son créancier originaire et il serait libéré. Mais cet avertissement au débiteur n'est soumis à aucune forme spéciale. Dans le cadre de l'affacturage, on envoie au débiteur un double de la facture avec une mention indiquant que celle-ci a été transmise à l'établissement de crédit et que c'est donc celui-ci qu'il faut payer. Jusqu'à la réforme française, la différence entre subrogation et cession de créance était cependant moins marquée au Luxembourg qu'en France, compte tenu de l'assouplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil par la loi de 1994. Mais désormais le nouvel article 1346-5 du Code civil français aligne le système d'opposabilité de la subrogation sur celui retenu en matière de cession : la subrogation est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé dès le paiement, mais elle doit être notifiée au débiteur pour l'empêcher de payer valablement le créancier originaire. De même, dans le nouveau droit belge, l'article 5.222 du

[2289] Cass. fr., 29 janvier 1991, n° 89-10085 ; Cass. fr. (1re civ.), 28 mai 2002, n° 99-17733.

[2290] Trib. Luxembourg, 5 juillet 2024, n° TAL-2022-06277.

[2291] Cour d'appel (réf.), 11 juillet 1995, *Pas.*, 29, p. 441 ; Cour d'appel, 6 février 2002, n° 25422 ; Trib. Diekirch, 27 novembre 2018, nos 21057 et 21295 ; Trib. Luxembourg, 20 décembre 2023, n° TAL-2023-04577.

[2292] Cour d'appel(réf.), 11 juillet 1995, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

nouveau Code civil renvoie pour la subrogation à l'article 5.181 selon lequel « le débiteur qui a payé de bonne foi avant que la cession ne lui ait été notifiée ou qu'il l'ait reconnue est libéré ».

Au Luxembourg, donc, la différence avec la cession de créance est plus sensible vis-à-vis des tiers autres que le débiteur cédé, dans la mesure où la notification au débiteur reste une condition d'opposabilité de la cession aux créanciers du cédant et aux autres cessionnaires. La subrogation, en revanche, leur sera opposable dès le moment du paiement. Néanmoins, ceux-ci pourraient prétendre que la date portée sur la quittance est fausse et que la subrogation a en réalité eu lieu après qu'ils ont acquis leurs droits. Il faut donc faire enregistrer la quittance subrogative pour lui donner date certaine, conformément à l'article 1328 du Code civil. Cependant, il faut rappeler que ce texte n'est pas applicable en matière commerciale, ce qui permet de se dispenser de la formalité de l'enregistrement dans le cadre de l'affacturage. En cas de contestation sur la date, il appartiendra au subrogé d'en prouver l'exactitude par tous moyens.

b. *La subrogation par le débiteur (ex parte debitoris)*

1029. **Principe.** Prévue par l'article 1250-2° du Code civil, cette subrogation, dite aussi *ex parte debitoris*, est rarement utilisée en pratique. L'hypothèse est que le débiteur emprunte à un tiers, à des conditions plus avantageuses, dans le but de rembourser sa première dette par anticipation (on suppose que ce remboursement anticipé est possible). Il peut alors subroger son nouveau créancier dans les droits du premier, ce qui peut permettre au second prêteur de bénéficier d'un rang avantageux : par exemple, si le prêt initial était garanti par une hypothèque de premier rang, celle-ci va bénéficier au second prêteur. Cette subrogation, qui ne suppose pas l'intervention du premier créancier, apparaît comme une forme d'expropriation de celui-ci. Pour éviter des fraudes, l'article 1250-2° du Code civil subordonne la validité de cette subrogation à des conditions formelles très lourdes, destinées à établir un lien incontestable entre le second emprunt et le remboursement de la dette primitive : il faut « que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant le notaire ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier ». Le nouvel article 1346-2 du Code civil français a maintenu cette forme de subrogation, mais en en assouplissant les conditions dans le cas où elle est consentie avec le concours du créancier. Le nouveau texte belge (art. 5.219), quant à lui, reprend sans changement l'article 1250-2.

B) *Les effets de la subrogation*

1030. **Comparaison avec la cession.** Que la subrogation soit légale ou conventionnelle, elle produit, comme la cession de créance, un effet translatif, quoique moins complet (**1**). À la différence de la cession de créance, en revanche, la subrogation, même lorsqu'elle

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

est conventionnelle, ne fait pas en principe naître d'obligations entre les parties, en particulier quant à la garantie que doit assurer le subrogeant (**2**).

1) *Transfert de la créance*

a. *Principe*

1031. Identité de la créance transmise. Le subrogé acquiert la créance, comme le cessionnaire, telle qu'elle existait dans le patrimoine du créancier originaire. Le subrogé bénéficie donc de tous les accessoires de la créance, et en particulier des sûretés qui en assortissaient le recouvrement. C'est du reste l'intérêt principal qu'il y a, pour celui qui a payé la dette d'autrui, de disposer d'un recours subrogatoire en plus du recours personnel qu'il peut éventuellement avoir contre le débiteur sur le fondement du mandat ou de la gestion d'affaires. Comme en matière de cession, la notion d'accessoire est largement entendue et ne se limite pas aux sûretés au sens strict. Par exemple, la Cour d'appel a jugé qu'un banquier, qui finançait l'acquisition d'un véhicule en payant directement le vendeur de celui-ci (au lieu de prêter l'argent à l'acheteur) bénéficiait par subrogation de la clause de réserve de propriété insérée dans le contrat de vente[2293]. De même une caution, subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur et les autres cautions pourra bénéficier de la clause attributive de compétence figurant dans le contrat entre le créancier et le débiteur[2294].

En sens inverse, le subrogé pourra se voir opposer, tout comme le cessionnaire, toutes les exceptions que le débiteur de la créance transmise aurait pu opposer à son créancier originaire : nullité du contrat générateur de la créance, inopposabilité de certaines clauses[2295], exception d'inexécution en raison de l'inexécution par le créancier de ses obligations envers le débiteur, compensation antérieure à la subrogation, etc. On peut ici transposer les solutions reçues en matière de cession, en particulier en ce qui concerne le moment de naissance des exceptions opposables. On peut du reste remarquer que, dans le nouveau texte français, les articles relatifs aux effets de la cession et de la subrogation sont sur ce point rédigés de manière strictement identique[2296].

[2293] Cour d'appel, 8 novembre 2007, n° 31076, *BIJ*, 2008, p. 223.
[2294] Cour d'appel, 10 juillet 2002, *Pas.*, 32, p. 284.
[2295] Cour d'appel, 6 février 2002, n° 25422, *BIJ*, 2003, p. 7.
[2296] Comp. art. 1346-5, al. 3 pour la subrogation et 1324, al. 2 pour la cession.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Tout cela ne signifie pas, cependant, que, lorsque la créance transmise est d'origine contractuelle, le subrogé devient partie au contrat qui l'a fait naître. La transmission ne concerne que la créance qui a été payée, le créancier originaire demeurant par ailleurs tenu de toutes les obligations nées du contrat. Là encore, la situation est la même que dans la cession de créance.

b. *Limite*

1032. Transfert limité au paiement. Dans la mesure où la subrogation est liée au paiement, le subrogé n'acquiert la créance que dans la limite de ce qu'il a payé : s'il n'a payé qu'une partie de la dette, il ne sera subrogé que pour ce montant (cf. C. civ. fr., art. 1346-4, al. 1 ; C. civ. be., art. 5.222, al. 1). C'est une différence importante avec la cession de créance où le cessionnaire acquiert la créance pour son montant nominal, quel que soit le prix qu'il a payé. Cette particularité exclut l'utilisation de la subrogation comme technique spéculative. En revanche elle n'interdit pas le versement d'une rémunération par le subrogeant au subrogé, pourvu que cette rémunération ne vienne pas en déduction du paiement de la dette. Dans la pratique, lorsque la subrogation est faite au profit d'un établissement de crédit (société d'affacturage qui « achète » les créances de ses clients, banque qui finance une acquisition faite par un client en payant directement le vendeur, etc.), l'astuce consiste à payer intégralement la créance et à débiter le compte du client de la rémunération du crédit ainsi accordé.

1033. Concours entre le subrogé et le créancier originaire. Cette limite à l'effet translatif pourrait être gênante pour le créancier originaire lorsqu'il n'a été payé qu'en partie par le tiers subrogé. Il devrait logiquement venir en concours avec le subrogé, chacun agissant pour obtenir le recouvrement d'une partie de la dette : par exemple, la dette est de 100 000 €, les biens du débiteur valent 70 000 € ; le créancier accepte d'un tiers un paiement partiel de 50 000 €. Sur les biens du débiteur, le créancier originaire et le subrogé devraient venir en concours, chacun recevant 35 000 €, le créancier originaire n'étant pas ainsi complètement payé.

L'article 1252 du Code civil (repris en substance par le nouvel article 1346-3 du Code civil français et par l'article 5.223 du nouveau Code civil belge) limite ce concours : selon ce texte, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie. C'est la traduction moderne d'un adage ancien « *nemo contra se subrogasse censetur* ». Cependant, la jurisprudence française n'applique traditionnellement ce texte que dans le cas où le créancier originaire avait une hypothèque ou une autre sûreté sur un bien du débiteur[2297], car c'est seulement dans ce cas que la subrogation pourrait nuire au créancier : si le créancier avait accepté un paiement

[2297] Cass. fr. (Req.), 1er août 1860, *DP*, 1860, 1, p. 246.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

partiel de son débiteur, il aurait conservé son hypothèque pour la totalité et aurait été complètement désintéressé ; il ne faut pas que le fait d'avoir accepté le paiement d'un tiers compromette ce paiement. En revanche, si le créancier désintéressé partiellement était chirographaire, la concurrence avec le subrogé ne lui nuit pas nécessairement ; il n'aurait rien eu de plus si d'autres créanciers avaient concouru. La jurisprudence française récente a cependant abandonné cette restriction dans le cas particulier d'un assuré partiellement indemnisé par son assureur, qui prime alors l'assureur dans son action contre l'auteur du dommage[2298]. Par ailleurs, dans la pratique contractuelle, notamment du cautionnement, on trouve fréquemment des clauses qui interdisent au subrogé, de manière générale, de venir en concours avec le créancier partiellement payé.

2) *Absence d'obligations des parties*

1034. Absence de garantie. La subrogation résulte d'un paiement, qui n'est pas un acte générateur d'obligations. Il en va ainsi même lorsque la subrogation est conventionnelle. Le subrogeant n'est pas tenu vis à vis du subrogé des obligations d'un vendeur. En particulier, il n'est pas tenu à garantie.

D'une part, pas plus que dans la cession de créance, il ne garantit le subrogé contre l'insolvabilité du débiteur. Dans le cadre de l'affacturage, cette absence de garantie est conforme à l'esprit de l'opération : à la différence des autres techniques de mobilisation des créances, l'affactureur prend normalement à sa charge le risque d'insolvabilité des clients – sauf naturellement à se faire payer plus cher. Il semble cependant qu'une clause contraire soit possible.

D'autre part – à la différence cette fois de la cession de créance – le subrogeant n'est même pas tenu de garantir le subrogé contre les vices de la créance. Mais, dans ce cas, le subrogé a payé une somme qui n'était pas due, et il a une action en répétition de l'indu, qui lui permettra d'obtenir de l'accipiens le remboursement de la somme payée.

§ 3. La transmission des créances aux ayants-cause d'un contractant

1035. Distinction des ayants-cause universels et particuliers. On désigne d'une manière générale par le terme d'ayant-cause (ou, parfois, d'ayant-droit) toute personne qui a acquis un ou plusieurs droits d'une autre – qu'on appelle son auteur. On distingue deux catégories d'ayants-cause. Les ayants-cause universels sont ceux qui ont acquis,

[2298] Cass. fr., 27 février 2007, n° 04-12414.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

par succession, ou par l'effet de la transmission du patrimoine d'une personne morale, l'intégralité (ou une quote-part : on parle alors d'ayants-cause à titre universel) du patrimoine de leur auteur. Les ayants-cause particuliers (ou à titre particulier), en revanche, n'ont acquis qu'un droit ou plusieurs droits particuliers de leur auteur, soit par l'effet d'un acte à titre onéreux (vente, échange), soit par un acte à titre gratuit (donation, testament par lequel le testateur lègue un ou plusieurs biens). Alors que les premiers deviennent titulaires des créances nées avant le décès sur la tête de leur auteur (A), cette transmission n'est qu'exceptionnelle pour les ayants-cause à titre particulier (B).

A) *Transmission aux ayants-cause universels ou à titre universel*

1036. Personnes physiques. Les héritiers d'une personne physique recueillent à son décès le patrimoine de leur auteur (ou une quote-part de ce patrimoine s'ils sont plusieurs), qui se fond dans leur propre patrimoine. Ils deviennent donc, dès le moment du décès, titulaires de toutes les créances et de toutes les dettes de leur auteur (C. civ., art. 724). S'agissant des créances, qui nous intéressent ici, cela vaut aussi bien pour les créances contractuelles que pour toutes les autres (créances de dommages et intérêts délictuels, par exemple). Si, par exemple, mon père, avant son décès, avait prêté de l'argent à un ami, et que celui-ci ne l'avait pas encore remboursé, c'est moi, son héritier, qui vais devenir créancier à sa place – sans bien sûr qu'on songe à voir là une dérogation au principe de l'effet relatif du contrat. Comme dans tous les mécanismes de transmission, je deviendrai titulaire de cette créance avec tous ses accessoires, et je pourrai donc me prévaloir des sûretés, réelles et personnelles, qui garantissaient cette dette. L'emprunteur, de son côté, pourra m'opposer toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à mon père. Cette transmission se produit de la même manière à l'égard d'un ayant-cause universel (un héritier unique, qui recueille l'intégralité de la succession) et des ayants-cause à titre universel (plusieurs héritiers), sauf à remarquer que, dans ce second cas, la créance se divise entre les héritiers, qui ne peuvent demander au débiteur que leur part[2299].

Pour les personnes physiques, une telle transmission universelle ne peut en principe s'opérer qu'à cause de mort. Du vivant de la personne, seules peuvent en principe être transmises des créances particulières ; le patrimoine, envisagé comme une universalité,

[2299] Sauf si la créance a un objet indivisible, ou si, divisible par nature, elle a été stipulée indivisible. Voy. *supra*, n° 632.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

est normalement incessible, à raison du lien étroit, fait, dans les pays du Code civil, entre le patrimoine et la personnalité juridique. Cependant, au Luxembourg, l'article 1050-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales permet aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle de transférer, de leur vivant, « tout ou partie de leur patrimoine professionnel avec actifs et passifs à un autre sujet de droit dans le cadre d'une affectation professionnelle »[2300]. L'acquéreur du patrimoine professionnel va donc devenir titulaire de toutes les créances du cédant liées à cette activité professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de respecter les formalités de l'article 1690 du Code civil, mais l'opposabilité aux tiers est subordonnée à une publication au Registre du commerce et des sociétés.

1037. Personnes morales. Pour les personnes morales, la transmission à cause de mort de l'ensemble du patrimoine trouve son équivalent dans les effets attribués aux opérations de fusion de sociétés, soit par absorption d'une société dans une autre préexistante, soit par regroupement de plusieurs sociétés dans une nouvelle (L. 10 août 1915, art. 1020-2). La société issue de la fusion (ou la société qui en a absorbé une autre) devient titulaire de toutes les créances qui étaient nées avant la fusion, au profit des sociétés fusionnées, ou de la société absorbée. Il en va de même en cas de scission d'une société en plusieurs sociétés, qui vont chacune recueillir une partie du patrimoine (donc en particulier des créances et des dettes) de la société scindée. Une transmission universelle ou à titre universel des créances et des dettes d'une société peut également s'opérer, sans que la personnalité juridique de la société soit affectée, dans le cadre d'un apport partiel d'actifs (L. 10 août 1915, art. 1040-2.), de l'apport d'une branche d'activité (L. 10 août 1915, art. 1040-3), ou d'un apport d'universalité, qui est « l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles » (L. 10 août 1915, art. 1040-4). Une société peut également opérer un transfert de patrimoine professionnel selon la même procédure que celle qui a été évoquée précédemment pour les personnes physiques. En principe, la cession d'une universalité par voie d'apport en société, portant sur l'intégralité d'une branche d'activité commerciale, est soumise aux dispositions de l'article 1690 du Code civil[2301].

[2300] Texte inséré par la loi du 23 mars 2007 (Mém. A46 du 30 mars 2007 P. 815).
[2301] Cass., 14 mars 2013, n° 18/13 ; Cour d'appel, 11 mai 2016, n° 33227.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

B) *Transmission aux ayants-cause à titre particulier*

1038. Principe de non-transmission. Les ayants-cause à titre particulier ne sont évidemment pas concernés de manière générale par les contrats passés par leur auteur, et n'ont aucune raison de devenir titulaire à sa place des créances que ces contrats ont fait naître : si j'achète une voiture à un commerçant, les créances que mon vendeur peut avoir contre ses différents clients ne me seront évidemment pas transmises. Mais la question se pose plus sérieusement lorsqu'il s'agit de contrats, et de créances, qui sont directement relatives au bien transmis : si mon vendeur avait passé, avec un garagiste, un contrat d'entretien de sa voiture, et qu'il me la vend alors que le garagiste n'a pas encore effectué toutes les prestations d'entretien prévues au contrat, on peut trouver rationnel que ce soit désormais moi, nouveau propriétaire de la voiture, qui puisse bénéficier de ces prestations d'entretien, et éventuellement demander réparation si elles ne sont pas ou mal effectuées.

1039. Transmission des créances comme accessoires du bien vendu. À partir de ces considérations, la jurisprudence française admet que les ayants-cause à titre particulier se voient transmettre, sans qu'il soit besoin d'une cession de créance expresse, les créances qui sont les accessoires indissociables du bien qui leur a été transmis. Ainsi, dans une espèce analogue à l'exemple donné, la Cour de cassation française a admis que l'acheteur d'un bateau pouvait exercer une action en responsabilité contractuelle contre l'entreprise qui avait, à la demande du vendeur, réparé ce bateau antérieurement à la vente, et avait mal exécuté ses obligations : pour la Cour de cassation « l'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre le réparateur de cette chose d'une action directe contractuelle fondée sur l'inexécution d'une obligation »[2302]. Sur le même fondement, on admet traditionnellement en France que l'acquéreur d'un fonds de commerce se voit transmettre le bénéfice de la créance de non-concurrence qui avait été accordée à son vendeur dans son propre contrat d'acquisition du fonds[2303]. Surtout, depuis le XIXe siècle, la jurisprudence française admet que le sous-acquéreur d'un bien défectueux peut agir contractuellement en garantie des vices cachés contre le vendeur initial, et cette solution a été, dans

[2302] Cass. fr. (1re civ.), 26 mai 1999, n° 97-14879.
[2303] Cass. fr. (1re civ.), 3 décembre 1996, n° 95-10913.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la période récente, rattachée par la Cour de cassation à l'idée de transmission comme accessoire de la chose transmise, de l'action en garantie qui appartenait à l'acheteur intermédiaire contre son vendeur[2304]. L'article 5.105 du nouveau Code civil belge dispose à cet égard que « sauf clause contraire, les droits cessibles qui sont étroitement liés à un bien en manière telle que l'intérêt de ces droits dépend de la propriété du bien, sont transmis à celui qui acquiert ce bien à titre particulier ».

Cette dernière solution a été reprise au Luxembourg, comme d'ailleurs en Belgique. Elle mérite une étude approfondie, mais nous ferons cette étude plus loin, dans le cadre de la problématique générale des actions directes dans laquelle elle s'inscrit[2305]. On la note simplement ici parce que le fondement retenu – bien qu'il soit discuté – illustre bien la reconnaissance en droit positif d'une transmission de plein droit d'une créance contractuelle sans passer par les mécanismes légaux de la cession de créance et de la subrogation.

SOUS-SECTION 2. LE REMPLACEMENT SANS TRANSMISSION D'UN CRÉANCIER PAR UN TIERS

1040. Principe. Ici, un nouveau créancier va prendre la place de l'ancien, mais la créance qui en résultera sera une créance nouvelle, sans les accessoires qui assortissaient l'ancienne, mais également purgée des vices qui pouvaient l'affecter. C'est ce qui se produit dans le cas de la novation par changement de créancier, rare en pratique, mais aussi dans la délégation, beaucoup plus fréquente.

1041. Novation par changement de créancier. On a vu précédemment que la novation était un mécanisme d'extinction des obligations, par remplacement d'une obligation ancienne par une obligation nouvelle. Selon l'article 1271 du Code civil cette novation peut s'opérer de trois manières : entre les parties, lorsque le débiteur contracte envers son créancier une dette nouvelle destinée à remplacer l'ancienne (par exemple, un nouveau prêt), ou par changement de la personne d'une des parties, qui peut être, soit le débiteur, soit le créancier. C'est seulement ce dernier cas qui nous intéresse ici. Cette novation résulte d'une convention tripartite entre l'ancien créancier, le débiteur, et le nouveau créancier[2306]. Le débiteur

[2304] Voy. *infra*, n°s 1111 et s.
[2305] Voy. *infra*, n°s 1104 et s.
[2306] Cour d'appel, 9 juillet 2014, n° 39019.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

est déchargé envers son créancier originaire, et contracte envers le nouveau créancier un nouvel engagement, qui va se substituer à l'engagement ancien. Comme la cession de créance et la subrogation, cette opération permet à un créancier de conférer à une autre personne le bénéfice de sa créance, soit à titre gratuit, soit pour en obtenir le paiement immédiat par le nouveau créancier, soit à titre de garantie d'un crédit qui lui est accordé par ce dernier. Mais les effets de la novation sont très différents de ceux de la cession et de la subrogation, parce qu'il ne s'agit pas d'un mécanisme translatif. Le débiteur prend envers le nouveau créancier un engagement nouveau qui n'est pas nécessairement identique à la créance initiale. Cela signifie que la nouvelle créance n'est pas en principe affectée par les vices qui pouvaient affecter l'ancien engagement : le débiteur ne peut pas opposer au nouveau créancier les exceptions qu'il aurait pu opposer à l'ancien (sauf s'il s'agit d'exceptions tenant à sa personne – son incapacité par exemple – qui se retrouvent dans le nouvel engagement). Par ailleurs, la nouvelle créance ne bénéficie pas en principe des accessoires qui assortissaient la créance primitive. Cependant l'article 1278 du Code civil prévoit la possibilité pour le nouveau créancier de stipuler expressément le maintien des sûretés qui assortissaient la dette. Tout comme la novation en général, la novation par changement de créancier ne se présume pas, elle doit résulter clairement de l'acte[2307]. Les solutions sont reprises en France par les nouveaux articles 1333 et 1334 du Code civil français, et par les articles 5.245 et 5.247 du nouveau Code civil belge.

Cette opération est rarement pratiquée à titre isolé. Mais elle s'intègre souvent dans le cadre d'une opération opérant à la fois changement de débiteur et changement de créancier, la délégation.

1042. Délégation (renvoi). La délégation, visée à l'article 1275 du Code civil, est une opération tripartite par laquelle une personne (délégant) obtient d'une autre (délégué) qu'elle prenne un engagement envers une troisième (le délégataire). Contrairement aux opérations précédemment étudiées, la délégation ne s'inscrit pas nécessairement dans un rapport d'obligation préexistant où les qualités de créancier, de débiteur, et de tiers prenant la place d'un des deux, seraient déterminées à l'avance. C'est un mécanisme abstrait qui peut avoir de multiples utilisations, y compris dans des

[2307] Trib. Luxembourg, 2 juillet 2019, n° TAL-2019-03398 (le fait pour un sous-locataire de payer ses loyers directement au propriétaire ne permet pas de conclure que ce dernier est devenu créancier de ces loyers à la place du locataire principal par l'effet d'une novation).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

hypothèses où aucune des parties n'est au départ créancière ou débitrice d'une autre : on peut s'en servir, par exemple, pour réaliser une double libéralité. Mais, dans l'immense majorité des cas, la délégation est liée à des rapports juridiques préexistants. En particulier, dans le contexte qui nous intéresse ici, on peut imaginer que le délégant soit créancier du délégué, et qu'il veuille transmettre le bénéfice de sa créance à un tiers (pour toutes les raisons qui ont été vues précédemment à propos de la cession). Au lieu de procéder par la voie d'une cession de créance ou d'une subrogation conventionnelle, il va déléguer son débiteur en lui demandant de s'engager à payer le tiers (délégataire). La différence essentielle avec la cession de créance est alors que la créance du délégataire contre le délégué est une créance nouvelle, qui n'est pas nécessairement identique à celle du délégant. Cependant, dans l'utilisation la plus typique de la délégation, le délégant, s'il est créancier du délégué, est en même temps débiteur du délégataire, et la délégation lui permettra, non seulement de « transmettre » sa créance au délégataire, mais aussi de faire reprendre sa dette par le délégué. L'étude complète de la délégation ne pourra donc être faite que dans le cadre des développements, qui vont suivre, consacrés à la reprise de la qualité de débiteur contractuel.

SECTION 2. LES TIERS PRENANT LA QUALITÉ DE DÉBITEUR CONTRACTUEL

1043. Mécanismes translatifs et non translatifs. Lorsqu'il s'agit de faire assumer par un tiers la charge d'une dette qui incombe à un débiteur contractuel, on retrouve la même distinction que précédemment entre les mécanismes translatifs et non translatifs. Dans les premiers, le tiers qui reprend la position de débiteur devient débiteur de la même dette qui était celle du débiteur originaire : cette dette lui est transmise avec ses accessoires et ses éventuels défauts. On peut alors véritablement parler d'une cession de dette. Dans les seconds, le tiers ne recueille pas à proprement parler dans son patrimoine la dette du premier débiteur, il prend, à sa place ou à ses côtés, l'engagement personnel de payer le créancier. Cette distinction n'a cependant pas du tout la même portée que pour le changement de la qualité de créancier, qui peut se faire selon l'un ou l'autre modèle (cession de créance ou subrogation *versus* novation par changement de créancier ou délégation). S'agissant des dettes, en effet, la

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

possibilité de transmission n'est reconnue que de manière très limitée (**Sous-Section 1**), ce qui laisse la première place aux mécanismes non translatifs (**Sous-section 2**).

SOUS-SECTION 1. LA TRANSMISSION DES DETTES CONTRACTUELLES

1044. Distinction. En droit luxembourgeois, comme c'était traditionnellement le cas dans les autres pays du Code civil, la possibilité de transmettre une dette n'est reconnue que dans le cadre d'une transmission universelle ou à titre universel de patrimoine (**§ 1**), mais non à propos d'une dette particulière (**§ 2**).

§1. Transmission universelle ou à titre universel

1045. Transmission des dettes avec les créances. On a précédemment étudié, à propos des créances, les divers cas de transmission du patrimoine, ou d'une partie de patrimoine, soit à cause de mort (transmission aux héritiers), soit entre vifs (transmission dans le cadre des opérations de fusion ou de scission d'une personne morale, apport partiel d'actifs, cession d'une branche d'activité, apport d'universalité par une société, transmission d'un patrimoine professionnel, même entre personnes physiques). Le principe de telles transmissions est que le successeur recueille l'intégralité des biens (y compris les créances), mais aussi des dettes de son auteur. C'est pourquoi, du reste, une telle transmission ne peut jamais être imposée : en cas de décès, la transmission s'opère certes de manière automatique au jour du décès, mais les héritiers, s'ils estiment que la charge des dettes est trop importante par rapport à l'actif, peuvent toujours refuser la succession (C. civ., art. 784 et s.), ou ne l'accepter que sous bénéfice d'inventaire, ce qui leur permet de n'être tenu des dettes que jusqu'à concurrence de la valeur des biens (C. civ., art. 793 et s.).

La transmission des dettes, dans le cas d'un décès, n'est par ailleurs pas aussi complète que celle des créances. Elle ne vaut pas, en principe, pour les obligations de faire : si j'ai contracté avec un artisan personne physique pour qu'il me repeigne mon appartement, et que cet artisan décède avant d'avoir fait le travail, je ne peux pas demander à ses enfants de le faire à sa place en leur qualité d'héritiers.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§ 2. Absence de transmission à titre particulier

1046. Comparaison avec la transmission des créances. Nous avons vu que la loi mettait en place divers mécanismes pour transmettre à un tiers une créance, et que, par ailleurs, la jurisprudence admet parfois la transmission automatique d'une créance contractuelle aux ayants-cause à titre particulier d'une partie. Ni l'une, ni l'autre, de ces solutions ne se retrouve pour les dettes.

A) *Interdiction de la cession translative de dette*

1047. Utilité de la cession de dette. Il paraît étonnant qu'on puisse vouloir céder une dette : de prime abord, la dette n'est pas un bien, c'est une valeur négative que personne ne devrait avoir envie d'acquérir. Il semble par ailleurs anormal que le débiteur puisse se « débarrasser » d'une dette, qu'il doit acquitter, en en transférant la charge à un tiers. La pratique, cependant, montre qu'une telle opération peut présenter un intérêt, et qu'elle n'est pas aussi antiéconomique qu'on pourrait le croire. Par exemple, il peut être intéressant pour l'acquéreur d'un immeuble, au lieu d'emprunter lui-même, de « reprendre » le crédit qui avait été consenti à son vendeur et qui n'était pas encore complètement remboursé, pour bénéficier des conditions avantageuses de ce crédit. Bien entendu, dans un tel cas, le vendeur, déchargé de sa charge de remboursement, devrait recevoir de l'acquéreur qui reprend sa dette un prix minoré du montant du crédit restant à rembourser. Une entreprise peut vouloir « nettoyer son bilan » en transférant à une autre société la charge d'une partie de ses dettes en même temps que des actifs financiers permettant de les payer : c'est ce qu'on appelle la « défaisance »[2308]. Plus exceptionnellement, une personne peut se faire céder une dette pour faire une libéralité au débiteur. Ces utilités diverses expliquent que certains droits nationaux aient consacré cette possibilité de céder une dette : tel est le cas en particulier du droit allemand qui réglemente la *Schuldübernahme* (BGB, § 414), ou du droit suisse qui connaît la reprise de dette (CO, art. 175 à 183). L'opération est également admise par les Principes du droit européen du contrat (art. 12:101 et s.) ainsi que par les Principes Unidroit (art 9.2.1).

1048. Rejet traditionnel de la cession de dette dans les pays du Code civil. Le Code civil de 1804, qui permet la cession de créance, ne permettant pas directement de céder une dette, dans le cadre

[2308] Le terme anglais de *defeasance* est plus souvent employé.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

d'une opération translative, on en déduisait traditionnellement que la cession de dette était interdite. Les arguments donnés pour interdire cette opération sont d'inégale valeur. Sur le plan théorique, on soutenait que la dette est inséparable du contrat qui l'a fait naître, et de la cause initiale de l'engagement du débiteur. Mais cet argument purement dogmatique semble relever de la pétition de principe : du reste, comme nous venons de le voir, la cession de dettes est parfaitement possible dans le cadre de la transmission à titre universel du patrimoine d'une personne décédée, ou d'une société dont la personnalité morale disparaît par suite d'une fusion ou qui opère une transmission de tout ou partie de son patrimoine. Sur le plan pratique, on observait qu'une telle cession ne pourrait pas s'opérer sans le consentement du créancier, qui ne peut pas être tenu d'accepter un nouveau débiteur. À cet égard, la cession de dettes est très différente de la cession de créance : alors que le changement de créancier ne change rien, en droit, à la situation du débiteur (dont le consentement n'est donc pas requis), le changement de débiteur peut s'avérer très dommageable pour le créancier, qui peut se retrouver avec un nouveau débiteur beaucoup moins solvable que le premier. Cependant cet argument ne permet pas de condamner dans l'absolu la cession de dettes : cela implique simplement d'en subordonner la validité, ou du moins la libération du débiteur cédant qui peut en résulter, au consentement du créancier – ce que font tous les droits qui admettent la cession de dette. Quoi qu'il en soit, l'interdiction de la cession de dette semble toujours être la position officiellement admise en droit luxembourgeois[2309]. Un arrêt de la Cour d'appel du 21 juin 2018[2310] laisse cependant planer le doute, en jugeant qu'une cession de dette n'est pas soumise pour son opposabilité aux formalités requises pour la cession de créance, mais qu'elle suppose le consentement du créancier. Cependant, cet arrêt concerne une cession de dette résultant d'une cession par une société d'une branche d'activité, emportant transmission globale des créances et des dettes s'y rapportant, et on en saurait en déduire la validité d'une cession de dettes qui serait réalisée à titre isolé. Mais on peut également citer un jugement récent du Tribunal de Luxembourg qui, sans émettre aucune réserve, fait produire effet à un « contrat de cession de

[2309] Trib. Luxembourg, 21 décembre 2016, n° 177986 (qui en déduit que, dans une cession de bail, le locataire cédant reste tenu du loyer à l'égard du bailleur).

[2310] N°s 33072 et 33104.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

dette » (« *Debt Assignement Agreement* »), par lequel une société s'engeait à payer à une autre un montant dû par une troisième[2311]. À dire vrai cependant, on peut se demander si, alors même que la qualification de « cession de dette » n'est pas remise en cause par les juges, l'opération réalisée ne pourrait pas tomber sous le coup d'une autre qualification comme la novation par changement de créancier ou la délégation qui, nous le verrons, permettent d'obtenir le même résultat économique qu'une telle cession[2312].

1049. Admission de la cession de dettes en France et en Belgique. Comme on vient de le voir, l'interdiction de la cession de dettes ne repose pas véritablement sur des arguments rationnels et elle n'a rien d'inéluctable dans le système du Code civil. Aussi bien est-il remarquable que, à l'occasion des réformes récentes, le mécanisme ait été introduit dans le code tant en droit français qu'en droit belge. En France, la solution est posée par le nouvel article 1327 du Code civil selon lequel « [u]n débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette ». En Belgique, l'article 5.187 admet de même, quasiment dans les mêmes termes, la « cession parfaite de dette ». Dans les deux droits, l'opération suppose le consentement du créancier, auquel, comme il a été dit, on ne peut pas imposer un changement de débiteur. L'opération se rapproche de ce fait de la novation par changement de débiteur ou de la délégation. Mais elle s'en distingue par le fait que le mécanisme mis en place est clairement translatif : le nouveau débiteur est tenu de la dette même de l'ancien, il peut donc opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette que le cédant aurait pu lui-même opposer (C. civ. be., art. 5.189, C. civ. fr., art. 1328), et le créancier bénéficie de toutes les sûretés qui assortissaient la dette (C. civ. be., art. 5.190, C. civ. fr., art. 1328-1). En principe, le cédant est libéré par l'effet de la cession, mais les parties peuvent stipuler qu'il restera tenu de la dette au profit du créancier (C. civ. fr., art. 1328-1 ; C. civ. be., art. 5.188), ce qui rapproche l'opération d'une délégation imparfaite dans laquelle les parties auraient écarté l'inopposabilité des exceptions. La même chose se produit, selon l'article 5.191 du Code civil belge, si le nouveau débiteur a entendu s'engager envers le créancier sans obtenir le consentement de celui-ci – ce que le texte nomme « cession de dette imparfaite ». D'une manière générale, la cession de dette, telle qu'elle est organisée dans les deux droits

[2311] Trib. Luxembourg, 5 juillet 2023, n° TAL-2023-04177.

[2312] Voy. *infra*, n°s 1052 et s.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

français et belge, n'est pas si éloignée des mécanismes préexistants (novation par changement de débiteur et surtout délégation), sauf à ce que la loi érige ici en solutions de principe des solutions qui, dans les mécanismes déjà connus, devraient être expressément stipulés (le maintien des sûretés, l'opposabilité des exceptions). On peut se demander si, plutôt que d'ajouter un nouveau mécanisme à ceux déjà connus, il n'aurait pas mieux valu repenser, en les fusionnant, les mécanismes existants

B) *Absence de transmission des dettes aux ayants-cause à titre particulier*

1050. Principe. On a vu précédemment que la jurisprudence admet que les ayants-cause à titre particulier peuvent se voir transmettre de plein droit certaines créances qui constituent des accessoires indissociables du bien qui leur a été transmis. On ne trouve pas l'équivalent pour les dettes. Prenons l'exemple du propriétaire d'un fonds de commerce qui est tenu, dans l'exploitation de ce fonds, d'une obligation de non-concurrence au profit d'un commerçant voisin (par exemple, un libraire, qui a acquis la partie librairie d'un fonds de librairie-papeterie, et qui s'est engagé à ne pas faire concurrence à son propre vendeur, qui a gardé la partie papeterie). Ce commerçant revend son fonds. L'acquéreur n'est pas personnellement tenu de l'obligation de non-concurrence (il peut impunément se mettre à vendre des cahiers), même s'il en avait connaissance. Il n'en sera tenu que s'il s'est personnellement engagé à ne pas faire concurrence au bénéficiaire de la clause – ce qui sera souvent exigé de lui comme une condition de la vente. Mais alors, on n'est pas véritablement en présence d'une cession de dette, mais d'un mécanisme non translatif de reprise de dette, comme ceux que nous allons étudier maintenant.

SOUS-SECTION 2. LES MÉCANISMES NON TRANSLATIFS DE REPRISE DE DETTE

1051. Substituts à la cession de dette. Si on ne peut pas, à proprement parler, céder une dette, on peut obtenir un résultat économique approchant en faisant prendre par un tiers un engagement personnel destiné à remplacer la dette originaire – cette obligation nouvelle étant, par principe, distincte de l'obligation préexistante. La question essentielle qui se pose, à propos de ces mécanismes, est de savoir s'ils sont substitutifs ou cumulatifs : en d'autres termes,

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

est ce que l'obligation assumée par le « repreneur » de la dette se substitue immédiatement à l'obligation du débiteur originaire (qui est alors libéré), ou est ce qu'elle s'ajoute à cette obligation, le créancier ayant alors deux débiteurs au lieu d'un ? Cette question ne reçoit pas la même réponse dans la novation par changement de débiteur – mécanisme nécessairement substitutif (**§ 1**) – et dans la délégation (**§ 2**) – mécanisme en principe cumulatif – ce qui assure un plus grand succès dans la pratique au second mécanisme qu'au premier.

§1. La novation par changement de débiteur

1052. Notion. Cette opération permet à un débiteur, avec l'accord du créancier, de se libérer en faisant reprendre sa dette par quelqu'un d'autre. La différence avec la cession de dette est que le nouveau débiteur est tenu envers le créancier d'une nouvelle obligation, l'ancienne n'étant pas transmise mais éteinte. Par conséquent, le nouveau débiteur ne peut pas opposer les exceptions que le débiteur libéré aurait pu opposer, et les accessoires de la dette initiale – en particulier les sûretés – disparaissent, sans possibilité de clause contraire (C. civ., art. 1279)[2313]. L'essence de la novation, qui est un mécanisme d'extinction des obligations, est d'éteindre la dette initiale. Par conséquent, le créancier (qui doit nécessairement consentir à l'opération) n'a, après comme avant, qu'un seul débiteur. Du coup, si, comme le souligne le Tribunal de Luxembourg, « le mécanisme de la novation par changement de débiteur permet de pallier de manière approximative l'absence, en droit positif luxembourgeois, de la technique de la cession de dette », ce n'est que si « le nouveau débiteur présente des garanties équivalentes à celles qu'offrait l'ancien, (que) le détour de la novation par changement de débiteur procure aux parties un résultat semblable à celui qui serait résulté d'une véritable cession de dette »[2314]. De ce point de vue, cependant, la délégation offre une souplesse beaucoup plus grande.

§2. La délégation

1053. Définition. La délégation n'est pas directement définie par le Code civil. Elle est abordée, dans la suite des textes relatifs à la novation, par l'article 1275 du Code civil, qui dispose précisément que « la délégation par laquelle le débiteur donne à son créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point novation ». Mais ce texte ne vise qu'une utilisation possible de la délégation, celle qui permet de réaliser un changement de débiteur. Or la délégation fait l'objet en pratique de bien d'autres utilisations, ce qui amène à en retenir une définition plus large, telle que celle

[2313] Pour un exposé des différences entre cession de dette et novation par changement de débiteur voy. p. ex. Trib. Luxembourg, 21 janvier 2014, n° 154824.

[2314] Trib. Luxembourg, 21 janvier 2014, préc.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

qui figure dans la nouvel article 1336 du Code civil français : : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur ». La définition de l'article 5.249 du Code civil belge est très proche : « La délégation est le contrat par lequel le délégant obtient du délégué qu'il s'engage envers le délégataire à exécuter une obligation dont le délégant est tenu envers le délégataire. » Bien que ce ne soit pas un élément de la définition, les deux textes ajoutent immédiatement que, en principe, le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant, ou des rapports entre le délégant et le délégataire. Cette règle marque d'emblée clairement le caractère non translatif de l'opération.

1054. Utilisations. Ainsi définie, la délégation apparaît comme une technique abstraite, qui peut servir à de multiples utilisations selon la nature des rapports qui existent entre les parties. Contrairement aux techniques précédemment étudiées, la délégation ne présuppose pas des qualités préétablies de créancier et de débiteur, et elle peut être utilisée pour réaliser tantôt un transfert de créance, tantôt l'équivalent d'une cession de dette, tantôt les deux. Par exemple, on peut concevoir que le délégant[2315] soit créancier du délégué, et que la délégation (qui va rendre le délégataire créancier à sa place) soit faite moyennant paiement par le délégataire du montant de la créance, ou en garantie du remboursement d'un crédit que le délégataire consent au délégué – comme on pourrait le faire par une cession de créance. Mais on peut aussi imaginer que le délégant soit débiteur du délégataire, et que le délégué, pour des raisons diverses, accepte de se substituer à lui en payant à sa place : c'est l'utilisation prévue par l'article 1275 du Code civil qui vise le cas où « le débiteur donne à son créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier ». La délégation permet alors, indirectement, de « céder une dette ». Dans l'utilisation typique de la délégation, le délégant est à la fois débiteur du délégataire et créancier du délégué. La délégation est alors un moyen pour le délégant de payer sa dette avec sa créance : lorsque le délégué paiera le délégataire, il se libérera de ce qu'il doit au délégant (comme s'il y avait eu cession de créance), et il libérera ce dernier de ce qu'il devait au

[2315] On écrit parfois « déléguant » (Poelmans, pp. 475 et s.). On a ici retenu l'orthographe communément suivie par la jurisprudence française et reprise par les textes actuels en France et en Belgique.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

délégataire (comme s'il y avait eu cession de dette). Par exemple, dans des relations de distribution, un détaillant, débiteur de factures émises par un grossiste, peut accepter de payer directement ces factures au fabricant qui a vendu les marchandises au grossiste. Ou encore, dans le cas d'une vente d'immeuble, l'acheteur, débiteur du prix, peut accepter de « reprendre le crédit » qui avait été consenti par une banque à son vendeur, et qui n'était pas encore soldé : c'est lui qui paiera les mensualités du prêt à la place de son vendeur, ce remboursement venant en déduction du prix qu'il doit payer au vendeur. La délégation, dans ces hypothèses, réalise à la fois l'équivalent d'une cession de créance et d'une reprise de dette.

Sans que les textes législatifs ni les conventions des parties n'y fassent expressément référence, la délégation est parfois invoquée par la doctrine comme mécanisme explicatif de certaines opérations juridiques. C'est ainsi qu'autrefois on analysait le mécanisme bancaire de la lettre de change comme reposant sur une délégation : une personne (tireur) donne l'ordre à une autre (tiré), qui est généralement son débiteur, de payer une certaine somme à une troisième (bénéficiaire), sans que le tiré qui accepte de payer puisse opposer au bénéficiaire les exceptions qu'il aurait pu opposer au tireur[2316]. Mais cette explication, qui ne rend pas compte de toute la complexité du mécanisme cambiaire, est aujourd'hui abandonnée. Plus convaincante est l'opinion qui voit une délégation (qui ne dit pas son nom) dans le mécanisme moderne des cartes de paiement ou de crédit[2317] : le titulaire de la carte (délégant), qui est débiteur d'un commerçant, donne l'ordre à son banquier (délégué), chez qui il a un compte normalement créditeur, de payer le montant de l'opération au commerçant (délégataire) ; le banquier délégué doit payer sans pouvoir opposer aucune exception tirée de ses rapports avec le titulaire de la carte (par exemple, que le compte de celui-ci est débiteur), ni tirée des rapports entre ce titulaire et le commerçant (par exemple, que la marchandise achetée est de mauvaise qualité ou n'a pas été livrée)[2318].

1055. Régime. Le Code civil ne définit que sur un point particulier (l'incidence de la délégation sur la dette du délégant envers le délégataire) le régime juridique de la délégation. C'est donc à la doctrine et à la jurisprudence qu'il a appartenu de définir ce régime, en laissant une large place à la liberté contractuelle. Les nouveaux textes français et belges reprennent très largement ces solutions (de manière beaucoup plus détaillée en France qu'en Belgique). La jurisprudence luxembourgeoisereprend pour l'instant les solutions dégagées en France, tant en ce qui concerne les conditions (A) que les effets (B) de la délégation.

[2316] L. 15 décembre 1962 sur la lettre de change et le billet à ordre, spéc. art. 17 « Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ».

[2317] Voy. p. ex. POELMANS, n° 383.

[2318] Cour d'appel, 13 juillet 1999, *Pas.*, 31, p. 220.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

A) *Les conditions de la délégation*

1056. Accord tripartite. La délégation suppose, pour sa validité, un accord tripartite entre le délégant, le délégué et le délégataire[2319]. Ce triple accord est nécessaire, car d'une part on ne peut pas obliger le délégataire à accepter un nouveau débiteur qui se substituerait à l'ancien, d'autre part, le délégué, même s'il était tenu antérieurement envers le délégant, prend envers le délégataire un engagement nouveau qui peut être plus lourd que l'ancien. Il résulte de l'article 1277 du Code civil que la délégation doit être bien distinguée de la simple indication de paiement, qu'il s'agisse de l'indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer pour son compte, ou de l'indication faite par le créancier d'une personne qui doit recevoir paiement pour son compte. Ce type d'opération, en effet, ne comporte aucun engagement d'une personne de payer à la place d'une autre.

La délégation n'est pas soumise à des formes particulières, ni pour sa validité, ni pour son opposabilité aux tiers. Il n'est même pas nécessaire de la notifier, puisque le délégué est nécessairement partie à l'opération.

B) *Les effets de la délégation*

1057. Dualité. Selon les rapports préexistants entre les parties, la délégation opère, soit comme un mécanisme de changement de débiteur, soit comme un mécanisme de changement de créancier, soit (le plus souvent) à la fois comme l'un et l'autre. Il faut donc voir successivement ses effets sur l'un et l'autre plan.

1) *La délégation comme mode de changement de débiteur*

1058. Questions. On suppose ici que le délégant était, au départ, débiteur du délégataire. Le délégataire, qui avait le délégant comme débiteur a maintenant un nouveau débiteur, le délégué. La première question qui se pose est de savoir quelle est l'étendue de cette obligation du délégué envers le délégataire (**a**). Mais l'autre question est de savoir ce que devient l'obligation initiale du délégant envers le délégataire (**b**).

[2319] Cour d'appel, 30 janvier 2024, n° CAL-2022-00920 ; Trib. Luxembourg, 14 février 2024, n° TAL-2022-07892.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

a. *L'étendue de l'obligation du délégué envers le délégataire*

1059. Obligation nouvelle. La question est de savoir si la dette du délégué est identique à celle du délégant. En d'autres termes, le délégué peut-il opposer au délégataire les exceptions que le délégant aurait pu lui opposer ? La logique de l'opération incite à répondre par la négative : le délégué prend un engagement nouveau, qui n'est pas simplement la reprise de celui qu'avait le délégant envers le délégataire. C'est précisément cela qui distingue la délégation, comme mode de changement de débiteur, d'une véritable cession de dette. Cependant, en France, la position de la jurisprudence n'était pas très claire sur ce point : alors qu'un arrêt de la chambre commerciale de 1992 avait jugé que « le délégué ne peut, sauf clause contraire, opposer au délégataire les exceptions dont le délégant pouvait se prévaloir à l'égard de celui-ci »[2320], la Première chambre civile avait pris la position contraire en estimant que « sauf convention contraire, le délégué est seulement obligé au paiement de la dette du délégant envers le délégataire, et qu'il se trouve déchargé de son obligation lorsque la créance de ce dernier est atteinte par la prescription »[2321]. Les auteurs de l'ordonnance de 2016 se sont clairement ralliés à la première solution en posant dans le nouvel article 1336 que « le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire »[2322] – formule textuellement reprise par l'article 5.249, alinéa 2, du nouveau Code civil belge. Et c'est également dans ce sens que se prononce la jurisprudence luxembourgeoise. Dans une décision du 2 mai 1996, le tribunal de Luxembourg a jugé que « l'obligation du délégué envers le délégataire étant une obligation nouvelle et autonome, le premier ne peut opposer au second aucune exception, ni aucun moyen de défense qu'il prétendrait tirer de ses relations avec le délégant ou encore du rapport entre le délégant et le délégataire »[2323]. Néanmoins, les textes français

[2320] Cass. fr. (comm.), 25 février 1992, n° 90-12.863. L'arrêt pose la solution pour le cas où la délégation est « imparfaite », c'est-à-dire ne décharge par le délégant envers le délégataire (Voy n° 1005). Mais la solution devrait s'appliquer tout aussi bien en cas de délégation parfaite (opérant novation). Le projet de réforme français, qui consacre la solution, ne distingue pas entre les deux hypothèses.

[2321] Cass. fr. (1re civ.), 17 mars 1992, n° 90-15707.

[2322] Sur l'inopposabilité des exceptions tirées des rapports entre le délégué lui-même et le délégant, voy. *infra*, n° 1062.

[2323] Trib. Luxembourg, 2 mai 1996, *Pas.*, 30, p. 219 ; Trib. Luxembourg, 14 mars 2002, n° 69695.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

et belge indiquent expressément que les clauses contraires sont possibles : rien n'interdit au délégué, lorsqu'il s'engage, de calquer son engagement sur celui du délégant, en déclarant qu'il entend payer « ce que doit le délégant », ou qu'il s'engage « dans la limite de ce que doit le délégant ». La délégation se rapproche alors d'une véritable cession de dettes.

b. *L'incidence de la délégation sur l'obligation du délégant envers le délégataire*

1060. Délégation parfaite et délégation imparfaite. La question est ici de savoir si la nouvelle dette remplace l'ancienne, ou si elle s'y ajoute. C'est le seul point sur lequel le Code civil de 1804 donne une réponse claire, et la solution est reprise par les nouveaux textes en France et en Belgique (C. civ. fr., art. 1337 et 1338, C. civ. be., art. 5.249, § 3) : en principe, la délégation n'emporte pas novation de la dette du délégant envers le délégataire (C. civ., art. 1275). En conséquence, l'obligation du délégant subsiste, celle du délégué ne fait que s'y ajouter. Le délégataire, s'il n'est pas payé par le délégué, a un recours envers le délégant (son débiteur originaire). La délégation est dite *simple* ou *imparfaite*[2324] – appellation curieuse car cette forme de délégation est la plus intéressante pour le délégataire, qui se retrouve avec deux débiteurs au lieu d'un[2325]. C'est ce qui permet à la délégation d'être utilisée comme sûreté, à la place du cautionnement : au lieu de demander une caution, le créancier peut demander à son débiteur de lui déléguer un tiers qui s'oblige envers lui tout en laissant subsister la dette initiale. Dans un jugement récent, le Tribunal de Luxembourg a jugé que, dans un tel cas, « c'est l'obligation du délégué qui a vocation à être exécutée. Si celle du délégant demeure, elle devient subsidiaire, mais sans que le délégant puisse opposer un bénéfice de discussion »[2326]. C'est dire qu'il n'existe pas vraiment de hiérarchie entre les deux débiteurs. Le texte français, qui dispose que dans un tel cas « [l]e paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence », semble aller dans le même sens.

Par exception, cependant, le délégataire peut accepter de décharger le délégant ; dans ce cas, la délégation opère novation, et le délégataire n'a pas de recours contre le délégant. La délégation est

[2324] Terminologie curieuse, car cette délégation est beaucoup plus avantageuse pour le créancier, qui se retrouve avec deux débiteurs au lieu d'un.

[2325] Cour d'appel, 21 avril 2010, n° 33830.

[2326] Trib. Luxembourg, 9 juin 2023, n° TAL-2020-02288.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

dite *novatoire* ou *parfaite* (formule assez curieuse car cette forme de délégation, qui opère substitution de débiteur, ne procure au créancier « aucune garantie autre que la meilleure solvabilité éventuelle de son nouveau débiteur »[2327]). Il faut cependant pour cela que le délégataire ait déclaré expressément qu'il entendait décharger son débiteur originaire. La seule acceptation de la délégation par le délégataire, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, ne suffit pas à opérer cette décharge[2328]. Ce principe est bien acquis au Luxembourg où des jugements anciens en ont déjà fait application. Un jugement du tribunal de Luxembourg du 15 octobre 1904 déclare ainsi que « à défaut d'une déclaration expresse du créancier libérant le débiteur primitif, la délégation n'est qu'imparfaite, elle n'emporte pas novation, ne décharge pas le débiteur et a pour effet de donner au créancier deux débiteurs au lieu d'un dont chacun est tenu pour le tout et directement »[2329]. Nous verrons que les mêmes principes sont appliqués en matière de cession de contrat[2330].

2) *La délégation comme mode de changement de créancier*

1061. Ressemblances et différences avec une cession de créance. On suppose ici que le délégant est créancier du délégué, et c'est pour éteindre sa dette que celui-ci accepte de s'engager envers le délégataire, qu'il paiera au lieu de payer le délégant. L'opération se rapproche alors d'une cession de créance, et, dans la pratique, il est parfois difficile de savoir si on a affaire à l'une ou à l'autre opération. Par exemple lorsqu'un bailleur d'immeuble, « délègue ses loyers » à une autre personne (notamment en garantie d'un crédit qui lui est accordé), cela peut être soit une véritable délégation (dans laquelle le locataire s'engage personnellement à payer le tiers), soit une cession de la créance de loyers. Les deux opérations diffèrent cependant de manière importante, en ce que la délégation, qui repose sur un engagement personnel et nouveau du débiteur, n'a pas d'effet translatif. C'est donc à tort qu'on parle souvent de « délégation de créance » : c'est le débiteur qui est délégué, non la créance. Les effets sont alors, en principe du moins très différents de ceux d'une cession de créance, tant dans les rapports entre le

2327 Trib. Luxembourg, 2 mars 2012, n° 137714.

2328 Dans ce sens, voy. p. ex. : Cass. fr. (comm.), 12 décembre 1995, n° 93-14438 ; Cass. fr. (3e civ.), 12 décembre 2001, n° 00-15627.

2329 Trib. Luxembourg, 15 octobre 1904, *Pas.*, 06, p. 591 ; dans le même sens : Trib. Luxembourg, 5 décembre 1951, *Pas.*, 15, p. 291 ; Trib. Luxembourg, 2 mai 1996, préc.

2330 Voy. *infra*, nos 1072 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

délégué (le débiteur) et le délégataire, son nouveau créancier (**a**) que dans les rapports entre le délégué et le délégant, son ancien créancier (**b**).

a. *Effets dans les rapports délégué-délégataire : le débiteur face au nouveau créancier*

1062. Délégation certaine et délégation incertaine. Comme on l'a dit, le délégué prend un engagement personnel envers le délégataire, qui est en principe distinct de celui qu'il avait envers le délégant. Les effets sont alors les mêmes que ceux d'une novation par changement de créancier. Il en résulte d'abord que la créance du délégataire contre le délégué n'est pas en principe assortie des accessoires de la créance originaire, et notamment des sûretés qui en garantissaient le paiement. Comme dans la novation par changement de créancier, les parties peuvent cependant convenir que les sûretés se reporteront sur cette nouvelle créance. De ce que la créance contre le délégué est une nouvelle créance, il résulte ensuite que le délégué ne peut pas en principe opposer au délégataire les exceptions qu'il aurait pu opposer au délégant. Le tribunal de Luxembourg a très nettement affirmé cette solution, sur le modèle français, en partant de l'idée que la délégation ne suppose pas que le délégant soit créancier du délégué ; même s'il l'est, l'obligation du délégué envers le délégataire est « une obligation nouvelle et autonome, et le premier ne peut opposer au second aucune exception, ni aucun moyen de défense qu'il prétendrait tirer de ses relations avec le délégant »[2331]. L'engagement du délégué ne risque donc pas d'être fragilisé par les exceptions affectant le rapport initial, ce pourquoi on parle dans ce cas d'une délégation *certaine*.

Cependant, cette autonomie n'est pas d'ordre public, et la possibilité de stipulation contraire est expressément reconnue par les nouveaux textes en France et en Belgique (C. civ. fr., art. 1336, C. civ. be., art. 5.249, § 2). Les parties ont la possibilité de calquer l'engagement du délégué envers le délégataire sur son engagement originaire : ainsi lorsque le délégué s'engage à payer « ce qu'il doit au délégant ». Le délégué peut alors opposer les exceptions tirées de ses rapports avec le délégant. Cette délégation, qui donne beaucoup moins de sécurité au délégataire, est parfois dite « *incertaine* » ; elle est très proche de la cession de créance.

[2331] Trib. Luxembourg, 2 mai 1996, préc., qui affirme aussi l'inopposabilité des exceptions tirées du rapport entre le délégant et le délégataire.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

b. *Effets dans les rapports délégué-délégant : le débiteur face à l'ancien créancier*

1063. Créance en suspens. Parce que la délégation n'opère pas un transfert de la créance du délégant contre le délégué, le principe est que le délégué reste débiteur du délégant. Cette solution s'impose en tout cas dans le cas (normal) où la délégation est imparfaite, c'est-à-dire n'opère pas novation dans les rapports entre le délégataire et le délégant. Dans ce cas, en effet, le délégataire, non payé par le délégué, aura un recours contre le délégant, et il faut que celui-ci puisse se faire rembourser par le délégué, qui est le véritable débiteur. La créance du délégant contre le délégué ne s'éteindra que lorsque le délégué aura exécuté son engagement envers le délégataire, ce qui bouclera toute l'opération. Telle est la solution que pose le nouvel article 1339 du Code civil français. Cependant, il serait anormal que, dans l'attente de ce paiement, le délégant puisse toujours réclamer le paiement de sa créance au délégué, alors que celui-ci s'est engagé à payer le délégataire. C'est pourquoi il était admis dans la jurisprudence française que, jusqu'à l'exécution de cet engagement, le délégant ne peut pas réclamer au délégué que la partie de sa créance qui excèderait l'engagement du délégué – solution raisonnable là encore consacrée en 2016 par l'article 1339 du Code civil. La créance existe toujours dans le patrimoine du délégant, mais elle est en quelque sorte paralysée jusqu'au dénouement de l'opération. Le délégant, dit le nouveau texte « ne recouvre ses droits qu'en exécutant sa propre obligation envers le délégataire ».

Cette paralysie produit également des effets dans les rapports avec les tiers. Vis-à-vis des tiers, la créance est immobilisée au profit du délégataire. D'une part, le délégant ne peut plus céder cette créance. D'autre part, les créanciers du délégant ne peuvent plus saisir la créance du délégant contre le délégué, tant que le délégataire n'a pas été payé. Consacrées par la jurisprudence française[2332], et reprises par l'article 1339 nouveau, ces solutions, qui évitent que le délégué soit tenu de payer deux fois, devraient être admises sans difficulté au Luxembourg. Le nouveau texte belge reste muet sur toutes ces questions.

[2332] Cass. fr. (comm.), 14 février 2006, n° 03-17457.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

SECTION 3. LES TIERS PRENANT LA QUALITÉ DE PARTIE AU CONTRAT

1064. De l'obligation au contrat. Dans la plupart des mécanismesqui ont été étudiés jusque-là, le tiers qui prend la place d'un créancier ou d'un débiteur contractuel ne devient pas à proprement parler partie au contrat qui a fait naître la créance ou la dette considérée. C'est évident dans les mécanismes non translatifs, dans lesquels le créancier devient titulaire d'un droit nouveau ou le débiteur prend un engagement nouveau, qui n'est pas pas celui du contrat initial. Mais c'est vrai également dans les mécanismes transférant une créance contractuelle : le cessionnaire d'une créance de prix de vente, par exemple, ne devient pas partie à la vente, et c'est toujours le vendeur originaire qui reste tenu envers l'acheteur à la délivrance ou à la garantie des vices cachés. Cependant il existe des cas, que nous allons étudier maintenant, dans lesquels un tiers va véritablement prendre la place d'un contractant, avec tous les droits et obligations qui y sont attachés. Ce remplacement d'une partie par un tiers peut s'inscrire dans le cadre d'une transmission universelle ou à titre universel du patrimoine (**Sous-section 1**), mais il peut aussi s'opérer à propos d'un contrat particulier (**Sous-section 2**).

SOUS-SECTION 1. LE REMPLACEMENT D'UNE PARTIE PAR UN AYANT-CAUSE UNIVERSEL OU À TITRE UNIVERSEL

1065. Principe. Les cas de transmission de tout ou partie du patrimoine d'une personne physique ou morale ou déjà été étudiés à propos de la transmission des créances et des dettes : décès, fusion, scission, apport partiel d'actif, transmission du patrimoine professionnel. Dans ces diverses hypothèses, il faut souligner que l'ayant-cause ne devient pas seulement créancier et débiteur des créances et des dettes de son auteur, il devient partie aux contrats que celui-ci a passés avant son décès ou avant l'opération de transmission, et qui ont fait naître ces dettes et ces créances. Par exemple, si j'hérite de mon père qui, avant son décès, avait vendu sa voiture, qu'il n'avait pas eu le temps de livrer ni de se faire payer, c'est moi qui suis désormais le vendeur : c'est donc moi qui serai obligé de livrer la voiture, et qui devrai, éventuellement, en assurer la garantie ; et c'est à moi que l'acheteur devra payer. Pour reprendre une distinction faite précédemment, les effets internes du contrat sont en quelque sorte déplacés de la tête de mon père à la mienne. Ce transfert s'opère aussi bien pour des contrats dits à exécution instantanée, dès lors qu'ils n'ont pas été complètement exécutés, que pour des

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

contrats successifs, que les ayants-cause universels ou à titre universel devront continuer : l'héritier devra ainsi continuer un contrat de bail passé par son auteur et ne pourra expulser le locataire du seul fait du décès, de même qu'une société issue d'une fusion devra continuer les contrats de fourniture, de concession ou de franchise passés par les sociétés fusionnées avec leurs différents distributeurs.

1066. Limites. Cette transmission des contrats aux héritiers et ayants-cause universels est cependant écartée par la loi dans différents cas. C'est ainsi que l'article 2003 du Code civil prévoit que le contrat de mandat se finit avec la mort du mandant ou du mandataire, et que l'article 1865 du Code civil prévoit la fin du contrat de société par la mort de l'un des associés[2333]. S'agissant du contrat de bail d'habitation, l'article 13 de la loi du 21 septembre 2006 prévoit que, en cas de décès du locataire, le bail ne se continue qu'au profit de certaines personnes proches du défunt (son conjoint ou son partenaire, ses enfants vivant avec lui, etc.) ; le texte précise qu'« à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de bail est résilié de plein droit par le décès du locataire ». Ces différents textes peuvent être regardés comme des applications d'un principe général qui exclut la transmission en cas de décès des contrats *intuitu personae*. Cette notion a, dans ce contexte, une signification beaucoup plus large que celle qui est habituellement retenue. D'une part, elle vise, comme dans d'autres contextes, les contrats qui ont été conclus en considération de la personne du cocontractant : si ce cocontractant décède, l'autre peut refuser de continuer le contrat avec ses héritiers. Par exemple, un employeur n'est évidemment pas tenu, en cas de décès d'un de ses salariés, d'embaucher son fils ou sa fille à sa place, et c'est la même idée qui explique les solutions légales précédemment exposées. Mais, d'autre part, la notion est parfois utilisée pour expliquer l'absence de continuation du contrat qui a été passé en considération de qualités ou de motifs personnels au contractant décédé lui-même. C'est ainsi qu'on peut expliquer la solution jurisprudentielle qui considère que les héritiers d'une caution de dettes futures et indéterminées d'un débiteur ne sont plus tenus de garantir les dettes nées à la charge du débiteur après le décès de leur auteur : la caution s'était engagée en raison de motifs qui lui étaient personnels

[2333] Ce principe ne s'applique qu'aux sociétés de personne, et il n'est pas d'ordre public (C. civ., art. 1868). Les sociétés de capitaux (sociétés anonymes) subsistent bien sûr au décès d'un actionnaire, dont les héritiers héritent des actions.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

(par exemple, parce qu'elle était dirigeante de la société débitrice) et qui ne se retrouvent pas nécessairement chez ses héritiers. Les deux séries de considérations s'additionnent très souvent : ainsi, dans le cas déjà rencontré de l'artisan peintre qui décède avant d'avoir fini la peinture de mon appartement, il est tout aussi vrai que ses héritiers ne peuvent être obligés de finir le travail même si je leur demande (parce que l'engagement de leur père reposait sur des qualités personnelles que ses héritiers n'ont pas nécessairement) et que ces héritiers, s'estimeraient-ils compétents, ne peuvent pas m'imposer de continuer le contrat avec eux (parce que j'ai contracté avec leur père en fonction de ses compétences, que je ne suis pas sûr de retrouver chez ses héritiers). Il faut par ailleurs souligner que, dans toutes ces hypothèses, l'*intuitu personae* met fin au contrat pour l'avenir, mais que les héritiers de la partie décédée restent débiteurs ou créanciers des dettes ou des créances qui avaient pu naître à la charge ou au profit de leur auteur avant le décès. Ainsi, les héritiers de mon peintre en bâtiment seraient-ils tenus de me dédommager pour le mauvais travail que leur père aurait fait chez moi avant son décès. De même les héritiers d'une caution sont-ils tenus de payer les dettes qui étaient nées à la charge du débiteur principal avant le décès de la caution.

SOUS-SECTION 2. LE REMPLACEMENT D'UNE PARTIE PAR UN TIERS DANS UN CONTRAT PARTICULIER

1067. Principe. En dehors des cas où le changement de contractant s'opère dans le cadre d'une transmission universelle de l'ensemble des droits et obligations d'une personne, on rencontre de multiples cas où une personne prend la place d'une autre comme partie à un contrat particulier. Pour prendre d'emblée quelques exemples : un locataire quitte les lieux loués et il cède son bail au nouvel occupant, l'acquéreur d'un immeuble reprend à son compte le contrat d'assurance souscrit par son vendeur, le concessionnaire d'une marque de voitures cède son contrat de concession à un nouvel exploitant, etc. Ce type d'opérations n'est pas organisé de manière générale par le Code civil de 1804, qui ne fait référence, pour les autoriser ou à l'inverse pour les interdire, qu'à certaines cessions particulières (la cession de bail notamment). Mais, en dehors du Code civil, plusieurs textes spéciaux sont relatifs à ce type d'opérations, soit pour prévoir la transmission automatique de tel ou tel contrat avec le bien auquel il se rapporte (par exemple, la transmission automatique

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

des baux à l'acquéreur de l'immeuble), soit pour autoriser, interdire ou réglementer une transmission conventionnelle de contrat. Par ailleurs, en dehors de ces cas, la jurisprudence, dans les trois pays du Code civil, a reconnu la validité d'une cession conventionnelle de contrat, en en précisant les conditions et les effets, et ce mécanisme a été légalement consacré lors des réformes en France et en Belgique. La jurisprudence luxembourgeoise, relativement abondante sur cette question, démontre le grand intérêt pratique de ce type de mécanisme.

Si les cas où le changement de contractant s'opère de plein droit en vertu de la loi ne méritent qu'un rapide survol (**§ 1**), le changement de contractant résultant d'un contrat entre ce contractant et un tiers suscite davantage de difficultés qui justifient de plus longs développements (**§ 2**).

§1. Le changement légal de contractant

1068. Transmission du contrat aux ayants-cause à titre particulier. En dehors du cas de transmission aux héritiers, de nombreux textes prévoient la transmission d'un contrat à un tiers au contrat initial, dans des cas ou un contrat est lié à un bien qui est lui-même transmis. C'est la même idée que celle qui justifie, selon la jurisprudence, la transmission aux ayants-cause à titre particulier des créances accessoires au bien transmis[2334]. Les textes en la matière répondent à des impératifs divers. Dans certains cas, il s'agit de protéger le cocontractant du cédant, dont la situation risquerait d'être fragilisée par la transmission du bien. La transmission du contrat est alors imposée à l'acquéreur du bien (**A**). Dans d'autres cas, il s'agit à l'inverse de protéger cet acquéreur, qu'on veut faire bénéficier – s'il le souhaite – des contrats passés par son auteur. La transmission du contrat sera alors imposée au cocontractant du cédant (**B**).

A) *La continuation du contrat imposée à l'acquéreur du bien*

1069. Contrat de bail. L'hypothèse est que le propriétaire d'un immeuble loué le vend à un tiers. L'acquéreur est alors tenu de continuer le bail avec le ou les locataires du vendeur. On dit parfois que le bail lui est opposable, mais la solution va bien au-delà de ce que commande le principe général d'opposabilité du contrat

[2334] Voy. *infra*, n°s 1111 et s.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

aux tiers : l'acquéreur n'est pas seulement tenu de respecter le bail passé par son vendeur, il devient partie à ce contrat, il devient bailleur à la place de son vendeur. Telle est la solution prévue par l'article 1743 du Code civil[2335], qui pose cependant deux limites à cette continuation du bail. D'une part, l'acquéreur n'est tenu que si le bail a été passé sous la forme authentique ou au moins s'il a date certaine au moment de la vente : il s'agit ici d'éviter la fraude consistant pour le vendeur à antidater un contrat de bail passé en réalité après la vente[2336]. D'autre part, l'article 1743 du Code civil prévoit que le bailleur originaire peut se réserver, dans le contrat de bail, le droit de mettre fin au bail en cas de vente ; cette faculté est cependant largement remise en cause en matière de baux à usage d'habitation par la loi du 21 septembre 2006 sur le bail. En toute hypothèse, le bailleur et l'acquéreur ne peuvent pas écarter dans le contrat de vente la continuation du contrat, qui est destinée à protéger le locataire et qui est d'ordre public. Après la vente, l'acquéreur devenu bailleur peut bien entendu lui-même mettre fin au bail ; mais il doit alors respecter les règles posées par la loi pour résilier le bail (qui varient selon que le bail est à durée déterminée ou indéterminée).

1070. Contrat de travail. Un cas très important en pratique de transfert légal de contrat est celui prévu par l'article L. 127-3 du Code du travail, relatif aux conséquences des transferts d'entreprise sur les contrats de travail passés par le cédant. Aux termes de ce texte : « Les droits et obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire ». Le texte s'applique à tous les transferts d'entreprise, quelle qu'en soit la forme : cession du fonds de commerce, fusion, apport partiel d'actif, etc. Le but est, comme dans le cas du bail, d'assurer aux salariés de l'entreprise le maintien de leur situation contractuelle. C'est pourquoi la cession est imposée aux parties au transfert d'entreprise, qui ne peuvent y déroger. L'article L. 127-4 du Code du travail précise à cet égard que le transfert de l'entreprise ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire.

[2335] « Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail ».

[2336] L'article 12 (5) de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation prévoit qu'il en va de même lorsque le locataire a été mis en possession du bien avant la vente.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Le cessionnaire, devenu employeur, peut sans doute licencier les salariés de l'entreprise qu'il a acquise, mais il doit alors respecter les conditions strictes du licenciement, et payer les indemnités qui y sont afférentes. L'article L. 127-3 du Code du travail précise les effets de la cession : si, pour l'avenir, le cessionnaire de l'entreprise prend complètement la place de l'ancien employeur (c'est à lui qu'est désormais due la prestation de travail et c'est lui qui doit payer les salaires), pour le passé, le cédant n'est pas complètement libéré. Il est tenu, solidairement avec le cédant, du paiement des salaires qui étaient échus avant la cession. Nous retrouverons ce découpage dans le temps des effets de la cession dans le cadre des cessions conventionnelles qui portent sur des contrats à exécution successive.

B) *La continuation du contrat imposée au cocontractant du cédant*

1071. Contrat d'assurance. Contrairement aux cas précédents, la transmission d'un contrat comme accessoire d'un bien peut être prévue dans l'intérêt du cessionnaire. Elle est alors imposée au cocontractant du cédant, le cessionnaire étant pour sa part libre ou non de continuer le contrat. C'est ce qui se passe en matière d'assurance : la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance prévoit la continuation temporaire du contrat d'assurance de dommages portant sur un immeuble avec le cessionnaire (acheteur ou donataire) de la chose assurée. Selon l'article 69 de cette loi « l'assurance prend fin de plein droit trois mois après la date de passation de l'acte authentique ». Jusqu'à cette date, le cessionnaire bénéficie de la garantie, sauf s'il est assuré par ailleurs. Le but de ces dispositions est de permettre à l'acheteur de l'immeuble de « se retourner », en décidant, soit de reprendre la même assurance que son vendeur, soit de conclure un nouveau contrat avec un autre assureur[2337]. Le texte ne s'applique pas en matière de vente de meubles (achat d'une voiture par exemple) : dans ce cas, le contrat d'assurance de la chose vendue prend fin dès que l'acheteur entre en sa possession (L. 27 juillet 1997, art. 69, al. 3).

[2337] La solution est différente en droit français (C. ass., art. L. 121-10) où le contrat d'assurance de l'immeuble se continue indéfiniment avec l'acheteur, tant que celui-ci ne l'a pas résilié.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§ 2. La cession conventionnelle de contrat

1072. Principe. Il s'agit d'un contrat entre une partie à un contrat (cédant) et un tiers (cessionnaire) par lequel le cédant confère au cessionnaire sa position de partie vis-à-vis de son cocontractant (cédé). La cession de bail consentie par un locataire en constitue un exemple typique : le locataire d'un immeuble (cédant) confère au nouvel occupant de cet immeuble (cessionnaire) sa qualité de locataire vis-à-vis de son bailleur (cédé). À l'avenir, le contrat de bail se continuera entre le nouveau locataire et le bailleur, dont la position reste inchangée. En dehors de cette hypothèse, déjà prévue par les rédacteurs du Code civil, ce type d'opération s'est développée en pratique, sans le soutien d'aucun texte, dans les contextes les plus divers : cession par un concessionnaire ou un franchisé de sa qualité de partie au contrat de distribution, cession par un entrepreneur de son contrat à un autre entrepreneur du contrat passé avec le maître de l'ouvrage (ou, à l'inverse, cession par le vendeur d'un terrain à l'acquéreur du contrat qu'il avait passé avec un entrepreneur pour la construction d'un immeuble sur ce terrain)[2338], cession d'une promesse unilatérale de vente par son bénéficiaire à une autre personne qui pourra exercer à sa place le droit d'option, cession par une société d'assurances de son « portefeuille » à une autre société, etc. La validité de ce type d'opérations n'a jamais été contestée, même si leur analyse juridique est très discutée, et s'il subsiste beaucoup d'incertitudes sur leurs conditions et sur leurs effets. Lors des réformes récentes en France et en Belgique, la cession de contrat a fait son entrée dans le Code civil des deux pays. Elle est désormais réglementée à l'article 5.193 du nouveau Code civil belge (dans le cadre du régime général de l'obligation, à la suite de la cession de créance et de la cession de dette), et aux articles 1216 à 1216-3 du Code civil français (dans la partie relative aux contrats).

La cession de contrat, ainsi définie, doit être soigneusement distinguée d'autres mécanismes contractuels qui peuvent avoir des finalités économiques assez proches. Elle se différencie, d'abord, des *contrats successifs portant sur une même chose* : lorsque l'acquéreur d'un bien revend ce bien à un tiers, il ne cède pas à celui-ci sa qualité d'acheteur dans le premier contrat. Ce contrat précédent a produit son effet essentiel (le transfert de propriété de la chose) et on est en présence d'un

[2338] Pour un exemple voy. Cour d'appel, 15 février 2012, n° 35639, *Pas.*, 36, p. 78, où on voit à la fois une cession d'un contrat d'architecte relatif à la construction d'un immeuble par un cabinet à un autre, et la cession de ce contrat par le maître de l'ouvrage à l'acquéreur du terrain.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

nouveau contrat portant sur la même chose. Le sous-acquéreur n'est pas lié par un contrat de vente avec le premier vendeur – même si, comme nous le verrons, il peut recueillir certaines créances qui appartenaient à son vendeur contre le premier. La cession de contrat doit également être distinguée de la figure du *sous-contrat*. Ce terme désigne un contrat par lequel un contractant confie à un tiers (sous-contractant) l'exécution de tout ou partie des obligations dont il est tenu, ou, à l'inverse, lui permet l'exercice de tout ou partie des droits qu'il tient de son propre contrat. L'exemple typique, pour le premier cas, est celui de la sous-traitance : un entrepreneur, chargé par un maître de l'ouvrage de construire une maison, sous-traite à un autre entrepreneur les travaux d'électricité ou de plomberie – parfois toute la construction. Sur le même modèle, un mandataire peut charger un tiers (sous-mandataire) de la mission qui lui avait été confiée. Le cas de la sous-location est un peu différent, car ici c'est l'exercice des droits du locataire qui est laissé au sous-locataire : c'est lui qui pourra occuper l'appartement sous-loué à la place du locataire, moyennant paiement de loyers à celui-ci. La différence essentielle entre ces hypothèses et une cession de contrat est que le contractant qui sous-traite ou qui sous-loue reste la partie principale du contrat passé avec le maître de l'ouvrage ou avec le bailleur. Vis-à-vis de celui-ci, le sous-traitant ou le sous-locataire ne deviennent pas partie au contrat d'entreprise ou de bail, à la différence d'un cessionnaire. Le sous-contrat s'ajoute au contrat initial, il ne s'y substitue pas. Nous verrons cependant que, comme dans les contrats successifs, la question se pose de savoir s'il ne convient pas de reconnaître un lien contractuel direct entre le sous-contractant et le contractant initial (bailleur ou maître de l'ouvrage). Nous retrouverons la question en étudiant les qualités de partie et de tiers dans les ensembles contractuels[2339].

1073. Nature juridique. La nature juridique de la cession de contrat a été abondamment discutée dans la doctrine française[2340], mais aussi en Belgique. Traditionnellement, la doctrine cherchait à expliquer l'opération en la décomposant en une cession des créances nées du contrat – soumise, en tant que telle, aux formalités de l'article 1690 – accompagnée d'une reprise par le nouveau contractant des dettes générées par ce contrat. Comme la cession de dettes n'était jusque là pas admise dans les pays du Code civil, cette reprise ne pouvait s'opérer qu'en utilisant un des mécanismes non translatifs précédemment étudiés – novation par changement de débiteur ou délégation – ou en imaginant une stipulation pour autrui par laquelle le cessionnaire prend envers le cédant l'engagement d'exécuter envers le cédé les obligations nées du contrat cédé. Dans une période récente, cetteanalyse a été contestée par divers auteurs qui ont fait observer que, dans l'esprit des parties, l'opération est conçue comme une opération unitaire portant sur un ensemble de droits et d'obligations, et non comme l'addition

2339 Voy. *infra*, n°s 1111 et s.

2340 Pour une présentation substantielle des diverses positions en France : J. GHESTIN, C. JAMIN, M. BILLIAU, *Les effets du contrat*, *op. cit.*, n°s 678 et s. ; en Belgique : VAN OMMESLAGHE, vol. 3, n°s 1368 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

d'une cession de créances et d'une reprise de dette[2341]. Cette conception unitaire – ou moniste – de la cession de contrat est elle-même susceptible de diverses variantes, soit qu'on y voie une véritable cession du contrat considéré en lui-même comme un bien susceptible de « circuler », soit qu'on mette l'accent sur la substitution, à l'intérieur du lien contractuel, d'un contractant par un autre contractant, soit encore que, de manière plus réductrice, on ramène l'opération à la conclusion d'un nouveau contrat entre le cédé et le cessionnaire. Cette approche unitaire est consacrée par plusieurs droits étrangers, notamment en Italie par les articles 1406 à 1410 du Codice civile[2342] ou aux Pays-Bas par l'article 6:159 du BWB[2343]. Elle rencontrait cependant encore certaines réticences doctrinales et jurisprudentielles dans les pays du Code civil. En 1982, la Cour de cassation française avait admis l'autonomie de la cession de contrat par rapport aux mécanismes classiques de cession de créance et de reprise de dette, mais certains arrêts postérieurs laissaient planer le doute sur l'analyse que le Cour faisait de l'opération[2344]. Le nouvel article 1216 du Code civil français consacre expressément l'analyse unitaire en disposant qu'« [u]n contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé ». En Belgique, après avoir semblé pencher en faveur d'une conception unitaire, la Cour de cassation était très nettement revenue, à partir de 1982, à un « dépeçage » de l'opération, ramenée à l'addition d'une cession de créance et d'une délégation[2345]. Le nouveau texte belge adopte ici une position ambiguë : tout en qualifiant l'opération de cession par une partie

[2341] Voy. en France L. Aynes, *La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes*, préf. P. Malaurie, Paris, Economica, 1984 ; en Belgique ; Van ommeslaghe, n° 1371.

[2342] L'article 1406 dispose que « *Ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta* ».

[2343] *Article 6 : 159 Transfer of a contractual position*

- *1. A party to an agreement may, with the cooperation of his counterparty, transfer his legal relationship with that counterparty to a third party by means of a private or notarial deed, drawn up for this purpose between him and that third party :*
- *2. As a result of such a transfer all rights and obligations that have arisen or will arise from the agreement for the transferring party will pass to the third party, as far as parties have not agreed otherwise with regard to secondary (minor) or already due and demandable rights or obligations :*
- *3. Articles 6 : 156 and 6 : 157, paragraph 1 up to and including 3, apply accordingly to a transfer of a contractual position as meant in the present Article.*

[2344] Voy. p. ex. Cass. (3e civ.), 12 décembre 2001, n° 00-15627 qui traite comme une délégation la cession d'un contrat d'entreprise.

[2345] Cass. be., 4 mars 1982, *R.C.J.B.*, 1984, p. 175, note M. Fontaine.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de sa « position contractuelle à un tiers », et en édictant quelques dispositions spéciales à cette opération, l'article 5.193 renvoie, pour le surplus aux dispositions des chapitres relatifs à la cession de créance et à la cession de dette. La jurisprudence luxembourgeoise s'est quant à elle très nettement ralliée à la conception unitaire. Dans un arrêt de 2009, la Cour d'appel a affirmé que « la substitution d'un tiers dans un contrat ne constitue par ailleurs pas une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités prévues à l'article 1690 du Code civil » et que « la cession de contrat peut se définir comme étant l'acte ayant pour objet le remplacement d'une partie par un tiers dans un rapport contractuel. La cession de contrat transmet donc au tiers la qualité de contractant, avec tous les droits et toutes les obligations qui y sont attachés. Elle est plus vaste qu'une cession de créance, une cession de contrat pouvant englober une cession de créance »[2346]. Un arrêt récent, se référant à la doctrine française, note de même que « la cession de contrat peut être définie comme l'opération par laquelle une partie à un contrat, le cédant, transfère à une autre personne, le cessionnaire, l'ensemble des effets de droit (dettes, créances et autres prérogatives ou charges) créés dans le contrat conclu avec un cocontractant, le cédé. Cette opération produit un effet translatif de la position contractuelle : le cessionnaire devient "partie au contrat cédé" »[2347]. Cette position n'est cependant pas toujours suivie par le Tribunal de Luxembourg : si certaines décisions adoptent clairement la conception unitaire[2348], le tribunal continue d' analyser la cession de bail comme l'addition de la cession de la créance de jouissance des lieux loués (soumise à la formalité de l'article 1690) et de la cession de la dette de loyer (ne pouvant se réaliser que par une novation par changement de débiteur[2349]. Cette conception a des conséquences importantes quant aux conditions (A) et aux effets (B) de la cession de contrat.

[2346] Cour d'appel, 4 mars 2009, *Pas.*, 34, p. 442. Sur la cession de contrat en droit luxembourgeois, voy. A. WAISSE, « La cession de contrat en droit luxembourgeois : le triomphe du consentement ? », *Mélanges en l'honneur du Professeur Pascal Ancel*, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 623-646.

[2347] Cour d'appel, 20 décembre 2023, n° CAL-2023-00025.

[2348] Trib. Luxembourg, 28 avril 2009, *J.T.L.*, 2010, p. 64 note D. HIEZ. ; Trib. Luxembourg, 16 mai 2014, n°s 152012 et 156894.

[2349] Trib. Luxembourg, 26 novembre 2013, n° 153738 ; Trib. Luxembourg, 21 janvier 2014, n° 154824 ; Trib. Luxembourg, 21 décembre 2016, n° 177986. Voy. déjà Trib. Luxembourg, 8 avril 2011, n° 130251.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

A) *Conditions de validité de la cession de contrat*

1074. Contrats susceptibles d'être cédés. On se demande d'abord quels sont les contrats qui peuvent être cédés. Le plus souvent, la cession porte sur un contrat à exécution successive (bail, contrat de distribution, d'assurance, d'entretien, etc.), divisible dans le temps, dont l'exécution peut commencer avec un contractant et se poursuivre avec un autre. Mais rien n'interdit de céder un contrat à exécution instantanée, dès lors qu'il n'a pas produit ses effets essentiels. Ainsi, on peut céder un contrat d'entreprise, bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un contrat à exécution successive, dès lors que les travaux, commencés par un entrepreneur, peuvent être continués par un autre. De même, si on ne peut pas céder une vente qui a transféré la propriété – il s'agit alors d'une revente – on peut céder une promesse de vente, synallagmatique ou unilatérale, dès lors que ce type de contrat n'a pas encore transféré la propriété du bien, et qu'un tiers peut parfaitement se substituer dans les droits et les obligations du bénéficiaire de la promesse unilatérale ou de celui qui a promis d'acheter. La possibilité d'un tel transfert est souvent prévue dans les promesses et compromis de vente, sous forme d'une clause de substitution.

Le fait qu'un contrat soit conclu *intuitu personae*, c'est-à-dire que la personne du cédant soit essentielle pour le cédé, n'en interdit pas par principe la cession[2350]. Mais la cession n'est alors concevable que si le cédé y donne expressément son accord et agrée la personne du cessionnaire – ce qui est discuté pour les autres contrats.

1075. Consentement des parties. La cession de contrat est elle-même un contrat, qui suppose l'accord des parties. Mais quelles sont exactement les parties ? Il faut, sans aucun doute, un accord entre le cédant et le cessionnaire. Mais faut-il, en plus, le consentement du cédé ? La solution a été très discutée en droit commun. La jurisprudence française avait d'abord considéré que le consentement du cédé n'était nécessaire que si le contrat cédé était *intuitu personae*, mais elle a ensuite considéré que ce consentement du cédé était toujours nécessaire, sauf à préciser qu'il pouvait être donné par avance dans une clause du contrat cédé[2351]. Cette solution a été consacrée par l'article 1216 du Code civil français, qui exige l'accord du contractant sans distinguer selon la nature du contrat

[2350] Cass. fr. (comm.), 7 janvier 1992, n° 90-14831 ; Cass. fr. (1re civ.), 6 juin 2000, n° 97-19347.
[2351] Voy. : Cass. fr. (comm.), 6 mai 1997, n° 95-10252 ; Cass. fr. (comm.), 31 janvier 2012, n° 10-27603.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

cédé, et qui précise que, lorsque cet accord est donné par avance, la cession ne prend effet qu'au moment où elle est notifiée au cédé. L'article 5.193 du nouveau Code civil belge est exactement dans le même sens. La Cour d'appel du Luxembourg a connu, dans la période récente, la même évolution : après avoir considéré que l'accord du cédé n'était nécessaire que si le contrat avait été conclu *intuitu personae*[2352], elle a affirmé, en 2012, que ce consentement était une « condition nécessaire à l'efficacité de la cession », sans considération du caractère *intuitu personae* ou non de la cession[2353], et depuis elle adopte clairement la même position[2354] La doctrine française a beaucoup débattu de la nature et de la portée de ce consentement du cédé : certains y voient une simple autorisation, laquelle ne fait pas du cédé une partie à la cession de contrat ; d'autres estiment qu'il s'agit en réalité du consentement à un contrat nouveau qui se forme entre le cédé et le cessionnaire. Cette seconde analyse suppose qu'on rejette le caractère translatif de la cession de contrat, et qu'on y voie plutôt une sorte de novation, ce qui ne semble guère correspondre à l'intention des parties.

Lorsque la cession conventionnelle est réglementée par des textes spéciaux, ceux-ci peuvent, selon les cas, la subordonner ou non au consentement du cédé. Ainsi, en matière de bail, l'article 1717 du Code civil prévoit que le locataire a la faculté de céder son bail si cette faculté ne lui a pas été interdite par le contrat, et cette solution est reprise par l'article 2 de la loi du 21 septembre 2006 sur les baux d'habitation. Cette solution se retrouve en matière de baux commerciaux, mais la clause interdisant au locataire de céder son bail avec le fonds de commerce est réputée non écrite. Cependant, le projet de cession doit être signifié au bailleur et celui-ci peut refuser son agrément s'il en a de justes motifs[2355]. En matière de baux ruraux, c'est la solution inverse qui l'emporte : la cession du bail n'est possible qu'avec l'autorisation écrite du bailleur[2356]. La solution rejoint ici le droit commun de la cession de contrat.

1076. Conditions de forme. Traditionnellement, la cession de contrat n'obéissait pas à des conditions de forme particulières entre le cédant et le cessionnaire, et il semble toujours en aller ainsi en droit belge, en l'absence de précision dans l'article 5.193. En droit français, en revanche, l'article 1216 dispose que la cession doit être

[2352] Cour d'appel, 4 mars 2009, préc.

[2353] Cour d'appel, 15 février 2012, *Pas.*, 36, p. 78.

[2354] Cour d'appel, 21 décembre 2016, n° 41762, *JN Obligations*, 2017, n° 3-4, pp. 41-44, note A. WAISSE ; Cour d'appel, 20 décembre 2023, n° CAL-2023-00025 ; Cour d'appel, 22 février 2024, n° CAL-2021-01087. Sur la possibilité de donner l'accord du cédé par anticipation, voy. Cour d'appel, 26 octobre 2024, n° CAL-2021-00855, *JN Obligations*, 2024, n° 2, pp. 187-189, note H. WESTENDORF.

[2355] C. civ., art. 1762-3.

[2356] L. 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme, art. 21.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

constatée par écrit, à peine de nullité. En pratique, dans l'immense majorité des cas, le contrat donnera lieu à la rédaction d'un écrit, à la fois pour servir de preuve et pour préciser les conditions de la cession. Le cédé peut donner son accord, soit de manière expresse, soit tacitement, même *a posteriori* (par exemple, en demandant l'exécution du contrat cédé au cessionnaire[2357]). Dès lors que l'opération ne s'analyse pas comme une cession de créance, il est inutile de respecter les formalités d'opposabilité de l'article 1690 du Code civil[2358]. De toute façon, le cédé, qui doit donner son accord, est nécessairement mis au courant de la cession, et il n'y a pas à craindre qu'il exécute ses obligations envers son contractant originaire.

§ 3. Effets de la cession de contrat

1077. Rapports cédé-cessionnaire. Le cessionnaire recueille l'ensemble des droits et des obligations du cédant. Dans le cas, le plus fréquent, où le contrat cédé est à exécution successive, seuls passent sur la tête du cessionnaire les droits et les obligations nés après la cession. Par exemple, dans le cas d'une cession de bail, le nouveau locataire n'est tenu de payer les loyers que pour la période postérieure à la cession, puisqu'il ne profite du bien loué qu'à partir de ce moment. Il n'en va autrement que si le cessionnaire accepte, par une clause expresse du contrat, de garantir l'exécution par le cédant de ses obligations antérieures.

On se demande si la cession a ou non un effet translatif. La réponse est évidemment négative pour les auteurs qui estiment que l'accord du cédé entraîne la conclusion d'un nouveau contrat avec le cessionnaire. Dans l'opinion dominante, cependant, c'est le même contrat qui se continue, avec simplement un changement de parties. Il en résulte que le cédé doit pouvoir opposer à son nouveau contractant toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au précédent, dès lors qu'elles sont antérieures à la cession (par exemple, la nullité du contrat), et le cessionnaire doit pouvoir bénéficier des accessoires des créances dont il devenu titulaire. Après avoir hésité, la Cour de cassation française a ainsi admis, à propos de la transmission légale du bail à l'acquéreur de l'immeuble, que le nouveau bailleur bénéficiait du cautionnement qui avait été donné à l'ancien pour garantir les dettes du locataire[2359]. À l'inverse, le cessionnaire devrait pouvoir se libérer du contrat en invoquant les causes de nullité initiale du contrat, à moins qu'il ne s'agisse de causes personnelles au cédant (par exemple : le nouveau locataire ne devrait pas pouvoir échapper à ses obligations en invoquant l'incapacité ou un vice du consentement dont aurait été victime le cédant lors de la conclusion du contrat). De même, si le cédé n'avait pas

[2357] Cour d'appel, 4 mars 2009 et 15 février 2012, préc. Le second arrêt précise cependant qu'un tel consentement tacite ne peut valoir accord pour libérer le cédant de ses obligations.

[2358] Cour d'appel, 4 mars 2009, préc.

[2359] Cass. fr. (ass. plén.), 6 décembre 2004, n° 03-10713.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

exécuté ses obligations envers le cédant, le cessionnaire devrait pouvoir invoquer cette inexécution pour échapper, par le jeu de l'exception d"inexécution au paiement des dettes antérieures dans la mesure où elles lui sont transmises. Ces solutions sont désormais certaines en droit belge dans la mesure où l'article 5.193, on l'a dit, renvoie aux textes sur la cession de créance et sur la cession de dette qui sont des mécanismes translatifs. Le nouveau droit français consacre également l'opposabilité des exceptions (C. civ. fr., art. 1216-2), mais il édicte une solution plus nuancée : elles ne continuent à bénéficier au cessionnaire que si le cédant n'a pas été libéré par le cédé (ce qui, nous allons le voir est le cas normal). En revanche, si le cédant est libéré, les sûretés ne sont maintenues que si le cédant ou le tiers garant donnent leur accord (C. civ. fr., art. 1216-3).

1078. Rapports cédé-cédant. La question est ici de savoir si le cédant reste tenu envers le cédé des obligations générées par le contrat cédé, ou s'il en est libéré par l'effet de la cession. Dans les contrats à exécution successive, le problème ne se pose que pour les dettes nées postérieurement à la cession, puisque de toute façon le cédant reste tenu des dettes antérieures : il s'agit de savoir, par exemple, si le locataire qui a cédé son bail reste tenu de payer au bailleur les arriérés de loyer du nouveau locataire. La jurisprudence française, par une assimilation à la délégation, décide que le cédant n'est pas libéré sauf décharge expresse du cédé[2360] et cette solution est consacrée par les nouveaux textes français (C. civ., art. 1216-1). La Cour d'appel du Luxembourg a très nettement consacré une solution analogue dans son arrêt du 15 février 2012[2361]. Pour cet arrêt « à défaut d'autre précision, la "cession" entraîne une simple addition de contractants. Le cessionnaire peut réclamer l'exécution au cédé et la lui imposer. Mais, le cédant n'est pas pour autant libéré. La libération du cédant en l'absence de la volonté expresse du cédé est inacceptable. La nécessité du consentement du cédé résulte de l'effet obligatoire du contrat s'opposant à une modification sans le consentement du cédé. Le cédant s'est obligé à son égard et il ne peut ni se délier, ni diminuer unilatéralement la portée de son engagement. La volonté du cédé de libérer le cédant, ou de ne le conserver que comme garant de l'exécution, ne saurait résulter de la seule autorisation de la cession ».

[2360] Cass. fr. (3e civ.), 12 décembre 2001, n° 00-15627.

[2361] Cour d'appel, 15 février 2012, préc. Dans le même sens, à propos d'une cession de bail : Trib. Luxembourg, 21 décembre 2016, n° 177986.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La distinction des parties et des tiers, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1073-1138
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

1079. Extension à des tiers véritables des effets internes du contrat. Les développements précédents ont contribué à cerner la portée de l'effet relatif du contrat. D'une part, ce principe, posé par l'article 1165 du Code civil, ne s'applique qu'aux effets « internes » du contrat, c'est-à-dire à la naissance d'obligations et à la création ou au transfert de droits réels. Le fait que les tiers – tous les tiers, plus ou moins intéressés – au contrat, doivent respecter la norme obligatoire créée par le contrat entre les parties et qu'ils puissent s'en prévaloir – ce qu'on appelle, dans les pays du Code civil, l'opposabilité du contrat, n'est pas en soi contraire au principe de l'effet relatif. D'autre part, les effets internes du contrat – et notamment la naissance de créances et de dettes entre les parties – peuvent, au cours de la vie du contrat, être transmis ou attribués à un tiers qui va devenir créancier ou débiteur d'une ou plusieurs créances ou d'une ou plusieurs dettes nées du contrat, voire devenir partie au contrat à la place d'une partie initiale. Ces mécanismes de transmission ne sont pas non plus, en eux-mêmes, contraires au principe de l'effet relatif, puisque la personne ainsi intégrée au contrat n'est plus, véritablement, un tiers.

Dans un certain nombre de cas, en revanche, des effets « internes » du contrat, et spécialement la création de droits et d'obligations, vont se produire directement au profit ou même à la charge de tiers qui étaient, et qui sont restés complètement étrangers au contrat. On est alors en présence de véritables exceptions au principe de l'effet relatif.

Cette distinction entre ce qui relève de la définition même de l'effet relatif – l'opposabilité, les mécanismes de transmission – et ce qui y fait exception, si elle est utile pour une présentation pédagogique de la matière, ne doit surtout pas être surestimée. D'une part, les deux séries de mécanismes – les fausses et les vraies exceptions à l'effet relatif – témoignent les uns et les autres de la manière dont le contrat, loin d'être une relation refermée sur elle-même qui ne concernerait que les deux parties, s'intègre au sein d'un ensemble de relations sociales avec lesquelles il est en constante interaction : face à cette interpénétration, le système juridique ne peut pas traiter le contrat comme un acte dont les effets seraient strictement limités aux parties, et c'est ce qui explique à la fois la portée limitée de l'article 1165 du Code civil et les exceptions qui lui sont apportées. D'autre part, les glissements d'une série de mécanismes à l'autre sont extrêmement fréquents. On a déjà vu, par exemple, que la notion d'opposabilité était parfois utilisée pour étendre en réalité à un tiers des effets obligationnels nés d'un contrat : ainsi lorsque la jurisprudence admet que la violation par un contractant de ses obligations vis-à-vis de l'autre partie constitue une faute délictuelle à l'égard des tiers. De même, l'idée de transmission à certains tiers de créances contractuelles n'est parfois qu'un « truc », une fiction de volonté, destinée à rendre compatible avec le principe de l'effet relatif une solution qui, en réalité, constitue une extension à ces tiers des

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1141-1142
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

effets du contrat. Aussi bien ne faut-il pas s'étonner si, dans ce second sous-titre, nous pouvons retrouver, sous un autre angle, des solutions déjà entrevues dans le sous-titre précédent.

L'extension à des tiers des effets obligationnels du contrat, objet de ce second sous-titre, peut avoir deux types de sources. Elle peut résulter de la convention des parties, et dans ce cas elle ne peut avoir pour effet que de créer des droits au profit de tiers (**Chapitre I**). Mais elle peut aussi résulter de la loi ou de la jurisprudence et dans ce cas elle joue parfois dans les deux sens (**Chapitre II**).

LARCIER INTERSENTIA
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Introduction, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1141-1142
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Chapitre I
L'extension volontaire des effets internes du contrat

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

1080. Problématique. Etant admis qu'un contrat ne crée pas, en principe, de droits et d'obligations au profit ou à la charge de tiers, peut-on admettre que, volontairement, les parties puissent déroger à ce principe ? Dans un système fondé sur la toute-puissance de la volonté, cela semble, à première vue, très difficile à admettre : comment les parties peuvent-elles décider, par leur accord, de lier une personne extérieure ? Pourtant, les rédacteurs du Code civil ont, en apparence du moins, posé deux exceptions au principe de l'article 1119 du Code civil, en permettant dans l'article 1120 du Code civil à une partie à un contrat de promettre le fait d'autrui, et, à l'inverse, dans l'article 1121 du Code civil, de stipuler (c'est-à-dire de faire naître une créance) pour autrui. Cette présentation, conservée dans le nouveau droit français (C. civ. fr., art. 1203 et s), comme dans le droit belge C. civ. be., art. 5.106 et s.), est trompeuse, du moins en ce qui concerne l'article 1120 du Code civil. En dépit de la place de ce texte, un contrat privé ne peut jamais rendre un tiers débiteur (§ 1). En revanche, il est bien possible de « stipuler au profit d'un tiers », c'est-à-dire de rendre un tiers créancier, bien au-delà d'ailleurs de ce que prévoit l'article 1121 (§ 2).

SECTION 1. L'IMPOSSIBILITÉ DE RENDRE UN TIERS DÉBITEUR DU CONTRAT

1081. Renvoi. Tout de suite après l'article 1119, les rédacteurs du Code civil ont semblé vouloir lui apporter une exception, en prévoyant dans l'article 1120 que « néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci […] ». Ce mécanisme a déjà été étudié, en liaison avec la technique de la représentation[2362]. On a vu que, lorsqu'une personne se porte fort de ce qu'un tiers fera (ou ne fera pas) quelque chose, cette promesse ne fait naître aucune obligation à la charge de ce tiers. Celui-ci demeure entièrement libre de s'obliger ou non envers le bénéficiaire de la promesse. S'il ne « tient pas l'obligation », ce tiers ne sera pas sanctionné[2363], c'est seulement le promettant qui le sera : la promesse n'engage donc que celui qui l'a faite, et ce n'est en aucune manière une exception au principe de l'effet relatif.

[2362] Voy. *supra*, n° 300.

[2363] À moins bien sûr qu'il ne soit personnellement engagé par ailleurs envers le bénéficiaire, dans le cas où le porte-fort est utilisé comme garantie d'exécution. Voy. *supra*, n° 300.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

SECTION 2. LA POSSIBILITÉ DE RENDRE UN TIERS CRÉANCIER : LA STIPULATION POUR AUTRUI

1082. Principe. De prime abord, la possibilité dans un contrat de créer dans un contrat un droit au profit d'un tiers semble beaucoup plus facile à admettre que celle de faire peser sur lui une obligation. Si les deux contractants sont d'accord pour que l'un s'oblige envers un tiers, pourquoi ne pas permettre à ce tiers d'en profiter, même s'il n'a pas consenti à ce contrat ? Cela ne semble pas présenter d'inconvénient, dès lors que l'effet produit est exclusivement favorable à ce tiers, pourvu du moins qu'il puisse refuser cette faveur s'il ne veut pas en profiter. Effectivement, les droits modernes, au Luxembourg comme dans la plupart des systèmes juridiques, admettent très largement cette possibilité de « stipuler pour autrui » (stipuler étant pris ici dans le sens étroit de faire naître un droit de créance) : une personne (le stipulant) fait promettre à une autre (le promettant) qu'elle fera quelque chose au profit d'un tiers (le bénéficiaire). On connaît aujourd'hui de multiples applications de ce mécanisme, dont la plus caractéristique est l'assurance-vie souscrite au profit d'un tiers : le souscripteur de l'assurance stipule de l'assureur qu'à son décès, l'assureur versera un certain capital à un tiers qu'il désigne. Le tiers est, au départ du moins, complètement étranger à cet accord, qu'il ne découvrira peut-être qu'au moment du décès du souscripteur. Il n'en aura pas moins le droit de réclamer à l'assureur le versement du capital en se fondant sur le contrat auquel il n'a pas été partie.

1083. Prohibition traditionnelle. Il faut savoir cependant que ce qui nous paraît évident aujourd'hui ne l'a pas toujours été, et ne l'est toujours pas, aujourd'hui encore, dans certains droits. Historiquement, la stipulation pour autrui a été pendant longtemps interdite, par application de la règle romaine « *Nemo alteri stipulari potest* ». Justifiée à l'origine, dans un système où le contrat était un acte ritualisé, par l'idée que seuls ceux qui avaient prononcé les paroles sacramentelles requises pouvaient être touchés par le contrat[2364], la prohibition a subsisté au cours des siècles en dépit de la montée du principe d'autonomie de la volonté, comme une sorte de dogme sur la justification duquel on ne s'interrogeait plus guère. À la fin du XVIII[e] siècle, Pothier affirmait encore l'impossibilité de principe de toute stipulation pour autrui, n'admettant que

[2364] J.-L. GAZZANIGA, *Histoire du droit des obligations*, n° 82.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

des cas où, en réalité, la stipulation apparaît comme faite d'abord au profit du stipulant[2365]. Le Code civil porte encore trace de cette conception : certes, l'article 1121 du Code civil, présenté comme une exception au principe de l'article 1119 du Code civil, admet qu'on peut « stipuler au profit d'un tiers », mais seulement dans des cas très limités « lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre ».

1084. Admission généralisée. Cette conception restrictive n'a pas résisté au temps. Dès la seconde moitié du XIXe siècle, la jurisprudence française, suivie en Belgique et au Luxembourg, a fait sauter les barrières étroites dans lesquelles les rédacteurs du Code avaient voulu l'enfermer, principalement dans le but de permettre le développement de l'assurance-vie. Cela a conduit à la fois à un assouplissement des conditions de la stipulation pour autrui et à un renforcement de ses effets. Au fil du temps, il n'est plus rien resté des restrictions posées par l'article 1121 du Code civil, et on peut dire qu'aujourd'hui la stipulation pour autrui est permise en principe dans les pays du Code civil. La matière est une des plus parfaites illustrations du rôle que peut jouer la jurisprudence en droit des obligations, et du décalage qui peut exister, aujourd'hui, entre la lettre de certains textes du Code et le droit réellement appliqué. La réforme française, dont l'un des objectifs était de réduire ce décalage, a introduit dans le Code civil un article 1205 selon lequel « [o]n peut stipuler pour autrui. L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire ». L'article 5.107 du nouveau Code civil belge dispose de même qu'« un contrat peut accorder à un tiers le droit de demander l'exécution d'une prestation déterminée ». Ces textes pourraient sans difficulté être transposés au Luxembourg, dont les solutions sont pratiquement les mêmes qu'en France et en Belgique, tant du point de vue des conditions (A) que des effets (B) du mécanisme.

1085. Droit comparé. Cette admission large de la stipulation pour autrui s'observe également en droit comparé, les jurisprudences et les législateurs des différents pays d'Europe continentale, ayant tous été sensibles aux intérêts pratiques du mécanisme, même si on note d'importantes variantes dans la réglementation du mécanisme d'un pays à l'autre[2366]. C'est dans les droits de *common law* que le refus

[2365] POTHIER, *Traité des obligations*, n°s 54 et s.

[2366] Voy. à titre d'exemples : Suisse, CO, art. 112 ; Allemagne, BGB, § 328 et s. ; Pays-Bas BWB, art. 6 : 253.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

traditionnel de la stipulation pour autrui s'est maintenu le plus longtemps (et qu'il subsiste encore dans certains droits nationaux), en raison du lien établi avec la doctrine de la *consideration*, qui n'admet en principe un contrat que si chaque contractant fournit à l'autre une contrepartie à son engagement : celle-ci, dans la conception traditionnelle, doit être fournie par celui-là même qui bénéficie de l'engagement, ce qui conduisait à exclure la création d'un droit au profit d'un tiers, qui ne fournit rien en échange[2367]. Même si la jurisprudence avait, au fil du temps, trouvé toutes sortes de palliatifs il a fallu attendre 1999 pour qu'une loi, le *Contract (Third parties) Act*, vienne admettre la possibilité pour un tiers de demander l'exécution d'un droit créé à son profit dans un contrat auquel il est resté extérieur. Tous les projets européens admettent de même le mécanisme de la stipulation pour autrui, quoiqu'avec diverses variantes dans les conditions et dans les effets du mécanisme[2368].

A) *Les conditions de la stipulation pour autrui*

1086. Accord de volontés entre le stipulant et le promettant. La stipulation pour autrui apparaît comme un accord entre deux personnes, l'une (le stipulant) qui fait promettre à l'autre (le promettant) qu'il exécutera une prestation envers un tiers (le bénéficiaire). Par exemple, le souscripteur de l'assurance-vie (stipulant) fait promettre à l'assureur (promettant) qu'il versera un capital au bénéficiaire de l'assurance. On remarquera d'emblée que le bénéficiaire n'intervient pas, au départ, à l'opération : nous verrons qu'il devra ultérieurement l'accepter pour demander au promettant l'exécution de son obligation, mais cette acceptation n'est pas une condition de validité du contrat, ni même de la naissance du droit du bénéficiaire. Cet accord entre le stipulant et le promettant (qui peut être un contrat à part entière ou une clause d'un contrat ayant un objet plus large) est d'abord soumis aux conditions générales de validité des actes juridiques : il doit intervenir entre personnes capables, être exempt de vices du consentement, ne pas être contraire à l'ordre public, etc. La spécificité de son objet amène cependant à se demander si la stipulation ne doit pas, en plus, être soumise à des conditions spécifiques, tant quant aux relations entre le stipulant et le promettant (**1**), que par rapport à la personne du bénéficiaire (**2**). Sur ces deux points, cependant, la jurisprudence s'est montrée très libérale.

[2367] *Tweddle v. Atkinson*, (1861) 1B & S393, 121 ER 362. V. J. CARTWRIGHT, *Contract law*, *op. cit.*, pp. 235 et s.

[2368] Voy. : DCFR, II-9 : 301 et s. ; PDEC, art. 6 : 110 ; Code Gandolfi, art. 72 et s. ; DCEV, art. 78.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

1) *Conditions tenant aux relations entre le stipulant et le promettant*

1087. Article 1121 du Code civil : nécessité d'un lien avec un autre contrat. Dans le Code civil de 1804, la stipulation pour autrui n'est admise que si elle est liée à un contrat ayant un autre objet. Le Code envisage, de manière apparemment limitative, deux hypothèses : « lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. » Le premier cas est celui d'un contrat faisant naître, d'abord, une créance envers le stipulant, et où celui-ci conditionne la passation du contrat au fait que son cocontractant accorde, en plus, un avantage à un tiers : on peut prendre l'exemple (moderne) d'une brasserie qui fournit de la bière à l'exploitant d'un café ou d'un restaurant en lui imposant d'acheter les autres boissons que la bière à une société tierce (qu'on suppose liée à la brasserie). Le second cas (beaucoup plus fréquent) est celui d'une personne qui fait une donation à la condition que le donataire accepte de fournir certains biens ou services à un tiers : par exemple, je vous fais donation de ma maison à condition que vous acceptiez d'y loger ma mère âgée, ou de lui verser une rente. La raison que les rédacteurs du Code civil avaient d'admettre la stipulation dans ces deux cas, est que, comme l'expliquait déjà Pothier, le stipulant y a un intérêt personnel à ce que son cocontractant s'engage envers le tiers, de sorte qu'on peut avoir l'impression que l'engagement est pris d'abord envers le stipulant. Ces deux cas se sont assez vite révélés trop étroits, lorsque s'est développé le mécanisme de l'assurance-vie : le souscripteur d'une telle assurance, en effet, ne demande rien pour lui-même, et il ne fait aucune donation à l'assureur (les primes n'étant que la contrepartie de l'engagement de payer pris par celui-ci). S'en tenir à la lettre de l'article 1121 du Code civil, c'était donc condamner le développement de l'assurance-vie. Sensible aux considérations pratiques, la jurisprudence a donc dépassé très largement la lettre du texte.

1088. Jurisprudence moderne : intérêt du stipulant. Dès la fin du XIXe siècle, la Cour de cassation française a admis qu'une stipulation pour autrui pouvait être faite en dehors des deux cas prévus par l'article 1121 du Code civil. Ces deux cas ont été regardés comme l'application de l'idée générale selon laquelle le stipulant devait avoir un intérêt personnel à la stipulation. On a donc décidé de valider toute stipulation visant à satisfaire un tel intérêt, qu'il soit

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

patrimonial ou moral : il faut et il suffit que le stipulant tire un quelconque avantage de la stipulation, ne serait-ce que la satisfaction de faire plaisir au tiers ou de lui assurer des revenus (ce qui est la motivation habituelle de l'assurance-vie). Cette idée se retrouve dès 1904 dans la jurisprudence luxembourgeoise, lorsqu'on voit la Cour d'appel affirmer que « est valable la stipulation faite en nom propre au profit d'un tiers, lorsque le stipulant a lui-même un intérêt à ce que ce tiers profite de la créance, intérêt qui consiste par exemple à éviter des frais qui, sans cette stipulation, tomberaient à charge du stipulant »[2369]. Il s'agissait en l'espèce du père d'une jeune fille enceinte qui avait fait souscrire au « séducteur » l'engagement de pourvoir aux besoins de la jeune fille et de l'enfant à naître. Un tel raisonnement aboutit, de fait, à valider par principe toute stipulation pour autrui puisqu'on ne conçoit guère qu'une personne demande à une autre de s'engager envers autrui si elle n'y trouve pas un intérêt quelconque. La seule exigence – tirée du droit commun des contrats – sera que l'intérêt du stipulant ne soit pas la poursuite d'un but illicite ou immoral, ce qui conduirait à l'annulation du contrat sur le fondement de l'article 1131 du Code civil[2370]. De manière assez curieuse, cependant, on trouvait encore affirmépar certains auteurs, avant les récentes réformes, que la stipulation doit être « l'accessoire d'un autre contrat » pour être valable[2371]. Cette présentation est trompeuse : s'il est vrai que la stipulation doit nécessairement s'intégrer dans un contrat entre le stipulant et le promettant[2372], il peut s'agir, comme dans le cas de l'assurance-vie, d'un contrat qui a pour seul objet de conférer un droit à un tiers. Comme on l'a vu, à l'occasion des réformes récentes en France et en Belgique, on a fait disparaître les limites posées par l'article 1121, pour permettre d'une manière générale le recours à la stipulation pour autrui.

1089. Applications multiples. À partir du moment où on sort des limites strictes de l'article 1121 du Code civil, la stipulation pour autrui peut être utilisée à des fins diverses. L'assurance constitue son domaine

2369 Cour d'appel, 29 avril 1904, *Pas.*, 6, p. 477.

2370 Ainsi, à l'époque où on considérait que les libéralités destinées à favoriser la poursuite de relations hors mariage avaient une cause illicite, on pouvait annuler pour la même raison une assurance-vie souscrite dans ce but par un homme au profit de sa concubine. Dans l'affaire de 1904, la Cour d'appel a considéré que le fait pour un homme de s'engager à subvenir aux besoins de la femme qu'il a séduite et de son enfant, à une époque où la loi interdisait par principe l'établissement de la paternité naturelle, n'était pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

2371 WÉRY, n° 869.

2372 FLOUR, AUBERT, SAVAUX vol. 1 2014, n° 470.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

d'élection : à côté de l'assurance-vie, qui a constitué la raison de son développement, on trouve une stipulation pour autrui dans l'assurance souscrite par un constructeur d'immeuble au profit de tous les propriétaires successifs de cet immeuble, dans l'assurance souscrite par un employeur au profit de ses salariés pour les couvrir dans leurs déplacements professionnels ou même privés, dans l'assurance que le propriétaire d'un véhicule souscrit pour couvrir sa responsabilité civile et aussi celle des tiers autorisés à conduire le véhicule[2373], dans l'assurance liée à un paiement d'un voyage par carte de crédit qui permet de couvrir tous ceux qui font partie du voyage, etc. Mais, en dehors de ce domaine, les applications du mécanisme sont très diverses : ainsi dans l'exemple précité de la brasserie qui stipule une obligation de s'approvisionner auprès d'une société qui lui est liée, ou lorsque, dans l'organisation d'un réseau de distribution, un fabricant s'engage envers ses concessionnaires à faire bénéficier les clients de ceux-ci de la garantie de l'ensemble du réseau, ou encore, pour prendre des exemples très différents tirés de la jurisprudence luxembourgeoise, ancienne ou très récente, lorsque le Conseil communal de la ville de Luxembourg s'engage envers l'évêque à faire bénéficier tous les vicaires de la paroisse d'une indemnité de logement[2374], ou lorsque les parties à un compromis de vente s'engagent, en cas de résiliation du compromis par l'une des parties, à verser à titre d'indemnité une certaine somme à l'agent immobilier qui a négocié la vente mais qui n'y est pas partie[2375]. A été également qualifiée de stipulation pour autrui la clause d'un contrat de vente d'un terrain par laquelle l'acquéreur (promettant) s'engage envers le vendeur à prendre à sa charge les frais d'infrastructure, ce qui vaut engagement de rembourser la société ayant engagé ces frais[2376], ainsi que la clause d'un contrat de fiducie par laquelle le fiduciaire s'engage envers le fiduciant à remettre le patrimoine fiduciaire à un tiers (bénéficiaire) au décès du fiduciant[2377]. Il convient de souligner, à propos de ces différentes applications, que toutes ne se présentent pas explicitement comme des stipulations pour autrui nommées comme telles par des clauses du contrat : c'est souvent *a posteriori*, pour savoir

[2373] Cour d'appel, 26 juillet 1950, *Pas.*, 15, p. 48 ; Cass., 28 mai 1959, *Pas.*, 17, p. 435.

[2374] Cour d'appel, 2 mai 1919, *Pas.*, 11, p. 106.

[2375] Trib. Luxembourg, 17 février 2015, n° 159-554 ; Cour d'appel, 23 décembre 2015, n° 42534.

[2376] Cour d'appel, 12 janvier 2012, n° 35307 ; Cour d'appel, 26 juin 2024, n° CAL-2022-00825.

[2377] Voy. dans la même affaire : Cour d'appel, 16 novembre 2021, n° CAL-2020-00936 ; Cour d'appel, 30 avril 2024, n^{os} CAL-2020-00936 et CAL-2023-00596.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

si un tiers peut agir directement pour obtenir un avantage prévu à son profit, que les juges seront amenés à qualifier (ou à refuser de qualifier) telle ou telle clause de « stipulation pour autrui ». C'est pour reconnaître un tel droit que les juges ont qualifié de stipulation pour autrui le contrat entre l'évêque et le Conseil communal, ou la clause d'indemnisation de l'agent immobilier dans le compromis de vente. En revanche, la jurisprudence luxembourgeoise refuse de voir une stipulation pour autrui dans l'ordre de virement donné par un client à sa banque au profit d'un tiers : celui-ci ne peut donc pas agir contre la banque pour obtenir le paiement de la somme virée[2378].

Dans la jurisprudence française, une stipulation pour autrui purement tacite a même été, à une certaine époque, reconnue dans certains contrats en l'absence de toute clause donnant un avantage à un tiers. Cette jurisprudence s'est développée spécialement dans le domaine du transport de personnes, en cas d'accident mortel survenu au passager. Les proches, agissant en réparation du préjudice personnel qu'ils subissent du fait de la mort du passager, sont des tiers au contrat de transport ; ils n'ont donc en principe contre le transporteur qu'une action délictuelle fondée sur les articles 1382 et suivants du Code civil. Pour leur permettre de bénéficier de l'obligation de sécurité contractuelle que la jurisprudence fait peser sur le transporteur[2379], certaines décisions avaient imaginé que, dans le contrat de transport, le passager stipulait tacitement du transporteur qu'il indemniserait les proches en cas de décès[2380]. Cette jurisprudence, souvent critiquée en raison du caractère purement fictif de la volonté prêtée aux intéressés, semble aujourd'hui être abandonnée[2381]. Elle ne semble jamais avoir eu d'écho ni au Luxembourg, ni en Belgique. On peut en revanche la rapprocher de la construction jurisprudentielle allemande du « contrat avec effets protecteurs pour les tiers » (*Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte*) : pour ouvrir à certains tiers une action en responsabilité contractuelle en cas d'inexécution d'un contrat qui leur cause un préjudice, la jurisprudence allemande admet que « sous certaines conditions, des tiers au contrat peuvent se trouver incluses dans la sphère de protection du contrat, ce qui a pour conséquence, non pas qu'ils aient une action en exécution de l'obligation primaire, mais qu'ils puissent se prévaloir de la protection offerte par le contrat, de sorte qu'en cas de violation de ces devoirs accessoires ils peuvent faire valoir en leur propre nom une action en dommages et intérêts »[2382]. Il a été ainsi admis que la fille de la cliente d'un magasin libre-service, qui a glissé sur une feuille de salade dans le magasin, peut agir en responsabilité contractuelle contre la société exploitante, alors que c'est sa mère et non elle qui a passé le contrat. Un autre exemple est celui de l'acheteur d'une maison qui se voit reconnaître une action contractuelle à l'encontre d'un expert en construction ayant délivré au vendeur, dans le cadre d'un contrat passé avec ce dernier, un certificat

[2378] Cour d'appel, 12 mars 1997, n° 17.979 ; Trib. Luxembourg, 8 juillet 2011, *Bull. Droit et banque*, 2012, n° 50 ; Cour d'appel, 23 novembre 2014, n° 39177.

[2379] Voy. *supra*, n° 534.

[2380] Cass. fr. (civ.), 6 décembre 1932, *DP*, 1933, 1, p. 137, note JOSSERAND ; *RTD civ.*, 1933, p. 109, obs DEMOGUE.

[2381] Cass. fr. (1re civ.), 28 octobre 2003, n° 00-18794 00-20065.

[2382] BGH 28.1.76, NJW, 1976, 712, 465, Gemüseblattfall.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

erroné sur le bon état de la maison[2383]. La différence avec la construction française fondée sur la stipulation pour autrui tacite est que la notion allemande est strictement objective et ne fait pas appel à l'idée d'une volonté supposée des parties[2384].

2) *Conditions tenant au bénéficiaire*

1090. Personne présente ou future. Dans la mesure où le bénéficiaire n'est pas une partie au contrat qui fait naître son droit, il n'est pas nécessaire qu'il existe et ait la personnalité juridique au moment où ce contrat est passé. Il est bien admis depuis longtemps qu'on peut stipuler au profit d'une personne qui n'est pas encore née, ni même conçue. C'est même une stipulation très courante en matière d'assurance-vie, lorsque le souscripteur conclut l'assurance au profit de ses enfants à naître. Cette possibilité de stipuler au profit d'une personne future est admise par tous les droits qui connaissent la stipulation pour autrui, ainsi que par tous les projets qui y sont relatifs. Elle figure expressément dans le nouvel article 1205 du Code civil français, et dans l'article 5.107 du nouveau Code civil belge. Cette solution révèle de manière particulièrement nette que le bénéficiaire est extérieur à l'opération.

1091. Personne déterminée ou déterminable. Le bénéficiaire peut être précisément désigné dans le contrat passé entre le stipulant et le promettant : je souscris une assurance-vie au profit de « mon épouse, Mme Maria Schlick », les parties à un compromis s'engagent, en cas de résiliation, à verser une indemnité de 3 % à tel agent immobilier, etc. Mais ce n'est pas indispensable : il suffit que le bénéficiaire, s'il n'est pas précisément nommé, soit déterminable, au plus tard lors de l'exécution de la promesse (cf C. civ. fr., art 1205, C. Civ. be., art. 5.107). Le stipulant peut donc se réserver la possibilité de désigner ultérieurement le bénéficiaire. L'article 49 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance admet ainsi la validité de l'assurance « pour le compte de qui il appartiendra » souscrite par exemple par un propriétaire pour garantir la responsabilité civile de ses futurs locataires, qu'il ne connaît pas encore[2385]. Il est de même fréquent qu'une assurance-vie soit souscrite au profit d'une catégorie de personnes qui ne sont pas précisément nommées : mon épouse, mes enfants, etc. D'une manière plus générale, l'article 30

[2383] BGH 10.11.94 NJW 1995, 392

[2384] Pour une présentation plus approfondie en français, voy. P. ANCEL, « Le contrat avec effets protecteurs pour les tiers », *R.D.C.*, 2004, n° 2, p. 471 et les auteurs cités.

[2385] Cour d'appel, 5 juin 2002, n° 26331. En droit français, l'article L. 112-1 du Code des assurances qualifie expressément cette assurance de stipulation pour autrui.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de la loi de 1997, qui prévoit la possibilité de faire bénéficier un tiers d'une assurance prévoit que « ce tiers ne doit pas être désigné ni même être conçu au moment de la stipulation, mais il doit être déterminable au jour de l'exigibilité des prestations d'assurances ».

B) *Les effets de la stipulation pour autrui*

1092. Rapports triangulaires. Contrat entre deux personnes qui confère un droit à une troisième, la stipulation pour autrui produit des effets dans les relations entre les trois parties concernées : le promettant et le bénéficiaire (**1**), le stipulant et le bénéficiaire (**2**) et enfin le stipulant et le promettant (**3**).

1) *Effets dans les relations promettant-bénéficiaire : le droit du bénéficiaire contre le promettant*

1093. Effet caractéristique. – Dans les pays du Code civil, comme du reste dans la plupart des systèmes juridiques qui l'admettent, c'est dans les relations entre le promettant et le bénéficiaire que se produit l'effet caractéristique de la stipulation pour autrui : le bénéficiaire acquiert un droit contre le promettant, il pourra lui demander directement l'exécution de l'obligation souscrite en sa faveur, au besoin recourir à l'exécution forcée contre lui, et faire sanctionner l'inexécution de cette obligation en mettant en jeu la responsabilité contractuelle du promettant. La principale question est de savoir comment et à quel moment ce droit naît dans le patrimoine du bénéficiaire (**a**). L'étendue exacte de ce droit suscite également quelques difficultés (**b**).

a. *Naissance du droit du bénéficiaire*

1094. Droit direct et immédiat. Au XIXe siècle, on tenait encore pour un dogme incontournable le principe de l'effet relatif. C'est pourquoi, alors même que l'article 1165 du Code civil qui pose ce principe en excepte « le cas de l'article 1121 », la doctrine avait cherché toutes sortes d'explications pour tenter de concilier l'existence d'un droit contre le stipulant avec la relativité du contrat. L'une de ces explications – dite « théorie de l'offre » – était que le contrat passé entre le stipulant et le promettant faisait d'abord naître une créance au profit du stipulant, qui, dans le même temps, offrait au bénéficiaire de lui transmettre. Dans cette conception, le droit du bénéficiaire naissait seulement de son acceptation de la promesse, et le bénéficiaire tirait son droit, non du contrat passé entre

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

le stipulant et le promettant, mais du contrat passé entre le stipulant et le bénéficiaire. Ramenée ainsi à un mécanisme conventionnel de transmission d'une créance[2386], l'opération ne constituait plus une exception au principe de l'effet relatif. Cette explication aboutissait cependant à fragiliser la situation du bénéficiaire, notamment dans le cadre de l'assurance-vie : le capital assuré faisait d'abord partie du patrimoine du souscripteur et il pouvait, du coup, être saisi par ses créanciers tant que le bénéficiaire n'avait pas accepté la stipulation ; en outre, si le souscripteur avait des héritiers directs, et que l'assurance était souscrite au profit d'un tiers, les héritiers pouvaient considérer que le capital faisait partie de la succession, et en réclamer une partie à l'encontre du bénéficiaire si son montant excédait la portion disponible des biens de la succession[2387]. Dans le but d'encourager le développement de l'assurance-vie, la Cour de cassation française, dans plusieurs arrêts célèbres de 1888 et 1896, posa que le capital assuré ne faisait à aucun moment partie de l'actif du souscripteur : la créance contre l'assureur naît directement dans le patrimoine du bénéficiaire, par le seul effet du contrat passé entre le stipulant et le promettant, même avant qu'il n'ait accepté la stipulation[2388]. Ce droit direct[2389] a été par la suite repris par les jurisprudences luxembourgeoise[2390] et belge[2391]. C'est lui qui fait de la stipulation pour autrui une *véritable exception au principe de l'effet relatif*, puisqu'on est bien en présence d'un contrat qui, directement et immédiatement, fait naître un droit au profit d'un tiers. Ce droit direct est aujourd'hui consacré par l'article 1206 du Code civil français et par l'article 5.107 du nouveau Code civil belge.

On trouve la même idée exprimée dans d'autres droits nationaux et dans certains projets européens. Pour s'en tenir à quelques formules caractéristiques, on peut citer le § 328 du BGB selon lequel « Par un contrat on peut convenir d'une prestation au profit d'un tiers, avec l'effet que le tiers acquiert le droit de demander directement

2386 Sur ces mécanismes, voy. *supra*, n°s 995 et s.

2387 En droit luxembourgeois, on ne peut pas complètement déshériter ses enfants : ceux-ci ont droit à une « réserve » sur les biens de la succession, et on ne peut disposer par testament ou donation que de la partie de la succession qui est au-delà de cette réserve (quotité disponible). Si le capital assuré fait partie de la succession, on doit le compter pour la détermination de la quotité disponible.

2388 Cass. fr. (civ.), 8 février 1888, *S.*, 1888, 1, p. 121 ; Cass. fr. (civ.), 7 août 1888, *DP*, 1889, 1, p. 118.

2389 L'expression « droit direct », traditionnelle dans la doctrine française, est particulièrement ambiguë : elle ne signifie pas seulement que le tiers peut agir directement contre le promettant, sans passer par le stipulant. Elle signifie que ce droit naît directement et immédiatement dans le patrimoine du tiers, sans avoir transité par le patrimoine du stipulant.

2390 Cass., 11 juin 1909, *Pas.*, 8, p. 137 ; Cour d'appel, 13 novembre 1985, *Pas.*, 27, p. 9.

2391 Cass. be., 2 mai 1930, *Pas.* 1930, I, p. 193 ; Cass. be., 13 janvier 1967, *Pas.*, 1967, I, p. 571 ; 16 janvier 2006, n° C.04.0302.F.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'exécution de cette prestation »[2392]. Le Code européen des contrats, dans son article 72 dispose de même : « Sauf convention contraire, le tiers bénéficiaire acquiert le droit contre le promettant par l'effet de la conclusion du contrat et sans que son acceptation soit nécessaire ». Cette conception n'est cependant pas unanimement admise. Par exemple, en droit néerlandais, l'article 6 : 253 du BWB dispose que « Un contrat crée le droit pour un tiers d'obtenir l'exécution de l'une des parties […] si le contrat contient une stipulation à cet effet et si le tiers a accepté cette stipulation ».

1095. Conséquences. La question de savoir par quel mécanisme et à quel moment naît le droit du stipulant n'est pas purement théorique, elle présente d'importantes conséquences pratiques, qui étaient du reste l'objectif de la construction jurisprudentielle du droit direct. Dès lors que le droit naît directement dans le patrimoine du bénéficiaire, cela signifie qu'il n'a, à aucun moment, fait partie du patrimoine du stipulant. Il échappe donc aux créanciers de celui-ci, qui ne pourront pas prétendre se faire payer sur les sommes que le promettant s'est engagé à payer au bénéficiaire (dans le cas de l'assurance sur la vie, le capital assuré leur échappe). Par ailleurs, en cas de décès du stipulant avant l'exécution de la promesse (ce qui est le cas normal dans le mécanisme de l'assurance-vie), les sommes dues ne font pas partie de la succession du stipulant : logiquement, les héritiers (s'ils ne sont pas eux-mêmes bénéficiaires) n'ont aucun droit sur ces sommes, et ils ne peuvent pas en particulier demander à en récupérer une partie en exerçant une action en réduction de la libéralité consentie au bénéficiaire. En ce sens, la Cour d'appel du Luxembourg a déclaré très nettement, à propos d'une assurance sur la vie, que « lorsque l'assuré, par application de l'article 1121 du Code civil, a spécialement attribué à certaines personnes l'émolument du contrat […] le montant de l'assurance est exclu de l'actif héréditaire et doit être directement perçu par les tiers appelés à le recueillir »[2393]. Un autre arrêt a jugé que, puisque l'assurance-vie ne transite pas par le patrimoine du souscripteur, il n'y pas d'obligation pour l'assureur de communiquer le contenu du contrat aux héritiers du souscripteur (qui n'ont aucun droit sur le capital)[2394].

Ces solutions, qui valent de manière générale pour tous les cas de stipulation pour autrui, ont été, dans les trois pays du Code civil, consacrées par le législateur en tout ou en partie en matière d'assurance sur la vie. Cela a été fait en France dans une loi

[2392] « *Durch Vertrag kann eine Leistung an einen Dritten mit der Wirkung bedungen werden, dass der Dritte unmittelbar das Recht erwirbt, die Leistung zu fordern* ».

[2393] Cour d'appel, 13 novembre 1985, *Pas.*, 27, p. 9. L'arrêt réserve cependant le cas où le stipulant n'a pas désigné nommément les bénéficiaires de l'assurance, mais s'est contenté de désigner ses « héritiers ». Dans ce cas, les héritiers ne recueillent pas le capital et leur nom propre, ils le trouvent dans la succession, où il peut être appréhendé par les créanciers du défunt.

[2394] Cour d'appel, 17 août 2002, *Bull. Droit et banque*, 2002, n° 34, p 58.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de 1930, intégrée depuis dans le Code des assurances[2395], et en Belgique par une loi de 1992 (dont les solutions ont été récemment reprises par une loi de 2014)[2396]. Au Luxembourg, l'assurance sur la vie est réglementée par la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance, largement inspirée de la loi belge de 1992. Le droit direct du bénéficiaire de l'assurance est proclamé par l'article 120 de cette loi selon lequel « par le seul fait de sa désignation, le bénéficiaire a droit aux prestations d'assurance » et l'article 123 en tire la conséquence que « *les créanciers du preneur d'assurance n'ont aucun droit sur les prestations d'assurance dues au bénéficiaire* ». Les lois française et belge contiennent cependant diverses dispositions pour éviter que l'assurance sur la vie ne devienne un moyen pour le souscripteur de faire échapper une partie importante de son patrimoine à ses créanciers et à ses héritiers directs. On retrouve cette préoccupation dans l'article 124 de la loi luxembourgeoise (copiée sur le texte belge), qui donne aux créanciers le droit de demander au bénéficiaire de l'assurance le remboursement des primes si celles-ci sont excessives et ont été versées en fraude de leurs droits, au sens de l'article 1167 du Code civil (action paulienne). On ne trouve en revanche rien dans la loi de 1997 au sujet des droits des héritiers, qui, en France[2397] et surtout en Belgique[2398], peuvent, sous certaines conditions, agir pour récupérer une partie du capital ou des primes portant atteinte à leur réserve.

b. *Étendue du droit*

1096. Droit identique à celui d'une partie au contrat. Le bénéficiaire a, en principe, les mêmes droits que ceux qu'il aurait s'il avait été partie au contrat et si le promettant s'était engagé directement envers lui. Comme l'exprime très bien le DCFR « le tiers a les mêmes droits à l'exécution et aux remèdes en cas d'inexécution que si la partie contractante était engagée envers lui par un contrat unilatéral » (art. II-9 : 302). Cela signifie que, si le promettant n'exécute pas volontairement son obligation envers lui, le bénéficiaire peut l'y contraindre dans la mesure où l'exécution en nature est possible. À défaut, il peut demander le paiement de dommages et intérêts, et si le contrat contient une clause pénale, il pourra s'en prévaloir. Cela, cependant, ne fait pas du tiers bénéficiaire une véritable partie au contrat. Il en résulte en particulier, selon une opinion doctrinale bien établie[2399] que relaie un jugement luxembourgeois[2400], que le bénéficiaire, à supposer qu'il y ait intérêt, ne pourrait pas demander la résolution pour inexécution du contrat contenant la stipulation.

[2395] C. ass. fr., art. L. 132-1 et s.

[2396] L. 25 juin 1992, art. 121 à 126 remplacés par L. 4 avril 2014, art. 185 à 190.

[2397] C. ass., art. L. 132-13 al. 2 (les héritiers peuvent demander le rapport ou la réduction des primes, si elles sont excessives, mais jamais du capital).

[2398] L. 4 avril 2014, art. 188 (la prestation d'assurance est désormais soumise à rapport et à réduction, ce qui remet en cause une des conséquences traditionnelles attachées au droit direct).

[2399] Voy. p. ex. FLOUR, AUBERT, SAVAUX, vol. 1 (2014) n° 481 ; WÉRY, n° 876.

[2400] Trib. Luxembourg, 17 février 2015, n° 159-554.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Ainsi, dans l'exemple précédemment cité du contrat de bière assorti d'une obligation pour le débitant de boissons de s'approvisionner en autres boissons auprès d'une société tiers, on n'admettra pas que cette société puisse demander la résolution du contrat de bière si le cafetier s'approvisionne ailleurs : seul le stipulant, qui a fourni la contrepartie (la brasserie dans cet exemple), peut se prévaloir de cette inexécution pour faire tomber le contrat.

1097. **Droit dépendant de celui du stipulant.** Parce qu'il tient son droit du contrat passé entre le stipulant et le promettant, le bénéficiaire peut se voir opposer par le promettant tous les moyens de défense, toutes les exceptions qui peuvent affecter l'obligation qu'il a souscrite envers le stipulant. C'est ainsi que, si le contrat contenant la stipulation est annulé, ou résolu par suite d'une inexécution de la part du stipulant, cela fait tomber le droit du bénéficiaire : le bénéficiaire d'une assurance-vie, par exemple, ne pourra pas obtenir le versement du capital assuré si le souscripteur a fait lors de la conclusion du contrat une fausse déclaration sur sa santé, ou s'il a cessé de payer les primes. C'est également le contrat entre le stipulant et le promettant qui va configurer le droit du bénéficiaire : si ce contrat contient une clause attributive de compétence, ou une clause d'arbitrage, ces clauses (à les supposer valables) seront applicables dans les relations entre le bénéficiaire et le promettant, comme elles le seraient dans les relations entre stipulant et promettant. Consacrées par la jurisprudence en France[2401] et en Belgique[2402], ces solutions se retrouvent dans divers droits nationaux et projets européens[2403]. L'article 5.107 du nouveau Code civil belge exprime cela parfaitement en disant que « [l]a nature et l'étendue du droit du tiers bénéficiaire sont déterminées par le contrat et sont soumises aux modalités et limitations du contrat ». Ces solutions devraient s'appliquer également au Luxembourg.

1098. **Droit assorti d'obligations ?** Le droit que le stipulant et le promettant décident de créer au profit du tiers peut-il être assorti d'obligations à la charge de celui-ci ? Bien que l'article 1121 du Code civil ne prévoie que la création de droits, il n'y a en réalité rien de choquant à ce que le droit stipulé au profit du tiers soit assorti d'obligations à sa charge, dès lors que, de toute façon, le tiers est libre d'accepter ou non la stipulation. S'il ne veut pas être chargé d'obligations, il refusera le droit. En revanche, s'il accepte le droit, il semble logique qu'il ne puisse en

[2401] Cass. fr., 11 juillet 2006, n° 03-11-983.

[2402] Bruxelles, 22 juin 1989, *Pas.*, 1990, II, p. 54 (clause d'arbitrage).

[2403] Voy. p. ex. en droit allemand : BGB, § 334. Dans les projets européens : DCFR, II-9 : 302 (b) ; DCEV, art. 78-5 ; Code Gandolfi, art. 73 (2).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

bénéficier qu'avec les obligations qui en sont la contrepartie. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation française, dans une affaire où la stipulation conférait au tiers le bénéfice d'une donation, qui était elle-même assortie de charges (l'obligation de ne pas vendre le bien donné pendant un certain temps). Pour la Cour, « *la stipulation pour autrui n'exclut pas, dans le cas d'acceptation par le bénéficiaire, qu'il soit tenu de certaines obligations* »[2404]. Cette solution, qui paraît logique, permet d'utiliser la stipulation pour autrui pour faire bénéficier un tiers, non pas seulement d'un droit, mais aussi d'un contrat synallagmatique : s'il accepte la stipulation, le tiers deviendra partie à ce contrat, avec les mêmes droits et les mêmes obligations[2405]. On peut analyser ainsi la clause permettant au bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente de se substituer un tiers qu'il désignera : le tiers, qui acceptera de reprendre la promesse, sera également tenu des obligations qu'elle implique (notamment l'obligation de payer une certaine somme s'il ne lève pas l'option). La jurisprudence française voit également une telle stipulation de contrat pour autrui dans la souscription (par un employeur, par un banquier) d'une assurance de groupe destinée à bénéficier à certains groupes de tiers (les salariés, les emprunteurs) : en adhérant à l'assurance, le tiers membre du groupe devient partie à un contrat d'assurance avec l'assureur[2406]. La doctrine belge se montre en revanche très réticente à l'admission de ce type de stipulation assortie d'obligations, qui lui semble dénaturer l'institution, dans la mesure où les effets de la stipulation sont alors subordonnés à l'acceptation du bénéficiaire[2407].

2) *Effets dans les relations stipulant-bénéficiaire*

a. *Effets nés de la stipulation*

1099. Révocabilité. La stipulation ne crée à proprement parler aucun droit ni aucune obligation entre le stipulant et le bénéficiaire. Le stipulant ne prend, par la stipulation, aucun engagement envers le tiers. Non seulement le tiers ne peut rien lui demander, mais surtout le stipulant a la faculté de révoquer la stipulation à tout moment jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. La règle est posée implicitement par l'article 1121, alinéa 2 du Code civil, selon lequel « celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter » – ce qui veut dire qu'il peut révoquer avant. La solution est reprise par les nouveaux textes français et belges. Le terme de « révocation » doit ici être entendu largement : le stipulant peut, non seulement décharger complètement le promettant de son obligation, il peut aussi convenir avec lui d'une modification du droit du bénéficiaire (par exemple, en diminuant le montant du capital

2404 Cass. fr. (1re civ.), 8 décembre 1987, n° 85-11769.

2405 Sur cette figure, voy. en France D. MARTIN, « La stipulation de contrat pour autrui », *D.*, 1994, p. 145.

2406 Cass. fr., 13 avril 2010, n° 09-13712.

2407 VAN OMMESLAGHE, n° 449 ; WÉRY, n° 880 – comp. en droit français, C. LARROUMET et D. MONDOLINI, *Encyclopédie Dalloz*, V° Stipulation pour autrui, n° 42-43, qui, tout en se montrant favorables à l'opération se demandent s'il s'agit bien encore d'une stipulation pour autrui.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

assuré), ou changer le nom du bénéficiaire. Dans le premier cas, le droit du bénéficiaire tombera dans le patrimoine du stipulant. Cette règle est commune à tous les systèmes juridiques qui connaissent la stipulation pour autrui. Cependant, alors que, dans le système du Code civil, c'est au stipulant qu'il appartient seul de révoquer, dans d'autres systèmes, la révocation peut être soumise à un accord entre le stipulant et le promettant. C'est le système notamment retenu par le DCFR (art. 9:303) et par le code Gandolfi (art. 72.4). Dans les pays du Code civil, il suffit que le promettant ait eu connaissance de la révocation, qui peut intervenir sans formes particulières. La Cour d'appel a eu récemment l'occasion de juger qu'il en allait ainsi même si la stipulation pour autrui s'insérait dans un contrat dont la révocation était soumise à des formes particulières. Il s'agissait en l'espèce d'un contrat de fiducie, avec désignation d'un tiers pour recevoir le patrimoine fiduciaire au décès du fiduciant. Il était prévu dans le contrat que le fiduciant pouvait y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception. Le fiduciant, sans utiliser cette forme pour mettre fin à la fiducie, avait, dans son testament, révoqué la stipulation faire en faveur du tiers bénéficiaire. La Cour d'appel a considéré que cette révocation était efficace, par application de l'article 1121[2408].

Un problème très pratique, notamment dans le cas de l'assurance sur la vie, est de savoir si la révocation peut encore être exercée par les héritiers du stipulant après la mort de celui-ci. Le risque est que ceux-ci, ayant connaissance d'une assurance souscrite par le défunt en faveur d'un tiers, ne privent celui-ci de son droit avant même qu'il n'en ait connaissance. Pour éviter ce risque, la jurisprudence luxembourgeoise a décidé que, lorsque la stipulation est une libéralité au profit du tiers, « le droit de révocation a un caractère personnel qui l'empêche de passer aux héritiers et créanciers du stipulant ; ce droit ne saurait en aucun cas appartenir à l'héritier qui cumule la qualité de continuateur de la personne du stipulant avec celle de promettant de la libéralité stipulée au profit du tiers »[2409]. En droit français, l'article L. 132-9 du Code des assurances prévoit que les héritiers ne peuvent révoquer qu'après avoir mis en demeure le bénéficiaire d'avoir à déclarer s'il accepte, et le nouvel article 1207 du Code civil généralise cette solution à tous les cas de stipulation pour autrui. En revanche, l'article 5.108 du nouveau Code civil belge prévoit que la révocation ne peut émaner que du stipulant.

1100. Irrévocabilité après l'acceptation. Selon les termes mêmes de l'article 1121 du Code civil, le stipulant ne peut plus révoquer (ni modifier) la stipulation après que le bénéficiaire « a déclaré vouloir en profiter ». C'est un principe qui se retrouve dans tous les droits

[2408] Cour d'appel, 30 avril 2024, n^os^ CAL-2020-00936 et CAL-2023-00596.
[2409] Trib. Diekirch, 9 décembre 1936, 14, p. 183.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

nationaux[2410], et dans tous les projets[2411], et qui est repris par les nouveaux textes français et belge, même s'il existe de nombreuses variantes quant à la manière dont doit s'exprimer cette acceptation de la stipulation, quant au moment où elle peut être faite, quant à la personne qui peut la faire, et à qui elle doit être faite. En droit luxembourgeois, comme en droit français et en droit belge, l'acceptation est un acte unilatéral (qui ne réclame ni l'intervention du stipulant ni celle du promettant) et non formel. Il suffit que le bénéficiaire ait clairement fait connaître son intention soit au stipulant, soit au promettant. L'article 1206 nouveau du code français pose en ce sens que « [l]a stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant ». L'acceptation peut être tacite, et résulter notamment du fait que le bénéficiaire réclame l'exécution du contrat au tiers[2412], ou de la signature d'un contrat qui fait état de la stipulation. Ainsi la Cour d'appel a jugé qu'une assurance couvrant la garantie décennale de l'entrepreneur au profit des acquéreurs de l'immeuble, ne pouvait plus être révoquée après la vente, dès lors que l'assurance était mentionnée dans le contrat de vente (l'acquéreur étant supposé l'avoir acceptée en signant la vente)[2413].

b. *Effets nés des relations sous-jacentes à la stipulation*

1101. Cause de la stipulation. La stipulation pour autrui trouve toujours sa cause (subjective) dans les relations qui unissent le stipulant et le bénéficiaire. Il peut s'agir de relations patrimoniales (stipulation faite par une société-mère au profit de sa filiale, stipulation d'assurance faite par un constructeur au profit des acquéreurs potentiels de l'immeuble, etc.), mais aussi, très souvent, de relations familiales ou d'affection (assurance vie au profit d'un proche). Dans ce dernier contexte, la stipulation pour autrui est généralement un moyen de réaliser une libéralité, sans passer par les formes requises pour une donation et en en évitant le coût fiscal. Dans un tel cas, les règles du droit des libéralités vont se superposer avec celle de la stipulation pour autrui. En particulier, la stipulation sera soumise aux règles qui régissent la révocation des donations, en cas d'inexécution des conditions assortissant la donation, d'ingratitude

[2410] Voy. p. ex. : Droit anglais : *Contract (Third parties right) Act* 1999 S 2 (1) (a), (b), (c) ; Droit suisse : CO, art. 112.3 ; Droit néerlandais : BWB, art. 6:253.2.

[2411] Voy. p. ex. : PDEC, art. 6:110 (3) (b) ; Code Gandolfi, art. 72.

[2412] Cour d'appel, 12 janvier 2012, n° 35307.

[2413] Cour d'appel, 5 juin 2002, n° 26331.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

du donataire ou de survenance d'enfants (C. civ., art. 953 et s.). Il en résulte que, si les conditions prévues par ces textes sont remplies, le stipulant pourra révoquer à la stipulation, alors même qu'elle a déjà été acceptée par le bénéficiaire[2414].

3) *Effets dans les relations stipulant-promettant*

1102. Droit pour le stipulant d'exiger l'exécution. Lorsqu'il promet de faire quelque chose au profit du bénéficiaire, le promettant s'engage du même coup envers le stipulant à exécuter cette promesse. S'il n'exécute pas, le stipulant peut certainement lui demander des dommages et intérêts (en réparation du préjudice qu'il subit lui-même du fait de cette inexécution), ou demander la résolution du contrat qui le lie au promettant. Mais peut-il également agir en exécution contre le promettant pour le contraindre à exécuter son obligation envers le bénéficiaire, bien qu'il n'en soit pas le créancier ? Il est remarquable qu'en droit anglais, où la possibilité de créer un droit au profit d'un tiers n'a été admise que récemment, c'est par le biais de cette action en exécution contre le stipulant que la jurisprudence avait réussi à donner une certaine efficacité à la stipulation pour autrui[2415]. Dans le Code des obligations suisse, cette possibilité pour le stipulant d'exiger l'exécution du tiers est toujours présentée comme le premier effet de la stipulation pour autrui, l'action personnelle du bénéficiaire contre le tiers n'apparaissant qu'en second lieu[2416]. Dans les pays du Code civil, où le droit direct du bénéficiaire est admis depuis longtemps, cette action en exécution du stipulant présente un intérêt moindre, et ce n'est que plus récemment que la jurisprudence a eu l'occasion de la reconnaître[2417]. On la trouve consacrée dans le nouvel article 1209 du Code civil français : « Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire ». La jurisprudence luxembourgeoise, qui n'a jamais été confrontée à la question, devrait admettre la même solution.

2414 Dans ce sens : WÉRY, n° 882.

2415 CARTWRIGHT, pp. 247 et s.

2416 CO, art. 112 al. 2.

2417 Voy. en droit français : Cass. fr. (1re civ.), 7 juin 1989, n° 87-14648 « le stipulant d'une stipulation pour autrui a qualité pour exiger l'application du contrat dont il est le souscripteur ». Pour la Belgique, voy. VAN OMMESLAGHE, n° 446.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension volontaire des effets internes du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 114...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Chapitre II
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

1103. Extension des droits et/ou des obligations. Lorsque c'est la loi qui décide de faire produire à un contrat des effets à l'égard des tiers, cela peut jouer aussi bien en défaveur qu'en faveur des tiers. L'extension peut ainsi concerner les droits nés d'un contrat, à travers le mécanisme des actions directes (**§ 1**), ou ses obligations, dans certains cas de solidarité légale (**§ 2**), ou encore, de manière globale, l'ensemble des effets du contrat, dans le contexte des contrats collectifs (**§ 3**).

SECTION 1. EXTENSION DES DROITS : LES ACTIONS DIRECTES

1104. Principe. Le mécanisme de l'action directe, qui n'est pas visé de manière générale par le Code civil de 1804, consiste à donner à un tiers, créancier de l'une des parties a un contrat, le droit de se prévaloir de ce contrat en lui accordant une créance contre le débiteur contractuel de son propre débiteur[2418]. L'exemple le plus parlant est celui de l'action directe conférée à la victime d'un accident contre l'assureur du responsable : au lieu de demander le paiement des dommages et intérêts au responsable, la victime peut, selon l'article 89 de la loi du 27 juillet 1997, en demander directement le paiement à l'assureur de celui-ci. Au lieu que celui-ci paye l'indemnité d'assurance à son cocontractant, il la paiera à la victime. Le mécanisme présente une certaine ressemblance avec l'action oblique de l'article 1166 du Code civil[2419], qui permet a tout créancier d'agir, au nom de son débiteur, contre les débiteurs de celui-ci. Mais il s'en distingue fondamentalement – ce que traduit le terme « direct » en opposition à celui d'oblique. Le créancier qui exerce l'action oblique, en effet, le fait au nom de son débiteur, et le résultat de son action sera de faire entrer ou rentrer le produit de l'action dans le patrimoine du débiteur, où il fera partie du gage commun de ses créanciers. L'action directe, très différemment, repose sur un droit personnel qui est accordé par la loi à un créancier contre le débiteur de son débiteur : dans l'exemple précité, la victime de l'accident devient directement créancière de l'indemnité d'assurance, c'est à elle que l'assureur est tenu de payer cette indemnité, pourtant stipulée dans le contrat qu'il a passé avec le responsable, et auquel la victime est étrangère. C'est en cela que l'action directe est, à la différence de l'action oblique, une véritable dérogation au principe

[2418] Voy. POELMANS, pp. 219 et s.
[2419] Voy. *supra*, n°s 723 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de l'effet relatif. Le contrat passé entre l'assureur et l'assuré fait naître directement, par l'effet de la loi, une créance au profit de toute victime éventuelle de l'assuré. Tout se passe comme si, dans le contrat d'assurance de responsabilité, il y avait une stipulation pour autrui légale en faveur de la victime. Il en résulte que les actions directes procurent une garantie de paiement très forte à leurs titulaires : dans la mesure où l'indemnité d'assurance est directement due à la victime, celle-ci, en cas d'insolvabilité du responsable, ne risque pas d'entrer en concours sur cette indemnité avec les autres créanciers de ce dernier. C'est pourquoi, à la différence de l'action oblique et de l'action paulienne, qui sont des moyens de protection du droit de gage général appartenant à tout créancier, les actions directes ne sont accordées qu'à certains créanciers que la loi veut spécialement protéger. Cela apparaît clairement à la lecture des nouveaux textes qui, en France et en Belgique, ont intégré le mécanisme de l'action directe dans le Code civil. Selon l'article 5.108 du Code civil belge – venant, de manière significative, à la suite du texte sur la stipulation pour autrui « la loi peut accorder à un créancier le droit de demander en son nom et pour son compte l'exécution d'une prestation du débiteur de son débiteur à concurrence de ce dont celui-ci est redevable à l'égard de son créancier ». En droit français, l'action directe est désormais prévue à l'article 1341-3 du Code civil, selon lequel « dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur ».

1105. Différents types d'actions directes. La garantie procurée est plus ou moins forte selon que la créance contractuelle du débiteur contre son propre débiteur est ou non immobilisée au profit du titulaire de l'action. Dans le cas de l'action directe de la victime contre l'assurance, la créance du responsable contre l'assureur est bloquée au profit de la victime ; l'assureur ne peut verser l'indemnité qu'entre les mains de la victime, et il ne pourra se libérer entre les mains de son assuré que si celui-ci a indemnisé lui-même la victime (ce qui est exceptionnel en pratique). Le créancier, qui est seul à pouvoir se payer sur la créance contre l'assureur, bénéficie à cet égard d'une situation d'exclusivité sur ce bien. On parle alors d'*action directe parfaite*. Dans d'autres cas, où l'action directe est dite *imparfaite*, le blocage de la créance du débiteur contre son sous-débiteur ne se produira qu'au moment où le créancier exercera l'action ; jusque-là, la créance reste dans le patrimoine du débiteur,

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

qui peut se la faire payer, et où elle peut être saisie par ses différents créanciers. C'est le cas, nous le verrons, de l'action directe du bailleur contre le sous-locataire.

Une autre distinction peut être faite entre les actions directes en paiement, qui (comme l'action directe de la victime) permettent au créancier d'appréhender directement une créance déjà liquide de son débiteur contre un tiers, et les actions directes en responsabilité, qui permettent à leur titulaire de faire liquider directement à leur profit une créance d'indemnité due par un débiteur de leur débiteur. Tel est le cas notamment de l'action reconnue au sous-acquéreur d'un bien contre le fabricant ou le vendeur initial de ce bien pour la réparation des préjudices que ce bien leur a causé. On peut également citer l'article 19 de la loi du 17 décembre 2010 relative aux fonds communs de placement qui permet aux porteurs de parts de mettre en jeu directement la responsabilité de la banque dépositaire en cas d'inaction de la société de gestion. Ces actions directes en responsabilité sont assez différentes des actions directes en paiement, car elles reposent sur l'idée que le débiteur est, au départ, directement responsable du préjudice subi par le créancier bénéficiaire de l'action. Elles ne sont pas liées à l'existence d'une créance du débiteur intermédiaire contre le débiteur final.

1106. Caractère légal des actions directes ? On considère traditionnellement que les actions directes n'existent que dans les cas expressément prévus par la loi[2420], et cette conception légaliste semble bien avoir été consacrée par les nouveaux textes en France et en Belgique. En France, l'article 1341-3 du code prévoit l'action directe « dans les cas déterminés par la loi », tandis que, selon, l'article 5.108 du nouveau code belge, « la loi peut accorder à un créancier » le bénéfice de l'action directe. Ces textes viennent condamner une opinion doctrinale qui prônait, principalement en France[2421], mais aussi en Belgique dans une période récente[2422], la reconnaissance d'actions directes en dehors des cas prévus par la loi, sans qu'il existe de consensus quant aux critères qui justifieraient une telle reconnaissance. Néanmoins, on ne peut que constater que, en dehors des cas légaux d'actions directes (**§ 1**), il existe certaines extensions jurisprudentielles, à vrai dire très limitées (**§ 2**)

[2420] Voy. spéc. M. COZIAN, *L'action directe*, Paris, LGDJ, 1969.

[2421] Voy. C. JAMIN, *Les actions directes*, préf. J. GHESTIN, Paris, LGDJ, 1991, qui fonde ces actions sur l'équité ; B. TEYSSIÉ, *Les groupes de contrats*, Paris, LGDJ, 1975, qui y voit une conséquence du lien entre les différents contrats d'un groupe.

[2422] VAN OMMESLAGHE, n°s 705 et s. et les auteurs cités.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§ 1. Les cas légaux d'actions directes

1107. Sous-contrats. En dehors des cas déjà cités (action directe en paiement de la victime contre l'assureur de responsabilité, action directe en responsabilité contre la banque dépositaire de titres d'un fonds commun de placement), la plupart des actions directes reconnues par la loi – et notamment celles qui figurent dans le Code civil – s'inscrivent dans un contexte de sous-contrat. Il s'agit d'hypothèses où une personne, tenue d'obligations en vertu d'un contrat (un entrepreneur ou un mandataire), passe un contrat par lequel elle charge un tiers (sous-traitant ou sous-mandataire) d'accomplir tout ou partie des prestations dont elle a été chargée ; ou bien, un contractant, bénéficiaire de droits contractuels (un locataire, par exemple) passe un contrat par lequel il permet à un tiers (sous-locataire) d'exercer ses droits tout en ayant les mêmes obligations (paiement du loyer, entretien de l'immeuble). Dans cette configuration contractuelle, on peut facilement imaginer que le tiers (sous-traitant, sous-mandataire, sous-locataire) exécute mal ses obligations contractuelles et on se demande si la partie au contrat originaire peut agir contractuellement contre lui, soit pour obtenir l'exécution (par exemple, le bailleur peut-il demander directement le paiement des loyers au sous-locataire ?) soit pour faire sanctionner l'inexécution (le mandant ou le maître de l'ouvrage mécontent du travail effectué par le sous-traitant ou le sous-mandataire peut-il agir en responsabilité contractuelle contre le sous-mandataire ou le sous-traitant ?). Mais le problème peut également se poser en sens inverse : le sous-traitant, par exemple, lorsqu'il n'est pas payé par l'entrepreneur principal, peut-il agir en paiement contre le maître de l'ouvrage qui a bénéficié des travaux effectués ? Il semble à première vue que la réponse à ces différentes questions doive être négative, dans la mesure où, en raison de l'effet relatif, aucune relation directe ne se noue entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant, entre le mandant et le sous-mandataire, entre le bailleur et le sous-locataire. Le législateur, cependant, dans diverses hypothèses, reconnaît l'existence d'une action contractuelle directe entre les parties extrêmes à ces relations.

1108. Action directe du bailleur contre le sous-locataire. La première hypothèse de reconnaissance d'une action directe dans un contexte de sous-contrat est celle de la sous-location : l'article 1753 du Code civil prévoit que « le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie ». Dès la fin du XIXe siècle, la jurisprudence luxembourgeoise a reconnu qu'il s'agissait là d'une action directe, distincte

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de l'action oblique de l'article 1166 du Code civil : le bailleur impayé qui demande le paiement au sous-locataire n'exerce pas les droits de son débiteur, le locataire principal ; il exerce un droit qui lui est propre[2423]. En conséquence, il n'entre pas en concours avec les éventuels autres créanciers du locataire principal. Cependant, un jugement beaucoup plus récent semble nier, au nom de l'effet relatif, l'existence d'une telle action directe du bailleur contre le sous-locataire. Selon cette décision, apparemment isolée, « le bailleur principal ne peut donc directement contraindre le sous-locataire à l'exécution du bail. Il peut tout au plus agir contre le locataire principal et le contraindre à exercer ses recours contre l'occupant défaillant. Il pourrait encore l'atteindre par la voie oblique (C. civ., art. 1166) ou en vertu du principe du droit commun (art. 1382 notamment, s'il y a faute établie) »[2424]. En toute hypothèse, l'action ne peut être exercée que tant que le sous-locataire n'a pas déjà payé le loyer au locataire principal (qui est son bailleur) : c'est une action directe imparfaite. L'article 1753 du Code civil réserve seulement le cas où les paiements ont été faits par anticipation : le sous-locataire qui aurait payé d'avance le locataire principal risque donc d'être amené à payer le bailleur une seconde fois.

1109. Action directe du mandant contre le mandataire substitué. La seconde action directe reconnue par le Code civil dans le cadre d'un sous-contrat est celle que l'article 1994, alinéa 2, du Code civil ouvre au mandant contre « la personne que le mandataire s'est substituée ». Ici, l'action ouverte au mandant est une action en responsabilité : le mandataire substitué répond de sa mauvaise gestion directement envers le mandant[2425]. La Cour d'appel a en particulier fait application de ce texte pour reconnaître au client d'une banque ayant effectué un virement sur le compte d'un tiers contre la banque de ce tiers qui n'avait pas vérifié la régularité de l'ordre de virement : le banquier du bénéficiaire a été considéré comme un mandataire que la banque de l'auteur du virement s'était substitué pour l'exécution de l'ordre[2426]. Cependant, un arrêt plus récent a condamné cette utilisation de l'article 1994 dans cette hypothèse, au motif que la responsabilité du banquier ne peut être engagée que sur le fondement de la loi du 10 novembre 2009 sur les services de paiement (LSP)[2427].

Alors que le texte n'ouvre que l'action en responsabilité du mandant contre le mandataire substitué, la jurisprudence française a, depuis longtemps, bilatéralisé l'action directe, en permettant, en sens inverse, au substitué d'agir contre le mandant en remboursement de ses frais et en paiement de sa rémunération[2428], et ceci même si la substitution de mandataire n'avait pas été autorisée par le mandant[2429]. Après avoir jugé le contraire, la Cour de cassation française juge désormais que l'action ne peut plus être exercée si le mandataire intermédiaire a déjà reçu sa rémunération du mandant[2430] : la solution s'impose si on ne veut pas que le mandant soit exposé à payer deux fois alors qu'il ne connaît pas nécessairement l'existence du

2423 J.P. Luxembourg, 25 novembre 1898, *Pas.*, 5, p. 64 ; Trib. Luxembourg, 8 janvier 1908, *Pas.*, 7, p. 402.

2424 Trib. Luxembourg, 18 décembre 1986, n° JUDOC 98608224.

2425 La doctrine belge soutient qu'il ne s'agit pas là d'une véritable action directe, du moins en cas d'autorisation de la substitution : il se formerait un contrat direct entre le mandant et le mandataire substitué (Cass. be., 16 décembre 1977, *R.C.J.B.*, 1981, p. 465, note P.-A. FORIERS).

2426 Cour d'appel, 13 mars 2013, *Pas.*, 36, p. 270 ; Cour d'appel, 13 mai 2015, *Pas.*, 37, p. 686.

2427 Cour d'appel, 7 mars 2023, n° CAL-2022-00563.

2428 Cass. fr. (1re civ.), 27 décembre 1960, *GAJC*, 11e éd., n° 268.

2429 Cass. fr. (comm.), 9 novembre 1987, n° 86-11989.

2430 Cass. fr. (comm.), 3 décembre 2002, n° 00-18988.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

sous-mandataire. Si la jurisprudence luxembourgeoise, qui n'a semble-t-il jamais eu l'occasion de se prononcer sur la question, voulait de même reconnaître une action directe au mandataire substitué, il serait sans doute préférable qu'elle la subordonne à l'acceptation de ce mandataire par le mandant – par une transposition de la solution admise en matière de sous-traitance.

1110. **Action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage.** L'hypothèse est qu'un entrepreneur a confié la réalisation de tout ou partie des travaux qui lui ont été confiés à un sous-traitant. Celui-ci peut-il se faire payer directement par le maître de l'ouvrage (celui pour qui les travaux ont été faits) la part correspondant aux travaux qu'il a effectués ? L'article 1798 du Code civil accordait déjà une telle action directe aux « maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise » en précisant que cette action n'était ouverte que « jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée ». On pouvait considérer que cette action directe imparfaite bénéficiait aussi aux sous-traitants qui avaient agi à titre indépendant sur le chantier. Une loi du 23 juillet 1991 relative aux activités de sous-traitance a considérablement accru la protection des sous-traitants : à la condition que le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que ses conditions de paiement aient été agréées par lui, ce dernier est tenu, selon l'article 7 de la loi de payer directement le sous-traitant pour la part du marché ou du contrat dont il assure l'exécution. Le texte précise que ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de faillite ou de gestion contrôlée, ce qui montre bien que l'action directe permet à son titulaire, à la différence d'une action oblique, d'échapper au concours avec les autres créanciers du débiteur intermédiaire. L'action directe reconnue ici est une action directe parfaite, dans la mesure où le maître de l'ouvrage ne peut pas se libérer entre les mains de l'entrepreneur : il ne peut payer que le sous-traitant. De ce point de vue, la loi luxembourgeoise se différencie nettement de la loi française correspondante de 1975 qui n'accorde un tel droit au paiement direct que dans le cadre des marchés publics. La Cour d'appel a bien souligné la différence dans un arrêt de 2011 : « La loi accorde au sous-traitant qui a été accepté par le maître de l'ouvrage et dont les conditions de paiement ont été agréées par ce dernier, un paiement direct. Dès son acceptation et dès l'agrément de ses conditions de paiement, le sous-traitant est titulaire d'un droit intangible au paiement par le maître de l'ouvrage. L'obligation du maître de l'ouvrage à l'égard du sous-traitant n'est pas limitée par la créance de l'entrepreneur principal parce que constitutive d'une obligation nouvelle et autonome pour le maître de l'ouvrage, sans référence au contrat de base. Seules les exceptions nées de l'exécution du contrat de sous-traitance, à l'exclusion de celles nées du contrat d'entreprise principal, peuvent être opposées au sous-traitant par le maître de l'ouvrage »[2431].

La question s'est posée de savoir si le maître de l'ouvrage a, à l'inverse, une action directe en responsabilité contre le sous-traitant qui aurait mal exécuté les travaux. Sur ce point, la jurisprudence, au Luxembourg comme en France et en Belgique, répond clairement par la négative, marquant son souci de ne pas étendre le domaine des actions directes en responsabilité dans les sous-contrats en dehors des cas prévus par la loi.

[2431] Cour d'appel (réf.), 14 décembre 2011, *Pas.*, 35, p. 436.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

§ 2. Les extensions jurisprudentielles des actions directes

1111. Groupes et chaînes de contrats. La question de la reconnaissance d'actions directes en dehors des cas prévus par la loi est liée à la problématique générale des groupes de contrats, ou, si on préfère, des ensembles contractuels ou des contrats liés, mise en lumière, notamment dans la doctrine française, à partir des années 1970. Nous avons déjà rencontré cette problématique à propos des incidences que peut avoir la nullité ou la résolution d'un contrat sur les autres contrats qui lui sont liés. C'est dans ce contexte des contrats interdépendants que la notion de caducité trouve principalement à s'appliquer[2432]. Cependant, même si ces solutions sont très représentatives de la reconnaissance par le droit de la notion de groupe ou d'ensemble contractuel, et d'un certain élargissement de la sphère contractuelle, elles ne constituent pas, à proprement parler, des dérogations au principe de l'effet relatif. Il ne s'agit pas en effet, dans tous ces cas, de faire produire à un contrat des effets à l'égard de tiers, mais de tenir compte, dans l'élaboration du régime d'un contrat, de sa raison d'être en relation avec d'autres rapports contractuels. Mais la notion de groupe de contrats a pu être utilisée sur un tout autre terrain, qui est directement lié à la problématique de l'effet relatif. Certains auteurs, en France, ont en effet prétendu étendre aux parties à un contrat les droits et obligations nés d'autres contrats qui lui sont liés, comme si les parties à chaque contrat du groupe étaient, dans une certaine mesure, parties à l'ensemble. Ce type d'élargissement de la sphère contractuelle, qui aboutit à reconnaître des actions directes contractuelles entre les parties des différents contrats du groupe peut s'observer à travers les cas légaux d'actions directes précédemment exposés, et on a pu lui rattacher la reconnaissance jurisprudentielle, au Luxembourg comme dans les deux autres pays, d'actions contractuelles directes dans certaines chaînes de contrats transférant la propriété une chose. Cependant, si cette jurisprudence s'est maintenue dans les trois pays du Code civil (**A**), la jurisprudence s'est finalement, après quelques hésitations, refusée à l'étendre à d'autres groupes de contrats (**B**).

[2432] Voy. *supra*, n° 561.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

A) *L'action directe dans les chaînes de contrats translatives de propriété*

1112. Principe de l'action directe. L'hypothèse-type est celle où un bien a été vendu et revendu successivement à plusieurs acquéreurs (par exemple, par son fabricant au grossiste, par le grossiste au détaillant, par le détaillant à l'utilisateur final). Si la chose est défectueuse, l'acquéreur final dispose d'une action contractuelle particulièrement avantageuse, l'action en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil[2433]. Cependant, en principe, il ne devrait pouvoir exercer cette action que contre son vendeur, avec lequel il a passé le contrat de vente. S'il veut agir contre l'un des précédents vendeurs, ou contre le fabricant (par exemple, parce que son vendeur est insolvable), il ne devrait pourvoir le faire que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, puisqu'il n'a passé personnellement aucun contrat avec ces précédents vendeurs. Pour obtenir satisfaction, il devrait donc prouver que le vice est dû à une faute de l'une de ces personnes[2434]. Telle est la solution admise par la plupart des droits nationaux en Europe, et, en droit européen, la Cour de justice a jugé de même qu'un litige entre le sous-acquéreur et le vendeur initial n'était pas un litige contractuel au regard de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (devenue depuis règlement de Bruxelles I puis I *bis*)[2435]. En droit français, en revanche, la jurisprudence admet depuis le XIXe siècle que le sous-acquéreur dispose contre n'importe lequel des vendeurs précédents (avec lesquels, pourtant, il n'a aucun lien contractuel) d'une action contractuelle directe en garantie, ce qui le dispense de prouver la faute de ces personnes pour obtenir réparation. La jurisprudence belge s'est ralliée depuis longtemps

[2433] Par suite de la transposition d'une directive européenne de 1999, cette garantie du Code civil est aujourd'hui doublée, si l'acheteur est un consommateur, d'une garantie spécifique réglementée aux articles L. 212-1 à L. 212-9 du Code de la consommation. Cette nouvelle garantie ne modifie en rien la problématique ici examinée.

[2434] Sous réserve aujourd'hui des règles spéciales qui s'appliquent en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Voy. *infra*, n° 1114.

[2435] C.J.C.E., 17 juin 1992, *Jakob Handte*, C-26/91. Le règlement de Bruxelles pose une règle particulière de compétence pour les litiges survenant « en matière contractuelle » : le demandeur peut assigner le défendeur, non seulement devant le tribunal de son domicile, mais aussi devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou devait être exécutée. La Cour a posé que la notion de « matière contractuelle » au sens de ce texte devait être interprétée de manière autonome en droit européen.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

à cette solution[2436], et la jurisprudence luxembourgeoise a fait de même[2437]. Cette action contractuelle suscite d'importants débats quant à son fondement, ce qui commande dans une certaine mesure son domaine et son régime.

1113. Fondement de l'action directe. L'action directe dans les chaînes de contrats de vente a été reconnue en jurisprudence, du moins en France, bien avant que ne se développe en doctrine la théorie des groupes de contrats ou des ensembles contractuels, à laquelle on l'a rattachée ensuite d'une manière assez artificielle. La doctrine a essayé depuis longtemps de lui trouver un fondement qui permette de la concilier avec le principe de l'effet relatif du contrat, à laquelle elle apparaît de prime abord comme profondément dérogatoire. Certains auteurs y ont vu la traduction d'une cession de créance tacite (en revendant le bien, chaque revendeur céderait tacitement à son acheteur la créance de garantie qu'il avait contre son propre vendeur), d'autres le résultat d'une stipulation pour autrui tacite (en achetant, l'acquéreur du bien stipulerait tacitement de son vendeur que celui-ci assurerait la garantie, non seulement à son profit, mais encore au bénéfice de tous les acquéreurs successifs), d'autres enfin une application de l'idée d'accessoire (le droit à garantie est l'accessoire du bien vendu, il passe donc automatiquement sur la tête des différents acquéreurs, par application de l'article 1615 du Code civil qui oblige le vendeur à délivrer la chose avec tous ses accessoires). C'est à cette dernière analyse que s'est finalement ralliée la Cour de cassation française, dans une série d'arrêts remarqués de 1986[2438]. C'est le même fondement qui est retenu en Belgique[2439], et qui est du reste consacré par l'article 5.105 du nouveau Code civil, selon lequel « sauf clause contraire, les droits cessibles qui sont étroitement liés à un bien en manière telle que l'intérêt de ces droits dépend de la propriété du bien, sont transmis à celui qui acquiert ce bien à titre particulier ». Au Luxembourg, la Cour d'appel a de même affirmé clairement, en 1996 que « les droits

[2436] Voy. déjà Cass. be., 9 mai 1901, *Pas.*, I, 1901, I, p. 229. Dans la période récente, voy. Cass. be., 15 septembre 2011, RG n° C.10.0456.N ; Cass. be., 20 avril 2012, n° C.10.0103.F.

[2437] Voy. déjà Trib. Diekirch, 24 mars 1901, *Pas.*, 6., p. 503. Parmi les décisions récentes voy. p. ex. : Cour d'appel, 12 juin 1996, *Pas.*, 30, p. 129 ; Cour d'appel, 27 octobre 1999, *Pas.*, 31, p. 185 ; Cour d'appel, 27 octobre 2004, n°s 26944, 27229 et 27316 ; Trib. Luxembourg, 22 novembre 2023, n^{os} TAL-2019-01219 et TAL-2019-09367.

Trib. Luxembourg, 31 janvier 2024, n^{os} TAL-2021-02088 et TAL-2021-09278.

[2438] Cass. (ass. plén.), 7 février 1986, n°s 83-14631 et 84-15189.

[2439] Cass. be., 5 décembre 1980, *Pas. be.*, I, p. 398.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

et actions originels du cocontractant du fabricant se transmettent, en tant qu'accessoires, avec la chose à laquelle ils sont attachés et conservent leur nature contractuelle »[2440]. Plus nettement encore, un arrêt de 1999 pose que « les droits et actions tenant à la garantie des vices cachés inhérente au contrat de vente passent lors de ventes ultérieures de plein droit en tant qu'accessoires des biens vendus aux nouveaux acquéreurs, permettant ainsi à ces derniers en tant qu'ayants-cause particuliers de leurs auteurs, d'agir par la voie contractuelle »[2441]. Cette explication, si elle n'est pas à l'abri des critiques, inscrit la jurisprudence dans le cadre de la problématique générale de la transmission des créances contractuelles aux ayants-cause à titre particulier, et elle permet de concilier techniquement l'action directe avec le principe de l'effet relatif.

1114. Domaine de l'action directe. Parce qu'elle repose sur l'idée de transmission de l'action comme accessoire de la chose, cette action directe sera reconnue chaque fois qu'une série de contrats successifs transmet la propriété d'une chose. Dans ses arrêts de 1986, la Cour de cassation française a précisé que ce mécanisme devait jouer, non seulement dans le cas de ventes successives, mais encore dans les chaînes hétérogènes formées de la succession d'un contrat d'entreprise (entrepreneur ayant fabriqué la chose pour son client) et d'un contrat de vente (revente de la chose par le client à un acheteur). Au Luxembourg, la Cour d'appel, statuant à propos de ventes successives, avait posé en 1996 que « la responsabilité contractuelle doit être appliquée en présence d'un groupe de contrats translatifs de propriété et ce, *notamment*, dans le cas d'une chaîne de contrats homogène, c'est-à-dire constituée par des contrats qui sont de même nature, *généralement* des ventes » – ce qui paraissait ouvrir l'application de la solution aux chaînes hétérogènes. La solution a été explicitement consacrée par un jugement du tribunal de Luxembourg de 2011 qui reprend textuellement la formule française de 1986[2442]. En revanche, l'idée d'accessoire ne peut justifier la reconnaissance d'une action directe dans des groupes de contrats qui ne sont pas translatifs de propriété – notamment dans le cas de la sous-traitance[2443].

[2440] Cour d'appel, 12 juin 1996, préc.

[2441] Cour d'appel, 27 octobre 1999, préc. Cour d'appel, 17 octobre 2024, n° CAL-2018-01101, *JN Obligations*, 2024, n° 3, pp. 194-198, note H. WESTENDORF.

[2442] Trib. Luxembourg, 6 mai 2011, n° 130679, BIJ 2011, p. 67 ; Voy. aussi Trib. Luxembourg, 22 novembre 2023, n^{os} TAL-2019-01219 et TAL-2019-09367.

[2443] Voy. *infra*, n°s 1117 et s.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

L'action directe a été d'abord reconnue, on l'a dit, à propos de l'action spécifique en garantie des vices cachés de la chose vendue. Mais le fondement retenu peut justifier de même la transmission de toutes les actions qui peuvent être considérées comme des accessoires de la chose. Dans ses arrêts de 1986, la Cour de cassation française a ainsi admis que le sous-acquéreur pouvait exercer contre le vendeur originaire une action en responsabilité sanctionnant la non-conformité de la chose aux spécifications du contrat. Des arrêts postérieurs ont admis le transfert de l'action en résolution du contrat pour inexécution[2444], et même d'une action en responsabilité contre un tiers qui avait mal réparé la chose avant sa revente[2445]. La Cour d'appel du Luxembourg n'a pas eu l'occasion de connaître de ces hypothèses, mais l'arrêt de 1996 parle de la transmission des « *droits et actions originels du cocontractant* » ce qui semble avoir un contenu assez large.

Le domaine de l'action directe dans les chaînes de contrats se trouve aujourd'hui considérablement restreint en raison de la transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux[2446]. Cette directive, transposée au Luxembourg par la loi du 21 avril 1989, accorde en effet à la victime d'un défaut de la chose qui a causé un dommage à sa personne ou à ses biens (que cette victime soit ou non un acquéreur de la chose, et qu'elle l'ait acquise d'un revendeur ou directement du fabricant) une action en responsabilité spécifique contre le fabricant de la chose, qui lui permet d'obtenir réparation sans avoir à prouver la faute de ce dernier. L'action directe conserve en revanche son intérêt lorsque le défaut de la chose a simplement causé à l'acquéreur une perte de jouissance ou un dommage purement économique (perte de clientèle, par exemple). La directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation[2447], qui réglemente cette situation sous l'angle de la garantie de conformité, et qui a été transposée dans le Code de la consommation luxembourgeois aux articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation, ne règle en effet que les relations de l'acquéreur et de son vendeur, laissant à chaque droit national le soin de déterminer quelles actions l'acquéreur peut exercer contre les précédents vendeurs ou le fabricant. Par exemple, si vous achetez un ordinateur et qu'il ne fonctionne pas, vous pouvez agir contre votre vendeur (sur le fondement de la garantie des vices cachés du Code civil ou sur le fondement de la garantie des biens de consommation) ; mais vous pouvez aussi agir en garantie contre le fabricant ou l'importateur par la voie de l'action directe.

1115. Régime de l'action directe. Parce qu'elle repose sur l'idée d'une transmission aux propriétaires successifs de la chose de l'action qui appartenait au premier acquéreur contre son vendeur, le

[2444] Cass. fr. (1re civ.), 27 janvier 1993, n° 91-11302.
[2445] Cass. fr., (1re civ.), 26 mai 1999, n° 97-14.879.
[2446] *J.O.C.E.*, L. 210, 7 août 1995.
[2447] *J.O.C.E.*, L. 171, 7 juillet 1999.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

régime de l'action directe est calqué – comme dans tous les cas de transmission – sur celui de l'action originaire. Le sous-acquéreur n'exerce pas une action qui lui est personnelle, il exerce l'action même du premier acquéreur. Il en résulte qu'il n'a pas plus de droits que ce dernier, et que le vendeur originaire peut lui opposer toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son propre contractant. Par exemple, si le premier acquéreur avait acheté la chose en connaissant ses défauts, il n'aurait pas pu bénéficier de la garantie des vices cachés, et le sous-acquéreur ne devrait logiquement pas en bénéficier non plus, alors que lui-même a acheté sans connaître les vices. Surtout, l'idée de transmission paraît avoir comme conséquence inéluctable que le vendeur originaire peut opposer au sous-acquéreur toutes les clauses du contrat contenues dans le contrat originaire, alors même que le dernier contractant, tiers au contrat initial, n'a pas pu connaître ces clauses. On retrouve ici les mêmes solutions que celles qui ont été exposées à propos de la cession de créance : le vendeur originaire peut opposer au sous-acquéreur une clause limitative de responsabilité, une clause attributive de compétence, une clause d'arbitrage, etc. contenues dans le premier contrat.

Cette opposabilité des exceptions et des clauses est de nature à limiter singulièrement les droits du sous-acquéreur exerçant l'action directe. Ce ne serait pas grave si ce dernier, barré ou limité dans son action contractuelle, pouvait exercer contre le premier vendeur une action en responsabilité délictuelle, à condition de prouver la faute du premier contractant ayant mis la chose en circulation. Mais on sait que ce n'est pas possible en droit luxembourgeois où, pas plus qu'en droit français, celui qui dispose d'une action contractuelle ne peut pas, en raison de la règle du non-cumul, agir contre son cocontractant par la voie délictuelle. C'est ce que rappelle fermement l'arrêt de la Cour d'appel de 1999 pour qui « le mécanisme de la transmission des actions en garanties contractuelles a pour corollaire nécessaire l'application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, et partant l'interdiction pour le sous-acquéreur d'agir contre le vendeur initial ou contre un autre vendeur antérieur sur base de la responsabilité délictuelle »[2448]. L'action directe peut donc finalement avoir pour le sous-acquéreur plus d'inconvénients que d'avantages, ce qui est une des raisons justifiant les critiques qui peuvent lui être adressées.

[2448] Cour d'appel (civ.), 27 octobre 1999, *Pas.*, 31, p. 185.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

1116. **Approche critique.** Très rarement admise à l'étranger en dehors des pays du Code civil, rejetée par la CJUE, l'action directe dans les chaînes de contrats n'échappe pas à la critique, et on peut sérieusement s'interroger sur l'opportunité de son maintien en droit luxembourgeois. Conçue à l'origine pour protéger le sous-acquéreur en lui permettant d'agir plus facilement contre le vendeur originaire ou le fabricant d'une chose défectueuse, et pour faire peser la responsabilité sur celui qui, dans la chaîne, est le premier à avoir mis la chose défectueuse en circulation, l'action directe s'est, au fil du temps, retournée contre le sous-acquéreur dont elle vient limiter les droits. La raison principale tient dans le fondement retenu – la transmission des droits et actions appartenant au premier acquéreur – qui permet au vendeur initial d'opposer au sous-acquéreur toutes les causes de limitation de l'action contractuelle résultant du contrat initial. Combinée avec la règle du non-cumul, cette solution aboutit parfois à donner au sous-acquéreur moins de droits que n'en aurait un tiers. Cela est d'autant plus vrai que, désormais, en droit luxembourgeois, on a transposé la jurisprudence française considérant que les tiers au contrat peuvent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer le manquement contractuel qui est à l'origine de leur dommage[2449]. Les sous-acquéreurs sont en définitive les seuls tiers à ne pas bénéficier de cette jurisprudence (par ailleurs fâcheuse !). Le récent arrêt de la Cour de cassation française qui soumet l'action délictuelle du tiers aux limitations de l'action contractuelle réduit cependant de manière opportune le décalage entre les deux situations[2450]. L'action directe est d'autant plus contestable que l'idée d'accessoire qui la fonde n'est pas elle-même à l'abri des critiques. En particulier, on ne comprend pas bien comment, alors que les droits et actions attachées à la chose sont censées transmises au sous-acquéreur, l'acquéreur précédent conserve le droit, s'il y a intérêt (par exemple, si, à cause du vice, il a vendu la chose moins cher) d'agir lui-même en garantie contre le vendeur. À tout prendre, si on voulait maintenir l'action directe, il vaudrait mieux la fonder sur une autre idée. On pourrait admettre – par une sorte de transposition de l'idée de stipulation pour autrui tacite admise autrefois par la jurisprudence française – que celui qui met sur le marché une chose défectueuse s'oblige à en assumer la charge, non seulement envers son cocontractant, mais envers tous les acquéreurs successifs. D'un autre côté, en acquérant la chose, ceux-ci acceptent tacitement cette garantie offerte par le fabricant. Il se formerait une sorte de contrat entre le premier vendeur et le fabricant et chaque acquéreur de la chaîne. L'idée n'est pas si artificielle qu'on pourrait le croire, si on considère que, lorsqu'on achète une chose de telle marque, on a au moins autant l'impression de l'acheter au fabricant (ou au titulaire de la marque) qu'à tel ou tel distributeur dont le choix est souvent le fait du hasard. Du reste, il est très fréquent que les fabricants s'engagent directement à garantir les produits qu'ils mettent sur le marché, et, même si cet engagement n'a qu'on objet très limité, il atteste de la possibilité de regarder le premier vendeur et le dernier acquéreur comme parties à un contrat global reliant les différents contrats particuliers de la chaîne de distribution. Resterait cependant à déterminer les règles applicables à ce contrat global – ce qui s'avérerait assez difficile si on en juge par la jurisprudence qui s'est développée en France à propos des groupes de contrats non translatifs.

[2449] Voy. *supra*, n° 987.
[2450] Voy. *supra*, n° 989.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

B) *Le rejet d'une action directe contractuelle dans les groupes de contrats non translatifs*

1117. Évolution de la jurisprudence française. À la fin des années 1980, la Cour de cassation française, alors très influencée par la thèse de B. Teyssié sur les groupes de contrats, avait accepté de reconnaître une action directe en responsabilité contractuelle dans le cadre des sous-contrats, et plus généralement de tous les groupes de contrats dès lors qu'une partie à un des contrats en cause, en n'exécutant pas ses obligations, causait un préjudice à une partie à un autre contrat. Un premier arrêt du 18 mars 1988, relatif à un cas de sous-traitance, avait posé que « dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d'une action de nature nécessairement contractuelle, qu'il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué »[2451]. Quelques mois plus tard, un autre arrêt posait, de manière plus générale, que « dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu'en effet, dans ce cas, le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d'une action de nature contractuelle, même en l'absence de contrat entre eux »[2452]. On voit que cette jurisprudence ne reposait pas – et ne pouvait pas reposer – sur l'idée de transmission des droits et actions comme accessoire d'une chose, aucune chose n'étant transmise d'un contractant à l'autre. La solution reposait plutôt sur la reconnaissance d'un lien contractuel direct entre les différentes parties aux contrats liés, la notion de partie et de tiers s'appréciant alors, non dans le cadre de chaque contrat, mais dans

[2451] Cass. (1re civ.), 8 mars 1988, n° 86-18182. L'arrêt était relatif à un photographe à qui un client avait confié le tirage de photographies, et qui avait sous-traité ce tirage à un laboratoire. Les photos ayant été perdues, le client avait agi en responsabilité contre le laboratoire, et s'était vu opposer la clause limitative de responsabilité figurant au contrat entre ce laboratoire et le photographe. La Cour de cassation, en jugeant que l'action du client contre le sous-traitant était contractuelle, a admis l'application de la clause.

[2452] Cass. (1re civ.), 21 juin 1988, n° 85-12609. Il s'agissait d'un accident survenu sur un aéroport lors du remorquage d'un avion par la société exploitant l'aéroport, accident cause par un vice de fabrication du tracteur de remorquage. L'arrêt considère que l'action de la compagnie aérienne propriétaire de l'avion endommagé est une action contractuelle, ce qui a pour effet de rendre applicable la clause de non-responsabilité insérée dans le contrat entre cette compagnie et la société exploitant l'aéroport.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

le cadre de l'ensemble contractuel. Comme l'exprime bien l'arrêt sur les groupes de contrats, cet élargissement de la sphère contractuelle visait à accroître la prévisibilité du contrat pour le débiteur assigné en responsabilité. Cette solution présentait cependant de sérieux inconvénients, principalement en raison de la difficulté de définir son domaine exact, ainsi que des incertitudes entourant le régime de ce « contrat global » liant les parties extrêmes de l'ensemble. La Cour de cassation avait commencé de définir ce régime, d'une manière très défavorable à la victime du dommage, en posant que le droit à réparation ne pouvait s'exercer, en matière de sous-contrat du moins, que « dans la double limite » du contrat principal et du contrat de sous-traitance, ce qui exposait la victime à un cumul des clauses de non-responsabilité contenues dans ces deux contrats. Ces inconvénients, joints au fondement théorique contesté de la notion de « groupe de contrats », ont finalement amené l'Assemblée plénière de la Cour de cassation à condamner ces solutions. Dans un arrêt très important du 12 juillet 1991 (Besse), la Cour a rappelé le principe de l'effet relatif des contrats, et en a déduit que, dans un contrat de sous-traitance, l'action du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant ne pouvait être fondée que sur la responsabilité délictuelle[2453]. Cette solution vaut *a fortiori* pour les autres groupes de contrats non translatifs. Elle a en revanche laissé subsister l'action directe dans les chaînes de contrats translatives, fondée sur l'idée d'accessoire[2454].

1118. Jurisprudence belge et luxembourgeoise. La jurisprudence française de 1988 sur le sous-contrat et les groupes de contrats n'a pas eu le temps d'avoir une influence en Belgique ni au Luxembourg. Dans ces deux pays, l'action en responsabilité entre parties extrêmes dans les groupes de contrats non translatifs, et en particulier dans le cas de sous-traitance, a toujours été considérée comme une action délictuelle[2455]. L'arrêt Besse de 1991, fréquemment cité dans les décisions

[2453] Cass. fr. (ass. plén.), 12 juillet 1991, n° 90-13602. Parmi les innombrables commentaires que cet arrêt a suscité, voy. les notes de J. Ghestin (*D.*, 1991, p. 549) et G. Viney (*JCP*, 1991, II, p. 21743).

[2454] Voy. *supra*, n° 1111. La combinaison des deux solutions ne va pas sans difficulté, notamment lorsqu'un sous-traitant achète les produits avec lequel il réalise le travail pour le compte de l'entrepreneur principal auprès d'un fournisseur : bien que, dans ce cas, il y ait transfert de propriété de la chose objet des différents contrats, la jurisprudence française a décidé que, dès lors que le sous-traitant, engageait sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant, devait, à l'égard du maître de l'ouvrage, répondre de ses actes sur le même fondement (Cass. fr., 28 novembre 2001, n°s 00-13559 et 00-14450).

[2455] Pour le Luxembourg : Cass., 11 janvier 1990, *Pas.*, 27, p. 350.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

luxembourgeoises, n'a fait que conforter cette jurisprudence[2456]. Cette jurisprudence n'est du reste nullement défavorable, du moins au Luxembourg, à la partie victime de l'exécution du sous-contrat ou du contrat lié : si elle est considérée comme tiers, elle bénéficie de la jurisprudence, copiée sur celle de la Cour de cassation française, qui assimile le manquement contractuel à une faute délictuelle. Le maître de l'ouvrage, par exemple, victime de malfaçons sur un travail fait par le sous-traitant, peut obtenir des dommages et intérêts de celui-ci sans avoir à prouver sa faute, en établissant simplement que le résultat promis n'a pas été atteint – mais sans par ailleurs risquer de se voir opposer des clauses contenues dans le contrat liant le sous-traitant à l'entrepreneur : confrontée à un litige de ce type, la Cour d'appel tout en admettant que la responsabilité du sous-traitant est délictuelle, a clairement rappelé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage[2457]. Elle a en conséquence infirmé un jugement qui avait estimé que le maître de l'ouvrage devait « établir une faute délictuelle envisagée en elle-même, indépendante et détachable des contrats de sous-traitance ». Nous avons dit par ailleurs tout le mal que nous pensons de cette jurisprudence, qui aboutit à mieux traiter les tiers victimes que les contractants eux-mêmes[2458].

SECTION 2. L'EXTENSION DES OBLIGATIONS : LA SOLIDARITÉ LÉGALE

1119. Principe. L'exécution d'une obligation contractuelle peut être garantie par un tiers, obligé de payer la dette si le débiteur ne le fait pas lui-même. Dans l'immense majorité des cas, cette obligation de garantie repose sur un engagement personnel du garant. Il n'y a alors aucune exception au principe de l'effet relatif du contrat : lorsqu'une personne se porte caution du paiement d'une dette née d'un contrat (par exemple, d'un prêt), elle sera tenue de cette dette, non en vertu du contrat cautionné (auquel elle n'est

[2456] Trib. Luxembourg, 30 juin 2000, n° 48733 ; Cour d'appel, 1er juillet 1998, n° 20546 ; Cour d'appel, 9 octobre 2008, *Pas.*, 34, p. 281.

[2457] Cour d'appel, 16 février 2000, n° 22963 ; Cour d'appel, 9 octobre 2008, *Pas.*, 34, p. 281 ; Cour d'appel, 25 octobre 2017, n° 40026 ; Cour d'appel, 1er juillet 2018, n° 20546 ; Trib. Luxembourg, 22 novembre 2023, nos TAL-2019-01219 et TAL-2019-09367. Sur cette jurisprudence, voy. « Chaînes de contrats : l'action directe du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant – Condition de l'action contractuelle et action de nature délictuelle », *JN Obligations*, 2018, n° 3, pp. 57-60.

[2458] Voy. *supra*, n° 989.

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

pas partie), mais en vertu du contrat de cautionnement qu'elle a elle-même passé avec le créancier. Il n'en va pas de même lorsque, exceptionnellement, c'est la loi qui fait peser sur un tiers une obligation de garantir le paiement de dettes nées d'un contrat auquel il n'a pas été partie. Tel est notamment l'effet de l'article 215 du Code civil selon lequel les dettes contractées par un époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants engagent l'autre époux solidairement (alors même qu'il n'a pas participé à la conclusion du contrat). De même, dans les sociétés en nom collectif, « tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de tous les engagements de la société »[2459], alors même que la société a une personnalité juridique distincte de la leur et qu'ils sont donc tiers aux contrats qu'elle passe. Bien entendu, cette extension légale des obligations contractuelles ne se conçoit que pour des tiers qui ont des liens étroits avec le débiteur contractuel. Comme dans le cas précédent, on pourrait tout aussi bien voir ces solutions sous l'angle de l'élargissement de la notion de partie au contrat : tout se passe, d'une certaine manière, comme si le contrat ayant pour but l'entretien du ménage et l'éducation des enfants était passé avec les deux époux, ou comme si, en raison d'une certaine transparence de la société en nom collectif, le contrat était passé avec tous les associés.

SECTION 3. EXTENSION GLOBALE DES EFFETS DU CONTRAT : LES CONTRATS COLLECTIFS

1120. Conventions collectives de travail. Réglementées par les articles L. 161-1 et suivants du Code du travail, les conventions collectives sont, selon la définition qu'en donne l'article L. 161-2 des « contrat(s) relatif aux relations et aux conditions de travail conclu(s) entre un ou plusieurs syndicats de salariés remplissant les conditions définies ci-après d'une part, et soit une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs, soit une entreprise particulière, soit un groupe d'entreprises ou un ensemble d'entreprises dont la production, l'activité ou la profession sont de la même nature, ou, encore, qui constituent une entité économique et sociale ». L'étude systématique du régime juridique de ces conventions relève du droit du travail, on se bornera ici à en relever le particularisme par rapport à la théorie générale du contrat, spécialement quant aux

[2459] L. 10 août 1915, art. 14.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

effets qu'elles produisent à l'égard des tiers. Ces conventions réglementent les relations entre salariés et employeurs sur toute une série de points (durée du travail, montant des rémunérations, régime des congés, conditions d'embauche et de licenciement, etc.). Or le point remarquable est que les droits et obligations qu'elles font naître vont s'appliquer à tous les salariés des employeurs signataires ou membres des organisations ou des groupements signataires, même si ces salariés n'étaient pas eux-mêmes affiliés à l'un des syndicats signataires [C. trav., art. L. 162-8 (2)] – de sorte qu'on ne peut pas considérer qu'ils ont été représentés par ces syndicats. Cela n'est admissible que parce que les syndicats habilités à négocier et à signer une convention collective doivent avoir une certaine représentativité, telle que définie aux articles L. 161-4 à L. 161-7 du Code du travail. Du côté des employeurs, la convention ne lie en principe que ceux qui l'ont signée ou qui appartenaient à une organisation signataire. Cependant un syndicat ou une organisation professionnelle d'employeur peut demander au Ministre du travail de déclarer qu'une convention collective est « d'obligation générale ». La déclaration d'obligation générale, qui prendra la forme d'un Règlement Grand-Ducal, aura pour effet d'étendre l'application de la convention à tous les employeurs du champ professionnel considéré, même s'ils n'ont pas personnellement signé et s'ils n'étaient pas membres d'un groupement signataire. La dérogation à l'effet relatif, résultant d'un acte réglementaire, est ici manifeste.

****

1121. Synthèse sur les effets du contrat à l'égard des tiers. Compte tenu de l'extrême complexité de la matière, il ne paraît pas inutile, arrivés au terme de ce long exposé des effets du contrat à l'égard des tiers, de tenter de résumer en quelques mots l'état du droit. Le principe est que le contrat ne peut, en principe, créer de droits au profit des tiers et encore moins mettre à leur charge des obligations. Mais ce principe souffre de nombreuses exceptions : soit parce que les parties au contrat décident d'y déroger en stipulant des droits au profit des tiers, soit parce que la loi ou la jurisprudence instituent une action directe contractuelle entre des personnes qui ne sont pas liées par un contrat, notamment dans le contexte des groupes de contrats. Même en dehors de ces exceptions, le principe de l'effet relatif, tel qu'il est conçu aujourd'hui,

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

n'a qu'une portée assez limitée. D'une part parce qu'il ne signifie pas, et ne peut pas signifier qu'un contrat ne produit aucun effet à l'égard des tiers : sur de nombreux plans, les tiers ne peuvent pas faire comme si le contrat n'avait pas été passé, ils doivent en subir les conséquences, et, à l'inverse, ils peuvent se prévaloir des effets favorables que le contrat peut avoir sur leur situation. C'est ce qu'on appelle l'opposabilité du contrat (aux tiers ou par les tiers), à laquelle la jurisprudence donne parfois des conséquences inattendues. D'autre part, lorsqu'on parle des « tiers », cela ne s'entend que des personnes qui sont complètement extérieures au contrat, qui n'ont pas bénéficié d'une transmission des droits nés du contrat (cession de créance, subrogation), et qui n'ont pas accepté de reprendre à leur charge des obligations nées de ce contrat (délégation, cession de contrat).

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
L'extension légale ou jurisprudentielle des droits et obligations nés du contrat, Contrats et obligations conventionnelles en d...
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Index alphabétique

LARCIER INTERSENTIA
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Index alphabétique, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1185-1194
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

strada lex

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Index alphabétique, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1185-1194
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

(les chiffres renvoient aux numéros des paragraphes)

A

Abus de droit : 177, 326, 493, 500, 516, 526, 551, 553, 556, 744, 779, 883
Voy. aussi Clause abusive

Acceptation : 152 et s.
- *conditions : 154 et s.*
- *divergences avec l'offre : 157*
- *effets : 160 et s.*
- *réception : 161 et s.*
- *silence : 156*

Accords de principe : 157, 190, 192

Acompte : 494

Acte juridique : 59 et s.
- *abstrait : 385 et s.*
- *collectif : 67, 1120*
- *d'administration : 287*
- *de disposition : 287*

Voy. aussi acte unilatéral

Acte unilatéral : 61 et s.
- *cause : 360 et s.*
- *conditions de validité : 208*
- *dol : 246*
- *engagement unilatéral : 63 et s., 144,*
- *formation : 128*
- *notion : 61 et s.*
- *preuve : 420*
- *révocation : 492*
- *sanctions de l'inexécution : 683*

Action oblique : 723 et s.
- *conditions : 724*
- *effets : 727 et s.*

Action paulienne : 729 et s.
- *conditions : 731 et s.*
- *effets : 734 et s.*

Actions directes : 728, 900, 1039, 1104 **et s.**

Analyse économique du droit : 98

Anatocisme : 850, 940

Annulation : *Voy. Nullité*

Apparence : 315

Arrhes : 494

Assistance bénévole : 40, 156, 806

Astreinte :
- *judiciaire : 746*
- *clauses d'astreinte : 869*

Attentes légitimes : 97

Autonomie de la volonté : 89 et s.

Avant-contrats : *voy. Contrats préliminaires*

Ayants-cause :
- *notion : 1035*
- *particuliers : 1035 et s., 1050 et s.*
- *transmission des créances aux ayants-cause : 1035 et s.*
- *transmission des dettes aux ayants-cause : 1045, 1050*
- *universels : 1036 et s.*

B

Bénévolat : 40

Bonne foi : 114 **et s.**, 177, 242, 495 **et s.**, 608, 712, 779

Bonnes mœurs : 107, 375 à 376, 388, 397, 401, 403

C

Caducité : 359, 369, 436, 557 et s.
- *de l'offre : 150 et s.*

Capacité : *voy. Incapacités*

Cause : 341 et s.
- *actes unilatéraux : 360 et s.*
- *cautionnement : 363*

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Index alphabétique, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1185-1194
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

– *consideration : 350*
– *contrats aléatoires : 352*
– *disparition : 359, 369*
– *fausseté : 369 et s.*
– *illicéité : 373 et s.*
– *libéralités : 362, 369*
– *moment d'appréciation : 515*
– *objective : 349 et s.*
– *prêt : 361*
– *preuve : 382 et s.*
– *sanction : 353*
– *subjective : 368 et s.*

Cause étrangère : 824 et s., 837 et s.

Cession de contrat : 1014, 1072 **et s.**
– *conditions de validité : 1073 et s.*
– *effets : 1077 et s.*
– *nature juridique : 1073*

Cession de créance : 428, 907, 996 **et s.**
– *conditions de validité : 997 et s.*
– *effets : 1010*
– *opposabilité aux tiers : 1004 et s.*
– *opposabilité des exceptions : 1015*

Cession de dette : 1047 et s.

Chaînes de contrats : 1111 et s.

Clause pénale : 12, 187, 700, 866 **et s.**
– *conditions de validité : 875 et s.*
– *notion : 866, 868 et s.*
– *révision : 881 et s.*

Clauses :
– *abusives : 170, 411* ***et s.,*** *452, 455, 876*
– *compromissoire : 490*
– *d'indexation : 410, 654*
– *de dédit : 494*
– *réputées non écrites : 415, 452, 455,*
– *résolutoire : 499, 774 et s.*

Clientèle (cession de) : 18, 340

Commerce juridique (choses hors du) : 337 et s.

Conclusion du contrat :
– *lieu : 161*
– *moment : 161 et s.*

voy. Offre, acceptation, négociations, contrats préliminaires, promesses

Condition : 588 et s.
– *potestative : 135, 494, 593* ***et s.***
– *résolutoire : 588, 603* ***et s.***
– *suspensive : 588, 599* ***et s.***

Conditions générales des contrats : 170 et s.
– *conflit : 158*
– *intégration des clauses : 170* ***et s.****, 857*
– *validité : 170 à 172*

Confiance : 97, 148, 149

Confirmation : 454 et s.

Contrats (différents types) :
– *à distance : 161 et s.*
– *à exécution instantanée : 81, 540, 542 à 543*
– *à exécution successive : 81, 540, 544* ***et s.***
– *à titre gratuit : 81*
– *à titre onéreux : 81*
– *administratifs : 85*
– *aléatoire : 80, 352*
– *avec soi-même : 303*
– *commerciaux : 86*
– *commutatif : 80*
– *contrats-cadres : 194, 321s*
– *d'adhésion : 46, 63, 83, 169* ***et s.****, 412, 528, 855, 864*
– *de consommation : 87*
– *définition : 1, 33 et s.*
– *électroniques : 164, 425*
– *innomés : 76*
– *intuitu personae : 134, 140, 151, 230, 641, 1066, 1074 à 1075*
– *liés : 372, 478, 631, 709, 797, 910, 1108 et s.*
– *réel : 78, 82, 361, 431*
– *relationnel : 81*
– *solennel : 82, 432* ***et s.***

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Index alphabétique, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1185-1194
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

– *synallagmatique : 78*
– *unilatéral : 78*

Contrats préliminaires : 145, 169 **et s.**

Consensualisme : 106, 137, 155, 416 **et s.,** 1003

Consideration : 97, 122, 342, 350
voy. aussi Cause

Contenu du contrat : 316 et s.
– *contenu obligationnel : 485*

Contractualisation : 3

Contre-lettre : *voy. Simulation*

Convention :
– *collective : 67, 1120*
– *distinction avec le contrat : 56*

Convention-loi : *voy. Force obligatoire*

Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (CVIM) : 25

Coutumes : 10

Culpa in contrahendo **:** 178, 195, 480

Curatelle : 215, 263, 290

D

Dation en paiement : 651

Délai de grâce : 506, 586**,** 658

Délais de paiement : 695

Délégation : 1042, 1053 **et s.**
– *certaine : 1062*
– *conditions de validité : 1056*
– *effets : 1057 et s.*
– *imparfaite : 1060*
– *incertaine : 1062*
– *inopposabilité des exceptions : 1059*
– *parfaite : 1060*

Dénaturation : 530

Dettes :
– *de valeur : 654, 846*
– *transmission : 1044 et s.*

Dol : 221, 237 *et s.*
– *caractère déterminant : 249*
– *dans l'exécution du contrat : 833, 862*
– *dolus bonus : 241*
– *incident : 249*
– *par réticence : 205, 242, 280*

Dommages et intérêts : 747 et s.
Voy. Responsabilité contractuelle

Draft common frame of reference **:** 30

Droit commun européen de la vente : 31

Droit de gage général : 720

Droit de la consommation : 28, 87, 106, 197, 200, 247, 269, 274, 279, 410 et s.

Droit de résiliation unilatérale : 546 et s.

Droit européen des contrats : 28 et s.

Droit transitoire : 519 et s.

Droits de l'homme : 28, 110, 135, 290, 404

Droits de préemption : 105

Droits de repentir : *voy. Droits de rétractation*

Droits de rétractation : 113, 167 **et s.** 277, 493

Durée du contrat : 540 et s.

E

Économie du contrat : 357, 359, 515

Effet relatif du contrat : 299, 722, 812, 953 **et s.**

Effets internes du contrat : *voy. Effet relatif*

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Index alphabétique, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1185-1194
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Effets externes du contrat :
voy. Opposabilité du contrat

Efficient breach of contract **:** 634, 650, 735

Engagement unilatéral : *voy. Acte unilatéral*

Enrichissement sans cause : 73

Ensembles contractuels : 1072, 1108, 1112
Voy. aussi Contrats liés, groupes de contrats

Erreur : 220 **et s.**
– *erreur-obstacle : 220*
– *sur la substance : 224 et s.*
– *de droit : 228*
– *sur les motifs : 231*
– *sur la valeur : 234*
– *déterminante : 235*
– *inexcusable : 236, 250*

Estoppel : 117, 499

Exception d'inexécution : 706 et s.
– *conditions : 708 et s.*
– *effets : 714 et s.*

Exécution :
– *en nature : 53, 185, 703, 716, 718 et s., 754*
– *forcée : 718 et s.*
– *sur les biens : 719*
– *volontaire : voy. Paiement*

Exigibilité : 574 et s.

F

Faillite : 297, 585 à 586, 720 à 721

Fait juridique : 59, 68 et s.

Force majeure : 335, 766 et s., 838 **et s.**

Force obligatoire : 88, 90, 111 à 113, 483 **et s.**

Formalisme : 276, 417 et s.
– *probatoire : 418 et s.*
– *de publicité : 428 et s.*
– *ad validitatem : 430 et s.*
– *informatif : 434*

Formation du contrat (processus) : 123 et s.

Fraude : 379, 729 et s., 731, 972

G

Gentlemen's agreements : 41

Gestion d'affaires : 71

Groupes de contrats : 1108 et s.
Voy. aussi Contrats liés, ensembles contractuels

H

Harmonisation européenne : 28 à 31, 87

I

Imprévision : 112, 359, 508 **et s.**

Imputation des paiements : 667

Inexécution des obligations contractuelles : 673 et s.
voy. Exception d'inexécution, Exécution forcée, Mise en demeure, Résolution, Responsabilité contractuelle

Inexistence : 122
– *distinction avec l'inopposabilité : 310*
– *distinction avec la nullité : 122, 155, 211, 220, 318, 440*

Incapacités : 283 et s.
– *d'exercice : 284 et s.*
– *de jouissance : 291 et s.*
– *majeurs protégés : 290*
– *mineurs : 289*
– *rescision pour lésion : 263*

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Index alphabétique, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1185-1194
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Inopposabilité : 310, 428, 734
– *distinction avec la nullité : 436*

Indivisibilité :
– *de l'obligation : 631 et s.*
– *du paiement : 657*

Interdépendance contractuelle : 561 et s.

Intérêts :
– *moratoires : 850*
– *compensatoires : 850*

Interprétation : 497, 522 **et s.**
– *contra proferentem : 528*

Irrévocabilité : 489 et s.

J

Justice contractuelle : 95

L

Lésion : 259 **et s.**, 349, 356
– *incapables : 263, 289, 290*
– *lésion qualifiée : 264 et s.*
– *partage : 262*
– *vente d'immeuble : 261*

Libéralisme : 92 à 93, 99

Liberté contractuelle : 90, 92, 102 à 110, 388, 396

Logement familial : 297

Loi applicable au contrat : 22 à 23

Lois :
– *impératives : 45, 390, 536*
– *supplétives : 44, 390, 536*

M

Mandat : 553, 1058

Mise en demeure : 685 et s.
– *domaine : 690 et s., 698 et s.*
– *du créancier : 648*
– *du débiteur : 685 et s.*
– *effets : 689*
– *formes : 705*

Moment et lieu de formation du contrat : 161 et s.

Monnaie : 656

Mutuus dissensus **:** 491

N

Négociations précontractuelles : 175 et s.
– *contrats organisant les – : 192*
– *rupture : 176 et s.*

Nemo auditur **:** 381, 467

Nominalisme monétaire : 654

Normativisme : 94

Novation : 919 et s.
– *effet extinctif : 924*
– *notion : 919*
– *par changement de créancier : 1041*
– *par changement de débiteur : 1052*
– *par changement de l'obligation : 920 et s.*

Nullité : 207
– *absence de cause : 353, 446*
– *absolue : 207, 380, 442* ***et s.****, 448, 452*
– *cause illicite : 380*
– *confirmation : 454 et s.*
– *distinction avec l'inexistence : 440*
– *effets : 458 et s.*
– *exception de nullité : 453*
– *incapacité : 444*
– *indétermination de l'objet : 446*
– *lésion : 444*
– *ordre public : 445*
– *partielle : 472 et s., 875*
– *prescription : 450 et s.*
– *régularisation : 454*

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Index alphabétique, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1185-1194
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

– *relative : 207, 217, 219, 286, 297, 353, 442* ***et s.****, 449, 451*
– *vices du consentement : 444*

O

Objet : 316 et s.
– *choses futures : 331 à 332*
– *clientèle : 340*
– *corps humain : 339*
– *détermination : 317 et s.*
– *existence : 333*
– *hors du commerce : 336 et s.*
– *possibilité : 334*

Obligations :
– *alternatives : 611*
– *conjonctives : 610*
– *d'information : 197* ***et s.****, 242, 275*
– *de conseil : 202*
– *de donner : 52, 674, 749*
– *de faire : 50*
– *de moyens et de résultat : 54, 670, 765, 823* ***et s.***
– *de ne pas faire : 51, 751*
– *de sécurité : 70,*
– *de somme d'argent : 53*
– *facultatives : 612*
– *implicites : 497, 534* ***et s.****, 810*
– *in solidum : voy. solidarité*

Offre : 127 et s.
– *au public : 138, 140*
– *caducité : 150*
– *nature juridique : 141 et s.*
– *révocabilité : 146 et s.*

Offres réelles et consignation : 648

Opposabilité du contrat aux tiers : 960 et s.
– *notion : 961*
– *conséquences : 965 et s.*
– *limites : 974 et s.*

Opposabilité du contrat par les tiers : 983 et s.

Ordre public et bonnes mœurs : 103, 107, 336 et s., 373 et s., 388 **et s.**
– *cause illicite ou immorale : 373 et s.*
– *de protection : 107, 390, 391, 445, 456*
– *économique : 107, 405*
– *international : 400*
– *objet contraire à l'ordre public : 336 et s.*
– *procédural : 400*
– *textuel : 394*
– *virtuel : 395*

P

Pacte de préférence : 193

Pacte sur succession future : 332

Paiement : 635 et s.
– *accipiens : 644 et s.*
– *dation en paiement : 651*
– *effet extinctif : 666*
– *frais : 663*
– *imputation des paiements : 667*
– *lieu : 661*
– *moment : 662*
– *monnaie de paiement : 656*
– *nature juridique : 636*
– *paiement de l'indu : 71, 642, 645, 615*
– *paiement par un tiers : 640 et s.*
– *preuve : 670 et s.*
– *solvens : 638 et s.*

Porte-fort : 300

Pourparlers : *voy. Négociations*

Pouvoir de contracter : 295 et s.

Prescription : 932 et s.
– *courtes prescriptions : 941*
– *durée : 938 et s.*
– *effets : 951 et s.*
– *interruption : 947 et s.*
– *interversion : 941, 948*
– *nature : 934*

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Index alphabétique, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1185-1194
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

– *notion : 932*
– *point de départ : 944 et s.*
– *quinquennale : 940*
– *suspension : 949 et s.*

Preuve
– *du paiement : 670*
– *des actes juridiques : 418 et s.*

Principes UNIDROIT : 26

Principes du droit européen du contrat : 29

Pratiques commerciales déloyales : 278

Prix
– *détermination : 324 et s.*
– *dérisoire : 356*

Promesses de contrat : 182 et s.
– *unilatérale : 183 et s., 741*
– *synallagmatique : 188 et s.*

Promesse de porte-fort : *voy. Porte-fort*

Q

Qualification : 122, 531

Quae temporalia **:** 453

Quasi-contrats : 71 à 74

R

Ratification : 312, 454

Reconduction : 555 à 556

Réfaction : 796

Réforme française du droit des obligations : 13

Régularisation : 454

Remise de dette : 926 et s.

Remplacement : 752

Représentation : 302 et s.
– *conventionnelle : 303*
– *imparfaite : 308*
– *judiciaire : 305*
– *légale : 304*
– *parfaite : 307*

Réserves : 134 à 136

Résiliation : *voy. droit de résiliation unilatérale, résolution pour inexécution*

Résolution pour inexécution : 437, 493, 701 à 702, 716, 753 **et s.**
– *clauses : 773, 774 et s.*
– *conditions : 756 et s.*
– *déclaration unilatérale : 782*
– *effets : 791 et s.*
– *judiciaire : 771 et s.*
– *résiliation pour inexécution : 794*
– *résolution anticipée : 760*

Responsabilité contractuelle : 800 et s.
– *distinction avec la responsabilité extracontractuelle : 69 à 70, 802, 804* ***et s.***
– *domaine : 805 et s.*
– *faute : 822 et s.*
– *force majeure : 838*
– *lien de causalité : 834 et s.*
– *nature : 801*
– *non cumul avec la responsabilité extracontractuelle : 70*
– *obligations de moyens et obligations de résultat : 823 et s.*
– *préjudice : 828 et s.*

par ricochet : 836

prévisibilité : 833

Responsabilité du fait des produits défectueux : 1114

Risques (Théorie des) : 766 et s.

T

Transfert de propriété :
– *moment : 52, 768*

Tutelle : 216, 289, 290

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Index alphabétique, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1185-1194
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

S

Saisies : 720 à 721
- *saisie-arrêt : 646*

Simulation : 730, 975 **et s.**

Solidarisme : 96

Solidarité : 615 et s.
- *active : 616*
- *commerciale : 621*
- *conventionnelle : 619*
- *effets secondaires : 628*
- *exceptions opposables : 627*
- *légale : 620*
- *obligation in solidum : 622, 839*
- *recours : 629 et s.*
- *passive : 617 et s.*

Specific performance **:** 735

Stipulation pour autrui : 301, 1082 **et s.**
- *acceptation : 1100*
- *conditions : 1087 et s.*
- *droit direct : 1094*
- *effets : 1092 et s.*
- *révocabilité : 1099*
- *tacite : 1089*

Subrogation : 642, 668, 1018 **et s.**
- *conventionnelle : 1024 et s.*
- *effet translatif : 1031 et s.*
- *légale : 1020 et s.*
- *personnelle : 1018*
- *réelle : 1018*

Surendettement : 506, 585 à 586, 720, 931

Terme :
- *déchéance : 577 et s.*
- *extinctif : 552 et s. 571*
- *prorogation : 585 et s.*
- *suspensif : 570 et s.*

Trouble mental : 215 et s.

U

Unilatéralisme : 324

V

Vices du consentement : 211 et s., 218 et s.
voy. aussi Erreur, dol, violence, lésion

Violence : 251 et s.
- *auteur : 255*
- *économique : 257*
- *gravité : 252*
- *légitimité : 256*
- *violence économique : 257 à 258*

Volonté réelle et volonté déclarée : 220

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Index alphabétique, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1185-1194
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Bibliographie

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Bibliographie, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1195-1200
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Bibliographie, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1195-1200
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

Si les écrits relatifs au droit des contrats au Luxembourg sont encore en nombre limité, la littérature juridique sur le contrat dans les deux autres pays du Code civil est immense, et il n'a évidemment été possible, dans cet ouvrage centré sur le droit luxembourgeois, que d'en donner un petit aperçu. Nous proposons ci-dessous, à côté des ouvrages de droit luxembourgeois, une liste des principaux ouvrages généraux actuellement disponibles sur le marché en France et en Belgique, dans lesquels les lecteurs pourront trouver les références des innombrables thèses, articles, notes de jurisprudence relatifs aux différentes questions traitées. Compte tenu des réformes d'ensemble de la matière intervenues récemment en France et en Belgique, et dans l'attente d'une éventuelle réforme luxembourgeoise, les juristes du Luxembourg devront encore de servir pendant un certain temps des ouvrages anciens (encore disponibles en bibliothèque) pour éclairer l'interprétation des articles du Code civil encore en vigueur au Luxembourg. C'est pourquoi on donne ici, pour les deux pays voisins, deux listes d'ouvrages, les uns antérieurs, les autres dans leur dernière édition postérieure à la réforme intervenue. Les ouvrages cités le sont donc habituellement dans leurs éditions antérieures, sauf lorsque l'objet de la citation concerne un point qui n'a pas été modifié par la réforme intervenue, ou une question d'interprétation d'un texte issu de celle-ci. Dans les notes de bas de page de cet ouvrage, les ouvrages français et belges ayant connu des éditions antérieures et postérieures à la réforme et qui sont cités par le seul nom de leur(s) auteur(s) sont accompagnés de la date de l'édition citée, pour que le lecteur sache à quelle édition se référer. On a ajouté ci-dessous aux ouvrages français et belges, quelques ouvrages de base de droit anglais, allemand et suisse, ainsi que de droit comparé des contrats, pour prolonger et élargir l'approche comparative limitée du présent manuel.

Luxembourg

POELMANS (O.), *Droit des obligations au Luxembourg, Principes généraux et examen de jurisprudence*, Les Dossiers du Journal des tribunaux, Bruxelles, Larcier, 2013 (cité POELMANS)

RAVARANI (G.), *La responsabilité civile des personnes privées et publiques*, 3e éd., Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, (cité RAVARANI)

France

1/ Ouvrages antérieurs à la réforme de 2016

BENABENT (A.), *Droit des obligations*, 14e éd., Paris, LGDJ, 2014, n° 63 (cité BENABENT 2014)

BILLIAU (M.), GHESTIN (J.), JAMIN (C.), *Les effets du contrat, Traité de droit civil* (GHESTIN (J.) dir.), 3e éd., Paris, LGDJ, 2001

CAPITANT (H.) TERRE (F.), LEQUETTE (Y.), CHENEDE (F.) *Les grands arrêts de la jurisprudence civile*, t. 2, *Obligations, contrats spéciaux, sûretés*, 13e éd., 2015

CARBONNIER (J.), *Droit civil*, t. 2, *Les biens, Les obligations*, coll. Quadrige, Paris, PUF, 2004 (cité CARBONNIER)

FABRE-MAGNAN (M.), *Droit des obligations 1 – Contrat et engagement unilatéral*, 3e éd., coll. Thémis, Paris, PUF, 2012 (cité FABRE-MAGNAN 2012)

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Bibliographie, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1195-1200
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

FAGES (B.), *Droit des obligations*, 4e éd., Paris, LGDJ, 2013 (cité FAGES 2013)

FLOUR (J.), AUBERT (J.L.), SAVAUX (E.), *Droit civil, Les obligations*, 3, *Le rapport d'obligation*, 9e éd., 2015 (cité FLOUR, AUBERT, SAVAUX, vol. 3 2015)

FLOUR (J.), AUBERT (J.L.), SAVAUX (E.), *Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique*, 16e éd., Paris, Sirey, 2014 (cité FLOUR, AUBERT, SAVAUX, vol. 1 2014)

GHESTIN (J.), BILLIAU (M.), LOISEAU (G.), *Traité de droit civil. Le régime des créances et des dettes* (GHESTIN (J.) dir.), Paris, LGDJ, 2005

GHESTIN (J.), LOISEAU (G.), SERINET (Y.M.), Traité de droit civil, La formation du contrat, t. 1, Le contrat. Le consentement (GHESTIN (J.) dir.), 4e éd., Paris, LGDJ, 2013 ; t. 2, *L'objet et la cause. Les nullités*, 4e éd., Paris, LGDJ, 2013 (cité GHESTIN, LOISEAU, SERINET)

LARROUMET (C.) et BROS (S.), *Traité de droit civil*, t. 3, *Les obligations*, le contrat, 7e éd. Paris, Economica, 2014

MALAURIE (P.), AYNES (L.), STOFFEL-MUNCK (P.), *Droit civil, Les obligations*, 6e éd., Paris, Lextenso, 2013, (cité MALAURIE, AYNES, STOFFEL-MUNCK 2013)

MALINVAUD (P.), FENOUILLET (D.), MEKKI (M.), *Droit des obligations*, 13e éd., Paris, Lextenso, 2014 (cité MALINVAUD, FENOUILLET, MEKKI 2014)

POTHIER (R.J.), *Traité des obligations*, 1re éd. 1761. Réédition : Dalloz, 2011, préface

HALPERIN (J.L.) (cité POTHIER)

TERRE (P.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.), *Droit civil, Les obligations*, 11e éd., Paris, Dalloz, 2013, (cité TERRE, SIMLER, LEQUETTE 2013)

VINEY (G.), *Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité* (GHESTIN (J.) dir.), 3e éd., Paris, LGDJ, 2008

VINEY(G.), JOURDAIN (P.), CARVAL (S.), *Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité* (GHESTIN (J.) dir.), 4e éd., Paris, LGDJ, 2013

VINEY (G.), JOURDAIN (P.), *Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité* (GHESTIN (J.) dir.), 3e éd., Paris, LGDJ, 2011

ZENATI-CASTAING (F.) et REVET (T.), *Cours de droit civil, Contrats (Théorie générale – Quasi-contrats)*, Paris, PUF, 2014 (cité ZENATI-CASTAING, REVET)

2/ Ouvrages postérieurs à la réforme de 2016

BENABENT (A.), *Droit des obligations*, 20e éd., Paris, LGDJ, 2023.

CABRILLAC (R.), *Droit des obligations*, 15e éd., Paris, Dalloz, 2022.

CAPITANT (H.), TERRE (F.), LEQUETTE (Y.), CHENEDE (F.), *Les grands arrêts de la jurisprudence civile*, t. 2, *Obligations, contrats spéciaux, sûretés*, 14e éd., Paris, Dalloz, 2024.

CHANTEPIE (G.), LATINA (M.), *Le nouveau droit des obligations : commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil*, 3e éd., Paris, Dalloz, 2024.

CHENEDE (F.), *Droit des obligations et des contrats : consolidations, innovations, perspectives*, Paris, Dalloz, 3e éd., 2023

DESHAYES (O.), GENICON (TH.), LAITHIER (Y.-M.), *Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : commentaire article par article*, Lexis Nexis, 2e éd., 2018.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Bibliographie, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1195-1200
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

DISSAUX (N.), JAMIN (C.), *Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : commentaire des articles 1100 à 1386-1 du Code civil*, Dalloz, 2016.

DISSAUX (N.), JAMIN (C.), *Réforme du droit des contrats : 10 articles à connaître*, Paris, Dalloz, 2018.

FABRE-MAGNAN (M.), *Droit des obligations 1 – Contrat et engagement unilatéral*, 7e éd., Paris, PUF, 2024 (cité FABRE-MAGNAN 2024).

FAGES (B.), *Droit des obligations*, LGDJ, 13e éd., 2023-2024 (cité FAGES 2023).

FLOUR (J.), AUBERT (J.-L.), SAVAUX (E.), *Droit civil, Les obligations, 1. L'acte juridique*, 17e éd., Paris, Sirey, 2022 (cité FLOUR, AUBERT, SAVAUX 2022).

FLOUR (J.), AUBERT (J.-L.), SAVAUX (E.), ANDREU (L.), FORTI (V.), *Droit civil, Les obligations, 3. Le rapport d'obligation*, Sirey, 10e éd., 2022. (cité FLOUR, AUBERT, SAVAUX, ANDREU, FORTI 2022)

FRANÇOIS (J.), *in* LARROUMET (C) [dir.), Traité de droit civil, *Les obligations, Régime général*, 6e éd., Paris, Economica, 2022. (cité FRANCOIS 2022)

HOUTCIEFF (D.), Droit des contrats, 8e ed., coll. Paradigme, Bruxelles, Bruylant, 2023 (cité HOUTCIEFF 2023)

LARROUMET (C.), BROS (S.), *in* LARROUMET (C.) [dir.], *Traité de droit civil – Tome 3 – Les obligations, le contrat*, 10e éd., Paris, Economica, 2021. (cité LARROUMET BROS 2021)

LE TOURNEAU (Ph.) [dir.], Droit de la responsabilité et des contrats, 13e éd., Paris, LGDJ, 2023 (cité LE TOURNEAU 2023)

MALAURIE (PH.), AYNES (L.), STOFFEL-MUNCK (P.), *Droit civil, Les obligations*, 12e éd., Paris, LGDJ, 2022 (cité MALAURIE, AYNES, STOFFEL-MUNCK 2022).

MALINVAUD (PH.), MEKKI (M.), SEUBE (J.-B.), *Droit des obligations*, 17e éd., Paris, LexisNexis, 2023 (cité MALINVAUD, MEKKI, SEUBE 2022).

TERRE (F.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.), CHENEDE (F.) *Droit civil, Les obligations*, 13e éd., Paris, Dalloz, 2022. (cité TERRE, SIMLER, LEQUETTE, CHENEDE 2022)

Belgique

1/ Ouvrages antérieurs à la réforme de 2022

VAN OMMESLAGHE (P.), *Traité de droit civil belge de DE PAGE*, t. 2, *Les obligations*, vol. 1, *Introduction, Sources des obligations (première partie)*, vol. 2, *Sources des obligations (deuxième partie)*, vol. 3, *Régime général de l'obligation, Théorie des preuves*, Bruxelles, Bruylant, 2013

WERY (P.), *Droit des obligations*, vol. 1, *Théorie générale du contrat*, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011 (cité WERY 2011), 3e éd. 2021 (cité WERY 2021)

En langue néerlandaise :

STIJNS (S.), *Verbintennissenrecht*, Bruges, die Keure, 3 volumes, 2013

2/ Ouvrages postérieurs à la réforme de 2022

CORBISIER (I), *La réforme du droit belge des contrats dans la perspective de la réforme luxembourgeoise*, Bruxelles, Larcier, Les dossiers du Journal des tribunaux Luxembourg, 2023

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Bibliographie, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1195-1200
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

KOHL (B.), WERY (P.), *Droit des obligations, Le nouveau droit des obligations*, coll. CUP, Liège, Anthémis, 2022

DERVAL (T.), JAFFERALI (R.), KOHL (B.) (dir.), *La réforme du droit des obligations*, Collection de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, Bruxelles, Larcier, 2023

WERY (P.), *Livre 5 du Code civil : les obligations, les sources des obligations*, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2024

Autres pays

CARTWRIGHT (J.), *Contract law, An introduction to the English Law of contract for the civil lawyer*, 4e éd., Oxford, Hart Publishing, 2023 (cité CARTWRIGHT)

KÖTZ (H.), *Vertragsrecht*, 2. *Auflage*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2012

TERCIER (P.) et PICHONNAZ (P.), *Le droit des obligations*, 5e éd., Zurich, Schulthess, 2012

Droit comparé des contrats

BEALE (H.), FAUVARQUE-COSSON (B.), RUTGERS (J.), TALLON (D.), VOGENAUER (S.), *Contract Law, Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe*, 2e éd., Oxford, Hart Publishing, 2010 (cite BEALE *et alii*)

CABRILLAC (R.), *Droit européen comparé des contrats*, Paris, Lextenso, 2012 (cité CABRILLAC)

KADNER GRAZIANO (T.), *Le contrat en droit privé européen, Exercices de comparaison*, 2e éd. Paris/Bruxelles, Helbing Lichtenhahn/LGDJ/Bruylant, 2010

RANIERI (F.), *Europäisches Obligationenrecht : Ein Handbuch mit Texten und Materialien (Springers Handbücher der Rechtswissenschaft)*, Springer Verlag, 2009

SMITS (J.), *Contract law. A comparative introduction*, 3e éd., Cheltenham, Edward Elgar, 2021, (cité SMITS)

Histoire du droit

DEROUSSIN (D.), *Histoire du droit des obligations*, 2e éd., Paris, Economica, 2012 (cité DEROUSSIN)

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Bibliographie, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1195-1200
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Abréviations

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Abréviations, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1201-1204
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Abréviations, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1201-1204
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

AC	Appeal cases (Angleterre)
B.I.J.	Bulletin d'informations juridiques du Jeune barreau de Luxembourg
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch (Allemagne)
BGH	Bundesgrichtishof (Allemagne)
BWB	Burgerlijk Wetboek (Pays-Bas)
C. civ. be.	Code civil belge (dispositions spécifiques à la Belgique)
C. civ. fr.	Code civil français (dispositions spécifiques à la France)
C. civ.	Code civil du Luxembourg (y compris pour les dispositions communes au Luxembourg, à la France et à la Belgique)
C. comm. fr.	Code de commerce français
C. comm.	Code de commerce du Luxembourg
C. consomm. fr.	Code de la consommation français (France)
C. consomm.	Code de la consommation (Luxembourg)
C.O.	Code des obligations (Suisse)
CAL	Cour d'appel du Luxembourg
Cass. be.	Cour de cassation de Belgique (les arrêts sont cités par leur numéro de rôle, ce qui permet de les retrouver dans la base Juridat)
Cass.	Cour de cassation du Luxembourg
Cass. fr.	Cour de cassation française (1re 2e, 3e civ., com., soc., ass. plén., ch. mixte, Req. : 1re, 2e, 3e chambres civiles, chambre commerciale, chambre sociale, Assemblée plénière, Chambre mixte, Chambre des requêtes (pour les arrêts antérieurs à 1947)) (les arrêts sont cités par leur numéro de pourvoi, ce qui permet de les retrouver dans la base Legifrance)
Cour eur. D.H.	Cour européenne des droits de l'homme
CEE	Communauté économique européenne
CJCE	Cour de justice des communautés européennes (avant le 1er décembre 2009)
CJUE	Cour de justice de l'Union européenne (depuis le 1er décembre 2009)
Code Gandolfi	Projet de code européen des contrats (dit : Code européen des contrats)
C. const. (fr.), Déc. N° 2013-672 DC du 13 juin 2013	Conseil constitutionnel français (Déc. DC : rendue dans le cadre de l'examen préalable de la constitutionnalité d'une loi ; Déc. QPC : rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité, à propos d'une loi déjà en vigueur)
CVIM	Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises
D.	Recueil Dalloz (France)
D.A.O.R.	Revue internationale de droit des affaires, « Le droit des affaires – Het Ondernemingsrecht » (Belgique)
DCEV	Droit commun européen de la vente, Annexe à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente (octobre 2011)

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Abréviations, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1201-1204
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

DCFR	Draft common frame of reference, élaboré par le Study group on an European civil code
Défrenois	Répertoire du notariat Défrenois (France)
DH	Dalloz hebdomadaire) (France)
DP	Dalloz périodique (France)
GAJC	Grands arrêts de la jurisprudence civile (France)
HL	House of Lords (Angleterre)
J.O.C.E.	Journal officiel des communautés européennes
J.O.U.E.	Journal officiel de l'Union européenne
J.T.L.	Journal des tribunaux luxembourgeois
JCl civ.	Jurisclasseur civil (France)
JLMB	Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles (Belgique)
JN Obligations	JurisNews droit des obligations et contrats spéciaux (Luxembourg)
JT	Journal des tribunaux (Belgique)
KB	King's bench division (Angleterre)
LPA	Les petites affiches (France)
Mich. L. Rev.	Michigan Law Review
N.j.W.	Nieuw Juridisch Weekblad (Belgique)
NCPC	Nouveau Code de procédure civile (Luxembourg)
NJW	Neue juristische Wochenschrift (Allemagne)
Pas.	Pasicrisie luxembourgeoise (Luxembourg)
Pas. (be.)	Pasicrisie belge (Belgique)
PDEC	Principes de droit européen des contrats
Principes Unidroit	Principes de l'Institut international pour l'unification du droit privé relatifs aux contrats du commerce international (3e éd. 2010)
R.D.C.	Revue des contrats (France)
Rep. civ. Dalloz	Répertoire Dalloz de droit civil (France)
Rev. crit. DIP	Revue critique de droit international privé (France)
RGDC	Revue générale de droit civil belge(Belgique) (idem TBBR)
RTD civ.	Revue trimestrielle de droit civil (France)
RTD eur.	Revue trimestrielle de droit européen
T. Not.	Tijdschrift voor Notarissen (Belgique)
Trib. Diekirch	Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Trib. Luxembourg	Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
TBBR	Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk recht (Belgique) (Idem RGDC)
UE	Union européenne
UNIDROIT	Institut international pour l'unification du droit privé
V°	Verbo
WLR	Weekly law reports (Angleterre)

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Abréviations, Contrats et obligations conventionnelles en droit luxembourgeois, p. 1201-1204
www.stradalex.com - 21/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite